Prof. Dr. Mustafa DURAL **Prof. Dr. Turgut ÖZ**

MİRAS HUKUKU

Yenilenmiş Sekizinci Bası

FİLİZ KİTABEVİ
İSTANBUL
2015

OCAK 2015

ISBN: 978-975-368-398-2

Copyright© Bu kitabın Türkiye'deki yayın hakları Filiz Kitabevi Basım Yayın Dağıtım Petrol Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.'ne aittir. Her hakkı saklıdır. Hiçbir bölümü ve paragrafı kısmen veya tamamen ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya başka herhangi bir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz. Normal ölçüyü aşan iktibaslar yapılamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur.

Baskı: Eren Ofset
Matbaacı Sertifika Numarası: 22782

YAYINLAYAN:
Filiz Kitabevi Basım Yayın Dağıtım
Petrol Ürünleri Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.
Cemal Yener Tosyalı Cad.
No: 57/A Vefa/İST.
Tel: (212) 527 07 18
Fax: (212) 519 20 71
www.filizkitabevi.com
Yayıncı Sertifika Numarası: 15544

SEKİZİNCİ BASIYA ÖNSÖZ

Kitabımızın bu basısında, bazı yollamalardaki kaynakların güncellenmesi ve küçük birkaç düzeltme dışında en önemli yenilik, 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu hükümlerini değiştiren 30.4.2014 Tarihli ve 6537 Sayılı Kanunla getirilen yeni düzenlemedir. Tarımsal arazilerin paylaştırılmasına ilişkin bu yeni düzenlemeyi miras hukuku açısından incelemiş bulunuyoruz. Her zamanki gibi bu basının hazırlanmasında da son derece özenli ve hızlı çalışmalarıyla büyük emeği geçen Filiz Kitabevi mensuplarına bir kere daha teşekkürü borç biliriz.

Prof.Dr. Mustafa Dural *Prof.Dr. Turgut Öz*

İstanbul 2014

İÇİNDEKİLER

§ 1. GİRİŞ 1

I. TANIM VE MİRAS HUKUKUNUN GEREKLİLİĞİ 1

1. Tanım 1
2. Miras Hukukunun Gerekliliği 1
3. Miras Hakkının Anayasa Teminatı Altında Olması 2
4. Miras Hukukunun Medenî Kanunun İçindeki Yeri ve Sistematiği 3

II. MİRAS HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI 5

1. Miras 5
2. Mirasbırakan 5
3. Mirasçı 5
4. Tereke 8

a. Malvarlığında bulunan, fakat terekede yer almayan hukukî ilişkiler 8
b. Malvarlığında bulunmayan, fakat terekede yer alan hukukî ilişkiler 10
c. Ölüm sebebiyle doğrudan doğruya mirasçıların şahsında doğan haklar . 11

5. Ölüme Bağlı Tasarruf 12

III. MİRAS HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMI OLARAK KÜLLÎ HALEFİYET VE SONUÇLARI 12

1. Küllî Halefiyet Kavramı 12
2. Küllî Halefiyetin İstisnası: Cüzî Halefiyet Hali 15

BİRİNCİ KISIM

YASAL MİRASÇILIK

§ 2. KAN HISIMLARININ YASAL MİRASÇILIĞININ TEMELİ OLAN ZÜMRE SİSTEMİNİN ESASLARI 18

I. GENEL BİLGİLER 18

1. Fert Sistemi 18
2. Sınıf Sistemi 18
3. Zümre (Parantel) Sistemi 18

a. Zümrenin tanımı 19
b. Yasal mirasçılık açısından Medenî Kanundaki zümre düzeni 19

II. ZÜMRE SİSTEMİNİN ANA PRENSİPLERİ 21

1. Mirasçı olabilmek için bir zümreye dahil olma 21
2. Bir önceki zümrede mirasçı bulunması, bir sonraki zümrenin mirasçılığını engeller 22
3. Zümre içinde ön sıradaki (derecedeki) mirasçılar, bir alt sıradaki mirasçıların mirasçılığını engeller 24
4. Zümre başları ve kök başlarının önceliği 25
5. Zümre başı ya da kök başına altsoyun halef olması 27
6. Mirasın, birinci zümrede kök başlarına, ikinci ve üçüncü zümrelerde, zümre başlarına göre eşit olarak paylaşılması 28

7. İkinci ve üçüncü zümrelerde mirasın ana ve baba hattı olarak ikiye ayrılması 29
III. MİRASBIRAKANA ÇİFT HISIMLIK BAĞI İLE BAĞLI OLANLARIN MİRASÇILIĞI 32
IV. YARIM KAN HISIMLARININ MİRASÇILIĞI 32
V. EVLİLİK DIŞINDA DOĞAN HISIMLARIN MİRASÇILIĞI 33
§ 3. EVLATLIĞIN (VE ALTSOYUNUN) MİRASÇILIĞI 35
I. GENEL OLARAK 35
II. EVLATLIK VE ALTSOYUNUN MİRASÇILIĞININ ÖZELLİKLERİ 35
§ 4. ZÜMRE SİSTEMİNİN GENEL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ 36
§ 5. EŞİN MİRASÇILIĞI 37
I. GENEL OLARAK 37
II. EŞİN DEĞİŞİK ZÜMRELERLE MİRASÇI OLMASI DURUMUNDA MİRAS PAYININ ORANLARI 37
III. EŞİN MİRASÇILIĞI İLE İLGİLİ BAZI ÖZEL DURUMLAR 42
1. Boşanma Davasının Eşin Mirasçılığına Etkisi 42
2. Evliliğin Butlanı Kararının Eşin Mirasçılığına Etkisi 45
3. Birden Fazla Sağ Kalan Eşin Mirasçılığı 47
§ 6. DEVLETİN MİRASÇILIĞI 47

İKİNCİ KISIM

ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR

§ 7. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARA İLİŞKİN ÖN BİLGİLER 50
I. KAVRAM 50
II. ÖLÜME BAĞLI BAĞIŞLAMALARIN ÖLÜME BAĞLI TASARRUF HÜKÜMLERİNE TÂBİ OLMASI 51
III. ÖLÜME BAĞLI TASARRUF KAVRAMININ İKİ ANLAMI 52
1. Şeklî Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruflar 52
2. Maddî Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruflar 55
§ 8. ÖLÜME BAĞLI TASARRUF YAPMA EHLİYETİ 56
I. GENEL OLARAK 56
II. VASİYETNAME YAPABİLME EHLİYETİ 56
1. Ayırt Etme Gücü 57
2. Yaş 58
III. MİRAS SÖZLEŞMESİ YAPMA EHLİYETİ 58
§ 9. ŞEKLÎ ANLAMDA ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR 61
I. ŞEKLÎ ANLAMDAKİ ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER 61
II. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFTA ŞEKLE UYMANIN YARARLARI 62
§ 10. RESMÎ VASİYETNAMELER 62
I. GENEL BİLGİLER 62
II. RESMÎ VASİYETNAMENİN DÜZENLENİŞ ŞEKİLLERİ 67

III. OKUNARAK VE İMZALANARAK DÜZENLENEN RESMÎ VASİYETNAMELER 68
1. Birinci Safha 69
2. İkinci Safha 71
IV. OKUNMADAN VE İMZALANMADAN DÜZENLENEN RESMÎ VASİYETNAMELER 73
V. KARMA ŞEKİLDE DÜZENLENEN RESMÎ VASİYETNAMELER 74
1. Okunmadan, Fakat İmzalanarak Düzenleme 74
2. Okuyarak, Fakat İmzalamadan Düzenleme 75
VI. BAZI ÖZEL DURUMLAR 76
1. Körlerin Durumu 76
2. Sağır ve Dilsizlerin Durumu 77
3. Türkçe Bilinmeyenlerin Durumu 78
§ 11. EL YAZILI VASİYETNAME 79
I. GENEL OLARAK 79
II. EL YAZILI VASİYETNAMENİN FAYDA VE MAHZURLARI 79
1. Faydaları 79
2. Mahzurları 80
III. EL YAZILI VASİYETNAMENİN ŞEKİL ŞARTLARI 81
1. Vasiyetnamenin Metni 81
a. Genel Olarak 81
b. Metnin kısmen üçüncü kişiler tarafından ya da mekanik bir araçla yazılmış olması 83
2. Düzenleme Tarihi 84
a. Düzenleme tarihinin gösteriliş şekli 84
b. Düzenleme tarihinin vasiyetnamede gösterilmesinin faydaları 85
c. Düzenleme tarihinin el yazısı ile olması şartı 86
d. Düzenleme tarihinin vasiyetnamede bulunmamasının müeyyidesi 86
3. İmza 88
a. Genel olarak 88
b. İmzanın el yazılı vasiyetnamedeki fonksiyonları 88
c. İmzanın atılış şekli 88
d. İmzanın vasiyetnamedeki yeri 89
IV. EL YAZILI VASİYETNAMENİN SAKLANMASI (TEVDİİ) 89
V. EL YAZILI VASİYETNAMEDE VASİYETÇİ TARAFINDAN SONRADAN YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 90
a. Vasiyetname daha tamamlanmadan yapılan değişiklikler 90
b. Vasiyetname tamamlandıktan sonra yapılan değişiklikler 90
§ 12. SÖZLÜ VASİYETNAME 91
I. GENEL OLARAK 91
II. SÖZLÜ VASİYETNAMENİN ŞEKİL ŞARTLARI 93
a. Birinci safha 93
b. İkinci safha 93
III. SÖZLÜ VASİYETNAMENİN HÜKÜMDEN DÜŞMESİ 98

§ 13. MİRAS SÖZLEŞMELERİ 99
I. TANIM VE GENEL BİLGİLER 99
1. Miras Sözleşmesi İle Vasiyetname Arasındaki Benzerlik 99
2. Miras Sözleşmesi ile Vasiyetname Arasındaki Farklar 99
II. MİRAS SÖZLEŞMESİNİN TÜRLERİ 100
1. Olumlu Miras Sözleşmeleri-Olumsuz (Mirastan Feragat) Sözleşmeleri ... 100
a. Miras sözleşmesi 100
b. Mirastan feragat sözleşmesi 101
2. Bir Taraflı ve İki Taraflı Miras Sözleşmeleri 101
a. Bir taraflı miras sözleşmeleri 101
b. İki taraflı miras sözleşmeleri 101
3. İvazlı ve İvazsız (Karşılıklı ve Karşılıksız) Miras Sözleşmeleri 101
a) İvazsız miras sözleşmesi 102
b) İvazlı miras sözleşmesi 102
III. MİRAS SÖZLEŞMESİ YAPMA EHLİYETİ 102
1. Ölüme Bağlı Tasarrufta Bulunan Tarafın Ehliyeti 102
2. Ölüme Bağlı Tasarrufta Bulunmayan Tarafın Ehliyeti 102
3. Taraflardan Birinin Ehliyetsizliğinin Sonuçları 104
a) Ölüme bağlı tasarrufta bulunmayan tarafın ehliyetsizliği 104
b) Mirasbırakanın ehliyetsizliği 105
IV. MİRAS SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ 106
1. Genel Olarak 106
2. Miras Sözleşmelerinin Şekil Yönünden Resmi Vasiyetnameden Farkları 107
a) Tarafların aynı anda noter huzurunda bulunmaları 107
b) Noterin beyanları yazması ya da yazdırması ve metnin okunması 108
c) Tarafların metni tanıklar önünde imzalamaları 108
d) Mirasbırakanın tanıklar önünde belgeyi okuduğunu ve son arzularına uygun olduğunu beyan etmesi 108
e) Tanıkların şerh ve imzası 108
f) Miras sözleşmesinin saklanması, tevdii ve açılması 109
§ 14. VASİYETNAMENİN GERİ ALINMASI, YOK OLMASI VE MİRAS SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ 109
I. VASİYETNAMENİN GERİ ALINMASI 109
1. Genel Olarak 109
2. Vasiyetnamenin Sonradan Yapılan Bir Ölüme Bağlı Tasarruf ile Geri Alınması 110
a) Vasiyetçi, sonraki vasiyetname ya da miras sözleşmesi ile daha önceki vasiyetnamesini geri aldığını açık olarak beyan eder 110
b) Vasiyetçi tarafından sonradan yapılan vasiyetnamede (ya da miras sözleşmesinde) önceki vasiyetnamenin geri alındığına ilişkin açık bir tasarruf bulunmamaktadır 111
3. Vasiyetnamenin Yok Edilerek Geri Alınması 112
4. Vasiyetname ile Yapılan Tasarrufun Sağlar arası Bir Tasarrufla Geri Alınması (Ademptio Legati) 113
II. VASİYETNAMENİN YOK OLMASI 114

III. MİRAS SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ (ORTADAN KALDIRILMASI).116
1. Miras Sözleşmesinin Tarafların Anlaşması ile Sona Ermesi (Miras Sözleşmelerine Son Verme Sözleşmesi)....116
a) Genel Olarak....116
b) Miras sözleşmesine son verme sözleşmesinin şartları....117
aa) Tarafların hayatta olması....117
bb) Ehliyet....118
cc) Şekil....118
c) Miras sözleşmesine son verme sözleşmesinin sonuçları....118
2. Miras Sözleşmesinin Bir Tarafı İrade Beyanı ile Sona Ermesi: (Miras Sözleşmesinden Dönme)....119
a) Genel olarak....119
b) Mirastan çıkarma sebeplerinden birinin varlığı hâlinde miras sözleşmesinden dönme....119
aa) Genel bilgiler....119
bb) Mirasçılıktan çıkarma sebeplerinden birinin varlığı hâlinde miras sözleşmesinden dönmenin şartları....120
aaa) Hak sahibi....120
bbb) Mirastan çıkarma sebeplerinden birinin varlığı....121
ccc) Ehliyet....122
ddd) Şekil....122
cc) Mirastan çıkarma sebeplerinden birine dayanılarak miras sözleşmesinden dönmenin sonuçları....123
c) Miras Sözleşmesinden Sağlar Arası İvaz (Karşılık) Borcunun Yerine Getirilmemesi Sebebiyle Dönülmesi (Sona Ermesi)....123
aa) Genel olarak....123
bb) Sağlar arası ivaz borcunun yerine getirilmemesi sebebiyle miras sözleşmesinden dönmenin şartları....124
aaa) Dönme hakkı kime aittir?....124
bbb) Sağlararası ivaz borçlusunun temerrüde düşmüş olması....125
ccc) Sağlar arası ivaz borçlusunun yeterli güvence (teminat) göstermemiş olması....125
cc) Miras sözleşmesinden sağlar arası ivaz borcunun yerin getirilmemesi sebebiyle dönmenin sonuçları....125
3. Mirasbırakanın Miras Sözleşmesine Aykırı Düşen Tasarrufları....127
a) Genel olarak....127
b) Kanunda düzenlenen haller....128
aa) Mirasbırakanın miras sözleşmesi ile bağdaşmayan ölüme bağlı tasarrufları....128
bb) Miras sözleşmesi ile bağdaşmayan sağlararası ivazsız (karşılıksız) tasarruflar....129
cc) Müeyyide....131
c) Mirasbırakanın, kanunda düzenlenmemiş olan miras sözleşmesine aykırı tasarrufları....131
aa) Sağlar arası ivazlı tasarruf....132
bb) Miras sözleşmesi ile yapılan tasarrufun, mirasbırakanın sonradan oluşan aile hukuku ilişkilerinden etkilenmesi....132

cc) Mirasbırakanın sağlığında malvarlığını israf etmesi ya da fiilî tasarruflar yoluyla miras sözleşmesi ile lehine tasarruf yapılan kimseye zarar vermesi ... 133
IV. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN KENDİLİĞİNDEN (KANUN GEREĞİ) SONA ERMESİ ... 133
1. Lehine Ölüme Bağlı Tasarruf Yapılan Kimsenin Mirasbırakandan Önce Ölmesi ... 134
2. Boşanma ... 135
3. Evliliğin butlanına karar verilmesi ... 136
4. Mirastan yoksunluk sebeplerinden birinin varlığı ... 136
5. Bozucu şartın gerçekleşmesi ya da geciktirici şartın gerçekleşmemesi ... 137
6. Sözlü vasiyetname ... 137
§ 15. MADDÎ ANLAMDA ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR ... 137
I. MADDÎ ANLAMDA ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER ... 137
II. MADDÎ ANLAMDA ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLA ŞEKLÎ ANLAMDA ÖLÜME BAĞLI TASARRUF ARASINDAKİ İLİŞKİ ... 138
1. Sadece Miras Sözleşmesi İle Yapılabilen Ölüme Bağlı Tasarruflar ... 139
2. Hem Miras Sözleşmesi Hem de Vasiyetname İle Yapılabilen Ölüme Bağlı Tasarruflar ... 140
3. Sadece Vasiyetname İle Yapılabilen Ölüme Bağlı Tasarruflar ... 141
§ 16. MADDÎ ANLAMDA ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN TÜRLERİ ... 141
I. MİRASÇI ATAMA ... 141
II. VASİYET (BELİRLİ MAL BIRAKMA) ... 142
1. Genel olarak ... 142
2. Vasiyetin bazı türleri ... 146
a) Belirli mal vasiyeti (bırakma) ... 146
b) Alt vasiyet ... 147
c) Ön vasiyet ... 147
d) Alacak vasiyeti ... 147
e) İbra vasiyeti ... 148
f) İntifa vasiyeti ... 148
g) İrat vasiyeti ... 148
3. Vasiyetin hükümleri ... 149
a) Vasiyet borçlusu kimdir? ... 149
b) Vasiyet alacaklısı kimdir? ... 150
c) Vasiyet borcunun doğumu ve muaccel hale gelmesi ... 151
d) Zamanaşımı ... 152
4. Vasiyet borcunun kapsamı ... 153
5. Vasiyetin tenkisi ... 155
III. KOŞUL (ŞART) ... 156
1. Genel olarak ... 156
2. Hukuka ve ahlâka aykırı koşullar ... 158
3. Anlamsız ve yalnız başkasını rahatsız edici (faydasız ve müziç) şartlar ... 162
4. İmkânsız koşullar ... 162
IV. YÜKLEME (MÜKELLEFİYET) ... 162

1. Genel olarak 162
2. Yüklemenin konusu 165
3. Yüklemenin yerine getirilmesi 165
4. Hukuka ve ahlâka aykırı ya da yalnız başkasını rahatsız edici yüklemeler 167
V. VAKIF KURMA 167
VI. YEDEK VE ARTMİRASÇI ATAMA (İKAMELİ TASARRUFLAR) 171
1. Yedek mirasçı atama 171
2. Artmirasçı atama 173
a) Kavram ve genel bilgiler 173
b) Artmirasçı atama 177
aa) Genel bilgiler 177
bb) Hükümleri 178
aaa) Mirasın artmirasçıya geçmesinden önceki safha 178
bbb) Mirasın artmirasçıya geçmesi safhası 182
c) Art vasiyet alacaklısı atanmasındaki özellikler 183
VII. VASİYETİ YERİNE GETİRME GÖREVLİSİ ATAMA 185
a) Genel bilgiler 185
b) Vasiyeti yerine getirme görevlisinin görevleri 189
c) Vasiyeti yerine getirme görevlisinin denetimi 192
d) Vasiyeti yerine getirme görevlisinin sorumluluğu 193
e) Vasiyeti yerine getirme görevlisinin görevinin sona ermesi 194
VIII. MİRASTAN FERAGAT 195
a) Tanım ve genel bilgiler 195
b) Mirastan feragat sözleşmesinin türleri 197
c) Feragatin hükümleri 198
aa) Feragat eden yönünden 198
bb) Feragatin altsoya etkisi 198
cc) Feragatin tasarruf edilebilir kısma (tasarruf nisabına) etkisi 200
dd) Feragatin mirasbırakanın alacakları yönünden etkisi 200
d) Feragatin hükümsüzlüğü 201
aa) Feragatin belirli bir ya da bir kaç kişi lehine yapılmış olması 202
bb) Feragatin en yakın ortak kökün altsoyu (tüm ortak yasal mirasçılar) lehine yapılması 202
IX. MİRASÇILIKTAN ÇIKARMA (MİRASTAN ISKAT) 204
1. Cezaî mirasçılıktan çıkarma 204
a) Genel olarak 204
b) Mirasçılıktan çıkarmanın şartları 205
aa) Şekil 205
bb) Mirasçılıktan çıkarmanın MK 510'da sayılan sebeplerden birine dayanması 206
cc) Mirasçılıktan çıkarma sebebinin ölüme bağlı tasarrufta gösterilmesi 209
c) Mirasçılıktan çıkarmanın hükümleri 211
d) Mirasçılıktan çıkarmanın hükümsüzlüğü 213
aa) İptal davası açılabilecek hâller 213

bb) Tenkis davası açılabilecek hâller 214
e) Affin mirasçılıktan çıkarmaya etkisi 215
2. Koruyucu mirasçılıktan çıkarma (borç ödemeden aciz sebebiyle mirasçılıktan çıkarma) 216
§ 17. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN YORUMU 218
I. GENEL OLARAK 218
II. VASİYETNAMENİN YORUMU 219
a) Genel olarak 219
b) Vasiyetnameye ilişkin özel yorum kuralları 221
aa) Favor testamenti (vasiyetname lehine yorum) 221
bb) Kanunî mirasın geçişi (intikali) kurallarına bağlılık 222
cc) Mirasçı ataması mı, vasiyet mi? 223
III. MİRAS SÖZLEŞMESİNİN YORUMU 224
§ 18. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARDA HÜKÜMSÜZLÜK 224
I. GENEL OLARAK 224
II. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN KANUN GEREĞİ (KENDİLİĞİNDEN) HÜKÜMSÜZ OLMASI 225
1. Evlilik Birliğinin Ölüm (ve Gaiplik) Dışında Sona Ermesi 225
2. Lehine Ölüme Bağlı Tasarruf Yapılan Kimsenin Mirasbırakandan Önce Ölmesi 225
3. Lehine Ölüme Bağlı Tasarruf Yapılan Kimsenin Mirastan Yoksun Olması 225
4. Bozucu Şartın Gerçekleşmesi ya da Geciktirici Şartın Gerçekleşmesi 226
III. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN İPTALİ 226
A. İPTAL SEBEPLERİ 226
1. Ehliyetsizlik (MK 557 b. 1) 226
2. İrade Sakatlıkları (MK 557 b. 2) 226
a) Hata (Yanılma) 226
b) Hile (Aldatma) (MK 57 b. 2) 228
c) Korkutma ve zorlama (tehdit yahut cebir) (MK 557 b. 2) 228
d) Mirasbırakanın hata ya da hileyi sağlığında öğrenmiş ya da korkutma ve zorlamanın etkisinden kurtulmasının özelliği 228
3. Ölüme Bağlı Tasarrufun İçeriğinin, Ona Eklenen Koşul ya da yüklemenin Hukuka ya da Ahlâka Aykırı Olması (MK 557 b. 3) 229
4. Şekil Noksanı (MK 557 b. 4) 230
B. İPTAL DAVASI 230
1. Genel Olarak 230
2. İptal Davasının Tarafları 232
a) Davacı 232
b) Davalı 233
3. Süre 233
a) Bir yıllık süre 233
b) On yıllık süre 233
c) Yirmi yıllık süre 233

d) Sınırsız defi hakkı 234

ÜÇÜNCÜ KISIM
SAKLI PAY, TASARRUF ORANI, TENKİS, DENKLEŞTİRME

§ 19. KAVRAMLAR 235
§ 20. SAKLI PAYLI MİRASÇILAR 239
I. KİMLER SAKLI PAYLI MİRASÇIDIR? 239
II. SAKLI PAYLAR 240
1. Saklı Pay Oranları 240
2. Eski Medenî Kanundaki Azaltılmış Saklı Paylar 245
3. Karı Koca Mal Rejimlerinin Saklı Paylara Etkisi 247
§ 21. TASARRUF ORANININ TEREKEYE GÖRE HESAPLANMASI 250
I. GENEL OLARAK 250
II. ÇIKARILACAK DEĞERLER 251
1. Mirasbırakanın Borçları 252
2. Cenaze Giderleri 253
3. Terekeyi Mühürleme ve Defter Tutma (Yazım) Masrafları 254
4. Mirasbırakan ile Bir Arada Yaşayan Kişilerin Üç Aylık Geçim Giderleri 254
III. EKLENECEK DEĞERLER 255
1. Denkleştirmeye (İadeye) Tabi Kazandırmalar 255
2. Tenkise Tâbi Sağlararası Kazandırmalar 256
a. Denkleştirmeye tâbi olması gerekirken bundan kurtulan kazandırmalar 256
aa. Mirasbırakanın mirasçılık sıfatını kaybeden yasal mirasçısına miras payına mahsuben yapmış olduğu sağlararası kazandırmalar 256
bb. Mirasbırakan tarafından denkleştirmeden muaf tutulduğu için denkleştirilmesi istenemeyen kazandırmalar 257
b. Mirastan ivazlı feragat halinde mirasçıya mirasbırakanın hayattayken ödediği karşılık 259
c. Bağışlayanın serbestçe dönme hakkını saklı tutarak yaptığı bağışlamalar ve âdet üzere verilen hediyeler hariç ölümünden önceki bir yıl içinde yapmış olduğu bağışlamalar 259
aa. Genel olarak 259
bb. Muvazaalı bir satışla gizlenmek istenen bağışlamalar 262
d. Vakıf kurmak için yapılan kazandırmalar 267
e. Saklı payı etkisiz kılma kastıyla yapılan kazandırmalar 268
3. Üçüncü Kişi Yararına Hayat Sigortası Alım Bedeli 270
§ 22. RED-ÇIKARILMA-FERAGAT VE YOKSUNLUĞUN ETKİSİ 271
1. Reddin Tasarruf Oranı Üzerindeki Etkisi 271
2. Mirastan Çıkarılmanın Tasarruf Oranı Üzerindeki Etkisi 273
3. Feragatin Tasarruf Oranı Üzerindeki Etkisi 274
a. İvazlı feragatte 274
b. İvazsız feragatte 274

4. Mirastan Yoksunluğun Tasarruf Oranı Üzerindeki Etkisi ... 275
§ 23. TENKİS ... 275
I. KAVRAM ... 275
II. TENKİS DÂVASI ... 276
1. Niteliği ... 276
2. Tarafları ... 278
a. Davacılar ... 278
aa. Saklı Paylı mirasçılar ... 278
bb. Saklı Paylı mirasçıların alacaklıları ve iflâs masası ... 280
b. Davalılar ... 282
3. Süresi ve Yetkili Mahkeme ... 285
III. TENKİS DEFİ ... 287
IV. TENKİSTE SIRA (TERTİP) ... 289
1. Tenkiste Sıra Sorunu ve Ölüme Bağlı Kazandırmalar İle Sağlararası Kazandırmalar Arasında Sıra ... 289
2. Sağlararası İşlem Yoluyla Ölüme Bağlı Kazandırmaların Özellikle Ölümden Sonraya Etkili Vekalet ve Temsil Yetkisinin Durumu ... 290
3. Ölüme Bağlı Kazandırmaların Tenkisi ... 294
a. Genel olarak ... 294
b. Saklı paylı mirasçılara yapılan kazandırmalar bakımından ... 296
4. Sağlararası Kazandırmaların Tenkisi ... 299
5. Kamu Yararına Kazandırmaların Tenkisi ... 301
V. TENKİSİ ÖZELLİK TAŞIYAN BAZI KAZANDIRMALAR ... 306
1. Değerinde Azalma Olmaksızın Bölünemeyecek Şeyin Vasiyetinde Tenkis ... 306
2. İntifa ve İrat Kazandırmalarında Tenkis ... 309
3. İvazlı Miras Sözleşmesinde Tenkis ... 311
4. İvazlı Feragat Halinde Feragat Edene Ödenen Karşılığın Tenkisi ... 312
5. Ölüme Bağlı Kazandırma Lehdarının Bir Vasiyet Borcu veya Yükleme (Mükellefiyet) ile Yükümlü Tutulması Durumunda Tenkis ... 313
6. Ön Mirasçının Saklı Paylı Olduğu Durumlarda Artmirasçı Atama (Fevkalâde İkame) ... 313
VI. TENKİS DAVASINDA ÖNCEDEN ALDIĞI KAZANDIRMAYI İADE YÜKÜMÜ ALTINA GİREN DAVALININ SORUMLULUĞU ... 314
VII. TENKİS HESAPLANMASINDA BİLİRKİŞİLERİN ROLÜ ... 318
§ 24. MİRASTA DENKLEŞTİRME (İADE) ... 319
I. DENKLEŞTİRME KURUMUNUN ANLAMI VE MİRAS HUKUKUNDA YERİ ... 319
II. DENKLEŞTİRMENİN TARAFLARI ... 321
1. Denkleştirme Borçlusu ... 321
a. Kanunî mirasçı olma şartı ... 321
b. Çeşitli kanunî mirasçıların durumları ... 323
aa. Altsoy dışındaki kanunî mirasçılar ... 323
bb. Altsoy ... 324

cc. Doğrudan kendisine kazandırma yapılmadığı hâlde denkleştirme ile yükümlü olanlar 325
2. Denkleştirme Alacaklısı 327
III. MİRASBIRAKANIN DENKLEŞTİRMEYE YÖNELİK OLUMLU VE OLUMSUZ İRADE BEYANININ NİTELİĞİ VE YAPILMASI 329
IV. DENKLEŞTİRMEYE TABİ KAZANDIRMALAR 331
1. Genel Olarak Denkleştirmeye Tâbi Kazandırmalar 331
2. Kanunen Denkleştirmeye Tâbi Kazandırmalar 333
a. Kuruluş Sermayesi 333
b. Çeyiz 334
c. Borçtan Kurtarmak 337
d. Malvarlığı devri 338
e. Diğer benzeri kazandırmalar 338
3. Denkleştirmeden Kanunen Muaf Tutulan Kazandırmalar 339
a. Eğitim ve öğrenim masrafları 339
b. Olağan hediyeler ve evlenme giderleri 340
c. Miras payını aşan kazandırmalarda bazı durumlarda aşan kısım 341
V. DENKLEŞTİRMENİN TALEP EDİLMESİ, GERÇEKLEŞMESİ VE DENKLEŞTİRMEDEN SORUMLULUK 342
1. Denkleştirme Dâvası 342
2. Denkleştirmenin Gerçekleşmesi ve Bu Sıradaki Sorumluluk 344
§ 25. MİRASBIRAKANIN ÖZEL DURUMDAKİ BAZI ÇOCUKLARININ ALACAK HAKLARI 347
I. EĞİTİM VE ÖĞRENİMİNİ TAMAMLAMAMIŞ VEYA SAKAT OLAN ÇOCUKLARIN ALACAK HAKKI 347
II. ANA BABA İLE VEYA BÜYÜK ANA VE BÜYÜK BABA İLE YAŞAYAN VE EMEĞİNİ VEYA GELİRİNİ AİLEYE ÖZGÜLEMİŞ ERGİN ÇOCUĞUN ALACAK HAKKI 349

DÖRDÜNCÜ KISIM
MİRASIN GEÇMESİ (İNTİKALİ)

§ 26. MİRASIN AÇILMASININ ŞARTLARI 357
I. MİRASIN AÇILMASINDA ÖNEM TAŞIYAN AN VE YER 357
1. Mirasın Açıldığı An 358
2. Mirasın Açıldığı Yer (Mirasa İlişkin Konularda Yetkili Mahkeme) 360
II. MİRASÇI VE VASİYET ALACAKLISI OLMANIN YASAL ŞARTLARI 362
1. Sağ Olmak 363
2. Ehil Olmak 365
3. Mirastan Yoksun Olmamak (MK 578/579) 368
a. Mirastan yoksunluk kavramı 368
b. Mirastan yoksunluk sebepleri 370
c. Mirastan yoksunluğun sonuçları 376
d. Affın etkisi 377
§ 27. MİRAS PAYLARININ DEVRİ 378
I. AÇILMAMIŞ MİRAS PAYININ DEVRİ 378

II. AÇILMIŞ MİRAS PAYININ DEVRİ ... 381
1. Genel Olarak ... 381
2. Devir Sözleşmesinin Şekli ve Konusu ... 382
3. Devir İşleminin Tarafları Bakımından Doğacak Farklar ... 383
a. Devrin mirasçılar arasında yapılması ... 383
b. Devrin mirasçı olmayan kişiye yapılması ... 385
4. Açılmış Miras Payının Rehni ve Haczi Sorunu ... 386
§ 28. GAİPLİĞİN MİRASIN GEÇMESİNDE ETKİSİ ... 387
I. GAİBİN MİRASI ... 388
II. MİRASÇININ GAİPLİĞİ ... 389
III. HAZİNENİN GAİPLİK KARARI ALMASI ... 390
§ 29. MİRASIN GEÇMESİNDE KORUMA ÖNLEMLERİ ... 391
I. TEREKENİN KORUNMASINA İLİŞKİN ÖNLEMLER ... 392
1. Terekenin Defterinin Tutulması ... 392
2. Terekenin Mühürlenmesi ... 393
3. Terekenin Resmen Yönetilmesi ... 394
a. Terekenin resmen yönetilmesi gereken haller ... 394
b. Terekeyi resmen yönetmekle görevli kişi ... 395
c. Resmen yönetimin yürütümü ve sona ermesi ... 395
II. MİRASÇILARIN SAPTANMASINA İLİŞKİN ÖNLEM ... 397
III. VASİYETNAMELERE İLİŞKİN ÖNLEMLER ... 397
1. Vasiyetnamenin Teslim (Tevdi) Edilmesi ... 397
2. Vasiyetnamenin Açılması ... 398
3. Vasiyetname Örneğinin Tebliği ... 400
§ 30. MİRASÇILIK BELGESİ (VERASET İLAMI) ... 400

BEŞİNCİ KISIM
MİRASIN KAZANILMASI (İKTİSABI)

§ 31. MİRASIN KAZANILMASINDAKİ (İKTİBASINDAKİ) TEMEL KURALLAR ... 403
I. KÜLLÎ HALEFİYET ... 403
II. VASİYET ALACAKLISININ DURUMU ... 405
1. Vasiyet Alacaklısının Sahip Olduğu Hak ... 405
2. Vasiyet Alacaklılarının Diğer Hak Sahipleri Karşısındaki Durumu ... 409
a. Mirasbırakanın alacaklılarına karşı ... 409
b. Mirasçıların alacaklılarına karşı ... 410
§ 32. MİRASIN REDDİ ... 410
I. KAVRAM VE ÇEŞİTLERİ ... 410
1. Gerçek red ... 410
a. Genel bilgiler ... 410
b. Ret hakkının düşmesi ... 413
aa. Sürenin dolması ... 413
bb. Süre dolmadan ret hakkının düşmesi ... 416

aaa. Açık kabul beyanı ile ret hakkının düşmesi 416
bbb. Tereke işlerine karışma nedeniyle ret hakkının düşmesi (örtülü kabul) 416
ccc. Ceza olarak ret hakkının düşmesi 418
2. Hükmi ret 418
II. REDDİN SONUÇLARI 419
1. Yasal Mirasçıların Mirası Reddetmesinin Sonuçları 419
a. Genel olarak 419
b. Özel durumlar 420
aa. En yakın yasal mirasçıların tümünün mirası reddi 420
bb. Mirasın altsoyun tamamı tarafından reddi 421
cc. Sonra gelen mirasçılar (madun derece) lehine ret 422
2. Atanmış Mirasçıların Mirası Reddetmesinin Sonucu 422
3. Vasiyet Alacaklılarının Vasiyeti Reddinin Sonucu 422
III. REDDE KARŞI ALACAKLILARIN KORUNMASI 423
1. Mirasçıların Kişisel Alacaklılarının Korunması 423
2. Mirasbırakanın Alacaklılarının Korunması 423
§ 33. RESMÎ DEFTER TUTMA 424
I. GENEL OLARAK 424
II. DEFTER TUTMA TALEBİ 425
III. RESMÎ DEFTER TUTULMASI İŞLEMLERİ 426
IV. RESMÎ DEFTER TUTULMASININ SONUÇLARI 428
1. Mirasçının Seçme İmkânının Doğması 428
2. Mirasın Tutulan Deftere Göre Kabulünün Sonuçları 429
§ 34. RESMÎ TASFİYE 432
I. RESMÎ TASFİYE KAVRAMI VE AMACI 432
II. RESMÎ TASFİYE TALEBİ 433
III. RESMÎ TASFİYENİN YAPILMASI 435
§ 35. MİRASÇILARIN SEÇİM HAKLARINI FARKLI ŞEKİLDE KULLANMALARININ SONUÇLARI 438
I. GENEL OLARAK 438
II. MİRASÇILARIN RESMÎ DEFTER TUTMA TALEBİNDEN ÖNCE SEÇİM HAKLARINI FARKLI YÖNDE KULLANMALARI 438
III. MİRASÇILARIN RESMÎ DEFTER TUTMA TALEBİNDEN SONRA SEÇİM HAKLARINI FARKLI YÖNDE KULLANMALARI 439
§ 36. MİRAS SEBEBİYLE İSTİHKAK DÂVASI 440
I. KAVRAM, NİTELİĞİ, ÖZELLİKLERİ 440
1. Mirasçılık Sıfatına Bağlı Özel Bir Dâva Olması 440
2. Mülkiyet Hakkına Dayanan İstihkak Davası ile Farkları 440
3. Koruyucu Önlemler (Tedbirler) 442
II. DAVANIN KONUSU 443
III. DAVANIN TARAFLARI 444
1. Dâvacı 444

2. Dâvalı 447
IV. SÜRE 448

ALTINCI KISIM

MİRAS ORTAKLIĞI VE MİRASIN PAYLAŞILMASI

§ 37. MİRAS ORTAKLIĞI 450
I. KAVRAM 450
II. MİRAS ORTAKLIĞININ HÜKÜMLERİ 451
1. Tereke Üzerinde Mirasçıların Hak ve Yetkileri, Dâvacı Olmaları 451
2. Mirasçıların Dâvalı Olması 455
a. Genel olarak 455
b. Vasiyet alacaklısı karşısında 455
3. Tereke Borçlarından Sorumluluk 457
a. Müteselsil sorumluluk kuralı ve çerçevesi 457
b. Borcu ödeyen mirasçının rücu hakkı 459
c. Mirasçıların güvence isteme hakkı 460
d. Paylaşmanın tamamlanmasından sonraki durum 461
4. Miras Ortaklığına Temsilci Atanması 463
III. MİRAS ORTAKLIĞININ SONA ERMESİ 465
1. Genel Olarak 465
2. Başlıca Sona Erme Hâlleri 465
a. Mirasın tamamen paylaşılması 465
b. Elbirliğiyle hak sahipliğinin paylı hak sahipliğine dönüşmesi 466
c. Miras ortaklığının başka bir ortaklığa dönüşmesi 467
§ 38. MİRASIN PAYLAŞTIRILMASI 468
I. GENEL OLARAK 468
II. PAYLAŞMA TÜRLERİ 469
1. Terekenin Tümünün Paylaşılması 469
2. Terekenin Bir Kısmının Paylaşılması 469
a. Objektif Kısmi Paylaştırma 470
b. Sübjektif Kısmi Paylaşma 470
III. PAYLAŞMAYA İLİŞKİN GENEL KURALLAR 471
1. İrade Özgürlüğü 471
2. Eşitlik 472
3. Aynen Paylaşmanın Asıl Olması 473
4. Bilgi Verme Yükümü 474
5. Aynî İkame 474
IV. TÜM MİRASÇILARIN ANLAŞMASIYLA PAYLAŞMA 475
1. Elden Paylaşma 475
2. Paylaşma Sözleşmesi 477
V. PAYLAŞMA (TAKSİM) DÂVASI 480
VI. PAYLAŞMAYI GECİKTİREN SEBEPLER 482
1. Paylaşmanın İradi Olarak Geciktirilmesi 482

a. Mirasçıların anlaşmasıyla 482
b. Mirasbırakanın tasarrufu ile 484
2. Paylaşmanın Kanun gereği geciktirilmesi: Mirasçılar arasında bir ceninin bulunması 484
3. Hâkim Kararı ile Paylaşmanın Geciktirilmesi 485
VII. PAYLAŞMAYA HAKİMİN ATADIĞI BİR KAYYIMIN KATILMASI 487
VIII. PAYLAŞMANIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ 488
1. Miras Paylarının Oluşması 488
2. Miras Paylarının Özgülenmesi (Tahsisi) 492
3. Paylaşmada Bazı Özel Durumlar 493
a. Değerinde önemli azalma olmaksızın bölünemeyen mal 493
b. Bir bütün oluşturan eşya topluluğu ve aile belgeleri ile özel anı değeri olan eşya 495
aa. Bir bütün oluşturan eşya 495
bb. Aile belgeleri ve aile için özel anı değeri olan eşya 497
c. Aile konutu ve ev eşyasının sağ kalan eşe özgülenmesi 499
aa. Genel olarak 499
bb. MK 652'nin uygulama alanı 502
cc. MK 652/I'e göre ortak konut ve ev eşyasının sağ kalan eşe özgülenmesinin şartları 504
d. Mirasbırakanın mirasçılardan birinden olan alacağı 505
e. Kat mülkiyetine çevirme yoluyla paylaşma 506
f. Tarımsal işletmelerin özgülenmesi 508
aa. Amacı ve özellikleri 508
bb. 6537 sayılı Kanun düzenlemesinin zaman bakımından uygulanması 509
cc. Tarımsal arazinin bölünme sınırları 511
dd. Mirasçıların bölünemez tarımsal araziyi belli süre içinde belli yöntemlerle paylaşma yükümü 512
ee. Mirasçılar veya Bakanlıkça açılacak dava ile paylaştırma 513
ff. Denkleştirme hükümleri 515
gg. Bazı taşınırların ve yan sınaî işletmenin devri 517
aaa) Bazı taşınırların devri 517
bbb) Yan sınai işletmenin devri 518
hh. Ölüme bağlı tasarrufla düzenlemeye getirilen sınırlar 518
ıı. Mülga MK 659-668 düzenlemesi 519
aaa) Tarımsal işletme kavramı 519
bbb) Mirasçıya özgüleme ve aile ortaklığı 521
IX. PAYLAŞMANIN SONUÇLARI 522
1. Mirasçıların Birbirine Karşı Sorumlulukları 522
2. Dışa Karşı Sorumluluk 526
BİBLİYOGRAFYA 527

KISALTMALAR CETVELİ

ABD:	Ankara Barosu Dergisi
ABGB:	Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch
Abs.:	Absatz
Acp:	Archiv für die zivilistische Praxis
AD:	Adalet Dergisi
Art:	Artikel
AÜHFD:	Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
B:	bend
BGB:	Bürgerliches Gesetzbuch
BGE.	Etscheidungen des Schweizerische Bundesgerichtshofs
BGHZ:	Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Zivilsachen
BK:	Borçlar Kanunu
Bkz.:	Bakınız
c.:	cümle, cilt
CCfr:	Cade Civil fransaise
Çev:	Çeviren
DJZ:	Deutsche Juristenzeitung
Dn:	Dip notu
Einl:	Einleitung
EMK:	Eski Medeni Kanun
GG:	Grundgesetz
HD:	Hukuk Dairesi
HGK:	Hukuk Genel Kurulu
HUMK:	Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu
İBD:	İstanbul Barosu Dergisi
İBK:	İçtihadı Birleştirme Kararı
İHFD:	İstanbul Hukuk Fakültesi Dergisi
İKİD:	İlmi ve Kazai İçtihatlar
JZ:	Juristische Zeitung
Krş:	Karşılaştırınız
m:	madde
MHAD:	Mukayeseli Hukuk Araştırmaları Dergisi
MK:	Medeni Kanun
N:	Nummer (Randnote)

NK:	Noterlik Kanunu
OR:	Obligationenrecht
RG:	Resmi Gazete
RGZ:	Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen
R:	Randnote
RKD:	Resmi Kararlar Dergisi
S:	sayı
SJZ:	Schweizerische Juristen Zeitung
TTK:	Türk Ticaret Kanunu
vd.:	ve devamı
Vorbem:	Vorbemerkung
YD:	Yargıtay Dergisi
YKD:	Yargıtay Kararları Dergisi
ZBJV:	Zeitschrift des bernischen Juristenvereins
ZGB:	Schweizerisches Zivilgesetzbuch
ZSR:	Zeitschrift für schweizerisches Recht

§ 1. Giriş

I. TANIM VE MİRAS HUKUKUNUN GEREKLİLİĞİ

1. Tanım

Miras Hukuku, mirasbırakan dediğimiz bir kimsenin, ölümü ile sona ermeyen,intikal edebilir hak ve borçları ile diğer hukuki ilişkilerinin akıbetini düzenleyen kuralların tümüdür[1]*. Kısa bir deyiş ile, Miras Hukuku, yukarıda sözü edilen durumlar yönünden, öleni kimin ikame edeceğini, ona ölüm sebebiyle (mortis causa) kimlerin halef olacağını düzenler.* 1

2. Miras hukukunun gerekliliği

Miras hukukunun temelinde iki husus yatar: özel mülkiyet ve bunun devamlılığı ile kişiye bağlı olanlar dışında alacak ve borçların, ölenin yerini alacak kişide (mirasçı) devam etmesi. Eğer mülkiyet ölümle sona erse ya da ölenin malları sahipsiz hale gelseydi; eğer ölüm ile birlikte alacaklar sona erseydi, ölene borçlu olan kimseler borçtan kurtulsaydı, miras hukukuna da gerek olmazdı. 2

Örneğin, kişinin hiç bir hakkının olmadığı, borçlarının topluma ait olduğu salt kollektivist bir düzende miras hukuku da olmazdı. Bugün dünyada var olan hiç bir toplumun böyle bir sistemi kabul ettiğini söylemek mümkün değildir. Nitekim, eski SSCB, 1919 yılında miras hakkını kanunla kaldırmış, fakat 1922 yılında yeniden düzenlemek zorunda kalmıştır[2]. 3

Miras hukukunun ana temellerinden biri, yukarıda da değinildiği gibi, özel mülkiyet ve bunun devamlılığıdır. Yani, kişilerin özel mülkiyetine tabi olan şeyler, yine özel mülkiyete tabi olacak şekilde ölümle başka kişilere intikal etmelidir, yoksa kamuya, yani devlete geçmemelidir. Eğer, ölümle mülkiyet sona erip, ölenin malları devlete intikal etseydi, önce, gerçek bir mülkiyet hakkından söz etmek mümkün olmazdı. Bu halde mülkiyet hakkı, kişinin ölümü ile sona eren bir intifa hakkından ibaret olurdu. İkinci olarak, miras yoluyla intikal etmeyen bir mülkiyet hakkı sosyal fonksiyonunu da yerine getirmezdi. Çünkü insan, sahip olduğu şeylerin, yakınlarına ya da is- 4

---

[1] Benzer tanımlar için bkz., *Kocayusufpaşaoğlu*, § 1, I; *Oğuzman*, Giriş, I.

[2] Eski SSCB ve diğer eski komünist ülkelerdeki miras hukuku sistemlerine ilişkin etraflı bilgi için bkz., *Kocayusufpaşaoğlu*, § 2, IV.

tediği kimselere kalacağını bildiği sürece bir şeyler edinebilmek için çalışır, üretici olur ve tasarruf yapar. Yakınlarına bir şey bırakabilmek insanın doğasında vardır. Bundan yoksun bırakılan bir kişi, artık sadece kendi ihtiyaçlarını karşılayacak kadar üretken olur ki, bu da, toplumun fakirleşmesi sonucunu doğurur. Kaldı ki, böyle bir arzu içinde bulunan bir insanın bu isteğini yerine getirmesine, miras yoluyla intikal yasağı engel olamaz. Çünkü, bu halde kişi, sağlararası tasarruflar yaparak, örneğin mallarını istediği kimselere hayatında bağışlayarak bu yasağı deler. Bu bakımdan malike, ancak, mallarını yakınlarına ya da istediklerine devir edebilme ve bu amacını, ölümden sonra da gerçekleştirebilme imkânının tanınması hâlinde gerçek bir özel mülkiyetten söz etmek mümkün olur[3]. Böylece, toplumun temeli olan aileye, devlete karşı belirli bir otonomi tanınmış olur. Özetle, miras hakkı ile özel mülkiyet hakkının birbirinden ayrılması mümkün değildir.

5 İtiraf etmek gerekir ki, mülkiyet hakkının miras yoluyla geçmesinin yararlı olmayan tarafları da vardır. Önce, intikal eden hazır bir malvarlığını yönetip çoğaltmak, kendi uğraşı ile malvarlığı edinmekten çok daha kolaydır. Böyle olunca da, fakir ailelerin çocukları, diğerlerine oranla, hayat yarışına, daha müsait olmayan şartlarla başlarlar. Bunun yanında bir malvarlığını miras yoluyla elde etme, kişileri tembelliğe itebilir. Kişiler, atalarının çalışarak oluşturdukları malvarlığını çoğaltmak için çalışmak yerine, onu tüketmeyi tercih edebilirler. Bundan da son tahlilde zarar görecek olan yine toplumdur[4].

6 Miras hukukunun gerekliliğini sadece özel mülkiyet açısından görmek yeterli değildir. Yukarıda da değinildiği gibi, ölenin, kişiye bağlı olanlar dışındaki alacak ve borçlarının da ölüm ile sona ermeyip, onun yerini alan kişilerde devam etmesi gerekir. Aksine bir anlayış, alışveriş hayatını felç eder. Çünkü, borçlunun ölümü hâlinde, karşısında, artık borcu ödeyecek bir muhatap kalmayacağı için, hiç kimse diğerine kredi açmazdı.

3. Miras hukukunun Anayasa teminatı altında olması

7 Anayasanın 35. maddesinin 1. ve 2. fıkralarına göre, *"Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bunlar ancak kamu yararı amacıyla kanunla sınırlanabilir"*.

8 Aynı hüküm, 1961 Anayasasının 36. maddesinin 1 ve 2. fıkralarında da bulunmaktaydı. Ancak, 1961 Anayasa Tasarısının 36. maddesinde miras hakkından söz edilmemekte, sadece mülkiyet hakkı düzenlenmekteydi. Miras hakkı, Kurucu Meclise verilen bir önerge ile maddeye eklenmiştir.

9 Maddenin, mülkiyet hakkı ile miras hakkını birlikte düzenlemesi, yukarıda da açıklandığı gibi, bu iki hakkın, özel mülkiyeti kabul eden bir sistemde, birbirinden ayrılmasının, biri olmadan, diğerinin olmasının tasavvur

---

[3] *Piotet*, § 1, I.
[4] *Koziol/Welser*, 284.

edilemeyeceğinin, Anayasa tarafından da kabul edildiğinin açık bir ifadesidir. Her iki hak da temel haklar ve hürriyetler arasında düzenlenerek garanti altına alınmışlardır. Acaba bu hüküm neyi ya da neleri garanti altına almaktadır? Bunun cevabını, benzer bir hüküm içeren Alman Anayasasının 14. paragrafı ile ilgili olarak Alman hukukunda ileri sürülen görüşleri gözönünde bulundurarak cevaplandırmaya çalışalım.

GG Art. 14 /I'e göre, *"Mülkiyet ve miras hakları teminat altındadır. İçerikleri ve sınırları kanunla belirlenir"*. Görüldüğü gibi, bu hüküm ile AY 35. arasındaki fark, sadece sınırlamanın kamu yararına olacağının GG'de öngörülmemiş olmasıdır. Ne var ki, Alman doktrininde de, getirilecek olan sınırlamanın, özel mülkiyet ve miras hakkını hiçe indirgiyecek biçimde olmaması gereği savunulmaktadır[5]. 10

Önce hüküm, miras hakkını, özel hukukun bir kurumu olarak korumaktadır. Yani, ölenin malvarlığının, onun ailesi ya da ölüme bağlı tasarruf ile tespit ettiği kişilere kalmasını garanti altına almakta; malvarlığına devletin el koymasını yasaklamaktadır. Bu sebeple, örneğin, devletin, bir kanunla, tüm hısımların mirasçılıklarını bertaraf edip, mirasın devlete kalacağına ilişkin bir kanun çıkartması Anayasaya aykırı olacaktır. Ya da böyle yapmamakla beraber, Anayasaya aykırı olmayan Veraset ve İntikal Vergisi Kanunundaki oranları, adeta terekenin müsaderesi niteliğinde sayılacak oranlara yükseltmesi de AY 35'e aykırı olacaktır[6]. 11

AY 35'in garanti altına aldığı ikinci husus, miras hürriyeti hakkıdır. Yani, kişinin, ölüme bağlı tasarruf yapma özgürlüğü de anayasal garanti altına alınmıştır. Böylece, yasal mirasçılarla birlikte, ölüme bağlı tasarrufla mirasa çağrılan kişilerin hakları da Anayasa tarafından temin edilmiştir[7]. 12

4. Miras hukukunun, Medenî Kanunun içindeki yeri ve sistematiği

Medenî Kanunun, sistematiği içinde Miras hukukuna verdiği yer, diğer Medenî Kanunlardan farklıdır. Şöyle ki, Alman Hukukunda, miras hukuku, modern Pandekt Hukukuna uygun olarak BGB'nin 5. kitabında, yani en sonda düzenlenmiştir. Avusturya Hukukunda, miras hukukuna ayrı bir kitap tahsis edilmemiş, eşya hukuku kitabında, mülkiyetin kazanılmasının bir yolu olarak düzenlenmiştir. 13

Oysa Türk/İsviçre Hukukunda, miras hukuku, aile hukukundan hemen sonra, fakat eşya hukukundan önce 3. kitap olarak yer almıştır. Miras hukununun, kimlerin mirasçı olacağı yönünden esas itibariyle hısımlığa dayandığı; öte yandan da ölenin malvarlığı ile yakın ilişkisi göz önünde tutulacak olursa, bu düzenleme biçimi daha uygundur. 14

---

[5] *Kipp/Coing*, § 1, I, 2; *Staudinger/Weber*, § 23; *Bortholomeyczik/Schlüter*, § 2, II, 4.
[6] *Kipp/Coing*, § 1, I, 2; *Bartholomeyczik/Schlüter*, § 2, II, 4.
[7] *Bartholomeyczik/Schlüter*, § 2, II, 4; ayrıca etraflı bilgi için bkz., *Kocayusufpaşaoğlu*, § 2, I, 9.

15 *Tuor*[8], BGB ile ZGB (MK) arasındaki bu farklı düzenlemeyi, kanunların, miras hukuku yönünden hareket noktalarındaki farklılık ile açıklamaktadır. Ona göre, BGB, malvarlığı ilişkisinden, yani hakkın konusundan hareket ettiği için, miras hukukunu 5. kitap olarak düzenlemiştir. Oysa ZGB (MK), malvarlığı haklarının sübjektif temeli, yani kişi ve aileden hareket ettiği için, miras hukukuna aile hukukundan hemen sonra yer vermiştir.

16 Miras Hukuku başlığını taşıyan üçüncü kitabın sistematiği şöyledir:

17	Birinci kısım	: Mirasçılar (MK 495 – 574)
18	Birinci bölüm	: Yasal Mirasçılar (MK 495 – 501)
19	İkinci bölüm	: Ölüme bağlı tasarruflar (MK 502 – 571)
20	Birinci ayırım	: Tasarruf ehliyeti (MK 502 – 504)
21	İkinci ayırım	: Tasarruf özgürlüğü (MK 505 – 513)
22	Üçüncü ayırım	: Ölüme bağlı tasarrufların çeşitleri (MK 514 – 530)
23	Dördüncü ayırım	: Ölüme bağlı tasarrufların şekilleri (MK 531 – 549)
24	Beşinci ayırım	: Vasiyeti yerine getirme görevlisi (MK 550 – 556)
25	Altıncı ayırım	: Ölüme bağlı tasarrufların iptali ve tenkisi (MK 557 – 571)
26	Yedinci ayırım	: Miras sözleşmesinden doğan davalar (MK 572 – 574)
27	İkinci kısım	Mirasın geçmesi (MK 575 – 682)
28	Birinci bölüm	: Mirasın açılması (MK 575 – 588)
29	İkinci bölüm	: Mirasın geçmesinini sonuçları (MK 589 - 639)
30	Birinci ayırım	: Koruma önlemleri (MK 589 – 598)
31	İkinci ayırım	: Mirasın kazanılması (MK 599 – 618)
32	Üçüncü ayırım	: Resmî defter tutma (MK 619 – 631)
33	Dördüncü ayırım	: Resmî tasfiye (MK 632 –636)
34	Beşinci ayırım	: Miras sebebiyle istihkak davası (MK 637 –639)
35	Üçüncü bölüm	: Mirasın paylaşılması (MK 640 – 682)
36	Birinci ayırım	: Paylaşmadan önce miras ortaklığı (MK 640 – 645)
37	İkinci ayırım	: Paylaşmanın nasıl yapılacağı (MK 646 – 668)
38	Üçüncü ayırım	: Mirasta denkleştirme (MK 669 – 675)

[8] *Tuor*, Einleitung N 1.

Dördüncü ayırım : Paylaşmanın tamamlanması ve sonucu (MK 676 – 682) 39

Belirtmek gerekir ki, miras hukukuna ilişkin münferit hükümlere, Medenî Kanunun diğer kitaplarında da rastlanır. Bunların üzerinde yeri geldikçe durulacaktır. Asıl önemli olan, mirastan doğan ilişkilere, MK 5 aracılığıyla Borçlar Kanunundaki genel hükümlerin uygulanabilmesidir[9]. Ancak, Borçlar Kanunundaki bir hükmün miras hukukuna uygulanabilmesi için, Medenî Kanunun diğer kitaplarına uygulanabilmesinde olduğu gibi, iki şartın bulunması gerekir. Bunlardan birincisi, miras hukuku kitabında o konuya ilişkin bir hükmün bulunmamasıdır. İkinci şart ise, uygulanmak istenen hükmün miras hukukunun bünyesine ve niteliğine aykırı olmamasıdır. Miras hukukunda özel düzenleme bulunmamakla beraber, Borçlar Kanunundaki hüküm, miras hukukunun bünye ve niteliğine uygun değilse, uygulama söz konusu olamaz. Örneğin red beyanının irade bozukluğu sebebiyle iptaline, Borçlar Kanunundaki irade bozukluğuna ilişkin hükümler (BK 30 vd) uygulanabilir. Çünkü bu konuda hem miras hukukunda özel bir düzenleme yoktur, hem de bu hükümlerin uygulanmasında miras hukukunun bünyesine bir aykırılık bulunmamaktadır. Buna karşılık, bir ölüme bağlı tasarrufun irade bozukluğu sebebiyle iptaline Borçlar Kanunu hükümleri uygulanamaz. Çünkü bu husus, MK 504'de özel olarak düzenlenmiştir. 40

II. MİRAS HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI

1. Miras

Miras, bir kimsenin ölümü ile mirasçılarına geçen özel hukuk ilişkilerinin tümünü ifade eder, yani tereke anlamına gelir. 41

2. Mirasbırakan

Bununla, ölümü ile, kendisine ait özel hukuk ilişkilerinin hukuki akıbetinin düzenlendiği kişi ifade edilmektedir. Ölüm, sadece insanlar için söz konusu olabildiğinden, mirabırakan da sadece gerçek kişi olabilir. Ölüme bağlı bir tasarrufun yapılmasının söz konusu olduğu hallerde, mirasbırakan yerine vasiyetçi terimi de kullanılır. 42

3. Mirasçı

Mirasbırakanın terekesi üzerinde *küllî halef sıfatıyla* hak sahibi olan kişidir. Mirasçılar, mirasa çağrılmaları, yani mirasçı olmalarının temelinde yatan sebebe göre, yasal ve atanmış (kanunî ve mansup, iradî) mirasçı olmak üzere ikiye ayrılırlar. Eğer mirasçı kanun (yasa) gereği mirasa çağrılmaktaysa, *yasal mirasçılıktan*; mirasbırakanın iradesi ile mirasa çağrılmaktaysa (mirasbırakan tarafından atanmaktaysa), *atanmış mirasçılıktan* söz edilir. Yasal mirasçılar arasında bir de *saklı paylı (mahfuz hisseli) mirasçı-* 43

[9] *Escher*, Einleitung N 7.

lar denilen daha küçük bir grup vardır. Bunlar, yine kanun gereği mirasa çağrılırlar, fakat mirasbırakan kendilerine, muhakkak miras paylarının belirli bir bölümünü bırakmak zorundadır[10].

44 Mirasbırakandan farklı olarak, mirasçı, hem gerçek hem de tüzel kişi olabilir. Ancak bu iki kişilik yönünden mirasçı olmada yine de bir fark vardır. Şöyle ki, gerçek kişiler hem yasal hem de atanmış mirasçı olabilirlerken; tüzel kişiler, devlet hariç, sadece atanmış mirasçı olabilirler. Devlet, hiçbir mirasçı bırakmadan ölen kişinin MK 501'e göre, yasal mirasçısıdır. Ancak, bunun yanında, devletin, atanmış mirasçı olmasına da bir engel yoktur.

45 Yasal ve atanmış mirasçı ayırımı, terekenin ya sadece yasal ya da sadece atanmış mirasçılara kalacağı anlamına gelmez. Başka bir deyiş ile, münferit bir olayda, tereke üzerindeki hak sahipleri , sadece yasal ya da sadece atanmış mirasçılar olabilecekleri gibi; bunların her ikisinin birlikte de mirasa çağrılmaları da mümkündür. Şöyle ki:

46 a) Mirasbırakanın, tereke üzerinde küllî halefiyeti gerektirecek ölüme bağlı tasarrufta bulunmadığı hallerde, miras sadece yasal mirasçılara geçecektir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur: *terekenin sadece yasal mirasçılara geçmesi için, mirasbırakanın hiç bir ölüme bağlı tasarrufta bulunmaması değil, küllî halefiyeti gerektirecek bir tasarrufta bulunmamış olması, yani mirasçı atamamış olması gerekir*. Mirasbırakanın, sadece muayyen mal bırakmalardan (vasiyet) oluşan bir vasiyetname yapmış olması hâlinde de, tereke tümüyle sadece yasal mirasçılara geçer. Çünkü kendilerine belirli mal bırakılan kişiler küllî halef değildirler[11].

47 b) Mirasbırakan, hiç bir saklı paylı mirasçısı olmadığından, bir ya da bir kaç kişiyi terekesinini tümü için mirasçı atarsa, miras sadece atanmış mirasçılara geçer.

48 c) Mirasbırakanın, terekesinin belirli bir oranı için mirasçı ataması hâlinde, geri kalanı yasal mirasçılara ait olacaktır. İşte bu halde, hem yasal hem de atanmış mirasçılar birlikte tereke üzerinde hak sahibi olurlar.

49 Yasal mirasçılık Cermen Hukukunun, mirasın aileye kalması prensibinin bir yansımasıdır. Bunun aksi olan atanmış mirasçılık ise Roma Hukukundan kaynaklanır. Çünkü, Roma Hukukunda, bir kimsenin ölümünden sonrası için, malvarlığının akıbetini istediği gibi düzenleyebilmesi, ölenin yakınlarının korunması gerekmediği görüşü kabul edilmişti.

50 Ancak her iki görüşte de zaman içinde yumuşamalar olmuştur. Örneğin, yasal

---

[10] Etraflı bilgi için bkz., aşağıda, § 18 vd.
[11] Bkz., aşağıda, § 16, II.

mirasçılığa dayanan Cermen Hukukunda, zamanla yasal intikalin yanında, mirasbırakanın iradesine dayanan intikale de yer verilmiştir. Aynı şekilde, başlangıçta, ölüme bağlı tasarruflar yönünden tam bir serbestiyi kabul eden Roma Hukukunda, zamanla, hısımlara asgarî bir şey bırakmayan ölüme bağlı tasarruflar ahlâka aykırı görülmeye başlanmıştır[12].

Türk Hukukunda yasal mirasçılığın mı yoksa atanmış mirasçılığın mı asıl olduğu meselesine gelince; yeni düzenlemeden önce bu durum tartışmalı olmakla beraber, baskın görüş yasal mirasçılığın asıl olduğu yönündeydi. Azınlıkta kalan görüş ise, asıl olanın atanmış mirasçılık olduğunu ileri sürüyordu[13]. 51

Ancak yeni Medenî kanunda *fikrimce* durum çoğunluğun görüşünün tersine dönmüştür. Başka bir deyiş ile, bugün asıl olan atanmış mirasçılık, istisna ise yasal mirasçılıktır. Önce, eşinki bir yana bırakılacak olursa, saklı pay oranları indirilmiştir. Bunun, mirasbırakana daha fazla tasarruf özgürlüğü tanımak amacıyla yapıldığı, *"... saklı payları düzenleyen 506ncı maddesinde mirasbırakanın tasarruf özgürlüğünün genişletilmesi yönündeki eğilimler göz önünde tutularak saklı pay oranları yeniden belirlenmiştir"* diyen Gerekçeden açık olarak anlaşılmaktadır[14]. Bu görüş. MK 514/II'ye de yansıyarak, kanunî temelini bulmuştur. MK 514/II'ye göre, *"Mirasbırakanın üzerinde tasarruf etmediği kısım yasal mirasçılara kalır"*. Bu da göstermektedir ki, mirasçılar ancak mirasbırakan tarafından tasarrufta bulunulmadığı hâllerde ve kadarıyla mirastan pay alabileceklerdir. Bunun anlamı, saklı paylı olmayan mirasçılar, mirasbırakanın, terekesinin tamamı üzerinde tasarrufta bulunması hâlinde, mirastan hiç pay alamayacaklardır. Saklı paylı mirasçıların varlığı, bu görüşte bir değişiklik yapmaz. Çünkü önce, saklı paylı mirasçıların kapsamı çok dardır ki, bu bile asıl olanın atanmış mirasçılık olduğunu göstermeye yeterlidir. Bunun yanında, saklı paylı mirasçıların varlığı bile, mirasbırakanın tasarruf özgürlüğünü ortadan kaldırmamakta, sadece sınırlamaktadır. Kaldı ki, mirasbırakanın, saklı paya tecavüz eden tasarrufları kesin hükümsüz olmamakta, sadece saklı paylı mirasçı isterse tenkis edilmektedir (MK 560 vd). Bu da asıl olanın atanmış mirasçılık olduğunu gösterir[15]. 52

Nihayet 2007 yılında MK 505 ve 506'da yapılan bir değişiklik ile[15a] kardeşlerin saklı payları kaldırılmış, böylece saklı paylı mirasçıların kapsamı daha da daraltılmış, mirasbırakanın terekesi üzerindeki tasarruf imkânı genişletilmiştir. Bu da kanun koyucunun amacının, iradî mirasçılık yönünde olduğunun bir göstergesidir. 53

---

[12] *Piotet*, § 1, III, 5.
[13] Bu tartışmalar için bkz., *Dural/Öz (Dural)*, c. 1, Giriş, II, 3 ve orada atıf yapılan yazarlar.
[14] Bkz., Gerekçe, 315.
[15] *Çağa*, 59 – 60.
[15a] RG 04.05.2007, sayı 26518.

54 Son olarak belirtelim ki, atanmış mirasçılık terimi, mirasbırakanın tasarruf özgürlüğü yönünden dar bir terimidir. Çünkü, mirasbırakan, terekesi üzerinde, sadece mirasçı atama yoluyla değil, muayyen mal bırakma yoluyla da tasarrufta bulunabilir. Bu ise bir mirasçı atama değildir. Ne var ki, bu terim ve eş anlamlıları (mirasçı nasbı, iradî mirasçılık) öteden beri Türk hukuk diline yerleşmiş olduğu için, burada da kullanılmaktadır. Bu bakımdan, buradaki atanmış mirasçı terimini *dar ya da teknik anlamda mirasçı*, yani sadece mirasbırakanın küllî halefi karşılığı değil de, geniş anlamda mirasçıları, yani mirasbırakanın kendisine cüzî halef ya da belirli mal[16] alacaklısı (vasiyet alacaklısı, musaleh) atadığı halleri de kapsayacak, bir başka deyişle, mirasbırakanın terekesi üzerindeki her türlü tasarruflarını kapsayacak şekilde geniş anlamak gerekir.

4. Tereke

55 Mirasbırakanın ölümüyle mirasçılarına geçen özel hukuk ilişkilerinin tümüne tereke denir[17]. Ters bir deyiş ile, tereke, mirasbırakanın şahsına bağlı olmayan, bütün hukukî ilişkilerini ifade eden bir kavramdır[18]. Miras kelimesinin de sık sık bu anlamda kullanıldığı yukarıda belirtilmişti[19].

56 Ölüm ile birlikte mirasçılara malvarlığı geçeceği için, kural olarak tereke, malvarlığına eşit bir kavramdır. Bu sebepledir ki, Medenî Kanunda bazen tereke yerine malvarlığı terimi kullanılmıştır (örnek olarak bkz., MK 576).

57 Yukarıda da değinildiği gibi, tereke, kural olarak ölenin malvarlığına eşittir. Ancak, yine sık sık değinildiği gibi, ölümle birlikte, mirasçılara, mirasbırakanın, sadece devir ve intikal edebilen özel hukuk ilişkileri geçer, onun şahsına bağlı olanlar ölüm ile sona erer. Bu bakımdan, bazen, ölenin malvarlığı ile mirasçılara geçen terekesi arasında fark olabilir. Bunun aksine, ölenin malvarlığında bulunmayıp, sadece terekesinde bulunabilen hukukî ilişkiler de vardır. Nihayet üçüncü bir ihtimal de, mirasçıların, miras yoluyla değil de, sırf ölüm sebebiyle kazanabilecekleri bazı haklar söz konusu olabilir. Bu üç duruma kısaca göz atalım.

a) Malvarlığında bulunan, fakat terekede yer almayan hukuki ilişkiler

58 Bunlar, mirasbırakanın şahsına bağlı olan, onun ölümü ile sona eren, hukukî ilişkiler, haklar ve borçlardır. Örneğin, MK 797'ye göre, intifa hak-

---

[16] Bu terimin eleştirisi için bkz., aşağıda, III, 2.

[17] *Kocayusupaşaoğlu*, § 3, II, ve dn. 4'de anılan yazarlar; *Oğuzman*, Giriş, I, 9; *Serozan/Engin*, Miras Hukuku, 3. Baskı, İstanbul 2014, § 1, 143.

[18] *Escher*, Einleitung, N 5.

[19] Bkz., yukarıda bu bölüm 1.

kı, hak sahibinin ölümü ile sona ereceğinden terekede yer almaz, dolayısıyla da mirasçılara geçmez. Aynı şey, oturma (sükna) hakkı için de söz konusudur (MK 823).

Ölenin şahsına bağlı hakların terekede bulunmayacağı kuralına, 3444 59
sayılı kanunla eski Medenî Kanuna eklenen 24a maddesinin 3. fıkrası bir istisna getirmişti. Söz konusu hükme göre, mirasbırakanın manevî tazminat isteme hakkı, onun tarafından sağlığında ileri sürülmemiş olsa bile, terekede yer alıp mirasçılara geçiyordu. Bunun doğru bir hüküm olup olmadığı çok tartışılmıştı[20]. Baskın görüş, bu hükme karşı çıkıyordu.

Yeni Medenî Kanun, baskın görüşe katılarak, bu hükmü 25. maddenin 60
4. fıkrasında değiştirmiştir. Yeni düzenleme, *"Manevî tazminat istemi, karşı tarafça kabul edilmiş olmadıkça devredilemez; mirasbırakan tarafından ileri sürülmüş olmadıkça mirasçılara geçmez."* şeklindedir. Bu hükme göre, bugün, artık, mirasbırakana ait manevî tazminat isteme hakkı, ancak mirasbırakan tarafından sağlığında ileri sürülmüşse, yani bir malvarlığı değeri olmuşsa, mirasçılara geçer. Belirtelim ki, mirasbırakan tarafından manevî tazminat isteminin ileri sürülmesinin muhakkak dava yoluyla olması gerekmez. Bunun için, *"...saldırıya uğrayan kişinin, bunu ortaya koyan ve kanıtlanabilir bir iradesi yeterli görülmüştür"*[21].

Manevî tazminat konusunda önemle belirtilmesi gereken husus şudur: 61
mirasçılara miras yoluyla geçmeyen, mirasbırakanın bizzat kendisine ait olan manevî tazminat talebidir. Mirasbırakanın ölümü dolayısıyla doğrudan mirasçılara ait olan manevî tazminat hakkı, aşağıda görüleceği gibi[22], miras yoluyla intikal etmeyen, ölüm sebebiyle mirasçıların şahsında doğan bir haktır. Bir örnekle açıklayacak olursak; bir trafik kazasında yaralanan mirasbırakanın BK 56'ya göre manevî tazminat isteme hakkı vardır. Onun bu talebinin mirasçılara geçmesi için, MK 25/IV'e göre, sağlığında ileri sürülmüş olması gerekir. Aynı madde, ölüm hâlinde ölenin ailesine de (bunu OR Art. 47'ye göre ölenin yakınları olarak anlamak gerekir), ölüm sebebiyle duydukları acı nedeniyle, manevî tazminat isteme hakkı vermiştir. İşte bu hak, terekede yer almayan, ölüm sebebiyle bizzat mirasçıların (hatta mirasbırakana yakın olan fakat mirasçı olmayan kişilerin de) şahsında doğan bir haktır, yoksa ölene ait olup da onlara geçen değil...

Mirasbırakanın şahsına bağlı olan haklar gibi, onun kişisel niteliklerinin 62
önemli olduğu borç ilişkileri de ölüme birlikte artık terekede yer almazlar. Örneğin BK 441/I'e göre, işçinin ölümü ile hizmet (iş) sözleşmesi sona

---

[20] Tartışmalar için bkz., *Dural/Öz (Dural)*, c. I, Giriş, II, 4
[21] Gerekçe, 338.
[22] Bkz., aşağıda, c.

erer. Yani, mirasbırakanın malvarlığının pasif bölümünde yer alan iş yapma borcu, terekede yer almaz, dolayısıyla da mirasçılara geçmez. Buna karşılık, aynı maddenin ikinci fıkrasına göre, işverenin ölümünde iş sözleşmesinin sona ermesi, yani işverenin ivaz borcunun terekede yer almaması başlıca onun şahsı nazara alınarak yapılmış olup olmamasına bağlıdır. Eğer, edim yönünden işverenin şahsı önemli değilse, hizmet sözleşmesi onun ölümü ile sona ermez; aksi durumda ise sona erer. Buna paralel bir düzenleme, eser (istisna) sözleşmesi için de öngörülmüştür. BK 486/I'e göre, "Müteahhit öldüğü.... takdirde mukavele müteahhidin şahsı nazara alınarak yapılmış ise istisna akti münfesih olur". Bunun gibi, vekâlet sözleşmesi de taraflardan birinin ölümü ile sona erer. Ne var ki, BK 513/II'ye göre bu, emredici bir hüküm olmayıp, taraflar aksini kararlaştırabilir ya da işin niteliğinden, ölümden sonra da devam edeceği (mandatum post mortem) anlaşılabilir.

63 Yukarıdaki açıklamalardan anlaşılacağı gibi, borç ilişkisinin sona ermesi ileriye etkilidir. Ölümden önce muaccel olup da, malvarlığında alacak olarak yer almış haklar, terekede bulunurlar. Örneğin, ölen işçinin, işveren tarafından ödenmemiş olan muaccel ücret alacağı, sözleşme, işverenin şahsı nazara alınarak yapılmış olsa bile, mirasçılara geçer ve onlar tarafından istenebilir.

b) Malvarlığında bulunmayan, fakat terekede yer alan hukukî ilişkiler

64 Kural olarak, malvarlığında yer almayan hukukî ilişkiler terekede de yer almazlar. Ancak, istisnaen, malvarlığında yer almayan, fakat maddî değeri olan haklar ve borçlar ile bazı kişivarlığı haklarının terekede bulunması mümkündür.

65 Malvarlığında yer almayan, fakat terekede bulunabilen malî değeri olan haklara örnek olarak, denkleştirmeye tabi malları gösterebiliriz. MK 669'a göre, mirasbırakanın, miras hissesine mahsuben, sağlığında mirasçılarına yapmış olduğu belirli nitelikleri taşıyan kazandırmalar, onun malvarlığından çıkmışlardır. Ancak, aşağıda açıklanacağı gibi[23], bunlar terekenin hesaplanmasında göz önünde bulundurulurlar, yani terekeye eklenirler.

66 Gene, evlilikte yasal mal rejimi olan "edinilmiş mallara katılma" rejiminin ölümle sona ermesinde, sağ kalan eşe karşı MK 236 uyarınca doğan "artık değere katılma alacağı", doğrudan terekede mirasçıların alacak hakkı olarak doğmuştur.

67 *Piotet*, denkleştirmeye tabi kazandırmaların, terekeye ancak bir paylaşma sözkonusu ise ekleneceği görüşündedir[24]. Yazar, tereke ile *paylaşma masası (Teilungs-*

[23] Bkz., denkleştirme bahsi. Denkleştirmeye (iadeye) tabi kazandırmaların, zaten tereke bulunduğuna ilişkin olarak bkz., *Kocayusufpaşaoğlu*, § 31, III, 1.

[24] *Piotet*, § 2, I, 7.

masse) arasında bir ayırım yapmakta ve mirası aynı sırada paylaşacak birden fazla mirasçı varsa, paylaşma masası terimini kullanmaktadır. İşte, *Piotet*'ye göre, mirasçılara, miras hisselerine mahsuben yapılmış sağlararası kazandırmalar, ancak paylaşma olacaksa terekeye dahil edilirler. Tek bir mirasçının söz konusu olduğu hallerde, denkleştirmeye gidilmeyecektir. Yeri gelmişken belirtelim ki, *Piotet*[25], saklı payların hesaplanmasına esas olacak tereke için, *mahfuz hisse hesaplama masası (Pflichtteilberechnungsmasse)* terimini kullanmakta ve bu masanın, fiilen mevcut tereke ile sağlararası tenkise tâbi tasarruflardan oluştuğunu söylemektedir. Doğrusu, bu tür ayırım ve terimlendirmenin pratik değerinin ne olduğunu anlamak güç gözüküyor.

Yukarıda da değinildiği gibi, miras yoluyla, mirasçılara geçecek olan haklar malvarlığı haklarıdır. Bu sebeple, kişiler hukuku ya da aile hukukuna ilişkin hak ve borçlar mirasçılara intikal etmez. Örneğin, boşanma davası sırasında eşlerden birinin ölümü ile boşanma davası sona erer, yoksa ölenin mirasçıları davaya devam edemezler. Aynı şekilde, eşlerden birinin diğerine karşı olan nafaka alacağı hakkı[26] ya da borcu da mirasçılara geçmez. Dernekteki üyelik hakkı da mirasçılara geçmeyen, kişiler hukukunda doğan hakka örnek olarak gösterilebilir. 68

Bununla beraber, kişivarlığına dahil olup da istisnaen mirasçılara geçen haklar da vardır. Örneğin MK 159'a göre, mirasbırakanın ölümünden önce açtığı, evlenmenin nisbî butlanı davasına mirasçılar devam edebilirler. Bunun gibi MK 301/II'ye göre, babalık davası, babanın ölmüş olması hâlinde mirasçılarına karşı açılabilir. Yine MK 298/II'ye göre, tanımanın iptali davası, tanıyan kişinin ölmüş olması hâlinde onun mirasçılarına karşı açılır. Bunun gibi, tanınan çocuğun ölmesi hâlinde, bu dava mirasçıları tarafından açılır (MK 298/I)[27]. 69

c) Ölüm sebebiyle doğduran doğruya mirasçıların şahsında doğan haklar

Buradaki durum şudur: öyle bazı haklar vardır ki,bunlar, önce mirasbırakana ait olup da miras yoluyla mirasçılara geçmezler. Bunlar, ölüm sebebiyle doğrudan doğruya mirasçıların, hatta bazen mirasçı olmayan kişilerin şahsında doğarlar. Başka bir deyiş ile, ölüm, bu hakların mirasçıların şah- 70

---

[25] *Piotet*, § 2, I, 7.

[26] *"Mirasbırakanın sağlığında faydalanmadığı nafaka hakkı mirasçılarına geçmez. Fakat, hak sahibi nafaka davası açtıktan sonra, ölmüşse, mirasçılar külli halef sıfatıyla davayı yürütebilirler. Murisin davayı açtığı günden ölümüne kadar olan nafaka hakkı nafaka davası açılmış olmakla onun mamelekine giren bir hak niteliğini almıştır. Mirasçılar bu devre içindeki, yani dava tarihi ile mirasbırakanın ölümü arasındaki zaman için nafaka isteyebilirler. Nafaka hakkı mirasçılara geçmediğinden,mirasbırakanın ölümünden sonraki devre için mirasçıların talep hakkı yoktur"* (YKD 1975, c. II, 47 vd). Ayrıca bkz., *Serozan*, Uluocak'a Armağan, 311).

[27] Farklı bir görüş için bkz. *Escher*, Einleitung N 5 ve 6.

sında doğmasının sebebidir, yoksa bu haklar terekede yer almazlar. Bu yüzden, mirasçı olan kişi, bu sıfatı kazanmasa dahi, söz konusu haklara sahip olur.

71 Bu hakların bir kısmı kamu hukukundan doğarlar. Örneğin dul ve yetim aylıkları gibi... Ancak özel hukuktan kaynaklanan bu tür haklar da vardır. Bunlara en güzel örnek BK 45'deki destekten yoksun kalma tazminatı ile BK 47'deki, ölenin yakınlarına tanınmış olan manevî tazminat hakkıdır.

5. Ölüme bağlı tasarruf

72 Miras hukukunun birinci kısmının ikinci bölümünde düzenlenmiş olan ölüme bağlı tasarruflar iki anlama gelir. Bunlardan birisi, mirasbırakanın ölümünden sonra yerine getirilmesini istediği son arzularıdır. Bunlara *maddî anlamda ölüme bağlı tasarruf* denir. Bunların en klâsik örnekleri, mirasçı atanması ve vasiyettir. Ölüme bağlı tasarrufun ikinci anlamı ise, mirasbırakanın, son arzularına ilişkin iradesini açıklarken uyması gereken şekil kurallarıdır ki, *bunlara da şeklî anlamda ölüme bağlı tasarruflar* denir. Şeklî anlamdaki ölüme bağlı tasarruflar, vasiyetname ve miras sözleşmesi olmak üzere iki türlüdür.

73 Medenî Kanun, maddî anlamda ölüme bağlı tasarrufları Miras hukuku kitabının birinci kısmının, ikinci bölümünün üçüncü ayırımında *ölüme bağlı tasarrufların çeşitleri* (MK 514 – 530); şeklî anlamda ölüme bağlı tasarrufları ise aynı yerde dördüncü ayırımda *ölüme bağlı tasarrufların şekilleri* başlığı altında (MK 531 – 549) düzenlemiştir. Her iki tür tasarruf üzerinde de ileride durulacaktır[28].

III. MİRAS HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMI OLARAK KÜLLÎ HALEFİYET VE SONUÇLARI

1. Küllî halefiyet kavramı

74 Küllî halefiyet denince, bundan, *bir malvarlığının, bütün olarak, aktifi ve pasifiyle, tek bir işlemle (hukukî olayla) bir kimseden başka bir kimseye geçmesi anlaşılır.* Başka bir deyişle, küllî intikalde, cüzî (halefiyet) intikalden farklı olarak, intikalin konusu olan şeye göre devir için gerekli olan işlemlerin ayrı ayrı yapılmasına gerek yoktur. Malvarlığına dahil taşınır taşınmaz mallar, alacak hakları ve borçlar tek bir hukukî işlem ile devir alana geçer.

75 Cüzî halefiyetten farklı olarak, küllî halefiyet, sadece kanunda belirtilen

[28] Bkz., aşağıda, § 9 ve § 15.

hâllerde söz konusu olabilir. Bu hâllerin en önemlisi kuşkusuz MK 599'da düzenlenmiş olan mirasın kazanılması (intikali) dir. Söz konusu hükme göre, *"Mirasçılar, mirasbırakanın ölümü ile mirası bir bütün olarak, kanun gereği kazanırlar. Kanunda öngörülen ayrık durumlar saklı kalmak üzere mirasçılar, mirasbırakanın aynî haklarını, alacaklarını, diğer malvarlığı haklarını, taşınır ve taşınmazlar üzerindeki zilyetliklerini doğrudan doğruya kazanırlar ve mirasbırakanın borçlarından kişisel olarak sorumlu olurlar"*. Bu hükümden hareketle, mirasın küllî intikalinin sonuçlarını böylece sıralayabiliriz:

a) Mirasbırakanın küllî halefleri, teknik ya da dar anlamda mirasçılarıdır. Bu açıdan mirasçının yasal ya da atanmış olması bir fark yaratmaz (MK 599 /III). Vasiyet alacaklıları, teknik anlamda mirasçı olmadıkları için küllî halef değildirler[29]. 76

b) Mirasbırakana ait olan her türlü hak ve zilyetliğin hukuki sonuçları, yani terekenin sadece aktifi değil, borçları da (pasif kısmı) mirasçılara geçer. 77

Alman Hukukunda, mirasbırakanın borçlarının küllî halefiyet yoluyla mirasçılara geçip geçmeyeceği tartışmalıdır. Bunun sebebi de, mirasta küllî halefiyeti düzenleyen BGB § 1922'nin, malvarlığından söz etmesi ve baskın görüşün de borçları, miras hukuku anlamında malvarlığına dahil saymamasıdır[30]. Ancak, yine bazı yazarlar, tereke borçlarından mirasçıların sınırsız sorumlu olmasını öngören. BGB § 967'den hareketle, bunun küllî intikalin bir sonucu olduğunu belirtirler[31]. *Escher*'e göre[32], MK 599/II (eski MK 539/I), mirasın (terekenin) kapsamına açıkca borçların da girdiğinin belirtilmiş olması, bu tür tartışmaların bizde ortaya çıkmasını engellemektedir. 78

c) Küllî halefiyet prensibinin bir sonucu olarak, terekeye dahil olan aynî haklar, alacak hakları, zilyetliğe bağlı sonuçlar ve borçlar, bir tek olayla, yani ölüm ile kendiliğinden mirasçılara geçer. Her bir hak türü için ayrı ayrı işlem yapılmasına gerek olmadığı gibi, alacakların geçmesi için temlike, borçların geçmesi için de nakle gerek yoktur. 79

d) Küllî halefiyetin diğer bir sonucu da, terekenin bir bütün olarak mirasçılara geçmesidir. Terekeye dahil olan bazı mal ya da hakların (örneğin Cermen Hukukunda olduğu gibi, taşınır ve taşınmazların) ayrı ayrı intikal etmeleri *(Sondererbfolge)* bizde kabul edilmemiştir. 80

Kural bu olmakla beraber, bazı özel kanunlarda belirtilen hakların, terekeden ayrılarak, özel olarak intikalleri düzenlenmiştir. Bunun en bariz örneği, BK 356 ve ye- 81

---

[29] Bkz., aşağıda, § 15, III, 2.

[30] Örnek olarak bkz., *Bartholomeyczik/Schlüter*, § 6, II ve orada anılan yazarlar; ayrıca, *Escher*, Art. 566 Vorbem. 2.

[31] Bu yazarlara örnek olarak bkz., *Kipp/Coing*, § 91, II.

[32] *Escher*, Art. 500, Vorbem 2; aynı görüşte, *Kocayusufpaşaoğlu*, § 4, I, 2.

rine geçtiği 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanunun 13. maddesidir. Bu hükme göre, kiracının ölümü hâlinde, kira ilişkisi bütün hak ve borçlarıyla, kiralanan yer işyeri ise, bu işe devam edecek olan mirasçılara; konut ise, ölenle birlikte oturan kişilere geçer. Başka bir deyişle, terekenin tümünden kira ilişkisi ayrılır ve özel intikal prensibine göre, yukarıda belirtilen kişilere geçer. Kanunun bu açık ifadesi karşısında, işyerleri yönünden bu hükmün uygulanabilmesi için, işe devam eden kişinin mirasçı olması zorunluyken; konut olarak kullanılan yerlerde bu şart aranmamış, sadece (ister mirasçı olsun, ister olmasın) ölen ile birlikte oturma yeterli görülmüştür[33].

82 e) Küllî halefiyet prensibinin uygulanması açısından, mirasçı sayısının önemi yoktur. Birden fazla mirasçının bulunduğu hallerde tereke, yine küllî halefiyet prensibine göre, onların oluşturdukları *miras ortaklığına* geçer (MK 640). Bu halde mirasçılar, tereke üzerinde elbirliği ile (tam) hak sahibi olurlar ve her birinin, paylaşmaya yönelik bir payı vardır.

83 Dikkat edilirse, mirasçıların tereke üzerinde elbirliğiyle mülkiyet haklarından değil, elbirliği ile haklarından söz edilmiştir. Bunun sebebi, sık sık değinildiği gibi, tereke, sadece mülkiyet hakkına konu olan mallardan oluşmaz. Bunun yanında, sınırlı aynî haklar, alacak hakları, fikrî haklar, hatta zilyetliğin hukuki sonuçlarına ilişkin durumlar da vardır (MK 599/II). Bu bakımdan, doktrinde bu durum ve tereke üzerindeki hakkın, kanundan doğan ve aynî haklara çok yaklaşan sui generis niteliğinden hareket eden yazarlar, eşya hukukunun bir terimi olan mülkiyet yerine, miras hukukuna özgü *tam hak (Vollrecht)* terimini kullanmayı tercih etmektedirler[34].

84 f) Terekedeki borçlar da, yukarıda da değinildiği gibi, MK 599/II'ye göre, küllî intikal prensibine uygun olarak mirasçılara geçer, Mirasçılar, aşağıda görüleceği gibi[35], şahsen ve sınırsız sorumludurlar. Bunun anlamı, tereke borçlarını, sadece kendilerine intikal eden tereke mevcudu ile *(cum viribus hereditatis)* değil de, şahsî malvarlıkları ile de karşılamak zorunda olmalarıdır.

85 Kural, mirasçıların, tereke borçlarından kendi malvarlıkları ile de sorumlu olmaları ise de, bu kuralın iki istisnası vardır. Bunlardan birincisi, devletin mirasçı olduğu haldir. MK 631/II'ye göre, devlet, tereke borçlarından, sadece *miras yoluyla edindiği değerler ölçüsünde* sorumludur. İkinci istisna, terekenin resmen tasfiye edildiği haller için MK 632/III'de öngörülmüştür. Bu hâlde mirasçılar tereke borçlarından sorumlu olmazlar[36].

86 g) Birden fazla mirasçı varsa, bunlar tereke borçlarından MK 681/I'e göre müteselsil olarak sorumludurlar. Miras hukukunda müteselsil sorumluluğun ne şekilde uygulanacağı özel olarak düzenlenmediği için, mirsaçıların sorumluluğuna MK 5 aracılığıyla BK 141 vd. hükümleri uygulanır.

---

[33] Başka istisnalar için bkz., *Kocayusufpaşaoğlu*, § 4, I, 2.

[34] Örnek olarak bkz., *Escher*, Einleitung, N 4; *Oğuzman*, 69; *Ayiter/Kılıçoğlu*, 193; *Kocayusufpaşaoğlu*, § 4, I, 1; *İmre/Erman*, 606/607.

[35] Bkz., aşağıda, § 35, II, 3.

[36] Bkz., aşağıda § 33.

Bu bakımdan burada BK 162/II anlamında kanundan doğan bir teselsül vardır[37]. Yine örneksemeyle uygulamanın bir sonucu olarak, alacaklı, BK 142'ye göre, alacağının tamamını, dilerse bütün mirasçılardan, dilerse onlardan birinden isteyebilir. Borcun tamamının mirasçılardan biri tarafından ödenmesi hâlinde, ödeyen, diğer mirasçılara payları oranında rücu edebilir (BK 167).

Müteselsil sorumluluk, bir ölçüde, elbirliğiyle hak sahipliğinin bir so- 87
nucu ise de, kanun bunu, bir yandan genişletmiş, öte yandan da buna son verme imkânı tanımıştır. MK 681/II, mirasçıların müteselsil sorumluluğunu, paylaşmadan itibaren beş yıl devam ettirerek genişletmiştir. Eğer alacak, paylaşmanın sona ermesinden daha sonraki bir tarihte muaccel oluyorsa, beş yıllık süre, muacceliyet tarihinden itibaren işlemeye başlar. Buna karşılık, MK 681/I'e göre, alacaklının, alacağının mirasçılar arasında paylaşılmasına ya da bir mirasçı tarafından yüklenilmesine açık ya da örtülü rıza göstermesi hâlinde, mirasçılar arasındaki teselsül sona erer[38].

2. Küllî halefiyetin istisnası: cüzî halefiyet hali

Miras hukukunda, küllî halefiyetin yanında istisna olarak cüzî halefiyet 88
de öngörülmüştür. Burada, tereke üzerinde, tam hak değil de, terekeye dahil münferit şeyler üzerindeki münferit hakların geçişi söz konusudur[39]. Cüzi halefiyet yoluyla tereke üzerinde hak sahibi olan kişiler, *vasiyet alacaklıları (musaleh)* dır.

Vasiyette (muayyen mal bırakma) mirasbırakan, bir ölüme bağı tasarruf 89
ile, terekesine dahil belirli bir mal ya da malvarlığı değerini, bir üçüncü kişiye ya da miras hakkından bağımsız olarak mirasçılardan birine bırakmaktadır. Mirasbırakanın, arkadaşı A'ya otomobilini ya da kızı B'ye, miras payından bağımsız olarak 10.000 TL bırakması, birer vasiyettir. Vasiyet alacaklıları, küllî halef olan mirasçılardan farklı olarak, tereke üzerinde bir tam hak elde etmeyip, sadece kendilerine vasiyet edilen şeye ilişkin mirasçılara karşı bir alacak hakkı elde ederler. Onlar, vasiyet edilen şey üzerinde, ancak mirasçılar tarafından bunun usulüne uygun devri ile (taşınır ise, zilyetliğin devri, taşınmaz ise tapu siciline tescil, alacak ise temlik vs.) hak sahibi olurlar. Cüzî halef olmaları sebebiyle, tereke borçlarından da sorumlu olmazlar[40]. Vasiyet alacaklısı, mirasbırakanın değil, mirasçıların cüzî halefidir[41].

---

[37] *Kocayusufpaşaoğlu*, § 4, I, 2.
[38] Etraflı bilgi için bkz., aşağıda, § 35.
[39] *Escher*, Einleitung, N 4.
[40] Etraflı bilgi için bkz., aşağıda, § 15, III, 2.
[41] *Oğuzman*, 7; *Kocayusufpaşaoğlu*, § 4, II, 2; *Tuor/Schnyder*, § 51, II, c. Ancak *Tuor* şer-

90 Bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, küllî halefiyet ile cüzî halefiyet arasında iki önemli fark vardır. Bunlardan birincisi, küllî halefler, mirasbırakanın ölümü ile tereke üzerinde, doğrudan, sırf ölüm olayına bağlı olarak, tam hak elde etmektedirler. Cüzî halefler ise, ölümle birlikte, kendilerine vasiyet edilen şey yönünden, mirasçılara karşı sadece bir alacak hakkı elde ederler.

91 İkinci fark, kendisini borçlardan sorumlulukta göstermektedir. Küllî halefler, tereke borçlarından kendi malvarlıklarıyla da sınırsız sorumlu olurlarken, cüzî haleflerin borçlardan sorumlulukları söz konusu değildir. Bu iki fark sebebiyledir ki, küllî halefler *gerçek ya da teknik anlamda mirasçı* sayılırlar.

92 Belirtmek gerekir ki, küllî intikal mirasta asıl olduğu için, *bizim hukukumuzda her mirasın en az bir küllî halefi vardır*. Bunun anlamı, mirasın intikalinde, sadece ve sadece küllî halefiyetin olacağı değildir. Başka bir ifadeyle miras, sadece küllî haleflere ya da küllî haleflerle birlikte cüzî haleflere geçebilir. *Fakat, mirasın sadece cüzî haleflere intikali söz konusu olamaz.* Örneğin, mirasbırakan, yapacağı bir ölüme bağlı tasarruf ile terekesinin tümünün, sadece vasiyet alacaklılarına (cüzî haleflere) intikal edeceği biçiminde bir düzenleme getiremez. Her ölümde tereke, mutlaka bir küllî halefe, bir yasal ya da atanmış mirasçıya, son tahlilde Devlete kalır. Bu bakımdan, bizim hukukumuzda küllî halefiyet bir *zorunluluktur*. Dolayısıyla da teknik anlamda mirasçısı olmayan bir tereke söz konusu olamaz.

---

hinde (Einleitung, N 18), vasiyet alacaklısının, vasiyet borçlusu olan mirasçılar aracılığıyla mirasbırakana cüzi halef olduğunu söylemektedir.

BİRİNCİ KISIM

YASAL MİRASÇILIK

Yasal mirasçılık, Miras Hukuku kitabında en başta düzenlenmiştir (MK 495 –501). Bu hükümlere göre, Türk Hukukunda, kanunî mirasçıların ilki mirasbırakanın hısımlarıdır. Hısımlar da kendi içlerinde kan hısımları (MK 495 – 498) ve mirasbırakanın evlâtlık ve altsoyu (MK 500) olmak üzere ikiye ayrılır.Yasal mirasçıların ikincisi sağ kalan eştir (MK 499). Nihayet üçüncü tür yasal mirasçıyı da devlet oluşturur (MK 501). 93

§ 2. Kan Hısımlarının Yasal Mirasçılığının Temeli Olan Zümre Sisteminin Esasları

I. GENEL BİLGİLER

94 Kimlerin kanunî mirasçı olabileceğinin düzenlenmesinde üç sistem düşünülebilir.

1. Fert sistemi

95 Özellikle İslâm Hukukuna özgü olan bu sistemde, mirasçılar önceden gruplandırılmamışlardır.Kimlerin mirasçı olacağı, her birinin mirasbırakanla olan ilişkilerine göre ayrı ayrı ele alınır.

2. Sınıf sistemi

96 Kaynağını Roma Hukukundan alan sınıf sistemi, bugün, biraz değişmiş olarak, Fransız Medenî Kanunu ve bu kanunun iktibas edildiği ülkelerde uygulanmaktadır. ZGB'nin yürürlüğe girmesinden önce İsviçre'nin Fransız kantonlarında da uygulanan bir sistemdi.

97 Bu sistem, kan hısımlarını, mirasbırakana olan yakınlıkları ve samimiyet derecelerine göre sınıflara ayırmaktadır. Her sınıf, kendisinden bir sonra gelen sınıfın mirasçılığını engeller. Örneğin, birinci sınıfı, mirasbırakanın altsoyu oluştururken, ikinci sınıfta, mirasbırakanın ana ve babası ile daha uzak asılları, yansoy kan hısımlarından kardeşleri ve onların altsoyu bulunmaktadır. Daha uzak kan hısımları ve varsa yarım kan kardeşler ile onların altsoyu da üçüncü sınıfı oluşturur. Bu sistemin iyi yanı elastiki olması, sosyal ve iktisadi ihtiyaçlara uydurulabilmesi; mahzuru ise, yapay, indî ve mantığa aykırı unsurlar içermesidir[42].

3. Zümre (parantel) sistemi

98 Zümre sistemi, Cermen Hukuku kökenli olup, İsviçre/Türk miras hukukları yanında, Almanya ve Avusturya hukukları ile, bu hukukları iktibas eden ülkelerde uygulanmaktadır. Sistem, nesillerinin birbirlerini izlemesinden kaynaklanan doğal ilişkiye dayanmaktadır. Açık, tutarlı ve mirasçıların kimler olacağının önceden belirlenebilir olması en önemli nitelikleridir.

---

[42] *Tuor/Schnyder*, § 53, I, 1; *Kocayusufpaşaoğlu*, § 5, I, a, 2.

a) Zümrenin tanımı

Zümre denince, bundan, bir kimse (zümre başı) ile birlikte ondan türe- 99
yen (altsoy) kimselerin tümü anlaşılır.

Benzer bir tanımı *Kocayusufpaşaoğlu* vermektedir[43]. Yazara göre, zümre, aynı 100
yakınlıktaki zümre ya da kök başı ile onların altsoyunun tümünü ifade eder. Oğuzman'a göre[44], bir şahıstan üreyenlerin, o şahısla birlikte meydana getirdikleri topluluğa zümre adı verilmektedir. Bütün bu değişik tanımlardan anlaşılacağı üzere, zümre başı, zümreye dahildir.

Zümre kavramının, bu dar ya da teknik anlamı yanında bir de geniş anlamı var- 101
dır. Bu geniş anlamı ile zümre, *aynı yakınlıktaki zümre ya da kök başı ile onların altsoyunun tümünü* ifade eder. Böyle olunca da, hısımlık kavramı yönünden, bir kimsenin, zümre başı olarak bir zümreye, altsoy olarak da başka bir zümreye dahil olması mümkündür. Örneğin mirasbırakanın ana ve babası, ikinci zümrenin zümre başlarını oluştururlar. Ancak, onlar, aynı zamanda ölenin büyük ana ve babasının altsoyu oldukları için bu sıfatları ile de üçüncü zümreye dahildirler[45]. Hemen belirtelim ki, bundan sonraki açıklamaların hepsinde, zümre, teknik ve dar anlamıyla kullanılacaktır, yani bir kimse ile ondan üreyen kişilerin tümü...

b) Yasal mirasçılık açısından Medenî Kanundaki zümre düzeni

Miras hukukunda hareket noktası mirasbırakan olduğu için, zümreler, 102
mirasbırakandan başlayarak saptanır ve onun her aslı zümre başı olarak alınıp, yakından uzağa doğru zümreler oluşturulur. Böyle olunca, mirasbırakandan sonra, onun anası ve babası ile başlayarak, yukarı doğru sınırsız zümreler oluşacaktır. Örneğin, mirasbırakanın, büyük ana ve babaları, onların ana ve babaları hatta onların büyük ana ve babaları da birer zümre oluştururlar. Ancak kanunkoyucu, bu sınırsız olan zümrelere dahil kişilerin hepsinin mirasçı olmasının, bir yönden pratik olarak mümkün olmadığı için (bir kimsenin yedinci ya da sekizinci dereceden aslının hayatta olmasına hemen hemen hiç rastlanmaz), öte yandan da bu derece uzak hısımların, mirasçı olmalarının sakıncalı bulduğu için, zümre sayısını sınırlamıştır.

Medenî Kanunda öngörülmüş olan zümre sayısı, 1990'a kadar, büyük 103
ana ve büyük babaların ana ve babaları ile onların birinci derecedeki altsoyu da mirasçı oldukları için dörttü. 1990 yılında 3678 sayılı kanunla, eski Medenî Kanundaki, büyük ana ve büyük babaların ana ve babası ile onların birinci derecedeki altsoyunun mirasçılığını düzenleyen 443. madde yürürlükten kaldırıldığı için zümre sayısı üçe düşmüştür. Yeni Medenî Kanun da bu değişikliğe uyarak, bu kişilerin yasal mirasçı olmalarını kabul etmemiştir. Bu sebeple bugün bizde *üç mirasçı zümresi* bulunmaktadır.

---

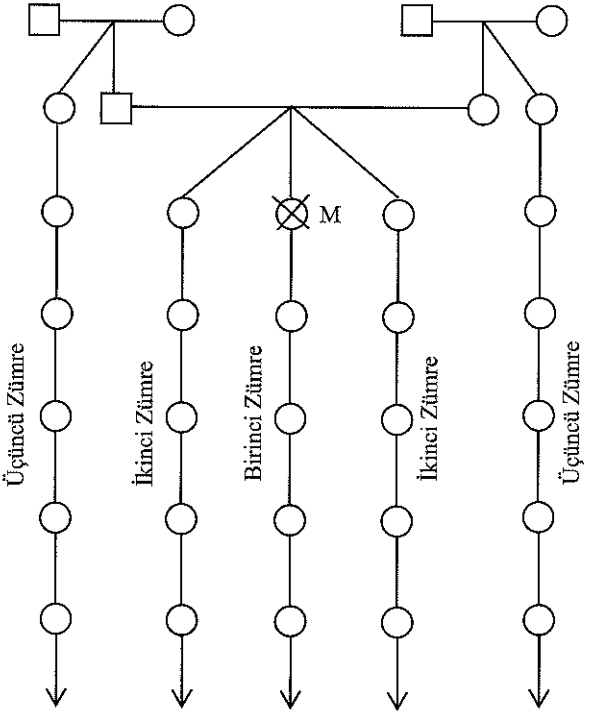
[43] *Kocayusufpaşaoğlu*, § 5, I, 2, a.
[44] *Oğuzman*, 20.
[45] *Escher*, Art. 457 Vorbem 8; *Tuor/Schnyder*, § 53, I, a, 2.

104 Benzer bir gelişme, daha önce İsviçre Medenî Kanununda da olmuştur. Orada da büyük ana ve büyük babaların ana ve babaları ile onların birinci derecedeki altsoyunu dördüncü zümre mirasçı olarak öngören ZGB Art. 460/I ve II, 1988 yılında yürürlükten kaldırılmıştır. Böylece, İsviçre'de de zümre sayısı üçe inmiştir.

105 *Birinci zümre mirasbırakanın altsoyudur* (MK 495). Zümrenin, bir zümre başı ile onun altsoyundan oluştuğu düşünülecek olursa, birinci zümrenin başının mirasbırakan olduğu kendiliğinden anlaşılır. Ne var ki, bir kimsenin, kendisinin mirasçısı olamayacağı düşünülecek olursa, birinci zümre, sadece mirasbırakanın altsoyundan oluşur. Deyim yerinde ise, birinci zümre,mirasçılık sıfatı taşıyan bir zümre başı olmayan zümredir. Birinci zümre aşağıya doğru sınırsızdır.

106 *İkinci zümre, mirasbırakanın ana ve babası ile onların altsoyudur* (MK 496). Yani, mirasbırakanın kardeşleri, kardeş çocukları, kardeş torunları vs., aşağıya ve yana doğru sınırsız olmak üzere ikinci zümreyi oluşturur.

107 **Zümre Sistemine Göre Mirasçıların Şeması**



Şekil 1

108 *Üçüncü zümre ise, yine aşağı ve yana doğru sınırsız olmak üzere, mirasbırakanın büyük ana ve babaları ile onların altsoyundan oluşur* (MK

497). Yani mirasbırakanın, amcası, halası teyzesi, dayısı ve onların altsoyu...

Ancak üçüncü zümrenin sağ kalan eşle birlikte mirasçı olması durumunda halefiyete bir sınırlama getirilmiştir (MK 499 b. 3). Bunun üzerinde aşağıda etraflı olarak durulacaktır[46]. 109

II. ZÜMRE SİSTEMİNİN ANA PRENSİPLERİ

1. Mirasçı olabilmek için bir zümreye dahil olma

Yukarıdan beri yapılan açıklamalardan anlaşılabileceği gibi, mirasçılık açısından önemli olan, mirasbırakana kan hısımı olmak ve bu sebeple bir zümreye dahil olmaktır. Kan hısımlığında iki noktanın açıklanması gerekir. Özellikle MK 498 göz önünde tutulacak olursa mirasçı olma yönünden önemli olanın *hukukî* hısımlık olduğu anlaşılır. Daha açık bir deyişle, sadece biyolojik anlamda kan hısımlığı bir kimsenin mirasçı olması için yeterli değildir. Bunun hukukî hısımlık (soybağı) kuracak nitelikte olması gerekir. Belirtmek gerekir ki, bu hukukî anlamda dediğimiz hısımlık, baba yönünden önemlidir. Çünkü ana yönünden her iki tür hısımlık da doğumla kendiliğinden kurulur (MK 282/I). Çocuk ister evlilik içinde doğmuş olsun ister evlilik dışında, doğumla birlikte anasına ve anasının hısımlarına hısım olur ve aynı zamanda onların mirasçısı da olur. Baba yönünden ise durum biraz farklıdır. Şöyle ki, evlilik içinde doğan çocuklar, doğumla birlikte babalarına (tıpkı analarına olduğu gibi) soybağı ile bağlanırlar (MK 282/II). Buna karşılık evlilik dışında doğmuşlarsa (gerçi o anda babalarına biyolojik olarak kan bağı ile bağlıdırlar), babaları aralarında henüz (hukukî) soybağı yoktur. MK 282/II'ye göre, bu soybağı ana babanın sonradan evlenmesi, çocuğun baba tarafından tanınması ya da babalığa hüküm verilmesi ile doğar. Çocuğun babası ve hısımlarına mirasçı olabilmesi, bu yollardan biri ile çocuk ile baba arasında soybağının kurulmuş olmasına bağlıdır. MK 498 bunu açık olarak ifade etmektedir. Bunun zıt kavramı, anası babası evli olmayan, tanınmamış ya da babalığı hüküm altına aldırtmamış çocuğun, babasına ve hısımlarına mirasçı olamayacağıdır. Belirtelim ki, gerek sonradan evlenme gerek tanıma ve babalık hükmü ile kurulan soybağı geçmişe etkili olduğu için, çocuk, doğum (hatta ana rahmine düşme) anından itibaren, babasına ve hısımlarına mirasçı olur. 110

Kan hısımlığı yönünden dikkat edilmesi gereken ikinci husus, sadece yukarıda açıklanan anlamda kan hısımı olmak değil de, az önce de değinildiği gibi bu sebeple bir zümreye dahil olmaktır. Örneğin, mirasbırakanın büyük ana ve büyük babalarının ana ve babaları, kan hısımı olmalarına 111

[46] Bkz. § 5, II, 4.

rağmen, bir zümre oluşturmadıkları için mirasçı değildirler. Yeri gelmişken belirtelim ki, bizim hukukumuz, hısımların yasal mirasçı olmalarını kan bağı esasına bağladığı için, *kayın hısımları asla yasal mirasçı olamazlar.* Örneğin, mirasbırakanın, kendisinden önce ölen oğlu A'nın karısı, ona mirasçı olamaz. Çünkü, mirasbırakan ile oğlu A'nın karısı arasındaki hısımlık kayın hısımlıktır.

112 Zümreye girebilmek için kan hısımı olmanın tek istisnası vardır, o da evlâtlık ve altsoyudur. Evlâtlık ve altsoyu ile mirasbırakan arasındaki hısımlık kan bağından değil de, hâkim kararından kaynaklandığı hâlde, bunlar mirasbırakanın birinci zümre mirasçılarıdırlar (MK 500)[47].

2. Bir önceki zümrede mirasçı bulunması, bir sonraki zümrenin mirasçılığını engeller

113 Bir sonraki zümrenin mirasçı olabilmesi, bir önceki zümrede hiçbir mirasçının bulunmaması ya da var olan mirasçıların hepsinin, red, mirasçılıktan çıkartma (ıskat), mirastan yoksunluk (mahrumiyet) ya da mirastan feragat gibi bir sebeple mirasa nail olamamaları gerekir. Bu bakımdan, bir zümrede tek bir mirasçının varlığı, bir sonraki zümrenin mirasa çağırılmasını engeller. Örneğin M'in (mirasbırakanın) oğlu A hayatta ise (birinci zümre), ana ve babası (ikinci zümre) mirasçı olamaz ya da M'nin kardeşinin çocuğunun varlığı (ikinci zümre), büyük ana ve babaların (üçüncü zümre) mirasçılığını engeller.

114 Burada önemli olan, bir önceki zümreye dahil olmaktır, yoksa kan hısımlığının derecesi değil... Bir önceki zümredeki mirasçı, bir sonraki zümredeki mirasçıya oranla daha uzak bir kan hısımı olsa bile, mirasın diğer zümreye geçmesini engeller.Örneğin, mirasbırakanın torun çocuğu, ona üçüncü dereceden; ana ve babası, birinci dereceden kan hısımıdır. Ne var ki, torun çocuğu birinci zümre mirasçı olduğu için, daha uzak kan hısımı olmasına rağmen, daha yakın kan hısımı, fakat ikinci zümre mirasçısı olan ana ve babanın mirasçılığını engeller.

115 Özellikle, ana babanın hayatta olmaları hâlinde, altsoyun, onların mirasçı olmalarını engellemesi, örf ve âdetimize uymadığı gerekçesiyle çok eleştirilmiştir[48]. Bu eleştirileri göz önünde bulunduran, Medenî Kanunun değiştirilmesiyle ilgili 1951 ve 1981 yılında kurulan komisyonlar değişik öneriler getirmişlerdir. 1951 tarihli komisyon, altsoyun yanında, ana ve babanın da sağ olması hâlinde, onlara belirli bir iradın verilmesini öngörmüşlerdir[49]. 1981 tarihli komisyon ise, bu sorunu, ana ve babaya,

---

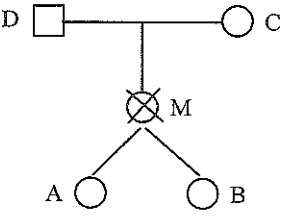
[47] Bkz. § 5, II, 4.

[48] Bu eleştiriler için bkz., *Kocayusufpaşaoğlu*, § 5, II, 1.

[49] Gerekçe için bkz., Türk Medenî Kanunu Öntararısı ve Gerekçeleri, Ankara 1971, 16 vd.

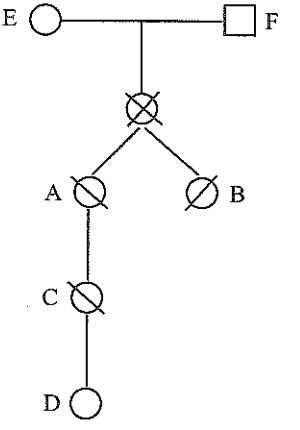
altsoy yanında 1/16 miras payı vererek çözmeye çalışmıştır[50]. Yeni Medenî Kanun hazırlanırken bu konu üzerinde hiç durulmadığı anlaşılmaktadır.

Fakat, bugünkü sistem içinde de, birinci zümre mirasçılarının bulunduğu hallerde, sağ olan ana ve babanın, sınırlı ölçüler içinde olsa da, yine de mirastan yararlanmaları mümkündür. Önce, mirasbırakan, isterse, tasarruf nisabının sınırları içinde, onları mirasçı atayabilir. İkinci olarak, ana ve baba, mirasbırakanla birlikte yaşıyorlarsa, MK 645'e göre, üç aylık bakım ve geçim masraflarının terekeden ödenmesini isteyebilirler. 116



Şekil 2

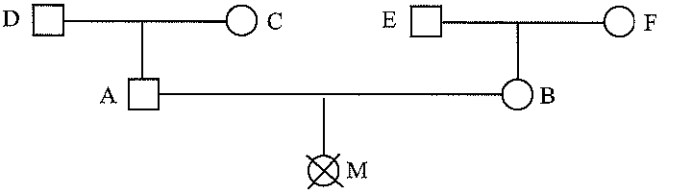
M'nin çocukları A ve B hayatta oldukları için (birinci zümre), anne ve babası C ve D (ikinci zümre) mirasçı olamazlar. 117



Şekil 3

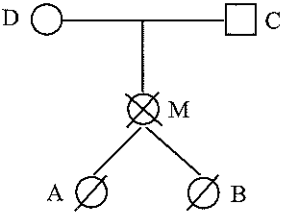
D, M'ye üçüncü dereceden kan hısımı olmasına rağmen, birinci zümre mirasçısı olduğu için, M'nin birinci dereceden kan hısımı, fakat ikinci zümreden mirasçısı olan E ve F'nin mirasçılığını engeller. 118

[50] Gerekçe için bkz., Türk Medenî Kanunu Öntasarısı ve Gerekçeleri, İstanbul 1984, 247 vd.



Şekil 4

119 İkinci zümrede A ve B'nin bulunması, üçüncü zümrede bulunan C, D, E ve F'nin mirasçılıklarını engeller.

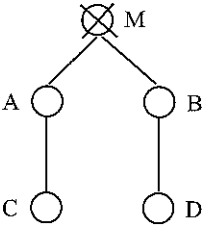


Şekil 5

120 Burada ise, A ve B, M'den önce öldükleri için, birinci zümrede hiç bir mirasçı yoktur. Bu sebeple miras ikinci zümreye (ana ve baba zümresine) geçer, yani C ve D mirasçı olurlar.

3. Zümre içinde ön sıradaki (derecedeki) mirasçılar, bir alt sıradaki mirasçıların mirasçılığını engellerler.

121 Bir zümre içinde, mirasbırakana daha uzak sırada olan kan hısımlarının mirasçı olabilmeleri, aynı zümre içindeki daha yakın sırada, hısımların bulunmaması ya da varsa bunların herhangi bir sebeple mirasa çağırılmamalarına bağlıdır.

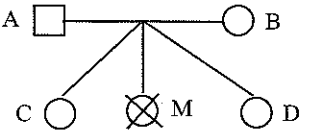


Şekil 6

A ve B, derece olarak, C ve D'den ön sırada bulundukları için, C ve D, M'ye mirasçı olamazlar. 122

4. Zümre başları ve kök başlarının önceliği

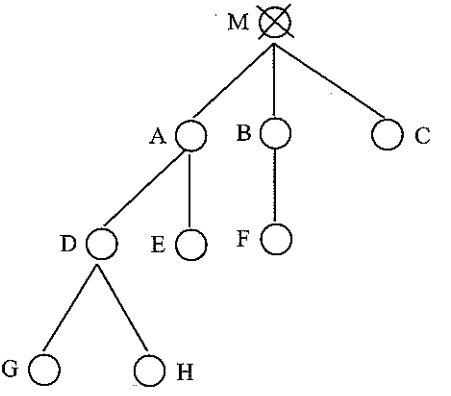
Esasında , yukarıda (3) altında söylenenlerin sonucu olan bu durum, bir zümre içindeki zümre başları ve kök başlarının, altsoyun mirasçılığını engellemelerini ifade eder. Buna göre, zümre başları hayatta olduğu sürece, onların altsoyu; kök başları hayatta olduğu sürece de onların altsoyları mirasçı olamaz. 123



Şekil 7

Zümre başları A ve B hayatta oldukları için, C ve D mirasçı olamazlar. 124

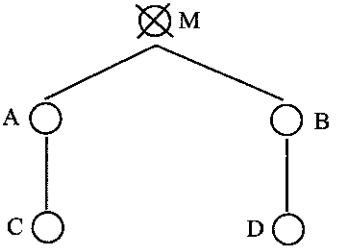
Aynı durum, *zümre içindeki kökler*[51] yönünden de söz konusudur. *Kök, bir zümre içindeki, zümre başından sonra gelen çocuğun, altsoyu ile birlikte oluşturduğu birimdir. Kök de alt köklere ayrılır.* 125



Şekil 8

A, G, D, E, H, A'nın kökbaşı olduğu; B ve F, B'nin kökbaşı olduğu kökleri oluştururlar.C'nin ise altsoyu bulunmadığı için, o bir kök oluşturmaz.A kökü içinde, D ile altsoyu G ve H alt kök oluştururlar. E'nin altsoyu olmadığı için, bir alt kökü de yoktur. 126

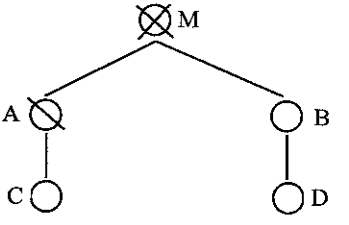
[51] *Oğuzman* (I. Bölüm, § 1, II) tabaka terimini tercih etmekte ve kök başının altsoyu için kök demektedir.



Şekil 9

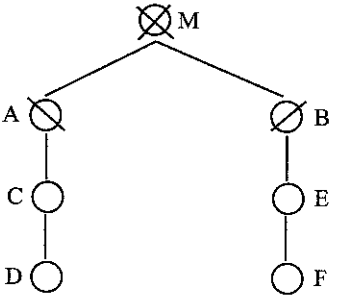
127 İşte, zümre başlarının mirasbırakandan önce ölmüş olması hâlinde, kök başları, kendi altsoylarının mirasçılığını engeller. Aynı durum, alt kök başları için de geçerlidir.

128 Kök başları A ve B hayatta oldukları için, C ve D mirasçı olamazlar.



Şekil 10

129 Bu örnekte, kök başı olan A, M'den önce öldüğü için, onun yerini C alır. Diğer kök başı B'nin hayatta olması, D'nin mirasçılığına engel olur.



Şekil 11

130 Kök başları A ve B, M'den önce öldükleri için, onların yerini, alt kök başları olan C ve E alırlar. Alt kök başlarının varlığı, mirasın, D ve F'ye geçmesini engeller.

Belirtmek gerekir ki, ZGB'nin Almanca metni, hem zümre hem de kökü ifade etmek üzere, aslında kök anlamına gelen, *Stamm* terimini kullanır. Fransızca metin ise, zümre karşılığın, *parantele*, kök (tabaka) karşılığı *souche* terimini kullanır. Fransızca metnin daha doğru olduğunda kuşku yoktur. 131

5. Zümre başı ya da kök başına altsoyun halef olması

Esasında bu da, yukarıda (3 ve 4) altında açıklanan prensibin doğal bir sonucudur. Buna göre, mirasbırakandan önce ölen ya da sağ olmakla beraber, herhangi bir sebeple mirasa çağırılmayan (nail olamayan) zümre başlarının ya da kök başlarının yerini altsoyun almasıdır. Bu durum Medenî Kanunda altsoyun halefiyet yoluyla mirasçı olacağı şeklinde ifade edilmektedir (MK 495/III, 496/II, 497/II). 132

Bazı yazarlar, altsoyun zümre başı ya da kök başının yerini alması prensibini, *tabakada halefiyet* ya da *tabakaya göre halefiyet* olarak ifade etmektedirler[52]. 133

MK 495, 496 ve 497, altsoyun, zümre başı ya da kök başına halef olması kuralını, sadece, bunların mirasbırakandan önce ölmüş olmaları ihtimalini göz önünde bulundurarak düzenlemiştir. Bu düzenleme biçimi, bir ölçüde eksiktir. Çünkü, altsoy, sadece mirasbırakandan önce ölmüş olmaları ihtimalinde zümre başı ya da kök başına halef olmaz. Bu kişiler, mirasbırakan öldüğü zaman sağ olmalarına rağmen, herhangi bir sebeple mirasa çağırılamamaları hâlinde de onlara halefiyet yoluyla mirasçı olurlar. Örneğin, mirasçılıktan çıkarma (ıskat) (MK 511), karşılıksız (ivazsız) feragat (MK 528), mirastan yoksunluk (mahrumiyet) (MK 579) ve red (MK 605) hallerinde de, zümre başı ya da kök başı hayatta olmasına rağmen sayılan sebeplerle mirasçı olamayacakları için, altsoy onlara halef olur[53]. 134

Ancak, feragat ve red halleri ile MK 497/V'in öngördüğü ihtimallerde, halefiyet yönünden durum yukarıda açıklananlardan farklı olabilir. Şöyle ki, MK 528/II'ye göre, aksine anlaşma olmadığı sürece, ivazlı feragat, feragat edenin altsoyunu da etkileyip, onların mirasçı olmasını engellediği için, halefiyet kuralı uygulanmaz. Benzer bir durum, en yakın yasal mirasçıların tümünün mirası reddetmesi hâlinde de vardır. Bu hâlde miras, iflas hükümlerine göre tasfiye edilir ve tasfiye sonucunda bir şey kalacak olursa (miras reddedilmemiş gibi) reddedenlere verilir, yani reddedenlerin yerini altsoyları almaz. Nihayet, ölenin eşinin üçüncü zümre ile birlikte mirasçı olması hâlinde, altsoyun halefiyetine bir sınırlama getirilmiştir. MK 497/V'e göre, mirasbırakanın eşinin sağ olması hâlinde, üçüncü zümrede halefiyet, zümre başlarının çocukları ile sınırlandırılmıştır[54]. 135

---

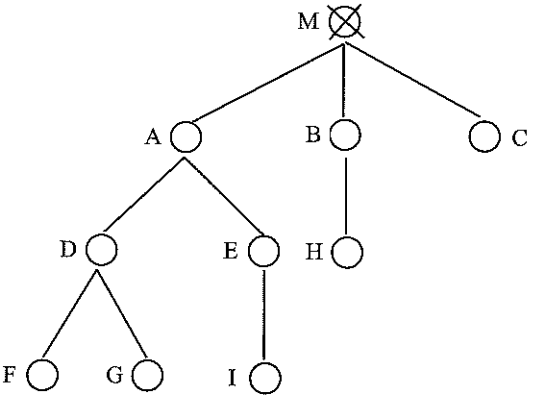
[52] *İmre/Erman*, § 3, II, 2, C.

[53] *Tuor/Schnyder*, § 53, I, 2, b; *Escher*, Art 457, Vorbem. 1; *Kocayusufpaşaoğlu*, § 5, II, 5; *Oğuzman*, 34.

[54] Etraflı bilgi için bkz., aşağıda § 5, II, 4.

6. Mirasın, birinci zümrede, kök başlarına, ikinci ve üçüncü zümrelerde, zümre başlarına göre eşit olarak paylaşılması

136 Bu paylaşmada, mirasçıların kadın ya da erkek olması bir fark yaratmaz. Zümre başları ya da kök başlarının mirasbırakandan önce ölmüş olmaları hâlinde, *onlara düşen miras payı, altsoyun, zümre başı ya da kök başına halef olacağı kuralı gereğince, altsoy arasında eşit olarak paylaştırılır.*



Şekil 12

137 a) M, öldüğü zaman, A, B ve C hayatta ise, her biri mirastan 1/3 oranında pay alırlar. Onların sağ olması, aynı zümre içindeki, daha alt derecede bulunan, D, E, F, G, I ve H'nın mirastan pay almalarını engeller.

138 b) A, M'den önce ölmüşse, ona düşen 1/3 miras payı alt kök başları (altsoy) D ve E arasında eşit olarak, 1/6 oranında paylaşılır. Bu durumda, B, 1/3, C, 1/3, D ve E 1/6'şar miras payı alırlar. D ve E'nin hayatta olması, F ve G'nin mirasçılığını engeller.

139 c) A'nın yanında, D de M'den önce ölmüşse, D'ye düşen 1/6 oranındaki miras payı, F ve G arasında eşit olarak (1/ 12) paylaşılır. Bu durumda mirastan, B, 1/3, C, 1/3, E, 1/6, F ve G 1/12'şer pay alırlar.

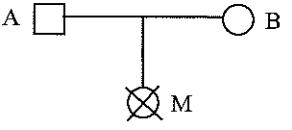
140 d) B de M'den önce ölmüşse, onun yerini H alır ve B'ye düşen miras payı halefiyet kuralı gereği ona ait olur. Bu durumda, C, 1/3, H, 1/3, E, 1/6, F ve G 1/12'şer pay sahibi olurlar.

141 e) A ve B, M öldüğü zaman hayatta, fakat C daha önce ölmüşse, C'nin yerini alacak altsoyu bulunmadığı için, miras, A ve B arasında eşit olarak paylaşılır ve her biri 1/2 oranında pay alır.

7. İkinci ve üçüncü zümrelerde mirasın ana ve baba hattı olarak ikiye ayrılması

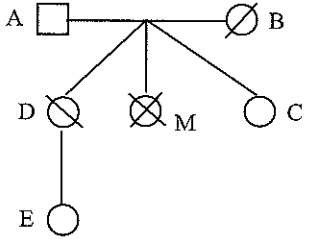
ZGB'nin Almanca metni (Art. 458/III, 459/II, IV) ve MK (496/III, 497/III, IV) taraf *(Seite)* terimini kullanmaktadırlar. Fransızca metinde ise hat *(ligne)* kelimesi kullanılmaktadır. İsviçre'de, Almanca yazan yazarlar hat terimini tercih etmektedirler[55]. *Oğuzman* da hat terimini tercih etmekle beraber, bunu, hem buradaki anlamda hem de, kaçıncı zümrede olursa olsun, mirasbırakandan mirasçılara giden bağ sayısı için kullanmaktadır[56]. *Kocayusufpaşaoğlu* ise, kol terimini kullanmaktadır[57]. 142

MK 496/I, c. 2'ye göre, ana ve baba eşit olarak mirasçıdırlar. Ana ya da babadan biri mirasbırakandan önce ölmüşse, ona düşen miras payı altsoyuna (yani mirasbırakanın kardeşleri, kardeş çocukları vd.) geçer (MK 496/II). Ölen ana ya da babanın altsoyu yoksa, mirasın tümü sağ olan diğerine ait olur (MK 496/III). Ana ve babanın her ikisi de altsoy bırakmadan mirasbırakandan önce ölürlerse, miras üçüncü zümreye geçer (MK 497). 143



Şekil 13

A ve B 1/2'şer miras payı alırlar. 144

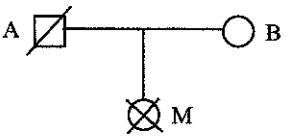


Şekil 14

B, M'den önce öldüğü için, onun payı, C ve D arasında, eşit olarak paylaşılır ve her biri 1/4 pay alırlar. Ancak, D'de mirasbırakandan önce öldüğü için, onun 1/4 miras payı E'ye geçer. Buna göre, A 1/2, C 1/4 ve E 1/4 miras payı alır. 145

---

[55] Örnek olarak bkz., *Tuor/Schnyder*, § 53, I, 3; *Escher*, Art. 457, Vorbem. 12.
[56] *Oğuzman*, 35, dn, 13.
[57] *Kocayusufpaşaoğlu*, § 5, II, 6.

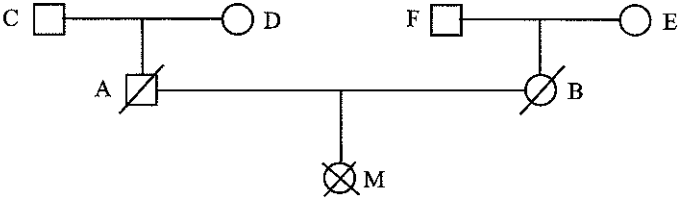


Şekil 15

146 Bu halde, A'nın yerine geçecek altsoyu olmadığı için, mirasın tamamı B'ye ait olur.

147 Aslında MK 496/III'deki bu düzenleme, hatlardan birinde, zümre başının yerine geçecek bir mirasçı olmaması hâlinde, ona düşecek miras paymın, yakın bir zümre mirasçısı varken, onunla birlikte, daha uzak zümredeki hısma düşmesini engellemek için getirilmiştir. Bu, iki zümrenin aynı anda mirasçı olamayacağı kuralına uygun olduğu gibi[58], hatların, ayrı ayrı zümreleri değil de, bir bütün olarak tek bir zümreyi oluşturmalarının sonucudur.

148 Aynı kurallar MK 497'ye göre (eşin varlığı hâlindeki özellik bir yana) üçüncü zümrede de geçerlidir. Ancak, burada miras, iki büyük ana ve iki büyük baba bulunduğu için, dört hat ya da kola ayrılır. Her bir hattaki zümre başlarından biri, mirasbırakandan önce ölmüşse, yerini varsa altsoyu alır; altsoyu yoksa, ona düşen miras payının tamamını sağ olan büyük ana ya da büyük baba alır. Ana ya da baba hattındaki büyük ana ve büyük babanın her ikisi de mirasbırakandan önce altsoy bırakmadan ölmüşlerse, mirasın tümü diğer hatta geçer.

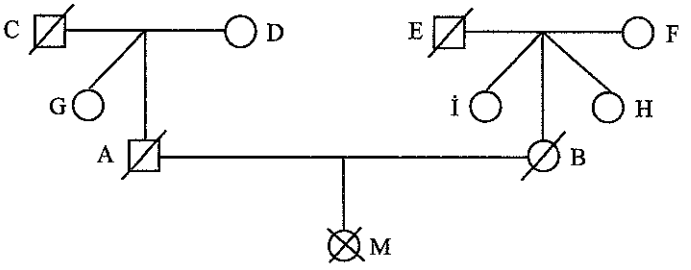


Şekil 16

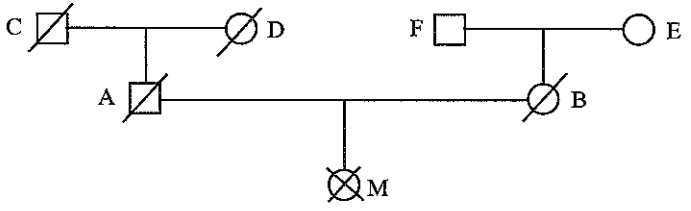
149 C, D, E ve F. 1/4'er oranda miras payı alırlar.

150 Baba kolunda E, M'den önce öldüğü için, onun yerini altsoyu H ve I; ana kolunda C, M'den önce öldüğü için onun yerini G alır. Buna göre, F ve D 1/4'er miras payı alırlarken, E'nin 1/4 miras payı, H ve I arasında eşit olarak paylaşılacak ve C'ye düşen 1/4 de G'ye ait olacaktır. Böylece, F ve D 1/4'er, H ve I 1/8'er ve G, 1/4 pay sahibi olacaklardır.

[58] *Tuor/Schnyder*, § 53, I, 2.



Şekil 17



Şekil 18

Ana hattında hiç bir mirasçı olmadığı için, miras, diğer hattaki zümre 151
mirasçılarına geçer ve E ile F arasında eşit olarak (1/2) paylaşılır. Eğer E de M'den önce ölmüş olsaydı, mirasın tümü F'ye kalırdı.

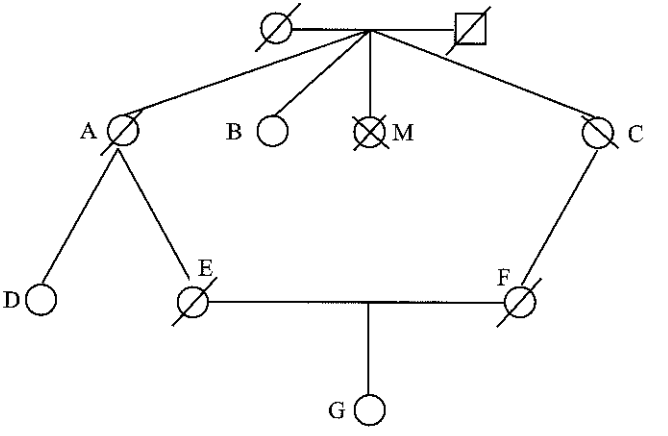
Hemen belirtmek gerekir ki, üçüncü zümrede, zümre başlarının miras- 152
bırakandan önce ölmüş olmaları hâlinde, altsoyun onlara halef olacağı kuralına, MK 497/V ve 499 b. 3 bir sınırlama getirmiştir. Aşağıda, eşin mirasçılığı bahsinde açıklanacağı gibi[59], üçüncü zümrede zümre başlarının mirasbırakandan önce ölmeleri hâlinde, mirasın halefiyet yoluyla altsoya geçmesi, ancak mirasbırakanın sağ olan bir eşinin bulunmaması hâlinde söz konusu olur. Eş sağ ise ve zümre başlarının tümü ölmüşse, *sadece zümre başlarının çocukları, yani mirasbırakanın amca, dayı, hala ve teyzesi halefiyet yoluyla mirasçı olurlar. Onların da ölmüş olması hâlinde, eşin varlığı, halefiyetin devam etmesini engeller ve eş tek başına mirasçı olur.*

Eski Medenî Kanunun 3678 sayılı kanunla kaldırılmasından önceki 442. madde- 153
sine göre, büyük ana ve büyük babaların ana ve babaları ile onların çocukları (birinci derecedeki altsoyu) dördüncü zümreyi oluşturuyorlardı. Ancak onlar tereke üzerinde tam hakka değil de intifa hakkına sahiptiler ve dolayısıyla da küllî halef değillerdi.Tereke üzerindeki tam hak eşe ait oluyordu. Yeni Medenî Kanun da, zümre mirasçılığını üç zümre ile sınırladığı için, mirasbırakanın büyük ana ve babalarının ana ve babası yine kanunî mirasçı değildirler. Ancak onların atanmış mirasçı olmalarına bir engel yoktur.

[59] Bkz., aşağıda § 5, II, 4.

III. MİRASBIRAKANA ÇİFT HISIMLIK BAĞI İLE BAĞLI OLANLARIN MİRASÇILIĞI

154 Aynı zümre içinde bir kimse mirasbırakana çift hısımlık bağı ile bağlı olabilir. Böyle bir durumda bu kimsenin mirastan nasıl pay alacağı, bu hısımlık bağlarının onu iki ayrı köke dahil edip etmediğine göre bulunur. Eğer iki hısımlık bağı bir kimseyi iki ayrı kök içine sokmuyorsa tek miras payı alır. Buna karşılık hısımlık bağları söz konusu kişiyi iki ayrı köke dahil ediyorsa, o zaman iki kökten ve ayrı miras payı alır.

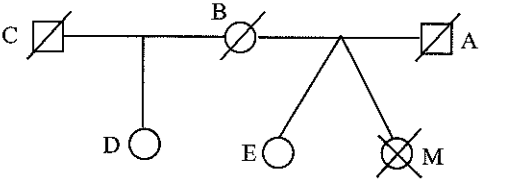


Şekil 19

155 G, annesi E dolayısıyla A köküne, babası F dolayısıyla C köküne, yani iki ayrı köke dahildir.Bu sebeple, mirastan, mirasbırakandan önce ölmüş olan E ve F'ye halef olarak hem A hem de C kökünden miras alacaktır. Buna göre, paylaşma şöyledir: B, 1/3, D, 1/6, G, (1/6 ve 1/3) 3/6 (1/2).

IV. YARIM KAN HISIMLARININ MİRASÇILIĞI

156 Yarım kan hısımlığı, zümre mirasçılığı içinde bir sorun yaratmaz. Yarım kan hısımı, mirasbırakan ile ortak olan asıllarının zümresinden pay alır.



Şekil 20

157 D, M'nin yarım kan, E ise M'nin tam kan hısımıdır. E, hem A hem de

B hattında olduğu için, her ikisinden de pay alır. D ise, sadece B hattında olduğu için, o hatta düşen miras payını E ile paylaşır[60]. Yani, E, (1/2 ve 1/4), D ise 1/4 pay alır.

V. EVLİLİK DIŞINDA DOĞAN HISIMLARIN MİRASÇILIĞI

Yukarıda değinildiği gibi[61], MK 498'e göre, evlilik dışı hısımların baba 158
yönünden mirasçı olabilmeleri için, soybağlarının, tanıma ya da hâkim kararıyla kurulmuş olması şarttır. Bu bağ kurulmuşsa, evlilik dışı hısımlar, baba yönünden tıpkı evlilik içi hısımlar gibi miras payı alırlar, aksi halde mirasçı olamazlar.

Acaba, MK 498'in, evlilik dışında doğan hısımın baba yönünden mi- 159
rasçılığını, soybağının kurulmuş olması şartına bağlaması, Anayasa Mahkemesinin, 11.9.1987 tarih ve 1/18 sayılı kararı[62] karşısında, Anayasa'ya aykırı mıdır? Açıklayacak olursak; sahih ve sahih olmayan nesep bağına dayanan eski Medenî Kanunda 443. madde, evlilik dışında doğan çocuğun, babasına mirasçı olabilmesini, babası ile arasında sahih olmayan nesep bağının kurulmuş olmasına bağlamıştı.Yani çocuk, ancak babası tarafından tanınmış ya da kişisel sonuçlu babalık hükmü ile babasına bağlanmışsa babasına mirasçı olabiliyordu. Bu yollardan biri ile babası ile arasında sahih olmayan nesep bağı kurulmayan ya da kurulamayan çocuklar, maddî sonuçlu babalık davası ile babaları tespit edilmiş olsa bile, babalarına ve baba yönünden hısımlarına mirasçı olamıyorlardı.

Sahih olmayan nesep bağı kurulmuş olsa bile, eski MK 443/II, bu ço- 160
cuklar aleyhine bir hüküm içermekteydi. Buna göre, sahih olmayan nesepli çocuk, babasının sahih nesepli çocukları ile birlikte mirasçı olduğu zaman, mirastan, sahih nesepli olanlara oranla yarım pay alıyorlardı.

İşte eski MK 443'ün bu hükümlerini Anayasa Mahkemesi, yukarıda be- 161
lirtilen kararında, Anayasa'ya aykırı bularak 1987 yılında iptal etmiştir. Anayasa Mahkemesi, özetle, babaları (maddî sonuçlu babalık davası ile) tespit edilmiş, fakat babalarına (tanınmadıkları ya da açılan dava kişisel sonuçlu olmadığı için) sahih olmayan nesep bağı ile bağlanmamış çocukların mirasçı olamamalarını ve babaları ile aralarında sahih olmayan nesep bağı kurulmuş çocukların, babanın sahih nesepli çocuklarına oranla yarım pay almalarını, Anayasa'nın başta eşitlik ilkesi olmak üzere, birçok hükmüne aykırı bularak iptal etmiştir[63]. Yani özetle Anayasa Mahkemesi, babalarına

---

[60] Örnek için bkz., *Kocayusufpaşaoğlu*, § 6, II, 75.
[61] Bkz, yukarıda II,1.
[62] RG 29.3.1988, sayı 19769.
[63] Bu konuda etraflı bilgi için bkz., *Dural/Öz*, § 1, VI

sahih olmayan nesep bağı ile bağlanmamış, fakat babaları tespit edilmiş çocukların mirasçı olabilmeleri gerektiği ve sahih nesepli olmayan çocukların ise sahih nesepli çocuklara eşit oranda pay alması gerektiği sonucuna varmıştır.

162 Anayasa Mahkemesinin eski MK 443'ün yukarıda belirtilen hükümlerini iptal etmesinden sonra, MK 443, 1990 yılında 3678 sayılı kanunla yeniden düzenlenmiştir. Ne var ki, maddenin yeni düzenlemesi, sahih nesepli olmayan çocukların, babalarından yarım pay miras almaları hükmünü kaldırmış, fakat babaya ve onun hısımlarına mirasçı olmayı, yine sahih olmayan nesep bağının kurulmasına bağlı tutmuştu. Yani yeni düzenleme de Anayasa'ya aykırı hüküm içermekteydi. 22.2.1997 tarih ve 1/1 sayılı İBK[64], söz konusu hükmü, Anayasa'ya ve Anayasa Mahkemesi kararına uygun olarak yorumlamış ve tabii babalığın tespitini (yani maddî sonuçlu babalık davası sonucu babanın tespit edilmiş olmasını), mirasçılık için yeterli görmüştür.

163 Bu açıklamalardan sonra, *fikrimce*, MK 498'deki yeni düzenlemenin Anayasa'ya aykırı olduğu söylenemez. Çünkü, eski Medenî Kanundan farklı olarak, evlilik dışında doğan çocukların, babalarına soybağı ile bağlanmaları (başka bir erkeğe soybağı ile bağlanmamış olmaları dışında), hiç bir sınırlama ve şarta bağlanmamıştır. Oysa eski Medenî Kanun, tanıma ve kişisel sonuçlu babalık davasının açılabilmesini, yani çocuğun sahih olmayan nesep bağı ile babasına bağlanmasını, ağır şartlara bağlamıştı. Hatta kişisel sonuçlu babalık davası, istisnai bir dava olarak düzenlenmişti[65]. Bu şartları içermeyen çocuklar için, ancak maddî sonuçlu babalık davası açılabiliyor ve bu dava, ancak babayı tespit edebiliyor, fakat baba ile çocuk arasında nesep bağını kurmuyordu. İşte bu farklı durum, Anayasa Mahkemesi tarafından Anayasa'ya aykırı bulunmuştur. Oysa yeni düzenleme, evlilik dışında doğan çocuklarda (başka bir erkeğe soybağ ile bağlı olmama hariç), hiç bir şart aramaksızın, çocuğun tanınması, tanınmaması hâlinde, tek tür olan babalık davası açma imkânı tanımıştır. Başka bir ifadeyle, evlilik dışında doğan her çocuğun, ana ve babasının sonradan evlenmesi, babası tarafından tanınması ya da babalık kararıyla, babasına soybağı ile bağlanması mümkündür. Bu sebeple, evlilik dışında doğan çocukların hangi şartlar altında doğmuş olurlarla olsunlar, babalarına soybağı ile bağlanmaları yönünden, eski Medenî Kanundan farklı olarak, bir ayrılık gözetilmemiştir. Bu bakımdan da, MK 498'in hükmü Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırı değildir.

---

[64] RG 22.5.1997, etraflı bilgi için bkz., *Dural/Öz*, § 1, VI.

[65] Bu konuda etraflı bilgi için bkz., *Oğuzman/Dural*, § 20, IV, 4.

§ 3. Evlâtlığın (ve Altsoyunun) Mirasçılığı

I. GENEL OLARAK

Kan hısımı olmayıp da zümre mirasçısı olabilen kişiler, sadece *evlâtlık ve altsoyudur*. MK 500'e göre, *"Evlâtlık ve altsoyu, evlât edinene kan hısımı gibi mirasçı olurlar. Evlâtlığın kendi ailesindeki mirasçılığı da devam eder"*. Bundan da anlaşılacağı gibi, mirasçılık açısından, evlâtlık ve altsoyu, mirasbırakanın altsoyu ile aynı haklara sahiptirler. 164

İslâm Hukukunun uygulandığı zamanlarda, bugünkü anlamda evlât edinme yoktu, sadece manevî evlât vardı. Manevî evlâtlık ise, evlât edinen ile bir hısımlık bağı kurmadığı için, mirasçılık hakkı da vermiyordu. Bu bakımdan o zamandan gelen manevî evlâdın, nüfus kütüğüne evlâtlık olarak kayıt edilmesi geçersizdir ve kaydın iptal edilmesi için dava açmaya dahi gerek yoktur[66]. 165

Evlâtlık ve altsoyunun mirasçı olabilmeleri için, evlât edinenin ölümü ânında, evlâtlık ilişkisinin geçerli olarak kurulmuş ve devam ediyor olması gerekir[67]. Evlât edinme işlemleri devam ederken, evlât edinmek isteyen kişi ölürse, işlem tamamlanmamış olacağı için, geçerli bir evlâtlık ilişkisi ölüm anında kurulmamış olur ve dolayısıyla da evlâtlık ve altsoyunun mirasçılığı söz konusu olamaz[68]. 166

7.12.1955 tarih ve 11/24 sayılı İBK'da[69], evlât edinenin, evlâtlık ilişkisine son vermek için açtığı dava sırasında ölmesi hâlinde, mirasçıların davaya devam edebilmeleri kabul edilmiştir. Böyle olunca da, mirasçıların, evlâtlık ilişkisini iptal ettirebilmeleri hâlinde, evlâtlık ve altsoyu, mirasbırakan öldüğü zaman hayatta olmalarına rağmen, mirasçı olamayacaklardır. Çünkü karardan, iptalin geçmişe etkili olacağı sonucu çıkmaktadır. 167

II. EVLÂTLIK VE ALTSOYUNUN MİRASÇILIĞININ ÖZELLİKLERİ

MK 500'e göre, evlâtlık ve altsoyu, evlât edinenin birinci zümre ve saklı paylı mirasçıları olmasına rağmen, hısımlıkları mahkeme kararına dayandığı için, yine de kan hısımı altsoyun mirasçılığına oranla bazı özellikler taşır. 168

Eski MK 257 /I, c. 2'de en geç evlât edinme sözleşmesiyle birlikte yapılacak bir sözleşmeyle, evlâtlık ve altsoyunun mirasçı olamayacakları ya da mirastan daha az pay alabilecekleri kararlaştırılabiliyordu. Eski MK 257'yi karşılayan MK 314'de bu hükme yer verilmediği için, bugün böyle bir anlaşma yapılamaz. Ancak, evlât edinen ile evlâtlık ya da altsoyunun mirastan feragat sözleşmesi yapmalarına bir engel yoktur. 169

---

[66] 2.HD 23.2.1984, 104/342 (YKD 1984, c.X, 1355); *İmre/Erman*, § 5, dn. 31.

[67] Bu konuda etraflı bilgi için bkz., *Oğuzman/Dural*, 266.

[68] *Escher*, Art. 465 N 7; *Kocayusufpaşaoğlu*, 89; *Oğuzman*, 58, dn. 36; *Ayiter/Kılıçoğlu*, § 2, II, A, bbb.

[69] RG 9229.

170 1. Evlâtlığın kendi ailesine, yani kan hısımlarına olan mirasçılığı devam eder (MK 500/I, c.2). Böylece evlâtlık ve altsoyu hem kendi hısımlarından hem de evlât edinenden miras alırlar.

171 Oysa durum İsviçre'de farklıdır. 1972'deki değişiklikle tam evlat edinmeyi benimseyen İsviçre, evlâtlığın asıl ailesi ile olan ilişkilerinin sona ereceğini kabul etmiştir. Buna paralel olarak, aynı tarihte MK 500'ü karşılayan ZGB Art. 465'i yürürlükten kaldırarak, evlâtlığın kendi ailesine karşı olan mirasçılığına son vermiştir.

172 2. Evlâtlık ve altsoyu, sadece evlât edinene mirasçı olurlar (MK 500/I, c. 1). Evlât edinme ile sadece evlât edinen ve evlâtlık ile onun altsoyu arasında hısımlık bağı kurulduğu için[70], evlâtlık ve altsoyu, evlât edinenin hısımlarına mirasçı olamazlar[71]. Ancak, evlât edinenin hısımları ile evlâtlık arasında, ayrıca kan bağına dayanan hısımlık varsa,o zaman evlâtlık ve altsoyu, evlâtlık ilişkisi dolayısıyla değil, fakat kan hısımlığı dolayısıyla mirasçı olur.

173 3. Evlât edinen ile evlâtlık ve altsoyu arasındaki mirasçılık tek yönlüdür. MK 500/II'ye göre, *"Evlât edinen ve hısımları, evlâtlığa mirasçı olamazlar"*. Burada sözü edilen yasal mirasçılıktır. Bu sebeple, evlât edinen ya da hısımlarının, evlâtlığın atanmış mirasçısı olmalarına bir engel yoktur. Örneğin evlâtlık E, evlât edinen A'yı terekesinin 1/4'ü için mirasçı atayabilir. Yine, evlât edinen ile evlâtlık arasında, mirasçı olmasını gerektiren bir kan bağının bulunması hâlinde de evlât edinen ve hısımları evlâtlığa (bu sefer yasal) mirasçı olabilirler.

§ 4. Zümre Sisteminin Genel Olarak Değerlendirilmesi

174 Zümre sisteminin en önemli yararı, açık ve sade olmasıdır. Diğer sistemlerden farklı olarak, kimlerin mirasçı olacağı, kanunkoyucunun iradesine bırakılmamıştır. Basit formüllerle, kimlerin mirasçı olacaklarının önceden belirlenmesi mümkündür. Çünkü zümreye girecek olan kan hısımlarının kimler olduğu kanun gereği bellidir.

175 Zümre sisteminin lehine söylenecek diğer bir husus da, mirasçıların mirastan ne nispette pay alacaklarının da önceden hesaplanabilmesidir[72].

176 Buna karşılık, sisteme karşı ileri sürülen eleştirilerin başında, daha uzak kan hısımlarının, bir önceki zümrede bulunmaları sebebiyle, daha yakın kan hısımı olmalarına rağmen, bir sonraki zümrede bulunan kan hısımlarının mirasçılığını engellemeleridir. Örneğin mirasbırakanın torunun torunu, onun dördüncü dereceden kan hısımı

---

[70] Evlâtlığın altsoyu ile evlât edinen arasında hısımlık bağı kurulmayacağına ilişkin aksi görüş için bkz., *Tekinay*, 465; *Öztan*, 344; *Zevkliler*, 330, 891; açık olmamakla beraber, *Silbernagel/Weber*, Art. 268, N 24. Bu görüş kabul edilirse, evlâtlığın altsoyunun, aralarında hısımlık bağı bulunmayan evlât edinene nasıl mirasçı olabileceklerini açıklamak güç olur.

[71] Bkz., *Oğuzman*, 60, dn. 41'de anılan Yargıtay kararları.

[72] Aksi görüş, *Oğuzman*, 55.

olmasına rağmen, mirasbırakanın birinci derecede kan hısımı olan ana ve babasının mirasçılığını engeller. Çünkü onlar, ikinci zümreden mirasçı olmaktadırlar.

Zümre başlarının sağ olmasının, onun altsoyunun mirasçılığını engellemesi de, 177
sisteme karşı ileri sürülen eleştirilerden biridir. Özellikle, zümre başı olan ana ve baba hayatta oldukları zaman mirasbırakanın kardeşlerinin pay alamamaları çok tereddütle karşılanmaktadır.

Kök başlarının, zümre başlarının, altsoyun da kök başlarının yerini alması (halef 178
olması) kuralının, aynı sırada yer alanların farklı miras payı almalarına sebep olması da başka bir mahzur olarak gösterilmektedir. Örneğin M'nin, A ile B adlı iki çocuğu, B'nin de C, D ve E adlı üç çocuğu bulunsa ve B, M'den önce ölmüş olsa, A, 1/2, C, D ve E, ise, 1/6 şar oranda pay alacaklardır. Ne var ki, B'nin, M'den sonra ölmesi hâlinde de C, D ve E'nin aynı payı alacakları düşünülecek olursa, sonuçta bir şey değişmeyeceği için, bunu mahzur olarak görmemek gerekir.

İleri sürülen eleştirilerden biri de, bu sistemin, mirasın küçük paylara bölünme- 179
sine sebep olabileceğidir. Ancak bu mahzur, sadece zümre sistemine özgü değildir. Hangi sistem kabul edilirse edilsin, mirasçı sayısı çok ise, tereke zorunlu olarak küçük parçalara bölünecektir.

§ 5. Eşin Mirasçılığı

I. GENEL OLARAK

Hemen belirtmek gerekir ki, *eş zümre mirasçısı değildir*. Sağ kalan eş, 180
her zümre ile birlikte mirasçı olur. İlk iki zümrede hiç bir mirasçı yoksa ve üçüncü zümrede de, zümre başları ile onların çocukları mirasbırakandan önce ölmüşlerse, eş tek başına mirasçı olur ve onun varlığı devletin (yasal) mirasçılığını engeller.

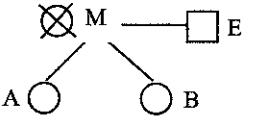
Eşin bu yukarıda sayılan hâllerde tek başına mirasçı olacağı söylenir- 181
ken, onun yasal mirasçılığı kast edilmektedir, yoksa mirasbırakanın mirasçı atadığı hâller değil. Eş dışında hiç bir yasal mirasçısı olmayan mirasbırakan, bir ölüme bağlı tasarruf ile tasarruf edilebilir kısmın sınırları içinde, mirasçı ya da mirasçılar atamışsa, eş bunlarla birlikte mirasçı olur.

II. EŞİN DEĞİŞİK ZÜMRELERLE BİRLİKTE MİRASÇI OLMASI DURUMUNDA MİRAS PAYININ ORANLARI

Eşin değişik zümrelerle birlikte mirasçı olması hâlinde miras payının 182
oranlarının ne olacağı MK 499'de düzenlenmiştir. Buna göre:

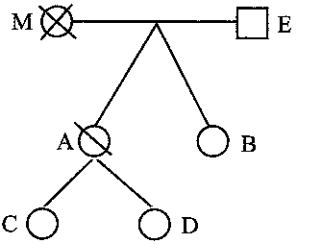
1. Eş, birinci zümre ile birlikte mirasçı olursa, miras payı terekenin 183
1/4'üdür (MK 499 b.1)[73].

[73] Bu miktar, İsviçre'de 1/2'dir (ZGB Art. 462, Ziff.1).



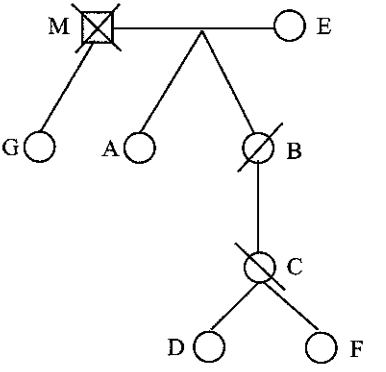
Şekil 21

184 E, 1/4, A ve B 3/8'er pay alırlar.



Şekil 22

185 E, 1/4, B, 3/8, C ve D 3/16'şar pay alırlar.

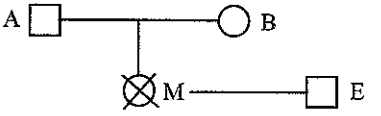


Şekil 23

186 E, 1/4, G, 3/12, A, 3/12; D ve F 3/24 miras payı alırlar.

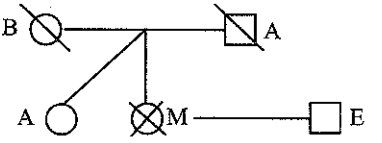
187 *2. Eş, ikinci zümre ile birlikte mirasçı olduğu zaman, terekenin 1/2'sini miras payı olarak alır (MK 499 b.2)*[74].

[74] Bu miktar, İsviçre'de 3/4'dür (ZGB Art. 462 Ziff 2).



Şekil 24

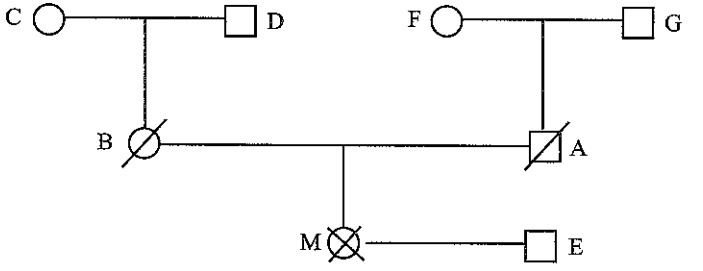
E, 1/2, A ve B 1/4'er miras payı alırlar. 188



Şekil 25

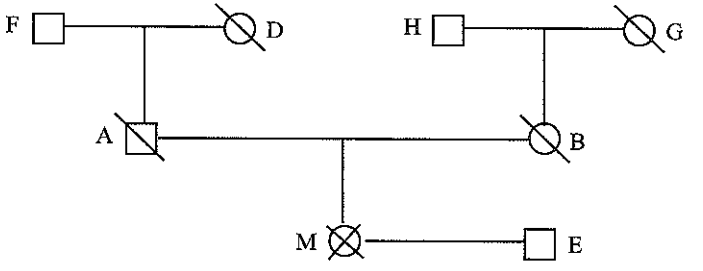
E, 1/2, C, 1/2 miras payı alır. 189

3. Eş, üçüncü zümre başları ve onların çocukları ile birlikte mirasçı olursa, miras payı terekenin 3/4'üdür (MK 499 b.3)[75]. 190



Şekil 26

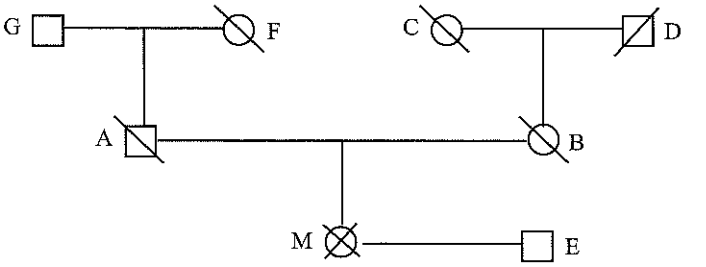
E, 3/4, C, D, F ve G 16'şar miras payı alırlar. 191



Şekil 27

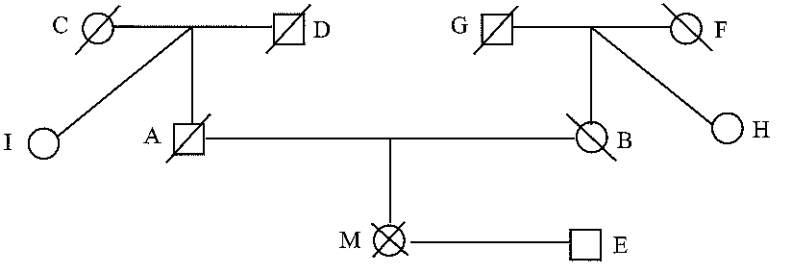
[75] İsviçre'de eşin varlığı, üçüncü zümrenin tümünün mirasçı olmasını engeller (ZGB Art. 462, Ziff 3).

192 E, 3/4, C ve H , 1/8'er miras payı alırlar.



Şekil 28

193 E, 3/4, G 1/4 miras payı alır.



Şekil 29

194 E, 3/4, I ve H 1/8'er miras payı alırlar.

195 4. Birinci ve ikinci zümrede hiç bir mirasçı yoksa, üçüncü zümrede de zümre başları ve onların çocukları hayatta değilseler, eş tek başına mirasçı olur.

196 MK 497/V'e göre, *"Sağ kalan eş varsa, büyük ana ve büyük babalardan birinin mirasbırakandan önce ölmüş olması hâlinde, payı kendi çocuğuna; çocuğu yoksa o taraftaki büyük ana ve babaya; iki taraftaki büyük ana ve büyük babanın her ikisinin de ölmüş olmaları hâlinde onların payları diğer tarafa geçer."* Yine MK 499 b.3'e göre eş, *"Mirasbırakanın büyük ana ve babaları ve onların çocukları ile birlikte mirasçı olursa, mirasın dörtte üçü, bunlar da yoksa mirasın tamamını alır".*

197 Her iki hükümden de açık olarak anlaşılacağı gibi, sağ kalan eş, üçüncü zümrede, sadece zümre başları ve onların çocukları ile birlikte mirasçı olmaktadır. Başka bir ifadeyle, eşin varlığı, üçüncü zümrede, altsoyun zümre başına halef olması kuralını, sadece zümre başlarının çocukları ile sınırlamakta, yoksa tüm altsoyu içermemektedir.Böyle olunca da, üçüncü zümre-

de eş, sadece mirasbırakanın büyük ana ve babalarıyla ve amca, dayı, hala ve teyzesi ile birlikte mirasçı olmaktadır. Zümre başları yanında, amca, dayı, hala ve teyzelerden hiç biri hayatta değilse, fakat onların altsoyu varsa, işte eşin varlığı altsoyun mirasçılığını engellemektedir. Örneğin mirasbırakanın eşi E yanında, sadece amca (ya da teyze, hala ve dayı) çocukları hayattaysa, E, tek başına mirasçı olur ve amca çocuklarının mirasçılığını engeller.

Özetle, birinci ve ikinci zümrelerde hiç mirasçı yoksa, üçüncü zümrede 198
de zümre başları ile onların çocukları mirasbırakandan önce ölmüşlerse, eş tek başına mirasçı olur. Eşin varlığı aynı zamanda devletin de mirasçılığını engeller.

Eşin üçüncü zümre birlikte mirasçılığı, 3678 sayılı kanunla değiştirilmiş olan 199
eski MK 441 ve 444/ II'de biraz farklı düzenlenmişti. Eski hükme göre, eşin varlığı, zümre başlarının altsoyunun tamamının mirasçılığını engelliyordu. Yâni eş, sadece üçüncü zümre başları ile birlikte mirasçı oluyordu. Onların, mirasbırakandan önce ölmüş olmaları hâlinde, çocukları bulunsa bile, eş yine tek başına mirasa sahip oluyordu. Bu hükmün değiştirilip, neden zümre başarının çocuklarına (yâni mirasbırakanın amca. hala, teyze ve dayısına) da eşle birlikte mirasçı olma hakkının verildiği, genel Gerekçede[76] şöyle açıklanmıştır: *"Tasarının 497. maddesine eklenen yeni hükümle, büyük analar ve büyük babaların kendi çocukları, yani mirasbırakanın amcası,halası, dayısı veya teyzesi hayatta iseler, mirasbırakandan önce ölmüş olan büyük analar ve büyük babalara düşen miras paylarının onların çocuklarına, yani yukarıda sayılan kişilere geçmesi imkânı tanınmıştır. Yürürlükteki Kanunun 441. maddesinde 14.11.1990 tarihli ve 3678 sayılı Kanunula yapılmış olan değişiklik, söz konusu miras payının bu kişilere geçmesini engellemektedir.Bu ise, Türk toplumunun aile yapısı ve amca , hala, dayı ve teyze ile yeğenleri arasındaki aile bağına ters düşmektedir. Bu sebeple yapılan değişiklik sayesinde sağ kalan eş varsa, büyük analar ve büyük babalardan birinin mirasbırakandan önce ölmüş olması hâlinde, ona düşen pay kendi çocuğuna,yani mirasbırakanın amca , hala, dayı veya teyzesine geçecektir".*

MK 497'nin gerekçesinde ise bu değişiklik şöyle ifade edilmiştir[77]: *"Büyük ana* 200
ve büyük babanın kendi çocukları varken, yani mirasbırakanın amcası, halası, teyzesi veya dayısı hayatta iken, kendisinden önce ölmüş olan büyük ana ve büyük babanın miras hisseleri bu kişilere intikal edememektedir. Bu durum haksızlıklara yol açacak niteliktedir.

Türk toplumunun aile yapısı düşünüldüğünde, amca, hala, dayı ve teyze ile ye- 201
ğenleri arasında yakın aile bağlarının mevcut olduğu, çoğu kez babanın ölümü hâlinde bu kişilerin yeğenlerine sahip çıktığı yadsınamaz bir gerçektir. Bu nedenle yakın aile bağları olan kişilerle sınırlı olmak üzere sağ kalan eş ile birlikte miras hakkı tanımak Türk toplumunun yapısına daha uygundur. Böylece sağ kalan eş varsa, yürürlükteki hüküm uyarınca, mirasbırakandan önce ölmüş olan büyük ana ve büyük babaların miras paylarının kendi tarafında bulunan ya da bu taraftakilerin ikisinin de ölmüş bulunması hâlinde diğer taraftaki büyük ana ve büyük babaya intikal etmesi yerine, bu kişilerin miras paylarının kendi çocuklarına intikal etmesi da-

[76] Gerekçe, 314.
[77] Gerekçe 471.

ha uygun görülmüştür. Bu suretle yeni düzenleme uyarınca mirasbırakandan önce ölmüş olan büyük ana ve büyük babaların miras payları kendi çocuklarına, yani mirasbırakanın amca, hala veya dayı ve teyzesine geçecek, bunlar da ölmüş ise onların çocuklarına yani mirasbırakanın kizen ve kuzenlerine geçmeyecek, bu zümrede başkaca mirasçı bulunmadığından sağ kalan eşe geçecek böylece sağ kalan eş mirasın tamamına sahip olacaktır"

202 *Fikrimce*, açığa vurulmayan asıl gerekçe, yukarıda yazılanlar değil de, malvarlığının mümkün olduğu kadar ölenin ailesinde kalmasını temindir ve yeğen ile amca, hala, teyze ve dayı arasındaki ahlâki bir borç olan karşılıklı bakma ve gözetme borcununun ivazıdır. Ne var ki, bu ivaz, hiç kuşkusuz mirasbırakana sözü edilen kişilerden daha yakın olan eş aleyhine verilmiştir. Kaldı ki, bu gerekçe, eşin, miras payı ile igili gelişmelerle de çelişmektedir. Şöyle ki, 3678 sayılı kanunla yapılan değişiklikten önce eş, hem üçüncü zümre mirasçıları ile birlikte mirasçı oluyordu ve miras payı da, terekenin 1/2'sinin mülkiyeti ile 1/4'ünün intifaı idi. 1990 yılında eski MK 444, 3678 sayılı kanunla değiştirilmiştir. Bu düzenlemede, eşin hem miras hakkı oran olarak artırılmış (3/4) hem de, zümre başlarının tüm altsoyunun mirasçı olması engellenerek, payı, miktar olarak da artmıştır. Görüldüğü gibi, eğilim, eşin mirastan pay almasının mümkün olduğu kadar (haklı olarak) artırmaktır. Şimdi 1990 yılında, eşin, onun amca, dayı, hala ve teyzenin mirasçı olmasını engellemesi, eşin korunmasına yönelik olarak hemen hemen herkes tarafından alkışlanırken, 1990 yılında sonra, Türk ailesinin yapısında ne gibi değişiklikler olmuştur da, artık bu durum kabul edilemez hale gelmiştir?

III. EŞİN MİRASÇILIĞI İLE İLGİLİ BAZI ÖZEL DURUMLAR

1. Boşanma davasının eşin mirasçılığına etkisi

203 **MK 181/I'e göre, boşanma kararının kesinleşmesiyle birlikte, artık eşler birbirlerine yasal mirasçı olamazlar. Aynı şekilde, eşlerin birbirleri lehine yapmış oldukları ölüme bağlı tasarruflar da kanun gereği (kendiliğinden) ortadan kalkar, yâni boşanan eşler, artık birbirleri lehine olan ölüme bağlı tasarrufları talep edemezler, eğer ki, ölüme bağlı tasarruftan aksi anlaşılsın. Eğer, ölüme bağlı tasarrufta,boşanma hâlinde dahi geçerli olacağı belirtilmişse, o zaman, lehine ölüme bağlı tasarrufta bulunulmuş olan eş, bunun ifasını isteyebilir.**

204 **MK 181/I'in bu hükmü, eşlerin, evlilik devam ederken birbirleri lehine yapmış oldukları ölüme bağlı tasarrufların geçersiz olması sonucunu doğurur ,yoksa, boşandıktan sonra birbirleri lehine yapacakları ölüme bağlı tasarrufların geçerliğine dokunmaz. Örneğin, koca, boşandıktan sonra, eski karısını mirasçı olarak atayabilir ve bu atama geçerlidir.**

205 **Boşanma davası devam ederken eşlerden birinin ölmesinin, sağ kalan eşin yasal mirasçılığının ya da birbirleri lehine yaptıkları ölüme bağlı tasarrufun akıbetinin ne olacağına MK 181/II cevap vermektedir. Söz konusu hükme göre, *"Boşanma davası devam ederken ölen davacının mirasçılarından birinin davaya devam etmesi ve davalının kusurunun saptanması hâlinde de yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır"*.**

Hükümden de anlaşılacağı üzere, kanun koyucu, bu halde, evliliğin, bo- 206
şanma ile değil de, ölümle sona erdiği noktasından hareketle, kural olarak eşlerin birbirlerine karşı olan yasal mirasçılıklarının devam edeceğini ve birbirleri lehine yapmış oldukları ölüme bağlı tasarrufların da geçerli olacağını kabul etmiştir. Bu kuralın istisnası, yine aynı fıkrada, o da sadece davacı eşin ölmesi hali için öngörülmüştür. Buna göre, davacı, boşanma davası devam ederken ölür ve mirasçılarından birinin, davaya devam ederek, davalı eşin kusurunu ispat etmesi durumunda, sağ kalan eş, artık ölen eşe ne mirasçı olabilir ne de onun tarafından lehine yapılmış olan ölüme bağlı tasarruftan bir hak talep edebilir.

Bu hükmün gerekçesinden anlaşıldığı kadarıyla[78], davacı eşini ölümü hâlinde, 207
mirasçılardan birinin davaya devam etmesinin anlamı, boşanma davasına devam etmek değil de, *"...boşanmada hangi eşin kusurlu olduğunun saptanmasına yönelik olacaktır"*. Yâni boşanma davası, tespit davasına dönüşecektir. Ancak mirasçı, bu davaya, ölen eşin küllî halefi sıfatıyla değil de, kendi adına devam edeceğine göre, bir dava devam ederken, istisnalar dışında, tarafın nasıl değişeceğinin, usul hukuku yönünden açıklanması çok zordur. Bunun gibi, yine iddia ve savunmanın değiştirilmesi yasağı karşısında da bu hükmün ne dereceye kadar uygulanabilir olacağı da açıklanmaya muhtaçtır. Ayrıca kişiye sıkı sıkıya bağlı olan boşanma davasına mirasçıların nasıl devam edebilecekleri de açıklanması gereken bir hususdur. Bu durum, boşanma davasının tespit davasına dönüşeceği gerekçesi ile açıklanamaz.

Sanırım ki, bu hüküm BGB § 1933 örnek alınarak konulmuştur. Ne var ki, Al- 208
man Hukukundaki düzenleme oldukça farklıdır. Şöyle ki, BGB § 1933'e göre, boşanmanın şartları gerçekleşmiş ve boşanma davası açılmışsa, eşler, başka hiç bir şeye gerek kalmadan, birbirlerine karşı olan yasal mirasçılık haklarını (nafaka talep hakları saklı kalmak şartıyla) kaybetmektedirler. Başka bir deyiş ile, eşlerin mirasçılık sıfatı sona ermektedir. Oysa bizde, MK 181/II tam tersine bir düzenleme getirerek, boşanma davasının açılmış olmasının, karar kesinleşmeden önce, eşlerin yasal mirasçılığını etkilemeyeceğini öngörmüştür. Bu sebeple, davanın ölüm sebebiyle düşmesi hâlinde dahi sağ kalan eş, ölene mirasçı olmakta, lehine yapılan ölüme bağlı tasarrufa dayanarak hak sahibi olmaktadır. Davacının ölümü hâlinde, sağ kalan eşin hakkının engellenmesinin tek yolu, mirasçılardan birinin davaya devam edip, onun boşanmadaki kusurunu ispatlamasıdır. Bu ise, *fikrimce*, MK 578'de öngörülmemiş olan bir mirastan yoksunluk sebebidir.

Fikrimce, açıklanması gereken bir husus da, mahkemenin vereceği ka- 209
rarın niteliği ve etkisidir.

Eğer bu karar, Gerekçe'de belirtildiği gibi, salt bir tespit kararı ise, sırf 210
davalının kusurlu olduğunun tespitinin, onun mirasçılığını engelleyememesi gerekir. Bundan sonra, büyük bir ihtimalle, bu karar sebebiyle eşin mirasçılığını engellemek için niteliğinin ne olacağının saptanması gereken bir başka davanın da açılması gerekecektir.Buna karşılık, mahkemece kusurun tespiti ile, sağ kalan eşin mirasçılığına da son veriliyorsa, o zaman, bu karar var olan bir hukuki duruma (sağ kalan eşin mirasçılık sıfatına) son vereceği

[78] Bkz., Gerekçe, 377 ve 296.

için, yenilik doğuran bir karar olacaktır.Çünkü bu karar ile birlikte sağ kalan eşin mirasçılığına son verilmektedir.

211 MK 181/II, Anayasa'ya aykırı olduğu iddiasıyla Manavgat Birinci Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından, aile mahkemesi sıfatıyla Anayasa Mahkemesine getirilmiştir. Anayasa Mahkemesi, bu iddiayı haklı görmüş ve 21.1.2010 tarih ve 102/14 sayılı kararı ile[78a] MK 181/II'deki *davacı ve davalı ibarelerini iptal etmiştir.* Yüksek Mahkeme ayrıca, yeni bir düzenleme yapılması için kanun koyucuya altı ay süre tanımıştır.

212 Anayasa mahkemesi, hükmün iptalini daha ziyade usul hükümleri ile gerekçelendirmiştir. Buna göre, davaya devam hakkının sadece davacının mirasçılarına tanınması AY 10'daki eşitlik ilkesine aykırıdır. Yine Yüksek Mahkemeye göre MK 181/II âdil yargılama hakkını düzenleyen AY 36'ya da aykırıdır[78b].

213 Anayasa Mahkemesinin iptal kararından sonra kanun koyucu 31.3.2011 tarih ve 6217 sayılı kanunun 19. maddesi ile[78c] hükmü şu şekilde yenilemiştir: *"Boşanma davası devam ederken, ölen eşin mirasçılarından birisinin davaya devam etmesi ve diğer eşin kusurunun ispatlanması hâlinde de yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır".* Bu düzenleme Anayasa Mahkemesinin iptal kararına paraleldir, yani eşitlikten yola çıkılmıştır. Böyle olunca da, yukarıda belirtilen maddi hukuka ilişkin problemler yine cevapsız kalmıştır.

214 İsviçre Hukukunda, boşanma kararının kesinleşmesinin, eşlerin mirasçılığına ve birbirleri lehine yapmış oldukları ölüme bağlı tasarruflara etkisinin ne olacağına ilişkin ZGB Art. 120/II'de, MK 181/I'e paralel bir hüküm bulunmaktadır. Buna karşılık, boşanma davası devam ederken, eşlerden birinin ölümünün, diğer eşin mirasçılığına ve lehine yapılan ölüme bağlı tasarrufa etkisinin ne olacağına ilişkin özel bir düzenleme yoktur. Bu durumda nasıl bir sonuca varılması gerektiğine evlenmenin iptali (butlanı) davasının sonuçlarını düzenleyen ZGB Art. 109'un hükmüyle varmak gerekir. Söz konusu hükme göre, iptal davasının açılmasıyla birlikte sağ kalan eş, miras hukukundan doğan tüm haklarını kaybetmektedir. Bundan da anlaşılacağı gibi, kanunkoyucunun, evliliğin iptali davasında, bu hususların çözümünü getirirken, boşanma davasındaki aynı duruma bir çözüm getirmemiş olmasının anlamı, boşanma davası için *bilinçli susmayı* tercih ettiğidir. Böyle olunca da, İsviçre hukukunda, boşanma davasının açılmış olmasının, dava sırasında eşlerden birinin ölmesi hâlinde, sağ kalan eşin yasal mirasçılığına ve lehine yapılan ölüme bağlı tasarruflardan kaynaklanan haklara (mirastan çıkarma ve yoksun kalma hükümleri saklı kalmak şartıyla), bir etkisinin olmayacağıdır. Yani sağ kalan eş, ölenin yasal mirasçısı olmaya devam edecek ve lehine yapılan ölüme bağlı tasarruflardan kaynaklanan haklarını talep edecektir. Bu, bir ölçüde, boşanma davasında taraf olma ehliyetinin, münhası-

---

[78a] RG 27737.

[78b] Etraflı bilgi için bkz., *Dural/Öğüz*, 3, 136 vd.

[78c] RG 27905.

ran eşlere ait olmasının, bu sebeple mirasçıların davaya takip edememelerinin ve evlenmenin boşanma ile değil de ölme ile sona ermesinin doğal bir sonucudur[79].

Bu konuyu bitirmeden önce bir hususun vurgulanmasında yarar vardır. 215
MK 181'de açıklanan hususlar, sağ kalan eşin, bu sıfatı ile mirasçı olmasını engeller. Eğer eşler arasında, ayrıca birbirlerine mirasçı olmalarını gerektiren bir kan hısımlığı varsa, sağ kalan eşin bu sıfatla mirasçılığı devam eder, meğer ki, sağ kalan eş mirastan çıkartılmış olsun ya da bir mirasçılıktan yoksunluk sebebi bulunsun.

Nihayet son olarak belirtelim ki, ayrılık kararının varlığı (MK 170 vd), 216
ayrılık sırasında ölen eşe, sağ kalan eşin mirasçı olmasına ve lehine yapılmış ölüme bağlı tasarruflardan kaynaklanan hakları istemesine engel değildir. Çünkü, ayrılık kararına rağmen evlenme devam etmektedir.

2. Evliliğin butlanı kararının eşin mirasçılığına etkisi

Evliliğin butlanı kararının, sağ kalan eşin miras hukukundan doğan 217
haklarına etkisinin ne olacağı MK 159'da öngörülmüştür. Buna göre, *"Evlenmenin butlanını dava etme hakkı mirasçılara geçmez. Ancak mirasçılar açılmış olan davayı sürdürebilirler: Dava sonucunda evlenme sırasında iyiniyetli olmadığı anlaşılan sağ kalan eş, yasal mirasçı olamayacağı gibi, daha önce yapılmış olan ölüme bağlı tasarruflarla kendisine sağlanan hakları da kaybeder"*.

Madde pek açık olmadığı için, bir kaç noktada açıklanmaya muhtaçtır. 218
Önce, mirasçıların açılmış olan davaya devam etmeleri, ancak nisbî butlan hallerinde söz konusu olacaktır. Bunun böyle olduğu, nisbî butlan sebeplerini öngören MK 148 vd'den anlaşılmaktadır. Çünkü bu maddelerde, nisbî butlan davası açma hakkı, kural olarak ilgili eşe; yaş küçüklüğü ve kısıtlılık hâlinde ise, yasal temsilciye (MK 153) tanınmıştır, yoksa mutlak butlan davasında olduğu gibi, her ilgiliye ve savcıya değil...

> Eşlerden birinin, nisbî butlan davasını açıp ölmesi hâlinde, mirasçıların, butlan 219
> davasına devam etmekte menfaatları bulunduğu için, bir dereceye kadar doğrudur. Çünkü, evliliği iptal ettirebilirlerse bu, onların miras haklarını olumlu etkiler. Fakat, yasal temsilcinin, özellikle de vasinin davayı açtıktan sonra ölmesi durumunda, *onun mirasçılarının* davaya devam etmekte hiç bir menfaatleri yoktur, dolayısıyla da bu kişilere dava hakkı tanımanın hiç bir anlamı yoktur. Bu bakımdan, maddedeki mirasçılar terimini, *fikrimce, ölen eşlerin mirasçıları* şeklinde anlamak daha doğru olur.

İkinci olarak belirtilmesi gereken husus, mutlak butlanla batıl olan ev- 220
lenmelerde, mutlak butlan davası açma hakkının, *kanunî halef* sıfatıyla mirasçılara geçmeyeceğidir. Yani MK 159 c.1'e göre, mirasçılara, mirasbıra-

---

[79] *Hegneuer*, Familienrecht, 12.09.

kandan intikal eden bir butlan davası açma hakkı yoktur. Fakat onlar MK 147/I, c.1'deki *ilgililerin* kapsamına giriyorlarsa, ölümle şahıslarında doğan haktan (yoksa mirasbırakandan intikal eden değil!) yararlanarak mutlak butlan davası açabilirler.

221 Son olarak üzerinde durulması gereken husus, MK 159 c. 2 ile c. 3 arasındaki ilişkidir. İkinci cümlede, mirasçıların açılmış olan (nisbi) butlan davasına devam edebilecekleri belirtildikten sonra; 3. cümle, *dava sonucunda* diyerek başlamakta ve sanki, sadece mirasçıların devam ettiği davanın kastedildiği zehabını uyandırmaktadır. Bu ise, mutlak butlan davasına, ilgili tarafından açılmış olması hâlinde, mirasçılık yönünden 3. cümlede varılan çözümün uygulanamayacağı sonucunu doğuracak niteliktedir. Öyle olunca da bu, mutlak butlan davasının en önemli sonucunun uygulanamaması anlamına gelir.Bu durum ise, ikisi de evlenmenin sona ermesi sonucunu doğuracak olan iki karara farklı sonuçların bağlanması sebebiyle eşitliğe aykırı olur.Bu bakımdan, Gerekçe'de doğru olarak belirtildiği gibi, cümledeki *butlan davası* ibaresini, hem mutlak hem de nisbî butlanı içerecek şekilde anlamak gerekir[80].

222 Bu açıklamalardan sonra, butlan kararının, eşlerden birinin ölümünden sonra açılan dava (mutlak butlan) ya da, eşlerden birinin davayı açtıktan sonra ölmesi sebebiyle, mirasçıların davaya devam etmesi sonucu (nisbî butlan) elde edilmesi hâlinde, sağ kalan eş iyiniyetliyse,hem yasal mirasçı olabilecek hem de, daha önce lehine yapılmış olan ölüme bağlı tasarruftan doğan haklarını isteyebilecektir. Buna karşılık iyiniyetli değilse, yâni yaptığı evlenmenin bâtıl olduğunu biliyor ya da bilmesi gerekiyorsa, yasal mirasçılık hakkını kaybedecek ve aynı zamanda, lehine bir ölüme bağlı tasarruf varsa, bundan doğan hakları da kanun gereği sona erecektir.

223 Eşlerden biri öldükten sonra mutlak butlan davası açılmaz ya da açılan davaya mirasçılar devam etmezse, evlilik ölüm sebebiyle sona ermiş olacak ve sağ kalan eşin miras hukukundan doğan hakları yönünden evliliğin ölümle sona ermesine ilişkin kurallar uygulanacaktır.

224 MK 159'a paralel bir hüküm eski Medenî Kanunda bulunmadığı için, mesele doktrinde butlan kararının sonuçlarını düzenleyen MK 114, 124 ve 127'ye göre çözülmeye çalışılıyordu. Bu konudaki görüşleri özetleyecek olursak, bazı yazarlar, sağ kalan eşin iyiniyetli olması hâlinde mirasçı olabileceğini kabul ederken, diğerleri, iyi ya da kötüniyet ayırımını yapmadan sağ kalan eşin her zaman mirasçı olacağını savunuyorlardı. Nihayet üçüncü bir grup yazar ise, sağ kalan eşin hiç bir zaman mirasçı olamayacağını ileri sürüyorlardı[81]. Bu konuda Yargıtay da değişik kararlar vermiştir. 1994 tarihli son kararında Yargıtay[82], eşin, iyi ya da kötüniyetli olduğuna ba-

[80] Bkz., Gerekçe, 372

[81] Etraflı bilgi için bkz., *Dural/Öz*, birinci bası, § ,III,2.

[82] HGK 26.10.1994, 756/638 (YKD 1995, c. XXI, 701). Bu kararın tahlili için bkz., *Öğüz*,

kılmaksızın mirasçı olacağı sonucuna varmıştır. Karara göre, MK 126'daki iyiniyetli kadının, evlenmenin butlanına karar verilmiş olsa bile, evlenmeyle iktisap ettiği durumu korur hükmü, ad, vatandaşlık ve erginlik ile ilgilidir. Oysa miras ölümle açıldığı için, evlenmeyle kazanılanlar arasında yer almaz ve iyi ya da kötüniyet ayırımı bu konuda yapılamaz.

Butlan davasının etkisi yönünden ZGB Art. 109'daki düzenleme bizden farklı- 225
dır. Şöyle ki, butlan davasının açılması ile birlikte eşler, iyi ya da kötüniyetli olup olmadıklarına bakmaksızın, birbirlerine karşı olan miras hukukundan kaynaklanan tüm haklarını kaybederler. Yâni davanın açılması ile birlikte artık hem birbirlerinin yasal mirasçısı olamazlar hem de, o ana kadar birbirleri lehine yapmış oldukları ölüme bağlı tasarruflar kanun gereği ortadan kalkar.

3. Birden fazla sağ kalan eşin mirasçılığı

Türk Hukukunda, ister erkek olsun ister kadın, aynı anda iki kişi ile evli 226
olmak mümkün değildir. Ancak iki istisnai halde, mirasbırakanın ardında iki eş bırakmış olması mümkündür. Bunlardan birincisi, bugün belki de hiç rastlanmayacak olan 1926'dan önceki hukuk zamanında yapılan evlenmelerdir. Eski ve yeni Tatbikat Kanunu 9'a göre, bu evlenmeler, eski Medenî Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra da geçerliklerini korudukları için, erkek, eski kanuna göre iki ya da daha fazla kadınla evlenmiş ve eski Medenî Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra ölmüşse, mirasçı olarak birden fazla eş bırakmış olabilirdi. İkinci ihtimal ise, her nasılsa iki defa evlenmiş kadın ya da erkeğin evlenmenin butlanına karar verilmeden önce ölmesi ve sağ kalan eşin iyiniyetli olması hâlidir. Bu hâlde de geride mirasçı olarak iki eş kalır.

İşte böyle bir halde, sağ kalan eşler, birlikte mirasçı oldukları zümreye 227
göre sahip oldukları miras payını aralarında eşit olarak paylaşırlar. Örneğin iki eşi olan mirasbırkanın birinci zümre mirasaçıları varsa, her bir eş, bu zümreyle birlikte mirasçı oldukları için, o zümreye göre hakları olan 1/4 miras payını aralarında 1/8'er olarak paylaşırlar.

§ 6. Devletin Mirasçılığı

MK 501'e göre, *"Mirasçı bırakmaksızın ölen kimsenin mirası Devlete* 228
geçer". Buna göre, Devletin, yasal mirasçı sıfatıyla terekeye el koyabilmesi için, mirasbırakanın hiç bir yasal mirasçısının bulunmamasının yanında, terekenin tümü için mirasçı atamamış olması da gerekir. Terekenin tümü için atanmış mirasçının bulunduğu hâllerde, Devlet yasal mirasçı sıfatını kazanamaz. Buna karşılık, hiç bir yasal mirasçısı bulunmayan mirasbırakan, te-

---

Butlan Kararından Önce Ölen Eşe Diğer Eşin Mirasçılığı Sorununda Yargıtay'ın Tutumu Üzerine Karar İncelemesi, Kocaeli Hukuk Fakültesi Dergisi, yıl, 1, sayı 1, Kasım 1997, 505 vd.

rekenin bir bölümü için mirasçı atamışsa, geri kalan kısım, yasal mirasçı sıfatıyla Devlete kalacağı için, Devlet, atanmış mirasçı ile birlikte, miras ortaklığını oluşturur.

229 Uygulamada, MK 597'ye dayanılarak, mirasbırakanın mirasçı atadığı hâllerde, yasal mirasçı sıfatıyla Devlete, itiraz imkânı tanımak için, vasiyetnamenin bir sureti tebliğ edilmekte ve iptal sebebi bulunsun bulunmasın, Devlet vasiyetnameye itiraz etmektedir.

230 Yukarıda da değinildiği gibi Devlet, mirasbırakanın hiç bir yasal ya da atanmış mirasçısının bulunmadığı hallerde terekeye mirasçı sıfatıyla el koymaktadır. Bu bakımdan önce, mirasbırakının hiç bir yasal mirasçısının bulunmadığının tespiti gerekir. Bunun için, ölenin son yerleşim yeri sulh mahkemesi, MK 594'e göre, bir ay arayla iki defa ilân verip, son ilân tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde ilgililerin başvurmasını ister. Bu bir yıllık süre içinde hiç bir mirasçı ortaya çıkmazsa, tereke, mirasçı sıfatıyla Devlete teslim edilir. Ancak Devlet, mirasçılık sıfatını bu bir yıllık sürenin sonunda değil, ölüm anında kazanır[83]. Sürenin geçmesinden sonra ortaya çıkan mirasçıların, miras sebebiyle istihkak davası açma hakları saklıdır.

231 Diğer mirasçılara oranla, Devletin mirasçılığının iki özelliği vardır. Önce, devletin mirasçı olduğu hâllerde, terekenin resen resmî defteri tutulur (MK 631/I). Oysa, diğer yasal ve atanmış mirasçıların bulunduğu hâllerde, terekenin resmî defterinin tutulabilmesi için, MK 619/I'e göre, mirasçılardan birinin talepte bulunması gerekir.

232 İkinci özellik, Devletin, mirasbırakanın borçlarından sorumluluğunda vardır. Devletin, diğer mirasçılardan farklı olarak, borçlardan sınırsız sorumluluğu yoktur. MK 631/II'ye göre Devlet, deftere yazılmış olan tereke borçlarından sınırsız ve kişisel olarak değil, *sadece miras yoluyla edindiği değerler ölçüsünde sorumludur.*

233 Bu konuda son olarak iki hususun açıklanmasında yarar vardır. Önce, burada, Devletin yasal mirasçı sıfatıyla terekeye el koyması üzerinde durulmaktadır, yoksa Devletin, kamu hukukundan doğan sahipsiz bir mala el koyma yetkisi üzerinde değil...İkinci olarak, Devlet, sadece hiç bir yasal mirasçının bulunmadığı hâllerde değil, var olan mirasçıların tümünün, mirasın reddi, mirastan çıkarma ya da yoksunluk sebebiyle mirasçılık sıfatını kazanamamış ya da kaybetmiş oldukları hâllerde de, terekeyi edinecek hiç bir mirasçı bulunmadığı için, yine yasal mirasçı olarak terekeye el koyar[84].

---

[83] Etraflı bilgi için bkz., *Kocayusufpaşaoğlu*, § 10, I.

[84] Devletin mirası reddedip edemeyeceğine ilişkin bkz., *Kocayusufpaşaoğlu*, § 10, II.

İKİNCİ KISIM

ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR

Aslında bu bölüme, birinci bölüme paralel olarak, atanmış (iradî, mansup) mi- 234
rasçılık denilmesi daha doğru olurdu. Ne var ki, bu bölümün konusunu oluşturan ve *Ölüme Bağlı Tasarruflar* başlığını taşıyan, birinci kısmın ikinci bölümü, sadece mirasçı atanmasını değil (MK 516), bütün maddî ve şeklî anlamda ölüme bağlı tasarrufları ve ayrı başlıklar altında inceleyeceğimiz, tasarruf özgürlüğü (nisabı), saklı pay (mahfuz hisse) ve tenkisi de düzenlemektedir. Burada da, ölüme bağlı tasarruflar bir bütün olarak inceleneceği için, *Ölüme Bağlı Tasarruflar* başlığı tercih edilmiştir[85].

[85] Krş., *Ayiter/Kılıçoğlu*, § 3'ün başlığı.

§ 7. Ölüme Bağlı Tasarruflara İlişkin Önbilgiler

I. KAVRAM[86]

235 Mirasbırakanın terekesi üzerinde, mirasçılık dahil, kanunun çizdiği sınırlar içinde düzenleme yapabilmek için bir irade beyanında bulunması gerekir. Bir başka deyişle, mirasbırakanın arzu ve isteklerine uygun, atanmış mirasçılığın ve diğer düzenlemelerin onun istediği sonuçları doğurabilmesi için, bunların bir hukukî işlemle açığa vurulması gerekir. İşte bu işleme ölüme bağlı tasarruf denir. O halde, *ölüme bağlı tasarruf, mirasbırakanın ölümünden sonra hüküm doğuracak emirlerini içeren bir hukukî işlemdir.*

236 Belirtmek gerekir ki, mirasbırakanın ölümünden sonra hüküm ifade edecek emirlerini *(Anordnung)* ifade etmek üzere tasarruf kelimesinin kullanılması yanıltıcıdır. Daha açık bir ifadeyle, miras hukukunda tasarruf kelimesi teknik anlamdaki (sağlararası) tasarruf kelimesinden farklı bir anlam taşır. Çünkü ölüme bağlı tasarruf anlamında *tasarruf*, var olan bir hakka doğrudan etki yapan, onu devir eden, ortadan kaldıran ya da içeriği yönünden değiştiren bir işlem değildir. Bu terim, miras hukukunda, mirasbırakanın ölümünden sonra hüküm ifade edecek her türlü emri anlamına gelir. Bunun yanında, sağlararası tasarruf işlemi, yapıldığı anda hüküm ifade ettiği hâlde, ölüme bağlı tasarruflarda durum farklıdır. Çünkü, ölüme bağlı tasaruf, niteliği gereği, malvarlığına değil de terekeye ilişkin olduğu için, yapıldığı anda etkili olmaz. Yâni, mirasbırakan ile lehine tasarruf yapılan kimse arasında, mirasbırakan sağ olduğu sürece (miras sözleşmesi ile mirastan feragat sözleşmesindeki bağlılık hariç), bir hukuki ilişki doğurmaz, sonuç ancak, mirasbırakanın ölmesinden, yâni mirasın açılmasından sonra gerçekleşir. Bu bakımdan, lehine ölüme bağlı tasarrufta bulunulan kimse (atanmış mirasçı, vasiyet alacaklısı), mirasbırakan ölmedikçe, hukuken korunan bir beklenen hak bile kazanmış değildir. Burada, *var olan değil de ümit edilen* bir hukukî ilişki söz konusu olduğu için, mirasbırakan sağ olduğu sürece, lehine tasarruf yapılan kimse, ölüme bağlı tasarrufun geçerliliği için tespit davası dahi açamaz[87]. Bunlardan da anlaşılacağı gibi, ölüme bağlı tasarruflardaki *tasarruf* kelimesi, *işlem* anlamında kullanılmıştır, yani *ölüme bağlı işlemi* ifade eder.

---

[86] Buradaki açıklamalar için bkz., *Dural,* Miras Sözleşmeleri, Giriş, II vd; *Dural,* Vasiyetname, § 1, I.

[87] BGHZ, 37, 137.

Ölüme bağlı tasarrufların, mirasbırakanın ölümünden sonra hüküm ifade etmeleri, işlemin niteliği gereğidir; ölüm, onun *causa*'sıdır. Bu sebeple, bir sağlararası tasarrufun hüküm doğurmasının, şart ya da vade olarak ölüme bağlanması, onu bir ölüme bağlı tasarruf hâline getirmez. Çünkü bu hâlde ölüm, işleme bağlanan arızi bir unsur olup, onun niteliğinin sonucu, yâni *causa*'sı değildir. 237

Doktrin ve uygulamada, bir hukukî işlemin ölüme bağlı tasarruf sayılabilmesi için, genellikle şu unsurları içermesi aranır: 238

a) Ölüm, hukuki işlemin sebebi, yani asıl unsuru olmalıdır. 239

b) Lehine ölüme bağlı tasarrufta bulunulan kişi, mirasbırakanın ölümünde sağ olmalıdır (MK 580). 240

c) Mirasbırakan sağlığında herhangi bir şekilde bağlanmamalıdır. 241

d) Mirasbırakan yaptığı kazandırmanın, malvarlığından değil de terekesinden çıkmasını istemiş olmalıdır. 242

e) Lehine tasarrufta bulunulan kişi, gerçek anlamda bir beklenen haktan yoksun bulunmalıdır. 243

f) Mirasbırakan sağ olduğu sürece tasarrufun etkisi gerçekleşmemelidir. 244

g) Mirasbırakan ifayı kendi malvarlığından yerine getirmeyip, bunu, terekesine, dolayısıyla da mirasçılara yüklemelidir. 245

Ancak, belirtmek gerekir ki, bugün gittikçe taraftar toplayan bir görüşe göre, bir hukuki işlemin yukarıda sayılan unsurların tamamını ya da büyük bir kısmını içermesi, onun muhakkak bir ölüme bağlı tasarruf olduğu anlamına gelmez. Kuşkusuz,bu unsurların varlığı, işlemin bir ölüme bağlı tasarruf olduğuna ilişkin bir fiilî karine yaratır. Fakat, buna rağmen, bir sağlararası hukuki işlemin mi yoksa bir ölüme bağlı tasarrufun mu bulunduğu, tarafların çıkarlarına göre değerlendirilmelidir. Federal Mahkemenin de aynı görüşte olduğu söylenebilir. BGE 99 II 271 vd.ye göre, sonuçlarını sağlararasında doğuran bir işlemin ölüme bağlı tasarruf olması mümkün değildir; fakat, tarafların amacına göre aksi olabilir. Başka bir deyişle, sonuçlarını ölümden sonra doğuran bir işlem, tarafların amacına göre, bir sağlararası işlem olabilir[88]. Yargıtay'a göre bir tasarrufun ölüme bağlı tasarruf mu yoksa sağlar arası bir işlem mi olduğunda kuşku duyulan hâllerde favor negotii (işlem lehine yorum) kuralı gereğince sağlar arası işlem kabul edilmesi gerekir[88a]. 246

II. ÖLÜME BAĞLI BAĞIŞLAMALARIN, ÖLÜME BAĞLI TASARRUF HÜKÜMLERİNE TÂBİ OLMASI

BK 290/II'ye göre, *"Yerine getirilmesi bağışlayanın ölümüne bağlı olan bağışlamada vasiyete ilişkin hükümler uygulanır"*. Hemen belirtmek gerekir ki, buradaki vasiyet teriminin OR 245'e uygun olarak ölüme bağlı tasarruf şeklinde anlaşılması gerekir. Böyle olunca da, bağışlamanın iki taraflı bir hukukî işlem olduğu düşünülecek olursa, uygulanacak hükümler, miras sözleşmesine ilişkin olanlar olacaktır. 247

---

[88] Krş., *Serozan*, Kazandırma, 17 vd.

[88a] 3. HD., 6.12.2004, 12296/13423 (YKD 2005, c. XXXI, 182).

248 Tenfizi ölüme bağlı bağışlamadan kasıt, aslında sağlararası bir hukukî işlem olan bağışlama vaadinin vade ya da ecel olarak bağışlayanın ölümüne bağlanmasıdır. İşte bu tür bir bağışlama, şekil, ehliyet, yasal temsil yasağı ve saklı pay yönünden BK 290/II'de miras sözleşmesi hükümlerine tabi tutulmuştur[89].

249 Aslında bu hüküm, yukarıda sözü edilen, bir işlemin ölüme bağlı tasarruf mu yoksa sağlararası bir tasarruf mu olduğunu menfaatler durumuna göre değerlendiren görüşe uygundur. *Oğuzman*[90], BK 290/II dışında, Medenî Kanun ve Borçlar Kanununda, etkisini ölümden sonra gösteren bağışlamalar için, bir hüküm bulunmadığından hareketle, klâsik görüşe uygun olarak, malvarlığı mı yoksa tereke üzerinde mi tasarruf edilmek istendiğine göre bir sonuca varılması gerektiği görüşündedir. Buna göre, eğer terekede tasarruf edilmek amacı güdülüyorsa, ölüme bağlı tasarruf hükümleri uygulanmalıdır. Esasında malvarlığı üzerinde tasarruf edilmekte, fakat ifa tesadüfen ölümden sonraya kalmışsa, sağlararası işlem hükümleri uygulanmalıdır[91].

250 *Kocayusufpaşaoğlu*[92], ölüme bağlı bağışlamalarda iki farklı durumun bulunduğunu söylemektedir. Bunlardan biri BK 292/I'de sözü edilen bağışlayana rücu şartı ile yapılanlardır. Yazarın geniş anlamda ölüme bağlı bağışlama olarak adlandırdığı bu durum,bir sağlararası işlem olarak Borçlar Kanununa tabidir. BK 290/II'deki durumu ise, dar anlamda ölüme bağlı bağışlama olarak adlandıran yazar, bunlara, yukarıda da belirtildiği gibi, miras sözleşmesine ilişkin hükümleri uygular.

III. ÖLÜME BAĞLI TASARRUF KAVRAMININ İKİ ANLAMI

251 Medenî Kanunun, Miras Hukuku kitabının, birinci kısmının, ikinci bölümünün üç ve dördüncü ayırımları incelendiği zaman, ölüme bağlı tasarruf teriminin iki ayrı anlamda kullanıldığı görülür. Üçüncü Ayırım, *Ölüme Bağlı Tasarrufların Çeşitleri başlığı* altında, içerik olarak ölüme bağlı tasarrufları düzenler ki, bunlara, *maddî anlamda ölüme bağlı tasarruflar* denir. Dördüncü ayırım ise, Ölüme Bağlı Tasarrufların Şekilleri başlığı altında, mirasbırakanın iradesini açıklarken uyması gereken şekil kurallarını düzenler ki, bunlara *şeklî anlamda ölüme bağlı tasarruf* denir.

252 Aslında bir maddî anlamda ölüme bağlı tasarruf olan mirastan çıkarma (ıskat), tasarruf özgürlüğünü etkilediği için, MK 510'da tasarruf özgürlüğü bölümünde düzenlenmiştir. Burada, niteliğine uygun olarak mirastan çıkarma, maddî anlama ölüme bağlı tasarruflar arasında incelenecektir[93].

1. Şekli anlamda ölüme bağlı tasarruflar

253 Bu, mirasbırakanın ölümünden sonra hüküm ifade etmesini istediği iradesini açıklarken uymak zorunda olduğu şekil şartlarını ifade eder[94]. Bu da

---

[89] 14.HD, 23.10.1997, 5934/7268 (YKD 1997, c. XXIII, 1877); *Öğüz*, 387.
[90] *Oğuzman*, 96/97.
[91] Yazara göre, 97, dn.99'da belirtilen Yargıtay kararları bu yöndedir.
[92] § 11, 11, II; iki kavram arasındaki fark için bkz., *Öğüz*, 389.
[93] Bkz., aşağıda, § 16, IX.
[94] Bazı yazarlar buna, geniş anlamda ölüme bağlı tasarruf demektedir. Örnek olarak bkz., *İmre/Erman*, § 9, II; *Eren*, İptal, 4 vd.

iki türlü olabilir: *vasiyetname* (MK 531 vd.) ve *miras sözleşmesi* (MK 545). Şu halde, şeklî anlamda ölüme bağlı tasarruf, mirasbırakanın son arzularını yansıtan belge ya da kalıptır.

Vasiyetnameler, varması (yöneltilmesi) gerekli olmayan irade beyanı 254
ile yapılan, bir taraflı ölüme bağlı tasarruflardır. Mirasbırakan, bunları ölümüne kadar her zaman serbestçe geri alabilir.

Belirtmek gerekir ki, dördüncü ayırımda terimler titizlikle kullanılmış değildir. 255
Çünkü burada, şeklî anlamda bir ölüme bağlı tasarruf olan vasiyetnameyi ifade etmek üzere *vasiyetname* teriminin yanında vasiyet terimi de kullanılmıştır (örnek olarak bkz., MK 531, ve kenar başlığı, MK 539). Bu kullanış şekli eski Medenî Kanunda da vardı. Oysa vasiyet, maddî anlamdaki bir ölüme bağlı tasarruf türü olduğu için, şeklî anlamda bir ölüme bağlı tasarruf türü olan vasiyetnameyi ifade etme için kullanılması doğru değildir. Gerçi yeni Medenî Kanun, 517. maddesinde, vasiyet terimi yerine (ve onunla birlikte), *belirli mal bırakma* terimini kullanmaktaysa da (bu terim üzerinde aşağıda durulacaktır[95]), bu, vasiyet teriminin kelime anlamında bir değişiklik yapmaz.

Miras sözleşmeleri, sözleşme olmaları niteliği gereği, iki taraflı hukukî 256
işlemler olup, kanunda gösterilen istisnalar dışında bunlardan bir taraflı olarak dönülemez.

Şeklî anlamda ölüme bağlı tasarruflar, tıpkı maddî anlamda ölüme bağlı 257
tasarruflar gibi, *numerus clausus* prensibine tâbidirler. Bunun iki anlamı vardır. Önce, mirasbırakan, şeklî anlamda ölüme bağlı tasarruf olarak, ya vasiyetnameyi ya da miras sözleşmesini seçecektir. İkinci olarak, özellikle vasiyetnamelerde, sadece kanunun öngördüğü, aşağıda etraflıca açıklanacak olan, vasiyetname türlerinden birini seçebilir ve seçtiği vasiyetname türünde de, o tür için öngörülmüş olan şekil şartlarına mutlaka uymak zorundadır.

Burada, sırası gelmişken,vasiyetname ve miras sözleşmesi arasında yer alan, 258
Alman Hukukunda düzenlenmiş (BGB § 2265 vd), fakat Türk/İsviçre Hukukunda düzenlenmemiş olan, ortak (müşterek) vasiyetnameler üzerinde kısaca duralım ve *numerus clausus* prensibi karşısında, bunların geçerli olup olamayacaklarını inceleyelim[96].

Birden fazla mirasbırakanın, ölümlerinden sonra hüküm ifde etmek üzere, mal- 259
varlıkları üzerinde bir taraflı olarak tasarrufta bulunmak amacıyla birlikte son arzularını açıkladıkları ölüme bağlı tasarrufa ortak vasiyetname denir.

Bir vasiyetnamenin ortak vasiyetname sayılabilmesi için önemli olan dış bir- 260
lik,yani vasiyetnamenin harici olarak bir işlemde birleşmesi değil, malvarlığı üzerinde birlikte tasarrufta bulunmaya yönelik ortak iradenin varlığıdır. Başka bir ifadeyle, ortak vasiyetnamelerde, ortak karar sonucunda, tasarrufta bulunan birden faz-

---

[95] Bkz., aşağıda, § 16, II.

[96] Bundan sonraki açıklamalar, *Dural*, İsviçre/Türk Hukukunda Ortak (Müşterek) Vasiyetnameler (MHAD, yeni seri, yıl 3, N 4, İstanbul 1969'dan ayrı bası) adlı makalenin özetidir. Bu bakımdan bu kısımda, gerekli olmadıkça, ayrıca atıf yapılmayacaktır.

la mirasbırakan vardır ve birlikte hareket etme iradesinin tek belgede haricileşmesi zorunlu değidir. Ortak vasiyetnameler üç şekilde yapılabilir.

261 *a) Birlikte vasiyetname (testamentum simultaneum):* Burada, birden fazla kişi, aynı anda ve aynı belge içinde son arzularını açıklarlar. Bu durumda, sadece belgede birlik vardır, yoksa tasarrufların da birbirine uygun olması aranmaz. Örneğin, aynı vasiyetname içinde, eşlerden biri belirli bir mal bırakmada bulunurken, diğeri bir vakıf kurar.

262 *b) Karşılıklı vasiyetname (testamentum reciprocum):* Burada, vasiyetçiler, birbirleri lehine ölüme bağlı tasarrufta bulunurlar. Örneğin, birbirlerini mirasçı atar ya da birbirleri lehine vasiyet yapabilirler ya da biri diğerini mirasçı atarken, diğeri de ona terekesi üzerinde intifa hakkı tanır. Artık burada, tasarruflar arasında bir iç bağlılık kurulmuştur.

263 *c) Birbirine bağlı vasiyetnameler (testamentum correspectivum):* Burada, birlikte yapılmış vasiyetnamelerin her birinin geçerliği, diğerinin geçerli olmasına bağlanmıştır. Yani her bir vasiyetnamenin geçerli olması, diğerinin geçerliliğine bağlıdır. Birbirine bağlı vasiyetnamenin aynı zamanda karşılıklı olması şart değildir.Örneğin, karı koca, birbirlerini, diğerinin vasiyetnamesinin geçerli olması şartıyla mirasçı atarlarsa, bu birbirine bağlı vasiyetnameler aynı zamanda karşılıklıdır da. Buna karşılık, karı kocadan her biri kendi terekesi için ortak bir dostlarını mirasçı atar ve kendi tasarrufunun geçerliliğini, diğerinin tasarrufunun geçerli olmasına bağlarsa, vasiyetnameler sadece birbirine bağlıdır, fakat karşılıklı değildir.

264 İsviçre Medenî Kanunu projesinde yer almış olan ortak vasiyetnameler, bir yandan karışıklık yaratacağı, öte yandan da, miras sözleşmesini kabul eden bir sistemde ortak vasiyetnameye gerek olmadığı gerekçesiyle projeden çıkartılmıştır. Böylece, Medenî Kanunda, ortak vasiyetnameler hakkında hiç bir hüküm kalmamıştır. Bu susma karşısında, ortak vasiyetnamelerin İsviçre'de yapılabilip yapılamayacağı tartışması ortaya çıkmıştır.

265 *Escher*, kanunda hiç bir hüküm bulunmadığı gerekçesiyle, uno actu yapılan, yâni birlikte vasiyetnameleri geçersiz kabul eder. Yazara göre bunun müeyyidesi, mutlak butlandır yoksa iptal edilebilirlik değil... Çünkü, ortak vasiyetname, sadece şekil hükümlerine aykırı olmayıp, onun hakkında özel bir hüküm de bulunmamaktadır.

266 *Tuor* da uno actu yapılmış ortak vasiyetnamelerin, kişiye sıkı surette bağlı olma karakterinden ve ölüme bağlı tasarrufların şekil kurallarını ihlâl etmelerinden hareketle,bunları geçersiz sayar. Ancak ona göre, bu geçersizliğin müeyyidesi mutlak butlan değil, iptal edilebilirliktir. Zira burada, bir yandan haricileşmiş, kural olarak tam bir ölüme bağlı tasarruf olgusu bulunduğu gibi, aynı zamanda vasiyetçinin kimliği de bellidir. Sakatlık,sadece içerik yönündendir. ZGB Art. 519 (MK 557) vd.nin öngördüğü anlamda bir iptal kabiliyeti vardır ve bu tür vasiyetnamelerin hüküm ifade etmesini engellemek için, süresi içinde iptal davası açılması gerekir.

267 *Kocayusufpaşaoğlu*, İsviçre/Türk Hukukunda, ortak vasiyetnamelerin yasaklandığını kabul etmekte ve müeyyide yönünden Tuor'un görüşüne katılmaktadır.

268 Bütün bu açıklamalardan anlaşılacağı üzere, İsviçre/Türk Hukukunda genel olarak ortak vasiyetnameler değil de, Medenî Kanun'daki şekil şartlarından birine uymadan yapılmış ortak vasiyetnamelerin geçersiz kabul edildiği söylenebilir ki, bu da *birlikte yapılmış vasiyetnamelerdir*. Daha iyi bir deyişle, eğer ortak vasiyetname, birden fazla kişi tarafından uno actu yapılmışsa, örneğin, bir elyazısıyla vasiyetnameyi, vasiyetçilerden biri,her iki vasiyetçinin de son arzularını içerecek şekilde düzenlemiş ve sonra her ikisi de imzalamışlarsa ya da vasiyetçiler, son arzularını birlikte noter önünde açıklamış ve noter de her ikisinin son arzularını içerecek biçimde

bir vasiyetname düzenlenmişse, o zaman ortak vasiyetnameler, kanunda belirtilmiş şekil şartlarına uygun olarak düzenlenmedikleri için geçersiz olacaklardır. Bu geçersizliğin müeyyidesi fikrimce mutlak butlan değil iptal edilebilirliktir. Zira ortada, şekil şartlarını ihlal etmiş olsa bile, bir vasiyetname vardır ve şekil kuralarının ihlalinin sonucu MK 557'ye göre iptal edilebilirliktir.

Üzerinde durulması gereken bir mesele, şekil kurallarını ihlâl eden ve bu sebeple 269
de geçersiz olan birlikte vasiyetnamelerin tahvil (çevirme) yoluyla geçerli olmalarının temin edilebilip edilemeyeceğidir. Bir örnekle açıklayalım: A ve B, birlikte bir vasiyetname yaparak, son arzularını açıklamaya karar verirler. A, her ikisinin de son arzularını içerecek şekide vasiyetnameyi kaleme alır ve kendisi imzaladıktan sonra, B de, "yukarıdaki vasiyetname, benim de son arzularımı içermektedir" diye yazar ve imzalar. Şimdi, ortak vasiyetname olarak geçersiz olan bu vasiyetname, tahvil yolundan yararlanarak, A'nın vasiyetnamesi olarak ayakta tutulabilir mi? Baskın olan görüş, ortak olarak geçersiz olan ve vasiyetçilerden biri yönünden şekil şartlarını yerine getirmiş olan vasiyetnamenin,tahvil yoluyla bir tek vasiyetname olarak ayakta tutulabileceğidir, meğer ki, her iki vasiyetname arasında, birinin yapılmaması hâlinde, diğerinin de yapılmayacağını gösteren bir bağ bulunsun, yani birbirine bağlı birlikte vasiyetname söz konusu olsun.

Şu halde, Türk/ İsviçre Hukukunda, birlikte vasiyetnameler hariç, şekil şartlarına 270
uygun olması şartıyla, diğer ortak vasiyetnamelerin geçerli sayılması gerekir. Yâni, birlikte vasiyetname olmamaları şartıyla, karşılıklı ve birbirine bağlı vasiyetnamelerin yapılmasına bir engel yoktur. Özellikle MK 515'in ölüme bağlı tasarrufların şarta bağlanabileceğini öngördüğü düşünülecek olursa, birbirine bağlı vasiyetname yapılmasına bir engel yoktur.

Yargıtay'a gelince; 2. Hukuk Dairesi 1955 tarihli bir kararında[97], karşılıklı oldu- 271
ğu anlaşılan bir ortak vasiyetnameyi geçerli olarak kabul etmiştir. Ancak kararda, bu karşılıklı olan vasiyetnamenin, birlikte olup olmadığı anlaşılamadığı için, doğruluğu hakkında bir fikir ileri sürmek mümkün değildir. Aynı Daire, 1990 tarihli bir kararında[98], noterde yapılan bir karşılıklı vasiyetnameyi, miras sözleşmesi olarak yorumlayıp, geçerli kabul etmiştir. Karara konu olan olayda, karı ve koca, müşterek mallarını belirli kişilere bırakmışlar, fakat, içlerinden birinin ölümü hâlinde, diğerinin ölümüne kadar, söz konusu olan tasarrufun geçerli olmayacağını, malvarlığının tümünün hayatta kalana geçeceğini ve ancak onun da ölmesinden sonra vasiyetnamede belirtilen kişilere intikal edeceğini öngörmüşlerdi, yani bir art mirasçı atama vardı. İkinci Hukuk Dairesi, tarafların yaptıkları tasarrufu, ki bunun bir karşılıklı vasiyetname olduğu anlaşılmaktadır, vasiyetname olarak adlandırmanın önemsiz olduğunu, mirasbırakanın son arzularını, ölüme bağlı tasarruf, miras sözleşmesi ya da *sair kurum* olarak yorumlamak mümkün oldukça ayakta tutmak gerektiğini; burada da tarafların vasiyetname olarak adlandırdıkları belgeyi bir miras sözleşmesi (Yargıtay'ın deyişi ile mal vasiyeti mukavelesi) sayıp geçerli kabul etmiştir.

2. Maddî anlamda ölüme bağlı tasarruflar

Maddî anlamda ölüme bağlı tasarruflar, şeklî anlamda ölüme bağlı ta- 272
sarrufların içeriğini, orada açıklanan arzuları ya da mirasbırakanın ölüme bağlı emirlerini belirler. Örneğin, mirasçı atanması, mirastan çıkarma, evli-

[97] 2.HD, 27.2.1955, 6030/5945 (Jurisdictio, yıl 1, No.8, 714).
[98] 2.HD 2.3.1990, 9067/ 2434 (YKD 1990, c. XVI, 1296).

lik dışı çocuğun tanınması, vasiyeti yerine getirme görevlisi atanması, birer ölüme bağlı tasarrufturlar. Burada da mirasçıları bağlayacak tasarruflar yönünden numerus clausus prensibi yürür.

§ 8. Ölüme Bağlı Tasarruf Yapma Ehliyeti

I. GENEL OLARAK

273 Baskın görüş, burada hak ehliyetinde söz eder. Zira kanunda öngörülen ehliyet şartları gerçekleşmemişse, ölüme bağlı tasarrufta bulunulamaz[99].

274 Ancak, son zamanlarda gittikçe taraftar kazanan ve doğru olan görüş, ölüme bağlı tasarruf yapma (ve evlenme) yönünden belirli şartların aranmasını, sadece hak ehliyetinin değil de, fiil ehliyetinin de şartı (sınırlaması) olarak kabul etmektedir. Bu görüşte olan yazarlara göre, her ne kadar hak ve fiil ehliyeti arasında bir ayırım yapılması gerekirse de; belirli bir hakka ilişkin hususlarda hak ve fiil ehliyeti için aranan şartların aynı olduğu görülmektedir. Bunun en iyi örnekleri ölüme bağlı tasarruflar ve evlenmedir. Şöyle ki, MK 502 ve 503, ölüme bağlı tasarruf yapabilmenin; MK 124 vd., de evlenmenin şartlarını saymıştır. Bu şartları haiz olmayan bir kimse, ne ölüme bağlı tasarruf yapabilme ne de evlenme hak ve ehliyetine sahiptir.Böyle olunca da, şartların bulunmaması, bu haklar yönünden hem hak hem de fiil ehliyetini ortadan kaldırır[100]. *Oğuzman* ise, tam tersinden hareketle aynı sonuca varmaktadır[101]. Yazara göre, *"Her iki madde de öngörülen fiil ehliyetidir. Fakat ölüme bağlı tasarrufta temsile cevaz verilmediği için, ölüme bağlı tasarruf yapma ehliyeti bulunmayanlar ölüme bağlı tasarruf yapma hakkından da yararlanamazlar. Bu sebeple fiil ehliyetinin bulunmaması hak ehliyetini de etkiler".*

275 Ölüme bağlı tasarruf yapma ehliyeti, MK 502'de vasiyetnameler, MK 503'de miras sözleşmeleri için ayrı ayrı düzenlenmiştir.

II. VASİYETNAME YAPABİLME EHLİYETİ

276 MK 502'ye göre, *"Vasiyetname yapabilmek için ayırt etme gücüne sahip ve onbeş yaşını doldurmuş olmak gerekir"*. Görüldüğü gibi madde, vasiyetname yapabilme ehliyetini iki şarta bağlamıştır: ayırt etme gücü ve yaş.

---

[99] Örnek olarak bkz., *Escher*, Art. 427-469, Vorbem. 3; *Tuor*, Art. 467-469, Vorbem. 4; *İmre/Erman*, § 11,II; *Ayiter/Kılıçoğlu*, § 3, II.

[100] Etraflı bilgi için bkz., *Dural/Öğüz*, 4.3.1.1.3.; *Kocayusufpaşaoğlu*, § 12, I.

[101] *Oğuzman*, 98.

1. Ayırt etme gücü

Bilindiği gibi, ayırt etme gücü, kişinin, yaptığı hukukî işlemin sebep ve 277
sonuçlarını anlayabilecek durumda olmasını ifade eder[102]. Bunu vasiyetnamelere uygulayacak olursak, kişi, vasiyetname yapmanın sebep ve sonuçlarını anlayabilecek durumdaysa, bu konuda ayırt etme gücüne sahip sayılır.

Ayırt etme gücünün vasiyetnamenin yapıldığı anda bulunması gerekir. 278
Daha önce ya da daha sonra bulunup bulunmaması önemli değildir. Bu bakımdan, vasiyetname yapmadan önce ayırt etme gücü bulunmayan bir kimse, vasiyetname yaparken buna sahipse, yapmış olduğu vasiyetname geçerlidir ya da aksine vasiyetname yaparken var olan ayırt etme gücünün sonradan kaybı, geçerliği etkilemez. Ancak, ayırt etme gücünün vasiyetname yapılmadan önce bulunmadığı ya da yapıldıktan sonra kaybı, ayırt etme gücünü ispat etme yükümü altında bulunana büyük kolaylık sağlar Şöyle ki, vasiyetname yapılmadan önce ayırt etme gücünün bulunmadığını ya da yapıldıktan sonra kaybolduğunu ispat eden bir kimse, artık ayrıca vasiyetname yapılırken ayırt etme gücünün bulunmadığını ispat etmekten kurtulur[103].

Uygulamada, resmî vasiyetnamelerde, noter, ayırt etme gücünün varlığından 279
kuşku duyuyorsa, NK 72'ye göre hekim raporu isteyebilir. Bu rapor, aksi ispat edilinceye kadar, ayırt etme gücünün varlığına karine teşkil eder. Bu bakımdan, ayırt etme gücünün bulunduğuna ilişkin bir raporun varlığı, mirasbırakanın ölümünden sonra, ayırt etme gücünün bulunmadığı iddiasını ileri sürüp ispat etmeye bir engel oluşturmazsa da, bunu çok zorlaştırır[104].

Vasiyetname yapılırken bulunmayan ayırt etme gücünün sonradan ka- 280
zanılması, vasiyetnameyi geçerli hale getirmez; eğer hüküm doğurması isteniyorsa, aynı vasiyetnamenin, ayırt etme gücü kazanıldıktan sonra yeniden yapılması gerekir.

Vasiyetnamenin içeriğinin mantıklı ya da mantıksız olması önemli de- 281
ğildir. Ancak, mantıksız bir içerik, ayırt etme gücünün yokluğu yönünden önemli bir emare oluşturur[105].

Son olarak belirtelim ki, ayırt etme gücüne sahip olan bir kimsenin, kı- 282
sıtlanmış olması, vasiyetname yapma ehliyetini ortadan kaldırmaz. Çünkü MK 502, vasiyetname yapabilmek için sadece erginlik ve ayırt etme gücünü yeterli görmektedir.

---

[102] Ayırt etme gücüne ilişkin etraflı bilgi için bkz., *Dural/Öğüz*, 5.4.2.

[103] *Tuor*, Art. 467-468, Vorbem., 7; *Escher*, Art. 467-469, Vorbem. 6; *Kocayusufpaşaoğlu*, § 12,II,1; *İmre/Erman*, § 11,I, 1,a ve I,2; etraflı bilgi için bkz., *Dural*, Miras Sözleşmeleri, § 3, II,1.

[104] Bkz., *Oğuzman*, 100 ve dn. 106'da anılan Yargıtay kararları; ayrıca, *Kocayusufpaşaoğlu*, § 1, I, 1.

[105] *Tuor/Schnyder*, § 58, I.

2. Yaş

283 MK 502'ye göre, ayırt etme gücüne sahip olan bir kimse,ancak 15 yaşını doldurunca vasiyetname yapma ehliyetine sahip olur. Kanunun, daha ergin olmadan, kişiye vasiyetname yapma imkânını tanımasının iki sebebi vardır. Bunlardan birincisi, vasiyetname yapmanın, *mutlak kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardan* olmasıdır. Bunun anlamı, vasiyetname yapmada yasal temsil yasağının bulunmasıdır. Kanunkoyucu, buradan hareket ederek, henüz erginliğini kazanmamış kimselere de bu haktan yararlanma imkânı vermek için, vasiyetname yapma yaşını 15'e indirmiştir.

284 İkinci sebep ise, vasiyetnameler, bir taraflı ölüme bağlı tasarruf oldukları için, mirasbırakanın ölümüne kadar her zaman geri alınabileceklerinden, kanunkoyucu erginliği aramamakta bir tehlike görmemiştir.

285 Özetleyecek olursak, 15 yaşını doldurmuş olmaları şartıyla, ayırt etme gücüne sahip küçük ve kısıtlılar, serbestçe vasiyetname yapabilirler. Aynı durum, MK 429'a göre, kendilerine yasal danışman atanan kimseler için de söz konusudur[106].

286 Eski MK 88, kadın için olağanüstü evlenme yaşını 14 yaşın doldurulması olarak düzenlemişti. Böyle olunca da, 14 yaşını doldurup, evlendiği için ergin olan kadının, 15 yaşını doldurmadığı için, ergin olmasına rağmen, vasiyetname yapabilip yapamayacağı tartışması vardı[107]. Yeni kanun, MK 124/II'de, her iki cins için de olağanüstü evlenme yaşını 16. yaşın doldurulması olarak öngördüğünden, bugün bu tartışmanın yeri kalmamıştır.

III. MİRAS SÖZLEŞMESİ YAPMA EHLİYETİ

287 MK 503'e göre, *"Miras sözleşmesi yapabilmek için ayırt etme gücüne sahip ve ergin olmak, kısıtlı bulunmamak gerekir"*. Bu hükümden anlaşılacağı üzere, miras sözleşmesi yapabilmek için tam fiil ehliyetine sahip olmak gerekir.Ancak, hemen belirtmek gerekir ki, tam fiil ehliyeti, miras sözleşmesi ile ölüme bağlı tasarrufta bulunan için aranır. Ölüme bağlı tasarrufta bulunmayan taraf, aşağıda açıklanacağı gibi, genel ehliyet kurallarına tabidir (MK 16, 463 b. 5).

288 Miras sözleşmesi ile ölüme bağlı tasarrufta bulunma, mutlak kişiye sıkı sıkıya bağlı bir hak olmasına rağmen, kanunkoyucunun, vasiyetnamelerden farklı olarak, tam fiil ehliyetine sahip olmayı aramasının sebebi, miras sözleşmelerinin bağlayıcı olmasıdır. Başka bir ifade ile, miras sözleşmesinden, ancak kanunda belirtilen hâllerde, bir taraflı olarak dönme imkânı bulunduğu için, burada tam fiil ehliyeti aranmıştır.Bu bakımdan tam fiil ehliyetine

---

[106] HD 29.2.1983, 978/2735 (YKD 1984, c. X, 204.

[107] Bu tartışmalar için bkz., *Dural/Öz*, § 8, II, 2.

sahip bulunmayanlar (tam ehliyetsiz ve sınırlı ehliyetsizler), yasal temsilcileri aracılığıyla bile miras sözleşmesi ile ölüme bağlı tasarrufta bulunamazlar. Bu kişilerin yapmış oldukları miras sözleşmesi MK 557 b. 1'e göre iptal edilebilir. Ancak, ayırt etme gücüne sahip olmaları şartıyla, 15 yaşını doldurmuş ya da kısıtlı olan kişilerin yapmış oldukları miras sözleşmesinin, çevirme (tahvil, konversiyon) yoluyla resmi vasiyetname olarak ayakta tutulmaları mümkün olabilir[108].

Tam fiil ehliyetine sahip olmayan bir kişinin, yasal temsilcisi aracılığıyla miras sözleşmesi ile ölüme bağlı tasarrufta bulunamaması, bu hakkın mutlak kişiye sıkı surette bağlı hak olması ile açıklanmaktadır[109]. *Fikrimce,* bu görüşe katılmak mümkün değildir. Çünkü, mutlak kişiye sıkı surette bağlı olma niteliğinin, yasal temsilci aracılığıyla miras sözleşmesi yapabilmeye engel olması için, bu hakkın doğmuş olması gerekir. Oysa miras sözleşmesi ile ölüme bağlı tasarrufta bulunma hakkı, daha doğrusu, miras sözleşmesi yapmaya ilişkin hak (ve fiil) ehliyeti[110], tam ehliyetli olma ile kazanılmaktadır. Böyle olunca da küçük ya da kısıtlı için hak doğmamıştır. Olmayan bir hakkın değil yasal temsilci, bizzat "hak sahibi tarafından" dahi kullanılması mümkün değildir. 289

Yukarıda da değinildiği gibi MK 503'deki ehliyet kuralları, miras sözleşmesi ile ölüme bağlı tasarrufta bulunan için aranır. Eğer her iki taraf da terekesi üzerinde tasarrufta bulunuyorsa her ikisinin de tam ehliyetli olması gerekir. Buna karşılık, diğer taraf, terekesi üzerinde tasarrufta bulunmuyor, sadece mirasbırakanın iradesini kabul etmekle yetiniyor ya da bir sağlararası borç altına giriyorsa, o, genel ehliyet kurallarına tabidir. Buna göre[111]: 290

a) Miras sözleşmesinin ölüme bağlı tasarrufta bulunmayan tarafı tam ehliyetli ise, isterse sözleşmeyi bir temsilci aracılığıyla yapabilir. 291

b) Ölüme bağlı tasarrufta bulunmayan taraf, tam ehliyetsiz ise, miras sözleşmesini onun adına yasal temsilcisi yapar. Ancak, tam ehliyetsiz vesayet altında ise, MK 463 b.5'e göre, sulh ve asliye mahkemelerinin de rızasının bulunması gerekir. Veli yönünden bu şart aranmaz. 292

c) Terekesi üzerinde tasarrufta bulunmayan taraf sınırlı ehliyetsizse MK 16 daki hükümlere tabidir. Buna göre, sınırlı ehliyetsiz, miras sözleşmesi ile bir sağlararası ivaz borcu yüklenmiyorsa (karşılıksız kazanma), MK 16/II'ye göre, miras sözleşmesini yasal temsilcisinin katılmasına gerek olmadan tek başına yapabilir. Oysa, sınırlı ehliyetsizin miras sözleşmesi ile sağlararası bir borç altına girmesi hâlinde, yâni bir ivazlı miras sözleşmesi yapılıyorsa, MK 16/I'e göre, yasal temsilcinin işleme katılması (bizzat 293

---

[108] Bkz., aşağıda § 17, II, b, aa.

[109] Bu görüşte olan yazarlar için bkz., *Dural*, Miras Sözleşmeleri, § 3, II,2 ve dn 23 ve 24'de anılan yazarlar.

[110] Bkz., yukarıda I.

[111] Bu açıklamalar için bkz, *Dural*, Miras Sözleşmeleri, § 3, III.

yapması ya da yapılmasına rıza göstermesi) gerekir. Fakat sınırlı ehliyetsiz vesayet altında ise, işlemin geçerliği, MK 463 b.5'e sulh ve asliye mahkemelerinin de rıza göstermelerine bağlıdır. Velâyette, sulh ve asliye mahkemelerinin rızasına gerek yoktur.

294 Miras sözleşmesi ile sınırlı ehliyetsiz lehine yapılan tasarruf vasiyet ise, vasiyetin yükümlü olması, yasal temsilcinin işleme katılmasını gerektirmez. Çünkü sınırlı ehliyesiz, miras sözleşmesi yapıldığı anda değil, mirasın intikalinde, vasiyeti kurallarına uygun olarak elde edince yükümlülüğü yerine getirme borcu altına girer. Aynı şekilde, sınırlı ehliyetsiz bizzat borç altına girmediği sürece, üçüncü kişi yararına miras sözleşmesini de tek başına yapabilir. Çünkü, bu tür miras sözleşmelerinde, sınırlı ehliyetsiz ne bir yarar elde etmekte ne de bir borç altına girmektedir.O, sadece, mirasbırakanın isteğinin yerine getirilmesine yardımcı olmaktadır, yoksa kendi malvarlığından bir şey çıkmamaktadır.

295 Baskın görüş, sınırlı ehliyetsizin mirasçı atanması hâlinde de miras sözleşmesini tek başına yapabileceği görüşündedir. Gerekçe olarak da, sınırlı ehliyetsizin miras sözleşmesi ile borç altına girmediği gösterilmektedir. Onun borcu, yani tereke borçlarından sorumluluğu, ileride mirasbırakanın ölümü ile doğacaktır ki, bu da tehlikeli bir durum yaratmaz. Çünkü o zaman, tam fiil ehliyetini kazanmışsa kendisi, hâlâ sınırlı ehliyetsiz ise yasal temsilcisi, mirası reddederek, sınırlı ehliyetsizin borçlardan sorumluluğunu bertaraf edebilir.

296 Eski Medenî Kanun zamanında, MK 463 b.5'i karşılayan eski MK 406 b 5 ve MK 503'ü karşılayan eski MK 450 ile birlikte ele alındığı zaman tartışmalara yol açıyordu. Çünkü, eski MK 450, MK 503'den farklı olarak, miras sözleşmesi yapabilmek için sadece erginlikten söz ediyor, kısıtlı olmamaya hiç değinmiyordu. Böyle olunca da eski MK 406 b.5'in (yeni MK 463 b.5), vesayet altındaki kişilerin sulh ve asliye mahkemesinin izni ile miras sözleşmesi yapabilecekleri hükmü karşısında, vesayet altındaki sınırlı ehliyetsizlerin, bu yolla miras sözleşmesiyle ölüme bağlı tasarrufta bulunmalarının mümkün olup olmadığı tartışma konusu idi. Tartışmalar girmeden belirtelim ki, baskın görüş, ölüme bağlı tasarrufların, kişiye mutlak sıkı sıkıya bağlı hak olmasından hareketle, eski MK 406 b.5'deki hükmün, miras sözleşmesinin diğer tarafın ehliyetini düzenlediği, bu sebeple kısıtlının, sulh ve asliye mahkemelerinin izni ile miras sözleşmesiyle ölüme bağlı tasarrufta bulunamayacağı yönündeydi[112]. Yeni Medenî Kanun'da, kanunkoyucu, MK 503'ü, doktrin ve uygulamadaki görüşlere uygun olarak düzenleyerek[113] bu tartışmalara son vermiştir.

297 Mirastan feragat sözleşmesi de bir miras sözleşmesi olduğu için (MK 528), ona da yukarıda açıklanan ehliyet kuralları uygulanır. Burada, aşağıda açıklanacağı gibi[114], mirasbırakan gerçekte, karşı tarafın feragat iradesini kabul etmekten başka bir şey yapmamasına rağmen, tasarruf nisabına etkisi dolayısıyla, ölüme bağlı tasarrufta bulunuyor sayılmaktadır. Bu sebeple MK 503'deki ehliyet kurallarına tâbi olmaktadır. Feragat eden ise, yine yukarıda açıklanan genel ehliyet kurallarına tabidir[115].

---

[112] Bu konudaki tartışmalar ve aksi görüşler için bkz. *Dural/Öz*, § 8, III.
[113] Bkz. Gerekçe, 473.
[114] Bkz., aşağıda, § 15, III, 8.
[115] Etraflı bilgi için bkz., *Dural*, Miras Sözleşmeleri, § 3, IV.

Durum böyle olmakla beraber, *Şener*[116], mirastan feragat sözleşmesinde, tarafların iradesi yönünden aynen şöyle demektedir: *"Mirastan feragat için miras mukavelesi yapılması hâlinde iki tarafın da reşit olması zorunludur (MK 450, yeni 503). Eğer vasiyet (vasiyetname olsa gerek) seçilmiş ise,yani tek taraflı bir feragat söz konusu olursa, mümeyyiz olup 15 yaşını doldurmak yeterlidir (MK 449, yeni 502). Hatta 14 yaşını bitirmiş olup, hâkimin izniyle evlenmiş olan kişi de (eski MK 88) vasiyet yapabilir".* 298

Bu açıklamalara göre yazarın, mirastan feragatin muhakkak miras sözleşmesi ile yapılması gerekmediğini, bir vasiyetname ile de yapılabileceğini kabul ettiği anlaşılmaktadır. Yine yazara göre, feragatin miras sözleşmesi ile yapılması hâlinde, her iki tarafın da ergin olması gerekirken, feragatin vasiyetname ile yapılması hâlinde, vasiyetname yapma ehliyetinin bulunması yeterlidir. 299

Şener'in bu görüşüne katılmaya imkân yoktur. Feragatin, vasiyetname ile yapılması bizim hukukumuzda mümkün değildir. Çünkü, mirastan feragat, bağlayıcı bir tasarruf olduğu için, bunun sadece miras sözleşmesi ile yapılabileceği kendiliğinden anlaşılan bir husustur. Bunun yanında, mirastan feragatin, nitelik ve amacından hareket edince de, vasiyetname ile yapılmasının mümkün olmadığı açık olarak görülür[117]. Bunun yanında, feragat eden ölüme bağlı tasarufta bulunmadığına göre, neden MK 503'deki hükümlere tabi olacağı da anlaşılmamaktadır.Yazar, aynı ayırımı, mirastan feragat sözleşmesinin şekli yönünden de yaptığı için, diğer eleştirilerimizi orada açıklayacağız. 300

§ 9. Şeklî Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruflar

I. ŞEKLÎ ANLAMDAKİ ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

Yukarıda da açıklandığı gibi[118], şeklî anlamda ölüme bağlı tasarruf dendiği zaman, bundan, *mirasbırakanın son arzularını ve ölümünden sonra hüküm ifade etmesini istediği emirlerini açıklarken uyması gereken şekil kuralları* anlaşılır. Yine şeklî anlamda ölüme bağlı tasarrufların – tıpkı bağlayıcı maddî anlamda ölüme bağlı tasarruflar gibi-, *numerus clausus* prensibine tâbi oduğu yukarıda açıklanmıştı. 301

Şeklî anlamda ölüme bağlı tasarruflar, Medenî Kanunda, bir taraflı olan *vasiyetnameler* (MK 531 vd) ve iki taraflı olan *miras sözleşmeleri* (MK 528,545) olarak düzenlenmiştir. Vasiyetnameler, ikisi olağan, biri istisnai olmak üzere üç şekilde düzenlenir. Olağan vasiyetname türleri, *resmî vasiyetname* (MK 532 vd), *el yazılı vasiyetnamedir* (MK 539). İstisnaî vasiyetname türü de *sözlü vasiyetnamedir* (MK 539 vd.) Miras sözleşmeleri, *(olumlu) miras sözleşmesi* (MK 545) ve *mirastan feragat sözleşmesi* (MK 528) olmak üzere iki türdür. Her ikisi de resmî şekilde yapılır. 302

---

[116] *Şener*, Miras Hukuku, I,207; *Şener*, YD, 119.
[117] Bkz., *Dural*, Miras Sözleşmeleri, § 3, IV.
[118] Bkz., § 7, III.

II. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFTA ŞEKLE UYMANIN YARARLARI

303 Medenî Kanun, ölüme bağlı tasarrufarı çok sıkı şekil şartlarına tabi tutmuştur. *"Ölüme bağlı tasarruflar, hükümlerini, arzu edilen şey hakkında bilgi verecek olan ağzın kapandığı anda doğuracaklarından"*[119], kanunkoyucunun sıkı şekil şartları araması yerindedir. Bu sıkı şekil şartına bağlı tutmanın sebepleri şu şekilde sıralanabilir[120]:

304 *a) Uyarma:* Şekle uyma, mirasbırakanı iyice düşünmeye zorlar, acele kararların alınmasını engeller.

305 *b) Açıklık (hukukî durumu belirleme):* Bir irade açıklamasında şekle uyma çoğu kez, onun kuşkuya yer vermeyecek şekilde açıklanmasını sağlar. Ölüme bağlı tasarrufların, mirasbırakanın ölümünden sonra hüküm ifade edeceği düşünülecek olursa, bunlarda şekle uyma daha da önem kazanır.

306 *c) Gerçek ölüme bağlı tasarruf ile ölüme bağlı tasarruf projesini birbirinden ayırma:* Ölüme bağlı tasarrufların içeriğinin tanıkla ispat edilmesi, sağlararası tasarruflara oranla hemen hemen hiç mümkün olmadığı için, şekle uyma, mirasbırakanın gerçek iradesinin ne olduğunun saptanmasında önemli rol oynar.

307 *d) Ölüme bağlı tasarrufun tahrifini engelleme:* Hüküm doğuracakları andan çok önce düzenlenmiş olan ölüme bağlı tasarruflar, ancak şekle uyma ile tahriflerden korunabilir.

§ 10. Resmî Vasiyetnameler

I. GENEL BİLGİLER

308 *Noter, sulh hâkimi ya da yetkili resmi memur önünde, iki tanığın katılmasıyla yapılan vasiyetnamelere, resmî vasiyetname denir* (MK 532). Yetkili resmî memura örnek olarak, yabancı ülkelerdeki Türk konsoloslukları[121], noter yetkisine sahip mahkeme başkâtipleri (yazı işleri müdürü)[122]

---

[119] Crome, System des deutschen Bürgerlichen Rechts, fünfter (Schluss) Band, Erbrecht, Tübingen 1912.

[120] Bu açıklamalar için bkz., *Dural*, Vasiyetname, § 1, IV; *Dural*, Miras Sözleşmeleri, Giriş, dn. 27.

[121] *İnan/Ertaş*, 116, dn. 61; *Oğuzman*, 110.

[122] 2. HD 20.5.1975, 3429/ 4566 (*Şener*, Miras, II, 661); 2.HD 16.11.1970, 5039/6017 (*Şener*, Miras II,662). Buna karşılık, noter yetkisine sahip olmayan mahkeme başkâtibinin, sulh hakimi adına düzenlediği vasiyetnamenin, hakim tarafından onaylansa bile geçersiz olacağına ilişkin bkz., 2. HD 28.11.1991, 9237/ 14821 (YKD 1992, c. XVIII, 361).

gösterilebilir. Yargıtay'ın 10.12.1952 tarih ve 4/5 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararına göre[123], miras sözleşmesiyle yapıldığı için, resmi vasiyetname şekline tabi olan ölünceye kadar bakma sözleşmesinde, mirasbırakanın edimi, bir taşınmazın mülkiyetini devirse, tapu sicil memuru da bunu düzenlemeye yetkilidir. Tapu memuru, bu halde, Tapu Kanunu 26 hükümlerine değil Medenî Kanunun resmî vasiyetnamenin şekil kurallarına uyar[124]. Uygulamada genel olarak resmî vasiyetnameleri noter düzenlediği için, bundan sonra bu doğrultuda açıklamalar yapılacaktır.

Bu konuda üzerinde durulması gereken mesele şudur: MK 532 vd. da, 309
aşağıda etraflı olarak üzerinde durulacak olan, resmî vasiyetnamede uyulması gereken şekil kuralları ve tanıklarda aranacak nitelikler (MK 536) etraflı olarak düzenlenmiştir. Bunun yanında NK 84, re'sen düzenlenecek senetlerde, noterin uyması gereken şekil kurallarını, NK 76 ve 78. maddelerde de tanıklarda aranacak özellikler belirtilmiştir. Şimdi noter, resmî vasiyetnameyi düzenlerken, kuşkusuz özel hüküm niteliğinde olan Medenî Kanundaki şekil şartlarına uymak zorundadır.. Fakat bunların yanında, ayrıca Noterlik Kanununda öngörülmüş olan re'sen düzenlemeye ilişkin şartları da yerine getirmek zorunda mıdır? Baskın görüş, Medenî Kanundaki resmî vasiyetnameye ilişkin kuralların, maddî hukuku ilgilendirdikleri ve özel hüküm olduklarından, Noterlik Kanunundaki hükümlerin ise şeklî hukuku ilgilendirdiğinden, Noterlik Kanunundaki şekil kurallarına uyulmamasının, resmî vasiyetnamenin geçerliğini etkilemeyeceği yönündedir. Daha açık bir deyişle, noter, Medenî Kanundaki şekil kurallarına uygun olarak resmî vasiyetnameyi düzenlemişse, Noterlik Kanunundaki şekil kurallarına uymamış olsa bile, resmî vasiyetname geçerli olur. Olsa olsa noter, Noterlik Kanunu hükümlerine uymadığı için disiplin cezası görür[125]. Örneğin, Medenî Kanun, resmî vasiyetnamenin geçerlik şartları arasında noterin mührünü aramamıştır. Oysa NK 84/I, b. 5'e göre, re'sen düzenlenen senetlerde noterin mührünün bulunması şarttır. Fakat resmî vasiyetnamede, noterin mührünün bulunmaması, vasiyetnameyi geçersiz kılmaz[126]. Buna karşılık note-

---

[123] RG No 8329. Buna karşılık Yargıtay'a göre, köy muhtarının resmi vasiyetname yapma yetkisi yoktur (16. HD 13.10.1989, 10845/14561, YKD 1990, c. XVI, 721). Yine Yargıtay'a göre, noter başkâtipleri ya da mahkeme başkâtipleri de resmi vasiyetname düzenleyemezler ve bunların düzenledikleri vasiyetnameler noter ya da sulh hakimi tarafından onaylanarak da geçerli hale getirilemez (2. HD 5.2.1980, 622/936, YKD 1908, c. VI, 498).

[124] HGK 18.11.1964, 1261/658 (İKİD, 1965, 3614).

[125] Baskın görüşe örnek olarak bkz., *Kocayusufpaşaoğlu*, § 14,II,2; *Oğuzman*, 109; *İmre/Erman*, § 14, I, 2; *Antalya*, 124; 2.HD 12.10.1965, 1531/ 5423 (ABD 1967, 2,1096); HGK 11.3.1970, 1250/17 (*Şener*,Vasiyet, 334); HGK 9.6.1976, 805/ 2205 (YKD 1977, c. III, 752); 2.HD 24.11.1980, (*Şener*, Vasiyet, 334).

[126] Krş., *Kocayusufpaşaoğlu*, § 14, 2, b, bb. Yazar buna rağmen vasiyetnameye mührün basılmasını ihtiyatlı bir davranış olarak görür.

rin, Medenî Kanunda öngörülen şekil şartlarına uymadan, sadece Noterlik Kanununda öngörülen şekil şartlarına uyarak yaptığı resmî vasiyetname, şekle aykırılık sebebiyle geçersiz olur. Bunun aksine, noterin hem Medenî Kanun hem de Noterlik Kanunu hükümlerine uyarak yaptığı resmî vasiyetname geçerlidir.

310 MK 536, resmî vasiyetnamenin yapılmasına yetkili memur ve tanık olarak kimlerin katılamayacağını özel olarak düzenlemiştir. Burada birbirinden ayrı iki yasaklama bulunmaktadır.

311 MK 536/I'e göre, *"Fiil ehliyeti bulunmayanlar, bir ceza mahkemesi kararıyla kamu hizmetinden yasaklılar, okur yazar olmayanlar, mirasbırakanın eşi, üstsoy ve altsoy kan hısımları, kardeşleri ve bu kişilerin eşleri, resmî vasiyetnamenin düzenlenmesine resmi memur veya tanık olarak katılamazlar".*

312 Tuor'un mutlak katılma yasağı olarak tanımladığı[127] bu halde, fıkrada yazılı olan kişilerin, resmî vasiyetnamenin yapılmasına katılmaları, vasiyetnamenini iptal edilebilmesi sonucun doğurur (MK 557 b.4). Bu halde, resmî vasiyetname sanki tanıksız yapılmıştır[128] ve bu da resmî vasiyetnameler için öngörülmüş olan şekil şartının ihlâlidir[129].

313 Tanıklık yapması ve resmî memur olarak görev yapması yasak olan kişilerin nitelikleri göz önüne alındığı zaman bunları iki grupta toplamak mümkündür. Bir grup (fiil ehliyeti olmayanlar, kamu hizmetlerinden yasaklılar, okuma yazma bilmeyenler), hiç bir resmî vasiyetnamenin yapılmasına katılamazlar. Onlar için mutlak bir düzenlemeye katılma yasağı vardır. Buna karşılık, mirasbırakanın eşi, üstsoy ve altsoy kan hısımları, kardeşleri ve bunların eşleri, sadece belirli bir kimsenin resmî vasiyetnamesinin düzenlenmesine katılamazlar[130], fakat başka herhangi bir kimsenin resmî vasiyetnamesine katılabilirler. Tabir caiz ise, bunlar yönünden yasak nisbidir.

314 Altsoy ve üstsoy yönünden hiç bir derece sınırlaması olmadığı gibi, mirasçı olup olmama da önemli değildir.

315 MK 536, evlâtlık ve evlat edineni, resmî vasiyetnamenin düzenlenmesine katılması yasak kişiler arasında saymamış olmasına rağmen, yasağın bunlar yönünden de geçerli olması gerekir[131]. Aynı şekilde, evlâtlığın eşinin

---

[127] *Tuor*, Art. 503 N 1.

[128] *Escher*, Art. 503 N 1.

[129] Okuma yazma bilmeyenlerin, resmî vasiyetnamenin yapılmasına tanık olarak katılmalarının şekil eksikliği doğuracağına ilişkin bkz., 2. HD 22.10.1990, 6085/9648 (YKD 1991, c, XVII, 28); 2. HD 25,2,1993, 4873/5543 (*Şener*, Vasiyet, 327).

[130] *Tuor*, Art. 503 N 1; *Escher*, Art. 503 N 1.

[131] *Escher* (Art. 503 N 6.), sadece evlâtlığın evlât edinenin yapacağı resmî vasiyetnameye

de, evlat edinenin vasiyetnamesinin düzenlenmesine katılamaması gerekir[132].

Eşlerin, birbirlerinin yapmış oldukları resmî vasiyetnameye katılma ya- 316
sağı, evlilik devam ettiği sürece vardır. Boşanma ya da evliliğin iptalinden sonra bu yasak kalkar[133]. Oysa NK 76/b. 2'ye göre, noter tarafından re'sen düzenlenen senetler yönünden evlilik sona ermiş olsa bile, tanıklık yasağı devam eder.

Şener'in[134], MK 536 (eski MK 483)'daki, mirasbırakanın eşinin tanıklık ya da 317
resmî memurluk yapamayacağı kuralını, evlilik sona erdikten sonra devam edecek şekilde genişletmesi doğru değildir. Yazar, buna gerekçe olarak, evlenmenin sona ermesiyle kayın hısımlığı sona ermez diyen MK 18/II hükmünü göstermektedir. Yani *Şener*'e göre karı koca arasında bir kayın hısımlığı kurulmakta ve evlenme sona erdikten sonra da hısımlık devam etmektedir. Oysa, evlenme ile karı koca arasında herhangi bir hısımlık kurulmaz. Kayın hısımlığı, karı ile kocanın kan hısımları;koca ile de karının kan hısımları arasında kurulur (MK 18/I). İşte MK 18/II'nin devam edeceğini söylediği hısımlık budur. Bu bakımdandır ki, Noterlik Kanunun 76 b. 2'nin, evlilik sona erse bile, karı ve kocanın diğerinin işlemlerine katılamayacağını söylemesinin bir anlamı vardır, yoksa, yazarın dediği gibi, zaten kayın hısımlığı devam ettiği için gereksiz bir hüküm değildir. MK 503'e göre, evlenmenin boşanma ya da iptal ile sona ermesinden sonra, eşlerden birinin, diğerinin yaptığı resmî vasiyetnameye katılmasında bir engel yoktur. Şener'in bu görüşüne gerekçe olarak gösterdiği ve kitabının 331. sahifesinde aynen verilmiş olan 2. HD'nin 8.3.1977 tarih ve 1882/ 1959 tarihli kararının konu ile hiç bir ilgisi yoktur. Zira kararda, ölen eşin kardeşi ile mirasbırakan arasında kayın hısımlığı bağının devam ettiği söylenmektedir, yoksa karı koca arasında kayın hısımlığının bulunduğu değil...Yazarı yanıltan, sanıyorum ki, karardaki, *"Medenî Kanunun 18. maddesi mahkemenin sandığı gibi, karı kocayı ayrık tutmuş değildir"* cümlesidir. Ancak, bununla kastedilen, karı koca arasında kayın hısımlığının bulunduğu değil, kayın hısımlığının kurulması ve devam etmesi yönünden, 18. maddenin karı koca arasında bir ayırım yapmadığıdır.

Evlenmenin sona ermesiyle birlikte, karı kocanın birbirlerinin resmî vasiyetna- 318
mesine resmi memur ya da tanık olarak katılmaları yasağı sona ererken, tanıklık yapmaları ya da resmî memur olarak katılmaları yasak olan kan hısımlarının, eşlerinin yasakları devam eder. Örneğin, M'nin kardeşinin eşi, boşanmış olsa bile, M'nin resmi vasiyetnamesinin düzenlenmesine katılamaz. Çünkü MK 18/II'ye göre, evlenmenin sona ermesi, M ile kardeşinin eşi arasındaki kayın hısımlığına son vermez. *Escher*[135] mirasbırakanın eşi ile, kan hısımlarının eşinin arasındaki bu farklılığı bir çelişki olarak görmekte ve de lege ferenda, boşanan eşin de kapsam içinde kalmasını teklif etmektedir.

---

katılamayacağı görüşündedir. Gerekçe olarak da, evlâtlığın, evlât edinene karşı olan yasal mirasçılığını göstermektedir. Fikrimce, yukarıda da açıklandığı gibi, resmî vasiyetnamenin düzenlenmesine katılma yasağı, mirasçılığa değil de hısımlık ilişkisine bağlandığı ve evlât edinen de, evlâtlığın hısımı olduğuna göre, bu tek taraflı yasaklama yerinde değildir.

[132] Evlâtlığın eşinin, evlât edinenin resmi vasiyetnamesine tanık sıfatıyla katılamayacağına ilişkin bkz., 2. HD 30.1.1973, 7895/419 (RKD 1973, II/2, 160).

[133] *Escher*, Art. 503 N 8.

[134] *Şener*, Vasiyet, § 3 III.

[135] *Escher*, Art. 503 N 8.

319 MK 536/I'deki yasakların dar yorumlanması gerektiği için, mirasbırakan ya da resmî memur ile hizmet ilişkisi içinde bulunanlarla, mirasbırakanın nişanlısının, resmî vasiyetnamenin yapılmasına katılmalarına bir engel yoktur[136]. Aynı şekilde, mirasbırakının vasisinin de vasiyetnamenin düzenlenmesine katılmalarına bir engel yoktur. Ancak, eğer vasi lehine bir ölüme bağlı tasarrufta bulunulmuşsa, sadece bu tasarruf, az sonra açıklanacağı gibi, MK 536/II'ye göre iptal olunur.

320 Kanunda belirtilmemiş olmakla beraber, herhangi bir bedeni sakatlıkları sebebiyle (örneğin, ama, ya da sağır dilsiz oldukları için), algılama noksanı olan kişilerin de resmî vasiyetnamenin düzenlenmesine tanık olarak (resmî memur olmaları zaten mümkün değildir)katılmamaları gerekir[137].

321 Tekrarlayacak olursak, MK 536/I'de sayılmış olan kişilerin resmî vasiyetnamenin yapılmasına katılmaları MK 557 b.4' e göre, şekil sakatlığı sebebiyle, resmî vasiyetnameyi bütünüyle iptal edilebilir hale getirir[138].

322 MK 536/I'deki bu hüküm yanında, NK 76 ve 78'de de, noter tarafından Noterlik Kanununa göre re'sen düzenlenen senetlere tanık olarak katılmaları yasaklanmış olan kişiler de vardır. Ne var ki, tıpkı resmî vasiyetnameye ilişkin şekil şartlarında olduğu gibi, tanıklar yönünden de NK 76 ve 78'deki hükümlere uyulmaması, MK 536/I'in özel hüküm olması karşısında resmî vasiyetnamenin geçerliğini etkilemez[139].

323 Yukarıda da değinildiği gibi,MK 536/II'de de farklı bir yasaklama vardır. Ancak, bu yasaklama, vasiyetnamenin yapılmasına katılacak kişiler yönünden değil de, bu kişiler lehine yapılmış ölüme bağlı tasarruflar yönündendir. Gerçekten MK 536/II'ye göre, *"Resmî vasiyetnamenin düzenlenmesine katılan memura ve tanıklara, bunların üstsoy ve altsoy kan hısımlarına, kardeşlerine ve bu kişilerin eşlerine o vasiyetname ile bir kazandırmada bulunulamaz"*. Görüldüğü gibi, MK 536/I'den farklı olarak, MK 536/II'nin müeyyidesi, bütün resmî vasiyetnamenin değil de, sadece söz konusu kişiler lehine yapılmış olan maddî anlamdaki ölüme bağlı tasarrufların iptal edilmesidir. Bu yüzden MK 536/II'nin bir nisbî hükümsüzlük sebebi olduğu söylenmektedir[140].

324 Açıklamalara geçmeden önce, MK 536/II'nin biraz yanıltıcı ifadesi karşısında, maddenin iki fıkrası arasındaki ilişki üzerinde biraz durmakta yarar vardır. Şöyle ki, MK 536/I'de belirtilen kişilerin resmî vasiyetnamenin yapılmasına katılmaları, MK

---

[136] *Tuor*, Art. 503 N 9; *Escher*, Art. 503 N 9.

[137] Sağır ve dilsizler için aksi, *Tuor*, Art. 503 N 8.

[138] Krş, *Dural/Öz*, 1.bası, § 10, I.

[139] *Oğuzman*, dn. 141; *İmre/Erman*, § 14, I; *Kocayusufpaşaoğlu*, § 14, I,1. Aynı görüş için bkz., HGK 9.6.1967, 805/2205 (ABD, 1977, sayı , 330); 2.HD 24.11.1980, 7187/8357 (*Şener*, Vasiyet, 320).

[140] *Tuor*, Art. 503 N 1; *Escher*, Art. 503 N 1.

557 b.4'e göre, şekil noksanı sebebiyle bütün vasiyetnameyi geçersiz kıldığına göre, bunlar ya da MK 536/II'de sayılan yakınları lehine bir ölüme bağlı tasarruf yapılmış olmasının hiç bir önemi yoktur. Başka bir deyiş ile, bu kişiler lehine bir ölüme bağlı tasarruf yapılmış olsa da olmasa da, sırf resmî vasiyetnamenin yapılmasına katılmaları bir şekil noksanıdır ve vasiyetname iptal ediebilir. Bu bakımdan MK 536/II'yi, MK 536/I'in kapsamı dışında kalan hâllerle sınırlamak gerekir. Daha açık bir deyişle, MK 536/II'nin uygulama alanının, birinci fıkranın dışında kalan (yani resmî vasiyetnamenin yapılmasına resmî memur ya da tanık olarak katılmalarına bir engel olmayan) ve vasiyetnamenin yapılmasına tanık ya da resmî memur olarak katılan kişileri ve onların fıkrada yazılı olan hısım ve eşleri ile sınırlaması gerekir. Örnekleyecek olursak; resmî vasiyetnameyi düzenleyen noter , mirasbırakanın çocuğu ise ve onun lehine de bir tasarrufta bulunulmuşsa, MK 536/II uygulanıp, sadece o tasarruf geçersiz sayılamaz. Bu halde de MK 536/I uygulanır ve tüm resmî vasiyetname geçersiz olur. Aksi halde MK 536/I'in bir anlamı kalmazdı. Buna karşılık, noterle mirasbırakan arasında, MK 536/I anlamında bir hısımlık bağı yoksa ve mirasbırakan onun ya da eşinin lehine bir ölüme bağlı tasarruf yaparsa, işte bu hâlde MK 536/II uygulanır ve sadece bu tasarruf hükümsüz olur, resmî vasiyetname geri kalan kısmı ile geçerliğini korur, meğer ki, iptal edilen ölüme bağlı tasarruf ile vasiyetnamedeki diğer tasarruflar arasında, mirasbırakanın, sakatlığı bilseydi vasiyetnamenin tümünü yapmayacağı şeklinde bir sıkı bağ bulunsun.

MK 536/II bir sınırlama getirdiği için, dar yorumlanması gerekir. 325

Son olarak belirtelim ki, yukarıda açıklanan hususlar, sözlü vasiyetnamelere de aynen uygulanacaktır. Ancak MK 539/III, sözlü vasiyetnameye tanık olarak okuma yazma bilmeyenlerin de katılmasına cevaz verdiği için, bunlara katılma yasağı uygulanmayacaktır. 326

II. RESMÎ VASİYETNAMENİN DÜZENLENİŞ ŞEKİLLERİ

MK 534 vd., iki tür resmî vasiyetname düzenleme şekli öngörmüştür. 327 Bunlardan birincisi MK 533/534'de öngörülmüş olan, vasiyetçi tarafından okunarak ve imzalanarak düzenlenen resmî vasiyetnamedir. İkincisi ise, MK 535'de düzenlenmiş olan vasiyetçinin okumadan ve imzalamadan yaptığı resmî vasiyetnamedir. Belirtmek gerekir ki, her iki şekil eşdeğerdedir. Ne var ki, bazen, vasiyetçinin bazı nitelikleri, belirli bir türe başvurmayı zorunlu kılabilir. Başka bir deyişle, herhangi bir sebeple okuyamayan ya da yazamayan bir kimse, resmî vasiyetnamesini muhakkak MK 535'de öngörülmüş olan şekle göre, yâni okumadan ve imzalamadan düzenletmek zorundadır. Örneğin, hiç okuyamayan ya da yazamayan bir kimse, ya da okuma yazma bilmesine rağmen, elleri sakat olduğu ya da vasiyetnameyi düzenlerken elleri kırık olduğu için imza atamayan bir kişi, sadece ve sadece MK 535'e göre resmî vasiyetnamesini yapabilir. Buna karşılık, okuma yazma bilen bir kişi, seçimlik hakka sahiptir. O, isterse vasiyetnamesini okuyarak ve imzalayarak düzenlettirir[141], isterse okumadan ve imzalama-

[141] Vasiyetnamede, vasiyetçinin okuma yazma bildiğinin belirtilmesine gerek olmadığına ilişkin bkz., HGK, 22.11.1972, 868/844 (İBD 1973, 55).

dan... Bunun yanında, aşağıda açıklanacağı gibi[142], iki şeklin meczedilerek, karma şekilde resmî vasiyetname düzenlemek de mümkündür. Gerçekten eski Medenî Kanun zamanında verilmiş olan 26.3.1962 tarih ve 23/3 sayılı İBK.'ya göre[143], *"MK 482. madde (yeni MK 535) uyarınca düzenlenmiş olan vasiyet senedinde, vasiyetçinin imzasının bulunmasının o senedin geçerliği üzerinde hiçbir etkisi olmaz"*.

328 MK 535'in karşılığı olan eski MK 482'nin kenar başlığı, *okuyup yazamayan vasiyetçi* idi. Maddeni bu farklı lafzı karşısında, 1962 yılına kadar, Türk Hukukunda, okuma yazma yeteneğine sahip olanların muhakkak MK 480 ve 481'e göre (yeni MK 533/534) resmî vasiyetname yapmalarının zorunlu olduğu, bu kişilerin MK 482'den yararlanamayacakları kabul ediliyordu. MK 480 ve 481'in, asıl resmî vasiyetname düzenleme şekli, MK 482'in ise, sadece okuma yazma bilmeme hâlinde başvurulacak bir istisnai şekil olduğu görüşü hâkimdi. Ancak, yukarıda sözü edilen 26.3.1962 tarih ve 23/3 sayılı İBK., tamamen farklı bir sonuca vararak tartışmalara son vermiştir. Kararın sonuç kısmına göre, *"Okuyup yazma bilen bir vasiyetçi, Medenî Kanunun 480 ya da 482. maddelerindeki resmî vasiyet şekillerinden birisini dilediğine göre ve hiçbir neden bildirmeye yahut resmî senede yazdırmaya gerek olmaksızın seçebilir"*[144]. Kararın gerekçe bölümünde ise şöyle yazılıdır: *"Yazılışına bakılarak 482. Maddenin ancak vasiyetçinin okuyup yazamaması hâlinde uygulanabileceği düşünülürse de bu doğru değildir... 482. Maddede okuyup yazamayanlardan söz edilmesi bu maddenin zorunlu olarak uygulanacağı hali belirtmek içindir. O halde vasiyetçi, resmî vasiyeti kendi serbest iradesine göre MK 481 veya 482'nci maddede gösterilen şekillerden biri ile düzenleyebilir"*. Görüldüğü gibi, bu günkü düzenleme, söz konusu İBK. ve İsviçre'deki düzenlemeye uygundur.

329 Yukarıda söylenenleri özetleyecek olursak; okuma yazma bilmeyenlerin MK 535'e göre resmî vasiyetnamelerini düzenletmeleri zorunludur. Okuma yazma bilenler ise, MK 533/534 ile MK 535 arasında bir seçim hakkına sahiptirler. Nihayet iki şeklin meczedilerek resmî vasiyetname yapılması da mümkündür (karma vasiyetnameler). O hâlde, bu gün, Türk Hukukunda a) okunarak ve imzalanarak, b) okunmadan ve imzalanmadan ve c) karma türde olmak üzere üç türlü resmî vasiyetname yapılabilir.

III. OKUNARAK VE İMZALANARAK DÜZENLENEN RESMÎ VASİYETNAMELER (MK 533/534)

330 Vasiyetçinin[145] okuyup imzalayarak düzenlettirdiği resmî vasiyetnamede (diğer resmî vasiyetname şekillerinde olduğu gibi) iki safha vardır.

---

[142] Bkz., aşağıda V.

[143] RG No 11122.

[144] Aynı doğrultuda, 2.HD 24.12.1980, 7187/8357 (YKD 1981, c.VII, 281); 2.HD 2.4.1996, 1971/ 3555 (YKD 1996, c.XXII, 1551).

[145] Eski Medenî Kanunda, yapılan işlemden (vasiyetnameden) hareketle, vasiyetçi terimi kullanılıyordu, Yeni Medeni Kanun ise, bu terimin yerine mirasbırakan terimini tercih etmiştir. Fikrimce, eski terim daha yerinde idi. Bu bakımdan, biz vasiyetçi terimini kullanmaya devam edeceğiz.

1. Birinci safha

Bu safhada vasiyetçi son arzularını resmî memura bildirecektir (MK 533/I, c. 1). Bildirme şeklinin önemi yoktur. Önemli olan, vasiyetçinin son arzularını doğrudan notere bildirmesidir[146]. Bu bildirme, sözlü olabileceği gibi yazılı da olabilir. Vasiyetçi, notere yazılı olarak verdiği son arzularını bir üçüncü kişiye yazdırmışsa, noterin, bu metnin vasiyetçinin son arzularına uygun olduğuna kanaat getirmesi gerekir[147]. Noterin, vasiyetçinin son arzularını ona soracağı sorulara alacağı cevaplara göre saptaması mümkündür[148]. Son arzuların bildirilmesinin belirli bir süre içinde tamamlanması şart değildir, kesin bir metne kadar bazan çok uzun sürmesi mümkündür. 331

Bu safhanın ikinci bölümünde noter, son arzuları ya bizzat yazacak ya da yazdıracak ve okuması için vasiyetçiye verecektir (MK 533/I, c. 2). Vasiyetname metninin, noterin antetli kâğıdına yazılması zorunlu değildir[149]. 332

Vasiyetçi metni okuyup, bunun son arzularına uygun olduğunu görünce imzalar ve onun imzasını noterin imzası ve tarih atması izler. Önemle belirtmek gerekir ki, bu safhada tanıkların bulunması zorunlu değildir. Bu husus, MK 534/I'den anlaşıldığı gibi, MK 533/534'e göre yapılan vasiyetnamenin en büyük özelliği, içeriğinin tanıklardan gizlenebilmesidir. Ancak, vasiyetçinin isteği üzerine, tanıkların bu safhaya katılmalarına bir engel yoktur. 333

Hem vasiyetçinin hem de noterin imzalarının el yazısı ile olması şarttır. Mirasbırakan, imza yerine el ile yapılmış bir işaret kullanamayacağı gibi, mühür de basamaz. Özellikle BK 15'deki, imza atamayan kimselere ilişkin hükümler burada uygulanamaz. Kişi, imza atamıyorsa, vasiyetnamesini MK 535'e göre yapmak zorundadır[150]. Noterin, vasiyetnameyi bizzat el yazısıyla imzalamasında kuşku yoksa da, tarihi de el ile yazmasının gerekip gerekmediği tartışmalıdır. Her ne kadar MK 533/III'ün lafzı bu yönde bir yoruma müsait ise de; doktrin ve uygulama baskın görüş, doğru olarak aksini savunarak, düzenleme tarihinin, noterin el yazısı ile olmasının bir zorunluk olarak görmemekte, tarihin, basılı daktilo ile yazılı ya da başka bir kimse tarafından yazılmış olmasını, geçerli kabul etmektedir. Gerekçe olarak, tarihten daha önemli olan metni bizzat noterin yazmak zorunda olma- 334

---

[146] Yargıtay'a göre, okuma yazma bilmeyen bir kimsenin, son arzularını evde noter kâtibine söylemesi ve noterin de, noter kâtibinin beyanına göre vasiyetnameyi düzenlemesi geçersizdir (2. HD 2.4.1996, 147/3555, YKD 1996, c. XXII, 1519).

[147] *Tuor*, Art. 500 N 3; *Escher*, Art. 500 N 3; *Kocayusufpaşaoğlu*, § 14, II, 2, b, aa.

[148] *Gautschi*, 154; *Kocayusufpaşaoğlu*, § 14, II,2,b,aa; *Oğuzman*, 112; *İmre/Erman*, § 14, II.

[149] 2. HD 22.4.1982, 1909/3674 (*Şener*, Vasiyet, 312).

[150] *Escher*, Art. 500 N 8; *Tuor*, Art. 500 N 14; *Fahrländer*, 104; *İmre/Erman*, § 14, II, 3.

yıp, başkasına da yazdırabilmesi (MK 533/I, c. 1) ve tarihin imzadan farklı olarak, yazanın kişiliğine sıkı sıkıya bağlı olmadığı gösterilmektedir[151].

335 Tarih, gün, ay ve yılı kapsayacak şekilde atılmalıdır. Buna karşılık, tarihin, saati de kapsaması gerekmez[152]. Aynı şekilde, düzenleme yerinin de gösterilmesine gerek yoktur.

336 Vasiyetçinin imzası, ilgili olduğu metnin kabulü ve kapandığı anlamına geldiği için, metni örtecek biçimde, en sonda bulunması gerekir. Ancak, vasiyetname başka bir şekilde kapanmışsa, imzanın sonda olmaması geçerliği etkilemez, yeter ki, metin ile imza arasında bağ bulunsun. Örneğin, vasiyetname metni, sayfanın son satırında bitmiş ve imza atacak yer kalmamışsa; imzanın sayfanın kenarına atılması mümkündür. Vasiyetnamenin birden fazla sayfadan oluşması hâlinde, vasiyetçinin her sayfayı imzalaması gerekli olmayıp,sadece son sayfaya imza atması yeterlidir[153].

337 Noter, tarihi ve imzasını vasiyetçiden sonra atacaktır. Ancak, tarihin, noterin imzasının yanında olmayıp, örneğin, metnin başında yazılı olması vasiyetnameyi geçersiz yapmaz[154], yeter ki, vasiyetçinin imzasından sonra, fakat noterin imzasından önce atılmış olsun.

338 Federal Mahkeme, bir kararında[155], doğru olduğundan kuşku duyulmaması şartıyla, tarihin, vasiyetnamenin düzenleneceği gün önceden hesaplanarak, bundan birkaç gün önce atılmasını da geçerli kabul etmiştir[156].

339 Noterin, imzasını vasiyetçiden sonra atması şarttır. Çünkü, noterin imzası, bir tevsik niteliğinde olduğu için, vasiyetçininkinden önce atılması hâlinde, bu fonksiyonunu yerine getirmiş olmaz[157]. Noterin imzası, kural olarak, hemen vasiyetçinin imzasının altında olacaktır. Ne var ki, vasiyetçinin imzasından sonra olması şartıyla[158], noterin imzasının başka bir yerde, örneğin, tanıkların şerhinden hemen sonra atılmış olması, vasiyetnameyi geçersiz yapmaz[159].

---

[151] *Escher*, Art. 500 N 14; *Gautschi*, 86 vd; *Kocayusufpaşaoğlu*,§ 14, II, 2, a,aa; *Köprülü*, § 7, IV, 1, a, aa; *Oğuzman*, 112; *Şener*, Vasiyet, § 4, III; BGE 53 II 442; 55 II 235; 2.HD 17.6.1963, 3847/ 3770 (*Dalamanlı*, 140); *Antalya*, 128; aksi görüşte, *Tuor*, Art. 500 N 17; krş., *İmre/Erman*, § 14, II.

[152] 2.HD 17.6.1963, 3847/3770 (*Olgaç*, 342).

[153] 2. HD 6.6.1961, 1562/3346 (*Yazıcı/Atasoy*, No. 1616)

[154] *Escher*, Art. 500 N 11; *Gautschi*, 88; *Köprülü*, § 7, IV,1, a, aa; *Oğuzman*, 112; *Kocayusufpaşaoğlu*, § 14, II, a, aa.

[155] BGE 55 II 235; ayrıca bkz., BGE 58 II 204.

[156] *Kocayusufpaşaoğlu*'nun bu görüşe katıldığı anlaşılmaktadır (Bkz., § 14, II, 2, a,aa); Krş., *Şener*, Vasiyet, § 4, III.

[157] *Şener*, Vasiyet § 4, III.

[158] 2. HD 17.4.1951, 147/298 (*Kocayusufpaşaoğlu*, § 14, dn. 25'den naklen), mirasbırakan ile noterin aynı anda imza atmalarını geçerli saymıştır.

[159] BGE 58 II 204; ayrıca bkz., *Oğuzman*, 112, dn. 150'de anılan yazarlar.

2. İkinci safha

Birinci safhada tanıkların bulunması zorunlu değilken[160], ikinci safha- 340
nın tanıklar huzurunda gerçekleşmesi gerekir. Bu safhada, MK 534'den anlaşılacağı üzere, biri vasiyetçi, diğeri de tanıklar tarafından gerçekleştirilecek iki işlem vardır. Vasiyetçi, tanıklar önünde, onlara hitaben[161], vasiyetnameyi okuduğunu ve bunun son arzularına uygun olduğunu beyan edecektir. Ancak, vasiyetnamenin içeriğini tanıklara bildirmek zorunda değildir (MK 534/III). Bunun üzerine tanıklar, vasiyetnamenin altına, *vasiyetçinin, beyanı huzurlarında yaptığını ve onu, ölüme bağlı tasarrufta bulunmaya ehil gördüklerini* şerh verip, el yazıları ile imzalayacaklardır (MK 534/II).

2. Hukuk Dairesinin 15.3.1973 tarih ve 1556/1575 sayılı kararına göre[162], 341
"Uyuşmazlık konusu vasiyetnamenin tetkikinden anlaşıldığı gibi, noter, vasiyetçinin arzularını tespit edip işlemi tamamladıktan sonra, tanıklar, el yazılarıyla yazılmış olup, vasiyetçinin arzularını belirten belgeyi imzalayıp notere vermişlerdir. Her şeyden önce, bu ifadeler noter tarafından tespit edilmemiş, vasiyetnamenin altına yazılmamış, muhteva noter tarafından tasdik olunmamış, hatta imzalar dahi onaylanmamış olduğuna göre bu yazılar hiçbir surette vasiyetnameye dahil bir işlem olarak kabul edilemez. Kaldı ki, şahit beyanlarının, notere ne surette ve ne zaman tevdi edildiği bile belli değildir. Bu bakımdan vasiyetname usulüne uygun olarak düzenlenmemiştir".

Karardan anlaşılacağı üzere, tanıkların şerhi noter huzurunda verip, bunu, yine 342
noter huzurunda imzalamaları geçerlik şartıdır. Aynı şekilde, şerhin ve tanık imzalarının, vasiyetname metninin altında bulunması, ayrı bir kâğıda yazılmaması da bir geçerlik şartıdır. *Fikrimce*, bu son halde, tanıkların şerh ve imzasının ayrı bir kâğıtta bulunmasının haklı bir sebebi varsa (örneğin, vasiyetname metni, sayfanın son satırına kadar devam etmiş, şerh ve tanık imzaları için yer kalmadığından yeni bir sayfa kullanılmıştır), iki sayfa arasında bağın kurulması şartıyla, *favor testamenti kuralı* gereğince, resmî vasiyetnameyi şekil yönünden geçerli saymak doğru olur[163].

Şerhin, muhakkak tanıkların el yazısı ile olması gerekmediği, başkası 343
tarafından ya da makine ile yazılabileceği MK 534 /II'de anlaşılmaktadır. 28.11.1945 tarih ve 15 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı[164] da bu yöndedir. Şerhin, her iki tanık için ayrı ayrı yazılması gerekmeyip, her iki tanık tarafından da imzalanmış olması şartıyla, tek bir şerh metninin bulunması yeterlidir.

---

[160] *Escher*, Art. 500 N 1; *Tuor*, Art. 501 N 1; *Spiro*, 217 vd; *Kocayusufpaşaoğlu*, § 14, II, 2, a,bb; *Ayiter/Kılıçoğlu*, 51.

[161] Beyanın tanıklar önünde yapılmasının zorunlu, fakat onlara hitaben olmasının zorunlu olmadığına ilişkin bkz., BGE 89 II 367.

[162] *Şener*, Vasiyet, madde 481, No.2.

[163] Nitekim, 2.Hukuk Dairesi, 13.5.1952 tarih ve 3122/2009 sayılı kararında, tanık beyanlarının, ayrı bir sayfada olmasının, muhakkak daha sonra yazıldıklarına delil olmayacağını belirtmiştir (TİK, c. 6, No. 1516).

[164] RG, 6365.

344 Tanık şerhinin geçerli olması için, MK 534/II'deki iki hususu da (vasiyetçinin, tanıklar önünde, vasiyetnamenin son arzularına uygun olduğunu beyan ettiğini ve tanıkların onu ölüme bağlı tasarruf yapmaya ehil gördüklerini) içermesi gerekir. Bunlardan ikisinin ya da birinin şerhte yer almaması, vasiyetnameyi geçersiz kılar[165]. Buna karşılık, vasiyetçinin, vasiyetnameyi tanıklar önünde okuması gibi bir zorunluk olmadığı için, vasiyetname tanıklar önünde okunmuş olsa bile, bunun şerhte belirtilmesi gerekmez[166]. Zaten MK 534/II, okunup imzalanarak yapılan resmî vasiyetnameye verilecek şerhte bunu aramamıştır[167].

345 MK 534/II'de belirtilen hususların muhakkak şerhin metninde bulunması gerekir. Bulunmaması hâlinde, bu eksiklik, vasiyetname dışı delillerle, örneğin tanık beyanları ile giderilemez[168].

346 Resmî vasiyetname, tanıkların imzası ile tamamlanmış olur. MK 533'e göre, tanık beyanlarının ayrıca noter tarafından onanması gerekli değildir[169]. Fakat, noterin, bundan sonra, vasiyetnameyi Noterlik Kanunu hükümlerine göre onaması, bir geçersizlik sebebi olmaz.

347 Okunarak ve imzalanarak düzenlenen resmî vasiyetname, tanıkların imzası ile tamamlandığı için, vasiyetçi, şerh yazıldıktan, fakat daha tanıklar tarafından imzalanmadan ölecek olursa, bu eksiklik artık giderilemez. Çünkü, bir kimsenin ölümünden sonra vasiyetnamesinin tamamlanması mümkün değildir. Böyle bir durumda, *Kocayusufpaşaoğlu*'na göre, yoklukla sakatlık söz konusu iken; *Oğuzman*, vasiyetnamenin iptal edilmesi gerektiği görüşünü savunur[170].

348 Son olarak belirtelim ki, bütün bu işlemlerin (diğer resmî vasiyetname türlerinde olduğu gibi) MK 534/I'e göre, *unitas actus (işlemde birlik)* içinde yapılması gerekir. Bunun anlamı, araya, birinci ve ikinci safhaların, bütünlüğünü bozacak bir fasılanın girmemesi, her iki safhanın birbiri ardından (MK 534/I'in ifadesiyle, *hemen sonra*) yapılmasıdır. İşlemde birliğin başlangıcı, resmî vasiyetnamenin metninin vasiyetçi tarafından okunduğu andır[171].

---

[165] 2. HD 13.10.1992, 8717/9523 (*Şener*, Vasiyet, madde 481 No.1); şerhte vasiyetçinin tasarrufa ehil görüldüğünün yazılmasının zorunlu olduğu, vasiyetnameye eklenen hekim raporunun bu beyanı ikame edemeyeceğine ilişkin bkz., 2. HD 6.10.1976,5906/6783 (*Şener*, madde 482, No. 6).

[166] HGK, 22.11.1972, 844/937 (İBD, 1973, sayı 1-2, 55).

[167] Bu bakımdan, *İmre/Erman*'ın (§14, II), şerhte, vasiyetçinin, tanıklar önünde okuduğunun belirtilmesini zorunlu görmeleri yerinde değildir.

[168] 2.HD 15.3.1973, 1556/1575 (*Şener*, Vasiyet, madde 481, No. 2).

[169] 2.HD 12.11.1996, 5008/ 5432 (*Şener*, Vasiyet, madde 480, No.6). Ancak aynı Daire, 15.3.1973 tarih ve 1556/1575 sayılı kararında, aksini savunuyor gözükmektedir.

[170] *Kocayusufpaşaoğlu*, § 14, dn. 35a; *Oğuzman*, 114, dn. 150h.

[171] Bkz., *Kocayusufpaşaoğlu*, § 14, dn. 67'de anılan yazarlar ve Federal Mahkeme kararları.

IV. OKUNMADAN VE İMZALANMADAN DÜZENLENEN RESMÎ VASİYETNAMELER

MK 535'de düzenlenmiş olan bu resmî vasiyetname şekline, sadece 349
okuma yazma iktidarından yoksun olanlar değil, bu iktidara sahip olan kişilerin de başvurabileceği, yukarıda etraflı olarak açıklanmıştı[172]. Kısaca özetleyecek olursak; okuma yazma iktidarı olmayan kimseler, resmî vasiyetnamelerini sadece MK 535'e uygun olarak düzenlettirebilirler. Buna karşılık, okuma yazma iktidarı olanlar MK 533/534 ya da 535'deki şekillerden birini seçerek resmî vasiyetname yapabilirler. Eğer bu kişiler, resmî vasiyetnamelerini okumadan ve imzalamadan düzenlemek istiyorlarsa, MK 535'deki şekil şartlarına uyarlar. Bu konuda, herhangi bir gerekçe göstermek zorunda değildirler[173]. MK 535'e göre düzenlenecek olan resmî vasiyetnamede de iki safha vardır. Birinci safhada, vasiyetçi son arzularını, yazılı ya da sözlü olarak notere bildirir ve noter bunları yazar ya da yazdırır. Birinci safha burada biter. Bundan sonra, okunarak ve imzalanarak yapılan resmî vasiyetnameden farklı olan ikinci safha başlar. Artık bu ikinci safhada, tanıkların bulunması zorunludur. Noter, tanıklar önünde, vasiyetname metnini yüksek sesle okur (MK 535/I). Vasiyetnameyi, noterin, vasiyetçi ve tanıklar önünde bizzat yüksek sesle okuması geçerlik şartıdır[174]. Bu yüzden, noter hazır bulunsa dahi, vasiyetnamenin, onun vasiyetçinin ve tanıkların önünde başka bir kimse tarafından okunması bir şekil eksikliği oluşturur. Bu okumadan sonra, vasiyetçi, tanıklar önünde, vasiyetnamenin son arzularına uygun olduğunu açıklar (MK 535/I). Vasiyetçi tanıklar önünde bu beyanı yapmadıkça, diğer şartlar bulunsa bile, vasiyetname geçerli olmaz[175]. Bu beyan, vasiyetçinin imzasının yerini tutar[176]. Bunu, noterin, vasiyetnameye tarih koyup imzalaması izler. Tarih ve noterin imzası yönünden, okunarak ve imzalanarak düzenlenen vasiyetnamelerde, yapılan açıklamalar, bu şekil için de geçerlidir[177]. Bu bakımdan, noterin imzasının, tanıkların şerhinden sonra atılması, vasiyetnamenin geçerliğini etkilemez[178]. Bundan sonra tanıklar, vasiyetnamenin altına şerh verip bunu imzalayacaklardır. Tanıkların vereceği şerhin içeriği, MK 533/534'e göre yapılan resmî vasiyetnamelerdeki şerhten daha kapsamlıdır. MK 535/II'ye göre, şerhte, vasi-

---

[172] Bkz., yukarıda I.

[173] 2. HD 30.3.1972, 1039/1902 (*Şener*, Vasiyet, madde 480, No.4); HGK 21.11.1972, 844/937 (*Şener*, Vasiyet, madde 480, No. 3); 2.HD 24.12.1980, 1187/8357 (YKD 1981, c.VII, 281).

[174] HGK 30.3.1952, 131/121 (TİK, c. 7, No. 60); 2.HD 5.7.1977, 4466/5505; BGE 45 II 135; 66 II 89.

[175] 2. HD 31.5.1973, 3721/3603 (*Şener*, Vasiyetname, madde 480, No.8).

[176] *Tuor/Schnyder*, § 60, II,b; *Tuor*, Art. 502 N 3; *Kocayusufpaşaoğlu*, § 14, II, 2, c, bb.

[177] Bkz, yukarıda II

[178] 2.HD, 8.4.1976, 2922/ 3112 (*Şener*, Vasiyet, madde 482, No.7).

yetçinin, vasiyetnamenin son arzularına uygun olduğunu beyan ettiği ve tanıkların, onu, vasiyetname yapmaya ehil gördüklerinin yanında, *vasiyetnamenin bizzat noter (resmî memur) tarafından, tanıklar önünde yüksek sesle okunduğu* da yer alacaktır[179]. Unitas actus prensibinin burada da yürüdüğünü hatırlatalım. Belirtmeye gerek yoktur ki, tanıklar, imzalarını el yazısı ile atmalıdırlar. Zaten bu husus, tanıkların okur yazar olmalarının aranmasının doğal bir sonucudur.

350 Resmî vasiyetname tamamlandıktan sonra, buna sonradan yapılacak çıkıntı ve ekler de, artık yeni bir ölüme bağlı tasarruf niteliğinde oldukları için, aynı şekil şartlarına uyulması gerekir[180]. Buna karşılık, çıkıntı ve ekler, vasiyetname tamamlanmadan yapılacak olurlarsa, yeniden şekil şartlarına uyulması gerekmez. Çünkü bu hâlde, hem vasiyetçinin imzası ya da beyanı tarafından kapanmış hem de noterin imzası ile tevsik edilmiş olurlar.

V. KARMA ŞEKİLDE DÜZENLENEN RESMİ VASİYETNAMELER

351 Yukarıda da değinildiği gibi[181], 26.3.1962 tarih ve 23/3 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı, İsviçre doktrini ve uygulamasına paralel olarak[182], karma şekilde, yâni kısmen MK 533/534, kısmen de MK 535'in aradığı şekil şartlarına uyularak da resmî vasiyetname yapılmasına cevaz vermiş ve bu görüş, Türk doktrini tarafından da kabul görmüştür[183]. Ancak, *Kocayusufpaşaoğlu*'nun haklı olarak belirttiği gibi[184], karma resmî vasiyetnamelere şu iki şartın gerçekleşmesi hâlinde izin vermek gerekir: a) karma şekil, resmî vasiyetnameler için öngörülmüş olan şekil hükümlerinin amacını tam olarak gerçekleştirmelidir; b) karma şeklin sağladığı garanti, MK 533/534 ya da MK 535'e göre yapılan resmî vasiyetnamelerin sağlayacağı garantiden daha az olmamalıdır.

352 Karma türde resmî vasiyetname iki şekilde yapılabilir.

1. Okunmadan, fakat imzalanarak düzenleme

353 Burada, esasında resmî vasiyetname, MK 535'in tüm şekil kurallarına

---

[179] 2.HD 21.10.1992, 9210/1008 (YKD, 1993, c.XIX, 116); 2 HD 3.4.2003, 3392/4805 (YKD 2004, c. XXX, 684).

[180] 2. HD 28.11.1991 tarih ve 9237/14871 sayılı kararında, resmi vasiyetnameye el ile yapılan çıkıntıları, doğru olarak geçersiz saymıştır (YKD 1992, c.XVIII, 361).

[181] Bkz., yukarıda I,B.

[182] *Escher*, Art. 502 N 26; *Tuor*, Art. 502 N 1,8; *Tuor/Schnyder*, § 60, II, b; BGE 89 II 368.

[183] Örnek olarak bkz., *Kocayusufpaşaoğlu*, § 14, II,2,d; *Oğuzman*, 116; *Dural*, Miras, 58; *Köprülü*, § 7, dn. 45.

[184] *Kocayusufpaşaoğlu*, § 14, II,2,d.

uyularak düzenlenmekte, fakat vasiyetçi, vasiyetnamenin noter tarafından tanıklar önünde okunmasından sonra, ayrıca bir de vasiyetnameyi imzalamaktadır. Bu halde, MK 535'in aradığı garantiden daha fazlası gerçekleşmiş olacağı için[185], bu vasiyetname geçerli olur. Nitekim yukarıda sözü edilen 1962 tarihli İçtihadı Birleştirme Kararında da, *"Özel olarak yurdumuzda okuma yazma bilmeyen bir çok kişinin sadece imzalarını atabilmeleri ve imzalı bir resmî belgenin ne de olsa imzasız bir resmî belgeden daha çok güven sağlayacak bir nitelikte olduğu göz önünde tutulunca, MK 482 (yeni 535). madde uyarınca düzenlenen bir resmî vasiyet senedinde, vasiyetçinin imzasının bulunması onun muteberliği üzerinde etkisiz sayılmalıdır".*

Burada tartışmalı olan husus, noterin, vasiyetnameyi tanıklar önünde okumasının zorunlu olup olmadığıdır. Bazı yazarlar bunu şart olarak aramamaktadırlar. Bu yazarlara göre, noter, vasiyetnameyi, tanıklar olmaksızın, sırf vasiyetçiye okumuş olsa dahi, vasiyetçinin, tanıklara, noterin vasiyetnameyi kendisine okuduğunu ve bunun son arzularına uygun olduğunu beyan ettikten sonra, bu beyanını imza ile tevsik etmesi, belgenin geçerliği için yeterli garantiyi oluşturur[186]. 354

Diğer bir grup yazar ise, okunmadan fakat imzalanarak yapılan resmî vasiyetnamelerde, noterin metni tanıklar önünde okumasını zorunlu görürler[187]. Aynı görüşte olan Federal Mahkemeye göre[188], tanıklar önünde okumayı zorunlu görmenin sebebi, metnin, vasiyetçi tarafından anlaşılacak şekilde okunduğunun kontrolü ve noterin hazırladığı ve imzalanan metin ile, vasiyetçinin, son arzularına uygun olduğunu söylediği metnin ayniyetinin saptanmasıdır. 355

Oğuzman, şu gerekçeler ile vasiyetnamenin tanıklar önünde okunmasını zorunlu görür: *"Mesela, körlüğü sebebiyle vasiyetnameyi okuyamayan fakat imza atabilen kimseye vasiyetnamenin şahitler bulunmaksızın okunması hâlinde vasiyetçinin imzaladığı senedin, kendisine okunan metin olup olmadığını kontrol etmesi mümkün değildir; imzası bu hususu tevsik edecek güçten yoksundur. Bu sebepledir ki, okuyamayanlar için MK 482 (yeni 535)'deki şekle tam uyulmasını aramak doğru olur. Fakat fazla olarak metinde vasiyetçinin imzası da olabilir"*[189]. *Kocayusufpaşaoğlu*, meseleye, bu tür karma vasiyetname düzenleyen kişinin okuma bilip bilmemesi açısından yaklaşmaktadır[190]. Buna göre, vasiyetçi okuma biliyorsa, vasiyetnamenin tanıklar önünde okunmasına gerek yoktur. Çünkü o, imza atarken, imzaladığı metin ile, noterin kendisine okuduğu metnin aynı olup olmadığını kontrol edebilecek durumdadır. Oysa, okuma bilmemesi hâlinde, bu kontrolü yapamayacağı için, noterin vasiyetnameyi tanıklar önünde okuması zorunludur. 356

2. Okuyarak, fakat imzalamadan düzenleme

Bu yola, okuma bilen, fakat herhangi bir sebeple imza atamayan kimseler başvurabilir. Burada, vasiyetçi, vasiyetnameyi notere okutacak yerde 357

[185] Bkz., *Oğuzman*, 117.
[186] *Tuor*, Art. 502 N 8b; *Escher*, Art. 502 N 7; *Gautschi*, 101.
[187] *Raschein*, 39; *Oğuzman*, Pratik Çalışmalar II, 63/64; *Oğuzman*, 116.
[188] BGE 66 II 99; 89 II 365.
[189] *Oğuzman*, 117.
[190] *Kocayusufpaşaoğlu*, § 14, II, 2, d.

kendisi okuyacak ve imzanın yerini almak üzere MK 535'deki kurallar uygulanacaktır. Baskın görüş, güvenlik açısından, okumanın tanıklar önünde olmasını arar[191]. *Kocayusufpaşaoğlu*'na göre, bu halde, tanıkların verecekleri şerhte, noterin değil de vasiyetçinin metni önlerinde okuduğu yazılmalıdır[192].

358 Belirtmek gerekir ki, resmî vasiyetnamenin hangi türü söz konusu olursa olsun, şekil kurallarına uyulduğunun doğrudan resmî vasiyetnamenin metninden anlaşılması gerekir. Eksikliğin, sonradan vasiyetname dışı olgulara başvurularak tamamlanması söz konusu olamaz. Örneğin, tanıklar, şerhte, vasiyetçiyi ölüme bağlı tasarrufta bulunmaya ehil gördüklerini belirtmemişlerse, bu eksiklik, vasiyetnameye eklenmiş bir hekim raporu ile giderilemez[193].

359 Bunun aksine, şekil şartlarını tümüyle içeren bir resmî vasiyetnamenin, vasiyetçinin, kendisin belirli bir şekle uymadığını üçüncü kişilere beyan etmesi, vasiyetnameyi geçersiz kılmaz. 2. Hukuk Dairesi bir kararında, doğru olarak bu sonuca varmıştır[194]. Karara konu olan olayda, vasiyetçi, vasiyetnameyi ve bunun son arzularına uygun olduğunu tanıklar önünde beyan etmiş, fakat daha sonra üçüncü kişilere vasiyetnameyi okumadığını söylemiştir. 2. Hukuk Dairesine göre, böyle bir beyan, şekle uygun olarak düzenlenen vasiyetnamenin iptal edilmesine yol açamaz. Olsa olsa burada, sahtelik davası açılabilir.

360 Vasiyetname tamamlandıktan sonra, noter ya da resmî memur, bunun bir suretini vasiyetçiye verir, aslını ise kendisi saklar (MK 537, krş. NK 81/II). Noter bu şekilde düzenlediği resmî vasiyetnameyi (aynı şekilde, düzenlediği miras sözleşmesi ve MK 538/II'ye göre kendisine saklanmak üzere verilen el yazılı vasiyetnameyi), vasiyetçinin ölümü hâlinde bilgi verilmesi için onun nüfus kütüğüne bildirir (NK 69). Nüfus memurunun, ölümü kendisine bildirmesi üzerine noter, vasiyetnameyi sulh hâkimine verilmek üzere, savcılığa tevdi eder. Ancak MK 537 ve NK 69, geçerlik şartı olmadıkları için, bunlara uyulmaması, vasiyetnameyi iptal edilebilir hale getirmez.

VI. BAZI ÖZEL DURUMLAR

1. Körlerin durumu

361 Körler alfabesini dahi bilmeyen körlerin, sadece MK 535'e göre resmî vasiyetname düzenleyebileceklerine kuşku yoksa da; bu alfabeyi bilenlerin MK 533/534'e göre resmî vasiyetname düzenleyebilip düzenleyemeyecek-

---

[191] Bkz., *Kocayusufpaşaoğlu*, § 14, dn.96'da anılan yazarlar.
[192] *Kocayusufpaşaoğlu*, § 14, II, d, bb,bbb.
[193] 2.HD 6.10.1977, 5906/6788 (*Şener*, Vasiyet, madde 482, No 6).
[194] 2.HD 30.3.2963, 1610/1979 (İKİD, 1964, 2817).

leri tartışmalıdır. Bazı yazarlar, körlerin, noter tarafından kaleme alınan metni bizzat okuyamayacakları için, onların sadece MK 535'e göre vasiyetname düzenleyebilecekleri görüşündedirler[195]. Diğer bir grup yazar ise[196], vasiyetçinin, körler alfabesini okuyabilmesinden hareketle, vasiyetname metnini aynı zamanda körler alfabesi ile yazılmış ve bunun vasiyetnameye, onun ayrılmaz bir parçası olarak eklenmiş olması şartıyla, körlerin de MK 533/534'e göre resmî vasiyetname düzenletebileceklerini savunmaktadırlar.

Fikrimce, bu ikinci görüş, özellikle kör bir kimsenin, normal bir yazı ile 362
yazılan metin ile körler alfabesi ile yazılan metnin birbirine uygunluğunu kontrol edebilmesinin imkânsızlığı karşısında oldukça sakıncalıdır. Bu sebeple körlerin MK 533/534'e göre resmî vasiyetname yapamayacaklarını kabul etmek daha doğru olur. Kaldı ki, onlara bu yolun kapatılmasının bir sakıncası da yoktur. Çünkü, MK 535'e göre resmî vasiyetname yapma imkânı ellerinden alınmamaktadır.

2. Sağır ve dilsizlerin durumu

Sağır ve dilsiz olan bir kimse, okuma yazma biliyorsa, MK 533/534'e 363
göre resmî vasiyetname düzenlettirebilir. Çünkü o, son arzularını notere yazılı olarak verebilir, noterin sorularına yazılı olarak cevap verebilir, nihayet, tanıklara yapması gereken beyanı da yazılı olarak yapabilir. Burada, sağır ve dilsiz, normal yazı ile yazılmış olan metni bizzat kendisi okuyacağı için, körler yönünden söylediğimiz mahzur söz konusu olmaz. Belirtmeye gerek yoktur ki, okuma yazma bilen sağır ve dilsiz, isterse MK 535'e göre de resmî vasiyetname yapabilir.

Buna karşılık, sağır ve dilsiz okuma yazma bilmiyorsa, o zaman, 2. Hu- 364
kuk Dairesinin 11.5.1992 tarih ve 2363/5457 sayılı kararında da belirttiği gibi[197], resmî vasiyetnamesini ancak MK 535'e göre düzenleyebilir. Sözü edilen karara göre, bu halde, vasiyetnamenin düzenlenmesine, onu anlayan bir tercüman da katılır. Ancak, yine karara göre, resmî memur ya da tanıklar, sağır ve dilsiz işaretlerini biliyorlarsa, tercümanın bulunması şart değildir.

Hem sağır hem dilsiz hem de kör olanlara gelince; baskın görüş bu kişi- 365
lerin hiçbir şekilde resmî vasiyetname düzenlettiremeyecekleri yönünde-

---

[195] Örnek olarak bkz., *Oğuzman*, 111, dn. 142; *İmre/Erman*, § 14, II,2; *Köprülü*, § 7, IV, 1, a, aa, aaa; *Kocayusufpaşaoğlu*, § 14, II, 2.

[196] Örnek olarak bkz., *Tuor*, Art. 500 N 3.

[197] YKD 1993, c. XIX, 512; *Oğuzman* (115, dn.158b), bu kararın tartışılabilir olduğu görüşündedir.

dir[198]. Ancak bazı yazarlar, bu durumda olup da körler alfabesini bilen bir kimsenin istisnaen MK533/534'e göre resmî vasiyetname düzenletebilecekleri görüşündedirler. Bu yazarlara göre, vasiyetçinin işaretlerini anlayan ve körler alfabesini bilen bir tercümanın vasiyetnamenin yapılmasına katılıp, vasiyetçinin yapacağı beyanları noter ve tanıklara anlatması, vasiyetçinin körler alfabesi ile yazdığı vasiyetnameyi normal yazıya çevirmesi hâlinde vasiyetname geçerli sayılmalıdır. Ayrıca, körler alfabesine göre yazılmış olan metin de vasiyetnameye, onun ayrılmaz bir parçası olarak eklenmelidir[199]. İtiraf etmek gerekir ki, bu yolla vasiyetname düzenleme imkânını tanımak, vasiyetçinin son arzularının tam olarak yansıtılması yönünden çok tehlikeli olmakla beraber zorunludur. Aksi hâlde, MK 538'e göre, el yazılı vasiyetname de düzenleyemeyecekleri düşünülecek olursa, onların elinden ölüme bağlı tasarruf yapma imkânı tümüyle alınmış olur.

3. Türkçe bilmeyenlerin durumu

366 Medenî Kanunda, Türkçe bilmeyen kimselerin- ki bunlar genellikle yabancılar olacaktır-, düzenlettirecekleri resmî vasiyetnamede uyacakları şekil şartlarına ilişkin düzenleme bulunmamaktadır. Bu sebeple, bu kişilerin, resmî vasiyetname düzenlettirmelerine NK 74'deki şekil kurallarının uygulanacağı kabul edilmektedir[200]. Söz konusu hükme göre, ilgilinin Türkçe bilmemesi hâlinde, bir tercüman işleme katılır. Ancak, noter, söz konusu yabancı dili biliyorsa, tercümana gerek yoktur. Tercüman ya da noter tarafından çevrilen metnin, yabancı dilde olan metne eklenmesi gerekir.

367 Burada önemli olan nokta, Türkçe bilmeyen bir vasiyetçinin, vasiyetnamenin son arzularına uygun olduğunu tanıklara ne şekilde ifade edeceğidir. Yargıtay, bu konuda, Türkçe bilmeyen vasiyetçinin kendi dilinde yapacağı beyanın yeterli olmadığı, bu beyanın tercüman tarafından tanıklara Türkçe olarak tekrarlanması ve tanıkların, beyanı nasıl öğrendiklerinin şerhte yer alması gerektiği görüşündedir. Çünkü, Yargıtay'a göre, *"Aksi halde, Türkçe'den başka dil bilmeyen tanıkların onama şerhini kontrol etmek ve onların tanıklık ettikleri konuyu en basit bir ölçü ile öğrenip öğrenmediklerini ve resmî belgenin ciddiyet derecesini anlamak zorlaşır. Eğer vasiyetnameden,tanıklarca nasıl olup da anlaşıldığını kestiremiyorsak ölenin beyanın gerçekten öğrenip anladıkları sonucunu çıkartamayız. Ayrıca bu işlerin ciddi ve emniyet verici şartlar altında yerine getirildiği de kabul edilemez. O halde geçerli bir onama şartından söz edilemez"*[201].

---

[198] *Köprülü*, § 7, 1,a,aa,aaa; *İmre/Erman*, § 14, II,2; *Gautschi*, 54; *Escher*, Art. 500 N 3; *Tuor*, Art. 500 N 3; *Kocayusufpaşaoğlu*, § 14, II, 2, a, aa.

[199] *Escher*, Art. 500 N 3; *Kocayusufpaşaoğlu*, § 14, II, 2, a, aa.

[200] *Oğuzman*, 111, dn.43; *Köprülü*, § 7, IV, a, aa, aaa; *Şener*, § 2, VIII; krş., *Kocayusufpaşaoğlu*, § 14, II, 2, a.

[201] 2. HD 23.1.1970, 71/489 (*Şener*, Vasiyet, madde 481, No. 3); 2.HD 23.1.1971,

Bu konuda üzerinde durulması gereken son bir nokta Türkçe bilmeyen kişinin, 368
MK 535'e göre resmî vasiyetname düzenlettirmesi hâlinde, vasiyetname metninin, o yabancı dili bilmeyen tanıklara noter tarafından nasıl okunacağıdır. Çünkü, noter Türkçe metni okursa, yabanca vasiyetçi, bunun son arzularına uygun olup olmadığını kontrol edemeyecektir. Eğer yabancı dildeki metin, tercüman tarafından okunacak olursa, vasiyetçi, bunun son arzularına uygunluğunu kontrol edebilecek, fakat bu sefer de MK 535'in, geçerlik şartı olarak aradığı , vasiyetnamenin bizzat resmî memur tarafından okunması şartı gerçekleşmemiş olacaktır. Doktrinin buna getirdiği ve fikrimce de doğru olan çözüm, her iki metnin de aynı anda tanıklara okunmasıdır. Yani, noter Türkçe metni okurken, tercüman da, onunla aynı anda yabancı dildeki metni okumalıdır[202].

§ 11. El Yazılı Vasiyetname

I. GENEL OLARAK

El yazılı vasiyetnameyi düzenleyen MK 538'e göre, *"El yazılı vasiyet-* 369
namenin yapıldığı yıl, ay ve gün gösterilerek başından sonuna kadar mirasbırakanın el yazısıyla yazılmış ve imzalanmış olması zorunludur.

El yazılı vasiyetname, saklanmak üzere açık veya kapalı olarak notere, 370
sulh hakimine veya yetkili memura bırakılabilir".

Görüldüğü gibi, kanun, el yazılı vasiyetnamede *nitelikli adî yazılı şekli* 371
geçerlik şartı olarak aramaktadır. Çünkü, Borçlar Kanununda öngörülmüş olan adî yazılı şekilden farklı olarak (BK 12 vd), burada şekil şartının gerçekleşmiş sayılması için, sadece imzanın el yazısı ile olması yeterli görülmemiş, düzenleme tarihinin de bulunması şart olarak arandığı gibi, tarih dahil, bütün metnin vasiyetçinin el yazısı ile yazılmış olması geçerlik şartı olarak aranmıştır. Ayrıca imzanın da el yazısıyla olması da aranarak, imza yerine parmak basılması ya da bir mekanik araçla imza atılması da yasaklanmıştır.

II. EL YAZILI VASİYETNAMENİN FAYDA VE MAHZURLARI

1. Faydaları

a) Yapılmasındaki kolaylık: El yazılı vasiyetnamenin yapılması ve de- 372
ğiştirilmesi her zaman kolaylıkla mümkündür. Vasiyetçi, vasiyetnamedeki

---

3991/1472 (*Şener,* Vasiyet, madde 482, No.9). Buna karşılık, 2.HD 13.5.1969 tarih ve 2395/2562 sayılı kararında,yabancının son arzularına uygun olduğunu beyan edecek kadar Türkçe bilmesi halinde, beyanın çevirisine gerek olmadığı sonucuna varılmıştır (yayınlanmamış olan bu karar için bkz., *Kocayusufpaşaoğlu,* § 14, 2, a, ee).

[202] *Kocayusufpaşaoğlu,* § 14, 2,c,cc; *Köprülü,* § 7, IV, 1, a, aa, aaa.

herhangi bir tasarrufu, istediği zaman, hiçbir zorluğa uğramadan değiştirebilir ya da vasiyetnameye yeni bir tasarruf ekleyebilir

373 *b) Masrafsız oluşu :* El yazılı vasiyetnamenin yapılması hiçbir masraf gerektirmez; sadece bir kâğıt ve kalem yeterlidir.

374 *c) Gizliliği :* El yazılı vasiyetnamenin son bir yararı da, hem yapıldığının hem de içeriğinin üçüncü kişilerden gizlenebilmesi imkânını vermesidir. Böylece vasiyetçi, kendisini (ve bir ölçüde ailesini) ilgilendiren hususları yabancılardan saklama imkânını bulur.

2. Mahzurları

375 *a) Yok olma tehlikesi :* El yazılı vasiyetnamenin en büyük mahzuru kolayca yok olabilmesidir. Bu yok olma, vasiyetnameden herhangi bir şekilde haberdar olup da, hayal kırıklığına uğrayan kimselerin, vasiyetnameyi ortadan kaldırmaları şeklinde olabileceği gibi,bizzat vasiyetçinin, yok etme iradesi olmadan (örneğin kazara yırtması) yok etmesi ya da bir olay (örneğin yangın) sonucunda gerçekleşebilir.

376 *b) Bulunamaması :* Vasiyetnamenin gizli kalması, onun bulunamaması tehlikesini de birlikte getirir.

377 *c) Kolayca tahrif edilebilmesi :* Normal olarak bir resmî makama tevdi edilmesi zorunlu olmayan el yazılı vasiyetnamede aradıklarını bulamayan bazı hısımların, çizerek ya da ona ekler yaparak, vasiyetnameyi kolayca tahrif etmeleri mümkündür.

378 *d) Vasiyetçinin kolayca etki altında kalması:* Resmî bir makam önünde yapılmayan el yazılı vasiyetnamede, vasiyetçi, vasiyetnamesini düzenlerken, başkalarının etkisi altında kalabilir. Bu suretle vasiyetçi, esasında yapmak istemediği bir tasarrufa vasiyetnamesinde yer verebilir.

379 *e) Gerçek vasiyetname ile vasiyetname projesini birbirinden ayırma zorluğu:* Vasiyetçinin kâğıtları arasında bulunan bir belgenin, gerçek bir vasiyetname mi yoksa sadece bir proje mi olduğunu tespit etmek güçtür. Bir başka deyişle,vasiyetçinin, o belgeyi yazarken *animus testandi* (vasiyetname yapma iradesi) ye sahip olup olmadığının tespiti imkânsız denecek kadar zordur ve bu sebeple de vasiyetçinin, vasiyetname yapma niyeti olmadan kaleme aldığı belgenin, belki de tesadüfen şekil şartlarını içermesi sebebiyle vasiyetname olarak kabul edilmesi tehlikesi vardır.

380 *f) Açıkça anlaşılabilir olmayabilmesi:* Son bir mahzur da, hukuk bilgisi olmayan bir kimsenin, yaptığı tasarrufları, muğlak, çeşitli anlamlara gelebilecek ifadelerle kaleme almasıdır.

Doğrusu el yazılı vasiyetnamenin mahzuru olarak gösterilen bu hususların bertaraf edilmesi çok zor değildir. Önce, yok olma, bulunamama ya da tahrif edilmeye karşı bizzat kanun bir çare göstermiştir ki, bu da vasiyetnamenin saklanmak üzere tevdiidir (MK 538/II). Bunun üzerinde aşağıda durulacaktır. Vasiyetnamenin baştan sona el yazısı ile olması şartı, onu tahriflere karşı korur. Çünkü, yazı farkı çok kolay olarak tespit edilebilir.Vasiyetçinin başkalarının etkisi altında kalması tehlikesi, belki el yazılı vasiyetnamedeki kadar yoğun olmamakla beraber resmî vasiyetnamede de vardır. Çünkü, resmî memur sadece vasiyetçinin söylediklerini kaleme alır, vasiyetçinin kendisine gelmeden önce etki altında kalmasını engelleyemez. *Animus testandinin* var olup olmadığı ise bir ispat meselesidir. Bu iddia, sadece bir vasiyetnamenin proje olup olmadığının tartışmalı olduğu hallerde değil her zaman ortaya çıkabilir. Vasiyetçinin teknik terimleri kullanmayarak gerçek iradesini yansıtamaması ihtimaline karşı, bizzat kanun yorum imkânları öngörmüştür[203]. 381

III. EL YAZILI VASİYETNAMENİN ŞEKİL ŞARTLARI

1. Vasiyetnamenin metni[204]

a) Genel olarak

MK 538'e göre, el yazılı vasiyetnamenin, tarihi ve imza dahil olmak üzere, metnin tümünün vasiyetçinin el yazısı ile olması gerekir. Bu hükmün amacı, vasiyetnamenin gerçekliğinin, vasiyetçiden sâdır olduğunun tespit edilebilmesini temindir. Çünkü, her insanın kişiliğini belirleyen bir yazısı vardır. İşte vasiyetçinin elyazısını arama şartı, vasiyetnamenin başkası tarafından tahrif edilmesini engeller. 382

MK 538/I, *mirasbırakanın el yazısıyla* demekle, kuşkusuz normal yazı tarzını (el ile yazmayı) belirtmiştir. Ancak bunu, *bizzat vasiyetçiden sâdır olan bir yazı* şeklinde anlamak gerekir. Böyle olunca da, haklı sebebin varlığı hâlinde, vasiyetçinin başka bir organı (örneğin iki eli de olmayan bir kimsenin, kalemi ayağı ya da ağzı ile tutarak) yazdığı metin de el ile yazılmış kabul edilmelidir. 383

Yazı yazabilen, fakat bedeni zayıflığı sebebiyle, elinin bir başka kimse tarafından desteklenmesi gereken kişinin yazdığı vasiyetnamede, el yazısı şartının gerçekleşmiş sayılıp sayılmayacağı hususunda bir ayırım yapmak gerekir. Bu destekleme, vasiyetçinin yazısının karakteristiğini değiştirmemişse, metin el ile yazılmış kabul edilmelidir. Aksine, yazı, tamamen destekleyen kişinin yazısının özelliklerini almışsa, metnin, vasiyetçinin el yazısı ile olması şartı gerçekleşmeyeceği için, vasiyetnamenin geçersiz olduğunu kabul etmek gerekir[205]. 384

MK 538'in vasiyetçinin el azısını araması şartı karşısında, daktilo, bilgisayar ya da başka bir kimsenin el yazısı ile yazılmış metni, vasiyetçi imzalasa dahi, bu metin, vasiyetname olarak geçersizdir[206]. 385

---

[203] Bu açıklamalara ilişkin etraflı bilgi için bkz., *Dural,* Vasiyetname, § 3, III.
[204] Buradaki açıklamalar için bkz., *Dural*, Vasiyetname, § 4.
[205] 2.HD, 20.2.1986, 1318/1722 (*Şener*, Vasiyet, madde 485, No 2).
[206] 2.HD 20.10.1975, 7023/7791 (*Şener*, Vasiyet, madde 485, No.3).

386 El yazılı vasiyetname, normal olarak, bir kalemle kâğıt üzerine yazılacaktır. Ancak, böyle olmayıp da, herhangi bir şeyle, herhangi bir şey üzerine yazılan vasiyetnamelerde, diğer şekil şartlarını içermeleri hâlinde, el yazılı vasiyetname olarak geçerlidirler. Örneğin, vasiyet edilen hisse senedinin arkasına yazılan ya da esir kampında bir kimsenin duvara çivi ile yazdığı vasiyetname geçerli olur; yeter ki, normal yazı araçlarından uzaklaşmayı haklı gösterecek bir durum olsun. Aksi hâlde, vasiyetnameyi yazan kimsenin niyetinin ciddiyetinden kuşku duymak gerekir. Örneğin, yazıhanesinde, masasının başında oturan bir kimsenin, vasiyetnamesini önündeki kâğıda kalemle yazacak yerde, bir çivi ile duvara yazması hâlinde, içinde bulunduğu şartlar, onda *animus testandinin* varlığından kuşku duyurur. Böyle olunca da, vasiyetnamenin, şekil şartına uyulmadığı için değil de, bu sebeple geçersiz olması gerekir.

387 Dış görünüş yönünden de el yazılı vasiyetname herhangi bir özel şarta bağlanmamıştır. Vasiyetnamenin, *son arzularımdır* ya da *vasiyetnamemdir* gibi bir başlık taşımasına gerek olmadığı gibi, bağımsız bir belge olması da zorunlu değildir. Önemli olan, vasiyetçinin MK 538'deki şekil şartlarına uygun olarak yaptığı beyan ile, bundan, kişinin hukuken bağlayıcı bir tasarrufta bulunma niyetinin anlaşılmasıdır. Bu bakımdan, mektup ya da posta kartı şeklinde veya bir kitabın kenarına yazılmış olan son arzular, *animus testandinin* bulunması şartıyla, el yazılı vasiyetname olarak geçerlidirler.

388 Birden fazla sayfadan oluşan vasiyetnamede, sayfalar arasında bir dahili bağ bulunmalıdır. Bu bağ, sayfaların numaralandırılması ya da içerik yönünden ilgisi ile kurulur.

389 Vasiyetname normal olarak Türk alfabesi ile yazılacaktır. Fakat, vasiyetçinin niyetinin ciddi olması şartıyla, herhangi bir yazı ile de yazılabilir. Yargıtay, oldukça eski bir kararında, arap harfleriyle yazılmış olan bir vasiyetnameyi geçerli kabul etmiştir[207]. Önemli olan, kullanılan yazının, vasiyetçinin kim olduğunun tespitine imkân vermesidir.

390 Körler alfabesi ile el yazılı vasiyetname düzenlenebilip düzenlenemeyeceği tartışmalıdır[208]. *Fikrimce*, sadece kabarık noktalardan oluşan bir yazı türünden, yazanın kişiliğini tespit edebilme imkânı olmadığından, böyle yazılmış olan bir vasiyetnamenin geçersiz olması gerekir. Aynı sonuca, nokta ve çizgilerden oluşan mors alfabesi ile de varmak gerekir[207a].

391 Tartışmalı olan bir başka yazı türü de stenodur[209]. Körler alfabesi ve mors alfa-

---

[207] 2.HD 22.12.1949, 5393/6298 (*Olgaç*, c. 1, 591); aynı mealde, 2.HD 8.4.1947, 4928/1964 (*Şener*, Vasiyet, madde 485, No.4).

[208] Tartışmalar için bkz., *Dural*, Vasiyetname, § 2,III.

[207a] Aksi görüş *Antalya*, 135, dn. 415.

[209] Tartışmalar için bkz., *Dural*, Vasiyetname, § 2,III.

besinden farklı olarak, stenoda yazanın kimliğinin tespit edilmesi mümkündür. Ne var ki, stenonun yaygın kullanılış şekli müsvedde ya da taslak yazılar içindir. Bu bakımdan böyle yazılmış olan bir vasiyetname, her ne kadar el ile yazılmış olma şartını gerçekleştirirse de, *animusu testandi* yönünden üzerinde dikkatle durulması gerekir.

Kullanılan yazı gibi, kullanılan dilin de vasiyetnamenin geçerliğine etkisi yoktur. Vasiyetçinin, bilmesi şartıyla, Türkçe'den, daha iyi bir deyişle, kendi anadilinden başka bir dili kullanmasına bir engel yoktur[210], yeter ki, sık sık değindiğimiz gibi, *animus testandinin* varlığı anlaşılsın. 392

Yukarıda yapılan açıklamalardan anlaşılacağı gibi, normal yazı şekli ile normal yazı araçlarından ayrılınarak yapılan el yazılı vasiyetnamelerde, şekil kurallarına uyma yanında *animus testandinin* varlığı da önemlidir. Normal araçlarla bir el yazılı vasiyetname hazırlama imkânı olan bir kimsenin, mutad olmayan araç ya da (Latince gibi) dille vasiyetname yapması hâlinde, vasiyetname yapma niyetinin çok dikkatli olarak araştırılması gerekir. Olağan dışı araçları kullanmayı, vasiyetnamenin içinde yazıldığı durum haklı gösteriyorsa, o zaman vasiyetname yapma niyetinden kuşku duymamak gerekir. Örneğin, ıssız bir adada olan ve elinde çividen başka bir şey bulunmayan kazazedenin, vasiyetnamesini bir taş parçası üzerine bununla yazması hâlinde, olağandışı durum sebebiyle, vasiyetname niyetinin varlığından kuşku duymamak gerekir. 393

b) Metnin, kısmen üçüncü kişiler tarafından ya da mekanik bir araçla yazılmış olması

MK 538/I'in, bütün vasiyetname metninin el yazısı ile olmasını araması karşısında, acaba, vasiyetnamenin bir kısmının üçüncü bir kişi tarafından ya da mekanik bir araçla yazılmış olmasının vasiyetnameye etkisi nedir? Burada iki sorunun cevaplandırılması gerekir: a) Üçüncü kişiler tarafından ya da mekanik olarak yazılan kısmın akıbeti nedir? b) Bu kısımların, vasiyetnamenin tamamı üzerindeki etkisi nedir? 394

Birinci sorunun cevabı açıktır. Böyle yazılı olan kısımlar MK 538/I'in aradığı, el yazısı ile olma şartını içermedikleri için, ne zaman yazılmış olurlarsa olsunlar geçersizdirler. 395

Üçüncü kişiler tarafından ya da mekanik araçla yazılan kısımların vasiyetnamenin tümüne etkisinin ne olacağının cevabı, bunların, vasiyetçinin bilgisi ile mi yoksa bilgisi dışında mı yazıldığına göre farklı olacaktır. Vasiyetname, daha tamamlanmadan, vasiyetçinin bilgisi ile yapılan bu şekildeki eklerin vasiyetnamenin tümüne etkisinin ne olacağı tartışmalıdır[211]. *Fikrimce* doğru olan görüş, bu eklerin, vasiyetnamenin esaslı noktaları ile ilgili olsun ya da olmasın, vasiyetnamenin tümünü geçersiz kılacağını kabul eden görüştür. Çünkü MK 557 b.4, esaslı noktalara ilişkin olma ya da ol- 396

[210] 2. HD 20.10.1984, 5977/79 (*Şener,* Miras, 970).
[211] Bu tartışmalar için bkz., *Dural,* § 2, V; *Oğuzman,* 120.

mama ayırımını yapmaksızın, mutlak bir ifade ile, her türlü şekil noksanını iptal sebebi saymıştır.

397 *Fikrimce*, sadece üçüncü kişiler tarafından ya da mekanik bir araçla yazılan kısımları geçersiz sayıp, vasiyetnamenin diğer kısımlarını ayakta tutmak MK 558/III karşısında mümkün değildir. Çünkü MK 558/III, hangi hallerde kısmı geçersizliğin söz konusu olabileceğini saymıştır ve bunlar arasında, burada tartışılan husus yoktur. Bu fikri, Türk hukukunda savunan yazarlar, belirli şartlarla, bu şekilde yazılmış kısımları geçersiz kabul edip, vasiyetnamenin geri kalan kısmını geçerli sayan BGB § 2985'e dayanmaktadırlar[212].

398 Buna karşılık, şekil şartlarına uyularak tamamlanmış olan el yazılı vasiyetnameye, üçüncü kişilerin yaptığı ya da mekanik bir araçla yapılan ekler, kural olarak tamamlanmış olan vasiyetnamenin MK 557 b. 4'e göre iptal edilmesi sonucunu doğurmazlar. Çünkü, vasiyetname, daha önce, şekil şartlarına uygun olarak yapılmış ve tamamlanmıştır. Bu yüzden, sonradan, şekil şartına uymayan eklerin yapılması, tamamlanmış olan vasiyetnameyi, kural olarak, iptal edilebilir hale getirmezler. Aksine MK 557 b. 4'e göre, bu sonradan yapılan ekler geçersiz olur. Vasiyetnamenin geri kalan kısmı geçerliğini korur, meğer ki, geçersiz olan kısımlar olmaksızın, vasiyetnamenin hiç yapılmayacağı anlaşılsın. Bu halde BK 20'ye göre, vasiyetnamenin tamamı geçersiz olur.

2. Düzenleme tarihi

399 MK 538/I'e göre, el yazılı vasiyetnamede düzenleme tarihinin bulunması ve bunun el yazısı ile atılmış olması geçerlik şartıdır.

a) Düzenleme tarihinin gösteriliş şekli

400 Genel olarak, gün, ay ve yıl şeklinde gösterilecek olan düzenleme tarihinin muhakkak vasiyetnamede böyle yer alması zorunlu değildir. Önemli olan, yazılış şeklinden, belirli bir yılın, belirli bir ayının, belirli bir gününün kesin olarak saptanabilmesidir. Bir bayram gününün yazılması ya da kesin olarak saptanabilmesi mümkün bir olaya atıf yapılması, geçerli bir tarihin vasiyetnamede bulunuyor sayılması için yeterlidir. Örneğin, *1996 Kurban Bayramının üçüncü günü, Hukuk Fakültesinden mezun olduğum gün* şeklinde belirleme de yeterlidir. Buna karşılık, *1996 yılı Kurban Bayramı*, şeklinde atılan bir tarih geçerli olmaz. Çünkü, Kurban Bayramı birden çok gün devam ettiği için, düzenleme zamanı kesin olarak saptanamaz, meğer ki, hangi günün kastedildiği vasiyetname içi ve dışı olgularla kuşkusuz bir şekilde tespit edilebilsin.

401 Vasiyetnamede birden fazla tarihin bulunması geçerliği etkilemez. Bunun anlamı, vasiyetnamenin birden fazla günde yapıldığıdır.

---

[212] Bkz., *Kocayusufpaşaoğlu*, 196/197.

MK 538/I, el yazılı vasiyetnamede düzenleme tarihi bulunmasını aramaktadır. Böyle olunca da, vasiyetnameye, düzenleme tarihi olarak ne yazılacaktır sorusuyla karşılaşırız. Bu mesele tartışmalıdır[213]. Bu konuda, eskimiş olmakla beraber, *Oğuzman*[214] tarafından, kanunun sistemine uygun olduğu savunulan görüş, vasiyetnamenin yazılmasının devam ettiği bütün günlerin tarihinin vasiyetnamede gösterilmesidir. Ancak yazar, aynı yerde, vasiyetnamenin tamamlandığı ânın tarihinin de kabul edilebileceğini de savunmaktadır. 402

Federal Mahkeme,eksik kaydın vasiyetnameye konulduğu zamanı vasiyetnamenin tamamlandığı an olarak kabul edip, o tarihin bulunmasını aramaktadır[215]. Baskın görüş ise, zaten çok sert olan şekil kurallarının daha da sertleştirilmemesi için, vasiyetnamenin hazırlanış safhalarından herhangi birinin tarihini yeterli görmekte, muhakkak vasiyetnamenin tamamlandığı ânın tarihinin bulunmasını zorunlu görmemektedir. Katıldığım bu görüş açısından, örneğin, vasiyetçi, vasiyetname metnini 1 Martta yazar,2 Martta imzalar ve ertesi gün de 3 Mart yerine 1 Mart tarihi atacak olursa, bu tarihin varlığı için yeterlidir. Çünkü, vasiyetnamede, düzenlendiği safhalardan birinin tarihi bulunmaktadır. Oysa tamamlanma ânını arayan görüş yönünden, vasiyetnamede 3 Mart tarihinin bulunması gerekir. Çünkü, vasiyetname, son unsuru olan tarihin atıldığı anda tamamlanmış olacaktır. 403

Kocayusufpaşaoğlu da, vasiyetnamenin yazıldığı safhalardan birinin tarihinin atılmasını geçerli gören görüşe katılmakla beraber, özellikle birden fazla vasiyetnamenin bulunduğu hallerde, tarihin, vasiyetnameler arasındaki sırayı tespit etme fonksiyonunun tehlikeye düşeceğine işaret etmektedir[216]. Yazara göre, *"... çünkü, onun (vasiyetçinin) 1 Mart 1960'da metnini yazdığı vasiyetnameyi, 31 Mart 1960'da imzalamış olması ihtimali vardır. Bu görüşe nazaran sözü edilen vasiyetnamede yer alan 1 Mart 1960 tarihi doğrudur. Mirasbırakanın arada 15 Mart 1960'da o günün tarihini taşıyan diğer bir vasiyetname düzenlediğini farz edelim. Bu takdirde, 1 Mart tarihli vasiyetname gerçekte 15 Mart tarihliden daha yenidir. Böyle olunca da, 1 Mart 1960'da yapılmış olan vasiyetname, daha sonra yapılan (15 Mart) vasiyetnameden, daha yeni tarihi taşıdığı için MK 489'a göre (MK 542) kendisinden sonra yapılmış olan vasiyetnamenin geri alınmış sayılması için garip bir durum ortaya çıkar".* 404

b) Düzenleme tarihinin vasiyetnamede gösterilmesinin faydaları

Doktrin bu konuda şu faydaların bulunduğunu ileri sürmektedir: 405

a) Vasiyetçinin, vasiyetnameyi yaptığı zaman, vasiyetname yapma ehliyetine sahip olup olmadığının tespiti; 406

b) birden fazla vasiyetname varsa, bunlar arasındaki sıranın tespiti; 407

c) vasiyetçiyi acele tasarruflara karşı koruması; 408

d) vasiyetname ve vasiyetname projesinin birbirinden ayrılmasını temin etmesi. 409

---

[213] Bu tartışmalar için bkz., *Dural*, Vasiyetname, § 5, VI.
[214] *Oğuzman*, 122.
[215] BGE 56 II 248; 75 II 345.
[216] *Kocayusufpaşaoğlu*, § 14, III, 3, b.

410 Düzenleme tarihinin vasiyetnamede bulunması zorunluluğunun, doktrinin ileri sürdüğü bütün bu faydaları temin ettiğini söylemek, *fikrimce* pek mümkün değildir. Tarihin, vasiyetçinin ehliyetini tespitte faydası, her zaman değil, sadece ehliyetin tartışmalı olduğu hâllerde söz konusu olacaktır. Bunun dışında ehliyetin tespiti yönünden tarihi aramanın bir yararı yoktur. Aynı şekilde, vasiyetnameler arasında sıranın tespiti açısından da tarih, sadece birden fazla vasiyetname varsa önemli olacak,bir tek vasiyetnamenin bulunduğu hâllerde- ki durumu çoğunlukla böyledir-, sıranın tespiti amacıyla tarihi aramanın hiçbir anlamı olmayacaktır. Aksine, ehliyetin tartışmalı olmadığı ve birden fazla vasiyetnamenin bulunmadığı hâllerde, düzenleme tarihini geçerlik şartı olarak aramanın bir yararı değil, vasiyetnameden düş kırıklığına uğrayan mirasçıların eline iptal için bir silah vermek ve böylece, vasiyetçinin isteklerinin yerine getirilmemesine imkân tanımak gibi çok tehlikeli bir mahzuru vardır.

411 Düzenleme tarihinin vasiyetnamede bulunmasının, vasiyetçiyi düşünceye sevk etmek, onu acele işlerden korumak amacının bulunduğunu iddia etmek de bana göre mümkün değildir. Çünkü, tarihin vasiyetnameye yazılması için harcanacak zaman, vasiyetçiyi düşünmeye sevk edemeyecek kadar kısadır. Kaldı ki, vasiyetçi, vasiyetnamesini yaparken her tasarruf üzerinde yeteri kadar düşünür. Onun bir de tarihi yazarken düşünmesini beklemek, pek gerçek olmayan bir iddiadır.

412 Yukarıdaki açıklamalardan anlaşılacağı gibi, düzenleme tarihinin, ehliyetten kuşku duyulan hâller ve birden fazla vasiyetnamenin bulunması hâlinde, bunlar arasındaki sıranın tespiti dışında bir yararı yoktur. Bu son hâlde de *fikrimce*, sıranın başka yollarla tespitinin mümkün olduğu hâllerde, sırf tarihin yokluğu sebebiyle vasiyetnameyi geçersiz saymamak gerekir. Bunları göz önünde bulunduran BGB § 2247/II, düzenleme tarihinin (ve yerinin) vasiyetnamede bulunmasını aramakla beraber, 5. fıkrasında, vasiyetnamenin geçerliğinden kuşku duyulan hâllerde, düzenleme tarihinin başka yollarla tespit edilmesinin mümkün olması şartıyla, vasiyetnamede bulunmasının, vasiyetnameyi geçersiz yapmayacağı hükmünü getirmiştir. Aynı şekilde ABGB § 578'e göre, düzenleme tarihinin (ve yerinin) vasiyetnamede bulunması şart değilse de, ihtilafların bertaraf edilmesi için varlığı tavsiye edilmektedir.

413 Bu konuyu bitirmeden belirtelim ki, eski MK 485, düzenleme tarihinin yanında, düzenleme yerinin de bulunmasını geçerlik şartı olarak aramaktaydı. Ancak yeni MK 538 yerin gösterilmesi şartını doğru olarak kaldırmıştır.

c) Düzenleme tarihinin el yazısı ile olması şartı

414 MK 538'e göre, düzenleme tarihinin, bütün metin gibi, el yazısı ile olması şarttır. Ancak, yüzyılı basılı, on ve bir yılı el yazısı ile olan tarihi de geçerli kabul etmek gerekir. Tarihin tamamının basılı ya da başka bir kimse tarafından yazılması, el yazılı vasiyetnameyi iptal edilebilir hale getirir[217].

d) Düzenleme tarihinin vasiyetname bulunmamasının müeyyidesi[218]

415 MK 538'den açık olarak anlaşılacağı gibi, düzenleme tarihinin el yazılı vasiyetnamede bulunması geçerlik şartıdır. Aksi halde, el yazılı vasiyetname MK 557 b.4'e göre iptal edilebilir.

---

[217] HGK 14.10.1964, 1227/629 (ABD 1965, 706).

[218] Bu konuda etraflı bilgi için bkz., *Dural,* Vasiyetname, § 5,V.

Tartışmalı olan konu, el yazılı vasiyetnamenin düzenleme tarihinin doğ- 416
ru olmasının gerekip gerekmediğidir.Bu konuda ileri sürülen iki farklı görüşü özetleyelim[219].

Düzenleme tarihinin amaçlarından hareket eden yazarlar, bunun doğru 417
olması gerektiğini savunurlar. Aksi halde, el yazılı vasiyetname geçersiz (iptal edilebilir) olur.

Tam aksi yönde olan görüş,el yazılı vasiyetnamede düzenleme tarihinin 418
bulunmasının, şekil şartı olarak zorunlu olduğunu, fakat doğru olmasının gerekmediğini savunmaktadır. Bu görüşe nazaran, yanlışlığın, bir hatadan kaynaklanması ve kasden olması arasında bir fark yoktur. Her iki hâlde de yanlışlık tespit edilince, doğru olan düzenleme tarihinin ispatına, vasiyetname içi ve dışı her olguyla imkân vermek gerekir[220]. *Fikrimce*, kasden olmaması şartıyla (çünkü bu halde, el yazılı vasiyetname *animus testandinin* yokluğu sebebiyle geçersizi olur), yanlışlığın her türlü delille giderilip, doğru tarihin ispat edilebilmesi hâlinde, el yazılı vasiyetanameyi geçerli kabul etmek gerekir. Bu görüş,Türk Hukuku için ilk defa *Kocayusufpaşaoğlu*[221], tarafından savunulmuştur.

Federal Mahkeme, uzun süre, düzenleme tarihi (ve eski metne göre düzenleme 419
yerinin) yanlış olması hâlinde, doğru olanın ancak vasiyetname içi olgularla tespit edilebileceğini savunmuş[222], fakat bu tutumunun, sürekli olarak doktrinde eleştirilmesi üzerine, 1990 yılında görüş değiştirmiştir[223]. Karara konu olan olayda, 8 Mart 1986 günü ölen bir kimsenin el yazılı vasiyetnamesi 10 Mart 1986 tarihini taşıyordu ve doğru tarihin de vasiyetname içi olgularla tespit edilmesi mümkün değildi. Bu vasiyetnamenin, Federal Mahkemenin o zaman kadar olan görüşüne göre geçersiz olması gerekiyordu. Ne var ki, Federal Mahkeme, yukarıda açıklandığı gibi, doktrinin bu haksız uygulamaya karşı olan eleştirilerini göz önünde tutarak ve MK 485 (yeni 538, ZGB 505)'in sert uygulamasını yumuşatmak amacıyla, hataen olan yanlışlıkların, vasiyetnamenin iptaline sebep olabilmeleri için, sadece yanlış olmalarını yeterli görmemiş, ayrıca, davacının da dava açmakta bir menfaatinin bulunmasını aramıştır. Başka bir deyişle, davacı, a) birden fazla vasiyetname varsa, ya da b) vasiyetçinin,el yazılı vasiyetnameyi yaptığı anda, vasiyetname yapma ehliyetine sahip olduğu kuşkulu ise, dava açabilecektir. Ancak bu hâllerde Federal Mahkeme davacının bir menfaati olduğunu kabul etmektedir. Böyle bir halde, doğru tarihin ispatı davacıya verilmiştir. Buna karşılık, doğru tarihin bilinmesinde, yukarıdaki hâllerden biri olmadığı için bir zorunluluk yoksa, dava reddedilecektir[224].

---

[219] Etraflı bilgi için bkz., *Dural*, Vasiyetname, § 5, VI, 3.

[220] *Kocayusufpaşaoğlu*, § 14,b,bb, bbb; *Tekinay*, Poroy'a Armağan, I.

[221] § 14, dn.157.

[222] BGE 50 II 6; 54 II 357; 56 II 240; 64 II 409; 75 II 354.

[223] BGE 116 II 117.

[224] *Tekinay* (Poroy'a Armağan, I), Federal Mahkemenin bu sonucu, vasiyetnamede hiç düzenleme tarihi bulunmaması haline uygulamasını, buna karşılık tarihin eksik olması haline uygulamamasını, iki durum arasında hiçbir fark olmadığı gerekçesiyle doğru bulmamaktadır.

420 Son olarak belirtelim ki, düzenleme tarihinin, el yazılı vasiyetnamede, belirli bir yerde bulunmasına gerek yoktur. Bulunduğu yere göre, metin ve imza ile arasında bir bağın bulunduğunun tespiti yeterlidir. Bir başka deyişle, el yazılı vasiyetnamenin üç unsuru olan, metin, imza ve düzenleme tarihi arasında, belgede birliği gösteren bir bağın ve belgede devamlılığı gösteren bir yakınlığın bulunması yeterlidir. Aynı şekilde, tarih bir irade açıklaması olmadığı için, imzanın üstünde olması, imza tarafından örtülmesi aranmaz[225]. Bu sebeple, el yazısı ile vasiyetname ile bütünlüğünün tespiti şartıyla, vasiyetnamenin içine konduğu zarfın üzerinde de bulunabilir[226].

3. İmza[227]

a) Genel olarak

421 El yazılı vasiyetnamenin geçerlik şartlarından biri de MK 538'e göre, *vasiyetçi tarafından el yazısı ile imzalanmasıdır*. MK 538'in, imzanın vasiyetçinin el yazısı ile olmasını araması karşısında, BK 15/II'in öngördüğü , bir araç ile imza atılması imkânı burada uygulanmaz. Bunun gibi, BK 16'daki, imza atamayan kimseler ile ilgili hükümler de el yazılı vasiyetnameye uygulanmaz. Bunun gibi güvenli elektronik imza da olmaz (BK 14).

b) İmzanın, el yazılı vasiyetnamedeki fonksiyonları

422 a) İmza, vasiyetçinin kimliğini belirtir, yani, vasiyetçinin kim olduğunu gösterir.

423 b) İmza, vasiyetnameyi kapatır. İmza ile vasiyetçi, metindeki beyanın, kendi iradesi olduğunu kabul eder.

c) İmzanın atılış şekli

424 Kural olarak imza, kişinin öz ad ve soyadı ile atılacaksa da (Soyadı Kanunu, 2), bu şart değildir. İmzanın, vasiyetçinin kimliğini belirtmesi fonksiyonundan hareket eden baskın görüş, bu görevini yerine getirmesi şartıyla, her şekilde atılan imzayı kabul etmektedir. Örneğin, bir kimse, toplumda tanındığı lakabı ya da müstear adı ile imza atabilir, veya, özellikle mektup şeklinde yazılmış olan vasiyetnamelerde, *baban* ya da *eşin* gibi terimlerin kullanılmış olması hâlinde de imza şartı gerçekleşmiş kabul edilir[228]. Ancak, kişinin, sadece özadını yazması veya imza yerine baban gibi bir kelime kullanması hâlinde, bundan vasiyetçinin kimliğinin kesin olarak anlaşılması

---

[225] BGE 70 II 10.
[226] BGE 51 II 372; RGZ 74,428.
[227] Etraflı bilgi için bkz., *Dural*, Vasiyetname, § 6.
[228] BGE 57 II 16.

gerekir. Aksi halde imza, belirleme fonksiyonunu yerine getiremeyecek, dolayısıyla da vasiyetnameyi geçersiz kılacaktır.

d) İmzanın vasiyetnamedeki yeri

İmzanın, beyanın vasiyetçiden sâdır olduğunu, onun tarafından benim- 425
sendiğini göstermesi, kısaca vasiyetnameyi kapatması gerektiği için, bu fonksiyonunu yerine getirebilmesi yönünden, kural olarak, metnin bittiği yerde, yani vasiyetnamenin sonunda bulunması gerekir. Böylece, ortada, bir vasiyetname projesi değil de,gerçek bir vasiyetnamenin bulunduğu belirlenmiş olur[229]. Yukarıda da değinildiği gibi, düzenleme tarihi bir irade açıklaması olmadığı için, imza tarafından kapatılması gerekmez, yeter ki, tarihin, metin ve imza ile bağı saptanabilsin[230]. El yazılı vasiyetname birden fazla sayfaya yazılmışsa, sayfalar arasındaki iç bağlantı (sayfaların birbirine raptedilmesi ya da sayfalar arasında fikir silsilesinin bulunması gibi) varsa, sadece son sayfaya imza atılması yeterlidir.

Kural, yukarıda açıklandığı gibi, imzanın, el yazılı vasiyetnamenin en 426
altında bulunması olmakla beraber, vasiyetnamenin başka bir şekilde kapanmış olduğunun açık olarak anlaşılması hâlinde (örneğin, vasiyetçi, son satırın altını çizmiştir ya da sayfa en sonuna kadar kullanıldığı için, imza atacak yer kalmamıştır), imzanın metnin başka bir yerine (örneğin, sayfanın kenarına ya da en başına) atılmış olması da yeterlidir. Federal Mahkemeye göre, imza, vasiyetnamenin içine konulduğu zarfın üzerine atılmışsa, bu, ancak zarfın, vasiyetnamenin devamı olarak görünmesi hâlinde mümkündür[231].

IV. EL YAZILI VASİYETNAMENİN SAKLANMASI (TEVDİİ)

MK 538/II'ye göre, "*El yazılı vasiyetname, saklanmak üzere, açık veya* 427
kapalı olarak, notere, sulh hâkimine veya yetkili memura bırakılabilir". Metinden anlaşılacağı üzere, el yazılı vasiyetnamenin saklanmak üzere notere, sulh hâkimine ya da yetkili memura bırakılması zorunlu olmayıp, vasiyetçinin isteğine bırakılmıştır[232]. Bu bakımdan, yukarıda sayılan şekil

---

[229] *Oğuzman* (123/124), imzası olmayan bir metnin, vasiyetname projesi olduğunu belirttikten sonra, *"imzasız bir yazının, vasiyetname olduğunu iddia eden, bunu ispat ile mükelleftir"* demektedir. Doğrusu bu görüşe katılmak mümkün değildir. *Piotet* ise (203), imzası bulunan bir metnin, vasiyetname değil de, bir vasiyetname projesi olduğunu (yani animus testandinin yokluğunu) iddia edenin ispatla yükümlü olduğunu söylemektedir.

[230] BGE 51 II 371; 70 II 10.

[231] BGE 51 II 371; 70 II 10.

[232] 2. HD 26.2.1974, 1079/1158 (*Şener*, Vasiyet, madde 495, No.1); 2.HD 28.3.1978, 2387/2516 (YKD 1978, c. IV, 1281); ayrıca, 2.HD 6.4.1951, 465/461 (*Şener*, Vasiyet, madde 485, No. 2).

şartlarından farklı olarak, saklamak üzere bırakma, bir geçerlik şartı değildir, tevdi edilmeyen el yazısı ile vasiyetname, bütün şekil şartlarını içeriyorsa geçerlidir.

428 Geçerlik şartı olmayan, vasiyetçinin iradesine bırakılmış olan saklamak için tevdiin yararı, el yazılı vasiyetnameyi, kaybolma, üçüncü kişiler tarafından yok edilmesi ya da tahrif edilmesine karşı korumasıdır. Buna karşılık mahzuru, el yazılı vasiyetnamenin en önemli faydalarından biri olan, gerek tasarrufun yapıldığının gerek içeriğinin gizli kalmasını ortadan kaldırmasıdır.

V. EL YAZILI VASİYETNAMEDE, VASİYETÇİ TARAFINDAN SONRADAN YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER[233]

429 Vasiyetçi, vasiyetnamesinde her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, metnin çizilmesi ya da silinmesi şeklinde olabileceği gibi, yeni eklemeler biçiminde de olabilir. Bunların geçerli olması için, nasıl bir usûle uyulması gerektiği ikiye ayrılarak incelenmelidir.

a) Vasiyetname daha tamamlanmadan yapılan değişiklikler

430 El yazılı vasiyetnamede, daha tamamlanmadan yapılan her türlü değişiklik, vasiyetnamenin düzeltilmesi amacını güttüğü için, hiçbir ayrı şekil şartına bağlı olmadan, yani, yeniden imzalanması, düzenleme tarihinin gösterilmesine gerek olmadan geçerlidir. Diğer bir deyişle, el yazılı vasiyetname daha bitirilmemiş, olduğu için, ekler ve diğer düzeltmeler yönünden, ayrıca şekil şartlarının yerine getirilmesi aranmaz.

b) Vasiyetname tamamlandıktan sonra yapılan değişiklikler

431 Silme ve çizilmeler, el yazılı vasiyetname tamamlandıktan sonra yapılmışsa, bu, o tasarrufun, yok etme yoluyla geri alındığı anlamına gelir (MK 543/I)[234]. Bu halde, silinen ve çizilen yerler hüküm ifade etmezler, geri kalan kısım geçerliğini korur, meğer ki, geri kalan kısım, çizilen ya da silinen yerler olmadan bir şey ifade etmesin. Böyle bir hâlde, artık bir anlam taşımayan vasiyetnamenin tümü geçersiz olur.

432 Vasiyetnamenin tamamlanmasından sonra yapılan eklere gelince; katıldığım baskın görüş, bu halde eklerin yeni bir vasiyetname oldukları gerekçesiyle MK 358'deki bütün şekil şartlarına uyularak yapılmasını arar. Ancak bu ekler, yeni bir ölüme bağlı tasarruf değil de, daha önce yapılmış

---

[233] Etraflı bilgi için bkz., *Dural*, Vasiyetname, § 8.
[234] Bkz., aşağıda, § 14.

olanların bir açıklaması niteliğindeyseler, şekil şartlarına uyulmadan da geçerli olurlar.

§ 12. Sözlü vasiyetname

I. GENEL OLARAK

MK 539/541'de düzenlenmiş olan sözlü vasiyetname[235], resmî ve el yazılı vasiyetnameden farklı olarak, istisnaî bir ölüme bağlı tasarruf şeklidir. MK 539, ancak belirli hâllerin bulunması ve bu sebeple resmî ya da el yazılı vasiyetname yapma imkânının bulunmadığı hâllerde sözlü vasiyetnameye cevaz vermektedir. Gerçekten MK 539/I'e göre, *"Mirasbırakan; yakın ölüm tehlikesi, ulaşımın kesilmesi, hastalık, savaş gibi olağanüstü durumlar yüzünden resmî veya el yazılı vasiyetname yapamıyorsa, sözlü vasiyet yoluna başvurabilir"*. 433

Hükümden anlaşılacağı üzere, sözlü vasiyetnameye başvurabilmek için iki şartın gerçekleşmesi aranmaktadır: a) olağanüstü bir hâlin varlığı; b) bu olağanüstü hâl sebebiyle, diğer vasiyetname şekillerinden birine başvurma imkânının bulunmaması. Bu iki şartın aynı anda bulunması, sözlü vasiyetname yapabilmek için zorunludur. Olağanüstü hâl bulunmasına rağmen, resmî ya da el yazılı vasiyetname yapabilme imkânı varsa, sözlü vasiyetname yapılamaz. 434

Yargıtay, yakın ölüm tehlikesinin varlığı konusunda hayli titiz davranmaktadır. Örneğin, 2. Hukuk Dairesi, bir kararında, Beyoğlu'nda bir hastahanede yatan ve kalp krizi geçiren bir hastanın, saat sekizde bir vasiyetname yapmak istediğini açıklayıp, saat 9.30'da sözlü vasiyetname yapması ve 11'de ölmesi karşısında, yakın ölüm tehlikesini kabul etmemiştir[236]. Çünkü, Yüksek Mahkemeye göre, Beyoğlu gibi, noterin bol olduğu bir yerde, en geç saat 9'da bir noterin temin edilmesi mümkündür. Kriz anı ile ölüm anı arasında geçen süre,ölüm tehlikesinin yakın olmadığını göstermektedir. 435

Yine Yargıtay'a göre, *"Ölüme yol açan beyin kanaması hâlinin ani hissedilmesi bir an düşünülse bile, vasiyet yapıldığı zaman şehirde bulunan ve evinde telefon olan bir şahsın şehirdeki noteri çağırması mümkündür. Kaldı ki, vasiyete tanıklık eden kişiler o sırada mirasbırakanın ani ölüm tehlikesi hâlinde bulunmadığını da* 436

---

[235] *Ayiter/Kılıçoğlu* (§ 4,dn.25), sözlü vasiyetname terilinin doğru olmadığını ileri sürerler. Yazarlara göre, name yazılı anlamına gelir. Sözlü vasiyetnamede ise, yazılı vasfi bulunmadığı için, burada vasiyetname teriminin kullanılması yanlıştır. Oysa, hem sözlü vasiyet hem de sözlü vasiyetname terimlerini aynı anda kullanan, *İmre/Erman*'ın haklı olarak belirttikleri gibi (§ 15, I ve dn. 3; aynı, *Kocayusufpaşaoğlu*, § 14, dn.187), başlangıçta sözlü olan vasiyetname, aşağıda görüleceği gibi, daha sonra yazılı hale geldiğinden, sözlü vasiyetname terimini kullanmak yanlış olmaz. Bu sebeple, MK 539'un da, gerek kenar başlığında gerek metinde *sözlü vasiyet* terimini kullanması yerinde değildir.

[236] 2. HD 10.6.1963, 3426 (İKİD, 1964, 3204).

söylemişlerdir. Üstelik vasiyetin yapıldığı 12.9.1963 günü tatil günü de değildir... Öyle ise raporlara ve tanık sözlerine göre ölenin MK 479-485 (MK 532/538). maddelerinde belirtilen vasiyetname düzenlemesinin kabulü gerekirken red olunması isabetsizdir"[237].

437 Yine Yargıtay'a göre, koma hâlindeyken yapılan sözlü vasiyetnamenin geçerli olması için komanın ölüme kadar devam etmesi gerekir[238]. Nihayet, aynı hukuk dairesinin 1992 tarihli bir kararına göre, sözlü vasiyetname yapan kimsenin, vasiyetnameyi yaptıktan bir gün sonra ölmesi de yakın ölüm tehlikesi sayılmaz[239].

438 Yakın ölüm tehlikesinin, uzun süren bir hastalık sonucu ya da âniden ortaya çıkmasının bir önemi yoktur. Önemli olan, sözlü vasiyetnamenin yapıldığı anda bulunmasıdır[240]. Ölüm tehlikesinin yakın olup olmadığının tespitinde hem objektif hem de sübjektif ölçütler birlikte esas alınacaktır. Şöyle ki, yakın ölüm tehlikesinin varlığının tespitinde, ilgili kişilerce, vasiyetnamenin düzenlendiği anda bilinen olgulardan, yani sübjektif olgulardan hareket edilecek; ancak, sadece ilgililerin yakın ölüm tehlikesi değerlendirmeleri tek başına yeterli olmayacaktır. Onlarca bilinen olayları, hayat tecrübelerinin ışığı altında, dürüst ve dikkatli bir kişinin yapacağı değerlendirme ile yakın ölüm tehlikesinin varlığına kanaat getirecek olması da aranacaktır[241].

439 Ulaşımın kesilmesi, gerek vasiyetçinin gerek vasiyetnamenin hazırlanmasına katılacak kişilerin (örneğin resmî vasiyetname düzenleyecek olan resmî memurun), yolların herhangi bir sebeple kesilmesi sonucu, bir yerden bir yere gitme imkânlarının ortadan kalkmasıdır. Örneğin, bir dağ köyünde oturan ve okuma yazma bilmeyen bir kimse, kar yolu kapadığı için, kente inip resmî vasiyetname yapamıyorsa, ulaşımın kesilmesi sebebiyle sözlü vasiyetname yapabilir[242].

440 Hastalığa gelince, MK 539'u karşılayan, eski MK 486, *bulaşıcı hastalıktan* söz ederken, yeni metin sadece *hastalık* demektedir. *Fikrimce*, bu ifade biraz geniş olmuştur. Çünkü grip de bir hastalıktır. Kanunun bu ifadesi karşısında, gribe yakalanan bir kimse de, eğer şu ya da bu sebeple el yazılı ya da resmî vasiyetname yapamıyorsa sözlü vasiyetnameye başvurabilecektir ki, bu biraz garip olur.

441 MK 539'un gerekçesine bakıldığı zaman, neden bulaşıcı teriminin kullanılmadı-

---

[237] 2. HD 20.4.1965, 1275/2033 (*Şener*, Vasiyet madde 486, No.4).

[238] 2. HD 20.11.1986, 9662/ 10190 (YKD 1987, c. XIII, 999).

[239] 2.HD 29.2.1992,7372/8705 (*Şener*, Vasiyet, madde 486, No.1).

[240] HGK 3.2.1969, 1205/ 94 (*Şener*, Vasiyet, madde 487 No 1); ayrıca bkz., BGE 77 II 216; *Tuor*, Art. 506-508 N 6; *Escher*, Art. 506 N 5.

[241] BGE 77 II 210; *Escher*, Art. 506 N 6; *İmre/Erman*, § 15, I, 2, a; *Kocayusufpaşaoğlu*, § 14,1; *Oğuzman*, 126.

[242] *İmre/Erman*, (§ 15, 2.a.bb); *Oğuzman* (127) ve *Şener* (Vasiyet, § 2,II,3), bu halde, yakın olmasa bile, bir ölüm tehlikesinin bulunduğu kanaatindedirler. Bu görüş tartışılabilir.

ğı şöyle açıklanıyor[243]. *"Sözlü vasiyet için tek başına bu olağanüstü koşullar içinde bulunmanın, yeterli olmadığı, buna ilaveten vasiyetçinin diğer vasiyetlerden birine başvurma olanağına sahip bulunmaması arandığından, olağanüstü hâllere örnek olan hastalığın salgın bir hastalık olmasının şart olmadığı öngürülmüştür. Buna göre, bir trafik kazası sonunda hastahaneye kaldırılan bir kişi de, diğer vasiyetlerden birini yapma olanağına sahip değilse, sözlü vasiyetname yapacaktır".*

Kanunkoyucunun, trafik kazasını hastalık sayarak, sırf trafik kazasına uğramış kimselere sözlü vasiyetname yapma imkânını tanımak için (söz konusu kişiler, yakın ölüm tehlikesi varsa bundan yararlanıp sözlü vasiyetname yapabilirler) *bulaşıcı* terimini kaldırmış olması ilginçtir. 442

Savaş hâlinde de, sadece savaşın varlığı sözlü vasiyetname yapmak için yeterli olmayıp, bu sebeple resmî ya da el yazılı vasiyetname yapma imkânının da bulunmaması gerekir. 443

Kanunda sayılan bu hallerin tüketici olmadığı, örnek olarak gösterildikleri, MK 539'daki *gibi* teriminden anlaşılmaktadır. Bu bakımdan, maddede yazılı olanlardan başka bir sebeple de diğer vasiyetname şekillerinden birine başvurulamıyorsa, sözlü vasiyetname yapılabilir. 444

II. SÖZLÜ VASİYETNAMENİN ŞEKİL ŞARTLARI

Sözlü vasiyetnamenin düzenlenmesi iki safhada gerçekleşir. 445

a) Birinci safha

Bu safhada, olağanüstü bir durum içinde bulunan vasiyetçi, son arzularını iki tanığa açıklar ve onlara bu açıklamalarına uygun bir vasiyetname yazma ya da yazdırma görevi yükler (MK 539/II). Tanıklar, okur yazar olma hâli hariç, resmî vasiyetnamede tanıklık etmeleri için gerekli olan şartlara sahip olmalıdırlar (MK 539/III). Bildirimin iki tanığa aynı anda yapılması gerekir[244]. 446

Beyanın iki tanığa sözlü olarak yapılması zorunludur. 2. Hukuk Dairesinin bir kararına göre, vasiyetçinin başkasına yazdırdığı son arzularını tanıklara vermesi geçerli değildir[245]. 447

Tanıkların vasiyetçiyi görmeleri şart değildir. Kimliğini sesinden tespit edebiliyorlarsa, sadece onu duymaları yeterlidir[246]. 448

b) İkinci safha

Bu safhada yapılması gereken işlemleri tanıklar gerçekleştireceklerdir. 449

---

[243] Gerekçe, 484.
[244] BGE 104 II 68.
[245] 2.HD 29.12.1975, 9769/9774 (*Şener*, Vasiyet, madde 486, No. 3).
[246] *Tuor*, Art. 506-508, N 19; *Kocayusufpaşaoğlu*, § 14, IV,2.

Belirtmek gerekir ki, tanıklar, vasiyetçinin kendilerine yüklediği belgeleme görevini kabul etmek zorunda değildirler. Ancak kabul etmişlerse, bundan sonra açıklanacak hususları yerine getirmek zorundadırlar.

450 Tanıkların görevi kabul etmeleri hâlinde, vasiyetçi ile tanıklar arasında bir vekâlet ilişkisinin doğduğu kabul edilmektedir[247]. Bu ilişkinin doğması zımni (örtülü) de olabilir[248]. Görevi kabul eden tanıkların, görevlerini gereği gibi yerine getirmemeleri hâlinde sorumluluklarının ne olacağında fikir ayrılığı vardır. *Tuor*, tanıkların görevlerini kusurlu olarak yapmamaları ya da mahkemeye geç başvurmaları hâlinde, MK 543'deki, vasiyetnamenin başkaları tarafından kusurlu olarak yok edilmesine ilişkin hükümlerin örneksemeyle uygulanacağı görüşündedir[249]. *Escher* ve ona katılan yazarlar, MK 5 aracılığıyla Borçlar Kanununun, vekilin sorumluluğuna ilişkin hükümlerin (BK 390 vd) uygulanacağını savunurlar[250]. *Piotet* ise, tanıkların görevlerini yerine getirmemeleri hâlinde, sadece tazminat ödeyeceklerini ve ayrıca MK 578 b.4'e göre, mirastan yoksun olacaklarını söyler[251].

451 Fikrimce, MK 578 b.4'ün uygulanması pek mümkün değildir. Çünkü MK 578 b.4'ün uygulanabilmesi için, tanıkların yasal mirasçı ya da daha önceki bir ölüme bağlı tasarrufla mirasçı atanmış olmaları gerekir. Bu son halde ise, 544'e göre, yapılan sözlü vasiyetname ile, tanıkları atanmış mirasçı yapan daha önceki tasarrufun geri alındığı karine olduğu için MK 578 b.4'ün uygulanmasını gerektiren bir durum söz konusu olamaz, meğer ki, sözlü vasiyetnamenin, önceki vasiyetnameyi tamamladığı kuşkusuz ve açık olarak anlaşılsın[252].

452 Tanıklar kendilerine yüklenmiş olan görevi iki şekilde yerine getirebilirler (MK 540):

453 a) Tanıklardan biri vasiyetçinin kendilerine beyan ettiği son arzularını, beyanın yapıldığı yer ve tarihi de yazarak imzalar, diğer tanığa imzalatır ve her iki tanık birlikte vakit geçirmeden bu belgeyi mahkemeye verirler. Mahkemeye her iki tanığın birlikte gitmesi şarttır[253]. Tanıkların, metni bir üçüncü kişiye yazdırabilip yazdıramayacakları tartışmalıdır. MK 540'ın, açık olarak metni tanıklardan birinin yazacağını belirtmesi karşısında, bunun mümkün olmayacağını kabul etmek gerekir[254]. Aynı şekilde, tanıkların metni el yazısı ile yazmalarının gerekip gerekmediği de tartışmalıdır. Baskın görüş, tanıklardan biri tarafından yazılması şartıyla, el yazısı ile olma-

---

[247] *Piotet*, § 39, II; *Escher*, Art.507 N 10; *İmre/Erman*, § 15, II,b; *Oğuzman*, 127.

[248] BGE 44 II 348; Piotet, § 39, II,A; *İmre/Erman*, § 15, II,b; *Şener*, (Vasiyet, § 3, III)'in ilişkinin zımni olarak doğmasını, kanundan doğan vekâlet olarak yorumlaması doğru değildir.

[249] *Tuor*, Art. 506-508, N 20.

[250] *Escher*, Art. 506 N 10; *Oğuzman*, 127; *Şener*, Vasiyet, § 3, II.

[251] *Piotet*, § 39, I, A.

[252] Benzer bir görüş için bkz., *İmre/Erman*, § 15, dn. 14.

[253] 2.HD 11.1.1974 8050/175 (*Şener*, vasiyet, madde 487 No 1); 2.HD 18.2.1969,1205/94 (*Şener*, vasiyet, madde 487, No 2); 2.HD 12.2.1975, 8610/1772 (*Şener*, Vasiyet, madde 487, No 4).

[254] Bu görüş ve aksi görüşte olan yazarlar için bkz., *Kocayusufpaşaoğlu*, § 14, dn.201.

sının gerekmediği, örneğin bir daktilo ile yazılabileceği yönündedir[255]. *Tuor* ve ona katılan *Kocayusufpaşaoğlu* aksi görüştedirler[256]. Yazarlar, kanunun, sıkı şekil şartlarını koyarken güttüğü, vasiyetçinin son arzularının senede doğru geçirilip hâkime ulaştırılması amacından hareket etmektedirler. Üçüncü kişi tarafından yazılmış metin gibi, daktilo ile yazılmış olan bir metin de bu amacı gerçekleştiremez ve hâkim, kendisine tevdi edilen daktilo ile yazılmış metnin, tanıklar tarafından yazılıp yazılmadığını kontrol edemez. Bu durumda, ayrıca, tanıkların metni daktilo ile bir üçüncü kişiye yazdırıp, okumadan imzalamış olmaları tehlikesi de büyüktür.

Ancak, *Kocayusufpaşaoğlu*'na göre, tanıkların üçüncü kişiye yazdırdıkları ya da daktilo ile yazılı olan metni hâkime götürmeleri hâlinde, sözlü vasiyetname geçersiz olmayacaktır. Böyle bir durumda hâkim, aşağıda (b)'de açıklanacak olan yola başvurup, kendisine sunulan metni sözlü olarak tekrar ettirip zapta geçirerek vasiyetnameyi düzenleyebilir[257]. 454

MK 540'a göre, tanıklar belgeyi herhangi bir sulh ya da asliye mahkemesine tevdi edebilirler. Sözlü vasiyetnamenin tevdi edildiği mahkeme, vasiyetçinin son yerleşim yeri mahkemesi değilse nasıl hareket edileceği, Velayet, Vesayet ve Miras Tüzüğünün 37. maddesinin ikinci fıkrasında belirtilmiştir. Buna göre, kendisine sözlü vasiyetname tevdi edilen mahkeme, vasiyetnameyi vasiyetçinin son yerleşim yeri mahkemesine gönderir. 455

MK 540/I'in (ve Tüzük'ün) tevdiin muhakkak vasiyetçinin son yerleşim yeri mahkemesine yapılmasını aramamasının sebebinin, vasiyetnamenin vakit geçirmeden mahkemeye tevdi edilmesi hükmü ile yakından ilişkisi vardır. Çünkü, tanıklar, vasiyetçi, son yerleşim yerinden uzak bir yerde ölmüşse, kendilerine en yakın mahkemeye başvurup, hem kanunun aradığı vakit geçirmeksizin şartını gerçekleştirmiş hem de vasiyetçinin son arzularını doğru olarak (çünkü vasiyetçinin yerleşim yerine gidinceye kadar unutmaları ihtimali vardır) iletilmesini temin etmiş olurlar. Nitekim, 2. Hukuk Dairesi, kanunda, tevdi edilecek mahkemenin özel olarak belirtilmemiş olması ve vakit geçirmeden tevdiin öneminden hareketle, İsviçre'de sözlü vasiyetname yapan bir Türk'ün vasiyetnamesinin, İsviçre'de bir mahkemeye tevdi edilmesinin MHÖK 7'ye göre geçerli olacağını kabul etmiştir[258]. Tanıkların belgeyi noter ya da savcılığa vermeleri geçersizdir[259]. 456

Tanıklar, MK 540/II'ye göre, hazırladıkları belgeyi *vakit geçirmeksizin* hâkime tevdi etmek zorundadırlar. Yargıtay'a göre, kanunun vakit geçir- 457

---

[255] *Escher*, Art. 507 N 2-3; *Raschein*, 47, *Piotet*, § 39, II,B; *İmre/Erman*, § 15, II, 2, a; *Şener*, Vasiyet, § 5, III.

[256] *Tuor*, Art. 506-508 N 25; *Kocayusufpaşaoğlu*, § 14, II,2,b,aa.

[257] *Kocayusufpaşaoğlu*, § 14, II,2, b, aa.

[258] 2.HD 29.9.1992, 7372/8705 (*Şener*, Vasiyet, madde 486,No.1).

[259] 2.HD 12.2.1975, 8610/1372 (*Şener*, Vasiyet, madde 487, N 3).

meksizin tevdi etmeyi öngörmesinin sebebi, *"suiistimalleri önlemek, tanıkların mirasçılarla görüşmesine fırsat vermemek ve bu yolla vasiyetçinin son arzularının saptırılmasına engel olmak"*tır[260]. Vakit geçirmeksizin ibaresini, derhal olarak anlamak gerekir, yani süre, makul ve hayatın akışına uygun olmalıdır[261].

458 Bundan da anlaşılacağı gibi, tanıklar ancak haklı bir sebep varsa, sözlü vasiyetnameyi derhal (vakit geçirmeksizin)'i aşan bir süre içinde tevdi edebilirler. 2. Hukuk Dairesine göre[262], "şahitlerin gecikmesi, kendi ve yakınları için hayati önemde zarar verebilecek işleri ancak mazeret oluşturabilir". Belirtmek gerekir ki, Yargıtay süre konusunda çok titiz davranmaktadır. Örneğin, hâkimi bulamadıkları gerekçesiyle, ölümden üç gün sonra tanıkların hâkim önüne çıkmalarında, derhal tevdi şartı gerçekleşmediği gerekçesiyle, sözlü vasiyetname geçersiz kabul edilmiştir[263]. Yine bir kararında Yargıtay, tanıklardan birinin, ölümün ertesi günü vasiyetnameyi sulh mahkemesine tevdi etmesi, fakat tanıkların, ikisinin tevdiin ertesi günü birlikte hâkim önüne çıkmalarında da, süre şartının gerçekleşmediği sonucuna varmıştır[264].

459 Tanıkların geç tevdi ettikleri bir sözlü vasiyetnameyi bu eksikliğe rağmen mahkeme, kabul etmek zorundadır. Çünkü, geç tevdi şekle ilişkin bir sakatlıktır ve şekil eksikliği de vasiyetnameyi kesin hükümsüzlükle sakatlamayıp, MK 559'da öngörülen süreler içinde vasiyetnamenin iptal edilmesi gerekir, aksi halde süre sonunda vasiyetname geçerli hale dönüşür[265].

460 Tanıklar, yukarıda belirtilen şekilde, vasiyetçinin son arzularını belgeleyip, birlikte hâkim önüne çıkınca, MK 540 c.2'ye göre, a) vasiyetçinin başka türde bir vasiyetname yapmasını engelleyen bir olağanüstü hâl içinde kendilerine son arzularını açıkladığını ve b) onu, ölüme bağlı tasarrufta bulunmaya ehil gördüklerini içeren bir beyanda bulunurlar. Her ne kadar MK 540 c. 2, bu beyanın tutanağa geçirilip tanıklarca imzalanmasını aramamışsa da, böyle bir tutanağın düzenlenmesi yerinde olur[266].

461 Belirtmek gerekir ki, tanıklardan birinin okuma yazma bilmemesi (hatta sadece imzasını atabilecek durumda olması hâlinde dahi), bu yola başvurmak söz konusu olamayacaktır. Çünkü, böyle bir durumda, okuma yazma bilmeyen tanık, ne diğer tanığın yazdıklarını okuyup, bunların, vasiyetçinin son arzularına uygun olup olmadığını saptayabilecek, ne de imza atabilecektir (ya da sadece imza atmayı biliyorsa, metni anlamadan imzalayacaktır). Böyle olunca da, tanıklardan en az birinin okuma yazma bilmemesi hâlinde, başvurulacak tek yol, aşağıda (b)'de açıklanan olacaktır.

---

[260] Bu karar için bkz., *Şener*, Vasiyet, madde 487, No.4.

[261] 2.HD 29.9.19982, 7372/ 8705 (*Şener*, Vasiyet, madde 486 No.1); 2.HD 9.5. 1985,4279/ 4539 (YKD 1985, c.XI, 1293).

[262] 2.HD 9.5.1958, 4279/4539 (*Şener*, Vasiyet, madde 487, No.2).

[263] 2. HD 9.3.1978, 414/1839 (*Şener*, Vasiyetname, madde 487 No 3).

[264] 2. HD 9.3.1978, 414/ 839 (*Şener*, Vasiyet, madde 487, No. 3).

[265] *Tuor*, Art. 506-508, N 8; *Kocayusufpaşaoğlu*, § 14,2,b,aa; 2.HD 18.7.1988, 499/1842 (YKD 1989, c. XIV, 211; aksi görüş, *Oğuzman*, 129; krş., *İmre/Erman*, § 15, II,2,e).

[266] *Escher*, Art. 507 N 8; *Tuor*, Art. 506-508, N 25; *Kocayusufpaşaoğlu*, § 14, IV, 2, b; *Oğuzman*, 128; *Piotet*, § 39, II,B; *İmre/Erman*, § 15, II, b.

Tanıklar için okuma yazma bilme şartının neden aranmadığı Gerekçe'de şöyle açıklanmıştır: *"Çünkü ülkemizde okur yazar insan sayısı ve özellikle sözlü vasiyetin olağanüstü koşullarda yapılabilen vasiyet olduğu göz önünde tutularak bir de tanıkların okur yazar olması koşulu arandığında bu vasiyetin hemen hemen hiçbir zaman yapılamaması sonucu doğmaktadır. Bunun önlenmesi ve vasiyete işlerlik kazandırabilmek amacıyla bu yönde bir değişiklik yapılmıştır. Öte yandan tanıkların okur yazar olması önemli görülmemiştir. Zira tanıklar vasiyetçinin son arzularını her zaman mahkemeye ulaştırmakla yükümlü bulunmaktadırlar. Bu durumda okur yazar olmaları çok önemli bir etki göstermemektedir"*[267]. 462

b) Tanıkların yararlanabilecekleri ikinci imkân, yazılı bir metni mahkemeye sunmak yerine, birlikte vakit geçirmeksizin mahkemeye başvurup, vasiyetçinin kendilerine söylediği son arzularını hâkime aktarmaktır. Yani burada tanıklar (a)'dan farklı olarak, hâkime kendi düzenledikleri belgeyi sunmayıp, onun önünde sözlü beyanda bulunurlar. Bunun üzerine hâkim önünde bir tutanak düzenlenir ve bu tutanak MK 540/II'ye göre tanıklar tarafından imzalanır. Tanıklar ayrıca, her ne kadar MK 540/II'de belirtilmemişse de[268] (vasiyetçinin son arzularını yazılı olarak vermelerinde olduğu gibi), vasiyetçinin, başka türde vasiyetname yapmasını engelleyen bir olağanüstü hâlin varlığını ve vasiyetçiyi ölüme bağlı tasarruf yapmaya ehil gördüklerini beyan ederler. 463

c) Sözlü Vasiyetnameyi yapan kişi askerlik hizmetinde bulunuyorsa, teğmen ya da daha yüksek rütbeli bir subay, ülke dışında seyreden bir ulaşım aracında bulunuyorsa, aracın sorumlu yöneticisi tedavi için sağlık kurumlarında bulunuyorsa o kurumun en yetkili yöneticisi hâkimin yerine geçer, yani sözlü vasiyetname bu kişilere tevdi edilir. Fikrimce,teğmen ya da daha yüksek rütbeli bir subaya tevdiin zorunluluktan kaynaklandığı kabul edilebilirse de,diğer tevdie yetkili kılınmış kişilerin, bir beyanı tutanağa geçirip, onaylama yetkileri olmadığı için, bu düzenleme yerinde değildir. 464

Aracın sorumlu yöneticisi ve sağlık kurumunun yöneticisinin hâkimin yerini alacağına ilişkin hüküm, eski MK 487'de yoktu. Bunların neden hâkimin yerini alabilecekleri MK 540'ın gerekçesinde şöyle açıklanmaktadır[269]. *"Maddenin üçüncü fıkrasına eklenen bir hükümle ülke sınırları dışında ulaşım araçlarında seyreden kişilerin sözlü vasiyetlerin ilgili ulaşım aracının sorumlu yöneticisinin; sağlık kurumlarında tedavi edilmekte olan kişilerin sözlü vasiyetlerinde ise sağlık kurumunun en yetkili yöneticisinin hâkim yerine geçeceği öngörülmüştür. Ülke sınırları içinde seyahat edenlerin olağanüstü koşullar içinde bulunması hâlinde yapacağı sözlü vasiyetin Türk mahkemelerine ulaştırılmasında güçlükler yaşanmadığı hâlde, yurt dışında seyahat esnasında yapılan sözlü vasiyetlerde çoğu kez tanıkların bu vasiyeti mahkemeye götürüp teslim etmekte gayret göstermeyeceği, bu yolla kişinin son arzularını yaşatmanın mümkün olmayacağı düşünülmüştür. Aynı şekilde sağlık kurumla-* 465

[267] Gerekçe, 484.

[268] Eski MK 487'de, bu hal için de sözü edilen şerhlerin verileceği açık olarak öngörülmüştü.

[269] Gerekçe, 485.

rında tedavi edilmekte olan kişiler için de kolaylık sağlanmak üzere sözlü vasiyetin tevdi edileceği makam konusunda yeni bir hüküm getirme ihtiyacı doğmuştur".

466 Doğrusu bu gerekçelerin doyurucu olduğunu söylemek mümkün değildir. Sağlık kurumu yöneticisine tevdiiden başlayacak olursak; her sağlık kurumunun bulunduğu yerde ya da yakınında, en az bir mahkemesinin olacağı düşünülecek olursa, sözlü vasiyetnamenin kurum yöneticisine tevdiini öngörmenin hiçbir haklı sebebi olamaz. Herhangi bir sebeple (örneğin köy yolu kardan kapalı olduğu için), mahkemeye derhal tevdii imkânı yoksa, mesele vakit geçirmeden kavramından hareketle (yani, bunun imkân hasıl olur olmaz derhal şeklinde anlaşılmasıyla) çözülebilir, ki, zaten vakit geçirmeksizin böyle anlaşılmaktadır.

467 Yurt dışında seyir eden araç yöneticisine tevdiin de, doğrusu kabul edilebilir yanı yoktur. Çünkü, aracın günlerce hatta bazen haftalarca yurt dışında kalacağı düşünülecek olursa, sözlü vasiyetnamenin tanıklarda kalması ile, araç yöneticisinin de kalmış olması arasında ne fark vardır? Kaldı ki, yukarıda sözü edilen Yargıtay kararına göre, sözlü vasiyetnameyi bulunulan yabancı ülkenin mahkemesine tevdi etmek imkânı da vardır[269a]. Burada da mesele yorumla çözülebilir. Bütün bunların dışında, araç ya da sağlık kurumu yöneticisi, kendilerine bir sözlü vasiyetnamenin tevdii hâlinde nasıl davranacaklar, bunu kime teslim edeceklerdir? Eğer onlar da bunu mahkemeye teslim edeceklerse, bu kişilerin araya girmelerinin hiçbir anlamı yoktur. Kısaca bu düzenleme olağanüstü mantıksız ve güvensizdir. Çünkü, sözlü vasiyetnamenin, tahrif edilmesine fevkalâde müsaittir.

III. SÖZLÜ VASİYETNAMENİN HÜKÜMDEN DÜŞMESİ

468 Sözlü vasiyetname, olağanüstü bir durumun varlığı hâlinde, istisnaen düzenlenen bir vasiyetname olduğu için, MK 541 şu hükmü getirmiştir: *"Mirasbırakan için sonradan diğer şekillerde vasiyetname yapma olanağı doğarsa,bu tarihin üzerinden bir ay geçince sözlü vasiyetname hükümden düşer".*

469 Hükümden de anlaşılacağı üzere, sözlü vasiyetname, olağan vasiyetname yapma imkânı vermeyen durumun ortadan kalkması ve olağan vasiyetname yapma imkânı doğduktan itibaren bir ay geçerliğini korur ve bu süre sonunda vasiyetçi sözlü vasiyetnamesini geri almasa bile, kanun gereği hükümden düşer. Şu halde, sözlü vasiyetnamenin hüküm ifade etmesi, vasiyetçinin bir aylık süre içinde ölmesi ya da ölümüne kadar sürekli ayırt etme gücünü kaybetmiş olmasına bağlıdır.

470 MK 541, sözlü vasiyetnamenin geçerliğini, yukarıda da açıklandığı gibi, olağan vasiyetname yapma imkânının doğmasından itibaren bir aylık süre ile sınırlamış, olağanüstü hâlin ölüme kadar devam etmesini aramamıştır. Bu bakımdan 2. Hukuk Dairesinin, bazı kararlarında, olağanüstü hâlin ve bu sebeple olağan vasiyetname yapma imkânsızlığının ölüm anına kadar devam etmesini araması doğru değildir. Örneğin, bu Dairenin, 20.11.1986 tarih ve 9962/10198 sayılı kararında, *"...sözlü vasiyet düzenlenmesini gerektiren sağlık şartlarının ölüme kadar geçen beş gün içinde de devam ettiğinin tespiti kesinlikle zorunludur"*[270] denilmesi, olağanüstü hâlin ölüme kadar devam etmesinin aranacağı anlamına geldiği için yerinde değildir.

[269a] Bkz. yukarıda dn. 258.

[270] Bu karar için bkz., *Şener*, Vasiyet, madde 486, No.25.

Olağan vasiyetname yapma imkânı doğduktan sonra, vasiyetçi bir aylık süre dolmadan ölecek olursa, sözlü vasiyetname kanun gereği hükümden düşmez, fakat MK 557'deki iptal sebeplerinden biri varsa, iptal ettirilebilir. Sırası gelmişken belirtelim ki, MK 539/III, okuma yazma dışında, tanıklık etme yönünden MK 536'daki yasaklar sözlü vasiyetname için de geçerli olacaktır. Örneğin, tanıklardan biri, vasiyetçinin eşi ise, sözlü vasiyetname şekil noksanı sebebiyle sakat olacaktır. Ya da vasiyetçi, tanıklardan biri ya da onun eşi lehine bir ölüme bağlı tasarrufta bulunmuşsa, bu tasarruf geçersiz olacak, fakat sözlü vasiyetnamenin geri kalan kısmı geçerliğini koruyacaktır (MK 536/II, MK 558/III). 471

§ 13. Miras Sözleşmeleri[271]

I. TANIM VE GENEL BİLGİLER

Yukarıda da açıklandığı gibi[272], şeklî anlamdaki ölüme bağlı tasarrufların ikinci türü miras sözleşmeleridir. Şekil yönünden MK 545'de düzenlenmiş olan miras sözleşmelerini şu şekilde tanımlayabiliriz: *miras sözleşmesi, mirasbırakan ile karşı taraf arasında yapılan öyle bir iki taraflı ölüme bağlı tasarruftur ki, bununla taraflardan en az biri,yâni mirasbırakan, bağlayıcı olarak ya kendi terekesi üzerinde maddî anlamda bir ölüme bağlı tasarrufta bulunur ya da karşı tarafın kendi terekesi üzerinde ileride doğacak olan mirasçılık hakkından vazgeçmesini (feragat etmesini) sağlar.* 472

Her ikisi de ölüme bağlı tasarruf oldukları için miras sözleşmeleri ile vasiyetnameler arasında benzerlik vardır. Ne var ki, iki ölüme bağlı tasarrufun nitelikleri farklı olduğu için (vasiyetname bir taraflı, miras sözleşmesi iki taraflı ölüme bağlı tasarruftur), aralarında farklar da bulunmaktadır. 473

1. Miras sözleşmesi ile vasiyetname arasındaki benzerlik

Her ikisinin de yapılması kişiye sıkı sıkıya bağlıdır. Bu bakımdan her ikisinde de ne rızaî ne de yasal temsil yürür. 474

2. Miras sözleşmesi ile vasiyetname arasındaki farklar

a) İlk fark ehliyet yönünden kendini gösterir. Vasiyetname yapabilmek için 15 yaşını doldurmak ve ayırt etme gücüne sahip olmak yeterlidir (MK 502). Yani, ayırt etme gücüne sahip olmak şartıyla, velayet altındaki kişiler ve kısıtlılar da vasiyetname yapabilir. Oysa, miras sözleşmesi yapabilmek için, kişinin tam fiil ehliyetine sahip olması gerekir (MK 503). 475

---

[271] Bu paragraftaki açıklamalar, *Dural*, Miras Sözleşmeleri adlı kitaptan aktarıldığı için, zorunlu olmadıkça başka kitaplara atıf yapılmayacaktır.

[272] Bkz., § 9.

476 b) Vasiyetnamenin, el yazılı, resmî ve olağanüstü durumlarda sözlü olarak yapılması mümkünken; miras sözleşmesi ancak resmî şekilde yapılabilir (MK 545).

477 c) Vasiyetname, yöneltilmesi gerekmeyen bir taraflı irade açıklamasıyla yapılır. Oysa miras sözleşmesi karşılıklı yöneltilmesi gerekli iki irade açıklamasıyla yapılan bir hukuki işlem, yani sözleşmedir.

478 d) Vasiyetnamenin ölüm anına kadar her zaman serbestçe geri alınması mümkündür. Oysa bir sözleşme olması sonucu, miras sözleşmesinden kural olarak bir taraflı olarak dönülmesi mümkün değildir.

II. MİRAS SÖZLEŞMELERİNİN TÜRLERİ

1. Olumlu miras sözleşmeleri- olumsuz (mirastan feragat) miras sözleşmeleri

479 Eski Medenî Kanunda, *olumlu miras sözleşmesi* terimi yoktu. Buna karşılık olumsuz miras sözleşmesi karşılığı *mirastan feragat (sözleşmesi)* kullanılıyordu. Olumsuz miras sözleşmesi karşılığı özel terim kullanılması karşısında, doktrin ve uygulamada miras sözleşmesi *olumlu* miras sözleşmesi karşılığı olduğu kabul ediliyor ve kullanılıyordu. Yeni Medenî Kanun ise, olumsuz miras sözleşmesi karşılığı mirastan feragati kullanmaya devam etmiş; fakat miras sözleşmesi yerine *olumlu miras sözleşmesi* terimini bizce gereksiz yere tercih etmiştir. Bu bakımdan burada, eskiden beri yerleşmiş olan doktrin ve uygulamaya bağlı kalınarak, *olumlu miras sözleşmesi* yerine sadece *miras sözleşmesi* terimi kullanılacaktır.

480 İsviçre Medenî Kanununda da olumlu miras sözleşmesi karşılığı sadece miras sözleşmesi (Erbvertrag) kelimesi kullanılmaktadır.Olumsuz miras sözleşmesi karşılığı olarak biz de olduğu gibi, mirastan feragat (sözleşmesi) (Erbverzichtsvertrag) kullanılmaktadır.

a) Miras sözleşmesi

481 Bununla, mirasbırakan, karşı taraf ya da bir üçüncü kişi yararına bağlayıcı bir ölüme bağlı tasarrufta bulunur. MK 527 göz önüne alınacak olursa, miras sözleşmeleri içerik yönünden üçe ayrılırlar.

482 *aa) Mirasçı atama sözleşmesi:* Burada mirasbırakan, karşı tarafı terekesinin tamamı ya da kesirli bir bölümü için mirasçı atamaktadır.

483 *bb) Vasiyet sözleşmesi:* Bu sözleşmeyle mirasbırakan, karşı taraf lehine, terekesinde bulunan belirli bir mal ya da malvarlığı değeri için kazandırmada bulunmakta, yâni onu vasiyet alacaklısı (musaleh) yapmaktadır.

cc) Üçüncü kişi yararına miras sözleşmesi: Bu halde, mirasbırakan, karşı tarafla yaptığı miras sözleşmesiyle, üçüncü bir kişiyi mirasçı atamakta ya da vasiyet alacaklısı yapmaktadır. 484

b) Mirastan feragat sözleşmesi

Mirastan feragat sözleşmesi ile muhtemel ve müstakbel bir mirasçı, kendisi lehine mirasbırakanın terekesi üzerinde ileride doğacak haklardan, bir ivaz karşılığı ya da ivazsız olarak vazgeçmektedir (MK 528)[273]. 485

2. Bir taraflı ve iki taraflı miras sözleşmeleri

Bu ayırım, miras sözleşmesi ile her iki tarafın mı yoksa taraflardan sadece birinin mi terekesi üzerinde bağlayıcı ölüme bağlı tasarrufta bulunduğuna göre yapılmaktadır[274]. 486

a) Bir taraflı miras sözleşmesi

Taraflardan sadece birisi terekesi üzerinde tasarrufta bulunmaktaysa, miras sözleşmesi bir taraflıdır. Bu tür miras sözleşmelerinde karşı taraf ya sadece mirasbırakanın irade açıklamasını kabul etmektedir ya da sağlararası borç altına girmektedir. Bu son halde, aşağıda görüleceği gibi, miras sözleşmesi ivazlı niteliğini alır, yoksa yapılan işlem iki taraflı miras sözleşmesi olmaz. 487

b) İki taraflı miras sözleşmesi

Her iki tarafın da terekesi üzerinde bağlayıcı ölüme bağlı tasarrufta bulundukları miras sözleşmesi, iki taraflı miras sözleşmesidir. 488

Belirtmek gerekir ki, miras sözleşmesinin iki taraflı olması için her iki tarafın da yaptığı tasarrufun bağlayıcı olması gerekir. Bu sebeple, taraflardan birinin yaptığı tasarruf, miras sözleşmesinin bağlayıcı olmayan içeriğini oluşturmaktaysa, miras sözleşmesi yine bir taraflı olur. Örneğin, mirasbırakanın A'yı terekesi için mirasçı atadığı miras sözleşmesinde, A da kendi terekesi için vasiyeti yerine getirme (tenfiz) memuru atarsa, A'nın tasarrufu bağlayıcı olmayan bir ölüme bağlı tasarruf olduğu için, miras sözleşmesi yine bir taraflı sayılır. 489

İki taraflı miras sözleşmesinden söz edebilmek için tarafların muhakkak birbirleri lehine ölüme bağlı tasarrufta bulunmaları gerekmez. Bağlayıcı olması şartıyla, tarafların üçüncü kişi lehine de miras sözleşmesi yapmaları mümkündür. 490

3. İvazlı ve ivazsız (karşılıklı ve karşılıksız)[275] miras sözleşmeleri

Bu ayırım, miras sözleşmesi ile ölüme bağlı tasarrufta bulunmayan ta- 491

---

[273] Mirastan feragat sözleşmesiyle ilgili olarak bkz., aşağıda § 15, III,8.

[274] *Oğuzman*, (133), bir yönlü ve iki yönlü miras sözleşmesi terimini kullanmaktadır.

[275] Yeni metinde kullanılan (örneğin MK 528), sinallagmatik sözleşme ile karıştırılmaya müsait olduğu için, biz yine ivazlı ve ivazsız terimini kullanmayı tercih edeceğiz.

rafın, sağlararası bir ivaz borcu altına girip girmediğine göre yapılmaktadır[276].

a) İvazsız miras sözleşmesi

492 Burada, taraflardan biri mirasbırakan sıfatıyla ölüme bağlı tasarrufta bulunurken,karşı taraf sadece mirasbırakanın iradesini kabul etmekte, kendisi herhangi bir sağlararası borç altına girmemektedir.

b) İvazlı miras sözleşmesi

493 Mirasbırakanın yaptığı ölüme bağlı tasarruf karşılığında karşı taraf sağlararası borç altına girmektedir. Örneğin, mirasçı atanan kimse, bunun karşılığında mirasbırakana sağlığında 10 bin TL vermektedir. Eğer yapılan ivazlı bir mirastan feragat sözleşmesiyse, sağlararası ivaz borcu altına giren mirasbırakandır.

III. MİRAS SÖZLEŞMESİ YAPMA EHLİYETİ[277]

494 Burada durumu, miras sözleşmesi ile ölüme bağlı tasarrufta bulunan kimse ile ölüme bağlı tasarrufta bulunmayan karşı taraf yönünden ayrı ayrı incelemek gerekir.

1. Ölüme bağlı tasarrufta bulunan tarafın ehliyeti

495 MK 503'e göre *"Miras sözleşmesi yapabilmek için ayırt etme gücüne sahip ve ergin olmak, kısıtlı olmamak gerekir"*. Bu hükme göre, sadece tam ehliyetli olanlar, ölüme bağlı tasarrufta bulunan sıfatıyla miras sözleşmesi yapabilirler.

2. Ölüme bağlı tasarrufta bulunmayan tarafın ehliyeti

496 MK 503, sadece miras sözleşmesiyle ölüme bağlı tasarrufta bulunan tarafın ehliyetini düzenler. Bu hüküm, miras sözleşmesinin iki taraflı olması hâlinde, her iki tarafa da uygulanır. Buna karşılık, miras sözleşmesi ile taraflardan sadece biri ölüme bağlı tasarrufta bulunuyorsa (bir taraflı miras sözleşmesi), diğer taraf genel ehliyet kurallarına tabidir. Bunun yanında, ölüme bağlı tasarrufta bulunmayan taraf için bir kişiye sıkı sıkıya bağlı hak söz konusu olmadığı için, onun yönünden hem yasal hem de rızai temsil yürür. Yani karşı taraf ehliyetli ise, isterse miras sözleşmesini kendisi yapar, isterse bir temsilciden yararlanabilir.

---

[276] *Kocayusufpaşaoğlu*, (§ 11,II,2) ve *Şener*, Vasiyet, § 2,I,1), ivazlı ve ivazsız miras sözleşmelerini, bir ve iki taraflı miras sözleşmeleri arasında incelemektedirler.

[277] Bu konuda ayrıca bkz., yukarıda, § 8,III.

Miras sözleşmesinin karşı tarafı tam ehliyetsizse, sözleşmeyi, genel ku- 497
rallara göre, onun yasal temsilcisi yapar. Ancak tam ehliyetsiz vesayet altındaysa MK 463 b.5'e göre sulh ve asliye mahkemelerinin (vesayet makamı ve denetim makamının) izini gerekir.

Miras sözleşmesinin karşı tarafı olan kişi sınırlı ehliyetsizse ve sağlara- 498
rası bir ivaz borcu altına girmiyorsa, bir karşılıksız kazanma söz konusu olduğu için, MK 16/II'ye göre, yasal temsilcinin işleme katılmasına gerek yoktur, sınırlı ehliyetsiz bunu tek başına yapabilir. Yapılan kazandırmanın yükümlü olması bu sonucu değiştirmez. Çünkü, sınırlı ehliyetsiz, miras sözleşmesi yapıldığı anda değil, mirasın geçmesi (intikali) ile borç altına girer. Bu kural, sınırlı ehliyetsizin hem mirasçı atanması hem de lehine vasiyet yapılması hâlinde geçerlidir. Gerçi, mirasçı atanan sınırlı ehliyetsiz, küllî halef sıfatıyla borçlardan da sorumlu olacaktır ne var ki, o, miras sözleşmesi yapıldığı anda değil, mirasın geçmesi ile borç altına gireceğinden bu sınırlı ehliyetsiz için bir tehlike yaratmaz. Çünkü, yasal temsilci, mirasın intikalinden sonra, onun adına mirası reddederek tehlikeyi bertaraf edebilir.

İvazlı miras sözleşmelerinde, sınırlı ehliyetsiz, sağlararası borç altına 499
girdiği ve bu sebeple de artık bir karşılıksız kazanma söz konusu olmadığı için, MK 16/I ve 451'e göre miras sözleşmesini ancak yasal temsilcisinin rızası ile yapabilir ya da yasal temsilci onun adına yapar. Sınırlı ehliyetsiz vesayet altındaysa, vasinin rızası yanında, sulh ve asliye mahkemelerinin de izni gerekir (MK 463 b.5).

Yasal temsilci sınırlı ehliyetsizle bir miras sözleşmesi yapacaksa, o za- 500
man sınırlı ehliyetsize bir kayyım atanması gerekir (MK 426 b.2). Eğer sınırlı ehliyetsiz velâyet altındaysa ve sağlararası borç altına giriyorsa, kayyımın işleme katılması yanında miras sözleşmesinin hâkim tarafından onaylanması gerekir (MK 345). Bu hükmün, velâyet altındaki kimsenin, mirasbırakan sıfatıyla ana ya da babası lehine ölüme bağlı tasarrufta bulunması hâlinde de örneksemeyle uygulanması yerinde olur.

Ehliyete ilişkin bu kurallar mirastan feragat sözleşmesi için de geçerli- 501
dir. Başka bir deyişle, feragat ettiren, ölüme bağlı tasarrufta bulunan taraf sayıldığı için, o, MK 503'deki kurallara tâbi olurken[278]; feragat eden genel ehliyet kurallarına tâbidir.

Durum böyle olmakla beraber, Şener, mirastan feragat sözleşmesi için, tarafların 502
ehliyeti yönünden aynen şöyle demektedir: *"Mirastan feragat için miras mukavelesi yapılması hâlinde iki tarafın da reşit olması zorunludur (MK eski 450). Eğer vasiyet yolu seçilmiş, yani tek taraflı bir feragat söz konusu olursa mümeyyiz olup, 15 yaşını*

[278] Aksi görüş, *Antalya*, 150/151. Ancak, miras sözleşmesinde ehliyeti düzenleyen eski MK 450 değiştiği için, bu görüşün bu gün savunulması mümkün değildir.

doldurmak yeterlidir (MK eski 449). Hatta (eski MK'ya göre) 14 yaşını bitirmiş olup hakimin izni ile evlenmiş olan kişi de vasiyet yapabilir".

503 Bundan da anlaşılacağı üzere, yazar, mirastan feragatin muhakkak bir miras sözleşmesi ile yapılması gerekmediği, bir vasiyet(name) ile de feragatin mümkün olacağını söylemektedir. Bir başka deyişle yazar, mirastan feragatin iki türlü olabileceğini, miras sözleşmesi ile yapılması hâlinde, her iki tarafın da tam ehliyetli olması gerektiğini (ki yazar, buna iki taraflı mirastan feragat demektedir); buna karşılık bir vasiyetname ile yapılması hâlinde, vasiyetname yapma ehliyetinin bulunmasını yeterli görmektedir (buna da yazar, bir taraflı mirastan feragat demektedir).

504 Doğrusu yazarın bu görüşlerine katılmaya imkân yoktur. Çünkü mirastan feragatin vasiyetname ile yapılması bizim hukukumuzda olduğu gibi, İsviçre (ve Alman) hukukunda söz konusu olamaz. Çünkü, mirastan feragatin bir sözleşme ile olabileceği, önce, bunun miras sözleşmesi ile birlikte düzenlenmiş olmasından açık olarak anlaşılmaktadır. İkincisi, mirastan feragatin amacından hareket edince de bunun, bir vasiyetname ile yapılmasının mümkün olmadığı açık olarak anlaşılır. Çünkü, mirastan feragatin amacı, kaba olarak, müstakbel ve muntazar (saklı paylı) mirasçının, kendi rızasıyla, mirasbırakana, tasarruf nisabının dışına çıkabilecek şekilde tasarrufta bulunmasını temindir. Böylece mirasbırakan, feragat edenin saklı payı üzerinde istediği gibi, ya da feragat edenin, kişi yönünden sınırladığı biçimde tasarruf etme imkânını elde eder ve bir ölçüde de olsa, ölümünden sonra tenkis davası açılmasını engellemiş olur. Bunun gerçekleşebilmesi için ise, özellikle mirasbırakanın bundan haberinin olması gerekir. Daha iyi bir deyişle, mirasbırakan feragatten haberdar olmalıdır ki, feragat edilen miktar üzerinde tasarrufta bulunabilsin. Durum böyle olunca da, A'nın bir vasiyetname yaparak, M'nin mirasından feragat ettiğini belirtmesinin bir anlamı yoktur. Kaldı ki, feragati vasiyetnamede B lehine yapsa, bunun M'yi bağlaması mümkün müdür? Buna olumlu cevap verilemez. Çünkü bir kimse, vasiyetname ile ancak kendi terekesin üzerinde tasarrufta bulunabilir. Böyle olunca A'nın yaptığı tasarruf vasiyetname olarak dahi kabul edilemez.

505 Bir de meseleye tersinden bakalım. Şöyle ki, M, vasiyetnamesinde A'nın, onun mirasından feragat ettiğini yazsa, bu A'yı bağlar mı? Bu konuda tartışabilmek için, önce, bir kimsenin kendi hakkından, başkasının iradesi ile nasıl feragat edebileceğinin cevaplandırılması gerekir. Buna olumlu cevap verilemeyeceğine göre, *Şener*'in görüşü tartışmaya dahi açılamaz.

506 Bütün bunlar bir yana, MK 528'in feragat sözleşmesinden söz etmesi dahi, feragatin vasiyetname ile yapılamayacağının en açık kanıtıdır.

3. Taraflardan birinin ehliyetsizliğinin sonuçları

a) Ölüme bağlı tasarrufta bulunmayan tarafın ehliyetsizliği

507 Miras sözleşmesinde, nasıl ölüme bağlı tasarrufta bulunmayan tarafın fiil ehliyetine genel kurallar uygulanıyorsa, fiil ehliyetsizliğinin sonuçları da genel kurallara tabidir.Böyle olunca da, ölüme bağlı tasarrufta bulunmayan tarafın tam ehliyetsiz olduğu hâllerde miras sözleşmesi MK 15'e göre kesin hükümsüzlükle sakat olacaktır. Ölüme bağlı tasarrufta bulunmayan taraf sınırlı ehliyetsizse ve yasal temsilcisinin iznini almadan ivazlı bir miras sözleşmesi yapmışsa, işlem askıda hükümsüz olur. Bu halde mirasbırakan MK 451/II'ye göre, sınırlı ehliyetsizin yasal temsilcisine beyanda bu-

lunması için bir süre verir ya da mahkemeye başvurarak bir süre tayin ettirir. Bu süre içinde yasal temsilci icazet verirse, miras sözleşmesi yapıldığı andan itibaren geçerli olur. Yasal temsilci icazet vermezse ya da süreyi susarak geçirirse, miras sözleşmesi yapıldığı anda itibaren kesin hükümsüzlükle sakat olur. Bu hâlde, mirasbırakan bir ivaz almışsa MK 452'ye göre geri verme borcu altına girer. Karşı taraf ise henüz bir şey almadığı için geri verme borcu altına girmez, meğer ki, MK 572'ye göre, miras payı ona sağlığında devir edilmiş olsun.

508 Yukarıda açıklanan hususlara *Piotet* karşı çıkmaktadır[279]. Yazara göre, aşağıda açıklanacağı gibi, mirasbırakanın ehliyetsizliği hâlinde iptali; karşı tarafın ehliyetsizliği hâlinde ise kesin hükümsüzlüğü ya da askıda hükümsüzlüğü kabul etmek, miras sözleşmesinin bütünlüğüne ve taraflar arasındaki eşitliğe aykırıdır. Bunun yanında, karşı tarafın fiil ehliyetsizliğinde kesin hükümsüzlüğün kabulü, onun, mirasbırakana oranla daha fazla korunması sonucunu doğurur. Çünkü, kamu düzenini ilgilendiren ahlâka ve hukuka aykırılık hâlinde dahi hâkim ölüme bağlı tasarruflarda re'sen hareket edemezken, burada, sadece tarafları ilgilendiren bir durum olmasına rağmen kesin hükümsüzlüğü kabul etmek bir çelişki olur. Bu bakımdan, diğer tarafın ehliyetsizliği hâlinde de, müeyyidenin iptal olması gerekir[280].

b) Mirasbırakanın ehliyetsizliği

509 Mirasbırakanın ölümünden sonra ehliyetsizliğinin ileri sürülmesi, MK 557, b.1'e göre olur. Çünkü bu hüküm, hem vasiyetnameler hem de miras sözleşmelerine uygulanır.

510 Mirasbırakanın sağlığında kendi ehliyetsizliğine dayanarak miras sözleşmesini iptal ettirebilip ettiremeyeceğine gelince; doktrin, bazı hâllerde, mirasbırakanın bir çıkarının olacağından hareketle buna olumlu cevap vermektedir. Örneğin, mirasbırakan, başka bir ölüme bağlı tasarrufta bulunmak ya da mirasçılarını, onun ölümünden sonra ehliyetini tartışmak ve dava açmak zahmetinden kurtarmak isteyebilir[281]. Ancak Medenî Kanunda bu konuda herhangi bir düzenleme yoktur. Bu bakımdan doktrin, bu imkânı, MK 504'den hareketle tanımaktadır. Buna göre, irade sakatlıklarında, mirasbırakana, sağlığında ölüme bağlı tasarrufu iptal hakkı tanıyan MK 504, daha ağır olan ehliyetsizlik hâlinde evleviyetle uygulanmalıdır. Ancak, irade sakatlıklarının aksine, ehliyetsizlik sebebiyle dava açılmasına MK 504/I, c. 2'deki bir yıllık süre uygulanamaz. Bu bakımdan mirasbırakanın ölümüne kadar her zaman ehliyetsizlik sebebiyle iptal davası açılabilir. Eğer açılmamışsa, ölümden sonra ilgililer, MK 559'da öngörülen süreler içinde iptal davası açabilirler.

---

[279] *Piotet*, 282/283.
[280] Bu görüşün eleştirisi için bkz., *Dural*, Miras Sözleşmeleri, § 3,V,1.
[281] Krş., *Kocayusufpaşaoğlu*, § 12, III,1.

511 Genel olarak kabul edilen bu görüşe göre, karşı taraf da mirasbırakanın sağlığında, onun ehliyetsizliğine dayanarak iptal davası açabilir. Ancak, sınırlı ehliyetsizlik hâlinde, mirasbırakanın yasal temsilcisine MK 451'deki sürenin verilmesi gerekmez. Çünkü, mirasbırakan yönünden ölüme bağlı tasarrufta bulunmak kişiye sıkı sıkıya bağlı bir hak olduğu için, yasal temsilcinin icazet vermesi söz konusu olamaz.

IV. MİRAS SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ

1. Genel olarak

512 MK 545'e göre, *"Miras sözleşmesinin geçerli olması için resmî vasiyetname şeklinde düzenlenmesi gerekir.*

513 *Sözleşmenin tarafları,arzularını resmî memura aynı anda bildirirler ve düzenlenen sözleşmeyi memurun ve iki tanığın önünde imzalarlar".*

514 Buna göre, miras sözleşmesinin şekil yönünden geçerliği, MK 532 vd. maddelerindeki resmî vasiyetnameler için öngörülen şekil şartlarına uyulmuş olmasına bağlıdır. Ancak, vasiyetnamelerden farklı olarak, miras sözleşmeleri iki taraflı ölüme bağlı tasarruflardır. Bu bakımdan, şekil yönünden kuşkusuz bazı farklılıklar olacaktır. Resmî vasiyetnamenin şekline ilişkin kurallar üzerinde yukarıda etraflı olarak durulduğu için[282], burada, sadece, miras sözleşmesinin iki taraflı olmasından kaynaklanan farklar üzerinde durulacaktır. Ancak, bunların incelenmesine geçmeden önce, bazı noktaların açıklanmasında yarar vardır.

515 Miras sözleşmesinde, resmî vasiyetname şekillerinden birine uyulması, sadece ölüme bağlı tasarrufta bululan taraf için söz konusudur. Bu bakımdan, her iki taraf da terekesinin üzerinde tasarrufta bulunuyorsa, her ikisinin de, beyanlarını resmî vasiyetname şekillerinden birine uyarak yapmaları gerekir. Karşı taraf, terekesi üzerinde tasarrufta bulunmuyorsa, sağlararası ivaz borcu altına girse bile, şekil yönünden, resmî vasiyetname şekline değil, genel hükümlere tabi olur. Örneğin, onun yönünden temsil yasağı işlemez, isterse bir temsilci kullanabilir.

516 Şekil yönünden sakat olan bir miras sözleşmesinin, tahvil (çevirme, konversiyon) yoluyla resmî vasiyetname olarak ayakta tutulması mümkündür. Ancak, bunun için, sakat olan miras sözleşmesinin, resmî vasiyetname için aranan bütün şekil şartlarını yerine getirmiş ve mirasbırakanın, karşılıklı bağlanma olmasa idi dahi, yine de ölüme bağlı tasarrufu yapacağının anlaşılması gerekir. Yargıtay, eski bir kararında[283], karşı tarafın, düzenlenmesine katıldığı, fakat imzalamadığı bir miras sözleşmesinin, resmî vasiyetname olarak kabul edilip edilemeyeceğini incelemesi gerektiğini belirterek, meseleye sadece değinmiş, fakat kesin bir tutum almamıştır. Yargıtay'ın burada incelenmesini aradığı husus, miras sözleşmelerinde karşılıklı birbirine bağlı kazandırmaların bulunup bulunmadığıdır. Eğer bu anlamda bir bağlılık yoksa,

---

[282] Bkz., yukarıda § 10.

[283] 2.HD 25.6.1973, 934/534 (*Olgaç*, No.1705).

Yargıtay'ın örtülü olarak, bu tek imzalı tasarrufun vasiyetnameye çevrilebileceğini kabul ettiğini söyleyebiliriz[284]. 1972 tarihli bir kararında ise, Yargıtay, tahvil üzerinde durmuş, fakat olayın özelliği gereği (olayda, resmî şekilde yapılmamış bir mirastan feragat sözleşmesinin, başka bir işleme, muhtemelen vasiyetnameye çevrilmesi meselesi söz konusudur), tahvili kabul etmemiştir[285].

Federal Mahkeme, şu şartların bulunması hâlinde tahvili mümkün görmektedir[286]: a) resmî vasiyetnamenin şekil şartlarına uyulmuş olması; b) miras sözleşmesiyle güdülen amacın elde edilmesinin vasiyetname ile de mümkün olması; c) mirasbırakanın, eğer miras sözleşmesinin geçersizliğini bilse idi, bir resmî vasiyetname yapacağının anlaşılması, fakat bunu yapma imkânının olmaması. 517

Geçersiz bir evlât edinme sözleşmesinin tahvil yoluyla bir ölüme bağlı tasarruf olarak ayakta tutulmasının mümkün olup olmadığı tartışmalıdır[287]. 518

Son olarak belirtelim ki, sadece miras sözleşmesi değil, 11.12.1959 tarih ve 16/14 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararına göre[288], mirastan feragat sözleşmelerinin de resmî vasiyetname şeklinde yapılması gerekir. Bu İçtihadı Birleştirme Kararının sonuç bölümüne göre, *"mirastan feragat sözleşmesinin bütün miras mukaveleleri gibi resmî vasiyet şeklinde yapılmasına karar verildi"*[289]. 519

2. Miras sözleşmesinin şekil yönünden resmî vasiyetnameden farkları

Bu farklar MK 545/II'de belirtilmiştir. Buna göre, *"Sözleşmenin tarafları, arzularını resmî memura aynı zamanda bildirirler ve düzenlenen resmî vasiyetnameyi memurun ve iki tanığın önünde imzalarlar"*. Bu hükmü göz önünde bulundurarak, miras sözleşmesindeki, resmî vasiyetnameye göre farkları şöylece sıralayabiliriz. Ancak, bunları açıklamaya geçmeden önce belirtelim ki, tıpkı resmî vasiyetname gibi, miras sözleşmesi de genel olarak noter önünde yapıldığı için, burada noter terimi kullanılacaktır. Ancak söylenenler, düzenleme yetkisi olan bütün resmî memurlar için de geçerlidir. 520

a) Tarafların aynı anda noter önünde bulunmaları

Bunun anlamı, tarafların iradelerini aynı anda açıklamaları değil, resmî vasiyetnamede aranan işlemde birlik (unitas actus) prensibine uygun bi- 521

---

[284] Krş., *Kaneti*, 203.
[285] 2.HD 5.5.1972, 2899/2815 (*Şener*, 967/968).
[286] Bu kararlar için bkz., *Dural*, Miras Sözleşmeleri, § 4, dn.9
[287] Bu tartışmalar için bkz., *Kocayusufpaşaoğlu*, § 14, II,2,a,bb ve orada atıf yapılan yazarlar; ayrıca *Şener*, § 7. Ancak yazarın *Kocayusufpaşaoğlu*'nu tahvili kabul eden yazarlar arasında göstermesi doğru değildir.
[288] RG 1959, sayı 10223.
[289] Bu konuda bkz., aşağıda, § 16, VIII.

çimde birbiri ardından açıklamalarıdır. Ölüme bağlı tasarrufta bulunanın bizzat noter önünde bulunup iradesini açıklaması gerekirken, diğer taraf, eğer o da ölüme bağlı tasarrufta bulunmuyorsa, temsilci gönderebilir. Karşı taraf tam ehliyetsizse, onun yerine yasal temsilcisi noter önünde bulunur. Karşı taraf, sınırlı ehliyetsizse ve sağlararası ivaz borcu altına giriyorsa,onun ve yasal temsilcisinin aynı anda noter önünde bulunmaları gerekir. Yasal temsilci vasi ise, *fikrimce*, sulh ve asliye mahkemelerinin izninin, miras sözleşmesi yapıldıktan sonra alınması gerekir. Çünkü mahkemelerin izni verip vermemeleri, miras sözleşmesinin içeriğini bilmelerine bağlıdır. Sulh ve asliye mahkemeleri izni verinceye kadar miras sözleşmesi geçerlik kazanmaz.

b) Noterin beyanları yazması ya da yazdırması ve metnin okunması

522 Noter tarafından yazılan ya da yazdırılan metin, eğer MK 533/534'e göre düzenleme yapılmışsa, bizzat mirasbırakan tarafından; eğer MK 535'e göre yapılmışsa, noter tarafından mirasbırakana bizzat okunur. Ölüme bağlı tasarrufta bulunmayan tarafın metni öğrenme biçiminin önemi yoktur. O, isterse metni bizzat okur, isterse metni notere ya da başka bir kimseye okutabilir.

c) Tarafların metni tanıklar önünde imzalamaları

523 MK 545/II, sadece tanıkların önünde imza atılmasını öngördüğü için, metnin içeriğinin tanıklara açıklanmasına gerek yoktur. Miras sözleşmesi, MK 533-534'e göre düzenleniyorsa, mirasbırakanın imzasının el yazısı ile olması gerekir. Miras sözleşmesinin MK 535'e göre düzenlendiği hallerde ise, mirasbırakanın imzasının yerine maddedeki kurallara uyulması gerekir. Sözleşmenin diğer tarafı ise (ölüme bağlı tasarrufta bulunmuyorsa), BK 14 vd. deki kurallara göre imza atar. Tarafların imzasını noterin imzası izler.

d) Mirasbırakanın, tanıklar önünde, belgeyi okuduğunu ve bunun son arzularına uygun olduğunu beyan etmesi

524 Karşı tarafın, ölüme bağlı tasarrufta bulunmadığı sürece, böyle bir beyanda bulunmasına gerek yoktur. Çünkü onun imzası, belgenin beyanına uygun olduğuna ilişkin yeterli garanti oluşturur.

e) Tanıkların şerh ve imzası

525 Tanıkların MK 534 ve 535'e göre verecekleri şerh, eğer her iki taraf da ölüme bağlı tasarrufta bulunuyorlarsa,her iki tarafı da kapsayacaktır[290]. Bu-

[290] Tanıkların verecekleri şerh için bkz., yukarıda § 10, IV.

na karşılık, sadece bir taraf ölüme bağlı tasarrufta bulunuyorsa, şerh sadece onunla ilgili olarak verilir.

Kanunda yazılı olmamakla beraber, *fikrimce*, ilerideki ihtilafları önlemek amacıyla, tanıkların şerh metnine, vasiyetnamenin önlerinde imzalandığını eklemelerinde yarar vardır. 526

f) Miras sözleşmesinin saklanması, tevdii ve açılması

Resmî vasiyetnamelerden farklı olarak (MK 537), miras sözleşmelerinde MK 545'de saklamaya ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. Bu sebeple baskın görüş, kural olarak miras sözleşmelerinde bir saklama yükümünün olmadığı yönündedir. Ne var ki, NK 84/II'ye göre, noterler, re'sen düzenledikleri senetlerin aslını saklayacakları için, uygulamada zorunlu olarak bir saklama söz konusu olacaktır. Ancak, noter tarafından saklanması bir geçerlik şartı olmadığı için, noterin bunu ihmal etmesi, miras sözleşmesinin geçerliğini etkilemez. 527

Yine resmî vasiyetnamelerden farklı olarak, miras sözleşmesinin hâkime tevdii ve açılması da söz konusu olmayacağı için, MK 595 hükmü, kural olarak miras sözleşmelerine uygulanmaz. Buna gerekçe olarak da, miras sözleşmesinin iki taraflı bir işlem olduğu, bu sebeple lehine ölüme bağlı tasarrufta bulunulan kimsenin bunu bildiği ve elinde resmî bir suret bulunduğu gösterilmektedir. 528

Ancak baskın görüş, iki hâlde miras sözleşmelerinin tevdi ve açılmalarının zorunlu olduğunu kabul eder. Bunlar, a) miras sözleşmesinin üçüncü kişi yararına olması, b) miras sözleşmesinde, bir taraflı, bağlayıcı olmayan, yâni vasiyetname niteliğinde tasarrufların bulunmasıdır. Birinci hâlde, üçüncü kişinin elinde miras sözleşmesinin bir sureti olmadığı ve bu sebeple de bilgisi bulunmadığı için; ikinci hâlde, vasiyetname hükümleri uygulanacağı için, bu tür miras sözleşmelerinin MK 595'e göre tevdi edilmeli ve açılmalıdırlar. 529

Bütün bu açıklanan hususlar, mirastan feragat sözleşmelerine de uygulanır. 530

§ 14. Vasiyetnamenin geri alınması, yok olması ve miras sözleşmesinin sona ermesi

I. VASİYETNAMENİN GERİ ALINMASI

1. Genel olarak

Bir taraflı bir ölüme bağlı tasarruf olan vasiyetname, vasiyetçinin ölümüne kadar her zaman serbestçe geri alınabilir. Bu geri alma, daha sonra yapılan bir ölüme bağlı tasarrufla ya da vasiyetnamenin yok edilmesi yo- 531

luyla olabileceği gibi, vasiyet olunan şeyde sağlararası tasarruf ederek de *(ademtio legati)* gerçekleştirilebilir. Aşağıda bunlar üzerinde ve vasiyetnamenin yok edilerek geri alınması ile benzer bir kavram olan, fakat onunla karıştırılmaması gereken vasiyetnamenin yok olması üzerinde durulacaktır.

2. Vasiyetnamenin sonradan yapılan bir ölüme bağlı tasarrufla geri alınması (MK 542)

532 Burada iki durumu birbirinden ayırmak gerekir.

533 *a) Vasiyetçi, sonraki vasiyetname ya da miras sözleşmesiyle, daha önceki vasiyetnamesini geri aldığını açık olarak beyan eder.*

534 Bu durumda, önceki tarihli vasiyetname artık yürürlükten kalkmış olur. Geri almanın, aynı vasiyetname türü ile olması gerekmez. Bir resmî vasiyetname, yeni bir resmî vasiyetname ile geri alınabileceği gibi; bir el yazılı vasiyetname ya da sözlü vasiyetname ile de geri alınabilir[291]. Aynı şekilde, önceki tarihli vasiyetname bir miras sözleşmesi ile de geri alınabilir. Ancak bu son hâlde, geri almaya ilişkin beyan, miras sözleşmesinin her zaman geri alınabilen bir taraflı içeriğini oluşturur[292].

535 Önceki tarihli vasiyetnamenin geri alınması amacıyla yapılan sonraki tarihli vasiyetnamenin istenilen sonuçları doğurabilmesi için, şekil şartlarına uygun olarak yapılmış olması gerekir. Aksi halde, geçersiz sayılacağı için, önceki tarihli vasiyetname geri alınmış sayılmaz[293].

536 Vasiyetnamenin geri alınmasının tam olması zorunlu değildir. MK 542/II' ye göre, vasiyetnamenin kısmen geri alınması da mümkündür. Ancak, kısmî geri alma hâlinde, geri alınmayan kısım tek başına bir şey ifade etmiyorsa, o zaman, geri kalanın anlamsızlığı sebebiyle, vasiyetnamenin tümünün geri alınmış sayılması gerekir. Aksi hâlde, zaten geri kalan kısım o hâliyle uygulanamaz durumdadır.

537 Geri almanın da yine bir ölüme bağlı tasarrufla geri alınması mümkündür. Bu halde, ilk vasiyetnamenin geçerlik kazanıp kazanamayacağı meselesi ile karşılaşırız. Çünkü, geri almanın geri alınması hâlinde, *a priori* ilk vasiyetnamenin yürürlüğe girdiği kabul edilemez. Geri almayı geri alan va-

---

[291] 2.HD 15.11.1982, 8099/8536 (*Şener*, Vasiyet, 374); 2.HD 18.10.1973, 6050/5853 (*Şener*, Vasiyet, 372); 2. HD 30.3.1963, 1610/1979 (*Şener*, Vasiyet, 375).

[292] *Escher*, Art. 509 N 3; *Öztrak*, 33; *Kocayusufpaşağlu*, § 16,I,2,a; *Oğuzman*, 176; BGE 73 II 148. Bu kararında Federal Mahkeme, resmî vasiyetnamenin,notere hitaben yazılan mektup şeklindeki el yazılı vasiyetnameyle geri alındığını kabul etmiştir.

[293] HGK 17.11.1993, 526/724 (*Şener*, Vasiyetname, 369); 2.HD 17.12.1972, 5977/6472 (*Şener*, Vasiyet, 374); *Oğuzman*, 176; *İnan/Ertaş*, 128; *Tuor*, Art. 509-511, N 7.

siyetnamenin yorumlanması ile bu sonuca varmak gerekir[294]. Kuşku hâlinde, ilk vasiyetnamenin yürürlüğe gireceği değil, mirasbırakanın, kanunî intikal kurallarına dönmek istediği kabul edilmelidir.

Yorumun yapılmasında, ilk vasiyetnameyi geri almaya yönelik vasiyetnamenin içeriği önemli bir rol oynar. Şöyle ki, birinci vasiyetnameyi açıkca geri alan vasiyetnamede, geri alma dışında başka bir ölüme bağlı tasarruf yoksa, aksi tespit edilmedikçe, vasiyetçinin, geri almayı geri almakla, ilk vasiyetnamenin tekrar yürürlük kazanmasını istediği kabul edilir. Buna karşılık, ilk vasiyetnameyi geri almaya yönelik vasiyetnamede, geri alma dışında başka ölüme bağlı tasarruflar da varsa, o zaman, aksi ispat edilmedikçe, ilk vasiyetnamenin hükümsüz olmasının istendiği sonucuna varılmalıdır[295]. *Fikrimce*, bu son hâlde, az sonra üzerinde durulacak olan MK 544'ün uygulanması ile bir sonuca varılmalıdır. 538

BGE 101 II 121'e göre, vasiyetnamesini yok ederek geri alan vasiyetçi, sonradan, vasiyetname şekillerinden birine uyarak yapacağı bir beyan ile, içeriğinin kuşkuya yer vermeyecek şekilde saptanması şartıyla, yok ettiği vasiyetnamesini tekrar yürürlüğe koyabilir. *Fikrimce*, MK 544'ü böyle bir olaya uygulamak çok tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Mirasbırakan, hayattayken yok ettiği vasiyetnamesinin hüküm ifade etmesini istiyorsa, İsviçre doktrininde doğru olarak savunulduğu gibi[296], aynısını bir vasiyetname şekline uyarak yeniden yapması gerektiğini aramak daha doğru olur. 539

b) Vasiyetçi tarafından sonradan yapılan vasiyetnamede (ya da miras sözleşmesinde), önceki vasiyetnamenin geri alındığına ilişkin açık bir tasarruf bulunmamaktadır. 540

Burada vasiyetçi, ilk vasiyetnamesini geri aldığını beyan etmeksizin, yeni bir vasiyetname yapmaktadır. Bu durumda, ikinci vasiyetname ile ilk vasiyetnamenin geri alınmış sayılıp sayılmayacağı sorusuna, *ikinci vasiyetnamenin birincisini tamamlamaması* hâlinde verilecek cevap kolaydır: daha sonraki vasiyetname ile, daha önceki vasiyetname geri alınmış sayılır. Fakat, iki vasiyetnamenin içeriklerinin, *birbirlerini tamamlamaları* hâlinde durum farklıdır. Çünkü, kanunkoyucu, bu halde iki farklı düzenlemeden birini seçebilir. Birinci seçeneğe göre, kanunkoyucu, geri alma aleyhine bir çözüm getirebilir. Bunun anlamı, her iki vasiyetnameye aynı anda uygulanma imkânının tanınmasıdır. İkinci seçeneğe göre ise, kanunkoyucu, tam aksine, yâni geri ama lehine bir düzenleme getirmiş olabilir. Bu hâlde, iki vasiyetnamenin içeriklerinin birlikte uygulanması imkânı bulunmasına rağmen, ikinci vasiyetname ile önceki vasiyetnamenin geri alındığı karinesi kabul edilmiş olur. 541

---

[294] *Tuor*, Art. 509-511, N 6; *Piotet*, 137 vd; *Öztrak*, 94 vd.

[295] *Oğuzman*, 177; *Kocayusufpaşaoğlu*, 232; BGE 90 II 264.

[296] *Tuor*, Art. 504- 510, N 12; *Escher*, Art. 510, N 5; *Piotet* (232), Federal Mahkemenin kararına, burada, vasiyetnamenin dış unsurlarla yorumlanması meselesi oduğu (yoksa yeniden yürürlüğe konması değil) gerekçesiyle karşı çıkmaktadır.

542 Bu durumu düzenleyen MK 544/I, *"Mirasbırakan, önceki vasiyetnamesini ortadan kaldırmaksızın yeni bir vasiyetname yaparsa, kuşkuya yer bırakmayacak surette önceki vasiyetnameyi tamamlamadıkça, sonraki vasiyetname onun yerini alır"* diyerek, geri alma lehine olan karineyi kabul etmiştir. Buna göre, her iki vasiyetnamenin birlikte uygulanması mümkün olsa bile, ikinci vasiyetname ile önceki vasiyetname geri alınmış sayılır, meğer ki, ikinci vasiyetnamenin birinciyi tamamladığı kuşkuya yer bırakmayacak şekilde anlaşılsın. O halde, ikinci vasiyetname ile birincisinin geri alınmadığını iddia eden kişi, ikinci vasiyetnamenin,birinciyi kuşkuya yer bırakmayacak şekilde tamamladığını ispat edip, MK 544'deki karineyi çürüterek, iki vasiyetnamenin birlikte uygulanmasını temin edebilir. Bunu yapamaz ise, her iki vasiyetnamenin içerikleri kabili telif olsa bile, birinci vasiyetname geri alınmış sayılır.

3. Vasiyetnamenin yok edilerek geri alınması

543 MK 543/I'e göre, *"Mirasbırakan, yok etmek suretiyle de vasiyetnameden dönebilir"*. Bu yolla vasiyetnamenin geri alınabilmesi için , yok etmenin geri alma niyetiyle *(animus revocandi)* olması gerekir. Böyle bir niyet olmadan vasiyetname, vasiyetçinin bir fiili ile yok olsa bile, geri alınmış sayılmaz. Bu halde, aşağıda (II) altında açıklanacak olan, yok olmayı düzenleyen MK 543/II uygulanır.

544 Yok etmeden kasıt, vasiyetnamenin okunamayacak hale getirilmesidir. Bu, yakma, yırtma[297] ya da karalama şeklinde olabilir. Bu bakımdan, yok etme yoluyla geri alma, prensip olarak, el yazılı vasiyetnamelerde söz konusu olabilir. Ancak, zor olmakla beraber, resmî vasiyetname ve sözlü vasiyetnamenin de yok edilerek geri alınması mümkündür. Resmî vasiyetnamenin bu yolla geri alınmış sayılabilmesi için, vasiyetçinin sadece kendi elindeki sureti yok etmesi yeterli değildir; noterde bulunan aslın da yok edilmesi gerekir[298]. Bunun gibi, sadece noterde bulunan aslın geri alınması da, BGB § 2256/I'den farklı olarak, vasiyetnamenin geri alınması sonucunu doğurmaz. Bu durumda, NK 84/II'nin notere düzenlediği senetlerin aslını saklama ve MK 537'nin, de resmî vasiyetnamenin noter tarafından saklanması yükümlülüğü getirmesi karşısında, noterdeki belginin nasıl yok edileceği sorusuyla karşılaşırız. Burada, önce, notere başvurularak, onun elindeki nüshanın da yırtılmasının, yakılmasının ya da çizilmesinin istenebileceği

---

[297] 2.HD 6.4.1964 tarih ve 1887/1795 sayılı kararında (*Şener*, Vasiyet, 375), düzenli bir biçimde yırtılan ve bu sebeple de içeriği anlaşılan bir vasiyetnameyi, yok etme yoluyla geri alınmış kabul etmeyip, geçerli saymıştır.

[298] *Tuor*, Art. 509/511, N 12; *Escher*, Art. 510, N 2; *Kocayusufpaşaoğlu*, 236; *İmre/Erman*, 95; *Oğuzman*, 178.

imkân dahilinde görülmektedir[299]. Ancak bu hâlde de noterin, durumu tespit eden bir tutanak düzenlemesi gerektiği ileri sürülmektedir[300]. Bazı yazarlar ise MK 537'deki, resmî vasiyetnamenin, resmî memur tarafından saklanması hükmünün, bir geçerlik şartı olmadığından hareketle, noterdeki asıl nüshanın istenebileceğini ileri sürmektedirler[301]. Ancak bu hâlde de noterden geri alınan nüshanın yok edilmesi gerektiğini belirtelim.

Kocayusufpaşaoğlu, bu son hâlde, resmî vasiyetnamenin saklanmasıyla amaçlanan garantiden yoksun kalacağına işaret etmektedir. Yazara göre bu durum NK 84/II'nin asıl nüshanının noterde saklanması zorunluluğu ile izlenen amaca tamamen aykırıdır. *"İşte bu sebepledir ki, açık bir hüküm bulunmamasına rağmen Noterlik Kanununa göre noterde kalan asıl nüshasının vasiyetçinin isteği üzerine geri verilmesi kabul edilemez"*, demektedir yazar. Ne var ki, yazara göre,vasiyetçinin herhangi bir şekilde, hattâ zorla, noterdeki nüshayı ele geçirip, geri alma amacıyla yok etmesi hâlinde, vasiyetname geri alınmış sayılır[302]. 545

Resmî vasiyetnamenin, noter tarafından geri verilmesinin mümkün olup olmadığına ilişkin tartışmalar, saklanmak üzere notere verilen el yazılı vasiyetnameler için yapılmamakta, vasiyetçinin bunu her zaman noterden geri alabileceği kabul edilmektedir[303]. 2. HD, notere tevdi edimiş el yazılı vasiyetnameyle ilgili olarak verdiği kararında[304] el yazılı vasiyetnamenin, şekil şartlarını içeren birden fazla *aslı* varsa, vasiyetnamenin geri alınmış sayılabilmesi için, bütün nüshaların geri ama niyeti ile yok edilmesi gerektiğini aramıştır. Buna karşılık, geri alma niyeti ile yok edilen el yazılı vasiyetnamenin, bir fotokopisi varsa, bunun yok edilmemiş olması, vasiyetnamenin geri alınmış sayılmasını engellemez. Çünkü bu halde,önceki ihtimalden farlı olarak, fotokopi şekle uygun el yazılı vasiyetname değildir. Fotokopinin varlığı, aşağıda (II) de görüleceği üzere, vasiyetnamenin yok olması (MK 543/II) durumunda rol oynar. 546

Sözlü vasiyetnamenin de, bir aylık süre dolmadan, hâkimden geri alınıp yok edilmesi mümkündür. 547

4. Vasiyetname ile yapılan tasarrufun, sağlar arası bir tasarrufla geri alınması (ademptio legati)

MK 544/II'ye göre, *"Belirli bir mal bırakma vasiyeti de vasiyetnamede* 548

---

[299] BGE 83 II 500. Bu kararın Türkçe çevirisi için bkz., *Ataay/Kocayusufpaşaoğlu/Sungurbey/Kaneti*, c. 3, No. 91.
[300] Bkz., *Kocayusufpaşaoğlu*, § 16, I, 3.
[301] *Escher*, Art. 504 N 1; *Tuor*, Art. 504 N 2; Art. 509/511, N 11; *Kocayusufpaşaoğlu*, 236.
[302] *Kocayusufpaşaoğlu*, 284.
[303] *Kocayusufpaşaoğlu*, 236, dn.21.
[304] 2.HD 3.5.1955, 1852/2428 (*Şener*, Vasiyet, 376).

aksi belirtilmedikçe, mirasbırakanın sonradan o mal üzerinde bu vasiyetle bağdaşmayan başka bir tasarrufta bulunmasıyla ortadan kalkar". Buna göre, bir kimse,belirli bir malı üzerinde ölüme bağlı tasarrufta bulunduktan sonra,aynı malla ilgili olarak, yaptığı ölüme bağlı tasarrufla bağdaşmayan bir sağlar arası tasarrufta bulunacak olursa, ölüme bağlı tasarruf geri alınmış sayılır. Bu hüküm, ölüme bağlı tasarrufta bulunmanın, sağlar arası tasarruf özgürlüğünü ortadan kaldırmayacağı kuralının doğal bir sonucudur. Örneğin, M, otomobilini A'ya vasiyet ettikten sonra B'ye satar ve teslim ederse, vasiyeti geri almış olur. Ancak, mirasbırakanın iradesinden, malvarlığından çıkan şeyin yerini alan karşılığının, ya da otomobilin temin edilerek[304a] ölüme bağlı tasarrufla lehine vasiyet yapılan kişiye verilmesini istediği anlaşılırsa (MK 544/II), o zaman ölüme bağlı tasarruf geçersiz olmayıp, vasiyet alacaklısına, terekeden çıkan şeyin karşılığında elde edilen şey verilir. Bunun için lehine vasiyet yapılan kimsenin, MK 544/II'deki geri almaya ilişkin karineyi çürütmesi gerekir[305]. Yargıtay'a göre, MK 544/II (eMK 491 c.2) nin uygulanabilmesi için, vasiyetin ifasının imkânsız olması gerekir. Vasiyet edilen mal üzerinde, bir bağışlama vaadi yapılmışsa, vasiyetin konusu olan şey terekede mevcut olacağından, vasiyetin ifasında imkânsızlık bulunmayacağı için, vasiyet geri alınmış sayılmaz[306].

549 Sağlar arası yapılan tasarrufla geri alma gerçekleştikten sonra, söz konusu şeyin tekrar malvarlığına geri girmesi hâlinde (mirasbırakan, vasiyet ettiği halıyı satıyor, fakat bir müddet sonra geri satın alıyor), vasiyet tasarrufunun tekrar canlanıp canlanmayacağı tartışmalıdır[307].

550 MK 544/II'nin getirdiği geri alma karinesi, sadece vasiyet edilen mala ilişkin sağlar arası tasarrufun kabili telif olmaması (terekede bulunmaması) hâlinde uygulanır. Bu bakımdan sağlar arası tasarrufa rağmen, vasiyetin ifası mümkünse, geri alma karinesi yürümez, vasiyet ifa edilir. Örneğin, vasiyet edilen şey üzerinde sonradan ipotek kurulmuş olması hâlinde, iki tasarruf kabili telif olduğu için, vasiyet ifa edilir[308].

II. VASİYETNAMENİN YOK OLMASI

551 Yukarıda sözü edilen, vasiyetnamenin yok edilmesinden farklı olarak, vasiyetname, vasiyetçinin geri alma niyeti olmaksızın yok olabilir. Örneğin vasiyetnamenin, başkası tarafından, yırtılması, çöpe atılması, hattâ vasiyetçinin bizzat kendisinin, farkında olmayarak, vasiyetnamesini yırtması

[304a] Bkz. aşağıda § 15, II, 2.

[305] *Escher*, Ar. 511 N 7; *Tuor*, Art. 509/511 N 26; *Kocayusufpaşaoğlu*, 237; *Oğuzman*, 180.

[306] 2.HD 30.9.1963,5131/ 5128 (*Şener*, Vasiyet, 379).

[307] Bu tartışmalar için bkz., *Piotet*, 227; *Oğuzman*, 180; *Kocayusufpaşaoğlu*, 237 dn. 24.

[308] HD 28.2.1947, 3701/1160 (*Şener*, Vasiyet, 380); ayrıca *Oğuzman*, 180; *İmre/Erman*, 192.

hâlinde, vasiyetname yok olmuştur, fakat niyet olmadığı için geri alınmamıştır. Bu durumda,yok olan vasiyetnamenin içeriğinin akıbetinin ne olacağı sorusuyla karşılaşırız. Bu soruya MK 543/II şöyle cevap vermektedir: *"Kaza sonucu veya üçüncü kişinin kusuruyla yok olan ve içeriğinin aynen ve tamamen belirlenmesine olanak bulunmayan vasiyetname hükümsüz kalır. Tazminat isteme hakkı saklıdır"*. Görüldüğü gibi, yok olan vasiyetnamenin hüküm doğurması, içeriğinin aynen ve tamamen belirlenmesine, yani ispat edilmesine bağlıdır. Eğer içerik, aynen ve tamamen saptanabiliyorsa, yok olan vasiyetname uygulanabilecektir.

Vasiyetnamenin yok olması değişik sebeplerden kaynaklanabilir. Örne- 552
ğin, bizzat vasiyetçi, geri alma niyeti olmaksızın vasiyetnameyi yok edebilir. Onun, gereksiz kâğıtlarını imha ederken vasiyetnamesini yırtmasında olduğu gibi...Bir başka ihtimal de, üçüncü kişinin vasiyetnameyi kasden ya da bilmeyerek yok etmesidir. Nihayet, vasiyetname, hiç kimsenin fiili olmaksızın, bir olay sonucu (örneğin yangın) yok olabilir[309].

İşte vasiyetnamenin bu sebeplerden biri ile yok olması hâlinde, MK 553
542/II c.1, az önce de belirtildiği gibi, vasiyetnamenin içeriğinin *aynen ve tamamen* ispat edilebilmesi şartıyla uygulanabilmesi imkânını tanımıştır. Bunun için iki hususun ispat edilmesi gerekir: a) vasiyetnamenin, vasiyetçinin geri alma niyeti olmaksızın yok olduğu, b) içeriğinin aynen ve tamamen tespiti. Her iki husus da, MK 6'daki genel kurala göre, vasiyetnameye dayanarak hak iddia eden kimse tarafından ispat edilmelidir[310].

Bundan da anlaşılacağı üzere, burada karine, vasiyetçinin bizzat geri alma niyeti 554
ile vasiyetnameyi yok ettiğidir. Bu karine, vasiyetnamenin, hem vasiyetçi nezdinde yırtılmış, karalanmış vs. olarak bulunması, hem de bu şekilde üçüncü kişiler nezdinde olması hâlinde geçerlidir. Ancak, bu iki durum arasında ispat yönünden fark vardır. Şöyle ki, vasiyetname, karalanmış ya da yırtılmış olarak vasiyetçinin evrakı arasında bulunursa, yok etmenin, bizzat vasiyetçi tarafından geri alma niyetiyle gerçekleştirilmiş olması ihtimali çok yüksektir, meğer ki, aksini gösteren durumlar bulunsun. Çünkü, yok etme niyeti olan üçüncü kişinin delil bırakmamak için böyle davranmayıp, vasiyetnameyi tamamen ortadan kaldırması daha mantıklıdır[311]. İkinci Hukuk Dairesi, yukarıda sözü edilen kararında[312], tamamen farklı bir sonuca vararak, vasiyetçinin, vasiyetnamesinin içeriğinin tamamen saptanabileceği şekilde, düzgün bir biçimde yırtmasında geri alma değil de, MK 543/II anlamında yok olmayı kabul etmiştir. Hukuk Genel Kurulu, 1967 yılında vermiş olduğu bir kararında ise, vasiyetçinin, sonradan lehine vasiyet yapılan kimse ile arasının bozulmasından hareketle, mirasbırakanın, vasiyetnamesini imha etmesini, yok etme yoluyla geri alma olarak yorumlamıştır[313].

---

[309] 2.HD 31.1.1977 , 572/748 (*Şener*, Vasiyet, 378).
[310] 2.HD 31.1.1977, 572/748 (*Şener*, Vasiyet 378).
[311] Bkz., *Kocayusufpaşaoğlu*, 286 ve orada dn. 27'de anılan yazarlar.
[312] Bkz., yukarıda I,3.
[313] HGK 14.10.1967, 308/ 449 (*Şener*, Vasiyet, 378).

555 Buna karşılık, vasiyetnamenin üçüncü kişinin nezdinde imha edilmiş olarak bulunması hâlinde, karine geri alma niyeti bulunmadan yok olmaya dönüşür.

556 Vasiyetnamenin içeriğinin aynen ve tamamen tespiti için her türlü delile başvurulabilir[314]. Örneğin delil olarak bir fotokopiye dayanılabilir, vasiyetçinin bir arkadaşına yazdığı mektuptan yararlanılabilir ya da tanık dinletilebilir. Kanundaki, aynen ve tamamen terimlerini kelime anlamında almamak gerekir. Aynenden maksat, kelime kelime değil, anlama göre tespittir. Tamamenin anlamı da, vasiyetnamenin içerinin tümünün saptanması değildir. Vasiyetnamedeki sadece bazı tasarrufların tespiti de vasiyetnamenin ifası için yeterlidir, meğer ki, ispat edilemeyen kısımlar olmadan ispat edilenlerin ifası mümkün olmasın.

557 MK 543/II c.2'ye göre, vasiyetname bir üçüncü kişinin haksız fiili sonucu yok olmuş ve içeriği de tespit edilemiyorsa, lehine tasarruf yapılan kimse, üçüncü kişiden BK 41'e dayanarak tazminat isteyebilir. Ancak, lehine tasarruf yapılan kimse, tazminat olarak ne isteyecektir? Çünkü, tazminat için zararın ispatı gerekir. Oysa vasiyetnamenin içeriği tespit edilemediğine göre, zararın ne olduğu belli değildir. Bu sebeple istenecek olan tazminat, vasiyetnamenin içeriğinin tespiti için yapılan masraflarla sınırlı kalacaktır[315]. Ancak bir hâlde, uğranılan zararın tümü istenebilir. Şöyle ki, vasiyetnamenin içeriğindeki tasarrufardan biri, aynen ve tamamen saptanmasına rağmen, saptanamayan diğer kısımlarla iç bağlantısı sebebiyle ifa edilemiyorsa, o zaman, artık zarar belli olduğu için, bunun tamamının tazmini istenebilir[316].

III. MİRAS SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ (ORTADAN KALDIRILMASI)[317]

1. Miras sözleşmesinin tarafların anlaşması ile sona ermesi (Miras sözleşmelerine son verme sözleşmesi)

a) Genel olarak

558 MK 546/I'e göre, *"Miras sözleşmesi, tarafların yazılı anlaşmasıyla her zaman ortadan kaldırılabilir"*. Bundan da anlaşılacağı üzere, miras sözleşmesini sona erdirme sözleşmesiyle, taraflar, miras sözleşmesi ile doğan hukuki ilişkiye her zaman son verebilirler. MK 546/I'in, miras sözleşmesinin

---

[314] . HD 31.1.1977, 572/ 748 (*Şener*, Vasiyet, 378).

[315] *Escher*, Art. 510 N 10; *Tuor*, Art. 510 N 5,11; *Kocayusufpaşaoğlu*, 241; *Oğuzman*, 181; *İmre/Erman*, 96.

[316] Bkz., *Kocayusufpaşaoğlu*, 241; *Oğuzman*, 181.

[317] Buradaki açıklamalar, *Dural*, Miras Sözleşmeleri, § 7'ye dayandığı için gerekli olmadıkça ayrıca atıf yapılmayacaktır.

karşılıklı anlaşmayla sona ermesini kabul etmesinin sebebi, miras sözleşmesinin bağlayıcı olması ve bu nedenle de, vasiyetnamelerden farklı olarak bir taraflı geri alma imkânının bulunmamasıdır. Burada gerçek anlamda bir sözleşme vardır, yoksa karşı tarafın rızası ile yapılan geri almaya yönelik bir vasiyetname değil...

Henrici[318], 546/I'in ortak vasiyetname yapma yasağının bir istisnası olduğunu ileri sürmektedir. Ona göre, miras sözleşmesine son verme sözleşmesi, gerçekte el yazısı ile yapılan ortak vasiyetnameden başka bir şey değildir. *Fikrimce*, Medenî kanundaki ortak vasiyetname yapma yasağına burada bir istisnanın getirilmesine gerektirecek bir haklı sebep yoktur. *Speckert*[319], bu görüşe, olumlu bir tasarruf içermeyen bir işlemin vasiyetname sayılmayacağı görüşü ile karşı çıkmaktadır. Oysa bir vasiyetnamenin mutlaka bir olumlu tasarruf içermesinin gerekmediği düşünülecek olursa (örneğin, sadece bir önceki vasiyetnamenin geri alınmasına ilişkin vasiyetnamelerde olduğu gibi), bu gerekçeye katılmak mümkün değildir. 559

Miras sözleşmesine son verme sözleşmesi bir ölüme bağlı tasarruftur. Çünkü, o da hükümlerini ölümden sonra doğurur; ölüme kadar her zaman bundan dönülmesi mümkündür. Bir ölüme bağlı tasarruf olduğu içindir ki, kişiye sıkı sıkıya bağlı bir haktır ve miras sözleşmesinin yapılmasına ilişkin ehliyet şartları (MK 503) burada da yürür[320]. 560

b) Miras sözleşmesine son verme sözleşmesinin şartları

aa) Tarafların hayatta olması

MK 546/I'in açık ifadesinden anlaşılacağı üzere, miras sözleşmesine son verme sözleşmesi, ancak miras sözleşmesinin tarafları arasında yapılabilir. Bu kural,üçüncü kişi yararına miras sözleşmeleri için de geçerlidir. Çünkü, üçüncü kişi yararına miras sözleşmesinde, üçüncü kişi miras sözleşmesinin tarafı hâline gelmez. Ancak, üçüncü kişi yararına olan tasarrufa son verilmek isteniyorsa, onunla bir mirastan feragat sözleşmesi yapılarak da aynı sonuca ulaşılabilir. 561

Bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, taraflardan birinin ölmesi hâlinde, sağ kalan diğeri, ölenin mirasçılarıyla bu sözleşmeyi yapıp miras sözleşmesine son veremez. Bu, taraflardan birinin ölümü üzerine, miras sözleşmesinin doğuracağı sonuç düşünülecek olursa, tabiidir. Çünkü, mirasbırakanın ölümü ile miras geçer (intikal eder) ya da vasiyet alacağı hüküm doğurur. Eğer bu sonucun engellenmesi isteniyorsa, hak sahibi ya MK 605'e göre mirası ya da vasiyet alacağını reddetmelidir, ya da mirasbırakanın mirasçıları ile sağlar arası feragat sözleşmesi yapmalıdır. 562

Miras sözleşmesinin ölüme bağlı tasarrufta bulunmayan tarafının ölmesi hâlinde MK 548/I'e göre, miras sözleşmesi kendiliğinden sona ereceği için, son vermeye ilişkin bir sözleşmesin yapılmasına gerek yoktur. 563

---

[318] *Henrici*, ZSR 33,176 ve 258.
[319] *Speckert*, 138.
[320] Bu konuda bkz., yukarıda § 8, III.

bb) Ehliyet

564 Miras sözleşmesine son verme sözleşmesi bir ölüme bağlı tasarruf olduğu için, ehliyet yönünden miras sözleşmesi yapmaya ilişkin kuralların burada da yürüdüğünden yukarıda (a)'da söz edilmişti.

cc) Şekil

565 MK 546/I, miras sözleşmesine son verme sözleşmesi için *sadece adî yazılı şekli* yeterli görmüştür. Bunun sebebi, mirasbırakanın, bu sözleşme ile yeni bir yüküm atına girmeyip, aksine tasarruf serbestisini kazanmasıdır. Bu bakımdan, miras sözleşmesine son verme sözleşmeleri BK 14 vd. hükümlerine göre düzenlenecektir. Böyle olunca da metnin ne şekilde yazıldığının önemi yoktur. Ancak BK 17/I'den farklı olarak, sözleşmeyi her iki tarafın da imzalaması gerekir. Gerçi, son verme sözleşmesiyle mirasbırakan borç altına girmemekte, aksine borçtan kurtulmaktadır, fakat sözleşmenin ölüme bağlı tasarruf olma niteliği bunu gerektirir. Şekle ilişkin bu kurallar, mirastan feragat sözleşmesinden dönme sözleşmelerine de uygulanır.

566 Miras sözleşmesine son verme sözleşmesinde, yukarıda açıklanan kurallara uyulmamasının sonucu, MK 557'ye göre, iptal edilebilir olmadır. Çünkü bu sözleşme, sık sık değinildiği gibi bir ölüme bağlı tasarruftur. Ölüme bağlı tasarrufta şekle uymamanın sonuçları, aşağıda görüleceği gibi[321], sağlar arası işlemlerden farklı olarak, kesin hükümsüzlük değil, iptaldir.

567 Belirtmek gerekir ki, adî yazılı şekil, sözleşmenin sadece miras sözleşmesine son vermesi hâlinde yeterlidir. Son verme sözleşmesinin aynı zamanda başka tasarrufları da içermesi hâlinde, ortada yeni bir miras sözleşmesi bulunduğu için, MK 545'deki şekil kurallarına uyulması gerekir. Bunun yanında, miras sözleşmesine, taraflar arasında yapılan, son vermeden hiç söz etmeyen, fakat birinci miras sözleşmesi ile bağdaşmayan yeni bir miras sözleşmesi ile de son vermek mümkündür. Bu halde, artık yeni bir miras sözleşmesi söz konusu olduğu için, bunun MK 545'e göre, resmî vasiyetname şekline uyulması gerekir. Belirtmeye gerek yoktur ki, miras sözleşmesine son vermeyen, fakat onu değiştiren miras sözleşmelerinde de MK 545'e göre resmî şekle uymak gerekir.

c) Miras sözleşmesine son verme sözleşmesinin sonuçları

568 Son verme sözleşmesi, miras sözleşmesinin tamamını kapsayacak şekilde yapılmışsa, miras sözleşmesi bütünü ile sona verer. Kısmi son vermede, son vermenin ilgili olduğu tasarruflar ortadan kalkar, bunun kapsamı dışında kalan tasarruflar geçerliklerini korurlar. Ancak, bunlar ile geri alınan tasarruflar arasında, geri kalanların tek başlarına geçerli olmalarına imkân

[321] Bkz., aşağıda, § 18.

vermeyecek biçimde bir iç bağ varsa, onlar da artık, bu sebeple uygulanamayacakları için, geçersiz hale gelirler.

Son verme sözleşmeleri yönünden üzerinde durulması gereken bir husus, bunun, miras sözleşmesindeki bir taraflı tasarruflara etkisinin ne olacağıdır. Tam sona erme hâli için kabul edilen görüşe göre, bunların da geri alındığı karinesi vardır. Çünkü, bu hâlde geri alma, miras sözleşmesinin tüm içeriğini ortadan kaldırır. Ancak,bu bir karine olduğu için, bir taraflı tasarruflar ile bağlayıcı tasarruflar arasında iç bağ bulunmadığı ispat edilerek çürütülebilir. Kısmî son vermede ise durum aksine olup, bir taraflı tasarruflar bundan etkilenmezler, meğer ki, kısmî son verme sözleşmesinde bir taraflı tasarrufların da geri alınmış olduğu belirtilmiş olsun. 569

2. Miras sözleşmesinin bir taraflı irade beyanı ile sona ermesi (miras sözleşmesinden dönme)

a) Genel olarak

Miras sözleşmeleri iki taraflı hukuki işlem oldukları için, vasiyetnamelerden farklı olarak, ancak kanunda öngörülmüş hâllerde bir taraflı irade açıklaması ile sona erdirilebilirler, yani bunlardan ancak kanunda belirtilen hallerde dönülebilir. 570

Dönmenin ne zaman mümkün olacağı MK 546/II ve 547'de öngörülmüştür. MK 546/II, mirasçılıktan çıkarma sebeplerinden birinin bulunması hâlinde dönmeyi düzenlerken; MK 547, sağlar arası ivaz (karşılık) alacaklısının, bu ivazın ifa edilmemesi sebebiyle dönmesini öngörmüştür. 571

Alman Hukukundan farklı olarak (BGB § 2293) bizim hukukumuzda,miras sözleşmesinden dönme hakkının saklı tutulması düzenlenmiş değildir. Ancak, sınırsız dönme hakkının saklı tutulmasını kabul eden Alman Hukukundan farklı olarak, bizde de süre ya da şarta bağlı dönme hakkının miras sözleşmesinde saklı tutulabileceği kabul edilmektedir. Sınırsız dönme hakkının, İsviçre/Türk Hukukunda kabul edilmesinin mümkün olmadığına gerekçe olarak, böyle bir dönme hakkının miras sözleşmesinin bağlayıcı karakteri ile bağdaşmayacağı, bunun, miras sözleşmesini vasiyetnameye çevireceği gösterilmektedir. Bu sebeple, sınırsız dönme hakkı geçersiz, buna karşılık, örneğin, lehine ölüme bağlı tasarruf yapılan kimsenin dört yılda Hukuk Fakültesini bitirememesi şartına bağlanmış olan bir dönme hakkı geçerli sayılacaktır. 572

b) Mirastan çıkarma sebeplerinden birinin varlığı hâlinde miras sözleşmesinden dönme

aa) Genel bilgiler

MK 546/II'ye göre, *"Miras sözleşmesiyle mirasçı atanan veya kendisine belirli mal bırakılan kişinin, mirasbırakana karşı miras sözleşmesinin yapılmasından sonra mirasçılıktan çıkarma sebebi oluşturan davranışta bulunduğu ortaya çıkarsa; mirasbırakan, miras sözleşmesini tek taraflı olarak ortadan kaldırabilir"*. Bu hükme göre, lehine tasarruf yapılan kimse- 573

nin, MK 510'daki mirasçılıktan çıkarma sebeplerinden birini gerçekleştirmesi hâlinde, mirasbırakan, aşağıda (*ddd*)'de açıklanacak şekil şartına uyarak, miras sözleşmesinden dönebilir. Dönme, bir taraflı bir hukukî işlem olduğundan, hüküm doğurması için, karşı tarafın kabule yönelik iradesine gerek yoktur. Bu bakımdan, yenilik doğuran bir irade açıklaması ile kullanılır ve bütün ölüme bağlı tasarruflar gibi, kişiye sıkı sıkıya bağlıdır.

574 Kanun, çıkarma sebeplerinden birini, miras sözleşmesinden dönme sebebi olarak görmekle, miras sözleşmesi ile mirasçı ya da vasiyet alacaklısı atanan kimseleri, bir tür sözleşmeden doğan saklı paylı mirasçı kabul edip, bunlarla (yasal) saklı paylı mirasçılar arasında bir paralellik kurmuştur. Çünkü, mirasbırakan her ikisiyle de bağlıdır ve onların beklenen haklarını iradesi ile bertaraf edemez. Ancak, nasıl saklı paylı mirasçıların korunmaya layik olmadıkları hâllerde kanun onları korumuyorsa (mirastan çıkarma), aynı durumlarda, miras sözleşmesiyle lehine tasarruf yapılan kimsenin de korunmaması gerekir. İşte MK 546/II, bu sebepledir ki, mirasbırakana dönme hakkı tanımıştır.

575 MK 546/II'nin açık hükmüne göre, çıkarma sebebinin, miras sözleşmesi yapıldıktan sonra ortaya çıkması gerekir. Çıkarma sebebi, miras sözleşmesi yapılmadan önce bulunmasına rağmen, miras sözleşmesinin yapılması af[322] ya da sebebin önemsenmediği anlamına gelir. Aynı şey, önceden var olan sebebin bilinmemesi hâlinde de söz konusudur. Ancak bu son hâlde, durumu sonradan öğrenen mirasbırakan, MK 504'deki hata hükümlerine dayanarak miras sözleşmesini iptal edebilir. Onun, süresi içinde dava açmadan ölmesi hâlinde, mirasçılar MK 557 b.2'ye göre iptal davası açabilirler.

bb) Mirasçılıktan çıkarma sebeplerinden birinin varlığı hâlinde dönmenin şartları

aaa) Hak sahibi

576 MK 546/II'nin açık ifadesinden anlaşılacağı gibi, bu hak sadece tanınmıştır. Kişiye sıkı sıkıya bağlı bir hak olduğu için, ne yasal ne de rızai temsil yürür, mirasbırakanın ölümü ile sona erer. Bu bakımdan, mirasbırakan, şekle uygun dönme beyanında bulunmadan ölmüşse, artık onun mirasçıları bir şey yapamazlar. Ancak, mirastan çıkarma sebebi aynı zamanda mirastan yoksunluk sebebi de (MK 578) oluşturuyorsa, o zaman, lehine tasarruf yapılan kimse kanun gereği lehine yapılan tasarruftan yoksun olur. Çıkarma sebebinin, miras sözleşmesinin karşı tarafının şahsında gerçekleşmesi gerekir. Ancak, bir üçüncü kişi lehine miras sözleşmesi söz konusuysa, çıkarma sebebini, bu üçüncü kişinin gerçekleştirmesi gerekir. Çıkarma sebebini

[322] Bkz., Gerekçe, 486.

üçüncü kişi değil de sözleşmenin diğer tarafı gerçekleştirmişse, bu, mirasbırakanın sözleşmeden dönmesi için yeterli değildir.

bbb) Mirastan çıkarma sebeplerinden birinin varlığı

Mirasbırakan, sadece MK 510'da öngörülen çıkartma sebeplerinden bi- 577
ri varsa miras sözleşmesinden dönebilir. Bunlar üzerinde aşağıda etraflı olarak durulacaktır[323]. Burada, sadece miras sözleşmesi yönünden tartışmalı olan noktalar incelenecektir.

Tartışmanın konusunu, MK 546/II ile MK 510'un metinleri arasındaki 578
ifade farkı oluşturmaktadır. Şöyle ki, MK 546/II mirastan çıkarma sebebinin, *mirasbırakana karşı* gerçekleşmesini ararken; çıkarma sebeplerini düzenleyen MK 510, birinci bendinde *mirasbırakana* veya *mirasbırakanın yakınlarından birine karşı*; ikinci bendinde *mirasbırakana veya mirasbırakanın ailesi üyelerine karşı* gerçekleşmesini aramaktadır. İşte bu ifadeler karşısında tartışmaya konu olan husus, mirastan çıkarma sebeplerinden birinin, mirasbırakana karşı değil de, yakınları ya da ailesine karşı gerçekleşmesi hâlinde, mirasbırakanın dönme hakkının bulunup bulunmadığıdır. Bazı yazarlar[324], MK 546/II hükmünü dar yorumlayarak, mirastan çıkarma sebebinin sadece mirasbırakana karşı gerçekleşmesi hâlinde, onun miras sözleşmesinden dönebileceğini savunurlar. Bu yazarlara göre, işlemin bir sözleşme olması karakteri böyle bir sınırlamayı zorunlu kılar. Çünkü, lehine tasarruf yapılan kimsenin hakkı bir sözleşmeye dayanmaktadır ve bu nedenle de, sadece sözleşmenin diğer tarafı olan mirasbırakana karşı gerçekleşen fiiller nazara alınmalıdır. Ancak, mirasbırakanın yakınları ya da ailesine karşı gerçekleşmiş olan bir fiil, somut olayda mirasbırakana karşı da yapılmış sayılacak şekilde taraflar arasındaki güven ilişkisini bozmuşsa, fiil, sanki mirasbırakana karşı işlenmiş gibi, dönme hakkı vermelidir.

Diğer bir grup yazar[325], MK 546/II'deki, *mirasbırakana karşı* ibaresi- 579
nin, sadece maddeye açıklık kazandırmak amacıyla kullanıldığı görüşündedirler. Bu bakımdan, dar yorumlamayı gerektiren bir durum söz konusu değildir. Kaldı ki, genellikle mirasbırakan ile arasında bir hısımlık bağı olmayan lehine tasarruf yapılan bir kişinin dar yorum sonucu, mirasbırakanın en yakın kan hısımları olan saklı paylı mirasçılardan daha fazla korunmasını gerektiren bir sebep de yoktur. Bu yüzden MK 546/II, MK 510'a uygun olarak geniş yorumlanmalı ve mirasbırakanın sadece kendisine değil, yakınlarına ya da ailesine karşı MK 510'da sayılan fiillerden biri işlenirse,

[323] Bkz., aşağıda § 16, XI.
[324] Bkz., *Dural*, Miras Sözleşmeleri, 236, dn.121'de anılan yazarlar.
[325] Bkz., *Dural*, Miras Sözleşmeleri, 238, dn. 129'da anılan yazarlar.

mirastan uzaklaştırmaya dayanılarak miras sözleşmesinden dönülmesine temel olabilmelidir[326].

ccc) Ehliyet

580 MK 546/III, mirastan çıkarma sebeplerinden birinin varlığı sebebiyle miras sözleşmesinden dönme için vasiyetname yapılmasını aradığına göre, mirasbırakanın vasiyetname yapma ehliyetine (MK 502) sahip olması gerekir. Ancak, miras sözleşmesi yapabilmek için ergin olmak şart olduğundan, dönme anında mirasbırakan daima ergin olacaktır. Aynı şekilde, miras sözleşmesi yaptıktan sonra kısıtlanan bir kimse, ayırt etme gücüne sahip olması şartıyla, miras sözleşmesinden dönebilir.

ddd) Şekil

581 Miras sözleşmesinden bir vasiyetname yapılarak dönülebilir (MK 546/III).

582 Dönme iradesi bir vasiyetname ile açıklanınca, lehine tasarruf yapılan kimsenin dönmeden zorunlu olarak mirasbırakanın ölümünden sonra haberi olacağından hareket edilerek, MK 546/III'ün bu hükmü, özellikle ivazlı miras sözleşmeleri yönünden çok tartışılmıştır[327]. Çünkü, mirasbırakan ivazı sağlığında elde etmekte ve bunu, miras sözleşmesinden dönmesine rağmen alıkoyabilecek, ivazı ödeyen kimse ise durumu onun ölümünden sonra öğreneceği için, ancak bundan sonra harekete geçebilecektir. Bu bakımdan, kanunda yazılı olmamakla beraber, mirasbırakanın, vasiyetname ile açıkladığı dönme iradesini karşı tarafa bildirmesinin doğru olacağı doktrinde haklı olarak teklif edilmektedir.

583 Dönme iradesinin vasiyetnamede açık olarak belirtilmesine gerek olmadığı ileri sürülmektedir. Vasiyetnamede, bu yolda yoruma müsait tutamak noktalarının bulunması şartıyla, vasiyetname içi ve dışı olgulara başvurularak yorum yoluyla anlaşılmasının da yeterli olduğu savunulmaktadır[328]. *Fikrimce*, baskın görüşle birlikte, mirastan çıkarma sebebinin MK 512/I'in örneksemeyle uygulanması sonucu dönmeye ilişkin vasiyetnamede gösterilmesi gerekir. Çünkü, ancak böyle olursa hâkim, itiraz hâlinde ileri sürülen sebebin mirastan çıkarma sebebi olup olmayacağını saptayabilir. Kaldı ki, saklı paylı mirasçılar ile miras sözleşmesiyle lehine tasarruf yapılan kimse arasında kurulan paralellik de bunu haklı gösterir. Nihayet, mirasbırakanın ölümünden sonraki tartışmaları önlemesi yönünden de sebebin gösterilmesinde yarar vardır.

---

[326] Borç ödemeden aciz sebebiyle mirastan uzaklaştırma hükümlerinin (MK 513) (koruyucu ıskat) miras sözleşmesine uygulanamayacağına ilişkin bkz., *Dural*, Miras Sözleşmeleri, 238 vd.

[327] Bu tartışmalar için bkz., *Dural*, Miras sözleşmeleri, 241 vd.

[328] BGE 64 II 339; 73 II 211.

cc) Mirastan çıkarma sebeplerinden birine dayanılarak dönmenin sonuçları

Miras sözleşmesinden, mirastan çıkarma sebeplerinden birine dayanıla- 584
rak dönmenin genel sonucu, diğer sona erme sebeplerinde olduğu gibi, ortadan kalkan tasarrufların yerine yasal mirasçılık hükümlerinin uygulanmasıdır, meğer ki, mirasbırakan aksine bir tasarrufta bulunmuş olsun.

Dönmenin miras sözleşmesine etkisine gelince; eğer sadece mirastan 585
çıkarma fiilini işleyen kişi lehine tasarruf ya da tasarruflar içeriyorsa, miras sözleşmesi artık konusuz kalacağı için, tümüyle hüküm doğurmaz. Buna karşılık miras sözleşmesinde başka tasarruflar da varsa, o zaman dönme, sadece mirastan çıkarmayı gerektiren fiili işleyen kişi yararına olan tasarrufları ortadan kaldırır, diğer tasarruflar yönünden miras sözleşmesi geçerliğini korumaya devam eder. Ancak, mirasbırakanın,mirastan çıkarmaya dayanarak döndüğü tasarruflar olmasa idi,diğer tasarrufları da yapmayacağı anlaşılıyorsa, o zaman iç bağlılık sebebiyle miras sözleşmesinin tümünden dönülmüş olur.

İvazlı miras sözleşmesinde, mirastan çıkarma sebeplerinden birine da- 586
yanılarak dönülmesi hâlinde, ivaz, ifa edilmişse sebepsiz zenginleşme kurallarına göre geri istenir. Ancak, dönme, mirasbırakanın ölümünden sonra hüküm ifade edeceği için, bu talep mirasçılara karşı ileri sürülebilecektir. Buna karşılık, ivaz henüz ifa edilmemişse, mirasbırakan ya da mirasçıları bunu isteme hakkını kaybederler.

İki taraflı miras sözleşmelerinde, taraflar, birbirleri lehine tasarrufta bulunmuş- 587
larsa,aradaki bağlantı sebebiyle, kural olarak, karşı tarafın da mirasbırakan lehine yaptığı tasarruflar ortadan kalkar. Ancak, tarafların böyle bir bağlantının bulunmadığını kararlaştırmaları mümkündür. Bu hâlde, diğer tarafın, sözleşmeden dönen lehine yaptığı tasarruflar geçerliklerini korurlar.

c) Miras sözleşmesinden, sağlar arası ivaz (karşılık) borcunun yerine getirilmemesi sebebiyle dönülmesi (sona ermesi)

aa) Genel olarak

MK 547'ye göre, *"Miras sözleşmesi gereğince sağlararası edimleri is-* 588
temeye hakkı bulunan taraf, bu edimlerin sözleşmeye uygun olarak yerine getirilmemesi veya güvenceye bağlanmaması hâlinde,borçlar hukuku kuralları uyarınca sözleşmeden dönebilir". Maddedeki borçlar hukuku kuralları ibaresi, iki tarafa borç yükleyen sözleşmelere ilişkin hükümlere, özellikle de BK 123/125'e yapılan atıf olarak anlaşılmalıdır[329].

[329] Bkz., Gerekçe, 486.

589 Hükümden açık olarak anlaşılacağı gibi, MK 547, sadece ivazlı miras sözleşmelerine uygulanır. Hükmün, ivazlı olması şartıyla, her iki tür miras sözleşmesini de,yani (olumlu) miras sözleşmesi ve mirastan feragat sözleşmesini kapsadığından kuşku yoktur.

590 Aslında, ivazlı miras sözleşmeleri, gerçek anlamda edim değiş tokuşu amacını güden tam iki tarafa borç yükleyen (sinallagmatik) sözleşmeler değildir. Çünkü, tam iki tarafa borç yükleyen sözleşmenin varlığı, her iki tarafın da hem alacaklı hem de borçlu olmasına bağlıdır. Oysa miras sözleşmesinde, mirasbırakan karşı tarafı ya da bir üçüncü kişiyi mirasçı atamak ya da vasiyet alacaklısı yapmakla borç altına girmemekte, aksine bir borcu yerine getirmiş olmaktadır. Karşı taraf, bir alacak hakkı elde etmeyip, sadece bir ivaz borcu altına girmektedir. Ne var ki, miras sözleşmelerinde, mirasbırakan yine de belli bir ölçüde karşı edimi elde etmek amacıyla bu sözleşmeyi yaptığından, tek bir işlem görünümünde olan ivazlı miras sözleşmelerini, kanunkoyucu, kolay bir çözüm elde etmek amacıyla, tam iki tarafa borç yükleyen sözleşmelere benzeterek, Borçlar Kanunu hükümlerine tabi tutmuştur.

591 Tüm dönme işlemleri gibi, MK 547'ye göre olan dönme de, yenilik doğuran bir irade açıklaması ile gerçekleşir. Karşı tarafa varması ile hüküm doğurur ve şekle tâbi değildir. Bu bakımdan, bir ölüme bağlı tasarruf olmasına rağmen, miras hukukundaki şekle bağlılığın bir istisnasıdır.

592 MK 547'ye göre dönmenin, bir ölüme bağlı tasarruf olmasının diğer bir sonucu, bunun da tüm diğer ölüme bağlı tasarruflar gibi, mutlak kişiye sıkı sıkıya bağlı bir hak olması, dolayısıyla da sadece hak sahibi tarafından (mirasbırakan ya da sözleşmenin karşı tarafı) kullanılabilmesidir. Bu sebeple dönme hakkı mirasçılara geçmez. Böyle olunca da, ivaz borcu yerine getirilmemesine rağmen, mirasbırakan, miras sözleşmesinden dönmeden ölecek olursa, mirasçılar da MK 547'ye göre miras sözleşmesini iptal edemeyeceklerine göre, ivaz borçlusu hem borcunu yerine getirmeyecek hem de miras sözleşmesinden doğan hakkını mirasçılardan isteyebilecek midir? Bu soruya kuşkusuz olumsuz cevap vermek gerekir. *Fikrimce*, böyle bir hâlde, ivazlı miras sözleşmeleri ile tam iki tarafı borç yükleyen sözleşmeler arasında kanunkoyucunun kurduğu benzerlikten hareketle, BK 81'den yararlanılarak, mirasçılara *ödemezlik defini* ileri sürme imkânı tanınmak suretiyle bir sonuca varılabilir. Şöyle ki, mirasbırakanın ivaz üzerinde sahip olduğu alacak hakkı terekesine dahil olduğu için, mirasçılara geçecektir. Şimdi, kendi ivazını hiç ya da gereği gibi yerine getirmemiş olan ölüme bağlı tasarruf lehdarı, mirasçılardan, miras sözleşmesinden kaynaklanan tasarrufun ifasını istediği zaman, mirasçılar (önce kendileri ifa yükümü altında olmamaları şartıyla) ödemezlik defini ileri sürerek, karşı edim, yanî miras sözleşmesindeki ivaz yerine getirilmediği sürece, ölüme bağlı tasarrufu yerine getirmekten kaçınabilirler.

bb) Sağlar arası ivaz borcunun yerine getirilmemesi sebebiyle miras sözleşmesinden dönmenin şartları

aaa) Dönme hakkı kime aittir?

593 Yukarıda da değinildiği gibi, MK 547'ye göre dönme hakkı, sağlar arası ivaz alacaklısına aittir. Buna göre miras sözleşmelerinde sağlar arası ivaz alacağı mirasbırakana ait olduğu için, dönme hakkı da ona aittir. Mirasbıra-

kan dönme anında sınırlı ehliyetsiz olsa bile, bu hakkı bizzat kendisi kullanır, yasal temsilcinin işleme katılmasına gerek yoktur. Çünkü, sınırlı ehliyetsiz mirasbırakan, dönme ile borç altına girmemekte, tam aksine, hem miras sözleşmesiyle yüklendiği taahhütten kurtulmakta hem de böylece tasarruf serbestisi elde etmektedir. Ancak belirtelim ki, yasal temsilcinin katılmasına gerek olmamakla beraber, bir engel de yoktur.

İvazlı mirastan feragat sözleşmelerinde, sağlararası ivaz alacaklısı, mi- 594
rastan feragat eden kimsedir. Böyle olunca da ivaz borcunun yerine getirilmemesi sebebiyle dönme hakkı da ona aittir.

bbb) Sağlar arası ivaz borçlusunun temerrüde düşmüş olması

MK 547'nin iki tarafa borç yükleyen sözleşmelere atıf yapması karşı- 595
sında, sağlar arası edim borcunun yerine getirilmemesi dolayısıyla miras sözleşmesinden dönebilmek için, edim borçlusunun BK 117'ye göre temerrüde düşürülmesi gerekir. Başka bir deyişle, sadece sağlar arası edim borcunu yerine getirmede gecikme, MK 547'ye göre dönme için yeterli olmayıp, bunun yanında BK 117/I'ye göre temerrüt ihtarı yapılmalı ya da BK 101/II'ye göre, ihtara gerek olmaksızın temerrüde düşülen hâllerden biri bulunmalıdır. Kuşku yoktur ki, ihtardan sonra BK 123/I'e göre, sağlar arası ivaz alacaklısı, karşı tarafa bir mehil verecek ya da mahkeme kanalıyla bir mehil verdirecektir. BK 124'ün şartlarının bulunduğu hallerde mehle gerek yoktur.

Bundan da anlaşılacağı üzere, her ne kadar burada sadece temerrüt hükümleri 596
üzerinde duruluyorsa da, MK 547 genel olarak iki tarafa borç yükleyen sözleşmelere atıf yaptığı için, bu sözleşmelere ilişkin diğer kurallar da ivazlı miras sözleşmelerine ve ivazlı mirastan feragat sözleşmelerine uygulanacaktır. Bu bakımdan, sağlar arası ivaz, borçlunun kusuru ile imkânsız hale gelirse, mirasbırakan ya da mirastan feragat eden kimse, BK 112'ye göre ifa etmeme sebebiyle tazminat isteyebilecektir. Sağlar arası ivaz borcunun kusursuz imkânsız hale gelmesinde, BK 136'ya göre sözleşme imkânsızlık sebebiyle sona ereceği için, dönmeye gerek kalmayacaktır.

ccc) Sağlar arası ivaz borçlusunun yeterli güvence (teminat) göstermemiş olması

Sağlar arası ivaz borcu altına giren diğer taraf ya da mirasbırakan, bor- 597
cun ifa edileceğine ilişkin yeterli teminat göstererek, diğer tarafın sözleşmeden dönmesini engelleyebilir.

cc) Miras sözleşmesinden, sağlar arası ivaz borcunun yerine getirilmemesi sebebiyle dönmenin sonuçları

Her ne kadar, MK 547, temerrüt yönünden BK 123'e atıf yapmaktaysa 598
da, maddede sadece dönmeden söz edilmesi karşısında, miras sözleşmesinden dönme hakkına sahip olan kimsenin BK 125/II'deki diğer hâllerden de

(ifa ve gecikme tazminatı ya da ifadan vaz geçip tazminat isteme) yararlanabilip yararlanamayacağı tartışmalıdır. Bu tartışmalara girmeden[330] baskın görüş üzerinde duralım. Baskın görüş, sağlar arası ivaz borcunun yerine getirilmemesi hâlinde, sağlar arası ivaz alacakısının, sadece dönme hakkına sahip olmadığı, BK 125/II'de belirtilen diğer haklardan da yararlanabileceği yönündedir. Buna gerekçe olarak, MK 547'nin sadece dönmeden söz etmesinin sebebinin, eski İsviçre Borçlar Kanununda temerrüt hâlinde sadece dönme hakkının tanınmış olması gösterilmektedir. Oysa bu günkü Borçlar Kanunu, dönme yanında diğer hakları da tanıdığına göre, yorumun da yeni metne uygun olarak geniş yapılması,böylece sağlar arası ivaz alacaklısına her üç imkânın da tanınması gerekir. Diğer bir gerekçe de ivazlı miras sözleşmeleri ile iki tarafa borç yükleyen sözleşmeler arasında her yönden paralellik kurulurken, burada, kanunun lafzına dayanarak bir fark yaratmayı haklı gösterecek bir durumun bulunmadığıdır. O halde, *fikrimce* doğru olan bu görüşe göre, ivazlı miras sözleşmesinde ivaz alacaklısı olan mirasbırakan, ivazlı mirastan feragat sözleşmesinde feragat eden, ivaz borçlusunun temerrüde düşmesi hâlinde, *sadece* dönme imkânından değil, BK 106/II'deki diğer iki imkân olan ifa ile birlikte tazminat ya da ifadan vaz geçip müspet tazminatı isteme yollarından birinden de yararlanabilir. Ancak güvence gösterilmişse, sağlar arası ivaz alacaklısı, BK 125/II'deki imkânlardan hiç birine başvuramaz.

599 Dönme hakkının kullanılması ile miras sözleşmesi ya da mirastan feragat sözleşmesi geçmişe etkili *(ex tunc)* ortadan kalkar ve tarafların borçları da sona erer. Sağlar arası edim borçlusu, borcunu kısmen yerine getirmişse, bunu sebepsiz zenginleşme kurallarına göre geri ister. Miras sözleşmesi ile ölüme bağlı tasarrufta bulunan taraf ise tasarruf serbestisini kazanıp, isterse yeni bir ölüme bağlı tasarrufta bulunabilir.Bunu yapmamışsa, yasal mirasçılık kuralları uygulanır. Mirastan feragat eden ise,dönme ile feragat hükümsüz kalacağından mirasçılık sıfatını kazanır.

600 Dönme ile miras sözleşmesinin sona ermesi kuşkusuz, miras sözleşmesinde sadece sağlar arası ivaz ile bağlantılı olan tasarruflar için söz konusudur. Miras sözleşmesinde, dönmeye sebep olan ivazlı tasarruflar yanında başka ivazsız tasarruflar ya da bir taraflı tasarruflar varsa, bunlar yönünden miras sözleşmesi geçerliğini korur. Ancak dönülen ivazlı tasarruflar ile geri kalanlar arasında, dönülen tasarruf olmasa idi, diğerlerinin yapılmayacağı sonucuna vardıracak kadar sıkı bir iç bağ varsa, o zaman miras sözleşmesinin tümü bu iç bağ dolayısıyla ortadan kalkar.

---

[330] Bu tartışmalar için bkz., *Dural*, Miras Sözleşmeleri, 258.

3. Mirasbırakanın, miras sözleşmesine aykırı düşen tasarrufları

a) Genel olarak

MK 527'ye göre, *"Mirasbırakan, miras sözleşmesiyle mirasını veya be-* 601
lirli malını sözleşme yaptığı kimseye ya da bir üçüncü kişiye bırakma yükümlüğü altına girebilir.

Mirasbırakan malvarlığında eskisi gibi tasarruf edebilir; ancak miras 602
sözleşmesindeki yükümlülüğü ile bağdaşmayan ölüme bağlı tasarruflarına ya da bağışlamalarına itiraz edilebilir"

Maddeden açık olarak anlaşılacağı üzere, miras sözleşmesi yapmak, 603
mirasbırakanın, sözleşmenin konusu olan mallar üzerinde, sağlar arası ya da ölüme bağlı tasarruf yapmasını kural olarak engellememektedir. Ancak, bağışlamalar (bunu sağlar arası ivazsız kazandırmalar şeklinde anlamak gerekir) ve ölüme bağlı tasarruflar için, MK 527/II bir istisna getirmekte ve miras sözleşmesi ile lehine tasarruf yapılan kimseye, bu işlemlere, miras sözleşmesine aykırı olduğu kadarıyla *itiraz* etme imkânı tanımaktadır. Belirtmek gerekir ki, itiraz imkânının bulunduğu hâllerde dahi, mirasbırakanın, miras sözleşmesi ile bağdaşmayan sağlar arası ivazsız kazandırmaları ya da ölüme bağlı tasarrufları yine geçerlidir. Ancak, miras sözleşmesi ile lehine tasarrufta bulunulan kişi, bunları kısmen ya da tamamen geçersiz hâle getirebilir.

Kanunkoyucunun, bir yandan mirasbıkakanın tasarruf serbestisinin de- 604
vam ettğine kabul etmesi, öte yandan da miras sözleşmesi ile lehine tasarruf yapılan kimselere,bu tasarrufla bağdaşmayan sağlar arası ivazsız ya da ölüme bağlı tasarruflara karşı ölümünden sonra itiraz etme imkânını tanımasının sebebi, bu yolla mirasbırakanın, kanunda öngörülen hâller dışında, miras sözleşmesinden bir taraflı olarak dönmesini engellemektir. Çünkü, bu imkân tanınmasaydı, mirasbırakan, bir dönme sebebi bulunmamasına rağmen, miras sözleşmesiyle bağdaşmayan tasarruflarla, dolaylı da olsa, her zaman dönme imkânını elde etmiş olurdu. Bu tasarrufların kendiliğinden hükümsüz sayılmayıp, itiraz etmeye bağlanmasının sebebi de, daha önce de değinildiği gibi, saklı paylı mirasçılar ile miras sözleşmesiyle lehine tasarruf yapılan kimse arasında kurulan paralelliktir. Nasıl saklı paya tecavüz teşkil eden tasarruflar ancak tenkis talebi ile indirilebiliyorlarsa, miras sözleşmesine aykırı olan tasarruflar da, itiraz edilmedikçe, geçerli kalsınlar istenmiştir. Miras sözleşmesi ile bağdaşmayan bu tür tasarruflara mirasbırakanın ölümünden sonra itiraz etme imkânının tanınması ise, mirasbırakanın tasarruf yetkisinin devam etmesinin doğal bir sonucudur.

605 MK 527/II, mirasbırakanın sadece miras sözleşmesi ile bağdaşmayan ivazsız sağlar arası kazandırmalarıyla ölüme bağlı tasarruflarının akıbetinin ne olacağını düzenlemektedir. Oysa, miras sözleşmesine aykırı tasarruflar sadece bunlardan ibaret değildir. Örneğin, mirasbırakan, miras sözleşmesi ile vasiyet ettiği malı satarak (ivazlı sağlar arası tasarruf) ya da fiili davranışlarla da (israf, vasiyet edilen şeyi hor kullanıp değerini düşürme ya da yok etme) miras sözleşmesine aykırı davranabilir. Bu sebeple, burada, önce kanunda belirtilen hâller, sonra da kanunda öngörülmemiş olan durumların nasıl çözüme bağlanması gerektiği üzerinde durulacaktır.

b) Kanunda düzenlenen hâller

aa) Mirasbırakanın, miras sözleşmesi ile bağdaşmayan ölüme bağlı tasarrufları

606 MK 527/II'ye göre, mirasbırakanın, miras sözleşmesinden sonra yaptığı, miras sözleşmesi ile bağdaşmayan ölüme bağlı tasarruflarına, lehdar (atanmış mirasçı ya da vasiyet alacaklısı), mirasbırakanın ölümünden sonra itiraz edebilir. Sonradan yapılan ölüme bağlı tasarrufun, vasiyetname ya da miras sözleşmesi olmasının önemi yoktur.

607 Miras sözleşmesinin, kendisinden önce yapılan vasiyetname ile bağdaşmaması hâlinde, bu vasiyetnameye itiraz etmeye gerek yoktur. Çünkü bu halde, MK 544/I'deki, vasiyetnamenin kendisinden sonra yapılan ölüme bağlı tasarruf ile geri alındığı karinesi yürür. Buna karşılık, bir miras sözleşmesi sonraki miras sözleşmesi ile bağdaşmıyorsa, MK 544/I'deki geri alınma karinesi işlemeyeceği için, MK 527 uygulanır. Ne var ki, bu halde de itiraz etme hakkı, bir önceki miras sözleşmesi ile lehine vasiyet yapılan kimsededir, yoksa bir sonraki ile lehine tasarruf yapılanda değil.

608 MK 527/II'ye göre, sonradan yapılan ölüma bağlı tasarrufun tümüne değil, sadece miras sözleşmesi ile bağdaşmayan hükümlerine itiraz edilebilir. O halde bağdaşmamanın ölçüsü nedir? Genel olarak denilebilir ki, sonradan yapılan ölüme bağlı tasarruflar, iptal edilmedikçe, miras sözleşmesi ile yapılan ölüme bağlı tasarrufun ifası imkânsızsa, bağdaşmazlık vardır. Örneğin, M, miras sözleşmesi ile A'ya vasiyet ettiği evini, sonraki bir vasiyetname ya da miras sözleşmesi ile B'ye vasiyet edecek olursa, B bu tasarrufa itiraz edebilir. Ya da M, terekesinin 3/4'ü için A'yı mirasçı atar ve daha sonra da, yaptığı ölüme bağlı tasarruf ile B'yi terekesinin 1/2'si için mirasçı atayacak olursa, A, B'ye bırakılan 1/2'nin, kendisine yapılan tasarrufla bağdaşmayan 1/4'üne itiraz edebilir. Aynı şekilde, miras sözleşmesi ile kayıtsız şartsız mirasçı atanan A'ya, sonraki bir ölüme bağlı tasarruf ile bir mükellefiyet yüklenecek olursa, A bu mükellefiyete itiraz edebilir. Bir defa daha hatırlatalım ki, itiraz ancak mirasbırakanın ölümünden sonra ileri sü-

rülebilir. Miras sözleşmesi ile bağdaşan sonraki ölüme bağlı tasarruflara ise itiraz edilemez.

Belirtmek gerekir ki, MK 527/II, miras sözleşmelerindeki bir taraflı ve bu sebeple de bağlayıcı olmadıkları için vasiyetname hükmüne tabi olan tasarruflara uygulanmaz. Çünkü bunlar, miras sözleşmesinde bulunmalarına rağmen MK 544'e tâbidirler, yani bu tasarruflar yönünden, sonraki ölüme bağlı tasarruf ile geri alınma karinesi yürür. 609

Bazı hâllerde, miras sözleşmesi ile bağdaşmamasına rağmen, sonradan yapılan ölüme bağlı tasarrufa itiraz edilemez. Örneğin, tarafların miras sözleşmesine aykırı tasarrufların geçerli olacağını kararlaştırmaları; miras sözleşmesinden dönülmüş ya da miras sözleşmesine anlaşmayla son verilmiş veya lehine tasarruf yapılan kimsenin, bu aykırı tasarrufa sonradan rıza göstermiş olması hâllerinde, sonraki ölüme bağlı tasarrufa MK 527/II'ye dayanılarak itiraz edilemez. 610

bb) Miras sözleşmesi ile bağdaşmayan sağlar arası ivazsız (karşılıksız) tasarruflar

MK 527/II'ye göre, miras sözleşmesinden sonra yapılan ve miras sözleşmesi ile bağdaşmayan sağlar arası ivazsız kazandırmalara (bağışlamalara) da itiraz edilebilir. Kazandırmaların hangi saikle yapıldığının önemi yoktur. Başka bir deyişle, mirasbırakan, sağlar arası ivazsız kazandırmayı, miras sözleşmesi ile lehine tasarruf yaptığı kimseye zarar vermek amacıyla yapmamış olsa bile, bunların bertaraf edilmesi mümkündür[331]. 611

MK 527/II, sağlar arası ivazsız kazandırmalarda da miras sözleşmesi ile bağdaşmamayı aradığına göre, yapılan sağlar arası kazandırmanın böyle bir nitelikte olup olmadığı yönünden durumu, miras sözleşmesi ile yapılan tasarrufun mirasçı atama ya da vasiyet tasarrufu olması yönünden ayrı ayrı incelemek gerekir. 612

Mirasçı atamada, mirasbırakan, miras sözleşmesi ile bir kimseyi, terekesinin tamamı ya da kesirli bir bölümü için hak sahibi yapmaktadır. Bu halde, mirasçı atanan kimse, mirasbırakanın sağlığında yapmış olduğu karşılıksız kazandırmalara MK 527/II'ye dayanarak, kural olarak, itiraz edemez. Çünkü, mirasbırakan ona belirli bir şeyi değil, terekesinin tamamı ya da kesirli bir bölümünü bırakmıştır. Mirasçı atanan kimsenin bu hakkının kapsamı, miras sözleşmesinin yapıldığı âna göre değil, ölüm ânına göre belirlenir. Mirasçı atanan kimse, miras açıldığı anda terekede ne varsa onunla ya da var olanın belirli bir kesirli oranıyla yetinmek zorundadır. Örneğin, A'nın miras sözleşmesi ile atandığı anda terekenin değeri bir milyar TL'dır ve A, terekenin 1/4'ü için mirasçı atanmıştır. Terekenin ölüm ânındaki değeri, mirasbırakanın sağlığında yaptığı ivazsız kazandırmalar sonucu 500 Milyon TL'na düşmüş olsa A, bu miktarın 1/4'ü ile yetinmek zorundadır. 613

[331] Farklı bir düzenleme için bkz., BGB § 2278/2288.

Çünkü, onun hakkının içeriği malvarlığının, yâni terekenin ölüm ânındaki değerine göre saptanacaktır. Aksinin kabulü hâlinde, mirasçı atanan kimse, mirasbırakanın sağlığında yaptığı her ivazsız kazandırmaya miras sözleşmesi ile bağdaşmadığı gerekçesiyle itiraz etme imkânını elde eder ki, bu da MK 527/II'deki mirasbırakanın tasarruf serbestisinin devam ettiği hükmüne aykırı olur.

614 Kural, mirasçı atanması hâlinde, mirasbırakanın sağlığında yaptığı ivazsız kazandırmalara itiraz edememek ise de, bunun iki istisnası vardır. Bunlardan birincisi, mirasbırakanın, miras sözleşmesine aykırı tasarruflarda bulunmayacağını taahhüt etmesidir. Bu taahhüt bir ölüme bağlı tasarruf olmadığı için, şekle bağlı değildir, örtülü olarak da yapılabilir. İşte, böyle bir taahhüt varsa, miras sözleşmesi ile mirasçı atanan kimse, sağlar arası tasarruflara itiraz edebilir. Bu itiraz MK 527/II'ye göre olacağı için, ancak mirasbırakanın ölümünden sonra mümkündür.

615 Miras sözleşmesi ile mirasçı atanması hâlinde, mirasçı atanan kimsenin, mirasbırakanın sağlığında yaptığı ivazsız kazandırmalara itiraz edebileceği ikinci hâl, mirasbırakanın atanmış mirasçıya zarar vermek amacıyla hareket etmesidir. Kötüniyetle hareket eden mirasbırakan, miras sözleşmesini içi boş bir kalıp hâline getirebilir. İşte bu sebepledir ki, mirasbırakanın, miras sözleşmesiyle atadığı mirasçıya, kötüniyetle zarar vermesini engellemek amacıyla, saklı paylı mirasçı ile *atanmış saklı paylı mirasçı* arasında kurulan parallelikten hareketle, MK 565 b. 4 örneksemeyle uygulanarak, atanmış mirasçının itiraz edebileceği kabul edilmektedir. Hemen belirtmek gerekir ki, MK 565 b. 4, ivazlı miras sözleşmelerine örneksemeyle dahi uygulanamaz. Çünkü ivazlı miras sözleşmelerinde, mirasbırakanın, atanmış mirasçıya zarar vermek için yaptığı sağlar arası ivazsız tasarruflar MK 527'ye tâbidirler.

616 Miras sözleşmesi ile vasiyet yapılmasına gelince; mirasbırakanın bir malını miras sözleşmesi ile vasiyet etmesi ve sonra da bunu sağlar arası bir ivazsız tasarruf ile üçüncü kişiye devir etmesi hâlinde, lehine tasarruf yapılan kimse MK 527/II'ye göre mirasbırakanın ölümünden sonra itiraz edip malı üçüncü kişiden alabilir. Bunun için ayrıca mirasbırakanın taahhüdü aranmaz. Yapılan ivazsız sağlar arası kazandırmanın bu taahhüdü de içerdiği kabul edilmektedir.

617 Aslında MK 527/II, MK 517/III'e bir istisna getirmektedir. MK 517/III'e göre, *"Bırakılan belirli mal terekede bulunmadığı takdirde, tasarruftan aksi anlaşılmadıkça, ölüme bağlı tasarrufu yerine getirmekle yükümlü olanlar borçtan kurtulurlar"*. Bundan da anlaşılacağı gibi, MK 517/III'e göre, vasiyet edilen şey terekede bulunmadığı zaman, vasiyet kural olarak hükümsüz hâle gelir. Oysa, miras sözleşmesinde durum, MK 527/III gereği tam tersinedir. Çünkü, miras sözleşmesi ile vasi-

yet edilen şey, terekede bulunmazsa (imkânsız olmaması şartıyla), itiraz ile vasiyetin ifası temin edilebilir.

Belirtmek gerekir ki, MK527/III, terekede bulunan muayyen bir şeyin vasiyet 618
edilmesi hâlinde uygulanmaktadır. Tedarik ya da çeşit vasiyetinin söz konusu olduğu hallerde, tedarik etme yükümlülüğü bulunduğu; çeşit vasiyetinde ise kural olarak imkânsızlık söz konusu olmayacağı için *(genus non perit)* vasiyet yine ifa edileceğinden için, MK 527/III'e gitmeye gerek yoktur.

cc) Müeyyide

Yukarıda da sık sık değinildiği gibi, MK 527/II miras sözleşmesine ay- 619
kırı ölüme bağlı ya da sağlar arası ivazsız tasarruflara karşı itiraz edilebileceğini söylemektedir. Bu terim MK 527/II'yi karşılayan ZGB Art. 494/III'e uygun olarak, *iptal (Anfechtung)* şeklinde anlaşılmalıdır. Bu iptal davasının niteliğinin ne olduğuna ilişkin kanunda açık bir hüküm yoktur. Miras sözleşmesi ile atanan mirasçı ya da vasiyet alacaklısının, bir çeşit sözleşmeden kaynaklanan saklı payının olduğundan hareketle, Gerekçede de *belirtildiği* gibi[332], iptal davasına, tenkis davasına ilişkin hükümlerin (MK 560) örneksemeyle uygulanacağı kabul edilmektedir.

İptal (tenkis) davası, mirasbırakanın hem sağlar arası ivazsız hem de 620
ölüme bağlı tasarruflarına karşı açılabilir. *Ancak davanın mirasbırakanın ölümünden sonra açılabileceğini bir defa daha hatırlatalım.*

İptal davasında davacı sıfatı, miras sözleşmesi ile lehine ölüme bağlı ta- 621
sarruf yapılan kimseye aittir. Bu sebeple, mirasbırakanın ölümünde herhangi bir sebeple mirasçı ya da vasiyet alacaklısı sıfatına nail olamayan kişiler iptal davası açamazlar. Eğer, yedek ya da art mirasçı varsa veya yedek ya da art vasiyet alacaklısı varsa, asıl ya da ön mirasçı veya vasiyet alacaklısının bu sıfatı kazanamadığı hâllerde, dava açma hakkı bu kişilere geçer. Davalıysa, lehine miras sözleşmesine aykırı sağlar arası ivazsız kazandırma yapılan ya da miras sözleşmesinden sonraki bir ölüme bağlı tasarruf ile mirasçı atanan ya da vasiyet alacaklısı yapılan kimsedir. Davaya tenkis hükümleri örneksemeyle uygulanacağından, davalının iyiniyetli olması hâlinde geri verme yükümlülüğü MK 566/I'e tabidir. Davada, mirasbırakanın miras sözleşmesine aykırı olarak yaptığı tasarrufun, miras sözleşmesi ile bağdaşmayan kısmının iptali (tenkisi) istenir.

c) Mirasbırakanın, kanunda düzenlenmemiş olan miras sözleşmesine aykırı tasarrufları

Yukarıda da değinildiği gibi, MK 527/III, sadece miras sözleşmesine 622
aykırı sağlar arası ivazsız kazandırmalar ve ölüme bağlı tasarrufların iptali-

[332] Gerekçe, 481.

ni öngörmüştür. Oysa, mirasbırakanın bunlar dışında da, özellikle sağlar arası ivazlı hukukî ya da fiili tasarruflar yoluyla miras sözleşmesine aykırı davranması mümkündür ya da, sonradan ortaya çıkan yeni aile ilişkileri miras sözleşmesini etkileyebilir. Burada, kanunda düzenlenmemiş olan bu ihtimallerin en önemlileri üzerinde durulacaktır.

aa) Sağlar arası ivazlı tasarruflar

623 Bu konuda, miras sözleşmesi ile mirasçı atanması ve vasiyet tasarrufu yapılması üzerinde ayrı ayrı durulması gerekir.

624 Genel olarak kabul edilen görüş, mirasçı atanması hâlinde, mirasçının, mirasbırakanın küllî halefi olacağından hareketle onun, ölüm ânında terekede ne varsa bununla yetinmek zorunda olduğu ve bu sebeple de mirasbırakanın ivazlı sağlar arası tasarruflarına karşı bir şey yapamayacağı yönündedir. Kaldı ki, ivazlı devir hâlinde, malvarlığından çıkan şeyin yerini alan kaim değer *(surrogat, Ersatz)* terekede bulunacağı için, atanan mirasçı bir zarara uğramaz da. Denilebilir ki, devir edilen şeyin karşılığında mirasbırakanın eline genellikle bir miktar para geçecek ve o da bunu harcayacağı için, ölüm ânında tereke yine atanan mirasçı aleyhine azalmış olacaktır. Ne var ki, böyle bir hâle karşı saklı paylı mirasçılar dahi korunmadığına göre, atanan mirasçının buna haydi haydi katlanması gerekir.

625 İvazlı sağlar arası tasarrufun vasiyete etkisine gelince, baskın görüş, bu hâlde MK 517/III'e göre vasiyetin düşeceği yönündedir, meğer ki, miras sözleşmesinde kaim değerin vasiyetin yerini alacağı kararlaştırılmış, ya da böyle bir hüküm bulunmamakla beraber, yorum yoluyla mirasbırakanın iradesinin bu yönde olduğu anlaşılsın.

bb) Miras sözleşmesi ile yapılan tasarrufun, mirasbırakanın sonradan oluşan aile hukuku ilişkilerinden etkilenmesi

626 Miras sözleşmesinin yapılmasından sonra, mirasbırakanın aile hukuku ilişkilerinde değişiklik sonucu saklı paylı mirasçılar ortaya çıkabilir. Örneğin, miras sözleşmesini yaptığı anda, çocuğu olmayan mirasbırakanın bir çocuğu ya da mirasbırakan sonradan evlenebilir. Bunlar miras sözleşmesi ile lehine tasarruf yapılmış kimsenin menfaatini etkiler. Ne var ki, ortaya çıkan bu yeni durum, ne kadar aleyhine olursa olsun, o buna katlanmak zorundadır. Çünkü, bizim miras sistemimizde, daima saklı paylı mirasçıların önceliği vardır. Bu bakımdan, miras sözleşmesi ile lehine tasarruf yapılan kimse, böyle bir durumda hiç bir şey yapamayacağı gibi; aksine, ortaya çıkan saklı paylı mirasçıların ona karşı tenkis davası açmalarına katlanmak zorundadır. Bu husus, *"Miras sözleşmesi veya vasiyetname ile yapılan ölüme bağlı kazandırmalar, mirasbırakanın tasarruf edebileceği kısmın*

sonradan daralması yüzünden hükümsüz olmaz; sadece tenkis edilebilir" diyen MK 549'dan açıkça anlaşılmaktadır. Hemen belirtmek gerekir ki, MK 549'un lafzından anlaşılacağı üzere, böyle bir durumda, miras sözleşmesi ile yapılan ölüme bağlı tasarruf kendiliğinden hükümsüz olmaz. Bunun için saklı paylı mirasçıların tenkis davası açması gerekir. Bu hâlde dahi, miras sözleşmesi ile yapılan tasarruf yine geçersiz olmayıp, sadece saklı paya tecavüz ettiği oranda tenkise tabi olur. Tabii, miras sözleşmesindeki tasarruf, saklı paya tecavüz dolayısıyla tümüyle tenkis edilecek olursa bu, son tahlilde, hükümsüz olma ile aynı sonucu doğurur.

cc) Mirasbırakanın sağlığında malvarlığını israf etmesi ya da fiilî tasarruflar yoluyla miras sözleşmesiyle lehine tasarruf yapılan kimseye zarar vermesi

Mirasbırakanın malvarlığını israf etme, vasiyet ettiği şeyi kırma, bozma 627
ya da tamamen yok etme gibi yollarla miras sözleşmesine aykırı davranması hâlinde ne yapılacağına ilişkin kanunda bir düzenleme yoktur. Bu durum, özellikle ivazlı miras sözleşmelerinde sıkıntı yaratır. Çünkü, sağlar arası ivaz borcunu yerine getiren kimse bu hâllerde hiç bir şey elde edemeyebilir. Bu bakımdan, kanunda boşluk olduğu kabul edilerek, bu boşluğun doldurulması için bazı çözümler ileri sürülmüştür. Örneğin savurganlık hâlinde mirasbırakanın MK 406'ya dayanılarak kısıtlanması teklif edilmiştir. Ne var ki, bu çözüm sadece kısıtlamanın şartlarının olduğu durumlarda yarar sağlar. Diğer bir çözüm olarak, ivazlı miras sözleşmelerinde, MK 547'nin örneksemeyle uygulanması sonucu ivaz borcunu yerine getiren karşı tarafa sözleşmeden dönme hakkının tanınması teklif edilmiştir. Bu görüş de, sadece ivazlı miras sözleşmeleri için bir çözüm olabilir. Bu bakımdan, *fikrimce*, en emin, bütün miras sözleşmelerinde korumayı temin edecek tek yol, miras sözleşmelerine böyle bir durumda, karşı tarafın dönme hakkının bulunduğuna ilişkin bir hüküm konulmasıdır.

IV. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN KENDİLİĞİNDEN (KANUN GEREĞİ) SONA ERMESİ

Burada söz konusu olan hâllerde, vasiyetnamelerde geri alma, miras 628
sözleşmelerinde dönmeden farklı olarak, bir ölüme bağlı tasarrufun hiç bir işleme gerek kalmadan kanun gereği (kendiliğinden, *ipso iure*) yürürlükten kalkmasıdır. Bu durumun, geçersiz vasiyetnamelerin iptali ile karıştırılmaması gerekir. Çünkü, kanun gereği sona erme, geçerli bir ölüme bağlı tasarrufta kendiliğinden gerçekleşir. Oysa iptal, geçerli olmayan ölüme bağlı tasarruflarda söz konusudur ve ilgilinin dava açması gerekir. Bu hâller şunlardır:

1. Lehine ölüme bağlı tasarruf yapılan kimsenin mirasbırakandan önce ölmesi

629 MK 580/I'e göre, *"Mirasçı olabilmek için mirasbırakanın ölümü anında mirasa ehil olarak sağ olmak şarttır"*, MK 581/I'e göre, *"Vasiyet alacaklısı olabilmek için , mirasbırakanın ölümü anında mirasa ehil olmak ve sağ olmak şarttır"* ve nihayet MK 548/I'e göre, *"Mirasçı atanan veya kendisine belirli mal bırakılan kişi mirasbırakanın ölümünde sağ değilse, miras sözleşmesi kendiliğinden ortadan kalkar"*. Bütün bunlardan anlaşılacağı gibi, gerek vasiyetname gerek miras sözleşmesi, lehine tasarruf yapılan kimse mirasbırakandan önce ölürse, hiç bir işlem yapılmasına gerek olmaksızın kendiliğinden hükümsüz hâle gelir. Bu hükümsüzlük tam ya da kısmî olabilir. Vasiyetname ya da miras sözleşmesinin içeriği ölen kişi yararına ölüme bağlı tasarruflardan ibaretse, tam geçersizlik söz konusudur. Buna karşılık, şeklî ölüme bağlı tasarrufta, ölen kişi lehine olanların yanında başka tasarruflar da varsa, sadece ölen lehine olanlar hükümsüz hâle gelir, diğerleri geçerliklerini korurlar, meğer ki, ölen kişi lehine yapılan tasarruflar ile diğer tasarruflar arasında bir iç bağlantı bulunsun.

630 Yukarıda belirtilen hükümlerden anlaşılacağı gibi, ölüme bağlı tasarrufun kanun gereği hükümsüz olabilmesi için, *lehine ölüme bağlı tasarruf yapılan kimsenin* mirasbırakandan önce ölmesi gerekir. Bu bakımdan üçüncü kişi yararına miras sözleşmelerinde, lehine tasarruf yapılan üçüncü kişinin (yoksa miras sözleşmesinin diğer tarafının değil) mirasbırakandan önce ölmesi gerekir. Ancak MK 548/I, mirastan feragat edenin mirasbırakandan önce ölmesi hâlinde uygulanmaz. Çünkü, mirastan feragat eden ne mirasçı ne de vasiyet alacaklısı atanmış olmadığı gibi, bu konuda, ileride üzerinde durulacak olan MK 528[333] özel bir hüküm öngörmüştür.

631 Esasında MK 580/I ve MK 581/I'in yanında, miras sözleşmeleri için MK 548/I'in hükmüne gerek yoktu. MK 548/I'in hükmünün getirilmesinin amacı aslında, ivazlı miras sözleşmelerinde, lehine tasarruf yapılan kimsenin, mirasbırakandan önce ölmesi hâlinde peşin ödenen ivaz borcunun ne olacağını düzenleyen MK 548/II'ye bir giriş mahiyetindedir. MK 548/II'ye göre, sağlar arası ivaz borcunu ödemiş olan kişinin mirasçıları, onun mirasbırakandan önce ölmüş olması durumunda, ödenmiş olan ivazı sebepsiz zenginleşme kurallarına göre geri isterler. Bu talep BK 66'daki zamanaşımına tabidir. Ancak MK 548/II emredici olmadığı için aksi kararlaştırılabilir.

632 Lehine tasarruf yapılan kişinin mirasbırakandan önce ölmesi hâlinde, söz konusu ölüme bağlı tasarrufun hükümsüz olacağı kuralı emredici değildir. Önce MK 520 vd.ye göre yedek mirasçı ve art mirasçı atama yoluyla (ikameli tasarruflar) bertaraf edilmesi mümkündür. Bunun üzerinde aşağıda

---

[333] Bkz., aşağıda, § 16, VIII.

durulacaktır[334]. İkinci olarak MK 572, miras sözleşmeleri için özel bir düzenleme getirmiştir. Bu hükme göre, *"Mirasbırakan sağlığında bütün malvarlığını miras sözleşmesiyle atadığı mirasçıya devretmişse, bu mirasçı resmî defter düzenlenmesini isteyebilir.*

Mirasbırakan malvarlığının tamamını devretmemişse veya tamamını 633
devrettikten sonra yeni mallar edinmişse; miras sözleşmesi, aksine bir kural içermedikçe, yalnız sağlıkta devredilmiş olan malları kapsar.

Mirasbırakanın sağlığında malları devretmesi hâlinde, miras sözleşme- 634
sinde başka bir kural yoksa, miras sözleşmesinden doğan hak ve borçlar atanmış mirasçının mirasçılarına geçer".

Görüldüğü gibi MK 572, biri konumuz ile ilgili olmak üzere iki karine 635
getirmiştir. MK 572/III'deki karineye göre, miras sözleşmesi ile mirasçı atanan kimseye hakkı mirasbırakan hayattayken devredilmişse, o, mirasbırakandan önce ölmüş olsa bile, teslim edilenler onun mirasçılarına ait olur, yoksa, ana kural gereği mirasbırakan bunları geri isteyemez. Fakat bu kural emredici olmadığı için aksi kararlaştırılabilir.

Miras sözleşmelerinde, hakkın sağlıkta devredilmiş olması hâli için 636
MK 572'nin getirdiği ikinci karineye göre, miras sözleşmesi ile mirasçı atanan kimseye mirasbırakan, malvarlığını ya da bunun, miras sözleşmesinde öngörülen oranını sağlığında devretmişse, atanmış mirasçının payı bundan ibarettir. Bunun anlamı, atanan mirasçının, mirasbırakanın ölümü hâlinde, tereke üzerinde hiç bir hakkının olmayacağıdır. Ancak bu hüküm bir karine olduğu için aksinin kararlaştırılması mümkündür[335].

2. Boşanma

MK 181/I'e göre, *"Boşanan eşler, bu sıfatla birbirlerinin yasal miras-* 637
çısı olamazlar ve boşanmadan önce yapılmış olan ölüme bağlı tasarruflardan kendilerine sağlanan hakları, aksi tasarruftan anlaşılmadıkça, kaybederler". Kanunun, evlenmenin sona ermesi sebebiyle, eşlerin birbirleri lehine yapmış oldukları ölüme bağlı tasarrufların sona ereceğini kabul etmesinin sebebi, bunların evlenmenin devam edeceği karinesiyle yapılmış olmalarıdır[336].

Aynı düzenleme, boşanma davası devam ederken davacının ölmesi ve 638
onun mirasçılarından birinin davaya devam edip, sağ kalan eşin boşanmada daha fazla kusurlu olduğunu ispat etmesi durumu için de öngörülmüştü.

---

[334] Bkz., aşağıda § 16, IV.
[335] Bu konuda etraflı bilgi için bkz., *Dural*, Miras Sözleşmeleri, 222 vd.
[336] *Dural*, Miras Sözleşmeleri, 209 ve dn. 14'de atıf yapılan yazarlar.

Ancak 6217 sayılı kanunla[337] hükümde değişiklik yapılarak bu hak hem davacı hem de davalının mirasçılarına tanınmıştır.

639 Evlilik boşanmayla sona erince, sadece, eşlerin birbirleri lehine yaptıkları miras sözleşmesi değil, onların üçüncü kişi lehine yaptıkları miras sözleşmeleri de sona erer. Ancak, üçüncü kişinin, eş ya da eşler ile bir hısımlığının ya da yakınlığının bulunmadığı hâllerde, yorumla, mirasbırakanın bu durumu (yani evliliğin sona ereceğini) bilseydi dahi miras sözleşmesini yine de yapacağı sonucuna varılabilirse, miras sözleşmesinin boşanmadan etkilenmeyeceğini kabul etmek gerekir[338].

640 Miras sözleşmesinin ivazlı olması hâlinde, evlenmenin boşanmayla sona ermesi durumunda, ivazın ne olacağına ilişkin özel bir düzenleme yoktur. Bu bakımdan MK 548/II örneksemeyle uygulanır ve ivaz geri istenir[339].

641 MK 181/I'in açık ifadesine göre, boşanma, eşlerin evlilik devam ederken birbirleri lehine yaptıkları yaptıkları ölüme bağlı tasarruflar kanun gereği hükümsüz olurlar. Boşanmadan sonra (eski) eşlerin birbirleri lehine yaptıkları ölüme bağlı tasarruflar geçerlidir.

3. Evliliğin butlanına karar verilmesi

642 MK 159, evlenmenin butlanına karar verilmesinin eşlerin birbirleri lehine yaptıkları ölüme bağlı tasarrufa etkisinin ne olacağı hususunda şu düzenlemeyi getirmiştir: *"Evlenmenin butlanını dava etme hakkı mirasçılara geçmez. Ancak, mirasçılar açılmış olan davayı sürdürebilirler. Dava sonunda evlenme sırasında iyiniyetli olmadığı anlaşılan sağ kalan eş, yasal mirasçı olamayacağı gibi, daha önce yapılmış olan ölüme bağlı tasarruflarla kendisine sağlanan hakları da kaybeder"*[340].

4. Mirastan yoksunluk sebeplerinden birinin varlığı

643 MK 578'deki mirastan yoksunluk sebeplerinden birinin varlığı hâlinde de vasiyetname ve miras sözleşmesi kanun gereği sona erer. İvazlı miras sözleşmelerinde, ivazın geri alınabilmesi için MK 548/II örneksemeyle uygulanır[341].

---

[337] RG 27905.
[338] *Dural*, Miras sözleşmeleri, 210.
[339] *Dural*, Miras Sözleşmeleri, 210.
[340] Bu konuda etraflı bilgi için bkz., yukarıda § 4, III, 2.
[341] *Dural*, Miras Sözleşmeleri, 211 ve dn 21 atıf yapılan yazarlar.

5. Bozucu şartın gerçekleşmesi ya da geciktirici şartın gerçekleşmemesi

Miras sözleşmelerinde ve vasiyetnamelerde bozucu şartın mirasbırakan 644
ölmeden gerçekleşmesi, geciktirici şartın ise onun ölümünden sonra gerçekleşmemesi gerekir[342]. Aksi hâlde miras sözleşmesi kanun gereği hükümsüz olur

6. Sözlü vasiyetname

MK 541'e göre, sözlü vasiyetname, vasiyetçinin olağan vasiyetname 645
türlerinden birine başvurabilmesi imkânının doğmasından itibaren bir ay geçince hükümden düşer.

§ 15. Maddî anlamda ölüme bağlı tasarruflar[343]

I. MADDÎ ANLAMDA ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

Maddî anlamda ölüme bağlı tasarrufların neler olduğu, kural olarak, 646
Medenî Kanunun, Miras Hukuku kitabının, birinci kısmının üçüncü ayırımında (MK 514-530) sayılmıştır. Ancak, hemen belirtmek gerekir ki, maddî anlamdaki ölüme bağlı tasarruflar, sadece orada sayılanlardan ibaret değildir. Medenî Kanunun diğer kitaplarında ve Miras Hukuku kitabının başka yerlerinde de (MK 510/513, 528, 550) maddî anlamda ölüme bağlı tasarruflar bulunmaktadır. Bunların bir kısmı miras hukuku ile ilgili, diğerleri ise miras hukuku ile ilgili değildir. Miras hukukuyla ilgili maddî anlamda ölüme bağlı tasarruflar, ister Medenî Kanunun Miras Hukuku kitabında, ister diğer kitaplarda yer alsınlar, mirasbırakanın terekesi ve ona halef olma ile ilgilidirler (dar anlamda maddî ölüme bağlı tasarruflar). Mirasçı atanması, vasiyet, yedek ya da art mirasçı atama, koşul (şart) ve yükleme (mükellefiyet), mirastan çıkarma, paylaşma kuralları, vasiyeti yerine getirme görevlisi (vasiyeti tenfiz memuru) atama, vakıf kurma, mirastan feragat başlıca önemli örneklerdir.

Hemen belirtmek gerekir ki, sayılan örneklerden bazıları dar anlamda ölüme 647
bağlı tasarruf olmadıkları hâlde, tereke ve mirasçılığı etkilediği için, maddî anlamda ölüme bağlı tasarruf kavramı geniş alınarak, buna dahil edilmişlerdir. Feragat, koşul ve yükleme buna örnek olabilir.

---

[342] *Dural*, Miras Sözleşmeleri, 212 ve orada dn. 23'de atıf yapılan yazarlar.

[343] Bu paragrafta verilen bilgiler, *Dural*, Miras Sözleşmeleri, 103-114'den alındıkları için, gerekli olmadıkça ayrıca başka yerlere atıf yapılmayacaktır.

648 Yukarıda örnek olarak sayılan maddî anlamda ölüme bağlı tasarruflar, doğurdukları etkiye göre iki grupta toplanabilirler. Bunlardan birincileri, doğrudan tereke üzerinde etki yapan tasarruflardır (mirasçı atanması, vasiyet, mirastan çıkarma gibi). İkinci grupta olanlar ise, mirasbırakanın ölüme bağlı emirlerinin yerine getirilmesini temin ederler (vasiyeti yerine getirme görevlisi atanması ve paylaştırma kuralları gibi).

649 Miras hukukuyla ilgili yapılabilecek maddî anlamda ölüme bağlı tasarruflarda (şeklî anlamda ölüme bağlı tasarrufarda olduğu gibi) *numerus clausus* prensibi yürür. Başka bir deyişe, mirasbırakanın yapmış olduğu ölüme bağlı tasarrufun mirasçıları bağlaması için, bunların MK 514 vd.da ya da Miras Hukuku kitabının başka bir yerinde veya Medenî Kanunun başka kitaplarında maddî anlamda ölüme bağlı tasarruf olarak öngörülmüş olması gerekir. Eğer mirasbırakanın yapmış olduğu tasarruf hiçbir yerde maddî anlamda ölüme bağlı tasarruf olarak belirtilmemişse ve yorumla da bir sonuca varılamıyorsa, bunun bağlayıcılığı yoktur, yani mirasçılar buna uymak zorunda değildirler ve bu konuda onları hiç kimse zorlayamaz. Örneğin mirasbırakanın, mezarının nasıl düzenlenmesini istediği bir ölüme bağlı tasarrufla belirtilmişse, bu, yukarıda sayılan anlamda bağlayıcı olmadığı için, mirasçılar bu isteği yerine getirmek zorunda değildirler. Meğer ki bu husus bir yükleme olarak öngörülmüş olsun (MK 515).

650 Yukarıda belirtildiği gibi, maddî anlamda ölüme bağlı tasarrufların bir kısmı, doğrudan miras hukukuyla ilgili olmayıp, Medenî Kanunun diğer dallarını da ilgilendirirler. Bunun en tipik örnekleri, ölüme bağlı tasarrufla vakıf kurma (MK101, 526) ve evlilik dışı çocuğun tanınmasıdır (MK 295 vd).

651 İçeriği sadece miras hukukuyla ilgili olmayan tasarruflardan oluşan bir ölüme bağlı tasarruf da gerçek şeklî anlamda bir ölüme bağlı tasarruftur. Başka bir deyişle, şeklî anlamda ölüme bağlı tasarruftan söz edebilmek için, içeriğinde mutlaka miras hukukuyla ilgili bir tasarrufun bulunması gibi bir zorunluluk yoktur. Örneğin, sırf evlilik dışı çocuğun tanınmasını içeren bir vasiyetname de gerçek anlamda bir vasiyetnamedir. Fakat, *fikrimce*, miras sözleşmesi yönünden buna bir istisna getirmek gerekir. Çünkü, miras sözleşmesinden söz edebilmek için, onun, niteliği gereği, en az bir bağlayıcı maddî anlamda ölüme bağlı tasarrufu içermesi gerekir. Bunun da tereke ile ilgili olması gerektiği, miras sözleşmesinin içeriğini düzenleyen MK 527'den anlaşılmaktadır.

II. MADDÎ ANLAMDA ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLA ŞEKLÎ ANLAMDA ÖLÜME BAĞLI TASARRUF ARASINDAKİ İLİŞKİ

652 Burada iki konu üzerinde durulacaktır.Birincisi, MK 514-530 arasında sayılan ölüme bağlı tasarrufların hepsinin hem vasiyetname hem de miras sözleşmesi ile yapılabilip yapılamayacaklarıdır. İkincisi ise, eğer bazı ölü-

me bağlı tasarruflar sadece vasiyetname ile yapılabiliyorlarsa, bunların miras sözleşmesi içinde yer almalarının akıbetinin ne olacağıdır.

MK 514- 530 incelendiği zaman, maddî anlamda ölüme bağlı tasarruf- 653
ları konumuzla ilgili olarak üç grupta toplamanın mümkün olduğu görülür.

1. Sadece miras sözleşmesi ile yapılabilen ölüme bağlı tasarruflar

Burada bir tek tasarruf vardır ki, bu da *mirastan feragattır*. Bu hususu, 654
MK 528 açık olarak belirttiği gibi, 11.2.1955 tarih ve 16/14 sayılı İBK da aynı sonuca varmıştır.

> Söz konusu İçtihadı Birleştirme Kararının gerekçesine göre, *"Medenî Kanunun* 655
> *Mirasa ait olan kitabının 3. Faslının adı (ölüme bağlı tasarrufların muhtelif suretleridir). Gerçekten bu fasıldaki maddelerde vasiyet ve miras mukavelesinin konularının ne olacağı bildirilmiştir Bunlardan 474 ve 475 (yeni 527-528). maddeleri muhtevalarıyla matlapları incelenecek olursa 474. madde miras mukavelesinin konusunun mirasçı nasbı veya belli bir malın bir kimseye bırakılması olabileceğinin 475. maddede ise, miras mukavelesinin konusunun mirastan feragat olabileceğinin bildirildiği görülür. Demek ki, kanunumuza göre mirastan feragat mukavelesi miras mukavelesinin bir nevinden ibarettir. Bu itibarla mirastan feragat mukavelesi (bütün miras mukaveleleri gibi) Medenî Kanunun 492.maddesi (yeni 545) hükmünce resmi vasiyet şeklinde yapılması gerekir"*
>
> Kanunun bu açık hükmü ve İçtihadı Birleştirme Kararının vardığı sonuç karşı- 656
> sında doktrin ve uygulama, mirastan feragat sözleşmesinin, miras sözleşmesi şeklinde yapılacağından hiç kuşku duymamakta ise de, sadece Şener aksi görüşü savunmaktadır[344]. Yazar, aynen şöyle demektedir: *"Mirastan feragat ölüme bağlı tasarrufla olur. O halde tek taraflı olabileceği gibi (MK 461, 478, yeni 514, 531) karışıklı irade açıklaması şeklinde de olabilir"*. Yazar daha sonra şöyle devam etmektedir: *"Madem ki, İçtihadı Birleştirme Kararı ölüme bağlı tasarruftan söz etmiştir öyleyse hem vasiyet hem de miras mukavelesi şeklinde olabilir. Yani ya bir mirasçı tek taraflı olarak mirastan feragat eder ki, bu ivazsız feragatlerde mümkün olabilir. Ya da mirasçı ile miras bırakan bir araya gelerek mirastan feragat sözleşmesi yaparlar"*. Aynı yerde yazar, mirastan feragatin tarafları başlığı altında şöyle diyor: *"a) Mirastan feragat tek taraflı ise mirasçıdan başkasına zaten gerek yoktur. b) Mirastan feragat karşılıklı ise, yani miras bırakan ile mirasçı arasında bir sözleşme yapılıyorsa iki kişi var demektir"*.
>
> *Şener*'in, mirastan feragatin miras sözleşmesi yanında vasiyetname ile de yapı- 657
> labileceğine ilişkin görüşüne katılmaya imkân yoktur. Her şeyden önce bu görüş eski MK 475 ve 476'nın olduğu gibi yeni MK 527 ve 528'in açık ifadelerine aykırıdır. Kaldı ki, Şener'in görüşüne gerekçe olarak gösterdiği ve yukarıda sözü edilen 11.2.1959 tarihli İçtihadı Birleştirime Kararı, yazarın iddiasının aksine, gerek gerekçede gerek sonuç bölümünde, *ölüme bağlı tasarruftan değil açık olarak miras sözleşmesinden söz eder*. Bu bakımdan, *Şener*'in, gerek kitabında gerek makalesinde sık sık belirttiği bu İçtihadı Birleştirme Kararını farklı anlayarak, kendi görüşüne gerekçe yapması doğru değildir. Kaldı ki, mirastan feragatin amacı göz önünde tutulacak olursa, bu görüşün isabetsizliği daha da açık olarak anlaşılır. Mirastan feragatin kaba hatlarıyla amacı, müstakbel ve muntazar mirasçının, kendi rızası ile mirasbıra-

[344] *Şener*, Miras, 159 vd; *Şener*, YD 1976, 119.

kanı, terekesi üzerinde, tasarruf serbestisinin (nisabının) dışı çıkabilecek biçimde tasarrufta bulunmasını temindir. Böylece, mirasbırakan, ileride, bir ölçüde de olsa tenkis davasının açılmasını engellemiş olur ve aynı zamanda, feragat edenin saklı payı üzerinde, kural olarak, dilediğince ya da karşı tarafın kişi yönünden sınırladığı biçimde tasarruf etmek imkânını bulur. Bunun gerçekleşmesi için ise, özellikle mirasbırakanın feragatten haberinin olması gerekir. Daha iyi bir deyişle, mirasbırakanın feragatten haberi olmalıdır ki, feragat edilen miktar üzerinde tasarrufta bulunabilsin. Durum böyle olunca; A'nın, bir vasiyetname yaparak, M'nin mirasından feragat ettiğini açıklamasının ne anlamı olur? Durumdan ancak A'nın ölümü ile haberi olacak M yönünden, feragat neyi sağlar? Kaldı ki A, vasiyetnamesinde, feragati B lehine yaptığını belirtmiş olsa dahi, bu, M'yi bağlar mı? Buna olumlu cevap vermeye imkân yoktur. Çünkü, bir kimse vasiyetname ile ancak kendi terekesi üzerinde bağlayıcı tasarrufta bulunabilir. Bu sebeple, A'nın yaptığı böyle bir tasarrufu vasiyetname olarak kabul edemeyiz. Çünkü A, M'nin haberi olmaksızın onun terekesi üzerine bir yüküm getiremez. Tersini düşünelim, M, A'dan önce ölürse, A'nın feragatinin anlamı ne olur? A, bu durumda mirasçı olmayacak mıdır? Olmayacaksa, onun yerini , M'ye mirasçı olarak kim alacaktır? Vasiyetname ile lehine feragat edilmiş kişi varsa A'nın yerine M'ye o mu mirasçı olacaktır? Bütün bu sorulara, miras sistemimiz ile çelişkiye düşmeden cevap vermek mümkün değildir. Ayrıca, çelişkiye düşmeyi göze alsak bile yine de olumlu cevaplandırmak imkânsızdır. Bu nedenle, *Şener*'in görüşüne sadece benim değil, hiç bir hukukçunun katılmayacağını söylemek abartılı olmaz.

658 Bazı yazarlar, ölünceye kadar bakma sözleşmesiyle tenfizi ölüme bağlı bağışlamaları da sadece miras sözleşmesi ile yapılabilen tasarruflar arasına dahil etmektedirler[345].

2. Hem miras sözleşmesi hem de vasiyetname ile yapılabilen ölüme bağlı tasarruflar

659 MK 527'ye göre, miras sözleşmesinin konusu mirasçı atanması ya da vasiyet olabilir. Bu tasarruflar, MK 516 ve 517'ye göre vasiyetname ile de yapılabileceklerine göre, bunlar, hem miras sözleşmesinin hem de vasiyetnamenin konusu olabilirler. Baskın görüş, MK 527'nin sınırlayıcı olmadığı yönündedir. Yâni, miras sözleşmesi ile yapılabilecek ölüme bağlı tasarruflar yönünden bir sınırlama yoktur. Bu sebeple, MK 527 dışında kalan ve niteliği gereği *bağlayıcı olmaması gereken* (yani mirasbırakanın her zaman serbestçe dönebileceği) tüm tasarruflar miras sözleşmesinin içeriğine girebilirler[346]. Buna göre, vasiyet ve mirasçı atama yanında örneğin yükleme, yedek ve art mirasçı atama da hem miras sözleşmesi hem de vasiyetname ile yapılabilirler.

---

[345] *Öztrak*, Rücu, 11; *Öztrak*, Miras, 76; *Speckert*, 18; *Knapp*, 224; ayrıca, *Picenoni*, Form, 66. Ayrıca yukarıda § 7, II.

[346] Baskın görüşe örnek olarak bkz., *Dural*, Miras Sözleşmeleri, 109, dn.17c.

3. Sadece vasiyetname ile yapılabilen ölüme bağlı tasarruflar

Yukarıda (1) ve (2) dışında kalan tüm maddî anlamda ölüme bağlı ta- 660
sarruflar sadece vasiyetname ile yapılabilirler.

Şimdi, yukarıda açıklanan ikinci meseleye dönecek olursak; acaba, sa- 661
dece vasiyetname ile yapılabilen maddî anlamdaki ölüme bağlı tasarruflar, miras sözleşmesi ile yapılırlarsa, bunların akıbeti ne olur? Meseleyi sadece vakıf kurma ve vasiyeti yerine getirme görevlisi atama yönünden ele alan yazarlar, sadece vasiyetnamenin konusu olabilecek maddî anlamda ölüme bağlı tasarrufların miras sözleşmesi ile yapılamayacağını savunmaktadırlar[347]. Katıldığım baskın görüş ise[348], sadece vasiyetname ile yapılabilecek maddî anlamdaki ölüme bağlı tasarrufların miras sözleşmesi ile yapılmasına bir engel yoktur. Çünkü, miras sözleşmesi, vasiyetnameler için aranan şekil şartını fazlasıyla içerir. Ancak, bu tasarrufların miras sözleşmesinde yer alması, onların bağlayıcı olacağı anlamına gelmez. Tıpkı vasiyetname ile yapılmış gibi, miras sözleşmesinin de bağlayıcı olmayan içeriğini oluştururlar. Bu sebeple, mirasbırakan bunları her zaman serbestçe geri alabilir; yoksa miras sözleşmesindeki dönme sebepleriyle bağlı değildir.

Miras sözleşmesinin bağlayıcı olma niteliği göz önünde bulundurulacak olursa, 662
sadece, bu gibi bağlayıcı olmayan maddî anlamda ölüme bağlı tasarruflardan oluşan bir miras sözleşmesi yapılamaz. Bu bakımdan, en az bir bağlayıcı tasarruf bulunmadıkça, miras sözleşmesinden söz etmek mümkün değildir. Ancak, böyle bir miras sözleşmesinin, tarafların iradesi göz önünde bulundurularak tahvil (çevirme) yoluyla resmî vasiyetname olarak ayakta tutulması mümkündür.

§ 16. Maddî anlamda ölüme bağlı tasarrufların türleri

I. MİRASÇI ATAMA

Yukarıda da açıklandığı gibi[349], teknik anlamda mirasçılık ya kanundan 663
doğar ya da mirasbırakanın iradesinden. Mirasbırakanın iradesine dayanan mirasçılık, yani atanmış (mansup) mirasçılık, bir vasiyetname ya da miras sözleşmesiyle, mirasbırakanın, bir ya da birden fazla kişiyi terekesinin tamamı ya da kesirli bir bölümü için hak sahibi yapmasıdır. Gerçekten MK 516/I'e göre, *"Mirasbırakan, mirasının tamamı ya da belli bir oranı için bir veya birden çok kişiyi mirasçı atayabilir"*. O halde mirasçı atanmasında önemli olan, lehine tasarruf yapılmış olan kişiye, terekedeki belirli bir şeyin ya da belirli bir malvarlığı değerinin değil, terekenin tamamının ya da ke-

[347] Bkz., *Dural*, Miras Sözleşmeleri, 110, dn. 19'da anılan yazarlar.
[348] Bkz., *Dural*, Miras Sözleşmeleri, 110, dn. 20'da anılan yazarlar.
[349] Bkz., yukarıda § 1, II, 3.

sirli bir bölümünün (3/4, 1/4 gibi) bırakılmasıdır. Eğer terekenin kesirli bir bölümü değil de, terekede bulunan belirli bir mal ya da malvarlığı değeri bırakılmışsa, ortada, aşağıda (II)'de açıklanacağı gibi, bir *vasiyet tasarrufu* vardır.

664 Mirasçı atanması hem vasiyetname hem de miras sözleşmesi ile yapılabildiği için, biri ya da diğerine başvurulması esas olarak bir fark yaratmaz[350]. Ancak, miras sözleşmesinde, atanan mirasçıya, miras payının, mirasbırakanın sağlığında devir edilmesinin özellikleri gözden uzak tutulmamak gerekir (MK 572)[351]. Yeri gelmişken belirtelim ki, MK 572, sadece miras sözleşmesi ile mirasçı atanmasına uygulanıp, vasiyet tasarruflarına uygulanmaz[352].

665 Miras sözleşmesiyle ilgili olarak MK 527/I, *"Mirasbırakan, miras sözleşmesiyle mirasını veya belirli bir malını sözleşme yaptığı kimseye ya da üçüncü bir kişiye bırakma yükümlülüğü altına girebilir"* demektedir. Cümledeki, *yükümlülüğü altına girebilir* ibaresi yanlıştır. Çünkü miras sözleşmesi ile mirasbırakan bir yükümlülük (borç) altına girmez, aksine o, miras sözleşmesini yapınca yükümlülüğünü yerine getirmiş olur. Mirasbırakan ölünce, miras sözleşmesi ile lehine vasiyet yapılan kimse, ayrıca mirasçılar tarafından yapılacak bir ifa işlemine gerek kalmadan mirasçı ya da vasiyet alacaklısı olur[353].

666 Atanmış mirasçı, hem gerçek kişi hem de tüzel kişi olabilir. Tıpkı yasal mirasçı gibi, mirasbırakanın külli halefidir. Bu bakımdan, mirasbırakanın ölümü ile kendiliğinden tereke üzerinde tam hak sahibi olur. Başka yasal ya da atanmış mirasçılar varsa, onlarla birlikte miras ortaklığını oluşturur, tereke borçlarından, şahsen ve diğer mirasçılarla birlikte müteselsil sorumlu olur (MK 599).

667 Son olarak belirtelim ki, mirasbırakan bir yasal mirasçının da, tasarruf nisabı oranında mirasçı atayabilir. Ancak bu hâlde gerçek bir mirasçı atama değil de, yasal mirasçının miras payının genişletilmesi söz konusudur.

II. VASİYET (BELİRLİ MAL BIRAKMA)

1. Genel olarak

668 MK 517, kenar başlığında, vasiyet yerine, *belirli mal bırakma* terimini kullanmıştır. MK 517'yi karşılayan eski MK 464'ün kenar başlığı da, *muayyen malda tasarrufdu.* Eski Medenî Kanunun bu ibaresi, yani vasiyet yerine, muayyen malda tasarruf terimini kullanması, haklı olarak çok eleştirilmişti. Çünkü vasiyetin konusu, sadece belirli bir malı bırakmaktan ibaret

---

[350] 2. HD 27.4.1976, 3108/3674 (YKD 1977, c. II, 630).
[351] Bkz., yukarıda § 14, II,1.
[352] *Tuor*, Art. 534 N 2; *Escher*, Art. 534 N 2; *Kocayusufpaşaoğlu*, 259, dn. 1.
[353] *Dural*, Miras Sözleşmeleri, 115 ve orada dn. 31'de anılan yazarlar.

olmayıp, aksine belirli mal bırakma, vasiyetin bir türüdür. Nitekim, MK 517/II, *"Belirli mal bırakma, ölüme bağlı tasarrufla bir kimseye terekedeki bir malın mülkiyetini veya terekenin tamamı ya da bir kısmı üzerinde intifa hakkının kazandırılmasına yönelik olabileceği gibi; bir kimse lehine tereke değeri üzerinden bir edimin yerine getirilmesinin, bir iradın bağlanmasının veya bir kimsenin borçtan kurtulmasının, mirasçılar veya belirli mal bırakılanlara yükletilmesi suretiyle de olabilir"*, diyerek bunu belirtmiş ve belirli mal bırakmaya, kenar başlığındaki anlamından çok daha geniş bir anlam vermiştir. Bu sebeple, belirli mal bırakmanın, vasiyetin karşılığı olarak değil, vasiyetin belirli bir mala ilişkin olması hâli için kullanılması gerekir. Başka bir ifade ile, vasiyet, mirasçı nasbını gerektirmeyen, mirasçılara karşı nisbî hak doğuran, bütün ölüme bağlı tasarrufları içeren üst kavram, muayyen mal vasiyeti ise, bu üst kavramın içinde yer alan, vasiyet türlerinden biridir. Kanunkoyucunun, bu gerçeği ve eleştirileri göz önüne almadan, terim yönünden eski Medenî Kanundaki yanlışlıkta ısrar etmesi doğru olmamıştır. Ne var ki, anlaşılan kanunkoyucunun kendisi de bu terimi çok beğenmemiş olacak ki, bir çok maddede (örnek olarak bkz., MK 544,552 b4, 581, 583, 598, 601, 647) belirli mal bırakma yerine ya da belirli mal bırakma ile birlikte (örneğin MK 544) vasiyet terimini de kullanmıştır.

Burada, cüzî halef olma sonucunu doğuran maddî anlamda ölüme bağlı 669
tasarruflar karşılığı doğru olan vasiyet terimini kullanmaya devam edeceğiz. Belirli mal bırakmayı ise, sık sık değinildiği gibi, vasiyetin bir türü olan, terekedeki bir malın bir kimseye bırakılması, yani belirli (muayyen mal vasiyeti) karşılığı olarak kullanılacaktır.

Yeri gelmişken belirtilmelidir ki, kanunkoyucu, *vasiyet* ve *vasiyetname* terimle- 670
rini kullanırken de doğrusu gerekli özeni göstermemiş, vasiyetname yerine bir çok yerde (örneğin, MK 502, 531, 539) vasiyet terimini kullanmıştır. Vasiyetnamenin şeklî anlamda, vasiyetin ise, maddî anlamda bir ölüme bağlı tasarruf olduğu düşünülecek olursa, vasiyetname yerine vasiyet teriminin kullanılmasının doğru olmadığı kendiliğinden anlaşılır.

Konumuza dönecek olarsak; MK 517/I'e göre, *"Mirasbırakan, bir kim-* 671
seye, onu mirasçı atamaksızın belirli bir mal bırakma yoluyla kazandırmada bulunabilir". Görüldüğü gibi, madde, vasiyeti olumsuz tanımlamakta, yani neyin vasiyet sayılmayacağını söylemektedir. Bu hüküm ve bunu karşılayan, ZGB 484 de yazılış şekli de göz önünde bulundurarak vasiyeti, *mirasbırakan tarafından, bir kimseye, ölüme bağlı olarak, alacak hakkı niteliğinde sağladığı bir malvarlığı menfaatidir* şeklinde tanımlayabiliriz[354].

Vasiyet genellikle ivazsız bir tasarruftur. Fakat miras sözleşmesi ile ya- 672
pıldığı zaman ivazlı da olabilir. Örneğin, mirasbırakan, aldığı 10 milyar li-

[354] Benzer tanımlar için bkz., *Piotet*, 125; *Kocayusufpaşaoğlu*, 259.

raya karşılık, A'ya miras sözleşmesi ile otomobilini bırakması ivazlı bir vasiyettir[355].

673 Tanımda da belirtildiği gibi, vasiyet alacaklısı (musaleh), mirasbırakanın küllî halefi olmayıp cüzî halefi olduğu için, ölümle birlikte, vasiyet edilen şey üzerinde doğrudan hak kazanmaz, sadece mirasçılara karşı, vasiyet borcunun yerine getirilmesine ilişkin bir alacak hakkı elde eder (MK 600/II). Vasiyet konusu şey üzerindeki hakkını ise, ancak vasiyet borçlusu, borcunu yerine getirince kazanır. Yine küllî halef olmadığı için, mirasbırakanın borçlarından sorumlu değildir. Lehine vasiyet yapılan kimsenin hakkının bir alacak hakkı olduğu, *"Vasiyet alacaklısı, vasiyeti yerine getirme görevlisi varsa ona; yoksa yasal veya atanmış mirasçılara karşı kişisel bir istem hakkına sahip olur"* diyen MK 600/I'den açık olarak anlaşılmaktadır.

674 Durumu örneklerle açıklayalım. M, vasiyetnamesinde arkadaşı A'ya otomobilini vasiyet etmiştir. M'nin ölümünde A, otomobilin mülkiyetini derhal kazanmayıp, vasiyet borçlusu kim ya da kimlerse, onlara karşı, mülkiyetin kendisine geçirilmesine ilişkin bir talep hakkı (istem) elde eder. Vasiyet borçlusunun ancak mülkiyeti devir amacıyla zilyetliği kendisine geçirmesinden sonra A mutlak hak sahibi olur. Vasiyet edilen şey taşınmaz olsaydı, A, ancak taşınmaz kendi lehine tapuda tescil edilince mülkiyeti kazanırdı. M, bir ibra vasiyeti yapmış olsa, ibra ettiği kişi, onun ölümüyle borçtan kurtulmayıp, mirasçılara karşı, vasiyetin yerine getirilmesine (borçtan ibra edilmesine) yönelik bir talep hakkı elde eder ve ancak onların ibra etmesi ile borçtan kurtulurdu.

675 Şimdi de vasiyet alacaklısı ile atanmış mirasçı arasındaki farkı bir örnekle açıklayalım. Oğlu A'dan başka mirasçısı olmayan M, arkadaşı B'yi, terekesinin 1/4'ü için mirasçı atar ve C'ye de otomobilini vasiyet eder. M'nin ölümü üzerine B, atanmış mirasçı sıfatıyla, başka bir işleme gerek kalmadan derhal, kendiliğinden terekenini 1/4'ü üzerinde tam (mutlak) hak sahibi olur ve A ile birlikte miras ortaklığını oluşturup, mirasbırakanın borçlarından kişisel ve A ile birlikte müteselsil sorumlu olur. Oysa C, M'nin ölümüyle, sadece otomobilin mülkiyetinin kendisine devredilmesine ilişkin, A ve B'ye karşı bir alacak hakkı elde eder. Otomobilin üzerindeki mülkiyeti ise, yukarıda da değinildiği gibi, ancak, zilyetliğin bu amaçla kendisine devri ile kazanır. Küllî halef, yani mirasçı olmadığı için, miras ortaklığına girmez ve mirasbırakanın borçlarından da sorumlu olmaz.

676 Vasiyet alacaklısının, mirasçılara karşı sadece bir talep hakkı (istem) elde etmesinin bir istisnası MK 601/II'de bulunmaktadır. Bu hükme göre,

---

[355] Aynı görüşte *Oğuzman*, 93, dn. 98a; aksi görüşte, *Kocayusufpaşaoğlu*, 259; *Tuor*, Art. 484 N 6; *Escher*, Art. 484 N 4.

"Kendisine mirasbırakanın ölümünde ödenecek bir sigorta alacağı vasiyet edilen kimse, sigorta sözleşmesinden doğan istem hakkını sigortacıya karşı doğrudan doğruya kullanabilir". Benzer bir hüküm TTK 1329'da da bulunmaktadır. Buna göre, *"Üçüncü şahıs lehine yapılan hayat sigorta mukavelesinden doğan hak ve menfaatleri sigortacıdan talep ve tahsil salahiyeti doğrudan doğruya o kimseye aittir.*

Sigorta mukavelesinde üçüncü şahsın mirasçı sıfatı gösterilmiş olmasa bile, o şahıs, birinci fıkra hükmü gereğince doğrudan doğruya sigortacıya karşı hak ve menfaatlere sahip olur. Medenî Kanunun 509. maddesi (yeni 567) hükmü mahfuzdur". 677

Özellikle MK 601/II'den anlaşılacağı gibi, mirasbırakan, yaptırmış olduğu hayat sigortasının bedelini bir kimseye vasiyet etmişse, lehine vasiyet yapılan kimse, ana kuralın aksine, mirasçılara karşı, sigorta bedelinin kendisine devir edilmesine ilişkin bir talep hakkı elde etmeyip, aksine, o bedelin kendisine ödenmesi için doğrudan sigortacıya başvurabilir. *Piotet*[356], ölüm ânında muaccel olması şartıyla, bu kuralı karma sigortalara da uygular. Yani, hayat sigortası, sadece mirasbırakanın ölümü hâli için değil, belirli bir süre sonra hayatta bulunması hâli için de yapılmışsa (TTK 1322), bu ihtimal için de, sigorta bedeli kendisine vasiyet edilen kimse, MK 601/II'ye göre, sigortacıya karşı doğrudan talep hakkına sahip olacaktır. *Fikrimce*, karma olarak yapılan hayat sigortalarına (ve sadece belirli bir zamanda hayatta olma şartına bağlı hayat sigortalarına), MK 601/II'nin uygulanması söz konusu olamaz. Şöyle ki, mirasbırakan hayattayken sigorta sözleşmesinde öngörülen süre dolmuşsa, bu, sigortaya karşı bir alacak hakkı olarak, mirasbırakanın malvarlığına girer. Mirasbırakan, bunu, daha sigortacıdan tahsil etmeden ölmüşse, bu alacak hakkı terekede yer alır. Böyle olunca da, mirasbırakanın terekede bulunan bir malvarlığı menfaatini vasiyet etmiş olacağı için, lehine böyle bir sigorta alacağı vasiyet edilen kimse, tıpkı alacak vasiyetinde olduğu gibi, mirasçılara karşı, bu alacağın kendisine temlik edilmesine ilişkin bir talep hakkı elde edip, ancak bu temlikten sonra sigortacıya başvurabilir. Bunun böyle olduğu, sadece MK 601/II'den değil, hep, *mirasbırakanın kendi ölümünde ödenmek üzere* ibaresini kullanan hayat sigortası ile ilgili diğer hükümlerden de (MK 509, 567) açık olarak anlaşılmaktadır[357]. 678

[356] *Piotet*, 429.

[357] Hayat sigortası ile ilgili MK 506 ve 567'nin sağ olma şartına bağlı ve karma hayat sigortalarının belirli bir zamanda hayatta olma hâlinde uygulanabileceğine ilişkin bkz., *Tuor*, Art. 476 N 6; *Escher*, Art. 476 N 2; *Kocayusufpaşaoğlu*, 404.

2. Vasiyetin bazı türleri

a) Belirli mal vasiyeti (bırakma)

679 Mirasbırakan terekesinde bulunan belirli bir malı üçüncü kişiye ya da (aşağıda, c'deki açıklamalar saklı kalmak şartıyla) mirasçısına vasiyet etmektedir. Eğer, vasiyet edilen şey ferden belirtilmişse (bir ev ya da bir otomobil) *parça ya da dar anlamda belirli mal vasiyeti vardır*. Mirasbırakan, belirttiği birden fazla şeyin içinden seçilecek birini vasiyet etmişse, *seçimlik vasiyetten* söz edilir. Örneğin, mirasbırakan, otomobili ya da motosikletinden seçilecek birini vasiyet etmişse, bu bir seçimlik vasiyettir. Seçim hakkının kime ait olacağı, vasiyette belirtilmemişse, BK 71 örneksemeyle uygulanıp, bu hakkın vasiyet borçlusuna ait olacağı kabul edilir[358]. Seçim hakkının, vasiyet borçlusu ve vasiyet alacaklısı dışında bir üçüncü kişiye bırakılabilip bırakılamayacağı tartışmalıdır[359].

680 Vasiyetin konusunun, terekede bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, nitelik ve miktar olarak belirtildiği hâllerde bir *çeşit vasiyeti* vardır. Çeşit vasiyetinin en önemli örneği, kuşkusuz belirli bir miktar paranın vasiyet edilmesidir. Bir ton pamuk, üç resim gibi yapılan vasiyetler de çeşit vasiyetidir. Çeşit vasiyeti, vasiyet edilen şey terekede bulunmasa bile, vasiyet borçlusu, bunu temin edip vasiyet borcunu yerine getirmek zorundadır. Bu bakımdan, *"Bırakılan mal terekede bulunmadığı takdirde, tasarruftan aksi anlaşılmadıkça, ölüme bağlı tasarrufu yerine getirmekle yükümlü olanlar borçtan kurtulurlar"* diyen MK 517/III çeşit vasiyetine uygulanmaz.

681 Bazen mirasbırakan çeşit vasiyetini tereke ile sınırlamış olabilir. *Pamuk depomdan 100 ton pamuk ya da kolleksiyonumdaki resimlerden üçü* gibi... Bu hâlde, çeşit vasiyeti, tereke ile sınırlandırılmış olduğu için, *bir sınırlı çeşit vasiyeti vardır*. Vasiyet borçlusu, bunlar terekede var ise borcunu yerine getirir. Aksi hâlde, onun çeşit vasiyetinde olduğu gibi, tereke dışından vasiyet edilen şeyi temin etme yükümü olmadığı için, sınırlı çeşit vasiyeti MK 517/III'e göre düşer.

682 Terekede bulunmayan bir malın vasiyet edilmesi hâlinde ise bir *tedarik vasiyeti* vardır. Terekede bulunmama değişik sebeplerden kaynaklanabilir. Örneğin, mirasbırakanın ölüme bağlı tasarrufu yaptığı zaman malvarlığında bulunan vasiyet konusu şey, sonradan,mirasbırakan sattığı ya da bağışladığı için terekede çıkmaz ya da vasiyet konusu mal, ölüme bağlı tasarruf yapıldığı zaman zaten terekede yoktur ve mirasbırakan bunu ölmeden önce te-

---

[358] *Escher*, Art. 484 N 12; *Gürsoy*, 185; *Kocayusufpaşaoğlu*, 263.

[359] Bu tartışmalar için bkz., *Kocayusufpaşaoğlu*, 263, dn. 10; *Oğuzman*, 142, dn. 178'de anılan yazarlar.

min de etmemiştir. Vasiyet edilen şey ne sebeple terekede bulunmazsa bulunmasın, MK 517/III'ün getirdiği karineye göre, vasiyet borcu düşer. Ne var ki MK 517/III emredici değildir. Bunun böyle olduğu, *tasarruftan aksi anlaşılmadıkça* ibaresinden anlaşılmaktadır. İşte, mirasbırakanın isteğinin, vasiyet edilen şey terekede bulunmasa bile, onun vasiyet borçlusu tarafından *tedarik edilip* yerine getirilmesi yönünde olduğu anlaşılırsa, o zaman bir tedarik vasiyeti vardır ve MK 517/III'deki vasiyet borcunun düşeceğine ilişkin karine yürümez[360].

b) Alt vasiyet

Alt vasiyette, bir vasiyet alacaklısına kendisine yapılan vasiyetten başka 683
bir vasiyeti yerine getirme borcu yüklenmektedir. Örneğin, M, A'ya kütüphanesini vasiyet edip ayrıca ona, kütüphanede bulunan polis romanlarını B'ye vermesi borcunu yüklerse, bu bir alt vasiyettir.

c) Ön vasiyet

Yasal ya da mansup mirasçılar lehine miras paylarından ayrı olarak bir 684
malvarlığı değerinin bırakılmasıdır. Mirasbırakanın, oğluna, miras payı dışında otomobilini vasiyet etmesi bir ön vasiyettir. Hemen belirtmek gerekir ki, bu şekilde yapılmış olan bir tasarrufun ön vasiyet mi yoksa mirasbırakan tarafından konulmuş bir paylaşma kuralı mı olduğunda kuşku duyulursa, karine MK 647/III'e göre paylaştırma kuralı olması lehinedir.

Ön vasiyette mirasçı sıfatı ile vasiyet alacaklısı sıfatı birbirinden ba- 685
ğımsızdır. Aynı zamanda vasiyet alacaklısı olan yasal ya da atanmış mirasçı, mirası reddetse bile vasiyeti alabilir (MK 519/III). Ancak mirasbırakan, ön vasiyeti, mirası reddetmeme şartına bağlayabilir. Böyle bir şart varsa, mirasın reddi, vasiyet alacağını da ortadan kaldırır[361]. Bunun aksine, ön vasiyeti reddeden mirasçı, mirasçılık sıfatını korumaya devam eder (MK 519/III).

d) Alacak vasiyeti

Burada, mirasbırakan, başka bir kimseden olan alacağını vasiyet etmek- 686
tedir. Lehine alacak vasiyeti yapılan kimse, mirasbırakanın ölümü ile alacağı elde etmeyip, vasiyet borçlusuna karşı, bu alacağın kendisine temlik edilmesine ilişkin bir talep hakkı kazanır; vasiyet edilen alacağı, ancak temlik işleminin yapılmasından sonra elde eder.Vasiyet borçlusu bu temliki rı-

[360] BGE 101 II 28;91 II 94; *Tuor,* Art. 484 N 20; *Benziger*, 81 vd; *Druey*, § 11, N 15; *Gürsoy*, 157; *Kocayusufpaşaoğlu*, 266.
[361] *Escher*, Art. 486 N 8; *Tuor*, Art. 487 N 17; *Kocayusufpaşaoğlu*, 262; *Oğuzman*, 145.

za ile yapmazsa, vasiyet alacaklısı mahkemeye başvurur ve alacağı *kazai temlik* yoluyla kazanır (BK 164).

e) İbra vasiyeti

687 Burada alacak vasiyetinin tam tersi söz konusudur. Bu bakımdan bazı yazarlar, ibra vasiyetini alacak vasiyetinin bir türü olarak görülür[362]. Mirasbırakanın, kendisine borçlu olan bir kimseyi, ölüme bağlı tasarrufla borcundan ibra etmesi, ibra vasiyetidir (MK 517/II). İbra vasiyeti, ibra edilen kimseyi mirasbırakanın ölümü ile borçtan kendiliğinden kurtarmaz, ona sadece vasiyet borçlusuna karşı, kendisini borçtan kurtarmasına yönelik bir talep hakkı verir. İbra ancak vasiyet borçlusunun ibrayı yapması üzerine gerçekleşir.

688 Mirasbırakanın bir kimseyi borçtan değil de, bir yükümdan (örneğin ipotekten) kurtarmak için yaptığı ölüme bağlı tasarruflar da ibra vasiyetine benzer ve vasiyet borçlusunu, o yükümden kurtarma borcu altına sokar[363].

f) İntifa vasiyeti

689 Burada, mirasbırakan, ölümünden sonrası için, terekesinin tümü ya da belirli bir kısmı üzerinde, üçünü kişi lehine bir intifa hakkının kurulmasını vasiyet etmektedir (MK 517/II), yoksa kendisine ait olan bir intifa hakkını değil... Çünkü, kişiye bağlı bir hak olan intifa, MK 797'ye göre, hak sahibinin ölümü ile sona erer. Burada da, lehine intifa hakkı vasiyet edilen kimse, mirasbırakanın ölümü ile, vasiyet borçlusuna karşı, intifa hakkının kurulmasına ilişkin bir talep elde eder. İntifa hakkını, kurulma işlemleri tamamlanınca kazanır. MK 601/I'e göre, intifa vasiyetine, tasarrufta başka bir esas öngörülmüş olmadıkça intifa hakkına ilişkin hükümler (MK 794 vd) uygulanır.

690 MK 517/II, her ne kadar sadece intifa hakkından söz etmekteyse de, diğer aynî hakların da vasiyet edilmesine bir engel yoktur. Federal Mahkeme, oturma (sükna) hakkının vasiyet edilebileceğini kabul etmiştir[364]. Ancak bizim eşya hukuku sistemimizde, alacaktan bağımsız bir rehin hakkı kurulamayacağı için, mirasbırakan, kendi lehine olan bir rehin hakkını, bağlı olduğu alacaktan ayrı vasiyet edemez[365].

g) İrat vasiyeti

691 Ölüme bağlı tasarruf, vasiyet alacaklısına, vasiyet borçlusu tarafından, belirli bir süre ya da hayat boyu, düzenli olarak bir miktar para ya da misli

---

[362] Bkz. *Tuor/Schyder*,§ 62, III,a,3; *Benziger*, 92 vd; *Gürsoy*, 151.
[363] *Oğuzman*, 142.
[364] BGE 91 II 94.
[365] *Escher*, Art 484, N 14; *Kocayusufpaşaoğlu*, 265; *Oğuzman*, 143, dn. 285.

eşya verilmesi şeklinde dönemsel edimler olarak yapılmışsa, bu bir irat vasiyetidir. Örneğin, mirasbırakan, yasal mirasçılarına, A'ya her ay 500 YTL vermelerini öngörürse, irat vasiyet yapmış olur. MK 601/I'e göre irat vasiyetine, tasarrufta aksine bir düzenleme yoksa, BK 507 hükümleri uygulanır.

3. Vasiyetin hükümleri

a) Vasiyet borçlusu kimdir ?

Vasiyet borçlusunun kim olduğu genel olarak MK 600/I'de ayrıca MK 552 b.4'de belirtilmiştir. MK 600/I'e göre, *"Vasiyet alacaklısı, vasiyeti yerine getirme görevlisi varsa ona; yoksa yasal veya atanmış mirasçılara karşı kişisel bir istem hakkına sahiptir"*. Bu hükme göre, vasiyet borçlusunun kim olduğunu kural olarak mirasbırakan yaptığı ölüme bağlı tasarrufta belirleyecektir. MK 600/I'deki *vasiyeti yerine getirme görevlisini* böyle anlamak gerekir. Başka bir ifade ile, buradaki vasiyeti yerine getirme görevlisi ibaresi, MK 550 vd. deki teknik anlamdaki vasiyeti yerine getirme görevlisi karşılığı kullanılmış olmayıp, eski metindeki *vasiyeti ifa ile mükellef* olan karşılığı kullanılmıştır. Bunun böyle olduğu, MK 600'ün gerekçesinde, eski MK 541'e göre hüküm değişikliği olmadığının açık olarak belirtilmesinden anlaşıldığı gibi[366], MK 552 b.4'den de anlaşılmaktadır. Çünkü MK 552 b. 4'de vasiyeti yerine getirme görevlisinin, görevleri arasında vasiyetleri yerine getirme açık olarak, ayrıca belirtilmiştir. Bu bakımdan, MK 600/I'deki *vasiyeti yerine getirme görevlisini*, mirasbırakanın, sadece belirli bir vasiyeti yerine getirme görevini yüklediği kişi, yani özel olarak atadığı *vasiyet borçlusu* olarak anlamak gerekir. 692

Mirasbırakan, vasiyet borçlusu olarak bir ya da bir kaç kanunî ya da yasal mirasçısını atamışsa, vasiyet alacaklısı, sadece bu mirasçı ya da mirasçılardan borcun yerine getirilmesini isteyebilir, diğerlerine başvuramaz. Mirasbırakanın birden fazla vasiyet borçlusunu belirttiği hallerde, bunlar, vasiyetin yerine getirilmesinden müteselsil sorumludurlar. Böyle bir hâlde vasiyet alacaklısı, borcun yerine getirilmesini, hepsinden ya da içlerinden birinden isteyebilir. 693

Vasiyet borcunu yerine getirecek ikinci kişi yukarıda da değinildiği gibi, MK 552 b.4'e göre, vasiyeti yerine getirme görevlisidir. Bu hâlde, vasiyeti yerine getirme görevlisi olarak atanan kişinin kanunî görevi olduğu için, ayrıca vasiyet borçlusu olarak belirtilmesine gerek yoktur. Ancak, mirasbırakan bunun aksini öngörebilir (MK 552/I). 694

Bazen, vasiyet borçlusunun kim olacağı vasiyetin niteliğinden anlaşılır. 695

[366] Bkz. Gerekçe, 505.

Örneğin alt vasiyette, vasiyet borçlusu, kendisine alt vasiyet yükümü ile vasiyet yapılmış olan vasiyet alacaklısıdır.

696 Yukarıda sayılanlardan hiç biri yoksa, o zaman vasiyet borçlusu ya da borçluları yasal ve atanmış mirasçılardır. Bunların, müteselsil olarak vasiyet borçlusu oldukları karinedir. Bu sonuca MK 641/I'in örneksemeyle uygulanmasıyla varılmaktadır. Aslında MK 641/I, açık olarak, mirasçıların, mirasbırakanın borçlarından (tereke borçlarından) müteselsil sorumlu olacağını öngördüğüne göre, bu hükmün, mirasbırakanın değil de, mirasçıların borcu olan vasiyete uygulanmaması gerekirdi. Ne var ki, doktrin bu hükmü geniş yorumlayarak, aksi mirasbırakan tarafından öngörülmüş olmadıkça, vasiyeti de kapsadığını kabul etmektedir[367].

697 Vasiyet borçlusunun, mirasbırakandan önce ölme, mirası red, mirastan yoksunluk sebeplerinden biri ile mirasçı sıfatını kazanamadığı hallerde, vasiyetin kimin tarafından yerine getirileceği sorusunun cevabını MK 519/II vermektedir. Söz konusu hükme göre, *"Vasiyeti yerine getirme yükümlüsü, mirasçılığı veya kendisine bırakılan kazandırmayı reddetmiş, ya da mirasbırakandan önce ölmüş veya mirastan yoksun kalmış olsa bile tasarruf yürürlükte kalır; yerine getirme borcu, bu durumlardan yararlananlara geçer"*. Hükümden anlaşılacağı gibi, vasiyet borçlusu herhangi bir sebeple mirasa ya da lehine yapılan kazandırmaya nail olamazsa, vasiyet borçlusu sıfatı onun yerini alan mirasçı ya da mirasçılara geçer. Örneğin, mirasbırakanın yasal mirasçıları kardeşleri A ve B ise ve mirasbırakan, Ü'lehine yaptığı vasiyetin yerine getirilmesini A'ya yüklemişse, A, mirastan yoksun olanca, vasiyeti yerine getirme borcu B'ye geçer. Fakat A'nın, C adında bir çocuğu olsaydı, A'nın yerini C alacağı için, vasiyeti ifa ile C yükümlü olurdu[368].

698 Vasiyet borçlusunun ayırt etme gücünü kaybetmesi, borçlu olma sıfatını etkilemez. Ne var ki, bu hâlde (tam ehliyetsize yönelik irade açıklaması hüküm ifade etmeyeceği için), vasiyetin yerine getirilmesine ilişkin talebin, yasal temsilciye yöneltilmesi gerekir. Aynı şekilde ifayı da yasal temsilci yapacaktır.

b) Vasiyet alacaklısı kimdir ?

699 Mirasbırakan öldüğü zaman (yedek ve art vasiyet alacaklısı atama hâlleri hariç) lehine tasarruf yapılmış hayatta olan her gerçek ve var olan tüzel kişi vasiyet alacaklısı olabilir. Bunun gibi, vasiyet yapılan kişinin aynı zamanda mirasçı olmasına (ön vasiyet) bir engel yoktur. Henüz var olmayan

---

[367] Bkz., *Kocayusufpaşaoğlu*, 266, dn. 227'de anılan yazarlar; *Oğuzman*,145; *Piotet*, 130 ve orada dn. 16'da atıf yapılan Federal Mahkeme kararları.

[368] *Tuor*, Art 486 N 11; *Escher*, Art. 484 N 6; *Piotet*, 130; *Kocayusufpaşaoğlu*, 267.

bir kimse de art vasiyet yolu ile (kurucu ikame) vasiyet alacaklısı olarak atanabilir.

Vasiyet alacaklısı birden fazla kişi de olabilir. Örneğin A,B ve C, bir- 700
likte vasiyet alacaklısı olarak atanabilirler. Bu halde *müşterek vasiyet* vardır. Aksi kararlaştırılmadıkça, müşterek vasiyet alacaklısı olan kimselerin, vasiyet konusu şey üzerinde eşit hak sahibi oldukları kabul edilir. Vasiyet olunan şey, para, bölünebilir eşya ya da bir hak ise (mirasbırakan, başkasında olan alacağını birden fazla kişiye vasiyet etmiştir), müşterek vasiyet alacaklısı olanlardan her biri, kendi payına düşenin ifasını isteyebilir. Vasiyetin konusu bölünemeyen bir şeyse BK 69 uygulanır ve müşterek vasiyet alacaklılarından her biri, vasiyetin konusunun bütün vasiyet alacaklılarına ifası için dava açabilir[369].

Vasiyet alacaklısı olarak, tüzel kişiliği olmayan bir kişi topluluğu da 701
öngörülmüş olabilir. Bu hâlde MK 577/II uygulanır.

MK 581/II'ye göre, vasiyet alacaklısı mirasbırakandan önce ölmüşse, 702
vasiyet tasarrufu vasiyet borçlusu lehine sona erer. Yâni vasiyet edilen şey vasiyet borçlusuna ait olur. Bu hükmü iki hâlde vasiyet edilen şeyin tereke-ye döneceği ve bundan bütün mirasçıların yararlanacağı anlamında yorumlamak gerekir. Bunlardan ilki, mirasbırakanın özel olarak vasiyet borçlusu belirtmediği, bu sebeple de bütün mirasçıların vasiyet borçlusu olduğu durumdur. Böyle bir hâlde, mirasçıların hepsi vasiyet borçlusu oldukları için, borcun sona ermesinden MK 581/II'ye göre hepsi yararlanırlar.

İkinci durum ise, vasiyeti yerine getirme görevlisinin atanmış olması- 703
dır. Bu hâlde, vasiyet alacaklısı mirasbırakandan önce öldüğü için vasiyetin konusunun vasiyeti yerine getirme görevlisine ait olmasının hiçbir mantıkî açıklaması olamaz.

Vasiyet alacaklısının mirasbırakandan önce ölmesi hâlinde vasiyet sona 704
ereceğine ilişkin MK 581/II kuralı alt vasiyet hâlinde uygulanmaz. Bu durumda, alt vasiyet alacaklısı vasiyetin yerine getirilmesini vasiyet borçlusundan isteyebilir[370].

c) Vasiyet borcunun doğumu ve muaccel hale gelmesi

MK 600/II, vasiyet borçlusunun sadece mirasçı olması ihtimali için bir 705
düzenleme getirmiştir. Buna göre, vasiyet borcu ölüm ile doğar, borçlunun mirası kabul etmesi ya da red hakkının düşmesi ile muaccel olur.

---

[369] *Piotet*, 129. Ancak yazar, her iki ihtimalde de mirasbırakanın, vasiyeti müteselsil alacak şeklinde kurabileceğini ve bu hâlde BK 148 gereğince her bir vasiyet alacaklısının, vasiyetin tümünün kendisine ifa edilmesi için dava açabileceği görüşündedir.

[370] *Piotet*, 130.

706 Vasiyet borcunun mirasbırakanın ölümü ile doğması kuralı, vasiyetin geciktirici şarta bağlanmış olması hâlinde yürümez. Bu hâlde, vasiyet alacağı ölüm ânında değil, geciktirici şart gerçekleşince doğar. Örneğin mirasbırakan bir arkadaşının çocuğuna, hukuk fakültesini dört yılda bitirmesi şartıyla bir ev vasiyet etmişse, bu vasiyet alacağı çocuğun hukuk fakültesi dört yılda bitirmesi hâlinde doğar. Bozucu şarta bağlı vasiyetlerde vasiyetin ölüm ânında doğacağı kuralında bir değişiklik olmaz. Fakat bozucu şart gerçekleştiği zaman vasiyet hükümsüz hale gelir.

707 Yukarıda da değinildiği gibi, MK 600/II, vasiyet borçlusunun, mirasçıdan başka bir kimse (örneğin alt vasiyette olduğu gibi, vasiyet alacaklısı) olması haline ilişkin bir düzenleme getirmemiştir. Böyle bir halde de vasiyet alacağının ölüm ile doğacağında kuşku yoktur. Muacceliyet yönünden, genel olarak, vasiyet borçlusu vasiyet alacaklısı ile alt vasiyet alacaklısının hakkının aynı anda muaccel olacağı kabul edilmektedir. Yani, alt vasiyet alacaklısına karşı borçlu durumunda bulunan vasiyet alacaklısının hakkının, kendi borçlusu olan mirasçıların, mirası kabul ettiği ya da red hakkının düştüğü anda, alt vasiyet alacaklısının da hakkı muaccel olur[371].

708 MK 600/II'den anlaşılacağı üzere, gerek vasiyet alacağının doğması gerek muaccel olmasına ilişkin kurallar emredici olmadıkları için, mirasbırakan bunun aksini öngörebilir. Örneğin vasiyet alacağının doğumunu bir vadeye bağlayabilir. Böyle bir hâlde vasiyet alacağı ölüm ile değil vadenin dolması ile doğar. Geciktirici şartta da durumun böyle olduğu yukarıda açıklanmıştı. Muacceliyet yönünden de mirasbırakanın bunu ileriye atacağı tartışmasız olarak kabul edilmekle beraber, (en fazla) ölüm ânına kadar öne alınabilip alınamayacağı tartışmalıdır. Bazı yazarlar bunu, ancak vasiyeti yerine getirme görevlisinin atanmış olması hâlinde mümkün görülür[372]. Bazı yazarlar ise, böyle bir şart aramaksızın mümkün olacağı görüşündedirler. Ancak, bu durumda, vasiyet borçlusunun tereke işlerine müdahale sebebiyle red hakkının ortadan kalkmayacağını da (MK 610/II) belirtirler[373].

709 Vasiyet edilen şey muayyen bir para ise, muaccel olmasından itibaren temerrüt ihtarına bağlı olarak temerrüt faizi işlemeye başlar[374].

d) Zamanaşımı

710 Vasiyet alacaklarında zamanaşımı MK 602'de düzenlenmiştir. Buna göre, *"Vasiyet alacaklısının dava hakkı, ölüme bağlı kazandırmayı öğrenmesinden veya vasiyet borcu daha sonra muaccel olacaksa muaccel olma*

---

[371] *Tuor/Picenoni*, Art. 462 N 7; *Krayenbühl*, 227; *Piotet*, 134; *Gürsoy*, 73; *Kocayusufpaşaoğlu*, 268.

[372] *Tuor/Picenoni*, Art. 562 N 9.

[373] *Escher*, Art. 462 N 10; *Picenoni*, 134; ayrıca, *Druey*, § 11 N 17.

[374] BGE 11 II 425 vd.; *Druey*, § 11, N 17. Oysa Federal Mahkeme daha önceki bir kararında (BGE 83 II 427) temerrüde düşmede BK 101/II'yi uygulayıp, ihtara gerek olmadığını kabul etmişti. Bu kararın eleştirisi için bkz., *Kocayusufpaşaoğlu*, 269.

tarihinin üzerinden on yıl geçmekle zamanaşımına uğrar". Bu hüküm, vasiyet alacağının muacceliyetini düzenleyen MK 600/II ile birlikte ele alındığı zaman, şöyle anlaşılmak gerekir: a) vasiyet alacağı, mirasçıların mirası derhal kabul ettikleri hâlde ya da vasiyet tasarrufu, vasiyet alacaklısına bildirilmeden mirası reddettikleri hâllerde, zamanaşımı bildirimden itibaren işlemeye başlar. Burada, zamanaşımının başlangıcı, muacceliyet tarihinden daha ileriye atıldığı için BK 128'e aykırı bir düzenleme vardır. b) Buna karşılık, vasiyet alacaklısına hakkı bildirildiği zaman, vasiyet borçlusu, daha mirası kabul etmemiş ya da red süresi dolmamışsa, zamanaşımı, bildirim tarihinde değil (çünkü daha muaccel olmamıştır) kabul etme ile ya da red süresinin dolması ile işlemeye başlar[375]. c) Mirasbırakan muacceliyet için başka bir süre öngörmüşse, zamanaşımı o süre ile işlemeye başlar.

Mirasçı nasıl mirası reddedebiliyorsa, vasiyet alacaklısı da vasiyeti red- 711
dedebilir (MK 616)[376]. Geşmişe etkili olan red,vasiyet alacağının, miras açıldığı günden itibaren hiç doğmamış sayılması sonucunu doğurur. Kanun, vasiyet alacağının reddi için bir süre öngörmemiştir. *Kocayusufpaşaoğlu*, vasiyet alacağının MK 602'ye göre, on yıl içinde zamanaşımına uğrayacağının burada unutulmaması gerektiği görüşündedir[377]. Böyle olunca da, red ancak 10 yıl içinde yapılabilir. Red beyanının vasiyet borçlusuna yöneltilmesi gerekir.

Piotet[378], mirasın reddi ile vasiyet alacağının reddinde, menfaatler durumunun 712
farklı olduğunu belirterek, vasiyetin reddinin şekle bağlı olmadığı gibi, şart ya da ihtirazi kayda bağlı olarak da yapılabileceği görüşündedir.

4. Vasiyet borcunun kapsamı

MK 518'e göre, *"Bırakılan belirli mal, mirasın açılması anındaki du-* 713
rumuyla teslim olunur; yarar ve hasar mirasın açılması anında kendisine belirli mal bırakılana geçer.

Tasarrufu yerine getirme ile yükümlü olan kimse, mirasın açılmasından 714
sonra bırakılan belirli mala yaptığı harcamalar ve mala verdiği zararlardan dolayı, vekâletsiz iş görenin haklarına sahip ve borçlarıyla yükümlü olur".

Buna göre, vasiyet olunan şey, mirasın açıldığı günkü durumu ile teslim 715
edilir. Bu bakımdan vasiyet alacaklısı, mirasın açılmasına kadar, vasiyet

---

[375] *Escher*, Art. 601 N 1; *Tuor/Picenoni*, Art. 602 N 2 vd; *Piotet*, 137; *Kocayusufpaşaoğlu*, 268; *Oğuzman*, 313; ayrıca bkz., 2.HD 4.7.1985, 4281/6339 (YKD 1986, c. XII, 503).

[376] *Druey* (§ 15, N 23), vasiyetin reddini teknik olarak bir alacaktan feragat olarak nitelendirir.

[377] *Kocayusufpaşaoğlu*, 260.

[378] *Piotet*, 137.

olunan şeyde meydana gelen değişikliklere katlanmak zorundadır. Örneğin, vasiyet olunan malın değeri azalmışsa, bu haliyle kabullenir; ya da vasiyet olunan şey bir taşınmazsa ve mirasbırakan bunun üzerinde vasiyetten sonra bir ipotek kurarak onu bir yüküm altına sokmuşsa, vasiyet alacaklısı buna da katlanmak zorundadır[379]. Bunun aksine, vasiyet edilen şeyde ölüme kadar meydana gelen olumlu değişiklikler de vasiyet alacaklısına ait olur. Örneğin, mirasbırakan, eski bir otomobilini A'ya vasiyet ettikten sonra, değerinin çok artmasına sebep olacak değişiklikler yapacak olursa, A, değer artışı sebebiyle hiç bir şey ödemesine gerek olmadan bundan yararlanır, yeter ki mirasbırakan aksini belirtmiş olmasın.

716 Mirasın açıldığı gün ile vasiyetin ifa edildiği gün arasında, vasiyet edilen şeye gelen zararlardan dolayı, vasiyet borçlusu vekâletsiz iş görme kurallarına göre kusuru varsa sorumlu olur (MK 518, BK 411). Mirasbırakanın açık talimatına aykırı hareket etmesi hâlinde vasiyet borçlusu meydana gelen zarardan, kusuru olmasa da, aynı kurallara göre sorumlu tutulur[380]. Buna karşılık, vasiyet borçlusu, mirasın açıldığı andan itibaren, vasiyet edilen şeye yapmış olduğu masrafları da vekâletsiz iş görme kurallarına göre ister (BK 414).

717 *Piotet*[381], MK 518/II'nin vekâletsiz iş görme kurallarına atıf yapmasını doğru bulmamaktadır. Ona göre, vasiyet borçlusunun, vasiyet edilen şeye mirasın geçmesinden sonra zarar vermesi, aslında borcun ihlalidir. Bu bakımdan doğru olan BK 96 vd'nin uygulanmasıdır. Ne var ki, yazar, vekâletsiz iş görme hükümlerine atıf yapılmasının BK 96'ya göre pratik açıdan (vasiyet borçlusunun, faydalı ve lüks masrafları talep etme hakkı dışında) bir fark yaratmayacağını da eklemektedir.

718 MK 518/II mirasın geçmesinden sonra, vasiyet konusunun değerindeki artışları düzenlemekte, fakat tabii ve hukukî semerelere ilişkin bir hüküm içermemektedir. Bu konuda, bir fikre göre, semere, temerrütten itibaren vasiyet alacaklısına ait olur[382]. Federal Mahkeme BK 101/II'yi uygulayarak, semerelerin geçiş anını, vasiyet borçlusunun red hakkının sona erdiği an olarak kabul eder[383]. *Piotet*[384], BK 101/II'nin, kanunen belirlenen vadelere uygulanamayacağını, bu sebeple bu hükmün, vadenin ancak mirasbırakan tarafından belirlendiği hâllerde uygulanacağını söyler. Oysa burada, müttefiken belirlenmiş bir vade bulunmadığı için BK 101/II'nin uygulanamayacağından yukarıda söz edilmişti. *Piotet*, MK 515/I'in yorumu ile farklı bir sonuca ulaşmaktadır[385]. Yazar, tabii semereleri, mütemmim cüz

---

[379] BGE 104 II 337. Katlanma yükümü dolayısıyla taşınmazın icra yoluyla satılmasına vasiyet alacaklısı itiraz edemez, fakat borçtan da şahsen sorumlu olmaz, meğer ki ölüme bağlı tasarrufta aksi belirtilmiş olsun. Krş., *Oğuzman*, 287, dn. 102.

[380] *Kocayusufpaşaoğlu*, 270 ve dn. 34'de atıf yapılan yazarlar.

[381] *Piotet*, 138.

[382] *Escher*, Art. 485 N 6; *Tuor*, Art. 485 N 17; *Krayenbühl*, 218; *Gürsoy*, 148; *Oğuzman*, 287, dn. 104.

[383] BGE 83 II 427 vd.

[384] *Piotet*, 140.

[385] *Piotet*, 140.

olarak; ölüm anında muaccel olmayan medenî semereleri de ferî olarak vasiyet edilen şeye dahil saymakta ve dolayısıyla da bunların mirasın açılmasıyla (yoksa temerrüt ânında değil) vasiyet alacaklısına geçeceğini kabul etmektedir.

5. Vasiyetin tenkisi

MK 519/I, üç halde vasiyetin tenkis edilebileceğini (indirilebileceğini) öngörmüştür: a) tereke mevcudunu aşan vasiyetler; b) vasiyet borçlusunun lehine olan tasarrufun miktarının aşılması (bu hâlde vasiyet borçlusu mirasçı ya da alt vasiyette olduğu gibi, vasiyet alacaklısı olabilir); c) tasarruf edilebilir kısmın (tasarruf nisabı) aşılması. 719

Bu üç ihtimalin ilk ikisinde tenkisi isteme hakkı, vasiyet borçlusu olan saklı paylı (mahfuz hisse) olmayan yasal mirasçılar ya da atanmış mirasçılar ile alt vasiyet borçlusu olan vasiyet alacaklısına tanınmıştır. Böylece, bu kimselerin, kendi ellerine geçenden fazlasını ifa yükümlülüklerinin olmadığı ifade edilmiştir. Son ihtimalde ise sadece *saklı paylı* olan mirasçılar yararlanabilirler. Bunun üzerinde, aşağıda *tenkis* bahsinde durulacaktır. Ancak, saklı paylı mirasçıların tenkis hakkı MK 560 vd.da etraflı olarak düzenlendiği için, ayrıca MK 519/I'de belirtilmesine gerek yoktu. 720

Tenkis kendiliğinden gerçekleşmez. Bunun için vasiyet borçlusunun tenkis davası açması ya da tenkis defini ileri sürmesi gerekir. Saklı paylı mirasçıların tenkis davasını düzenleyen hükümleri saklı paylı olmayan vasiyet borçlularının açacakları tenkis davasına örneksemeyle uygulanır. MK 519/I'de sözü edilen tereke, aktif (net), yani borçlar çıktıktan sonra geri kalan terekedir. 721

Bu konuya son vermeden önce kısaca *kanunî* (yasal) vasiyet kavramı üzerinde duralım. Kanunî vasiyet kavramı iki anlamda kullanılmaktadır. Bunlardan birincisi, kanunun bazı kişilere miras ortaklağına karşı tanıdığı bir alacak hakkıdır (örneğin MK 645, 674/II). Burada, gerçi alacak mirasbırakanın iradesinden değil de kanundan doğmasına rağmen, vasiyet ile benzerliği dolayısıyla kanuni vasiyet terimi kullanılmaktadır[386]. 722

İkinci olarak bu terim, büyük ana ve büyük babaların ana ve babaları ile onların çocuklarının miras payı ve sağ kalan eşin miras payının bir bölümü olan *kanuni intifa hakkının* karşılığı olarak kullanılıyordu. Ne var ki, büyük ana ve büyük babaların ana ve babaları ile onların çocukları 3678 sayılı kanunla daha eski Medenî kanun zamanında mirasçı olmaktan çıkartılmış; eşin miras payının intifa hakkı bölümü de aynı kanunla kaldırılmış ve yeni Medenî Kanunda da 3678 sayılı kanunun bu değişikliği aynen korunmuştur. Bu sebeple, kanuni vasiyet teriminin bugün, bu ikinci anlamda kullanılması söz konusu değildir. 723

---

[386] *Piotet*, 68 vd; *Kocayusufpaşaoğlu*, 271/272; *Oğuzman*, 140, dn. 270.

III. KOŞUL (ŞART)

1. Genel olarak

724 *Koşul, bir hukukî işlemin sonuçlarının bağlandığı müstakbel ve gerçekleşip gerçekleşmeyeceği kuşkulu bir olaydır.* Koşul, hukukî işlemin sonuçlarına etkisine göre, *geciktirici (taliki) (BK 170)* ve *bozucu (infisahi)* (BK 173) olmak üzere ikiye ayrılır. Geciktirici koşul hâlinde, hukukî işlemin hüküm doğurması, koşulun gerçekleşmesine bağlanmıştır (örneğin, A'nın dört yılda hukuk fakültesini bitirmesi koşuluyla ona bir otomobil bağışlıyorum). Bozucu koşulda ise, işlem yapıldığı anda hüküm doğurmaya başlar, fakat öngörülen koşul gerçekleşince, işlemin sonuçları ortadan kalkar (örneğin, A'ya bir otomobil bağışlıyorum. Fakat dört yılda hukuk fakültesini bitiremezse, bağış geçersiz olacaktır).

725 MK 515 /I c.1'e göre, ölüme bağlı tasarrufar da koşula bağlanabilir. Ölüme bağlı tasarruflar açısından koşulu, *mirasbırakanın, ölüme bağlı tasarrufun hükümlerini bağladığı, müstakbel ve gerçekleşip gerçekleşmeyeceği kuşkulu bir olay* şeklinde tanımlayabiliriz. Sağlar arası tasarruflar gibi, ölüme bağlı tasarruflar da geciktirici ya da bozucu koşula bağlanabilirler. Geciktirici koşula bağlı ölüme bağlı tasarruf, mirasbırakanın ölümü ânında değil de koşul gerçekleşince hüküm ifade edecektir. Buna karşılık bozucu koşula bağlı ölüme bağlı tasarruf, mirasbırakan ölünce derhal hüküm ifade eder, fakat bozucu koşul gerçekleşince hükümden düşer.

726 Belirtmek gerekir ki, koşul, gerçek anlamda bir ölüme bağlı tasarruf olmayıp, sadece ölüme bağlı tasarrufun etkisinin bağlandığı bir olaydır. Başka bir deyişle, koşul, nasıl sağlar arası bir işlem olmayıp, işlemin hükümlerinin bağlandığı bir olaysa, ölüme bağlı tasarruflar yönünden de durum aynıdır. Sırf koşuldan oluşan ne bir sağlar arası işlem ne de bir ölüme bağlı tasarruf yapılabilir. Ancak gerçek anlamda bir ölüme bağlı tasarruf koşula bağlanabilir. Ne var ki, MK 515, koşulu (yükleme ile birlikte) *Ölüme Bağlı Tasarrufların Çeşitleri* başlığı altında üçüncü ayırımda düzenlediği için, bilimsel eserlerin çoğunda, bu sistematiğin etkisi altında, maddî anlamdaki ölüme bağlı tasarrufların bir türü olarak incelenir[387]. Burada da geleneksel sisteme bağlı kalınarak, koşul ölüme bağlı tasarruflar arasında incelenmiştir. Ne var ki, bir şekle bağlı tasarrufun bütününün de koşula bağlanabileceği düşünülecek olursa, koşulun bir ölüme bağlı tasarruf türü olmadığı daha kolay anlaşılır.

---

[387] Son zamanlarda yazılan eserlerde bu sistematikten ayrılınmaktadır. Örneğin, *Piotet* (98 vd), şartı, şart ve vade diye ayrı bir başlık altında inceler. *Druey* (§ 9, N 6; § 11, N 30), bunu bile yapmayıp, ilgili olduğu kadarıyla MK 515'e (ZGB Art. 482)'ye atıf yapmakla yetinmektedir.

Koşula bağlanma, genellikle, mirasçı atanması ve vasiyette söz konusu olur. Ancak başka bir tasarrufun da (örneğin bir yüklemenin) koşula bağlanmasına bir engel yoktur. Geciktirici koşula bağlı mirasçı atanması, mirasçıların ölüm ile tereke üzerinde hak sahibi olacaklarının bir istisnasıdır. Çünkü koşul geçmişe etkili değildir ve geciktirici koşula bağlı olarak mirasçı atanan kimse bu sıfatını şart gerçekleştiği anda kazanır[388] ve o andan itibaren (varsa) miras ortaklığına girer, o andan itibaren tereke üzerinde tam hak sahibi olur, borçlardan kişisel sorumluluğu o anda başlar. Geciktirici şarta bağlı mirasçı atanması, artmirasçı atamanın (MK 521 vd) bir türüdür. Burada önmirasçı sıfatı, yasal mirasçıya, artmirasçı sıfatı da, geciktirici koşula bağlı olarak mirasçı atanan kimseye aittir[389]. 727

Artmirasçı atama yerine *fevkâlade ikame* terimini kullanan eski MK 468 zamanında, şarta bağlı mirasçı (ve vasiyet alacaklısı) atama fevkâlade ikamenin bir türü olan kurucu ikame kavramı ile açıklanıyordu[390]. Artmirasçı atamanın bir türü olan kurucu ikamede, ön ya da artmirasçılardan biri mirasçılık sıfatını, mirasbırakanın iradesinden değil de kanundan alır. 728

MK 580/I'in, *"Mirasçı olabilmek için mirasbırakanın ölümü ânında mirasa ehil olarak sağ olmak şarttır"* diyen hükmü karşısında, mirasçı atanan kimsenin, mirasbırakanın ölümü ânında sağ olması şart ise de; acaba koşulun gerçekleştiği anda da sağ olması gerekir mi? Bu konuda Medenî Kanunda bir hüküm yoktur. Sorunun cevabının önemi ise şuradadır: Eğer sadece mirasbırakanın ölümü ânında sağ olma yeterli görülürse, o anda sağ olan, fakat koşul gerçekleşmeden ölen atanmış mirasçının beklenen hakkı kendi mirasçılarına geçecek ve koşul gerçekleştiği zaman onlar mirasa nail olacaklardır. Aksi sonuca varılırsa, bu durumda beklenen hak mirasçılara geçmez ve koşula bağlı mirasçı atama kendiliğinden ortadan kalkar. Bu konuda, mirasçının iradesinden aksi anlaşılmadıkça BGB § 2074'de ikinci görüşe uygun bir çözüm bulunurken, yukarıda da değinildiği gibi, Türk/İsviçre Hukukunda bir düzenleme yoktur. Ancak, İsviçre/Türk Hukukunda da geciktirici şarta bağlı mirasçı atamanın, artmirasçı atamanın hükümlerine tâbi olmasından hareketle aynı sonuca varılmaktadır. Yani MK 525'in örneksemeyle uygulanması sonucu, geciktirici koşul gerçekleştiği zaman da mirasçı atanan kimsenin hayatta olması gerekir, meğer ki, mirasbırakanın iradesinin aksi yönde olduğu anlaşılsın[391]. 729

Bozucu koşula bağlı mirasçı atanmasında durum tam tersinedir. Böyle bir koşula bağlanarak mirasçı atanan kimse, genel kurala uygun olarak, mi- 730

---

[388] *Escher*, Art. 482 N 8 ve 12; *Kocayusufpaşaoğlu*, 273.

[389] *Escher*, Art. 488 Vorbem. 2, 20; *Tuor*, Art. 488 Vorbem. 7-8; *Piotet*, 177 vd; *Kocayusufpaşaoğlu*, 273; *Oğuzman*, 150, dn. 315 ve 156.

[390] Bkz., *Dural/Öz*, § 15, III, 3,a.

[391] *Escher*, Art. 482 N 10; *Tuor*, Art. 482 N 35; *Krayenbühl*, 148; *Piotet*, 103; *Gürsoy*, Şart ve Mükellefiyet, II, 423, 430; *Kocayusufpaşaoğlu*, 273; *Oğuzman*, 150, 157.

rasbırakan öldüğü anda kanun gereği, terekede küllî halef sıfatıyla tam hak elde eder, miras ortaklığına dahil olur ve borçlardan da şahsen sorumludur. Fakat, bozucu koşul gerçekleştiği anda, mirasçılık sıfatı, geçmişe etkili olarak değil de, ileriye etkili olarak sona erer. Aslında burada da bir artmirasçı atanması vardır. Önmirasçılık sıfatı atanmış mirasçıya, artmirasçılık sıfatı yasal mirasçıya aittir[392].

731 Geciktirici ve bozucu koşula bağlı olarak mirasçı atanmasına ilişkin yukarıda yapılan açıklamalar, bünyesine uygun olduğu kadarıyla, koşula bağlı vasiyet tasarruflarına da uygulanır.

2. Hukuka ve ahlâka aykırı koşullar

732 MK 515 /II'ye göre, *"Hukuka ve ahlâka aykırı koşullar ve yüklemeler, ilişkin bulundukları tasarrufu geçersiz kılar"*. Aslında bu hüküm, sağlar arası işlemler yönünden, *"Kanuna ve ahlâka (adaba) mugayir bir fiil ve ihmal şart olarak tayin edilmiş olduğu takdirde bu şarta bağlı borç hükümsüz olur"* diyen BK 176'ya paralel bir düzenleme getirmektedir. MK 515/II, açık olarak sadece koşulun değil de, hukuka ve ahlâka aykırı koşula bağlanmış olan tasarrufun da geçersiz olacağını belirttiği için, sadece koşulu geçersiz sayıp, tasarrufu koşulsuz olarak geçerli kabul etmek mümkün değildir.

733 Bazı yazarlara göre kanunkoyucu bu sonuca, koşula bağlı hukuki işlemlerin niteliğinden hareketle, koşulun ve tasarrufun tek ve aynı iradeden kaynaklandığı için, bölünme zorluğunu kabul ederek varmıştır[393]. O hâlde, mirasbırakan için şartın değil de, tasarrufun önem taşıdığı, eklediği koşulun hukuka ya da ahlâka aykırı olduğunu bilseydi tasarrufu koşulsuz yapacağı anlaşılırsa, sadece koşulu hükümsüz sayıp, tasarrufu geçerli kabul etmek mümkün olabilmelidir[394]. Bazı yazarlar bu sonuca, koşulun kendisinin de açık ya da örtülü olarak, ikinci bir koşula (geçerli olma koşuluna) bağlı olarak yapıldığı ile açıklamaktadırlar[395].

734 MK 515/II'deki renksiz *geçersiz* kılar terimini MK 557 b.3 ile birlikte ele alıp, kanunun sistemine uygun olarak, *iptal edilebilir* şeklinde anlamak gerekir. İptal davasının açılmaması hâlinde, hukuka ya da ahlâka aykırı koşula bağlanmış olan ölüme bağlı tasarruf geçerli olacaktır[396].

735 Belirtmek gerekir ki, ölüme bağlı tasarruflar için Medenî Kanun, geçer-

---

[392] *Kocayusufpaşaoğlu*, 274 ve orada dn.5'de atıf yapılan yazarlar.

[393] *Escher*, Art. 482 N 28; ayrıca bkz., *Tuor*, Art. 482 N 24.

[394] *Tuor*, Art. 482 N 27/28; *Escher*, Art. 482 N 30; *Kocayusufpaşaoğlu*, 274; *Piotet*, 99; *Druey*, § 12, N 66; *Şener*, Miras, 357; *Oğuzman* (147, dn.310), *Şener*'i eleştirdiği için aksi görüşte gözükmektedir.

[395] *Tuor*, Art. 482 N 27/28; *Kocayusufpaşaoğlu*, 274; *Druey*, § 12 N 66.

[396] Bununla beraber, katıldığım, ölüme bağlı tasarruflarda hukuka ve ahlâka aykırılığı da batıl sayan görüş için bkz., aşağıda, § 18, III, 3.

sizliğe ilişkin hüküm bir yana, koşulla ilgili özel düzenlemeler getirmiş değildir. Bu bakımdan Borçlar Kanunundaki şarta ilişkin hükümler, bünyesine uygun olduğu kadarıyla örneksemeyle koşula bağlı ölüme bağlı tasarruflara da uygulanır (MK 5)[397]. Örneğin koşulun gerçekleşmesine, mirasçılar ya da, çok ender olmakla beraber, bizzat mirasbırakan dürüstlük kuralına aykırı olarak engel olursa BK 175'e göre koşul gerçekleşmiş sayılacaktır.

MK 515/II'nin kastettiği tasarruf maddî anlamda ölüme bağlı tasarruf- 736
tur. Bu bakımdan, bir vasiyetnamede bulunan ölüme bağlı tasarruflardan biri hukuka ya da ahlâka aykırı koşula bağlanmışsa, sadece o tasarruf hükümsüz olur, diğerleri geçerliklerini korurlar. Ancak, iptal edilen tasarruf olmasaydı, diğer tasarrufların da yapılmayacağı anlaşılıyorsa, o zaman BK 20/II'nin örneksemeyle uygulanması sonucu vasiyetnamenin tümü geçersiz olur[398].

Koşul yönünden üzerinde tartışılan iki önemli konu, evlenmeye ilişkin şartlar ile 737
ceza ve mirastan yoksun bırakma kayıtlarıdır. Evlenmeye ilişkin koşullar, değişik şekillerde olabilir. Mirasbırakan, bir kimse lehine evlenmesi koşuluyla bir ölüme bağlı tasarruf yapar. Bu halde, lehine tasarruf yapılmış kişi, evlendiği zaman bu hakkı kazanacağından, evlenme koşulu bir geciktirici koşuldur. Bunun aksine, mirasbırakan, yaptığı ölüme bağlı tasarrufun, lehine tasarruf yapılan kimsenin evlenmesi hâlinde geçersiz olacağını öngörebilir. Bu halde, evlenmemeye ilişkin bir şart vardır ve bu şart niteliği gereği bozucudur. Çünkü, lehine ölüme bağlı tasarrufta bulunulan kimse, ölümle birlikte atanmış mirasçı ya da vasiyet alacaklısı sıfatını kazanacak, fakat evlenmesi hâlinde bozucu koşul gerçekleşeceği için, tasarruf iptal edilebilecektir. Bunun gibi, mirasbırakanın, ölümünden sonra evlenmemesi koşuluyla (dul kalma koşulu) eşi lehine yaptığı ölüme bağlı tasarruf da bozucu şarta bağlanmıştır. İşte tartışılan husus, bu tür koşulların hukuka ve ahlâka aykırı olup olmadıklarıdır. Çünkü, meselenin temelinde, böyle bir şartın kişilik hakkına (MK 23) aykırı sayılıp sayılmayacağı yatmaktadır.

Fransız hukukunda, tasarrufa eklenen evlenme ya da evlenmeme şartı geçerlidir. 738
Çünkü, kişi kazandırmadan vazgeçebileceği için evlenme hürriyetine de bir müdahalenin söz konusu olmadığı kabul edilmektedir[399]. Türk/İsviçre hukukunda hâkim olan görüş ise bunun aksinedir. Bu hukuklarda, evlenme ya da evlenmeme koşulu MK 23'e, yâni kişilik hakkına aykırı görülmekte ve kural olarak hükümsüz kabul edilmektedir. Çünkü, kişinin, böyle bir koşula rağmen evlenip evlenmemekte serbest olduğu iddiasının pratik uygulanabilirliği yoktur. Önemli bir kazanmayı kaybetme endişesi, kişinin evlenme ya da evlenmeme yönündeki kararını serbestçe vermesine engel olur. Bu sebeple, burada, ekonomik çıkar sağlama yoluyla kişilik hakkına müdahale vardır[400].

İsviçre/Türk hukukunda, özellikle de İsviçre hukukunda, kural yukarıda belirtil- 739

---

[397] *Oğuzman*, 149.

[398] *Gürsoy*, Şart ve Mükellefiyet, II, 468; *Kocayusufpaşaoğlu*, 275; *Oğuzman*, 147.

[399] Fransız hukukuyla ilgili etraflı igi için bkz., *Kocayusufpaşaoğlu*, 276.

[400] *Raschein*, 56; *Tuor*, Art. 482 N 28a; *Escher*, Art. 482, N 32a; *Herzer*, 96; *Druey*, § 12,N 66; *İmre*, MHAD 1967, 144; *Eren*, İptal, 60 vd; *Gürsoy*, Şart ve Mükellefiyet II,442; *Şener*, Vasiyet 220; *Kocayusufpaşaoğlu*, 276.

diği gibi olmakla beraber, mirasbırakanın, objektif olarak caiz görülebilir *saikler ve temiz hislerle* hareket ettiği hâllerde, istisnaen evlenme ve evlenmemeye ilişkin koşulların geçerli kabul edilebileceği ileri sürülmektedir[401]. Mirasbırakanın, kızı lehine yaptığı kazandırmayı, ilişkide olduğu ahlâksız bir erkekle evlenmemesi, ırsî bir hastalığı olan arkadaşına evlenmemesi koşuluyla kazandırma yapması ya da kolaylıkla aldatılabilecek eşinin, malvarlığının kendisinin ölümünden sonraki kocası tarafından elinden alınmasını engellemek amacıyla lehine yaptığı tasarrufu dul kalma şartına bağlaması, mirasbırakanın caiz görülebilir amaçlarla hareket ettiğine örnek olarak gösterilmekte ve dolayısıyla geçerli şartlar olarak kabul edilmektedir.

740 *Kocayusufpaşaoğlu*, doktrinde verilen bu örneklere haklı olarak karşı çıkmaktadır[402]. Yazar, özetle, kanunda bulunmayan evlenme engellerini, mirasbırakanın maddî bir çıkar karşılığında kişilere dayatmasını kişiliğe aykırı görmekte ve evlenme ya da evlenmemeye ilişkin koşulların amacı ne olursa olsun geçersiz olması gerektiğini savunmaktadır.

741 Bu açıklamalardan anlaşılacağı üzere, evlenme, evlenmeme ya da dul kalma koşulu, kişilik hakkını ihlal ettiği için hukuka aykırı ve dolayısıyla da hükümsüzdürler. Bunun zıt kavramından, özellikle evlenmeye ilişkin koşulun, evlenme özgürlüğünü kısıtlamadığı hâllerde geçerli olacağı sonucu çıkar. Örneğin, mirasbırakan, yaptığı ölüme bağlı tasarrufta, *"kızım A ile evlenmesi koşuluyla, B'ye 10 milyar lira vasiyet ediyorum"* demişse, bu koşul, B'nin evlenme özgürlüğüne hukuka aykırı bir müdahale olacağı için geçersizdir. Buna karşılık, mirasbırakan, *"B, evlendiği takdirde ona 10 milyar lira vasiyet ediyorum"* derse, bu geçerlidir. Çünkü bu örnekte, mirasbırakan tarafından ileri sürülen koşul, B'nin iradesini etkilemek için konulmuş olmayıp, bir evlenme hediyesi olarak öngörülmüştür[403].

742 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi de bir kararında[404], mirasbırakanın, vasiyetnamesinde, *eşinin kendisine nispetini koruduğu*, yani evlenmediği sürece, miras payı dışında, Kızılay'a yapılmış olan vasiyetin gelirinden 3/4 oranında yararlanmasını öngörmesini MK 515'e aykırı bularak geçersiz kabul etmiştir. Buna karşılık Hukuk Genel Kurulu bir kararında, mirasbırakanın, eşi lehine yaptığı ölüme bağlı tasarrufu, evlilik bağının devam etmesi şartına bağlamasını, bu şartın, mirasbırakanın ölümünden sonrasına da şamil olmadığı, dolayısıyla da evlenme özgürlüğünü sınırlamadığı gerekçesiyle ahlâka ve hukuka aykırı bulmamıştır[405].

743 Üzerinde durulması gereken diğer bir konu da,yukarıda da değinildiği gibi, ölüme bağlı tasarrufun geçerliğinin ceza (mirastan yoksun bırakılma) kaydına bağlanması durumudur. Esasında *iradi bozucu koşul*[406] olan bu kayıtla, mirasbırakan, lehine ölüme bağlı tasarruf yaptığı kimsenin, tasarrufa nail olmasını, yaptığı ölüme bağlı tasarrufun iptal edilmemesi koşuluna bağlamaktadır. Daha açık bir deyişle lehine ölüme bağlı tasarrufta bulunulan kişi, ölüme bağlı tasarrufu iptal ettirmezse vasiyete nail olacak, aksi halde vasiyet geçersiz olacaktır. Örneğin, mirasbırakan vasiyetnamesinde, tasarruf nisabının yarısını Kızılay'a, diğer yarısını da- miras payından ayrı

---

[401] Bkz., dn 400,de anılan yazarlar veayrıca *Piotet*, 91.

[402] *Kocayusufpaşaoğlu*, 277 vd.

[403] *Tuor*, Art. 482 N 28a; *Escher*, Art. 482 N 32a; *Piotet*, 91; *Kocayusufpaşaoğlu*, 279; ayrıca krş., *Herzer*, 98.

[404] 2. HD, 28.3.1968,1276/2002 (*Yazıcı/Atasoy*, 899); aynı karar için bkz., *Şener*, Vasiyet, 264).

[405] HGK 16.2.1983, 268/136 (Hukuk Genel Kurulu 10 Yıllık Emsal Kararlar, 694).

[406] *Tuor*, Art. 482 N 29; *Escher*, Art. 482 N 33; *Herzer*, 60; *Kocayusufpaşaoğlu*, 280; *Oğuzman*, 146, dn. 305.

olarak- kızına vasiyet etmiş, fakat kızının, Kızılay'a yapılan vasiyeti iptal ettirmesi hâlinde, sadece saklı payı ile yetineceğini belirtmişse, mirasbırakanın kızı lehine yaptığı tasarruf cezai şarta bağlanmıştır[407]. Böyle bir ceza şartının geçerli olup olmayacağı, ilgili olduğu tasarrufun hukuka ve ahlâka aykırı olup olmadığına bağlıdır. Eğer asıl tasarruf hukuka ve ahlâka aykırı değilse, ceza kaydı da geçerlidir. Örneğin, mirasbırakan arkadaşı A'ya evini vasiyet etmiş, ancak teyzesinin de bu evde kirada oturmaya devam edeceğini belirtmiş, A'nın, kira sözleşmesinin feshini ihbar etmesi hâlinde yapılan vasiyetin geçersiz olacağını öngörmüşse, asıl tasarruf hukuka aykırı olmadığı için ceza kaydı geçerlidir[408]. Buna karşılık, ceza kaydının bağlı olduğu asıl tasarruf hukuka ya da ahlâka aykırı ise, ceza kaydı da geçersiz olur ve lehine tasarruf yapılan kişinin bunun hükümsüzlüğünü ileri sürmesi tasarrufu elde etmesini engellemez[409]. Örneğin, mirasbırakan, yapmış olduğu vasiyetnamesinde, *"Mirasçılarım, hamiline yazılı hisse senetlerini veraset ve intikal vergisi için beyan etmesinler. Beyan edecek olurlarsa, sadece saklı payları ile yetinsinler"* demişse, asıl tasarruf hukuka aykırılık sebebiyle geçersiz olduğu için ceza kaydı da hükümsüz olur ve hisse senetlerini ibraz eden mirasçılar tam paylarını alırlar.

Yargıtay'a göre, bir vasiyetnamedeki, *"...bütün taşınmazlarımın satılmadan kullanılmasını arzuluyorum, satılması hâlinde gelirinin TEV ve TSK Güçlendirme Vakfına verilmesini arzu ediyorum"* şeklinde bir ceza kaydı, hukuka ve ahlâka aykırı olmadığı için geçerlidir[410]. Fikrimce, bu karar, bir kaç noktadan kabul edilemez. Önce, ceza kaydı, mirasçının tasarruf yetkisini sınırladığı için, *"Bir şeye malik olan kimse, hukuk düzeninin sınırları içinde, o şey üzerinde dilediği gibi kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisine sahiptir"* diyen MK 683/I'e aykırıdır. İkinci olarak, eğer mirasçılar saklı paylı iseler, bu kayıt onların saklı payına açık bir tecavüz oluşturur. Nihayet, eğer mirasbırakanın bu yolla bir aile fidei komisi kurma arzusu varsa, bu tasarruf MK 372/II'ye aykırı olur. 744

Yukarıdaki kararında, tasarruf yetkisinin sınırlandırılmasını geçerli kabul eden Yargıtay, başka kararlarında[411], mirasbırakanın, ergin olmayan mirasçıların miras paylarından, velilerinin yönetim ve yararlanma hakkını kaldırmasını, kanuna aykırı olduğu gerekçesiyle geçersiz kabul etmiştir. Yüksek Mahkeme, kararlarında, velâyet hakkının kullanılmasının kamu düzeni ile ilgili olduğu için sınırlanamayacağını ve böyle bir sınırlamanın, MK 9,339, 342, 438, 461-465. maddelere aykırı olacağı gerekçesiyle bu sonuca varmıştır. Ne var ki Yargıtay bu kararlarında MK 357'yi göz ardı etmiş gözükmektedir. Şöyle ki, MK 357, ergin olmayan çocuk yararına, velinin yönetim ve yararlanma yetkisine bir sınırlama getirme imkânı tanıdığı için, bu hükmün, ergin olmayan bir çocuğun mirasçı atanması ya da vasiyet alacaklısı yapılması hâlinde, sağlar arası bağışlamalar gibi, bunlara da doğrudan; yasal mirasçılarda ise hükmün amacından hareketle örneksemeyle uygulanmasına ve şartı geçerli kabul etmeye bir engel yoktur. Eğer böyle bir koşul, mirasçının ergin olmasından sonra belirli bir süre tasarruf yetkisini sınırlıyorsa, o zaman kısmî hükümsüzlük söz konusu olur[412]. 745

---

[407] Örnek için bkz., *Kocayusufpaşaoğlu*, 280.
[408] Örnek için bkz., *Druey*, § 1N 34.
[409] BGE 85 II 378 vd; 91 II 473; ayrıca bkz., *Kocayusufpaşaoğlu*, 280; *Piotet*, 91; *Druey*, § 12, N 34.
[410] 2.HD 2.12.1991, 1307/14711 (YKD 1992, c. XVII, 188).
[411] 2. HD 18.4.1977, 2708/3258 (*Şener*, Vasiyet, 261); 2.HD 28.12.1976, 8837/9404 (*Şener*, Vasiyet, 262); 2.HD 28.3.1968, 1276/ 2002 (*Yazıcı/Atasoy*, 899)
[412] Bkz., 2.HD 28.12.1976, 8837/9404 (*Şener*, Vasiyet, 622).

3. Anlamsız ve yalnız başkasını rahatsız edici (faydasız ve müziç) şartlar

746 MK 515/III'e göre, *"Anlamsız ve yalnız başkalarını rahatsız edici nitelikte koşullar ve yüklemeler yok sayılır"*. Bu hükme göre, hiç bir anlamı olmayan ya da sadece başkalarını rahatsız eden koşullar, iptale gerek olmadan, kendiliğinden hükümsüz olurlar ve tasarruf koşulsuz olarak geçerliğini korur. Örneğin, bir kimseye, haftada bir gün başına huni takarak dolaşması şartıyla 10.000 YTL vasiyet edilmişse, bu koşul anlamsız olduğu için, kendiliğinden hükümsüz, vasiyet ise koşulsuz geçerli olur.

4. İmkânsız koşullar

747 MK 515, koşulun imkânsız olması hali için bir düzenleme getirmez. Baskın görüş, koşulun bozucu ya da geciktirici olmasına göre bir ayırım yapar. Buna göre, koşul geciktirici ise, tasarruf geçersiz olur. Buna karşılık, bozucu koşulun imkânsız olması hâlinde, tasarruf koşulsuz yapılmış kabul edilip hüküm ifade eder[413].

IV. YÜKLEME (MÜKELLEFİYET)

1. Genel olarak

748 MK 515'de koşul ile birlikte düzenlenmiş olan yükleme öyle bir ölüme bağlı tasarruftur ki, *bununla mirasbırakan yasal ya da atanmış mirasçılarına, herhangi bir kimse lehine alacak hakkı doğurmaksızın*[414], *belirli bir şeyi yapma ya da yapmama taahhüdünü yükler*[415]. Bu yolla mirasbırakan bir çok isteğinin ölümünden sonra yerine getirilmesini temin edebilir. Örneğin, cenaze töreninin nasıl yapılmasına ilişkin isteğini, terekedeki bir malın nasıl kullanılmasını istediğini terekedeki bir malın satılması hâlinde bunun önce diğer mirasçılara teklif edilmesini yükleme yoluyla temin edebilir. Bunun gibi, mirasbırakanın bir arkadaşına 10.000 YTL vasiyet edip, ayrıca ondan her yıl bir öğrenciye burs vermesini isterse, bu bir yükleme olur. Aynı şekilde, vasiyet edilen bir kütüphanenin ilgili olan kimselere açık tutulmasını isteme de bir yüklemeden başka bir şey değildir.

749 Görüldüğü gibi, yüklemede ön plana çıkan *amaçtır*. Mirasbırakan belli bir amacın gerçekleşmesi için mirasçılara ya da vasiyet alacaklılarına bir yüklemede bulunur. Kuşkusuz, şart olmamakla beraber, bu amaçtan yarar-

---

[413] *Escher*, Art. 482 N 34; *Tuor*, Art. 482 N 30; *Piotet*, 99; *Oğuzman*, 148; *İmre/Erman*, 119; *İnan/Ertaş*, 172; aksi görüş, *Şener*, Vasiyet 167; krş., *Köprülü*, 179, dn. 106.

[414] BGE 101 II 25.

[415] *Piotet*, 147; benzer tanımlar için bkz., *Tuor*, Art. 482 N 6; *Escher*, Art. 482 N 13; *Kocayusufpaşaoğlu*, 281; *Oğuzman*, 145; *İmre/Erman*, 121.

lanacak kişiler de olabilir. Ne var ki, bu şart olmadığı gibi, yararlanacak kişiler varsa, bunların belirli olması da gerekmez ve yararlanacak kişiler lehine bir alacak hakkı doğmaz. Bunun sonucu ise, yüklemeden yararlanacak kişinin, yüklemenin yerine getirilmemesi hâlinde tazminat isteme hakkının olmamasıdır[416].

> Yüklemeden yararlanacak olan kimselerin, bunun yerine getirilememesi hâlinde tazminat isteyememeleri mantıklıdır. Özellikle yararlanacak kişilerin sayısının belli olmadığı hâllerde bir zorunluktur da... Örneğin, mirasbırakanın, kütüphanesini vasiyet ettiği kimseye, bunu, ilgili olan herkese açık tutmasını yüklemiş ve lehine vasiyet yapılan kimse de bu yüklemeyi yerine getirmemişse, ondan ilgili olan herkese tazminat ödemesi beklenemez[417]. Ne var ki,yüklemeden sadece bir kişinin yararlanabileceği durumda tazminat isteme hakkının yokluğunun biraz aykırı olacağı düşünülebilirse de, bu hâlde yorum yoluyla yüklemeyi bir alt vasiyet olarak kabul edip, yararlanacak kişiye dava hakkı tanınabilir[418]. 750

Bu açıklamalardan sonra yükleme ve benzer kavramlar olan vasiyet ve koşul arasındaki farklar üzerinde kısaca duralım. Önce, vasiyetin bir malvarlığı değeri olmasına karşın, yüklemede böyle bir zorunluk yoktur. Örneğin, mirasbırakanın, oturduğu evde, ölümünden sonra 10 yıl süreyle hiçbir değişiklik yapılmamasına ilişkin talimatı, bir malvarlığı değeri içermemesine rağmen bir yükleme olarak öngörülebilir. 751

Vasiyette daima bir vasiyet alacaklısının bulunması gerekirken, yüklemede (çoğunlukla bulunacak olmasına rağmen) tek bir yararlanacak kişinin dahi bulunmasına gerek yoktur. Mirasbırakanın mirasçı atadığı kişiye kedisine bakmayı yüklemesinde olduğu gibi... 752

Vasiyet, vasiyet alacaklısına, bir alacak hakkı, dolayısıyla da ifa etmeme hâlinde ifa davası açma hakkı verirken; yükleme, yararlanacak kişi lehine bir alacak hakkı, dolayısıyla da kendi lehine ifa davası açma hakkı tanımaz. 753

> *Druey*[419], yüklemenin dava açma hakkı vermemesi yüzünden, yararlanacak olan kişinin durumunun zayıf olmasından hareketle, malvarlığı değeri olan yüklemelerin, kuşku hâlinde vasiyet olarak yorumlanması gerektiği görüşündedir. 754

Yükleme ile koşul arasındaki farka gelince; önce koşul, bağımsız bir ölüme bağlı tasarruf değildir, ancak başka bir ölüme bağlı tasarruf koşula bağlanabilir. Oysa yükleme bağımsız bir ölüme bağlı tasarruftur. Bu sebeple sırf yüklemelerden oluşan bir ölüme bağlı tasarruf yapmak mümkündür. 755

---

[416] *Tuor*, Art. 482 N 18; *Escher*, Art. 482 N 22; *Druey*, § 11 N 28; *Gürsoy*, Şart ve Mükellefiyet, I, 537; *Kocayusufpaşaoğlu*, 281; *Oğuzman*, 151.
[417] Krş., *Druey*, § 11 N 28.
[418] *Druey*, § 11 N 28.
[419] *Druey*, § 11 N 30.

Örneğin, mirasbırakanın yapmış olduğu vasiyetnamenin içeriği, sadece cenazesinin nasıl kaldırılacağından ibaret olabilir.

756 Koşul ile yüklemenin farkı, *Savigny*'den beri gelen bir deyişle, *şart geciktirir, yüküm altına sokmaz, yükleme, yüküm altına sokar fakat geciktirmez* şeklinde açıklanmaktadır[420]. Ancak bu deyiş, sadece geciktirici koşul ile yükleme arasındaki farkı gösterir.

757 Koşullu bir ölüme bağlı tasarrufun yerine getirilmesi ya da hükümsüz hâle gelmesi, koşulun gerçekleşmesine bağlıdır. Oysa yüklemenin, ölüme bağlı tasarrufun üzerinde bir etkisi yoktur. Onun müeyyidesi dava edilebilmesidir. Bununla bağlantılı olarak belirtilmesi gereken bir fark da, koşulun yerine getirilmesi için dava açılmasının mümkün olmamasıdır.

758 Belirtmek gerekir ki, MK 515/I'in koşulun yerine getirilmesinin dava edilebileceğine ilişkin hükmü doğru değildir. Aynı yanlışlık ZGB Art. 482'de de vardır[421]. Çünkü, koşulun gerçekleşmesi bir çok hâlde ilgililerin elinde olan bir şey değildir. Örneğin, *Türk Milli Takımının Hollanda Millî Takımını yenmesi koşuluyla sana bir milyar vasiyet ediyorum* denmesi hâlinde, şartın gerçekleşmesi için nasıl dava açılacaktır ve bu davayı kim açacaktır? Belki bir an için, başkası lehine olan bir edimin ifa edilmesini içeren bir iradî şartın yerine getirilmesi için dava açılabileceği düşünülebilir. Örneğin, *A'ya yüz milyon lira vermen koşuluyla sana evimi vasiyet ediyorum ya da terekem üzerinde sana intifa hakkı tanıyorum, ancak teyzeme bakmaya son verdiğin zaman bu hakkın ortadan kalkacaktır* biçimindeki ölüme bağlı tasarruflarda olduğu gibi... Ne var ki, birinci hâlde iradî şartı gerçekleştirmeyen kişi vasiyete nail olamayacağı; ikinci hâlde ise intifa hakkı sona ereceği için, usul hukuku açısından davalı olacak kişi bulunamayacağından iradi şartın gerçekleşmesi ya da gerçekleşmemesi için dava açmak mümkün gözükmemektedir[422]. Sadece bir hâlde ölüme bağlı tasarruf ile lehine bir edimin yerine getirilmesi istenen kişinin ifa davası açması mümkündür ki, o da iradî koşulun bir yükleme olarak yorumlanabilmesi durumudur. Çünkü, bir çok hâlde, özellikle bir malî değerin söz konusu olduğu hâllerde, koşul ile yükleme arasındaki sınırı çizmek çok zordur. Örneğin, *A'ya, teyzeme bakması koşuluyla 20.000 YTL vasiyet ediyorum diyen bir ölüme bağlı tasarruf ile, A'ya 20.000 YTL vasiyet ediyorum ve ondan teyzeme bakmasını istiyorum* diyen bir ölüme bağlı tasarruf arasında ne fark vardır? Lafza bağlı kalacak olursak, birincisi koşula bağlı bir vasiyet, ikincisi ise bir bir yüklemedir. Böyle olunca da, birinci hâlde koşulu yerine getirmeyen A, vasiyeti elde edemeyecek ve ona karşı dava açılamayacak, dolayısıyla da mirasbırakanın son arzusu, yani teyzesine bakılması gerçekleşmeyecektir. Oysa aynı kelimelerin değişik düzende kullanıldığı ikinci hâlde, bir yükleme söz konusu olduğu için teyze, bakılmasına yönelik dava açabilecek ve dolayısıyla da mirasbırakanın asıl amacı gerçekleşmiş olacaktır. Mirasbırakan kelimeleri farkı kullandı diye tasarrufu bir hâlde geçersiz,ikinci hâlde ise geçerli kabul etmek *favor testamenti (vasiyetname lehine yorum)*[423] kuralına aykırı düşeceği için, birinci örneği

---

[420] *Kocayusufpaşaoğlu*, 2827den naklen.
[421] *Tuor* (Art. 482 N 22) bunu bir yazım hatası olarak görmektedir.
[422] *Tuor*, Art. 482 N 23; ayrıca bkz., *Oğuzman*, 146; *Kocayusufpaşaoğlu*, 284.
[423] Bkz., aşağıda, § 17, II, 1,a,aa.

de koşul yerine yükleme olarak yorumlayıp, dava açma hakkını tanımak mümkün olmalıdır[424].

2. Yüklemenin konusu

Federal Mahkeme, önceleri bir borcun konusu olabilen her şeyin yük- 759
lemenin de konusu olabileceğini, ancak buna bir sınırlama getirilmesi gerektiği görüşündeydi. Buna göre, yüklemenin konusu, mirasçı ya da vasiyet alacaklısına intikal eden tereke ya da vasiyetle ilgili olup, bunun nasıl kullanılacağı ya da kullanılmayacağına yönelik olmalıydı. Bunu aşan bir yüklemeyi ise, Federal Mahkeme kendiliğinden hükümsüz saymış ve durumun her zaman bir tespit davasının konusu olabileceğini kabul etmişti[425]. Bu karar bazı yazarlarca eleştirilmiş ve hukuka, ahlâka aykırı ve imkânsız olmayan her şeyin yüklemenin konusu olabileceği savunulmuştur, yeter ki, cebrî icra konusu olabilsin[426]. Eğer cebrî icra konusu olamıyorsa (örneğin bir kimseye, artık içki içmemesi yükümüyle bir ölüme bağlı tasarruf yapılmışsa), o zaman tasarruf koşula bağlanmalıdır[427]. Bu eleştiriler üzerine Federal Mahkeme, yukarıda belirtilen kararından dönerek, yüklemenin tereke ile ilgili olması şartından vazgeçmiştir[428]. Ancak tereke ile ilgili olmayan bir yüklemenin de , kişilik alanına müdahale etmemesi gerekir, aksi hâlde geçerli olmaz[429]. Bu bakımdan, yüklemenin, az da olsa, belirli bir ölçüde tereke ya da mirasbırakan ile ilgili olması önerilmektedir[430].

3. Yüklemenin yerine getirilmesi

Yüklemenin yerine getirilmesi ya rıza ile ya da dava ile olur. Dava, 760
yüklemeyi yerine getirmek zorunda olan yasal ya da atanmış mirasçı veya vasiyet alacaklısına karşı açılır. Davacı sıfatı, yüklemenin yerine getirilmesiyle ilgili olan herkese aittir (MK 515/I). İlgili kişi ile kastedilen, mirasbırakan tarafından yükleme ile izlenen amacın yerine getirilmesinde menfaati olan herkestir. Bu menfaatin herhangi bir malvarlığı menfaati, hatta hukuken korunan bir menfaat olması da gerekmez. Haklı olan herhangi bir manevî ya da etik menfaat de yeterlidir; tek şart, menfaatin, mirasbırakanın izlediği amaç ile doğrudan ilgisinin bulunmasıdır. Böyle bir menfaati olan kişinin, mirasbırakanın mirasçısı ya da hısımı da olması gerekli değildir; mi-

---

[424] Zımmen, *Druey*, § 11, N 31.
[425] BGE 94 II 88,93.
[426] *Merz*, ZBJV, 106 (1970), 50; *Piotet*, 148; *Druey*, § 11 N 29; ayrıca, *Kocayusufpaşaoğlu*, 282.
[427] *Piotet*, 448.
[428] BGE 101 II 25 vd.
[429] *Escher*, SJZ, 1962, 329 vd.; *Druey*, § 11 N 29; ayrıca, BGE 99 I 378 vd.
[430] *Druey*, § 11 N 29.

rasbırakanla hiç bir bağı olmayan bir üçüncü kişi de yüklemenin yerine getirilmesini dava edebilir[431]. Örneğin, mirasbırakan, kütüphanesinin doğduğu şehirdeki enstitüye verilmesini bir yükleme olarak mirasçılarına yüklemişse, bunun yerine getirilmesini, enstitü yönetim kurulu, o şehirde oturan bir öğretim üyesi ya da enstitünün faaliyetlerine katılan herhangi bir kimse isteyebilir. Çünkü, hepsinin, yüklemenin yerine getirilmesinde menfaatleri vardır[432]. Fakat, o şehirde oturan ve konu ile uzaktan yakından ilgisi olmayan bir kimse yüklemenin yerine getirilmesini isteyemez. Aynı şekilde, varsa, vasiyeti yerine getirme görevlisi ya da mirası resmen idare ile memur kişi de yüklemenin yerine getirilmesini isteyebilirler. Fakat, ilgili kişilerden farklı olarak, bu memurların, yüklemenin yerine getirilmesinde bir menfaatlerinin bulunması aranmaz. Onlar, yüklemenin yerine getirilmesini görevleri gereği, mirasbırakanın iradesinin yerine getirilmesini temin için dava açarlar. Bu sebeple, ilgili kişilerden farklı olarak, vasiyeti yerine getirme görevlisi ve terekeyi resmen idareye memur kişi, yüklemenin yerine getirilmesini dava edip etmemekte serbest olmayıp, aksine dava etmek zorundadırlar[433]. Belirtmeye gerek yoktur ki, ölüme bağlı tasarrufta yüklemeden yararlanacak kişi ya da kişiler açık olarak belirtilmişse, dava açma hakkına, ilgili sıfatıyla sadece onlar sahiptir.

761 İlgilinin açacağı davaya gelince; yukarıda da değinildiği gibi (vasiyetten farklı olarak), yükleme ifa davası açma hakkını vermez. Bu sebeple burada açılacak olan dava, sadece yüklemenin yerine getirilmesine ilişkin olacaktır *(Vollziehungsklage)*. Buna göre, davacı, kendisine bir ifada bulunulmasını değil, mirasbırakan tarafından izlenen amacın yerine getirilmesini ister. Ne var ki, bu sonuçtan davalı da dolaylı olarak yararlanabilir[434].

762 Yüklemenin ne zamandan itibaren yerine getirilmesinin istenebileceği MK 515/I c.2'de belirtilmiştir. Söz konusu hükme göre, *"Tasarruf hüküm ve sonuçlarını doğurduğu andan itibaren, her ilgili koşul ve yüklemenin yerine getirilmesini isteyebilir"*. Bundan da anlaşılacağı gibi, yüklemenin ifası *tasarruf icra edilir edilmez* istenebilir.

763 Hüküm bu hali ile, sadece *bağımsız olmayan* yüklemeleri, yani mirasbırakanın yüklemeli bir ölüme bağlı kazandırma yaptığı hâlleri içerdiği için, eksiktir. Bu bakımdan durumun *bağımsız olan ve olmayan* yüklemeler için ayrı ayrı incelenmesi gerekir.

---

[431] *Tuor*, Art. 482 N 14 vd; *Escher*, Art. 482 N 20; *Piotet*, 149; *Druey*, § 11 N 26/27; *Kocayusufpaşaoğlu*, 282.

[432] Örnekler için bkz., *Escher*, Art. 482 N 20; *Kocayusufpaşaoğlu*, 283; ayrıca krş., BGE 100 II 98.

[433] *Escher*, Art. 482 N20; *Tuor*, Art. 482 N 14 vd; *Piotet*, 149/150; *Kocayusufpaşaoğlu*, 283.

[434] *Escher*, Art. 482 N 1; *Tuor*, Art. 482 N 17; *Kocayusufpaşaoğlu*, 282; *Oğuzman*, 151.

Bağımsız olmayan yükleme bir atanmış mirasçıya yüklenmişse, yerine getirilmesi, atanmış mirasçının, tereke mallarına fiilen zilyet olduğu (malları teslim aldığı) andan itibaren istenebilir. Bağımsız olmayan yüklemeyi yerine getirecek olan vasiyet alacaklısıysa, ona karşı dava, vasiyet borcunun yerine getirilip, vasiyetin konusu ona fiilen teslim edildiği andan sonra açılabilir. 764

Bağımsız yüklemeleri yerine getirme borcu yasal mirasçılardadır. Onlar lehine yerine getirilecek bir ölüme bağlı tasarruf bulunmadığı için, yasal mirasçılara karşı yüklemenin yerine getirilmesi, mirasın kesin olarak iktisabı, yâni red hakkının herhangi bir şekilde düştüğü tarihten itibaren ileri sürülebilir. 765

Yüklemenin yerine getirilmesi yönünden MK 515 bir azami süre öngörmemiştir. Federal Mahkeme kural olarak, mirasbırakanın yüklemeyi yerine getirecek kişiyi, hayatı boyunca yüküm altına sokmak istediği farazi-yesini kabul etmekle beraber, mirasbırakanın böyle bir farazî iradesinin tespit edilemediği hallerde, MK 521/II'yi örneksemeyle uygulayıp, süreyi, yükümlü ile onun ilk sıradaki mirasçılarının hayatı boyu ile sınırlandırmaktadır[435]. 766

4. Hukuka ve ahlâka aykırı ya da yalnız başkasını rahatsız edici yüklemeler

Bu tür yüklemelere, kural olarak MK 515/II ve III'deki, aynı türden koşullara ilişkin hükümler uygulanır[436]. Ancak bağımsız, yani yasal mirasçılara yüklenmiş yüklemelerde hukuka ve ahlâka aykırı koşullara ilişkin hükümler, yüklemenin niteliği gereği uygulanamaz. Bu hâlde, hukuka ya da ahlâka aykırı olan yükleme hükümsüz olur, fakat mirasçı yasal miras hakkını alır[437]. 767

V. VAKIF KURMA

MK 102/I'e göre, *"Vakıf kurma iradesi resmi senetle veya ölüme bağlı tasarrufla açıklanır. Vakıf, yerleşim yeri mahkemesi nezdinde tutulan sicile tescil ile tüzel kişilik kazanır"*. Hüküm, ölüme bağlı tasarruftan söz ettiğine göre, vakıf, hem vasiyetname hem de miras sözleşmesi ile kurulabilir. Ancak, vakıf kurma işlemi, niteliği gereği bağlayıcı olmayan bir ölüme bağlı tasarruf olduğu için, miras sözleşmesi ile yapılsa bile, onun bağlayıcı olma- 768

---

[435] BGE 87 II 355,362; ayrıca bkz., *Druey*, § 11 N 35, 36; *Escher*, Art. 482 N 26; *Kocayusufpaşaoğlu*, 284; *Oğuzman*, 151.

[436] Bkz., yukarıda III, 3 ve 4.

[437] *Tuor*, Art. 482 N 26; *Piotet*, 151.

yan içeriğine girer ve bu sebeple de, tıpkı vasiyetnamede öngörülmüş gibi, mirasbırakan tarafından ölümüne kadar her zaman serbestçe geri alınabilir.

769 MK 102/I'e paralel olarak, MK 526/I, *"Mirasbırakan, terekesinin tasarruf edilebilir kısmının tamamı veya bir bölümünü özgülemek suretiyle vakıf kurabilir"*, hükmünü getirmiştir.

770 Ölüme bağlı tasarrufla kurulan vakıf da MK 526/II'ye göre, sağlar arası kurulan vakıf hükümlerine tabi olduğuna göre, MK 526'nın da ayrıca vakıf kurmaya ilişkin bir hüküm içermesinin amacı nedir? Yazarlar, bu hükmün amacını şöyle açıklamaktadırlar: a) mirasbırakanın vakıf kurarken tasarruf edilebilir kısım (tasarruf nisabı) ile bağlı olduğunu ve b) mirasın geçişi ânında, vakıf tüzel kişilik kazanmamış (yani mirasçı olma ehliyetine sahip olmamış) bulunmasına rağmen, bunun tasarrufun geçerliğine engel olmayacağını belirtmek[438].

771 Ölüme bağlı tasarruf ile kurulan vakfın, ne zaman tüzel kişilik kazanacağı ve kendisine tahsis edilen (özgülenen) mal ya da malvarlığını ne zaman iktisap edeceğini açıklamaya başlamadan önce, MK 526'nın uygulama alanını belirtelim. MK 526, ölüme bağlı tasarrufun bir tüzel kişilik (vakıf) kurma ve müstakbel tüzel kişiye mal tahsis edilmesi amacını izlenmesini düzenlemektedir. Bu bakımdan önce, zaten var olan bir vakıf lehine yapılan ölüme bağlı kazandırmalara uygulanmaz. Örneğin kurulu olan *Fakirleri Koruma Vakfına* bir miktar para vasiyet edilir ya da bu vakıf (tasarruf edilebilir kısmın sınırları içinde) mirasçı atanırsa, bu tasarruflara MK 526 hükümleri değil de MK 516 ya da 517 ye ilişkin hükümler uygulanır. Aynı şey, mirasçılara, var olan bir vakfın amacının gerçekleştirilmesi için bir yüklemenin yapılması hâlinde de söz konusudur. Bazı yazarlar, kurulu bir vakıf lehine ölüme bağlı tasarruf yapılan hâllerde bağımsız olmayan ya da inançlı vakıftan söz ederler[439].

772 Mirasbırakanın ölüme bağlı tasarruf ile kurduğu vakfa, üçüncü kişilerin kazandırma yapmalarına da MK 526 değil, MK 516 ya da 517 uygulanır. Aynı şekilde, mirasbırakanın bizzat sağlığında kurduğu bir vakıf lehine ölüme bağlı kazandırma yapması da MK 526'ya girmez[440].

773 Belirli bir amaç öngören, tüzel kişiliği olmayan birden fazla kişi lehine yapılan tasarruflarda, amacın bu yolla gerçekleşmesi mümkün olmadığı için MK 577/II'ye göre kurulan vakıfların MK 526'ya tabi olup olmayacağı tartışmalıdır[441].

---

[438] *Tuor*, Art. 493 N 1; *Escher*, Art. 493 N 1; *İmre/Erman*, 140; ayrıca bkz., *Piotet*, 124.

[439] *Escher*, Art. 482 N 14; Art. 493 N 10; *Tuor*, Art. 493 N 11; *Tuor/Schyder*, 116; *Hatemi*, 261; BGE 48 II 165.

[440] *Escher*, Art. 493 N 2.

[441] Tartışmalar için bkz., *Tuor*, Art. 492 N 15; *Tuor/Picenoni*, Art. 539 N 15; *Escher*, Art. 539 N 15; *Kocayusufpaşaoğlu*, 530.

Baskın görüş, ölüme bağlı tasarruf ile vakıf kurmanın tek bir işlem ola- 774
rak gözükmesine rağmen aslında birbirinden farklı iki hukuki işlemi içerdiğini kabul eder. Bu işlemler, yeni bir tüzel kişiliğin kurulması ve bu yeni tüzel kişiliğe malvarlığı özgülenmesidir[442]. Azınlıkta kalan yazarlar ise bu görüşe karşı çıkmaktadırlar. Onlara göre vakıf kurmanın tek bir amacı vardır, o da bir tüzel kişilik yaratmadır. Mal tahsisi ayrı bir işlem olmayıp, tüzel kişiliğin temel unsurudur[443].

Vakfın tüzel kişilik kazanmasına dönecek olursak; MK 526, ölüme bağ- 775
lı tasarruf ile kurulan vakıflar yönünden özel bir düzenleme öngörmemiş, tam aksine ikinci fıkrasında, *"Vakıf ancak kanun hükümlerine uyulmak koşuluyla tüzel kişilik kazanır"* diyerek, MK 102 vd.na yollama yapmıştır. Bu hükümden anlaşılacağı üzere vakıf, mirasbırakanın ölümü ile değil, daha sonra kanuni şartlar gerçekleşince (mirasbırakanın yerleşim yeri asliye hukuk mahkemesindeki sicile tescil ile) tüzel kişilik kazanacaktır[444]. Ancak sağlıkta kurulan vakıflardan farklı olarak, şekil yönünden resmî senedin yerini (resmî, elyazılı ya da sözlü) vasiyetname ya da miras sözleşmesi alır.

Kimlerin vakfın tescil edilmesi isteminde bulunacağına gelince; MK 776
102/III'e göre, *"Mahkemeye, başvurma resmi senet düzenlenmiş ise vakfeden tarafından; vakıf ölüme bağlı tasarrufa dayanıyorsa ilgililerin veya vasiyetnameyi açan sulh hakiminin bildirimi üzerine ya da Vakıflar Genel Müdürlüğünce re'sen yapılır". Türk Medeni Kanununa Göre Kurulan Vakıflar Hakkındaki Tüzük*'ün 5. maddesine göre, *"Vasiyet yoluyla kurulan vakıflarda vakfedenin mirasçısı veya vakfeden tarafından mirası resmen idare etmekle görevlendirilmiş kişi, tescil talebinde bulunabilir. Vasiyetnamenin açılması tarihinden itibaren, üç ay içinde bunlar tarafından tescil talebinde bulunulmamış ise vakfın tescili hususundaki başvurma Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılır"*. Hemen belirtmek gerekir ki, *vakfeden tarafından mirası resmen idare etmekle görevlendirilmiş kişi, vasiyeti yerine getirme görevlisi* (MK 550 vd) olarak anlaşılmalıdır.

Ölüme bağlı tasarrufla kurulan vakıfların kendilerine özgülenen malı 777
hangi anda kazanacağı tartışmalıdır Tartışmanın kökeninde iki husus yatmaktadır. Bunlardan birincisi, ölüm ânında vakfın tüzel kişiliğe sahip olmaması ve dolayısıyla da (hak ehliyetine sahip olmadığı için) mirasçı olma ehliyetine sahip olmaması; ikincisi ise, *"Özgülenen malların mülkiyeti ile haklar, tüzel kişiliğin kazanılması ile vakfa geçer"* diyen MK 105/I hükmüdür.

---

[442] *Escher*, Art. 493 N 1 ve 4; *Tuor*, Art. 493 N 3; *Kocayusufpaşaoğlu*, 283; *Köprülü*, 201.
[443] Örnek olarak bkz., *Hatemi*, Vakıf, 350 vd; *Oğuzman*, 158/159.
[444] Gerekçe, 480.

778 Çoğunlukta olan görüş[445], buraya, ceninin mirasçılığına ilişkin hükümleri örneksemeyle uygulamaktadır. Buna göre, vakıf, lehine yapılmış kazandırmayı ölüm ânında kazanır. Ancak, vakıf daha tescil edilip, tüzel kişilik kazanmadığı için, onun bu iktisabı, sonradan tescil ile tüzel kişiliği elde etmesi kanunî şartına bağlıdır. İşte bu sebepledir ki, vakfın durumu cenine örneklenmektedir. Şöyle ki, ceninin durumunu düzenleyen MK 582/I'e göre, *"Cenin sağ doğmak koşuluyla mirasçı olur"*. Bu hüküm, çocuğun sağ doğması şartıyla ana rahmine düştüğü andan itibaren hak ehliyetine sahip olacağını söyleyen MK 28/II ile birlikte ele alındığı zaman, çocuğun hak ehliyeti ana rahmine düştüğü andan itibaren başlamakta ve cenin, sağ doğmak şartıyla geçmişe etkili olarak tereke üzerinde hak sahibi olmaktadır. Bu hüküm, örnekseme yoluyla ölüme bağlı tasarrufla kurulan vakfa uygulanınca, vakfın, tüzel kişilik kazanması şartıyla, geçmişe etkili olarak, miras açıldığı andan itibaren hak sahibi olacağı sonucuna varılmaktadır. Böyle olunca da, mirasbırakan kurduğu vakfı mirasçı nasbetmişse, vakıf tüzel kişilik kazanması şartıyla mirasbırakan öldüğü anda ona küllî halef olacaktır. Vakıf vasiyet alacaklısı yapılmışsa, yine miras açıldığı anda alacak hakkına sahip olacak, ancak bunu, tüzel kişiliği kazandıktan sonra ileri sürecektir. Vakfa malvarlığı bir yükleme şeklinde özgülenmişse, o zaman tüzel kişiliğin kazanılmasıyla, ilgili sıfatıyla vakıf yönetimi MK 515/I'e göre yüklemenin yerine getirilmesini isteyebilir.

779 Vakfın, mirasın açıldığı anda hak sahibi olacağı görüşünün, vakfın tüzel kişiliği kazanması ile birlikte kendisine özgülenen mallar üzerinde hak sahibi olmasını öngören 105/I ile nasıl bağdaştırılabileceğine gelince; bu konuda özellikle vakfın mirasçı atanması hali için değişik çözümler ileri sürülmektedir. Önce, MK 105/I'in daha ziyade sağlararası işlemle kurulan vakıfları göz önünde bulundurduğu, MK 526'nın ölüme bağlı tasarruflarla kurulan vakıflar için özel bir düzenleme getirdiği belirtilmekte, bu sebeple de vakfın tescilden önce mirasçı sıfatıyla özgülenenleri iktisap ettiği söylenmektedir[446]. Bir başka gerekçeye göre,bu hâlde vakıf yine tescille mülkiyeti kazanmakta, fakat mirasçı atanan vakıflarda bu kazanma MK 599 ve örneksemeyle uygulanan MK 28/II gereğince geçmişe etkili sayılmaktadır. MK 105/I'de de bu geçmişe etkiyi engelleyecek bir hüküm bulunmamaktadır[447]. Özetle vakıf yine tescille tüzel kişilik kazanmaktadır. Ancak bu gerekçeyi ileri süren yazarlardan bazıları, vakfın vasiyet alacaklısı atanması

---

[445] *Tuor*, Art. 493 N 10; *Escher*, Art. 493 N 7; *Egger*, Art. 81 N 7; *Gutzwiller*, 593; *İmre/Erman*, 141/142; *Ayiter/Kılıçoğlu*, 128; *Kocayusufpaşaoğlu*, 296; *İşeri*, 114; *Köprülü*, 203; ayrıca bkz., BGE 99 II 246.

[446] *Kocayusufpaşaoğlu*, 287; *İmre/Erman*, 142; (fakat krş., *İmre*, AD 1968, 133; *İmre*, Miras, 213); *Köprülü*, 203; krş., *Akünal*, 133.

[447] *Kocayusufpaşaoğlu*, 287; *İşeri*, 117; *Özsunay*, 174.

hâlinde, MK 105/I'e bir istisna bulunduğunu ve vakfın vasiyete yönelik alacak hakkını tescilden önce ölüm ânında kazanacağını ileri sürmektedirler[448]. Azınlıkta kalan yazarlar,vakfın iktisabının geçmişe etkili sayılması için yeterli dayanak bulunmadığını ileri sürerek ölüme bağlı tasarrufla kurulan vakıflarda artmirasçılığa ilişkin hükümlerin uygulanacağını, bu sebeple vakfa tahsis edilen malların ölümle yasal mirasçılara ait olacağını ve vakfın artmirasçı sıfatıyla bunları tescilden sonra iktisap edeceğini savunurlar[449].

Tartışmalı olan bir başka konu da, mirasçı atanan vakfın mirası reddedebilip edemeyeceğidir. Baskın görüş, mirasçı atanan vakfın mirası reddedemeyeceği yönündedir. Denilmektedir ki, her ne kadar vakıf kurma iki ayrı işlemi (tüzel kişilik yaratma ve mal özgülenmesi) içermekteyse de, bunlar ayrılmaz bir bütün oluştururlar ve bu sebeple de ya ikisi birden vardır ya da ikisi birden hükümden düşerler. Red hakkını kabul etmemenin, terekenin pasifinin aktifinden fazla olduğu hâller için de bir mahzuru yoktur. Çünkü böyle bir durumda vakıf malvarlığından yoksun olduğu için kurulamayacaktır. Kaldı ki, böyle bir hâlde vakfın, resmî defter tutulmasını istemesine de bir engel yoktur[450]. 780

Son olarak belirtelim ki, vakfın mirasçı atanması durumunda, mirasbırakanın borçlarından sorumluluğuna bir sınırlama getirilmiştir. MK 105/III'e göre ölüme bağlı tasarrufla kurulan vakıfların mirasbırakanın borçlarından sorumluluğu kendisine özgülenen mal ya da haklar ile sınırlıdır. Bu hükmün amacı Gerekçe'de şöyle açıklanmaktadır: *"Böylece, vakfın kurulmasından sonra bazı mal ve haklar elde etmesi ihtimali bakımından, mirasbırakanın alacaklılarının, vakfa mirasbırakana intikal eden mal ve haklar dışında vakfı sorumlu tutmaları önlenmek istenmiştir"*[451] 781

VI. YEDEK VE ARTMİRASÇI ATAMA (İkameli Tasarruflar)

Eski Medeni Kanun, yedek mirasçı atama yerine alelade ikame (MK 467), artmirasçı atama yerine de fevkalade ikame (MK 468) terimlerini kullanıyordu. Ancak, doktrinde, ZGB 487 ve 488, BGB § 2096 ve 2190' da kullanılan ve daha doğru olan yedek mirasçı ve artmirasçı atama terimleri yerleşmişti. Yeni MK 520 ve 521 vd. maddelerinde bu doğru terimleri tercih etmiştir. 782

1. Yedek mirasçı atama

MK 520'de düzenlenmiş olan yedek mirasçı atama ile mirasbırakan, mirasçı atadığı ya da vasiyet alacaklısı olarak nasbettiği kimsenin herhangi bir sebeple mirasa ya da vasiyet alacağına nail olamaması hali için onun ye- 783

---

[448] *İşeri*, 119; *Özsunay*,174; bu görüşün eleştirisi için bkz., *Kocayusufpaşaoğlu*, 288.

[449] *Oğuzman*, 160; *İnan/Ertaş*, 194; krş., *Hatemi*, Vakıf, 183, 343 vd.

[450] *Tuor*, Art. 493 N 6; *Escher*, Art. 493 N 6; *Piotet*, 124; *Kocayusufpaşaoğlu*, 287; aksi görüş, *Hatemi*, Vakıf 182 vd.

[451] Gerekçe 358.

rini kimin alacağını belirlemektedir. Örneğin, *"A'yı terekemin 1/4'ü için mirasçı atıyorum (ya da A'ya otomobilimi vasiyet ediyorum)*. A'nın mirasçı (vasiyet alacaklısı) olamaması hâlinde onun yerine B mirasçı (vasiyet alacaklısı) olacaktır" biçimindeki tasarruf bir yedek mirasçı ya da yedek vasiyet alacaklısı atamadır. MK 520/II'ye göre yedek mirasçı atamaya ilişkin hükümler, yedek vasiyet alacaklısı atamaya da uygulanacağından, bundan sonra –bir özellik olmadığı sürece-, yedek mirasçı atama açıklanacaktır.

784 MK 520, bu hükmü ile, lehine tasarruf yapılan kimsenin, ölüme bağlı tasarrufta öngörülen hakkı elde edememesi hâlinde, onun yerini yasal mirasçılığın alacağı kuralına (MK 580/I, 581/II, 611/II) bir istisna getirmekte ve böylece mirasbırakana terekesi üzerinde daha geniş bir tasarruf imkânı tanımaktadır. Yukarıda verdiğim örnek üzerinde duracak olursak; atanmış mirasçı A, mirası reddetmiş olsaydı, onun payı genel kurala göre en yakın yasal mirasçılara geçecekti. Oysa mirasbırakan, yedek mirasçı atayarak bu hükmün uygulanmasını engellemekte ve A'nın payını red hâlinde yasal mirasçılara değil de B'ye geçmesini temin etmektedir[452]. Hatta yedek mirasçı atama yoluyla, mirasbırakan yasal mirasçılıktaki halefiyet kuralını da bertaraf edebilir. Örneğin, mirasbırakanın hayatta olan hısımları kardeşi ve kardeş çocuklarıdır. M, kardeşinin, herhangi bir sebeple mirasa nail olamaması hâlinde, kardeşinin çocuklarının mirasçı olmasını istememektedir. İşte bu durumda mirasbırakan bir yedek mirasçı atayarak, kardeşinin mirasçı olamaması hâlinde onun yerini kimin alacağını belirterek, mirasın yeğenlerine geçmesini engelleyebilir[453]. Belirtmeye gerek yoktur ki, bu son söylenenler, ön sırada yer alıp da herhangi bir sebeple mirasa nail olamayana halef olacak mirasçıların saklı paylı olmaları hâlinde uygulanamaz.

785 MK 520/I, ölüm ya da mirası reddetmesi hâlinde yedek mirasçının hak sahibi olacağını öngörmektedir. Baskın görüş, haklı olarak, yedek mirasçı atama hükümlerinin sadece bu hâllerde değil, asıl mirasçının bunlar dışındaki herhangi bir sebeple de (mirastan yoksunluk ve çıkarma, feragat ya da lehine olan ölüme bağlı tasarrufun iptali) hakkına nail olamadığı durumlarda da yedek mirasçı atama hükümlerinin uygulanacağını kabul eder, meğer ki, yorum yolu ile mirasbırakanın iradesinin aksi yönde olduğu anlaşılsın[454]. Örneğin, mirasbırakan vasiyetnamesinde, *"A'yı terekemin 1/4'ü için mirasçı atıyorum. A herhangi bir sebeple mirasçım olamazsa, onun yerine B'yi atıyorum"* demiş ve A, yoksunluk sebeplerinden biri gerçekleştiği için, mirasçı sıfatını kazanamamışsa, yoksunluk MK 520'de belirtilmemiş olmasına rağmen, B mirasçı olur. Buna karşılık mirasbırakan, vasiyetnamesinde, sadece ölümün yedek mirasçılık sebebi olacağını belirtmiş olsaydı, B mirasçı olamazdı. Çünkü bu hâlde, mirasbırakanın ifadesinden, diğer hâllerde yedek mirasçılık değil de, yasal geçiş kurallarının uygulanacağı açık olarak anlaşılmaktadır.

---

[452] *Tuor*, Art. 487 N 7; *Escher*, Art. 487 N 1; *Piotet*, 102; *Ayiter/Kılıçoğlu*, 118.

[453] Krş., *Tuor*, Art. 487 N 7; *Escher*, Art. 487 N 1; *Piotet*, 102; *Ayiter/Kılıçoğlu*, 118.

[454] *Escher*, Art 487 N 4; *Tuor*, Art. 487 N 5 ve 6; *Krayenbühl*, 152; *Piotet*, 102; *Kocayusufpaşaoğlu*, 298; *Ayiter/Kılıçoğlu*, 117; *İmre/Erman*, 128; *Oğuzman*, 152; *İnan/Ertaş*, 185; *Köprülü*, 183.

Bu açıklamalardan anlaşılacağı gibi, yedek mirasçının (ve yedek vasi- 786
yet alacaklısının) hakkı geciktirici şarta bağlanmıştır[455]. Eğer şart, miras açıldığı zaman (örneğin asıl mirasçı mirasbırakandan önce öldüğü ya da feragat ettiği için) zaten gerçekleşmişse, yedek mirasçı hakkını ölüm ânında elde eder. Buna karşılık şart ölümden sonra gerçekleşmişse (örneğin mirasbırakandan sonra ölme, red ya da ölüme bağlı tasarrufun iptali), hak mirasbırakanın ölümü ânında asıl mirasçıya ait olur ve şart gerçekleştikten sonra yedek mirasçıya geçer[456].

Asıl mirasçı (ya da vasiyet alacaklısı) olarak birden fazla kimsenin 787
atandığı hâllerde mirasın yedek mirasçıya (ya da yedek vasiyet alacaklısına) geçmesi için, yedek mirasçı atanmasına temel olan olayın bütün asıl mirasçılar için gerçekleşmesinin gerekip gerekmediği, mirasbırakanın iradesinin yorumundan çıkartılır. Eğer yorum, şartın hepsinde değil de, sadece birinde gerçekleşmesinin yeterli olduğu yönündeyse o zaman yedek mirasçı sadece şartın şahsında gerçekleştiği kişinin payına orantılı hak elde eder[457].

Yedek mirasçı atamanın karşılıklı olarak da yapılması mümkündür *(substitutio reciproca)*. Burada birden fazla asıl mirasçı aynı zamanda yedek mirasçı olarak da atanmaktadır. Örneğin M, A,B ve C'yi mirasçı olarak atar. A'nın ölmesi hâlinde B ve C'nin; B'nin ölmesi hâlinde, C ve A'nın mirası alacaklarını öngörmüşse, bu bir karşılıklı yedek mirasçı atama olur[458]. 788

Baskın görüş, yedek mirasçının, mirasbırakan öldüğü anda sağ olmasını 789
aramaktaysa da, yedek mirasçılığa esas olan olayın gerçekleştiği anda sağ olmasını aramamakta, bu hâlde hakkın onun mirasçılarına geçeceğini kabul etmektedir[459].

Son olarak belirtelim ki, artmirasçı atamadan farklı olarak yedek miras- 790
çı atamada sayı yönünden bir sınırlama yoktur.

2. Artmirasçı atama

a) Kavram ve genel bilgiler

Artmirasçı atama kurumu MK 521-525. maddeler arasında düzenlen- 791
miştir. MK 521/I'e göre, *"Mirasbırakan, ölüme bağlı tasarrufuyla önmirasçı atadığı kişiyi mirası artmirasçıya devretmekle yükümlü kılabilir"*. Görüldüğü gibi burada, mirasbırakan, kendisine ard arda mirasçı olacak ki-

---

[455] *Tuor*, Art. 487 N 1; *Escher*, Art. 487 N 2; *Ayiter/Kılıçoğlu*, 117.
[456] *Piotet*, 102.
[457] *Tuor*, Art. 487 N 7; *Escher*, Art. 487 N 5; *Piotet*, 100.
[458] *Tuor*, Art. 487 N 10; *Escher*, Art. 487 N 5; *Piotet*, 100 ve 103.
[459] *Tuor*, Art. 487 N 11; *Piotet*, 102; *Köprülü*, 184; *İmre/Erman*, 129; *İnan/Ertaş*, 185; *Escher*, birinci basısında (Art. 487 N 4a) bu görüşü benimsemişse de, ikinci basısında (Art. 487 N 2) aksi görüşü savunmuştur.

şileri belirlemektedir. Bu bakımdan artmirasçılık, kural olarak iradi mirasçılıkla ilgili bir kurumdur. Başka bir deyişle, mirasbırakan, kendisine ard arda küllî halef olacak kişiyi belirlemektedir. İşte artmirasçılık ile yedek mirasçılık arasındaki en önemli fark buradadır. Yedek mirasçı atamada (MK 520) mirasbırakan yedek mirasçı (ya da yedek vasiyet alacaklısı) olarak belirlediği A ile B'den ya biri ya da diğeri hak sahibi olurken; artmirasçı (ya da art vasiyet alacaklısı) atamada hem A hem de B sıra ile mirasçı (ya da vasiyet alacaklısı) olurlar.

792 MK 521/I kurumu, mirasçı atanması yani küllî halefiyet için düzenlemişse de, MK 521/III, *"Bu kurallar belirli mal bırakmada da uygulanır"* diyerek, bu yolla vasiyet de yapılabileceğini, yani cüzî halefiyetin de düzenlenebileceğini belirtmiştir. Bu bakımdan, burada yapılacak açıklamalar, her ne kadar artmirasçı atanmasına ilişkin olacaksa da, aynı kurallar bu yolla vasiyet alacaklısı atanması hâli için de geçerlidir. Her ikisine de ilişkin özel durumlar, aşağıda (b ve c)'de ayrıca incelenecektir.

793 MK 521 vd., ilk sırada mirasçı olacak kişi için *devretmekle yükümlü önmirasçı*, ondan sonra mirasçı olacak kişi için de *artmirasçı* terimini kullanmıştır.Vasiyet söz konusuysa, *ön vasiyet alacaklısı ve art vasiyet* alacaklısı terimleri kullanılmaktadır[460].

794 Görüldüğü gibi, artmirasçı atama, terekesinin akıbetini düzenleme açısından mirasbırakana daha geniş imkânlar tanıyan bir kurumdur ve bu da bir ihtiyaçtan kaynaklanmaktadır. Bu kurumun düzenlenmesinin temelinde iki görüşün yattığı ileri sürülmüştür[461]. Bunlardan birincisi, terekesinin tamamı ya da belirli bir bölümünün mirasçısına geçmesini isteyen, fakat bunun mirasçısının mirasçılarına geçmesini istemeyen mirasbırakana bunu engelleme imkânının verilmesidir. Örneğin E, M'nin karısıdır. Fakat E'nin daha önceki bir evliliğinden çocukları vardır. M'nin eşi E'den başka mirasçısı yoktur. M, mirasının eşi E'ye kalmasını istemekte, fakat E'nin ölümünden sonra çocuklarına geçmesini istememektedir. İşte M, terekesinin, en azından E'nin saklı payı dışında kalan kısmı için, E'nin ölümü hâlinde kendisine kimin mirasçı olacağını artmirasçı atayarak belirleyip, istemediği sonucun gerçekleşmesine engel olabilir.

795 İkinci olarak da, malvarlığının (terekesinin) mirasçıları tarafından yeteri kadar iyi yönetilmeyeceği ve değerinin azalacağı endişesi duyan mirasbırakanın, bu yolla artmirasçılıktaki güvence hükümlerini harekete geçirerek malvarlığının değerini koruyabileceği ileri sürülmüştür. Nihayet, bunlara bir de, mirasbırakana, henüz ana rahminde dahi bulunmayan bir kimseyi mirasçı atama imkânını da verdiğinin eklenmesi gerekir (MK 583).

796 Artmirasçılığın en önemli özelliği, gerek önmirasçının gerek artmirasçının mirasbırakanın halefi olmalarıdır. Bu halefiyet, mirasçı atanmasında küllî, vasiyetçi atamada cüzî halefiyettir. Her ikisi yönünden de halefiyet

---

[460] Bkz., *Kocayusufpaşaoğlu,* 294.

[461] *Escher,* Art. 488-493 Vorbem. 5; *Tuor*, Art. 488-493 Vorbem. 12.

şart ya da ecele bağlıdır. Bunlar üzerinde aşağıda durulacaktır. Her iki halefiyetin aynı türden olması gerekir,bu bakımdan, mirasbırakanın, mirasçı atadığı bir kimseye (küllî halef), terekede bulunan bazı malları başkasına vermesini (cüzî halefiyet) öngördüğü bir tasarruf, artmirasçı olmayıp, bir ecele ya da şarta bağlı bir vasiyettir[462].

Artmirasçılığa karşı ileri sürülen en önemli eleştiri, bunun sınırsız kabul 797
edilmesi hâlinde, bu yolla bir malvarlığı, onun bir kısmı ya da terekeye dahil olan bir malın artık tedavülden kalkacağı, bunun bugünkü ekonomik hayat ile bir çelişki yaratacağı ve orta çağın fidei komisine benzer bir kuruma yeniden hayat kazandıracağı endişesidir. Kanunkoyucu, bu eleştirileri bertaraf etmek için, MK 521/II'de, *"Aynı yükümlülük artmirasçıya yüklenemez"* diyerek, artmirasçılığı bir dereceli olarak sınırlamıştır. Böylece mirasbırakan artmirasçılık yoluyla, sırasıyla mirasçı olmak üzere A veB'yi atayabilir, fakat B'ye de C'ye devir etme yükümünü getiremez. Böyle, üçüncü kişiye de devir etme yükümünü içeren artmirasçı atama tasarrufları, MK 557 b.3 anlamında kanuna aykırı oldukları için iptal edilirler. Böyle bir tasarruf, kanuna aykırı olduğu için, artmirasçının, kendisine üçüncü kişiye devir etme yükümünü getiren tasarrufu iptal ettirmeyeceğini miras sözleşmesi ile (bağlayıcı olarak) taahhüt etmesi de geçersiz olur[463]. Belirtelim ki, MK 521/II'deki bu hükmün, aile vakfı kurulmasına imkân veren MK 372 yoluyla dolanılmasını engellemek için, maddenin ikinci fıkrasına şu hüküm konulmuştur: *"Bir malın veya hakkın başkalarına geçmemek üzere aynı soydan gelenlere kuşaktan kuşağa kalacak şekilde özgülenmesi yasaktır. Böyle bir özgülenme vakıf yoluyla da yapılamaz"*

Bir dereceli artmirasçılık kuralı, artmirasçılığın yedek mirasçılık ile birlikte bu- 798
lunmasına engel değildir. Örneğin M, vasiyetnamesinde B'yi artmirasçı atamış, onun mirasçı olamaması hâlinde C'nin mirasçı olacağını öngörmüşse bu tasarruf geçerlidir. Çünkü artmirasçı atanması yine bir derecelidir ne var ki yedek mirasçı atama ile birlikte yapılmıştır.

Belirtmek gerekir ki, emredici bir kural olan MK 521/II'nin bu ifade tarzı ile 799
hükmün izlediği amacı (tasarruf konusu mal ya da malvarlığının tedavülden çekilmesini ve ortaçağ anlamında aile fidei komisinin kurulmasını engellemek) aştığı ileri sürülmüştür. Bu görüşte olan yazarlara göre[464], sözü edilen ekonomik ve politik tehlikelerin bulunmadığı hallerde daha çok dereceli artmirasçı atanmasına izin vermemenin hiç bir haklı nedeni yoktur. Özellikle artmirasçılığın nesiller boyunca süregelmesini engellemek isteyen MK 521/II'ye dayanarak aynı nesil içinde ikameye engel olmanın hiç bir haklı sebebi yoktur. Örneğin, mirasbırakanın üç kardeşini (aynı nesil) sırayla artmirasçı atamasını bu hükme göre engellememek gerekir.

MK 521/II hükmünün amacını aştığı görüşünde olan yazarlar, bizzat kanunun bu 800
kuralı ihlal ettiği fikrindedirler. Bu yazarlara göre, örneğin MK 513 böyle bir hü-

---

[462] *Escher*, Art. 488-493 Vorbem 5; *Tuor*, Art. 488-493 Vorbem. 12.
[463] *Tuor*, Art. 488 N 8 ve 9; *Escher*, Art. 488 N 4; *Piotet*, 105.
[464] Örnek olarak bkz. *Tuor*,Art. 468 N 10; *Escher*, Art. 468 N 8; *Piotet*, 105/106.

kümdür. Bu hükmü göre, borç ödemeden aciz sebebiyle mirasçılıktan çıkarma (aciz sebebiyle mirastan ıskat) hâlinde, mirasbırakan borç ödemekten aciz olan altsoyunun saklı payının yarısını, onun, henüz cenin olarak dahi bulunmayan çocuğuna tahsis edebilir. Bu bir tür artmirasçı atamadır (kurucu ikame). Kanunkoyucu burada artmirasçıların sayısı yönünden bir sınırlama getirmiş değildir. Kaç çocuk doğacak olursa olsun, bunlar saklı payın 1/2'sinden pay alacaklardır. Örneğin M, oğlu A'yı borç ödemedeki aczi sebebiyle mirastan uzaklaştırarak, onun saklı payının 1/2'sini o anda var olan ve ileride doğacak olan çocuklarına tahsis etmiştir. M'nin ölümünde, A'nın var olan çocuğu B, önmirasçı olarak 1/2 payı alacaktır. Eğer A'nın daha sonra C adında bir çocuğu olursa B, önmirasçı olarak aldığı miras payının yarısını artmirasçı sıfatıyla C'ye verecektir. Buraya kadar artmirasçılık hükümlerini ihlal eden bir durum yoktur. Problem, A'nın daha sonra D adında bir çocuğunun olması hâlinde ortaya çıkacaktır. Çünkü B ve C kendilerinde olan miras payının 1/2'sini MK 513/I gereğince D'ye vermek zorunda kalacaklardır ve böylece MK 521/II'ye aykırı iki dereceli bir artmirasçılık ortaya çıkacaktır. Diğer bir grup yazar ise, MK 513/II'deki durumun MK 521/II'ye aykırı olmadığını bu hükmün *ratio legis*'inden hareket ederek açıklamaktadırlar[465]. Buna göre MK 521/II'nin amacının artmirasçılığı zaman yönünden sınırlamak olduğu düşünülürse, MK 513/II'de buna bir aykırılık yoktur. Çünkü burada artmirasçılık, ailenin aynı zaman içinde var olan belirli bir kuşağı ile sınırlandırılmıştır ve mirası bu kuşak birlikte iktisap etmektedir, yoksa kuşağa dahil olan mirasçılardan her biri ayrı ayrı artmirasçılık yoluyla değil...

801 İleri sürülen diğer bir görüş, bizzat MK 321'in artmirasçılık hükümlerinin kanunun öngördüğü bir dereceli olma amacını ihlal ettiğidir[466]. Şöyle ki, aşağıda açıklanacağı üzere artmirasçılığın açılması bir ecele bağlanmış ve ecel dolmadan önmirasçı ölmüşse, MK 522/I'e göre miras, güvence (teminat) göstermeleri şartıyla, ecel gerçekleşene kadar önmirasçının mirasçılarına geçer. Böylece MK 521/II ile, ard arda üç intikal olduğu için bu hüküm arasında bir çelişki bulunduğu söylenmektedir. Gerçi bazı yazarlar kanunun iki dereceli artmirasçılığı yasakladığı, fakat iki dereceli intikali yasaklamadığı[467] ya da bu durumda bir artmirasçılığın değil de önmirasçılığın benimsenmiş bulunduğu[468] ileri sürerek, derece yönünden bir çelişki bulunmadığını söylemişlerse de bu ayırımın pratik sonucunun ne olacağını anlamak zordur. Özellikle kanunun ecel yönünden bir zaman sınırlaması getirmemiş olması, MK 522/II hükmünün MK 521/II hükmünü ihlal ettiği kuşkusunu daha da pekiştirmektedir. Örneğin, bugün bir vasiyetname yapan mirasbırakan, vasiyetnamesinde, *"Arkadaşım A'yı önmirasçı atıyorum. O, 2100 yılında mirası Çocuk Esirgeme Kurumuna verecekdir"* demiş olsa[469]; 2100 yılına kadar en az iki nesil mirasa el koyacak ve böylece iki, üç ve belki de daha fazla dereceli artmirasçılık söz konusu olacaktır ki, bu da MK 521/II hükmü ile bağdaşamaz. Bu yüzden *Piotet*[470], MK 521/I hükmünü *nesil yönünden değil de zaman yönünden* bir sınırlama getirmek istediği şeklinde yorumlayıp, MK 797'yi örneksemeyle uygulayıp, ecel süresinin azami 100 yıl ile sınırlandırılmasını önermektedir.

---

[465] *Escher*, Art. 488 N 5; *Tuor*, Art. 488 N 12; *Piotet* (106), bu görüşe kısmen katılmakta kısmen ise eleştirmektedir.
[466] *Escher*, Art. 488 N 5; *Tuor*, Art. 488 N 12; *Piotet*, 106.
[467] *Escher*, Art. 488 N 5.
[468] *Tuor*, Art.488 N 13.
[469] Örnek için bkz., *Tuor*, Art. 488 N 13; *Piotet*, 106.
[470] *Piotet*, 106 ve 107.

b) Artmirasçı atama

aa) Genel bilgiler

Yukarıda da değinildiği gibi, mirasbırakanın, biri diğerinden sonra ge- 802
lecek şekilde kendisine iki mirasçı ataması hâlinde artmirasçı atamadan söz edilir. Bu halde mirasbırakan ölür ölmez ona mirasçı olan kişiye *önmirasçı*; daha sonra mirasçı olacağa ise *artmirasçı* denir. Yine yukarıda belirtildiği gibi, gerek önmirasçı gerek artmirasçı doğrudan doğruya mirasbırakanın küllî halefidirler ve bu sıfatlarını mirasbırakanın iradesinden alırlar. Eğer ön ya da artmirasçıdan biri sıfatını mirasbırakanın iradesinden değil de kanundan alıyorsa, o zaman artmirasçı atama hükümlerinin örnekseme yoluyla uygulandığı kurucu artmirasçı atamadan (kurucu ikame) söz edilir[471]. Örneğin, MK 515'e göre bir kimsenin geciktirici şarta bağlı olarak mirasçı atanması, bir kurucu artmirasçı atamasıdır. Çünkü burada, şart gerçekleşinceye kadar önmirasçı sıfatı yasal mirasçılara, şart gerçekleştikten sonra artmirasçı sıfatı ise mirasçı atanan kimseye aittir[472]. Aynı şekilde, mirasbırakanın MK 583'e göre henüz cenin olarak dahi bulunmayan bir kimseyi mirasçı ataması durumunda, önmirasçı sıfatı yasal mirasçıya ait olacağı için, yine bir kurucu artmirasçı atama söz konusudur.

Buna karşılık, İnan/Ertaş'ın[473], mirasçılar arasında ceninin bulunduğu durumu 803
da kurucu artmirasçı atama (kurucu ikame) olarak görmeleri yerinde değildir. Çünkü, MK 582'ye göre, ceninin mirasçılığı onun doğması ile doğrudan, kanun gereği gerçekleşir yoksa artmirasçılık yoluyla değil[474].

Her ikisi de mirasbırakanın mirasçıları olan önmirasçı ve artmirasçının 804
mirasçılıkları şarta ya da ecele bağlıdır. Önmirasçının hakkı yönünden bozucu şart ya da ecel; artmirasçının hakkı yönünden ise geciktirici şart ya da yine ecel söz konusudur[475]. *"Tasarrufta geçiş ânı belirtilmemişse miras, önmirasçının ölümüyle artmirasçıya geçer"*, diyen MK 522/I'den anlaşılacağı üzere, artmirasçı atamada kural olarak şart söz konusudur. Ecel, ancak mirasbırakanın artmirasçıya mirasın geçmesini kesin bir tarihe bağlamış olması hâlinde vardır. Örneğin mirasbırakan, terekenin tamamı ya da belirli bir bölümünün 1.1.2004'de artmirasçıya geçeceğini, onun bu tarihte sağ olmaması hâlinde yerini mirasçılarının alacağını öngörmüşse (artmirasçı atama ile birlikte yedek mirasçı atama) ecele bağlı bir artmirasçı atama söz

---

[471] Özellikle kurucu ikame kavramı için bkz., *Escher*, Art. 488 N 3; *Tuor*, Art. 488 N 5; *Kocayusufpaşaoğlu*, 291; *Oğuzman*, 153; *İmre/Erman*, 133; *Köprülü*, 189; *Ayiter/Kılıçoğlu*, 123.

[472] Bkz., yukarıda III.

[473] *İmre/Ertaş*, 186.

[474] Krş., *Tuor/Picenoni*, Art. 545 N 5; *Kocayusufpaşaoğlu*, 291, dn.6.

[475] *Escher*, Art. 488 Vorbem 3; *Tuor*, Art. 488 Vorbem 12/13; *Kocayusufpaşaoğlu*, 291; *Oğuzman*, 163; *İmre/Erman*, 131.

konusudur. Belirtmek gerekir ki, ecelden söz edebilimek için, en az kesin tarih kadar, artmirasçının bu tarihte hayatta olmaması hâlinde, onun beklenen hakkının mirasçılarına geçeceğini de öngörmüş olması da önemlidir[476]. Aksi halde, MK 525/II'ye göre önmirasçı kesin olarak mirası iktisap edeceği için artmirasçı atama hükümsüz olur.

805 Gerek önmirasçı gerek artmirasçı mirasbırakanın küllî halefi oldukları için, tereke borçlarından kişisel olarak sorumludurlar. Ancak, nasıl onların mirasçılığı sıra ile ise, borçlardan sorumlulukları da sıralıdır. Şöyle ki, artmirasçıya intikal ânına kadar önmirasçı, intikalden sonra ise artmirasçı tereke borçlarından sorumlu olur[477].

806 Son olarak belirtelim ki, MK 569, mirasbırakanın artmirasçı atama yoluyla tasarrufta bulunmasına sınırlama getirmiştir. Bu hükme göre, önmirasçının bir saklı paylı mirasçı olması hâlinde, onun saklı payı üzerinde artmirasçılık yoluyla tasarrufta bulunulamaz. Aksi halde tenkis davası açılır[478].

bb) Hükümleri

aaa) Mirasın artmirasçıya geçmesinden önceki safha

807 MK 524/I'e göre, *"Önmirasçı, mirası atanmış mirasçılar gibi kazanır"*. Bundan da anlaşılacağı gibi, önmirasçı, terekenin tamamı ya da belirli bir kısmına, MK 599'un kurallarına göre, mirasbırakanın ölümünde kendiliğinden, kanun gereği sahip olur. Ancak, diğer mirasçılardın farklı olarak, önmirasçının iktisabının bir özelliği vardır, o da, onun iktisabının artmirasçıya devir yükümü ile yükümlü olmasıdır. Bu husus, *"Önmirasçı, mirası artmirasçıya geçirme yükümlülüğü ile sahip olur"* diyen MK 524/II'den açık olarak anlaşılmaktadır.

808 Önmirasçı, artmirasçılık gerçekleşinceye kadar hak sahibi olmasına rağmen, gerçek anlamda mirasçı, yani küllî haleftir. Bu bakımdan tereke üzerinde tam hak sahibidir, taşınır ve taşınmazların maliki, alacakların sahibi ve borçlardan (miras artmirasçıya geçinceye kadar) kişisel olarak ve birden fazla mirasçı varsa onlarla müteselsil sorumludur. Bütün mirasçılar gibi, mirası reddedebilir ya da resmî defter tutma isteminde bulunabilir[479], şartları varsa mirastan yoksun olabilir.

---

[476] *Escher*, Art. 488 N 3; *Tuor*, Art. 488 N 13; *Kocayusufpaşaoğlu*, 291.

[477] *Piotet*, 104.

[478] *Escher*, Art. 531 N 2; *Tuor*, Art. 531 N 2-4; *Krayenbühl*, 54; *Piotet*, 514; *Oğuzman*, 157; *İmre/Erman*, 131; *Ayiter/Kılıçoğlu*,124; ayrıca *Kocayusufpaşaoğlu*, 432. HGK 1.2.1961, 17/3 (İKİD 1962, 1228); HGK 16.5.1975, 203/566 (YKD 1975, c.I, 540); ayrıca bkz., BGE 108 II 288; 75 II 190.

[479] *Tuor*, Art. 491 N 2; *Escher*, Art. 491 N 1 (ancak yazar önmirasçının resmi tasfiye isteminde bulunamayacağı görüşündedir); *İmre/Erman*, 135, dn. 18; *Köprülü*, 291.

Mirasın reddi hâlinde, artmirasçı MK 525/III gereği mirası derhal iktisap eder. 809
Ancak, henüz ana rahmine düşmemiş bir kimse artmirasçı olarak atanmışsa, onun doğumuna kadar miras, önmirasçının mirasçılarına geçer[480].

Önmirasçının kendisine intikal eden mallar üzerindeki hakkının, intifa 810
hakkına benzer olduğu söylenmekteyse de[481], esasında bu benzerlik ve intifa hakkına ilişkin hükümlerin örneksemeyle uygulanması, özellikle mirasın artmirasçıya intikali ânında çok belirgin olarak ortaya çıkar. İntifa hakkı sahibinden farklı olarak önmirasçı mülkiyet hakkına sahip olduğu için tam bir tasarruf yetkisini haizdir. Ne var ki o, bozucu şarta bağlı olarak hak sahibi ve kendisine intikal edenleri bir zarara uğratmadan artmirasçıya geçirmek yükümü altında olduğu için, tasarruflarının geçerliği bunlarla sınırlıdır. Bu bakımdan artmirasçının haklarını sınırlayacak ya da ona intikali engelleyecek tasarruflarda bulunamaz; bulunursa, bunlar, artmirasçının haklarını zedelediği ölçüde geçersizdir. Bu, önmirasçının hakkının bozucu şarta bağlı olmasının doğal bir sonucudur. Çünkü, *nemo plus iuris* kuralı gereğince, hiç kimse, sahip olduğundan fazlasını başkasına devir edemeyeceği için, önmirasçının devir ettiği hak, bozucu şarta bağlı ya da onunla yükümlü olarak üçüncü kişiye geçer ve artmirasçılık açıldığı zaman, artmirasçıya karşı hüküm ifade etmez, meğer ki üçüncü kişi iyiniyetli olsun (MK 938, 1023). Bu son hâlde üçüncü kişiye intikal şartla yüklü olmadan gerçekleşir ve artmirasçı da önmirasçıdan ancak tazminat isteyebilir[482].

Önmirasçıya tereke, mirasbırakanın öngördüğü kurallara uygun olarak 811
geçeceği için, önmirasçının malvarlığına karışmayıp, ondan ayrı, *özel bir malvarlığı* oluştururlar[483]. Bu malvarlığında aynî ikame prensibi yürür. Yâni, önmirasçının hakkına uygun olarak elden çıkardığı bir malın yerini ne almışsa, şartlar gerçekleşince artmirasçıya o intikal eder. Örneğin, önmirasçı, kendisine intikal eden mallar arasında bulunan bir otomobili satıp yerine bir motosiklet almışsa, artmirasçıya bu motosiklet geçer[484].

Gerek önmirasçının tasarruf yetkisine ilişkin sınırlamalar gerek ayni ikame prensibi, bakiyeye ilişkin artmirasçılıkta *(Nacherbeneinsetzung auf den Überrest, fidei comissum de residuo, fidei comissum eus quod supererit)* söz konusu olduğu hâllerde uygulanmaz. Mirasbırakanın, artmirasçının, önmirasçıya geçen malvarlığından, kendisine intikal ânında elinde ne kalmışsa onunla yetinmesini istediği hâllerde, bakiye üzerindeki artmirasçılıktan söz edilir. Böyle bir tasarrufun olup olmadığı, mirasbırakanın iradesinin yorumundan anlaşılır. Özellikle mirasbırakanın, önmirasçıyı 812

[480] *Tuor*, Art. 491 N 4; *Escher*, Art. 491 N 2.
[481] *Kocayusufpaşaoğlu*, 294; *Oğuzman*, 155; *İmre/Erman*, 134; *Tuor/Schnyder*, 354; fakat krş., *Tuor*, Art. 491 N 11.
[482] Bu konuda etraflı bilgi için bkz., *Piotet*, 107 vd; *Escher*, Art.490 N 3.
[483] Bu konuda etraflı bilgi için bkz., *Piotet*, 107 vd; *Escher*, Art. 490 N 3.
[484] *Tuor*, Art. 491 N 30; *Escher*, Art. 488-493 Vorbem 11; *Piotet*, 121; *İmre/Erman*, 137; *Oğuzman*, 155, dn. 336.

güvence verme yükümünden muaf tuttuğu hâllerde (MK 523/II) iradesinin bu yönde olduğu söylenebilir[485].

813 Mirasın artmirasçıya geçmesi için ölümden başka bir ecel ya da şart öngörülmüş ve önmirasçı, bu şart ya da ecel gerçekleşmeden ölmüşse, ne olacağı MK 522/II'de düzenlenmiştir. Söz konusu hükme göre, güvence göstermeleri şartıyla miras, şart ya da ecelin gerçekleşmesine kadar önmirasçının mirasçılarına geçer. Bu hâlde, şart ya da ecel gerçekleşince, artmirasçıya devir yükümü, önmirasçının mirasçılarına ait olur. Önmirasçının mirasçıları güvence gösteremez ya da gösterdikleri güvence yeterli olmazsa, biraz aşağıda açıklanacak olan MK 523/III hükmü onlara da uygulanır. Eğer herhangi bir sebeple artmirasçıya intikal imkânsız hâle gelirse, önmirasçı mirası mutlak olarak kazanmış olur.

814 Artmirasçıya geçme bir şarta bağlanmış ve önmirasçı bu şartın gerçekleşmesini dürüstlük kuralına aykırı olarak engellemişse, BK 154'ün örneksemeyle uygulanması sonucu şart gerçekleşmiş sayılır ve miras, yine artmirasçıya ya da onun mirasçılarına teslim edilir. Buna karşılık artmirasçı kötüniyetle şartın gerçekleşmesini temin ederse, miras kesin olarak önmirasçıya ait olur[486].

815 Artmirasçılık gerçekleşinceye kadar, konusu olan miras payı üzerinde iki kişinin hakkı vardır. Bunlardan birincisi, önmirasçının tam hakkı ve ikincisi de artmirasçının beklenen hakkıdır[487]. Önmirasçının tam hakkı dolayısıyla tasarruf yetkisine sahip olması, artmirasçının hakkının zarar görmesi, tehlikeye düşmesine sebep olabilir. Bu bakımdan Medeni Kanun, artmirasçının zarara uğramasını engellemek amacıyla MK 523'de bazı düzenlemeler yapmıştır. Kısaca güvence hükümleri denilen bu kurallar farklı amaçlar izlerler. Önce, artmirasçının herhangi bir zarara uğramasını engellemek için, önmirasçıya güvence gösterme yükümü getirilmiştir. İkinci olarak, yine önmirasçının zarar verici fiillerinin engellenmesi için, resmî idare ve taşınmazlar için şerh öngörülmüştür. Nihayet, tarafların karışılıklı hak ve yükümlülüklerinin, devredilecek malvarlığının kapsam ve içeriğinin tespiti için resmî defter tutma şart olarak düzenlenmiştir.

816 MK 523'e göre, artmirasçılığın söz konusu olduğu hâllerde, sulh mahkemesi önmirasçıya geçen mirasın defterini tutar. Bu, emredici bir hüküm olup, mirasbırakan tarafından aksi öngörülemez. Artmirasçı terekenin tamamı için değil de bir kısmı için atanmış olsa bile, yine terekenin tamamının defteri tutulur. Çünkü, artmirasçıya intikal edecek olan, terekedeki belirli mallar değil, terekenin kesirli bir bölümüdür. Buradan hareket edince,

---

[485] *Tuor*, Art. 491 N 30; *Escher*, Art. 488- 493 Vorbem 11; *Piotet*, 121; *İmre/Erman*, 137; *Oğuzman*, 155, dn.336.

[486] *Tuor*, Art. 489 N 10.

[487] *Escher*, Art 490 N 1.

art vasiyetlerde, vasiyetin içeriğini oluşturan mal ya da mallar belirli oldukları için resmi defter tutulmasına gerek yoktur[488].

Buradaki defter tutma, terekenin tespitine ilişkin olduğu için, MK 590'daki kurallara tabidir[489]. *Tuor*'a göre[490], defterde, sadece intikal eden eşyanın belirtilmesi yeterlidir, ayrıca değerinin gösterilmesi gerekmez. Ancak, yazar, yine de toptan değerin gösterilmesini önermektedir. Tutulan defter, MK 7 anlamında resmî belge olduğu için doğruluğu karinedir[491]. 817

Resmî defter tutmanın aksine, önmirasçının güvence (teminat) göstermesi emredici kural olmadığı için, mirasbırakan ölüme bağlı tasarrufla bunun aksini öngörebilir, yâni önmirasçıyı güvence gösterme yükümünden kurtarabilir (MK 523/II). Ancak hemen belirtilmelidir ki, mirasbırakan, önmirasçıyı güvence göstermekten muaf tutsa bile, yine de defter tutulması zorunludur. Güvence verilmesi, artmirasçının hakkının tehlikeye düşmesi şartına bağlı değildir[492]. 818

Önmirasçının, şartın gerçekleşmesinden önce öldüğü için ,mirasın şart gerçekleşinceye kadar önmirasçının miraşçılarına geçtiği hâllerde, onların MK 522'ye göre göstermek zorunda oldukları güvenceden mirasbırakan tarafından muaf tutulabilip tutulamayacakları tartışmalıdır[493]. 819

Gösterilecek olan güvencenin türü önemli değildir, yeter ki, artmirasçıyı muhtemel tehlikelere karşı koruyacak nitelikte olsun. Bu güvence, rehin, kefalet ya da teminat mektubu olabilir. Eğer bir taşınmaz söz konusu ise, yeterli görülmesi şartıyla, tapu kütüğüne şerh de güvence yerine geçebilir (MK 523/II, 1010, b. 3). Belirtmek gerekir ki, şerh önmirasçı için bir yükümlülük olmayıp, ona tanınmış bir haktır. Bu haktan yararlanmak istemezse, o zaman yukarıda sayılan güvencelerden birini verir. Yapılan şerh tapu kütüğünü kilitlemez; sadece hakları ile bağdaşmayan tasarrufların artmirasçıya karşı ileri sürülmesini engeller. Taşınmaz artmirasçıya geçince şerhin hükmü sona erer ve artmirasçı bunun terkinini isteyebilir[494]. 820

Artmirasçının hakkını korumayı amaçlayan diğer bir tedbir de MK 523/III'de öngörülmüş olan mirasın mahkeme tarafından resmen idaresine 821

---

[488] *Tuor*, Art. 490 N 10. Ancak yazar, artvasiyetin konusunun bir kütüphane ya da hayvan sürüsünün oluşturduğu hâllerde yine de resmi defter tutulmasını önerir.

[489] *Tuor*, Art. 490 N 5; *Escher*, Art. 490 N 3 ve 4.

[490] *Tuor*, Art. 490 N 7.

[491] *Tuor*, Art. 490 N 9.

[492] *Tuor*, Art. 490 N 11; *Escher*, Art. 490 N 5; *İmre/Erman*, 136.

[493] Tartışmalara örnek olarak bkz., *Tuor*, Art. 490 N 11; *Escher*, Art. 490 N 5; *İmre/Erman*, 136.

[494] Bazı yazarlar, bu halde bir kısmi hükümsüzlüğün bulunduğu görüşündedirler. Örnek olarak bkz., *Tuor*, Art. 490 N 17; *Escher*, Art. 490 N 8; *Piotet*, 118; ayrıca, *Oğuzman*,155, dn.335'de anılan yazarlar.

karar verilmesidir. Bu hükme göre, önmirasçı, muaf tutulmamasına rağmen güvence göstermez ya da güvence göstermesine rağmen artmirasçının haklarının yine de zarar görmesi tehlikesi varsa, mahkeme, artmirasçıya geçinceye kadar ya da tehlike oradan kalkıncaya kadar artmirasçıya geçecek olan mirası resmen idare eder. Kanun her ne kadar bu iki hâlden söz ediyorsa da, verilen güvencenin yeterli olmaması hâlinde de resmen idareye gidilebilmelidir. Aynı şekilde, mirasbırakanın önmirasçıyı güvence göstermekten muaf tuttuğu hâllerde de, artmirasçının hakları tehlikeye düşüyorsa resmen idareye karar verilmesi mümkün olmalıdır[495], meğer ki, *bakiye üzerinde artmirasçılık* söz konusu olsun.

822 Belirtelim ki, güvencenin gösterilmemesi mirasın önmirasçıya geçmesini engellemez. Çünkü, miras, mirasbırakanın ölümü üzerine MK 599/III gereği kendiliğinden önmirasçıya geçmiştir. Başka bir ifade ile güvence, mirasın önmirasçıya geçmesinin önşartı değildir. Güvence, önmirasçıya geçmiş olan mirasın ona fiilen teslim edilmesi ile ilgilidir. Yeterli güvence gösterilirse, miras, önmirasçıya fiilen teslim edilir, aksi halde teslim edilmeyip resmen idare edilir.

bbb) Mirasın artmirasçıya geçmesi safhası

823 Artmirasçılık için gerekli olan şart gerçekleşince miras, önmirasçıdan artmirasçıya geçer. Geçiş, mirasbırakan aksini belirtmemişse, önmirasçının ölümü ile olur (MK 522/I). Ancak, mirasbırakan, artmirasçıya geçiş için başka bir şart ya da ecel öngörmüşse, geçiş bu şartın ya da ecelin gerçekleşmesiyle olur (MK 522/I, MK 525/I). Bu bakımdan, artmirasçının mirası iktisap edebilmesi için, geçiş için öngörülmüş olan şart ya da ecel gerçekleştiği zaman hayatta olması (en azından cenin olarak bulunması) gerekir[496]. Bu zamanda artmirasçı hayatta olmazsa, miras kesin olarak önmirasçıya geçer (MK 525/II). Bu kural emredici olmayıp, mirasbırakan böyle bir ihtimalde kimin mirasçı olacağını düzenleyebilir. Böyle bir düzenleme hâlinde artmirasçılık ile yedek mirasçılık bir arada bulunur.

824 Kural, mirasın artmirasçıya geçebilmesi için şart ya da ecelin gerçekleşmesi olmakla beraber, istisnaen miras daha önce de artmirasçıya geçebilir. MK 525/III'e göre, *"Önmirasçı, mirasbırakanın ölümünde sağ değilse veya mirastan yoksun kalmışsa ya da mirası reddederse, miras artmirasçıya geçer"*. Ancak bu kural emredici olmayıp, mirasbırakan böyle bir hâlde, şart ya da ecel gerçekleşinceye kadar kimin mirasçı olacağını öngörebilir. Böyle bir hâlde yine, artmirasçılık ile yedek mirasçılık birlikte bulunurlar[497].

---

[495] *Kocayusufpaşaoğlu*, 293.
[496] *Tuor*, Art. 493 N 3; *Escher*,Art. 493 4 .
[497] *Tuor*, Art 492 N 8; *Escher*, Art. 492 N 12; *Kocayusufpaşaoğlu*, 292 dn. 10.

Artmirasçı, mirasbırakanın küllî halefidir, yoksa önmirasçının değil[498]. 825
Bu husus, *"Artmirasçı, nakil için öngörülen belirli zamanda hayatta ise* ***mirasbırakanın*** *mirasını iktisap eder"* diyen, MK 525/I karşılayan ZGB Art. 492/I'den açık olarak anlaşılmaktadır. Bundan da anlaşılacağı üzere, artmirasçının, mirasın kendisine geçiş anına kadar bir beklenen hakkı vardır ve bu durum (güvence ve resmen idarenin istenmesi dışında) ona hiç bir yetki vermez[499]. Geçiş ile beklenen hak tam hakka dönüşür.

Artmirasçının, mirasbırakanın mirasçısı olmasının sonuçları şunlardır: 826

1. Artmirasçı, geçiş şartlarının gerçekleştiği anda, kanun gereği (MK 827
599) mirası kendiliğinden iktisap eder. Ancak bu iktisap, mirasbırakanın ölümü ânında değil de, hakkı şarta ya da ecele bağlı olduğu için, bunların gerçekleştiği anda olur. Bu bakımdan artmirasçının, mirasbırakan öldüğü anda değil, geçiş için şart ya da ecel gerçekleştiği anda (en azından cenin olarak) hayatta olması gerektiğinden yukarıda söz edilmişti.

2. Geçiş ile birlikte artmirasçı miras üzerinde tam hakka sahip olur. Bu 828
andan itibaren,teslim gerçekleşinceye kadar, önmirasçı *vekâletsiz iş gören durumundadır*[500].

3. Mirasın reddi, resmî tasfiye ya da resmi defter tutmayı isteme süre- 829
ri, geçişle birlikte işlemeye başlar[501].

4. Artmirasçı, mirasbırakanın küllî halefi olduğu için, mirasın kendisine 830
intikal ettiği andan itibaren tereke borçlarından kişisel sorumlu olur. Artmirasçı, miras ortaklığına dahil oluyorsa aynı andan itibaren aynı zamanda diğer mirasçılarla müteselsil olarak borçlardan sorumlu olur. Önmirasçının, miras kendisinde bulunduğu sürece yapmış olduğu borçlardan, bunlar tereke borçları olmadığı için, artmirasçı miras hukuku kurallarına göre sorumlu olmaz[502]. Ancak, bu borçlardan dolayı önmirasçının, intifa hakkı ya da vekaletsiz işgörme kurallarına göre artmirasçıya karşı bir alacak hakkının doğması mümkündür[503].

c) Art vasiyet alacaklısı atanmasındaki özellikler

Yukarıda da değinildiği gibi, MK 521 esas itibariyle artmirasçı atanma- 831

---

[498] *Tuor*, Art. 488-493, Vorbem 13 ve 14; Art 492 N 10; *Escher*, Art. 488- 493 N 3; biraz farklı Art. 492 N 2; *Piotet*, 103; *Kocayusufpaşaoğlu*, 291; *Oğuzman*, 153; *İmre/Erman*, 130.

[499] *Tuor*, Art. 492 N 9,10.

[500] *Tuor*, Art. 492 N 12.

[501] *Tuor*, Art. 492 N 10; *Escher*, Art. 492 N 9.

[502] *Tuor*, Art. 492 N 10; *Escher*,Art. 492 N 9.

[503] *Escher*, Art. 492 N 9.

sını düzenlemiş, fakat üçüncü fıkrasında bu kuralların art vasiyet alacaklısı atanması hâlinde de uygulanacağını öngörmüştür[504]. Bu bakımdan art vasiyetçi atanmasına da esas itibariyle artmirasçı atanmasına ilişkin hükümler uygulanacaktır. Şu farkla ki, bu yolla vasiyet yapılan kimse, mirasbırakanın cüzî halefi olup, sadece vasiyet borçlularına karşı şarta ya da ecele bağlı bir alacak hakkı elde eder.

832 Burada üzerinde tartışılan konu şudur: Geçiş şartı gerçekleştiği zaman, acaba art vasiyet alacaklısı, alacak hakkını ön vasiyet alacaklısına (ya da onun mirasçılarına) karşı mı, yoksa vasiyet borçlusu olan mirasbırakanın mirasçılarına karşı mı ileri sürecektir? Bir örnekle durumu açıklayalım: M, terekesinde bulunan bir halıyı 10 yıl sonra C'ye devretmesi şartıyla B'ye vasiyet eder ve bu vasiyeti yerine getirme borcunu A'ya yükler. Şimdi, on yılın sonunda C, halıyı ön vasiyet alacaklısı olan B'den mi, yoksa vasiyeti ifa ile mükellef olan A'dan mı isteyecektir? *Tuor* ve ona katılan *Gürsoy*[505], ön vasiyet alacaklısı ile art vasiyet alacaklısı arasında hiçbir hukukî ilişki bulunmadığı gerekçesiyle, art vasiyet alacaklısının talebini vasiyet borçlusu olan A'ya karşı ileri sürmesi gerektiği görüşündedirler. Ne var ki A, C kendisine talebini yönelttiği zaman, vasiyet konusu mal kendisinde bulunmadığı için (çünkü o, halıyı ön vasiyet alacaklısına vermiştir) bu talebi yerine getiremeyecektir. O halde ifa nasıl gerçekleşecektir? Yazarlar, bu zorluğun, geçiş şartlarının gerçekleşmesiyle birlikte, A'ya, önmirasçıya karşı bir iade talebinin tanınmasıyla giderilebileceği görüşündedirler.

833 *Escher* ve ona katılan çoğunlukta olan yazarlar[506], fikrimce, daha pratik olan bir yol önermektedirler. Bu görüş, *"Mirasbırakan, ölüme bağlı tasarrufuyla önmirasçı atadığı kişiyi mirası artmirasçıya devretmekle yükümlü kılabilir"* diyen MK 521/I, *"Bu kurallar belirli mal bırakmada da uygulanır"* diyen aynı maddenin üçüncü fıkrasının birlikte uygulanmasından hareket etmektedir. Buna göre, birinci fıkradaki hüküm mahiyetine uygun biçimde uygulanınca, ön vasiyet alacaklısı, yani B, tıpkı önmirasçı gibi, vasiyeti art vasiyet alacaklısına, yani C'ye devretmekle yükümlü olacaktır. Başka bir deyiş ile, bu hâlde B, vasiyet borçlusu durumuna girmiş kabul edilmektedir. Böylece art vasiyet açıldığı zaman C, halıyı doğrudan B'den talep edebilecektir.

---

[504] BGE 68 II 155; 71 II 265.

[505] *Tuor*, Art. 488 N 16; *Gürsoy*, Vasiyet 183. Ve ayrıca BGE 105 II 253. Belirtelim ki, Escher de daha önceki basılarında aynı görüşü savunuyordu.

[506] Bu yazarlara örnek olarak bkz., *Escher*, Art 488-493 Vorbem.8; *Kocayusufpaşaoğlu*, 294; *Köprülü*, 197; *Oğuzman*, 156.

VII. VASİYETİ YERİNE GETİRME GÖREVLİSİ ATAMA

a) Genel bilgiler

Mirasbırakanın, bir ölüme bağlı tasarruf yapmış olması hâlinde, onun 834
bu yolla açıkladığı son arzularını yerine getirme borcu yasal ya da atanmış mirasçılara aittir. Ancak bazı hâllerde mirasçıların çıkarları ile mirasbırakanın yaptığı ölüme bağlı tasarruf arasında çelişki olabileceği için, mirasçılar bunları yerine getirmekten kaçınabilir ya da mirasçılar bu son arzuları yerine getirmek için gerekli yeteneğe sahip olmayabilirler. İşte bunu göz önünde bulunduran kanunkoyucu, son arzularının istediği gibi yerine getirilebilmesini temin için, mirasbırakana MK 550-556'da bir vasiyeti yerine getirme görevlisi atama imkânını tanımıştır. Şu halde, vasiyeti yerine getirme görevlisinin görevi, *genel olarak, mirasbırakanın bir ölüme bağlı tasarruf ile açıkladığı son arzularını yerine getirmektir*. MK 550/I'e göre, vasiyeti yerine getirme görevlisi atama bir ölüme bağlı tasarruf olduğu için vasiyetname ile yapılır. Ancak bir miras sözleşmesi ile de yapılmasına bir engel yoktur. Bu son hâlde, vasiyeti yerine getirme görevlisi atama, miras sözleşmesinin, bir taraflı bağlayıcı olmayan içeriğine girer ve tıpkı vasiyetname ile yapılmış gibi, mirasbırakanın ölümüne kadar her zaman tek taraflı olarak geri alınabilir[507]. Bağımsız bir ölüme bağlı tasarruf olduğu için, içeriği sadece vasiyeti yerine görevlisi atamadan ibaret bir vasiyetname yapılabilir ve bu vasiyetname hükümsüzlük yönünden MK 557'ye tabidir. Yani mirasçılar, bu maddede yazılı sebeplerden birine dayanarak tasarrufun iptali için dava açabilirler. Bu davada, 7.12.1955 tarih ve 16/25 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararına[508] göre hasım olarak vasiyeti yerine getirme görevlisi gösterilir.

> Tuor'a göre, aslında vasiyeti yerine görevlisi atama, mirasın açılması ile ilgili 835
> olduğu için, koruma önlemlerinden (MK 589 vd) hemen sonra düzenlenmeliydi. Ne var ki, ölüme bağlı tasarruf olma niteliği daha ağır bastığı için, kanunkoyucu onu ölüme bağlı tasarruflar arasında düzenlemiştir[509].

Vasiyeti yerine getirme görevlisi olarak atanmanın tek şartı, göreve 836
başlandığı anda fiil ehliyetine sahip olmaktır (MK 550/II), yoksa, kendisini atayan ölüme bağlı tasarrufun yapıldığı anda değil. Fiil ehliyeti tam fiil ehliyeti olarak anlaşılmakta ve kısıtlı (yani göreve başladığı anda sınırlı ehliyetsiz) olan bir kimsenin vasiyeti yerine getirme görevlisi olarak atanamayacağı kabul edilmektedir[510]. Böyle olunca da herhangi bir gerçek ya da tü-

---

[507] *Tuor*, Art. 517 N 1; *Escher*, Art.517 N 1; *Piotet*, 157; *Kocayusufpaşaoğlu*, 295; *Oğuzman*, 160; *Akbıyık*, Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi, İstanbul 2012, 41-42.

[508] RG, sayı 930; ayrıca bkz., BGE 44 II 115.

[509] *Tuor*, Vorbem. 3 zum fünften Abschnitt.

[510] *Tuor*, Art. 517 N 4; *Escher*, Art. 517 N 3.

zel kişi ya da makamın, daha doğrusu bir makamda bulunan kişinin (örneğin hukuk fakültesi dekanlığının ya da bir noterliğin) vasiyeti yerine getirme görevlisi olarak atanması mümkündür[511]. Ancak bu son hâlde, mirasbırakanın, o makamda bulunan belirli bir (örneğin vasiyetnameyi yaptığı andaki hukuk fakültesi dekanı olan) kişiyi mi, yoksa o makamı kim işgal ederse etsin onu mu kastettiği bir yorum meselesidir. Çünkü birinci ihtimalde söz konusu olan kişi, o makamdan ayrılsa bile, şahsı kastedildiği için vasiyeti yerine getirme görevlisi sıfatı devam edecektir. İkinci ihtimalde ise, mirasbırakan için kişilik değil de o makamda bulunma önemli olduğundan, makamdan ayrılan kişinin vasiyeti yerine getirme görevlisi sıfatı sona erecek ve ölüm ânında makamda kim bulunuyorsa, vasiyeti yerine getirme görevlisi de olacaktır[512].

837 Tam fiil ehliyetine sahip olan herkes vasiyeti yerine getirme görevlisi olarak atanabilir. Bu mirasçılardan biri olabileceği gibi, herhangi bir üçüncü kişi de olabilir. Ancak AY 140'a göre hâkimler ve savcılar vasiyeti yerine getirme görevlisi olamazlar. Çünkü, hâkimler ve savcılar, kanunlarda gösterilenlerin dışında hiç bir resmi ya da özel görev alamazlar[513]. Bir tek mirasçının bulunduğu hâllerde, onu vasiyeti yerine getirme görevlisi olarak atamak, zaten mirasçı sıfatıyla sahip olduğu yetkileri ona tekrar vermek olacağı için anlamsızdır[514].

838 Mirasbırakanın, vasiyeti yerine getirme görevlisini bizzat atamayıp, bunu bir üçüncü kişiye bırakabilip bırakamayacağı tartışmalıdır[515]. *Fikrimce*, mirasbırakanın objektif ölçüler koyması ve seçilecek kişi grubunun sınırlarını dar tutması şartıyla, seçimi bir üçüncü kişiye bırakmasının geçerli kabul edilmesi gerekir. Sınırsız bir serbesti, ölüme bağlı tasarrufun kişiye sıkı sıkıya bağlı olma niteliği ile bağdaşmaz.

839 Vasiyeti yerine getirme görevlisinin ikameli olarak da atanması mümkündür[516]. Mirasbırakanın, atadığı vasiyeti yerine getirme görevlisinin herhangi bir sebeple bu sıfatı kazanamaması hâli için ek bir atama yapması, bu yedek vasiyeti yerine getirme görevlisi atamadır. Mirasbırakanın atadığı

---

[511] *Escher*, Art. 517 N 3; *Tuor*, Art. 517 N 4; *Piotet*, 157; *Kocayusufpaşaoğlu*, 295; *Oğuzman*, 163; *Köprülü*, 203; ayrıca bkz., BGE 69 II 36; 91 II 177.

[512] Bkz., dn. 511'de anılan yazarlar.

[513] Benzer bir hüküm 1961 Anayasasının 164. maddesinde de vardı. 1961 Anayasasındaki hükme göre, hakim ve savcıların vasiyeti yerine getirme görevlisi atanamayacaklarına ilişkin bkz.,2. HD 9.12.1971, 6576/7008 (*Şener*, Vasiyet, 391).

[514] *Tuor*, Art. 517 N 4; *Escher*, Art. 17 N 5; *Oğuzman*, 163; bazı durumlar için aksi görüşte, *Piotet*, 157; *Akbıyık*, Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi, 13-14.

[515] Bu konuda bkz., *Escher*, Art. 517, N 1; *Tuor*, Art.517 N 3; *Piotet*, 156; *İmre/Erman*, 145-156; *Oğuzman*, 163; *Akbıyık*, Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi, 43-44.

[516] *Piotet*, 156; *Escher*, Art. 517 N 2; *Oğuzman*, 163.

vasiyeti yerine getirme görevlisinin, işe başladıktan sonra, herhangi bir sebeple görevini yerine getirememesi hâli için başka bir vasiyeti yerine getirme görevlisi ataması ise art vasiyeti yerine getirme görevlisi atanmasıdır.

MK 551/I'e göre, mirasbırakan isterse, birden fazla kişiyi aynı anda gö- 840
rev yapacak şekilde vasiyeti yerine getirme görevlisi olarak atayabilir. MK 551/I'e göre, tasarruftan ya da işin niteliğinden aksi anlaşılmadıkça bunlar, görevi birlikte yürütürler. Ancak bu husus emredici değildir (MK 551/I). Mirasbırakan her birinin hangi işi yapacağını belirtmiş olabilir. Böyle bir hâlde artık birlikte hareket etme zorunluluğu yoktur, her biri kendisine yüklenmiş olan görevi yerine getirir ve her biri vermiş olduğu zarardan tek başına sorumlu olur. Oysa birlikte hareket hâlinde, verilen zarardan hepsi müteselsil sorumludurlar[517]. Birden fazla vasiyeti yerine getirme görevlisinden biri görevi kabul etmeyecek ya da herhangi bir sebeple görevi sona erecek olursa, diğerleri göreve devam eder, meğer ki ölüme bağlı tasarruftan aksi anlaşılsın (MK 551/II).

Atanan kişinin vasiyeti yerine getirme görevini kabul etmesi zorunlu 841
değildir. Atanan kişi, durumun kendisine sulh mahkemesi tarafından bildirilmesinden itibaren 15 gün içinde görevi kabul ya da reddettiğini sulh mahkemesine bildirmek zorundadır. Süre susarak geçirilirse, görev kabul edilmiş sayılır (MK 550/III). Bu aksi ispat edilemeyen bir karinedir *(praesumtio de iuris et iure)*. MK 550/II'nin aradığı fiil ehliyetinin bu anda bulunması gerekir. Çünkü vasiyeti yerine getirme görevlisinin görevi bu anda başlar[518]. Kabul ya da red bir yenilik doğuran irade açıklaması olduğu için şarta bağlanamaz[519].

Vasiyeti yerine getirme görevlisinin yaptığı işin karşılığı olarak bir üc- 842
ret isteme hakkı vardır (MK 550/IV). Bu ona tanınmış bir haktır. Bu bakımdan mirasbırakan, ölüme bağlı tasarrufla, vasiyeti yerine getirme görevlisinin ücret isteyemeceğini öngöremez, böyle bir hüküm geçersiz olur ve vasiyeti yerine getirme görevlisi yine de ücret isteyebilir[520].

---

[517] *Escher*, Art. 518 N 34; *Tuor*, Art. 518 N 26; *Piotet*, 156; *Kocayusufpaşaoğlu*, 300; *Köprülü*, 213; *Oğuzman*, 164.

[518] *Tuor*, Art. 517 N 4; *Escher*, Art. 517 N 3; *Piotet*, 157; *Akbıyık*, Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi, 7.

[519] *Escher*, Art. 517 N 7.

[520] *Escher*, Art. 517 N 10; *Tuor*, Art. 517 N 12; *İmre/Erman*, 147; *İnan/Ertaş*, 197. Aksi düşüncede: *Akbıyık*, Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi, 202; ayrıca krş. *Oğuzman*, 164, dn. 385. İmre/Erman ve İnan/Ertaş, mirasbırakan tarafından konulan ücret isteme yasağının geçerli olmamasının gerekçesi olarak, ücret isteme hakkının bir emredici hüküm olmasını göstermektedirler. Oysa burada, fikrimce, bir emredici hükmün değil, bir kimsenin, başkalarının sahip olduğu bir hakkı bir taraflı irade açıklaması ile kaldıramayacağı kuralı yatmaktadır. Belirtmek gerekir ki, BGB § 2221, tam aksine bir düzenleme getirerek, mirasbırakanın ücret istemeyi yasaklayabileceğini öngörmüştür.

843 Ücreti bizzat mirasbırakan da belirleyebilir. Mirasbırakan tarafından belirlenmemişse, ücret, kural olarak vasiyeti yerine getirme görevlisi ve mirasçılar tarafından birlikte belirlenir. Anlaşamama hâlinde ücreti mahkeme belirler[521]. Mahkeme tarafından ücretin tespitinde, yapılacak işin niteliği, süresi ve terekenin değeri göz önünde bulundurulur. Belirtilmelidir ki, ücretin mirasbırakan tarafından belirlendiği hâllerde dahi, vasiyeti yerine getirme görevlisi bunu yeterli görmezse, artırılması isteminde bulunabilir[522]. Bu hâlde de, ücretin belirtilmediği hâllere ilişkin yukarıdaki kurallar uygulanır.

844 Mirasbırakanın, vasiyetnamesinde vasiyeti yerine getirme görevlisi lehine bir ölüme bağlı tasarrufta bulunmuş olması hâlinde, bunun ücret sayılıp sayılmayacağı bir yorum meselesidir. Yorum ile ücret sayılması gerektiği sonucuna varılırsa, bunun uygun bir ücret olup olmadığı ayrıca tartışılabilir[523].

845 Vasiyeti yerine getirme görevlisine ödenecek olan ücret , tereke borcu niteliğinde olduğu için, vasiyet alacaklılarının haklarından önce gelir. Aynı şekilde, saklı payların belirlenmesinden önce, net terekenin tespiti icin, terekeden çıkartılır. Bu sebeple, *"... işlerin tasfiyesine kadar tenfiz memuruna ayda 500 TL verilmesinde, miras bırakanın tasarruf nisabı dahilinde olması şartıyla kanuni bir mani olmamaktadır"* sonucuna varan HGK 7.3.1951 tarih ve 89/90 sayılı karar[524] doğru değildir.

846 Vasiyeti yerine getirme görevlisi kurumunun niteliği son derece tartışmalıdır[525]. Temsil- vekâlet görüşüne taraftar olan yazarların bazılarına göre, vasiyeti yerine getirme görevlisi ölenin, bazılarına göre mirasçıların, diğer bir gruba göre de terekenin temsilcisidir. Bu görüşe karşı, vasiyeti yerine getirme görevlisinin, mirasbırakan öldüğü için onun temsilcisi olamayacağı; mirasçıların ise, *mandatum post mortem*'den farklı olarak, vasiyeti yerine getirme görevlisine talimat verme ve onu azletme yetkileri bulunmadığı için onların temsilcisi olamayacağı; terekenin ise tüzel kişiliği olmadığı için onun temsilinin söz konusu olamayacağı eleştirisi ileri sürülmüştür. Bu gün Türk/İsviçre Hukukunda hakim olan görüş, vasiyeti yerine getirme görevliliğini, *güvenilir kişi (Teuhand)* kurumu ile açıklamaktadır. Buna göre, vasiyeti yerine getirme görevlisi, tereke üzerinde, mirasçıların haklarını sınırlayan ve mirasbırakanın talimatına uygun olarak kullanabileceği *bir sınırlandırılmış ayni hak sahibidir*. Nihayet üçüncü görüş, vasiyeti yerine getirme görevliliğini *sui generis bir kurum* olarak kabul eder[526].

---

[521] BGE 78 II 123; *Piotet*, 159.

[522] *Escher*, Art. 517, 10; *Tuor*, Art. 517 N 12; *Oğuzman*, 164.

[523] *Escher*, Art. 517 N 10; *Tuor*, Art. 517 N 12; *Piotet*, 159.

[524] *Tepeci*, 614.

[525] Burada üzerinde durulacak görüşlerin dışındaki görüşler için bkz., *Escher*, Art. 571-518 Vorbem 2; *Saymen*, İBD 1938, c. XII, 481 vd.

[526] Bu konularda etraflı bilgi için bkz., *Tuor*, Art, 517-518 Vorbem 3; *Tuor/Schnyder*, 355; *Escher*, Vorbem 517-518, Vorbem 2 vd; *Piotet*, 153; *Kocayusufpaşaoğlu*, 300; *İmre/Erman*, 144; *Oğuzman*, 161-162; *İnan/Ertaş*, 296; *Ayiter/Kılıçoğlu*, 129; *Köprülü*, 204. Ayrıca bkz. *Akbıyık*, Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi, 20 vd., 36 vd.; *Saymen*, İBD 1938, c. XII, 481 vd ; BGE 43 II 260; 78 II 123; 90 II 376; 2.HD 15.12.1970, 5509/6637 (*Dalamanlı*, 375); 2. HD 8.1.1974, 144/469 (RKD, 1974, II 166).

b) Vasiyeti yerine getirme görevlisinin görevleri

MK 552/I'e göre, *"Mirasbırakan tasarrufunda aksini öngörmüş veya sınırlı bir görev vermiş olmadıkça vasiyeti yerine getirme görevlisi, mirasbırakanın son arzularının yerine getirilmesi için gerekli bütün işlemleri yapmakla görevli ve yetkilidir"*. Hükümden anlaşılacağı üzere, vasiyeti yerine getirme görevlisinin görevlerinin ne olduğu önce mirasbırakan tarafından yapılan ölüme bağlı tasarrufta belirlenir. Böyle bir düzenleme varsa, vasiyeti yerine getirme görevlisi bununla bağlıdır. Mirasbırakan tarafından görevi düzenlenmemişse, vasiyeti yerine getirme görevlisi, mirasbırakanın son arzularını yerine getirilmesi için gerekli olan tüm iş ve işlemleri yapar. Bunların en önemlileri, MK 552/II'de yedi bent hâlinde örnek olarak şöyle sıralanmıştır: 847

a) Göreve başladıktan sonra gecikmeksizin terekedeki malların, hakların ve borçların olanak olduğu ölçüde mirasçıların huzurunda listesini düzenleme; 848

b) terekeyi yönetme ve yönetmenin gerektirdiği ölçüde tereke mallarının zilyetliğinin kendisine devrini isteme; 849

c) terekenin alacaklarını tahsil ve borçlarını ödeme; 850

d) vasiyetleri yerine getirme; 851

e) terekenin paylaşılması için plan hazırlama; 852

f) tereke ile ilgili dava ve takiplerde miras ortaklığını temsil etme ve mirasçılar tarafından açılan davalara, görevi ile ilgili olduğu ölçüde müdahil sıfatıyla katılma; 853

g) açtığı ya da aleyhine açılan davaları mirasçılara bildirme. 854

Vasiyeti yerine getirme görevlisi, görev alanına giren hususlarda münhasır yetkiye sahiptir. Bu alanlarda artık mirasçıların yetkileri olmadığı gibi, vasiyeti yerine getirme görevlisi sadece mirasbırakanın isteklerine göre hareket eder, mirasçıların istek ve talimatları ile bağlı değildir[527]. Ancak mirasçılar, vasiyeti yerine getirme görevlisini her zaman sulh mahkemesine şikâyet ederek, onun görevden alınmasını (azlini) temin edebilirler (MK 555). 855

Vasiyeti yerine getirme görevlisinin varlığı, sadece mirasçıların, terekeye ilişkin bazı haklarını kullanmalarını sınırlamakla kalmaz. MK 592'ye göre, mirasın resmen idaresinin söz konusu olduğu hâllerde[528], bu görev doğrudan doğruya vasiyeti yerine getirme görevlisine verilir, meğer ki bu konuda önemli bir engel bulunsun. 856

[527] *Kocayusufpaşaoğlu*, 298; *Oğuzman*, 160.
[528] Bkz., aşağıda § 28, I, 2.

857 Vasiyeti yerine getirme görevlisi terekenin yönetimi ve tasarruf yetkisinin gerekli kıldığı ölçüde tereke malları üzerinde zilyetliğe sahiptir (MK MK 552/II, b2). Mirasbırakanın ölümü ile terekedeki malların zilyetliğinin kendiliğinden mirasçılara geçeceği düşünülecek olursa; bu durumda mirasçılar aslî ve dolaylı, vasiyeti yerine getirme görevlisi ise ferî ve dolaysız zilyet olur[529]. Bu bakımdan yönetim ve tasarrufun gerektirdiği ölçüde gerek mirasçılar, gerek malı özel bir sebeple elinde bulunduran üçüncü kişilere karşı zilyetlikten doğan davaları açabileceği gibi, tecavüz hâlinde de zilyetliği koruyan davalardan yararlanabilir. Bunun aksine, vasiyeti yerine getirme görevlisinin, görevinin gerektirdiği şeyden fazlası üzerinde zilyetliğe sahip olduğu hâllerde, mirasçılar ona karşı zilyetliğin iadesi davası açabilirler.

858 Vasiyeti yerine getirme görevlisinin, görevine girdiği kadarıyla zilyet olduğu tereke malları üzerinde mirasçılar, tasarruf yetkileri bulunmadığı için, tasarrufta bulunamazlar. Ancak iyiniyetli üçüncü kişilerin, bir taşınırı, mirasçıların yetkisi olmamasına rağmen onlardan devir almaları hâlinde, MK 988 ve 990'dan yararlanacaklarının gözden uzak tutulması gerekir. Aynı durum vasiyeti yerine getirme görevlisinin yetkisiz olarak üçüncü kişiye devir ettiği taşınır için de söz konusu olur.

859 Vasiyeti yerine getirme görevlisinin, taşınmazlarla ilgili bir görevinin bulunduğu hâllerde, malik mirasçı ya da mirasçılar olacağı için, mirasın geçmesinden sonra tescil yine onlar adına yapılacaktır[530]. Fakat görevi ile ilgili olduğu kadarıyla, bunlar üzerinde tasarruf yetkisi vasiyeti yerine getirme görevlisine ait olacaktır. Vasiyeti yerine getirme görevlisi, yine görevi ile ilgili olduğu kadarıyla, taşınmazı satabilir ya da sınırlı aynî hakla yükümlendirebilir. Ancak bu hâlde, ileride doğacak sorunları ortadan kaldırmak için, mirasçıların görüşünü alması gerektiği genel olarak kabul edilmektedir[531].

860 Yukarıdaki açıklamalardan anlaşılacağı gibi, vasiyeti yerine getirme görevlisinin tasarruf yetkisi, bir vasiyetin ifası ya da tereke borçları ile ilgili hususlarla sınırlıdır. Buna karşılık, mirasbırakan tarafından taahhüt edilmiş olmadıkça, vasiyeti yerine getirme görevlisinin, (olağan giderler için gerekli olanın dışında) terekeye dahil bir malı devretmesi ya da bir sınırlı aynî hakla yüküm altına sokması için sulh hâkiminden yetki alması gerekir (MK 553). Sulh hâkimi yetkiyi vermeden önce mümkün olursa mirasçıları dinler

---

[529] *Escher*, Art. 518 N 9; *Tuor*, Art. 518 N 13; *Piotet*, 162; *Kocayusufpaşaoğlu*, 298.

[530] *Piotet* (163) intikalle kendiliğinden mirasçılara geçen taşınmazların tescilinin, bir idari işlem olduğu için, vasiyeti yerine getirme görevlisi tarafından yaptırılması gerektiği görüşündedir. *Fikrimce*, böyle bir genelleme yapmak doğru değildir. Bu yetkiyi, ancak, vasiyeti yerine getirme görevlisinin görevine girdiği hâllerde var olarak kabul etmek gerekir. Aksi halde, tescili isteme yetkisi yine mirasçılara ait olur. Bu konuda ayrıca bkz. *Akbıyık*, Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi, 115 vd.

[531] Bkz., *İmre/Erman*, 149, dn 3 ve orada anılan Federal Mahkeme kararı.

(MK 553 c.2). Buna karşılık olağan giderleri karşılayacak ölçüde tasarruflar için, sulh hâkiminden izin alınmasına gerek yoktur (MK 553 c.3).

Federal Mahkemeye göre[532], tapu memuru, sadece vasiyeti yerine getirme görevlisinin yetkili olup olmadığını incelemekle yükümlüdür, yoksa onun söz konusu işlemi yapmaya yetkili olup olmadığını değil...*Fikrimce,* vasiyeti yerine getirme görevlisinin yetkisini aşan bir işlem yapması, örneğin gereği olmadan ve izin almadan bir taşınmazı satması hâlinde, üçüncü kişiler MK 1023'e dayanarak iyiniyet iddiasında bulunamazlar. Çünkü böyle bir hâlde, üçüncü kişilerin iyiniyeti, tapu kütüğündeki bir kayda yönelik olmayıp, vasiyeti yerine getirme görevlisinin yetkisine ilişkindir. Buna karşılık, vasiyeti yerine getirme görevlisinin görevinin kapsamına giren bir taşınmazın, mirasçılar tarafından üçüncü bir kişiye satılması hâlinde, MK 1023 işleyecektir. Çünkü bu hâlde, üçüncü kişi, tapu kütüğündeki tescile güvenmektedir. Bu bakımdan, mirasçıların, bu yolla vasiyeti yerine getirme görevlisinin görevini yerine getirmesini engelleme tehlikesi vardır. Bazı yazarlar bu konuda kanunda bir boşluğun bulunduğu görüşündedirler[533]. *Homberger*'in, bu boşluğun MK 1010 b.1'e göre verilecek bir şerhle doldurulabileceği görüşü[534], tapu siciline yapılacak kayıtlarda *numerus clausus* bulunduğu gerekçesiyle pek rağbet görmemiştir[535]. *Piotet* ise Federal Mahkemenin, vasiyeti yerine getirme görevlisinin bulunduğu hâllerde, verilecek veraset ilamında, vasiyeti yerine getirme görevlisinin varlığının belirtilmesini arayan uygulamasından hareketle, bu yolla, mirasçıların, taşınmazı üçüncü kişiye devirleri hâlinde, artık MK 1023'ün uygulanamayacağı görüşündedir[536]. Çünkü böyle bir hâlde, müspit evrak arasında, vasiyeti yerine getirme görevlisinin bulunduğunu gören tapu memuru, işlemleri yapmaktan kaçınacak, yapsa bile, üçüncü kişi bu evrakın varlığını bilmediğini ileri süremeyecektir. 861

Vasiyeti yerine getirme görevlisinin dava ehliyetine gelince; bunu değişik ihtimallere göre inceleyelim. 862

a) Tereke üzerinde yönetim yetkisinin kapsamına girdiği ölçüde vasiyeti yerine getirme görevlisi hem aktif hem de pasif dava ehliyetine sahiptir. Tereke alacaklarını tahsil için de dava açabilir ya da takipte bulunabilir. Görevine giren alanlarda yetkisi inhisari olduğu için, mirasçılar dava açamazlar, fakat isterlerse ferî müdahil olarak davaya katılabilirler (HUMK 53). 863

Buna karşılık, mirasbırakanın alacaklılarının alacaklarını elde etmek amacıyla açacakları davalarda vasiyeti yerine getirme görevlisinin davalı olma sıfatı münhasır değildir. Alacaklılar, isterlerse vasiyeti yerine getirme görevlisini, isterlerse mirasçıları dava edebilirler. Ancak davanın sonucu, açıldığı kişiye göre farklı olacaktır. Şöyle ki, dava sadece vasiyeti yerine getirme görevlisine karşı açılmışsa, alacaklılar sadece tereke mallarına başvurabilirler, mirasçıların malvarlığına el atamazlar. Bunun aksine, dava sa- 864

[532] BGE 61 I 382; ayrıca *Piotet,* 161; *İmre/Erman,* 149 dn. 13.
[533] Örnek olarak bkz., *Escher,* Art. 518 N 9.
[534] *Homberger,* Art. 960 N 9.
[535] *Escher,* Art. 518 N 9; *Piotet,* 163; *İmre/Erman,* 149 dn. 13.
[536] *Piotet,* 163.

dece mirasçılara karşı açılmışsa, o zaman mirasçılar alacaklarını sadece mirasçıların malvarlığından tahsil edebilirler, henüz paylaşılmamış olan terekeye başvuramazlar. O hâlde alacaklılar, hem tereke hem de mirasçıların malvarlıklarından alacaklarını elde etmek istiyorlarsa vasiyeti yerine görevlisi ve mirasçıları birlikte dava etmek zorundadırlar[537]. Vasiyeti yerine getirme görevlisi, ister davacı ister davalı olsun, mirasçıların temsilcisi olarak değil, kendi adına taraftır[538].

865 b) Vasiyeti yerine getirme görevlisi, yine görevinin yerine getirilmesinin gerektirdiği ölçüde, tereke mallarının zilyetliğini elde etmek amacıyla, gerekli olan davaları mirasçılara ya da o şeyi geçerli bir sebep olmaksızın elinde bulunduran üçüncü kişilere karşı açabilir.

866 c) Ölüme bağlı tasarrufun iptali davalarında vasiyeti yerine getirme görevlisi davacı sıfatını haiz değildir, yâni ölüme bağlı tasarrufun iptali davasını açamaz[539]. Buna karşılık kendisini atayan ölüme bağlı tasarrufun iptali davasının vasiyeti yerine getirme görevlisine karşı açılması gerekir[540].

867 d) Kendisi ile ilgili olmadığı için vasiyeti yerine getirme görevlisi tenkis davasında ne davacı ne de davalı olabilir[541].

868 MK 552 b. 5' e göre, mirasbırakan aksini öngörmemişse, vasiyeti yerine getirme görevlisi, birden fazla mirasçının bulunduğu hâllerde, terekenin paylaşılması planını yapar. Onun paylaştırma yönünden yetkilerinin ne olduğu, mirasçıların hazırlanan plana uymak zorunda olup olmadıkları son derece tartışmalıdır. Bunun üzerinde aşağıda mirasın paylaşılması bahsinde durulacaktır.

c) Vasiyeti yerine getirme görevlisinin denetimi

869 Vasiyeti yerine getirme görevlisi görevini sulh mahkemesinin denetimi altında yapar (MK 555/I). Sulh hakimi, görevin yerine getirilmesi sırasında re'sen ya da şikâyet üzerine gerekli önlemleri alır (MK 555/II). Vasiyeti yerine getirme görevlisi azletme yetkileri olmayan mirasçılar, şikâyet yoluyla, şartları varsa, sulh hâkimi tarafından vasiyeti yerine getirme görevlisinin görevine son verilmesini temin edebilirler. Sulh hâkimi, vasiyeti yerine getirme görevlisinin yetersiz olması, görevini kötüye kullanması ağır ihmali

---

[537] *Escher*, Vart. 518 N 31; *Piotet*, 164; BGE 94 II 141; 116 II 139 vd; *Kocayusufpaşaoğlu* 297; *İmre/Erman*, 150.

[538] BGE 94 II 141; *Kocayusufpaşaoğlu*, 297; *İmre/Erman*, 150; *Alangoya*, Yargılama Sırasında Tarafta (Yanda) İradi Olarak Meydana Gelen Değişme Hakkında Düşünceler, MHAD, yeni seri yıl 3, No.5'den ayrı bası, 12 vd., 19 vd., 42.

[539] Bu konuda etraflı bilgi için bkz., § 18, III, B, 2,a.

[540] İBK 7.12.1955, 16/25 (RG, sayı 930); BGE 51 II 54; 44 II 107.

[541] BGE 90 II 376; 86 II 601.

hâlinde onun görevine son verir. Görevine son verilen vasiyeti yerine getirme görevlisi, karara karşı asliye mahkemesine itiraz edebilir. Asliye mahkemesinin, itiraz üzerine verdiği karar kesin olup, karara karşı Yargıtay'a başvurulmaz (MK 555/III).

MK 555/III her ne kadar, sadece vasiyeti yerine getirme görevlisinin görevden alınması hâlinde ona asliye mahkemesine başvurma hakkı tanıyorsa da, şikâyetleri sulh mahkemesi tarafından kabul edilmeyen mirasçıların da aynı hakka sahip olmaları gerekir. 870

d) Vasiyeti yerine getirme görevlisinin sorumluluğu

Vasiyeti yerine getirme görevlisi işini yaparken gerekli olan özeni göstermezse, bundan doğan zararlardan vekil gibi BK 390'a göre sorumlu olur (MK 556). Bundan da anlaşılacağı gibi, vasiyeti yerine getirme görevlisi, özel hukuk kurallarına göre sorumludur. Onun sulh hâkiminin denetiminde iş yapması, verdiği zarardan Devletin sorumlu olması sonucunu doğurmaz[542]. Vasiyeti yerine getirme görevlisi, ancak gerekli özeni göstermede kusurunun bulunmadığını ispat ile sorumluluktan kurtulabilir. 871

Vekâlet vermemiş olmalarına rağmen, mirasçıların BK 390'a göre tazminat istemelerinin sebebi, vasiyeti yerine getirme görevlisinin tasarrufta bulunduğu malvarlığının onlara ait olmasıdır[543]. Federal Mahkemenin yukarıda sözü edilen BGE 101 II 47'deki kararına göre, MK 677/II'ye dayanarak, bir mirasçının miras payını devir alan üçüncü kişi, mirasçı sıfatını kazanmadığı için, vasiyeti yerine getirme görevlisine karşı tazminat davası açamaz, meğer ki, devir sözleşmesi ie birlikte dava hakkı da BK 162'ye göre üçüncü kişiye devir edilmiş olsun[544]. Belirtmek gerekir ki, mirasçılar kendilerine zarar veren işleme izin ya da icazet vermişlerse, vasiyeti yerine getirme görevlisinin sorumluluğuna gidemezler[545]. 872

Burada son olarak üzerinde durulması gereken mesele, vasiyeti yerine getirme görevlisinin kendi kendisi ile sözleşme yapabilip yapamayacağıdır. Örneğin, vasiyeti yerine getirme görevlisi, terekeye dahil ve kendisi tarafından satılacak bir taşınmazı satın alabilir mi? *İmre/Erman*, böyle bir işlemin ahlâka aykırı olacağı gerekçesiyle, BK 20'ye göre kesin hükümsüz olacağı görüşündedirler[546]. *Piotet* ise, vasiyeti yerine getirme görevlisinin kendi kendisiyle işlem yapmada genel sınırlamalar tabi olduğunu, böyle bir hâlde yasal temsilci olmamasına rağmen MK 426 b.2'nin örneksemeyle uygulanarak bir kayyım atanması gerektiği görüşündedir[547]. 873

---

[542] *Piotet*, 155; *İmre/Erman*, 153. Ancak yazarlar, denetimi yapan sulh mahkemesi hakiminin kusurlu olması hâlinde (kanuni temelini göstermeden) verdiği zarardan sorumlu olacağı görüşündedirler. BGE 47 II 38'de mirasın resmen idaresi hali için devletin sorumlu olmayacağı sonucuna varılmıştır.

[543] *Escher*, Art. 518 N 14; *Tuor*, Art. 518 N 24; *Oğuzman*, 163 dn.375; *İmre/Erman*, 152; Piotet'eye göre (155), burada, vekâlet hükümlerine başvurulmasını gerektirmeyen bir sözleşme benzeri sorumluluk vardır. Bu konuda farklı düşüncede: *Akbıyık*, Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi, 209.

[544] Bu konuda ayrıca bkz., *İmre/Erman*, 152 dn. 22.

[545] Ayrıca bkz., *İmre/Erman*, 152, dn. 22.

[546] *İmre/Erman* 153.

[547] *Piotet*, 162.

e) Vasiyeti yerine getirme görevlisinin görevinin sona ermesi

874 Vasiyeti yerine getirme görevlisinin görevi kuşkusuz, görevini tamamlaması ile kendiliğinden sona erer. Bunun dışında görevin hangi hâllerde sona ereceği MK 554 ve 555/III'de sayılmıştır.

875 MK 554/I'e göre vasiyeti yerine getirme görevlisinin görevi, ölüm ya da kendisini atayan ölüme bağlı tasarrufta bir geçersizlik sebebi varsa kendiliğinden sona erer. Kuşkusuz bu son hâlde, kendisini atayan ölüme bağlı tasarrufun iptal edilmiş olması gerekir.

876 Vasiyeti yerine getirme görevlisinin görevi istifa ile de sona erer. Bu istifa beyanının sulh mahkemesine yöneltilmesi ve uygun olmayan bir zamanda yapılmaması gerekir (MK 554/II). Nihayet, MK 555/III'deki sebeplerden biri varsa sulh mahkemesi vasiyeti yerine getirme görevlisinin görevine son verir[548].

877 Kanunda belirtilmemiş olmasına rağmen, vasiyeti yerine getirme görevlisi fiil ehliyetini kaybedecek olursa da görevinin sona ermesi gerekir. Bu husus, geniş bir yorumla MK 555/III'de öngörülmüş olan *yeteneksizliğe* dahil edilebilir[549].

878 Görevi herhangi bir sebeple sona eren vasiyeti yerine getirme görevlisi mirasçılara hesap verir. Ölümü hâlinde bu hesabı mirasçıları vermelidir. Fiil ehliyetsizliği hâlinde bu hesabın, sulh mahkemesi tarafından atanacak bir memur tarafından verilmesi doğru olur. Belirtmek gerekir ki, vasiyeti yerine getirme görevlisi, görevi devam ederken de mirasçıların ya da denetimine tabi olduğu sulh mahkemesinin isteği üzerine de hesap vermesi gerekir[550].

879 Vasiyeti yerine getirme görevliliğinin daha görev tamamlanmadan sona ermesi hâlinde, mahkemenin yeni bir vasiyeti yerine getirme görevlisi atamayacağı, ona ait yetkilerin mirasçılara geçeceği kabul edilmektedir[551]. Terekenin resmen idare edileceği ya da iflas hükümlerine göre tasfiye edileceği hâllerde bu yetkiler mirasçılara geçmez.

---

[548] Bu konuda bkz.,yukarıda (c).

[549] *Escher*, Art. 518 N 21; *Piotet*, 159.

[550] *Escher*, Art. 518 N 21; *Piotet*, 159.

[551] *Tuor*, Art. 518 N 18; *Piotet*, 159; *Ayiter/Kılıçoğlu*, 133; *İmre/Erman*, 146 (son yazarlar bu hâlde, mirasçılar ya da mahkemenin miras ortaklığına temsilci atayacağı görüşündedirler). 2.HD 10.6.1982, 4696/5208 (YKD 1982, c. VIII, 1522); Yargıtayın, aksi yöndeki, yani mahkemenin vasiyeti yerine getirme görevlisi atayabileceğine ilişkin görüşü için bkz., 2.HD 14.7.1982, 5704/6331 (YKD 1983, c.IX, 42). Bu kararın eleştirisi için bkz., *İmre/Erman*, 146.

VIII. MİRASTAN FERAGAT

a) Tanım ve genel bilgiler

Mirastan feragat ile müstakbel ve muhtemel mirasçı, mirasbırakana karşı ileride doğacak olan miras hakkından mirasbırakan ile yapacağı bir sözleşmeyle vazgeçer. Yapılan sözleşmeye mirastan feragat sözleşmesi denir (MK 528). Mirastan feragat edenin vazgeçtiği beklenen bir haktır, yoksa miras hakkı değil. Çünkü miras hakkı, mirasbırakanın ölümü ile doğacaktır; ölüm ânına kadar feragat edenin, *bir miras hakkı değil beklenen bir hakkı vardır.* 880

Ölüme bağlı tasarruf kavramı mutlak olarak düşünülecek olursa, mirastan feragat ve dolayısıyla da mirastan feragat sözleşmesinin bir ölüme bağlı tasarruf olmaması gerekir. Çünkü, bu sözleşmede mirasbırakan mutlak anlamda bir ölüme bağlı tasarrufta bulunmayıp, sadece karşı tarafın mirastan feragat ettiğine ilişkin iradesini kabul etmektedir. Buna rağmen mirasbırakan yönünden ölüme bağlı tasarruf hükümlerinin uygulanması, feragat sonucunda onun, tereke üzerindeki tasarruf imkânının genişlemesi, yâni yasal mirasçılığı değiştirebilmesi ve buna bağlı olarak da bir (beklenen) miras hakkına son vermesi ile açıklanmaktadır[552]. 881

Piotet'ye göre, mirastan feragatin ölüme bağlı tasarruf sayılmasının sebebi, onun akdî (iki taraflı) bir mirastan çıkarma olmasıdır[553]. Tuor ise mirastan feragat sözleşmesini bir ölüme bağlı tasarruf değil de bir ölüme bağlı işlem olarak nitelendirmektedir[554]. Ölüme bağlı tasarruftaki , tasarruf kelimesinin hukuki işlem karşılığı olarak kullanıldığı düşünülecek olursa, yazarın bu terim farkını teklif etmesinin ne gibi bir nitelik farkı yaratacağını anlamak güçtür. 882

Mirastan feragat niteliği gereği sadece, mirasbırakanın feragat eden ile yapacağı sözleşmeyle gerçekleşir. 11.2.1959 tarih ve 16/14 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı bu hususu açık olarak belirmiştir[555]. Karara göre, *"Kanunumuza göre mirastan feragat mukavelesi miras sözleşmesinin bir nevinden ibarettir. Bu itibarla mirastan feragat mukavelesinin bütün miras mukaveleleri gibi MK 492 (545) hükmünce resmi vasiyet şeklinde yapılması lâzımdır. Bunun sonucu olarak mirastan feragat mukavelesi hariçte düzenlenip noter tarafından onama suretiyle yapılamaz. Resmi senet gibi noterde re'sen düzenlenmelidir"*. Gerek mirastan feragatin niteliği gerek İçtihadı Birleştirme Kararından anlaşılacağı gibi, mirastan feragat, zorunlu olarak, sadece miras sözleşmesi ile yapılabilen yegâne ölüme bağlı tasarruftur, yani 883

---

[552] *Escher*, Art. 494 N 5; *Oğuzman*, 165.
[553] *Piotet*, 173.
[554] *Tuor*, Art. 495 N 5. Aynı terim için bkz., *Ayiter/Kılıçoğlu*, 144.
[555] RG 10233; ayrıca bkz., 2.HD 12.10.1992, 8409/9487 (YKD 1993, c. XIX, 993); 7.HD 20.12.1990, 16105/15573 (YKD 1991, c. XVII, 355).

niteliği onun vasiyetname ile yapılmasına engeldir[556]. Bunun yanında, Medenî Kanunun mirastan feragat, "miras sözleşmesi" kenar boşluğu altında düzenlemiş olması da İBK'daki görüşü destekler.

884 Mirastan feragat sözleşmesinde, ölüme bağlı tasarrufta bulunan mirasbırakan olduğu için, bu onun yönünden, bütün ölüme bağlı tasarruflarda olduğu gibi, kişiye sıkı sıkıya bağlı bir haktır. Bu sebeple onun miras sözleşmesini bizzat yapması gerekir, temsilci kullanamaz[557]. Buna karşılık, feragat eden ölüme bağlı tasarrufta bulunmadığından, genel kurallara göre temsilci kullanabilir. Bundan başka feragat eden velâyet altındaysa velisinin, vesayet altındaysa vasisinin rızası yanında sulh ve asliye mahkemelerinin onayının da bulunması gerekir (MK 463 b.5).

885 Mirastan feragat tam olabileceği gibi kısmî de olabilir. Tam feragat hâlinde, feragat eden muhtemel ve müstakbel mirasçı, ileri doğacak olan miras hakkından tamamen vazgeçtiği için mirasa çağırılmaz. Kısmî feragat hâlinde, ya feragat edenin miras payı azalır ya da (eğer feragatin konusu o ise) saklı payın korumasından yararlanamaz, fakat mirasçılık sıfatı devam eder. Kısmî feragat, saklı payın korumasından vazgeçme şeklindeyse bu, mirasbırakana feragat edenin saklı payı üzerinde (ivazsız feragat edenin altsoyunun saklı pay istemi saklı kalmak şartıyla) istediği gibi tasarruf etme imkânı verir. Ancak mirasbırakan tasarrufta bulunmamışsa, feragat eden, mirasçılık sıfatından vazgeçmediği için, yine mirasçı olur[558]. Belirtelim ki, bazı yazarlar mirastan feragat sözleşmesinin, belli bir maldan feragat şeklinde yapılmasını da mümkün görmektedirler[559].

886 Mirastan feragat sözleşmesi kural olarak her tür mirasçı ile yapılabilir. Mirasçının, mirasbırakana, ölüm ânında en yakın sıra ya da ilk derecede olması gerekmez. Daha uzaktaki bir mirasçıyla da mirastan feragat sözleşmesi yapılabilir. Örneğin, hasta olduğu için kendisinden önce ölme ihtimali bulunan bir oğlu olan mirasbırakan kardeşi ile bir mirastan feragat sözleşmesi yapabilir. Böylece oğlunun kendisinden önce ölmesi hâlinde, kardeşinin mirasçılığını engelleyerek tasarruf serbestisini genişletebilir.

887 Mirasçı kavramının içine atanmış mirasçılar da girdiği için, onunla da mirastan feragat sözleşmesinin yapılmasına gerek var mıdır? Vasiyetname ile atanan mirasçı yönünden, onu mirastan uzaklaştırabilmek için mirastan fergat sözleşmesinin yapılmasına gerek yoktur. Çünkü mirasbırakan, vasiyetnamesini geri alarak bunu temin edebilir. Miras sözleşmesi ile atanmış mirasçı yönünden de, *fikrimce*, bazı yazarların

---

[556] *Şener* tarafından savunulan, mirastan feragatin vasiyetname ile de yapılabileceğini mümkün gören, kabul edilemez görüşün eleştirisi için bkz., yukarıda § 15, IV.

[557] 2. HD 12.10.1992, 8409/9487 (YKD 1993, c. XIX, 993).

[558] *Büttiker*, 60, 61, 90; *Kocayusufpaşaoğlu*, 301.

[559] *Ayiter/Kılıçoğlu*, 144; *İnan/Ertaş*, 206

görüşünün aksine[560], onun mirasçılığına son vermek için muhakkak mirastan feragat sözleşmesinin yapılmasına gerek yoktur. Çünkü, mirastan feragat sözeşmesinden daha basit bir şekle tâbi olduğu için daha ucuz olan miras sözleşmesine son verme sözleşmesiyle (MK 546/I) aynı sonuç elde edilebilir. Ancak, bir hâlde miras sözleşmesi ile atanan mirasçının bu sıfatına son verebilmek için mirastan feragat sözleşmesinin yapılması zorunlu olabilir. Bu da, *Escher*'in belirtmiş olduğu gibi, miras sözleşmesiyle bir üçüncü kişinin mirasçı atanmış olması hâlidir. Bu durumda, üçüncü kişiyi mirastan uzaklaştırabilmek için, onunla mirastan feragat sözleşmesinin yapılması gerekir.

Yukarıda da değinildiği gbi, mirastan feragat sözleşmesinin her mirasçı ile yapılması mümkünse de, sözleşmenin işlevinin mirasbırakanın tasarruf nisabını genişletmek olduğu düşünülecek olursa, asıl önemini saklı paylı mirasçılar yönünden gösterecektir. Çünkü, mirasçı saklı paylı değilse, mirasbırakan zaten onun payı üzerinde istediği gibi tasarruf edebileceğinden, ayrıca bir de mirastan feragat sözleşmesi yapmasına gerek yoktur. Mirasbırakanın yasal mirasçıları kardeş çocuklarıysa, saklı payları olmadığı için, mirasbırakan onların payları üzerinde istediği gibi tasarrufta bulunabilir. Bu sebeple, onları mirasından uzaklaştırabilmek için ayrıca bir de mirastan feragat sözleşmesi yapılmasına gerek yoktur; yukarıda da değinildiği gibi, bir vasiyetname ile kardeş çocuklarının payları üzerinde tasarrufta bulunması yeterlidir. 888

Oysa, mirasbırakan, mirastan çıkarma sebebi bulunmadıkça, mirastan feragat sözleşmesi yapmadığı sürece, saklı paylı mirasçılarını mirastan uzaklaştıramaz, yani onların saklı payları üzerinde tasarrufta bulunamaz. 889

b) Mirastan feragat sözleşmesinin türleri

Mirastan feragat sözleşmesi ivazlı ve ivazsız olmak üzere iki türlü yapılabilir. 890

İvazsız mirastan *feragat* sözleşmesinde mirasçı, mirasbırakandan, onun sağlığında hiç bir bedel almadan, müstakbel ve muhtemel mirasçılık sıfatından (miras payından) vazgeçer. Mirasbırakan, sadece karşı tarafın feragat beyanını kabul edip, ayrıca sağlar arası herhangi bir borç altına girmez. 891

İvazlı mirastan feragat sözleşmesinde mirasçı, mirasbırakandan sağlığında aldığı ya da alacağı bir bedel karşılığında feragat eder. Bu tür sözleşmelerde, mirasbırakan sadece feragat beyanını kabul etmemekte, feragat edene karşı sağlığında bir ivaz ödeme borcu altına da girmektedir. İki mirastan feragat sözleşmesi arasında, feragatin altsoya etkisi ve bazı hâllerde mirasbırakanın borçlarından sorumlu olma dışında bir fark yoktur. 892

[560] Örnek olarak bkz., *İnan/Ertaş*, 206; *Ayiter/Kılıçoğlu*, 144.

c) Feragatin hükümleri

aa) Feragat eden yönünden

893 MK 528/II, *"Feragat eden mirasçılık sıfatını kaybeder"* diyerek, feragat edenin mirasçı olamayacağını öngörmüştür. Hemen belirtmek gerekir ki bu hüküm, sadece feragatin tam olduğu durumları göz önünde bulundurmaktadır. Çünkü mirasçılık sıfatının kazanılmaması ancak tam feragat hâlinde söz konusudur. Kısmi feragat hâlinde, yukarıda da değinildiği gibi, ya miras payı azalmakta ya da saklı payın korumasından mahrum kalınmakta, fakat feragat eden mirasbırakanın ölümü hâlinde mirasçılık sıfatını korumaktadır. Bu bakımdan, kısmi feragatin etkisi, mirasçılık sıfatının kaybedilmesi değil de, yukarıda belirtilen şekillerde ortaya çıkmaktadır[561].

894 Gerek tam gerek kısmi feragatin sonuçları mutlak değildir. Aşağıda açıklanacağı gibi, feragatin kanunen bozucu şarta bağlı olarak yapıldığının kabul edildiği hâllerde (MK 529), bozucu şart gerçekleşince feragat hükümsüz olur ve feragat eden mirasçılık sıfatını kazanır ya da kısmî feragatin sonuçları ortadan kalkar.

bb) Feragatin altsoya etkisi

895 İsviçre'de feragat ister ivazlı olsun ister ivazsız, feragat edenin altsoyunu da etkiler ve onlar da mirasçı olamazlar, meğer ki, sözleşmede aksine bir hüküm bulunsun (ZGB Art. 495 Abs. 3).

896 İsviçre'de, feragatin ivazlı olduğu hâllerde, ivazdan, feragat edenin altsoyunun da yararlanarak tatmin olabileceği gerekçesiyle, bunun altsoya etkili olması tartışmasız kabul edilirken; ivazsız feragatin altsoyu etkilemesi tereddütle karşılanmaktadır. Söz konusu hükmün, kanunkoyucunun, feragatin kural olarak ivazlı olacağı noktasından hareket etmesinin bir sonucu olduğu söylenmektedir. Bu sebeple, ivazsız feragat hâlinde, mirasbırakanın aksi yönde bir idaresinin varlığını kabulde yumuşak davranılması, hatta ölüme bağlı tasarruf dışındaki emarelere de başvurularak, aksi yöndeki iradenin varlığının ispatına imkân tanınması; mirastan feragatin, MK 2 anlamında dürüslük kuralına aykırı düştüğü, hakkın kötüye kullanılması sayılacak hâllerde altsoyu etkilememesi gibi yollarla, altsoyun mirasçılığının temin edilmesi teklif edilmektedir[562].

897 Türk Hukukunda MK 528/III farklı bir düzenleme getirmiştir. Buna göre, *"Bir karşılık sağlanarak mirastan feragat, sözleşmede aksi öngörülmedikçe feragat edenin altsoyu için de sonuç doğurur"*. O halde bizim sistemimizde, feragat ivazlı ise, feragat edenin altsoyunu da etkileyecek ve onlar, saklı paylı olsalar bile, feragat edenin yerini alarak mirasçı olamayacak-

---

[561] Bkz.,yukarıda (a).

[562] *Escher*, Art. 495 N 8; *Tuor*, Art. 495 N 14; *Büttiker*, 126; *Piotet*, 185.

lardır. Buna karşılık, ivazsız feragatin altsoya hiç bir etkisi olmayacak, yâni onlar, feragat edene halef olup mirasçılık sıfatını elde edeceklerdir.

Kanunun bu hükmünün açık olmasına karşılık, fıkradaki, *aksi öngörül-* 898
medikçe ibaresinin her iki feragati de kapsayıp kapsamadığı tartışmalıdır. İvazlı feragatin altsoyu etkilemeyeceğinin kanuna uygun olarak kararlaştırılabileceğinde kuşku yoktur. Tereddüt, ivazsız feragat hâlinde, feragat edenin altsoyunun da mirasçı olamayacağına ilişkin bir anlaşma yapılmasının mümkün olup olmayacağındadır. Bazı yazarlar ivazsız feragat hâlinde de altsoyun mirasçı olamayacağına ilişkin bir anlaşmanın yapılabileceğini savunurlar[563]. *Fikrimce*, ivazsız feragat hâlinde altsoyun da mirasçı olamayacağına ilişkin bir şartın konulamayacağını kabul eden görüşe üstünlük tanımak gerekir[564]. Çünkü, önce MK 528/III'de sadece ivazlı feragatin aksinin öngörülebileceği açık olarak belirtilmiştir. Bunun yanında menfaatler durumu da ivazsız feragat hâlinde feragat edenin altsoyunun mirasçı olamayacağının kararlaştırılmamasını gerektirir. Çünkü, ivazlı feragatte aksinin kararlaştırılması altsoyun lehine bir durum yaratır. Buna karşılık ivazsız feragatte durum tamamen aksine olup, altsoy, *kanunun kendisine tanıdığı bir haktan yoksun bırakılmaktadır*. Nihayet bir kimsenin, sahip olduğu bir haktan, onun adına başkasının vazgeçmesi hukuk mantığına da aykırıdır. Denilebilir ki, ivazlı feragat için kanun (muhtemel) hak sahibinin beyanını aramadan onu kanun gereği feragat etmiş saydığına göre bu itiraz geçerli olmaz. *Fikrimce*, bu gerekçe kabul edilemez. Çünkü ivazlı feragat hâlinde bir ivaz alınmaktadır. Bu ivaz, büyük bir ihtimalle ölmesi hâlinde feragat edenin terekesinde yer alacak ve bundan, kanun gereği feragat etmiş sayılan altsoyu yararlanacaktır. İşte ivazlı feragatin altsoya etkili olmasını kanunkoyucu bu gerekçe ile kabul etmiştir. Kaldı ki, bu çözüm kabul edilmeseydi, feragat edenin daha önce ölmesi hâlinde, onun altsoyu hem ivazdan yararlanacak, hem de feragat edenin ölümünde onun halefi olarak, feragat ettirenin mirasından da pay alacak ve böylece diğer mirasçılar aleyhine bir sonuç doğacaktır. Oysa ivazsız feragat hâlinde bu durum söz konusu olmayacağı için, iki tür feragat arasında bu konuda benzerik yoktur. Tam aksine, ivazsız feragatin altsoyu etkileyeceği kararlaştırılabilirse, onlar kanunun kendilerine tanığı haktan yoksun kalacaklardır ki, bu da kendi iradelerinin dışında olacaktır. Kaldı ki, Türk kanunkoyucusunun, İsviçre'deki düzenlemeyi bilmesine rağmen, oradan farklı bir düzenleme getirmiş olması da, iradesinin, ivazsız feragatin altsoyu hiç bir şekilde etkilememesi yönünde olduğunun açık bir delilidir. İvazsız feragat hâlinde, feragatin altsoyu etkilemeyeceğinin aksinin kararlaştırılabileceğini kabul, kanunkoyucunun

[563] Örnek olarak bkz., *Kocayusufpaşaoğlu*, 302; *Ayiter/Kılıçoğlu*, 145; *İmre/Erman*, 171.
[564] Örnek olarak bkz., *Oğuzman*, 166, dn.395; *Köprülü*, 128, dn. 180a; *İnan/Ertaş*, 208.

amacının aksine bir sonuç doğurur. Bu sebeple MK 528/III'ün sadece ivazlı feragat hâlinde uygulanacağını kabul etmek doğru olur. Mirasbırakan, ivazsız feragatin altsoyu etkilemesini istiyorsa, bunun çözüm yolu, eğer saklı paylı iseler onlarla da mirastan feragat sözleşmesi yapmasıdır. Altsoy saklı paylı değilse, zaten mirasbırakan onların miras payı üzerinde serbestçe tasarruf edebileceği için, MK 528/III'de olduğu gibi, feragatin onları da etkileyeceğine yönelik bir hükmün konulmasına gerek yoktur[565]. Son olarak belirtelim ki, MK 528' gerekçesinde, *"Düzenlemenin zıt anlamından da feragat karşılık sağlanmadan yapılmışsa, feragat, feragat edenin füruunu etkilemeyecektir. Bu prensibin aksi de mirastan feragat sözlemesi ile kararlaştırılabilir; ancak feragat edenin altsoyunun mirasbırakana karşı saklı paydan doğan hakları saklıdır"* denilmek suretiyle, gerek olmasına rağmen, aksinin ancak altsoyun, ancak saklı paylı mirasçı olmaması hâlinde aksine anlaşma yapılabileceği belirtilerek, kanunkoyucunun da (saklı paylı mirasçı olmaması hâlinde dahi MK 528/III'e gerek olmadığı hariç) burada savunulan fikre katıldığı belirtilmiştir[566].

cc) Feragatin tasarruf edilebilir kısma (tasarruf nisabına) etkisi

899 Bu hususta bkz., aşağıda § 22, 3.

dd) Feragatin mirasbırakanın alacakları yönünden etkisi

900 Yukarıda da değinildiği gibi, MK 528/II'ye göre mirastan tam feragat eden mirasçı, mirasçılık sıfatını kaybeder, ölüm hâlinde mirasa çağırılmaz. Bunun sonucunda, sadece mirastan pay almamakla kalmaz, küllî halef (mirasçı) sıfatı bulunmadığı için, borçlardan da sorumlu olmaz. Kısmî feragat hâlinde ise, mirastan daha az pay almakla , ya da saklı payın korumasından yoksun olmakla beraber, mirasçılık sıfatı devam ettiği için, diğer mirasçılarla birlikte kişisel ve müteselsil sorumluluğu devam eder.

901 Borçlardan sorumlu olmama açısından, kural olarak ivazlı ve ivazsız feragat arasında bir fark yoktur. Ne var ki, ivazlı feragat hâlinde, feragat eden, miras payının tamamı ya da bir kısmının karşılığını ivaz olarak mirasbırakanın sağlığında elde etmektedir. Böylece o, feragat etmemiş olsaydı, terekeye dahil olacağı için, mirasbırakanın alacaklarının el atabilecekleri bir miktarı daha önce elde ettiğinden, hem bundan alacaklıların yararlanması engellenmiş olmakta hem de borçlardan sorumlu olmamaktadır. Bunun ne dereceye kadar mirasbırakanın alacaklıları aleyhine olduğu açıktır. Bu sebeple MK 530, belirli şartların bulunması hâlinde, mirastan (sadece) ivazlı feragat eden mirasçının, borçlardan sorumlu olmasını öngörmüştür.

---

[565] Krş. *Oğuzman*, 166, dn. 395.
[566] Bkz., Gerekçe, 481.

MK 530'un feragat edenin borçlardan sorumluluğu için aradığı şartlar şunlardır:

1) Miras açıldığı zaman, terekenin borçları karşılayamaması. Terekenin 902
borca batık olması şart değildir[567]. Herhangi bir sebeple borçların tereke-den karşılanamaması, feragat edene başvurmak için yeterlidir.

2) Mirasbırakanın alacaklılarının tamamen ya da kısmen diğer mirasçı- 903
lar tarafından tatmin edilmemiş olması. Alacaklı ancak ödenmeyen kısım için ivazlı feragat edene başvurabilir. Bu bakımdan ivazlı feragat edenin sorumluluğu tâli (ikinci derecede) dir. O, ancak, alacaklıların diğer mirasçılara başvurup da alacaklarını elde edememeleri hâlinde sorumlu olur. Eğer miras, MK 612'ye göre, en yakın bütün yasal mirasçılar tarafından reddedildiği için iflas hükümlerine göre tasfiye ediliyorsa, alacaklıların önce iflas masasına başvurmaları gerekir[568].

3) Feragat eden, ölümden ancak beş yıl öncesine kadar elde ettiği ivaz- 904
dan, talep anında zenginleştiği oranda sorumludur. Görülüyor ki, MK 530, ivazlı feragat edenin sorumluluğunun tâli olması yanında sınırlı olmasını da öngörmüştür. Bu sınır, önce zaman yönündendir. Feragat eden, ancak ölümden önceki son beş yıl içinde aldığı ivaz ile sorumludur. İvazı daha önceki bir tarihte almışsa (talep anında zenginleşmesi bulunmasına rağmen) sorumlu olmaz. İkinci sınır miktar yönündendir. Feragat eden son beş yıl içinde almış olduğu ivazdan, sadece talep anında zenginleştiği oranda ödeme yükümü altındadır. Eğer zenginleşme yoksa, ivazlı feragat edenin sorumluluğu da olmaz. Çünkü onun sorumluluğu zenginleştiği orandadır[569].

d) Feragatin hükümsüzlüğü

Feragatin hükümsüz olduğu hâllerde, feragat eden tekrar mirasçı sıfatını 905
kazanır. Hangi hâllerde geçerli olarak yapılmış bir feragatin hükümsüz olacağı MK 529'da öngörülmüştür. Ancak belirtelim ki, MK 529'da öngörülmüş olan hâller, mirastan feragat sözleşmesine özgü sebeplerdir. Bunun yanında mirastan feragat sözleşmesinde, genel olarak ölüme bağlı tasarruflar için öngörülmüş iptal sebeplerinden biri varsa (MK557), sözleşme bu sebeple de iptal edilebilir ve feragat eden tekrar mirasçı sıfatını kazanabilir. Burada sadece MK 529'daki düzenlemeler üzerinde durulacaktır.

MK 529 incelendiği zaman, kanunkoyucunun mirastan feragatin iki bo- 906
zucu şarttan birine bağlı olarak yapıldığını ve bu sebeple de bu bozucu şartlardan birinin gerçekleşmesi hâlinde feragatin geçersiz olacağını kabul ettiğini görüyoruz. Bu haller şunlardır:

---

[567] Krş, ZGB Art. 497.
[568] *Tuor*, Art. 497 N 2; *Escher*, Art. 497 N 3; *Piotet*, 188.
[569] *Tuor*, Art. 497 N 3; *Escher*, Art. 497 N 5; *Piotet*, 186.

aa) Feragatin belirli bir ya da bir kaç kişi lehine yapılmış olması

907 Mirastan feragatin kim ya da kimler lehine yapılmış olduğu açık olarak belirtilmişse, sözleşmeden aksi anlaşılmadıkça MK 529/I bunun bir bozucu şart altında yapıldığı karinesini getirmiştir. Bunun anlamı, feragatin, ancak o kişi ya da kişilerin mirasçı olmaları hâlinde geçerli olacağıdır. Lehine feragat edilen kimse, red, mirastan çıkarma ya da yoksunluk veya mirasbırakandan önce ölme gibi bir sebeple mirasçı olamazsa, bozucu şart gerçekleşmiş olacağı için, feragat sözleşmesi geçersiz olacak ve feragat eden (ya da onun feragatten etkilenen altsoyu) tekrar mirasçılık sıfatını kazanacaktır. Feragatin bu sebeple hükümsüz olması için bir iptal davasının açılmasına gerek yoktur. Ancak ihtilâf hâlinde bir tespit davası açılabilir. Birden fazla kişi lehine feragat edilmişse, bozucu şartın gerçekleşmiş sayılması için tümünün mirasa nail olamaması gerekir. İçlerinden birinin mirasçı olamaması durumunda, ona düşen pay diğerleri arasında paylaşılır. MK 529/I'in bu hükmü hem ivazlı hem ivazsız feragatte uygulanır[570].

908 Belirli kişiler lehine feragat aynı zamanda yedek mirasçı atama ile birlikte yapılmışsa, bozucu şartın gerçekleşmiş sayılıp mirasın tekrar feragat edene dönebilmesi için, yedek mirasçının da mirasçılık sıfatını kazanamaması gerekir.

bb) Feragatin en yakın ortak kökün altsoyu (tüm ortak yasal mirasçılar) lehine yapılmış olması

909 MK 529/II'ye göre, *"Mirastan feragat sözleşmesi belli bir kişi lehine yapılmamışsa, en yakın ortak kökün altsoyu lehine yapılmış sayılır ve bunların herhangi bir sebeple mirasçı olamaması hâlinde feragat yine hükümden düşer"*. Maddenin lafzına göre, kimin lehine yapıldığı belirtilmemişse, feragat, feragat edenin en yakın ortak kökünün altsoyu lehine yapılmış sayılacak ve bunların hiç biri mirasçı olamazsa, bozucu şart gerçekleştiği için, feragat hükümsüz sayılacak ve feragat eden tekrar mirasçı olacaktır. Bu hüküm üzerinde biraz duralım.

910 MK 529/II'yi karşılayan eski MK 476 c.2, *en yakın ortak kökün altsoyu lehine, yerine en yakın aslı müşterekin füruu* demekteydi. Bu ibare Türk doktrininde en yakın zümre başı ve feragat edenin içinde bulunduğu zümre olarak anlaşılmaktaydı[571]. MK 529/I (eski MK 476)'nın karşıtı olan ZGB Art. 496 *"...dass er nur gegenüber den Erben des Stammes, der sich vom nächsten ihnen gemeinsamen Vorfahren ableitet..."* demektedir. Buradaki Stamm kelimesi ZGB'de hem zümre (örnek olarak bkz., ZGB Art. 457/III, 458/I ve III 459, 462) hem de kök anlamında kullanılmıştır. MK 529/II (es-

[570] *Büttiker*, 97; *Tuor*, Art. 496 N 3; *Escher*, Art. 496 N 3; *Piotet*, 185; *Kocayusufpaşaoğlu*, 303; *Oğuzman*, 400.

[571] Örnek olarak bkz., *Kocayusufpaşaoğlu*, 306 ve orada anılan yazarlar.

ki MK 476 c.2)'yi karşılayan ZGB Art. 496'da bunun *kök değil de* zümre karşılığı kullanıldığı hemen hemen bütün İsviçre doktrini tarafından kabul edilmektedir[572]. Türk Hukukunda da buna paralel olarak eski MK 476'da kullanılan ve yukarıda verilmiş olan ibarenin *feragat edene en yakın zümre başı* (kök başı değil) ile onun altsoyunu ifade ettiği doğru olarak kabul ediliyordu.

Oysa MK 529/II'de, kanunkoyucu, *Stamm* kelimesinin zümre anlamına 911
geldiği ve ZGB Art. 496/II'de bu anlamda kullanıldığının farkında olmayarak bunu *kök* diye almıştır. Bu, çeviri yanlışlığından öte hüküm değişikliğine (hem de *fikrimce* doğru olmayan) sebep olmuştur. Bunu bir örnekle açıklayalım:

M, oğlu A'nın çocuğu T ile ,kimin lehine olduğunu belirtmeden, bir mi- 912
rastan feragat sözleşmesi yapmıştır. M öldüğü zaman, çocukları A, B ve C, A'nın oğlu T ve T'nin çocukları D ve F hayattadır. Şimdi, T, kimin lehine feragat ettiğini belirtmediği için MK 529/II'ye göre, en yakın kökbaşı olan A'nın kökü yani A,D ve F lehine feragat etmiş sayılacaktır. B ve C, T'nin içinde bulunduğu köke dahil olmadıkları için (oysa T'nin içinde bulunduğu zümreye dahildirler) feragatten yararlanamayacaklardır. Böyle olunca da MK 529/II'nin lafzına göre B ve C mirasçı sıfatını kazansalar bile, T'nin içinde bulunduğu kökteki A, D ve F herhangi bir sebeple mirasçı olamazlarsa, feragat geçersiz olacak ve T, B ve C ile birlikte yeniden mirasçı olacaktır. Oysa kanunkoyucunun amacının bu olmadığı açıktır. Amaç, ancak o *zümrede*, yoksa kökte değil, bulunan mirasçılardan hiç birinin bu sıfatı kazanamamaları hâlinde feragati hükümsüz kılmaktır ki, doğrusu da budur. Yani, A,B,C ile D ve F'nin (bütün zümrenin) mirasçı olamamaları hâlinde feragatin geçersiz olması gerekir. Aksi hâlde, yani sadece feragat edenin içinde bulunduğu zümredeki mirasçıların bu sıfatı kazanamamaları hâlinde feragati geçersiz kabul etmek özellikle ivazlı feragatte menfaatler durumuna aykırıdır. Çünkü T, hem ivazı alacak hem de B ve C ile birlikte mirasçı olacaktır. İşte bu çeviri yanlışlığının bizi götürdüğü sonuç. Bu bakımdan, MK 529'un gerekçesinde iddia edildiğinin aksine önemli bir hüküm değişikliği vardır[573].

Bu durumda yapılacak şey, hükmün uygulanmasında ısrar etmenin, 913
hükmün amacını aşacağı, hatta normunu kötüye kullanılması olacağından hareketle, kanunda örtülü bir boşluğun bulunduğunu kabul ile, MK 1'den yararlanarak kök başını zümre başı olarak kabul etmektir.

---

[572] Örnek olarak bkz., *Escher*, Art. 496 N 4; *Tuor*, Art. 496 N 9-10; *Tuor/Schnyder*, 359; *Piotet*, 185.

[573] Bkz., Gerekçe, 483.

914 MK 529/II'nin aynı zümrede (kökte) başka mirasçıların da bulunmasını araması, bu hükmün, feragat edenin o zümrede tek bir mirasçı olması hâlinde uygulanamayacağının açık bir ifadesidir. Aynı şekilde, feragat edenle birlikte aynı zümrede mirasçılar bulunmasına rağmen, feragat bunlardan biri ya da bir kaçı lehine yapılmışsa (örneğin mirasbırakanın oğlu A, kardeşlerinden B,C ve D'den sadece B lehine feragat etmiştir), MK 529/II yine uygulanamaz. Bu hâlde feragat, belirli bir kişi lehine yapılmış olduğu için MK 529/I uygulanır.

915 İşte MK 529/II hükmüne göre, miras açıldığı zaman, feragat edenle birlikte mirasçı olanlardan hiç biri herhangi bir sebeple mirasa nail olamazsa, bozucu şart gerçekleşmiş olur ve feragat eden tekrar mirasçı olur, yoksa miras bir sonraki zümreye geçmez.

IX. Mirasçılıktan çıkarma (mirastan ıskat)

916 Medeni Kanun, mirasçılıktan çıkarmayı cezai (MK 510-512) ve koruyucu (MK 513) olmak üzere iki türde düzenlemiştir.

1. Cezai mirasçılıktan çıkarma

a) Genel olarak

917 *Mirasçılıktan çıkarma, mirasbırakana, saklı paylı mirasçısını mirastan uzaklaştırma imkânı veren bir ölüme bağlı tasarruftur*. Bu bakımdan saklı pay kurumu ile yakından ilişkisi vardır. Çünkü bu yolla mirasbırakan, saklı paylı mirasçısı bulunmasına rağmen terekesi üzerinde daha geniş bir tasarruf imkânı elde edebilir[574].

918 Kanunkoyucunun bu hükme neden yer verdiğinin sebebini, saklı payın temelinde yatan görüşle açıklamak gerekir. Saklı pay kurumunun kabul edilmesinin sebebi, mirasbırakan ile bazı yasal mirasçılar arasında, yakın ve kopmaz kabul edilen aile bağlarının varlığıdır. Bu bağ dolayısıyladır ki, kanunkoyucu, bu tür mirasçı olan hısımlara miras paylarının belirli bir oranının mutlaka bırakılmasının gerektiğini öngörmüştür. Ne var ki, bu, var olduğu kabul edilen aile bağı, saklı paylı mirasçının bir davranışı yüzünden kopmuşsa, bu durum artık onun saklı payın korumasından yararlanmaya layik olmadığını gösterir. Buna rağmen onu korumak, layik olmayan bir kimseyi, artık kalmamış olan aile bağına rağmen korumaya devam etmek olur. İşte kanunkoyucu, böyle bir hâlde mirasçılıktan çıkarma kurumunu, o kişiyi saklı payın korumasının dışında bırakmak için düzenlemiştir. Ne var ki, aile bağının kopup kopmadığının tespitinde, mirasbırakanın sübjektif değerlendirmesi önemli bir rol oynayacağı için, sebebin gerçekleşmesine rağmen

[574] *Escher*, Art. 477 N 1.

mirasçılıktan çıkartıp çıkartmama, mirasbırakanın iradesine bırakılmıştır. Bu sebepledir ki, mirasçılıktan çıkarmanın gerçekleşmesi için mirasbırakanın bu yöndeki iradesini açığa vurması gerekir. Bu irade, mirasçılıktan çıkarma zorunlu bir taraflı ölüme bağlı tasarruf olduğu için, kural olarak vasiyetname ile açığa vurulur. Ancak, mirasçılıktan çıkarmanın bir miras sözleşmesi ile yapılmasına da bir engel yoktur. Bu halde mirasçılıktan çıkarma, miras sözleşmesinin bağlayıcı içeriğine dahil olmaz; bağlayıcı olmama niteliği devam eder ve vasiyetname hükümlerine tabi olur. Bunun anlamı, mirasbırakanın, miras sözleşmesinin içinde yapmış olmasına rağmen mirasçılıktan çıkarmayı her zaman bir taraflı irade açıklaması ile, tıpkı vasiyetname ile yapılmış gibi geri alabilmesidir.

Hemen belirtmek gerekir ki, cezai mirasçılıktan çıkarmadan söz edebilmek için, saklı paylı mirasçıların, saklı paylarının tamamı ya da bir kısmından yoksun bırakılmaları gerekir. Bu bakımdan saklı paylı olmayan bir mirasçının mirastan yoksun bırakılması, mirasçılıktan çıkarma olmayıp alelade bir mirastan uzaklaştırmadır[575]. Başka bir deyiş ile, MK 505'de saklı paylı mirasçılar arasında sayılmayan yasal mirasçılardan birinin, mirasçı olamayacağının belirtilmesi ya da onun payının tümü üzerinde tasarrufta bulunulması mirasçılıktan çıkarma değildir. Bu bakımdan böyle bir tasarrufun mirasçılıktan çıkarma sebeplerinden birine, hatta herhangi bir sebebe dayandırılması gerekmez. Ancak böyle bir uzaklaştırmanın da (mirasçılıktan çıkarma gibi) bir ölüme bağlı tasarrufla yapılması gerekir. Bu şekilde mirastan uzaklaştırılan mirasçı, ölüme bağlı tasarrufta bir iptal sebebi bulunmadıkça, buna karşı bir şey yapamaz. 919

Aynı şekilde, saklı paylı mirasçının, *sadece saklı payı ile yetinilmesinin öngörülmesi de, tasarruf saklı payla ilgili olmadığı için mirasçılıktan çıkarma değildir.* Çünkü, mirasbırakan, mirasçılıktan çıkarma sebeplerinden birinin bulunmasına gerek olmadan ve herhangi bir sebep göstermeden, saklı paylı mirasçının, saklı payı dışında kalan kısmı üzerinde, kanun gereği istediği gibi tasarrufta bulunabilir. Bu kısım onun tasarruf edilebilir bölümüne (tasarruf nisabına) dahildir. Örneğin, oğlu A'dan başka mirasçısı bulunmayan M, terekesinin 1/2'si için arkadaşı B'yi mirasçı atayacak olursa, altsoyun saklı pay oranı 1/2 olduğu için bir mirasçılıktan çıkarma tasarrufu yapmış olmaz. 920

b) Mirasçılıktan çıkarmanın şartları

aa) Şekil

Mirasçılıktan çıkarma, mirastan yoksunluktan farklı olarak (MK 578 vd), kendiliğinden değil, mirasbırakanın bir ölüme bağlı tasarrufu ile ger- 921

[575] *Kocayusufpaşaoğlu*, 306.

çekleşir (MK 510). Bu ölüme bağlı tasarruf, mirasçılıktan çıkarma bağlayıcı olmayan bir maddi anlamda ölüme bağlı tasarruf olduğu için, yukarıda da açıklandığı gibi, vasiyetnamedir. Fakat, yine yukarıda açıklandığı gibi, bağlayıcı içeriğine girmeyecek şekilde, miras sözleşmesi ile de yapılabilir. Bu bakımdan evlât edinen tarafından açılan evlâtlığın kaldırılması (refi) davasında, *"Kaldı ki dava dilekçesi de ıskatı amir bir tasarruf olarak kabul edilebilir"* sonucuna varan, 7.12.1955 tarih ve 11/1 sayılı İçtihadı Birleştirime Kararı doğru değildir[576].

bb) Mirasçılıktan çıkarmanın MK 510'da sayılan sebeplerden birine dayanması

922 MK 510'da mirasçılıktan çıkarma sebebi olarak görülen hâller şunlardır:

923 *1. (Saklı paylı) mirasçı,mirasbırakana veya mirasbırakanın yakınlarından birine karşı ağır bir suç işlemişse* (MK 510 b.1). Hemen belirtmek gerekir ki, buradaki ağır kelimesi ceza hukuku anlamında kullanılmış değildir. Buradaki ağır terimi hukuk hâkimine yönelik olup, hâkim, suçun ağır olup olmadığına ceza hukuku kurallarıyla bağlı olmaksızın karar verir. Başka bir deyişle, kanunkoyucu, burada fiilin niteliğine değil de sonucuna önem verdiği için, hâkim, suçun ağır olup olmadığına, aile bağını koparacak nitelikte olup olmadığına ve fiilen de koparmış olup olmadığına göre karar verecektir. Koparacak nitelikte olmasından kasıt suçun objektif olarak aile bağını koparacak nitelikte olmasıdır. Fiilen koparmış olması da, sübjektif unsur olup, somut olayda aile bağını koparmış olmasıdır. Kanunun ağır terimi ile kastettiği işte budur. Şu halde bir fiil aile bağını koparacak nitelikte olmakla beraber, somut olayda koparmamışsa, sübjektif şart gerçekleşmediği için, mirasçılıktan çıkarma sebebi olamaz. Bunun takdiri hâkime aittir ve hâkim, daha çok sübjektif durum yönünden değerlendirme yapmalıdır[577].

924 Ceza hukukunda suç olarak tespit edilen bir fiilin, mirasçılıktan çıkarma sebebi olabilmesi için, failin cezalandırılmış olması şart değildir. Fail, suç zamanaşımına uğradığı ya da şikâyette bulunulmadığından cezalandırılmamış olsa bile, mirasçılıktan çıkarma sebebi gerçekleşmiş olur, yeter ki, aile bağını koparmış olsun. Failin aslî fail olması da gerekli değildir. Örneğin, çok kızdığı kocasını sakat bırakacak şekilde dövmesi için oğlunu teşvik eden kadın da, MK 510 b.1 kapsamında mirasçılıktan çıkartılabilir.

925 MK 510 b.1 suçtan söz ettiğine göre, fiilin hukuka aykırı ve kasten ika

---

[576] RG sayı 8889.

[577] *Tuor*, Art. 477 N 2; *Escher*, Art. 477 N 8; *Kocayusufpaşaoğlu*, 309.

edilmiş olması gerekir. Bu bakımdan kendisine saldıran babasını yaralayan çocuk meşru müdafaa durumunda olduğu için ıskat edilemez. Bunun gibi mirasbırakana saldırıp da onu yaralayan saklı paylı mirasçı ayırt etme gücüne sahip değilse, kusurlu olmayacağı için mirasçılıktan çıkartılamaz. Buna karşılık ayırt etme gücünün geçici olarak kaybedildiği hallerde BK 54/II örneksemeyle uygulanmalıdır[578]. Bu halde mirasçılıktan uzaklaştırma fiilini gerçekleştiren saklı paylı mirasçı, kendi kusuru ile bu duruma düşmediğini ispat edemezse MK 501 b.1'e göre mirasçılıktan çıkartılabilmelidir.

Son olarak belirtelim ki, fiilin işlenmesinde mirasbırakanın müterafik 926
kusuru varsa ve bu mirasçınınkinden fazla ya da en az aynı derecede ise mirasçılıktan çıkarmaya gidilememelidir[579].

MK 510 b. 1'e göre, aile bağlarını koparacak nitelikte olan fiilin miras- 927
bırakan ya da onun yakınlarına karşı işlenmiş olması gerekir. Yakınları terimi, mirasbırakanla aralarındaki sıkı bağ dolayısıyla, onlara karşı işlenmiş fiilden mirasbırakanın, sanki o fiil kendisine karşı işlenmiş gibi etkilendiği kişileri ifade eder[580]. Bunun kapsamına hiç kuşkusuz mirasbırakanın eşi , kan ve sıhri hısımları girecektir. Ancak, mirasbırakanla aralarında hısımlık bağı bulunmayan kişiler de, eğer mirasbırakan bunlara karşı işlenen suçtan etkilenmişse, onun yakını sayılırlar. Mirasbırakanın nişanlısı, evlât edinmeden yetiştirdiği kişiler ya da içtikleri suyun ayrı gitmediği arkadaşları gibi... Bunun aksine, mirasbırakanla aralarındaki sıkı aile bağı kopmuş olan bir kişi, sırf hısım olduğu için yakınları kapsamına girmez. Örneğin daha önce kendisini öldürmeye teşebbüs ettiği için mirasçılıktan çıkarttığı oğlu A'yı diğer, oğlu B yaraladığı için M, onu mirasçılıktan çıkartamaz. Çünkü A ile aralarındaki aile bağı zaten kopmuştur[581].

2. Mirasbırakan ya da ailesine karşı aile hukukundan doğan görevlerin 928
önemli ölçüde (ağır) ihlâli. Bu bentte, aile hukukundan doğan görevlerin ihlali öngörüldüğü için, fiilin muhatabı olarak sadece mirasbırakan ve aile fertleri sayılmıştır. Bunun kapsamı üzerinde az sonra durulacaktır.

Aile görevlerinin ihlâlinin başında MK 364'deki nafaka borcunun yeri- 929
ne getirilmemesi yer alır. Daha genel bir hüküm ise MK 322'de vardır. Ana baba ve çocuğun, aile çıkarlarının gerektirdiği ölçüde, karşılıklı olarak yar-

---

[578] *Kocayusufpaşaoğlu*, 310; *Oğuzman*, 211.

[579] *Escher*, Art. 477 N 6; *Tuor*, Art.477 N 13. Yazarın verdiği örneğe göre çocuğun fiili ikamında ana babanın kötü eğitimi ve örnek olmaları sebep olmuşsa, ana ya da baba çocuğu ıskat edememelidirler. Ayrıca bkz., *Çubukgil*, AHFD 1950, sayı 3-4, 453; *Kocayusufpaşaoğlu*, 310; *Piotet*, 419.

[580] *Piotet*, 420; *Kocayusufpaşaoğlu*, 311; *Çubukgil*, AHFD 1950, syı 3-4, 451; ayrıca *Tuor*, Art. 477 N 27; *Escher*, Art 477 N 15 ve 17.

[581] *Piotet*, 311.

dım ve saygı göstermelerini öngören bu hükme aykırı davranış, mirasçılıktan çıkarma sebebi olur[582]. Aynı şekilde karı koca arasındaki sadakat borcunun ihlali de (MK 185/II, III) bu bende göre mirasçılıktan çıkarma sebebi oluşturur.

930 Iskat sebebi olabilmesi için, aile hukukundan doğan görevin ihlâli kusurlu olmalıdır. Ancak aile hukukundan doğan her görevin sırf kusurlu ihlâli de mirastan çıkarma sebebi oluşturmaz. Mirasçılıktan çıkarma için görevin *önemli ölçüde (ağır)* ihlâl edilmiş olması gerekir.

931 MK 510 b.1'de olduğu gibi burada da, aile hukukundan doğan görevin önemli ölçüdeki ihlâlinin, mirasçılıktan çıkarma sebebi olabilmesi için, objektif ve sübjektif unsurların bulunmasına bağlıdır. Daha açık bir deyişle, fiil, önce objektif olarak aile bağlarını koparacak nitelikte olmalıdır. Fakat daha da önemlisi, görevi ihlâl eden fiilin sübjektif olarak da aile bağını koparmış olması gerekir[583]. Örneğin, mirasbırakanın çocuğunun, onun istemediği bir kimse ile evlenmesi ya da ona aykırı bir siyasi görüşe sahip olması, objektif olarak aile bağını koparacak nitelikte fiiller değildir[584]. Bunun aksine bir karı ya da koca, eşinin zina yapmasından hiç etkilenmemiş, hattâ evlilik dışı ilişkiye devam ettiğini bilmesine rağmen ses çıkartmamışsa, objektif olarak aile hukukundan doğan sadakat görevinin ihlali vardır, fakat sübjektif olarak aile bağını koparmadığı için, mirasçılıktan çıkarma sebebi olmaz.

932 Bu konuda uygulamaya bir göz atacak olursak; 2.HD 9.1.1948 tarih ve 4478/151 sayılı kararında[585], ağır hasta ve bakıma muhtaç babasına bakmayan, zevk ve eğlence içinde kendi hayatına devam eden çocuğun (MK 510 b.2) mirasçılıktan çıkartılabileceğini kabul etmiştir. Buna karşılık, Yüksek Mahkeme, bakım ihtiyacı olmayan bir kimsenin, sırf bayramlarda ve hastalığında kendisini ziyaret etmemesi sebebiyle, aile görevini önemli ölçüde ihlal ettiği gerekçesine dayanarak çocuğunu mirasçılıktan çıkartamayacağı sonucuna varmıştı[586]. BGE 106 II 304 vd'na göre, zina mirasçılıktan çıkarma sebebidir. Yine Federal Mahkemeye göre, mirasbırakanın kızının, eşi ve çocuklarını terk ederek başka bir erkekle yaşaması, mirasbırakan, yâni kızın babası için bir mirasçılıktan çıkarma sebebi oluşturur[587]. Buna karşılık Yüksek Mahkemeye göre, ticaret hayatı kurallarına uygun olarak mirasbırakan ile rekabet[588], bir kocanın spekülasyon sonucu borsada para kaybetmesi[589], mirasçılıktan çıkarma sebebi olamaz. Aile şerefinin ihlali Yargıtay tarafından mirasçılıktan çıkarma sebebi olarak görülmektedir[590].

---

[582] BGE 76 II 265; 106 II 304
[583] BGE 76 II 264; 106 II 304 vd; ayrıca *Kocayusufpaşaoğlu*, 313.
[584] *Escher*, Art. 477 N 7; *Tuor*, Art. 477 N 16; *Kocayusufpaşaoğlu*, 313.
[585] *Tepeci*, 435.
[586] 2.HD 15.1.1968, 5592/180 (*Yazıcı/Atasoy*, 891).
[587] BGE 46 II 9.
[588] BGE 52 II 114.
[589] BGE 53 II 283.
[590] HGK 19.6.1987 (İKİD 1987, 269).

MK 510 b 2'deki aile üyeleri kavramına kimlerin girdiği tartışmalı ol- 933
makla beraber, yazarlarca verilen örneklerden,baskın görüşün (geniş ya da dar kapsamlı) olarak kan hısımları eş ve evlâtlığı kapsadığı yönünde olduğudur[591]. Farklı bir görüş ise, aile üyeleri kavramına nişanlı ve kayın hısımlarını da dahil eder[592]. *Fikrimce*, MK 510 b 2'nin kapsamını ikinci görüşteki kadar geniş tutmak kanunu amacına ters düşer. Bu bakımdan aile kavramını, eş, kan hısımları ve evlâtlık ile sınırlamak, fakat özelliği gereği nişanlıyı da dahil etmek buna karşılık kayın hısımlarını MK 510b.1'in kapsamına girecek kişiler arasında saymamak daha doğru olur.

cc) Mirasçılıktan çıkarma sebebinin, ölüme bağlı tasarrufta gösterilmesi

Mirasçılıktan çıkarmanın geçerli olması, sebebinin mirasçılıktan çıkar- 934
maya ilişkin tasarrufta gösterilmiş olmasına bağlıdır (MK 512/I). Aksi halde, mirastan uzaklaştırılan kişi, tenkis davası açarak, saklı payını alır (MK 512/III)[593]. Kanunun bunu aramasının sebebi, dava açılması hâlinde, hâkime mirasçılıktan çıkarmanın haklılığının tespit edilmesi imkânının temin edilmesidir[594]. Sebep bu olunca da, mirasbırakanın genel ifadeler kullanması, mirasçılıktan çıkarma sebebinin gösterilmiş sayılması için yeterli olmayacaktır. Somut olayların gösterilmesi gerekir. Örneğin, *"aile görevlerini yerine getirmedi", "bana karşı suç işledi"* gibi genel ifadelerin kullanılmış olması, sebebin gösterilmiş sayılması için yeterli değildir. *"Beni dövdü, muhtaç olmama rağmen hastalığımda bakmadı"* gibi somut olaylara dayandırılmalıdır mirasçılıktan çıkarma[595]. Buna karşılık mirasçılıktan çıkarma iradesinin varlığının anlaşılması şartıyla, mirasçılıktan çıkartıyorum ifadesinin bulunmasına gerek yoktur. Örneğin, *"oğlum A beni dövdüğü için onun payı diğerlerine kalsın"* şeklinde bir ifade mirasçılıktan çıkarmanın varlığı için yeterlidir[596].

Sebebin, mirasçılıktan çıkarma tasarrufunun yapıldığı anda bulunması 935
gerekir. Daha iyi bir ifade ile, mirasçılıktan çıkarma sebebi, tasarruf yapıldığı anda var olmalı ya da (tasarruf yapıldığı anda sona ermiş olsa bile) tasarruftan önce gerçekleşmiş olmalıdır; yoksa ölüm anına kadar devam et-

---

[591] *Tuor*, Art. 477 N 27; *Escher*, Art. 477 N 18 vd; *Ayiter/Kılıçoğlu*, 177; *Köprülü*, 284; *Oğuzman*, 212; HGK 15.6.1968, 1117/462 (*Yazıcı/Atasoy*, 885).

[592] *Piotet*, 420; *Kocayusufpaşaoğlu*, 314.

[593] HGK 11.4.1990, 130/329 (YKD 1990, c. XVI, 793); 2.HD 10.6.1991, 6596/9044 (YKD 1991,c. XVII, 1637).

[594] *Escher*, Art. 479 N 1; *Tuor*, Art. 479 N 2; *Piotet*, 425.

[595] BGE 48 II 430; 52 II 116; 73 II 211; *Tuor*, Art. 479 N 2; *Escher*, Art. 479 N 2; *Kocayusufpaşaoğlu*, 316; *Oğuzman*, 213; *İmre/Erman*, 219.

[596] *Tuor*, Art. 479 N 2.

mesi aranmaz. Örneğin, çocuğun babasını yıllar önce dövmüş olması mirasçılıktan çıkarma için yeterli bir sebeptir[597].

936 Tartışmalı olan, ileride bir sebebin ortaya çıkması ihtimali için mirasçılıktan çıkarmanın şartlı olarak yapılabilip yapılamayacağıdır. Örneğin, mirasbırakanın, *"karım zina yaparsa, açacağım boşanma davası kesin hükme bağlanmadan ölsem bile mirasçım olmayacaktır. Onu, bu ihtimalin gerçekleşmesi hâli için mirasımdan ıskat ediyorum"* şeklinde yapacağı bir mirasçılıktan çıkarma geçerli olur mu[598]? Yazarların bir kısmı MK 512/I'in mirasçılıktan çıkarma sebebinin vasiyetnamede gösterilmesini aramasından hareketle, şarta bağlı bir mirasçılıktan çıkarmanın yapılamayacağı görüşündedirler. Aksi hâlde, bir sınır konulmasının mümkün olmayacağı, daha doğmamış olan bir mirasçının bile şarta bağlı olarak mirasçılıktan çıkartılabileceğini söylemektedirler. Kaldı ki, bu yazarlara göre, mirasbırakanın şartlı olarak öngördüğü bu sebep, onun ölümüne kadar gerçekleşirse, zaten var olan bir sebebe dayanarak mirasbırakan söz konusu kişiyi her zaman mirasçılıktan çıkartabilir[599]. Buna karşılık diğer bir grup yazar, henüz gerçekleşmemiş bir sebebin, ileride gerçekleşmesi ihtimaline dayanarak, şartlı mirasçılıktan çıkarmayı mümkün görürler. Bu yazarlara göre, her ölüme bağlı tasarruf MK 515'e göre koşula bağlanabilir ve kanun, mirasçılıktan çıkarma için bir istisna getirmiş değildir. Bunun yanında böyle bir imkân, saklı paylı mirasçının davranışlarında dikkatli olması yönünde bir araç olur. Ayrıca, ileride ölüme bağlı tasarruf yapma ehliyetinin kaybedimesi ihtimali için, mirasbırakanın zamanında mirasçılıktan çıkarmayı gerçekleştirmesini temin eder[600].

937 *Fikrimce*, henüz gerçekleşmemiş bir sebebe dayanarak mirasçılıktan çıkarmaya gidilmesi mümkün değildir. Bu, ölüme bağlı tasarrufta mirasçılıktan çıkarma sebebinin gösterilmesini arayan MK 512/II'den açık olarak anlaşılmaktadır. Kaldı ki, mirasçılıktan çıkarma sebebi olan fiilleri sayan, MK 510'u karşılayan ZGB Art. 477'nin *geçmiş zamanda* yazılmış[601] olması da bu görüşü destekler. Buna karşılık, mirasçılıktan çıkarmaya ilişkin ölüme bağlı tasarrufun yapıldığı anda gerçekleşmiş bir sebebin bulunması hâlinde, mirasçılıktan çıkarmanın geciktirici ya da bozucu şarta bağlanması mümkündür. Örneğin mirasbırakan, zina yapmış olan eşinin mirasçılıktan çıkar-

---

[597] *Tuor*, Art 477 N 22; *Escher*, Art. 477 N 12.
[598] Örnek için bkz., *Kocayusufpaşaoğlu*, 314.
[599] *Escher*, Art. 477 N 12; *İnan/Ertaş*, 294; *Oğuzman*, 213.
[600] *İmre*, 385 (fakat İmre/Erman'da bu konuya temas edilmemiştir); *Stadtler*, 27; *Piotet*, 422; *Tuor*, Art. 477 N 22; *Kocayusufpaşaoğlu*, 314'de taraf tutmaksızın iki görüşü de açıklamıştır. Bu bakımdan onun ikinci görüşte olduğunu söylemek (*Oğuzman*, 213, dn. 572) doğru değildir.
[601] *Tuor*, Art. 477 N 22.

tılmasını, zinayı tekrarlamaması (geciktirici) şartına bağlayabilir. Ya da kendisine saldırdığı için oğlunu mirasından çıkartan bir baba, onun zayıfları koruma vakfı kurması hâlinde ıskatın geçersiz olacağını (bozucu şart) öngörebilir.

Yukarıda değinildiği gibi, mirasçılıktan çıkarma sebebinin tasarrufta gösterilmesi şart ise de, buna ilişkin delillerin de belirtilmesine gerek yoktur. Fakat ileride, sebebin varlığının ispatına kolaylık sağlamak için, delillerin de gösterilmesinde ya da tasarrufa eklenmesinde yarar vardır[602]. 938

Bu konuya son vermeden önce belirtilmelidir ki, mirasbırakanın mirasçılıktan çıkarmaya ilişkin tasarrufta sebep göstermesi zorunlu olmakla beraber, fiili yanlış nitelendirmesinin önemi yoktur, gerekirse hâkim kendisi nitelendirebilir. Mirasbırakanın suç olarak nitelendirdiği bir fiil, eğer aile hukukundan doğan görevin ihlâliyse, hâkim doğru nitelendirmeyi yaparak davayı görür, yoksa yanlış nitelendirme sebebiyle davayı reddedemez[603]. 939

c) Mirasçılıktan çıkarmanın hükümleri

a) MK 511/I'e göre, *"Mirasçılıktan çıkartılan kimse, mirastan pay alamayacağı gibi; tenkis davası da açamaz"*. Mirasçılıktan çıkartılan saklı paylı mirasçının artık tereke üzerinde hiç bir hakkı olmadığını söyleyen bu hüküm, sadece mirasçılıktan tam çıkarma hâli için geçerlidir. Kısmi mirasçılıktan çıkarma hâlinde, saklı paylı mirasçının sadece saklı payı azalır, fakat mirasçı sıfatı devam eder. 940

b) Mirasçılıktan çıkartılan kişinin miras payının ne olacağı MK 511/II'de belirtilmiştir. Buna göre, mirasçılıktan çıkartılan mirasçının miras payı, mirasbırakan bunun üzerinde herhangi bir tasarrufta bulunmamışsa, onun yerini alan mirasçılara geçer (mirasçılıktan çıkarmanın şahsiliği). Örneğin, mirasbırakanın oğulları A ve B ile A'nın oğlu C hayatta ve mirasbırakan A'yı mirasçılıktan çıkarmışsa, çıkarmanın şahsiliği gereği, A'nın yerini C alır, yani A'nın miras payı C'ye geçer. Mirasbırakanın mirasçıları sadece A ve B ise, o zaman mirasçılıktan çıkarma sonucu bütün miras B'ye kalır. Mirasbırakanın hayatta olan hısımları oğlu A ile babası B ve annesi C ise, A mirastan uzaklaştırılınca, birinci zümrede onun yerini alacak başka mirasçı olmadığı için, miras ikinci zümre mirasçıları olan B ve C'ye geçer. 941

MK 511/II'de belirtildiği gibi bu kural, mirasbırakanın, mirasçılıktan çıkardığı mirasçının miras payı (saklı payı) üzerinde bir tasarrufta bulunmamışsa yürür. Bu hükmün zıt kavramına göre, mirasbırakanın mirasçılık- 942

---

[602] *Escher*, Art. 479 N 1; *Tuor*, Art. 479 N 2; *Kocayusufpaşaoğlu*, 316; *Oğuzman*, 212, dn. 570; *İmre/Erman*, 219.

[603] *Oğuzman*, 213, dn. 571 ve orada anılan Federal Mahkeme kararları.

tan çıkardığı saklı paylı mirasçının saklı payı üzerinde (saklı paylı altsoy yoksa) tasarrufta bulunma hakkı vardır. Başka bir ifade ile, mirasçılıktan çıkarma, mirasbırakanın tasarruf nisabını (tasarruf edilebilir kısım) *artırabilir*. Artırıp artırmayacağı, mirasçılıktan çıkartılanın yerini, mirasbırakana göre, saklı paylı mirasçının alıp almadığına ve bunların saklı pay oranlarına bağlıdır. Şöyle ki:

943 1. Mirasçılıktan çıkartılanın, mirasbırakana göre saklı paylı altsoyu yoksa, onun saklı payı tümü ile mirasbırakanın tasarruf nisabına eklenir. Örneğin, mirasbırakanın eşi E yanında annesi A'dan başka mirasçısı yoksa ve A'yı mirastan çıkartmışsa, A'nın saklı payının tamamı (miras payının 1/4'i) mirasbırakanın tasarruf nisabına dahil olur. A'nın B adında bir çocuğunun (mirasbırakanın kardeşinin) olması, yukarıda açıklananlar yönünden bir değişiklik yapmaz. Çünkü B, mirasbırakanın saklı paylı mirasçısı değildir. Aynı şekilde, mirasbırakan çocukları A ve B'den A'yı mirastan çıkarmış ve A'nın altsoyu yoksa, onun saklı payının tamamı (miras payınınl/2'si) mirasbırakanın tasarruf nisabına eklenir, yoksa B bundan yararlanamaz, meğer ki mirasbırakan, yukarıda açıklandığı gibi, hiç bir tasarrufta bulunmamış olsun.

944 2. Buna karşılık mirasçılıktan çıkartılan saklı paylı mirasçının yerini alan mirasçı altsoy ve mirasbırakana göre saklı paylı mirasçı ise MK 511/III'e göre kendi saklı payını ister. Bu halde, mirasbırakanın tasarruf nisabının artıp artmayacağı, altsoyun saklı pay oranının, mirasçılıktan çıkartılan ile aynı olup olmamasına bağlıdır. Örneğin, mirasbırakanın mirasçılıktan çıkardığı oğlunun yerini torunları almışsa, tasarruf nisabında bir değişiklik olmaz, Çünkü altsoy olmaları sıfatıyla her ikisinin de saklı pay oranları aynı, yani 1/2'dir (MK 506 b.1). buna karşılık, mirasbırakan annesini mirasçılıktan çıkarmış ve onun yerini kardeşi almışsa tasarruf nisabı artar. Çünkü annenin saklı pay oranı 1/4 (MK 506 b.2) iken kardeşin saklı payı yoktur.

945 3. Mirastan çıkartılanın ne altsoyu ne de onunla birlikte aynı zümrede başka mirasçılar varsa miras, kanunî intikal gereği bir sonraki zümreye geçer. Fakat, o zümredeki yasal mirasçılar, saklı paylı olsalar bile, saklı payın korumasından yararlanamazlar. Çünkü mirasçılıktan çıkarma hâlinde MK 511/III'e göre. saklı payı, *sadece mirasçılıktan çıkartılanın, mirasbırakana göre, saklı paylı altsoyu isteyebilir*. Mirasbırakan, tek oğlu A'yı mirasçılıktan çıkartır ve mirasbırakanın babası B hayatta olursa miras, kanuni intikal gereği, B'ye geçer. Ne var ki, B, saklı paylı mirasçı olmasına rağmen, *mirastan çıkartılan A'nın mirasbırakana nispeten saklı paylı altsoyu olmadığı*

için, saklı payın korumasından yararlanamaz. Böylece terekenin tamamı mirasbırakanın tasarruf nisabına dahil olur[604].

Kanunun lafzına uygun olan bu durum, *fikrimce* adil olmadığı gibi, mirasçılıktan çıkarmanın şahsi olduğu kuralına da aykırıdır. Çünkü böylece, altsoy dışındaki mirasçılar da cezalandırılmaktadırlar. Kaldı ki, bu düzenlemeyi, feragat red, mirasçılıktan çıkarma ve mirastan yoksunluk hariç, saklı paylı mirasçının muhakkak saklı payını elde etmesi gerektiği kuralı ile de bağdaştırmak mümkün değildir. Bu bakımdan, mirasçılıktan çıkarma sebebiyle zümre atlanması hâlinde de bu zümrede bulunan saklı paylı mirasçıların, tıpkı mirasçılıktan çıkartılanın altsoyu gibi korunması yerinde olur. 946

Tasarruf nisabına ilişkin yukarıda açıklanan kurallar, mirasçılıktan çıkartılanın mirasbırakandan önce ölmesi hâlinde uygulanmaz. Çünkü bu halde mirasçı olamama, mirasçılıktan çıkarmaya değil de mirasbırakandan önce ölmeye dayanmaktadır. Bu sebeple tasarruf nisabı da mirasbırakandan önce ölme hâline göre hesaplanır ve mirasçılıktan çıkartılanın saklı payı tasarruf nisabına eklenmez; ya da mirasçılıktan çıkartılanın altsoyu ve birlikte mirasçı olduğu kimseler bulunmadığı için miras bir sonraki zümreye geçer ve oradaki mirasçılar yine saklı payın korumasından yararlanırlar[605]. 947

d) Mirasçılıktan çıkarmanın hükümsüzlüğü

Mirastan çıkartılan kimse, tenkis ya da iptal davası açarak, çıkarmaya itiraz edebilir. 948

aa) İptal davası açılabilecek hâller

1. Ölüme bağlı tasaruflara ilişkin genel iptal sebepleri. Mirastan çıkartılan mirasçı, önce genel olarak, vasiyetnamelerin iptaline ilişkin esaslara göre (şekil, ehliyetsizlik irade sakatlığı, hukuka ve ahlâka aykırılık) iptal davası açarak, mirastan çıkarma tasarrufunu ortadan kaldırabilir. Eğer geçersizlik sebebi, bütün vasiyetnameyi etkiliyorsa, vasiyetname bütünü ile geçersiz olur. 949

Piotet[606], mirasçılıktan çıkarma yönünden vasiyetnamedeki şekil eksikliğini, çıkarmaya özgün olan ve olmayan diye ikiye ayırmaktadır. Yazara göre, çıkarma sebebinin gösterilmemesi ya da gösterilen sebebin yeterli olmaması, mirasçılıktan çıkarmaya özgü şekil eksikliğidir ve bu sebeple iptal hâlinde mirasçılıktan çıkartılan saklı payını alır. *Fikrimce*, yazarın belirttiği bu durumlar, mirasçılıktan çıkarmaya özgü şekil noksanı olarak görülemez, çünkü bunlar maddî hukuka ilişkin şartlardır. 950

2. Mirasbırakanın mirasçılıktan çıkarma sebebinde açık bir hataya 951

---

[604] *Tuor*, Art. 478 N 17; *Piotet*, 429; *Oğuzman*, 214. Ancak, *Oğuzman*'ın, bu halde mirasçı olunamayacağını söyleyerek, *Piotet*'ye atıf yapması, en azından *Piotet*'nin kitabının Almanca metni yönünden doğru değildir.

[605] *Tuor*, Art. 478 N 16.

[606] *Piotet*, 426/427.

düşmüş olması (MK 512/III). Örneğin mirasbırakan gerçekte öyle olmamasına rağmen, oğlunun kendisini öldürmeye teşebbüs ettiğini sanarak onu mirasçılıktan çıkarmıştır. İşte, böyle bir hâlde, mirasçılıktan çıkarma sebebinde açık bir hata bulunduğu için, mirasçılıktan çıkartılan çocuk, tasarrufun iptalini dava ederek onu geçersiz hâle getirebilir. Yukarıda belirtilen iptalden farklı olarak, buradaki iptal daima kısmidir, sadece mirasçılıktan çıkarma geçersiz olur, fakat diğer ölüme bağlı tasarruflar geçerliklerini korurlar.

952 Belirtmek gerekir ki, MK 504'ün, saik hatası dahil, bütün hata hâllerini vasiyetnamenin iptal sebebi saydığı düşünülecek olursa, MK 512/III'deki *açık* kelimesinin önemsememek gerekir. İki madde arasındaki bu farkı, İsviçreli yazarlar *açık (offenbar)* kelimesinin sonradan gereksiz yere Uzmanlar Komisyonunda eklenmesi ile açıklamaktadırlar[607].

953 Hata sebebiyle iptal davası, mirastan çıkarılan mirasçı tarafından bu iskattan yararlanan mirasçı ya da mirasçılara karşı açılır. Ancak Yargıtay farklı bir görüşte olup, iptal davasının sadece bundan yararlanan mirasçılara karşı değil de bütün mirasçılara karşı açılmasını aramaktadır. HGK 9.4.1997 tarih ve 888/306 sayılı kararında[608] mirasçılıktan çıkarılanın sadece kendi mirasçısına (altsoyuna) karşı açtığı iptal davasını, davada bütün yasal mirasçıların hasım gösterilmesi gerektiğini, aksi halde kararın diğer mirasçıları bağlamayacağı gerekçesiyle reddetmiştir. Aynı şekilde 2. Hukuk Dairesi de, mirasçılıktan çıkarılanın altsoyuna karşı açtığı davayı, davanın bütün mirasçılara karşı açılması gerektiğini ileri sürerek reddetmiştir[609].

954 *Hangi sebeple iptal davası açılmış olursa olsun, başarılı olma hâlinde mirastan çıkartılan kişi miras payının tamamını alır.*

955 Davada ispat yükü genel kurala tabidir (MK 6, 512/II). Buna göre, mirasbırakanın açık bir hataya düştüğünü mirastan çıkarılan kişi, aksine, mirastan çıkarma sebebinin varlığını davalı ispat edecektir[610].

bb) Tenkis davası açılabilecek hâller

956 Mirastan çıkarılan kişi, sebebin gösterilmemiş ya da gösterilen sebebin yeterli olmadığı hâllerde, tenkis davası açarak *sadece saklı payını alır*[611].

---

[607] *Tuor*, Art. 479 N 4; *Escher*, Art. 479 N 2; ayrıca bkz., *Kocayusufpaşaoğlu*, 317.

[608] YKD 1997, c. XXIII, 1687.

[609] 2.HD 13.9.1994, 6102/7991 (YKD 1994, c.XX, 1910).

[610] 2.HD'nin 18.5.1995 tarih ve 4699/5842 sayılı kararına göre, mirasçılıktan çıkarmanın iptali kademelidir. Açık hata ve çıkarma sebebinin varlığı ispat edilemezse, davaya tenkis davası olarak devam edilir (YKD 1995, c.XX, 1910).

[611] 2.HD 18.1.1995, 4699/ 5842 (YKD 1995, c. XXI, 973); HGK 1.4.1990, 130/239 (YKD 1990, c. XVI,973); 2.HD .11.1987, 6672/8263 (YKD 1988, c.XIV, 331); ayrıca bkz., *Oğuzman*, 215, dn. 58a'da anılan kararlar.

Bu hâllerde tenkis davasının açılmasının sebebi, çıkarma tasarrufunda bulunan mirasbırakanın, her şeye rağmen mirasçılıktan çıkardığı kişinin, saklı payı ile yetinmesini istemeye yönelik bir (mefruz) iradesinin varlığının kabul edilmesidir[612].

Tenkis davasında ispat yükü davacıda değil davalıdadır (MK 512/II). 957
Davalı, mirasçılıktan çıkarmadan yararlanan kişi ya da kişilerdir (diğer yasal ya da atanmış mirasçılar). Başka bir deyişle, mirasçılıktan çıkarma sebebinin yeterli olduğunu ya da bulunduğunu davalılar ispat edeceklerdir, yoksa aksini davacı değil[613].

Mirasçılıktan çıkarma sebebi gösterilmiş fakat yeterli olmadığı iddia ediliyorsa, 958
davalı, sebebin yeterli olduğunu ispat edecektir, yoksa o, bunu bırakıp, *sebebin varlığını ispat ederek*, çıkarmanın geçerli kalmasını temin edemez.

Tenkis davasının açıldığı hâllerde, ispat yükünün davalıya yüklenmiş olması, 959
bazı yazarlara göre, ispat yükünün MK 6 anlamında yer değiştirmiş olması değildir. Çünkü, davalının hakkı bu hususun ispatına bağlıdır. Bu sebeple davalı, hakkının varlığını MK 6'daki genel kurala göre ispat etmek zorundadır. Yani MK 512/II, MK 6'yı teyit eden bir hükümdür[614]. Ayrıca aksi olsaydı, davacı olumsuz olan bir hususu ispat etmek zorunda kalırdı ki, bu da hemen hemen imkânsız olurdu[615].

İptal ve tenkis davalarını, mirasçılıktan çıkarılan kişinin açmaması hâ- 960
linde, onun alacaklıları ya da iflas masası açabilir mi? Yazarlar, iptal davası yönünden, MK 558/I'in, dava açma hakkını sadece mirasçılar ve vasiyet alacaklılarına tanıdığından hareketle bu soruya olumsuz cevap vermektedirler[616]. Buna karşılık, *"mirasçılıktan çıkarılanın çıkarma tasarrufuna itiraz etmemesi durumunda da iflas idaresi veya alacaklılar, aynı koşullarla tenkis davası açabilirler"* diyen MK 562/II hükmü karşısında, mirasçılıktan çıkarılan kişinin alacaklıları ve iflas masası, MK 562/I'deki şartların gerçekleşmesi hâlinde çıkarmaya karşı tenkis davası açabilirler[617].

e) Affın mirasçılıktan çıkarmaya etkisi

Mirasbırakan, mirasçılıktan çıkarmayı içeren vasiyetnameyi, daha sonra 961
yapacağı bir ölüme bağlı tasarruf ile (MK 542) her zaman geri alabilir. Bu hâlde mirasçılıktan çıkarma artık hüküm ifade etmez. Ancak, burada incelenecek olan mesele, mirasbırakanın bu yola başvurmadan, yani bir ölüme bağlı tasarruf yapmadan, mirasçılıktan çıkardığı kişiyi affedebilip edeme-

---

[612] *Escher*, Art. 479 N 3; *Tuor*, Art. 479 N 6; *Kocayusufpaşaoğlu*, 316.
[613] Bkz., dn. 612'de anılan kararlar.
[614] *Escher*, Art. 479 N 4; *Tuor*, Art. 479 N 7; *Piotet*, 426; aksi fikir, *Stadtler*, 85.
[615] *Piotet*, 426.
[616] *Escher*, Art. 479 N 5; *Piotet*, 426; *İmre/Erman*, 223 ve orada dn. 29; aksi görüş, *Oğuzman*, 215, dn. 58a
[617] *Escher*, Art. 479, N 5; *Piotet*, 426; *İmre/Erman*, 223 ve orada, dn. 29; BGE 76 II 99; krş, *Oğuzman*, 215, dn. 58a.

yeceğidir. Bu durum, mirastan yoksunluk hâli için MK 578/II'de düzenlenmiştir, fakat mirasçılıktan çıkarma için böyle bir hüküm yoktur. Bu sebeple durum tartışmalıdır. Bazı yazarlar ve bazı kararlarında Federal Mahkeme, bu şekildeki bir affın mirasçılıktan çıkarma üzerinde bir etkisinin olmayacağını, mirasbırakanın sağlığında af iradesini (şekle bağlı olmayarak) açığa vurmasına rağmen, mirasçılıktan çıkarmanın yine de hüküm doğuracağı görüşündedirler. Gerekçe olarak da, mirastan yoksunlukta affin düzenlenmiş olmasına rağmen mirasçılıktan çıkarmada böyle bir hükmün bulunmaması, bu konunun Uzmanlar Komisyonunda tartışılıp reddedildiği, bu sebeple de bir boşluğun değil olumsuz (menfi) çözümün bulunduğu ileri sürülmüştür[618].

962 *Tuor* ve ona katılan yazarlar[619], affin mirasçılıktan çıkarmayı doğrudan doğruya ortadan kaldırmayacağını, fakat ıskat edilene MK 512/III'e göre tenkis davası açarak saklı payını isteme imkânını vereceğini haklı olarak savunmaktadırlar. Bu görüşte olan yazarlar, mirasbırakanın mirasçılıktan çıkardığı kişiyi sağlığında affetmesinin, kopmuş olan aile bağlarının yeniden kurulduğunu ve çıkarma sebebinin artık ortadan kalktığını gösterdiğini ileri sürmektedirler. Böyle olunca da, ölüm ânında bulunması gereken mirasçılıktan çıkarma sebebi artık yoktur. Sebebin yokluğuysa, yukarıda da değinildiği gibi, MK 512/III'e göre tenkis davası açma hakkı verir ve mirasçılıktan çıkartılan kişi, bu davayı açarak saklı payını alır.

2. Koruyucu mirasçılıktan çıkarma (borç ödemeden aciz sebebiyle mirasçılıktan çıkarma)

963 Cezai mirasçılıktan çıkarmadan farklı olarak, sadece birinci zümre mirasçılıkta, yani mirasbırakanın altsoyu yönünden uygulanabilen MK 513'de düzenlenmiş olan koruyucu mirasçılıktan çıkarma, mirasçının cezalandırılmasını değil de, mirasçılıktan çıkartılan mirasçının altsoyunu koruma amacını güder. Çünkü kanunkoyucu, bu mirasçılıktan çıkarmayı, belirli fiillerin mirasbırakanla, saklı paylı mirasçı arasındaki aile bağını koparması şartına değil, altsoyun, borçlarını ödemeden âciz olması hâlinde, saklı payın bir bölümünü, mirasçılıktan çıkarılanın altsoyuna geçmesini temin amacıyla öngörmüştür.

964 MK 513'e göre, koruyucu mirasçılıktan çıkarmanın ilk şartı, mirasçılıktan çıkartılacak olan altsoyun, borçlarını ödeyecek yeterli malı bulunmadığı için, alacaklıların onun aleyhine İİK 143'de öngörülmüş olan aciz vesikası-

---

[618] *Escher*, Art. 477 N 9; *İmre/Erman*, 220; *Ayiter/Kılıçoğlu*, 176; *Oğuzman*, 216; BGE 55 II 164; 73 II 08.

[619] *Tuor*, Art. 477 N 19; *Tuor/Schnyder*, 340; *Piotet*, 424; *Kocayusufpaşaoğlu*, 318; *İnan/Ertaş*, 298 (ancak bu son yazarlar MK 2'ye dayanmaktadırlar).

nı almış olmalarıdır. Bu belgenin, mirasçılıktan çıkarma tasarrufu yapıldığı anda bulunmasının gerekip gerekmediği tartışmalıdır. Bazı yazarlar, aciz vesikasının mirasın açıldığı anda bulunmasını yeterli görmekte, yoksa mirasçılıktan çıkarmanın yapıldığı anda bulunmasını aramamaktadırlar. Mirasçılıktan çıkarma tasarrufu yapıldığı anda aciz vesikası yoksa, mirasçılıktan çıkarmanın, mirasın açıldığı anda aciz vesikasının alınmış olması geciktirici şartına bağlı olarak yapıldığı kabul edilmektedir[620]. Ne var ki, bu görüşün, alacaklıların miras açılıncaya kadar zamanaşımını kesmek için icra takibini aciz vesikası alma safhasına kadar getirip, aciz vesikasını, mirasın açılmasından sonra talep etmek suretiyle MK 513'ün pratik olarak uygulanmasının engelleneceği de söylenmektedir[621].

İkinci şart, mirasbırakanı, aleyhine aciz vesikası alınmış olan altsoyunun saklı payının yarısını onun doğmuş ya da doğacak olan çocuklarına tahsis etmesidir. Doğacak çocuklar MK 524 anlamında ana rahmine düşmüş çocukları ifade eder[622]. Kanun, her ne kadar, tahsisin çocuklara yapılacağını söylemişse de, bunu altsoy olarak anlamak gerekir. Böyle olunca da, mirasbırakan, mirasçılıktan bu sebeple çıkardığı oğlu A'nın saklı payının yarısını, A'nın daha önce ölmüş olan çocuğu B'nin çocuğu C'ye (mirasbırakanın torun çocuğu) tahsis ederse bu şart gerçekleşmiş olur[623]. 965

Bir ölüme bağlı tasarruf olan koruyucu mirasçılıktan çıkarmanın da vasiyetname ile yapılması gerekir. Ancak, bağlayıcı içeriğine girmeyecek şekilde miras sözleşmesi ile de yapılması mümkündür. Yapılan mirasçılıktan çıkarmanın sonunda, mirasçılıktan çıkarılan, saklı payının yarısı ile yetinirken, diğer yarısı onun altsoyuna geçer. 966

Koruyucu mirasçılıktan çıkarmanın ne zaman geçersiz olacağı MK 513/II'de özel olarak düzenlenmiştir. Buna göre miras açıldığı zaman a) aciz belgesinin hükmü kalmamışsa, b) aciz vesikasında gösterilen borç miktarı miras payının yarısını aşmıyorsa, mirasçılıktan çıkarma hükümsüz olur. Ancak bunun için iptal davasının açılması gerekir. Bunun sonucunda, mirasçılıktan çıkarılan miras payının tamamını alır. Ancak mirasbırakan, onun miras payının kendi tasarruf nisabına giren bölümü üzerinde tasarrufta bulunmuşsa, o zaman saklı payının tamamı ile yetinmek zorundadır. Belirtmeye gerek yoktur ki, mirasçılıktan çıkarmayı içeren vasiyetnamede MK 557'deki iptal sebeplerinden biri varsa, buna dayanılarak da çıkarma iptal ettirilebilir. 967

---

[620] *Escher*, Art. 480 N 3; *İmre/Erman*, 224; *Kocayusufpaşaoğlu*, 319; *Ayiter/Kılıçoğlu*, 181; *İnan/Ertaş*, 300; açık olmamakla beraber, *Tuor* Art. 480 N 7.

[621] Bkz., dn. 622'e anılan yazarlar.

[622] *Kocayusufpaşaoğlu*, 319; *Oğuzman*, 217.

[623] *Tuor*, Art. 480 N 13; *Escher*, Art. 480 N 8; *Piotet*, 433; *Kocayusufpaşaoğlu*, 319.

§ 17. Ölüme Bağlı Tasarrufların Yorumu

I. GENEL OLARAK

968 Ölüme bağlı tasarrufun yorumu, mirasbırakanın açık olmayan iradesinin ne anlama geldiğini bulmaktır. Buna *açıklayıcı yorum* denir.

969 Mirasbırakanın ölüme bağlı tasarrufta açığa vurduğu iradesinin tam olarak anlaşılmasına hizmet eden bu *açıklayıcı yorum* yanında, bir de *tamamlayıcı yorum* söz konusu olabilir. Bu yorum türünü, mirasbırakanın, esasında ölüme bağlı tasarrufa yansımamış olan iradesini araştırıp bularak, ölüme bağlı tasarrufu onun *gerçek (aslında farazi)* iradesine uygun olarak uygulamak gerektiğini söyleyenler savunmaktadırlar. Açıklayacak olursak; mirasbırakan vasiyetnamesini düzenlerken, o anda var olan durumları esas alır. Ne var ki, tasarrufu yaparken göz önünde bulundurduğu durumlar, vasiyetname açıldığı zaman, olağanüstü değişikliklere uğramış ve bu sebeple de mirasbırakanın vasiyetnamesini yaparken izlediği amacın gerçekleşmesi imkânsız hâle gelmiş olabilir. Örneğin hısım olarak büyükbabasının babasından başka hiç kimsesi olmayan mirasbırakan, eski MK 442'nin yürürlükten kaldırılmasından önce, örneğin 1985 tarihinde, *"büyükbabamın babasının intifa hakkı saklı kalmak şartıyla Kızılay'ı terekemin tümü için mirasçı atıyorum"* demiş ve 2003 yılında ölmüş olsa ne olacaktır? Çünkü mirasbırakan bu vasiyetnameyi yaparken, büyükana ve büyükbabaların ana ve babaları yasal mirasçı idi ve bu sebeple de yapılan tasarrufun bir anlamı vardı. Oysa, ölüm ânında bu kişiler yeni Medenî Kanuna göre mirasçı değildirler. Bu durumda zaman içindeki değişiklik vasiyetnameyi nasıl etkileyecektir? Ya da mirasbırakan kızını mirasından uzaklaştırmış, fakat mirastan hiç bir şey almamasına gönlü razı olmadığı için, onun lehine yüklüce bir vasiyet öngörmüş ve ölümünden sonra kızı, mirasçılıktan çıkarmayı iptal ettirmişse ne olacaktır? Çünkü mirasbırakan mirastan çıkarmanın geçerli olacağından hareket ederek vasiyeti yapmıştır. Onun bu düşüncesi ölümden sonra gerçekleşmemesine rağmen kızı, miras payı ya da saklı payı ile birlikte vasiyeti de alacaklı sıfatıyla isteyebilecek midir? Böyle bir durum, mirasbırakanın vasiyeti yapmasındaki amacına uygun düşer mi? Bu ve buna benzer durumlarda nasıl hareket edileceğine ilişkin görüşler birbirinden farklıdır. Alman Hukukuna hâkim, fakat İsviçre Hukukunda azınlıkta olan görüş, bu hâllerde mirasbırakanın farazi iradesini araştırıp, ölüme bağlı tasarrufun buna uygun tamamlanmasıdır[624]. Buna göre araştırılacak şey şudur: mirasbırakan eğer gerek maddî gerek kişisel ilişkilerde sonradan meydana gelebilecek değişiklikleri tahmin edebilseydi ne gibi bir düzenlemede bulunur, nasıl bir tedbir alırdı? İşte bu tespit edilebilirse ölüme bağlı tasarruf ona göre tamamlanır.

970 Doğrusu bu görüşe hiç bir sınırlama getirmeden katılmak mümkün değildir. Önce, bu yol açılacak olursa, mirasbırakanın lehine tasarrufta bulunmayı hiç düşünmediği bir kimse lehine bile sonuç elde etmek mümkün olacaktır. Böylece mirasbırakanın iradesine uygun yorum yapmak yerine, tam aksine, onu hiç istemediği bir ölüme bağlı tasarrufu yapmış saymak yolu açılmış olur. Örneğin, mirasbırakanın Darüşşafaka yazacak yerdi Darülaceze yazdığı[625] ve bunu dalgınlıktan kaynaklandığı, onun gerçek iradesinin Darüşşafaka olduğu nasıl ileri sürülüp ispat edilebilir?

---

[624] Alman Hukuku için bkz., *Kocayusufpaşaoğlu*, 326, dn. 15'de anılan yazarlar. İsviçre Hukukunda bu görüşe taraftar olan yazarlar için bkz., *Druey*, § 12 N 12 vd.; *Serozan*, Yorum, 425 vd.

[625] *Serozan*, Yorum, 432.

Bunun yanında, bir çok hâlde mirasbırakanın farazî iradesini tespit etmek mümkün de olmaz, hatta tam aksi yönde tespit edilmesi de mümkündür. Mirasbırakanın, büyükbasının babasının intifa hakkını saklı tuttuğu örnekte, eğer onun ileride yasal mirasçı olmayacağını bilseydi nasıl bir düzenleme getirirdi sorusuna iki farklı cevap verilebilir. Denilebir ki, mirasbırakan onun yasal mirasçı olmayacağını bilseydi, intifa hakkını saklı tutmazdı. Ya da tam aksine, ona muhakkak intifa hakkını vermek istediği için, mirasçı olmayacağını bilseydi bile yine bu hakkı tanırdı. Birinci yorum söz konusu kişinin aleyhine, ikincisi ise lehinedir ve hiç kimse bunlardan birinin mirasbırakanın farazi iradesi olmayacağını iddia edemez. Aynı durum mirasçılıktan çıkarma örneği için de söz konusudur. Acaba, mirasbırakanın farazi iradesi, mirasçılıktan çıkarmanın iptal edileceğini bilseydi, yine kızı lehine tasarrufta bulunacağı yönünde mi olurdu yoksa tasarrufu yapmaz mıydı? İki şekilde düşünmek mümkün... Eğer ikinci sonuca varılırsa, o zaman da bunun af sayılıp sayılmayacağına ilişkin mirasbırakanın farazî iradesi aranacak; eğer af olarak yorumlanırsa, o zaman da, mirasbırakanın farazî iradesinin taksim kuralı mı koymak yoksa ön vasiyet mi yapmak olduğu araştırılacaktır. 971

Kuşkusuz bu görüş, ileride etraflıca açıklanacak olan, *favor testamenti* kuralının geniş olarak uygulanmasını ifade eder. Ne var ki, favor testamenti kuralını bu şekilde fütursuz uygulamak, kuralın amacını açan sonuçlara varılmasına yol açar. Kaldı ki, bir çok hâlde sorunun, farazî iradeye başvuracak yerde, aşağıda açıklanacağı gibi, MK 504 aracılığıyla açık hataya dayanılarak ya da , yine aşağıda açıklanacağı gibi, karineler yoluyla da çözülmesi mümkündür. 972

Yukarıdaki açıklamalardan, tamamlayıcı yorumun hiç kabul edilemeyeceği sonucu çıkartılmasın. İtiraz, sınırsız bir şekilde açığa vurulmamış olan farazî iradeye göre ölüme bağlı tasarrufu yorumlayıp, mirasbırakanın dahi istemediği sonuçlara farazi olarak varılmasıdır, yoksa tümüyle red değil[626]... Çünkü ölüme bağlı tasarrufun, mirasbırakanın öngöremeyeceği şekilde değişmesine rağmen onun yapıldığı âna göre uygulamak da, mirasbırakanın iradesine aykırı davranış olabilir. Bu bakımdan tamamlayıcı yorumu, sınırlı, belirli şartlara bağlı olarak kabul eden yazarların görüşüne katılmak yerinde olur[627]. Buna göre, ancak ölüme bağlı tasarrufta, değişen durumlara nasıl uydurulabileceğine ilişkin tutamak noktası bulunabilirse, yâni mirasbırakanın iradesinin ne yönde olabileceği saptanabiliyorsa, tamamlayıcı yoruma gidilmelidir. Bunun ise, son tahlilde bizi açıklayıcı yoruma götüreceğini de belirtmek gerekir[628]. 973

II. VASİYETNAMELERİN YORUMU

a) Genel olarak

Vasiyetnamelerin yorumunda uygulanacak olan kural *irade prensibidir*. 974

---

[626] Tümüyle tamamlayıcı yorumu reddedenlere örnek olarak bkz., *Escher*, Einletung zum 18. Titel, N 13 vd.; *Tuor*, Dritter Abschnitt Vorbem 1 vd.; *Piotet*, 268 vd; *Oğuzman*, 171; *İmre/Erman*, 99; BGE 49 II 12; 94 II 98.

[627] Bkz., *Druey*, § 12, N 16'da anılan yazarlar. Ancak, *Druey*'in kendisi, mutlak ve sınırsız uygulama taraftarıdır (§ 13 N 12). Aynı şekilde Serozan da mutlak sınırsız uygulama taraftarıdır (Yorum, 425 vd.). Bunun dışında bkz., *Kocayusufpaşaoğlu*, 327; BGE 75 II 286; 76 II 14.

[628] Federal Mahkemenin uygulamasının da bu yönde olduğunu söylemek mümkündür. Bkz., BGE 56 II 254, 89 II 437, özellikle de BGE 100 II 98.

Daha açık bir deyişle, vasiyetnameler bir taraflı, varması gerekli olmayan irade beyanı ile yapılan ölüme bağlı tasarruflar oldukları için, korunması gereken bir beyan muhatabı yoktur. Bu sebeple yorumla bulunması gereken, vasiyetçinin açık olmayan iradesinin ne anlama geldiğidir, yoksa muhatap olmadığı için, onun açısından beyanın ne anlama geldiği araştırılmaz[629]. Fakat, vasiyetnamenin yorumunda irade beyanının hiç rolü olmadığı söylenemez. Çünkü yoruma, vasiyetçinin bir vasiyetnamede açıklanmış (beyan edilmiş) bir iradesinin bulunması hâlinde başvurulur. Daha açık bir deyişle, yorum için, vasiyetçinin şekle uygun bir irade açıklamasının varlığı şarttır[630]. Bu irade beyanı yoksa ya da yapılmış olan beyan şekle uygun değilse, yorum yoluyla bunları vasiyetnameye dahil edemeyiz[631]. Ancak, yorum için şekle uygun irade beyanın varlığı şartından, mirasbırakanın her irade beyanının yorumlanacağı sonucu çıkartılmamalıdır. Yorumun amacı, gerçek iradeyi tespit etmek olduğuna göre, anlamı açık ve vasiyetçinin iradesine uygun beyanlara yorum yoluyla farklı anlamlar verilemez[632]. Bu bakımdan, vasiyetçinin, sadece, muğlak eksik ya da gizli beyanları yoruma tabi olur.

975 Yoruma başvurabilmek için, vasiyetçinin iradesinin vasiyetnamede somutlanması şartsa da, bunun yorumlanması için başvurulacak olayların da vasiyetnameden anlaşılması zorunlu değildir. Yorum için vasiyetname dışı olgulara da başvurulabilir. Örneğin, vasiyetçinin mektupları, ilişkileri, öğrenimi, alışkanlıkları ya da tanık beyanları[633], yoruma esas alınabilir[634].

976 Şimdi, yukarıda belirtilenleri örneklerle açıklayacak olursak[635]; vasiyetçinin Ahmet ve Mehmet adlı iki yeğeni olsa ve vasiyetnamesinde, *"Yeğenim Ahmet'i bütün terekem için mirasçı atıyorum"* demiş olsa, Mehmet vasiyetçinin, kendisini terekenin tümü için mirasçı atamak istediğini ileri sürse bu iddia dinlenmez. Çünkü vasiyetnamede bunu gösteren bir dayanak yoktur. Buna karşılık, vasiyetçinin Ahmet adlı iki yeğeni olsa ve vasiyetnamesinde, *"Yeğenim Ahmet'i terekemin tamamı için mirasçı atıyorum"*

---

[629] *Picenoni*, 92; *Escher*, 14. Titel Einleitung N 14; *Tuor*, Art. 481 Vorbem.15 (yazar, miras sözleşmesi ile vasiyetname arasında bir ayırım yapmamaktadır); *Piotet*, 207; *Kocayusufpaşaoğlu*, 321; *Oğuzman*, 171; *Köprülü*, 23; *İmre/Erman*, 100.

[630] Genel olarak kabul edilen bu fikre, mutlak tamamlayıcı yorum taraftarları karşı çıkarlar. Örnek olarak bkz., *Druey*, § 12 N 12; *Serozan*, Yorum, 425.

[631] BGE 69 II 46; 83 II 345; *Fahrländer*, 32; *Kocayusufpaşaoğlu*, 323.

[632] BGE 83 II 345.

[633] *İmre/Erman* (100) ve HGK 7.12.1966, 738/ 309 (*Yazıcı/Atasoy*, 835) tanık beyanlarına başvurulamayacağı görüşündedirler.

[634] *Tuor*, Art. 481 Vorbem. 12,14; *Tuor/Schnyder*, 350; *Escher*, Art. 467-469, Vorbem 13, 14; *Druey*, § 12, N 7 vd; *Kocayusufpaşaoğlu*, 322; *İmre/Erman*, 100; *Oğuzman*, 171; BGE 73 II 211,79 II 36,86 II 463, 88 II 67, 91 II 269, 100 II 98, 89 II 437.

[635] Örnekler için bkz., *Kocayusufpaşaoğlu*, 322/323.

demiş olsa, vasiyetçinin hangi Ahmet'i kastettiğine ilişkin yorum yapılır. Çünkü ortada, vasiyetçinin şekle uygun fakat açık olmayan bir iradesi vardır. Onun gerçek iradesini bulmak için artık vasiyetname dışı olgulara (örneğin bir ile kavgalı, diğerindense büyük bir iyilik gördüğü gibi) başvurulabilir.

b) Vasiyetnamelere ilişkin özel yorum kuralları

Medenî Kanunda vasiyetnamelerin yorumuna ilişkin pek fazla hüküm yoktur. Var olanların arasında en önemlileri şunlardır: 977

> Belirtmek gerekir ki, vasiyetnameler yönünden öngörülmüş olan bu kurallar, güven prensibine uygun oldukları ölçüde miras sözleşmelerinin yorumuna da uygulanırlar[636]. 978

aa) Favor testamenti (vasiyetname lehine yorum)

Favor testamenti kuralı, Medenî Kanunda doğrudan düzenlenmiş değildir. Buna karşılık BGB § 2084 bu kuralı, *"Bir ölüme bağlı tasarrufun içeriğinin farklı şekillerde yorumlanması mümkünse, tasarrufun sonuç doğurmasına imkân veren yoruma öncelik tanınır"* şeklinde belirtmiştir. Bu hükümden hareket edince, favor testamentinin, yapılmış olan ölüme bağlı tasarrufun mümkün olduğu kadar geçerliğini temin etmeye yönelik bir yorum kuralı olduğu kendiliğinden anlaşılır. Çünkü, bu kural sayesinde bir ölüme bağlı tasarrufun ya da bir hükmünün hem geçerli hem de geçersiz sayılacak şekilde yorumlanması mümkünse, onu geçerli yapacak yoruma üstünlük tanınır ve böylece mirasbırakanın son arzularına mümkün olduğu kadar saygı gösterilmiş olur[637]. Zaten Roma Hukukunda beri gelen bu yorum kuralının amacı da budur. 979

Hemen belirtmek gerekir ki, bu yorum, yukarıda sık sık değinildiği gibi, ancak bir ölüme bağlı tasarufta, eksik olsa bile, bir irade beyanının bulunduğu hâllerde yapılabilir. Çünkü, favor testamentinin amacı, şekil kurallarına uygun olarak yapılmamış olan bir beyanı vasiyetnameye dahil etmek değil; şekle uygun yapılmış, eksik ya da açık olmayan bir irade beyanını düzeltmek ya da hatalı bir tasarrufu ortadan kaldırmaktadır[638]. buna karşılık yorum yapılırken, vasiyetname içi olgular yanında, vasiyetname dışı olgulara da başvurulabileceğini bir defa daha hatırlatalım[639]. 980

---

[636] *Picenoni*, 92; *Kocayusufpaşaoğlu*, 327; *Oğuzman*, 172.

[637] Bu konuda bkz., *Şener*, Vasiyet, 346'da anılan kararlar ve HGK 21.11.1990, 346/586 (YKD 1991, c. XVII, 661.

[638] BGE 50 II 446; 83 II 435 (bu kararın çevirisi için bkz., *Ataay/Kocayusufpaşaoğlu/Sungurbey/Kaneti*, c.3, No 90); *Fahrländer*, 82; *Picenoni*, 59; HGK 21.11.1990, 346/586 (YKD 1991, c. XVII, 661).

[639] Bkz., dn. 639'da anılan kararlar.

981 Medenî Kanunun, BGB'den farklı olarak favor testamentiye yönelik bir genel kural içermediğinden yukarıda söz edilmişti. Ancak yazarların çoğunluğu, münferit bazı hükümlerde bu kuralın öngörülmüş olduğu görüşündedirler[640]. Örneğin, MK 504/II'ye göre, *"Ölüme bağlı tasarrufta kişinin ve şeyin belirtilmesinde açık yanılma hâlinde mirasbırakanın gerçek arzusu kesin olarak tespit edilebilirse, tasarruf bu arzuya göre düzeltilir"*. Bu hükme göre, vasiyetçi, iradede değil de beyanda hata yapmışsa, yani doğru olan iradesini dışa yanlış aksettirmişse ve gerçek iradesinin ne olduğu açık olarak anlaşılıyorsa, o zaman mirasçılar, MK 557 b.2'ye dayanarak vasiyetnameyi iptal ettiremezler, tasarruf vasiyetçinin gerçek iradesine göre yorumlanıp, favor testamenti kuralı gereğince, vasiyetçinin istediği sonucun doğması temin edilir. Örneğin, mirasbırakan, vasiyetnamesinde, *"Yeğenim Ahmet'e otomobilimi vasiyet ediyorum"* demiş olsa ve onun bir tek Mehmet adlı yeğeni varsa, tasarruf beyan hatası sebebiyle iptal edilmeyip, gerçek iradesine uygun yorumlanıp geçerli sayılır.

982 Ölüme bağlı tasarrufun tahvil (çevirme) yoluyla ayakta tutulması da favor testamenti kuralının bir sonucudur. Bunun dayanağı olarak, *"Tüzel kişiliği bulunmayan bir topluluğa belli bir amaç için yapılan kazandırmaları, o topluluk içindeki kişiler, mirasbırakan tarafından belirlenen amacı gerçekleştirmek kaydıyla birlikte edinmiş olurlar; amacın bu yolla gerçekleşmesine olanak yoksa, yapılan kazandırma vakıf kurma sayılır"* diyen MK 577/II'yi göstermektedirler[641].

983 Maddî anlamda ölüme bağlı tasarruflarda favor testamenti kuralının uygulanacağında kuşku olmamakla beraber, aynı kuralın şekil eksikliğinde de uygulanabilip uygulanamayacağı tartışmalıdır[642].

bb) Kanunî mirasın geçişi (intikali) kurallarına bağlılık

984 Bunun anlamı, mirasbırakanın bir ölüme bağlı tasarruf ile kanunî mirasçıları lehine yaptığı kazandırmaların, aksi anlaşılmadıkça, kanunî paylaşma kuralı olarak kabul edileceğidir. Yâni, kanunî paylaşma kuralları lehine, aksi ispat edilebilen bir karine vardır. Bu kuralın öngörüldüğü iki madde MK 560/ II ve 647/III'dür. MK 560/II'ye göre, *"Yasal mirasçıların paylarına ilişkin olarak tasarrufta yer alan kurallar, mirasbırakanın arzu-*

---

[640] Örnek olarak bkz., *Tuor*, Dritter Abschnitt Vorbem. 16; *Escher*, Einleitung zum 14.Titel N 16; *Picenoni*, 59; *Fahrländer*, 82; *Druey*, § 12, N 22-23; *Piotet*, 211 vd.; *Kocayusufpaşaoğlu*, § 27, II, 2,a; *Oğuzman*, 172.

[641] *Oğuzman*, 173; *Serozan*, 172.

[642] Tartışmalar için bkz., *Escher*, Art. 467-469, Vorbem. 21; Art. 469 Einleitung N 16; *Tuor*, Art. 481 Vorbem. 16; *Druey*, § 12 N 22; *Oğuzman*, 172; *Kocayusufpaşaoğlu*, § 27, II, 2, a; BGE 101 II 31 vd.

sunun başka türlü olduğu tasarruftan anlaşılmadıkça, sadece paylaştırma kuralları sayılır". Örneğin M, oğlu A'yı mirasçılıktan çıkardığı vasiyetnamesinde, onun payının eşi E ile diğer oğlu B arasında paylaşılmasını istemiştir. Şimdi, bu paylaşmanın nasıl yapılacağı iki şekilde yorumlanabilir. Denilebilir ki, M, mirasçılıktan çıkardığı oğlu A'nın payının, E ile B arasında eşit olarak paylaşılmasını, yâni her birinin payın 1/2'sini almasını istemiştir. Ya da, yine denilebilir ki, M, E ve B'nin bu payı kendi yasal miras payı oranlarına uygun olarak paylaşmalarını istemiştir. İşte MK 560/II paylaşma kuralı lehine bir karine koymuş olduğu için, paylaşma miras payları oranında yapılır. Böylece E, A'nın payının 1/4'ünü, B ise 3/4'ünü alır. Ancak, vasiyetnamenin yorumundan, M'nin iradesinin aksi (E ve B'nin eşit paylaşması) yönde olduğu anlaşılırsa, o zaman buna uyulur ve MK 560/II uygulanmaz.

MK 647/III ise, bir ölüme bağlı tasarruf ile, terekede bulunan bir malın, 985
mirasçılardan birine tahsisi öngörülmüşse, bunun paylaşma kuralı sayılacağını öngörür, meğer ki mirasbırakanın iradesi, bunun paylaşma kuralı değil de bir vasiyet olarak yapıldığı şeklinde yorumlansın. Örneğin M, vasiyetnamesinde otomobilini oğul A'ya tahsis etmişse, MK 647/III'e göre bunun anlamı, A'nın otomobili miras payına mahsup etmesidir. Ancak, M'nin bunu A'ya vasiyet ettiği yorum yoluyla anlaşılırsa, A miras payından ayrı olarak otomobili de alır.

cc) Mirasçı ataması mı, vasiyet mi?

MK 516/II'ye göre, *"Bir kimsenin mirasın tamamı veya belirli bir ora-* 986
nını almasını içeren her tasarruf mirasçı atanması sayılır". Bu hüküm, mirasbırakanın yaptığı tasarrufun niteliğininin ne olduğunun, onun kullandığı terimlere göre değil de, gerçek iradesine göre tespit edileceğini ifade etmektedir. Özellikle yapılan tasarrufun belirli bir mal bırakma vasiyeti mi yoksa mirasçı atama mı olduğunun tespitinde bu hükme başvurulur. Örneğin, mirasbırakan, A'ya terekesinin 1/4'ünü *vasiyet ettiğini* belirtmesine rağmen, bu tasarruf mirasçı atama olarak kabul edilir. Çünkü MK 516/II'ye göre, terekenin kesirli bir bölümünün tahsisi, mirasçı atamadır. Bunun aksine, mirasbırakan, bir halısı için A'yı *mirasçı atadığını* belirtmişse, bu tasarruf niteliği gereği vasiyet olarak yorumlanır. Çünkü, tasarrufun konusu, terekenin kesirli bir bölümü değil, terekedeki belirli bir mal, yani halıdır. Buna karşılık, bir çiftliği ve bankada 20 bin liradan başka bir şeyi olmayan bir kimse, çiftliğini arkadaşı A'ya vasiyet ettiğini belirtirse, bu tasarruf bir mirasçı atanması olarak kabul edilir. Çünkü, yapılan tasarruf, hemen hemen terekenin tamamına tekabül etmektedir ki, bu da MK 516/II'ye göre, mirasçı atanmasından başka bir şey değildir.

III. MİRAS SÖZLEŞMESİNİN YORUMU

987 Yukarıda[643], vasiyetnamelerin yorumunun irade prensibine göre yapılacağı, bunun sebebinin de, vasiyetnamelerin bir taraflı irade beyanı ile oluşan, bir hukukî işlem olduğu, yani iradenin bir muhatabının olmadığı şeklinde açıklanmıştı. Oysa miras sözleşmeleri iki taraflı hukukî işlemlerdir. Dolayısıyla da iradenin yöneldiği bir kişi vardır. Böyle olunca da, artık miras sözleşmelerinde yorumun, irade prensibine göre değil de MK 2'den kaynaklanan güven prensibine göre yapılması gerekir[644]. Buna göre, yorum yapılırken, tarafların iradesinin ne olduğu değil de, *karşı tarafın içinde bulunulan hâl ve şartlara göre yapılan beyana ne anlam vermesi gerektiği araştırılır*. Bu bakımdan, vasyetnamenin yorumlanmasına ilişkin kurallar, ancak güvene göre yorumu ihlal etmedikleri ölçüde miras sözleşmesinin yorumuna da uygulanırlar[645].

988 Belirtmek gerekir ki, miras sözleşmesinin, bağlayıcı olmayan, yâni vasiyetname niteliğinde bulunan hükümlerine güven prensibi uygulanmaz. Onlar, bir taraflı tasarruf oldukları için, yine irade prensibine göre yorumlanırlar[646].

§ 18. Ölüme Bağlı Tasarruflarda Hükümsüzlük

I. GENEL OLARAK

989 Medenî Kanunun, Miras Hukuku hükümleri incelendiği zaman, ölüme bağlı tasarrufların iki tür hükümsüzlüğe tabi oldukları görülür: *iptal ve kanun gereği (kendiliğinden) hükümsüzlük*. Bu bölümde bunlar üzerinde durulacaktır.

990 Sadece kanun gereği hükümsüzlük ve iptalin öngörülmüş olması, ölüme bağlı tasarrufların- nadir de olsa-, yokluk ya da mutlak butlan ile de sakat olamayacakları anlamına gelmez. Bir ölüme bağlı tasarruf, eğer kurucu unsurları yoksa, bütün hukukî işlemler gibi, yoklukla sakat olur. Örneğin, mirasbırakanın haberi olmaksızın üçüncü kişinin sanki onunmuş gibi düzenlediği bir vasiyetname ya da vasiyetname olduğu iddia edilen belge, esasında mirasbırakan tarafından yapılmış bir vasiyetname projesi ise, bunlar yoklukla sakattır. Mirasbırakan yapmış olduğu vasiyetnamesinde, vasiyet alacaklısı ya da atanmış mirasçının belirlenmesini objektif sınır koymadan üçüncü kişiye bırakmışsa, bu vasiyetname mutlak butlanla sakattır. Aynı şekilde, muvazaa, zihni kayıt ya da latife beyanıyla yapılan vasiyetname de mutlak butlan sonucunu doğurur[647].

---

[643] Bkz., II

[644] *Picenoni*, 92; *Piotet*, 207; *Kocayusufpaşaoğlu*, § 27, III; *Oğuzman*, 171; *İnan/Ertaş*, § 21, II; *Serozan*, 151.

[645] *Kocayusufpaşaoğlu*, § 27, III; *Oğuzman*, 171; *İnan/Ertaş*, § 21, I.

[646] *Kocayusufpaşaoğlu*, § 27, III; *Serozan*,151.

[647] Bu konuda etraflı bilgi için bkz., *Kocayusufpaşaoğlu*, § 28, III.

Gerek iptal gerek kanun gereği sona erme tam ya da kısmî olabilir. Eğer 991
iptal sebebi (örneğin şekil eksikliğinde olduğu gibi), ölüme bağlı tasarrufun tamamını etkiliyorsa, iptal tam olur. Buna karşılık, vasiyetnamedeki tasarruflardan sadece biri ahlâka aykırıysa, sadece o hükümsüz olur, geri kalanlar geçerliklerini korurlar. Ancak iptal edilen tasarruf ile diğer tasarruflar arasında sıkı bir iç bağ varsa, o zaman BK 20/II'nin örneksemeyle uygulanması sonucu, ölüme bağlı tasarrufun tümü hükümsüz sayılır. Aynı şekilde, boşanma hâlinde, eşlerden birinin yaptığı vasiyetname, diğer eş lehine olanların yanında başka tasarruflar da içeriyorsa MK 181/I gereği sadece diğer eş lehine yapılan tasarruflar kanun gereği hükümsüz hâle gelir; geri kalanlar geçerliklerini korurlar.

II. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN KANUN GEREĞİ (KENDİLİĞİNDEN) HÜKÜMSÜZ OLMASI

Aşağıda belirtilen hâllerde, geçerli olan bir ölüme bağlı tasarruf, kanun 992
gereği ortadan kalkmaktadır.

1. Evlilik birliğinin ölüm (ve gaiplik) dışında sona ermesi

MK 181/I'e göre, boşanmanın kesinleşmesiyle beraber, eşlerin birbirle- 993
ri lehine yapmış oldukları ölüme bağlı tasarruflar, geri alınmalarına gerek olmadan kanun gereği hükümsüz hâle gelirler, meğer ki ölüme bağlı tasarrufta aksi belirtilmiş olsun. Aynı kural evlenmenin mutlak ya da nisbî butlan ile sona ermesinde de uygulanır (MK 159)[648]. Aynı şekilde, boşanma davası devam ederken, davacının ölmesi ve mirasçıların davaya devam edip, davalının boşanmada daha kusurlu olduğunu ispat ederlerse de eşlerin birbirleri lehine yaptıkları ölüme bağlı tasarrufların kendiliğinden hükümsüz olacağından yukarıda söz edilmişti[649].

2. Lehine ölüme bağlı tasarruf yapılan kimsenin mirasbırakandan önce ölmesi

Bu hâlde, ölen kimse lehine yapılmış olan tasarruf (yedek mirasçı ya da 994
artmirasçı ataması yoksa) kendiliğinden sona erer (548/I, 580/II, 581/II).

3. Lehine ölüme bağlı tasarruf yapılan kimsenin mirastan yoksun olması

MK 578'de yazılı olan sebeplerden birinin gerçekleşmesi hâlinde, fiili 995
gerçekleştiren kimse, mirastan yoksun olacağı için, lehine yapılmış olan ta-

[648] Bkz., yukarıda § 5, III, 2.
[649] Bkz., yukarıda § 5, III, 1.

sarruflar da kendiliğinden hükümsüz olur. Ancak, mirasbırakan söz konusu kişiyi affetmişse (MK 578/II), ölüme bağlı tasarruf yine hüküm ifade eder.

4. Bozucu şartın gerçekleşmesi ya da geciktirici şartın gerçekleşmemesi

996 Her iki halde de şart gerçekleşince ya da gerçekleşmeyince, ölüme bağlı tasarruf kendiliğinden hükümsüz olur.

III. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN İPTALİ (MK 557 vd.)

A. İptal sebepleri

1. Ehliyetsizlik (MK 557 b.1).

997 MK 557 b.1'e göre gerek vasiyetnamelerde gerek miras sözleşmelerinde, ölüme bağlı tasarrufu yapan kimse, tasarruf ânında, ölüme bağlı tasarruf yapma ehliyetine sahip değilse (MK 502, 503), tasarruf iptal edilebilir.

2. İrade sakatlıkları (MK 557 b.2)

a) Hata (yanılma)

998 Hata hâlinin (diğer irade sakatlıkları gibi), vasiyetnameler ve miras sözleşmeleri yönünden ayrı ayrı incelenmesi gerekir.

999 Vasiyetnamelerde, sağlar arası tasarruflardan farklı olarak, yapılan tasarrufla arada illiyet bağının bulunması şartıyla, her türlü hatanın iptal sebebi olacağı, gerek doktrin gerek uygulamada tereddütsüz kabul edilmektedir. Bu bakımdan *adi saik hatası dahi vasiyetnamenin iptali için yeterlidir*[650]. Başka bir ifadeyle, iradenin oluşmasındaki hata (yoksa beyan hatası değil), iptal için yeterlidir. Örneğin M, Avrupa'da bulunan yeğeni A'nın, iyi okumadığını sanarak (adi saik hatası), onu mirasından uzaklaştırırsa ve gerçek bu değilse, söz konusu ölüme bağlı tasarruf hata sebebiyle iptal edilebilir.

1000 Vasiyetnamelerde iptal için hatanın esaslı olması gerekmemesine iki gerekçe gösterilmektedir. a) MK 504 ve 557 b.1, BK 30'dan farklı olarak, *esaslı hatadan değil sadece hatadan* söz etmektedirler; b) vasiyetnameler, bir taraflı varması gerekli olmayan bir irade açıklaması ile yapılan, her zaman serbestçe geri alınabilen tasarruflar oldukları için, korunması gereken bir muhatap yoktur.

---

[650] 2.HD 24.10.1977, 6939/2770 (*Şener*, Vasiyet, 451).

Özellikle adi saik hatasının dahi, vasiyetnamenin iptaline imkân vermesinin sınırlandırılması amacıyla, Federal Mahkeme, vasiyetnamenin bu sebeple iptal edilebilmesi için, sadece saik hatası ile vasiyetnamenin yapılması arasında illiyet bağının bulunmasını yeterli görmemiş, vasiyetçinin gerçek durumu bilseydi, yaptığı tasarrufu o şekilde bırakacak yerde iptal edeceğinin de ispat edilmesini aramıştır[651]. Doktrin, illiyet bağı yanında ayrıca bir de böyle bir şart aranmasını eleştirmiştir[652]. 1001

Miras sözleşmelerinde ise hata sebebiyle iptalin ne şekilde yapılacağı tartışmalıdır. Bazı yazarlar, ölüme bağlı tasarrufta bulunan yönünden, kanunun, vasiyetname ile miras sözleşmesi arasında bir fark yaratmadığı gerekçesiyle, vasiyetnamedeki kuralın aynen uygulanacağı görüşündedirler. Yâni miras sözleşmesini, ölüme bağlı tasarrufta bulunanın iptal edebilmesi için adi saik hatası yeterli görülmüştür. Buna karşılık, miras sözleşmesiyle ölüme bağlı tasarrufta bulunmayan karşı taraf, genel hükümlere tâbi olduğu için, BK 30 vd.'ye göre, ancak esaslı hataya dayanarak iptale gidebilir. Böyle olunca da karşı taraf, saik hatası BK 30 anlamında temel hatası hâlini almışsa saik hatasına dayanarak miras sözleşmesini iptal ettirebilecektir[653]. 1002

Doğru olan görüş, yukarıda açıklanan fikre şiddetle karşı çıkmakta, MK 504 ve 557 b.1'in, ölüme bağlı tasarruf terimini kullanmasının, zorunlu olarak her iki tür tasarrufun da aynı hükümlere tabi tutulmasını gerektirmeyeceğini savunmaktadır[654]. Bu hükümlerin, ölüme bağlı tasarrufların bünyelerine uygun olarak yorumlanması gerekir. Nitekim bu sebepledir ki, vasiyetnamelerde, korunması gereken bir muhatap bulunmadığı için adi saik hatası bile bir iptal sebebi olarak kabul edilmiştir. Oysa, miras sözleşmesi iki taraflı bir hukukî işlem olduğundan, korunması gereken bir muhatap vardır. Bu sebeple, mirasbırakan miras sözleşmesinden serbestçe geri dönmez, beyanı bağlayıcıdır. Bunun sonucundaysa, karşı tarafın beyana güveninin korunması gerekir. Mirasbırakanın, adi saik hatasına dahi dayanarak, miras sözleşmesini iptal etmesi, güven prensibi ile bağdaşmaz. Kaldı ki, mirasbırakana, adi saik hatasi ile iptal edebilme, buna karşılık sözleşmenin diğer tarafının ise, ancak esaslı hata sebebiyle iptal hakkının olması, taraflar arasında eşitsizlik yaratır ki, bunu haklı gösterecek bir sebep yoktur. Bu yüzden, miras sözleşmelerinde, hata sebebiyle iptal için her iki taraf yönünden de hatanın BK 24 anlamında esaslı olması gerekir. 1003

---

[651] BGE 75 II 84; 94 II 139.

[652] *Raschein*, 25; *Escher*, Art. 469 N 7; *Merz*, ZBJV 1970 (107), 48/49; *Kocayusufpaşaoğlu*, § 28 II,1,aa,aaa; ayrıca, *Picenoni*, 62.

[653] *Tuor*, Art. 469 N 2; *Escher*, Art. 469 N 2,6; *İmre/Erman*, § 22,II, 2,a; *Eren*, İptal, 38.

[654] *Picenoni*, 96; *Raschein*,18 vd; *Merz*, ZBJV 1970 (106) 48; *Piotet*, 220; *Kocayusufpaşaoğlu*, 330; *Oğuzman*, 102; *İnan/Ertaş*, § 23,A, 2, aa; *Dural*, Miras Sözleşmeleri, 274.

b) Hile (aldatma) (MK 557 b.2)

1004 Hata için miras sözleşmesi ile vasiyetname arasında yapılan ayırım hile için de söz konusudur.

1005 Vasiyetnamelerde BK 36 uygulanmaz. Bu, özellikle üçüncü kişinin hilesi yönünden söz konusudur. Şöyle ki, BK 28/I'e göre, hile üçüncü kişi tarafından yapılmışsa, ancak lehine hile yapılan bunu biliyorsa iptal sebebi olur. Oysa vasiyetnamelerde durum böyle değildir. Yani vasiyetnamelerde, lehine tasarrufta bulunulan kişi, üçüncü kişinin kendi lehine hile yaptığını bilmese bile, vasiyetname iptal edilir, yeter ki hile ile yapılan ölüme bağlı tasarruf arasında illiyet bağı bulunsun.

1006 Miras sözleşmelerinde ise, hile sebebiyle iptalde her iki taraf için BK 36 uygulanır. Böyle olunca da hem mirasbırakan hem de karşı tarafın miras sözleşmesini üçüncü kişinin hilesi sebebiyle iptal edebilmesi için, lehine hile yapılanın bunu bilmesi gerekir.

1007 Belirtmek gerekir ki, hata yönünden miras sözleşmelerinde, irade nazariyesini savunan görüş kabul edilecek olursa, miras sözleşmelerinde de üçüncü kişinin hilesi durumunda, lehine hile yapılan kişinin bunu bilmesine gerek yoktur. Çünkü bu hâlde lehine hile yapılan kimse bunu bilmese bile, üçüncü kişinin hilesi saik hatası oluşturur ve mirasbırakan da buna dayanarak miras sözleşmesini iptal edebilir.

c) Korkutma veya zorlama (tehdit yahut cebir) (MK 557 b. 2)

1008 MK 557 b.2, ikrahı, korkutma veya zorlama olarak ifade etmiştir. Zorlama, maddi korkutma (örneğin mirasbırakanın başına tabanca dayanması), korkutma ise, manevi korkutma (örneğin, mirasbırakanın, kimsenin bilmesini istemediği bir sırrının açıklanacağı tehtidi) anlamına gelir[655].

1009 Vasiyetnamede korkutma ya da zorlama ile vasiyetnamenin yapılması arasında illiyet bağının bulunması şartıyla, iptal için BK 29 ve 30'un uygulama şartlarının bulunması aranmaz. Buna karşılık miras sözleşmesinin korkutma ya da zorlama ile iptali için miras sözleşmesinin her iki tarafı yönünden de BK 37 ve 38'in şartlarının bulunması gerekir[656]. Bu sebeple üçüncü kişinin korkutması hâlinde, bunu lehine tehdit yapılan kimse bilmiyorsa, karşı taraf miras sözleşmesini iptal edince BK 37/II'ye uygun bir tazminat öder.

d) Mirasbırakanın hata ve hileyi sağlığında öğrenmesi ya da korkutma ya da zorlamanın etkisinden kurtulmasının özelliği

1010 MK 504/I'e göre, *"Mirasbırakanın yanılma, aldatma korkutma veya*

[655] *Oğuzman*, 103.
[656] Aksi görüş, *Oğuzman*, 103.

zorlama etkisi altında yaptığı ölüme bağlı tasarruf geçersizdir. Ancak, yanıldığı veya aldatıldığını öğrendiği ya da korkutma veya zorlamanın etkisinden kurtulduğu günden başlayarak bir yıl içinde tasarruftan dönmediği takdirde tasarruf geçerli sayılır" . Hükümden anlaşılacağı gibi, gerek vasiyetname gerek miras sözleşmesi olsun, mirasbırakan, sağlığında hata ya da hileyi öğrendiğinden ya da korkutma ya da zorlamanın etkisinden kurtulduktan sonra bir yıl içinde vasiyetnamesini geri almaz ya da miras sözleşmesinden dönmezse, bunlar geçerlik kazanırlar ve mirasçılar artık mirasbırakanın ölümünden sonra MK 557 b.2'ye dayanarak dava açamazlar. Bu bir yıllık süre hak düşürücü süredir. O hâlde, mirasçıların mirasbırakanın ölümünden sonra irade sakatlığına dayanarak iptal davası açabilmeleri için ya mirasbırakanın sağlığında hata ya da hileyi öğrenmemiş veya korkutma ve zorlamanın etkisinden kurtulmamış olması; ya da öğrenmiş veya etkiden kurtulmuş olmasına rağmen daha bir yıl dolmadan ölmüş olması gerekir.

Bir yıllık sürenin iptal hakkı kullanılmadan geçmiş olması, aslında miras sözleşmeleri yönünden önemlidir. Çünkü vasiyetnamelerde, vasiyetçi bu süreyi geçirmiş olsa bile, vasiyetnamesini ölünceye kadar her zaman geri alarak onu yürürlükten aldırabilir. Oysa miras sözleşmelerinde geri alma kural olarak mümkün olmadığı için, süre geçince miras sözleşmesi geçerlik kazanır ve dolayısıyla da artık yapacak bir şey kalmaz[657]. 1011

İrade sakatlığı sebebiyle vasiyetnamesini geri almak isteyen vasiyetçi, MK 542'deki yollardan birine başvuracaktır[658]. Miras sözleşmelerinin nasıl iptal edileceği ise tartışmalıdır. Bir fikre göre , mirasbırakan bir vasiyetname yaparak miras sözleşmesini ortadan kaldırmalıdır. İkinci fikre göre, mirasbırakan hem bir vasiyetname yapmalı hem de, BK 39'un örneksemeyle uygulanması sonucu iptal ettiğini karşı tarafa bildirmelidir. Diğer bir fikir ise, mirasbırakanın yenilik doğuran bir dava açarak miras sözleşmesine mahkeme kararı ile geçmişe etkili olarak son vermesidir. Son görüşe göre de, mirasbırakanın BK 39'a göre miras sözleşmesini iptal ettiğini karşı tarafa bildirmesi yeterlidir. 1012

3. Ölüme bağlı tasarrufun içeriğinin, ona eklenen koşul ya da yüklemenin hukuka ya da ahlâka aykırı olması (MK 557 b.3)

MK 557 b.3 anlamında ahlâka aykırılıktan söz edebilmek için, sadece ölüme bağlı tasarrufla güdülen saikin ahlâka aykırı olması yeterli değildir; ölüme bağlı kazandırmanın kendisinin ahlâka aykırı olması gerekir[659]. Ölüme bağlı kazandırmanın niteliğinin ahlâka aykırı olması açısından, mirasbırakanın bunu önceden görmüş ve tasvip etmiş olup olmamasının öne- 1013

[657] 2.HD 16.2.1980, 8932/9323 (YKD 1981, c. VII, 816).
[658] Bkz., yukarıda § 14,I.
[659] BGE 93 II 165; ayrıca bkz., BGE 85 II 378, 73 II 15.

mi yoktur. Bunun yanında Federal Mahkeme, ahlâka aykırılıktan söz edebilmek için ikinci bir şart daha aramaktadır ki o da, lehine ölüme bağlı tasarruf yapılan kimsenin, düzenlemenin yapıldığı zamanda, zamandan önce ya da sonra bu kazandırmayı ve onun esaslı şartlarını bilmesidir[660].

1014 Sağlar arası hukuki işlemlerde hukuka ve ahlâka aykırılığın kesin hükümsüzlük sonucu doğurmasına rağmen, MK 557 b.3'ün ölüme bağlı tasarruflarda iptali öngörmesi, son zamanlarda oldukça eleştiriye uğramaya başlamıştır[661]. Bu eleştirilerin temelinde özellikle, öngörülmüş olan iptal süresinin geçirilmesi hâlinde, ölüme bağlı tasarrufun ahlâka aykırı olmasına rağmen geçerlik kazanması ve ahlâka aykırılığın temelinde kamu düzenini ilgilendirmesi yatmaktadır. Bunun yanında, yine haklı olarak ileri sürüldüğü gibi, ahlâka (ve hukuka) aykırılığın müeyyidesini düzenleyen BK 27 genel hüküm niteliğindedir ve ölüme bağlı tasarruflarda bu genel hükümden ayrılmayı haklı gösterecek bir menfaat durumu da yoktur; hüküm bir yanlışlık sonucu kanuna girmiştir[662]. Bu sebeple BK 27'ye MK 557 b.3 karşısında üstünlük tanımak ve ahlâka (ve hukuka) aykırı ölüme bağlı tasarrufları da, tıpkı sağlar arası tasarruflar gibi, kesin hükümsüzlükle sakat saymak gerektiği savunulmaktadır. Bunun hukuki dayanağı ise, ahlâka aykırılık hâlinde MK 557 b. 3 ve MK 559'a dayanmanın MK 2 anlamında hakkın kötüye kullanılması, daha açık bir deyişle *normun kötüye kullanılmasıdır*[663].

4. Şekil noksanı (MK 557 b.4)

1015 Ölüme bağlı tasarruflarda şekil kurallarına uyulmaması, sağlar arası tasarruflardan farklı olarak kesin hükümsüzlük değil, iptal edilebilirlik sonucunu doğurur. Ancak, şekil noksanı sebebiyle iptale gitmeden önce, tahvilin (çevirme) mümkün olup olmadığının araştırılması gerekir.

1016 Şekle aykırılık, kural olarak, bütün ölüme bağlı tasarrufun iptal edilmesi sonucunu doğurur. Ancak MK 558/III bu kurala bir istina getirmiştir. Sadece resmî vasiyetnamelere uygulanan bu hükme göre, şekil eksikliği vasiyetnamenin yapılmasına resmî memur ya da tanık olarak katılan kimseler ya da eşleri veya hısımları lehine ölüme bağlı tasarruf yapmaktan ibaretse, o zaman sadece o tasarruflar iptal edilip, diğerleri geçerliklerini korurlar.

B. İptal davası

1. Genel olarak

1017 Yukarıda, III sayılan sebeplerden biri ile sakat olan ölüme bağlı tasarruf

---

[660] BGE 85 II 376, bu konuda etraflı bilgi için bkz., *Kocayusufpaşaoğlu*, § 28, II, 1,c.

[661] Bu konuda bkz., *Kocayusufpaşaoğlu*, § 28, II, 3 ve orada anılan yazarlar; ayrıca krş., *Piotet*, 90.

[662] Krş., *Escher*, Art. 519-521, Vorbem 2.

[663] BK 20'ye paralel olduğu söylenen MK 557 b 3'ün hukuka ve ahlâka aykırılık yanında BK 20'de olduğu gibi, *imkânsızlıktan* söz etmemesini *Oğuzman* (104) konusu imkânsız olan ölüme bağlı tasarrufların kesin hükümsüz olacağı ile açıklamaktadır.

kendiliğinden hükümsüz olmayıp, mirasbırakanın ölümü ile birlikte geçerli bir tasarrufmuş gibi hüküm doğurur. Onun hüküm doğurması istenmiyorsa, bozucu yenilik doğuran bir dava olan *iptal davasının* açılması (ya da belirli şartlar varsa, sakatlığın defî olarak ileri sürülmesi) gerekir.Bu açıdan durum, evlenmenin butlanına benzerse de aralarında üç fark vardır. Bunlardan birincisi, mahkemenin vermiş olduğu bozucu yenilik doğuran karar, evlenmede geçmişe etkili değilken; ölüme bağlı tasarrufun iptalinde karar, ölüm anına (mirasın açıldığı ana) kadar geçmişe etkilidir[664]. İkinci fark, kendisini mutlak butlan ile sakat evlenmeler ile ölüme bağlı tasarruflar arasında gösterir. Şöyle ki, evlenmenin mutlak butlanı davasının açılması hiç bir hak düşürücü süreye bağlanmamışken, ölüme bağlı tasarrufların iptaline ilişkin davanın MK 559'da öngörülmüş olan hak düşürücü süreler içinde açılması gerekir. Bu süreler geçirilirse artık iptal davası açılamaz ve ölüme bağlı tasarruf sakat olmaktan kurtulur ve dolayısıyla da ifası gerekir. Son fark, kararın etkisi açısındandır. Evlenmenin iptaline ilişkin karar herkes için hüküm ifade ederken; ölüme bağlı tasarrufun iptali, kural olarak, sadece taraflar arasında hüküm ifade eder. Daha açık bir deyişle, iptal davası kimin tarafından açılmışsa onun yönünden uygulanabilirliğini kaybeder, diğer kişiler yönünden geçerliğini korur. Örneğin, mirasbırakanın A ve B adlı iki oğlundan A, mirasbırakanın yapmış olduğu bir vasiyetnameyi iptal ettirirse, vasiyetnamenin içeriği onun yönünden hüküm ifade etmez; fakat dava açmamış olan B'den, vasiyetnamenin yerine getirilmesi istenebilir. Bu bakımdan, vasiyetnamenin hiç bir mirasçı yönünden hüküm ifade etmemesi isteniyorsa, bütün mirasçıların dava açması gerekir[665]. Aynı durum, davalı için de söz konusudur. İptal davası kime karşı açılmışsa, sadece ona karşı hükümsüz olur. Yargıtay, 7.12.1955 tarih ve 15/25 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararında[666], bu prensibi açık olarak belirtmiştir. Karara konu olayda, vasiyeti yerine getirme görevlisi atanmasının iptali için dava açılmış ve Yargıtay, verilen kararın sadece vasiyeti yerine getirme görevlisine karşı hüküm ifade edeceğini, diğer tasarrufların iptalden etkilenmeyeceği sonucuna varmıştır.

Yukarıdaki açıklamaların doğal bir sonucu, iptal davasının, ölüme bağlı 1018
tasarrufun tümüne yönelik olarak açılmasının gerekmediğidir (MK 558/II). Ölüme bağlı tasarruftaki hususlardan sadece biri ya da bir kaçında iptal sebebi varsa, dava sadece onlara karşı açılıp kısmi iptal istenebilir. Bu hâlde, iptali istenmeyen tasarruflar kural olarak geçerliklerini korurlar. Ancak, kısmi iptal davası açabilmek için, iptal sebebinin tüm ölüme bağlı tasarrufu

---

[664] Bu yönde, baskın görüşten ayrılan *Piotet* (§ 44, II), kararın işlemin yapıldığı ana kadar geçmişe etkili olduğunu savunur.

[665] *Kocayusufpaşaoğlu*, § 28, II, 2,a; *Oğuzman*, 190, n. 497 ve 195.

[666] RG, sayı 9230.

etkileyecek nitelikte olmaması gerekir. Örneğin sebep ehliyetsizlik ya da (MK 558/III'deki durum saklı kalmak şartıyla) şekil noksanı ise kısmi iptal söz konusu olamaz. Çünkü bu sebepler, ölüme bağlı tasarrufun tümüne etkilidirler.

1019 İptal sebebinin sadece bir ya da bir kaç tasarrufa ilişkin olduğu hâllerde, o tasarruf ile iptali istenmeyen tasarruflar arasında, mirasbırakanın söz konusu sakatlığı bilseydi diğer tasarrufları da yapmayacağı şekilde bir iç bağ varsa, o zaman BK 20/II'nin örneksemeyle uygulanması sonucu ölüme bağlı tasarrufun tamamı geçersiz olur[667].

1020 Her ne kadar iptal ölüme bağlı tasarrufu geçersiz hâle getirip, lehine tasarruf yapılan kimsenin hakkına son verirse de, eğer davalı kendisine bırakılan malın zilyetliğini iptalden önce ele geçirmişse, bunun geri alınmasını temin etmez. Böyle bir hâlde iptal davası ile birlikte ya da iptalden sonra ayrıca bir de miras sebebiyle istihkak davası açılması gerekir (MK 637)[668].

2. İptal davasının tarafları

a) Davacı

1021 MK 558/I'e göre, *"İptal davası, tasarrufun iptal edilmesinde menfaati bulunan mirasçı veya vasiyet alacaklısı tarafından açılabilir"* Bundan da anlaşılacağı üzere, iptal davasında davacı sıfatı, ölüme bağlı tasarrufun iptalinde menfaati olan mirasçı ya da vasiyet alacaklısına aittir. Örneğin, yeğeni A'dan başka mirasçısı olmayan M, Ü'yü terekesinin tamamı için mirasçı atarsa, A (örneğin hileyi dayanarak) vasiyetnameyi iptal ettirebilir. Ya da M, terekesinde bulunan bir malı B'ye vasiyet ettikten sonra, aynı malı yeni bir vasiyetname ile C'ye vasiyet ederse, B (örneğin şekil noksanına dayanarak) ikinci vasiyetnameyi iptal ettirebilir. Buna karşılık M'nin oğlu A hayattaysa, onun yapmış olduğu bir vasiyetnameyi M'nin babası B iptal ettiremez. Çünkü B'nin iptalde (vasiyetname iptal edilse bile bundan A'nın yararlanacağı düşünülecek olursa) bir menfaati yoktur.

1022 Vasiyeti yerine getirme görevlisinin iptal davası açma hakkı olmadığı genel olarak kabul edilmektedir[669]. Buna gerekçe olarak, önce, MK 558/I'in davacılar arasında vasiyeti yerine getirme görevlisini saymadığı gösterilmektedir. Diğer bir gerekçe olarak da, vasiyeti yerine getirme görevlisi yönünden, kimin mirasçı olacağının önemli olmadığı ve gerçek mirasçıların kim olduğunun tespitinin onun görevleri arasında yer almadığı ileri sürülmektedir[670].

---

[667] Bkz., *Kocayusufpaşaoğlu*, § 28,II,2,a.
[668] *Escher*, Art. 519 N 8; *Kocayusufpaşaoğlu*, § 28, II,2,a; *Oğuzman*, 196.
[669] Bkz., *Kocayusufpaşaoğlu*, § 28, II,2,a, aa ve orada dn.62'de anılan yazarlar.
[670] *Escher*, Art. 518 N 28; *Kocayusufpaşaoğlu*, § 28, II,2,a,aa.

b) Davalı

Davalı, iptali istenen ölüme bağlı tasarufla, davacı aleyhine bir miras 1023
hukuku menfaati elde eden kimsedir. Bu, atanan mirasçı, vasiyet alacaklısı bir yükümün lehdarı ya da kurulan bir vakfın yönetim organı vs. olabilir. Vasiyeti yerine getirme görevlisi kendi aleyhine açılan davalarda davalı olur[671].

3. Süre

MK 559, iptal davası için bir, on ve yirmi yıllık süreler öngörmüş, ayrı- 1024
ca ikinci fıkrasında iptal sebeplerinin daimi defî olarak ileri sürülmesi imkânını tanımıştır.

İptal davası bozucu yenilik doğuran bir hak olduğu için bu süreler hak 1025
düşürücü sürelerdir.

a) Bir yıllık süre

Bir yıllık süre, davacının kendi hak sahipliğini, ölüme bağlı tasarrufu ve 1026
iptal sebebini öğrenmesinden itibaren işlemeye başlar. Ancak, iptal davası asla mirasbırakanın sağlığında açılamayacağı için, dava açma hakkı olan kişi, bütün bu sayılan hususları, mirasbırakanın sağlığında öğrenmiş olsa bile, süre mirasbırakanın ölümünden önce işlemeye başlamaz[672].

b) On yıllık süre

Davalının iyiniyetli olması hâli için öngörülmüş olan on yıllık sürenin 1027
başlangıcı, vasiyetnamelerde, vasiyetnamenin açıldığı (MK 596) andır. Miras sözleşmelerinde açılma söz konusu olmadığı için on yıllık süre mirasbırakanın ölümü yâni mirasın geçmesi ile işlemeye başlar (MK 559).

c) Yirmi yıllık süre

Davalının kötüniyetli olması için öngörülmüş olan yirmi yıllık sürenin 1028
başlangıcı, on yıllık süreninkinin aynısıdır.

Buradaki kötüniyet MK 3 anlamındadır. Yani davalının, ölüme bağlı tasarruftaki 1029
iptal sebebini bilmesi ya da gerekli araştırmayı yapmadığı için öğrenememiş olması ve buna rağmen ölüme bağlı tasarrufun yerine getirilmesini istemesidir. İyiniyet MK 3'e göre asıl olduğu için, davalının kötüniyetli olduğunu davacı ispat edecektir, meğer ki davalı, hâlin icabına göre iyiniyet iddiasında bulunamayacak durumda olsun (MK 3/II). Kötüniyetin ölüme bağlı tasarrufun yapıldığı anda bulunması şart değil-

[671] Bkz., İBK 7.12.1955, 15/25 (RG sayı 9230).
[672] *Escher*, Art. 521 N 2; *Kocayusufpaşaoğlu*, § 28, II, 2,c; *Oğuzman*, 192.

dir. Davalı daha sonra, fakat bir ve on yıllık süreler geçmeden kötüniyetli hâle gelecek olursa, yine ona karşı yirmi yıllık süre uygulanır. Fakat, davalının bir ve on yıllık sürelerin geçmesinden sonra kötüniyetli olması hâlinde yirmi yıllık süre uygulanmaz[673].

d) Sınırsız defi hakkı

1030 MK 559/II, iptal davası açılmamış olan hâllerde, karşı tarafın ölüme bağlı tasarrufun ifası için açtığı davada, ölüme bağlı tasarrufun sakatlığının defi olarak ileri sürülmesini süreye bağlı olmaksızın öngörmüştür. Ancak daimi defi hakkının kullanılmasının bir şartı vardır ki o da *sakat olan ölüme bağlı tasarrufun ifa edilmemiş olmasıdır*. Eğer ölüme bağlı tasarruf yerine getirilmişse, sakatlığın defi olarak ileri sürülmesiyle ifa edilen şey geri alınamaz; süresi içinde iptal davası açılması gerekir.

[673] *Tuor*, Art. 521 N 12; *Escher*, Art. 521 N 7; *Kocayusufpaşaoğlu*, § 28, II, 2, a,cc; *Oğuzman*, 193.

ÜÇÜNCÜ KISIM

SAKLI PAY, TASARRUF ORANI, TENKİS, DENKLEŞTİRME

§ 19. Kavramlar

Miras Hukukunda kanunî mirasçıların kimler olacağı sorununu hemen takip eden ikinci önemli sorun, bu kanunî mirasçıların miras paylarından ne zaman ve ne ölçüde yoksun bırakılabilecekleridir. Belirtelim ki, ret, çıkarma(ıskat), yoksunluk (mahrumiyet), miras payının devri gibi sebeplerle bir mirasçının miras payından tamamen yoksun kalması mümkünse de, bu özel durumlar yerinde incelenecek olup, burada kastedilen miras bırakanın bir tasarrufu ile yasal mirasçısını arzusuna aykırı olarak kanunda belirtilen miras payından (özellikle üçüncü bir kişi lehine olarak) yoksun bırakıp bırakamayacağıdır. 1031

İlk bakışta bu hususta akla iki radikal çözüm gelir: Mirasçıların tereke üzerindeki haklarının mutlak olarak miras bırakanın arzusuna ve tasarruflarına tabi olduğu kabul edilebilir. Böylece mirasbırakan en yakın yasal mirasçısını bile ölüme bağlı bir tasarruf veya sağlararası bir işlem yoluyla tamamen ve keyfî şekilde miras payından yoksun bırakabilir. Ya da, miras bırakanın mirasçılarının yasaca belirlenen mirasçılık haklarına ve miras paylarına zarar verecek bir tasarrufta bulunması yasaklanır. Böylece, kişi ölümünden sonra kanunun belirlediği yakınlarına gidecek tereke değerlerini başka kişilere bırakamaz veya kanunun saptadığından farklı oranlarda paylaşılmasını öngöremez. 1032

Çeşitli hukuk sistemlerine bakıldığında, Anglosakson Hukuk Sisteminin (İngiltere, ABD) birinci düşünce doğrultusunda olduğu ve mirasbırakana yasal mirasçıları aleyhine sınırsız bir tasarruf serbestliği tanıdığı gözlenmekte[674], buna karşılık bizim de içinde yer aldığımız Kıta Avrupası Hukuk sistemlerinin mirasbırakanın mirasçılarına zarar verecek tasarruflarını sınırladığı gözlenmektedir. Belirtelim ki, mirasbırakanın yasal mirasçıları korumak için tasarruflarının sınırlandırılması işlem özgürlüğüne ve mülki- 1033

[674] Amerikan filmlerinde ve TV dizilerinde zengin işadamının yapacağı vasiyetle bazı çocuklarını ve eşini tamamen mirasından uzaklaştırması ve yabancı birine yahut gene mirasçılarından birine bütün servetini bırakması, bu sebeple sık rastlanan bir gerilim unsurudur.

yet hakkına[675] bir müdahale olduğundan, bu sınırlandırma mutlak şekilde yapılmamakta, yasal mirasçıların tüm miras payları değil, bunun belirli bir oranı korunmaktadır. Saklı pay (mahfuz hisse) denilen bu kısma aşağıda değineceğiz.

1034 Gene belirtelim ki, burada tartışılan tasarruf sınırlaması kural olarak miras bırakanın ölüme bağlı tasarrufları bakımındandır. Yoksa mirasbırakanın sağlar arası işlem yoluyla ileride bırakacağı terekesini sağken azaltan işlemler yapmasına sınırlar getirilecek değildir. Böylece, yasal mirasçıları en çok koruyan hukuk sistemleri de mirasbırakanın sağken bazı mallarını satmasına veya çeşitli amaçlarla parasını harcamasına müdahale etmemektedir. Bizim hukukumuzda da durum böyledir. Kural olarak dememizin sebebi, istisnaen bazı sağlararası işlemlerin de ölüme bağlı tasarruf gibi sınırlandırılmasıdır. Bunlara ileride değineceğiz.

1035 Mirabırakanın ölüme bağlı tasarruflarıyla yasal mirasçılarını dilediği gibi etkilemesini, dilerse tereke üzerindeki tüm hakkından yoksun bırakmasını caiz gören hukuk sistemleri, kişinin kendi malında mutlak şekilde tasarruf etme hakkı olması gerektiği düşüncesinden yola çıkmaktadır. Bu görüşe göre, yasal mirasçılar esasen elde edilmesinde, kazanılmasında hiçbir katkıları olmayan ve çok yakınları da olsa başkasına ait bir malvarlığı üzerinde hiçbir karşılık ödemeden miras sebebiyle hak sahibi olmaktadırlar. Onların bu karşılıksız kazanımlarını miras bırakanın kendi malında tasarruf imkânını sınırlamak pahasına korumak adil değildir. Böylece, örneğin, bir baba yaptığı vasiyetle öz çocuklarına hiçbir şey bırakmayıp, tüm terekesini hiçbir akrabalık bağı olmayan çok sevdiği bir arkadaşına vasiyet edebilir. Babanın çocuğuna karşı aile hukuku hükümleri çerçevesinde barındırma, besleme ve eğitme yükümünü sağlığında yerine getirmiş olması ve ölümü anında çocuğun artık aile hukuku çerçevesinde bakılıp eğitilecek yaşı geçmiş olması yeter[676].

1036 Buna karşılık yasal mirasçıların tereke üzerindeki haklarını miras bırakanın tasarruflarına karşı hiç olmazsa kısmen koruyan hukuk sistemleri, olaya bambaşka bir düşünceyle yaklaşmaktadır. Buna göre, ölüme bağlı bir tasarrufla yasal mirasçısını miras hakkından tamamen yoksun bırakan kişi aslında kendi malı üzerinde tasarrufta bulunmamaktadır. Zira yaptığı işlemin sonuçları ancak o ölünce doğacaktır. Öldüğünde ise artık hukuken kişi

---

[675] Mülkiyet hakkına müdahale sadece sağlararası işlem yoluyla yapılan kazandırmalara getirilen kısıtlamalar bakımındandır. Ölüme bağlı tasarrufla gerçekleştirilen kazandırma, esasen kazandırmada bulunanın mülkiyet hakkını değil, ölümü üzerine mirasçıların çıkarını etkilemektedir.

[676] İngiliz – Amerikan hukuklarının bu özelliği hakkında bkz. *Ferid-Firsching*, Internationales Erbrecht, Bd. VI, München 1999, US, Grdz FI, 83 vd.

olmaktan çıktığı için hiçbir şeye sahip olamayacağından, esasen kendisine ait olmayacak bir malvarlığı üzerinde tasarruf etmektedir. Şayet yasal mirasçısı yerine kazandırmada bulunmak istediği kişiye gerçekten kendinden bir şey vermek isterse, bu kazandırmayı sağlığında yapabilir ve işlem miras hukukuna konu olmaktan çıkar. Fakat böyle yapmayıp, sağken kendisini asla etkilemeyecek olup sadece yasal mirasçısına kalacak malvarlığını başkasına devretmekle, deyim yerindeyse "başkasının kesesinden" kazandırmada bulunmuş sayılmalı ve bu davranışına karşı yasal mirasçı korunmalıdır[677].

Yasal mirasçının mirasbırakana karşı korunup korunmaması hususundaki tartışmada temelde bu iki akıl yürütme tarzı çatışmakla birlikte; varılacak sonuçta sistemin uygulanacağı ülkenin örf ve âdetleri, ekonomik ve sosyal yapısı, aile kurumuna yüklediği roller gibi somut ve maddî bazı veriler etkili olmaktadır. Genel hatlarıyla denebilir ki, bireyciliğin çok geliştiği, aile ve akraba dayanışmasının fazla önem taşımadığı, ekonomik yapının ve sosyal güvenlik sisteminin kişileri aile servetine muhtaç kılmadığı ülkelerde mirasbırakanın tasarruflarında tamamen özgür bırakılması fazla sakınca yaratmayacak iken; bu özelliklere sahip olmayan ülkelerde mirasbırakanın yasal mirasçıları aleyhine tasarruflarını sınırlamak daha büyük bir gereksinim olacaktır. 1037

İsviçre ve Türk Medeni Kanunları da çoğu Kıta Avrupası Ülkesinde olduğu gibi, mirasbırakana belli yakınlıkları olan yasal mirasçıları mirasbırakanın bazı tasarruflarına karşı korumuştur. Özellikle yoğun ekonomik ve sosyal sorunları olan, gelir dağılımının ve sosyal güvenlik sisteminin bozuk olduğu böylece geniş kitlelerin büyük ölçüde aile dayanışması sayesinde temel gereksinimlerini karşılayabildikleri ülkemizde, yasal mirasçıların mirasbırakanın tasarruflarına karşı korunması isabetli bir düzenleme olmuştur. 1038

Belirtelim ki, yasal mirasçıları koruyan diğer hukuk sistemlerinde olduğu gibi, hukukumuzda da bu koruma kapsam bakımından sınırlıdır. Yasal mirasçıların hepsi korunmayıp sadece mirasbırakanın çok yakını sayılan belirli kişiler korunduğu gibi; bunların da tüm miras payı değil miras paylarının gene yasada belirlenmiş oranları korunmuştur. Böylece, yasa, mirasbırakana bazı sınırlamalar getirmişse de geniş bir ölüme bağlı tasarruf payı da bırakmıştır. Bu sistemde yasanın miras payını koruduğu mirasçılara "saklı paylı (mahfuz hisseli) mirasçılar" ve bunların miras paylarının mirasbırakanın tasarruflarına karşı korunan kısmına da "saklı pay" (mahfuz hisse) 1039

[677] Gerçi yasamızda bu prensibin de ötesine geçerek, mirasbırakanın sağken yaptığı bazı kazandırmaların (özellikle bağışlama gibi ivazsız olanlarının), bazı özel şartlarla, istisnaen, ölümünden sonra tenkisini (azaltılmasını) düzenleyen hükümler (MK 565) mevcuttur. Bak ilerde § 21 III 2

denilir. Bu mirasçıların kimler olduğunu ve mahfuz hisse miktarlarını aşağıda açıklayacağız.

1040 Mirasbırakanın, saklı paylı mirasçılarının bu saklı payları toplamının dışında kalan ve serbestçe (dilediği gibi) tasarruf etmesi mümkün olan tereke kısmına ise, "tasarruf oranı (nisabı)" denir.

1041 Hukukumuzda saklı paylı mirasçıların bu miras paylarının korunması kendiliğinden (otomatik olarak) gerçekleşmez. Bir diğer deyişle, mirasbırakanın ölüme bağlı bir tasarrufla saklı paylı mirasçısının bu saklı payına tecavüz eden (: Tasarruf nisabını aşan) bir işlem yapması hâlinde, sözkonusu tasarruf işlemi kendiliğinden kısmen veya tamamen hükümsüz sayılmaz. Saklı paylı mirasçı kendisine tanınan özel bir dava ile bu tasarrufun saklı payına tecavüz eden kısmının etkisizleştirilmesini isteyebilir. Ancak belirli süreler içinde açılabilecek bir dava ile ileri sürülebildiğinden, saklı paylı mirasçının bu talebine "tenkis davası" (MK 560) denir. Bu dava ile ileri sürülen talep doğrultusunda ve özel bir yönteme bağlı olarak (MK 561-571) yapılan, mirasbırakanın tasarruflarını saklı paylara zarar vermeyecek hale getirme işlemine de "tenkis" denir.

1042 Saklı paya tecavüz eden tüm ölüme bağlı tasarruflar tenkise tabi iken, sağlararası tasarrufların ancak istisnaen kanunda belirtilmiş bazıları (MK 565) tenkise tabidir. Bu iki tür tasarrufun tenkis tarzında da farklılıklar vardır. İleride bunları ayrıntılı şekilde açıklayacağız.

1043 Medeni Kanunda tenkis kavramı asıl anlamıyla bu belirttiğimiz saklı paylı mirasçıların saklı paylarını koruyan kurum için kullanılmaktaysa da; bunun dışındaki iki durumda da tenkisten sözedilmektedir: Birincisi, miras sözleşmesi ile mirasçı atanan veya lehine vasiyet yapılan kişinin mirasbırakanca yapılan ölüme bağlı bir tasarrufla veya bağışlamayla miras sözleşmesinden veya vasiyetten doğan haklarının ihlal edilmesi üzerine açacağı davaya da öğretide "tenkis davası" denmesidir[678] (MK 527). İkincisi, vasiyet borçlularının tereke değerini veya kendilerine kalan tereke kısmını aşan vasiyetler hakkında açabilecekleri davaya da kanun "tenkis isteme" demektedir (MK 519/1). Hemen belirtelim ki, ilgili yerlerde değindiğimiz bu hükümlerin aşağıda açıklayacağımız tenkis kurumu ile - özellikle şartları bakımından- karıştırılmaması gerekir.

1044 Gene tenkis ve saklı pay kurumlarıyla karıştırılmaması gereken bir kurum "mirasta denkleştirme (iade)"dir. MK 669-675) hükümlerinde düzenlenmiş olan denkleştirme kurumunda, mirasbırakanın bazı mirasçılarına yaptığı bazı sağlararası kazandırmalar, herhangi bir mirasçının saklı payına

[678] *Kocayusufpaşaoğlu*, Miras hukuku 3.Bası, İstanbul 1987, .36

tecavüz etmese bile terekeye iade edilmektedir. denkleştirme kurumunu ve denkleştirmeye tabi kazandırmaları ileride özel olarak inceleyeceğiz.

§ 20. Saklı Paylı Mirasçılar

I. KİMLER SAKLI PAYLI MİRASÇIDIR?

Saklı Paylı mirasçıların kimler olduğu MK m.505/f.1 hükmünde belir- 1045
tilmiş ve bunların saklı pay oranları da MK m.506 hükümlerinde ayrı ayrı gösterilmiştir. MK m.505/f.2 hükmünde, ancak saklı paylı mirasçısı olmayanların terekelerinde sınırsız şekilde tasarrufta bulunabileceği açıklanmıştır.

Buna göre, hukukumuzda saklı paylı mirasçılar, miras bırakanın altsoyu 1046
(füruu), ana ve babası ve eşidir. Görüldüğü üzere, mirasbırakanın altsoyu bütünüyle (çocuklar, torunlar, torunların çocukları vd.) saklı paylı kılınmışken, mirasbırakanın üstsoyunda (usulünde) sadece ana ve babası saklı paylı kılınmıştır. Nihayet, mirasbırakanın eşi de saklı paylı mirasçısıdır.

Günümüzde eğilim saklı paylı mirasçıların sayısının azaltılmasıdır. Bu 1047
doğrultuda olmak üzere, İsviçre Hukukunda kardeşler saklı paylı mirasçı olmaktan çıkarılmıştır[679]. Hukukumuzda ise, saklı paya ilişkin hükümler, ilki 13.7.1967 tarihinde 903 Sayılı Kanunla, ikincisi ise 23.11.1990 tarihinde 3678 Sayılı Kanunla ve nihayet 4721 Sayılı ve 22.11.2001 Tarihli Yeni Medeni Kanunla olmak üzere üç kere değiştirildikten sonra; 10 Mayıs 2007 tarih ve 26518 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan 5650 sayılı kanunla MK 505 ve 506'da değişiklik yapılarak saklı paylı mirasçıların kapsamı daraltılmıştır. Söz konusu kanun, MK 505'in birinci fıkrasındaki *kardeşler* ibaresini metinden çıkartarak, kardeşlerin zaten eski kanuna göre azaltılarak 1/8 yapılmış olan saklı paylarını kaldırmıştır. Buna paralel olarak, saklı payların oranını düzenleyen 506. madde de değişikliğe uğramış ve kardeşlerin saklı pay oranını miras paylarının 1/8'i olarak öngören ikinci bent yürürlükten kaldırılmıştır. Bu yeni düzenlemeye göre, hukukumuzda artık sadece altsoyun, ana ve baba ile eşin saklı payları bulunmaktadır[680].

Belirtelim ki, mirasbırakanın altsoyunun varlığı hâlinde esasen ana ba- 1048
bası ve kardeşleri mirasçı olamayacağından ve hem ana hem de babasının varlığı hâlinde de kardeşlerin mirasçılığı önleneceğinden, saklı paylı mirasçıların tümünün bir arada bulunacağı bir durumla karşılaşılmayacaktır.

---

[679] *Kocayusufpaşaoğlu*, Miras Hukuku 2. ve 3. Basılara Ek Kitap, İstanbul 1992, 15.

[680] Bununla birlikte, 5650 SK'nun yayını tarihinde yürürlüğe girmesi hükme bağlandığından; 10 Mayıs 2007 gününden önce gerçekleşen ölümlerde, bundan sonraki bir tarihte açılan tenkis davasına konu olsalar da, kardeşlerin 1/8 saklı payı gözönüne alınacaktır.

II. SAKLI PAYLAR

1. Saklı Pay Oranları

1049 4721 Sayılı Yeni Medeni Kanunumuzun 506. maddesine göre, saklı paylar şu şekilde saptanmıştır:

1050 1) Altsoy için yasal miras payının yarısı (1/2'si)

1051 2) Ana ve babanın her biri için yasal miras payının dörtte biri (1/4'ü)

1052 3) Sağ kalan eş için, altsoy (1.zümre) veya ana baba zümresi (2. zümre) ile birlikte mirasçı olması durumunda yasal miras payının (altsoy ile: 1/4, ana baba zümresi ile: 1/2) tamamı; diğer durumlarda (3.zümre ile veya tek başına mirasçı ise) yasal miras payının (3/4) dörtte üçü (3/4'ü) (Buna göre, eş 3. zümre ile birlikte ise: 3/4 x 3/4 = terekenin 9/16'sı)

1053 Yeni Medeni Kanunumuzun 506. maddesiyle getirilen düzenin, 743 Sayılı Eski Medeni Kanunumuzun 453. maddesine göre, saklı pay oranlarını önemli ölçüde indirdiği görülmektedir. Bu durum, uluslararası bir eğilim olan ve İsviçre Hukukunda da gözlenen "saklı payları azaltma" düşüncesinin bir sonucudur. İsviçre Medeni Kanunun 471. maddesinde yapılan değişiklikle de yeni bir saklı pay sistemi getirilmiştir[681]. Bizde 5650 SK ile kardeşlerin saklı payı kaldırılınca, durum bu sisteme benzemiştir. Ancak İsviçre Kanununda sağ kalan eşin saklı payı daima yasal miras payının yarısıdır.

1054 Eski Medeni Kanunumuzun 3678 Sayılı Kanunla değişik 453. maddesine göre ise, saklı paylar şöyle idi:

1055 1. altsoy için yasal miras payının dörtte üçü (3/4'ü)

1056 2. Ana ve babanın her biri için yasal miras payının yarısı (1/2'si).

1057 3. Kardeşlerden her biri için yasal miras paylarının dörtte biri (1/4'ü)

1058 4. Sağ kalan eş, altsoy ile beraber mirasçı ise yasal miras payının (terekenin 1/4'ünün) tümü, diğer mirasçılarla birlikte ise veya tek başına mirasçı ise yasal miras payının yarısı (Buna göre, eş 2. zümre ile birlikte ise: 1/2 x 1/2 = terekenin 1/4'ü; 3. zümre başlarıyla birlikte ise: 3/4 x 1/2 = terekenin 3/8'i).

1059 Görüldüğü üzere, Yeni Medeni Kanunumuz eskiye oranla, altsoyun saklı payını 3/4'den 1/2'ye indirmiş; ana babanın saklı payını 1/2'den 1/4'e indirmiş; kardeşlerin saklı payını 1/4'den 1/8'e indirmiştir. Ancak, zümre mirasçılarında yaptığı bu büyük indirimlere karşılık, sağ kalan eşin saklı payında indirim yapmadığı gibi, bazı durumlarda bunu arttırmıştır: Sağ ka-

---

[681] *Kocayusufpaşaoğlu*, Miras Hukuku 2. ve 3. Basılara Ek Kitap, İstanbul 1992, 16

lan eşin saklı payı altsoy ile birlikte ise eski kanunla aynı (1/4 miras payının tamamı) kalırken; ana baba zümresi ile birlikte ise miras payının yarısından (1/2 x 1/2 = 1/4) miras payının tamamına (1/2), büyükana ve büyükbabalar ve bunların çocuklarıyla birlikte ise miras payının yarısından (3/4 x 1/2 = 3/8) miras payının dörtte üçüne (3/4 x 3/4 = 9/16), tek başına mirasçı ise terekenin yarısından (1/2'sinden) terekenin 3/4'üne yükseltilmiştir. Eşin saklı paylardaki indirimden muaf tutulması hatta saklı payının arttırılması, tasarruf oranındaki artışın tamamen zümre mirasçılarının sırtına yüklenmesi, adaletsiz olmuştur. Özellikle, Yeni Medeni Kanunun yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejiminde esasen sağ kalan eşe ölen eşin malvarlığında mirasçılık dışında haklar tanındığı da düşünülürse; bu adaletsizlik daha da göze batar. Zira, bu rejime göre, ölen eşin paylaşmaya konu edinilmiş malları yaşayan eşten daha fazla ise (yaşam deneyimlerine göre genellikle ölen erkek olup onun mülkiyetindeki edinilmiş mallar karısınınkilerden daha fazla olacaktır), sağ kalan eş hem hesaplamada lehine çıkacak artık değerin yarısını alacak, hem de daha da iyileştirilmiş bir mirasçılık statüsünden yararlanacaktır[682].

Belirtelim ki, Yeni Medeni Kanunumuzun yürürlüğe girdiği 1.1.2002 tarihinden önce gerçekleşen ölümlerden dolayı miras paylarının ve saklı payların belirlenmesinde, bundan sonraki davalarda da eski sisteme göre paylaştırma ve saklı pay hesapları yapılacaktır. 4722 Sayılı ve Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında 3 Aralık 2001 Tarihli Kanun'un 17. maddesinde, "mirasçılık ve mirasın geçişi, mirasbırakanın ölümü tarihinde yürürlükte olan hükümlere göre belirlenir." denmektedir. 1060

[682] MK 236 uyarınca ölen eşin mirasçılarının da artık değere katılması, ancak sağ kalan eşin edinilmiş mallarının ölen eşin edinilmiş mallarına eşit değerde (veya daha fazla) olması halinde, bu sakıncayı kaldırabilir. Çoğu kez durum böyle olmayacaktır. Karşılaşılabilecek rahatsız edici durumlara şu örnek verilebilir: Bay (M) genç yaşta evlendiği ilk eşi bayan (E1)'den (A), (B) ve (C) olmak üzere üç çocuk sahibi olmuştur. (E1) yıllarca geçim sıkıntılarına da katlanarak üç çocuğu fedakârca büyüttükten sonra, yaşı kırkı geçtiği sıralarda iş hayatında başarılı olan ve durumu düzelen (M) tarafından, genç bayan (E2) ile evlenmek maksadıyla terkedilmiştir. (M) (E1)'den boşanıp (E2) ile evlendikten sonra asıl servetini kazanmış ve (E2) ile evli iken varlıklı bir kişi olarak ölmüştür. (M)'nin (E2)'nin telkini sonucu hazırladığı vasiyetname ile, çocuklarının aleyhine olarak, tasarruf oranının tamamını (E2)'ye bıraktığı anlaşılmıştır. Burada, (E1) esasen eş sıfatı taşımadığından (M)'nin terekesi üzerinde hiç bir hakka sahip olamayacak; sağ kalan eş (E2), daha miras paylaşmasına girmeden, (M)'nin kendisi ile evli iken kazandığı ve tüm malvarlığını oluşturan 100 milyon Tl servetin yarısını yani 50 milyon Tl.sını, yasal mal rejimini düzenleyen MK m. 218-241 hükümleri uyarınca alacak; geri kalan ve terekeyi oluşturan 50 milyonun ise, (M) nin çocukları (B), (C) ve (D)'nin yeni kanunla indirilmiş saklı payları olan 1/4 x 1/2 x 3 = 3/8 dışında kalan kısmını, yani 50 milyon Tl.nin 5/8 oranı olan 31,25 milyon Tl.sını da alacaktır. Sonuçta, (E1) 81,25 milyon Tl. elde ederken; 18,75 milyon Tl.yi paylaşacak çocuklardan her birinin eline 6,2 milyon Tl geçmiş olacaktır. Şayet (E2)'nin (M)'den olma çocuğunun(veya çocuklarının) bulunduğu varsayılırsa, böyle bir durumda (A), (B) ve (D)'nin payları daha da azalacaktır.

Saklı paylara ilişkin hükümler,"mirasçılık" hükümlerinden sayılmalıdır. Böylece, bir tenkis davasında, şayet dava konusu kazandırmada bulunan Yeni Medeni Kanunumuzun Yürürlüğe girdiği 1.1.2002 gününden önce ölmüşse, dava bu tarihten sonra açılsa bile, Eski Medeni Kanunumuzdaki saklı paylara göre hesaplama yapılacaktır[683]. Tenkis davalarının vasiyetnamelerin açılmalarından itibaren azamî on yıllık hak düşümü süresine tabi olduğu (MK 571) göz önüne alınırsa; daha uzun yıllar Eski Medeni Kanuna göre tenkis hesabı yapılması gerekebilir. Bu bakımdan, eski kanundaki saklı payların da bilinmesi gerekir.

1061 Gene, 5650 SK'un MK 505'de yaptığı değişikliğin yürürlüğe girdiği 10 Mayıs 2007 tarihinden önceki ölümlerde, mirasçı kardeşlerin miras paylarının 1/8'i oranında saklı payları, bu tarihten sonraki tenkis davalarında da gözönüne alınacaktır.

1062 Aynı önemi taşımamakla birlikte, Eski Medeni Kanunun 453. maddesinin 23.11.1990 yürürlük tarihli ve 3678 Sayılı Kanunla değiştirilmesinden önceki saklı pay hükümlerine kısaca değinelim. Zira, bu tarihten önce gerçekleşen ölümler sebebiyle –vasiyetnamenin çok geç açılması üzerine- nadir de olsa açılabilecek veya sürmekte olan tenkis davalarına, bu hükümler uygulanacaktır.

1063 Sözkonusu hükümlere göre, altsoyun, ana babanın ve kardeşlerin saklı payları 23.11.1990 sonrasından (23.11.1990 - 1.1.2002 arası durumdan) farklı değilken; eşin saklı payı farklıdır. Buna göre eşin saklı payı, herhangi bir yasal mirasçı ile birlikte ise mülkiyet payının tümü; kendisinden başka yasal mirasçı bulunmaması hâlinde ise mülkiyet payının yarısı idi[684].

1064 23.11.1990 öncesi sistemde asıl önemli sorun, bu sisteme özgü bir imkân olarak, birinci zümre ile birlikte mirasçı olan eşin 1/4 mülkiyet yerine 1/2 intifa hakkını seçmesi durumunda doğardı. Bu sorun, eşin intifa hakkını seçmesi hâlinde tasarruf oranının nasıl hesaplanacağı idi. Bu sisteme göre intifa hakkını seçen eşin saklı payı

---

[683] Buna karşılık, tenkise konu tasarrufun 1.1.2002 tarihinden önce yapılmış olması onu Eski Medeni Kanuna tabi kılmaz. Burada, Tatbikat Kanununun Genel Hükümlerini içeren 1. maddesinin 1. fıkrasında yer alan, Yeni Medeni Kanunun yürürlüğe girmesinden önce yapılan işlemlerin sonuçlarının Yeni Kanun zamanında da Eski Medeni Kanuna tabi olacağı kuralı uygulanmaz. Tatbikat Kanununun miras hukukuna ilişkin 17. maddesi, burada özel hüküm sayılarak öncelikle uygulanır. Böylece, 1.1.2002 tarihinden sonra ölen bir kişinin, 1.1.2002 tarihinden çok zaman önce düzenlediği vasiyetnamesinin tasarruf oranını aşıp aşmadığı da Yeni Kanundaki saklı paylara göre belirlenecektir.

[684] Bu sistemin 23.11.1990 –1.1.2002 arası sisteme göre farkı, eşin mirasbırakanın büyükana ve büyükbabası ile birlikte mirasçı olması hâlinde, 23.11.1990'dan önce bu durumdaki 1/2 mülkiyet payının tamamının saklı pay sayılmasına karşılık, 23.11.1990-1.1.2002 sisteminde bu durumdaki miras payı 1/4'ün 1/2'si olan 3/8 oranında saklı payı olmasıdır. Diğer durumlarda bir fark doğmazdı. Şöyle ki: Eşin birinci zümreyi oluşturan mirasbırakanın füru ile birlikte mirasçı olması hâlinde durum aynıydı. Eşin ikinci zümreyi oluşturan mirasbırakanın ana baba ve kardeşleriyle birlikte mirasçı olması hâlinde 23.11.1990 öncesi sistemde 1/4 miras payının tamamı mahfuz hisse iken; 23.11.1990 – 1.1.2002 sisteminde bu durumdaki 1/2 miras payının 1/2'si saklı payı olarak kabul edilmiştir ki bu da 1/4 ederdi.

olmayacaktır. Burada eş bakımından saklı pay problemi ile karşılaşılmayacak ise de, intifa hakkı seçen eşle birlikte diğer mirasçıların varlığı bakımından saklı paylar toplamının ve tasarruf oranının nasıl hesaplanacağı tartışılmakta idi. Şu kadarını belirtelim ki, bu durumda Federal Mahkemenin ve Yargıtayın da benimsediği baskın görüş, tasarruf oranını bulmak için eş mülkiyet hakkını seçmiş gibi hesaplama yapılması idi[685].

Biz açıklamalarımızı, Yeni Medeni Kanunun yürürlüğe girdiği 1.1.2002 tarihinden önceki hükümlere göre değil, Yeni Medeni Kanunumuzdaki sisteme göre örneklendireceğiz. 1065

Saklı pay hesaplamasındaki prensipleri örnekler vererek açıklayalım: 1066

a) Aynı zümredeki mirasçıların sayısı ister az ister çok olsun, bunların saklı payları toplamı ve mirasbırakanın tasarruf oranı değişmez. Örneğin, (M)'nin ölümü üzerine sadece bir çocuğu (ç) hayatta ise, (Ç)'nin tüm tereke üzerindeki (:1/1) hakkının 1/2'si saklı payı olduğuna göre, (M)'nin saklı payı terekesinin 1/2'si kadardır. Şayet (m)'nin ölümü üzerine geriye üç çocuğu (Ç1), (Ç2) ve (Ç3) kalmış ise; bunların her birinin miras payı 1/3 (Ç1), 1/3 (Ç2) ve 1/3 (Ç3) şeklindedir. Her bir çocuğun saklı payı miras payının 1/2'si kadar olduğuna göre, (Ç1)'in saklı payı: 1/3 x 1/2 (1/3'ün 1/2'si) = 1/6 ; (Ç2)'nin saklı payı 1/3 x 1/2 = 1/6 ve (Ç3)'ün saklı payı = 1/3 x 1/2 = 1/6 kadardır. Saklı paylar toplamı: 1/6 + 1/6 + 1/6 = 3/6 = 1/2 eder. Şu halde burada da (M)'nin tasarruf oranı terekenin 1/2'si kadardır. 1067

b) Mirasbırakanın yasaca aynı oranda saklı paya sahip mirasçıları bulunsa bile , bunların miras payları farklı ise, sonuçta sahip olacakları tereke üzerinden saklı pay miktarları farklı olacaktır. Zira, mirasbırakanın tasarruflarına karşı ellerine geçecek olan saklı kısım, miras paylarının saklı payları oranı kadardır. Örneğin: (M)'nin ölümü üzerine oğlu (Ç1) ve kendisinden önce ölen kızı (Ç2)'nin çocukları (torunları) (T1) ve (T2) kalmışsa; hepsi (M)'nin altsoyu olan mirasçılar (Ç1), (T1) ve (T2)'nin saklı payları aynı olup miras paylarının 1/2'si kadar ise de; sonuçta terekenin tümü üzerinde, (Ç1)'in elde edeceği saklı kısım 1/2 olan miras payının 1/2'si olan 1/4 iken; (T1)'in elde edeceği saklı kısım 1/4 miras payının 1/2'si olan 1/8 1068

---

[685] Yarg.2.HD. 6.3.1973, E.1402 K.1406 (İBD 1973, s.437).; BGE 45 II 384; BGE 59 II 1289; Bu görüşte: *Escher*, Art.470,471; *Tuor*, Art.470,471; *İmre*, 358; *Ayiter*, 125. Bu görüşün gerekçesi, tasarruf nisabının mirasbırakanın ölümünden sonra eşinin yapacağı ve önceden bilinemeyen bir seçimle değişmesinin doğru olmadığıdır.
Buna karşılık, öğretide savunulan diğer bir görüş, eşin intifa hakkı da dikkate alınarak zümre mirasçılarının tam mülkiyetli ve kuru mülkiyetli paylarına göre hesaplanmalıdır. Bu görüş benimsenirse eşin intifa hakkını seçmesi hâlinde tasarruf oranı artabilecektir. Bu görüşte: *Kocayusufpaşaoğlu*, 374 vd.; *Oğuzman*, 202; *Çağa*, 97 vd. Bu görüşün gerekçesi, mirasbırakanın yapacağı bir ölüme bağlı tasarrufla eşin intifa hakkını seçme yetkisini elinden alabilmesidir.

ve (T2)'nin elde edeceği saklı kısım da 1/4 miras payının 1/2'si olan 1/8'dir.

1069 c) Saklı paylı mirasçının mirasbırakandan önce ölmesi hâlinde saklı paylarının altsoyu tarafından temsil edilmesi sözkonusu olmaz. Yani durum miras payının intikalindeki gibi değildir. Her mirasçının mirasbırakana yakınlık derecesi bakımından yasaca saklı paya sahip kılınıp kılınmadığına ayrı ayrı bakılır. Örneğin: (M)'nin ölümü üzerine babası (B) ve kardeşi (K1) hayatta ise; (B)nin saklı payı miras payı olan 1/2'nin 1/4'ü olacağından (1/2 x 1/4=) 1/8; (K1) daha önce ölen annesinin yerine mirasçı oluyorsa da kardeş K1'in mirasçı sıfatına halef olduğu annesi yaşasaydı miras payının 1/4'ü kadar saklı payı olacak iken kendisi hiç saklı paya sahip olmadığından, bu olayda saklı paylar toplamı: (B) 1/8 ve (M)'nin tasarruf oranı da 7/8 olur.

1070 Ancak, miras bırakanın altsoyu her derecede saklı paya sahip kılındığı için, bu bakımdan aralarında fark yoktur. Örneğin: (M)'nin ölümü üzerine oğlu (Ç1), kendisinden önce ölen oğlu (Ç2)'nin çocuğu (torunu) (T1) ve gene kendisinden önce ölen oğlu (Ç3)'ün kendisinden önce ölen kızı (T2)'nin çocuğu (torunun çocuğu) (K) kalmıştır. Burada Oğul (Ç1), torun (T1) ve torun çocuğu (K) nın her birinin saklı payı miras paylarının 1/2'si kadardır ve aynıdır. Olayda miras paylarına göre saklı paylar: (Ç1) 1/3 x 1/2 = 1/6, (T1) 1/3 x 1/2 = 1/6, (K) 1/3 x 1/2= 1/6 olarak aynıdır. (Saklı paylar toplamı: 3/6 = 1/2 ve tasarruf oranı= 1/2'dir).

1071 d) Sağ kalan eşin altsoy ile birlikte mirasçı olmasında 1/4 miras payının tümü saklı payı sayılacaktır. Örneğin, (M)'nin ölümü üzerine geriye mirasçısı olarak çocuğu (Ç1) ve kendisinden önce ölen çocuğu (Ç2)'nin kızı (T) ile eşi (E) kalmıştır. Burada sağ kalan eş (E)'nin saklı payı aynı zamanda miras payının tamamı olan 1/4 olacak; geriye kalan 3/4 eşit şekilde, (Ç1) 3/8 ve (T) 3/8 olarak paylaşılacaksa da mirasbırakanın altsoyu olan bu kişilerin saklı payları miras paylarının 1/2'si kadar olduğundan, (Ç1)'in saklı payı 3/8 x 1/2 = 3/16, (T)'nin saklı payı 3/8 x 1/2= 3/16 olacak; saklı paylar toplamı 1/4 (4/16) + 3/16 + 3/16 = 10/16 eder. (M)'nin tasarruf oranı ise 6/16'dır.

1072 Sağ kalan eş mirasbırakanın ikinci zümre (ana baba zümresi) mirasçıları ile birlikte ise, Eski Kanundan farklı olarak, gene yasal miras payının tamamı saklı payı sayılacaktır. Örneğin, (M)'nin ölümü üzerine mirasçıları eşi (E), babası (B) ve kardeşi (K) kalmış ise, burada eş (E) ikinci zümre ile birlikte mirasçı olduğundan, miras payı terekenin 1/2'si ve saklı payı da bunun tamamı olacağından, terekenin 1/2'si saklı payıdır. Baba (B)'nin miras payı terekenin diğer 1/2'sinin 1/2'si olan 1/4 iken, saklı payı miras payının 1/4'ü olan 1/16 olarak hesaplanır. Kardeş (K)'nın da miras payı 1/4

iken saklı payı olmadığından; saklı paylar toplamı 1/2 + 1/16 = 9/16'dır. (M)'nin tasarruf oranı 7/16'dır.

Sağ kalan eş mirasbırakanın büyükana ve büyükbabaları ile yahut bunların çocuklarından (hala,amca,dayı teyze) biri ile birlikte mirasçı ise, gene Eski kanundan farklı olarak, yasal miras payının dörtte üçü saklı payı olacaktır. Örneğin, (M)'nin ölümü üzerine geriye mirasçı olarak eşi (E) ve teyzesi (T) kalmış ise, burada üçüncü zümre ile birlikte bulunan (E)'nin miras payı 3/4 ve (T)'nin miras payı 1/4 olacak; (E)'nin saklı payı miras payının 3/4'ü olacağından, 3/4 x 3/4 = 9/16 olarak bulunacaktır. (T)'nin saklı payı bulunmadığından, tasarruf oranı 7/16'dır. 1073

Sağ kalan eş tek başına mirasçı ise, tüm terekenin dörtte üçü saklı payı olacağından, örneğin geriye mirasçı olarak sadece eşi (E)'yi bırakarak ölen (M)'nin tasarruf oranı, terekesinin 1/4 kadarı olacaktır. 1074

2. Eski Medeni Kanundaki azaltılmış saklı paylar

Eski Medeni Kanunumuzun 453. maddesi hükümleri, Kaynak İsviçre Hukukundan farklı olarak, bazı özel durumlarda saklı paya ilişkin olarak yukarıda belirttiğimiz saklı pay oranlarının azaltılacağını öngörmüştü. İstisnaî durumlarda sözkonusu olacak bu tür saklı paya "azaltılmış mahfuz hisse"[686] veya "indirilmiş mahfuz hisse"[687] denilmekte idi. Saklı payların azaltıldığı durumlarda mirasbırakanın tasarruf oranı artacağından, bu özel hâller aynı zamanda "arttırılmış (veya genişletilmiş) tasarruf nisabı" olarak da adlandırılmakta idi. 1075

Yeni Medeni kanunumuzda, İsviçre'dekine paralel olarak, azaltılmış saklı payları düzenleyen hüküm kaldırılmıştır. Artık, miras hukukumuzda yukarıda açıkladığımız saklı pay oranları dışında, isisnaî durumlar için farklı saklı paylar sözkonusu değildir. Bu değişikliğin gerekçesi, Yeni medeni kanunumuzun esasen eskisine göre saklı pay oranlarını indirmesi sebebiyle, ayrıca bazı durumlarda özel olarak saklı payların azaltılmasına gerek kalmadığıdır. 1076

Bununla birlikte, Türk Medeni kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 17. maddesi uyarınca, 1.1.2002 tarihinden önce gerçekleşen ölümler sebebiyle açılan miraslarda yapılacak tasarruf oranı hesaplamalarında, bundan sonra da Eski Kanunun azaltılmış saklı paylara ilişkin hükümleri uygulama alanı bulabilecektir. Bu sebeple, azaltılmış saklı paylara ilişkin eski düzenlemeyi bilmek gerekmektedir: 1077

---

[686] *Oğuzman*, 208;
[687] *Kocayusufpaşaoğlu*, 361 vd.; *Kocayusufpaşaoğlu*, Ek Kitap, 18 vd.

1078 Türk Hukukunda azaltılmış saklı pay ilk kez 13.7.1967 tarih ve 903 sayılı Kanun ile Eski MK 453 hükmünde yapılan değişiklik sonucu kabul edilmiştir[688]. Sonradan tekrar değişen bu hükme göre, miras bırakanın kamu yararına bağışlama yapması veya gelirinin yarısından fazlası kamu görevi niteliğindeki işlerin yapımına tahsis edilen vakıf kurması hâlinde, normal saklı paylar yerine bunların 1/3'ü saklı pay teşkil edecekti. Şu kadar ki, sözkonusu azaltılmış saklı pay miktarı, mirasçının içtimaî durumuna uygun nafakadan az olmayacaktı. Gene, 1659 sayılı Kanunla da değiştirilen 3 fıkraya göre, vakıf gelirinin % 20'si veya bu vakıflara bağışlanan yahut ölüme bağlı tasarruf suretiyle tahsis edilen malların gelirinin % 20'si kendisine bırakılan saklı paylı mirasçılar tenkis davası açamazlardı. Nihayet, 4.fıkraya göre, vakıf gelirinin %20 sinin saklı paylı mirasçılara bırakıldığı hâllerde yalnız bunların da saklı paylı mirasçıları bu gelirden yararlanacak olup, bunların ölümü üzerine mirasçı olacaklara ancak vakıf senedinde açık hüküm bulunmak şartıyla muavenet nafakası verilebilecekti.

1079 Belirtelim ki bu düzen 23.11.1990 tarihinde yürürlüğe giren 3678 Sayılı kanunla değiştirilmiştir. Bu tarihten itibaren ve 1.1.2002 tarihine kadar gerçekleşen miras intikallerinde uygulanacak bu değişikliğe göre, MK 453/f.2 uyarınca, "gelirin yarısı kamu görevi niteliğindeki işlerin yapımına bırakılarak vakıf kurulmasında mahfuz hisseler 2/3 oranında azalacaktır". 3.Fıkraya göre, "Genel ve katma bütçeye dahil kurum ve kuruluşlarla, il özel idarelerine, belediyelere, kanunla kurulan fonlara, kamu yararına çalışan derneklere ve gelirinin yarısından fazlasını kamu görevi niteliğindeki işlere harcayan vakıflara yapılan ölüme bağlı tasarruflar ve hibelerde yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır".

1080 Görüldüğü üzere, Yeni medeni kanunun yürürlüğe girdiği 1.1.2002 tarihine kadar uygulanacak olan bu yeni sistem, önceki düzenlemeye göre şu hususları değiştirmiştir.

1081 a) Saklı paylardaki azaltma normal saklı payların 1/3'ünden 2/3'üne çıkarılmıştır. Böylece, saklı payın azaltıldığı durumlarda saklı paylı mirasçıları biraz daha himaye eden ve mirasbırakanın tasarruf oranını daraltan bir değişiklik yapılmıştır.

1082 b) Vakıf gelirinin %20'sinin tahsisi karşılığı saklı payı tamamen kaldıran ve öğretide "mahfuz gelir" denilen hüküm yasadan çıkarılmıştır. Böylece mirasbırakan bir seçenekten yoksun bırakılmışsa da, hukukî bakımdan çözümü güç tartışmalarla mahkemeleri oyalayacak olan bu kurumun kaldırılması hukukî ihtilafları azaltmıştır[689].

1083 c) Eski metnin genel ifadesine karşılık yeni metinde hangi kurum ve kuruluşlara yapılacak harcamanın kamu görevi niteliğindeki işler için yapılan harcama sayılacağı ayrıntılı şekilde ve açıkça düzenlenmiştir. Böylece, bu bakımından da olası tartışmalar önlenmiştir.

1084 1.1.2002 tarihine kadarki ölümlerde uygulanacak bu sisteme göre saklı paylı mirasçıların azaltılmış saklı payları, her birinin Eski Medeni Kanundaki normal saklı paylarının 2/3'ü alınarak, şöyle bulunmaktadır:

1085 Altsoyun azaltılmış saklı payı: 3/4 x 2/3= 1/2 (miras payının yarısı).

---

[688] Bu kanunun bir vakıf kurmak isterken Medeni Kanunun saklı pay kuralları yüzünden bunda zorlanan ünlü işadamımız Vehbi Koç'un teşvik ve gayretleriyle çıktığı belirtilmektedir. Bkz: *Kocayusufpaşaoğlu*, 362

[689] *Kocayusufpaşaoğlu*, Ek Kitap, 19

Baba ve ananın her birinin azaltılmış saklı payı: 1/2 x 2/3 = 1/3 (miras payının üçte biri). 1086

Kardeşlerin azaltılmış saklı payı: 1/4 x 2/3= 1/16 (miras payının onaltıda biri). 1087

Eşin azaltılmış saklı payı: Altsoy ile birlikte ise, miras payının tamamının 2/3'ü = 1/4 x 2/3= terekenin 1/6'sı; diğer mirasçılarla birlikte veya tek başına mirasçı ise, 1/2 x 2/3 = 1/3 (miras payının üçte biri Buna göre: şayet 2. zümre ile birlikte ise 1/2 x 1/3= terekenin 1/6'sı, şayet 3.zümre başlarıyla birlikte ise 3/4 x 1/3 = terekenin 1/4'ü, şayet tek başına mirasçı ise terekenin 2/3'ü). 1088

Uygulamada ortaya çıkacak bir sorun da, mirasbırakanın bazı tasarruflarının normal saklı pay kurallarına tabi olurken bazı tasarruflarının azaltılmış saklı paya konu olmasıdır. Tenkis bahsini ilgilendiren bu durumda, tasarruf oranı hesaplanırken, her iki tür saklı paya göre ayrı ayrı hesaplama yapılması ve normal tasarrufların normal saklı paylara göre bulunan tasarruf oranına göre tenkise tabi tutulurken, gerek kamu yararına gerekse normal tasarrufların azaltılmış saklı paylara göre bulunan (arttırılmış) tasarruf oranına göre tenkise tabi tutulması kabul edilmektedir[690]. 1089

3. Karı Koca mal rejimlerinin saklı paylara etkisi

Şu anda Medeni Kanunumuzda karı koca mal rejimleri bakımından, seçimlik rejimlerden "mal ayrılığı" olsun, Yeni Türk Medeni Kanununa mahsus bir sistem olan "paylaşmalı mal ayrılığı rejimi olsun, mahfuz hisse kurallarına yönelik bir hüküm getirmiş olmayıp, sadece özel statüye tabi olan bazı malların (aile konutu ve ev eşyası gibi) eşler arasında paylaşımına ilişkin hükümler getirmişlerdir. Bu hükümler hakkındaki açıklamalar genellikle aile hukuku eserlerinde yer almakta olup, miras hukukunu ilgilendiren yönlerine mirasın paylaşılması bahsinde değineceğiz. Sağ kalan eşin ve ölen eşin diğer mirasçılarının bu mal rejimlerinden etkilenmesi dolaylı yoldan olup, saklı pay bahsini ilgilendiren bir özellikleri yoktur. 1090

Yeni Medeni Kanunumuzda yasal mal rejimi olan "Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi" bakımından ise, MK m. 237/2 hükmü, bazı mirasçıların saklı payını eşlerin katılma paylarına ilişkin anlaşmalarına karşı korumaktadır. MK 236 uyarınca –evliliğin sona ermesi üzerine– her bir eşin diğerinin artık değerine 1/2 oranında katılması esas ise de, MK 237/1 mal rejimi sözleşmesi ile eşlerin farklı bir paylaşma esası kararlaştırabileceklerini düzenlemiştir. İşte MK 237/2 uyarınca, "Bu tür anlaşmalar, eşlerin ortak olmayan çocuklarının ve onların altsoylarının saklı paylarını zedeleyemez." Görüldüğü gibi koruma ölen eşin tüm saklı paylı mirasçıları için değil, sağ kalan eşten olmayan çocukları, bunlardan olan torunları ve varsa bunların çocukları içindir. Ortak çocuklar ve torunlar koruma dışıdır. Madde, çocuğun payının kendi anasına/babasına ve torunun payının kendi dedesine/büyükannesine kaçırılmasını sorun olarak görmemiştir. Bu düşünce eleştirilebilir. 1091

---

[690] Bak ileride § 23 IV 5

1092 Üvey ana ve babalara, üvey dede ve büyükannelere kanuna göre esas kabul edilenden daha fazla katılma payı veren sözleşmelere saklı payları ihlâl ettiği ölçüde itiraz edilecektir. Saklı payın ihlâl edilip edilmediği şu şekilde hesaplanacaktır: Tereke hesabı yapılırken eşlerin artık değere katılma payları MK 236/1 uyarınca normal durum olan 1/2 imiş gibi hesaplama yapılarak ölenin tenkise esas terekesi bulunacaktır. Buna göre alt soyun miras payı bulunduktan sonra, bu payın yarısı olan saklı payı bulunacaktır (alt soyun saklı payı miras payının 1/2'sidir). Ardından, eşlerin sözleşme ile kararlaştırdıkları artık değere katılma paylarına göre hesaplama yapılarak ölen eşin başkasından olan alt soyuna ne kadar miras payı düştüğü bulunacaktır. Bu miktar 1/2 katılma payına göre yapılan hesaplamadaki saklı payı karşılamadığı takdirde, bunu tamamlayacak kadar miktar sağ kalan eşin katılma alacağından indirilecektir[691]. Kanımca bu indirim katılma payını belirleyen eşler arasındaki sözleşmenin kısmi butlanı ile değil, miras hukukuna göre bir tenkis davası ile sağlanmalıdır[692].

1093 Durumu bir örnekte gösterelim: (M)'nin ölen eşi (A)'dan olan katılma alacağı normal durum olan 1/2 oranına göre hesaplansa 100.000 TL ise (M)'nin diğer malvarlığı da 60.000 TL ise, buna göre (M)'nin başkasından olan oğlu (B)'nin saklı payı = (100.000 + 60.000=) 160.000 x 3/4 = 120.000 x 1/2 = 60.000 TL'dir. (A) ve (M) anlaşarak (M)'nin katılma payını 1/8'e indirdikleri için (B)'nin miras payı: (25.000 + 60.000=) 85.000 x 3/4 = 21.250 olacağından; (B), (A)'ya karşı, 60.000 - 21.250 = 38.750 TL tenkis talebi ile (M)'nin katılma payını bu miktara çıkartabilecektir.

1094 Bir diğer örnek: (A)'nın ölen eşi (M)'den katılma alacağı olup bu normal durum olan 1/2 oranına göre hesaplansa 100.000 TL.'dir. Bu borç (M)'nin terekesini oluşturan 220.000 TL çıkınca = 120.000 TL kalmakta ve (B)'nin saklı payı = 120.000 x 3/4 x 1/2 = 45.000 TL olmaktadır. Oysa (A) ve (M) anlaşarak (A)'nın (M)'den olan katılma payını 4/5 oranına çıkarmışsa, (B)'nin miras payı: 220.000 - 160.000 (A'nın katılma payı) = 60.000 x 1/2 = 30.000 TL olmaktadır. Bu durumda (B), (A)'ya yönelteceği tenkis talebi ile onun katılma alacağını (45.000 - 30.000=) 15.000 TL indirecektir.

1095 Bu prensipler dışında, edinilmiş mallara katılma rejiminin –normal durumda– saklı paylara yapacağı bir etki yoktur[693].

---

[691] *Acar, F.*, 4721 sayılı Türk Medeni Kanununda Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi Bağlamında Eşin Yasal Miras Payının Belirlenmesi, Ankara, 2003, s. 114 vd.

[692] Aksi görüşte: *Acar*, a.g.e., s. 114.

[693] Yasal rejim olan edinilmiş mallara katılma sisteminde, sağ kalan eş ölen eşinin edinilmiş mallarının değerinin yarısını miras payı dışında ve yanında talep edebilecek; keza ölen eşin diğer mirasçıları da sağ kalan eşin edinilmiş mallarındaki ölen eşin payını ölüm sebebiyle doğan ve terekedeki paylarından ayrı bir alacak olarak ondan talep edebilecek-

Eşler MK 256 vd. hükümlerine göre "mal ortaklığı" rejimini seçmişler- 1096
se, MK 276 hükümleri bu rejimde karşılaşılacak özel bir durumda, saklı payları koruyan özel bir hüküm getirmektedir. Şöyle ki, mal ortaklığı rejiminde eşlerden birinin ölümü hâlinde ölenin "kişisel malları" normal miras hükümlerine göre intikal edecek iken, "ortaklık malları" önce kural olarak yarı yarıya olmak üzere bölüşülür ve böylece sağ kalan eşe giden yarı, terekeye dahil olmaz. Ölen eşe giden yarı ise, ölenin terekesine dahil olarak, miras hukuku hükümlerine göre taksim olunur. Böylece bu kısımdan sağ kalan eş kanunî miras payını alır. Ne var ki, MK 276/2, eşlerin aralarında yapacakları anlaşma ile, ortaklık mallarının yarı yarıya paylaşılmasından farklı bir paylaşmayı kararlaştırabileceklerini belirtmektedirler. Hatta bu hükme göre, eşler içlerinden biri ölünce ortaklık mallarının paylaşılmayıp tamamının sağ kalan eşe gitmesini kararlaştırabileceklerdir. İşte böyle durumlarda, sağ kalan eşe giden ortaklık malları tereke ve miras dışı kalacağından, ölen eşin diğer mirasçılarının bundan zarar görecekleri açıktır. Eski MK 222 ölen eşin sadece altsoyu için bu durumda onları koruyacak özel bir saklı pay getirmişti. Buna göre, ölüm anında mevcut ortaklık mallarının 1/4'ünden ölenin altsoyu yoksun bırakılamayacaktı[694]. Görüldüğü üzere, Eski Medeni Kanunumuzda altsoy dışındaki diğer saklı paylı mirasçıları (ana baba) koruyucu bir hüküm bulunmadığı gibi, altsoy da ortaklık mallarının 1/4'ü gibi düşük bir oranda korunmaktaydı. Bugün yürürlükte olan Medeni Kanunumuzun bunu karşılayan m. 276/3 hükmünde, koruma gene altsoyla sınırlanmakla birlikte, altsoyun saklı payı tam olarak korunmuştur. Şu halde, altsoyun saklı payı terekenin 1/2'si olduğuna göre, ölen eşin kişisel malları ile ortaklık malları tam yarı yarıya paylaşılsa ölen eşe düşecek malların değeri toplanacak ve bu toplamın 3/4'ünün (altsoyun miras payı) 1/2'si olan 3/8'i değerinde mal altsoya kalıncaya kadar, ortaklık mallarının sağ kalan eşe bırakılan kısmı geçersiz sayılacaktır. Belirtelim ki 1.1.2002 tarihinden önceki ölümlerde, ortaklık mallarının paylaştırılması anlaşmaları altsoy bakımından Eski Medeni Kanundaki 1/4 oranına tabi olacaktır[695]. İsviçre Federal mahkemesi, ortaklık mallarının paylaşımına dair sözleşmenin eşlerden birinin saklı paylı mirasçılarına zarar vermek yapıldığı açık ise, tarafların kararlaştırdığı taksim tarzının "hakkın kötüye kullanılması yasağı"na aykırı sayarak geçersiz kabul etmektedir[696]. Yargıtayımız ise, sağ ka-

---

lerdir. (Elbette bu borcun tereke hesabında önce çıkarılması sebebiyle, diğerleriyle birlikte katılma payı alacaklısı da azalmış bir terekede mirasçı olacaktır).

[694] Diğer bir deyişle, altsoyu olan eşin ölümü halinde diğer eşe ortaklık mallarının en fazla 1/4'ünün gideceği kararlaştırılabilecekti.

[695] Her ne kadar sözkonusu kural Medeni Kanunun Aile Hukuku kitabında yer almaktaysa da gerçekte Miras Hukuku hükmü olduğundan, mal ortaklığı sözleşmesinin yapıldığı tarihteki kanuna değil, sözleşmenin tarafının öldüğü tarihteki kanuna tabi olmalıdır.

[696] BGE 112 II 390; BGE 99 II 9. Böylece, yasal paylaşma oranı olan yarı yarıya "1/2 paylaşım uygulanacaktır.

lan eşin korunmasına büyük önem vermekte olup, dürüstlük kuralı[697] gerekçesiyle paylaştırma anlaşmasının geçersiz sayılamayacağı görüşündedir[698].

§ 21. Tasarruf Oranının Terekeye Göre Hesaplanması

I. GENEL OLARAK

1097 Tasarruf edilebilir tereke kısmının oransal olarak hesaplanmasının her miras intikalinde geriye kalan mirasçıların gene oransal olarak saptanacak saklı payları toplamına göre yapılacağını açıklamıştık. Burada tereke 1 tam sayı kabul edilerek, saklı paylar toplamını ifade eden kesirli sayının 1'den çıkarılması üzerine bulunacak bayağı kesir, tasarruf oranını ifade edecektir. Örneğin, bir olayda saklı paylar toplamı 3/4 ise, mirasbırakanın tasarruf oranı terekenin 1/4'ü demektir.

1098 Ne var ki bu oransal sonuç hukukî ihtilafları çözmeye yetmez. Tasarruf oranının terekenin kaç para değerindeki kısmını ifade ettiği bulunmalıdır ki, mirasbırakanın yaptığı bazı kazandırmaların tasarruf oranını aşıp aşmadığı saptanabilsin. Şu halde, soyut oransal hesaplamayı takiben, bu oranın tatbik edileceği terekenin toplam parasal değerini hesaplamak gerekir. Mirasbırakanın terekesi denilince akla önce mirasbırakanın öldüğü an bakımından sahip olduğu ve mirasçılarına intikal eden tüm hakları yani malvarlığının intikali mümkün aktifi gelirse de, tasarruf oranının hesaplanmasında gözönüne alınacak tereke unsurları bunlardan ibaret değildir. Yasa tasarruf oranı hesaplanırken bir dizi özel hüküm ile, mirasbırakanın ölümünde mevcut ve ekonomik değer taşıyan her türlü hakkının dışında bazı kalemlerin de terekeye eklenmesini öngörmüş; öte yandan bunun tersine, başka bazı kalemlerin ise terekedeki hakların toplam değerinden çıkarılmasını düzenlemiştir. İşte bu yüzden, tasarruf oranının uygulanacağı terekenin, mirasbırakanın geriye bıraktığı aktif değerler (haklar) toplamına başka bazı değerlerin eklenmesi ve bazılarının da bu toplamdan çıkarılmasıyla bulunacak kaydî-hesabî bir toplam olmasından hareketle, "fiktif (varsayımsal) tereke" de denmektedir[698a].

1099 Belirtelim ki, mirasbırakanın ölüm anına kadar mevcut fakat ölümle sona eren haklar, esasen tereke ile intikal etmeyeceğinden, hesaba katıl-

---

[697] Yargıtay Kararında hatalı olarak "iyi niyetli olmak" diye geçmektedir.

[698] Bak. 2.HD. 27.10 1986, E.1986/7867, K.1986/9356 (YKD 1987, S.6, s.846. Bu kararın ve İsviçre Federal mahkemesinin kararlarındaki eğilimin yorumu için bkz. *Kocayusufpaşaoğlu*, Ek Kitap, 22 vd.

[698a] Bu çıkarma ve eklemenin sadece kağıt üzerinde olmasına dayanan bu ifade için bak. *Serozan/Engin*, Miras Hukuku, 3. Baskı, § 3, N. 14.

mazlar. Örneğin, mirasbırakanın intifa hakkı,[699] oturma (sükna) hakkı, kişiliğine bağlı öncelikler (imtiyazlar) böyledir.

Yeni Medeni Kanunumuzun evlilikte yasal mal rejimi olarak kabul ettiği "edinilmiş mallara katılma" rejimine göre, ölümle biten evlilikte MK 236 uyarınca ölen eşin sağ kalan eşe karşı "artık değere katılma alacağı" varsa, bu miktar da mirasbırakanın (ölen eşin) terekesinde "alacak hakkı" olarak yer almalıdır. Bu alacağın ve karşılığı olan borcun ölüm üzerine doğduğu, mirasbırakanın sağlığında doğmadığı söylenerek tereke dışı bırakılması sözkonusu olmaz[700]. 1100

Bu terekenin hesaplanmasında mirasbırakanın malvarlığının aktifinde mevcut değerler, MK 507/II uyarınca, "mirasbırakanın ölümü günündeki" yani "mirasın açılma günündeki" parasal karşılıklarıyla değerlendirilecektir. Böylece, örneğin terekedeki bir malın mirabırakanın ölümünden önce daha iyi durumda olması veya mirasbırakanın ölümünden sonra hasara uğraması veya değerini kaybetmesi gözönüne alınmaz.[701] Keza, terekedeki malların parasal değerleri de mirasbırakanın ölüm anındaki piyasa durumuna göre hesaplanacak olup, daha sonra pahalılanması veya ucuzlaması gözönüne alınmaz. 1101

Mirasbırakanın bir alacak hakkının borçlusu mirasçılardan biri ise, mirasın intikali ile alacaklı ve borçlu sıfatlarının birleştiği ve (BK 135 uyarınca) borçlu mirasçının miras payı oranında bu alacağın ve karşılığı borcun sona erdiği söylenemez. Zira mirasın paylaşılmasına kadar elbirliği (iştirak) hâlinde sahip olunan bu alacağın borçlu mirasçıya ait bir kısmı yoktur. Ancak, paylaşma gerçekleşince bu alacak ve karşılığı borç, borçlu mirasçının miras payı oranında BK 135 uyarınca son bulur[702]. 1102

II. ÇIKARILACAK DEĞERLER

MK 507/II hükmü, tasarruf oranının hesaplanmasında terekeden çıkarılacak değerleri belirtmiştir. Bunlar, mirasbırakanın ardında bıraktığı malvarlığının ölüm anındaki toplam piyasa değerinden çıkarılacak kalemlerdir. Madde metnine göre bunlar, mirasbırakanın borçları, cenaze giderleri, terekeyi mühürlemek ve defter tutma (yazım) masrafları ve mirasbırakan ile bir 1103

---

[699] Buna karşılık, terekenin yükümlü olduğu intifa hakları mirasbırakanın ölümüyle sona ermeyip, intikal eden pasif bir değer olarak, mirasçıları yüküm altında tutmaya devam eder.

[700] *Acar, F.*, 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununda Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi Bağlamında Eşin Yasal Miras Payının Belirlenmesi, Ankara 2003, s. 123.

[701] *Acar*, a.g.e., s. 120.

[702] Tereke malına sonradan verilen bu tür zararlar tasarruf oranı ve tenkis hesaplarında gözönünde alınmamakla birlikte, buna kusuruyla sebep olanın eşya hukuku ve borçlar hukuku kuralları uyarınca sorumluluğu sözkonusu olabilir.

arada yaşayan ve onun tarafından bakılan kimselerin üç aylık iaşe masrafıdır.

1104 Bu kalemleri ayrı ayrı açıklayalım:

1. Miras Bırakanın Borçları

1105 Miras bırakanın borçları tereke aktifinden çıkarılacaktır. Zira bunlar borçlunun ölümü ile sona ermeyecek olup, sonuçta mirasçılar tarafından ödenecektir. Şu halde, mirasçılara intikal edecek tereke hisseleri üzerinden gerçekçi bir tasarruf oranı hesaplamak için, bunların ödenmesi için terekenin ne kadarlık kısmının elden çıkarılması gerektiği hesaba katılmalıdır. Borçların geçerli olmaları ve henüz ifa edilmemiş olmaları yeter. Vadelerinin gelmiş veya gelmemiş olmaları önem taşımaz. Ancak unutulmamalıdır ki, vadesi geçen borca temerrüt faizi yürümüş olacağından, mirasbırakanın ölüm anı itibariyle bu temerrüt faizi de indirime dahil olacaktır.

1106 Bozucu şarta bağlı borçlar da henüz şart gerçekleşmemişse indirime dahil edilecektir. Ancak, geciktirici şarta bağlı borçların indirilmemesi savunulmaktadır[703]. İrat borçları ve intifa yükümlülüğü için bunların sermaye değerlerinin indirilmesi kabul edilmektedir.[704] İhtilaflı borçların tahmini değerinin indirilmesini savunanlar varsa da[705] kanımca –ister borcun geçerliliğine ister miktarına ilişkin olsun- bu ihtilafın çözümü tasarruf nisabı hesaplanmasında bekletici mesele sayılmalıdır. Aynı sonuç geciktirici şarta bağlı borçlarda şartın beklenmesi için de kabul edilebilir[706].

1107 Buna karşılık, vasiyet borcu terekeden indirilmez.[707] Bu vasiyet borcunun şeklî anlamda bir vasiyetnameden veya bir miras mukavelesinden doğması fark etmez. Esasen tasarruf oranı hesaplaması mirasbırakanın ölümüyle doğan bu borçların ne ölçüde hüküm ifade edeceğini belirlemek için yapılmaktadır.

1108 İstisnaen, mirasbırakanın ölümü üzerine doğan borçlardan MK 674/II hükmündeki mirasbırakanın henüz eğitimlerini tamamlamamış veya engelli çocuklarına yapılacak ödemenin de tereke aktifinden çıkarılacağı kabul edilmektedir[708].

---

[703] *Oğuzman*, 219

[704] *Oğuzman,.219*; *İmre*, 368, 373.

[705] *Oğuzman*, 219

[706] Bu görüş, şartın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği belli oluncaya kadar tarafları borcun ifasını tehlikeye düşürecek davranışlardan kaçınma zorunda bırakan ve şartı ihlal eden temliki tasarrufları geçersiz sayan BK 150 hükmüne de dayandırılabilir.

[707] *Escher*, Art.474, N.10; *Kocayusufpaşaoğlu*, 376; *Oğuzman*, 219

[708] *Kocayusufpaşaoğlu*, 379; *Oğuzman*, 219; *İmre*, s.369

Gene, MK 614/II uyarınca ana baba veya büyük ana ve büyük baba ile birlikte yaşayıp emeklerini[709] veya gelirlerini onlara tahsis eden ergin çocuklara verilecek uygun miktardaki tazminat da terekeden çıkarılacaktır. 1109

Yeni Medeni Kanunumuzun evlilikte yasal mal rejimi olarak kabul ettiği, "edinilmiş mallara katılma rejimine göre, ölümle biten evlilikte MK 236 uyarınca sağ kalan eşin ölen eşe karşı "artık değere katılma alacağı" varsa; bu miktar ölen eşin terekesinden çıkarılmalıdır[710]. Her ne kadar bu borcun mirasbırakan sağken doğmayıp ölümü üzerine doğduğu söylenebilirse de tereke hesabında çıkarılacak borçlar arasında yer aldığından kuşku duyulmamalıdır. 1110

Mirasbırakanın ölümü ile sona eren borçların terekeden indirilmesi sözkonusu olmaz. Örneğin, vekilin iş yapma borcu ve müvekkilin ileride yapılacak işin bedelini ödeme borcu, BK 513 uyarınca istisnalar hariç vekalet taraflardan birinin ölümü ile sona ereceğinden, vekilin veya müvekkilin ölümü ile son bulacağı için ölen tarafın terekesinden indirilmez. 1111

2. Cenaze Giderleri

Mirasbırakanın cenazesinin defnedilmesi için yapılan bütün masraflar terekeden indirilir. Bu indirim kaleminin sebebi, ölenin cenaze masrafını kimsenin bu arada en yakın mirasçılarının bile bizzat ödemekle yükümlü tutulmamasıdır. Cenaze masrafları ölen kişinin terekesinden karşılanacaktır. Ancak, bu masrafların ölenin dinî ve sosyal durumuna göre nazara alınacak örf ve adete uygun masraflar olması gerekir. Makul cenaze töreni, mezar yeri, mezar taşı ve çevre duvarı[711], dinî tören, gömü hazırlıkları ve gömü yapılması, ölüm ilanı masrafları bu çerçevede kabul edilmektedir[712]. Buna karşılık, cenaze işlerini üstlenen mirasçı veya diğer yakınların normal olmayan, aşırı, abartılı cenaze masrafları (örneğin: büyük bir tören düzenleme veya gösterişli mezar inşası yahut çok pahalı gazete ilanları verme), terekeden indirilmez. Bu durumda makul masraf kadar bir indirim yapılır, bunun ötesi masrafı yapanın üzerinde kalır. 1112

Cenaze masrafları hem henüz yapılmamışsa fakat yapılacağı söylenebiliyorsa, hem de fiilen yapıldığı durumlarda, terekeden indirilir. Yapılmış 1113

---

[709] Yarg. 2.HD 25.10.1977, E.5634, K.7388 (İBD 1978, s.124).

[710] *Acar, F.*, 4721 Sayılı Yeni Türk Medeni Kanununda Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi Bağlamında Eşin Yasal Miras Payının Belirlenmesi, Ankara 2003, s. 120, 121.

[711] Yargıtayın, ölenin sosyal durumu ile örf ve adete uygun olsa bile mezar yaptırma bedelinin terekeden indirilemeyeceği hakkında bir kararı için bak: Yarg.2.HD 1.6.1961, E. 1585, K. 3116 (*Yazıcı/Atasoy*, s.872).

[712] *Kocayusufpaşaoğlu*, 377; *Oğuzman*, 219; *İmre*, S 369; *Serozan/Engin*, Miras Hukuku, 3. Baskı, § 3, N. 18; *Escher*, Art. 474, N.11; *Tuor*, Art.474, N.27

masrafın indirilmesi, bunu yapanlara mirasbırakanın bir borcu gibi düşünüldüğü içindir ki, indirime konu olmaktadır.

3. Terekeyi Mühürleme ve Defter Tutma (yazım) Masrafları.

1114 İleride belirteceğimiz üzere, mirasbırakanın son ikâmetgâhı sulh hakiminin MK 589, 590, 591 hükümleri uyarınca terekenin hak sahiplerine fiilen intikaline kadar korunması için alacağı tedbirlerden terekeyi mühürleme ve defter tutma[713], bazı masrafları gerektirir. İşte bu masraflar da terekeden düşülecektir.

4. Mirasbırakan İle Bir Arada Yaşayan Kişilerin Üç Aylık Geçim Giderleri

1115 Bu hükmün anlamı, mirasbırakan ölümü üzerine onun bakımını üstlendiği ve üstelik yanında tuttuğu bazı kişilerin aniden ortada kalmalarını önlemek, onlara kendilerine yeni bir hayat düzeni kurmak, çarelerine bakmak için üç aylık intikal süresi tanımaktır. Eski MK 454/II uyarınca bu süre bir ay idi. Kanımızca da üç aya çıkarılması isabetli olmuştur. Böylece, hem insanî bir anlayışın gereği yapılmakta hem de mirasbırakanın varsayımsal arzusuna ve anısına saygı gösterilmiş olmaktadır. Hemen belirtelim ki, MK 507/II hükmünün yanı sıra, terekenin paylaşılmasına ilişkin hükümlerden "Birlikte yaşayanların hakkı" kenar başlıklı m.645 hükmünde de bu kişilerin mirasçı olması şartı aranmamıştır. Şu halde, mirasbırakanın yanında barınan ve onun tarafından bakılan kimseler mirasçısı olmasalar bile, üç aylık geçim giderlerini terekeden alabileceklerdir. Belirtelim ki MK 645 hükmünün karşılığı olan Eski MK 585 hükmünde mirasbırakanla birlikte yaşayanlardan sadece mirasçı sıfatını taşıyanların bir aylık masrafının terekeden alınabileceği düzenlenmişti. Eski MK 454/II (MK 507/II) de bu doğrultuda yorumlanmakta ve böylece mirasbırakanla birlikte yaşayanlardan sadece mirasçı sıfatını taşıyanların bir aylık masrafının terekeden düşüleceği kabul edilmekteydi[714]. Bu sınırlamanın kaldırılması da isabetli olmuştur.

1116 Bir aylık bakım masrafının terekeden düşülmesi için bu kişilere mirasbırakanca bakılıyor, masraflarının karşılanıyor olması yetmez. Ölüm tarihine kadar mirasbırakanla aynı evde yaşıyor olmalıdırlar. Bu şartlar gerçekleşmişse, üç aylık bakım masrafları bu kişilerin hem beslenme hem de onla-

---

[713] Bak § 29 I 1,2

[714] *Escher*, Art.606, N.1; *Kocayusufpaşaoğlu*, 377, 378; *Oğuzman*, 219,220. Buna karşılık, ölüm anında mirasbırakanla yaşayanların mirasçı olmasalar da bir aylık süreden yararlanacakları görüşünde: *Şener*, 2.Bası, s.907 ve orada belirtilen Yarg. 2.HD 25.12.1980. 8542/ 9537 tarih ve sayılı karar; 2.HD. 7.2.1974, 8135/705 (YKD 1975, S.4, s.23. Bugün bu görüş yasalaştırılmıştır.

ra bu süre zarfında oturacak yer sağlama masraflarını kapsar[715]. Mirasbırakanın bu kişilere yasal olarak bakmakla yükümlü olması aranmayacağı gibi[716], bu kişilerin kendi bakımlarını ve barınmalarını sağlayacak imkânlara sahip olmamaları da aranmaz.

Şayet bu kişiler aynı zamanda mirasçı ise, alacakları üç aylık geçim masraflarını miras hisselerine mahsup etmeyeceklerdir. Zira bu talebe mirasçı sıfatıyla sahip olmadıkları için, ayrıca miras paylarını da tam olarak alırlar. 1117

III. EKLENECEK DEĞERLER.

Mirasbırakanın ölümü üzerine terekede mevcut mülkiyet hakları, sınırlı aynî haklar, alacak hakları vb. toplamına, tasarruf oranının hesaplanması bakımından, ayrıca bazı eklemeler yapılır. Bu eklemeler, herşeyden önce MK 669 uyarınca denkleştirmeye tabi kazandırmalar ile MK 508 ve 509 hükümlerinde belirtildiği üzere MK 560'da belirtilen mirasbırakanın sağken yaptığı bazı kazandırmalar ve MK 567'de belirtilen bazı hayat sigortalarının alım (iştira) bedelidir. 1118

Buna karşılık, Mirasbırakanın tenkise tabi ölüme bağlı tasarrufları, tenkis edilecek miktarın hesaplanması sırasında, terekenin aktifine eklenmezler (toplanmazlar). Zira bunlar henüz terekeden çıkmamış olduğundan, böyle bir toplama yanlış ve yanıltıcı sonuçlar verir. Tenkise tabi ölüme bağlı tasarrufların konusunu oluşturan değerler esasen terekede mevcut değerlerden karşılanacaktır. 1119

Şimdi terekeye eklenecek unsurları ayrı ayrı ele alalım:

1. Denkleştirmeye (iadeye) Tabi Kazandırmalar.

İleride açıklayacağımız üzere[717], mirasbırakanın MK 669 hükmünde belirtilen ve mirasçılarına yönelik olan bazı sağlararası tasarrufları, tasarruf oranını aşmamış olsa bile mutlak suretle terekeye iade edilecektir. Bunlara "denkleştirmeye (eski Kanunun ifadesiyle: iadeye) tabi kazandırmalar" denir. Kanunî mirasçılara miras paylarından indirilmek üzere (miras hisselerine mahsuben) mirasbırakanın sağlığında yaptığı kazandırmalar ve mirasbırakan tarafından aksi kararlaştırılmadıkca sağlığında altsoyuna yaptığı, çeyiz, kuruluş sermayesi ve borçtan kurtarmak gibi kazandırmalar, böyledir. Bunları denkleştirme bahsinde ayrıntılı şekilde ele alacağız. Şimdilik belirtelim ki, şayet denkleştirmeye tabi bir kazandırma bir sebeple denkleş- 1120

---

[715] *Escher*, Art 606, N.4; *Kocayusufpaşaoğlu*, 378; 220

[716] *Escher*, Art.606, N.3; *Kocayusufpaşaoğlu*, 379; *Oğuzman*, .220.

[717] Bak § 23

tirmeden kurtulmuş fakat tenkise tâbi ise, bunun değeri gene terekeye eklenecektir.

2. Tenkise Tâbi Sağlararası Kazandırmalar.

1121 Aslında mirasbırakanın yaptığı sağlararası kazandırmalar, miras hukukumuzun ana kurallarına göre tenkise tabi olmaz. Zira miras hukuku, kural olarak, kişinin sağken malvarlığından başkalarına devrettiği değerlerle değil, ölümünden sonra hüküm ifade etmek üzere yani mirasçılarına kalacak miras paylarını etkilemek üzere yaptığı "ölüme bağlı" kazandırmalarla uğraşır. Ne var ki, bu kuralı mutlak olarak benimsemek, tenkis yaptırımı ile korunmak istenen mirasçı çıkarlarının ölüme bağlı tasarrufa benzer etkiye sahip bazı sağlararası tasarruflarla hatta mirasbırakanın kasten bu niyetle yaptığı sağlararası tasarruflarla zarara uğramasını engelleyememek anlamına gelirdi[718]. İşte bu yüzden, yasakoyucu, istisnaen, mirasbırakanın yaptığı bazı sağlararası kazandırmaları da ölüme bağlı tasarruflar gibi tenkise tabi tutmuştur. Tenkise tabi tutulan bu kazandırmalar, tasarruf oranı hesabında terekeye eklenecektir. Diğer ifade ile, bunların değeri tereke aktifi ile toplanacaktır.

1122 Belirtelim ki, bu kazandırmaların değerlerinin terekeye eklenmesi için haklarında bir mirasçı tarafından tenkis davası açılmış olması aranmaz[719]. Burada yapılan sadece, tenkisi gereken bir kazandırma (saklı paylara tecavüz) bulunup bulunmadığını belirleyecek bir kağıt üzerinde hesaplamadır.

1123 Tenkise tabi sağlararası kazandırmalar şunlardır:

a) Denkleştirmeye tabi olması gerekirken bundan kurtulan kazandırmalar.

1124 Bunlar şu iki gurupta toplanır:

aa) Mirasbırakanın mirasçılık sıfatını kaybeden yasal mirasçısına miras payına mahsuben yapmış olduğu sağlararası kazandırmalar.

1125 MK 565/b.1 uyarınca, mirasbırakan bir yasal mirasçısına yasal miras payından düşülmesi şartıyla sağlararası bir kazandırmada bulunmuş fakat bu kişi mirasbırakanın ölümü anında bir sebepten mirasçılık sıfatını kazanamamışsa, bu kazandırmanın değeri tereke hesabında eklenecektir. Böylece, mirastan uzaklaştırılma (ıskat), yoksunluk (mahrumiyet), red gibi bir sebeple mirasçı olamayan kişi, esasen mirasbırakan tarafından hak kazana-

---

[718] *Kocayusufpaşaoğlu*, 380, 381; *Oğuzman*, 220; *Serozan/Engin*, Miras Hukuku, 3. Baskı, § 3, N. 29; *Escher*, Vorbem. zu Art.470-480, N. 15.

[719] *Oğuzman*, 601a.

cağı varsayılan miras hissesinin bir parçası olarak önceden kendisine verilmiş değeri, mevcut mirasçıların sakjlı paylarını ihlal ettiği oranda onlara vermek (tenkise tabi kılmak) zorundadır. Bu durumdaki kişiler esasen mirasçı sıfatını kazansalar idi denkleştirme ile yükümlü olacaklardı. Şu halde, bu tür kazandırmalar da tereke hesabında toplanacaktır. Zira tenkisten farklı olarak, ancak mirasçı sıfatına sahip olan bir kişinin MK 669 uyarınca denkleştirme yükümlüsü olması mümkündür. Mirasçı sıfatı bulunmadığı için denkleştirmeden kurtulan kazandırma lehdarının, bu kez hiç olmazsa tenkisle yükümlü olması istenmiştir. Eski MK 507/b.1 hükmünde bu durum açıkça ifade edilmemişti.

Bu çerçeveye giren kazandırmalarda değinilmesi gereken bir sorun, mi- 1126
rasçılardan birinin mirasçılık hakkını kaybetmiş olması hâlinde ona ilişkin denkleştirme yükümlülüğünün payını alana geçeceğini düzenleyen MK 670 hükmünün etkisidir. Zira, bu hükmün uygulanması sonucunda, denkleştirmeye tabi kazandırmayı iade yükümlüsünün mirasçılık sıfatını kaybetmesiyle denkleştirme yükümü sona ermemekte, sadece denkleştirme yükümlüsü değişmektedir. Bu ise, denkleştirmeye tabi iken bundan kurtulan kazandırmaların bu şıkta nasıl gerçekleşeceği sorusunu doğurur. Öğretide bu soruya cevap olarak, denkleştirme yükümlüsünün mirasın açılmasından önce veya sonra mirasçı sıfatını kaybettiği durumlarda, ancak yerine geçen (hissesini alan) denkleştirme yükümlüsünden bu kazandırma kısmen veya tamamen alınamıyorsa tenkis davasının sözkonusu olabileceği belirtilmektedir[720].

bb) Mirasbırakan tarafından denkleştirmeden muaf tutulduğu için denkleştirilmesi istenemeyen kazandırmalar.

MK m.565/b.1 hükmü, denkleştirmeye tabi olmamak üzere (geri veril- 1127
memek kaydıyla) altsoyuna malvarlığı devri, alışılmışın dışında çeyiz verme, kuruluş sermayesi sağlama veya borçtan kurtarma şeklindeki ölüme bağlı olmayan kazandırmaların da tenkise tabi olduğunu ifade etmiştir. Buna göre, MK 669 uyarınca denkleştirmeye tabi iken herhangi bir sebeple bundan kurtulan kazandırmaların bu kez tenkise tabi olduğunun ve bu sebeple tereke hesaplanmasında eklenmeleri gerekeceğinin düzenlendiği kabul edilmiştir[721].

---

[720] *Kocayusufpaşaoğlu*, 386, 387. Yazar bunları, iadenin/denkleştirmenin fiilen gerçekleşmediği her durum olarak değil, mirasçılık sıfatını kaybedenin yerine geçen mirasçıların hem iade borçlusu hem de iade alacaklısı olacağı durumlar ile gene bu yerine geçen mirasçıların tenkis davası açabilecekleri durumlar olarak belirtmektedir.

[721] Eski MK'da bu hükmün karşılığı olan 507/b.1 hükmünün kapalı anlatımına rağmen bu sonucun çıkartılması için bkz. *Kocayusufpaşaoğlu*.385 vd.; *Oğuzman*, 221 vd.; *Tuor*,

1128 Niteliği gereği denkleştirmeye tabi olduğu halde aksi kararlaştırıldığı için denkleştirmeden kurtulan kazandırmalar, bu kez tenkise tabi olacağından, tereke hesaplanmasında mevcut değerlere eklenecektir. İadeye ilişkin MK 669/II hükmü, mirasbırakanın altsoyuna yaptığı denkleştirmeye tabi kazandırmaların açıkça kararlaştırması şartıyla denkleştirmeden muaf tutulacağını düzenlemiştir[722]. İşte mirasbırakanın açık irade beyanı ile denkleştirmeden kurtardığı bu tip kazandırmalar bu kez tenkise tabi olacağından (mirasbırakanın denkleştirmeden farklı olarak tenkisi önlemeye yetkisi bulunmadığından), tasarruf nisabı hesaplanmasında tereke ile toplanacaktır.

1129 Eski MK düzenlemesinde, mirasbırakanın Eski MK 603/I uyarınca altsoy dışındaki mirasçılarına yaptığı iade kararlaştırılmaksızın gerçekleşen kazandırmaların da Eski MK m.507/b.1 çerçevesine girip girmediği yani tasarruf nisabı hesaplanmasında tereke toplamına eklenip eklenmeyeceği tartışmalıydı. Bazı yazarlar bunların da hesaplamada toplanmasını kabul ederken[723], Özellikle Türkiye'de baskın görüş, bunların denkleştirilmeleri kararlaştırılmış olmadıkça miras hisselerine mahsuben yapılmış sayılmayacaklarını düzenleyen Eski MK 603/I ifadesi karşısında, MK 507/b.1'e girmedikleri ve terekeye toplanmayacakları yolundaydı[724]. Yukarıda (aa) harfi altında açıkladığımız üzere, Yeni MK 565/b.1 hükmünün açık ifadesi karşısında artık bunların da terekeye toplanacağı tartışılmayacaktır.

1130 Eski MK zamanında yapılan kazandırmalar bakımından, baskın görüşe göre, sadece kazandırma lehdarının ekonomik bağımsızlığını kazanmasını veya devam ettirmesini sağlamak için yapılmışsa (:Eski MK 603 çerçevesine giriyorsa), iade edilmeyeceğinin kararlaştırılması Eski MK 507/b.1 çerçevesine girer ve bu sebeple terekeye ilave edilir[725]. Buna karşılık bir diğer görüş, mirasbırakanın yaptığı herhangi bir ivazsız kazandırmayı iadeden muaf tuttuğunu belirtmesinin MK 507/b.1 uyarınca tasarruf nisabı hesaplanırken terekeye toplanması gerekeceği şeklindedir[726]. Belirtelim ki Yeni MK 565/b.1 hükmünün açık ifadesi karşısında, artık bu görüş yasalaştırılmış olup mirasbırakan tarafından geri verilmemek kaydıyla yapılmış her malvarlığı devrinin terekeye toplanması gerekecektir.

Art.527, N.3-7; *Escher*, Art.527, N.7 vd.; *Eren, F.*, Türk Medeni Hukunda Tenkis Davası, Ankara 1973, 70 vd.

[722] Bu hükmü karşılayan Eski MK .603/II metninde "mirasbırakan tarafından aksi kararlaştırılmış olmadıkça.." demek yerine, "müteveffa tarafından hilafına açıkça bir teberru yapılmış olmadıkça .." şeklinde hatalı bir ifade yer almaktaydı.

[723] *Escher*, Art.527, N.10; *Tuor*, Art.527, N.4a, 5; JdT 1982 I 10

[724] *Kocayusufpaşaoğlu*, 338; *Oğuzman*, 221 Not 604a

[725] *Kocayusufpaşaoğlu*, 389; BGE 77 II 36; BGE 76 II 188; *Oğuzman*, 222

[726] *Gubler*, Die ausgleichungspflichtigen Zuwendungen, Bern 1941, 51 vd.

b) Mirastan ivazlı feragat hâlinde mirasçıya miras bırakanın hayattayken ödediği karşılık.

MK 565/b.2 hükmünde, "Miras haklarının ölümden önce tasfiyesi mak- 1131
sadıyla yapılan kazandırmalar" şeklinde belirtilen bu şıkta; bir mirasçıya mirastan feragat etmesi karşılığı miras bırakanın sağlığında yapılan kazandırma kastedilmiştir. Böylece, bu tür kazandırmalar da tereke hesabına eklenecek ve bu toplam üzerinden yapılacak tasarruf nisabı hesaplanması sonucu tenkisi gerekip gerekmeyeceği bulunacaktır. Nitekim, MK 573 hükmünde bunların tenkis edileceği açıkça düzenlenmiştir.

Örneğin, (M)'nin mirasçıları çocukları (A) ve (B)'dir. (M) sağlığında 1132
(A) ile ivazlı bir mirastan feragat sözleşmesi yapmış ve (A) 10 milyon Lira karşılığı ileriki miras hakkından feragat etmiştir.(A) 10 milyonu almış ve sonra (M) ölmüştür. (M)'nin terekesinde 2 milyon Lira çıkmıştır. Bu durumda, tasarruf oranı hesaplanmasında tereke 2 milyon + 10 milyon = 12 milyon Lira olarak kabul edilecektir. (B)'nin saklı payı= 12 milyon x 1/2 x 1/2 = 3 milyon Liradır. Terekede fiilen bulunan 2 milyonu (B) almakla birlikte, geri kalan 1 milyon Lira için (B)'ye karşı tenkis davası açabilecektir.

Belirtelim ki, mirastan feragat sözleşmesindeki ivaz henüz mirasçıya 1133
ödenmemişse, esasen terekeden çıkmadığı için, bu miktar hesaplamada tereke mevcuduyla toplanmaz.

Gene belirtelim ki, mirastan feragat sözleşmesi saklı paylı mirasçılar 1134
için sözkonusu olur. Saklı payı olmayan mirasçıların esasen mirasbırakanın tek yanlı tasarrufuyla tamamen miras haklarından yoksun bırakılmaları mümkündür.

c) Bağışlayanın serbestçe dönme hakkını saklı tutarak yaptığı bağışlamalar ve âdet üzere verilen hediyeler hariç ölümünden önceki bir yıl içinde yapmış olduğu bağışlamalar.

aa) Genel olarak

Bu hükümle birisi belirli süre sınırı içinde yapılmış olması gereken iki 1135
gurup bağışlama, tenkise tabi tutulmaktadır. İlk gurup, mirasbırakanın ölümünden önceki bir yıl içinde kalan her türlü bağışlamalar; ikinci gurup ise mirasbırakanın serbestçe dönme (kayıtsız şartsız rücû) hakkını saklı tutması şartıyla ne kadar eski olursa olsun yapılan tüm bağışlamalardır[727].

---

[727] Bu bağışlama çeşitlerini belirten Eski MK.507/b.3 hükmü, ifadesindeki bozukluktan ve özellikle gereksiz bir virgülden dolayı, yanlış anlaşılmaya yatkındı. Bend şu şekildeydi: "Bağışlayanın, kayıtsız ve şartsız rücua hakkı olan bağışlamalar ile âdet üzere verilen hediyeler müstesna olarak, vefatından evvelki bir sene içinde yapılmış bağışlamalar."

1136 İster bir yıl içinde ister dışında olsun tenkise tabi olmayacak bağışlamalar, "âdet üzere verilen hediyeler"dir. Burada kastedilenin, yılbaşı, doğum günü, evlilik yıldönümü, bayram, mezuniyet vb. özel günler ve olaylar sebebiyle verilen ve bağışlayanın malvarlığına uygun düşen hediyeler olduğu kabul edilmektedir[728]. Görüldüğü üzere, bu çerçeveye girdiği için tenkise tabi olmayacak hediyelerde iki unsur birlikte aranacaktır. Bu hediyeler, hediye vermenin ve almanın olağan olduğu bazı özel günler veya durumlar için verilmiş olmalı ve ayrıca hediye verenin ekonomik durumu bakımından makul sınırı da aşmamalıdır. Makul sınırdan maksat, hediye verenin malvarlığı durumu bakımından mirasçılarının menfaatini hissedilir şekilde zarara uğratmayacak büyüklükte hediyelerdir. Çok zengin bir işadamının okulunu bitiren yeğenine son model araba hediye etmesi makul görülebilecek iken; birikmiş parasının büyük kısmını harcayarak sevdiği kişiye ucuz bir araba alan memurun bu hediyesi makul görülmeyebilecektir.

1137 Adet üzere verilen hediye çerçevesini aşan bağışlamalarda, bağışlama sözleşmesinde mirasbırakan hiçbir gerekçe göstermeksizin ve zamanla sınırlı olmaksızın bağışlamadan dönme hakkını saklı tutmuş ise, bu bağışlamalar mirasbırakanın ölümünden yıllar önce yapılmış olsalar da tenkise tabidir ve tereke hesaplanmasında toplama dahil edilir.

1138 Şayet böyle bir hak saklı tutulmamışsa, mirasbırakanın ölümünden önceki bir yıl içinde gerçekleşmiş bağışlamalar, kesin şekilde tenkise tabi tutulmuştur. Bunların özellikle mahfuz hisseleri bertaraf kasdıyla yapılmış olması da aranmaz. Burada önemli taşıyan bu süre içinde miras bırakanın malvarlığından karşılıksız bir değer çıkması olduğundan; bağışlama vaadi daha eski tarihli olsa bile ifası ölümden önceki bir yıl içinde gerçekleşmişse, bu kazandırma da tenkise tabidir[729]. Örneğin, miras bırakan ölümünden iki yıl önce mahfuz hisseleri ihlal eden bir bağışlama sözleşmesi ile hisse senetlerini üçüncü kişiye bağışlamış fakat bunları bağışlanana ölümünden 11 ay önce teslim etmiş ise, bu bağışlama da tenkise tabi olacaktır.

1139 Buna karşılık, bağışlama vaadi ölümden önceki bir yıl içinde gerçekleşmiş olsa bile ölüm anında hâlâ ifa edilmemişse, bunun sağlararası işlem olarak tenkis edilip edilmeyeceği tartışmalıdır. Bir görüşe göre bunlar da MK 565/b.3 çerçevesinde tenkise tabidir.[730] Bir diğer görüşe göre bunlar

---

Bu yazılış biçiminden (özellikle ikinci virgül yüzünden), sanki bağışlayanın kayıtsız şartsız rücua hakkı olan bağışlamaların da tenkisi mümkün değilmiş gibi bir anlam çıkmaktaydı. Oysa ki, o zaman da sadece âdet üzere verilen hediyeler değil bağışlayanın kayıtsız şartsız rücua hakkı olan bağışlamalar ile ölümünden önceki bir yıl içinde yaptığı diğer bağışlamalar tenkise tabi tutulmuştu.

[728] Benzer örnekler için bkz. *Kocayusufpaşaoğlu*, 398, 399; *Oğuzman*, 222

[729] *Kocayusufpaşaoğlu*, 392; *Oğuzman*, 223

[730] *Kocayusufpaşaoğlu*, 392, 393; *İmre*, 417

sağlararası kazandırma sayılamazlar ve BK 290/2 hükmüne kıyasen "yerine getirilmesi bağışlayanın ölümüne bağlı bağışlamalar" gibi ölüme bağlı tasarruf hükümlerine göre tenkis edilmelidir[731].

Değinilmesi gereken bir diğer durum, karma bağışlamaların tenkisidir. 1140
Öğretide belirtildiği üzere bir karma bağıştan sözedebilmek için hem iki tarafın edimleri arasında önemli bir değer farkı bulunmalı hem de taraflar bu değer farkının bir tarafa kısmen karşılıksız kazandırmada bulunma amacıyla gerçekleştirildiği hususunda anlaşmış olmalıdırlar. Bunlardan ilkine karma bağışlamanın objektif unsuru, diğerine ise sübjektif unsuru denmektedir[732]. Öğretide belirtildiği üzere, böyle bir bağışlamanın da tenkisi sözkonusu olabilir ve burada tenkis daha değerli edimin karşılıksız sayılabilecek kısmı gözönüne alınarak yapılacaktır.[733] Örneğin, mirasbırakan (M) kısmen bağışlamada bulunmak amacıyla sevgilisi (Ü)'ye 100.000 liralık arabasını 50.000 liraya satmış ise, burada (Ü) ye 50.000 lira bağışlanmış gibi tenkis yapılacaktır[734]. Belirtelim ki öğretide karma bağışlamalarla gerçek hayatta hemen hemen daima MK 669 çerçevesinde denkleştirmeye tabi bir kuruluş sermayesi verme şeklinde karşılaşılacağı belirtilerek, bunların iadeden kurtuldukları ölçüde MK 565/b.1 çerçevesinde tenkise tabi olacakları ileri sürülmektedir[735].

Ölünceye kadar bakma sözleşmelerinde edimler arasında bakım alacak- 1141
lısı durumundaki mirasbırakanın aleyhine önemli fark varsa bu fark oranında kazandırmanın tenkise tabi olacağı, BK 615 hükmünde özel olarak düzenlenmiştir.

---

[731] İki görüş arasındaki en önemli pratik fark, tenkis hesabında sıralama bakımından çıkacaktır. Zira ölüme bağlı tasarruflar oransal olarak tenkis edilirken sağlar arası işlemler son tarihliden başlayarak tenkis edileceğinden (bkz. İleride § 23 IV), diğer tenkise tabi tasarrufların durumuna da bağlı olarak, bu tür bir bağışlamanın tenkisi gerekip gerekmeyeceği veya tenkis miktarı benimsenen görüşe göre değişebilecektir.

[732] Karma bağışlamalar hakkında bkz. *Akbıyık*, Karma bağışlama Kavramı ve Miras hukukunda Yeri, İstanbul 1997, 8 vd.

[733] *Kocayusufpaşaoğlu*, 393 vd.; *Oğuzman*, 224, 225; *Serozan/Engin*, Miras Hukuku, 3. Baskı, § 3, N. 47.

[734] Burada karma bağışlamanın varlığını belirleme bakımından ivazlar arasındaki değer farkının sözleşmenin yapıldığı andaki duruma göre gözönüne alınacağı kabul edilmektedir. (bkz.: *Kocayusufpaşaoğlu*, 397). Ne var ki, sonradan gerçekleşen değer oranı değişinlerinin tenkis miktarını nasıl etkileyeceği tartışmalıdır. Bu hususta, sonradan gerçekleşen değer farkının hiç önem taşımaması, satış anında ödenen bedel ile malın mirasın açıldığı tarihteki gerçek bedeli arasındaki farkın esas alınması ve kazandırma yapıldığı andaki malın gerçek değerinin sözleşmedeki ivaza oranını bulup malın mirasın açıldığı andaki değerine bu oranı uygulamak suratiyle çıkacak tutarı esas almak şeklinde üç ayrı görüş vardır. Sonuncu hesap tarzı en adil bulunarak çoğunlukça benimsenmektedir. Bu hususlarda bkz. *Kocayusufpaşaoğlu*, 397, 398

[735] *Escher*, Art.626, N.25 vd.; *Kocayusufpaşaoğlu*, 395 vd.

bb) Muvazaalı bir satışla gizlenmek istenen bağışlamalar

1142 Bağışlamaların tenkisine bağlı olarak uygulamada sıklıkla rastlanılan bir sorun, muvazaalı bir satışla gizlenmeye çalışılan bağışlamalardır[736]. Saklı paylı mirasçılarının tenkis davasını önlemek isteyen kişiler, yaptıkları ivazsız kazandırmaları çoğu kez satış gibi göstermekte, böylece sözde sattıkları mal karşılığında para almış sayılacaklarından, ilerideki tenkis davalarını önlemektedirler. Zira, mirasbırakanın malvarlığından yaptığı satışlar karşılığı terekeye para girmiş sayıldığından, kanunumuz gerçek bir satış sözleşmesiyle yapılan tasarrufları –ölümden bir gün önce yapılmış olsa bile- tenkise tabi tutmamaktadır. Böylece, örneğin evlilik dışı ilişki sürdürdüğü kadına veya çok sevdiği bir çocuğuna saklı pay kurallarını ihlal edecek kadar fazla kazandırmada bulunmak isteyen kişi, gerçekte ivazsız verdiği malı ona satmış görünmekte, böylece ölümünden sonra eşi ve diğer çocuklarının tenkis hakkını önlemiş olmaktadır.

1143 Bilindiği üzere, yapılan bir sözleşmeyi olduğundan başka gösterme şeklindeki muvazaalara "nitelikli"(mevsuf) muvazaa denir ve bunun normal sonucu görünürdeki işlemin muvazaa sebebiyle geçersiz olmasına karşın gizli işlemin geçerli sayılmasıdır[737]. Böylece, yaptığı bağışlama sözleşmesini satış gibi göstererek gizlemek isteyen mirasbırakanın asıl amacı ortaya çıktığında, normal olarak, yapmış göründüğü satış sözleşmesi geçersiz sayılırken gizlediği bağış sözleşmesi geçerli kalacaktır. Bu durumda, saklı paylı mirasçılar bu kazandırmayı bağışlama olarak tenkis ettireceklerdir.

1144 Belirtelim ki, muvazaalı işlemin tarafı olmayanlar muvazaanın varlığını her türlü delille ispat edebileceklerinden[738], tenkis haklarını kullanmak isteyen mahfuz hisseli mirasçılar göstermelik satış sözleşmesi şekle bağlı olarak yapılmış olsa da, yazılı bir delil bulmaya mecbur olmaksızın, tanık dinletmek dahil her türlü delille muvazaayı ispatlayabilirler. Uygulamada en sık rastlanan ispat biçimleri, özellikle tanık beyanları ile de desteklenmeleri hâlinde, şunlardır: Mirasbırakanın satmış göründüğü malı sözde satın alan kişinin ekonomik durumunun o sırada bu bedeli ödemeye uygun olmadığının anlaşılması[739]; sözde alıcının özellikle satıcı mirasbırakan ile ilişkisinin niteliğinin ona ivazsız bir kazandırma yapıldığını göstermesi[740]; miras bıra-

---

[736] Bunları karma bağışlamalarla karıştırmamalıdır. Karma bağışta yapılan karşılıksız kazandırma gizlenmeye çalışılmazken, burada ivazsız kazandırma göstermelik bir işlem arkasında gizlenmektedir.

[737] Bkz. *Oğuzman/Öz*, Borçlar Hukuku, Cilt 1, 12. Bası, s. 133, 134.

[738] *Oğuzman/Öz*, Borçlar Hukuku, Cilt 1, 12. Bası, s. 132.

[739] Mirasbırakanın çalışmayan ve bir geliri de olmayan hatta geçimini bizzat kendisinin sağladığı anlaşılan eşine hisse senetlerini satmış görünmesi böyledir.

[740] Mirasbırakanın kanserden ölümünden az önce uzun süredir yanında olup kendisine bakan çocuğuna evini satması böyledir.

kanın malını satmaya ve sözde alıcının da böyle bir malı o sırada satın almaya hiç ihtiyacı olmaması ve bunun mantıksız bir işlem olarak görülmesi. Bu hususların ispatı hâlinde hâkim yapılan kazandırmanın gerçekte bağışlama olduğuna karar vererek bunu tenkis edebilir. Ancak, davalı bütün bu hususlara rağmen gerçekten bedel ödediğini ispatlayabilir ise[741], artık muvazaa iddiası kabul edilemez.

Şayet yapılmak istenen kazandırma kanunen geçerlilik şekline tabi bir 1145
işlem olup bu işlem değil de ardına gizlendiği muvazaalı işlem şekle uyularak yapılmışsa; öğretide baskın olan ve uygulamada kabul edilen görüş, muvazaalı işlemin şeklinin gizli işlemi kurtarmayacağı ve gizlenmek istenen işlemin şekle aykırılıktan geçersiz olacağıdır[742]. Bu gibi durumlarla daha çok, mirasbırakanın bağışlamak istediği taşınmazı tapuda satmış görünmesi şeklinde rastlanır. Yapılan satış sözleşmesinin muvazaalı olduğu ispatlandığında, satış muvazaa sebebiyle geçersiz sayılacak, gizlenmek istenen bağışlama ise tapu sicilinde resmî şekilde yapılmadığından şekle aykırılıktan dolayı geçersiz olacaktır. Sonuç olarak, her iki kazandırma da geçerli sebebe dayanmadığından, tapudaki tescil baştan itibaren yolsuz ve mülkiyet esasen mirasbırakandan hiç çıkmamış sayılacaktır. Bu durumda, esasen mülkiyet olarak terekede mevcut ve kimseye de devri borçlanılmamış olan bu taşınmaz hakkında tenkise yer olmayıp, mirasçılar sadece MK 1025 uyarınca yolsuz tescilin düzeltilmesi davası açacaklardır. Böylece, sadece saklı paylara tecavüz eden miktar değil, saklı paya tecavüz olsun olmasın, tüm taşınmaz mirasçılara kalacaktır. Ayrıca, saklı paylı olmayan mirasçılar da bu davayı açabileceklerdir. Mirasçıların çıkarının mutlak şekilde korunduğu bu şıkta, onları bekleyen tek tehlike, onlar harekete geçinceye kadar taşınmazı iyi niyetle devralan üçüncü kişilerin iktisaplarının MK 1023 uyarınca korunmasıdır.

Genel sonuç bu olmakla birlikte, burada muvazaanın ispatının şekle ta- 1146
bi olup olmayacağı, mirasçıların saklı paylı olup olmamasının talebe etkisi ve mirasçıların iptal yerine tenkis talep etmelerinin sonucu, öğretide çeşitli görüşlerin ileri sürüldüğü tartışmalara yol açmaktadır.

Bu tartışmalardan önce, Yargıtayın bu konularla ilgili görüşlerini ve 1147
uygulamasını ortaya koyan Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 1.4.1974 Tarihli ve 1/2 Sayılı Kararı[743] ile gene Yargıtay İçtihadı

---

[741] Örneğin banka havalesi yaptığını ispatlar ve ödediği para terekede çıkar yahut bu paranın mirasbırakan tarafından ne şekilde kullanıldığına dair delil bulunur ise.

[742] *Von Tuhr/Peter*, § 35, III, 294 not 15A; *Esener*, MuvazaaTürk Hususi Hukukunda Muvazaalı Muameleler, Ankara 1956, 31; *Oğuzman/Seliçi*, Eşya Hukuku 6. Bası, 352; *Oğuzman/Öz*, Borçlar Hukuku, Cilt 1, s. 134; Yarg. İç.Bir.K. 1.4.1974, (RG 30.5.1974).

[743] RG Sayı 14900

Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 22.5.1987 Tarihli ve 4/5 Sayılı Kararındaki[744] sonuçları belirtelim. 1974 Tarihli İçtihadı Birleştirme Kararının eleştiriler doğrultusunda değiştirilmesi talebi, Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 16.3.1990 Tarihli ve 1/2 Sayılı Kararı[745] ile reddedilmiştir.

1148 1.4.1974 Tarihli İç. Bir. Kararına göre: görünüşteki satım sözleşmesinin muvazaalı olduğunu ve gizli bağışlama sözleşmesinin şekle aykırılıktan batıl olduğunu, saklı paylı olsun olmasın, her mirasçı tek başına ileri sürebilir ve tapu sicilinin düzeltilmesini isteyebilir. Fakat bu düzeltme, sadece bu davayı açan mirasçının miras payı kadar yapılacaktır. Kararda açıkça belirtilmemişse de, mirasçılarının külli halef sıfatıyla değil de sahip oldukları mirasçılık haklarının ihlali gerekçesiyle bu talebi ileri sürebileceklerinin kabulünden, muvazaanın taraflarına uygulanacak HUMK 290 hükmünün (=HMK. m. 201) burada uygulama alanı bulmayacağı, mirasçıların senede dayanma zorunluluğu olmadan her türlü delille (bu arada tanık beyanları ile) muvazaayı ispat edebilecekleri anlaşılmaktadır.

1149 Mirasçıları her bakımdan en ileri düzeyde koruyan bu görüşü benimseyenler[746], hileli bir işlemle mirasçılarına zarar vermek kasdıyla hareket eden mirasbırakana karşı, bu işleme maruz bırakılan mirasçıların mirasçılık haklarının mutlak şekilde ve ayrı ayrı (her biri tek başına dava açabilecek şekilde) korunmasının, adaletin ve Dürüstlük Kuralının gereği olduğunu ileri sürmektedir. Bu görüşe göre, bir takım şekli gerekçelerle onların bu haklarını ellerinden almak veya kullanmalarını güçleştirmek, ahlâka aykırı bir davranışı himaye etmek olur.

1150 22.5.1987 Tarihli İçtihadı Birleştirme Kararı ise, saklı paylı mirasçıların muvazaa ve şekle aykırılık sebebiyle tapu sicilinin düzeltilmesi talebi ile birlikte tenkis talebini aynı davada terditli olarak ileri sürebileceklerini, hatta bu iki talebin aynı mirasçı tarafından ayrı davalarda serbestçe ileri sürebileceğini kabul etmiştir. Buna göre, aynı mirasçı dava dilekçesinde önce tenkis ileri sürüp bu kabul edilmezse muvazaa sebebiyle tapu iptalini veya tersi bir sıralama ile bu ikisini talep edebileceği gibi; önce bu taleplerden biri için(örneğin tenkis için) dava açıp, bu davayı kazansız kazanmasın, daha sonra muvazaa sebebiyle tapu iptali davası açabilecektir.

1151 Hemen belirtelim ki, bu sonuçlar da öğretide çeşitli bakımlardan tartışma konusu olmakla birlikte, hemen herkes, önce tenkisi talep edip bu kabul

---

[744] RG Sayı 19595

[745] RG Sayı 19595; YKD 1990, S.7

[746] *Sungurbey*, Mirasbırakanın Muvazaası Durumuna İlişkin Yargıtay'ın 1.4.1974 gün, 1/2 Sayılı Doğru İçtihadı Birleştirme Kararı Değiştirilemez., YASA Der., 1989, S.6, 749 vd.

edilmezse muvazaa ileri sürme şeklinde bir terditin yapılmasını ve önce tenkis davası açılıp daha sonra muvazaa/şekle aykırılık sebebiyle dava açılmasını eleştirmektedir[747]. Zira, tenkis talep ederek sadece saklı payını geri almaya razı olduğunu birinci sırada belirten davacı, aynı maddi hususların (:gerçekte bağışlama yapıldığının) ispatını gerektiren ve daha kapsayıcı nitelikte olan muvazaa/şekle aykırılık sebebiyle geçersizlik iddiasını artık ikinci sırada ileri sürememelidir. Olsa olsa, önce muvazaa/şekle aykırılık gerekçesiyle tüm mülkiyet hakkının korunması ve ancak bu kabul edilmezse sadece mahfuz hissenin tenkisi şeklinde bir terdit veya dava sırası takip edilmelidir.

Saklı payı olmayan mirasçıların muvazaa gerekçesiyle serbestçe tapu iptali isteyememesi gerektiğini ve bunların ancak yazılı delille muvazaayı ispatlayabileceklerini öne süren hukukçular ise[748], şu hususlara dikkat çekmektedirler: Hukukumuzda mirasbırakanın tasarruflarına karşı sadece saklı paylı mirasçılar saklı payları oranında korunmuşlardır. Şu halde saklı paylı olmayan bir mirasçının mirasbırakanın muvazaalı işlemle devrettiği malı hususunda şahsına mahsus herhangi bir talep hakkı olamaz. Aynı şey, saklı paylı bir mirasçının saklı payını aşan tasarruf kısmı için ileri süreceği talep için de sözkonusudur. Bunlar, muvazaalı işlemle adına tescil yapılan üçüncü kişiye karşı, ancak mirasbırakanlarından küllî halefiyetle kendilerine intikal eden bir hakkı kullanabilirler, Mirasbırakanları ise, şekle tabi yapılan muvazaalı işlemin tarafı olarak, muvazaayı HMK m. 201 uyarınca sadece yazılı delille ispatlayabileceği için, onlar da ancak yazılı delile dayanarak muvazaayı ispatlayabileceklerdir[749]. Ayrıca, mirasbırakandan intikal eden butlanı ileri sürme hakkını miras ortaklığını oluşturan tüm mirasçıların Eski MK 581 uyarınca birlikte kullanması gerekeceğinden, içlerinden biri bile katılmazsa diğerleri tapu sicilinin düzeltilmesini –sadece kendi payları için dahî- dava edemeyeceklerdir. Şu kadar ki, miras ortaklığına bir temsilci tayin ettirilmişse, temsilci bu davayı tüm mirasçılar adına açabilecektir. 1152

---

[747] *Kocayusufpaşaoğlu*, Miras Hukuku Ek Kitap, 26, 27 (Yazar, tenkis davası açılırken muvazaa iddiasının saklı tutulmasını bile geçersiz saymaktadır); *Sungurbey*, YASA Der. Özel Sayı; 431 *Oğuzman*, Miras Hukuku 229 (Bu yazar tenkis davasından sonra muvazaa davası açılmasını imkân dahilinde görüyorsa da, bunun ancak, tenkis davasının bir saklı paylı mirasçı tarafından açılmasına karşılık muvazaa sebiyle sicil düzeltme davasının ancak tüm mirasçılarca birlikte açılması ve yazılı senetle ispat zorunluluğu bulunması şeklinde gerçekleşebileceğini belirtmektedir.

[748] *Oğuzman*, Miras Hukuku, 226 vd.; *Karayalçın*, Mirasçının Muvazaa Nedeniyle İptal Davası Açma Hakkı Var Mıdır?, YASA Der. 1989/1-4 Özel Sayı, 323 vd., Akipek'e Armağan, 1991, 209 vd.; *Kocayusufpaşaoğlu*, Ek Kitap, 26 vd.(Yazar sadece adıgeçen İçtihadı Birleştirme Kararına yönelik eleştirileri yansıtmakla yetinmiş görünüyorsa da, üslubundan ve özellikle bazı dipnotlarından (örneğin dip not 8, 14.) onun da bazı bakımlardan bu karara katılmadığı ve eleştirenlere yakın durduğu izlenimi doğmaktadır).

[749] Muvazaanın ispatı hususunda bkz. *Oğuzman/Öz.*, Borçlar Hukuku, 107

1153 Ancak, ileride açıklayacağımız üzere, Yeni MK 640/IV, "mirasçılardan her biri terekedeki hakların korunmasını isteyebilir, sağlanan korunmadan mirasçıların hepsi yararlanır" hükmünü getirdiğinden; artık bu görüş çerçevesinde de sadece bir mirasçının tapu sicilinin düzeltilmesi davası açabileceği ve sicilin tüm mirasçılar lehine düzeltilebileceği savunulabilir.

1154 Görüldüğü üzere bu görüş, mirasbırakanın muvazaalı olarak satış gösterdiği bağışlamalara karşı mirasçıların haklarını çeşitli yönlerden sınırlamaktadır. Bu görüşe göre böyle bir durumda, Yeni MK uyarınca artık mirasçıların hep beraber hareket etmesi gerekmediği söylenebilecekse de, muvazaayı gösteren yazılı delil bularak[750] tapu sicilini düzelttirmeleri uygulamada çok güç olacaktır[751]. Bu görüş çerçevesinde daha ziyade mümkün olacak koruma, sadece saklı paylı mirasçıların kanunen korunmuş saklı paylarına dayanarak açacakları tenkis davasında, muvazaa olgusunu her türlü delille ispat etmeleri karşısında[752], buna rağmen tenkis talebinin çerçevesine girmediğinden yolsuz tescilin düzeltilmesine gidilmeyip, saklı payları kadar taşınmaz hissesinin adlarına tescilini sağlamak olacaktır.

1155 Mirasçılara muvazaayı serbestçe ve her biri tek başına ileri sürerek tescili düzeltme imkânı tanıyan ve Yargıtayca benimsenmiş bulunan görüşün adalet duygusuna ve ahlâki duyarlılığa daha uygun gelmesine karşılık, onları muvazaayı ileri sürme bakımından mirasbırakanla aynı şartlara bağlayan ve sadece saklı payları özel olarak koruyan görüşün kanunun sistemine ve amacına daha uygun geldiği söylenebilir. Özellikle, şayet mirasbırakan böyle bir muvazaa yapmayıp açıkça malını bağışlasaydı ileri sürecek hiçbir hakka sahip olmayan saklı paysız mirasçıların ve saklı payları dışında bir şey talep edemeyecek olan saklı paylı mirasçıların, mirasbırakan muvazaaya başvurdu diye fazladan hakka sahip olmaları, Yargıtayın benimsediği görüşü tereddütle karşılamaya yeterlidir. Zira burada, bir tarafın (mirasbırakanın) ahlâki bakımdan kınanacak bir davranışını cezalandırmak için bir başkasına (mirasçılara) kanunun normalde tanımadığı haklar fazladan verilmektedir.

1156 Muvazaalı kazandırmalar bakımından Yargıtay'ın ilginç bir uygulaması

---

[750] Bu muvazaalı işlemi mirasbırakanları çoğu kez onlara karşı tasarladığı için, yazılı delil ele geçirmeleri imkânsıza yakın güçlükte olacaktır.

[751] Hatta daha da ileri giden bir görüş, mirasbırakan muvazaalı işlemi yaparak kasten şekle aykırılığa yolaçtığı için, kendi sebep olduğu şekle aykırılığı ileri sürmesinin dürüstlük kuralına aykırı düşeceği ve hakkın kötüye kullanılması sayılarak önleneceğinden bahisle; külli halefiyet sebebiyle onunla aynı durumda sayılacak olan mirasçıların, hep birlikte hareket etseler ve muvazaayı yazılı delille ispatlasalar bile, tapu sicilini düzelttiremeyeceklerini benimsemektedir. Bkz. *Kocayusufpaşaoğlu*, Ek Kitap, 29, 30

[752] Zira, tenkisin temel şartı olan gerçekte bağışlama yapıldığı hususunun ispatı, aynı zamanda muvazaanın da ispatı anlamına gelir.

da şudur: Bazı kararlarda, muvazaa davası açan mirasçının kendisine de muvazaalı veya açık bir bağışlama ile mirasbırakan tarafından kazandırmada bulunulduğu durumlarda, burada bir "paylaştırma" yapıldığı gerekçesiyle, dava reddedilmektedir[753]. Yapılan kazandırmaların değerlerinin birbiriyle uyumlu olduğu durumlarda adalete ve usul ekonomisine uygun görünen bu çözümün sağlam bir yasal dayanağı yoktur.

d) Vakıf kurmak için yapılan kazandırmalar.

MK 526 hükümleri, mirasbırakanın ister vasiyetname yoluyla ister sağ- 1157
lığında yapacağı işlemle kurduğu vakıflara tahsis ettiği malları tenkise tabi tutmuştur. Kurulacak vakfa özgülenen malvarlığı, vakıf kurucusu mirasbırakanın tasarruf oranını aşmamalıdır. MK 526'da bu sınırlama açıkça belirtilmiştir.

İşte, mirasbırakan böyle bir vakfı sağlığında resmî senet düzenlemek 1158
yoluyla kurmuşsa, bu vakfa tahsis ettiği malvarlığı da ölümü üzere tereke hesaplanırken toplanacak değerler arasındadır. Bu sonuç MK 565 hükmünden çıkmakta olup, tenkise tabi sağlararası kazandırmaları topluca belirten MK 565 hükümlerinde vakıf kurmanın belirtilmemiş olması bu niteliğini önlemez.

Vakıf kurmayı tenkise tabi kılan MK 565 hükmünde vakfın mirasbıra- 1159
kanın ölümünden ne kadar süre önce kurulmuş sayılması gerektiği hususunda bir hüküm yoktur. Acaba mirasbırakanın yaptığı bağışlamaları kural olarak ölümünden en fazla bir yıl önceye kadar yapılmışsa tenkise tabi tutan MK 565/b.3 hükmü vakıf kurma şeklindeki kazandırmalara da uygulanacak mıdır? Kanımca gerek bir hukukî işlemi ayakta tutacak yorumun tercih edilmesi kuralı gerekse mirasbırakanın vakıf kurmasını bir üçüncü kişiye bağışlamada bulunmasından daha az korumanın mantıksızlığı gözönüne alınarak; mirasbırakanın ölümünden önceki bir yıl içinde kalma şartı vakıf kurma işlemlerinde de aranmalıdır. Bu tarihten daha önce kurulan vakıflar, ancak, hemen aşağıda açıklayacağımız MK 565/b.4 çerçevesinde saklı pay kurallarını etkisiz kılma kastıyla kurulmuşsa, tenkise tabi olmalıdır.

Tenkis davası başarıya ulaştığı oranda Vakıf malvarlığının tenkise tabi 1160
kısmını davacıya vermek zorunda kalacak; kalan malvarlığı ile tüzel kişiliği devam edecektir. Şayet tenkis vakfın tüm malvarlığının verilmesini gerektiriyorsa, vakıf kişiliğini kaybedecektir. Zira MK 101 uyarınca vakıf esasen kişilik verilmiş bir malvarlığından ibarettir.

---

[753] 1. HD., E. 2004/7005, K. 2004/7526, t. 21.6.2004; 1. HD., E. 2011/7019, K. 2011/10389, t. 17.10.2011; 1. HD., E. 2011/2205, K. 2011/7825, t. 1.7.2011: (www.kazanci.com).

e) Saklı payı etkisiz kılma kastıyla yapılan kazandırmalar.

1161 MK 565/b.4 hükmü, "Mirasbırakanın saklı pay kurallarını etkisiz kılmak amacıyla yaptığı açık olan kazandırmalar"dan sözederek, bunların da tenkis edileceğini düzenlemiştir. Bu bende giren tasarruflarda yapılan işlemin tipi değil, hangi maksatla yapıldığı önem taşıyacaktır. Bu bakımdan, bu bendin kapsamına mirasbırakanın ölümünden önceki bir yıldan daha eski bağışlamalar girebileceği gibi, bu sürenin içinde veya dışında bağışlamadan başka bir yolla yapılan kazandırmalar da girebilir. Burada önem taşıyan, yapılan işlemin saklı payı ihlal etme kastıyla yapılmasıdır.

1162 Kastın sadece kazandırmada bulunan mirasbırakanda bulunması yeterli görülmektedir[754]. Kazandırma yapılanın da bu kasıtla davranması gerekmediği gibi, onun bu kazandırma sonucu müstakbel bir mirasçının saklı payının ihlal edileceğini bilmesi de gerekmez. Tenkis imkânının doğması için varlığı araştırılacak olan sadece kazandırmada bulunanın amacıdır. Bu isabetli bir görüştür. Zira, başkasından bağış kabul eden veya düşük bedelle mal satın alan kişilerin bağışlayan veya satıcılarının saklı paylı mirasçıları bulunduğunu, ileride öldüğünde geriye bırakacağı terekesinin mevcudu bakımından kendisine yapılan kazandırmanın onların saklı paylarına zarar vereceğini bilmesi, hem ender rastlanacak hem de ispatı çok güç bir durumdur. Böyle bir şartla MK 565/b.4'ün uygulama alanını sınırlamak yerine, sadece kazandırmada bulunanın niyetine göre tenkise izin vermek, maddenin amacına uygundur.

1163 Öte yandan, kazandırmada bulunanın amacı araştırılırken de genişletici bir yorum yapılmakta, onun bu kazandırmayı yaparken biricik maksadının saklı paylı mirasçılarına zarar vermek olması aranmamakta, sadece kazandırma sırasında yaptığı bu tasarrufun saklı paylı mirasçılarının bu paylarına tecavüz edeceğini bilmesi ve bunu göze alması yeterli sayılmaktadır[755]. Böylece, örneğin, özellikle hiç sevmediği karısının saklı payına zarar vermek maksadıyla mallarını sağlığında sağa sola dağıtan kişinin bu tasarrufları kadar, çok sevdiği bir dostuna güç durumunda yardım etmek için ona büyük miktarda bağışta bulunan ve bu davranışının istemese de karısının saklı payına ileride zarar vereceğini bilen ve bunu göze alan kişinin bu tasarrufu da MK 565/b.4 uyarınca tenkis edilebilecektir[756].

---

[754] *Escher*, Art. 527, N.24; *Kocayusufpaşaoğlu*, 400; *Oğuzman*, 230

[755] *Kocayusufpaşaoğlu*, 399; *Oğuzman*, 231; *İmre*, 481; *Köprülü*, 308

[756] Bununla birlikte, şayet kendisine karşılıksız kazandırmada bulunulan kişi kazandırmada bulunana (miras bırakana) dürüstlük kuralına göre bunu açıkça hak edecek derecede yararı dokunmuş biri ise, Yargıtay artık yapılan bu kazandırmanın tenkisini kabul etmemektedir. Örneğin, 2.HD. 7.2.1977 tarihli bir kararında, bir kimsenin hiçbir mecburiyeti olmadığı hâlde kendisine otuz yıl süreyle fedârca bakmış olan kimseye yaptığı kazandırmanın, ölümü üzerine mahfuz hisseli mirasçılarına zarar vermesine karşılık, BK m.

Kanımızca bu yorumda aşırıya kaçılması, MK 565/b.4 hükmünün ama- 1164
cına aykırı derecede tenkise konu tasarrufların alanını genişletir. Şayet herkesin kanunu bilmesi gerektiğinden hareketle herkesin mevcut saklı paylı mirasçılarının korunmuş haklarını bildiği kabul edilirse ve gene üçüncü kişiye bağışta bulunan herkesin malvarlığına bu bağışın yapacağı etkiyi de bilmesi gerektiği benimsenirse, tasarruf oranını aşan bir bağışlamada (veya başka bir kazandırmada) bulunan kişilerin yaptıkları bu işlemin hemen hemen daima MK 565/b.4 hükmüne göre tenkis edileceği sonucuna varılır. Oysa bu sonuç, sağlararası işlemler bakımından sadece mirasbırakanın ölümünden önceki bir yıl içinde yapılan bağışlamaları tenkise tabi tutan ve bu tarihten eski kazandırmaları istisnaî bir durum olarak ancak "saklı pay kurallarını etkisiz kılmak amacıyla" yapılmışsa tenkise tabi tutan yasanın sistemiyle bağdaşmaz. Bu bakımdan, mirasbırakan yaptığı kazandırmadan bir yılı aşkın süre sonra ölmüşse, kazandırma sırasında ileride saklı paylı mirasçılarına zarar vereceğini bilmesi gerektiğinden bahisle bu kazandırma MK 565/b.4 uyarınca tenkis edilememeli; saklı paylı bir mirasçısına zarar vermek onun biricik amacı olmasa bile hiç olmazsa bu mirasçısının saklı payına tecavüz edeceğini somut şekilde değerlendirerek gözönüne aldığı ve buna rağmen sözkonusu kazandırmayı yaptığı anlaşılmalıdır.

Belirtelim ki, özellikle bu kazandırmadan sonra mirasbırakanın malvar- 1165
lığı başka sebeplerle daha da eksilmiş ve sözkonusu kazandırma sonradan saklı paylara zarar verir duruma gelmişse, burada saklı payı ihlâl kastının varlığından sözedilemez[757].

Bu bendin çerçevesi her ne kadar bağışlama işlemleriyle sınırlanma- 1166
mışsa da saklı paya zarar verecek derecede tereke mevcudunu azaltan tasarruflar büyük çoğunlukla bağışlamalar olacaktır. Zira, satım sözleşmesi gibi karşılıklı edimler içeren bir sözleşme uyarınca yapılan kazandırmalarda karşı edim elde edileceğinden, bundan satıcının ve alıcının malvarlıklarının kayda değer ölçüde eksilmesi sonucu doğmaz.

Bu yüzden, MK 565/b.4 hükmünün uygulama alanı, büyük çoğunlukla, 1167
mirasbırakanın ölümünün bir yıl öncesinden daha eski tarihli yapıldıkları için MK m.565/b.3 uyarınca tenkis edilemeyen fakat saklı paylara zarar verme kastıyla yapıldıkları ispatlanabilen bağışlamalar olmaktadır. Öte yandan, mirasbırakanın ölümünden önceki bir yıl içinde yapılan ve saklı payı bertaraf etme amacı taşıyan bağışlamalar da MK 565/b.4 kapsamına girmekteyse de, bunları kastı ispat mecburiyetinde kalınmaksızın MK

507/b. 4 uyarınca tenkis edilemeyeceği sonucuna varmıştır. (bkz: YKD 1977, S.11, s.1525).

[757] *Oğuzman*, 231, 232

565/b. 3 uyarınca tenkis ettirmek çok daha kolay ve tercih edilen yol olacaktır.

1168 Uygulamada Şayet mirasçılardan mal kaçırmak için bağışlama sözleşmesi satış olarak gösterilmişse veya ölünceye kadar bakma sözleşmesi olarak gösterilmişse[758], bu hususun ispatı şartı ile, şayet işlem mirasbırakanın ölümünden itibaren bir seneden daha eski tarihli ise, saklı paylı mirasçılar görünüşteki satış sözleşmesine rağmen MK 565/b.4 uyarınca tenkis isteyebileceklerdir. Taşınmazlar hakkında yapılmış böyle bir muvazaada gizli bağışlama sözleşmesi şekle aykırılık sebebiyle geçersiz olacak ise de, saklı paylı her bir mirasçı bir başına açacağı tenkis davasında gene de tenkis sonucuna varacaktır. Burada Yargıtay'ın tenkisle birlikte veya sonradan gizli bağışın geçersizliği sebebiyle tapu sicilinin tamamen düzeltilmesinin de istenebileceği ve bu geçersizliği saklı paylı olmayan mirasçıların da her türlü delille ispatlayabilecekleri görüşü ile bu görüşe yönelik eleştirileri daha önce ayrıntılı olarak yansıtmıştık[759]. Bu tartışmalar MK 565/b.4 çerçevesine giren muvazaalı işlemler bakımından da aynı değere sahiptir. Bu açıdan aynı açıklamalara yollama yapmakla yetiniyoruz.

1169 Özellikle bu tür bir muvazaanın ispat edilmesi ve mirasbırakanın da bu muvazaayı yapması için saklı paylı mirasçılarına zarar vermek dışında makul bir sebebi[760] bulunmaması durumunda, artık saklı payları bertaraf kastının varlığı ispatlanmış sayılmaktadır[761].

3. Üçüncü Kişi Yararına Hayat Sigortası Alım Bedeli

1170 MK 509 ve 565 uyarınca, Mirasbırakanın sağlığında yaptığı bir hayat sigortası sözleşmesi uyarınca üçüncü bir kişi hak sahibi olmuşsa, bu sigortanın alım (iştira) değeri tenkise tabi olup hesaplama sırasında terekeye eklenecektir. Bu hüküm, mirasbırakanın primlerini bizzat ödediği bir hayat sigortası sözleşmesi ile üçüncü kişiye dolaylı olarak yaptığı bu kazandırmanın doğrudan ona yapılmış bir bağışlamadan farklı görülmemesine ve böylece aynı hukukî yaptırıma tabi olması gereğine dayanır.

1171 Mirasbırakan ölümünde sigorta bedelinin üçüncü kişiye ödeneceği

---

[758] Sonuncu durum için bak Yarg. 2.HD 31.10.1974, E.5750, K.6246 (İBD 1975, s.857); Yarg. 2.HD 2.2.1978, E.7866, K.762 (Yasa Der. Mayıs 1978, s.853). Böyle durumlarda Yargıtay kendisine bakılacak kişinin bakım ihtiyacı içinde olmamasını veya böyle bir ihtiyacı bulunsa bile bakım borçlusunun esasen ona bakmakla yükümlü olmasını (eşi olması gibi), muvazaanın ispatına yeterli delil saymaktadır.

[759] Bkz.§ 21 III 2 c bb

[760] Örneğin, alacaklılarının haciz tehdidinden dolayı mallarını onlardan kaçırmak için satması.

[761] *Kocayusufpaşaoğlu*, 400,401; *Oğuzman*, 230,231; *İmre*, 418; *Köprülü*, 308

hükmünü sözleşme yaparken koydurmuş olabileceği gibi, bu kişiyi sözleşmede saklı tuttuğu hakkına dayanarak sonradan da tayin edebilir. Ayrıca, mirasbırakanın doğrudan kendi lehine olarak yaptığı sigorta sözleşmesinden doğan hakkını sonradan alacağın temliki yoluyla üçüncü kişiye devretmesi de mümkün olduğu gibi, bu hakkını ölüme bağlı bir tasarrufla üçüncü kişiye vasiyet etmesi de mümkündür[762].

Ancak, hangi yol seçilirse seçilsin, üçüncü kişiye yapılan bu kazandırma ivazsız olmalıdır. Şayet bir ivaz (örneğin bir miktar peşin para) karşılığı üçüncü kişiye bu hak sağlanmışsa, nasıl satım sözleşmeleri –muvazaalı veya karma bağışlama niteliğinde olmadıkça- tenkise tabi değilse, bir tür hak satımı niteliği taşıyacak böyle bir kazandırma da tenkise tabi olmayacaktır. 1172

Bu hükümlere göre tenkise tabi olmak için, TTK 1493 uyarınca hayat sigortasında sigorta tutarının ödenmesi mirasbırakanın ölümüne bağlanmış olmalıdır. Mirasbırakanın belli bir tarihte hayatta olması hâlinde ödenecek hayat sigortaları ile mirasbırakandan başkasının ölümü üzerine ödeneceği kararlaştırılan hayat sigortaları, bu sözleşmeleri mirasbırakan yapmış ve primlerini ödemiş olsa bile, tenkise tabi değildir. 1173

Mirasbırakanın ölümü üzerine tenkise tabi olarak terekeye eklenecek tutar, MK 567 uyarınca, şayet sigortalı mirasbırakan ölüm anında hayatta olup da poliçeyi iade etseydi TTK 1500 uyarınca sigortacıdan alabileceği poliçe iade karşılığıdır. Yoksa lehdarın alacağı sigorta tazminatı değildir. Şunu da belirtelim ki, TTK 1500 uyarınca, en az bir yıllık prim ödenmeden önce sigortalının poliçeyi sigortacıya iade ederek alım (iştira) bedeli isteme hakkı doğmayacaktır. Böylece, henüz bu şart gerçekleşmeden mirasbırakan ölmüşse, ortada tenkise konu bir sigorta alım bedeli bulunmayacaktır. 1174

§ 22. Red – Çıkarılma – Feragat ve Yoksunluğun Etkisi

1. Reddin Tasarruf Oranı Üzerindeki Etkisi

Red[763] hâlinde, reddeden mirasçı ya da mirasçılar geçmişe etkili olarak, mirasbırakanın ölüm anından itibaren mirasçılık sıfatını kaybettiklerinden 1175

---

[762] *Escher*, Art.476 N.7; *Tuor*, Art.476, N.13; *Kocayusufpaşaoğlu*, 404 vd.; *Oğuzman*, 232; *Serozan/Engin*, § 3, N. 107 vd.
Belirtelim ki, şayet lehdar vasiyet yoluyla belirlenmiş ve hak sahibi kılınmışsa, burada sağlararası işlem değil ölüme bağlı bir tasarrufla yapılmış kazandırma sözkonusu olacağından, bu şıkta tenkis sırası ölüme bağlı tasarruflardaki gibi olacaktır. Bkz. s. 285 vd. Buna karşılık, lehdarın mirasbırakanın sağlığında sözleşmeye konulan bir şartla veya alacak temliki yoluyla hak sahibi kılınması durumlarında, lehdarın sigorta alacağı ancak mirasbırakanın ölümünde doğacak olsa bile, burada tenkise tabi olan bu alacak değil ölüm tarihi itibariyle poliçenin alım değeri olduğundan, ortada sağlar arası kazandırma vardır.

[763] Bkz. § 31

(MK. 611/I), tereke, reddeden sanki mirasbırakandan önce ölmüş gibi paylaşılır. Bu sebeple, saklı paylar ve tasarruf oranı reddeden mirasçı göz önüne alınmadan hesaplanır. Bunun, tasarruf oranı ve saklı paylara etkisi, reddedene halef olan kişilerin bulunup bulunmadığına; haleflerin saklı paylı mirasçı olup olmadıklarına ve saklı pay oranlarına göre farklı olacaktır. Örneklerle açıklayalım:

1176 a) M'nin ölümünde terekesi üç oğlu A, B ve C arasında paylaşılır. Buna göre her birinin miras payı 1/3 olur. Her birinin saklı payı ise (1/3x1/2=) 1/6'dır. M'nin tasarruf oranı ise 6/6 - (1/6 x 3=) 3/6, yani 1/2'dir. A'nın mirası reddettiğini ve altsoyu olmadığını varsayalım. Bu durumda miras B ve C arasında 1/2 oranında paylaşılacaktır. B ve C'nin saklı paylarının toplamı (1/2 x 1/2 x 2=) 1/2'dir. M'nin tasarruf oranı ise (2/2 –1/2=) 1/2 yani üç oğlunun da mirasçı olduğu durumla aynıdır. Bundan da anlaşılacağı gibi kök ya da zümre başları, halefleri olmadan mirası reddetmişlerse, aynı zümre ve hattaki saklı paylı mirasçıların miras paylarına bağlı olarak saklı pay miktarları artmakta, fakat mirasbırakanın tasarruf oranında bir değişiklik olmamaktadır.

1177 b) Aynı örnekte, mirası reddeden A 'nın D adında bir çocuğu olduğunu kabul edelim. Bu halde, A 'nın yerini MK 611/I 'e göre D alacağı için ne M'nin tasarruf oranında ne de B ve C ' nin saklı pay miktarlarında bir değişiklik olur. Yani B, C ve D'nin saklı paylarının toplamı (1/3 x 1/2 x 3=) 3/6= 1/2 edeceğinden; M'nin tasarruf oranı da yine 1/2 olur.

1178 c) M öldüğü zaman oğlu A ile annesi B hayattadır ve A mirası reddetmiştir. A, mirası reddetmeseydi, terekenin tamamını miras payı, 1/2'sini de saklı payı olarak alacak ve M'nin tasarruf oranı da 1/2 olacaktı. A mirası reddedince, birinci zümrede başka mirasçı olmadığı için, miras, ikinci zümre mirasçısı olan B'ye geçecektir. Bu halde, gene terekenin tamamı B'nin miras payı ise de, terekenin sadece 1/4'ü B'nin saklı payı olur. M'nin tasarruf oranı ise 3/4'e yükselir. Bundan da anlaşılacağı gibi, reddedenin yerini alan mirasçının saklı payı, reddedeninkinden az ise, mirasbırakanın tasarruf oranı, aradaki fark oranında artar .

1179 d) M'nin mirasçıları annesi A ve babası B ise de, A mirası reddetmiştir. M'nin kardeşi K, A'nın yerine mirasçı olmuştur. Red olmasaydı tereke A ve B arasında eşit olarak paylaşılacak ve ana babanın saklı pay oranları 1/4 olduğu için, her birinin saklı payı (1/4 x 1/2=) terekenin 1/8'sidir. M'nin tasarruf oranı, 8/8 - (1/8 x 2=) 1/4 olacaktı. A, mirası reddedince, yerini mirasçı sıfatı ile K alır. Ancak K, saklı paylı mirasçı olmadığı için, A'nın saklı payı M'nin tasarruf oranına eklenir ve tasarruf oranı (8/8-1/8=) 7/8 olur. Buna göre, reddedenin yerini saklı paylı olmayan bir mirasçı alınca, mirasbırakanın tasarruf oranı, reddedenin saklı payı oranında artar.

2. Mirastan Çıkarılmanın Tasarruf Oranı Üzerindeki Etkisi

Mirastan çıkarılmanın (ıskatın) tasarruf oranı üzerindeki etkisi retten 1180
tamamen farklıdır. Burada prensip, hesap yapılırken ıskat edilen mirasçının göz önünde bulundurulması ve sonra onun saklı payının mirasbırakanın tasarruf nisabına eklenmesidir. Bu prensip, "Mirasbırakan başka türlü tasarrufta bulunmuş olmadıkça, mirasçılıktan çıkarılan kimsenin miras payı, o kimse mirasbırakandan önce ölmüş gibi, mirasçılıktan çıkarılanın varsa altsoyuna yoksa mirasbırakanın yasal mirasçılarına kalır." Diyen MK. 511/II'den açık olarak anlaşılmaktadır. MK 511/III ise, bu kurala mirastan çıkarılanın altsoyunun bulunması hali için istisna getirmiştir. Önce kuralı sonra da istisnayı örneklerle açıklayalım.

a) M'nin mirasçıları oğulları A ve B ' dir. M, A 'yı mirasından çıkarmış- 1181
tır. Ana kurala göre A, sanki mirastan çıkarılmamış gibi göz önünde bulundurulup saklı payı M nin tasarruf oranına eklenecektir .Şöyle ki, A ve B'nin ', miras paylan 1/2'şer, saklı payları ise (1/2 x 1/2=) 1/4'erdir. M'nin tasarruf oranı ise, (4/4 –1/4 x 2=) 2/4, yani 1/2'dir. Ancak A mirastan çıkarıldığı için onun saklı payı M'nin tasarruf oranına eklenir ve tasarruf oranı (1/2 + 1/4=) 3/4 olur.

b) M'nin mirasçıları annesi A ile babası B olup, M, A 'yı mirasından çı- 1182
karmıştır. M şayet A'yı mirasından çıkarmasa, M'nin tasarruf oranı ana ve babasının (A ve B'nin) saklı payları toplamından (1/2 x 1/4 x 2 = 1/4) geriye kalan 3/4 oranı olacaktı. A'nın mirastan çıkarılması üzerine, yukarda açıklanan aynı prensip burada da yürüyecek, A'nın 1/2 miras payının 1/4'ü olan 1/8 saklı payı M'nin tasarruf oranına eklenerek (1/8 + 3/4=)onu 7/8'e yükseltecektir.

Görüldüğü gibi mirastan çıkarılma, retten farklı olarak, diğer mirasçıla- 1183
rın paylarında bir değişiklik yapmamakta, sadece mirasbırakanın tasarruf oranını artırmaktadır. Bu son söylenen husus, mirasbırakanın çıkarılan mirasçının saklı payı üzerinde tasarrufta bulunmuş olması hali için geçerlidir. Eğer mirasbırakan böyle bir tasarrufta bulunmamışsa, o zaman mirastan çıkarılanla aynı düzeyde mirasçı olanların paylarının miktar olarak artacağı MK. 511/II'den açık olarak anlaşılmaktadır.

Bu açıklamalar, çıkarılanın mirasbırakana da mirasçı olabilecek saklı 1184
paylı altsoyunun bulunması hâlinde uygulanmaz. MK. 511/III'e göre, bu durumda mirastan çıkarılanın altsoyu ona halef olur ve kendi saklı payını alır. Mirasbırakanın tasarruf oranının artıp artmayacağı, halef olan altsoyun saklı pay oranının çıkarılanla aynı olup olmamasına bağlıdır

a) M öldüğü zaman hayatta olan hısımları oğulları A ve B ile, A 'nın 1185
çocuğu C'dir. A, mirastan çıkarılmıştır. Çıkarma olmasaydı, miras A ile B

arasında eşit olarak (1/2) paylaşılacak ve saklı paylar toplamı (1/2 x 1/2 x 2=) 1/2, tasarruf oranı da (2/2 – 1/2=) 1/2 olacaktı. A ıskat edildiğine göre onun yerini altsoyu olan C alacaktır. C'nin saklı pay oranı A ile aynı olduğu için M'nin tasarruf oranında bir değişiklik olmaz, yine 1/2 olarak kalır.

1186 b) M'nin hısımları, annesi A, babası B ve kardeşi C'dir. A mirastan çıkarılmıştır. Çıkarılma olmasaydı miras A ve B arasında eşit olarak paylaşılacak ve saklı pay toplamları (1/2 x 1/4 x 2=) 1/4, tasarruf oranı da 3/4 olacaktı. A, mirastan çıkarıldığına göre yerini C alacak ve miras B ve C arasında 1/2 oranında paylaşılacak; B'nin saklı payı (1/2 x 1/4=) gene 1/8 iken, C'nin saklı payı bulunmadığından, tasarruf oranı (8/8-1/8=) 7/8 olacaktır. Görüldüğü gibi, bu halde, M'nin tasarruf oranı A'nın mirasçılığından kurtulduğu oranda artmaktadır.

3. Feragatin Tasarruf Oranı Üzerindeki Etkisi

1187 Durumu feragatin ivazlı yada ivazsız olmasına göre ayrı ayrı incelemek gerekir.

a) İvazlı feragatte

1188 MK 565/b.2'ye göre, ivazlı feragatte ivaz net terekenin hesaplanmasında terekeye eklenir. Böyle olunca da, feragat eden kişi, tıpkı çıkarılmada olduğu gibi terekenin paylaşılmasında göz önünde bulundurulur. Bunun sonucunda ise, feragat edenin saklı payının mirasbırakanın tasarruf oranına eklenmesi buna karşılık diğer saklı paylı mirasçıların paylarında bir değişiklik olmamasıdır. Ancak, hesap çıkarılmada olduğu gibi yapılmakla beraber, feragat edenin altsoyu, mirasbırakana karşı saklı paylı mirasçı olsa bile, MK 528/III'deki kural gereği bir şey alamayacaktır. Meğer ki, mirasbırakanın aksine bir iradesi bulunsun. Örneğin M, geride çocukları A, B ve C ile C'nin çocuğu D'yi bırakarak ölmüş, fakat ölmeden önce C ile bir ivazlı miras sözleşmesi yapmıştır. İvaz olarak C'ye 6 Milyon TL. vermiştir. Ölüm anında net tereke 12 Milyon TL.'dir. C'ye verilen ivaz terekeye ekleneceğine göre, tereke kağıt üzerinde 18 Milyon TL. olacaktır Bu durumda, A, B ve C'ye 6'şar Milyon TL. miras payı düşecek, saklı payları 3'er Milyon TL., tasarruf oranı da 9 Milyon TL. olacaktır. C mirastan ivazlı olarak feragat ettiği için, onun saklı payı M'nin tasarruf oranına eklenir, tasarruf nisabı 12 Milyon TL'ye çıkar. D ise, yukarıda da değinildiği gibi, MK 528/III gereği, aksine bir açıklama bulunmadıkça C'ye halef olamayacaktır.

b) İvazsız feragatte

1189 Belirtelim ki, İsviçre'de ivazsız feragat de ivazlı feragat gibi altsoyu etkilediği için, hesabın ivazlı feragatteki gibi yapılacağı çoğunluk tarafından

kabul edilmektedir[764]. Türk Hukukunda ise, ivazsız feragat altsoyu etkilemediği için (MK 528/III'ün zıt anlamından), hesabın mirastan çıkarılmadaki gibi yapılacağı kabul edilmektedir. Böylece, feragat edenin altsoyu MK 511/III'deki hükümden yararlanabilecek ve mirasbırakana karşı olan saklı payını isteyebilecektir[765].

4. Mirastan Yoksunluğun Tasarruf Oranı Üzerindeki Etkisi

Yoksunluk (mahrumiyet) hâlinde hesabın nasıl yapılacağı tartışmalıdır. 1190
Baskın görüş, yoksunluğun çıkarılmayı tamamlayan bir kurum olmasından hareketle hesabın çıkarılmadaki gibi yapılacağını savunur[766]. Azınlıktaki yazarlar ise, hesabın reddeki gibi yapılacağı görüşündedirler[767]. Bu görüşte olan yazarlar gerekçe olarak, mirasbırakanın yoksunluk sebeplerinden birini bilemeyeceğini (örneğin öldürülmesi), hatta bilse bile (örneğin sürekli olarak ölüme bağlı tasarruf yapamayacak hale getirilme) yeni bir tasarruf yapamayacağını göstermektedirler.

§ 23. Tenkis

I. KAVRAM

Yukarıda açıkladığımız ilke ve kurallar çerçevesinde mirasbırakanın yap- 1191
tığı bazı ölüme bağlı ve sağlararası kazandırmaların saklı payları ihlal ettikleri (=tasarruf oranını aştıkları) oranda etkisizleştirilmeleri, şayet henüz ifa edilmemişlerse mirasçıların bunları ifa borcundan kurtulması ve şayet ifa edilmişlerse bu oranda geri iadelerinin kararlaştırılmasına kanunumuzda "tenkis" dendiğini belirtmiştik[768]. Bu anlamıyla tenkis, bir dava hatta bir hukukî işlem olmayıp, gereken hukukî şartların gerçekleşmesi üzerine doğacak karmaşık ve çok yönlü bir hukukî sonuçtur. Bir diğer deyişle, miras hukuku hükümlerine göre tenkise tabi kazandırmalara karşı başvurulacak yolların, yapılacak işlemlerin ve doğacak sonuçların toplandığı bir çerçeve kavramdır. "miras hukukumuzun tenkise ilişkin hükümleri" ifadesi bunu gösterir.

Bunun yanında, uygulamada tenkisin sadece tenkis hükümlerine tabi bir 1192

---

[764] Azınlıkta kalan yazarlar ise, ivazsız feragatte hesabın reddeki gibi yapılacağını savunurlar. Bu konuda etraflı bilgi için bkz., *Çağa*, 144 vd.

[765] Etraflı bilgi için bkz., *Kocayusufpaşaoglu*, 410-411; Ayrıca *Oğuzman*, 234; *Serozan/Engin*, § 4, N. 198 vd.

[766] Bkz., *Kocayusufpaşaoğlu*, 411. dn. 7'de anılan yazarlar.

[767] Bkz., *Kocayusufpaşaoglu*, 411, dn. 8'de anılan yazarlar ve ayrıca *Oguzman*, 232.

[768] Yeni Medeni Kanunda pek çok miras hukuku terimi Türkçeleştirildiği halde, tenkis terimi uygun bir karşılık bulunamadığı için korunmuştur. Oysa, buna "indirim", davasına da "indirim davası" denebilirdi.

tasarrufta indirim/kesinti yapılmasını ifade edecek tarzda dar anlamda kullanıldığı da görülmektedir. " ..vasiyetin 1 milyar liralık kısmı tenkis edilecektir" ifadesinde tenkis bu dar anlamda kullanılmıştır.

1193 Genellikle tenkis kavramı, bir başına kullanılmaktan çok, içerdiği konuları tamlayan bir şekilde kullanılır. "Tenkis davası", "tenkis defi", "tenkiste sıra (tertip)", "tenkis hesabı", gibi.

1194 Bu ifadeler içinde en sık rastlanan kavram "tenkis davası"dır.Zira, MK 560 ve 571 hükümlerinden ve 560 ile başlayan (B) bölümünün başlığından açıkça anlaşıldığı üzere, tenkis kural olarak ancak dava yoluyla gerçekleşir. Sadece, henüz ifa edilmemiş kazandırma taahhütleri için açılan ifa davalarına karşı MK.571/III uyarınca tenkis defi yoluyla da ileri sürülebilir. Bu düzenlemeye uygun olarak, açıklamalarımıza tenkis davası ile devam edeceğiz.

II.TENKİS DAVASI

1. Niteliği

1195 Tenkis davası, kural olarak saklı paylı mirasçıların ve istisnaen de saklı paylı mirasçıların alacaklılarının, hâkimden mirasbırakanın tasarruf oranını aşan kazandırmalarının bu oranda etkisizleştirilmesini talep ettikleri davadır.

1196 Bu hâliyle tenkis davası yenilik doğuran bir dava niteliğindedir. Zira, bu davadaki talep doğrultusunda hâkimin vereceği kararla, mirasbırakanın yaptığı bazı kazandırıcı işlemler, mirasın açıldığı (mirasbırakanın öldüğü) tarihten itibaren (geçmişe etkili olarak) hüküm doğurmak suretiyle, kısmen veya tamamen geçersizleşmiş olacaklardır[769]. Burada miras hukukuna özgü özel bir iptal davası sözkonusudur. Buradaki iptalin, aile hukukundaki evliliğin mutlak veya nispî butlanındaki iptal kararından ve borçlar hukukundaki irade sakatlıkları ve gabin sebebiyle iptal durumlarından hatta yine miras hukukundaki ölüme bağlı tasarrufların ehliyetsizlik, iade sakatlığı ve şekil noksanı sebepleriyle iptaline ilişkin davalardan farkı, mirasçının ancak mirasbırakanın ölümü üzerine ileri sürebildiği bu talebi doğrultusunda mahkemece tenkis kararı verilinceye kadar, tenkise tabi işlemde her iki taraf için de hiçbir eksiklik ve sakatlığın bulunmamasıdır. Tenkis kararı ile, esasen bünyesinde kuruluşundan gelen bir aksaklık veya sakatlık bulunan bir işlem kesin geçersiz hâle getiriliyor değil, tamamen geçerli ve her iki ta-

---

[769] *Kocayusufpaşaoğlu*, 411,412; *Oğuzman*, 246; *Tuor*, Vorbem. Zu. Art.522-533; *Serozan/Engin*, Miras Hukuku, 3. Baskı, § 3, N. 83; Yarg. HGK 28.9.1979, 13-360/1269 (YKD 1980, S.7, s.907).

rafı da tam olarak bağlayan bir işlem yasanın getirdiği özel bir himaye sonucu, tenkis davası açma hakkına sahip kişi tarafından, kısmen veya tamamen, hükümden düşürülmektedir.

Bu hâliyle tenkis davasında verilen karar sadece yenilik doğuran bir ka- 1197
rar sayılacak ise de; şayet karara konu kazandırma fiilen yapılmışsa, örneğin sağlararası bir kazandırma (üçüncü kişiye elden bağışlama) sözkonusuysa, mahkeme kararının bu verilen şeyin –karara göre kısmen veya tamamen- iadesine yönelik bir eda hükmünü de kapsayıp kapsamadığı tartışmalıdır. Öğretide baskın görüşe göre, tenkis talebiyle birlikte veya sonradan ayrıca bir eda davasının da açılması gerekir.[770] Bu eda davasının dayanağının sebepsiz zenginleşme mi olacağı, miras sebebiyle istihkak davası[771] mı olacağı yoksa tenkis kararına dayanan özel bir eda davası mı olacağı tartışılmaktadır.[772] Buna karşılık, öğretide zayıf olmakla birlikte uygulamada Yargıtayın benimsediği görüş[773], Tenkis davasındaki talebin zımnen eda talebini de kapsadığı doğrultusundadır. İkinci görüşü teknik olarak savunmak çok güçse de birinci görüşe nispeten çok daha pratik olduğu açıktır.

Tenkis davası ancak mirasbırakanın ölümü hâlinde açılabilir. Saklı pay- 1198
lı mirasçılar, henüz mirasbırakan sağken, yapılan kazandırmanın mahfuz hisselerini bertaraf ettiği kesin olsa ve onun ölümü beklenirse telafisi imkânsız zararlar doğacak olsa (örneğin bağışlanan malı veya parayı zaman kaybedilirse geri almak imkânsızlaşacak olsa) bile, tenkis davası açamazlar. Herhangi bir gerekçeyle ihtiyatî tedbir talebinde de bulunamazlar[774]. Onların hakları kesin şekilde mirasbırakanın ölümüne bağlıdır. Böylece bir eş veya evlat, ileride kendi miras haklarını tamamen etkisizleştirecek şekilde varını yoğunu başkasına bağışlayan eşinin veya babasının bu tasarrufuna karşı harekete geçmek için ölümünü beklemek zorunda olacaktır.

---

[770] *Escher*, Art.528, N.2; *Tuor*, Art.528, N.2; *Oğuzman*, 246.

[771] Bkz. § 36.

[772] Bu tartışmalar için bkz. *Tuor*, Art.528, N.2; *Escher*, Art.528, N.2; *Kocayusufpaşaoğlu*, 412; *Eren*, Türk Medeni Hukukunda Tenkis Davası, Ankara 1973, 175; *Yavuz*, Miras Hukukunda Tenkisten Sonra Tenkis Konusunu Geri Verme (İade) Yükümlülüğü, İHFM, C.LL, s.1-4, İstanbul 1986, 261 vd.

[773] *Şener*, Eski ve Yeni Miras Hukuku, Ankara 1988 C.I, 621; *Postacıoğlu*, Medeni Usul Hukuku Dersleri, 5. bası, İstanbul 1970, 243; Yarg.2.HD. 24.5.1983, 4525/4669 (YKD 1984, S.10, s.1485)

[774] Şayet kazandırmada bulunanın bu tutumu aynı zamanda onun müstakbel mirasçılarına (örneğin, eşine ve çocuklarına) karşı aile hukukundan doğan yükümlülüklerini yerine getirememesine sebep oluyorsa, bu kişilerin şahsın hukuku ve aile hukuku kuralları çerçevesinde haklar talep etmeleri, örneğin şartları gerçekleşmişse nafaka veya bu kişinin kısıtlanmasını istemeleri mümkündür. Fakat bu tedbirlerin miras hukukuyla ilgisi yoktur.

2. Tarafları

a) Davacılar

aa) Saklı paylı mirasçılar.

1199 Kural olarak tenkis davasını açabilecek olanlar MK 560/I uyarınca sadece saklı paylı mirasçılardır. Saklı payın anlamını ve saklı paylı mirasçıların kimler olduğunu daha önce açıklamıştık[775]. Mirasbırakana bu derecelerde yakın olmadıkları için saklı paylı olmayan mirasçılar (örneğin kardeşler, kardeş çocukları) tenkis davası açamayacakları gibi, saklı pay tanınan derecede mirasbırakanın yakını olsa bile kendisinden önce gelen bir mirasçı sebebiyle esasen miras hakkını kazanamayanlar da tenkis davası açamaz (örneğin: annesi sağ olduğu için anne annesine mirasçı olamayan torun).

1200 Tenkis davası açma hakkı münhasıran her bir saklı paylı mirasçıyı koruyan bir hak olduğundan, gerek miras şirketine tayin edilen temsilci gerekse vasiyeti yerine getirme görevlisi (vasiyeti tenfiz memuru) bu davayı açma yetkisine sahip değildir[776].

1201 Davayı her saklı paylı mirasçı diğerlerinden bağımsız olarak bir başına açabilir. Bu takdirde, tasarruf oranına tecavüz miktarı aşağıda açıklayacağımız üzere tüm saklı paylar gözönüne alınarak hesaplanacaksa da, böylece bulunacak tenkisi mümkün tutarın tümü değil sadece dava açan mirasçının saklı payını karşılayacak kadarı tenkis edilecektir. Dolayısıyla, dava açmayan saklı paylı mirasçılar bu tenkis kararından yararlanamayacaktır. Böylece, tenkise tabi kazandırma lehdarı onların bu davayı açmamalarından yararlanacaktır.

1202 Şayet saklı paylı mirasçının fiil ehliyeti yoksa, örneğin küçük yaşta bir çocuksa, tenkis davasını kanunî temsilcisi onun adına açacak, bunu ihmâl ederse veli veya vasinin sorumluluğuna dair hükümler çerçevesinde sorumlu olacaktır.

1203 MK 560/I hükmünün ifadesinden sonuç çıkarılarak, şayet mirasbırakan saklı paylı bir mirasçısına bazı kazandırmalarda bulunmuşsa, onun saklı payına tecavüz edilip edilmediği hesaplanırken bunların da gözönünde bulundurulması kabul edilmektedir[777]. Saklı paylı mirasçının hissesine mahsup etmesi gereken kazandırmalar, ölüme bağlı olsun sağlararası olsun tenkise tabi kazandırmalar[778] ve denkleştirmeye tabi kazandırmalardır.[779] Fakat

---

[775] Bkz. § 19, § 19 I. 5650 SK'nun yayınlandığı 10 Mayıs 2007 tarihine kadar kardeşlerin de miras paylarının 1/8 oranında saklı paya sahip olduklarını hatırlatalım.

[776] *Oğuzman*, 247,

[777] *Kocayusufpaşaoğlu*, 413, 414; *Oğuzman*, 248; *Tuor*, Art.522, N.5; *Escher*, Art. 522, N.3; *Serozan/Engin*, § 3, N. 90.

[778] Bkz. § 21 III 2

bunlar dışındakileri mahsup etmek zorunda değildir. Böylece, örneğin, saklı paymа 1 milyon lira tecavüz edilen mirasçı, mirasbırakanı tarafından kendisine hissesi dışında 1 milyon lira vasiyet edilmiş veya mirasbırakanın ölümünden önceki bir yıl içinde ondan 1 milyon Lira bağış kabul etmişse, tenkis davası kabul edilmeyecektir. Buna karşılık, aynı mirasçı mirasbırakanın ölümünden geriye doğru bir yıldan daha eski tarihte bir milyon Lira bağış almışsa, bunu hesap dışı tutup ayrıca bir milyonluk tenkis davası açabilecek ve mirasbırakanın üçüncü kişilere yaptığı tenkise tabi kazandırmaları bu miktarda tenkis ettirebilecektir[779a].

Şayet saklı paylı mirasçıya yapılan kazandırma bir intifa hakkı veya irat 1204
alacağı ise, gene hem bunları elinde tutup hem de almamış gibi tenkis isteyemeyecekse de, bu kazandırmaları reddederek saklı payı kadar tenkis isteyebileceği kabul edilmektedir.[780] Burada mirasçıya seçimlik bir imkân tanınmasının sebebi, niteliği bakımından hemen paraya veya başka bir malamenfaate çeviremeyeceği bu kazandırmalara razı olmaya ve bunların farazî değeri kadar saklı payından mahrum kalmaya zorlanmasının adil olmamasıdır.

Tenkis davasını sınırlayan bir başka husus, MK 560/II uyarınca, miras- 1205
bırakanın aksini amaçladığı anlaşılmadıkça, ölüme bağlı tasarrufunda mirasçıların hisselerine ilişkin olarak kararlaştırdığı hükümlerin bir kazandırma değil sadece paylaştırma kuralı (alelâde taksim kaidesi) sayılmasıdır. Buna göre, şayet mirasbırakan vasiyetnamesinde hangi mallarının hangi mirasçısına verileceğini belirtmişse, vasiyetnamedeki ifadelerden aksi anlaşılmadıkça, onların yasal paylarını değiştirmeden sadece kimin neyi alacağını düzenlemiş olacaktır. Örneğin, Mirasbırakan (M) vasiyetnamesinde Etilerdeki dairesini oğlu (A)nın, Suadiyedeki dairesini ise kızı (B)'nin alacağını belirtmişse; Etilerdeki dairenin 350 bin lira Suadiyedeki dairenin ise 100 bin lira değerinde olması hâlinde, (M) oğlu (A)'ya 250 bin liralık bir kazandırma yapmak istemiş sayılmayacak, sadece paylaştırma kuralı getirmiş sayılarak, Etilerdeki daireyi alan (A)'nın Suadiyedeki daireyi alan (B)'ye 125 bin lira denkleştirme parası ödemesi gerekecektir. Bu çözümde esasen tenkise konu bir kazandırma yoktur. Ancak, (M) vasiyetinde Etilerdeki daireyi alan (A)'nın "değer farkından dolayı (B)'ye hiçbir ödeme yapmayacağını" da belirtmişse veya aynı anlama gelecek şekilde, örneğin, "her zaman bana çok daha yakın ve saygılı olan Oğlum (A)'ya bu davranı-

---

779 Bkz. § 24 IV

779a Ancak, Yargıtayın bazı kararlarında tarihine bakılmaksızın hatta muvazaalı olsa da bazı kazandırmaların diğer mirasçıya yapılan aynı nitelikteki kazandırmalar karşısında "paylaştırma" sayılarak geçerli tutulduğunu belirtmiştik. Bak. s. 258.

780 *Kocayusufpaşaoğlu*, 414; *Oğuzman*, 248 not 663; *Eren*, Tenkis Davası, 53; BGE 70 II 146

şından ötürü Etilerdeki dairemi bırakıyorum" demişse, bu durumda (A)'ya alacağı dairenin değer farkı (250 bin lira) kadar ölüme bağlı kazandırmada bulunmuş demektir. Bunun (B)'nin saklı payına tecavüz edip etmediği bulunacak ve eden miktar kadarı ancak (B)'nin açacağı bir tenkis davası ile istenebilecektir[781].

1206 Belirtelim ki MK 560/II getirdiği karinenin aksinin "tasarruftan anlaşılması"nı aradığı için, tasarruf metninden anlaşılmayan bir kazandırma maksadının bu metnin dışındaki olgularla ve delillerle ispatlanması kabul edilmemelidir. Sözgelimi, vasiyetname metninde sadece paylaştırma kuralı gibi görünen hükmün aslında bir mirasçıya diğerinden fazla şey vermeyi amaçladığı mirasbırakanın hatıra defterine veya sağlığında bu doğrultudaki konuşmalarını duyan tanıklara dayanılarak ileri sürülemez.

bb) Saklı paylı mirasçıların alacaklıları ve iflas masası

1207 MK 562, saklı paylı mirasçıların dışında, istisnaen, onların alacaklılarının da tenkis davası açabileceklerini düzenlemiştir. Esasen saklı paylı mirasçılar dışında tenkis davası açabilecek olan tek kategori, alacaklılarıdır. Kanun bir saklı paylı mirasçının tenkis davası açarak saklı payına tecavüz oluşturan kazandırmayı istemekten nasılsa alacaklısı tarafından haczedileceği düşüncesi ile kaçınması ihtimaline karşı, alacaklısını korumuştur.

1208 Bu alacaklıların dava açma hakkı, saklı paylı mirasçılara göre bazı bakımlardan sınırlıdır:

1209 İlk olarak, bunlar ancak alacaklısı oldukları saklı paylı mirasçı hakkında ellerinde aciz vesikası varsa tenkis davası açabilirler. Aciz vesikası mirasın açıldığı tarihte bulunmalıdır. Şayet aciz vesikası miras açıldıktan sonra alınmışsa, borçlu mirasçı aleyhine mahkeme kararı ve icra takibi daha önce gerçekleşmiş olsa bile alacaklı tenkis davası açamaz.

1210 Saklı paylı mirasçı iflas etmişse, bu takdirde her bir alacaklı değil ancak iflas masası tenkis davası açma hakkına sahiptir.

1211 İkinci olarak, alacaklılar ve iflas masası ancak saklı paylı mirasçıya tenkis davası açması için bir süre verip bunun verimsiz geçmesi üzerine tenkis davası açabilirler. Verilecek sürenin "uygun süre" olması gerekecektir. Durum BK 123 hükmündeki borçlu temerrüdünde ifadan vazgeçmek için verilen önelde olduğu gibidir.[782] Oradaki görüşümüze paralel olarak,

---

[781] Burada tereke 350 bin + 100 bin = 450 bin Tl olup (B)'nin miras payı 225 bin lira olduğundan; Mahfuz hissesi bunun 1/2'si kadar yani 112.500 liradır ve bu miktarı tamamlamak için (A)'ya 12.500 liralık bir tenkis davası açabilecektir.

[782] Bu hususta bkz.: *Oğuzman/Öz*, Borçlar Hukuku, Cilt 1, s. 517 vd.

kanımızca, verilen süre uygun değilse kendiliğinden uygun süre kadar uzamamalı, alacaklı geçersiz süre vermiş olarak tekrar doğru dürüst süre vermedikçe tenkis davası açma hakkı doğmamalıdır.

Kanımızca, gene BK 124/b.1 hükmüne kıyasen, şayet saklı paylı mirasçının tutumundan ve beyanlarından süre vermenin yararsız olacağı kesin olarak anlaşılıyorsa, alacaklı doğrudan tenkis davası açabilmelidir. Borçlu saklı paylı mirasçının alacaklısına kesinlikle tenkis davası açmayacağını yazıyla bildirmesi böyledir. 1212

Alacaklılar açacakları tenkis davasında sadece kendi tahsil edilmemiş alacakları ile sınırlı olarak tenkis isteyebilirler. Aynı sınır iflas masası içinde vardır. Fakat bu takdirde masaya giren tüm alacaklar kadar tenkis istenebilecektir. Böylece, şayet borçlu mirasçının saklı payına tecavüz borcundan daha fazla ise bu fazlalık alacaklılarının açacakları davada tenkis edilemeyip ancak kendisi tarafından tenkis ettirilebilecektir. 1213

Alacaklıların ve iflas masasının dava açmak için saklı paylımirasçı ile aynı sürelere tabidir. 1214

Aranan şartlar gerçekleştiğinde alacaklıların dava hakkı alacağın esasen rehin-kefalet gibi yeterli teminata sahip olduğu gerekçesiyle engellenemez. Alacaklı nasıl bu teminatlara başvurmaya mecbur olmadan borçlusunu takip edebiliyorsa, bununla tutarlı olarak, yeterli teminata rağmen tenkis davası açabilir. 1215

Değinilmesi gereken bir sorun, saklı paylı mirasçının süre vermeye gerek kalmadan veya kendisine verilen süre içinde tenkis davasını açması, fakat davayı kasten kaybedecek şekilde davranması, davalı ile sulh olması veya davayı takip etmemesidir. Kanunun alacaklılara sadece saklı paylı mirasçının tenkis davası açmaması hâlinde bir hak tanıdığı göz önüne alınırsa, bu durumlarda alacaklılar için yapacak bir şey olmadığı sonucuna varılır. Fakat böyle bir sonuç MK 562 hükmünün amacına tamamen aykırıdır ve mirasçının davayı açıp da sonraki kötü niyetli tutumuyla tenkisi önlemesi, bu hükme karşı yapılmış bir hile oluşturur. Mirasçının bu tür dürüstlüğe aykırı tutumu sonucu açılan tenkis davası sonuçsuz kalırsa, bundan zarar gören alacaklıların, mirasçının kastî davranışını ispat etmek kaydıyla, gene de MK 562 uyarınca tenkis davası açabilmeleri gerekir. Zira, MK 2 uyarınca, kanuna karşı hilenin (yasayı dolanmanın) yaptırımı dolanılmak istenen yasa hükmünün uygulanmasıdır. 1216

MK 562/II uyarınca, saklı paylı mirasçının mirasbırakan tarafından mirasçılıktan çıkarılması (mirastan ıskatı) hâlinde, alacaklıları tahsil edilmemiş alacak tutarı kadar saklı pay kısmı için çıkarmanın iptalini dava edebilirler. Çıkarma işlemi mirasbırakanın hatasına dayandığı için mirasçı tara- 1217

fından tamamen iptali için dava açmak mümkün olsa da alacaklılara bu hak verilmemiştir. Onlar bu durumda da MK 512/III uyarınca ıskatın sadece borçlularının saklı payını kurtaracak kadar kısmını iptal ettirebilirler.

1218 Çıkarmanın alacaklılar veya iflas masası tarafından iptali için de önce mirasçıya dava açması için süre verme ve mirasçının iflası veya alacaklının aciz vesikası alması gibi yukarıda belirttiğimiz şartlar aynen geçerlidir.

b) Davalılar.

1219 Tenkis davasında davalılar, mirasbırakanın tasarruf oranını aşarak saklı paylara tecavüz eden ve kanunen tenkise tabi tutulan kazandırmaların[783] yapıldığı kişilerdir. Bunlar üçüncü kişiler olabileceği gibi, bazı mirasçılar da olabilir. Tenkisin şartları, hesaplanması ve tenkis davası bakımından davalının mirasçı olup olmamasının hiçbir önemi yoktur. Şayet kazandırma yapılan kişi ölmüşse, mirasçıları davalı olacaktır.

1220 Şayet birden fazla kazandırmanın tenkisi gerekiyorsa ve bunlar başka başka kişilere yapılmışsa, birden fazla kişi davalı olacaktır.[784] Saklı paylı mirasçı bunların tümünü dava etme hakkına sahipse de buna mecbur değildir. Fakat sadece bazısını dava ederse, bunun sonuçlarına kendi katlanacaktır. Böyle bir durumda, ileride açıklayacağımız üzere[785] MK 570 uyarınca tenkiste sıraya ilişkin kurallara göre dava açtığı kişiler lehlerine yapmış kazandırmayı ne ölçüde tenkis ettirmek zorundaysa sadece bu miktarın tenkisi mümkün olacaktır[786].

1221 Tenkis davası daha önce değindiğimiz üzere ancak şahsî ve nispî bir talep hakkına imkân vereceğinden, tenkise tabi tasarrufun mirasbırakan tarafından yapıldığı kişiye karşı yöneltilebilir. Bununla birlikte, tenkis edilecek kazandırma konusu malı vaktiyle devralan davalının bunu üçüncü kişiye devretmiş olması hâlinde, bu kişiye başvurulup vurulamayacağı; şayet başvurulabilecekse bu başvurunun hukukî gerekçesi son derece tartışmalıdır.

---

[783] Hangi kazandırmaların tenkise tabi olduğunu açıklamıştık bkz. § 20 III 2

[784] Bu kişilere karşı aynı davada tenkis istenebileceği gibi süresi içinde ayrı ayrı davalar da açılabilir. Bu takdirde bu davalar birleştirilecektir.

[785] Bkz. § 23 IV

[786] Örneğin, mirasbırakan tasarruf oranını 1 milyon lira aşarak, (A)'ya 3 milyon lira (B)'ye de 1 milyon lira vasiyet etmişse, oranlı tenkis kuralına göre (A)'dan 750 bin lira (B)'den ise 250 bin lira tenkis edilebileceğinden, sadece (B) ye karşı tenkis davası açan saklı paylı mirasçı ancak 250 bin liralık bir tenkis sağlayabilecektir, asla (B)den tüm tecavüz miktarı olan 1 milyonu isteyemez. Sağlararası tenkise tabi kazandırmalarda tarih sırasına göre tenkis yapıldığından, sonraki tarihli bir kazandırma dururken daha eski tarihli kazandırmayı alana dava açan saklı paylı mirasçı, sonraki tarihli kazandırmayı tamamen tenkis ettirse idi gene de tenkisi gerekli bir tecavüz kalacak ise önceki tarihli kazandırmayı alandan sadece bu kadar tenkis isteyebilecektir.

İlk akla gelen şey, tenkis davasının şahsî-nispî niteliği sebebiyle, mi- 1222
rasbırakanın tenkise konu kazandırmayı yaptığı kişiden başkasına açılamayacağıdır. Ancak, Yargıtay istisnaî durumlarda bunun mümkün olduğu görüşündedir. 13.1.1975 tarih ve E. 1974/7, K.1975/1 Sayılı İçtihadı Birleştirme Kararında[787] bu istisnaî durum şöyle ifade edilmiştir:

"Mirasbırakanın saklı pay kurallarını gidermek amacı ile yaptığı temlikî 1223
tasarruftan sonra, bundan yararlanan kişinin, mirasbırakanın bilgi ve talimatı dışında sırf saklı pay sahibi mirasçıları bu haklarından yoksun kılmak için, durumu bilen üçüncü kişilere taşınmazları temlik etmesi hâlinde, kötü niyetli bu kişilere karşı saklı pay sahibi mirasçılar tarafından tenkis davası açılabilir."

Bu içtihadı birleştirme kararı doğrultusunda, tenkis konusu malın (özel- 1224
likle taşınmaz mülkiyeti devri şeklindeki) el değiştirmelerinde, kendilerine doğrudan mirasbırakan tarafından devir yapılmamış yeni malikler de mirasçıların tenkis talebiyle karşılaşabilmektedirler. Bunun için iki şartın varlığı aranacak ve yeterli olacaktır: 1-Tenkis yükümlüsünün bu malı tenkisten kaçırmak için üçüncü kişiye devretmesi. 2-Üçüncü kişinin bu maksadı bilerek malı devralması.

Öğretide neredeyse ittifakla belirtildiği üzere, bu içtihadı olduğu gibi 1225
benimsemek hukuken mümkün değildir. Herşeyden önce, yenilik doğuran dava yönüyle tenkis davası yasada açıkça ve sadece mirasbırakanın yaptığı bazı kazandırmalara karşı kazandırma lehdarına yönelik bir dava olarak düzenlenmiştir ve bunun dışındaki (sonraki) kazandırmalar hakkında açılamaz. Şu halde, burada olsa olsa tenkis hükmüne konu edim talebi bakımından üçüncü kişilerin durumu tartışılabilir. Bu bakımdan dahî, Yargıtay içtihadının kabul edilmesi mümkün olmayan yönleri vardır:

Bir kere, şayet burada dava açma imkânının dayandırıldığı kötü niyet 1226
MK m. 3 anlamında iyi niyetli olmamak ise; bu anlamda kötü niyet ancak bir hakkın doğumu için kanunun iyi niyetli olmayı aradığı durumlarda bu hakkın kazanılmasını engeller. Oysa tenkis yükümlüsünden malı devralan üçüncü kişinin iktisabı iyi niyetli olma şartına bağlı değildir. Onun gerçek malikten bir mal devralırken, kendisine devirde bulunan gerçek malikin bu malı kısmen veya tamamen diğer mirasçılara vermekle yükümlü olduğunu bilmesi devri etkilemez. Zira bu şahsî yüküm, devreden için bir tasarruf yetkisi eksikliği değildir. İkinci olarak, şayet kararda sözü geçen kötüniyet MK 2 anlamında Dürüstlük Kuralına aykırı davranış anlamında ise, birisinin başkasına devretme hususunda şahsî yüküm altında olduğu malı bunu bilerek ondan devralmak başlı başına dürüstlük kuralına aykırı davranış sa-

[787] RG 15196

yılmadığı gibi; tasarruf yetkisine sahip gerçek malikinden bir malın mülkiyetini geçerli şekilde devralan kimsenin kendisinin taraf olmadığı nispî bir ilişki dolayısıyla bu mala yönelik taleplere karşı mülkiyet hakkını ileri sürmesi de hakkın kötüye kullanılması sayılamaz.

1227 Böylece, sadece Yargıtayın ileri sürdüğü gerekçelerle üçüncü kişilere ellerindeki malı kısmen veya tamamen iade etmelerine yönelik bir dava açılamayacağı görülmektedir. Normal sonuç, elindeki malı tenkisten kurtarmak için üçüncü kişiye devreden tenkis yükümlüsüne karşı tenkis davasının açılmasıdır. Şayet tenkis yükümlüsü tenkis konu malı elinden çıkarırken bir bedel elde etmişse, kendisine yapılan kazandırma bu çerçevede devam ediyor sayılarak parasal bir tenkise tabi olmaya devam edecektir. Şayet davalı tenkisle yükümlü olduğunu bilmediği bir sırada elinden çıkardığı maldan bir karşılık da elde etmemişse veya elde ettiği karşılığı da elinden çıkarmışsa, MK 566 uyarınca mirasın açıldığı günde elinde kalanla sorumlu olacaktır. Üçüncü kişi bu etkilerin tamamen dışındadır.

1228 Bununla birlikte, öğretide, başka bazı hukukî mekanizmalarla ve gerekçelerle, saklı paylı mirasçıların tenkise konu malı devralan üçüncü kişiye karşı da bazı taleplerde bulunabileceği kabul edilmektedir. Bu talepleri şu gerekçelere dayandırmak mümkündür:

1229 1- Üçüncü kişinin malı devralırken özellikle saklı paylı mirasçının tenkis imkânını etkisiz bırakmayı amaçlaması hâlinde bu tutumu BK 49/II uyarınca "ahlâka aykırı kasıtla başkasına zarar verme" sayılarak, saklı paylı mirasçının haksız fiil hükümlerine göre ondan uğradığı zararın tazminini istemesi ve mal hâlâ üçüncü kişinin elinde ise "aynen tazmin" talebiyle tenkis gerçekleşse idi davacıya kalacağı oranda malın mülkiyetinin istenmesi.

1230 2- Üçüncü kişinin tenkis yükümlüsünden malı devralırken ortak maksatlarının malı tenkisten kurtarmak olması BK 27 anlamında "ahlâka aykırı" bir sözleşme yaptıkları şeklinde yorumlanıp, bu sebeple batıl sayılacak devir işleminin[788] mülkiyeti geçirmediği kabul edilerek, saklı paylı mirasçının hâlâ tenkis yükümlüsüne ait sayılacak malın tenkis oranında mülkiyetinin kendisine devrini istemesi ve bunu takiben sadece mala haksız zilyet sayılacak üçüncü kişiye karşı istihkak davası açması.

1231 3- Tenkis kararı mirasın açıldığı ana kadar geçmişe etkili sayıldığından, tenkise tabi bir ölüme bağlı tasarrufta tenkis yükümlüsü tarafından bu an-

---

[788] Burada hem devre yönelik satım-bağış gibi borçlandırıcı işlem hem de mülkiyet devri sırasındaki aynî sözleşme BK 27 uyarınca geçersiz olacağından, taşınmazların yanı sıra, taşınır mülkiyeti nakli sebepten soyut sayılsa bile tasarruf işlemi de batıl olacağından mülkiyet geçmemiş olacaktır. Bu konularda bkz. *Öz*, Öğreti ve Uygulamada Sebepsiz Zenginleşme, İstanbul 1990, 209.

dan sonra üçüncü kişiye yapılan devirlerde, üçüncü kişinin mülkiyet hakkı da geçmişe etkili olarak düşmüş sayılacağından[789], bu kişilere karşı istihkak davası ileri sürmek.

4- Son olarak, şayet tenkisten mal kaçırmak için tenkis yükümlüsü ve üçüncü kişi gerçekte bir sözleşme ve devir yapmak istemedikleri halde bir satış, trampa veya bağış sözleşmesi yapmış gibi görünüyorlarsa, saklı paylı mirasçı bu muvazaanın varlığını her türlü delille ispat ederek, tenkis yükümlüsünün hâlâ malik olduğunu ortaya çıkarıp tenkis ve bu oranda malın kendisine verilmesini sağlayabilir. 1232

3. Süresi ve Yetkili Mahkeme

Tenkis davasının açılma süreleri MK 571 hükmünde düzenlenmiştir. Buna göre tenkis davası açma hakkı, mirasçılar saklı paylarına tecavüz edildiğini öğrendikleri günden itibaren bir yıl ve her halde vasiyetnameler hakkında açıldıkları tarihten diğer tasarruflar hakkında mirasın açılmasından itibaren on yıl[790] geçmesiyle düşecektir. Ancak, bir tasarrufun iptali diğerini ihya ediyorsa (canlandırıyorsa) süreler ancak bu iptal kararının kesinleştiği tarihte işlemeye başlayacaktır (MK 571/II) 1233

Görüldüğü üzere, burada kanun iki süre öngörmüş ve özel bir durum için de farklı bir süre başlangıcı düzenlemiştir. 1234

Bir yıllık sürenin başlangıcı saklı paylı mirasçının saklı payına tecavüz edildiğini öğrenmesidir. Burada tecavüz eden tasarrufun varlığını bilmesi yetmez. Şayet bunu saklı payına tecavüz etmeyeceğini düşünmüş fakat sonradan terekenin umduğundan az çıkması üzerine bu tasarrufun saklı payına tecavüz ettiğini anlamışsa, bir yıllık süre bu andan itibaren işler. Önemle belirtelim ki, mirasın açıldığı yani mirasbırakanın öldüğü tarihten önce bu süre işlemez. Örneğin bir oğul babasının yaptığı bir kazandırma ile müstakbel miras payının saklı payına tecavüz ettiğini bilse bile, bu şekilde ne kadar uzun bir süre geçmiş olursa olsun, babası ölüp miras açılmadan önce bir yıllık süre işlemeye başlamaz. Zira ölümden önce elinde bu tasarrufa karşı başvuracak hukukî bir imkân bulunmayan mirasçı için süre işlemesi kabul edilemez. Vasiyetnameler bakımından ise, 571.madde metninden vasiyetname MK m.596 uyarınca açılmadan önce fakat mirasbırakan öldükten sonra sadece tecavüzü öğrenen bakımından bir yıllık sürenin işlemeye başlayacağı anlamı çıkmaktadır. Bu normal görülmelidir. Aksi takdirde kazan- 1235

[789] Taşınır mülkiyeti iktisabı sebepten soyut sayılırsa bu sonuç taşınırlar bakımından doğmaz.

[790] Eski MK 513 uyarınca bu süre beş yıl idi.

dırma lehdarı lehine vasiyetnameyi bir yılı aşkın süre elinde saklayarak saklı paylı mirasçının bir yıllık süreyi kaçırmasını sağlayabilirdi.

1236 On yıllık sürenin başlangıcı ise, sağlararası kazandırmalar ve miras mukaveleleri için mirasın açıldığı tarih, vasiyetnameler için ise vasiyetnamenin açıldığı tarihtir. Vasiyetnamenin açılması tarihi, MK 596 uyarınca vasiyetnamenin sulh mahkemesine tevdi edilmesini takiben hakim tarafından bilinen mirasçılar çağırılarak huzurlarında açıklandığı gündür. Vasiyetnameler hakkında on yıllık süre bu andan itibaren işleyecektir. On yıllık sürenin dolması üzerine saklı paylı mirasçı henüz saklı payına tecavüzü öğrenmemiş bile olsa tenkis davası açma imkânını kaybedecektir. Gene, örneğin, on yıllık sürenin dolmasına bir gün kala tecavüzü öğrense, tenkis davası açmak için sadece bir günü olacaktır.

1237 Özel bir durum olarak, şayet bir tasarrufun iptali ile tenkise tabi bir tasarruf geçerlik kazanıyor ise, süreler bu andan itibaren başlayacaktır. Zira saklı paylı mirasçının bu andan önce tenkis davası açmasına imkân ve gerek bulunmamaktadır. Örneğin, mirasbırakan önce bir vasiyetname ile tenkise tabi bir kazandırmada bulunmuş, fakat daha sonra yaptığı ikinci bir vasiyetname ile ilk vasiyeti yürürlükten kaldırmış olsun. Mirasbırakanın ölümünden bir yıl sonra bu ikinci vasiyet MK 557-559 hükümlerine göre iptal edilir ise, canlanan ilk vasiyetnamedeki kazandırmaya karşı mirasçıların tenkis davası açma süreleri bu iptal anından başlar. Böylece, saklı paya ilk vasiyetnamedeki tecavüzü önceden bilen mirasçının bir yıllık süresi ancak ikinci vasiyetin iptalinin kesinleştiği tarihten itibaren işlemeye başlayacağı gibi, tecavüzü öğrenmiş olsun olmasın on yıllık azamî süre de bu iptal tarihinden itibaren işleyecektir.

1238 Tenkis davasında süreleri düzenleyen MK 571 hükümlerinde ölüme bağlı tasarrufların iptali davasında süreleri düzenleyen MK 559 hükmündeki gibi kötüniyetli davalılara karşı yirmi yıllık bir süre öngörülmemiştir. Bu bakımdan, örneğin, tenkise tabi kazandırma lehdarı kazandırmayı aldığı andan beri bunun saklı paya tecavüz oluşturduğunu biliyor olsa hatta özellikle bir mirasçının saklı payını ihlâl maksadıyla bu kazandırmayı almış olsa bile, yukarıdaki prensiplere göre hesaplanacak bir ve on yıllık sürelerin dolmasıyla tenkisten kurtulur.

1239 Tenkis davasının tabi tutulduğu bu bir ve on yıllık süreler Yeni MK 571 hükmünün gerek kenar başlığından gerekse içeriğinden anlaşıldığı üzere, zamanaşımı değil hakdüşürücü süreler olarak düzenlenmiştir. Oysa bu maddenin karşılığı olan Eski MK 513 hükmünün kenar başlığı müruru zaman idi ve bu hükme göre sürelerin hak düşürücü süre mi yoksa zamanaşı-

mı süresi mi olduğu tartışmalıydı[791]. Tenkis davasının bir yenilik doğuran dava olmasından hareket edenler, maddenin ifadesine bakmayarak o zaman da bunların hak düşürücü süre olduğu görüşündeydiler.[792] Buna karşılık, maddenin kenar başlığında ve 1.fıkranın son cümlesinde zamanaşımı ifadesinin geçmesinden hareket edenler, burada istisnaen zamanaşımına tabi tutulmuş bir yenilik doğuran dava olduğu görüşündeydiler.[793] İki görüş arasındaki pratik farklar, bu sürelerin hakdüşürücü süre sayılması hâlinde hâkim tarafından kendiliğinden gözönüne alınması ve zamanaşımının durması ve kesilmesi hallerinden (BK 153, 154) etkilenmemesi; buna karşılık zamanaşımı süreleri sayılması hâlinde davalı tarafından ileri sürülmedikçe hâkimin gözönüne alamaması ve bazı sebeplerle durmasının ve kesilmesinin sözkonusu olmasıdır. Görüldüğü gibi, süreleri hak düşürücü süre olarak belirleyen yeni hüküm, tenkis davasının davalı tarafını daha çok himaye eder niteliktedir.

III.TENKİS DEFİ

MK 571/III uyarınca, "tenkis iddiası defi yoluyla her zaman ileri sürü- 1240
lebilir." Böylece kanun koyucu, tenkis davasının sürelerini kaçırdığı için tenkis davası açamayacak olan saklı paylı mirasçıya, tenkisi kendisine yönelik taleplere karşı def'i yoluyla ileri sürme imkânı tanımıştır. Bu hüküm iptal davası bakımından aynı imkânı getiren MK m.559/II hükmünün tenkis bakımından tekrarıdır.

Tenkis def'i saklı paylı mirasçıya tenkise konu kazandırmanın lehdarı 1241
tarafından yöneltilecek her talepte ileri sürülemez. Sadece, kazandırma lehdarının doğrudan bu kazandırmaya dayanarak kazandırma konusu malın veya paranın kendisine verilmesine yönelik taleplerine karşı ileri sürülebilir. Bu husus maddede açıkça belirtilmemişse de, tenkis definin niteliğinden ve düzenlenme amacından çıkar. Böylece, örneğin, kendisine mirasbırakan tarafından tasarruf oranını aşacak şekilde bir ev veya bir miktar para vasiyet edilmiş kişiye karşı tenkis davasını süresi içinde açmayan saklı paylı mirasçı, aradan ne kadar süre geçmiş olursa olsun, vasiyetin tenfizine (:küllî halefiyetle sahip olduğu bu ev ve paranın vasiyet lehdarına verilmesine) dair lehdar tarafından kendisine karşı açılan bir eda davasında, saklı payına tecavüz ettiği oranda bu ev ve parayı vermekten kaçınabilecektir. Şayet saklı paya tecavüz mirasçı atanması yoluyla gerçekleşmişse, saklı paylı mirasçı tenkis defi'ni atanan mirasçı tarafından açılan miras sebebiyle

---

[791] Aynı tartışma Eski MK 501 hükümlerindeki ölüme bağlı tasarrufların iptali davasının tabi olduğu süreler için de yapılmaktaydı.

[792] *Eren*, Tenkis, 141; *Oğuzman*, Miras hukuku, 351, 352; *İmre*, 408; Yarg. 2.HD. 29.9.1977, 5720/6550 (YKD 1979, S.12, s.1700

[793] *Kocayusufpaşaoğlu*, Ek Kitap, 31; Yarg HGK 22.11.1989, E.1989/2-479, K.608 (İKİD 1990, S.353, s.7197; 2.HD. 15.3.1990 E.2066 K.2812 (İKİD 1990, S.359, s. 7578).

istihkak davası veya mirasın paylaşılması davasında[794] da ileri sürebilecektir. Buna karşılık, tenkis davası açma süresini kaçıran bir mirasçı, kazandırma ifa edildikten sonra, kazandırma lehdarı tarafından başka bir sebeple kendisine yönelttiği taleplere karşı tenkis def'i ileri süremez. Örneğin, tenkise tabi kazandırma hakkında tenkis davası açma süresini kaçıran saklı paylı mirasçı (bu kazandırma konusu mal lehdarın eline geçmiş olsun olmasın), kazandırma lehdarının bir haksız fiil sebebiyle kendisine karşı yönelttiği tazminat talebine karşı veya aralarındaki bir sözleşmeden doğan borcunun ifası için yönelttiği talebe karşı, tenkis def'inde bulunamaz.

1242 Tenkis def'i bu niteliği sonucu, henüz ifa edilmeyen ölüme bağlı kazandırmalara karşı saklı paylı mirasçıları koruyan bir ek imkân şeklinde karşımıza çıkacaktır. Tenkis yükümlüsünün esasen kazandırma konusunu iktisap ettiği tenkise tabi sağlararası kazandırmalarda ise, bu konuda saklı paylı mirasçıya karşı bir talep ileri sürülmeyeceğinden, tenkis def'ine yer olmayacaktır.

1243 Tenkis def'i asıl faydasını tenkis davası açma süreleri kaçırıldıktan sonra gösterecekse de, henüz tenkis davası açma süreleri dolmadan önce kendisine karşı yöneltilecek taleplere karşı da saklı paylı mirasçı tenkis def'inde bulunabilir. Böyle bir durumda tenkis def'i Usul Hukuku anlamında bir karşı davanın yerine geçmiş olacaktır.

1244 Tenkis def'i her def'i gibi hâkim tarafından kendiliğinden gözönüne alınmayıp saklı paylı mirasçıya karşı açılan davada bu mirasçı tarafından açıkça ileri sürülmesi gerekir. Şayet birden fazla saklı paylı mirasçının saklı payına tecavüz eden bir kazandırma varsa, kazandırma lehdarı tarafından açılan davada hangi saklı paylı mirasçı bu def'i ileri sürmüşse, def'i sadece onun saklı payı kadar ve onun lehine etkili olacaktır.

1245 Tenkis def'inin ileri sürülmesi herhangi bir süreye bağlı değildir. Fakat tenkis def'inden açık veya örtülü şekilde feragat mümkündür ve bu feragat bir şekle bağlı değildir.[795] Böylece, örneğin, kazandırma lehdarına yönelik beyan ve davranışları Dürüstlük Kuralından kaynaklanan Güven İlkesine göre artık bu def'i kullanmayacağı taahhüdü olarak anlaşılan saklı paylı mirasçı da, kendisine yönelik talebe karşı bu def'i kullanamaz. Esasen böyle bir durumda tenkis def'ini kullanması "çelişkili davranmama" (venire contra factum proprium) ilkesine de ters düşer.

---

[794] *Oğuzman*, 256 Not 688 (JdT 1978 I 49)
[795] *Oğuzman*, 257

IV. TENKİSTE SIRA (TERTİP)

1. Tenkiste Sıra Sorunu Ve Ölüme Bağlı Kazandırmalar İle Sağlararası Kazandırmalar Arasında Sıra.

Mirasbırakanın ölümü üzerine yukarıdan beri belirttiğimiz kurallara göre tenkis gereken bir durum ortaya çıktığında, şayet mirasbırakan tenkise tabi tek bir kazandırıcı işlem yapmışsa durum basittir. Sadece bu kazandırmanın tasarruf oranını aşan miktarda tenkisiyle yetinilecektir. Burada hesaplama bakımından da kimin davalı olacağı (veya davalılardan hangisi aleyhine hüküm verileceği) bakımından da bir sorun yoktur. Ancak, mirasbırakanın tenkise tabi birden fazla kazandırmada bulunduğu durumlarda şayet tenkisi gereken miktar bu kazandırmaların tamam oluncaya kadar evvelemirde ölüme bağlı tasarruf tümünün toplamından daha az ise, önemli bir sorun çıkar. Bu kazandırmalardan hangisi veya hangileri ne oranda tenkis edilecektir? İşte bu sorunun cevabı "tenkiste sıra" konusunu oluşturur ve MK 570 hükümleriyle düzenlenmiştir. MK 570/I hükmüne göre göre, "Tenkis, saklı pay tamamlanıncaya kadar, önce ölüme bağlı tasarruflardan; bu yetmezse, en yeni tarihlisinden en eskisine doğru geriye gidilmek üzere sağlararası kazandırmalardan yapılır" Ancak, Yeni MK ile getirilen bir değişiklik olarak, MK 570/II uyarınca, "Kamu tüzel kişileri ile kamuya yararlı dernek ve vakıflara yapılan ölüme bağlı tasarruflar ve sağlararası kazandırmalar en son sırada tenkis edilir." 1246

Görüldüğü üzere bu hükümlerde bir taraftan ölüme bağlı kazandırmalar ile sağlararası kazandırmalar arasındaki tenkis sırası belirtilirken diğer yandan sağlararası kazandırmaların kendi aralarındaki tenkis sırası da düzenlenmiştir. Ölüme bağlı kazandırmalarda ise, ayrıca açıklayacağımız üzere, MK 563/I uyarınca (kazandırma saklı paylı mirasçılara yapılmışsa MK 561 uyarınca) sıra değil orantılı tenkis sözkonusudur. 1247

Buna göre, şayet tasarruf oranının aşıldığı (saklı paylara tecavüz edilen) bir durumda, tenkise tabi hem sağlararası kazandırma hem de ölüme bağlı kazandırma mevcutsa, önce ölüme bağlı kazandırma tenkis edilecektir. Şayet bu kazandırmanın tenkisi ile saklı paylar kurtuluyorsa, tenkise tabi sağlararası kazandırmaya hiç dokunulmayacaktır.[796] Sağlararası kazandırmalar lehine ölüme bağlı kazandırmaları öncelikle feda eden bu kuralın temelinde yatan mantık, yasaca ölüme bağlı kazandırmaların kural olarak tenkise tabi sayılmasına karşılık sağlararası kazandırmaların istisnaen tenkise tabi sayılmasıdır. Böylece, örneğin, ölümünden sonra tasarruf oranını 1 milyon li- 1248

[796] Kuşkusuz bu başka şey, mirasbırakanın tasarruf oranınını aşıp aşmadığı hesaplanırken ölüme bağlı ve sağlar arası kazandırmaların tümünün toplanarak hesaba katılması başka şeydir. Bkz. § 21 I

ra tecavüz ettiği anlaşılan mirasbırakan 1 milyon liralık muayyen mal vasiyetinde bulunmuş ve ayrıca ölümünden kısa süre önce 1 milyon liralık elden bağışlama yapmışsa; saklı paylı mirasçıları sadece 1 milyon liralık vasiyetin tenkisini isteyebilecekler, bağışlamayı tenkis ettiremeyeceklerdir. Şayet tasarruf oranına tecavüz 1 milyon 100 bin lira ise, gene vasiyet tamamen tenkis edilirken elden bağışlamanın sadece 100 bin liralık kısmı tenkis ettirilebilecektir[797].

1249 Tenkis sırasını düzenleyen MK 570 hükümlerinin emredici olduğu kabul edilmektedir. Böylece, mirasbırakan yapacağı bir vasiyetname ile bu kanunî sırayı değiştiremez. Örneğin, yaptığı sağlararası kazandırmanın önce ölüme bağlı kazandırmanın sonra tenkisini öngöremez. Keza, yaptığı sağlararası kazandırmalardan daha eski tarihlisinin önce tenkisini öngöremez. Bu tür kayıtlara itibar edilmez.[798] Ancak, mirasbırakanın serbestçe dönebileceği (rücû edebileceği) kazandırmaların (MK 565/b.3) yasal sırasından daha önce tenkis edilmesini kararlaştırabileceği kabul edilmektedir[799].

2. Sağlararası İşlem Yoluyla Ölüme Bağlı Kazandırmaların Özellikle Ölümden Sonraya Etkili Vekalet ve Temsil Yetkisinin Durumu

1250 Ölüme bağlı kazandırmalarla sağlararası kazandırmalar arasındaki sıra bakımından, bir kazandırmanın hangi tipe girdiği tartışması önem taşımaktadır. Buna göre, örneğin, ölüme bağlı kazandırma mı yoksa sağlararası kazandırma mı sayılacağı tartışmalı olan, mirasbırakan sağken yapılmış fakat ölüm anında henüz ifa edilmemiş bağışlama taahhüdü[800], mirasbırakanın hayat sigortasında lehdar tayini[801] ve ölümden sonraya etkili vekalet (mandatum post mortem) ile yapılan kazandırmalar; nitelikleri hakkında benim-

---

[797] Şayet saklı paylı mirasçı vasiyet alacaklısına dava açmayıp sadece elden bağışlamayı alana dava açmak isterse, bu mümkün olmakla birlikte, tenkis davasında davalıları anlatırken belirttiğimiz üzere, sanki ölüme bağlı tasarruf (vasiyet) tamamen tenkis edilmiş gibi sadece 100 bin liralık tenkisle yetinecektir.

[798] *Tuor*, Art. 532 N.2; *Escher*, Art.532, N.4; *Oğuzman*, 236; *Eren*, Tenkis, 151; *İnan*, 255; *Kocayusufpaşaoğlu*, 420 Not 34

[799] Zira, bu tasarruflardan serbestçe dönebilen mirasbırakanın bunun yerine öncelikle tenkisini düzenlemesi "çoğun içinde azı da vardır" ilkesi sonucu yetkisi dahilinde görülmektedir. Buna karşılık, mirasbırakanın bu kazandırmaları yasal sırasından daha geride tenkise tabi kılması mümkün değildir. Bkz.: bir önceki dip notta belirtilen yerler.

[800] Bkz. § 21 III 2 c

[801] Bu tasarrufun niteliği hakkındaki tartışmalar ve bazı ayırımlar için bkz. *Kocayusufpaşaoğlu*, 421 (Yazar, özel iki durum olarak, mirasbırakanın kendi lehine akdettiği sigortayı sağlığında devretmesini sağlararası kazandırma, sigorta vasiyetini ölüme bağlı kazandırma olarak nitelendirmektedir).

senecek görüşe göre diğer kazandırmalardan önce veya sonra tenkise tabi olacaklardır. Öğretide "sağlararası işlem yoluyla ölüme bağlı kazandırmalar" başlığı altında toplanan bu işlemlerin niteliği ve tabi olacakları hükümler tartışmalıdır[801a].

Bunlar arasında sadece, mirasbırakanın sağlığında yapılmış olmakla birlikte tenfizinin (ifasının) bağışlayanın ölümünde gerçekleşeceği şartı içeren bağışlamalar, BK 290/II hükmü ile özel olarak ve açıkça "ölüme bağlı tasarruf" hükümlerine tabi tutulmuştur. Bu özel hüküm karşısında, bu tür bağışlamalar yoluyla yapılan kazandırmalar, ölüme bağlı tasarruflar gibi sağlar arası kazandırmalardan önce (MK 570) ve diğer ölüme bağlı tasarruflarla orantılı olarak (MK 563) tenkis edilecektir. 1251

Yasada akibeti düzenlenmemiş olan ölümden sonra da hüküm ifade edecek sağlararası işlemler arasında en sık karşılaşılan ve en çok tartışılan durum, mandatum post mortem olarak bilinen ve ölümden sonraya etkili vekalet olarak da adlandırılan, "ölümden sonraya etkili temsil yetkisi"dir. 1252

Bu tür işlemlerin niteliği ve sonuçları Roma Hukukundan beri tartışmalıdır. Hemen belirtelim ki bu tartışma, ölümden sonraya etkili vekaletlerin geçersiz olması hakkında değil (böyle bir görüş yoktur), gerçek hukukî niteliğinin ve sonuçlarının ne olduğu hakkındadır. 1253

Ölümden sonraya etkili vekaletname hakkındaki bu tartışmalar, özellikle bu işlemin miras hukuku bakımından bir sağlararası işlem mi yoksa ölüme bağlı bir tasarruf mu sayılacağı sorunu ile, gerçekten ölümden sonra – mirasçılarla- devam eden bir vekâletname mi yoksa gerçekte bir miras hukuku işlemi mi olduğu sorununda yoğunlaşmaktadır. 1254

Bir görüşe göre, ölümden sonraya etkili vekalet gibi sağken yapılmakla birlikte ölümden sonra da etkili olması istenen işlemler, gene mutlak şekilde sağlararası işlem sayılmalıdır.[802] Buna göre, böyle bir vekaletname ile müvekkilin sağlığında yapılan işlemler mutlak şekilde geçerli olduğu gibi, müvekkilin ölümünden sonra da bu vekâlet tarafların yaptıkları anlaşma doğrultusunda geçerli kalmaya devam edecektir. Zira, ölümün vekâleti ve temsil yetkisini sona erdirmeyeceği yolundaki anlaşmayı taraflar sağlıklarında geçerli şekilde yapmışlardır ve bunun sonuç doğurmasına bir engel yoktur. 1255

[801a] Bu konuda bak. *Serozan/Engin*, § 4, N. 42-48.

[802] Bu görüşte: *Von Tuhr/Peter*, Allgemeiner Teil des schweizerischen Obligationenrechts, Band I, Zürich 1979, § 42 Not 80'e ait metin; *Esener, T.*, Selahiyete Müstenit Temsil, Ankara 1961, s.178, 179; *Gürsoy, K.T.*, Vekalet Akdinin Ölüm Nedeniyle Sona Ermesi ve Sonuçları, Temsil ve Vekalete İlişkin Sorunlar, Sempozyum 14-16 Haziran 1976, İstanbul 1977, 31,32.

1256 Bu görüşün bir dayanağı, BK 513/II hükmündeki, "vekaletin sona ermesi vekalet verenin menfaatlerini tehlikeye düşürüyorsa, vekalet veren veya mirasçısı ya da temsilcisi işleri kendi başına görebilecek duruma gelinceye kadar vekil veya mirasçısı ya da temsilcisi vekaleti ifaya devam etmekle yükümlüdür" şeklindeki düzenlemedir. Bu hükümle yasakoyucunun bazı özel durumlarda ve ihtiyaç hallerinde, taraflar arasında kararlaştırılmış olmasa bile, vekaletin ölümle sona ermeyip devam edebileceği kabul edilmiş olmaktadır. Şu halde, ihtiyaç hâlinde taraflar kararlaştırmamış olsalar bile vekaletin ölümden sonra devam edebileceğini kabul eden yasakoyucunun, tarafların sözleşme yapılırken özellikle müvekkilin ölümünden sonra da vekaletin (ve temsil yetkisinin) devam edeceğini kararlaştırmalarını öncelikle geçerli sayması gerekir.

1257 Görüşün bir diğer dayanağı, bu şekilde vekaletin ölümden sonra devam etmesinin aslında temel hukuki kavramlarla ters düşmediği gibi sorun da yaratmayacak olmasıdır. Buna göre, böyle bir vekalet ilişkisinde müvekkilin ölümü üzerine sözleşmenin taraflarından birinin kişiliği (ölümle) sona erdiği için sözleşme bir tarafını kaybetmiş olmamakta, ölen müvekkilin mirasçıları külli halefiyet ilkesine göre ölüm anında kendiliğinden vekalet sözleşmesinin tarafı olmaktadır. Üstelik bunun da önemli bir sakıncası yoktur. Zira, BK 512 (OR Art. 404) uyarınca mirasçılar her zaman hiçbir sebep göstermeksizin vekalet sözleşmesini feshedebilirler.

1258 Bir başka görüşe göre, ölümden sonraya etkili vekaletname ölüme bağlı bir tasarruf sayılıp, özellikle vekile müvekkil tarafından tek yanlı bir kazandırma yapılması amaçlanmışsa, "yerine getirilmesi bağışlayanın ölümüne bağlı bağışlama" sayılmalıdır[803]. Bu durumda, BK 290/II hükmü uyarınca, "yerine getirilmesi bağışlayanın ölümüne bağlı bağışlamalarda vasiyetlere ilişkin hükümler uygulanır" kuralı burada da uygulanacaktır. Bu maddedeki ifadenin İsviçre Borçlar Kanunundaki karşılığı (OR Art.245) gözönüne alınarak bu fıkradaki "vasiyet" deyimiyle "ölüme bağlı tasarruf" denmek istendiği kabul edilmektedir. Ölüme bağlı bağışlama bir sözleşme biçiminde olduğuna göre, burada uygulanacak ölüme bağlı tasarruf hükümleri miras sözleşmesi (miras mukavelesi) hükümleri olacaktır.[804]

1259 Bu görüşün bir sonucu, bu tür vekaletlerdeki ivazsız kazandırma taahhütleri ölüme bağlı tasarruf hükümlerine tabi olacağından, bu tür kazandırmaların iptali davaları ölüme bağlı tasarrufların iptali şartlarına bilhassa

---

[803] Bu görüşte: *Tuor, P.*,das Erbrecht, Kommentar zub ZGB Band III, Bern 1952, Einleitung zu Titel XIV, Nr.3; *Escher, A.*, das Erbrecht, 3.Aufl. Einleitung zu Titel XIV, N. 8; *Oğuzman*, Miras Hukuku, 5.Bası, 105.

[804] MK 503, 504, 514, 515, 527, 528, 545, 549, 572, 573

bunlara ilişkin iptal sürelerine tabi olacak ve tasarruf nisabını tecavüz hâlinde ölüme bağlı tasarruflar gibi tenkise tabi olacaktır.

Buna karşılık, bu tür tasarrufların geçerlilik şekli bakımından, miras 1260
sözleşmesinin şekline tabi olup olmadığı, bu görüşün kendi içinde tartışmalıdır. Örneğin, bir Yargıtay kararında, ölümden sonra da vekâletin devamı yönündeki sözleşmenin geçerli olduğu ve müvekkilin ölümünden sonra vekilin özel yetkisine dayanarak onun adına bir taşınmazı bağışlayabileceğine, ancak bu bağışlamanın saklı payı giderme kasdı aranmaksızın tenkis edileceğine hükmedilirken, alelade bir vekaletnamenin miras sözleşmesine dair MK 545 (ZGB Art. 512) hükmündeki şekle aykırı düşmesinin tasarrufu esasen geçersiz kılacağı kabul edilmemiştir[805].

Buna karşılık, bu görüş yanlılarından bazıları, bu tür ölümden sonraya 1261
etkili vekaletlerle verilen tasarruf yetkilerinde, esasen miras sözleşmesi veya vasiyetnamenin resmî şekline uyulmadığı için bu taahhütleri –ölümden sonrası için- şekle aykırılıktan geçersiz saymaktadırlar. Ancak hemen belirtelim ki, genel hükümlerden farklı olarak, ölüme bağlı bir tasarrufun şekle aykırılığı kendiliğinden geçersizlik sonucu doğurmayıp, MK 557/b.4 (ZGB Art. 520) uyarınca bir iptal davası açılması hâlinde hakimin kararı ile gerçekleşecektir. Ayrıca, bu iptal davası MK 559'da belirtilen süreler içinde açılmalıdır.

Yukarıdaki iki temel görüşü bağdaştırmak isteyen bazı hukukçulara gö- 1262
re ise, ölümden sonraya etkili bir vekâletname ile vekile müvekkilin ölümünden sonra bir kazandırmada bulunma yetkisi verilen hâller toptan ve götürü şekilde "sağlararası kazandırma" veya "ölüme bağlı tasarruf" sayılamaz. Her bir somut olayın özelliği ayrı ayrı incelenerek, duruma göre bu iki sonuçtan birine varılabilir[806]. Bu hususun belirlenmesinde önerilen başlıca ölçüt ise, bu vekalet anlaşması sırasında tarafların ve özellikle müvekkilin iradesinin daha ziyade neye yönelik olduğudur. Denmektedir ki: şayet ölümden sonrası içinde etkili vekaletname verirken müvekkilin asıl amacı vekile veya onun aracılığıyla üçüncü bir kişiye ölümünden sonra bir kazandırma yapmak ve bu şekilde miras hukukunun bazı kurallarını dolanmak ise, bu işleme ölüme bağlı tasarrufa ilişkin kurallar uygulanmalı; buna karşılık şayet müvekkil bu vekaletnameyi imzalarken daha ziyade sağlığında bir işin yürütülmesini vekile bırakmak istemiş ve bunun uzantısı olarak öldükten sonra da vekilin yetkisini kullanmaya devam etmesini işin niteliği

---

[805] Bkz.: Yarg.2.HD. 5.4.1977, E. 1460, K.2882, Ankara Barosu Dergisi 1977, s. 915, 916.

[806] Bu görüşte, *Becker*, Kommentar zum ZGB, Art.405, N.3; *Oser/Schönenberger*, Kommentar zum ZGB, Art.35, N.4; *Serozan, R.*, Sağlararası İşlem Yoluyla Ölüme Bağlı Kazandırma, İstanbul 1979, 177, 178

gereği istemişse, burada asıl amaç miras hukukuna ait bir işlem yapmak olmadığından, işleme sağlararası tasarruflara ait hükümler uygulanmalıdır.

1263 Nihayet son bir görüşe göre, ölümden sonraya etkili bir vekaletnamede vekile müvekkilin malvarlığından onun ölümünden sonra tasarruf yetkisi verilmişse, bu vekilin gerçekte bir vasiyeti yerine getirme görevlisi (vasiyeti tenfiz memuru) olarak atanması anlamına gelir[807]. Bu görüş çerçevesinde, vekilin müvekkilin ölümünden sonra onun iradesi doğrultusunda yaptığı tasarruflar, gerek kendi lehine gerekse üçüncü kişiler lehine olsun, bir vasiyeti yerine getirme görevlisinin vasiyete uygun yasal davranışları olarak değerlendirilecektir. Bu görüş, aslında yukarıdaki görüşlerden tamamen bağımsız bir değere sahip olmayıp, yukarıdakilerden 2. veya 3. görüş benimsenir ise, vekilin buna göre işlem yaparken miras hukukuna ait bir temsil müessesesine (vasiyeti yerine getirme görevlisine) tabi olmasını sağlamaktadır. Mirasçılar, mirasbırakan tarafından tayin edilen vasiyeti tenfiz memuruna belirli yasal gerekçeler dışında itiraz edemeyeceklerinden, vekilin sözleşmesini keyfî olarak feshedemeyeceklerdir.

1264 Başta ölümden sonraya etkili vekalet-temsil yetkisi olmak üzere, sağlararası işlem yoluyla ölüme bağlı kazandırmalar, yukarıdaki görüşlerden hangisinin benimsendiğine göre, şayet geçerli sayılır ise, sağlararası kazandırma gibi veya ölüme bağlı kazandırma gibi sıraya girecektir.

3. Ölüme Bağlı Kazandırmaların Tenkisi.

a) Genel olarak

1265 Şayet mirasbırakanın yaptığı birden fazla ölüme bağlı kazandırma varsa ve tenkisi gerekli miktar bu ölüme bağlı kazandırmaların toplamından daha azsa, ölüme bağlı kazandırmalar arasında tenkisin nasıl paylaştırılacağı sorunu çıkar.

1266 Bu hususta ilk önce mirasbırakanın bir tenkis tarzı öngörüp öngörmediğine bakılır. Şayet mirasbırakan yaptığı ölüme bağlı tasarrufların bazısının öncelikle tenkis edilmesini öngörmüşse[808], buna uyulacaktır (MK 563/I). Mirasbırakanın tenkiste önce ele alınmasını istediği kazandırmalar tamamen tenkis edilmeden arka sıraya koyduğu kazandırmalara dokunulmaz[809].

---

[807] Bu görüşte, *Piotet,* 139, 140: *Tandoğan, H.*, Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, C.II, 3.Bası, 658.

[808] Elbette bu ancak gerekli şekle uyularak yaptığı bir ölüme bağlı tasarrufla öngörülmüşse hukukî bir etkiye sahip olabilir.

[809] Mirasbırakanın bir kazandırmayı arka sıraya koyduğu buna ilişkin ölüme bağlı tasarrufunda kullandığı bazı ifadelerden de anlaşılabilir. Örneğin, birden fazla vasiyette bulunan mirasbırakan bunlardan sadece birine ilişkin vasiyetnamesinde bu kazandırmanın tenkis edilmemesini istediğini beyan etmişse, bunun anlamı, ancak diğer tüm vasiyetlerdeki ka-

Keza, mirasbırakan ölüme bağlı kazandırmaları arasında bir tenkis sırası öngörmek yerine bunların kanunun öngördüğünden farklı oranlarla tenkis yapılmasını kararlaştırmış olabilir. Örneğin, bunların farklı miktarlarda kazandırmalar olmasına rağmen hepsinden eşit miktarda tenkiste bulunulmasını veya eşit miktardaki kazandırmaların farklı miktarlarda tenkise tabi olmasını düzenlemiş olması mümkündür. Yasanın öngördüğü tenkisi toplam olarak gerçekleştirmek ve böylece tüm saklı paylı mirasçıların saklı paylarını kurtarmak şartıyla, yasanın tenkis düzenine değil mirasbırakanın arzusuna uyulur.

Şayet miras bırakan farklı bir tenkis düzeni öngörmemişse, ölüme bağlı 1267
kazandırmalar -kural olarak- MK 563/I uyarınca orantılı olarak (mütenasiben) tenkis edilecektir. Kanun orantılı tenkisten ne kastedildiğini belirtmemiştir. Öğretide kabul edildiği ve uygulamada benimsendiği üzere, orantılı tenkis, tasarruf oranına tecavüzün her ölüme bağlı tasarruftan aynı oranda tenkis edilmesi demektir. Şayet tenkise tabi ölüme bağlı tasarruflar farklı miktarlarda ise, bunlara aynı tenkis oranı uygulanınca farklı miktarlarda tenkise tabi olacaklardır. Özellikle, daha büyük olan kazandırma daha çok daha küçük olan kazandırma daha az tenkis edilecektir.

Örneğin: 1268

Terekesi 100 milyon lira olan mirasbırakan (M)'nin geride çocuğu (Ç) 1269
kalmış olup, sevdiği dostlarından (A)'ya 30 milyon lira ve (B)'ye de 45 milyon lira vasiyet etmişse, tenkis şöyle olacaktır:

Ç'nin saklı payı: 1/2 x 100 = 50 milyon lira. (M)'nin tasarruf oranı: 100 1270
-50 = 50 milyon Lira. Ölüme bağlı kazandırmalar toplamı: 30 + 45 = 75 milyon lira. Tasarruf oranına tecavüz eden ve tenkisi gereken miktar: 75 – 50 = 25 milyon lira. Bu 25 milyon liranın (A) ve (B)'ye yapılan vasiyetlerden orantılı tenkisi, aynı sonucu verecek iki tarzda hesaplanabilir:

a) Tenkis edilecek tecavüz miktarının ölüme bağlı tasarruflar toplamına 1271
oranı her kazandırmanın tenkisinde ayrı ayrı uygulanır[810]: 25 / (30 + 45=) 75 = 1/3. (A)'dan tenkis edilecek miktar: 30 milyon x 1/3= 10 milyon lira; (B)'den tenkis edilecek miktar: 45 milyon x 1/3= 15 milyon lira olacaktır.

b) Ölüme bağlı tasarrufların birbirlerine olan oranı bulunup her kazan- 1272
dırma toplam tenkis miktarının bu oranı kadar tenkis edilir[811]: (A) ve (B)'ye yapılan kazandırmaların birbirine oranı: 30 milyon - 45 milyon = 6-9 = 2-3,

---

zandırmaların tamamen tenkisine rağmen hâlâ tenkisi gereken bir miktar kalmışsa bu vasiyetteki kazandırmanın tenkis edilebileceğidir.

[810] Bu hesaplama için bkz. *Oğuzman*, 237

[811] Bu hesaplama için bkz. *Kocayusufpaşaoğlu*, 421, 422

(A)'nın ikisinin toplamına oranı: 2/5, (B)'nin toplama oranı: 3/5'dir. Toplam tenkis miktarı 25 milyar olduğuna göre, (A)'dan tenkis edilecek miktar: 25 x 2/5= 10 milyon lira; (B)'den tenkis edilecek miktar. 25 x 3/5= 15 milyon lira olacaktır.

1273 Görüldüğü gibi sonuç aynı yöntem değişiktir.

1274 Mirasbırakanın, gene bir ölüme bağlı tasarrufla, tenkise tabi ölüme bağlı tasarrufların tenkis oranını değiştirmesi veya tüm tenkisin sadece bazısından yapılmasını öngörmesi mümkün ve geçerlidir. Yeter ki saklı paylara tecavüz tamamen giderilsin. Yukarıdaki olay üzerinden örmek verelim: (M) vasiyetnamesinde, tenkis davası açılırsa sadece (A)'ya yaptığı kazandırmanın tenkis edilmesini veya (B)'ye yaptığı kazandırmanın ikinci sırada tenkis edilmesini belirtmişse; 25 milyon liralık tasarruf oranı tecavüzünün tenkisi için, (A)'ya yapılan 30 milyon liralık vasiyetin 25 milyonu tenkis edilerek bu vasiyet 5 milyona indirilecek ve (B)ye yapılan 45 milyon liralık vasiyete dokunulmayacaktır. Şayet tenkis edilecek miktar varsayalım ki 35 milyon lira olsa idi, (M) sadece (A) lehine kazandırmanın tenkis edilmesini vasiyet etseydi bile, (A)'nın 30 milyonu tamamen tenkise tabi tutulmakla yetinilmeyip, (B)'den de 5 milyon tenkis edilerek(B)'nin vasiyet alacağı 40 milyona indirilecekdi.

b) Saklı paylı mirasçılara yapılan kazandırmalar bakımından.

1275 Tasarruf oranına tecavüz eden ölüme bağlı kazandırmaların bazı saklı paylı mirasçılara yapılması hâlinde bunların tenkis oranları, MK 561 hükmünde özel olarak düzenlenmiştir. Bu hükme göre, birden fazla saklı paylı mirasçıya yapılan ölüme bağlı kazandırmalar, her biri lehine kazandırmanın saklı payını aşan miktarların birbirine oranına göre tenkis edilecektir. Yasakoyucu, saklı paylı mirasçılara yapılan ölüme bağlı kazandırmalar tenkis edilirken, tenkisin bu kazandırmaların birbirine oranının değil, her birinin saklı payından ne kadar fazla kazandırma almışsa bu miktarların birbirine oranının esas alınmasını istemiştir. Bu istisnanın sebebi, mirasbırakanın saklı paylı mirasçılarına saklı paylarını zaten sağlamak zorunda olmasıdır. Bu özellik gözden kaçırılmamak şartıyla, tenkis miktarının hesabı yukarıda belirttiğimiz normal durumdaki gibidir.

1276 Örneğin: (M) ölmüş ve geriye oğulları (A), (B) ve (C)'yi bırakmıştır.(M)'nin terekesi 120 milyon lira olup, (A)'ya 80 milyon ve (B)'ye 40 milyon vasiyet etmiştir. Safdışı edilmek istenen (C)'nin saklı payı olan (120 x 1/3 x1/2=) 20 milyon lirayı almak için açacağı tenkis davasında şu sonuca varılacaktır. (A)'nın miras payı 1/3 x 120 milyon = 40 milyon lira ve saklı payı: 40 x 1/2 = 20 milyon liradır. (B) için de aynı şey sözkonusudur ve onun da saklı payı 20 milyon liradır. (A)'ya yapılan 80 milyon lira-

lık kazandırmanın saklı payını aşan kısmı: 80 – 20 = 60 milyon lira ve (B)'ye yapılan 40 milyon liralık kazandırmanın saklı payını aşan kısmı: 40 – 20 = 20 milyon liradır. Bundan sonra gene iki türlü hesap yapılarak sonuca varılabilir: a) kazandırmaların lehdarlarının saklı paylarından fazla kısımların toplamı 60 + 20 = 80 milyon liranın, tenkisi gerekli (tasarruf oranına tecavüz eden) 20 milyon liraya oranı: 20/80= 1/4 her kazandırmanın lehdarının saklı payından fazlasına uygulanacak tenkis oranı olacaktır. Böylece, (A)'dan 60 x 1/4 = 15 milyon lira ve (B)'den 20 x 1/4 = 5 milyon lira tenkis edilecektir. b) Yahut (A) ve (B)'nin alacakları kazandırmaların saklı paylarını aşan miktarların birbirine oranı bulunacaktır ki bu (B) 20 - (A) 60 = 1-3 olduğundan, bu kesirleri tamlayan 4 paydaya göre, toplam tenkisi gereken 20 milyonun (A) ve (B)'den tenkis oranları: 20 x 3/4 = 15 milyon lira (A)'dan ve 20 x 1/4 = 5 milyon lira (B)'de tenkis edilecek miktar olarak bulunur.

Oysa bu özel kural olmasa, ölüme bağlı tasarruflar miktarları oranında 1277
tenkis edileceğinden, 40 - 80 = 1-2; (B)'dan tenkis edilecek miktar: 20 x 1/3 = 6,66 milyon lira ve (B)'den tenkis edilecek miktar: 20 x 2/3 = 13,33 milyon lira[812] olacaktı.

Görüldüğü gibi, MK 561 istisnaî hükmü sayesinde, saklı paylı mirasçı- 1278
lara yapılan kazandırmaların tenkisinde, normal tenkis oranlarına göre, lehine daha büyük miktarda kazandırma yapılandan daha fazla, daha küçük miktarda kazandırma yapılandan daha da az miktarda tenkis yapılmakta; daha az kazandırma alan saklı paylı mirasçılar genel hesaplama tarzına göre çok daha fazla himaye edilmiş olmaktadır.

Elbette bu hesaplama yapılırken, saklı payına tecavüz edilen mirasçı 1279
şayet varsa kendisine yapılan kazandırmayı saklı payına mahsup edecektir. Bunu da gösteren bir örnek verelim:

(M) ölmüş ve geriye 160 milyon liralık tereke ile eşi (E), çocukları (A) 1280
ve (B)'yi bırakmıştır. (M)'nin vasiyetnamesi açılınca, (E)'ye 100 milyon lira, (A)'ya 50 milyon lira, (B)'ye ise 10 milyon lira vasiyet ettiği görülmüştür. (B) diğerlerine karşı tenkis davası açmıştır. Burada (E)'nin miras payı 1/4 olup, geri kalan 3/4 iki çocuk arasında paylaşılacağından, (B)'nin miras payı 3/4 x 1/2 = 3/8 ve saklı payı: 3/8 x 1/2= 3/16 olup, bu da 160 milyon x 3/16 = 30 milyon lira eder. (B) kendisine yapılan 10 milyonluk vasiyeti saklı payına mahsup edeceğinden, 30 – 10= 20 milyon liralık tenkis talep edebilecektir. Sağ kalan eş olarak (E)'nin miras payı olan 40 milyon lira aynı zamanda saklı payı olduğundan, kendisine yapılan kazandırmanın bunu aşan kısmı: 100 – 40 = 60 milyon liradır. (A)'ya yapılan kazandırmanın

[812] Diğer hesap tarzıyla: 20/120=1/6, (B)'den tenkis edilecek miktar: 40 x 1/6 = 6,66 milyon lira, (A)'dan tenkis edilecek miktar: 80 x 1/6 = 13,33 milyon lira; olacaktı.

saklı payını aşan kısmı da: 50 – 30 = 20 milyon liradır. Bunların birbirine oranı 20-60 = 1-3 olup; 20 milyonluk tenkisin 1/4 kadarı (A)'dan yapılarak: 20 milyon x 1/4= 5 milyon lira (A) lehine 50 milyonluk kazandırmadan indirilerek ona 45 milyon verilecek; 3/4 kadarı (E)'den yapılarak: 20 milyon x 3/4= 15 milyon lira (E) lehine 100 milyonluk kazandırmadan indirilerek ona 85 milyon verilecektir.

1281 Saklı paylı mirasçılar lehine yapılan kazandırmalarda, şayet her birine yapılan kazandırma miktarı ile saklı paylar tamamen karşılanıyorsa, yapılan ölüme bağlı kazandırmalar toplamı soyut olarak mirasbırakanın tasarruf oranını aşsa bile, burada üçüncü kişilere değil bizzat saklı paylı mirasçılara kazandırmada bulunulmuş olup her biri aldıkları kazandırmayı saklı paylarına mahsup edeceklerinden, hiç birinin saklı payı ihlal edilmemiş olacağı için tenkise yer olmayacaktır. Örneğin: (M)'nin terekesi 120 milyon lira olup, Çocuklarından(A)'ya 50 milyon liralık, (B)'ye (40) milyon liralık vasiyette bulunsa ve (C)'ye bir vasiyeti olmasa; tasarruf oranı: 120 x 1/2 = 60 milyon olup, ölüme bağlı tasarruflar toplamı (50 + 40=) 90 milyon lira ile tasarruf oranını (90 – 60=) 30 milyon lira tecavüz etmiş görünmesine karşılık; burada kazandırmalar esasen saklı paylı mirasçılara yapıldığından, (A) miras hissesi olan 40 milyondan sadece 10 milyon fazla alacak ve (B) de aldığı 40 milyon ile tam miras hissesini almış olacağından, bunların toplamını oluşturan (50 + 40=) 90 milyon çıktıktan sonra geriye kalan miktar (120 – 90=) 30 milyon olarak (C)'nin 20 milyonluk saklı payını fazlasıyla karşıladığından (C'nin saklı payı: 120 x 1/3 x 1/2= 20); tenkise yer olmayacaktır.

1282 Bazen tasarruf oranını aşan kazandırmaların bazısı saklı paylı mirasçılara bazısı başka kişilere yapılmış olabilir. Eski MK 503 hükümleri bu durumu düzenlememiş olmasına rağmen, öğreti işin niteliğinin zorunlu kıldığı gerekçesiyle, saklı paylı mirasçıların yanı sıra başka kişilere de ölüme bağlı kazandırma yapılan durumlarda hatta sadece bir saklı paylı mirasçıyla birlikte başka kişilere kazandırmalar yapıldığında, gene Eski MK 503 hükmüne göre tenkis miktarlarının hesap edilmesini uygun görmekteydi[813]. Yeni MK 561 ise açıkça, saklı pay sahibi mirasçıya yapılan kazandırmanın saklı payı aşan kısmı ile saklı pay sahibi olmayan kimselere yapılan kazandırmaların orantılı olarak tenkisini öngörmüştür. Böylece, bu gibi durumlarda tenkis oranları hesaplanırken, saklı paylı mirasçı veya mirasçılar lehine yapılan kazandırmaların onların saklı paylarını aşan miktarları ile diğer kişilere yapılan kazandırmaların tamamı arasındaki oranlara göre bu kazandırmalar tenkis edilecektir.

---

[813] *Tuor*, Art. 523, N.12; *Escher*, Art.523, N.7; *Kocayusufpaşaoğlu*, 423; *Oğuzman*, 238; *Eren*, tenkis, 159 vd.; *İmre*, 448 vd.

Örneğin: (M) ölmüş ve yerine oğlu (A) ile kızı (B) kalmıştır. Terekesi 1283
120 milyon lira olan (M)'nin vasiyetnamesinden kızı (B)'ye 60 milyon ve sevgilisi (Ü)'ye 60 milyon lira vasiyet ettiği anlaşılmıştır. Burada mağdur olan oğul (A)'nın saklı payı, 120 x 1/2 x 1/2 = 30 milyon liradır. Bu 30 milyon (B) ve (Ü)'ye yapılan kazandırmalardan tenkis edilir iken tenkis oranlarının saptanmasında, (Ü)'ye yapılan kazandırmanın tamamı (60 milyon Lira) ile (B)'ye yapılan kazandırmanın sadece (B)'nin saklı payını aşan kısmı (60 - 30 = 30) milyon lira) arasındaki oran esas alınacaktır. Bu oran (30-60 =) 1-2 = 1/3 – 2/3 olduğuna göre, 30 milyonun 1/3'i yani 10 milyonu (B)'ye yapılan vasiyetten; 2/3'si'i yani 20 milyonu (Ü)'ye yapılan vasiyetten tenkis edilecektir.

MK 561 hükmünde getirilen tenkis oranlarının emredici olmadığı, mi- 1283
rasbırakanın başka bir oranlama ile tenkis yapılmasını öngörebileceği, kabul edilmektedir[814]. Mirasbırakan, burada tenkis hesabının MK 563/I hükmündeki ana kurala göre yapılmasını da öngörebilir[815].

4. Sağlararası Kazandırmaların Tenkisi

Mirasbırakanın ölüme bağlı kazandırmada bulunmadığı veya yaptığı 1285
ölüme bağlı kazandırmaların tümünün tamamen tenkisine rağmen hâlâ tenkisi gereken bir miktar kaldığı durumlarda, daha önce belirttiğimiz[816] bazı sağlararası kazandırmalar da tenkise tâbi olacaktır. Bunların arasında tenkis orantı esasına göre değil, tarih sırasına göre yapılacaktır. MK 570 hükmüne göre, tenkise tabi birden fazla sağlararası kazandırma bulunup bunların tamamen tenkisi gerekmiyorsa, yapıldıkları an bakımından en son tarihliden başlamak eskiye doğru sırayla tenkis edileceklerdir. Yasakoyucu, mirasbırakanın ölümüne daha yakın tarihli kazandırmanın eskiye oranla öncelikle gözden çıkarılmasını kabul etmiştir.

Sıralama yapılırken sağlararası kazandırmaya yönelik borçlandırıcı iş- 1286
lemin (örneğin, bağışlama taahhüdü) yapıldığı tarihin mi yoksa bunun ifası tarihinin mi (örneğin, bağışlanan malın teslimi) esas alınacağı tartışmalıdır. Çoğunluk, borçlandırıcı işlemin yapıldığı tarihi esas almaktadır[817]. Buna karşılık, özellikle yerine getirilmesi bağışlayanın ölümüne bağlı bağışlamaları sağlararası işlem değil ölüme bağlı tasarruf sayan BK 290/II hükmünden esinlenen bir görüş, sağlararası kazandırmaları sıralarken ifa tarihinin

---

[814] Bkz yukarıda 3a.

[815] Bu takdirde saklı paylı mirasçılara yapılan kazandırmaların bunların saklı paylarını aşan kısımları değil lehlerine yapılan kazandırmanın tümü üzerinden orantı kurulacaktır.

[816] Bkz. § 21 III 2.

[817] *Tuor*, Art.532, N.4; *Escher*, Art.582, N.3; *Kocayusufpaşaoğlu*, 423; *İmre*, 441; *Eren*, Tenkis, 162

esas alınmasını savunmaktadır[818]. Böylece, örneğin (M) ölümünden 6 ay önce (A)'ya ve 5 ay önce de (B)'ye 1 milyon lira bağışlama taahhüdünde bulunmuş olup, ölümünden 4 ay önce (B)'ye ve 3 ay önce de (A)'ya bu vaad ettiği paraları ödemişse; bu kazandırmalara karşı (M)'nin oğlu (O)'nun 1 milyon liralık tenkis davası açması hâlinde, şayet birinci (baskın) görüş kabul edilirse (A) aldığı parayı tamamen vermekle yükümlü tutulurken (B) aldığı parayı elinde tutacak, ikinci görüş kabul edilirse (A) tenkisten tamamen kurtulurken (B)'nin aldığı para bütünüyle tenkis edilecektir. Nihayet, öğretide bir üçüncü görüş, MK 507/b.3 çerçevesine giren bağışlamalarda ifa tarihinin diğer tenkise tabi sağlararası kazandırmalarda taahhüt tarihinin esas alınması şeklindedir[819].

1287 Tenkise tabi sağlararası kazandırmalar arasındaki en küçük bir zaman farkı bile sıralamaya sebep olur. Örneğin bir bağışlama diğerinden sadece birkaç dakika sonra yapılmış bile olsa (elbette bunun ispatı şartıyla), önceki tamamen tenkis edilmeden ona sıra gelmeyecektir[820].

1288 Buna karşılık, aynı anda yapılan (örneğin aynı kağıda iki ayrı kişiye bağışlama yapıldığının yazılıp altının mirasbırakanca imzalanması) veya hangisinin önce yapıldığı tespit edilemeyen sağlararası kazandırmaların varlığı hâlinde, bunların ölüme bağlı kazandırmalar gibi (MK 563/I hükmüne kıyasen) miktarları oranında tenkisi kabul edilmektedir[821].

1289 Şayet tenkise tabi sağlararası kazandırmaların bazısının tarihi belirli bazısının tarihi belirsiz ise ne olacağı tartışmalıdır. Bir görüşe göre böyle bir durumda tarihi belirsiz sağlararası kazandırma en son tarihli sayılarak ilk önce tenkis edilmelidir[822]. Bir başka görüş, bunun adil olmadığı, muhtemel en yakın tarihe göre sıralama yapılması şeklindedir[823]. Gerçekten de, kazandırmaların tarihinin belirsiz olması başka şey, bunların hangisinin önce hangisinin sonra yapıldığının anlaşılması başka şeydir. Örneğin ikisinin tarihi de bilinmeyen yazılı bağışlama taahhütlerinden birinde diğerinden sözediliyorsa, hangisinin önce hangisinin sonra olduğu bellidir ve önceki

---

[818] *Oğuzman*, 239. yazar bu görüşün, ayrıca, MK 507/3 hükmündeki ölümden önceki 1 yıl içinde yapılan bağışlamaları saptarken bağışlama taahhüdünün değil bağışlananın teslîminin (ifanın) yapıldığı tarihin esas alınması görüşüyle de tutarlı olacağını belirtmektedir.

[819] *Rösli, A.*, Herabsetzungsklage und Ausgleichung im schweizerischen Zivilgesetzbuch, Andelfingen 1936, 104 (*Kocayusufpaşaoğlu*, s.423 not 39'dan naklen).

[820] *Oğuzman*, 239; *Escher*, Art.532, N.3; Yarg. 2.HD 30.9.1963 5273/5242 (*Şener*, 2.Bası, 1147)

[821] *Escher*, Art.532, N.3; *Tuor*, Art.532, N.4; *Kocayusufpaşaoğlu*, 424; *Oğuzman*, 239; *Eren*, Tenkis, 163; Yarg. 2.HD 15.12.1981, 7897/8093 (YKD 1982, S.8, s.1095).

[822] *Kocayusufpaşaoğlu*, 424; *Tuor*, Art.532, N.4; *Escher*, Art.532, N.3

[823] *Oğuzman*, 239, not 645 c

(kendisinden bahsedilen) bağışlama tamamen tenkis edilmeden diğerine dokunulamaz. Belirtmek gerekir ki, hangi kazandırmanın daha yakın tarihli olduğu muhtemelen dahî anlaşılamıyorsa, gene ilk görüş çerçevesinde orantılı tenkis yapılacaktır.

5. Kamu Yararına Kazandırmaların Tenkisi.

Yeni MK 570/II, Kamu tüzel kişileri ile kamuya yararlı dernek ve va- 1290
kıflara yapılan ölüme bağlı tasarruflar ve sağlararası kazandırmaların en son sırada tenkis edileceği kuralını getirmiştir. Eski MK zamanında mevcut olmayan bu kuralın getirilme sebebi, Eski MK 453 /II hükümleriyle kamu yararına kazandırmalarda saklı payların özel olarak azaltılmasına karşılık Yeni Kanunda bu özel indirimin düzenlenmemiş olmasıdır. Böylece, artık kamu yararına bazı kazandırmalarda saklı paylar herhangi bir azalmaya uğramamakla birlikte, bu kazandırmalar en son sırada tenkis edilecektir. Bu yeni hüküm, kamu yararına kazandırmaları özel olarak korumasının yanında, Eski MK 453 /II hükmünün bunlar için özel saklı pay kabul etmesi sebebiyle kamu yararına kazandırmalarla alelade kazandırmaların bir arada olması durumunda tenkiste farklı saklı paylara göre tasarruf oranı hesaplanmasından doğan zorluk ve tartışmaları da sona erdirmiştir.

Bir kazandırmanın MK 570 uyarınca kamu yararına kazandırma sayıl- 1291
ması ve son sırada tenkis edilmesi, kazandırmadaki öznel amaca göre değil kazandırmanın yapıldığı kişiye göre belirlenmiştir. Ancak şu üç tip tüzel kişiye yapılan kazandırmalar son sırada tenkis edilecektir. A- Kamu tüzel kişileri, b- kamuya yararlı dernekler, c-kamuya yararlı vakıflar.

Kamu tüzel kişileri Anayasanın 123. Maddesine göre kanunla veya ka- 1292
nunun verdiği yetkiyle kurulan, kamu otoritesine sahip, kamu görevi yapan tüzel kişilerdir. Kamu idareleri ve kamu kurum ve kuruluşları olarak iki gurupta toplanırlar. Kamu iktisadi teşebbüslerinin ise kamu hukuku tüzel kişisi olup olmadıkları tartışmalıdır.

Kamuya yararlı dernekler 2908 SK 58,59 hükümlerindeki şartları ger- 1293
çekleştirerek Bakanlar Kurulunun onayı ile bu sıfatı kazanan derneklerdir.

Kamuya yararlı vakıflar ise (bu tabir yasada kullanılmamakla birlikte) 1294
903 SK 4 hükmündeki ve 19.3.1982 tarihli Tüzüğün 37. maddesindeki şartları gerçekleştirerek Bakanlar Kurulunun kararı ile vergi muafiyeti tanınan vakıflardır. MK 570/II sadece bu tür bir vakfa yapılan kazandırmadan söz ettiğinden, mirasbırakanın böyle bir vakıf kurmak amacıyla malvarlığı tahsis etmesi maddenin kapsamı dışında kalmış görünmektedir. Böylece, esasen kurulmuş bu nitelikteki bir vakfa bağışta bulunma veya vasiyette bulunma hâlinde kazandırma son sıraya konulacak iken, mirasbırakanın sağlı-

ğında kendisinin bu nitelikte bir vakıf kurması veya böyle bir vakıf kurulması için vasiyette bulunarak malvarlığı tahsis etmesi hâlinde bu kazandırmalar son sıraya konulmayacaktır. Kanımca bu sonuç yasanın amacına uygun ve adil değildir. Şayet mirasbırakanın sağlığında kurduğu vakıf sonradan kamuya yararlı vakıf haline gelmişse, bu sağlararası kazandırma da MK 570/II uyarınca tenkiste son sıraya konulmalıdır Buna karşılık, mirasbırakan kamuya yararlı vakıf olmaya elverişli bir maksatla vakıf kurulmasını vasiyet etmişse, bir ayırım yapılmalıdır: Şayet tenkis davası açılıncaya kadar vasiyet konusu vakıf kurulmuş ve Bakanlar Kurulu kararı ile vergi muafiyeti almışsa, bu kazandırma gene son sıraya konulmalıdır. Şayet tenkis davası açıldığında henüz vasiyet konusu vakıf kurulmamış veya kurulmuşsa da henüz vergi muafiyetine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı alınmamışsa, tenkis davasında hakim bu şartların gerçekleşmesini bir bekletici mesele yapmalıdır. Vakıf en kısa zamanda kurulup Bakanlar Kuruluna başvurarak vergi muafiyeti alırsa bu kazandırma son sıraya konularak tenkis davası devam etmeli, vergi muafiyeti alamazsa alelade ölüme bağlı kazandırma gibi diğer ölüme bağlı kazandırmalarla oransal tenkise tabi tutulmalıdır.

1295 MK 570/II kapsamına giren kazandırmalar ister sağlararası ister ölüme bağlı olsunlar son sırada yer alacaklardır. Keza birlikte tenkis edilecek alelade kazandırmalrın da sağlararası veya ölüme bağlı olması da bunların son sıraya konulmasını değiştirmez. Böylece, örneğin, kamu yararına kazandırma sayılan bir vasiyet, bu nitelikte olmayan bir sağlararası bağışlamadan sonra tenkis edilecektir. Keza daha yeni tarihli bir kamuya yararlı bağışlama daha eski tarihli bir alelade bağışlamadan sonra tenkis edilecektir.

1296 Tüm kazandırma çeşitlerini içeren örnek verelim: (M) öldüğünde geriye eşi (E) ile 100 milyon lira banka hesabı bırakmıştır. (M) vasiyetnamesinde arkadaşı (A)'ya 25 milyon lira ve (Ü) Üniversitesine 20 milyon vasiyet etmiş olup, ölümünde beş ay önce sevgilisi (S)'ye 30 milyon lira bağışladığı ve gene ölümünden üç ay önce de kamuya yararlı (D) derneğine 10 milyon lira bağışladığı anlaşılmıştır. (E) tenkis davası açtığında, tereke: (100 + 30 + 10=) 140 milyon lira. (E)'nin saklı payı: 140 milyon x 3/4 = 105 milyon lira; tasarruf oranı (140 – 105=) 35 milyon lira. Tenkise tabi kazandırmalar toplamı = (25 + 20 + 30 + 10=) 85 milyon liradır. Tasarruf oranı (85 – 35=) 50 milyon lira aşılmıştır. (A)'ya yapılan 25 milyonluk vasiyetin tamamı ile (S)'ye yapılan bağışlamanın 5 milyon lirası tenkis edilecek (30-5= 25 milyon (S)'ye bırakılacak); Ü'ye yapılan vasiyet ile (D)'ye yapılan bağışlamaya dokunulmayacaktır. Zira bunlar MK 570/II kapsamındadır.

1297 Şayet birden fazla kamuya yararlı kazandırmanın tenkisi gerekiyor ise, bunların kendi arasındaki sıra bakımından tenkiste sıraya ilişkin genel ku-

rallar uygulanacaktır. Yani önce ölüme bağlı kazandırma şeklinde olanlar tenkis edilip bu yeterli olmazsa sağlararası kazandırma şieklinde olanlar tenkis edilecek; birden fazla kamuya yararlı ölüme bağlı kazandırma oransal olarak, birden fazla kamuya yararlı bağışlama ise son tarihliden itibaren tenkis edilecektir.

Kamuya yararlı kazandırmalarda saklı payları indiren Eski medeni ka- 1298
nunun yürürlükte olduğu sırada yapılmış kazandırmalar, şayet mirasbırakan yeni Medeni Kanunun yürürlüğe girdiği 1.1.2002 tarihinde veya bu tarihten sonra ölmüşse, mirasçıların haklarını mirasbırakanın ölümü tarihindeki kanuna tabi tutan Tatbikat kanununun 17.maddesi uyarınca, Yeni Medeni kanunun yukarıda açıkladığımız hükümlerine tabi olmalıdır. Bu durumlarda, Tatbikat Kanunu 1/II hükümünün işlemlerin geçerliliği yapıldıkları tarihteki kanuna tabi tutan kuralı gerekçe gösterilerek, Eski Medeni kanunun indirilmiş saklı payları uygulanmamalıdır. Böyle bir yorum yasakoyucunun amacına ters düşer. Buna karşılık, şayet mirasbırakan yeni medeni kanunun yürürlüğe girdiği 1.1.2002 tarihinden önce ölmüşse, bu tarihten sonra açılan tenkis davalarında da Eski Medeni kanunun indirilmiş saklı paylarına göre hesaplama yapılmalı ve yeni Medeni Kanunun bu kazandırmaları son sıraya bırakan hükmü uygulanmamalıdır. Ancak böyle bir durumda Tatbikat K 20 uyarınca Eski kanundaki süreler uygulanacağından, tenkis davası Eski MK 513 uyarınca azamî beş yıllık süreye tabi olacaktır. Şu halde, Eski MK hükümlerine göre indirilmiş mahfuz hisselerin uygulaması en geç 1.1.2007 tarihinde sona erecektir. Bu tarihe kadar uygulanma olasılığı bulunan eski sistem aşağıdaki gibidir.

Saklı payı daraltan kazandırmalarda tenkis ve bunların alelâde kazandırmalarla 1299
birarada bulunması.

Daha önceki açıklamalarımızda belirttiğimiz üzere[824], 3678 Sayılı ve 23.11.1990 1300
tarihli Kanunla MK 453. maddesine getirilen hükümle, kamuya yararlı sayılan bazı kazandırmaların varlığı hâlinde saklı payların, her bir saklı paylı mirasçı için normal saklı pay oranının 2/3 kadar azaltılmış hâli olacağı düzenlenmişti. Şayet bu hükümde belirtilen kamuya yararlı kazandırmalar sözkonusu ise, yapılacak şey, mirasbırakanın tüm saklı paylı mirasçılarının saklı paylarını 2/3 azaltarak tasarruf oranını bulmak ve buna rağmen bu çoğalmış tasarruf oranına tecavüz varsa, tecavüz eden miktarı normal tenkis tarzı ve sırasıyla tenkis etmekti.

Gene daha önce belirttiğimiz üzere[825], bu değişiklikten önce MK.453 hükmünün 1301
903 sayılı Kanunla değişik hâline göre, azaltılmış saklı paylar normal saklı payların 1/3 kadarı idi ve ayrıca 1659 Sayılı Kanunla yapılan değişikliğe göre, kendisine "mahfuz gelir"[826] tahsis edilen saklı paylı mirasçının tenkis hakkı tamamen kaldırılmıştı. Şu kadarını belirtelim ki, mirasbırakanın bu hükümleri değiştiren

[824] Bkz. § 20 II 2
[825] Bkz.. § 20 II 2
[826] Bu kurum için bkz. § 20, II, 2, dip not 14'e ilişkin metnin devamı.

3678 Sayılı kanunun yürürlüğe girdiği 23.11.1990 tarihinden önce öldüğü durumlarda[827], bu tarihten sonra ileri sürülecek tenkis talep veya defilerinde, azami dava açma süresinin dolduğu 23.11.1995'e kadar bu daha da eski düzene göre tenkis hesabı yapılmıştır. Böyle bir durumda, mahfuz gelirin varlığı hâlinde gelir tahsis edilen tenkis hakkını kesin olarak kaybeder ve diğer saklı paylı mirasçılar da saklı payları 1/3 azalmış olarak yapılacak hesaba göre tenkis isteyebilir veya isteyemezlerdi.

1302 Tenkise tabi kazandırmaların tümünün saklı payı azaltan (kamu yararına) kazandırmalar olması hâlinde, durum basitti. Belirttiğimiz üzere, saklı pay oranlarının değişmesi (azalması) dışında, her zamanki tenkis hesabının tamamen aynısı yapılırdı. Gelgelelim, şayet tenkise konu kazandırmaların arasında hem saklı payı azaltan kazandırmalar hem de alelâde kazandırmalar varsa, tenkis hesabının nasıl yapılacağı bir sorun olarak ortaya çıkardı. Örneğin, mirasbırakan terekesinin bir kısmını kamuya yararlı bir vakfa bir kısmını ise sevdiği bir dostuna vasiyet etmişse, durum böyleydi. Kanun böyle bir durumda tenkisin hangi esaslara göre yapılacağını belirtmemişti. Elbette burada alelâde kazandırma var diye tenkis hesabı normal saklı paylar dikkate alınarak yapılamazdı. Aksi takdirde kamu yararına kazandırma yasanın emrettiği korumadan yoksun bırakılmış (onun lehine saklı paylar azaltılmamış = tasarruf nisabı çoğaltılmamış) olurdu. Buna karşılık, tenkis hesabı saklı paylar azaltılarak yapılırsa, bu kez de alelâde kazandırma lehdarı yasanın istemediği şekilde tasarruf oranının genişlemesinden yararlanırdı. Şu halde, her iki tip kazandırmanın da niteliğine ters düşmeyecek bir hesaplama yapılmalıydı.

1303 Böyle bir hesaplamanın nasıl olacağı hakkında, her bir ihtimal için başlıca iki farklı yöntem önerilmişti:

1304 a) Hem kamu yararına kazandırmaların hem de alelâde kazandırmaların ölüme bağlı olması hâlinde:

1305 Bir hesap tarzına göre[828], önce sadece alelâde kazandırmalar toplamının alelâde tasarruf oranını aşıp aşmadığına bakılacak, şayet aşıyorsa bu oranda tenkis edilecekler; bu tenkisten geriye kalan alelâde kazandırmalarla kamuya yararlı kazandırmalar toplanarak, bu miktarın çoğaltılmış tasarruf oranını aşıp aşmadığına bakılacak, şayet aşıyorsa bu miktar sadece kamu yararına kazandırmalardan tenkis edilecekti.

1306 Diğer bir hesap tarzına göre[829], Alelâde olsun kamuya yararlı olsun tüm kazandırmaların toplamının çoğaltılmış tasarruf oranını aşan kısmının gene bu tüm kazandırmalar toplamına oranı bulunacak ve gerek alelâde kazandırmalardan gerekse kamuya yararlı kazandırmalardan bu oranda tenkis yapıldıktan sonra; bu kez tüm kazandırmalar toplamının alelâde tasarruf oranına oranı bulunarak her bir tasarruftan bu oranda ikinci bir tenkis yapılacak fakat bu tenkis sırasında daha önce tenkis edilen miktarlar düşülecektir.

1307 b) Hem kamu yararına kazandırmaların hem de alelâde kazandırmaların sağlararası olması hâlinde:

1308 Bir hesap tarzına göre[830], burada da önce sadece alelâde kazandırmalar toplamı-

---

[827] Önemli olan ölümün bu tarihten önce olmasıdır. Ölüm bu tarihten sonra gerçekleşmişse, tenkise tabi kazandırmalar bu tarihten önce yapılmış olsa bile yeni hükümlere göre tenkise tabi olurlar.

[828] *Kocayusufpaşaoğlu*, 425 vd..

[829] *Oğuzman*, 243 vd.

[830] *Kocayusufpaşaoğlu*, 426 vd.

nın alelâde tasarruf oranını aşan kısmı tenkis edilecek, ardından bu tenkisten geriye kalan alelâde kazandırma kısmı ile kamuya yararlı kazandırmalar toplanarak bu toplamın çoğaltılmış tasarruf oranını aşan kısmı sadece kamuya yararlı kazandırmalardan tenkis edilecekti. Görüldüğü üzere burada, şayet biri kamuya yararlı diğeri alelâde kazandırma ise, Eski MK. 512'den farklı olarak, daha sonraki tarihli sağlararası kazandırmanın varlığına rağmen daha önceki tarihli sağlararası kazandırma da tenkise tabi tutulabilmekteydi.

Bir diğer hesap tarzına göre[831], kamuya yararlı ve alelâde kazandırmalar toplamının çoğaltılmış tasarruf oranını aşan kısmı bertaraf edilinceye kadar yapıldıkları tarihten geriye doğru bütün kazandırmalar türüne bakılmadan sırayla tenkis edilecek; bundan sonra, gene bütün kazandırmalar toplamının alelâde tasarruf oranını aşan kısmı bertaraf edilinceye kadar bu kez sadece alelâde kazandırmalar son tarihliden itibaren sırayla tenkis edilecekti. Bu sırada alelâde kazandırmalardan daha önce yapılmış tenkis miktarları mahsup edilecekti. 1309

c) Alelâde ve kamuya yararlı kazandırmaların bazısının ölüme bağlı bazısının sağlararası olması hâlinde. 1310

Bir hesap tarzına göre[832], Ölüme bağlı veya sağlararası olsun, önce alelâde kazandırmaların alelâde tasarruf oranını ne kadar aştığı bulunacak ve bu aşan miktar önce ölüme bağlı alelâde kazandırmalardan oransal olarak bu da yetmezse gene sağlararası alelâde kazandırmalardan son tarihliden itibaren tenkis edilecekti. Ardından, ölüme bağlı ve sağlararası kazandırmalardan ilk tenkisten geriye kalan miktarlar ile ölüme bağlı ve sağlararası kamuya yararlı kazandırmalara toplanarak bunun çoğaltılmış tasarruf oranını ne kadar aştığı bulunacak, bu aşan miktar, önce ölüme bağlı kamuya yararlı kazandırmalar arasında oransal olarak ve bu yetmezse sağlararası kamuya yararlı kazandırmalardan son tarihliden başlayarak geriye doğru tenkis edilecekti. 1311

Diğer hesap tarzına göre, gene sağlararası ve ölüme bağlı tüm kazandırmaların çoğaltılmış tasarruf oranına tecavüz ettiği miktar bulunacak ve bu miktarın tüm teberrulara oranında ölüme bağlı kazandırmaların (alelâde veya kamu yararına) tümü tenkis edilecekti. Şayet bu tenkiste sağlararası kazandırmalara gidilmesine gerek kalmamışsa, alelâde tasarruf oranının tüm kazandırmalarca aşılıp aşılmadığına bakılarak şayet aşılmışsa bu tecavüz miktarının tüm kazandırmalara oranı kadar önce ölüme bağlı alelâde kazandırmalar orantılı olarak ve bu yetmezse sağlararası alelâde kazandırmalar son tarihliden itibaren –fakat önceden yapılan tenkis mahsup edilerek- tenkis edilecekti. Şayet çoğaltılmış tasarruf nisabına tecavüz ölüme bağlı kazandırmaların tümünden fazla ise, bu fazlalık alelâde ve kamu yararına kazandırma ayırt edilmeksizin en son tarihliden geriye doğru sağlararası kazandırmalardan tenkis edilecekti. Bu tamamlandıktan sonra, tüm kazandırmaların alelâde tasarruf oranını aştığı oranda, sadece alelâde kazandırmalar son tarihliden geriye doğru tenkis edilecektir. Bu arada, zaten yapılmış tenkis bu tenkisten mahsup edilecekti. 1312

Görüldüğü gibi, Yeni Medeni Kanunun bu son derece karmaşık ve tartışmalı hesaplamaları tamamen kaldıran ve bunların yerine kamuya yararlı kazandırmaları tenkiste son sıraya koymakla yetinin düzenlemesi, gayet isabetli olmuştur. 1313

---

831 *Oğuzman*, 244 vd.

832 *Kocayusufpaşaoğlu*, 427 vd.

V. TENKİSİ ÖZELLİK TAŞIYAN BAZI KAZANDIRMALAR

1. Değerinde Azalma Olmaksızın Bölünemeyecek Şeyin Vasiyetinde Tenkis.

1314 Bir miktar veya başka bir mislî eşyanın tenkisi kolaydır. Bu para veya eşyadan tenkis miktarı kadar terekede alıkonarak saklı paylı mirasçılara bırakılır ve kalan kısmı kazandırma lehdarına verilir. Fakat şayet tenkis konusu kazandırma bölünemeyecek bir mal ise, tenkisin "aynen" yapılması mümkün olmaz. Bir ev, araba, tablo vb. vasiyet edilmiş olup tenkisi gerektiği durumlar böyledir. Kuşkusuz bu durumlarda da tenkis kazandırmanın parasal değerine göre hesaplanacaktır. Fakat tenkisi gereken miktarın tahsili hususunda, MK 564 hükmü bu durumlar için vasiyet alacaklısına bir seçim hakkı tanımıştır. Buna göre, elindeki mal tenkis edilecek olan vasiyet alacaklısı, dilerse tenkis edilecek miktarı para olarak (nakden) öder ve malın verilmesini talep eder, dilerse malı terekeye bırakarak tenkis dışı kısmın değerini para olarak talep eder.

1315 Örneğin, (M) tarafından kendisine 20 milyon lira değerinde otomobil vasiyet edilen (A), (M)'nin oğlu (B) nin açtığı tenkis davası üzerine bu kazandırmanın 5 milyon lirasının tenkisi gerektiği ortaya çıkmışsa, dilerse (B)'ye 5 milyon lira verip vasiyet konusu otomobili alacak, dilerse otomobili almaktan vazgeçtiğini bildirerek (B)'den (20 – 5=) 15 milyon lira isteyecektir.

1316 Şayet birden fazla saklı paylı mirasçı bulunup da bunlardan bazısı tenkis davası açmış bazısı açmamışsa, tenkis hükmünden sadece dava açanlar yararlanacağından, vasiyet alacaklısı sadece tenkis davası açanın yararlanacağı tenkis miktarını para olarak ödeyip vasiyet edilen malın tümünü isteyebilecektir. Bu vasiyet alacaklısı için çok kârlı bir seçenek olacaktır. Buna karşılık, vasiyet alacaklısının malı istemekten vazgeçip para istemesi, bu şıkta daima aleyhine sonuç verecek ve tercih etmeyeceği bir seçenek olacaktır. Zira, şayet bu hakkını seçerse, malı terk etmesi karşılığında sadece tenkis davası açanın bu mal üzerindeki hissesinin tenkis ettireceği miktarı aşan kısmı kadar para isteyebilecektir.

1317 MK 564/II aynı kuralların sağlararası kazandırmaların tenkisinde de uygulanacağını hükme bağlamıştır. Eski MK 506'da sadece vasiyet alacaklıları için bu seçimlik imkânlar düzenlenmişti. Buna rağmen öğretide ve uygulamada, sağlararası kazandırmaların tenkisinde de kıyasen aynı hükmün uygulanması kabul edilmekteydi[833]. Bunun yasada açıkça ifade edil-

[833] *Escher*, Art.526, N.3; *Oğuzman*, 254; *Kocayusufpaşaoğlu*, 430 Not 43; Yarg. 2.HD. 12.5.1951 10647/8976 (TİK C.4 , no.1864).

mesi isabetli olmuştur. Böylece, örneğin, mirasbırakanın ölümünden önceki bir yıl içinde kendisine bağışladığı evin veya arabanın tenkisi gerektiğinde, bağışlanan, tenkis tutarını ödeyerek bu malları elinde (mülkiyetinde) tutacak veya mülkiyetini saklı paylı mirasçılara geçirerek tenkis tutarı kadar eksiltilmiş piyasa değerinin ödenmesini isteyecektir. Bu seçimlik imkânın sağlararası kazandırmalarda da tanınmasında çıkacak bir sorun, kazandırma konusu malın tenkis yükümlüsü tarafından elden çıkarılmış olmasıdır. Böyle bir durumda tenkisin malı elinde bulunduran üçüncü kişiye etkisi hakkındaki tartışmalara daha önce değinmiştik[834]. Orada açıkladığımız çerçevede malı elinde bulunduran üçüncü kişiden iade istenemeyen durumlarda, tenkis davasında davalının (kazandırma yapılanın) malı iade ederek tenkis dışı kısmının değerini istemesi mümkün olmayacaktır.

Önemli bir nokta, davalının seçim hakkını kullanması üzerine, tenkis 1318
edilecek malın ve tenkis kısmının değerinin hangi tarihe göre hesaplanacağıdır. MK 564/II malın ve tenkis edilecek kısmın değerinin seçim hakkının kullanılmasını takiben karar tarihine göre belirleneceğini hükme bağlamıştır. Elbette mahkeme karar verirken değer hesabı yapamayacağından, bu, "olabildiğince karar tarihine uygun zamanda yapılmış değer tespitine göre" anlamına gelecektir. Eski MK 506'da ise böyle bir hüküm yoktu. Öğretide ve uygulamada uzun bir süre boyunca, tasarruf oranının hesabında terekenin mirasbırakanın öldüğü günkü değerlerin esas alınacağını söyleyen Eski MK 454/I (Yeni MK 507/I) hükmünden esinlenerek, tenkis konusu malın değerinin mirasbırakanın ölüm (mirasın açılma) tarihine göre belirlenmesi kabul edilmişti. Ancak, özellikle ülkemizdeki gibi davaların (bu arada tenkis davalarının da) uzun sürdüğü ve enflasyonun genellikle yüksek olduğu şartlarda, bu hesaplama tarzı adalete aykırı derecede mahfuz hisseli mirasçılar aleyhine sonuç vermekte idi. Zira, mirasbırakanın ölümünden tenkis davasının sonuçlanmasına kadar geçen zamanda tenkise konu malın değeri birkaç misli artmış olmasına rağmen, kazandırma lehdarı malın mirasbırakanın ölümü zamanındaki parasal değeri üzerinden hesaplanan ve böylece hayli düşük bir miktar olan tenkis tutarını ödeyerek malı tamamen elinde tutabilmekte idi. Öğretide bu çarpık sonuca yönelik eleştiriler[835] sonuç vermiş ve 1994 tarihli bir Yargıtay içtihadı Birleştirme kararından[836] itibaren, Eski MK m. 506 hükmünün uygulanmasında ödenecek bedelin belirlenmesi sırasında, malın seçimlik hakkın kullanıldığı tarihteki değerinin esasa alınması kabul edilmekteydi. Şimdi bu uygulama MK 564/II ile he-

---

[834] Bkz. § 23 II 2 b

[835] Özellikle: *Kocayusufpaşaoğlu*, Miras hukuku Ek Kitap, 35 vd.; *Kocayusufpaşaoğlu*, Tenkis (=İndirim) Konusu Kazandırmalarda Mirasın Açılmasından Sonra Ekonomik istikrarsızlık sebebiyle Gerçekleşen Değer değişiklikleri (MK 454 ile MK 506 Arasındaki İlişki), Yasa Dergisi, Yıl 1986, S.8, 1053 vd. 454 ile MK. 506 Arasındaki İlişki), Yasa Dergisi, Yıl 1986; S.8, s.1053 vd.

[836] Yarg. İç.Bir. K. 11.11.1994, 4/4 (RG. 2.1.1995, S.22159)

men hemen aynı sonucu verecek bir yasa hükmü haline gelmiştir[836a]. Ancak, belirtelim ki, tenkis oranının hesaplanması sırasında diğer tenkise tâbi kazandırmalar gibi bu mal da mirasbırakanın ölümü tarihindeki değeriyle hesaplamaya girecek, sadece, buna göre bulunacak tenkis oranı MK m.506 hükmündeki seçimlik hakların kullanılmasında uygulanırken malın o anki değeri esas alınacaktır[837].

1319 Davalı seçim hakkını mahkemece kendisine yapılan ihtara rağmen kullanmazsa, seçim hakkının davacı saklı paylı mirasçıya geçeceği kabul edilmektedir[838]. Şayet davacılar birden çoksa ve her biri farklı bir şıkkı seçmek isterse ne olacaktır? Kanımca bu durumda, tasarruf oranını ödemeyi üstlenen mirasçının seçimi esas alınarak bu parayı yatırması için süre verilmeli ve bu sürede parayı yatırırsa, artık vasiyet konusu mal terekede bırakılarak mirasçılar arasında paylaştırılmalıdır. Böylece, diğer şıkkı seçen mirasçıların seçimleri etkisiz kalmakla (artık tenkis isteyememekle) birlikte, onlar tasarruf oranı kadar parayı vasiyet alacaklısına tek başına ödeyen mirasçı sayesinde terekedeki malı vermekten kurtularak aralarında paylaşacaklardır. Dolayısıyla bu sonuç, onlara ekonomik bakımdan sadece yarar sağlar. Belirtelim ki, şayet tasarruf oranını ödemeyi seçen mirasçı belirtilen sürede parayı vasiyet alacaklısına ödemez ise, diğer mirasçıların seçimi

---

[836a] MK 564/II düzenlemesinin Yargıtay'ın 1994 tarihli İçtihadı Birleştirme Kararından daha da ileri giden ve daha adil bir sonuç öngördüğü görüşünde; *Serozan/Engin*, Miras Hukuku, 3. Baskı, § 3, N. 77. Kanımızca ikisi arasında pratik bir fark olmayacaktır. Mirasçının seçim hakkını kullandığı davada bilirkişinin değer tespiti ile seçim beyanı arasında değer farkı pratikte gündeme gelmez.

[837] Örneğin: (M)'nin tek mirasçısı oğlu (A) olup, (B)'ye 2 milyon lira ve (C)'ye de mercedes arabasını vasiyet ettikten sonra bankada 1 milyon lira para ve ölüm tarihi itibariyle 7 milyon liralık bir ev bırakarak ölmüştür. (M)'nin ölüm tarihinde mercedes arabası 4 milyon lira değerindedir. (M)'nin tasarruf nisabı hesaplanırken, terkesi: 1 milyon lira parası + 7 milyon liralık evi + 4 milyon liralık mercedesi= 12 milyon lira olarak hesaplanacaktır (B'ye vasiyet edilen 2 milyon lira terekedeki bu değerlerden ödenecek olup ayrıca mevcut olmadığından toplama katılmaz). (A)'nın mahfuz hissesi 12 x 1/4 = 9 milyon lira, (M)'nin tasarruf nisabı (12 – 9=) 3 milyon liradır. Yapılan tenkise tabi kazandırmalar toplamı (2 + 4=) 6 milyon lira, tasarruf nisabını (6 – 3=) 3 milyon lira tecavüz etmektedir. Ölüme bağlı tasarrufların birbirine oranı: 2-4 = 1-2 olduğuna göre, (B) den 3 milyon x 1/3 = 1 milyon lira tenkis edilerek 2 milyonluk vasiyet alacağı (2-1=) 1 milyon liraya indirilecek; (C)'den 3 milyon x 2/3 = 2 milyon lira tenkis edilerek 4 milyon lira değerindeki vasiyet alacağı (4-2=) 2 milyon liraya indirilecektir. Ne var ki, (C)'nin vasiyet alacağına konu olan mercedes araba bölünemez bir mal olup, tenkis sırasında MK m. 506'daki seçimlik hakkını kullanacağı zaman bu arabanın değeri 6 milyon liraya çıkmış ise; arabanın değeri 4 milyonken yapılan hesapla tenkisi gereken kısım 2 milyon olduğuna göre, tenkis oranı 2/4 = 1/2 arabanın tenkis sırasındaki değerine uygulanarak, (C) ancak(A)'ya (6 x 1/2=) 3 milyon lira ödeyerek mercedesin kendisine verilmesini isteyecek veya mercedesi (A)'ya bırakarak kendisine 3 milyon lira ödenmesini isteyebilecektir.

[838] Mahkemenin davalıyı seçim hakkı konusunda bilgilendirerek açıkça uyarması, şayet duruşmaya gelmezse seçim hakkının davacıya geçeceği hususu tebligatla bildirmesi gerektiği hakkında bkz.: Yarg. 2.HD. 17.3.1983, 2283/2261 (YKD 1983, S.11, s. 1611).

doğrultusunda, malın vasiyet alacaklısına verilmesi karşılığında her mirasçı sadece kendisine düşen tenkis kısmının ödenmesini istemelidir.

Seçim hakkı yenilik doğuran bir hak olduğundan, davalı veya onun kullanmaması üzerine davacı tarafından bir kez kullanıldıktan sonra artık değiştirilemez. Fakat, yasanın tenkis hakkının ancak dava yoluyla kullanılabileceğini düzenlemesinden hareketle, davalının davadan önce veya dava sırasında mahkeme dışında yaptığı seçim beyanlarının hüküm ifade etmeyeceği, bunlarla çelişse bile tenkis davası sırasında yapacağı beyana göre sonuç doğacağı kabul edilmelidir. Yeter ki somut olayda dava sırasında kararını değiştirmesi dürüstlük kuralına aykırı bir "hakkın kötüye kullanılması" oluşturmasın. 1320

Şayet vasiyet alacaklısı tenkis bedelini ödeyip malı almayı seçmişse, tenkis bedelini ödemedikçe mirasçı malı teslimden kaçınabilmeli ve mirasçı malı teslimden kaçındığı sürece de tenkis bedelini ödemekten kaçınabilmelidir. Sağlararası kazandırmalarda ise, malı önceden almış bulunan davacının aynı seçimlik hakkı kullanması üzerine aynı sonuçlar doğacağı gibi; burada ayrıca, davalı malı geri verip tenkis miktarı dışındaki değerini talep ettiğinde de her bir taraf kendi yükümünü yerine getirmeden karşı taraftan ifa isteyememelidir[839]. 1321

2. İntifa ve İrat Kazandırmalarında Tenkis

İntifa ve irat kazandırmaları, miras bırakanın bir malını veya bir hakkını başkasına vasiyet etmeyip veya devretmeyip, mevcut bir malı veya hakkı üzerinde başkasına intifa hakkı tanıması veya bunun gelirini bırakması şeklindeki kazandırmalardır. Bu tür kazandırmalarda, kazandırmanın ekonomik değerini ve mirasbırakanın tasarruf oranını aşıp aşmadığını hesaplamak güç olacaktır. Zira, intifa hakkının ve zamana yayılıp giden bir gelirin belli bir mal veya hak gibi piyasa değerinin saptanması mümkün değildir. Bu tür kazandırmalarda, kazandırma konusu intifa ve gelirin "kapitalize değeri"nin bulunarak buna göre tenkis hesabı yapılması kabul edilmektedir[840]. Kapitalize değerden maksat, bu intifa hakkının veya tahsis edilen gelirin kazandırmayı alan bakımından muhtemel yararlanma süresi boyunca bundan elde edeceği kazancın toplam bir para miktarı olarak mirasbırakanın ölüm anına göre ifadesidir. Bu tıpkı Borçlar Kanunundaki "destekten yoksun kalma zararı"nın (BK. 45/b. 3) hesabı gibi, varsayımsal ve yaklaşık bir hesaplama olacaktır. Zira, bu hesabın yapılmasında da, bir yandan intifa ve 1322

---

[839] Malı elinde bulunduran davalı bunu iade etmeden tenkis dışı bedel kısmını mirasçıdan isteyemeyecek ve davacı mirasçı da bu değeri davalıya ödemeden malın teslimini isteyemeyecektir.

[840] *Tuor*, Art.530, N.1; *Escher*, Art. 530, N.1; *Çağa*, Mahfuz Hisseli Mirasçıların Hukukî Vaziyeti, İstanbul 1950, 115; *Kocayusufpaşaoğlu*, 431; *Oğuzman*, 256; *Serozan/Engin*, Miras Hukuku, 3. Baskı, § 3, N. 79.

gelirden kazandırma lehdarının ne zamana kadar yararlanacağı, şayet insan ömrünü aşacak bir süreklilik sözkonusuysa kazandırma lehdarının ne kadar yaşayacağı saptanacak; diğer yandan uzun bir süre boyunca elde edilecek yararlanma ve gelirin yerine peşin para verilseydi hangi miktar peşin parayla aynı değerde sayılacağı saptanacaktır. Bu hesaplama tarzıyla bulunacak değerin tahmin ve varsayımdan ibaret olacağı, gerçeğe tam olarak uymayabileceği açıktır. Özellikle, gelişmiş ülkelerdekinin (örneğin İsviçre'dekinin) aksine, ülkemizde bu hususlarda bilimsel esaslara göre hazırlanmış ve güncelleştirilmiş istatistik cetvellerinin bulunmaması karşısında, yapılacak hesaplamanın gerçeğe uygunluğu iyice kuşkulu olacaktır.

1323 İşte bu hesaplamanın çok sağlam sayılamayacak bir varsayımdan ibaret olduğunu gözönüne alan kanunkoyucu, MK 568 hükmünde bu durumlar için saklı paylı mirasçılara bir seçim yetkisi tanımıştır. Bu hükme göre, saklı paylı mirasçılar intifa ve irat kazandırmalarını bulunacak kapitalize değerine göre tenkis ettirebilecekleri gibi, bunun yerine mirasbırakanın tasarruf oranını vererek intifa ve irat kazandırmalarını tamamen kaldırtabilirler. Örneğin, (M) sahip olduğu evi üzerinde (Ü) lehine intifa hakkı kurulmasını vasiyet etmiştir. (M)'nin ölümü üzerine mirasçısı olarak oğlu (A) kalmıştır. (M)'nin terekesi 20 milyon lira olup, ev üzerindeki intifa hakkının kapitalize değeri mahkemece 12 milyon lira olarak saptanmışsa; saklı payı: 1/2 x 20= 10 milyon lira olan (A) karşısında tasarruf nisabı (20-10=) 10 milyon lira olan (M)'nin bu nisabı sadece (12-10=) 2 milyon lira aştığı kabul edilecek ve (A) tenkis davasında (Ü)'den sahip olduğu intifa hakkı karşılığında sadece 2 milyon lira isteyebilecektir. Ne var ki, (A) bu kadar az bir para karşılığı babasından kalan evde (Ü)'nün ömür boyu intifa hakkına sahip olmasına razı değilse, MK 568 hükmünün verdiği seçimlik yetkiyi kullanarak, (Ü)'ye (M)'nin tasarruf oranının tamamı olan 10 milyon lirayı vermek suretiyle ev üzerindeki intifa hakkını kaldırabilir. Kuşkusuz bu yetki her zaman değil, tenkis davası sırasında kullanılabilecek bir imkândır.

1324 Şayet birden fazla saklı paylı mirasçıdan sadece bazısı tenkis davası açmışsa, dava açan mirasçının (veya mirasçıların) MK 568 hükmüne göre tasarruf oranını verip intifa veya iratı kaldırması genellikle kârlı olmayan bir seçenek olacaktır. Zira tasarruf oranını tek başına ödeyip kazandırma konusu malı yükümlülükten kurtarmasına karşılık, bu malın sadece kendi payına düşen kısmına sahip olacaktır. Öte yandan, ödediği tasarruf oranı kadar parayı yükümlülüğün kalkmasından yararlandıkları gerekçesiyle diğer mirasçılardan hisseleri oranında dahî isteyemez. Zira böyle bir talebi, intifa ve irat sahibine ödeme yaparken diğer mirasçılara karşı bu sonucu sağlama borcu olmadığını bildiği için (BK m. 78) sebepsiz zenginleşmeye ve diğer mirasçıların bu ödemeye rızalarının bulunmadığını bilecek durumda olduğu için de vekâletsiz işgörmeye (BK m. 526) dayandırması mümkün değildir.

1325 Birden fazla saklı paylı mirasçı tenkis davası açmış olup da bunlardan

bazısı intifa veya iradın kapitalize değeri üzerinden tenkis tutarının ödenmesini bazısı ise tasarruf oranını ödeyerek bu intifa veya iradın kaldırılmasını istemişse ne olacaktır? Kanımca böyle bir durumda yukarıdaki ile aynı sonuç doğmalı, tüm tasarruf oranını ödeyerek intifa hakkını veya iradı kaldırmak isteyen kişinin seçimine uyulmalıdır. Ancak burada, mahkeme bu şıkkı seçen mirasçıya mirasbırakanın tasarruf oranını (kapitalize değerin tenkis dışındaki kısmını) ödemesi için süre vermeli ve bu süre içinde parayı yatırmazsa diğer mirasçının seçimi doğrultusunda tenkis miktarı istenebilecektir.

Şayet intifa ve irat kazandırması yanında mirasbırakan başka tenkise 1326
tabi kazandırmalar da yapmışsa, mal üzerindeki yükümlülüğü tamamen kaldırmak isteyen saklı paylı mirasçıyı mirasbırakanın tasarruf oranı kadar ödeme yapmakla yükümlü tutmak doğru olmaz. Zira, diğer kazandırmaların varlığı sebebiyle, mirasbırakan esasen tasarruf oranını tamamen bu intifa veya irat sahibine tahsis edecek değildir. MK 568 hükmünün ifadesine rağmen, amaca göre yorum yapmak suretiyle, böyle durumlarda saklı paylı mirasçıya, intifa ve irat'ın kapitalize değerinden gene bu değer üzerinden yapılacak tenkis miktarı düşüldükten sonra kalan tutarı ödemekle, bu yükümleri kaldırma hakkı tanınmalıdır. Örneğin: (M)'nin tek mirasçısı oğlu (A) olup terekesi 20 milyon liradır. (M) vasiyetnamesinde (B)'ye 4 milyon lira para ve (C)'ye de evi üzerinde kapitalize değeri 12 milyon lira olarak hesaplanan bir intifa hakkı tanımıştır. Bu durumda, (M) tasarruf nisabı olan 10 milyon lirayı, ölüme bağlı kazandırmalar toplamı (4 + 12=) 16 milyon lira olduğuna göre, (16-10=) 6 milyon lira tecavüz etmiştir. Kazandırmaların oranı 4–12 = 1-3 olduğuna göre (B)'ye vasiyet edilen 4 milyon liranın 6 x 1/4 = 1,5 milyon lirası; (C)'ye yapılan 12 milyon kapitalize değerli kazandırmanın ise 6 x 3/4 = 4,5 milyon lirası tenkis edilecektir. (A) bu tenkis miktarını (C)'den talep etmek yerine MK 568 hükmündeki seçimlik yetkisini kullanırsa, (C)'ye, 12 – 4,5= 7,5 milyon lira ödeyerek (tasarruf nisabının tümü olan 10 milyon lira ödeyerek değil) ev üzerindeki intifa hakkını kaldırabilmelidir[841].

3. İvazlı Miras Sözleşmesinde Tenkis.

MK 566/II'ye göre, ivazlı bir miras sözleşmesi ile kendisine ölüme bağ- 1327

[841] Kitabımızın önceki basısında s.314'de Eski kanunun saklı pay oranına göre bu örnek verilirken bu hesap yanlış yapılmıştır. Doğrusu: "...(B)'ye yapılan 4 milyar lira kazandırmanın 5 x 2/5 = 3 milyar lirası; (C)'ye yapılan 6 milyar kapitalize değerli kazandırmanın, 5 x 3/5 = 3 milyar lirası tenkis edilecektir. (A) MK m.510 hükmündeki seçimlik yetkisini kullanırsa, (C)'ye, 6 – 3= 3 milyon lira ödeyerek (tasarruf nisabının tümü olan 5 milyon lira ödeyerek değil) ev üzerindeki intifa hakkını kaldırabilmelidir." Şeklinde olmalıydı.

lı kazandırma yapılan kimse, bu kazandırmanın tenkisi hâlinde, mirasbırakana verdiği karşılığın (ivazın) tenkis oranındaki kısmının kendisine geri verilmesini isteyebilir. Bu hüküm, bu tür kazandırmaların özelliği sebebiyle adaletin bir gereğidir. Zira, kendisine yapılan kazandırma tek yanlı olarak hesaba katılıp tenkis edilen kimse, bu kazandırma karşılığı olarak mirasbırakana vaktiyle bir ivaz ödemişse, bunu aynı oranda geri alabilmelidir. Zira, bu kazandırmanın tenkis isteyen mirasçılara kalması, sözleşmedeki ekonomik dengeyi bozacaktır.

1328 Böylece, örneğin, (A) yaptığı bir miras mukavelesi ile, (M)'nin sağlığında ona verdiği 1 milyon lira karşılığında (M)nin kendisine 2 milyon liralık evini vasiyet etmesini sağlamışsa; (M)'nin ölümü üzerine saklı paylı mirasçıları bu vasiyetin 1 milyon liralık kısmını (yarısını) tenkis ettirirlerse, (A) bu mirasçılardan vaktiyle (M)'ye verdiği 1 milyon liranın bu oranını yani (1 milyon x1/2=) 500 bin lirayı kendisine geri ödemelerini isteyebilir.

4. İvazlı Feragat Hâlinde Feragat Edene Ödenen Karşılığın Tenkisi

1329 MK 565/b.2'de belirtildiği üzere, Mirastan ivazlı feragat hâlinde, feragat edene mirasbırakanın ödediği ivaz, onun ölümünden sonra saklı paylı mirasçıları tarafından tenkis ettirilebilir. Ancak, MK 573/I uyarınca, burada tenkis hesabı bakımından sadece feragat eden mirasçının feragat ettiği saklı payını aşan miktar gözönüne alınır. Zira, esasen bu feragat sözleşmesi ile saklı payından vazgeçen mirasçı, dolaylı yoldan diğer mirasçılara bu kadar bir kazandırmada bulunmuş sayılır. Şu halde bu mirasçıların feragat eden mirasçıya yapılan kazandırmadan gördükleri zarar, gerçekte sadece bu kendilerine kalan saklı pay miktarını aşan kısımdır. Tenkise de sadece bu kısım konu olmalıdır. Böylece, örneğin: (M)'nin oğlu (A) ya verdiği 10 milyon lira karşılığı (A) saklı payından ve böylece mirasçılık sıfatından feragat etmiş olup, (M) nin ölümü üzerine diğer oğlu (B)'nin (A)'ya yapılan bu kazandırmaya karşı tenkis davası açmak istemesi hâlinde, önce (A) feragatte bulunmayıp mirasçı olsaydı (M)'nin öldüğü tarihte saklı payının ne kadar olacağı bulunacak, şayet bu varsayımsal saklı pay, diyelim ki (M) geriye 2 milyon lira bırakmış olup terekesi 2 + 10 = 12 milyon lira olduğundan, (A)'nın saklı payı 12 x1/2 x 1/2 = 3 milyon lira idi ise; (A)'ya yapılan kazandırma, (10 milyon (A'ya verilen ivaz) – 3 milyon (A'nın feragatte bulunmasaydı saklı payı) =)7 milyon lira kabul edilerek, tenkis bu miktar üzerinden yapılacaktır. Buna göre, (M)'nin tasarruf oranı 12 x 1/2 = 6 milyon lira olduğundan, 7 milyon – 6 milyon = 1 milyon lira (A)'dan tenkis edilecek miktardır.

1330 Bu durumlarda, MK 574 hükmü feragatte bulunana bir de seçimlik hak tanımıştır. O dilerse, tenkis edilen miktarı ödeyeceği yerde, aldığı ivazı ta-

mamen iade ederek tekrar mirasçı olabilir ve miras payını isteyebilir. Yukarıdaki örnekten gidersek, (A) 1 milyon lira tenkis tutarını (B)'ye ödeyeceği yerde, aldığı 10 milyon lira ivazı tamamen terekeye iade ederek, miras payını (12 milyon x 1/2 = 6 milyon lira) isteyebilir.

5. Ölüme Bağlı Kazandırma Lehdarının Bir Vasiyet Borcu Veya Yükleme (Mükellefiyet) İle Yükümlü Tutulması Durumunda Tenkis.

Şayet mirasbırakan ölüme bağlı bir kazandırmada bulunduğu kişiye, aynı zamanda bir başkasına karşı vasiyet borçlusu olma veya bir yüklemeyi (mükellefiyeti) yerine getirme yükümü yüklemişse, bu kişi kendisine yapılan kazandırmanın tenkisi dava edildiğinde, MK 563/II uyarınca, kendisine yüklenen vasiyet borcunun veya yüklemenin de aynı oranda tenkisini isteyebilir. Örneğin, (M)'nin iki oğlu (A) ve (B) olup, (A)'ya 10 milyon lira vasiyet etmiş, fakat vasiyetnamesinde aynı zamanda (A)'yı bir derneğe 5 milyon lira vermekle yükümlü tutmuşsa; (B) nin saklı payı tecavüze uğradığı için (A)'dan örneğin 5 milyon liralık tenkis istemesi hâlinde; 10 milyon liralık vasiyet alacağı (10-5=) 5 milyon liraya inecek (1/2 azalacak) olan (A), buna karşılık, derneğe 5 milyon lira verme yükümünün de aynı oranda(1/2 oranında) indirilmesini isteyebilecek ve böylece bu yükümü (5x1/2=) 2,5 milyon liraya inecektir. 1331

Tenkis davasına maruz kalan vasiyet alacaklısı, kendisine yüklenen borç veya yüklemenin aynı oranda indirilmesini bir dava ile talep edebileceği gibi, bu borç veya yüklemenin ifası istendiğinde def'i yoluyla da ileri sürebilir[842]. Buna karşılık, şayet henüz kendisine karşı tenkis davası açılmamışsa, lehine yapılan kazandırmanın tasarruf oranını aştığını kendisi ileri sürerek borç veya yüklemenin bu oranda indirilmesini isteyemez, kendisinden bu borç veya yüklemenin yerine getirilmesi istendiğinde defi olarak ileri süremez. 1332

Mirasbırakan ölüme bağlı tasarrufta bulunurken, yaptığı kazandırma tenkis edilse bile kazandırma lehdarına yüklediği borç veya yüklemenin indirilemeyeceğini kararlaştırmışsa, bunun geçerli olduğu ve artık tenkis gerekçesiyle borç ve yüklemenin indirilemeyeceği kabul edilmektedir[843]. 1333

6. Ön Mirasçının Saklı Paylı Olduğu Durumlarda Artmirasçı Atama (Fevkalâde İkame).

Saklı paylı mirasçı, mirastan yoksunluk ve mirasçılıktan çıkarma gibi 1334

---

[842] Tenkis davasına maruz kalanın açacağı yükümlülüğü indirme davasının bir tenkis davası olmamasına karşılık, tenkis davasına ilişkin hükümlerin kıyasen burada da uygulanması hakkında bkz. *Escher*, Art.525, N.6; *Kocayusufpaşaoğlu*, 432; *Oğuzman*, 255, 256

[843] *Escher*, Art.525, N.8; *Kocayusufpaşaoğlu*, 433; *Oğuzman*, 255

çok özel sebepler dışında, mirasbırakan tarafından saklı payından yoksun edilemeyeceği ve saklı payına kayıtsız şartsız sahip olacağı için; artmirasçı atama[844] yoluyla da bir mirasçının saklı payından yoksun bırakılması mümkün olmayacaktır. Yani, mirasbırakan ölümü üzerine saklı paylı mirasçısının bir süre kendisine mirasçı olup belirlediği süre dolunca veya şart gerçekleşince bir başkasının onun yerine mirasçı olacağı belirtilmişse, ön mirasçının saklı payı bakımından bu işlem hüküm ifade etmeyecektir. MK 569 hükmü bu tür ikame için, "Mirası artmirasçıya geçirme yükümlülüğü ile saklı payı zedelenen mirasçı, aşan kısmın tenkisini isteyebilir" demektedir. Hükmü karşılayan Eski MK 511'de ise, " .tasarruf mirasçının mahfuz hissesine taalluk ettiği nisbette bâtıldır." denmekte idi. Bu ifade, tenkis davasına gerek olmaksızın zaten artmirasçı atama sadece ön mirasçının saklı payı hariç hüküm ifade edeceği anlamı taşımaktaydı. Ancak o zaman dahî, öğretide burada mirasbırakanın yaptığı tasarrufun batıl veya iptal edilebilir olmayıp, ön mirasçının mahfuz hissesi kadar kısmının tenkise tabi olacağı kabul edilmekteydi[845]. Yeni madde buna uygun kaleme alınmıştır. Böylece, örneğin, (M) oğlu (A)'nın kendisinden kalacak miras payını 3 yıl sonra (B)'ye veya torunu (T) doğduğunda (T)'ye devretmesini öngörmüşse, (A) bu tasarrufun saklı payı kadar kısmının tenkisini isteyebilecektir.

VI. TENKİS DAVASINDA ÖNCEDEN ALDIĞI KAZANDIRMAYI İADE YÜKÜMÜ ALTINA GİREN DAVALININ SORUMLULUĞU.

1335 Şayet tenkis edilen kazandırma sağlararası bir işlemle gerçekleşmişse, davalının tenkis edilen kısmı davacıya iade borcu doğacağını belirtmiştik. İşte MK 566 hükmünde bu iade yükümlüsünün iyi niyetini koruyan bir kural getirilerek, "Kendisine tenkise tabi bir kazandırma yapılmış olan kimse iyiniyetli ise sadece mirasın geçmesi anında kazandırmadan elinde kalanı geri vermekle yükümlüdür....." Ölüme bağlı kazandırmalarda esasen kazandırma konusu terekeden çıkmamış ve lehdara devredilmemiş olduğundan[846], bu hükmün uygulama alanı sağlararası tenkise tabi kazandırmalar bakımından olacaktır.

1336 Kazandırma lehdarının iyi niyetli sayılması için, kendisine yapılan kazandırmanın mirasbırakanın tasarruf oranını aştığını bilmemesi ve içinde

---

[844] Bkz. § 16 III 6 c

[845] *Tuor*, Art.531, N.5; *Escher*, Art.531, N.2; *İmre*, 226; *Kocayusufpaşaoğlu*, 432; *Oğuzman*, 157; Yarg. HGK 16.5.1975, E.2-203 K.566 (YKD 1958, S.8, 40).

[846] Ölüme bağlı kazandırma konusunu her nasılsa önceden eline geçiren kişi ise, kendisine karşı açılacak olan "miras sebebiyle istihkak davasında", MK 638 uyarınca, haksız zilyedin iade yükümüne ilişkin genel hükümler olan MK 993-995 hükümlerine göre sorumlu olacaktır. Bkz. *Kocayusufpaşaoğlu*, 433

bulunduğu durum bakımından bilmesinin de kendisinden beklenemeyecek olmasıdır[847]. Lehdarın iyiniyetli sayılamaması için kendisine yapılan kazandırmanın tasarruf oranını ne kadar aştığını ve tenkis edilecek kısmın ne kadar olduğunu bilmesi gerekmez. Tam tenkis miktarı çoğu kez, mahkemece hesaplanmadan önce kesinlikle bilinemeyecek bir rakamdır. Lehdarın tenkis tutarını hesaplayacak durumda olmamasına rağmen, aldığı kazandırmanın en azından bir miktarının tenkise tabi olduğunu kestirecek durumda olması, iyi niyetli sayılmamasına yeter.

MK 566 hükmünün iyi niyetli tenkis yükümlüsünün sadece mirasbırakanın öldüğü anda elinde kalanla sorumlu olduğundan sözetmesi karşısında; bu tarihten sonra bir süre daha (örneğin, aleyhine tenkis davası açılıncaya kadar) iyiniyetli olması sorumluluğunu azaltmayacaktır. Böylece, kazandırma lehdarı=tenkis yükümlüsü, miras bırakanın ölümünden sonra iyi niyetle kazandırmayı elinden çıkarmış olsa bile, mirasbırakanın ölümü anındaki duruma göre tenkisle yükümlü olmaya devam edecektir[848]. 1337

MK 566 hükmünde kazandırma lehdarının iyi niyetinin korunması düzenlenirken sadece mirasbırakanın öldüğü andaki durumdan sözedilmişse de şayet kazandırma lehdarı bu tarihten daha önce fakat kazandırmanın yapılmasından sonra bu kazandırmanın saklı payları ihlâl ettiğini öğrenmişse, bu durumda iyi niyetin ortadan kalktığı anda elinde kalanla sorumlu olacaktır. 1338

Sonuç olarak, mirasbırakanın ölüm tarihini aşmamak kaydıyla, kazandırma lehdarının aldığı kazandırmayı elinden çıkardığı-azalttığı anda iyi niyetli sayılıp sayılamayacağına bakılacak ve şayet iyiniyetli ise elinde kalanla tenkisten sorumlu olacaktır[849]. 1339

Şayet kazandırma lehdarı kazandırma konusunu mirasbırakanın ölümünden önce elinden çıkarırken bir kaim değer=surrogat elde etmişse, bu değer tutarı kazandırma tutarı sayılarak tenkise tabi olmalıdır. Örneğin, kazandırma lehdarının kendisine bağışlanan 20 milyon lira ile 20 milyon lira değerinde bir araba alması veya kendisine bağışlanan bir arabayı 20 milyo- 1340

---

[847] *Escher*, Art.528, N.9; *Kocayusufpaşaoğlu*, 434; *Oğuzman*, 254

[848] Bu kural öğretide eleştirilmekte ve sorumluluğun mirasbırakanın ölümü anına göre değil, en geç tenkis davasının açıldığı tarih olmak üzere, kazandırma lehdarının iyi niyetinin kalktığı ana göre saptanması önerilmektedir. Bak: *Escher*, Art. 528, N.10; *Kocayusufpaşaoğlu*, 433 Not 61

[849] Hatta, kazandırma lehdarının önce kötü niyetli iken sonradan iyi niyetli sayılabileceği de belirtilmekte, örneğin çok nadir rastlanacak bir durum olarak, kendisine kazandırma yapanın tasarruf nisabını aştığını bilen lehdarın, bu kişinin sonradan çok zenginleştiğini ve böylece yapılan kazandırmanın artık tasarruf nisabı içinde kaldığını sanmaya başlaması örnek gösterilnektedir: *Tuor*, Art. 528, N.6; *Kocayusufpaşaoğlu*, 434

na satması hâllerinde, kazandırma lehdarı bu işlemler sırasında iyi niyetli olsa bile 20 milyon liralık kazandırma üzerinden tenkise tabi olmalıdır. Aynı şey, mirasbırakan tarafından sigortalanan malın hasara uğraması üzerine kazandırma lehdarının aldığı sigorta bedeli için de sözkonusudur. Keza, kazandırma lehdarının kazandırma konusu mal veya parayı vererek bir ihtiyacını karşılaması durumunda şayet bu kazandırma olmasaydı aynı ihtiyacını kendi cebinden harcama yaparak karşılayacağı söylenebiliyorsa, iyi niyetli de olsa, masraftan kurtulma miktarı üzerinden tenkise tabi olmalıdır[850]. Örneğin, Kazandırma konusu paralarla birkaç aylık beslenme giderini karşılayan lehdarın, bu tutar kadar kişisel gelirini harcamaktan kurtulup tasarruf ettiği gözönüne alınarak, bu miktar kadar tenkis yükümlülüğü devam etmelidir. Buna karşılık, kazandırma lehdarı kendisine bağışlanan malı iyi niyetliyken bir başkasına bağışlamış veya iyi muhafaza etmediği için hasara uğratmışsa, burada kaybı karşılığında eline bir şey geçmediğinden, tenkisten birinci durumda tamamen kurtulacak ikinci durumda ise malın hasarlı değeriyle sorumlu olacaktır.

1341 İyi niyet, sadece kazandırmanın hiç tenkis edilmeyeceğinin sanılmasında değil, tenkisi gereken miktardan daha az miktarda tenkis edileceğinin sanılmasında da sorumluğu azaltmalıdır. Kazandırma lehdarı, kendisine yapılan kazandırmanın bir miktar tenkis edileceğini tahmin etmesine karşılık, geriye kalan kısmın tenkisi karşılayacağına iyi niyetle inanarak kazandırma konusunu kısmen elden çıkarmışsa, tenkis miktarının öngörmediği kadar yüksek çıkması hâlinde, gene sadece elinde kalanla sorumlu olmalıdır.

1342 MK 566 hükmü çerçevesinde iyi niyetin korunduğu durumlarda, kazandırmanın elde kalan kısmının değerinin, sadece tenkis davası sonucunda davalının iade borcu bakımından mı gözönüne alınacağı[851] yoksa daha tenkis hesabı yapılırken sözkonusu kazandırmanın bu azalmış değeriyle mi terekeye ekleneceği[852], tartışmalıdır. İki görüşün farkını şu örnekle gösterelim: (M) ölümünden 6 ay önce (A)'ya 8 milyon lira değerinde 1000 cumhuriyet altını bağışlamıştır. (A) çok zengin biri sandığı (M)'nin kendisine yaptığı bu kazandırma ile tasarruf oranını asla aşmış olamayacağına inandığı sırada, bu altınlar arasından 6 milyon lira değerinde 600 cumhuriyet altınını bir hayır derneğine bağışlamış, böylece elinde 2 milyon lira değerinde altın kalmıştır. Daha sonra (M) ölmüş ve geriye 4 milyon lira değerinde malvar-

---

[850] Bu konuda, büyük benzerlik taşıyan sebepsiz zenginleşenin iade yükümüne ilişkin açıklamalarımdan yararlanılabilir. Bkz. *Öz*, Öğreti ve Uygulamada Sebepsiz Zenginleşme, İstanbul 1990, 149 vd.

[851] Bu görüşte: *Escher*, Art.532, N.8

[852] Bu görüşte: *Oğuzman*, 253, Not 679e; Yarg.2 HD., 17.5.1977, E.2730 / K.4137 (*Şener*, Eski Ve Yeni Miras hukuku, Ankara 1988, C. II, 109, 518

lığı ile tek mirasçı olarak oğlu (B)'yi bırakmıştır. Bu olayda, şayet birinci görüş benimsenirse: (M)'nin terekesi: 4 milyon + 8 milyon = 12 milyon lira olup; (B)'nin saklı payı: 12 x 1/2 = 6 milyon lira; (M)'nin tasarruf oranı: 12 – 6= 6 milyon liradır. (A)'ya yapılan 8 milyon lira kazandırma, 8 – 6= 2 milyon lira tenkis edilecektir. Esasen MK m.566 uyarınca (A) sadece elinde kalan 2 milyon liralık altınla sorumlu olduğundan (B)'ye bunu verecektir. İkinci görüşe göre ise: (M)'nin terekesi: 4 milyon + 2 milyon(A'nın elinde kalan) = 6 milyon lira olup; (B)'nin saklı payı: 6 x 1/2= 3 milyon lira; (M)'nin tasarruf nisabı: 6 – 3= 3 milyon liradır. (A)'ya yapılan kazandırma 2 milyon lira sayıldığından,esasen tasarruf oranı içinde kalan bu kazandırmadan hiçbir şey İade etmeyecektir. Görüldüğü gibi, MK m.566 hükmündeki indirimi daha terekenin hesaplanmasında devreye sokan görüş, tenkis davalısının (kazandırma lehdarının) çok daha lehine sonuç vermektedir.

Kazandırma lehdarı iyi niyetli sayılmadığı sırada tenkis konusu şeyi el- 1343
den çıkarması, tamamen veya kısmen zayi etmesi veya hasara uğratması durumunda, MK 566 hükmünün ifade ettiği üzere, iyi niyetli olmayan haksız zilyedin iade yükümüne ilişkin hükümlere göre sorumlu olur. Böylece, MK 995 hükümleri bu sorumluluğun çerçevesini belirleyecektir[853]. Kural olarak sanki bu değer kaybı veya eksilmeleri hiç olmamış gibi, başlangıçtaki iktisabının mirasbırakanın ölümü tarihindeki piyasa şartlarına göre bulunacak değeri üzerinden tenkise tabi olur. Burada kazandırma lehdarı kazandırma konusunun kendi kusuru olmaksızın bir kaza sonucu zayi olduğunu veya değer azalmasına uğradığını ileri sürerek de sorumluktan kurtulamayacaktır. Zira, tenkise tabi olacağını bilmesi gereken bu kazandırmayı kabul etmeyerek veya bu durumu öğrenince hemen geri vererek, bu zararı önleyebilirdi. Kazandırma lehdarı sadece, BK 119/II hükmüne kıyasen, bu kazandırmayı kabul etmemiş veya tasarruf nisabına tecavüz ettiğini öğrenir öğrenmez geri vermiş olsaydı bile, bu malın aynı kaza sonucu aynı zarara uğrayacak olduğunu ispat edebilirse, gene bu oranda sorumluluktan kurtulmalıdır. MK 995/III iyiniyetli olmayan zilyedin şeyi kime vereceğini bilmediği sürece ancak kusuruyla verdiği zaararlardan sorumlu olacağını düzenlemiştir. Kanımızca tenkis yükümlüsünün bu yükümlülüğünün doğacağını tahmin ettiği sırada kusursuz olarak uğradığı kayıplardan sorumluluğu, kimin tenkis davası açacağını henüz bilmediği gerekçesi ile bu hükme tabi tutularak kaldırılmamalıdır. Onun kendisine kazandırma yapan kişinin tenkis davası açma hakkını kullanabilecek saklı paylı mirasçıları bulunduğunu bilmesi yeter.

Tenkisle yükümlü davalının, şayet tenkis konusu mala yaptığı bazı 1344

[853] Böylece, burada BK 63-64 hükümlerindeki sebepsiz zenginleşenin iade yükümüne ilişkin kurallar uygulanmayacaktır.

masraflar olmuşsa, bunları davacıdan isteyip isteyemeyeceği, MK 566/I hükmünün yaptığı atıf sonucu, gene haksız zilyedin iade yükümüne ilişkin kurallara göre çözümlenecektir. Şayet bu masrafları yaptığı sırada iyi niyetli ise, MK 994 uyarınca zorunlu ve yararlı masraflarını isteyip lüks (fuzulî) masraflarını isteyemeyecek iken; kötü niyetli ise MK 995/II uyarınca, sadece zorunlu masraflarını isteyebilecektir. Eski MK 508 hükümlerinde haksız zilyetlik hükümlerine atıf bulunmadığından, öğretide, bu masraflar hakkında, sebepsiz zenginleşme hükümleri arasında sebepsiz zenginleşenin isteyebileceği masraflar hakkındaki BK 64 hükmünün uygulanması önerilmekteydi[854].

VII. TENKİS HESAPLAMASINDA BİLİRKİŞİLERİN ROLÜ.

1345 Uygulamada tenkis davalarında tenkis edilecek kazandırmaları ve tenkis miktarlarını hesaplamak, çoğu kez gayet karmaşık ve yorucu hesaplar gerektirmektedir. Zira, gerçek hayattaki tenkis sorunları, bu kitapta tasarlayarak ve seçerek verdiğimiz örneklerdeki gibi yalın ve kolay hesaplanamayacak kadar farklı unsurlar taşırlar. Terekenin hesabında eklenecek değerlerin ve yapılan kazandırmaların miras bırakanın ölüm anına göre tesbiti, çok sayıda ve çok çeşitli malların belli tarihteki piyasa değerlerinin saptanması gibi sorunlar buna örnek gösterilebilir. Bu yüzden, tenkis davasında çoğu kez hakimler dosyayı bilirkişiye göndermekte ve bu hesaplamaları bilirkişiye yaptırmaktadırlar. Hesaba girecek malların belirli tarihlerdeki piyasa değerlerinin tespiti bakımından bu bilirkişi incelemesi normal ve gerekli olmakla birlikte; hakimlerin ayrıca hukukçu bilirkişi de tayin ederek, miras hukuku hükümlerine göre kimden hangi oranda tenkis istenebileceğini de sordukları görülmektedir. Yargıtay bazı kararlarında, bu hususun hakimin mesleki bilgisi içine girmesi sebebiyle, bu tür bilirkişi tayininin HMK 266 hükmüne aykırı olduğunu belirtmektedir[855]. Buna rağmen, özellikle mahkemelerin içinde bulunduğu yoğun iş yükü başta olmak üzere elverişsiz çalışma şartları karşısında, tenkis hesabını her bakımdan yapacak bilirkişi tayini uygulamasını anlayışla karşılamak gerektiği belirtilmektedir[856].

---

[854] *Oğuzman*, 254

[855] Yarg. 2.HD 18.12.1986, E.1986/11256, K.1986/1700 (YKD 1986, S.11, s.1613). Bu kararda, hukukî bakımdan da inceleme yapmakla görevli bilirkişinin ücretinin davacı tarafından yatırılmadığı gerekçesiyle davayı reddeden mahkemenin bu red kararı, Yargıtayca bozulmuştur. Bozma gerekçesi, hakimin mirasçıların mahfuz hisselerini ve mirasbırakanın tasarruf nisabını bilmek ve buna göre tenkis hesabını yapmak zorunda olduğudur.

[856] *Kocayusufpaşaoğlu*, Ek Kitap, 45

§ 24. Mirasta Denkleştirme (İade)

I. DENKLEŞTİRME KURUMUNUN ANLAMI VE MİRAS HUKUKUNDA YERİ

Yasakoyucu tenkise ilişkin hükümlerle mirasbırakanın saklı paylı mirasçılarının bu payını ihlal eden kazandırmalarını azaltma imkânı getirmekle kalmamış; kanunî mirasçılardan bazılarına yapılan belirli nitelikteki kazandırmaların tasarruf oranını aşmasalar da mutlak şekilde terekeye iadesini düzenlemiştir. İşte Medeni Kanunumuzun Miras Hukuku Kitabının İkinci Kısmının "Mirasta Denkleştirme" adını taşıyan üçüncü Ayırımı (MK 669 - 675), ilgili bazı hususlarla birlikte, bu kurumu düzenlemektedir. 1346

Eski Medeni Kanunun 603 –610 hükümleri bu kurumu "Mirasta iade" olarak adlandırmış ve gerek öğreti gerekse uygulamada da bu kurum çoğunlukla "iade" olarak adlandırılagelmiştir. O tarihlerde de bu kuruma Almanca karşılığına (Ausgleichung) uygun şekilde, "mirasta denkleştirme" demeyi daha uygun görenler vardı[857]. Bazı Yargıtay kararlarında, "mirasta geriverme" teriminin kullanıldığı da görülmekteydi[858]. Özellikle "iade" kelimesinin renksiz ve soyut anlamı karşısında, "denkleştirme" kurumu daha iyi ifade etmektedir. Zira, burada bazı mirasçıların elde ettiği menfaat terekeye geri verilerek onların miras payları ile denkleştirme amaçlanmaktadır. Ayrıca, "iade" başka taleplerle de karıştırılabilecek nötr bir terimdir. Örneğin tenkis davası sonucu bir sağlararası kazandırma tenkis edilmişse kazandırma lehdarının tenkis miktarını davacıya "iade borcu" bulunduğundan sözedilecektir ki bunun burada incelediğimiz "iade" kurumu ile ilgisi yoktur. Bu sakıncalara rağmen, kitabımızın ilk basısında Eski Medeni Kanunun kullandığı "iade" terimini kullanmıştık. Şimdi biz de Yeni Medeni kanunun kullandığı "denkleştirme" terimini kullanıyoruz. Ancak, belirtelim ki, miras hukukunun bu denkleştirme kurumu borçlar hukukunun zararın hesaplanmasında kullanılan denkleştirme kurumu ile ilgisizdir ve karıştırılmamalıdır. 1347

Biz, mirasın geçmesini düzenleyen İkinci Kısmın diğer bahislerini aşağıda topluca ele almakla birlikte, denkleştirmeyi kanundaki sırasında değil hemen tenkisin ardından ele almayı uygun gördük. Miras hukuku kitaplarında genellikle takip edilen kanunî sıra yerine, bu farklı planı kendi kitabında uygulayarak bize ilham veren Kocayusufpaşaoğlu'nun belirttiği gibi[859], benzer işlevleri ve birbirine karıştırma ihtimali karşısında, öğretim kolaylığı bakımdan bu iki kurumu ard arda incelemek daha isabetlidir. Ka- 1348

---

[857] *Kocayusufpaşaoğlu*, 438; *Kocayusufpaşaoğlu*, Ek Kitap, 45; *Serozan/Engin*, Miras Hukuku, 3. Baskı, § 7, N. 39a vd.

[858] Yarg.2.HD.18.12.1986, E.1986/11256, K.1986/1700 (YKD 1986, S.11, s.1613).

[859] *Kocayusufpaşaoğlu*, 436 vd.

nundaki sırayı izleyen diğer miras hukuku kitaplarında, denkleştirmenin mirasın paylaşılmasının da sonlarında incelenmesi, böylece tenkise yakınlığına ters ve önemiyle bağdaşmayacak bir "son bahis" olarak ele alınması, tercih etmediğimiz bir yöntem olmuştur.

1349 Her ne kadar tenkisle işlevsel benzerliğinden sözetsek de, tenkisten farklı olarak denkleştirmeden maksat, mirasbırakanın tasarruf oranını aşan kazandırmalarının yasal bir sınıra çekilmesi değil, mirasbırakanın kanunî mirasçılardan bazısına diğerleri aleyhine sağlığında yaptığı bazı kazandırmaların terekeye geri verilmesidir. Böylece, sözkonusu kazandırmalar, terekenin paylaştırılmasında hesaba katılmış olacaktır. Böylece, denkleştirmenin maksadı kanunî mirasçılardan bazısının mirasbırakandan vaktiyle elde ettiği özel çıkarı -bu yüzden terekenin değeri azaldığından- almasaydı doğacak duruma göre paylaştırma yapmak olduğundan, kurum bu adı almıştır.

1350 Mirasta denkleştirme kurumu sayesinde, örneğin, iki çocuğundan birine hiçbir karşılık gözetmeksizin 50 milyar lira masraf yaparak işyeri açan babanın ölümü üzerine terekesi paylaşılırken; diğer oğul, saklı payına tecavüz oranı ile bağlı olmaksızın ve tenkis davası açması gerekmeksizin, MK 669/II uyarınca, kardeşinden bu 50 milyarı tam olarak terekeye iade etmesini, paylaşmanın bura göre yapılmasını isteyebilecektir.

1351 Buna göre, denkleştirme kurumunun özellikleri ve tenkis kurumundan farkları şunlardır:

1352 1) Şayet bir kazandırma denkleştirmeye konu ise, olduğu gibi (tümüyle) terekeye iade edilecektir. Oysa tenkise tabi kazandırma ancak tasarruf oranını aştığı kadarıyla indirilir.

1353 2) Denkleştirmeye konu kazandırmalar sadece miras bırakanın sağlığında yaptığı (sağlararası) kazandırmalardır. Oysa tenkise tabi kazandırmalar kural olarak ölüme bağlı kazandırmalar olup istisnaen bazı sağlararası kazandırmalar tenkis edilir.

1354 3) Denkleştirme yükümlüsü de denkleştirmeyi talep hakkına sahip olan da ancak kanunî mirasçılar olabilir. Vasiyet alacaklıları, atanmış (mansup) mirasçılar ve miras bırakanın ölümü anında herhangi bir sebeple kanunî mirasçılık sıfatını kaybetmiş sayılanlar, denkleştirme yükümlüsü de alacaklısı da olamazlar. Zira, belirttiğimiz üzere, denkleştirmenin amacı kanunî mirasçılar arasındaki miras paylaşımını denkleştirmek-adil hâle getirmektir. Böylece, denkleştirme kurumunun işlemesi için, mirasbırakanın en azından iki kanunî mirasçı bırakarak ölmesi gerekir. Oysa, tenkis davası, mirasbırakanın tasarruf oranını aşan bir kazandırma yaptığı herkese, bu arada mirasçı olmayıp sadece vasiyet alacaklısı olanlara da açılır. Tenkis kurumunun iş-

lemesi için mirasbırakanın geride sadece bir saklı paylı (kanunî) mirasçı bırakması yeter.

4) Mirasta denkleştirme terekenin paylaştırılmasına ilişkin ve paylaştırma aşamasında sözkonusu yapılabilen (paylaştırmaya bağlı) bir kurumdur. Yasada düzenleniş yeri de böyledir. Oysa tenkis, ayrı bir davaya konu olup, her saklı paylı mirasçının paylaştırmadan önce ve sonra kanunî süreleri içinde ileri sürebileceği bir haktır. 1355

5) Denkleştirme yükümünün bulunup bulunmayacağı tamamen mirasbırakanın iradesine bırakılmıştır. Kanun bu hususta sadece belirli durumlar için irade karineleri koymuş olup (MK 669/II, 672) bunların aksinin ispatı mümkündür. Oysa tenkise tabi bir kazandırma yapan mirasbırakanın bunun tenkis edilmeyeceğini öngörmesi geçersiz ve etkisizdir. Tenkis hakkının doğmasında ve kapsamının belirlenmesinde, bazı istisnaî yan hususlar (MK 560/II, 563/I) dışında, mirasbırakanın iradesi rol oynamaz. Bu sebeple, aslında denkleştirmeye tabi olması mümkün iken mirasbırakanın iradesiyle denkleştirmeden kurtulan kazandırmaların, şayet tasarruf oranını aşıyorlarsa, tenkise tabi olması düzenlenmiştir (MK 565/b.1). 1356

II. DENKLEŞTİRMENİN TARAFLARI.

1. Denkleştirme Borçlusu.

a) Kanunî mirasçı olma şartı.

Denkleştirme borçlusu, mirasbırakanın ölümü anında kanunî mirasçı sıfatına sahip olan ve kural olarak denkleştirmeye tabi kazandırmayı almış bulunan kişidir[860]. Kazandırmanın yapıldığı anda kanunî mirasçı olmayan bir kişi mirasbırakanın ölümü anında kanunî mirasçı sıfatına sahipse, baskın görüşe göre, gene iade borçlusu olabilir[861]. Örneğin, (M) henüz oğlu (A) sağ iken (A)'nın oğlu (T)'ye MK 669/II çerçevesinde bir kazandırmada bulunmuş olup, bu kazandırmadan sonra, önce (A) daha sonra (M) öldüğünde, mirasçı sıfatını kazandırmayı aldıktan sonra elde eden (T) diğer kanunî mirasçılara karşı denkleştirme ile yükümlü olur. Karşılıksız kazandırmada bulunulan kişinin sonradan tanıma veya babalık davası sonucu mirasçı olmasında da aynı şey sözkonusudur. Buna karşılık, diğer bir görüş, kazandırmanın yapıldığı anda mirasçı sıfatına sahip olacak pozisyonda bulunmayanların, onlara yapılan kazandırma "miras paylarına mahsuben" ya- 1357

[860] Kural olarak dememizin nedeni, aşağıda belirtileceği üzere, MK 670 hükmünde istisnaen kazandırma eline geçmemiş olsa bile bazı kanunî mirasçıların denkleştirmeyle yükümlü tutulmasıdır. Bkz. § 24 II 1 b cc

[861] *Tuor/Picenoni*, Art.627, N.26; *Kocayusufpaşaoğlu*, 445

pılmış sayılamayacağından, sonradan mirasçı sıfatını kazansalar da denkleştirmeye tabi olmayacağı şeklindedir[862].

1358 Yasal mirasçı olmayıp atanmış (mansup) mirasçı olanlar, mirasbırakandan sağlığında karşılıksız kazandırma almış da olsalar, kanunî mirasçılara karşı denkleştirme yükümlüsü olmazlar[863]. MK 669/I. hükmünde bu açıkça belirtilmiştir. Atanmış mirasçılara karşı ancak, aldıkları miras payı bazı mirasçıların saklı paylarını ihlâl ediyorsa tenkis davası açılabilir. Sadece, istisnai bir durum olarak, mirasbırakanın esasen kanunî mirasçısı olacak birini atanmış mirasçı olarak vasiyetnamesinde göstermesi hâlinde, bu kişinin aldığı karşılıksız kazandırmalar için denkleştirme yükümlüsü olabileceği kabul edilmektedir[864]. Burada dahî, denkleştirme yükümlülüğünün sebebi bu kişinin kanunî mirasçılık vasfından kaynaklandığından, gerçek bir istisna sözkonusu değildir.

1359 Kanunî intifa hakkı sahipleri de denkleştirme yükümlüsü olamazlar[865]. Zira kanunî intifa hakkı sahibi olma bir tür mirasçılık değil buna alternatif bir durumdur. Böylece, örneğin, Eski MK 444 hükmünün 3678 Sayılı kanunla değiştirilmesinden önce mevcut imkândan yararlanarak intifa hakkını seçen eş, artık kanunî mirasçı sayılarak denkleştirmeyle yükümlü tutulamayacaktır[866].

1360 Kanunî mirasçı olma özelliği taşıyan bir kişi, miras bırakanın ölümünde yoksunluk(mahrumiyet)[867], çıkarılma(ıskat)[868], feragat[869], veya ret[870] sebebiyle bu sıfatı kazanamamış sayılıyorsa, denkleştirme borçlusu olamaz[871]. Bunların ilk üçünde kanunî mirasçılık sıfatı hiç kazanılamamakta, redde ise miras bırakanın ölüm anına kadar geçmişe etkili şekilde kaybedilmektedir.Ancak, birazdan belirteceğimiz üzere, MK 670 hükmüyle, bu şekilde mirasçılık sıfatını yitiren birinin payını alan mirasçılar onun yerine denkleştirmeyle yükümlü olacaktır[872].

1361 Buna karşılık, mirasın tutulan deftere göre kabulü[873] ve resmi tasfiye is-

---

[862] *Escher*, Art.626, N.15.
[863] *Escher*, Art.626, N.5; *Tuor/Picenoni*, Art.626, N.5a; *Kocayusufpaşaoğlu*, 442
[864] *Kocayusufpaşaoğlu*, 442
[865] *Kocayusufpaşaoğlu*, 442; *Tuor/Picenoni*, Art.626; N.5
[866] Belirtelim ki bu seçim hakkı ancak 25.11.1990 tarihinden önceki ölümlerde sözkonusu olacağından ve iade talebi de ancak mirasın paylaşılması tamamlanıncaya kadar ileri sürülebileceğinden, esasen artık böyle bir durumla karşılaşılması pek mümkün olmayacaktır.
[867] Bkz. § 26 II 3
[868] Bkz. § 16 III 9
[869] Bkz. § 16 III 8
[870] Bkz. § 32.
[871] *Oğuzman*, 328; *Kocayusufpaşaoğlu*, 441
[872] Bkz. § 24 II 1 b cc
[873] Bkz. § 33 IV 2

tenmesi durumlarında, kanunî mirasçıların bu sıfatları devam ettiği için, denkleştirme ile yükümlü olmaya devam ederler. Resmî tasfiye yapılan durumlarda ise, tasfiyeden geriye bir tereke kısmı kalmışsa, bu kalanın paylaştırılması sırasında denkleştirme yükümü sözkonusu olacaktır.

Yukarıda belirttiğimiz sebeplerle denkleştirme yükümünden kurtulan 1362
kişilere karşı, mirasbırakandan aldıkları kazandırmalar için, şartları varsa tenkis davası açılabilecektir.

b) Çeşitli kanunî mirasçıların durumları.

aa) Altsoy dışındaki kanuni mirasçılar.

Mirasbırakanın altsoyu dışındaki kanunî mirasçılarının denkleştirme 1363
yükümlüsü olmaları, mirasbırakanın bu kazandırmanın iade edileceğini beyan etmiş olmasına bağlıdır. Bu husus MK 603/I hükmünün "Yasal mirasçılar mirasbırakandan miras paylarına mahsuben elde ettikleri sağlararası karşılıksız kazandırmaları denkleştirmeyi sağlamak için terekeye geri vermekle birbirlerine karşı yükümlüdürler." şeklindeki ifadesinden anlaşılmaktadır. Burada kazandırmanın "miras paylarına mahsuben" yapılmış olmasının anlamı, mirasbırakanın bu kazandırma kadar yasal mirasçının miras payının azalacağını belirtmesidir. İşte yasa bu beyanı geçerli saymakla, mirasbırakanın ölümü anında kestirme yoldan bir denkleştirmeyi sağlamaktadır. Zira, mirasbırakanın ölümü üzerine miras payını isteyen bu mirasçılar, aldıkları kazandırmayı mirasbırakanın iradesi doğrultusunda miras hisselerinden indirmek (mahsup etmek) zorunda kalmakla, kısa ve dolaysız yoldan iade etmiş = denkleştirilmelerini sağlamış olacaklardır. (Şayet aldıkları kazandırma miras payları kadarsa ne terekeden bir şey alabilecek ne de terekeye bir şey vereceklerdir. Şayet aldıkları kazandırma miras paylarından fazla ise, MK 672 uyarınca, mirasbırakanca aksi belirtilmemişse, gene terekeye bir şey verip terekeden bir şey almayacaklarsa da, bu fazlalık tasarruf oranını aşıyorsa tenkise tabi olacaktır). Ayrıca, MK 671 uyarınca, bu mirasçılar mahsup yerine aldıkları kazandırmayı olduğu gibi iade edip miras paylarını tam olarak isteyebilirler. Bu takdirde iade /denkleştirme fiziksel bir somutluk da kazanmış olacaktır.

Böylece, mirasbırakanın eşine veya ikinci zümre (örneğin, ana, baba, 1364
kardeş, yeğen) yahut üçüncü zümre (büyükanne, büyükbaba, amca, hala, dayı, teyze, kuzen) mirasçılarından birine yaptığı karşılıksız kazandırma, ancak ölümü üzerine bunun terekeye iade edileceğini belirtmişse denkleştirmeye tabi olur. Bunların tabi oldukları bu düzene, iradî denkleştirme/iade rejimi" de denmektedir[874].

---

[874] *Kocayusufpaşaoğlu*, 447

1365 Mirasbırakanın denkleştirmeyi gerekli kılan beyanının şekle tabi olmadığı belirtilmektedir[875]. Bu beyanın niteliği hakkında, altsoy bakımından denkleştirmeye tabi kazandırmaları içerecek şekilde, aşağıda ayrıca açıklamalarda bulunacağız. Şimdilik şu kadarını belirtelim ki, mirasbırakanın kazandırma sırasında bunun denkleştirmeye tabi olduğunu belirtmesine rağmen sonradan iadesini/denkleştirilmesini istemeyeceğini beyan etmesi, bizce de denkleştirme yükümünü kaldırmalıdır.[876] Buna karşılık, altsoy dışındaki mirasçılara mirasbırakan hiçbir bildirimde bulunmadan veya –gereksiz olmasına rağmen- kazandırmanın denkleştirmeye tabi olmayacağını bildirerek kazandırmada bulunmuşsa, sonradan bunun denkleştirmeye tabi olacağını beyan etmesi etkisiz sayılmalıdır[877].

bb) Altsoy

1366 MK 669/II hükmüne göre, "Mirasbırakanın çeyiz veya kuruluş sermayesi vermek ya da bir malvarlığını devretmek veya borçtan kurtarmak ve benzerleri gibi karşılık almaksızın altsoyuna yapmışolduğu kazandırmalar, aksi mirasbırakan tarafından açıkça belirtilmiş olmadıkça, denkleştirmeye tabidir." Hükmün ifade etmek istediği, şayet altsoya yapılmış ve burada sayılan nitelikte bir kazandırma varsa, mirasbırakan açıkça denkleştirmeye/iadeye tabi olmayacağını bildirmemişse, bunların denkleştirilmesinin/iadesinin gerekeceğidir.

1367 Görüldüğü gibi, şayet belirtilen karşılıksız kazandırmalar altsoy lehine yapılmışsa, aynı maddenin birinci fıkrasında diğer kanunî mirasçılar için getirilen kuralın aksine, kendiliğinden denkleştirmeye tabi sayılacak; ancak mirasbırakan açıkça iade edilmeyeceklerini bildirmişse denkleştirmeden kurtulacaklardır. Bu hükümle yasakoyucu, mirasbırakanın altsoy gibi en yakın derece mirasçıları arasında eşitlik ve adaleti gözetmesini, diğer kanunî mirasçıları arasındaki eşitlik ve adaletten çok daha fazla gerekli gördüğünü ortaya koymaktadır. Böylece, MK 669/II hükmünde belirtilen kazandırmaları alan altsoyun iadeyle yükümlü olması –aksi kararlaştırılabilir de olsa- bir yasa kuralı olduğundan, diğer kanunî mirasçıların iade yükümünü mirasbırakanın beyanına bağlayan MK 669/I hükmünden çok daha fazla uygulama alanı bulmaktadır. Gerek uygulamadaki yaygınlığı gerekse ayrıca irade beyanına gerek olmaksızın doğan iade yükümünü düzenlemesi karşısında; miras hukukunda denkleştirme konusunda önem taşıyan ve bu

---

[875] *Kocayusufpaşaoğlu*, 454; Ek Kitap, 48; *Oğuzman*, 331; Yarg. HGK 12.10.1988, E. 1988/2-326, K. 1988/785 (YKD 1989, S.8, s.1074.

[876] *Oğuzman*, 331; *Kocayusufpaşaoğlu*, 463

[877] Bu doğrultuda, *Kocayusufpaşaoğlu*, 462 vd.; mirasbırakan sadece kazandırmanın iadeye tabi olmayacağını açıkça bildirmişse sonraedan tek taraflı olarak iadeye tabi tutamayacağı görüşünde: *Oğuzman*, 331

kuruma asıl kimliğini veren, MK 669/II hükmündeki "altsoyun denkleştirme borcu"dur.

Kanun bu guruba giren mirasçıları "..altsoyuna.." olarak ifade ettiğinden, yalnızca mirasbırakanın çocukları değil, mirasçı sıfatına sahip torunları ve torunlarının çocukları (bütün birinci zümre) da bu hükme tabiolacaktır. MK 500/I uyarınca mirasbırakanın çocuğu gibi mirasçı olan evlâtlık ve -şayet evlatlık mirasçı olamıyorsa- evlatlığın altsoyu da aynı hükme tabi olacaktır. 1368

cc) Doğrudan kendisine kazandırma yapılmadığı hâlde denkleştirme ile yükümlü olanlar

MK 670 hükmüne göre, bazı durumlarda, mirasbırakan tarafından kazandırmada bulunulmayan kişiler de bu kazandırmayı denkleştirme yükümü altına girmektedir. 1369

Bunlardan ilki, denkleştirme yükümlüsünün mirasbırakanın ölümü sırasında sağ ve mirasçılık sıfatına sahip olduğu için denkleştirme yükümü altına girmesine rağmen, bu yükümlülüğünü henüz yerine getirmeden mirasın paylaşımı sırasında ölmesi üzerine, bu kazandırmayı onun mirasçılarının iade etmek zorunda kalmasıdır. Bu sonucun, küllî halefiyetle borçların mirasçılara geçmesi genel kuralının uygulanmasından başka bir özelliği yoktur. Belirtelim ki, bu şekilde denkleştirme borcunu devralan kişilerin, denkleştirmeye tabi kazandırmayı yapanın mirasçısı olması da gerekmez. Denkleştirme yükümlüsünün mirasçısı olması yeter. Örneğin, (M)'nin oğlu (A)'ya yaptığı denkleştirmeye tabi kazandırmadan sonra (M) ölmüş ve (A) da terekeye iadede bulunmadan önce mirasın paylaşımı sırasında ölerek geriye evlatlığı (E)'yi bırakmıştır. Burada (E), (M)'nin ölümünde tek sağ kalan olsaydı bile (M)'nin mirasçısı olamayacaksa da, kendisine (A)'dan intikal eden denkleşitirme sebebiyle iade yükümünü (M)'nin kanunî mirasçılarına ifa etmek zorunda kalacaktır. 1370

Bu normal durum dışında, MK. 670 hükmü, denkleştirmeye tabi kazandırmayı alan mirasçının mirasbırakanın ölümü sırasında mirasçılık sıfatını kazanamadığı veya geçmişe etkili olarak kaybettiği durumlarda da onun payını alanı denkleştirme ile sorumlu tutmaktadır. MK 670 metninin "Mirasın açılmasından önce veya sonra mirasçılık sıfatını kaybeden mirasçıya ait geri verme yükümlülüğü, onun yerini alan mirasçılara, miras paylarında meydana gelen artış oranında geçer" şeklindeki ifadesinin anlamı şudur: Mirasbırakandan denkleştirmeye tabi kazandırma alan kanunî mirasçı, çıkarılma, yoksunluk, feragat sebebiyle mirasçı sıfatını kazanamamış veya mirası reddettiği için kaybetmişse, onun kaybettiği payı karşılığı hangi kanunî mirasçının payı artmışsa, o veya onlar, kendilerine yapılmamış olan bu ka- 1371

zandırmayı terekeye iade ile yükümlü olacaklardır. Bu maddenin karşılığı olan Eski MK 604 hükmünde geri verme yükümünün yeni yükümlünün miras payındaki artış oranında ona geçeceği açıkça ifade edilmemiş olmasına rağmen, öğretide bu sonuca varılmıştır[878].

1372 Kanımca maddedeki "mirasçılık sıfatını kaybeden.." ifadesinin kapsamına kazandırmayı alan kanunî mirasçının mirasbırakandan önce ölmesi de sokulmalıdır. Zira, mirasbırakan ölmeden önce denkleştirme borcu doğmayacağından, mirasbırakandan önce ölen kazandırma lehdarının bu henüz doğmamış yükümünün küllî halefiyete ilişkin genel hüküm uyarınca kendi mirasçılarına geçtiğini söylemek güçtür. Şayet bu "önce ölüm" hâli MK.. 670'den de dışlanırsa, örneğin, dedesinin vaktiyle babasına yaptığı denkleştirmeye tabi kazandırmanın sonuçlarından babasının ölümü üzerine istifade eden kişinin, dedesi daha sonra öldüğünde terekeye bir şey iade etmeksizin dedesine mirasçı olması; buna karşılık, babası mirastan uzaklaştırıldığı veya yoksunluğa uğradığı için onun yerini aldığında, dedesinin ona yaptığı kazandırmayı bu kez iadeyle mükellef olması, mantıksız ve adaletsiz bir çelişki olur.

1373 Kanunda mirasçı sıfatını kazanamayan veya kaybedenin payını alanların denkleştirme ile yükümlü tutulmasının sebebi, mirasçı sıfatını kazanamayan veya kaybedenin yerini olumlu ve olumsuz sonuçlarıyla birlikte almaları gereğidir. Madem ki bu kişinin yerini alarak normalde ona gidecek olan miras payına sahip olmaktadırlar, mirasçılık sebebiyle onun sorumlu olacağı iade yükümünden de sorumlu tutulmalıdırlar. Örneğin, (M), sağlığında oğlu (A)'ya denkleştirmeye tabi bir kazandırmada bulunmuş, ardından (A) ölmüştür. (M) daha sonra haklı bir sebeple (A)'yı mirasından uzaklaştırmıştır. (M)'nin ölümünde geriye mirasçıları olarak kızı (B) ve uzaklaştırdığı (A)'nın oğlu (torunu) (T) kalmıştır. Bu durumda, (B) ve (T) mirası yarı yarıya paylaşacaksa da, (T) paylaşma sırasında babası (A)'ya yapılmış olan denkleştirmeye tabi kazandırmayı terekeye vermekle yükümlü olacaktır.

1374 Burada, yapılan denkleştirmeye tabi kazandırmanın karşılığı değil, kazandırma lehdarının mirasçı sıfatını kaybetmesinden yararlanmanın karşılığı verildiğinden, iadeyle yükümlü tutulan mirasçı fiilen bu kazandırma konusunu almamış veya bundan bir çıkar elde etmemiş olsa bile, (aynen iade mümkün değilse para olarak) iade ile yükümlüdür. Bu husus, Eski BK 604/II hükmünde altsoy(füru) bakımından açıkça ifade edilmişti. Buna göre "füru kendi eline geçmemiş olsa bile aslına yapılan teberruları iade ile mü-

[878] *Kocayusufpaşaoğlu*, 447 vd.; *Oğuzman*, 328.

kelleftir." Öğretide haklı olarak belirtildiği üzere[879], sadece altsoy değil, mirasçılık sıfatını kazanamayan veya kaybeden kazandırma lehdarının bu durumundan yararlanan diğer mirasçılar da bu kazandırmadan şahsen yararlanmamış olsalar bile iade ile yükümlü olmalıdır. Nitekim Yeni MK 670, sadece altsoy bakımından bu sonucu düzenleyen Eski maddedeki ifadeye yer vermeyerek, bunu ifade etmiş sayılmalıdır. Böylece, örneğin, (M)'nin kendisinden önce ölmüş oğlu (A)'nın çocuklarından (T)'ye denkleştirmeye tabi bir kazandırma yapmasından sonra ölümünde, (T) mirastan yoksunluğa uğradığı için, mirasçı olarak geriye diğer oğlu (B) ile (A)'nın diğer çocuğu (Ç) kalmışsa; 1/4 miras payına sahip olacak iken (T)'nin mirastan mahrum olması sayesinde miras payı 1/2'ye çıkan (Ç), (B)'nin talebi üzerine, (T)'nin aldığı kazandırmayı iadeyle yükümlü tutulacaktır.

Şayet kendisine denkleştirme/iade yükümü intikal eden mirasçı, aynı 1375
zamanda denkleştirme/iade alacaklısı ise, bu durumda alacaklı ve borçlu sıfatları birleşeceğinden, iade yükümü doğarken sona erer. Örneğin, (A) ve (B) adlı iki oğlu bulunan (M) oğlu (A)'ya işyeri açması için para vermiş fakat sonradan (A) ölmüşse ve kanunî mirasçısı kardeşi (B) ise, esasen (A)'ya yapılan kazandırmadan dolaylı olarak yararlanan (B)'nin kendi kendisine iade yükümü sözkonusu olmaz.

2. Denkleştirme Alacaklısı.

Denkleştirme alacaklısı olabilecek kişiler, sadece, mirasbırakanın ölü- 1376
mü anında onun kanunî mirasçısı sıfatına sahip olanlardır. Atanmış mirasçılar ve mirasbırakanın ölümü anında çıkarılma, yoksunluk, feragat veya ret sebebiyle mirasçı sıfatını kaybetmiş sayılanlar, denkleştirme alacaklısı olamaz[880]. Kanunî intifa hakkı sahipleri (23.11.1990 tarihinden önceki ölümlerde intifa hakkını seçen eş) de denkleştirme alacaklısı olamaz. Denkleştirme sebebiyle iade alacaklısı olmak için saklı paylı mirasçı olmak gerekmeyip, herhangi bir yasal mirasçılık yeter.

Mirasbırakan yasal mirasçılarından sadece birinin veya bazısının denk- 1377
leştirme alacaklısı olacağını bildirip, diğerlerinin denkleştirme alacağını önleyebilir. Böylece denkleştirme yükümlüsü sadece mirasbırakanın beyan ettiği mirasçıya iadeyle yükümlü olacaktır. Kuşkusuz diğer mirasçıların, şartları gerçekleşmişse ve saklı payları varsa, tenkis davası açma hakları saklıdır.

Sağ kalan eşin durumu öğretide ve uygulamada tartışmalıdır. Tartışma 1378
eşin mirasbırakanın altsoyu ile birlikte mirasçı olduğu durumlar bakımın-

---

[879] *Kocayusufpaşaoğlu*, 447,448; *Escher*, Art.627, N.1; *Tuor/Picenoni*, Art.627; N.15.
[880] *Oğuzman*, 328; *Kocayusufpaşaoğlu*, 454

dandır. Zira, şayet eş mirasbırakanın altsoyu dışındaki yasal mirasçılarla birlikte mirasçı ise, denkleştirme ancak MK 669/I uyarınca mirasbırakanın açıkça emretmesi hâlinde ve onun bu beyanı doğrultusunda gerçekleşeceğinden, tartışılacak bir durum olmayacaktır. Oysa ki eş altsoy ile birlikte mirasçı ise, altsoyun MK 669/II uyarınca doğacak yasal denkleştirme yükümünün ifasının altsoy dışında bir mirasçı tarafından istenip istenemeyeceği sorusu gündeme gelir. Bir görüşe göre, sağ kalan eşin kendisi aynı kazandırmayı alsa sadece altsoyu kanunen denkleştirme borçlusu sayan MK 669/II çerçevesinde denkleştirme (aldığını iade) ile yükümlü olmayacağına göre, denkleştirme yükümlüsü altsoydan kendisi de denkleştirme isteyememelidir.[881] Bu görüş denkleştirmenin ancak karşılıklı olarak aynı yüküm altına girebilecek kişiler arasında sözkonusu olabileceği düşüncesine dayanmakta ve MK 669/I hükmündeki "..geri vermekle birbirlerine karşı yükümlüdürler." (Eski MK 603/I: "iade ile birbirine karşı mükelleftirler.") ifadesini de buna dayanak göstermektedir[882]. Yargıtayın görüşünün de bu doğrultuda olduğu söylenebilir[883]. Buna karşılık, bir başka görüş, sağ kalan eşin denkleştirme yükümlüsü altsoydan her zaman denkleştirmeyi talep edebileceği doğrultusundadır[884]. Buna göre, MK 669/II kendisi yasal denkleştirme yükümlüsü olmamasına rağmen, sağ kalan eş, denkleştirme ile yükümlü altsoydan aldıkları kazandırmayı terekeye vermelerini isteyebilecektir. Kanımca da isabetli görüş bu olup, MK 669/I hükmünde geçen "birbirlerine karşı" ifadesine dayanan zorlama bir yorumla, MK 669/II'deki altsoyun denkleştirme yükümünü zayıflatacak şekilde, sağ kalan eşin elinden denkleştirme isteme hakkı alınamaz. Hukukta yorumun, bir hakkın kullanılmasını sınırlayıcı değil kolaylaştırıcı olması asıldır.

1379 Birden fazla denkleştirme isteme hakkına sahip yasal mirasçı bulunup da bunlardan sadece biri veya bazısı denkleştirme talep etmişse, bu tüm kazandırmanın terekeye eklenmesi sonucu vereceğinden, kendisi denkleştirme talep etmemiş bulunan kanunî mirasçılar da denkleştirmeden yararlanmış olacaktır. Zira, denkleştirme talep edene değil, terekeye kanunen yapılması gereken bir eklemedir. Bu bakımdan, durum, tenkis hakkına sahip mirasçıların sadece bazılarının tenkis talep etmesinden farklıdır[885].

1380 Atanmış mirasçı denkleştirme alacaklısı olamaz. Şayet mirasbırakan sağken yaptığı bir kazandırmanın mirasçı atadığı kişiye iadesini öngörmüşse, bunun gerçek anlamda (MK 669/I anlamında) bir denkleştirme değil,

---

[881] *Escher,* Art.626, N.6 vd.; *Tuor/Picenoni*, Art.626, N.10 vd.

[882] Bu görüşün Alman hukukundaki durumu yansıttığı hakkında bkz.. *Kocayusufpaşaoğlu*, 451

[883] Bkz. Yarg. 2.HD. 3.4.1980, 1214/2923 (YKD 1981, S.5, s.554).

[884] *Oğuzman*, 328, Not 310; *Kocayusufpaşaoğlu*, s.453; BGE 77 II 228

[885] Tenkiste bu durum için bkz § 23 II 2 a aa

atanmış mirasçının miras payını belirleyen bir tasarruf olduğu belirtilmektedir[886]. Mirasbırakan geride hem denkleştirme isteme hakkına sahip bir veya birkaç yasal mirasçı hem de bir atanmış mirasçı bırakmış ise; miras payları hesaplanırken, önce denkleştirmeye tabi kazandırma hesaba katılmaksızın bulunan terekeye göre atanmış mirasçının miras payının belirlenmesi, ardından bu pay terekeden çıkartıldıktan sonra denkleştirmeye tabi kazandırma terekeye eklenerek yasal mirasçıların miras paylarının belirlenmesi kabul edilmektedir[887].

Bu yöntem, sağ kalan eşin iade alacaklısı olup olamayacağı hakkında 1381
yukarıda açıkladığımız görüşlerden olamayacağı görüşü benimsenirse, eş bakımından da uygulanacaktır. Denkleştirmeye tabi kazandırma hesaba katılmadan eşin miras payı bulunacak, bu payla birlikte eş bir tarafa bırakılarak, terekenin kalan kısmına denkleştirmeye tabi kazandırma eklenerek yasal mirasçıların (altsoyun) miras payları bulunacaktır[888].

III. MİRASBIRAKANIN DENKLEŞTİRMEYE YÖNELİK OLUMLU VE OLUMSUZ İRADE BEYANININ NİTELİĞİ VE YAPILMASI..

Yukarıdan beri açıkladığımız denkleştirmeye ilişkin düzenleme, miras- 1382
bırakanın irade beyanı ile tamamen değiştirilebilir. Bir kere, MK m. 669/I uyarınca, denkleştirme kural olarak sadece mirasbırakanın yasal mirasçısına yaptığı kazandırmada açıkça denkleştirmeyi öngördüğü durumlarda olur. Öte yandan, MK 669/II'de altsoy'ya yapılan bazı karşılıksız kazandırmalar kanunen denkleştirmeye tabi ise de, mirasbırakanın bunların denkleştirilmeyeceği = iade edilmeyeceği hususundaki beyanı üzerine sözkonusu kazandırmalar denkleştirmeden kurtulur. Şu halde, MK 669/II uyarınca altsoya yapılan kazandırmalarda mirasbırakanın irade beyanı bunların denkleştirilmeyeceği doğrultusunda, MK 669/I uyarınca diğer yasal mirasçılara yapılan kazandırmalar için ise bunların denkleştirileceği doğrultusunda olacaktır.

Denkleştirmeyi emreden veya kaldıran bu beyanlar miras bırakanın 1383
ölümüyle hüküm ifade etmeleri sebebiyle, maddeten ölüme bağlı tasarruf sayılmaktadırlar.[889] Ancak, bunların ölüme bağlı tasarrufların şekline tabi olmadıkları (vasiyetname veya miras sözleşmesi şekliyle yapılmalarının gerekmediği), hatta herhangi bir şekle tabi olmadıkları kabul edilmektedir.

---

[886] Buna "gerçek olmayan iade" (uneigentliche Ausgleichung) da denmektedir: *Escher*, Art.626, N.16; *Kocayusufpaşaoğlu*, 454

[887] *Kocayusufpaşaoğlu*, 454

[888] *Kocayusufpaşaoğlu*, 452

[889] *Escher*, Art.626, N.47; *Tuor/Picenoni*, Art.626, N.2,2 a; *Kocayusufpaşaoğlu*, 454

Üstelik yapılan kazandırmanın kendisi şekle tabi olsa bile bu sonucun değişmeyeceği belirtilmektedir[890].

1384 Buna karşılık, irade beyanı "açık" olmalıdır. Bu husus MK 669/II'de belirtilmiştir. Şu halde, mirasbırakanın bazı tavır ve ifadelerinden anlam çıkarmak, sözlü veya yazılı bazı beyanları yorumlanmak suretiyle denkleştirmeyi yasakladığı veya emrettiği sonucuna varılamaz. Herhangi bir şekle bağlı olmasa da, mirasbırakan dolaysız ve açık bir ifade ile, denkleştirmeyi yasakladığını veya emrettiğini belirtmiş olmalıdır[891]. Kuşkusuz, sözlü bir beyanın ispatı güç olacaktır. MK 669/I uyarınca bir mirasçıya denkleştirme emredildiğini, denkleştirmeyi talep hakkına sahip diğer yasal mirasçılar; MK 669/II uyarınca kendisine kanunen denkleştirmeye tabi bir kazandırma yapılan altsoy ise mirasbırakanın bunun denkleştirilmesini istemeyi yasakladığını ispat etmek zorundadır.

1385 Mirasbırakanın denkleştirmeyi emreden veya yasaklayan beyanının kazandırma anında veya daha sonra yapılması mümkündür. Fakat bununla da bağlantılı bir sorun olarak, denkleştirmeyi emreden ve yasaklayan beyanların tek taraflı olarak sonuç doğurup doğuramayacakları tartışmalıdır. Bir görüşe göre bu beyanlar daima bir taraflı olarak sonuç doğurur[892]. Denkleştirme yükümünün doğmasında ve kalkmasında yasal mirasçının iradesine hiç rol vermeyen bu görüş uyarınca, mirasbırakan beyanını kazandırma işleminin içinde yapmış olsa bile, sonradan yeni bir beyanla durumu değiştirebilir, denkleştirmeyi emreden beyanından vazgeçerek denkleştirme yükümünü kaldırabileceği gibi, daha önemlisi, altsoyunu denkleştirmeden kurtaran beyanından da her zaman tek taraflı olarak vazgeçip onu denkleştirme ile yükümlü tutabilir. Diğer bir görüş ise, mirasbırakanın beyanının ancak kanunî mirasçının –hiç olmazsa örtülü olarak yapılmış sayılacak- kabulü ile hüküm doğuracağı, denkleştirme yükümü getiren veya bu yükümü kaldıran işlemin daima iki taraflı bir işlem olduğudur[893]. Buna göre, mirasbırakan tekrar kanunî mirasçıyla anlaşmadan, kazandırma yaptığı sıradaki beyanıyla doğan durumu değiştiremez. Bir başka görüş, altsoya yapılan kazandırmada bu kazandırmayı yaparken denkleştirmeden muaf tutmamış olsa da mirasbırakanın sonradan tek yanlı olarak yasal denkleştirme yükümünü kaldırabileceği; fakat şayet bu kazandırmayı bir kere denkleştirmeden muaf tutmuşsa sonradan tek yanlı olarak bu beyanını değiştiremeyeceği;

---

[890] *Kocayusufpaşaoğlu*, 455; *Escher*, Art.626; N.44; *Tuor/Picenoni*, Art.626, N.2

[891] Yarg. HGK 12.10.1988, E.1988/2-326, K.1988/785 (YKD 1989/8, s.1074). Kararda şöyle denmektedir: "..iradenin davanın özelliklerine bakılarak dolayısıyla anlaşılması mesela mirasbırakanın diğer beyanlarından yahut onun mirasçılarından bazılarıyla olan münasebetlerinden veya tebnerruun niteliğinden anlam çıkarılması diğer deyimle ortada irade gösteren eylemler bulunması, hukukî sonuç doğurmaya yetmez."

[892] *Tuor/Picenoni*, Art.626, N.2,a; BGE 68 II 81

[893] *Müller*, Das Verhaeltniss von Augleichung und Herabsetzung im schweizerischen Erbrecht, Bern 1949, 46 vd.

altsoyu dışındaki kanunî mirasçılara denkleştirme şartı getirmeden kazandırma yaptıktan sonra da tek yanlı olarak denkleştirme yükümü getiremeyeceği şeklindedir[894]. Nihayet dördüncü bir görüş, denkleştirmeyi emreden veya yasaklayan işlemin tek yanlı beyanla gerçekleşeceği gibi iki taraflı da olabileceğini, her somut olayda bunun araştırılması gerektiğini ileri sürmektedir[895]. Ancak, bu görüş çerçevesinde ispat kolaylığı bakımından, bağışlama sözleşmesinde yer alan denkleştirmeden muafiyet kaydının iki taraflı yapıldığı; denkleştirmenin emredildiği beyanların ise tek yanlı yapıldığı karinesi kabul edilmektedir[896].

Kanımızca, denkleştirmeyi emreden veya yasaklayan beyanların yapıl- 1386
dıktan sonra tek yanlı olarak değiştirilip değiştirilemeyeceğinin bunların tek taraflı veya iki taraflı sayılmalarının zorunlu sonucu sayılması isabetli değildir. Hangi görüşe katılınırsa katılınsın, denkleştirmeye ilişkin olumlu veya olumsuz etkinin mirasbırakanın tek yanlı beyanıyla gerçekleştiği kabul etmek, bunun her zaman gene tek yanlı bir irade beyanıyla değiştirilmesini mümkün kılmaz. Şayet mirasbırakanın tek yanlı irade beyanının denkleştirme borcunu doğuran veya ortadan kaldıran yenilik doğurucu bir işlem olduğu kabul edilirse, karşı tarafa ulaşıp hukukî sonucunu doğuran bir yenilik doğurucu işlemin sonuçlarını tek yanlı bir beyanla ortadan kaldırmak kural olarak mümkün değildir. Şu halde kanımızca, yasanın amacına göre yorum yaparak, ancak hukukî durumu kazandırmayı alan kanunî mirasçı lehine değiştiren (kanunî veya iradî bir denkleştirme yükümünü kaldıran) tek yanlı beyanlar geçerli sayılmalıdır.

IV) DENKLEŞTİRMEYE TABİ KAZANDIRMALAR.

1. Genel Olarak Denkleştirmeye Tabi Kazandırmalar.

MK 669/I hükmüne göre, bir kazandırmanın denkleştirmeye tabi olması 1387
için kural olarak onun denkleştirmeye tabi olduğunun mirasbırakanca beyan edilmesi gerektiğini belirtmiştik. Ne var ki, her kazandırma mirasbırakanın beyanı ile denkleştirmeye tabi olmaz. Bu sonucun doğması için, MK 669/I uyarınca, sözkonusu kazandırma sağlararası bir ivazsız kazandırma olmalıdır. Şayet kazandırma ivazlı ise, mirasbırakan verdiği şeyin karşılığında malvarlığına bir şey kazandığından, gerçekte terekesini azaltmış sa-

---

[894] *Escher*, Art.626, N.45; *Oğuzman*, 330, 331 (Ancak yazar, altsoy dışındaki mirasçılara kazandırma yapılırken bu kazandırmanın denkleştirmeye tabi olmayacağı belirtilmişse tek taraflı olarak denkleştirmeye tabi tutulamayacağını söylemektedir).

[895] *Piotet*, ZSR, NF 90, 27 vd.

[896] Bütün bu görüşlerin ayrıntılı açıklaması ve eleştirisi için bkz *Kocayufuspaşaoğlu*, 458-464

yılmayacak, böylece, ne kanunen ne de iradî olarak bu kazandırma denkleştirmeye tabi olacaktır.

1388 Aynı sebeple, ölüme bağlı kazandırmalar da denkleştirmeye tabi tutulamaz. Zira, bunlar ölüm anında terekeden çıkmış, terekeyi eksiltmiş değildir. Ölüme bağlı kazandırma ancak tenkise konu olur. Buna karşılık, şayet mirasbırakan sağlararası bir karşılıksız kazandırma taahhüdünde (örneğin: bağışlama taahhüdünde) bulunmuş fakat ölümü anında bu henüz ifa edilmemişse[897], bu kazandırmanın da denkleştirmeye tabi olabileceği kabul edilmektedir[898].

1389 Denkleştirmeye tabi karşılıksız kazandırmalar biçimsel olarak, bağışlama (bağışlama taahhüdü veya elden bağışlama), ivazsız kısım bakımından karma bağışlama ve ahlâkî bir vazifenin ifası (BK 285/III) şeklindeki sağlararası kazandırmalardan ibarettir. Ayrıca bu kazandırma, MK 669/II'de özel olarak belirtildiği üzere, borçtan ibra şeklinde de olabilir[899]. Sigorta vasiyeti ölüme bağlı tasarruf olduğundan denkleştirmeye tabi olamazsa da mirasbırakan kendi lehine sigorta sözleşmesinden doğan hakkını sağlığında yasal mirasçıya ivazsız devrederse denkleştirmeye tabi olacaktır. Sigorta sözleşmesinde yasal mirasçının lehdar tayini hâlinde durum tartışmalı olduğu gibi, şayet lehdar tayini denkleştirmeye tabi bir tasarruf sayılırsa denkleştirmeye esas kazandırmanın nasıl hesaplanacağı da tartışmalıdır[900].

1390 Uygulamada en çok bağışlama biçiminde denkleştirmeye tabi kazandırmaya rastlanacaktır. Ne var ki, denkleştirmeye tabi olduktan sonra bunların gerçek bir bağış sayılıp sayılamayacakları tartışmalıdır. Bir görüşe göre, kanunî mirasçının miras hakkına mahsuben yapıldıkları için denkleştirmeye tabi olan bu kazandırmalar, bir ivaza sahip olmadıkları hâlde, gerçek bağışlama sayılamazlar. Zira gerçek bağışlamada, ekonomik olarak ve hukuken kalıcı bir ivazsız kazandırma yapılır. Halbuki burada yapılan kazandırma mirasbırakanın ölümü üzerine tereye iade edileceğinden ve bu husus kazandırma yapılırken iradî olarak veya kanunen belirtildiğinden, ortada kalıcı bir kazandırma yoktur. Bu görüşe göre, denkleştirmeye tabi kazandırma "bağışlama taahhüdü" veya "elden bağışlama" oluşturmayıp, "miras

---

[897] Buna karşılık, esasen ifası(tenfizi) bağışlayanın ölümüne bağlı bir bağışlama vaadi varsa, BK 290/II uyarınca ölüme bağlı tasarruf hükümlerine tabi olacağından, denkleştirmeye tabi tutulamaz, ancak tenkise tabi olur.

[898] *Escher,* Art.626, N.19; *Kocayusufpaşaoğlu*, 467

[899] Eski MK 603/I "karşılıksız kazandırmalar" değil de "teberrular (bağışlamalar)" ifadesi taşıdığından, borçtan ibranın, Eski MK .603/II'de zikredilmesi sebebiyle, buradaki altsoya mahsus bir denkleştirme gerektiren işlem olduğu düşünülebilirdi.

[900] Bu görüşler hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. *Escher*, Art.476, N.20; *Kocayusufpaşaoğlu*, 467

payına mahsuben yapılan kazandırma" adıyla türü kendine özgü bir işlem olarak kabul edilmelidir[901]. Buna karşılık, miras payına mahsuben yapılan karşılıksız kazandırmanın bir tür bağışlamadan başka şey olmadığını savunanlar da vardır[902]. Bunlara göre, mirasbırakanın ölümünden sonra denkleştirme yükümü getirilmesi kazandırmanın yapıldığı sıradaki niteliğini değiştiremez. Kaldı ki kazandırmayı alanın mirasbırakanın ölümünde mirasçı sıfatını kaybetmesi ve böylece denkleştirme yükümü altına girmemesi her zaman mümkündür. Biz de denkleştirmeye tabi olmanın karşılıksız kazandırmayı Borçlar Hukuku bakımından bağışlama olmaktan çıkarmayacağı, aksinin zorlama bir yorumla gereksiz bir işlem tipi yaratma olacağı görüşündeyiz.

2. Kanunen Denkleştirmeye Tabi Kazandırmalar.

MK 669/II uyarınca mirasbırakanın altsoyuna yaptığı bazı kazandırmalar, açıkça miras paylarına mahsuben yaptığını belirtmese (denkleştirmeyi öngörmüş olmasa) dahî, aksini beyan etmedikçe denkleştirmeye tabi tutulmuştur. Kanunî denkleştirme yükümü denilen bu durumlar, uygulamada denkleştirme kurumuyla asıl karşılaşılacak yerlerdir. 1391

Bu kazandırmalar MK 669/II'de "...çeyiz veya kuruluş sermayesi vermek, ya da bir malvarlığını devretmek veya borçtan kurtarmak ve benzerleri gibi karşılık almaksızın altsoyuna yapmış olduğu kazandırmalar.."[903] olarak belirtilmiştir. Şimdi bu kazandırmaları teker teker ele alalım. 1392

a) Kuruluş sermayesi.

Mirasbırakanın altsoyuna bağımsız bir ekonomik durum sağlamak maksadıyla yaptığı kazandırmadır[904]. Uygulamada en çok, mirasbırakanın çocuğuna iş kurması şeklinde rastlanır. Babanın oğluna dükkân, yazıhane, muayenehane açması, taksicilik yapması için araba alması, tipik kuruluş sermayesi vermedir. Geleneksel olarak daha çok oğula verilirse de kuruluş 1393

---

[901] Bu görüş yanlıları, denkleştirmeye tabi kazandırmaya "gerçek olmayan bağışlama" da demektedirler. Bkz. *Tuor*, Art.527, N.4,a; *Becker*, Art.239, N.8; *Oser/Schönenberger*, Art. 239, N.16

[902] *Tuor/Picenoni*, Art.626, N.18; *Piotet* ZSR 90, 23

[903] Eski MK 603/II'de bunlar, "...cihaz, tesis masrafı, borçtan ibra suretiyle ve bu kabilden sair suretlerle bahşedilen menfaatler.." olarak sayılmıştı. "malvarlığı devri" eski maddede yer almamakla birlikte, İsviçre'de bu hükmün karşılığı olan OR Art. 626/2 hükmünde, "Vermögensabtretung" olarak zikredilmişti. Buna rağmen, bizde de işin niteliği ve tenkise ilişkin Eski MK 507/b.1'de (Yeni MK 565/b.1) "mal terki" terimiyle aynı kazandırmanın yer almasından da kıyasen yararlanılarak, bu kazandırmanın da kanunen denkleştirmeye tabi olması savunulmuştur.

[904] *Escher*, Art. 626, N.36; *Tuor/Picenoni*, Art. 626, N.39 a; *Kocayusufpaşaoğlu*, 469; *Oğuzman*, 32.

sermayesi verilmesinde cinsiyetin önemi yoktur. Mirasbırakan kızına da kuruluş sermayesi vermiş olabilir. Mirasbırakanın bu kazandırmayı bizzat dükkân, yazıhane, vb. temin ederek hazırlatması şeklinde yapması zorunlu değildir. Tarafların bu maksatla kullanılmak üzere verildiği hususunda anlaşmış olmaları kaydıyla, altsoya doğrudan verilen paralar veya sair mallar da kuruluş sermayesidir.

1394 Altsoyun kurulan tesisi veya bu maksatla kendisine verilen para yahut malı ziyan etmesi, başka yerde sarf etmesi, batırması, kendisine kuruluş sermayesi verme şeklinde kazandırma yapılmış olduğu gerçeğini değiştirmez ve onu denkleştirme yükümünden kurtarmaz.

1395 Buna karşılık, altsoya verilen para veya bir diğer şey, onun ekonomik bağımsızlığına yönelik kalıcı bir tesis kurmak için değil de sadece geçinmesi, harcaması için verilmişse veya bu şey gereğinde satması için yahut hatıra olarak saklaması için verilmişse; ortada kuruluş sermayesi yoktur. Çocuğa/toruna geçinmesi için verilen paralar, oturması için devredilen ev, hatıra olarak kalsın diye bağışlanan mücevherler, böyledir. Bunlar açıkça denkleştirmeye tabi tutulmuş olmadıkça, ancak tenkise tabi olabilir. Şu kadar ki, altsoyun ticarî işletmesinin ekonomik sıkıntıya düşmesi üzerine durumunu düzeltmesi için yapılan kazandırma da tesis masrafı sayılmaktadır[905].

1396 Altsoyun meslek sahibi olması için eğitimini tamamlaması maksadıyla yapılan masraflar, örneğin okul paraları ve eğitim araç gereç masraflarının durumu tartışılabilir. Kanunun ifadesine çok şeklî yaklaşırsa, bir işyeri açma ve yürütme masrafı olmadıkları gerekçesiyle bunların hiçbir zaman kuruluş sermayesi sayılamayacağı söylenebilir. Fakat, bu takdirde de, aşağıda belirteceğimiz üzere, "..benzerleri gibi karşılık almaksızın altsoyuna yapmış olduğu kazandırmalar.." ifadesine sokularak bunların da denkleştirmeye tabi tutulması mümkündür. Örneğin, iki oğlundan birine yazıhane açan babanın bu masrafı tereddütsüz denkleştirmeye tabi ve miras paylaşımında payından düşülmesi gereken bir kazandırma sayılırken; iki oğlundan birini gene büyük masraflarla Amerika'da okutup ömür boyu ekonomik bağımsızlığını garanti eden iyi bir meslek sahibi olmasını sağlayan babanın bu kazandırmasını denkleştirmeye tabi tutmamak, en azından mantıklı ve adil gelmeyen bir sonuç olacaktır. Böylece, sonuncu kazandırma da, kuruluş sermayesi vermeye benzer bir kazandırma olarak, denkleştirmeye tabi tutulabilecektir.

b) Çeyiz.

1397 Çeyiz, mirasbırakanın evlenen altsoyuna evlenme sebebiyle ev açması

[905] *Kocayusufpaşaoğlu*, 469

için (evliliğin ortak konutunu edinmesi ve döşemesi için) yaptığı kazandırmalardır[906]. Eski Kanunda bu masraf "cihaz" olarak adlandırılmıştı ve Batı ve hiristiyan kültüründe, kökü Roma hukukunun eski dönemlerine uzanan bir gelenekle, daha çok evlenen kıza babası tarafından sağlanan maddî menfaatler bu isimle anılırdı. Yeni Kanundaki çeyiz terimi bizim dilimizde kurumu daha iyi ifade etmiştir. Bununla birlikte belirtelim ki, bizim kültürümüzde ev kurmanın asıl destekçisi daha çok evlenen erkeğin (damadın) babası olduğu halde bu masraflar çeyiz olarak anılmamakta; "çeyiz" olarak adlandırılan evlenen kıza ana babası tarafından zaman içinde hazırlanıp evlenme sırasında verilen daha çok kişisel eşyaları ve evin döşenmesine yardımcı (genellikle kumaş işleri) unsurları içeren kazandırmalar olmaktadır. Oysa, kız – erkek ayrımı yapmayan yasada her iki masraf da "çeyiz" adı altında denkleştirmeye tabi tutulmuştur.

Yasadaki anlamıyla çeyiz, evleneceklerin oturması için verilen ev gibi 1398
taşınmaz bir mal veya oturulacak evin eşyası (mobilya, buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon) gibi taşınır mallar olabilir. Mirasbırakan bu malları bizzat alacağı veya zaten malvarlığında mevcut mallardan vereceği yerde, bunların alınması için altsoyuna para verebilir ve bu para da çeyiz sayılır. Paranın ev kurma masraflarına genel bir katkı için verilmesi yeterli olup, hangi malların alınmasına sarfedileceğinin belirtilmiş olması gerekmez.

Çeyiz verildikten sonra evlenmenin gerçekleşmemiş olması (örneğin 1399
nişanın bozulması) veya çeyizin evlenme gerçekleştikten bir zaman sonra verilmiş olması, denkleştirme yükümünü kaldırmaz. Hatta henüz evlenilecek kişi belirlenmeden önce çeyiz verilmesi de mümkündür. Önemli olan husus, Mirasbırakanın bu kazandırmayı altsoyu evlendiği takdirde veya evlenmesini takiben bir ev kurmasını kolaylaştırmak kastıyla vermiş olmasıdır. Şu kadar ki, altsoya bekâr olarak da yaşaması için verilen şeyler (örneğin: bekâr çocuğa evlenmeden de otursun diye verilen ev), elbet bir gün evlenir düşüncesiyle, çeyiz sayılamaz ve kanunen denkleştirmeye tabi olmaz.

Altsoyun ev kurma masrafları dışındaki evlenme harcamaları çeyiz 1400
oluşturmaz. Örneğin, düğün masrafları, balayı için çıkılan gezinin masrafları, evlilik hediyesi olarak takılan mücevherler, çeyiz sayılmaz. Bunlar evlilik sebebiyle yapılmışsa da evlenenlerin ev kurmaları için yapılmamıştır. Bu gibi masraflar MK 675/I hükmüne tabidir ve ilerde açıklayacağımız bu hükme göre geleneğe uygun gider niteliğinde değilse, denkleştirmeye tabi olacaktır. Evlenen kızın getirdiği elbiseler, gecelikler, iç çamaşırları gibi giyim eşyasının, halk arasında çeyizin tipik unsurlarından sayılmasına rağmen, MK 669/II anlamında çeyiz sayılıp sayılmayacağı tartışmalıdır[907].

---

[906] *Escher*, Art.626, N.35; *Oğuzman*, 329; *Kocayusufpaşaoğlu*, 470

[907] *Kocayusufpaşaoğlu*, 470, 471

Bunların çeyiz sayılması, kurulan evde yaşamaya başlamak için zorunlu eşyalar sayılabilecekleri düşüncesine dayanmaktadır. Gelinlik ve damatlık masrafları için ise aynı yorumu yapmak güçtür.

1401 Yeni medeni kanunla getirilen bir hüküm, çeyiz niteliğindeki kazandırmaların denkleştirmeye tabi olmasına önemli bir sınır getirmektedir. MK 675/II, alışılmış ölçüler içinde yapılan çeyiz giderleri hakkında mirasbırakanın bunları denkleştirmeden muaf tutmayı istediğini varsaymaktadır. Bunun anlamı, çeyiz niteliği taşısa bile, bunların ancak mirasbırakan tarafından iadelerinin/denkleştirilmelerinin istendiği ispat edilirse denkleştirilecekleridir. Belirtelim ki, bu yeni hüküm çeyiz masrafını denkleştirmeye tabi tutan MK 669/II'deki kuralın pratik değerini büyük ölçüde kaldıracak niteliktedir. Zira, buna göre, alışılmış ölçüler içinde görülebilen çeyiz masrafları, hemen hemen daima denkleştirmeden kurtulacaktır. Zira, bu masrafları oğlu,kızı veya torunu için yapan mirasbırakanın, aynı zamanda, öldüğünde terekeye iade edilmelerini/denkleştirilmelerini de arzu ettiği (ve bu arzusunun ispat edildiği) durumlarla pek karşılaşılmaz. Oysa Eski MK m.606/c.2, mutad/alışılmış ölçüler içindeki çeyiz masrafının sadece altsoyun miras payını aşan kısmının iade edilmeyeceğini (denkleştirilmeyeceğini) düzenlemişti. Böylece, bu kazandırmayı alan altsoyun miras payı kadar olan çeyiz masrafını alışılagelmiş(mutad) ölçüde olsa bile denkleştirme/iade yükümü doğmaktaydı ve bunun için mirasbırakanın denkleştirme arzusu gerekmezdi. Mirasbırakanın denkleştirme arzusunun ispatı, sadece altsoyun miras payını aşan masraf kısmının da denkleştirilmesi/iadesi için aranırdı[908]. Oysa Yeni MK 575/II karşısında, böyle sınır getirilmeksizin, alışılmış miktarda sayılabilecek tüm çeyiz masrafları kural olarak denkleştirmeden kurtulacaktır.

1402 Bu yeni hüküm karşısında çeyiz masrafının ne zaman alışılagelmiş miktarı geçeceği hususunun saptanması büyük önem taşıyacaktır. Acaba hükmün ifadesinin çağrıştırdığı üzere, tamamen objektif ölçüler mi kullanılacaktır. Böyle yapılırsa, örneğin, evlenen çocuğuna ev almak Türk Kültüründe objektif olarak alışılagelmiş bir çeyiz olduğu için; son derece zengin bir babanın evlenen oğluna aldığı ev kadar, neredeyse tüm malvarlığı birikimini evlenen çocuğuna ev almak için harcayan dar gelirli bir babanın bu kazandırması da alışılagelmiş sayılarak denkleştirmeden kurtulacaktır. Buna karşılık, sübjektif ölçüte ağırlık verilirse, mirasbırakanın yaptığı çeyiz masrafının o sıradaki ekonomik durumu ve imkânları bakımından makul olup olmadığına karar verilecektir. Bu takdirde, yukarıdaki örnekte birinci babanın yaptığı masraf denkleştirmeye tabi tutulmazken ikinci babanınki

[908] Bkz. *Dural/Öz*, Miras hukuku dersleri, birinci bası, İstanbul 2001, 341

tutulacaktır. Kanımızca, hakim sübjektif ölçüte ağırlık vererek hakkaniyete uygun bir değerlendirme yapmalıdır.

c) Borçtan kurtarmak

Eski MK 603/II hükmünde "borçtan ibra" olarak belirtilen bu kazan- 1403
dırma, Yeni MK 669/II'de "borçtan kurtarmak" olarak ifade edilmiştir. Ne var ki, bu ifade ile amaçlanan "ibra" kelimesini Türkçeleştirmek ise, maksadı aşmaktadır. İbra BK 132 uyarınca borçlu ve alacaklının anlaşarak ifada bulunulmadan ve ivazsız olarak borcun sona ermesini sağlamalarıdır[909]. Borçtan kurtarma ise, mirasbırakanın mirasçısının kendisine olan borcunu ibra etmesi şeklinde olabileceği gibi, mirasçısının bir üçüncü kişiye olan borcunu ödemesi suretiyle BK 83 uyarınca da olabilir. Yeni kanundaki ifade bu ikinci tür kazandırmaları da içermektedir[910]. Belirtelim ki, MK 669/II'deki "borçtan kurtarma" ifadesinin sadece ibrayı ifade ettiği kabul edilirse, ibra dışındaki karşılıksız borçtan kurtarmaların aynı fıkradaki "..ve benzerleri gibi karşılık almaksızın altsoyuna yapmış olduğu kazandırmalar.." kapsamına girip girmediği tartışılacak ve buna göre denkleştirmeye tabi olup olmadığı sonucuna varılacaktır[911].

Şayet mirasbırakan altsoyunun kendisine olan bir borcunu ibra ile orta- 1404
dan kaldırmışsa, bu suretle borçtan kurtulan altsoy, mirasbırakan öldüğünde kurtulduğu borç oranında denkleştirmeyle yükümlü olacaktır. Bu yükümlülüğün doğması için, borcun mirasbırakanla yapılan ibra sözleşmesi ile karşılıksız bir kazandırma niteliğinde sona ermesi bir yolla gerekir. Örneğin, altsoyun borcu mirasbırakanla yaptığı yenileme (tecdit) anlaşması ile sona erdirilmişse ve böylece sona eren borç yerine mirasbırakan lehine bir hak yaratılmışsa, ortada denkleştirmeye tabi bir karşılıksız kazandırma yoktur.

Mirasbırakanın ölüme bağlı bir tasarrufla örneğin bir vasiyetneme ile 1405
altsoyunun borcunu sildiğini beyan etmesi, gerçekte bir ibra değil ona yapılan ölüme bağlı bir kazandırma olduğundan, denkleştirmeye tabi olmaz, olsa olsa tenkise tabidir.

---

[909] Bkz. *Oğuzman/Öz*, Borçlar Hukuku, Cilt 1, s. 554 vd.

[910] Ancak belirtelim ki, bu durumda, şayet mirasbırakan yaptığı ödeme sonucu BK 127 uyarınca üçüncü kişiye halef olmuşsa veya borcunu ödediği mirasçıya karşı sebepsiz zenginleşmeden (BK 77 vd) yahut vekaletsiz işgörmeden (BK 526 vd.) kaynaklanan bir talep hakkına sahip olmuşsa; bu haklar da terekede yer alarak diğer mirasçılara geçeceğinden, artık denkleştirmeye tabi bir karşılıksız kazandırmanın varlığından sözedilememelidir. Şu halde, ancak, mirasbırakan mirasçısına karşılıksız bir kazandırmada bulunmak amacıyla (mirasçısından hiç bir şey talep etmeyeceği beyanı ile) onun üçüncü kişiye karşı borcunu ifa etmişse, bu denkleştirmeye tabi bir kazandırma olabilir.

[911] Eski Kanundaki ifadeye göre yazılmış olan Kitabımızın önceki basısının 337. sayfasında, mirasbırakanın mirasçısının üçüncü kişiye olan borcunu ödemesinin denkleştirmeye (iadeye) tabi olmadığını belirtmiştik. Oysa şimdi, yukarıdaki dip notta belirttiğimiz şartlarla, bunların da denkleştirmeye tabi olabilecekleri kanısındayız.

1406 İbra edilen borcun para borcu olması gerekmez. Başka bir şey verme veya yapma borçlarının ibrası da denkleştirmeye tabidir. Paradan başka bir şey verme borcunun ibrasında mirasbırakanın ölümü üzerine altsoy ibra edilen borcunun konusu olan şeyi terekeye iade edecektir. Dilerse, MK 671 uyarınca bunun değerini miras hissesine mahsup ettirebilir[912].

d) Malvarlığı devri.

1407 Eski MK 603/II hükmünde yer almayan bu kazandırma, İsviçre Medeni Kanununda (ZGB Art.626/II) "Vermögensabtretung" adıyla yer almakta idi. Şimdi MK 669/II hükmüne bu kazandırma da eklenerek İsviçre Hukuku ile paralellik sağlanmıştır. Malvarlığı devri, birden çok hakkı ve bazen de bunlarla birlikte borçları içeren bir toplu devri ifade eder. Şayet devredilen malvarlığında borçlar da varsa, denkleştirmeye tabi kazandırma sadece hakların bu borçlardan fazla kısmı (malvarlığının pasifinin aktifinden çıkarılması üzerine kalan kısım)dır. Böylece, örneğin, mirasbırakan oğluna, kuruluş sermayesi verme yerine, ticarî veya tarımsal bir işletmesini içerdiği tüm haklar ve borçlarla birlikte devretmişse, bu çerçevede devredilen hakların (aynî haklar, sınaî ve fikrî haklar, alacak hakları) değerleri toplamından gene bu çerçevede nakledilen borçların toplamı çıkarılmak suretiyle bulunacak miktar, miras paylaşımında terekeye iade edilerek denkleştirilecektir.

e) Diğer benzeri kazandırmalar.

1408 Kanunen denkleştirmeye tabi kazandırmaları sayan MK 669/II hükmü, açıkça saydığı ve yukarıda belirttiğimiz kazandırmalardan sonra, "ve benzerleri gibi karşılık almaksızın altsoyuna yapmış olduğu kazandırmalar,.."[913] İfadesini kullanmaktadır. Bu ifadenin kapsamına hangi kazandırmaların gireceği tartışmalıdır.

1409 Bir görüşe göre, altsoya yapılan tüm ivazsız kazandırmalar bu fıkra hükmüne göre denkleştirme kapsamına girer[914]. Hem uygulanması basit hem de adalete uygun görünen bu çözüm, MK 669/II'de her türlü ivazsız kazandırma iadeye tabidir demek varken niçin sadece bazı ivazsız kazandırmaların belirtildiği sorusu karşısında, zayıf kalmaktadır.

1410 Çoğunluğun katıldığı diğer görüşe göre, sadece altsoyun ekonomik ba-

---

[912] Aslında burada ibra edilen borcun konusu olan edim, iade yükümlüsü açısından, MK 605 anlamında "aldığı şey" değildir. Burada aldığı şey, "bu borcunun ibra edilmesi"dir. Fakat, işin niteliği bakımından, "ibra"nın iadesi, ibra edilen borcun geçerlilik kazanması demek olacağından, bu borcunu ifa ile diğer mirasçılara karşı yükümlü sayılması, iadenin konusu sayılacaktır.

[913] Eski MK 603/II ifadesiyle: "..ve bu kabilden sair suretlerle bahşedilen menfaatler.."

[914] *Tuor/Picenoni*, Art. 626, N.40, 41

ğımsızlığını kazanmasını, devam ettirmesini veya genişletmesini, onun hayata yerleşmesini sağlayan kazandırmalar MK 669/II kapsamına girer[915]. Bu görüş bizce de kanunun sözüne ve ruhuna daha iyi uymaktadır. Ne var ki, her somut olayda yapılan ivazsız kazandırmanın denkleştirmeye tabi olup olmadığı hususunda dikkatli bir araştırma ve değer yargısı gerektirecektir. Bu görüşe göre, örneğin, mirasbırakanın iki oğlundan birine yaptığı normalin üstünde eğitim masrafları MK 669/II uyarınca kanunen denkleştirmeye tabi kazandırma sayılabilecekken, diğer oğluna gezmesi için aldığı araba kanunen denkleştirmeye tabi bir kazandırma sayılmayacaktır. Bu görüş çerçevesinde altsoya yapıldığı hâlde MK 669/II uyarınca kanunen denkleştirmeye tabi sayılmayan ivazsız kazandırmalar, sadece MK 669/I uyarınca mirasbırakan tarafından iadesi açıkça öngörülmüşse denkleştirmeye tabi olacak; bu yapılmamışsa ancak tenkise tabi olabilecektir.

Aşağıda açıklayacağımız MK 674/I uyarınca alışılmış ölçüleri aşan eğitim ve öğrenim giderleri ile gene aşağıda açıklayacağımız MK 675/I uyarınca geleneğe uygun sayılmayacak evlenme giderleri de "benzeri kazandırma" kapsamına girerek denkleştirmeye tabi olacaktır. 1411

3. Denkleştirmeden Kanunen Muaf Tutulan Kazandırmalar

a) Eğitim ve öğrenim masrafları.

MK 674/I uyarınca, mirasbırakanın çocuklarına yaptığı eğitim ve öğrenim (Eski MK 608/I: talim ve terbiye) masraflarının "alışılmış ölçüleri aşan kısmı" (Eski MK: mutad olan miktardan fazlası), aksini kararlaştırmamışsa, denkleştirmeye tabidir. Bu hükmün kapsamına, çocuğun gönderildiği özel okullara ödenen paralar, aldırılan özel derslerin ve kursların ücretleri, şayet başka bir şehirde veya başka bir ülkede eğitim yaptırılmışsa, bu maksatla yapılan yurt, pansiyon, seyahat giderleri, başta kitap, özel giysi, deney ve inceleme malzemeleri gibi meslekî araç gereçler girer. Kanun hükmünden anlaşıldığı gibi, sözkonusu masraflar bir ayırıma tabi tutulacak ve olağan-normal görülebilecek olanlar denkleştirmeden muaf tutulurken, olağandışı-aşırı görülecek olanlar denkleştirmeye tabi tutulabilecektir. Burada hem yapılan masrafın objektif değeri hem de mirasbırakanın ekonomik durumu birlikte ele alınacaktır[916]. Örneğin, ekonomik durumu bakımından kendisi için fedakârlık sayılacak masraflarla oğlunu Amerika'da okutan kişinin bu harcamaları denkleştirmeye tabi olurken; Türkiye'deki bir özel okulda okutması normal masraf sayılarak denkleştirmeye tabi olmayabilir. Buna karşılık, daha zayıf olan ekonomik durumu sebebiyle, bir başkasının oğlunu 1412

---

[915] *Kocayusufpaşaoğlu*, 472 vd.; *Oğuzman*, 329, 330; BGE 77 II 36

[916] *Escher*, Art.631, N.9; *Tuor/Picenoni*, Art. 631, N. 8; *Kocayusufpaşaoğlu*, 475,476

Türkiye'de özel okulda okutması da kendisi için olağandışı masraf sayılıp denkleştirmeye tabi tutulabilir.

1413 Maddenin ifadesine göre, alışılmış ölçüleri aşan bir eğitim masrafının tümü değil, sadece alışılmış/normal görülebilecek miktardan fazla kısmı denkleştirmeye tabi olacaktır. Örneğin, durumu bakımından oğlu için 5 milyon Liraya kadar eğitim masrafı yapması normal karşılanabilecek bir baba, oğluna 15 milyon lira eğitim masrafı yapmışsa, öldüğünde bu oğul denkleştirme borcu sebebiyle terekeye 10 milyon lira iade edecektir.

1414 Sözkonusu hüküm, mirasbırakanın tüm altsoyunu kapsamayıp sadece çocuklarına ilişkindir. Böylece, mirasbırakanın torunlarına yaptığı eğitim masrafları "alışılmış" sınırlar içinde kalsa bile MK 674/I uyarınca denkleştirmeye tabi tutulabilir.

b) Olağan hediyeler ve evlenme giderleri

1415 MK 675/I uyarınca, "Olağan hediyeler ile evlenme sırasında yapılan geleneğe uygun giderler denkleştirmeye tabi değildir." Bunu izleyen II. Fıkrada da, altsoy hısımlarının evlenmelerinde, alışılmış ölçüler içinde yapılan çeyiz giderleri hakkında mirasbırakanın bunları denkleştirmeden muaf tuttuğu varsayılmaktadır. Bu fıkradaki sınırlama hükmünü çeyizin denkleştirilmesini anlatırken açıkladık. Burada sadece, olağan hediyeler ve evlenme giderlerini açıklayacağız. Belirtelim ki, evlenme giderleri ile çeyiz kazandırması arasındaki sınır her zaman net olmayacağı gibi, esasen ikisinin de denkleştirilmesine (birincisi için "olağan", ikincisi için "alışılmış" terimleriyle ifade edilen) aynı ölçülerle sınırlama getirildiğinden, bu farkın pratik anlamı da bulunmamaktadır.

1416 Olağan hediyeleri denkleştirmeden muaf tutan hüküm, adet üzerine verilen hediyeleri tenkisten de kurtaran MK 565 b..3 hükmüne paraleldir. Olağan hediyeden maksat, verilen kişiye kayda değer bir ekonomik katkı sağlamayan, verilmesindeki amaç da karşı tarafın ekonomik bağımsızlığını sağlamak veya pekiştirmek yahut onu bir ekonomik sıkıntıdan kurtarmak olmayan, adet gereği verilen hediyelerdir[917]. Doğum günü, yılbaşı, mezuniyet hediyeleri böyledir. Bir hediyenin ne zaman olağan sayılarak denkleştirmeye tabi olmayacağı ve ne zaman olağanı aşarak denkleştirilmesi gereken bir kazandırma sayılacağı, o hediyenin objektif değeri kadar mirasbırakanın ekonomik durumuna da bağlıdır. Örneğin, üniversiteden mezun olan oğluna otomobil alan çok zengin bir babanın bu hediyesi denkleştirmeye tabi sayılmayabilecek iken aynı hediyeyi alan fakat bu kadar zengin olma-

[917] *Escher*, Art.632, N.2; *Kocayusufpaşaoğlu*, 477,478;

yan bir başka babanın bu kazandırması tesis masrafı sayılarak denkleştirmeye tabi tutulabilir.

Hediyenin olağan miktarı aşıp aşmadığı mirasbırakanın kazandırmada bulunduğu sıradaki ekonomik durumuna göre mi yoksa ölüm anındaki ekonomik durumuna göre mi kararlaştırılacaktır? Denkleştirme borcunun mirasbırakanın ölümü anında doğduğu dikkate alınırsa bu ana göre değerlendirme yapılması akla gelirse de, kanımca burada değerlendirme işin niteliği gereği kazandırma anına göre yapılmalıdır. Zira, kendisine kazandırma yapılan kişinin mirasbırakanın o sıradaki malvarlığına göre bu kazandırmayı alması karşısında, sonraki değişikliklerin riskini üstlenmesi doğru olmaz. 1417

Hediyenin olağan miktarı aşması hâlinde tümü mü yoksa sadece aşan kısmının mı denkleştirmeye tabi olacaktır? Öğretide olağan miktarın çok fazla aşılmaması şartı ile sadece aşan kısmın denkleştirmeye tabi olacağı, çok aşılmışsa artık tümünün denkleştirmeye konu olması savunulmaktadır[918]. Kanımca bu çözüm hem tutarsız hem de bazı durumlarda sınırların belirsizliği bakımından uygulanması çok güç bir çözümdür. Bence en isabetli çözüm, bölünebilir edimlerde sadece mutadı aşan miktarın iadeye tabi olması, bölünemeyen edimlerde ise kazandırmanın tümünün iadeye tabi olmasıdır. Böylece, örneğin, verilen 100 bin liralık hediye çeki ile yapılan kazandırmanın mutadı aşan 80 bin lirası denkleştirmeye tabi tutulacak iken, verilen 100 bin lira değerindeki otomobilin tümü denkleştirmeye tabi tutulabilecektir. 1418

Kanun evlenme sırasında yapılan geleneğe uygun giderleri de olağan hediye ile aynı hükme tabi tutmuştur. Böylece, örneğin, geline veya damada verilen takılar, nikah ve normal sayılabilecek düğün masrafları, denkleştirmeden muaf olabilecektir. Buna karşılık, özellikle mirasbırakanın durumuna uymayacak kadar değerli veya çok takılar vermesi, gene mirasbırakanın durumu ile bağdaşmayan pahalılıkta bir düğün masrafı yapması, denkleştirmeye tabi olacaktır. 1419

c) Miras payını aşan kazandırmalarda bazı durumlarda aşan kısım.

Kural olarak, denkleştirme yükümlüsünün aldığı kazandırmanın miras payından az veya fazla olması denkleştirme yükümünü değiştirmez. Mirasbırakanın sağlığında yaptığı denkleştirmeye tabi kazandırmalar bazen kazandırmayı alan yasal mirasçının miras payından fazla olabilir. Kural olarak bu takdirde de aşan kısım dahil tüm kazandırmayı iade etmelidir. Örneğin, (M)'nin ölümüne bıraktığı para 10 milyon lira olup iki çocuğu (A) ve (B) iken; (A)ya sağlığında 20 milyon lira denkleştirmeye tabi kazandırma 1420

[918] *Tuor/Picenoni*, Art. 632, N.4; *Kocayusufpaşaoğlu*, 478

yapmışsa, (A)'nın miras hissesi: 10 + 20 =30.1/2 = 15 milyon lira olduğuna göre, miras hissesinden 5 milyon lira daha fazla bir iadeye tabi kazandırma almıştır ve terekeye bu fazlalıkla birlikte 20 milyonu iade ederek miras payını alacaktır.

1421 Ne var ki, MK 672 hükmünde, denkleştirmeye tabi kazandırmanın miras payını aşan kısmının denkleştirmeden muaf olmasını sağlayabilecek bir imkân tanınmıştır. Buna göre, yapılan kazandırma miras payını aştığı takdirde mirasçı, mirasbırakanın bunu kendisine bırakmak istediğini ispat ederse, bu fazlalık denkleştirmeye tabi olmaz. Bu ifade biçiminden, mirasbırakanın belirtilen fazlalığı denkleştirmeden muaf tutmasının örtülü (zimnî) bir beyanla da yapılmış sayılabileceği, açık beyanın şart olmadığı anlaşılmaktadır[919]. Mirasbırakanın fazlaya ilişkin kısmın denkleştirmeye tabi olmasını istemediğini kazandırmayı alan mirasçı ispat edecektir. Böyle bir durumda MK 672'nin son cümlesi, denkleştirmeden kurtulan bu fazlanın tenkise tabi olduğunu, diğer mirasçıların bu kısmın denkleştirilmesini isteyemeseler de saklı paylarına tecavüz ettiği oranda tenkisini isteyebileceklerini hükme bağlamıştır.

1422 Hesaplama bakımından, önce denkleştirmeye tabi kazanma bütün olarak terekeye eklenecek ve bu suretle bulunacak miktardan kazandırmayı alanın miras payı tespit edilecektir. Sonra bu paydan ne kadar fazla kazandırma aldığı bulunacak; bu fazlanın kendisine kalması öngörüldüğünden, sadece miras payı kadar miktar tereke mevcuduna eklenerek her bir mirasçıya kalacak miras payı bulunacaktır[920].

V. DENKLEŞTİRMENİN TALEP EDİLMESİ, GERÇEKLEŞMESİ VE DENKLEŞTİRMEDEN SORUMLULUK.

1. Denkleştirme Davası.

1423 Denkleştirme mirasın paylaştırılmasına ilişkin bir kurum olduğu için,

---

[919] Eski MK 606'daki aynı anlamdaki hüküm bakımından: *Escher*, Art.629, N.5; *Tuor/Picenoni*, Art. 629/N.11; *Kocayusufpaşaoğlu*, 480

[920] *Kocayusufpaşaoğlu*, 480, 481 Yazar şu örneği vermektedir: Mirasbırakan (M)'nin ölümünde mevcut tereke 40.000 lira ve oğulları (A), (B) ve (C)'dir. (A) mirasbırakandan sağlığında 140.000 lira kuruluş sermayesi almıştır. Mirasbırakan, bu kazandırmadan dolayı (A)'nın paymdan fazla kısmı denkleştirme yükümlülüğü olmadığını beyan etmiştir. Bu durumda hesap şöyle olacaktır: (A)'nın miras payı: 40.000 + 140.000 = 180.000 .1/3= 60.000. liradır. Şu halde (A) sadece miras payını karşılayan 60.000 lirayı iade/denkleştirme ile yükümlüdür. Paylaştırma bakımından ise, tereke: 40.000 + 60.000 = 100.000 olacak, terekeden (A)'ya ait 60.000 liralık pay çıkartıldığında geri kalan 40.00 lirayı 20.000 lira (B) ve 20.000 lira (C) olarak paylaşacaklar, (A) 60.000 liralık kanunî payına denkleştirmeye tabi kazandırmayı mahsup edeceğinden fiilen mevcut 40.000 liralık terekeden eline bir şey geçmeyecektir. Bu sonuç denkleştirme bakımından olup, (B) ve (C)'nin (A)'ya tenkis davası açma hakları saklıdır.

kanunda "tenkis davası"nın düzenlenmesi gibi bir "denkleştirme davası" düzenlenmemiştir. Denkleştirmeyi düzenleyen MK 669-675 hükümleri arasında denkleştirmenin şartları ve hesaplanması hükümlere bağlanırken denkleştirme davasından ve ne zamana kadar denkleştirme istenebileceğinden sözedilmemiştir. Bununla birlikte, denkleştirme yükümünün var olup olmadığı veya ne miktarda olduğu uyuşmazlık konusu ise veya böyle bir uyuşmazlık olmasa bile denkleştirme yükümlüsü denkleştirmeden kaçınıyorsa, denkleştirme alacaklısı yasal mirasçıların bir dava ile bu haklarını tanıtmaları ve denkleştirmeyi sağlamaları gerekecektir. Denkleştirme (eski terimle: iade) davası adı altında anılan bu davalardan, denkleştirmenin konusunu ve çerçevesini belirlemeye yönelik davanın bir tür "tespit davası" olduğu, bu bakımdan mirasbırakanın ölümü anından itibaren ve mirasın paylaşılması aşamasından önce de açılabileceği; buna karşılık denkleştirme konusu şeyin verilmesine yönelik davanın bir tür paylaştırma davası şeklinde eda davası olduğu ve ancak mirasın paylaşılması aşamasında açılabileceği kabul edilmektedir[921]. Kuşkusuz, paylaştırma aşamasında açılacak denkleştirmeye yönelik eda davası buna yönelik tespiti de içerecektir[922].

Yasada bir süre bulunmamakla birlikte, İster sadece tespite ister denk- 1424
leştirmenin ifasına yönelik olsun, denkleştirme davalarının mirasın paylaşılması aşamasının sonuna kadar açılması gerekir[923]. Mirasın paylaşılması ileride göreceğimiz üzere tarafların gerekli şekilde anlaşması veya hâkim kararı ile sona erince, denkleştirme yükümlülüğü ve bunu karşılayan denkleştirme davası açma hakkı da son bulur. Henüz mirasın paylaşılması safhası sona ermemişse, aradan ne kadar zaman geçmiş olursa olsun denkleştirme davası açma hakkı düşmez veya zamanaşımına uğramaz. Yargıtayın bazı kararlarında denkleştirme (iade) davasının zamanaşımı süresinden sözetmesi ve bu sürenin genel kurala uygun olarak 10 yıl olacağını ileri sürmesi[924] bu bakımdan isabetsizdir ve denkleştirmenin mirasın paylaşılması aşamasının ayrılmaz bir parçası olduğunun gözden kaçırılmasına dayanmaktadır. Denkleştirme konusu kazandırmayı bilen veya bilmesi gereken mirasçı, paylaştırmanın tamamlanmasına kadar denkleştirme/iade davası açmamışsa, bu hakkı düşecektir. Ancak, denkleştirme alacaklısı mirasçının denkleştirme konusu kazandırmayı bilmediği ve bilmesi de gerekmediği bir durumda paylaştırma gerçekleşmişse, bu hususun irade sakatlığı (yanılma veya aldatma) oluşturduğu gerekçesiyle paylaşım iptal edilebilirse, yeniden

---

[921] *Kocayususufpaşaoğlu*, 484 vd.; *Escher*, Art. 626, N.16 *Oğuzman*, 328, Not 307.

[922] Paylaştırma aşamasında esasen bir başına tespit davası açılamayıp iade yükümünün ifası davası açılabileceği hakkında bkz.. *Kocayusufpaşaoğlu*, 485; BGE 84 II 685 vd.

[923] *Escher*, Vorbem. Vor Art.626, N.7, 20 ; *Tuor/Picenoni*, Vorbem Art. 626, N.7 ; *Kocayusufpaşaoğlu*, 440, 484 vd.; *Oğuzman*, 328.

[924] Yarg. 2.HD 9.4.1987, 2384/3175 (İKİD 1989, s.6424); '.HD. 11.11.1969 E.2862 K.5059 (*Yazıcı/Atasoy*, Şahıs, Aile ve Miras hukuku ile İlgili Yargıtay tatbikatı, Ankara 1970, 1279)

paylaşma aşamasına dönüleceği için denkleştirme davası açma hakkı yeniden elde edilebilir.

2. Denkleştirmenin Gerçekleşmesi Ve Bu Sıradaki Sorumluluk.

1425 Denkleştirme konusu kazandırmanın paradan başka bir şey, bir taşınır veya taşınmaz mal olması hâlinde, kendisinden denkleştirme istenen denkleştirme yükümlüsüne yasakoyucu MK 671/I hükmü ile bir seçme hakkı tanımıştır. Buna göre, denkleştirme yükümlüsü, dilerse aldığı şeyi aynen terekeye iade eder[925], dilerse bu şeyi elinde tutarak parasal değerini iade eder. Maddede, ikinci şıkkı seçen denkleştirme yükümlüsünün terekeye ödeme yapmak yerine, aldığı şeyin değerini terekedeki miras payına mahsup edeceği belirtilmiştir. Böylece, bu yasal takas ile işlemler kısaltılıp basitleştirilmiştir. Madde metninde denkleştirme değerinin denkleştirme yükümlüsünün miras payından fazla olsa bile mahsup edileceği ayrıca belirtilmiştir. Bu durumda, denkleştirme yükümlüsü tüm miras payından yoksun kalacağı gibi, üstüne terekeye bir miktar da ödeme yapacaktır.

1426 Böylece, örneğin, taksicilik yapması için babası tarafından kendisine otomobil alınan oğul, babasının ölümü üzerine kardeşlerinin talebi hâlinde, isterse terekeye bu otomobili iade ederek tereke paylaşımına eşit pay ile katılır, isterse otomobili elinde tutarak bunun değeri kadar miras payının azalmasına razı olur. İkinci şıkkı seçtiğinde, şayet kendisine düşen miras payı bu otomobilin değerinden az ise, mirastan hiçbir şey alamayacağı gibi üste aradaki fark kadar terekeye ödeme yapacaktır.

1427 MK 671/II uyarınca, mirasbırakan denkleştirmenin aynen mi yoksa mahsuben mi yapılacağı hususunu kararlaştırmış ise buna uyulacaktır. Belirtelim ki mirasbırakanın aynen iadeyi emreden beyanı, mirasın açıldığı sırada denkleştirme yükümlüsünün henüz elinden çıkarmamış bulunduğu kazandırmalar için bir anlam ifade eder.

1428 MK 673 hükümlerine göre, seçimlik hakkın kullanılmasında denkleştirme konusu malın denkleştirmenin yapıldığı tarihteki değeri esas alınacaktır. Eski MK 607 ise mirasın açıldığı (mirasbırakanın öldüğü) tarihteki değeri esas almıştı. Yeni hüküm, bölünemez kazandırmaların kısmî tenkisinde karar günündeki değeri esas alan MK 564/II hükmüyle de uyumludur.

1429 MK 673/II uyarınca, denkleştirilecek mala ilişkin yarar ve zarar ile gelir ve giderler hakkında denkleştirme yükümlüsü ile diğer mirasçılar arasında sebepsiz zenginleşme hükümleri (BK 77-82) uygulanacaktır. Bu yollama

---

[925] Bu şekilde terekeye iade edilen malın kısmen de olsa paylaştırma sonucunda gene aynı mirasçıya düşmesinin mümkün olduğu hakkında: *Tuor/Picenoni*, Art.628, N.2; *Kocayusufpaşaoğlu*, 482

işin niteliğine, aynı durumda zilyetliğin iadesine ilişkin hükümlerinin (MK 993-995 /Eski 906-908) uygulanacağını düzenleyen Eski MK 607'den daha uygundur. Denkleştirme konusu mal mirasın açılmasından önce denkleştirme yükümlüsünün kusuru olmaksızın değer azalmasına uğramışsa veya telef olmuşsa, denkleştirme yükümlüsü bundan sorumlu değildir. O sadece mirasın açıldığı sırada elinde kalanın değeri ile sorumludur. Keza, malın değeri denkleştirme anına kadar artmışsa, denkleştirme yükümlüsü aynî veya nakdî olarak, bu artmış değeri de iade ile yükümlü olacaktır. Örneğin, iade konusu hisse senetleri, denkleştirme anında değeri ne kadar düşmüş veya ne kadar yükselmiş olursa olsun, bunların önceki değerleri hiçbir surette gözönüne alınmaz. Ancak, malın değeri denkleştirme yükümlüsünün harcadığı bir emek veya yaptığı sarfiyat sayesinde artmışsa, bu fazlalığı denkleştirme yükümü bulunmadığı kabul edilmektedir[926]. Denkleştirme yükümlüsünün kusuru yüzünden malın değerinin azalması veya telef olması hâlinde ise, kötüniyetli veya iyiniyetli sebepsiz zenginleşen sayılmasına göre BK 80 hükümleri çerçevesinde sorumlu olacak veya olmayacaktır. Sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre sorumluluk hakkında açıklamalar için Borçlar hukuku eserlerine başvurulacaktır. Şu kadarını belirtelim ki, denkleştirme konusu kazandırmayı alan mirasçı, denkleştirme yükümlüsü olduğunu biliyor veya bilmesi gerekiyor ise bu andan itibaren kötü niyetli sebepsiz zenginleşenin iade rejimine tabi olacak, denkleştirme yükümlüsü olduğunu bilmesi kendisinden beklenemediği sürece iyi niyetli sebepsiz zenginleşenin iade rejimine tabi olacaktır.

Belirtelim ki, denkleştirmeye tabi kazandırmanın değerinin belirlenmesi 1430
için denkleştirme anındaki değerinin esas alınması başka, denkleştirme anına kadarki değer artışı ve azalmaları ile bu kazandırma sayesinde elde edilen artı kazançlarla kayıpların hesaplaşmaya etkisi başkadır. Sebepsiz zenginleşme hükümlerine yollama bu sonraki gelişmeler için yapılmıştır. Böylece, örneğin, (A) mirasbırakanından denkleştirmeye tabi bir ev almışsa, bu evin denkleştirme değeri, iktisap edildiği sıradaki hali gözönüne alınarak fakat denkleştirmenin yapıldığı sıradaki rayiçler bakımından saptanacaktır. Fakat, sonradan bu evdeki hasarların sebep olduğu kayıplar veya evin kiraya verilmesi sayesinde elde edilen kazançlar, gerçekleştikleri sırada (A)'nın durumuna göre iyiniyetli veya kötüniyetli sebepsiz zenginleşme hükümleri çerçevesinde çözümlenecektir.

MK 673 hükümlerinin kazandırmanın denkleştirme anındaki değerine 1431
göre denkleştirilmesini ve yarar- zarar ile gelir -giderin sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre sonuca bağlanmasını öngören yeni düzenlemesi üzerine, artık Eski MK 607 hükmünün mirasbırakanın ölüm gününü ve

[926] *Kocayusufpaşaoğlu*, 487

haksız zilyetlik hükümlerini esas almasından kaynaklanan bazı görüş ve tartışmalar önemini kaybetmiştir. Buna rağmen, eski kanunun getirdiği düzen bakımından yapılmış açıklama ve tartışmalara özetle değinelim:

1432 Denkleştirme konusu malın mirasın açılmasından sonra denkleştirme yükümlüsünün kusuru olmadan değerinin azalması veya katkısı olmadan değerinin artması hâlinde i, varılacak sonucun aynen iadeyi mi yoksa mahsup yoluyla iadeyi mi seçtiğine bağlı olarak değişeceği belirtilmekteydi[927]. Şayet denkleştirme yükümlüsü aynen iadeyi seçerse, malı iadenin fiilen yapıldığı andaki hâliyle terekeye vererek borcundan kurtulacaktı. Buna karşılık, değerini iadeyi = mahsup yoluyla iadeyi seçerse, Eski MK m607/c.1 uyarınca, denkleştirme konusu malın mirasın açıldığı tarihteki değerini iade ile borçlu olacaktı[928]. Böylece, mirasın açılmasından sonra denkleştirmeye konu malın değeri düşmüşse aynen iadeyi seçmek, değeri yükselmişse değerini mahsuben iadeyi seçmek, iade yükümlüsü için daha kazançlı olurdu.

1433 Şayet mirasın açılmasından sonra fakat iadeden önce denkleştirme konusu şeyin değeri denkleştirme yükümlüsünün kusurlu davranışı sonucu azalmış veya telef olmuşsa, denkleştirme yükümlüsü mirasın açılmasından önceki dönemde olduğu gibi, bu zarardan dolayı Eski MK 607/c.2 uyarınca haksız zilyedin sorumluluğuna ilişkin Eski MK 908/c.son hükmüne göre sorumu olurdu[929]. Denkleştirme yükümlüsünün mala eklediği fazlalıklar, muhafazası için yaptığı masraflar, elde ettiği ve elde etmeyi ihmal ettiği semereler hakkında da, niteliğine uygun düştüğü ölçüde gene haksız zilyedin iade yükümüne ilişkin MK.906-908 hükümleri uygulanacaktı[930].

---

[927] *Escher,* Art.630, N.14, a; *Kocayusufpaşaoğlu*, 487,488

[928] *Escher*, Art.630, N.14 a; *Kocayusufpaşaoğlu*, 487, 488

[929] Ancak bu sonuç tartışmalıydı. Bir görüşe göre denkleştirme yükümlüsü mirasın açılmasına kadar sadece kusuru ile yol açtığı zararlardan mirasın açılmasından sonra kazadan dahî sorumlu olmalıydı. Bir başka görüşe göre böyle bir dönem ayırımı yapılmaksızın denkleştirme yükümlüsünün ancak ağır kusuruyla (kasıt ve ihmali ile) yol açtığı zararlardan sorumlu tutulması söz konusu olmalıydı. Nihayet üçüncü bir görüş, gene dönem ayırımı yapmamakta fakat denkleştirme yükümlüsünü her türlü kusurundan dolayı sorumlu tutmaktaydı. Bu görüşler hakkında bkz. *Kocayusufpaşaoğlu*, 490 (Yazar üçüncü görüşe katılmaktadır. Bizce de Eski Kanun sisteminde en makul sonuç buydu).

[930] Öğretide benimsendiği üzere, denkleştirme yükümlüsü iade anına kadar iyi niyetli haksız zilyet gibi elde ettiği semerelerden yararlanma hakkına sahipti ve bunları terekeye verme borcu yoktu. Buna paralel olarak, denkleştirme konusu kazandırma bir miktar para ise, denkleştirme yükümlüsünün faiz ödemekle de yükümlü olmadığı kabul edilmekteydi. Ancak, denkleştirme yükümlüsü malın özüne dokunan aşırı yararlanmaları tazmin etmekle yükümlü sayılmaktaydı. Denkleştirme yükümlüsünün mala yaptığı masraflar bakımından da iyi niyetli haksız zilyede ilişkin hükümlere tabi olacağı belirtilmekteydi. Bu hususlarda bkz.: *Escher*, Art. 630, N.15; *Tuor/Picenoni*, Art.630, N.9; *Kocayusufpaşaoğlu*, 490, 491.

§ 25. Mirasbırakanın Özel Durumdaki Bazı Çocuklarının Alacak Hakları.

I. EĞİTİM VE ÖĞRENİMİNİ TAMAMLAMAMIŞ VEYA ENGELLİ[930a] OLAN ÇOCUKLARIN ALACAK HAKKI

MK 674/II uyarınca, mirasbırakanın ölümünde henüz eğitim ve öğre- 1434
nimleri tamamlanmamış olan veya engelli bulunan çocuklara, mirasın paylaştırılması sırasında hakkaniyete uygun bir ödeme yapılacaktır. Bu hükümle, mirasbırakanın henüz eğitim ve öğrenimleri süren çocuklarına veya engelli çocuklarına terekeden karşılanmak üzere diğer mirasçılara karşı özel bir alacak hakkı sağlanmıştır. Hükmün getiriliş sebebi, eğitimini mirasbırakanın sağlığında tamamlamış bulunan çocuğu ile bu imkâna sahip olamayan çocuğu arasında eşitlik sağlamak şeklinde açıklanmaktaysa da[931]; eğitim ve öğrenimini tamamlamamış çocuğun bu alacak hakkına mirasbırakanca eğitim ve öğrenim masrafı yapılmamış kardeşlerine ve mirasbırakanın sağ kalan eşine karşı da sahip olacağı dikkate alınırsa[932], bu pek doğru görünmemektedir. Hükmün konuluş sebebinin, eşitlik sağlama çabasından çok, eğitim ve öğrenimi teşvik ve kolaylaştırma olduğu söylenebilir. Alacağın çocuklarla sınırlanması ise, aile hukukuna göre mirasbırakanın sağlığında sadece çocuklarının eğitimini ve öğrenimini sağlama görevi olmasıyla bağlantılıdır. Eğitim ve öğrenimi devam etmese bile engelli çocuklara aynı alacak hakkının tanınması, hükmün bu amacını daha da açıkça ortaya koymaktadır.

Bu alacak hakkına mirasbırakanın sadece çocukları sahiptir. Mirasbıra- 1435
kan ölümü anında eğitimini tamamlamamış torunları, babaları daha önce öldüğü için mirasbırakanın çocuğu gibi ona mirasçı olsalar bile, MK 674/II uyarınca bir alacak hakkına sahip olmazlar. Mirasbırakanın sağlığında bu eğitim masraflarını karşılıyor olması da bu sonucu değiştirmez.

Çocukların eğitim ve öğrenim sebebiyle alacak hakkına sahip olmaları 1436

[930a] 25.4.2013 tarihli ve 6462 SK 1/52-d hükmü ile değiştirilinceye kadar, maddede "sakat" ifadesi yer almakta idi. Bu kaba tabirin "engelli" olarak değiştirilmesi isabetli olmuştur.

[931] *Escher*, Art.631, N.12; *Kocayusufpaşaoğlu*, 493

[932] Kanımızca, MK 674/II'de eğitimini sürdüren çocuğa tanınan alacak hakkı, aynı maddenin birinci fıkrasında düzenlenen ve daha önce açıkladığımız (bkz. § 24 IV 3 a), eğitim masrafları mirasbırakanca karşılanmış çocukların alışılmış ölçüde eğitim masraflarını terekeye iadeden/denkleştirmeden muaf tutulması kuralının uygulandığı durumlara özgü ve sadece böyle durumlarda eğitimini sürdüren çocuğun durumunu dengelemek için getirilmiş değildir. Şayet öyle olsaydı, MK 674/II hükmünün "böyle bir durumda" ifadesi ile veya buna benzer bir ifade ile başlaması gerekirdi. Öte yandan, kanunun tanıdığı bir hakkın (özellikle eğitim ve öğrenimi teşvik eden böyle bir hakkın) uygulama alanı saptanırken daraltıcı yorumun tercih edilmesi temel yorum ilkelerine de aykırıdır.

için mirasbırakanın onları sağlığında okutuyor olması gerekmez. Mirabırakanın ölümü anında henüz okula başlamamış veya eğitim masraflarını başka bir kaynaktan karşılaya gelmiş çocuklar da bu alacak hakkına sahiptir. Buna karşılık, kendilerini meslek sahibi yapacak şekilde eğitimini tamamlamış çocukların örneğin Üniversiteyi bitirmiş olanların ayrıca ihtisas yapmak istemeleri veya bir başka mesleğin okuluna gitmek istemeleri ya da eğitimini yarıda kesmiş olanların makul ve inandırıcı görülmeyecek şekilde kaldıkları yerden veya yeni bir yerde eğitime başlayacaklarını ileri sürmeleri, terekeye karşı alacak hakkı kazandırmamalıdır.

1437 Eğitim ve öğrenimini sürdüren çocuğun mirastan alacağı payın eğitimine yeterli hatta çok daha büyük bir servet oluşturması, MK m.674/II uyarınca ayrıca alacak hakkına sahip olmasını engellemez. Bununla birlikte, hâkim uyuşmazlık hâlinde alacak hakkını belirlerken, çocuğun eğitim ve öğrenimini tamamlaması için gerekli tüm masrafın toplam değerine hükmetmek zorunda olmayıp, terekenin durumuna, okuyan çocuğun şartlarına ve diğer mirasçıların durumuna (şayet daha önce eğitimi mirasbırakanca yaptırılmış bir mirasçı varsa burada dikkate alınabilir) göre makul bir miktara hükmedecektir.

1438 MK 674/II ayrıca mirasbırakanın engelli çocuklarına da terekeye karşı "uygun" miktarda bir alacak hakkı tanımaktadır. Bunun sebebi, onların hayata karşı bazı desteklere ihtiyacı olmasıdır. Engelli olma fiziksel olacağı gibi ruhsal da (zekâ özürlü olmak gibi) olabilir. Hatta kanımızca, iyileşmeyecek nitelikte olup sürekli bakım ve tedavi gerektiren hastalıklar da (bazı kanser hastalıkları, ruh hastalıkları vb.) bu hükme sokulmalıdır.

1439 Mirasbırakanın çocukları dışındaki mirasçıları (örneğin, torunları, eşi), engelli olsalar bile böyle bir alacak hakkı kazanmazlar.

1440 Engelli olma sebebiyle tanınan alacak hakkının miktarı uyuşmazlık konusu olursa, hâkim sakatlığın derecesi, terekenin değeri, engelli çocuğun sahip olduğu imkânlar gibi unsurları gözönüne alarak bunu takdir edecektir. Şayet engellinin malî durumu veya terekeden kendisine düşen pay her türlü ihtiyacını fazlasıyla ve sürekli şekilde karşılayacak düzeyde ise, hâkimin herhangi bir miktara hükmetmeyebileceği de ileri sürülmektedir.[933] Kanımca bu görüş MK 674/II hükmü çerçevesinde savunulması zor bir görüş olup kanunun öngördüğü bir hakkı yasal bir dayanak olmadan tamamen kaldırmak anlamına gelmektedir[934]. Buna karşılık, hâkimin somut olayın özellik-

[933] *Escher*, Art.631, N.14; *Tuor/Picenoni*, Art.631, N.16; *Kocayusufpaşaoğlu*, 494

[934] Bu madde hükmüyle düzenlenen alacak hakkının gerçekte bir "tazminat" olmadığı, dolayısıyla bir zararın giderimi niteliği taşımadığı, gözden kaçırılmamalıdır.

lerini dikkate alarak, sembolik denecek kadar düşük bir miktara hükmetmesi mümkündür.

MK 674/II'deki alacak hakkının doğmasının miras bırakanın bir tasar- 1441
rufuyla önlenemeyeceği kabul edilmektedir.[935] Gerçekten de, mirasbırakanın eğitim ve öğrenim çağındaki çocuklarına ve engelli çocuklarına yasaca tanınmış bir hakkı etkisiz bırakma imkânı olmamalıdır.

Diğer mirasçılar bu alacağa karşı sadece tereden kendilerine düşen pay- 1442
la sorumlu olacaklar ve sorumlulukları müteselsil de olmadığından, miras payları oranında kısmî sorumluluk şeklinde olacaktır.

Buna karşılık, MK 674/II bu hak mirasçılık sıfatına bağlı olduğundan, 1443
mirasbırakandan önce ölen çocukların mirasçıları bu hakkı ileri süremeyeceği gibi; feragat, iskat, mahrumiyet, mirası red gibi bir sebeple mirasçı sıfatını kazanamayan çocuklar da böyle bir hakka sahip olamayacaklardır.

Eğitim ve öğrenimini sürdüren çocuklar olsun engelli çocuklar olsun, 1444
MK 674/II'den doğan alacak haklarını mirasın paylaştırılması tamamlanıncaya kadar ileri sürmelidirler. Fıkra metnindeki "paylaşmada hakkaniyete uygun bir ödeme yapılır" ifadesi bunu açıkça ortaya koymaktadır. İşin niteliği sonucu burada bir zamanaşımı değil hak düşümü bulunduğu kabul edilmelidir. Hak sahipleri bu haklarını ileri sürmeden mirasın paylaşımı tamamlanmışsa, artık hakları son bulmuş olacaktır.[936] Belirtelim ki, paylaşma sırasında diğer mirasçılarca kabul edilmiş alacak, artık bu anlaşmadan doğmuş bir alacak olarak 10 yıllık zamanaşımına tabi olacaktır.

II. ANA BABA İLE VEYA BÜYÜK ANA VE BÜYÜK BABA İLE YAŞAYAN VE EMEĞİNİ VEYA GELİRİNİ AİLEYE ÖZGÜLEMİŞ ERGİN ÇOCUĞUN ALACAK HAKKI.

MK 641/II hükmü ile, ana babası ile veya büyük ana ve büyük babası 1445
ile birlikte yaşayan ve emeğini veya gelirini ailesine özgüleyen (tahsis eden) ergin (reşit) çocuğa, mirasbırakanın ölümü üzerine, paylaştırma sırasında uygun bir tazminat verileceği düzenlenmiştir. Bu madde ile tanınan hakkın amacı şudur.

Ergin olmayan çocuk kendisine karşı velayet ilişkisinden doğan gö- 1446
revlerini yerine getiren ana babasına karşı, kural olarak, istifade ettikleri kazançtan dolayı, onların sağlığında kendilerine veya ölümlerinden sonra mi-

---

[935] *İmre/Erman*, 470

[936] Buna rağmen, mirasın paylaşımından sonra bu çocuklara eğitimlerini sürdürmeleri için kardeşleri veya sağ kalan eş (anneleri veya üvey anneleri) kendi rızaları ile bir kazandırmada bulunursa, bunun BK 78/II uyarınca "ahlâki bir görevin ifası" sayılarak kalıcı kılınması mümkündür.

rasçılarına karşı herhangi bir alacak hakkı kazanmaz (MK 355) Ancak, ergin çocuğun malları ve kazancı üzerinde ana babanın velayet hakkı bulunmadığından, durum değişir. Burada, ana babanın ergin çocuğun emeğinden veya gelirinden yararlanmalarının hukukî sebebini oluşturacak bir kanun hükmü yoktur. Sorun, taraflar arasında bir anlaşma (sözleşme) varsa buna göre çözülecek, şayet böyle bir anlaşma yoksa, ana babanın bu yararlanması bir sebepsiz zenginleşme oluşturacaktır. Ne var ki, sebepsiz zenginleşme hükümleri arasında yer alan BK m. 78 uyarınca, borçlu olmadığı edimi bilerek başkasına kazandıran kişi, artık bunun iadesine yönelik bir talep ileri süremez. Böylece, ana babasının yanında olduğu için hiçbir sözleşmeye dayanmaksızın emeğini veya gelirini onlara kazandıran ergin evlat,"borç olmayan şeyi bilerek ifa ettiği" için onların sağlığında olduğu gibi ölümlerinde de hiçbir hakka sahip olmayacaktır.

1447 Şu halde, Borçlar Hukuku çerçevesinde, ana babası ile yaşayan ergin çocuk şayet bu sırada onlara emeğiyle ve parasıyla yaptığı katkıların tamamen karşılıksız kalmasını istemiyorsa, bu verdikleri karşılığında hangi haklara sahip olacağı, ne alacağı konusunda onlarla anlaşmalıdır. Aynı sonuç, büyük ana ve büyük babası ile birlikte yaşayıp onlara kazandırmada bulunan torunlar içinde geçerlidir. Oysa ki, aile içindeki duygusal ortam, geleneksel saygı kuralları, ergin çocuğun bu şekilde ana babası veya büyük ana ve büyük babası ile karşılık pazarlığı yapmasına, hatta bunu hatırlatmasına bile engel oluşturabilir. Bu tür bir sözleşme ayıp sayılacağından, fiilî bir tek yanlı kazandırma sürer gider. İşte, ana babası ile yaşadığı için onlara emeğiyle veya parasıyla sağladığı ekonomik katkıyı bir sözleşmeye bağlamaya çekinmiş olan çocuğun mağdur olmaması için, kanun bazı hükümler getirmiştir.

1448 Bunlardan biri MK 370 hükmü olup, Ana baba veya büyük ana ve büyük baba ile birlikte yaşayan ve emeklerini ya da gelirlerini aileye özgüleyen ergin altsoyların buna karşılık uygun bir bedel isteyebileceklerini düzenlemiştir[937]. Bu hükümle ana babanın sağlığında çocuğu korumak için getirilmiştir.

1449 Ana babanın ölmesi hâlinde ise, başka bir sorun ortaya çıkar, emeğini ve kazancını ana babasına harcamış çocuk, ana babasından uzakta yaşamış olup onlara ne emek ne de para olarak hiçbir faydası dokunmamış olan kardeşleriyle eşit miras payına sahip olacaktır. İşte bu adaletsiz sonucu hafifletmek ve ana babasına katkıda bulunmuş çocuğu bu aşamada da korumak için, MK 641/II hükmü ona diğer mirasçılara yöneltebileceği özel bir ala-

[937] Bu hükmün karşılığı olan Eski MK 321 ise, sadece ana babanın iflası yahut mallarına haciz konulması halinde çocuklarına iflas masasına veya hacze katılarak ileri sürebileceği bir hak tanımıştı.

cak hakkı tanımıştır. Bu maddeye göre, ana babası ile veya büyük ana veya büyük babası ile[938] birlikte yaşayan ve ivazından açıkça feragat etmeksizin kendi emeğini veya gelirini aileye tahsis etmiş olan reşit evlât paylaştırma sırasında "uygun miktarda tazminat" isteyebilir. Buradaki alacağı tanımlayan "tazminat" ifadesi, yanlış sayılmaz. Zira, hak sahibi, karşılıksız olarak harcadığı emeğin ve paranın kendi malvarlığında yarattığı eksilmeyi, dolaylı olarak bundan yararlanan diğer mirasçılara bir nebze olsun kapattırmak istemektedir. Maddenin kenar başlığının "Mirasçıların sorumluluğu" olması da aynı maksadı işaret etmektedir.

Hükmün uygulanması için Madde metnindeki ifade ana baba ile birlikte yaşama şeklindeyse de, sadece babasıyla veya sadece anasıyla yaşayan ve ona destek olan reşit çocuğun da MK 641/II uyarınca hak sahibi olacağı kabul edilmelidir. Aksine sonuç mantıksız şekilde hükmün uygulama alanını sınırlamak olur. Ancak, sadece üvey babasına (annesinin eşine) veya üvey annesine (babasının eşine) bakan kişi, bu hakka sahip olamaz. 1450

Ana veya babanın ölümü anında desteğin sürüyor olması gerekmez. Yıllar önce (fakat erginken) ana babasına karşılıksız destek olmuş çocuk, öldükleri tarihten yıllar önce destek olmayı bırakmış olsa da[939], ölenin diğer mirasçılarına karşı hakkını ileri sürebilecektir[940]. 1451

Çocuk ana babasına emeğiyle destek olabileceği gibi para veya mal vererek de destek olabilir. Parasal desteğin bir kerelik toplu bir ödeme olması da sürekli gelir sağlama şeklinde olması da mümkündür. Baba ve ananın borçlarını ödeme şeklinde destek de olabilir. Ana babanın bu desteğe ihtiyaçları olması, aksi takdirde işlerinin bozulacak olması şart değildir. Durumları çok iyi olsa, örneğin çocukları onlara emeğini tahsis etmese aynı işi başkasına yaptıracak zenginlikte olsalar bile, fiilen destek olan çocuk MK 641/II uyarınca alacak hakkı kazanır. Yeter ki, harcadığı emek veya tahsis ettiği gelir ana babasını zenginleştirmiş olsun. 1452

Ana babasına veya büyük ana ve büyük babasına emeğini veya gelirini tahsis eden ergin çocuğun onlarla birlikte yaşaması gerekmektedir[941]. İhti- 1453

---

[938] Bu hükmün karşılığı olan Eski MK 610'da büyük ana ve büyük baba ifadeleri yer almamaktaydı. Alacak sadece ana babaya yapılan karşılıksız kazandırmalar için sağlanmış görünmekteydi.

[939] Burada miras hukukundan doğan özel bir alacak hakkı bulunup destekte bulunulan zamana gerçmişe doğru getirilmiş yasal bir sınır olmadığından, mümkün olan en eski destek ve fedâkârlıklar için bile, mirasın paylaşılması sırasında bu hak ileri sürülebilecektir.

[940] *Escher*, Art.633, N.14; *Tuor/Picenoni*, Art. 633, N.17; *Kocayusufpaşaoğlu*, 496; *İmre/Erman*, s.473.

[941] Ana babasının evinin yanında ayrı evde oturan evli çocuğun ev ve mutfak ihtiyaçlarının ana baba tarafından karşılanması hâlinde, MK m.610 uyarınca hak sahibi olabileceği doğrultusunda bir federal Mahkeme kararı için bkz.: BGE 52.II 111

yaçlarını kendisinin karşıladığı ayrı bir evde oturan ergin çocuk, ana babasına veya büyük ana ve büyük babasına emeği veya parasıyla ne denli katkıda bulunursa bulunsun, ölümleri hâlinde MK 641/II uyarınca bir hakka sahip olamaz. Ana baba veya büyük ana ve büyük baba ile aynı yerde oturmaktan maksat, en azından barınma ihtiyacını birlikte karşılamalarıdır. Aynı evde yaşama buna tipik örnek olmakla birlikte, aynı çiftlikte iki ayrı yapıda oturmaları da bu şartı gerçekleştirir. Ana babasının evinde ve belki de onların yemeğine iştirak ederek yaşayan kişiye onlara harcadığı emek ve paranın karşılığını isteme hakkı tanımak, buna karşılık ana babasından uzakta ve hiçbir bakımdan onlardan istifade etmeksizin yaşayan kişiye ise onlara harcadığı emek ve parayı isteme hakkı tanımamak, ilk bakışta adaletsiz gelebilir. Ama unutmamalıdır ki MK 641/II hükmünün amacı, kişinin ana babasına veya büyük ana ve büyük babasına yaptığı kazandırmaların bedelini almasından çok, aslında karşılıksız yapmak istemediği hâlde birlikte yaşadığı için açıkça hakkını arayamadığı kazandırmalar sebebiyle hiç olmazsa onların ölümünde bu hakkını aramasını sağlamaktır[942].

1454 Şayet ergin çocuk birlikte yaşadığı sırada ana babasına veya büyük ana ve büyük babasına harcadığı emek ve yaptığı masraftan dolayı bir karşılık almışsa veya tam tersine bundan dolayı hiçbir şey istemeyeceğini açıkça belirtmişse, artık MK 641/II hükmünden bir hakkı doğmaz. Eski MK 610 hükmünde, ergin mirasçının "ivazından sarahaten feragat etmeksizin" emek veya gelir tahsis etmiş olması şartı açıkça belirtilmişti. Kanımca yeni maddede bunun belirtilmemiş olması esasen olağan bir sonuç sayılmasından kaynaklanmaktadır ve farklı bir düzen getirmek değildir. Diğer deyişle, Yeni Kanuna göre de, açık bir irade beyanı ile ve tamamen özgür bir irade ile harcadığı emek veya masraf karşılığında hiçbir şey talep etmeyeceğini ortaya koyan mirasçının, bu beyanı tereke bakımından da sonuç doğurmalıdır.

1455 Ergin çocuğun hizmet ve masrafının karşılığını hizmet sözleşmesiyle alması mümkündür. Ana baba veya büyük ana ve büyük baba çalışan ergin çocuğa ücret ödemişse durum böyledir. Ana baba veya büyük ana ve büyük baba ücret yerine mal veya karşılık hizmet vermek, bir borcundan kurtarmak gibi yolarla da onun emek ve masrafını karşılamış sayılabilirler. Buna karşılık, ergin çocuğun ana babasına veya büyük ana ve büyük babasına ait evde yatması ve onların aldıkları yiyeceklerle beslenmesi, emeğinin ve

[942] Gene de belirtelim ki, hükmün kapsamının yetersiz olduğu, çekinme, utanma veya çaresizlik sebebiyle değil de sadece ihtiyaçlarını karşılamak ve mutlu olmalarını sağlamak için uzaktaki ana babasına büyük maddi katkılarda bulunan çocukların da ana babalarının ölümleri hâlinde diğer mirasçılara karşı bir alacak hakkına sahip olması gerektiği belirtilmektedir: *Egger*, Art.334, *Escher*, 10

masraflarının karşılığı sayılamaz. Aksi takdirde MK 641/II hükmünün asıl uygulama alanı safdışı edilmiş olur.

Ergin çocuğun harcadığı emek veya yaptığı masrafın karşılığını ana ba- 1456
ba veya büyük ana büyük baba değil de bir üçüncü kişi ödemiş olabilir. Bu takdirde de artık MK 641/II uyarınca tazminat istenemez. Fakat bunun için, ana baba veya büyük ana büyük baba yerine ödeme yapan üçüncü kişiye karşı ergin mirasçının bu sebeple hiçbir borç altına girmemesi gerekir.

Ana babasına tahsis ettiği emek ve gelirinin karşılığı için MK m.321 1457
uyarınca iflas ettikleri için iflas masasına ve aleyhlerine yapılan hacze iştirak eden reşit çocuk da, şayet bu suretle hakkını alabiliyorsa, artık MK 641/II hükmüne başvuramaz[943].

Ergin çocuğun ana babasına veya büyük ana ve büyük babasına sağla- 1458
dığı katkı sebebiyle lehine ölüme bağlı bir tasarruf yapılması, örneğin kendisine belirli mal vasiyet edilmesi durumunda, kanımca bu kazandırma geçerli olduğu ölçüde artık MK 641/II hükmündeki hakkını kullanamamalıdır. Yeter ki ana veya babasının kendisine bu ölüme bağlı kazandırmayı yaşarlarken onlara tahsis ettiği emeği veya geliri sebebiyle yaptıkları anlaşılsın ve bu suretle elde edeceği menfaat katlandığı fedâkârlığı karşılayacak miktarda olsun

Bir başka ele alınması gereken husus MK 641/II hükmünün hizmet söz- 1459
leşmesine ilişkin BK m. 394/II hükmü karşısındaki durumudur. BK m. 394/II uyarınca, açıkça bir hizmet sözleşmesi yapılmamış olsa bile, ancak ücret karşılığı yapılan işlerin belirli bir süre boyunca yapılmasını kabul etme, hizmet sözleşmesinin kurulmuş sayılmasına yol açar. Bu durumda, bir ücret konuşulmamış da olsa, işi gören BK m. 401 uyarınca bu gibi işlerde âdet olan ücreti istemeye hak kazanacaktır. Böylece, ana babasının veya büyük ana ve büyük babasının yanında oturan ergin çocuk, esasen hizmet sözleşmesine konu olacak bazı işleri bir süre boyunca yapmayı üstlenmekle, BK m. 394/II uyarınca örtülü olarak (zımnen) kurulmuş sayılacak hizmet sözleşmesi sebebiyle ücret talep edebilecektir. Henüz ücreti ödenmeden ana veya babası yahut büyük ana veya büyük babası ölürse, bu ücret ödeme borcu küllî halefiyetle ölenin mirasçılarına geçeceğinden, ergin çocuk MK 641/II hükmüne gerek kalmadan sözleşmeden doğan bir ücret talebiyle diğer mirasçılara başvurabilecektir[944].

BK m. 394/II hükmünün uygulama alanı bazı bakımlardan MK 641/II 1460
hükmünden daha geniş, bazı bakımlardan daha dardır. MK 641/II hükmüne

---

[943] *İmre/Erman*, 474

[944] *Tuor/Picenoni*, Art.633,N.15; *Escher*, Art.633, N.4; *Kocayusufpaşaoğlu*, 500 vd.; *Oğuzman*, 332;

göre sadece mirasbırakanın çocukları ve torunları hak sahibi olurken; BK 394/II'ye göre çocuklar ve torunlar dışındaki akrabalar (kardeş, yeğen vb.) da hak sahibi olabileceği gibi hiçbir akrabalık ve miras ilişkisi bulunmayan kişiler de hak sahibi olabilir. Böylece, mirasbırakanın ölümünde bir sebeple mirasçı sıfatını kaybetmiş çocuklar MK 641/II uyarınca bir hak elde edemez iken[945], BK. 394/II hükmüne dayanabilirler. Ayrıca, BK 394/II'deki hakkın ana babanın veya büyük ana ve büyük babanın sağlığında ileri sürülmesi mümkün iken MK 641/II uyarınca bir hakka sahip olmak ancak ana baba veya büyük ana ve büyük baba ölünce mümkündür. Bunlara karşılık, BK 394/II hükmünde sadece emeğini başkasına tahsis edenler hak sahibi olurken, MK 641/II hükmüne göre (emek harcamaksızın) gelirini ana babasına tahsis eden çocuk da hak sahibi olacaktır. Gene, BK m.394/II hükmüne göre ileri sürülecek talep hizmet sözleşmesinden doğan bir ücret alacağı olduğundan, BK m.147/b.1 uyarınca 5 yıllık zamanaşımına tabi olacak ve hak sahibi ancak bu hakkını talep ettiği andan önceki 5 sene içinde yaptığı işlerin karşılığını isteyebilecek (bundan eski hizmetlerinden doğan talebi zamanaşımı defi ile karşılaşacak) iken, MK 641/II çerçevesinde hak sahibi olan çocuk mirasbırakanın ölümünden önceki 5 seneden daha eski hizmetleri için de (geçmişe doğru hiçbir süre kaydı olmaksızın) diğer mirasçılara başvurabilecektir. Bunlara karşılık, BK 394/II uyarınca alacak talebi her zaman ileri sürülebilecek iken, MK 641/II uyarınca alacak talebi terekenin borç ödemeden dolayı acze düşmemesi şartıyla ileri sürülebilir.

1461 Hem MK 641/II hem de BK m.394/II hükmünün şartlarını gerçekleştiren bir durumda hak sahibinin bu iki hükümden dilediğine dayanma hakkına sahip olup olmayacağı tartışmalıdır. Bir görüşe göre, bu iki hüküm yarışmaz, ergin çocuğun BK m.394/II hükmüne göre ücret isteme hakkı doğmuşsa artık MK 641/II hükmüne dayanamaz[946]. Zira o geçerli bir hizmet sözleşmesi ile emeğinin karşılığı olarak ücret alacağı kazanmıştır, oysa ki MK 641/II hükmü sarfettiği emeğin (ve gelirin) karşılığını başka bir hukukî sebeple talep hakkına sahip olamayanlar için getirilmiştir. Bir diğer görüş ise, bu iki hükmün biri borçlar hukuku diğerinin ise miras hukuku çerçevesinde iki ayrı imkân getirdiği ve ana babasına veya büyük ana ve büyük babasına emeğini tahsis eden çocuğun her iki hükümden de yararlanabileceği şeklindedir[947]. Belirtelim ki, birinci görüş hukuk tekniği bakımından daha makul görünmekle birlikte, emek tahsisi dolayısıyla MK 641/II hükmünün şartlarının gerçekleştiği hemen her durumda BK m.394/II'nin de şartları

---

[945] Ancak, birazdan belirteceğimiz üzere bu nokta tartışmalıdır.

[946] *Escher*, Art.633, N.3; BGE 90 II 446

[947] *Kocayusufpaşaoğlu*, 508 vd. (yazar burada yarışan talep haklarından çok iki ayrı hukukî dayanağı olan tek bir talep hakkından sözetmektedir); *Oğuzman*, 332

gerçekleşmiş olacağından[948], MK 641/II'nin uygulama alanını neredeyse tamamen gelir tahsisi durumuyla sınırlayacaktır.

MK 641/II hükmündeki alacak hakkının niteliği konusunda da tartışma vardır. Bir görüşe göre buradaki alacak miras hukukuna ilişkin bir taleptir ve bu bakımdan ergin evladın bu hakka sahip olması için ana veya babasının ölümü anında mirasçılık sıfatını kazanması gerekir[949]. Şayet ergin çocuk feragat, mirastan yoksunluk, mirastan çıkarılma, ret, gibi bir sebeple mirasçı olamamışsa, MK 641/II uyarınca da bir hakka sahip olamayacaktır. Buna karşılık, bir diğer görüşe göre, buradaki hak miras hukuku hükümleri arasında tanınmış olsa da Borçlar Hukukundan doğan bir haktır. Böylece, ergin çocuk herhangi bir sebeple mirasçılık sıfatını kaybetmiş olsa da bu hakka sahip olacaktır[950]. İki görüşü farklı şekilde uzlaştırmaya çalışan yazarlar da vardır[951]. Kanımızca, özellikle yukarıda açıkladığımız üzere BK m. 394/II'nin varlığı karşısında, MK 641/II hükmünün bir miras hukuku hakkı olduğu ve ancak mirasçı sıfatına sahip olanlarca kullanılabileceği görüşü benimsenmelidir. 1462

MK 641 hükmündeki alacak hakkı mirasbırakanın sağlararası tek yanlı bir beyanı veya ölüme bağlı bir tasarrufuyla etkisizleştirilemez. Ancak, yukarıda belirttiğimiz üzere, mirasbırakan ergin çocuğun harcadığı emek ve yaptığı masraf karşılığı olarak ona belirli mal vasiyetinde bulunarak bu tazminat hakkını kullanmasını önleyebilir. 1463

MK 641/I hükmünün mirasçıları tereke borçlarından sorumlu tutmasının altında MK 641/II ile ergin çocuğun hakkı düzenlendiğinden, mirasçıların bu tazminatı ödemekte müteselsilen sorumlu oldukları anlaşılmaktadır. Esasen bu yeni maddenin gerekçesinde de bu husus belirtilmiştir. Oysa, Eski MK 610 hükmünün yeri bakımından, ergin çocuğun talebi karşısında diğer mirasçılar tereke değeriyle sınırlı olarak ve her biri miras payı oranında sorumluluğu paylaşarak borçlu oldukları kabul edilmekteydi. 1464

MK 641 hükmünde ergin evlat veya torunun alacak hakkına Eski MK 610 hükmünde bulunmayan bir sınır getirilmiştir. Buna göre, hükmedilecek alacak, terekeden ödendiği takdirde terekeyi borç ödemekten acze düşür- 1465

---

[948] *Kocayusufpaşaoğlu*, 500, 501; *Oğuzman*, 332

[949] *Escher*, Art.633, N.21 vd.; *Vonrufs*, Die Ausgleichung der Erbennach dem Scheiweizerischen ZGB, Zürich 1910, 54; *Scwendener*, Die Ausgleichungspflicht der Nachkommen unter sich und in Konkurrenz mit dem überlebenden Ehegatten, Diss Zürich 1959, 68; *İmre/Erman*, 472; BGE 79 II 369

[950] *Piotet*, SJZ 59 (1963), 247; *Edis*, Birlikte Yaşadığı Ailesine Emeğini veya Gelirlerini Tahsis Eden Reşit Çocuğun Tazminat Alacağı, AÜHFD 1964, C.21, 375-412

[951] *Kocayusufpaşaoğlu*, 508 vd. Yazar burada iki ayrı hukukî sebebe dayanan tek talep bulunduğu görüşündedir.

meyecek derecede olmalıdır. Bu hükmün anlamı şudur: Emek ve masraftan dolayı alacaklı olan mirasçıya ödenecek miktar konusunda taraflar anlaşamayıp hakim bunu belirleyecekse, bu alacak terekeden çıkartıldıktan sonra kalan tereke değeri, mirasbırakandan intikal eden veya terekede doğan tüm tereke borçlarını karşılayabilmelidir. Sadece bir tereke borcu kısmen dahî karşılanamayacak ise, hakim bu miktarda tazminata hükmetmeyecektir. Acaba mirasbırakanın vasiyet alacaklılarının alacaklarının da tam olarak karşılanması aranacak mıdır? Bu husus tartışma götürürse de, kanımca, bir vasiyet alacaklısı bu yüzden alacağını tam tahsil edemeyecek olsa bile, ergin evlat veya torunun karşılıksız harcadığı emek ve paralar için gene de tazminat isteyebilmesi gerekir.

1466 Kanımca MK 641/II hükmünün kanundaki yerinden de anlaşıldığı üzere, tıpkı eski MK zamanında olduğu gibi, ergin evlat bu hakkını mirasın paylaşılması sırasında ileri sürmelidir. Paylaşma tamamlandıktan sonra bu hak ileri sürülememelidir. Paylaşmadan sonra, şayet şartları gerçekleşmişse, BK m. 394/II uyarınca sahip olunan hak ileri sürülebilir. Bununla birlikte, mirasın paylaşılması aşamasında kabul edilen ergin çocuğun alacak hakkı, 10 yıllık zamanaşımına tabi olur[952].

[952] *Oğuzman*, 332; *İmre/Erman*, 476; Buna karşılık, Kocayusufpaşaoğlu'ya göre (s. 512, 513, 514), MK 641/II (Eski MK 610) hükmündeki alacak hakkının muaccel olduğu tarih, mirasın açıldığı tarihtir.

DÖRDÜNCÜ KISIM

MİRASIN GEÇMESİ (İNTİKALİ)

Medeni Kanunumuzun Miras Hukuku Kitabı "Mirasçılar" adlı birinci kısmında kimlerin ne ölçüde mirasçı olacağını, ölüme bağlı tasarrufları, vasiyeti yerine getirme görevlisini, ölüme bağlı tasarrufların iptalini ve tenkisi düzenledikten sonra; "Mirasın Geçmesi" adlı ikinci kısımda (MK 575-682), mirasın mirasçıya geçmesini miras bırakanın ölümünden mirasın paylaşılmasının tamamlanmasına kadar şu üç ana başlık altında düzenlemiştir: "Mirasın Açılması" (birinci bölüm 575-588), "Mirasın Geçmesinin Sonuçları" (:ikinci bölüm 589-639) ve "Mirasın Paylaşılması" (üçüncü bölüm 640-682)[953]. 1467

İkinci kısmın ilk bölümü olan mirasın açılması, mirasbırakanın ölüm anında ortaya çıkan hukukî durumu, mirasçı olma ehliyetini açıklamaktadır. Buradaki "açılma" sözü anlam bakımında isabetli değildir. İkinci bölümü oluşturan mirasın geçmesinin sonuçları, isabetli bir adlandırmadır. Burada mirasın geçmesi sebebiyle alınacak koruma önlemleri (ihtiyatî tedbirler), mirası iktisabın sonuçları ve yolları ile mirasçılıktan kaynaklanan özel bir dava olan miras sebebiyle istihkak davası düzenlenmiştir. Nihayet üçüncü ve son bölüm olan mirasın paylaşılması (taksimi) adı da içeriğine uygun olup, birden fazla mirasçı bulunan durumlarda terekenin bu mirasçılar arasında pay edilmesini ve buna bağlı kavram ve kurumları düzenlemektedir. 1468

§ 26. Mirasın Açılmasının Şartları

I. MİRASIN AÇILMASINDA ÖNEM TAŞIYAN AN VE YER.

Medeni kanunumuz mirasın geçmesini ve buna bağlı olan hukukî sonuçlara ilişkin hükümlerini "mirasın açılması" olarak adlandırmış olup, miras hukuku kitaplarında da alışılagelmiş bu kavrama uyulduğu görülmektedir. Oysa ki kelime olarak bu deyiş yanıltıcı olabilir. Türk ve İsviçre Hukuklarında mirasın geçmesi yani mirasbırakanın malvarlığının mirasçılara intikali, ölüme bağlı tasarruflarının yürürlüğe girmesi, miras olgusuna bağlı hakların ve yükümlülüklerin doğması, mirasbırakanın ölümü anında ve 1469

[953] Eski Medeni Kanunumuzda bu kısım, bölüm ve ayırımların çoğunun isabetsiz başlıklarla ifade edildiği hakkında bkz. *Dural/Öz*, a.g.e., 1.bası, 353

hiçbir işleme, irade beyanına, başvuruya gerek olmaksızın gerçekleşmektedir. Kanunun mirasın açılması olarak adlandırdığı olgu da budur. Ortada önceden kapalı veya atıl durumda iken şimdi üzerindeki kayıt ve yasaklar kalkan veya kaldırılan bir şey yoktur. Bu bakımdan, mirasın açılmasına nispeten "geçmesi", hukukî olayı daha isabetli şekilde yansıtmakla birlikte; az önce belirttiğimiz üzere, burada sadece mirasbırakanın malvarlığının mirasçılarına geçmesi(intikali) değil, miras hukukuna ilişkin başka bazı yan sonuçlarında doğması da ifade edildiğinden, alışılagelmiş "açılma" tabiri – anlamını bilerek- muhafaza edilebilir. Burada kastedilen, Medeni Kanunun miras hukukuna ilişkin hükümlerinin uygulanmaya başlama noktasıdır.

1470 Mirasın geçmesi bakımından ilk hükümler olan MK 575-576 daha sonra gelen hükümlerin uygulanması bakımından büyük önem taşımak üzere, belli bir anı ve belli bir yeri referans noktası olarak düzenlemiştir. Bunlara, mirasın açılma anı ve mirasın açıldığı yer denmektedir.

1. Mirasın Açıldığı An.

1471 MK 575 hükmünün ilk cümlesi, "Miras ölümle açılır" demekte; aynı maddenin 2. cümlesi ise, mirasbırakanın sağlararası kazandırmalarının mirasın geçmesi ile ilgili kurallara tabi olmaları hâlinde terekenin ölüm anındaki hâline göre değerlendirileceğini yazmaktadır.

1472 Maddenin miras ölüm ile açılır şeklindeki ifadesi, mirasbırakanın ölümü anında kendiliğinden miras konusu malvarlığının mirasçılara geçtiği ve miras hukukunun bu durum için getirdiği hükümlerin uygulamaya girdiği anlamına gelmektedir. Mirasbırakan öldüğü anda, bu ölüm sonradan tespit edilse ve mirasçıların ölümden daha sonra haberleri olsa bile, miras onlara geçer ve miras hukukunun mirasbırakanın ölümüne bağladığı diğer tüm hukukî sonuçlar kendiliğinden doğar (ölüme bağlı tasarruflar hüküm ifade eder, tenkis ve denkleştirme isteme hakları doğar vb.).

1473 Hukukî olarak ölüm anı gerçek kişilerde kişiliğin sona ermesi olarak kişiler hukukunun konusudur. Burada sadece şu kadarını hatırlatalım ki, bugün hâlen kabul gören anlayış, kişinin beyin fonksiyonlarının geri dönüşsüz şekilde kaybolması ile kalbinin durmasının (kan dolaşımının durmasının) birlikte gerçekleştiği anı ölüm anı olarak kabul etmektedir[954]. Ölüm anından önce miras hukukundan kaynaklanan hiçbir hak ileri sürülemeyeceği gibi; ne denli kesin bir tehlike veya ihtiyaç olursa olsun, ölüm üzerine miras hukuku sebebiyle doğacak hakların korunması için de ölümden önce bir talep ileri sürülemez, tedbir veya tespit için mahkemeye başvurulamaz.

---

[954] *Dural*, Türk Medeni Hukukunda Gerçek Kişiler, İstanbul 1987, 25; *Zevkliler*, Medeni Hukuk, Giriş, Başlangıç Hükümleri, Kişiler Hukuku, Aile Hukuku, 6.Baskı, Ankara 199, 558; *Oğuzman/Seliçi/Oktay*, Kişiler Hukuku, Kişiler Hukuku, 7.Baskı, 16,17

Ölümün gerçekleştiği an ise, ölenin kayıtlı olduğu nüfus siciline öldüğü 1474
kaydı düşülmeden veya başka bir suretle (hastane veya polis raporu) bu ölüm olayı belgelenmeden, miras geçer/açılır. Diğer tüm kayıtlar ve raporlar, ancak ölümün ne zaman gerçekleştiği hususunda delil niteliği taşıyabilir.

MK 29/I uyarınca, bir kimsenin ölümüne bağlı olarak bir hak iddia 1475
eden, bu ölümü ispat etmek zorunda olduğu gibi, ileri sürdüğü hakkın varlığı ölümün belli bir zamanda gerçekleşmesine veya ölüm gerçekleştiği anda bir başka kişinin sağ olmasına bağlı ise, bu hususların da gerçekleştiğini ispatla yükümlüdür.

Ölüm MK 30 uyarınca önce resmî nüfus kayıtları ile ispatlanır nüfusta 1476
öldüğü belirtilmiş bir kişinin ölümünü ve böylece mirasın açıldığını ispata gerek yoktur. Ancak, henüz nüfusta öldüğü kaydedilmemiş kişinin de ölümü ispatlanabilirse de ispat yükü bunu iddia edene aittir. Ölümüne kesin gözüyle bakılacak durumda kaybolan fakat cesedi bulunamayanlar (havada infilak eden uçağın yolcuları gibi), MK 44'de düzenlenen "ölüm karinesi" uyarınca mülkî amirin beyanıyla nüfus kaydında ölü olarak belirtilecektir. Gerek böyle bir durumda gerekse doğal ölümlerde mirasın açıldığı an, nüfus kütüğüne ölü kaydının işlendiği an değil, gerçek ölüm anıdır.

Ölüm anını saniyesi saniyesine bilmek miras hukukunda bazen çok 1477
önemlidir ve büyük çıkar kaybına veya kazanca sebep olur. Örneğin: karı koca olan bay (A) ve bayan (B) bir araba kazasında aynı arabanın içinde ölmüşlerdir. (A)'nın annesi (C)) ve (B)'nin de önceki evliliğinden oğlu (K) hayattadır. Şayet önce (A) ve ondan bir dakika sonra (B) ölse, (A)nın mirasının yarısı annesi (C)'ye ve yarısı eşi (B)'ye gitmiş olacak, (B)'nin ölümü ile de hem (A)'dan gelen hem de zaten sahip olduğu mal varlığı oğlu (K)'ya geçecektir. Oysa, önce (B) ve ondan bir dakika sonra (A) ölse, (B)'nin malvarlığının 3/4'ü oğlu (K)'ya ve 1/4'ü eşi (A) gidecek ve (A)'nın ölümü ile de gerek (B)'den gelen kısım gerekse zaten mevcut malvarlığı (C)'ye gidecektir. Şayet (A) ve (B)'nin hangisinin önce öldüğü tespit edilemezse, MK 29/II hükmündeki "birlikte ölüm karinesi" uyarınca bunlar birbirine mirasçı olamayacaklar ve (A)'nın malvarlığı olduğu gibi (C)'ye, (B)'nin malvarlığı olduğu gibi (K)'ya gidecektir.

Bir diğer örnek: Bay (A) ile evlenen bayan (B) 5 aylık hamile olduğu 1478
sırada boşanmıştır. Çok zengin bir kişi olan bay (A), boşandıktan 2 ay sonra bir uçak kazasında ölmüş olup, geriye kardeşi (K)'yı bırakmıştır. Bunun üzerinden 2 ay daha geçtikten sonra bayan (B) bir hastanede çocuğu (Ç)yi doğurur iken, şayet (Ç) anasının karnından ayrıldığı anda bir iki saniye yaşayıp ölse, o sırada birinci zümre mirasçısı olarak babası (A)'nın tüm servetine ana rahmine düştüğü andan itibaren (MK 28) sahip olacak ve öldüğü

anda da sahip olduğu bu serveti anası (B)'ye geçirmiş olacaktır. Burada (K)'nın alacağı bir şey yoktur (mirasçı olamaz). Oysa (Ç) ölü doğmuş olsa, (B)'nin tüm serveti kardeşi (K)'ya kalacaktır.

1479 Ölüm anı sadece ölenin terekesindeki malların mirasçılara geçtiği an olarak değil, miras hukukunun başka bazı hükümlerinin uygulanması bakımından da önem taşır. Daha önce açıkladığımız üzere, MK 507/I uyarınca tenkis davası bakımından tasarruf oranının hesaplanması için terekeye eklenecek ve çıkarılacak şeylerin değerleri ölüm anına göre dikkate alınacağı gibi; MK 575, ölüme bağlı olmayan (sağlararası) kazandırmalar bakımından mirasın açıldığı günün yani mirasbırakanın ölüm anının esas alınacağını ve mirasın paylaştırılmasında da aynı günün esas alınacağını, ayrıca düzenlemiştir[955].

1480 Gaiplik hâlinde mirasın geçmesinde ölüme göre bazı özellikler vardır. Gaipliğe ilişkin genel hükümler kişiler hukukunun konusu olmakla birlikte şu kadarını belirtelim ki, gaiplik kararı verilmeden önce miras hukukuna ilişkin bir sonuç doğmazsa da mahkemenin gaipliğe hükmetmesi geriye etkili olup, ölüm –gaipliğin türüne göre- gaibin ölüm tehlikesi içinde kaybolduğu gün veya gaipten son haberin alındığı gün gerçekleşmiş gibi gaibin mirası açılır (MK 35). Mirasın açılması dışında, gaibin ölümüne bağlı hakların intikali bakımından gaiplik ile ölüm arasında bazı farklar vardır. MK 584-588 hükümlerinde düzenlenen gaipliğe mahsus bu farklılıkları ileride inceleyeceğiz[956].

2. Mirasın Açıldığı Yer (Mirasa İlişkin Konularda Yetkili Mahkeme)

1481 MK 576/I hükmü, ".Açılma Yeri ve Yetkili Mahkeme." Adı taşımakta olup, madde metninde "Miras, malvarlığının tamamı için mirasbırakanın yerleşim yerinde açılır" demekte; 576/II hükmü ise, "Mirasbırakanın tasarruflarının iptali veya tenkisi, mirasın paylaştırılması ve miras sebebiyle istihkak davaları bu yerleşim yeri mahkemesinde görülür." denmektedir.

1482 Bu ifadelerden hareketle, mirasın açıldığı yer/mirasın geçtiği yer ifadesi öğreti ve uygulamaya yerleşmişse de sözkonusu ifade yanıltıcıdır. Bir kere mirasbırakanın malvarlığının ölüm olayıyla ve külli halefiyet yoluyla mirasçılarına geçmesinin yeri olmaz. Terekede yer alan malvarlığı değerleri

---

[955] Fakat denkleştirme bakımından, MK 673 uyarınca, denkleştirilecek kazandırmaların denkleştirme anındaki değerleri esas alınacaktır. Oysa Eski MK 517/I metnindeki "taksimler" ifadesinin denkleştirmeye/iadeye tabi kazandırmaları ifade ettiği, böylece bunlar bakımından da ölüm anının esas alınacağı kabul edilmekteydi. bkz. *Escher*, Art.537, N.4; *Tuor/Picenoni*, Art.537, N.7; *Kocayusufpaşaoğlu*, 520.

[956] Bkz. § 28.

mirasbırakanın öldüğü anda nerede ise orada mirasçılara geçmiştir[957]. Örneğin, mirasbırakanın Ankara'daki evi Ankara'da, İstanbul'daki hisse senetleri İstanbul'da, Londra'daki mücevherleri Londra'da, o anda sahip değiştirmiştir. Öte yandan, mirasın açılmasıyla doğacak hakların da doğdukları yer diye bir şey olmaz. Ölüme bağlı tasarruf lehdarlarının (örneğin vasiyet alacaklısının) bu tasarruflardan doğan hakları; mirasçıların tenkis, denkleştirme veya miras sebebiyle istihkak davası açma hakları, belli bir yere bağımlı olmaksızın doğmuştur.

Şu hâlde, yukarıda yansıttığımız MK 576 hükmünün II. fıkrasından anlaşılacağı üzere, kanunun mirasın açılması (geçmesi) yeri ile kastettiği, gerçekten miras hukukuna göre sonuçların doğduğu yer değil, miras sebebiyle sahip olunan hakların ileri sürülmesi için ve çıkacak uyuşmazlıkların çözülmesi için açılacak davaların yeridir. Bu bakımdan biz, öğretinin[958] tersine, Eski MK 518/c.1 metninde İsviçre Medeni Kanununun (ZGB) 538. maddesindeki gibi mirasın "mirasbırakanın son ikâmetgâhında" açılacağından sözedilmekle yetinilmeyip mirasın "müteveffanın son ikâmetgâhı mahkemesinde." açılacağının düzenlenmiş olmasını –en azından İsviçre metnine göre- isabetsiz bulduğumuz gibi; Yeni MK 576/I metnindeki "Miras ..... mirasbırakanın yerleşim yerinde açılır." ifadesini de yanıltıcı buluyoruz. 1483

Mirasbırakan son yerleşim yerinden başka bir yerde, örneğin bir gezide, bir misafirlikte, tatilde ölmüş olabilir. Bu durumlarda da miras hukukuna ilişkin davalar bakımından yetkili mahkeme, öldüğü yer mâhkemesi değil, son yerleşim yeri mahkemesi olacaktır. MK 589/IV uyarınca, böyle bir durumda, mirasbırakanın öldüğü yerin sulh hakimi mirasbırakanın yerleşim yeri sulh hâkimine durumu bildirmek ve kendi bölgesindeki tereke mallarının korunması için gereken tedbirleri almakla yükümlüdür. 1484

Mirasbırakanın son yerleşim yeri mahkemesinde, MK 576/II'de belirtilen iptal, tenkis, mirasın paylaşılması (bu arada denkleştirme) ve miras sebebiyle istihkak davalarının açılmasının dışında; mirasın reddi (MK 609) ve ihtiyati tedbirler (MK 589 vd.) bakımından da bu mahkeme yetkilidir. 1485

Ayrıca, HMK m.11/a uyarınca, paylaşmanın butlan ve feshine (iptaline olacak) dair davalar ile mirasçılar arasında terekenin yönetimi sebebiyle çıkacak ihtilaflara ilişkin davalar, ayrıca, terekenin kesin olarak paylaşılmasına kadar tereke aleyhine açılacak davalar bakımından da mirasbırakanın son yerleşim yeri mahkemesi yetkili olacaktır[959]. 1486

---

[957] Buna rağmen yazarların, "intikal son ikâmetgâhta vuku bulur." Şeklindeki ifadeleri isabetli değildir. Bkz. *Oğuzman*, 261; *Kocayusufpaşaoğlu*, 521;

[958] *Kocayusufpaşaoğlu*, 520; *Oğuzman*, 261; *İmre/Erman*, 259

[959] Ancak, gene aynı madde de, üçüncü kişinin terekedeki bir mal için açacağı istihkak dava-

1487 Vasiyet alacaklısı tarafından vasiyet borçlusu mirasçılara karşı açılacak davanın da mirasbırakanın son yerleşim yeri mahkemesinde açılması gerekip gerekmediği tartışmalı olmakla birlikte, bize göre de en isabetli sonuç, şayet dava tüm mirasçılara karşı açılıyorsa mirasbırakanın son yerleşim yerinde fakat sadece bazı mirasçılara karşı açılıyorsa davalının ikâmetgahında açılmasıdır[960].

1488 Görev bakımından ise, MK 589, 609, 620 ve 634 hükümleri ile HUMK 561 hükümlerinde bu maddeler çerçevesine giren davaların sulh hukuk mahkemelerinde açılacağı belirtilmiştir. Bu maddelerin düzenlemediği davaların sulh hukuk mahkemelerinde mi yoksa asliye hukuk mahkemelerinde mi açılacağı tartışmalıdır. Bir görüşe göre Medeni Kanunda aksine açık hüküm bulunmayan tüm durumlarda asliye hukuk mahkemeleri yetkili sayılırken[961], bir başka görüşe göre, görevli mahkeme HUMK 8'deki prensiplere göre belirlenmelidir[962].

II. MİRASÇI VE VASİYET ALACAKLISI OLMANIN YASAL ŞARTLARI

1489 Bir kimsenin mirasbırakan dediğimiz kişinin ölümü ile onun mirasçısı veya vasiyet alacaklısı olması için sadece daha önce belirttiğimiz derecede yakını veya eşi olması, yahut lehine ölüme bağlı kazandırma yapılmış bulunması yetmez. Ayrıca, mirasbırakanın ölümü anında mirasçı olacak kimsenin yasaca aranan bazı özelliklere sahip olması gerekir. Bunlar, özellikle MK 577-583 hükümleri arasında düzenlenmiş olup, üç grup hâlinde toplanabilir. Bu üç şartın ilk ikisi olumlu, üçüncüsü olumsuz şarttır.

1490 İlk olarak, mirasbırakanın ölümü anında mirasçı veya vasiyet alacaklısı sağ olmalıdır.

1491 İkinci olarak, mirasçı veya vasiyet alacaklısı olacak kişi hak ehliyetine sahip bulunmalıdır. Miras hukuku bakımından buna mirasçılık ehliyeti denmektedir.

1492 Üçüncü olarak, mirasçı veya vasiyet alacaklısı, mirastan yoksunluk sebeplerinden biriyle bu sıfatını kaybetmiş olmamalıdır[963].

---

sının terekenin yazımı ve tespiti zamanında bulunduğu yer mahkemesinde ve bir kimsenin mirasçılığının tespitine ve miras hissesinin belirlenmesine dair davaların (uygulamadaki adıyla, veraset ilamı almak için açılan davaların) mirasçıların her birinin bulunduğu yer mahkemesinde de açılabileceği düzenlenmiştir. Böylece, bu bakımlardan seçimlik bir yetki sözkonusudur.

[960] Bu tartışma hakkında ve belirttiğimiz görüş doğrultusunda bak. *Tuor/Picenoni*, Art.538, N.17; *Kocayusufpaşaoğlu*, 523.

[961] *Saymen*, Miras Hukuku Dersleri, İstanbul 1958, 299

[962] *İnan*, Miras Hukuku, Ankara 1969, 284.

[963] Burada ayrıca mirastan çıkarılma ve mirastan feragat sebebiyle mirasçı olamama yer al-

Şimdi bu şartları ayrı ayrı ele alalım. 1493

1. Sağ Olmak.

MK 580/I uyarınca, Mirasçı olabilmek için mirasbırakanın ölümünde 1494
mirasçılığa ehil olarak sağ olmak lazımdır. Buna göre, mirasbırakanın ölümünden önce veya onunla aynı anda ölen kişiler, yasal veya atanmış (mansup) mirasçı konumunda olsalar bile, ölenin mirasçısı olamazlar. MK 581 aynı kuralı vasiyet alacaklıları bakımından tekrar etmiştir. Buna göre, vasiyetname ile alacak hakkı kazanacak kişi mirasbırakanın ölümünde hayatta değilse, bizzat vasiyette başka bir çözüm belirtilmedikçe, bu tasarruf yürürlüğe girmeyecektir.

Mirasçılık sıfatının mirasbırakanın ölümü anında hayatta olmaya bağ- 1495
lanmasının sebebi, bu sıfatın ölümden önceye etkili olarak kazanılamamasıdır. Miras hukukuna göre mirasın açıldığı sırada hayatta olmayan kişi, MK 28 uyarınca kişiliği sona erdiğinden, hiçbir hak sahibi olamayacağından, miras hukukundan doğan bir hakka da sahip olamaz[964]. Böylece, mirasbırakandan önce ölen kişi, yaşasaydı mirasçı olacağından bahisle, bu sıfatının sonuçlarını kendi mirasçılarına devretmiş de sayılamaz. Bir diğer deyişle, mirasçılık sıfatına mirasçılık olmaz. Ancak bu durumu, kanunun her zümrede mirasbırakandan önce ölenlerin altsoyları ile temsil edilmesi kuralı ile karıştırmamalıdır. Orada daha önce ölenin sahip olduğu bir miras hakkı altsoyuna geçmemekte, yasa gereği mirasçı olamayan bu kişi yerine altsoyu mirasçı olmaktadır (Mirasbırakanın kendisinden önce ölen oğlunun yerine ondan olma torununun mirasçı olması gibi). Buna karşılık, kanunun böyle bir "yerine geçme"yi düzenlemediği hâllerde, mirasbırakandan önce ölen miras payını alamamakla kalır ve kendi mirasçıları bundan yararlanmaz. Zira, kendi sahip olmadığı bir hakkı başkasına geçiremez. Örneğin, (M)'nin iki oğlundan (A) kendisinden önce ve çocuksuz ölmüş olup (M)'nin ölümünde diğer oğlu (B) yaşamaktadır. Bu durumda, ölü (A) (M)'nin mirasçısı sıfatını kazanamadığından, (A)'nın eşi (E) kocasının mirasçısı olmasına rağmen kayınpederi (M)'nin mirasına ilişkin olarak hiçbir hak ileri süremeyecek ve (M)'nin terekesi tamamen (B)'ye kalacaktır. Bir diğer örnek: (Ç) önce annesi (A)'yı daha sonra babası olmamakla birlikte

---

mamaktadır. Zira bu durumlar, yasa gereği (yasanın aradığı şartlar bulunmadığından) ölüm anında mirasçı sıfatını kazanamama hâlleri değil, mirasbırakanın sağlığında yapılan bazı hukukî işlemler sonucu bu hakkın kaybedilmesidir. Keza mirasın reddi de mirasın açılmasından sonra yapılan bir hukukî işlemle hak kaybını sağladığından, bu çerçeveye girmez. Bütün bu bahisler, mirasçı olmanın yasal şartları arasında değil, ait oldukları bahislerde incelenmiştir.

[964] Bu açıdan, mirasbırakanın ve mirasçısı olan kişinin ölüm anlarının saptanmasının bazen ne kadar önemli olduğuna örneklerle değinmiştik bkz § 26 I, 1

annesinin eşi (üvey babası) olan (B)'yi kaybetmiştir. (Ç), şayet annesi (A) yaşasaydı (B)'ye mirasçı olacağından sözederek (B)'nin mirasında hak iddia edemez.

1496 Aynı sonuçlar mirasçı atananlar ve vasiyet alacaklıları bakımından da geçerlidir. Mirasbırakandan önce ölen kişi kendisi lehine yapılmış bulunan belirli mal vasiyeti veya mirasçı atanması uyarınca bir hakka sahip olamayacağı için, onun mirasçıları da bu etkisiz vasiyet veya mirasçı atama sebebiyle bir hakka sahip olmazlar. Şayet mirasçı atanan kişinin veya vasiyet alacaklısının daha önce ölmesi hâli öngörülmüş ve bu durumda kimin hak sahibi olacağı belirlenmiş ise, bu durumda esasen bu kişiler lehine yapılmış şarta bağlı bir tasarruf vardır[965]. MK 581/II vasiyet alacaklısının daha önce ölmesi hâlinde vasiyeti yerine getirme yükümlülüğünün vasiyet yükümlüsü yararına ortadan kalkacağını düzenlemiştir[966].

1497 Mirasbırakandan önce ölmek mutlak suretle yasal mirasçı veya vasiyet alacaklısı olamamayı ifade ederse de, mirasbırakanın öldüğü anda "henüz doğmamış olmak" aynı şekilde mutlak suretle mirasçı veya vasiyet alacaklısı olamama anlamına gelmez. Bazı durumlarda henüz doğmamış kişiler mirasçı veya vasiyet alacaklısı sıfatını kazanabilir. Buna tipik örnek, mirasçılar arasında bir ceninin (dölütün) bulunmasıdır. Örneğin, mirasbırakanın ölümü anında henüz doğmamış fakat ana karnında bir çocuğu varsa, MK 582 hükmüne göre sağ doğmak şartıyla mirasçı sıfatını kazanacaktır. Bu hüküm, MK 28/II uyarınca sağ ve tam olarak doğumun ana rahmine düşme anından itibaren kişilik kazandırmasının bir sonucudur. Bu durumda cenin sağ olarak doğup doğmayacağı anlaşılana kadar bir belirsizlik durumu olacaktır. İlerde açıklayacağımız üzere, mirasçılar arasında cenin bulunması, mirasın paylaştırılmasında bir bekleme sebebidir.

1498 Kanunumuz hatta henüz cenin olarak dahî varolmayan kişilerin, ileride dünyaya gelme ihtimali bulunması şartıyla, mirasçı atanmasına veya vasiyet alacaklısı olarak tayinine izin vermiştir. MK 583/I hükmünde düzenlenen bu durum, bu hükümde açıkça belirtildiği üzere, diğer bütün mirasçıların ön mirasçı ve diğer vasiyet alacaklılarının ön vasiyet alacaklısı sayılacakları bir "artmirasçı atama" (fevkalade ikame) veya "art vasiyet alacaklısı belirleme" oluşturacaktır. Artmirasçı atama kurumunu (MK 521-525) daha önce açıklamış bulunuyoruz[967]. Kanımızca aynı hükümlere göre, ileride ku-

[965] Mirasçı atanması bakımından yedek mirasçı atama (alelade ikame) olarak adlandırılan bu durum hakkında bkz. § 16 III 6 b

[966] Bu maddenin karşılığı olan Eski MK 523 hükmünde bu sonuç açıkça belirtilmemiş olmasına rağmen, öğreti tarafından benimsenmekte idi. Bkz. *Kocayusufpaşaoğlu*, 528; *Oğuzman*, 263

[967] Bkz. § 16 III 6 c

rulacak bir tüzel kişinin de mirasçı olarak atanması veya lehine vasiyet yapılması mümkündür.

Mirasçının veya vasiyet alacaklısının mirasbırakandan sonra ölümü 1499
onun mirasçılık sıfatını ve vasiyetten doğan alacağını etkilemez. Bu hükümlere göre doğan hakları küllî halefiyetle kendi mirasçılarına geçer. İsterse bu mirasçıları kendi mirasbırakanının mirasçıları olmasın. Örneğin, Babası (A)'nın ölümünden on dakika sonra ölen oğul (B) geriye eşi (E)'yi bırakmışsa, (E) (A)'nın mirasçısı olmamasına rağmen, (A)'nın ölümü anında (B)'ye intikal eden haklar (B)'nin terekesine girerek (E)'ye geçecektir.

2. Ehil Olmak.

Mirasçı olma ehliyeti hak ehliyetinin miras hukuku bakımından görü- 1500
nümüdür. MK 580/I mirasçı olmanın bu şartını belirtmiş olup MK 581/I vasiyet alacaklısı olmak bakımından da aynı ehliyetin aranacağını düzenlemiştir.

MK 8 uyarınca her insan yaşadığı sürece hak ehliyetine sahip olacağın- 1501
dan, mirasbırakanın ölümünde sağ olan gerçek kişi, daima mirasçılık ehliyetine de sahip olacaktır.

Buna karşılık hukuken kişi sayılmayan varlıklar, mirasçılık ehliyetine 1502
sahip olamayacaklardır. Bu bakımdan, magazin haberlerinde ara sıra rastlanan "bütün servetini köpeği Fifi'ye bıraktı" şeklindeki haberler; hayvanların, bitkilerin, eşyaların kişiliği ve hak ehliyetleri bulunmadığından, bir mirasçı nasbı veya vasiyet alacaklısı tayini anlamına gelmez. Mirasbırakan ancak, mirasçısı olan veya muayyen mal vasiyet ettiği gerçek ya da tüzel kişilere, MK 515 çerçevesinde, örneğin köpeğine (yahut diğer bir kişiliği olmayan varlığa) bakma yükümü yükleyebilir. Burada bakılacak köpek bir hak kazanmaz.

Tüzel kişilerin yasal mirasçı olmaları sözkonusu değildir. Bunun tek is- 1503
tisnası, MK 501 uyarınca son sırada mirasçı olarak "Devlet"tir.

Buna karşılık, tüzel kişiler atanmış mirasçı veya vasiyet alacaklısı ola- 1504
bilir. MK 583'deki art mirasçı atamaya başvurulması hâli dışında, mirasçı veya vasiyet alacaklısı olan tüzel kişi mirasın açıldığı anda kişilik kazanmış ve henüz kişiliği son bulmamış olmalıdır (tasfiye hâlinde olma hak sahipliğini engellemeyecektir). Ancak, şayet ölüme bağlı tasarrufla bir vakıf kuruluyorsa, MK 526 uyarınca, vakıf mirasın açılmasından sonra tescil edilmesine yani tüzel kişilik kazanmasına rağmen, geçmişe etkili olarak mirasbırakanca kendisine tahsis edilen hakları iktisap edecektir. Bu, hak ehliyetinin (kişiliğin) mirasın açıldığı sırada kazanılmış olması şartına yasal bir istisnadır.

1505 Bu şartlarla her türlü özel hukuk tüzel kişisi (dernek, vakıf, ticaret şirketleri, kooperatifler) ve kamu hukuku tüzel kişisi (Devlet, Üniversite, Belediye vb.) veya tüzel kişiliği olan meslek örgütleri (sendika, baro vb.), atanmış mirasçı veya vasiyet alacaklısı olabilir. Ölüm anında kişilik sahibi olma şartıyla, mirasçı atanamayacak veya vasiyet alacaklısı olamayacak tüzel kişi türü yoktur.

1506 Burada "ultra vires" teorileri (özellikle Eski TTK 137 hükmünün ticaret şirketlerine getirdiği sınırlamalar) de sonucu değiştirmemelidir. Zira miras hukukuna göre hak kazanma, amaç dışı bir faaliyetle hak iktisabı değildir. Böylece, örneğin, yasal mirasçısı bulunmayan veya yasal mirasçılarından hoşlanmayan bir sanayici, çoğunluk hisssine sahip ve yöneticisi olduğu anonim şirketi şahsî serveti bakımından mirasçı atayabilmeli veya şahsî mallarını ona vasiyet edebilmelidir. Ancak, ticaret şirketlerinin yapısı gereği, mirasçı naspedildikleri veya vasiyet alacaklısı tayin edildikleri için sahip oldukları hakları, ticarî kazanç gösterip kâr payı olarak ortaklarına dağıtamazlar. Bunlar sahip olacakları bu hakları, personelin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak, şirketin borçlarını ödemek, bina vb. ihtiyacını karşılamak gibi alanlarda sarfedecektir. Çoğu kez, bu hakların nasıl kullanılacağı mirasbırakan/vasiyet eden tarafından ölüme bağlı tasarrufta bir mükellefiyet olarak şirkete yüklenmiş olacaktır. Bu takdirde, buna göre hareket edilecektir. Herhangi bir açıklık yoksa, bu kazandırma şirket öz kaynaklarına eklenerek özkaynaklardan yapılacak bir esas sermaye artışına dönüştürülebilir.

1507 Tüzel kişiliğin sona ermesi gerçek kişilerdeki ölüme benzediğinden, mirasçı atanan veya lehine vasiyette bulunulan tüzel kişi mirasbırakandan önce sona ermişse, mirasçı veya vasiyet alacaklısı sıfatını kazanamayacaktır. Belirtelim ki sona erme sebebi doğmuş fakat henüz tasfiye süreci tamamlanmamış tüzel kişiler ehliyetleri daralmış olarak devam ediyor sayıldığından, mirasbırakanın bu aşamada ölümü üzerine atanmış mirasçı ve vasiyet alacaklısı sıfatını kazanıp kazanamayacakları tartışılabilir. Bu aşamada tüzel kişinin yalnız fiil ehliyetinin değil hak ehliyetinin de tasfiye ile sınırlandığı kabul edilirse, mirasçılık ehliyeti bulunmadığı düşünülebilir. Ne var ki, tasfiye hâlinde tüzel kişinin ehliyetine getirilen sınırlamanın, tasfiye faaliyetleri dışında hukukî işlem yapmamasından ibaret olduğu kabul edilirse; mirasçı veya vasiyet alacaklısı olmanın tüzel kişinin yaptığı bir hukukî işleme bağlı olmaması ve bu yolla iktisap edilen hakların tahsilinin de "tüzel kişinin alacaklarının ve sair haklarının tahsili" sayılması sayesinde, mirasçılık ehliyetinin bulunduğu kabul edilecektir. Bu durumda, tüzel kişinin miras payı veya vasiyet alacağı da diğer mallarıyla birlikte tasfiye sonucuna tabi olacaktır.. Birinci görüş, mirasbırakanın yaşasaydı muhtemelen tasfiyeye girmiş tüzel kişiye yapmak istemeyeceği bir kazandırmayı geçerli saydığı öne sürülerek eleştirilebilirse de; tüzel kişinin alacaklılarını daha iyi koruduğu için isabetlidir.

1508 Şayet mirasbırakan tarafından tüzel kişiliği olmayan bir topluluk mirasçı atanmış veya böyle bir topluluk vasiyet alacaklısı tayin edilmişse, normal

durum ortada mirasçılığa veya alacağa ehil kişi bulunmadığından, bu tasarrufların geçersiz sayılmasıdır. Ne var ki, kanun, mümkün olduğu kadar ölenin arzularını gerçekleştirme ilkesinden hareketle, bu tür batıl sayılacak tasarrufları kurtarmak için özel hüküm getirmiştir. MK 577/II hükmüne göre, tüzel kişiliği olmayan bir topluluğa (cemaate) belirli bir amaç için yapılan kazandırmalar, o amacın temini şartıyla topluluğu oluşturan kimselere ait olur. Bu suretle amacın gerçekleşmesi mümkün değilse o kazandırma vakıf kurma sayılacaktır. Görüldüğü üzere, burada yasaca düzenlenmiş bir "çevirme"(tahvil) sözkonusudur. Kanunun geçersiz saydığı bir işlem (topluluk lehine kazandırma) kanunun geçerli saydığı bir başka işleme (bir topluluğu oluşturan her bir gerçek kişi lehine kazandırma veya vakıf kurma) çevrilerek geçerli tutulmaktadır. Böylece, örneğin, mirasbırakanın hayranı olduğu tiyatro topluluğu mensuplarını mirasçı atadığı veya vasiyet alacaklısı tayin ettiği ölüme bağlı kazandırma, mirasın açıldığı anda bu tiyatroda çalışan herkesin tek tek mirasçı atanması veya vasiyet alacaklısı kılınmaları şeklinde anlaşılacaktır.

Böyle durumlarda, miras veya vasiyet konusu haklar, topluluğu oluştu- 1509
ran kişilere eşit olarak paylaştırılacak ve bunların her biri kendisine düşen miktar kadar atanmış mirasçı veya vasiyet alacaklısı olarak bundan doğan talepleri ileri sürebileceklerdir[968].

MK 577/II bu tür bir çevirmenin topluluğa yönelik amacın (gayenin) 1510
gerçekleştirilmesi şartıyla yapıldığını belirtmektedir. Şu halde, yapılan kazandırmanın tek tek bireylere yapılmış sayılarak ayakta tutulması, mirasbırakanın amacına hizmet etmelidir. Yukarıdaki örnekte, tiyatro topluluğunun sınırlı sayıda ve belirli düzeydeki üyelerinin bu suretle elde edecekleri ekonomik imkânın, onları mirasçı atayan veya mal vasiyet edenin hayranı olduğu tiyatronun faaliyetini kolaylaştıracağı ve teşvik edeceği söylenebilecektir.

Buna karşılık, şayet bu kazandırmanın topluluğun bireylerine dağıtıl- 1511
ması kazandırmada bulunan mirasbırakanın amacına yeterince hizmet etmeyecekse ve bu kazandırmanın bir elde toplanıp koordineli kullanılması bu amaca daha çok yarayacaksa, sözkonusu tasarruf "vakıf kurma" sayılacaktır. Özellikle üyeleri çok sayıda ve dağınık olan topluluklar lehine kazandırmalarda durum böyledir. Örneğin, mirasbırakanın mezun olduğu lisede okuyanların mirasçı atandığı veya vasiyet alacaklısı tayin edildikleri ölüme bağlı kazandırma, mirasın açıldığı sırada bu lisede öğrenci olan herkese miras bırakılan veya vasiyet edilen malların dağıtılması değil; bu lise

[968] Şayet topluluk bir adi şirket ise, bu haklara iştirak (elbirliği) halinde sahip olacaklardır. Bkz. *Kocayusufpaşaoğlu*, 530

öğrencilerinin ihtiyaçlarının düzenli şekilde karşılanması için bir vakıf kurma arzusu şeklinde yorumlanacaktır.

1512 Böyle bir ölüme bağlı tasarrufun varlığı hâlinde, niteliğe ilişkin yorumu hâkim yapacaktır. Bunun için, kazandırma yapılmak istenen topluğun her üyesi, mirasçı atanmasını veya vasiyetnameyi öğrenince mahkemeye başvurarak hâkimin yapacağı yoruma göre, ölüme bağlı tasarruf konusu malların dağıtılması sonucu kendisine düşecek miktarı veya vakfın tescilini talep edebilir.

3. Mirastan Yoksun Olmamak (MK 578/579)

a) Mirastan Yoksunluk Kavramı

1513 Mirastan yoksunluk (mahrumiyet) denince bundan, genel olarak mirasçı olabilme (hak) ehliyetine sahip olan bir kimsenin, kanunda belirtilen sebeplerden biri gerçekleştiği için, belirli bir mirasbırakan yönünden Miras Hukukuna ilişkin bir talep ileri sürebilme ehliyetsizliği anlaşılır. Baska bir ifade ile, mirastan yoksun olan bir kimse artık, belirli bir mirasbırakanın terekesi üzerinde herhangi bir hakka sahip olamaz. Bu yolla sadece mirasın kanunî intikali engellenmez. Saklı paydan doğan talepler de ileri sürülemeyeceği gibi mirasbırakanın iradesinden (atanmış mirasçılık ve vasiyet alacaklısı olmadan) kaynaklanan talepler de sona erer. Bu açıdan bakıldığı zaman, yoksunluk MK. 577 anlamında mirasçı olma ehliyetinin yokluğu olarak da görülebilir[969].

1514 MK. 578'de öngörülmüş olan yoksunluk sebepleri incelendiği zaman, yasakoyucunun hangi ortak sebeplerden hareket ederek mirastan yoksunluğu düzenlediğini söylemek mümkün değildir. Buna rağmen bu sebepleri iki ortak paydaya oturtmak mümkündür: a) Yoksunluğa sebep olan fiillerin mirasbırakana karşı işlenmiş olması; b) bu fiil sebebiyle mirasbırakan ile fail mirasçı arasındaki samimi bağ kopacağından, failin miras üzerinde hak iddia etmesinin mirasbırakanın iradesine aykırı olacağı[970]...

1515 Bu açıklamalardan anlaşılacağı gibi, mirastan yoksunluk, layik olmayan bir mirasçıyı (ya da vasiyet alacaklısını) mirastan uzaklaştırma amacını güder. Bu bakımdan, yukarıda açıklanmış olan mirastan çıkarılma ile arasında bir paralellik vardır.[971] O zaman, çıkarılma kurumu varken, kanunkoyucunun neden bir de yoksunluğu düzenleme ihtiyacı duyduğu sorusunun cevaplandırılması gerekir. Bu sorunun cevabı ise şudur: Kanunkoyucu, mirasbırakanın çıkarma tasarrufunu yapma imkanının olmadığı hallerde, mi-

---

[969] *Escher*, Art. 540 N. I
[970] *Escher*, Art. 540 N. 6.
[971] Bkz., yukanda § 16, III, 9.

rasa layik olmayan bir kimsenin, sırf mirasbırakanın çıkarma imkânı olmadığı için mirastan pay almasını engellemek istediğinden, çıkarılmanın yanında ayrıca yoksunluğu da düzenlemiştir. Durum, iki kurum karşılaştırılarak aralarında fark ve benzerliklerin görülmesi ile daha iyi anlaşılır. Şöyle ki:

1) Çıkarılma ancak mirasbırakanın yapacağı bir ölüme bağlı tasarrufla 1516
gerçekleşebilirken; yoksunluk kanun gereği (ipso iure) olur. Yoksunluk için mirasbırakanın herhangi bir tasarrufta bulunmasına gerek yoktur .Sebep gerçekleşince fail kendiliğinden mirasa nail olamaz. Bu yönü ile yoksunluk çıkarılmadan daha önemlidir, onu güçlendirir.

2) İki kurumun uygulama alanları farklıdır. Çıkarılma sadece saklı paylı 1517
mirasçılar için sözkonusudur. Oysa yoksunluk, saklı paylı olsun olmasın bütün kanuni mirasçılar yanında atanmış mirasçıları, hatta vasiyet alacaklılarını da mirastan uzaklaştırır. Bu açıdan yoksunlukt çıkarılmadan daha geniştir.

3) Bir halde yoksunluk çıkarılmadan daha dardır ki, bu da fiilin kime 1518
karşı işlendiği yönündendir. Fiilin, mirasbırakan yanında, yakınlarına (MK. 510/b.1) ya da yine mirasbırakan yanında ailesine (MK. 510 b. 2) karşı işlenmesi çıkarılmayı mümkün kılarken; yoksunluk, sadece yoksunluğu gerektiren fiilin mirasbırakana karşı işlenmesi hâlinde söz konusu olur. O halde MK. 578'de sayılan fiillerden birinin, mirasbırakanın yakını ya da ailesinden birine karşı işlenmesi, yoksunluğu gerektirmez[972]. Ancak, mirasbırakan dışında bir kimseye karşı gerçekleştirilen bu fiil, aynı zamanda bir çıkarılma sebebi de oluşturuyorsa, o zaman mirasbırakan çıkarılma kurumundan yararlanarak sözkonusu kişiyi bir ölüme bağlı tasarruf ile mirasından çıkarabilir.

4) İki kurum arasındaki diğer bir fark da af yönündedir. MK. 578/II af 1519
ile yoksunluğun ortadan kalkacağını açık olarak öngörmüştür. Çıkarılmada ise, bu şekilde açık bir hüküm bulunmadığı için, durumun tartışmalı olduğu yukarıda açıklanmıştı[973].

Mirastan yoksunluk için, yoksun bırakılan kişinin bir fiili aranacağına 1520
göre, acaba, mirasçı olarak atanmış bir tüzel kişi ya da kanuni mirasçı olan devlet mirastan yoksun olabilir mi? Durum, devlet dışındaki tüzel kişiler yönünden tartışmalıdır. Baskın görüş, ya MK.50'deki, tüzel kişinin organlarının fiilinden sorumlu tutulacağı[974] ya da BK. 66'da istihdam edenlerin sorumluluğunu düzenleyen hükümden hareketle[975] tüzel kişilerin de mirastan

---

[972] 2. HD. 7.6.1977, 4637/4778 (*Şener*, Miras 1177).
[973] Bkz., yukanda, § 16, 111, 9, a, ff.
[974] Örnek olarak bkz., *Kocayusufpaşaoğlu*, 533; ayrıca *İmre/Erman*, 265.
[975] Örnek olarak bkz., *Tuor/Picenoni*, Art. 540/541, N. 13

yoksun olabilecekleri görüşündedir. Buna karşılık kanuni mirasçı olan devletin mirastan yoksun bırakılamayacağı oybirliği ile kabul edilmektedir.

1521 Mirastan yoksunluk sebeplerini incelemeye geçmeden önce belirtelim ki, MK. 578'de sayılan fiillerin hepsinin kasden ve hukuka aykırı olarak işlenmesi gerekir. Bu husus MK. 578 bent 1, 2 ve 4'de açık olarak öngörülmüştür. 3. Bentte kast ve hukuka aykırılıktan söz edilmemesi, aldatma, korkutma ve zorlama hallerinde bu unsurların aranmayacağı anlamına gelmez. Çünkü, aldatma, zorlama ve korkutma, nitelikleri gereği kendiliğinden kast ve hukuka aykırılığı içerirler[976].

b) Mirastan yoksunluk sebepleri

1522 Mirastan yoksunluk sebepleri esasen MK. 578'de dört bent hâlinde sayılmış ise de, Yeni Medeni Kanunumuzun 159. ve 181. maddelerinde iki özel yoksunluk hâli daha getirilmiştir. MK m. 578 hükmünde belirtilen sebeplerin tüketici (sınırlı sayıda = numerus clausus) olduğu, benzer olaylara örneksemeyle uygulanamayacağı kabul edilmektedir[977].

1523 Bütün bu hükümlerde düzenlenen yoksunluk sebepleri şunlardır:

aa) Kasten ve hukuka aykırı olarak mirasbırakanı öldürmek ya da öldürmeye teşebbüs etmek (MK. 578/ b. 1)

1524 Yukarıda değinildiği gibi, bu fiiller için kast ve hukuka aykırılık arandığından, ihmalle mirasbırakanı öldürmek yoksunluk sebebi oluşturmayacağı gibi; kasıt bulunsa bile bu fiiller hukuka aykırı değilse, yine fail yönünden yoksunluk sebebi gerçekleşmez. Örneğin, bir baba, oğlunun yaptığı trafik kazasında ölürse (ihmal), oğul mirastan yoksun bırakılmaz. Bunun gibi, ayırdetme gücü olmayan bir kimsenin mirasbırakanını öldürmeye teşebbüs etmesinde de kusur bulunmadığı için yoksunluk sonucu doğmaz[978]. Aynı şekilde, mirasbırakanın öz savunma (meşru müdafaa) sebebiyle öldürülmesi de, hukuka aykırılık bulunmadığı için, mahrumiyet sebebi oluşturmaz.

1525 Yoksunluk için failin ceza mahkemesince mahkum edilmesi şart değildir. Fail, örneğin af dolayısıyla mahkum edilmemiş olsa bile, yine de mirastan yoksun olur. Çünkü yoksunluk için önemli olan fiildir, yoksa failin cezalandırılması değil.

1526 Ötenazinin (birisini kendi isteği üzerine öldürmenin) bir yoksunluk sebebi olup olmayacağı tanışmalıdır. Baskın görüş, mirasbırakanın, önceden öldürülmesine rıza

---

[976] *Escher*, Art 540, N. 7.

[977] *Escher*, Art. 540, N. 6; *Tuor/Picenoni*, Art.540/541, N. 15; *Kocayusufpaşaoğlu*, 533; *Oğuzman*, 265. Miras bırakana yapılan saldırı ve tecavüzün kanunda belirtilen yoksunluk sebeplerinden daha ağır olması halinde bile, bunların yoksunluk değil, ancak mirasbırakana "mirasçılıktan çıkarma" hakkı veren sebepler olacağı hakkında: *Serozan/Engin*, § 5, N. 34.

[978] Ayırdetme gücünün bulunmadığı hallerde yoksunluk sonucunun doğmayacağına ilişkin olarak bkz., BGE 7411 202.

göstermesini MK. 578/II anlamında af olarak yorumlar ve bu yüzden yoksunluk sebebi olamayacağı yönündedir[979].

Öldürme ya da öldürmeye teşebbüs sebebiyle yoksunluk, sadece fail için değil, suça müşevvik ya da yardımcı sıfatıyla katılanlar için de sözkonusu olur. Örneğin oğlu, annesinin teşvikiyle ya da yardımı ile babası olan mirasbırakanı öldürürse; sadece oğul değil, mirasbırakanın eşi de mirastan yoksun olur[980]. 1527

Belirtmek gerekir ki, mirasbırakanı öldürmeye teşebbüs etmek aynı zamanda MK. 510/b.1 'e göre bir çıkarılma sebebidir. Mirasbırakan yapacağı bir ölüme bağlı tasarrufla faili mirasından çıkarabilir. Buna rağmen kanunkoyucu (muhtemelen mirasbırakanın bir ölüme bağlı tasarruf yapma imkanından yoksun olabileceğini düşünerek) aynı fiili ayrıca mirastan yoksunluk sebebi olarak da düzenlemiştir. Ancak, mirasbırakanın çıkarma imkanı olmasına rağmen bunu yapmamasının yoksunluk bakımından af (MK 578/II) anlamına gelip gelmeyeceğinin dikkatle araştırılması gerekir. 1528

bb) Kasten ve hukuka aykırı olarak mirasbırakanı, sürekli şekilde ölüme bağlı tasarruf yapamayacak duruma getirmek (MK 578/ b. 2)

Burada kastedilen, mirasbırakanın ölüme bağlı tasarrufta bulunma ehliyetini kaybetmesine sebep olmaktır. Ölüme bağlı tasarruf yapma ehliyetinin kaybına sebep olan fiilinin türünün önemi yoktur. Önemli olan kaybın devamlı olması, yani ölüm anına kadar devam etmesidir. Ehliyet kaybı geçici ise bu, MK. 578/ b. 2'ye göre yoksunluk sebebi oluşturmaz. Çünkü, mirasbırakan iyileştikten sonra faili mirasından çıkarma ya da onun lehine yaptığı ölüme bağlı tasarrufu geri alma imkânını elde eder. Bunu yapmamış olması, büyük bir ihtimalle, faili affettiği anlamına gelecektir. 1529

cc) Aldatma, zorlama veya korkutma yoluyla, mirasbırakanı bir ölüme bağlı tasarruf yapmasını ya da onun bir ölüme bağlı tasarruftan dönmesini sağlamak veya engellemek(MK. 578/ b. 3)

Dikkat edilirse, burada dört ayrı fiil söz konusudur: 1530

aaa) Mirasbırakanın bir ölüme bağlı tasarruf yapmasını sağlamak; 1531

bbb) Mirasbırakanın, var olan bir ölüme bağlı tasarrufu geri almasını sağlamak, 1532

ccc) Mirasbırakanın bir ölüme bağlı tasarruf yapmasını engellemek, 1533

---

[979] Baskın görüşe örnek olarak bkz., *Escher*, Art. 540 N. 8; (fakat, krş. 2. bası N. 8); *Tuor/Picenoni*, Art. 540/541, N. 20; *İmre*, Miras Hukuku, 3. bası, 425, dn. 20; *Kocayusufpaşaoğlu*, 534; *İnan/Ertaş*, 324.

[980] *Tuor/Picenoni*, Art. 540/541 N. 18; *Escher*, Art. 540 N. 7; *İnan/Ertaş*, s. 371; *Oğuzman*, 266.

1534 ddd) Mirasbırakanın var olan bir ölüme bağlı tasarrufu geri almasını engellemek.

1535 Ancak bu fiillerin soyut olarak işlenmesi mirastan yoksunluk sebebi olmayıp, ancak aldatma, korkutma veya zorlama suretiyle gerçekleştirilmesi yoksunluk sebebi olacaktır.

1536 Bu bentte ilk iki bentten farklı olarak fiilin kasten ve hukuka aykırı olması belirtilmemiştir. Bunun sebebinin, aldatma, korkutma ve zorlama fiillerinin kendiliğinden hukuka aykırılık ve kastı içermesi olduğundan yukarıda söz edilmişti.

1537 Burada "aldatma"nın BK 36 çerçevesindeki anlamı ve "korkutma"nın da BK 37, 38 çerçevesindeki anlamı ifade ettiği anlaşılmaktadır. Şu halde, mirastan yoksunluk için aldatma veya korkutma unsurlarının gerçekleşip gerçekleşmediği, bu Borçlar Hukuku hükümleri çerçevesinde saptanacaktır[981]. Fakat MK 578/b.3 hükümlerinde bunlara ek olarak bir de "zorlama"dan sözedilmiştir. Oysa, Borçlar Hukuku sisteminde "korkutma" (ikrah) dışında ayrıca "zorlama" diye bir kavram yoktur. Hukuka aykırı zorlamalar da BK 37, 38 hükümlerine tabi bir "korkutma"(ikrah) oluşturur. Bir açıklamaya göre, korkutma sadece manevi tehditleri (bir sırrın açıklanmasıgibi) zorlama (cebir) ise fiziksel tehditleri (başına tabanca dayama gibi) ifade etmektedir[982]. Ancak Borçlar Hukukunda korkutma zaten ikisini de içeren bir kavram olarak kullanıldığından, bu ifade gene de yersizdir. Burada akla, korkutma (ikrah) olmayan bir zorlama olarak, olsa olsa, mirasçının mirasbırakanı bağlayarak veya bir odaya kapayarak ölüme bağlı tasarruf yapmasını önlemesi geliyorsa da; aynı maddenin 1. bendi en azından kıyasen uygulanarak, mirasbırakan ölmeden önce bu durumdan çıkarak ölüme bağlı tasarrufta bulunmaya yeterli zaman ve imkân bulmuşsa, artık onu zorla engelleyen mirasçı mirastan yoksun bırakılmamalı, bu durumda mirasbırakanın onu mirasından çıkarması gerekmelidir. Görüldüğü üzere, hükümde korkutma yanında ayrıca zorlamadan da sözedilmesinin pratik bir anlamı bulunmamaktadır.

1538 Burada üzerinde durulması gereken bir diğer nokta şudur: Daha önce değinildiği gibi,[983] MK. 504 ve 557-558 hükümlerinde aldatma ve korkutma halleri iptal sebebi olarak öngörülmüştür. Buna rağmen kanunkoyucu, acaba ayrıca bir de MK 578/ b. 3'deki düzenlemeyi getirme ihtiyacını neden duymuştur? Yoksa bu hüküm, kanunkoyucunun bir unutkanlığı sonucu mu

---

[981] Bu hükümler için bkz. *Oğuzman/Öz*, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Cilt 1, 12. Bası, s. 111 vd., 115 vd.

[982] Bkz. Kitabımızın ilk cildinde § 18 III A 2 c; *Oğuzman*, 103

[983] Bkz., § 17, II, A. 2.

kanuna yeniden girmiştir? Bunun cevabını MK. 504 ve 557-558 ile 578/ b.3'ü karşılaştırarak verelim[984].

aaa) MK. 504 ve 557 sadece aldatma ve korkutma sonucu yapılan ölü- 1539
me bağlı tasarruflardaki hükümsüzlüğü düzenlemiştir. Oysa MK. 578/ b.3, sadece yapılmış olan ölüme bağlı tasarrufta aldatma ve korkutmayı bir yoksunluk sebebi olarak öngörmemiş, aynı zamanda bu sebeplerden biri ile yapılmamış: geri alınmış ya da geri alınamamış ölüme bağlı tasarruflar için de yaptırım getirmiştir.

bbb) Aldatma ya da korkutma bütün ölüme bağlı tasarrufun geçersiz 1540
olması sonucunu doğurur. Buna karşılık, MK. 578/ b.3'e göre, bu fiiller, sadece fiili işleyen kişi lehine olan ölüme bağlı tasarrufu hükümsüz hale getirir, vasiyetnamenin diğer kısımları kural olarak geçerliklerini korurlar.

Bu açıklamalardan da anlaşılacağı gibi, MK. 578/ b.3'ün uygulama ala- 1541
nı MK. 504 ve 557'ye göre daha geniş, buna karşılık kişilere etkisi yönünden daha dardır. İşte bu farklılık sebebiyledir ki, kanunkoyucu her iki hükme de yer vermiştir.

dd) Bir ölüme bağlı tasarrufu, mirasbırakanın yeniden yapamayacağı bir durum ve zamanda kasten ve hukuka aykırı olarak ortadan kaldırmak[985] veya bozmak (MK. 578/b.4).

Ortadan kaldırmaya örnek olarak, bir el yazısı ile vasiyetnamenin yırtı- 1542
larak ya da yakılarak yok edilmesini veya bulunamayacak şekilde kaybedilmesini gösterebiliriz. Bozmak ise, ölüme bağlı tasarrufu yok etmeksizin şekil bakımından hükümsüz sayılmasına sebep olmaktır. Tasarrufun esaslı bir unsurunu (örneğin elyazısı ile vasiyetnamedeki imzayı ya da ölüme bağlı tasarruftaki lehdarın adını) keserek ya da karalayarak tespitini imkansız hale sokmayı, ölüme bağlı tasarrufu bozmaya (hükümsüz hale getirmeye) örnek olarak gösterebiliriz.

Belirtmek gerekir ki, MK. 578/b.4 hükmünün resmi vasiyetnamelere uygulan- 1543
ması hemen hemen imkansızdır. Çünkü resmi vasiyetnamenin aslı noterdedir. Noterin elindeki vasiyetnameyi (noterin işbirliği yapma durumu bir yana) yok edilmesi ya da hükümsüz hale getirilmesi mümkün değildir. Mirasbırakandaki nüshanın im-

---

[984] *Tuor/Picenoni*, Art. 540/541, N. 23 vd.; *Escher*, Art. 540 N. 12; *Kocayusufpaşaoğlu*, 535.

[985] Bu hükmü karşılayan Eski MK 520/ b.4 hükmünde "ortadan kaldırma" yerine "gizleme" deyimi kullanılmıştı. Bu isabetsiz bir ifadeydi. Zira, gizlenen ölüme bağlı tasarruf (örneğin bundan zarar gören mirasçı tarafından gizili bir yere saklanan vasiyetname) sonradan bulunur ise, gizleyenin MK. 595/II uyarınca vasiyetname lehdarının gecikme zararını tazmin etme dışında, ayrıca mirastan yoksunluk yaptırımına maruz kalması sözkonusu olmaz. Nitekim, isabetsiz ifade içeren eski hüküm zamanında da, "gizleme" İsviçre Medeni Kanununun Almanca metnine uygunlukla, "ortadan kaldırma" olarak anlaşılmaktaydı. Krş. *Kocayusufpaşaoğlu*, 536

hası ya da bozulması ise, aslı var olduğu sürece resmi vasiyetnamenin geçerliliğini etkilemez.

1544 Ortadan kaldırma veya bozma kasten ve hukuka aykırı şekilde olmalıdır. Aksi takdirde bunlara sebep olan mirastan yoksun bırakılmaz. Örneğin, ihmali sebebiyle çıkardığı yangında babasının vasiyetnamesinin yanmasına yol açan kişi kastı olmadığından; bizzat vasiyetnameyi düzenleyen babasının isteği üzerine yakan kişi de hukuka aykırı davranmadığından, mirastan yoksun olmaz.

1545 MK 543/II uyarınca, yok edilen vasiyetnamenin içeriğini aynen ve tamamen belirlenebilmesi hâlinde, bu vasiyetname hüküm ifade edecektir. Acaba böyle bir durumda gene de vasiyetin yazıldığı kağıdı kasten ve hukuka aykırı şekilde yok eden mirastan yoksun bırakılacak mıdır? Kanımca, MK 578/b.4'ün ifadesinden sadece mirasbırakanın son arzularının gerçekleşmesini engellemenin yaptırıma bağlanmak istendiği anlamı çıktığından; bu durumda yoksunluk olmamalıdır. Böylece, babasının vasiyetini kardeşine yapılan kazandırmayı önlemek için yakan oğul, kardeşin vasiyetin tam metninin fotoğrafını ibraz ederek hüküm ifade etmesini sağlaması üzerine, mirastan yoksun olmayacak, sadece MK 595/II uyarınca verdiği zararı tazminle sorumlu olacaktır.

1546 MK 578/b.4'e göre mirastan yoksunluk için, mirasbırakanın yokedilen veya bozulan ölüme bağlı tasarrufu tekrar yapamayacak durumda olması gerekir. Buna tipik örnek, mirasbırakanın ölümünden sonra vasiyetnamesini yoketmek veya bozmaktır. Mirasbırakanın ehliyetini kaybettikten sonra vasiyetnamesinin imha edilmesi de yoksunluk sebebidir. Hükmün sözüne değil de amacına bakarak, mirasbırakanın yenisini düzenleyebileceği durumda ölüme bağlı tasarruf yok edilmiş/bozulmuş olsa bile, mirasbırakan bundan haberdar değilse ve haberdar olamadan ölmüş yahut ehliyetini kaybetmişse; yok eden/bozan bu durumda da mirastan yoksun bırakılmalıdır.

1547 Buna karşılık, ölüme bağlı tasarrufunun yok edildiğini veya bozulduğunu öğrenen mirasbırakan, ehliyetli olarak yeni bir tasarrufta bulunacak kadar vakti olduğu halde bunu yapmamışsa, tasarrufu yok eden veya bozan mirastan yoksun olmayacaktır.

ee) Eşin ölümünden sonra mirasçının devam ettiği butlan davasında sağ kalan eşin iyi niyetli olmaması

1548 Evliliğin butlanında mahkemenin iptal kararının kesinleşmesinden sonra eşlerin birbirine bu sıfatla mirasçı olmayacakları açıktır. Fakat Yeni Medeni Kanunumuz bununla yetinmeyerek, 159. maddesinde butlan davası açıldıktan sonra ölen eşin yerine mirasçılarının bu davayı sürdürerek ka-

zanmaları hâlinde, diğer eşin iyi niyetli olmaması durumunda, mirasçı olmayacağını ve lehine yapılmış ölüme bağlı kazandırmaların da hükümsüzleşeceğini düzenlemiştir. Butlan kararları geriye yürümediğinden, burada geçerli bir evlilik mevcud iken ölen eşine mirasçı olması engellenen kişi bakımından, bir mirastan yoksunluk sebebi düzenlenmiş olmaktadır. Bu yoksunluğun ilk şartı mirasçının butlan davasını kazanması, ikinci şartı ise mirasçılığı önlenecek eşin iyi niyetli olmadığının ispatıdır (MK 6 uyarınca bunu davacı ispat edecektir). İyi niyetten kasıt, davalı eşin evlendiği sırada butlan sebebini bilmemesi ve bilecek durumda da olmamasıdır. Madde metninde "mirasçılar" ifadesi geçiyorsa da diğerleri mirasçılar katılmasa bile sadece bir mirasçı davayı sürdürebilmeli ve diğer eşin kötü niyetini ispatlayabilmelidir. Aksi takdirde boşanma davasına devam etmeye ilişkin MK 181/2 hükmünün buna imkan veren düzenlemesinden yersiz şekilde farklı bir sonuç benimsenmiş olur. Oysa evliliğin boşanmaya nispeten daha ağır bir sona erme hali olan butlanında, davaya devamı ve mirasçılığı önlemeyi, boşanmaya nispeten zorlaştırmanın mantıksızlığı açıktır.

MK 159 hükmünün ifadesi, sadece eşin açtığı davaya mirasçılarının 1549
devamından sözettiğinden, sadece nispi butlan durumlarını kapsar görünmektedir. Bu durumda, "geçici olarak temyiz kudretini kaybetmiş kişinin evlenmesi" (MK 148), "yanlışlıkla evlenme veya yanlış kişiyle evlenme veya evlenilen kişinin önemli bir vasfında yanılarak evlenme" (MK 149), "aldatılarak evlenme" (MK 150), "korkutularak evlenme" (MK 151), hallerinde dava sırasında ölenin eşinin kötü niyeti ispatlanarak mirasçılığı önlenebilecek; buna karşılık, "ikinci evlilik", "ayırdetme gücünden sürekli yoksunluk", "evlenmeye engel akıl hastalığı", "yakın hısımlık" şeklinde mutlak butlan hallerinde (MK 145) davayı ölen eşin mirasçıları da açsa ve diğer eşin kötü niyeti de ispatlansa, mirasçılık önlenemeyecektir. Bu sonucun mantıksızlığı açıktır. Bu yüzden MK 159 hükmünün amaca göre yorumlanması suretiyle, maddenin sözüne uymasa bile, bir mutlak butlan durumunda MK 146/2 uyarınca "ilgili" ispatlanarak mirastan yoksun kalması sağlanabilmelidir[986]. Diğer deyişle, mutlak butlanda "açılmış davaya devam" şartı aranmamalı, sadece "bir mirasçının dava açması" yeterli olmalıdır. Fakat dava açan ölen eşin bir mirasçısı değil de MK 146 uyarınca diğer dava hakkı sahiplerinden "mirasçı olmayan bir ilgili" ise bunun diğer eşin kötü niyetini ispatlayarak mirasçılığına engel olmaları mümkün olmayacaktır.

---

[986] *Dural/Öğüz/Gümüş*, Türk Özel Hukuku Cilt III, Aile Hukuku, İstanbul 2005, s. 98, 99.

ff) Boşanma davası devam ederken ölen eşin mirasçısının davaya devam ederek davalı eşin kusurlu olduğuna dair karar alması

1550 6217 sayılı kanunla[987] kanunla değişik MK 181/II'ye göre, boşanma davası devam ederken eşlerden biri ölür ve mirasçılarından biri davaya devam edip sağ kalan eşin boşanmada daha kusurlu olduğunu ispat ederse, sağ kalan eş ölene mirasçı olamaz.

1551 Mirasçılar birden fazla ise sadece biri bile davaya devam edebilir. Davayı kazanırsa, sağ kalan eş mutlak şekilde mirastan yoksun kalacağından, davaya katılmayan mirasçıların miras payı da artacaktır. Fakat davayı yürüten mirasçı yaptığı dava masraflarını diğer mirasçılardan vekâletsiz işgörme hükümlerine göre miras payları oranında talep edebilir.

1552 Davaya devam edilince ölenin boşanma hakkına sahip olduğu saptanmalıdır. Davalı ne kadar kusurlu olursa olsun, boşanma şartları gerçekleşmemişse, davalı ölen eşinin mirasından yoksun bırakılamaz. Örneğin, davalının kusuruna rağmen evlilik MK 166 uyarınca temelinden sarsılmamışsa veya terk eden kusurlu olsa bile ölüm anına kadar terk altı ay sürmemişse (MK 164), mirastan yoksunluk olmaz. Buna karşılık, boşanma şartları gerçekleşmişse, davalı tarafın tek başına kusurlu olması (ölen eşin kusursuz olması) aranmamalıdır. Davalının kusurunun ölen eşin kusurundan fazla olduğunun tespiti, mirastan yoksun bırakılmasına yeterli sayılmalıdır.

c) Mirastan Yoksunluğun Sonuçları

1553 aa) Yukarıda sık sık değinildiği gibi, yoksunluk kendiliğinden hüküm ifade eder ve sözkonusu kişi mirasçılık ehliyetini kaybettiği için miras açıldığı anda mirasçılık ya da vasiyet alacaklısı sıfatını kazanamaz. Yani o, mirasbırakandan önce ölmüş gibi kabul edilir ve paylaşmaya katılamaz ya da vasiyet alacaklısı ise, mirasçılara karşı vasiyetin yerine getirilmesine ilişkin talep hakkını elde edemez.

1554 Bir halde yoksunluk sebebi, mirasbırakanın ölümünden sonra ortaya çıkabilir ki, bu da, mirasçının ölüme bağlı tasarrufu, mirasbırakanın ölümünden sonra imha etmesi, yani MK. 578/b.4'deki şartı gerçekleştirmesidir. Bu halde yoksunluk, mirasbırakanın ölümüne kadar geçmişe etkili olur ve mirasçı yine mirasın açıldığı andan itibaren bu sıfatı kazanamaz[988].

1555 Yoksunluk kendiliğinden hüküm ifade ettiği için, ayrıca bu konuda bir mahkeme kararına da gerek yoktur. Ancak, taraflar arasında, yoksunluğun varlığına ilişkin bir ihtilaf çıkarsa, o zaman bu hususun saptanabilmesi için bir tespit davası açılır. Bu davada, eğer mirastan yoksun olduğu ileri sürülen mirasçı (ya da vasiyetten doğan

[987] RG 27905.

[988] *Escher*, Art. 540, N. 2; *Tuor/Picenoni*, Art. 540/541, N. 2; *Kocayusufpaşaoglu*, 538; *Oğuzman*, 268.

haktan yoksun olduğu ileri sürülen vasiyet alacaklısı) tereke mallarına zilyet ise, davalı sıfatını o taşır. Bu halde, malların gerçek hak sahibine geri verilmesi amacı güdüleceği için, açılacak olan dava esas itibariyle miras sebebiyle istihkak davasından başka bir şey değildir. Buna karşılık, mirastan mahrum olduğu iddia edilen kimse tereke mallarına zilyet değilse, davada, davacı sıfatı ona ait olur ve davalı olan mirasçılar onun mirastan yoksun olduğunu ispat etmek zorunda kalırlar. Bu halde açılan dava yerine göre, miras sebebiyle istihkak davası, paylaştırma davası ya da vasiyetnamenin yerine getirilmesini isteme davalarından biri olur[989].

bb) Yoksunluk nispidir. Bunun anlamı mirasçının, sadece kime karşı yoksunluk gerektiren fiili işlemişse, ona karşı mirasçılık sıfatını kaybetmesidir. Örneğin, babası (M)'ye karşı yoksunluğu gerektiren fiili işlemiş olan (A), sadece ona mirasçı olamaz, fakat (M)'nin babasına, yani kendi büyük babasına karşı bu sıfatı korur. 1556

cc) MK. 579'da açıkça belirtildiği üzere, Yoksunluk kişiseldir. Bunun anlamı, yoksunluğun, yoksun olan kişinin altsoyunu etkilemeyeceğidir. Altsoy, halefiyet kuralı gereği yoksun olan kişinin yerini alır ve onun payına sahip olur. Örneğin (B) adında bir çocuğu olan (A), babası (M)'yi öldürmüşse, sadece (A) mirastan mahrum olur ve onun payı halefiyet kuralı gereği (B)'ye geçer, (M)'nin mirasçısı (B) olur. Bundan da anlaşılacağı üzere, mirastan yoksun olan kişi, tıpkı mirasbırakandan önce ölmüş gibi kabul edilmektedir. Bu sebeple eğer yoksun bırakılanın ona halef olacak altsoyu yoksa, o mirasbırakandan önce ölmüş gibi kabul edildiği için, paylaşmada hiç nazara alınmaz ve miras, aynı sıradaki diğer mirasçılar arasında paylaştırılır. Mirasbırakan (M)'nin (A), (B) ve (C) adlı oğullarından (A) mirasbırakanı öldürmeye teşebbüs etmişse, miras (B) ve (C) arasında 1/2 oranında paylaştınlır. Yoksun olan kişi o zümredeki tek mirasçıysa, miras bir sonraki zümreye geçer. Yoksun olan kişi, atanmış mirasçı ya da vasiyet alacaklıysa, bunlar lehine yapılan kazandırmalar hükümsüz olur, meğer ki mirasbırakan bir ikameli tasarruf yapmış yani yedek mirasçı veya yedek vasiyet alacaklısı tayin etmiş olsun. İkameli bir tasarrufun bulunmadığı durumlarda, atanmış mirasçı yada vasiyet alacaklısı lehine yapılan kazandırmalar kanunî mirasçılara ait olur (MK. 581). 1557

Elbette altsoy, mirasçısı sıfatını kazanabileceği kişi için yoksun olan kişinin yerine geçer. Esasen mirasçısı olamayacağı kişinin bu yolla mirasını alamaz. Örneğin (A)'nın eşi (B) mirastan yoksun bırakıldığında (B)'nin başkasından olan oğlu (C), (A)'ya mirasçı olmaz. 1558

d) Affin Etkisi

MK. 578/II'ye göre, "Mirastan yoksunluk, mirasbırakanın affıyla orta- 1559

[989] Bkz., *Kocayusufpaşaoğlu*, 540; *Oğuzman*, 268 ve orada dn. 32'de atıf yapılan yazarlar.

dan kalkar." Hemen belirtmek gerekir ki, buradaki af, mirasbırakandan kaynaklanan bir aftır. Çünkü ancak mirasbırakanın affi iledir ki, fiilin kopardığı bağ onarılabilir. Bu yüzden Ceza Hukuku alanındaki af kanunlarının yoksunluğa bir etkisi olmaz[990].

1560 Af, hukuki sonuç doğuran bir duygu (his) açıklaması olup, geçerliliği herhangi bir şekil şartına bağlı değildir. Bu bakımdan örtülü bir irade açıklaması ya da istidlal edici fiillerde de açıklanabilir. Ancak bir irade açıklamasını gerektirdiği için, mirasbırakanın af beyanı anında ayırtım gücüne sahip olması gerekir.

1561 Bu konuyu bitirmeden son olarak belirtelim ki, MK. 578/II, her ne kadar bir ayırım yapmıyorsa da, bazı yoksunluk sebeplerinde nitelikleri gereği af söz konusu olamaz. Mirasbırakanın öldürülmesi, daimi şekilde ayırt etme gücünden yoksun bırakılması ya da mirasbırakanın ölümünden sonra ölüme bağlı tasarrufunun imha edilmesi gibi...

§ 27. Miras Paylarının Devri

1562 Kuşkusuz herkes miras yoluyla kendisine intikal eden hakları Eşya Hukukunun ve Borçlar Hukukunun ilgili hükümlerine göre dilediği kişiye bedel karşılığı veya karşılıksız olarak devredebilir. Fakat, henüz mirasın paylaşılması tamamlanıp terekedeki mallar ve haklar her bir mirasçının malvarlığında tek başına tasarruf edebileceği şekilde yerini almadan önce, bu intikali sağlayan miras payının devri mümkün müdür? Şayet mümkünse nasıl olacaktır? Belirtelim ki, bu sorulara cevap verirken, birbirinden çok farklı iki durumu ayırt etmek gerekir: Mirasbırakanın henüz sağlığında müstakbel mirasçısının müstakbel miras payını devretmesi ve mirasbırakanın ölümünden yani mirasın açılmasından sonra fakat paylaştırmadan önce (intikal etmiş) miras payının devri. MK 677 hükümleri açılmış miras payının devrini, MK 678 hükümleri ise henüz açılmamış miras payının devrini düzenlemiştir. Aşağıda, kanunun sırasının tersine fakat olguların kronolojik sırasına uygun şekilde, bu iki durumu ayrı ayrı açıklayacağız.

I. AÇILMAMIŞ MİRAS PAYININ DEVRİ

1563 Açılmamış miras payının devri, bir kişinin henüz kendisine mirasçı olacağı kimse yaşıyorken, ileride doğması muhtemel mirasçılık hakkını şimdiden devretmek istemesidir. Kanunumuz bir kişinin müstakbel (gelecekteki)

---

990 *"Murisi kasten öldürmekten mahkum olan ve cezasını kısmen çektikten sonra Af Kanununa göre tahliye dilen mirasçının mirastan mahrumiyet hali, bu sebebe binaen kalkmaz."* (7.HD. 29.11.1952, 4173/4447; *Kocayusufpaşaoğlu*, 542 dn.56'dan naklen).

mirasçılık hakkını serbestçe dilediği kişiye devretmesini kabul etmemiştir. Bu hususu düzenleyen MK 678 hükmüne göre, bir kimsenin sağlığında mirasçılarından (daha doğrusu: mirasçısı olabilecek kişilerden) birinin diğer bir mirasçıyla veya üçüncü kişilerle yaptığı gelecekteki mirası hakkındaki sözleşmeler, kendi katılımı veya onayı bulunmadıkça geçersiz olacaktır.

Gelecekteki miras payının önceden devrinin geçersiz sayılmasının ge- 1564
rekçeleri, öğretide şu şekilde açıklanmaktadır[991]: İleride gerçekleşecek mirasçılığın garantisi yoktur. Müstakbel mirasçı müstakbel mirasbırakanından daha önce ölebilir, onu mirasçılıktan uzaklaştıracak birisi çıkabilir (miras beklediği kardeşinin çocuğu olması gibi), mirasın açıldığı sırada çıkarılma, yoksunluk gibi bir sebeple mirasçı sıfatını kazanamayabilir, saklı paylı mirasçı değilse mirasbırakanın tasarrufu ile miras hakkını kaybedebilir. Gene, ileride kazanılacak mirasçılık sıfatına bağlı olarak elde edilecek malvarlığının değeri önceden bilinemez. Mirasın açılmasına kadar mirasbıranın malvarlığı artabilir ve azalabilir. Ayrıca, bir kişinin henüz yaşayan bir yakınının ölümüne bağlı olarak kazanacağı hakları önceden devretmeye kalkması (babasının, anasının vb. ölümünü hesaplaması ve şimdiden kazanca dönüştürmesi) ahlâken kınanabilecek, hoş olmayan bir tutumdur. Hatta, şayet bu yol açılırsa, bazen müstakbel mirasbırakanların hayatının tehlikeye düşeceği (miras payını devralanın onu öldürmeye teşebbüs edebileceği) bile ileri sürülmektedir.

MK 678 Hükmüne göre, şayet müstakbel mirasbırakan bu sözleşmeye 1565
katılır veya izin verir ise, bu şartla henüz açılmamış miras payının devri sözleşmesi geçerli olacaktır. Bu maddenin karşılığı olan Eski MK 678 hükmü katılma (iştirak) ile izini (muvafakati) "veya" yerine "ve" bağlacı ile bağlamış olmasına rağmen, o zaman da öğreti bunları ayrı ayrı mümkün saymaktaydı[992]. Yeni maddede bu hsus açıklığa kavuşturulmuştur. Onmay, devir sözleşmesinden sonra da verilebilir. Bu onay beyanı bir şekle de bağlı değildir. Sözlü olarak hatta zımnen verilmesine bir engel yoktur. Fakat ispat sorunu bakımından en azından yazılı verilmesi büyük önem taşıyacaktır. Şayet bu onay verilmemişse, miras devri sözleşmesi devreden ve devralan arasında bile geçersiz sayılacak, mirasın açılmasından sonra da onları herhangi bir yüküm altına sokmayacaktır[993].

---

[991] *Kocayusufpaşaoğlu*, 543 vd.; *İmre/Erman*, 491 vd.; *Serozan/Engin*, § 7, N. 24; *Escher*, Art. 636, N. 2; *Tuor/Picenoni*, Art. 636, N. 1-2

[992] *Kocayusufpaşaoğlu*, 543 vd.; *Tuor/Picenoni*, Art. 636, N.6 vd.; *İmre/Erman*, 494; *Özakman*, Miras Payının Devrine İlişkin Sözleşmeler, İstanbul 1984, 123 vd: *Çilingiroğlu*, Miras Paylarının Devri, (MK 612-613), İBD 1993, S.7-8-9, s.548; BGE 98 II 281

[993] Bu bakımdan, MK 678 hükmünü özel bir geçersizlik sebebi getiren bir hüküm olarak görmek de mümkündür. Zira, bu hüküm olmasa, ileride elde edilmesi mümkün bir hak-

1566 MK 678 hükümlerinde sözleşmenin şeklinden sözetmemekle birlikte, devreden ve devralan arasındaki devir sözleşmesinin şayet ikisi de (sözleşme yapıldığı sıradaki durum bakımından) müstakbel mirasçı ise adi yazılı şekilde, devralan o sırada mirasçı olabilecek pozisyonda bulunmayan bir kişiyse noterde düzenleme şeklinde yapılması, geçerlilik bakımından gerekli ve yeterli görülmelidir[994]. Bu sonuca, mirasın açılmasından sonraki devir sözleşmelerini düzenleyen MK 677 hükmüne kıyasen varılmaktadır. Müstakbel terekede taşınmaz mallar bulunsa bile müstakbel mirasçılar arasında adi yazılı şekil yeterli sayılacaktır.

1567 Ancak, ister bu şekilde ister noterde düzenleme şekliyle bu yapılmış bir devir sözleşmesinin, mirasbırakanın bu sözleşmeye katılarak veya dışarıdan onay vermesine rağmen, devralanı mirasın açılmasında küllî halef mirasçı kılmayacağı; onun sadece devredene yönelik olarak açılan mirastan devredenin elde ettiği hakları kendisine geçirmesini isteme konusunda bir alacak hakkı kazanacağı belirtilmektedir. Buna göre, mirasbırakanın ölümünde mirasçı sıfatını gene de devreden kazanacak, tenkis ve denkleştirme davalarını açma hakkına o sahip olacak ve paylaştırmaya o katılacak, sadece paylaştırma sonunda kendisine kalacak tereke unsurlarını devir sözleşmesine göre devir alacaklısına geçirmekle yükümlü olacaktır. Görüldüğü üzere, burada gerçek bir miras payı devri değil, miras sebebiyle kazanılacak müstakbel hakların önceden temliki taahhüdü vardır. Belirtelim ki, payını devreden mirasçı, mirasın paylaşılması aşamasında tenkis veya denkleştirme davası açmama, mirası reddetme gibi davranışlarla miras payını devralana zarar verirse, bu yüzden ona karşı aralarındaki sözleşme çerçevesinde borca aykırılık hükümlerine göre sorumlu olacak, örneğin bu suretle engellediği kazanımları devralana tazmin etmek zorunda kalabilecektir. Öte yandan, MK 648 hükmüne[995] kıyasen, miras payını devralanın hâkime müracaatla paylaşmaya katılmak üzere bir kayyım atanmasını istemesini mümkün görenler de vardır[996].

1568 Şayet devir sözleşmesi MK 545 uyarınca miras sözleşmesi şeklinde yani resmî şekilde yapılırsa ve mirasbırakan da bu şekil çerçevesinde işleme

---

kın devrinin önceden taahhüt edilmesi, borçların genel hükümlerine göre –en azından tereddütsüz olarak- geçersiz sayılamaz.

[994] Bu maddenin karşılığı olan Eski MK 612 sözleşme mirasçılar arasında olsun mirasçı olmayan birisi ile olsun adi yazılı şekil aradığından, o zamana göre açılmamış miras payının devrinde de bu hükme kıyasen adi yazılı şekli yeterli gören: *Özakman*, 123 vd.; *Çilingiroğlu*, 548; *Kocayusufpaşaoğlu*, 545; *İmre/Erman*, 495; *Escher*, Art.633, N.10; *Tuor/Picenoni*, Art 638, N.14.

[995] Bu hüküm mirasın açılmasından sonraki devirler içindir.

[996] Bu hükmün karşılığı olan Eski MK 588 uyarınca, kayyım atanmasını istemek değil hakimin paylaşmaya katılmasını istemek mümkün olduğundan, kıyasen bunun uygulanacağı hakkında: *Kocayusufpaşaoğlu*, 548; *İmre/Erman*, 496

katılmışsa; bu takdirde payını devreden bakımından "mirastan feragat sözleşmesi"(MK 528) ve bu payı devralan bakımından da "mirasçı atama" şeklinde bir "miras sözleşmesi" (MK 527) etkisine sahip olacak bu sözleşme ile mirasbırakanın ölümü (mirasın açılması) üzerine devreden mirasçı sıfatını kazanamayacak, devralan onun payı kadar olmak üzere mirasçılık sıfatına sahip olacaktır[997]. Bu durumda mirasın paylaşılması tamamlanıncaya kadar mirasçılığa bağlı her türlü hak, payı devralan tarafından kullanılacaktır.

Şayet açılmamış miras payının devri sözleşmesi mirasbırakanın katılması veya izni olmadığı için yahut taraflar arasında gereken şekilde yapılmadığı için geçersiz ise, MK 678/II, böyle bir sözleşme uyarınca verilen şeylerin geri istenebileceğini belirtmektedir. Bu batıl sözleşmeler uyarınca verilen şeylerin sebepsiz zenginleşme oluşturmasının normal sonucudur. Esasen sebepsiz zenginleşme oluşturacak bu kazanımların iadesinin bu hükümle ayrıca düzenlenmiş olmasının yaratacağı farklar, sebepsiz zenginleşme zamanaşımının (BK m. 82) değil genel zamanaşımının (BK m. 146) uygulanması ve kazandırmanın ahlâka aykırı amaç taşıdığından sözedilerek BK m. 81 uyarınca iadesinin engellenmemesini sağlamasıdır[998]. 1569

Açılmamış miras payının rehninin ise hiçbir şekilde mümkün olmadığı, miras payının sağladığı imkânın soyut şekilde rehnin konusu olmaya elverişli bulunmadığı kabul edilmektedir[999]. 1570

II. AÇILMIŞ MİRAS PAYININ DEVRİ

1. Genel Olarak.

Mirasın açılması üzerine mirasçılar tereke üzerinde hak sahibi olurlar ve bu hak miras paylarına göre terekenin paylaşılması sona erinceye kadar sürer. İşte, paylaşmanın tamamlanmasına kadar, mirasçıların tereke üzerinde birbirinden bağımsız hakları bulunmayıp, terekeyi paylaşmaya yönelik olarak, iştirak hâlinde elbirliği (iştirak) hâlinde hak sahibidirler. Aslında elbirliği hâlinde hak sahipliği elbirliği hâlinde maliklere üzerinde tasarruf edebilecekleri paylar sağlamaz. Bu ilişkide her türlü tasarruf oybirliği ile yapılmalıdır. Bu prensip uyarınca, aslında miras açıldıktan sonra da hiçbir mirasçının paylaşma tamamlanmadan önceki dönemde terekeye ilişkin haklarını başkasına devredememesi gerekir. Ne var ki, özellikle paylaşmanın sonuna kadar beklemeye malî durumu uygun olmayan mirasçıların varlığı 1571

---

[997] *İmre/Erman*, 494

[998] İkinci fark için bkz. *Escher*, Art.636, N.14; *Kocayusufpaşaoğlu*, 548

[999] *Escher*, Art.636, N.16; *İmre/Erman*, 497

gibi bazı sebeplerle, kanunumuz istisnaen daha elbirliği hali aşamasında miras hakkının devrini mümkün kılan hükümlere yer vermiştir.

1572 Mirasın açılmasından sonra miras payının devrini düzenleyen MK 677 hükümleri, özel şekil şartı getirmenin yanında, payı devralacak kişinin diğer bir mirasçı veya mirasçı olmayan bir kimse olmasını ayırmıştır..

2. Devir Sözleşmesinin Şekli Ve Konusu

1573 MK 677/I hükmünde, mirasçılar arasında yapılacak devirlerin yazılı şekilde yapılacağı açıkça belirtilmiştir. Burada kastedilen adi yazılı şekildir. Böylece, mirasbırakanın iki oğlundan birinin miras payını diğerine devretmesi için, bu hususta ki anlaşmayı aralarında yazıya döküp imzalamaları yeterlidir. Şayet miras payı devri ivazsız ise BK 14/I uyarınca, bu devirden karşılıksız yararlanan tarafın yazılı sözleşmeyi imzalamasına da gerek yoktur. Sadece payını devredenin imzalaması yeter[1000]. MK 677/I özel bir şekil kuralı getirdiğinden, terekedeki mallar arasında taşınmazlar bulunsa bile, adi yazılı şekilde yapılan devir sözleşmesi geçerli olacaktır. Tapu sicilinde resmi senet düzenlenmeksizin, devralanın tüm tereke üzerindeki miras payı arttığı oranda, bu taşınmazlar üzerindeki miras payı da artmış olacaktır.

1574 Bir mirasçı tüm miras payını bir başkasına devredebileceği gibi, sadece bir oranını da başkasına devredebilir. Örneğin, (M)'nin ölümü üzerine mirasçıları çocukları (A) ve (B) olup, (A) miras payını tümüyle kardeşi (B)'ye devredebileceği gibi, miras payının yarısını da devredebilir. Sonuncu şıkta, (A)'nın tereke üzerindeki miras payı 1/4'e inerken, (B)'nin miras payı 3/4'e çıkmış olur.

1575 Mirasçı olmayan kimselere yapılacak devirler ise MK 677/II'de düzenlenmiştir. Buna göre, bir mirasçının mirasçı olmayan kişiyle[1001] yapacağı sözleşmeler noterde düzenleme şeklinde tabidir. Böylece, örneğin babasından veya eşinden kalan miras payını acil paraya ihtiyacı olup mirasın paylaşılmasını bekleyemediği için bir yabancıya devretmek isteyen oğul veya sağ kalan eş, devralacak kişiyle birlikte notere giderek bu sözleşmeyi düzenletmek zorundadır. Eski Medeni Kanunda (EMK 612) bu şekil hükmü yer almadığı için, mirasçı olmayan kişiye yapılacak devrin şekli belirsizdi. Yasada şekle bağlanmamış işlemlerin şekilsiz yapılabileceği ilkesine rağmen, öğretide, mirasçı olmayan kişiye yapılacak devrin mirasçıya yapılacak devre göre kolaylaştırılmasının anlamsızlığına dikkat çekilerek, mirasçı olmayanlara yapılacak devirlerin de yazılı şekle tabi olacağı kabul edilmek-

---

[1000] Fakat bu, kazandırmayı alanın da uygun irade beyanında bulunması (devre razı olması) şartını kaldırmaz.

[1001] Maddede isabetsiz olarak "üçüncü kişiyle.." demektedir.

teydi[1002]. Yeni MK 677/II ile bu sorun isabetli şekilde çözülmüştür. Ancak, birazdan belirteceğimiz üzere, mirasçı olmayan kişiyle yapılan devir sözleşmesinin gerçek bir hak devri değil sadece devralana şahsi bir talep hakkı sağlaması kuralı Yeni Maddede de korunmuştur.

Miras payının devri sözleşmesi, terekedeki mallar üzerinde mevcut aynî 1576
ve şahsî hakların münferit devrine yönelik olmayıp, mirasçılık sıfatına bağlı hakların devrini konu aldığından, terekedeki münferit bazı malların miras payının devri sözleşmesine konu olamaması gerekir.zira, henüz miras ortaklığı ve elbirliği hâlinde mülkiyet ilişkisi sürerken, terekedeki mallar üzerinde hiçbir mirasçının tasarruf edebileceği bir hakkı yoktur. Sadece, terekenin bütünü üzerinde oranla belli bir mirasçılık hakkı vardır. Ne var ki, pratik bazı ihtiyaçlar sebebiyle Yargıtayımız, mirasçılar arasında yapılmak şartıyla, bu tür sözleşmelerin de geçerli olacağını kabul etmiştir. 24.5.1985 tarihli ve E.1984/2 K.1985/5 Sayılı İçtihadı Birleştirme Kararına[1003] göre, henüz paylaşılmamış ve elbirliği hâlinde mülkiyete tabi bir miras şirketinde, mirasçılardan birinin belli bir tereke malı (örneğin bir taşınmaz) üzerindeki miras payını bir başka mirasçıya devri mümkündür. Böyle bir durumda, elbirliği hâlinde mülkiyet ilişkisi ve miras ortaklığı devam ettiği halde, örneğin devre konu taşınmazın sicilinde bu taşınmaz üzerindeki payını tamamen devreden mirasçı adına tescil silinerek devralan adına tescil yapılacaktır. Öğretide de bu çözümü pratik bularak savunanlar vardır[1004]. Biz ise, böyle bir miras payı devri sözleşmesinin, miras payı, miras ortaklığı ve elbirliği hâlinde mülkiyet kavramlarıyla bağdaştırılamayacağı görüşüne katılıyoruz[1005]. Kanımızca, terekedeki münferit bir malın ve hakkın devri mirasçılar arasında ancak mirasın paylaşılması yoluyla mümkündür.

3. Devir İşleminin Tarafları Bakımından Doğacak Farklar.

a) Devrin mirasçılar arasında yapılması.

Miras payının devri sözleşmesi mirasçılar arasında yapıldığında, baskın 1577
görüş uyarınca[1006], devredenin miras payı derhal devir oranında azalır ve devralanın miras payı artar. Şayet devreden tüm miras payını devretmişse,

---

[1002] *İmre/Erman*, 480; *Oğuzman*, 324; *Kocayusufpaşaoğlu*, 557

[1003] RG 18817; YKD 1985, S.8, s.1123 vd.

[1004] *Sungurbey*, Elbirliğiyle (İştirak Halinde) Mülkiyetin ne Olduğu ve Elbirliği ilişkisinin Yaşamsal Gücü, Yargıtay Dergisi, Özel Sayı 1989, 253 vd.; *Kocayusufpaşaoğlu*, Miras Ek Kitap, 55. (Yazar açık bir ifade kullanmamakla birlikte, bu görüşe eğilimli olduğu izlenimi vermektedir).

[1005] *İmre/Erman*, 480; *Oğuzman*, 323; *Özakman*, Miras Payının Devrine İlişkin Sözleşmeler, İstanbul 1984, 26; *Çilingiroğlu*, a.g.m., 560 vd.

[1006] *Escher*, Art.635, N. 10,11; *Guhl*, Gesamthandverhaeltnisse und deren grundbuchliche Behandlung, ZbJV 53, 5 vd; *Özakman*, a.g.e., 183 vd.

miras ortaklığından çıkar. "Miras payı devrine aynî etki tanıyan görüş"[1007] de denilen bu fikrin esas dayanağı, aşağıda belirteceğimiz üzere, miras payının mirasçı olmayan kişiye devri hâlinde bu kişiye paylaştırmaya katılma hakkı vermeyen MK 677/II hükmüdür. Bu hükmün zıt anlamından, miras payının diğer bir mirasçıya devri hâlinde, devralanın paylaştırmaya katılacağı, bir diğer deyişle, devir sözleşmesi yapılır yapılmaz devralanın bu miras payına sahip olacağı sonucu çıkarılmaktadır. Böylece, devralan buna göre paylaştırma isteyebileceği gibi, tenkis, denkleştirme, miras sebebiyle istihkak davası ve terekeyi koruyucu tedbirlere başvurma imkânları da devraldığı pay dikkate alınarak saptanacaktır.

1578 Bir diğer görüş, şayet devreden miras payını diğer tüm mirasçılara devretmişse[1008] o anda miras payının el değiştirdiği, diğer mirasçılardan sadece birine veya bazısına devretmişse devralanların sadece paylaştırma sonucunda devredene karşı ileri sürebileceği kişisel bir talep hakkı bulunacağı, şeklindedir[1009]. Bu görüş uyarınca, devre konu miras payının sadece bazı mirasçılara devri hâlinde hukukî sonuç, aşağıda belirteceğimiz üzere miras payının mirasçı olmayan kişiye devri ile aynı olacaktır.

1579 Üçüncü bir görüşe göre, mirasçıya yapılan devirlerde her bir devir sözleşmesinin yorumu yoluyla farklı sonuçlara varılabilir. Şayet devir sözleşmesinden pay devralanın derhal ve herkese karşı miras payının artmasının amaçlandığı anlaşılıyorsa, devir aynî etkili sayılmalı, aksi takdirde devralanın sadece paylaştırma sonucu devredene düşecek kısma ilişkin bir talep hakkına sahip olduğu kabul edilmelidir[1010].

1580 Kanımızca birinci görüş isabetlidir. MK 677/II hükmünde sadece mirasçı olmayan kişiye yapılan devirde payın devir anında intikal etmeyip devralana bir alacak hakkı sağlandığı belirtildiğine göre; diğer mirasçılara yapılan devirler, ister bazısına ister tümüne ister kısmen ister tamamen olsun, devir anında miras paylarını intikal ettirmelidir.

1581 Bununla birlikte, bu görüş çerçevesinde dahî, payını devredenin miras bırakanın alacaklılarına karşı tereke borçlarından MK 681 uyarınca 5 sene süreyle müteselsilen sorumlu olması[1011] kabul edilmektedir ki[1012] bu bizce de isabetlidir.

[1007] Terekede sadece aynî haklar bulunmadığından, bu pek isabetli bir ifade değildir. Bu ifade ile anlatılmak istenen, devralanın terekedeki her hak türüne devir anında ve herkese karşı hüküm ifade edecek şekilde sahip olmasıdır.

[1008] Bu durum "sübjektif kısmî paylaştırma" ya benzetilmektedir: *Kocayusufpaşaoğlu*, 554; *Oğuzman*, 325

[1009] *Tuor*, Art.635, N.12 vd.

[1010] *Tuor/Picenoni*, Art.635, N.20 vd.; *İmre/Erman*, 487.

[1011] Bkz. ileride § 37 IX 2

MK 677'nin karşılığı olan Eski MK 612/c.1'de miras payının diğer mi- 1582
rasçılara devrinin yanında mirasbırakanın sağ kalan eşine ortak çocuklarının miras paylarının devrinden de sözedilmiş olması, sağ kalan eşin intifa hakkını seçmesi olasılığına dayanmaktaydı. Zira, Medeni kanunumuzun eskiden tanıdığı bu intifa hakkını seçen eş, mirasçılık hakkına sahip olmazdı. Oysa artık sağ kalan eşin intifa hakkı seçmesi imkânı kanundan çıkarıldığına göre, esasen sağ kalan eş daima miras payına sahip olacağından, çocuklarının ona yapacağı pay devirlerinden özellikle sözetmenin anlamı kalmamıştı. Yeni Medeni Kanunda sağ kalan eşe yapılacak devirden sözedilmemiş olması isabetli olmuştur.

b) Devrin mirasçı olmayan kişiye yapılması.

MK 677/II hükmü bir mirasçının miras payını mirasçı olmayan kişiye 1583
devrini mirasçılar arasındaki devirden ayrı tutmuş, bu durumda noterde düzenleme şeklini şart kılmasının yanında, buna rağmen payın aynî etkili olarak el değiştirmeyeceğini, sadece devir alacaklısının mirasın paylaştırılması üzerine devredene düşen kısmı isteme hususunda bir alacak hakkı kazanacağını düzenlemiştir.

Hemen belirtelim ki bu hükmün uygulama alanı bulması, devirde bulu- 1584
nan mirasçı dışında mirasbırakanın en azından bir mirasçısı daha olmasını gerektirir. Şayet devirde bulunmak isteyen kişi terekeye tek başına mirasçı ise, esasen miras ortaklığı ve elbirliği hâlinde mülkiyet sözkonusu olmadan tek başına ve mirasın geçtiği anda tüm terenin sahibi olacağından, terekedeki tüm malları ve hakları kısmen ve tamamen dilediği kişiye devredebilir. Bu şıkta ortada devredilecek bir "miras payı" yoktur, külli halefiyetle terekeye tek başına malik olan bir kişi vardır ve her bir hakkın devri için Eşya Hukukunun ve Borçlar Hukukunun aradığı şartlarla (örneğin, taşınmazlarda tapu sicilinde resmî senet ve tescil, alacak haklarında alacağın temliki, taşınırlarda anlaşma ve teslim şeklinde) devir işlemleri yapması gerekir. MK 677/II birden çok mirasçıdan birinin payını devretmesini düzenlemektedir.

Mirasçılardan biri bu şekilde payını mirasçı olmayan kişiye devretmek 1585
üzere noterde sözleşme düzenlettirdiğinde, devralan sadece devredene karşı ileri sürebileceği şahsî bir hak kazanacağından, paylaştırmaya katılamayacak, tenkis, denkleştirme ve miras sebebiyle istihkak davaları açamayacak, terekenin korunması tedbirlerine başvuramayacaktır. Bir diğer deyişle, sadece şahsî sonuç doğuran pay devri sözleşmesi ile o mirasçı sıfatını kazanmış, miras şirketine katılmış değildir.

[1012] *Kocayusufpaşaoğlu*, 558; *Oğuzman*, 325

1586 Sözleşmede bunun aksinin kararlaştırılması da mümkün değildir. Zira, taraflar yaptıkları sözleşme ile üçüncü kişilere etkili haklar kazanamazlar.

1587 Bununla birlikte, şayet sözleşmede devreden ayrıca belli süre içinde mirasın paylaştırılmasını sağlamayı (örneğin, paylaştırma davası açmayı) üstlenmişse, bu yükümlülüğünü yerine getirmesini devralan ondan talep edebilir[1013]. Fakat kendiliğinden diğer mirasçılardan paylaşma talep edemez ve paylaştırmaya katılamaz. Bununla birlikte, devir sözleşmesinde veya sonradan kendisine paylaştırmaya yönelik olarak bazı işlemler yapma hususunda devreden mirasçı tarafından temsil yetkisi verilmişse, temsilci sıfatıyla hareket edebilir[1014].

1588 Doğrudan doğruya yasanın devralana tanıdığı bir imkân ise, MK m. 648 hükmüdür. Buna göre, bir mirasçıya düşen payı devralan veya haczeden yahut o mirasçı aleyhine aciz vesikası alan alacaklı, hakimden bu mirasçının yerine paylaşmaya katılmak üzere bir kayyım atamasını isteyebilir[1015]. Kanımızca, maddedeki diğer durumlarla birlikte, miras payını devralan üçüncü kişinin bu hükümdeki hakkını kullanarak hâkime başvurması üzerine, hâkim[1016] masrafı devralana ait olmak üzere devreden yerine paylaştırmaya katılmak üzere kayyım tayinine mecbur sayılmalı, paylaştırmanın devreden tarafından yapılmasında bir sakınca görmediğini beyan ederek devralanın talebini geri çevirme imkânı olmamalıdır.

1589 Her halükârda, paylaştırma tamamlanıp miras payını devredene düşen tereke unsurları onun mülkiyetine geçtikten sonra, payı devralan devir sözleşmesinin ifasını dava edebilir ve devralana düşen malvarlığı unsurları arasında taşınmazlar bulunsa bile, noterde düzenleme şeklinde yapılmış devir sözleşmesine dayanarak tescile zorlama davası açabilir ve hakim MK 716 uyarınca mülkiyetin geçmesine karar verir.

4. Açılmış Miras Payının Rehni Ve Haczi Sorunu

1590 Açılmış miras payı bir ayni hak oluşturacak şekilde rehne konu olamayacaktır. Zira soyut miras payı taşınmaz sayılamayacağına göre, taşınır rehni veya hakların rehni usulüne göre rehnedilmesi gerekecektir ki bu da mümkün değildir. Zira, miras payı rehin hakkı kazanacak kişiye teslim edilemeyeceğinden taşınır rehnine, münferit bir alacak hakkı olarak düşünü-

---

[1013] *İmre/Erman*, 482

[1014] *Kocayusufpaşaoğlu*, 551,552

[1015] Bu hükmün kıyasen açılmamış miras payını devralanlar lehine de uygulanabileceği görüşü için bkz. *Kocayusufpaşaoğlu*, 552,553

[1016] Bu hükme göre kayyım tayin edecek (Eski MK'na göre: devreden adına paylaştırmaya katılacak) olan hakimin paylaştırma dava ile gerçekleşiyorsa paylaştırmayı yapacak olan hakimden başkası olması gerektiği görüşü için bkz.. *İmre/Erman*, 484

lemeyeceğinden de alacak rehnine konu olamaz. Bununla birlikte, öğretide miras payının rehni sözleşmesinin (Eski MK 612 sadece adi yazılı şekli düzenlediğinden) yazılı şekilde yapılmak şartıyla, mirasın paylaştırılmasından sonra rehin kurmayı vaadeden mirasçıya kalacak mallar için "rehin verme taahhüdü" sayılmasını savunanlar vardır[1017]. Yeni MK 677/II hükmü karşısında bu görüş noterde düzenlenecek sözleşmeyi "rehin verme taahhüdü" sayacaktır. Kanımızca özellikle taşınmazlar bakımından böyle bir sözleşmenin ipotek kurma borcu doğuracağını ileri sürmek güçtür. Paylaştırma sonrası devir yükümlüsüne kalacak malları devretme taahhüdünü düzenleyen MK 677/II hükmüne kıyasen ipoteğin tapuda düzenlenen resmi senede dayanması kuralına istisna getirmek, yasayı aşırı zorlamak olur.

Miras payının haczinin ise mümkün olduğu kabul edilmektedir. Bu hem 1591
ekonomik değer taşıyan her varlığın –yasaca belirtilen istisnalar dışında- haczinin mümkün olması kuralından hem de MK 648 hükmünün açıkça miras payının haczinden sözetmesinden çıkartılmaktadır[1018]. Ancak, haczedilen miras payının miras payı olarak icra dairesince sattırılıp paraya çevrilmesi mümkün değildir. Hacizli alacaklı ancak MK 648 uyarınca hakimden paylaştırmaya kayyım atamasını isteyebilir ve paylaştırma sonucunda haczedilen payın sahibine düşen tereke mallarının sattırılmasını talep edebilir[1019].

§ 28. Gaipliğin Mirasın Geçmesinde Etkisi

Gaiplik aslında Medeni Kununun Kişiler (Şahsın) Hukuku kitabında m. 1592
32-35 hükümleri arasında düzenlenmiş olan, ölüm dışında kişiliğin sona ermesi hâlidir. Gaiplik konusundaki genel kurallar, gaiplik kararı alınmasının şartları, Kişiler Hukukuna ilişkin eserlerde yer alır. Bununla birlikte, gaipliğin en önemli sonuçları Miras Hukuku bakımından doğar. Bu bakımdan, Medeni Kanunun Miras Hukukuna ilişkin hükümleri arasında gaipliğe dair özel düzenlemeler vardır. Gaipliğin Miras Hukuku bakımından sonuçlarını aşağıdaki ayırımla ele alabiliriz.

[1017] *İmre/Erman*, 489

[1018] *İmre/Erman*, 489 vd.; Yarg.İc.İf.Dai. 5.12.1961 t. 10416/11515 sayılı kararı (Adalet Der., 1962, s.660).

[1019] *İmre/Erman*, 490, 491.; BGE 96 III 10; Yarg. 14.4.1943 t. Ve 48/15 Sayılı İç Bir Kararı (*İmre/Erman*, 490)
Aslında burada da hukukî bir zorlama vardır. Haciz miras payı üzerine konulmuş olmasına rağmen paylaştırma üzerine bu miras payına bağlı olarak kazanılan mallar ve haklar üzerine konulmuş sayılarak paraya çevrilme istenmektedir. Oysa teknik düşünülürse, paylaştırma sonucu borçlu mirasçıya düşen malların ve hakların ayrıca haczi gerekir. Fakat burada pratik sebeplerle, miras payına konulan haczin paylaştırmadan sonra kendiliğinden bu paya bağlı olarak kazanılan malların ve hakların üzerine geçtiği varsayılmaktadır.

I. GAİBİN MİRASI

1593 MK.32 vd. hükümlerine göre alınan gaiplik kararı, ölüm gibi kişiliği sona erdirir. Bu durumda, gaibin mirası ölmüş gibi açılır. Bu husus MK 35/I hükmünde "..ölüme bağlı haklar, aynen gaibin ölümü ispatlanmış gibi kullanılır." İfadesiyle belirtilmiştir. Aynı maddenin 2. Fıkrasında ise, gaiplik kararının ölüm tehlikesi veya son haber gününden itibaren hüküm ifade edeceği düzenlendiğinden; hakkında gaiplik kararı alınan kimsenin mirası, ölüm tehlikesi içinde kaybolmada bu kaybolma anında, çoktan beri haber alınamamada ise son haberin alındığı tarihte, açılır ve mirasçıların hakları doğar. Bu bakımdan, gaiplik kararı Miras Hukuku bakımından da geçmişe etkilidir. Gaibin mirasçılarının kimler olduğu, tasarruf oranının hesaplanmasına esas terekesi, gaiplik kararının verildiği tarihteki duruma göre değil, kararın hüküm ifade ettiği bu ana göre gözönüne alınacaktır. Sözgelimi, gaibin kaybolduğu tarihten sonra fakat gaiplik kararı alınmasından önce ölmüş bulunan eşi de ona mirasçı olmuş sayılacak ve başkasından olan çocuğuna (gaibin üvey oğluna) kendi terekesine intikal etmiş bu malvarlığını da geçirecektir.

1594 Gaiplik ne de olsa gerçek bir ölüm olmadığından, gaibin mirasçılarına hakim 584 hükmüne göre istenecek bu teminat, ölüm tehlikesinde kaybolma hâlinde terekenin mirasçılara tesliminden itibaren 5 yıl ve uzun süredir haber alınamama hâlinde ise son haberden itibaren 15 yıl içindir. Fakat, bu süreler dolmadan önce gaibin 100 yaşını doldurması hâlinde teminatlar kalkar. Keza, şayet Devlet mirasçı ise teminat verme yükümlülüğü yoktur. Gaibin öldüğünün kesin olarak ispatlanması üzerine de teminatların düşeceği kabul edilmektedir[1020].

1595 Teminatlar rehin, kefalet veya üçüncü kişinin fiilini taahhüt şeklinde olabilir. Teminatın türü ve miktarını hakim takdir eder. Teminatlar gerek sonradan ortaya çıkan gaibin gerekse terekedeki mallar üzerinde sonradan ortaya çıkacak üstün hak sahiplerinin (gaibin bir başka mirasçısının)[1021] korunması içindir. Zira, MK 585/I hükmünün zilyetlik kurallarına yaptığı yollama sonucu, sonradan bu kişilerin taleplerine muhatap olan mirasçılar şayet iyi niyetli iseler yani gaibin ölmediğini veya üstün hak sahiplerinin haklarını bilmiyor ve bilmeleri de gerekmiyorsa, MK 933 çerçevesinde, aldıkları mirastan sadece ellerinde kalanı iade ile yükümlü olacaklardır. İşte bu durumda, gaip veya diğer hak sahibi, isteyemedikleri kısmı bu teminatlardan tahsil edeceklerdir. Ayrıca, iyi niyetli olmayan mirasçının elden çıkar-

---

[1020] *Kocayusufpaşaoğlu*, 561

[1021] Örneğin miras gaibin kardeşine teslim edilmiş fakat daha sonra bir oğlu çıkmışsa, durum böyledir.

dığı malları tazmine yetecek malvarlığı bulunmayan durumlarda da teminatlar işe yarayacaktır.

Teminatların süresi dolduğu için sona ermesi ortaya çıkan gaibin veya 1596
üstün hak sahibinin hakkını düşürmez. Sadece teminatlardan istifade edememesi sonucunu doğurur.

Gaip ortaya çıkması durumunda mirasçıların tereke mallarını zilyetlik 1597
kuralları uyarınca geri vereceği belirtilmişse de (MK 585/I), bu terekede yer alan aynî haklar (taşınır - taşınmaz mallar üzerindeki haklar) bakımından sözkonusudur. Terekedeki alacak hakları, yenilik doğuran haklar gibi hakları ise gaip esasen hiç kaybetmediğini ileri sürmekle yetinecektir. Bu arada, aynî hak konusu malları eline geçiren kişinin iyi niyetli olması hâlinde kazandırıcı zamanaşımı yoluyla bunları iktisap etme ihtimali de unutulmamalıdır. Yeter ki eşya hukuku bakımından zamanaşımıyla iktisap şartları gerçekleşmiş olsun.

Üstün hak sahibi mirasçılar ortaya çıkarsa, bunlar terekedeki malları 1598
"miras sebebiyle istihkak davası" ile talep edeceklerdir (MK 585/II). Şayet malların teslim edildiği kişi iyi niyetli ise, MK 585/II uyarınca miras sebebiyle istihkak davasının zamanaşımı süresi (1 ve 10 yıl: MK 639/I) burada da uygulanacaktır[1022]. Şayet iyi niyetli değilse, madde metninin zıt kavramından anlaşıldığı üzere, miras sebebiyle istihkak davasının kötü niyetli zilyetler için getirdiği 20 yıllık süreye (MK 639/II'ye) de tabi olmayacak, sınırsız şekilde hakkını ileri sürebilecektir.

II. MİRASÇININ GAİPLİĞİ

Mirasçının gaipliği iki şekilde gündeme gelebilir. Kendisine miras ka- 1599
lan kişi ortadan kaybolmuş olup henüz hakkında gaiplik kararı alınmamıştır veya hakkında gaiplik kararı alınmış bir kişiye miras kalmıştır.

MK 586/I, hakkında gaiplik kararı bulunmadığı için o sırada mirasçı sı- 1600
fatını kazanmış görünen bir kişiye miras kaldığında, durum aydınlanana kadar bu kişinin miras payının mahkeme tarafından yönetileceğini öngörmüştür. Belirtelim ki, burada sadece kanunî ve atanmış mirasçıların bulunamaması sözkonusu olup, vasiyet alacaklısının ortada olmaması bu hükümlere girmez[1023].

Şayet ortadan kaybolan fakat hakkında gaiplik kararı alınmamış bulu- 1601
nan kişiye miras kalmışsa, MK 586/II uyarınca, bu kişinin yokluğu hâlinde ölene mirasçı olacak kimseler bu gaiplik kararı için ilgili hükümlere göre

---

[1022] Bkz. § 35 IV 1

[1023] *Escher*, Art.458, N.1; *Oğuzman*, 271, 272; *İmre/Erman*, 273

dava açabileceklerdir. Dava açma süresi, 33 uyarınca, ölüm tehlikesi içinde kaybolmadan itibaren 1 yıl ve çoktan beri haber almamada son haberden itibaren 5 yıl olacaktır. MK 33/III uyarınca bunlara, eklenen en az 6 aylık ilan süresi eklenecektir.

1602 Belirtelim ki, her şeyden önce mirasın açılma anının gaiplik kararının hüküm doğurma anından önce mi sonra mı olduğuna bakılmalıdır. Şayet gaibin mirasbırakanı gaiplik kararının hüküm ifade ettiği (ölüm tehlikesi içinde kaybolma veya son haber tarihinden) önce ölmüşse, gaip gene de mirasçı olmuştur ve miras paylaşımı onun varlığı dikkate alınarak yapılacağı gibi sahip olduğu miras payını da kendi mirasçılarına geçirmiş olacaktır. Şayet gaibin mirasbırakanı gaiplik kararının hüküm ifade ettiği andan sonra ölmüşse, karar tarihinden önce ölse bile, gaip mirasçı sıfatını kazanamamıştır. MK m. 586. maddesinde gözönüne alınan bu durumda, gaip mirasbırakanından önce ölmüş gibi miras paylaştırılır. Örneğin, (A)'nın kardeşi (B)'nin oğlu (C) ölüm tehlikesi içinde kaybolduktan sonra (B) ölmüştür. (C)'nin (E) adlı eşi hayattadır. (A) MK 586 uyarınca açacağı dava ile (C) hakkında gaiplik kararı alınca, (B)'nin öldüğü anda (C) yaşamıyor gibi, (A) kardeşi (B)'nin tüm mirasına sahip olabilecektir. Oysa, örneğin (C) (B)'nin ölümü anından sonra kaybolmuşsa, hakkında gaiplik kararı alınsa bile, kaybolmadan önce babası (B)'ye mirasçı olmuş sayılacağından, (A) kardeşi (B)'ye mirasçı olamayacak ve (C) kendisine babası (B)'den intikal eden tüm malvarlığını gaiplik kararı ile eşi (E)'ye bırakmış olacaktır.

1603 Esasen hakkında gaiplik kararı alınmış kişiye miras kalması, gaipliğe ilişkin genel hükümlere tabidir. Bu kişi mirasbırakandan daha önce ölmüş gibi miras paylaştırılır. Sonuçlar yukarıda belirttiğimiz gaiplik kararının hüküm ifade ettiği tarihten sonra ölen kişinin mirasının durumu gibidir.

1604 MK 58/I Hükmüne göre, bir kolaylık olarak, zaten gaipliğine karar verilmiş bir kimseye miras kalırsa, bu kişinin ölümü hâlinde ona mirasbırakana mirasçı olacak kimseler, ayrıca gaiplik kararı almak zorunda olmaksızın miras hisselerini talep edebileceklerdir. Aynı maddenin 2. fıkrasına göre, bunun tersi de mümkün olacak, yani gaip yerine mirasçı olacak kişiler bu gaiplik kararını almışlarsa gaibin kendi mirasçıları ayrıca karar almalarına gerek olmaksızın gaibin mirasını talep edebileceklerdir. Bu hüküm, başka maksatla ve başka kişiler tarafından alınmış gaiplik kararlarından çıkarı buna bağlı olan başkalarını da yararlandırarak hukukta ekonomi sağlamaktadır.

III. HAZİNENİN GAİPLİK KARARI ALMASI

1605 Hayatta olup olmadığı bilinmeyen bir kişi ortaya çıkmadığı ve hakkında gaiplik davası açan bulunmadığı için malvarlığı veya ona düşen miras payı

en az on yıldır mahkeme tarafından idare ediliyorsa[1024] veya on sene dolmamakla birlikte bu kişi yüz yaşını doldurmuşsa, MK 588 Hazineye gaiplik kararı talep etme görevi vermektedir.

Burada gaipliğin mahkemeye başvurma öncesi şartları (ölüm tehlikesi içinde kaybolmanın veya uzun süredir haber alınamamanın sözkonusu olması ve birincide 1 yıl ikincide 5 yıl geçmesi) aranmayacaksa da, Hazinenin mahkemeye başvurması ve mahkemenin en az 6 aylık ilan vermesi şartlarının aranacağı MK 588/II hükmünden anlaşılmaktadır[1025]. Üstelik bu hükme göre, bu ilan süresi içinde, sadece gaibin sağlığı hususunda gelecek haber değil, Hazineye tercihen hak sahibi olan bir başka kişinin (bir mirasçının) çıkması da malların Hazineye intikalini önleyecektir. Hazine bu gaiplik kararı ile yönettiği malvarlığını devralırken, teminat verecek değildir. MK 588/III uyarınca, hazine sonradan ortaya çıkacak olan gaibe veya mirasçılarına karşı daha önce gördüğümüz MK 585 hükmüne göre sorumlu olacaktır. 1606

Şayet malvarlığı veya miras payının Hazinece yönetimi on yılı veya ilgili kişi yüz yaşını doldurmuş olmasına rağmen henüz ortada bir gaiplik kararı bulunmamakla birlikte, hak sahipleri tarafından açılmış ve süren bir gaiplik davası varsa, Hazine gaiplik davası açamamalıdır. Aksi çözüm, hazinenin açacağı davada mahkemece verilecek ilan süresi içinde bu kişiler tarafından yapılacak başvurunun hükme engel olacağını düzenleyen MK 588/II hükmüyle bağdaşmaz. 1607

MK 588/I şartları gerçekleştiğinde, diğer mirasçılardan farklı olarak, Hazine gaiplik davası açmaya mecbur olup bu hususta takdir yetkisi yoktur. 1608

§ 29. Mirasın Geçmesinde Koruma Önlemleri

Mirasın açılması üzerine her ne kadar terekedeki haklar yasa gereği kendiliğinden mirasçılara intikal edecek ve vasiyet alacaklıları da kendiliğinden doğacak olan bu haklarını ileri sürebilecek ise de, yasaca, işin sadece bu hükümlere bırakılmayıp, mirasın paylaşılmasına kadar bazı koruma önlemleri getirildiği görülmektedir. MK 589 – 598 hükümleri arasında toplanan bu önlemlerin amacı, gerçek hak sahiplerinin saptanması ve tereke mallarının paylaştırmaya kadar korunmasıdır[1026]. Medeni kanunun bu hükümlerinin yanında, "Medeni kanunun velayet, Vesayet ve Miras hükümle- 1609

[1024] Bu hükmü karşılayan Eski MK 530, sadece malların idaresinden sözetmişse de, öğreti o zaman da bu ifadenin miras payının yönetimini de kapsadığı kabul edilmekteydi: *Kocayusufpaşaoğlu*, 563; *Oğuzman*, 272

[1025] *Oğuzman*, 272; *Kocayusufpaşaoğlu*, 564.

[1026] *Kocayusufpaşaoğlu*, 564; *Oğuzman*, 274; *İmre/Erman*, 276; *Serozan/Engin*, § 5, N. 57.

rinin Uygulanmasına Dair Tüzük" 29-39 hükümlerinde de sözkonusu önlemler düzenlenmiştir. Aşağıda bu önlemleri, yasanın sistemine uyarak ele alacağız.

I. TEREKENİN KORUNMASINA İLİŞKİN ÖNLEMLER

1610 Terekenin korunmasına ilişkin olarak aşağıda açıklanacak önlemleri MK 589/I uyarınca kural olarak mirasbırakanın yerleşimyeri sulh hâkimi alırsa da, MK 589/IV uyarınca, mirasbırakanın yerleşimyeri dışında bir yerde ölmesi hâlinde bu yerin sulh hâkimi, mirasbırakanın yerleşimyeri sulh hakimini haberdar ederek, kendi yetki alanındaki malların korunması için gereken önlemleri alacaktır. Mirasbırakanın yerleşimyerinin bulunduğu yer olmadığı gibi öldüğü yer de olmayan bir mahalde tereke malları bulunsa ve tedbir gerekse bile, o yerin sulh hakimi yetkisizdir. Bu konuda tedbiri yerleşimyeri hakimi almalıdır.

1611 MK 589/II, alınacak önlemleri, terekede bulunan mal ve hakların yazımı, terekenin mühürlenmesi, terekenin resmen yönetilmesi ve vasiyetnamelerin açılmasına ilişkin önlemler olarak saymaktadır.

1612 MK 589/III uyarınca, önlemlerle ilgili giderleri ileride terekeden karşılanmak üzere önlem için müracaaat eden kişi, şayet önlem re'sen hakim tarafından kararlaştırılmışsa Devlet karşılar.

1. Terekenin Defterinin Tutulması.

1613 MK 590 ve ilgili Tüzüğün 30. Maddesine göre terekenin deftere geçirilmesi şu durumlarda sözkonusu olur:

1614 1- Mirasçılardan birinin vesayet altına alınması veya vesayet altına alınmasının gerekmesi: Görüldüğü üzere, henüz hiçbir mirasçı mahkeme kararı ile kısıtlanmamış bile olsa, hâkim kısıtlanması gereken veya esasen tam ehliyetsiz olup kanunî temsilciden yoksun bir mirasçının varlığı hâlinde, bu durumu öğrenir öğrenmez önlem alabilecektir.

1615 2- Temsilcisi bulunmayan bir mirasçının uzun süredir ortada bulunmaması: Bunun gerçekleşmesi ortadan kaybolan mirasçının gaiplik kararı alma şartlarını taşımasına bağlı olmadığı gibi[1027], bir başka iş için atadığı temsilcinin bu mirasçının miras hukukundan doğan menfaatlerini koruyacak işlemler yapma hususunda yetkili olmaması hâlinde de temsilcisi yok sayılır.

1616 3- Mirasçılardan veya ilgililerden birinin ölüm tarihinden başlayarak bir

[1027] *Escher*, Art.553, N.8

ay içinde talepte bulunması: Görüldüğü gibi, yasa koyucu, ortada önlem alınması gereken somut bir tehlike bulunmamasına rağmen, bir mirasçının talebi üzerine hâkimi terekeyi mühürlemek ve defter tutmakla yükümlü kılmıştır. Burada hâkimin takdir hakkı yoktur. Ancak, mirasçı mirasbırakanın ölümden itibaren bir ayı geçirmişse, bu süreyi geçirmekte ne kadar mâzur olursa olsun, önlem için başvuramaz.

MK 590/II uyarınca, defter tutma işlemi gecikmeksizin tamamlanır. 1617
Gecikmeme şartı koruma önleminin niteliğinden doğmaktadır. Kesin bir süre öngörülmemesi isabetli olmuştur. Eski MK m.532/f.2 uyarınca, defter tutma işlemi mirasbırakanın ölümünden itibaren bir ay içinde tamamlanmalıydı. Bu sınırlayıcı hükme rağmen, öğreti ve uygulamada bu sürenin defter tutulması hususunda hak düşürücü bir süre olmayıp, sadece hâkime yönelik bir emir olduğu, yoksa bu süreden sonra da defter tutmanın talep edilebileceği (ve gereğinde hâkimin resen başvurabileceği) kabul edilmekteydi[1028]. Yeni düzenleme karşısında bu sorun çözülmüştür.

Burada incelediğimiz MK 590 uyarınca koruma önlemi olarak defter 1618
tutma ile ilerde açıklayacağımız MK 619 vd. hükümlerindeki defter tutma birbirine karıştırılmamalıdır. İlerde göreceğimiz ve çok daha ayrıntılı bir düzenleme olan MK 619 vd. hükümlerine göre defter tutma sonucu, mirasçıların bazı seçimlik hakları doğacaktır.

2. Terekenin Mühürlenmesi

Mühürleme, MK 591/I uyarınca, sadece MK 590 çerçevesinde yazımı 1619
gereken tereke mallarından hakim tarafından mühürlenmesi gerekli görünenler hakkında, talep üzerine veya re'sen uygulanan bir önlemdir. Gene MK 591/I uyarınca, Mühür altına alma işlemi, yazımdan önce de yapılabilir. Fakat şartları aynı olduğundan ve işin niteliği gerektirdiğinden, mühürlemeyi takiben hakim yazıma da karar vermek zorundadır. Buna karşılık, istisnaen, mühürlenmeyip mirasçıların zilyetliğine bırakılan tereke malları hakkında yazım (deftere geçirme) kararı alınabilir (Tüzük m. 30/f.4).

Mühürleme, bu önlemi gerektiren tereke mallarının mahkeme kararı ile 1620
kapalı bir yerde koruma altına alınarak, bu yerin kapısına veya bu yer bir dolap, çekmece vb. ise kapağına resmî mühür konulmasını ifade eder. Hâkim tereke mallarının bulundukları yerden alınarak bir depo veya banka kasasına taşınıp mühürlenmesine karar verebileceği gibi, bulundukları yerde, örneğin gene terekede yer alan mirasbırakana ait bir evin içinde evin kapısının veya bahçe kapısının mühürlenmesi suretiyle korumaya alınması-

---

[1028] *Kocayusufpaşaoğlu*, 567; *Oğuzman*, 275, 276; *İmre/Erman*, s. 278; Yarg. HGK 23.12.1972, E. 19970/2 K. 1308 (RKD Yıl 8 (1973) S.4-5, s.25 vd.

na da karar verebilir. Mühürle korumaya alınmış malları bu karar kalkmadıkça kimse –bu arada mirasçılar da- alamaz.

1621 MK 591/II'ye göre, tereke mühürlenirken mirasbırakanla birlikte oturanların ihtiyaçları için gerekli eşya bir tutanakla tespit edilip güvenilir kişi olarak kendilerine bırakılır. Taşınmazların onların oturmaları için zorunlu olan bölümleri, mühürlemenin dışında tutulur.

1622 Alacaklıların istemi üzerine yapılan mühürlemede MK 591/III özel iki sınır getirmiştir. Buna göre, alacaklıya yeterli teminat (güvence) gösterildiği takdirde mühürleme yapılmayacağı gibi, yeterli teminat gösterilemediği için yapılacak mühürleme de alacak miktarını karşılayacak kadar tereke malı ile sınırlı olacaktır. Ayrıca, alacak kadar tereke malının mühürlenmesi tamamlandıktan sonra mirasçılar alacaklıya yeterli teminat verirlerse, yapılmış mühürleme kaldırılacaktır.

3. Terekenin Resmen Yönetilmesi

1623 MK 592 hükümlerinde belirtilen durumlarda, yasakoyucu terekenin resmen yönetimini[1029] öngörmüştür. Resmen yönetimden maksat, terekenin paylaştırmaya kadar mirasçılar veya onların ortak temsilcisi tarafından değil, doğrudan doğruya sulh hâkimi tarafından atanan veya kanunun belirttiği bir kişi tarafından idare edilmesidir. Belirtelim ki, mirasçıların yönetim konusunda anlaşamamaları sebebiyle bir mirasçının talebi üzerine MK 640/III hükmü uyarınca hâkimin miras ortaklığına temsilci tayin etmesi, buradaki resmen yönetime girmez. Zira o temsilci koruma önlemi olarak atanmadığı gibi, aşağıda belirteceğimiz resmen yönetimde yapılacak bazı işlemleri yapma yetkisi bulunmaz.

a) Terekenin resmen yönetilmesi gereken hâller

1624 Terekenin resmen yönetiminin hangi durumlarda sözkonusu olacağı, genel olarak MK 592 hükümlerinde ve başka bazı maddelerde belirtilmiştir.

1625 MK 592 hükümlerine göre şu durumlarda resmen yönetim sözkonusu olur:

1626 1-Temsilci tayin etmeden ortadan kaybolan mirasçının çıkarının korunması için gerekli olması: Burada da –mühürleme ve yazımdaki gibi- mirasçının gaiplik şartlarıyla kaybolması gerekmez.

[1029] Bazı yazarların bu kurumu "mirasın resmen idaresi" olarak adlandırmaları (örneğin, *İmre/Erman*, 278) isabetsizdir. Zira burada, külli intikal ve paylaştırma gibi bir dizi hukukî olay bütünü olan "miras" kavramının idaresi değil, mirasa konu tereke mallarının bir süre mahkemece idaresi sözkonusudur.

2- Mirasçılık iddia eden bazı kişilerin bunu ispat edememeleri veya bazı mirasçıların bu sıfatlarının kuşkulu olması. 1627

3- Mirasbırakanın bütün mirasçılarının saptanamaması. 1628

4- Kanunda özel olarak öngörülen durumlar. 1629

MK 592/b.4'de belirtildiği üzere, başka bazı kanun maddelerinde de resmen yönetim düzenlenmiştir. Bunlar, a- MK 523/III göre artmirasçı atamada nakil ile yükümlü mirasçının teminat gösterememesi durumunda tereke mallarının; b- MK 586/I'e göre gaibin miras payının; c- MK 595/II'e göre vasiyete konu tereke mallarının; d- MK 634'e göre resmi tasfiyesine karar verilen terekenin resmen yönetimidir. 1630

Resmen yönetim sebeplerinden birinin varlığı hâlinde, sulh hakimi bir talep olmaksızın kendiliğinden resmen yönetime karar vermek zorundadır. 1631

b) Terekeyi Resmen Yönetmekle Görevli Kişi

MK 593/I uyarınca, kural olarak, terekenin resmen idaresine karar veren mirasbırakanın son yerleşimyeri sulh hâkimi, resmen yönetimi bizzat üstlenir veya bu işle kimi görevlendireceğine karar verir. Hâkim mirasçıların talebi ile bağlı olmayıp, uygun göreceği dilediği kişiyi serbestçe atar. 1632

Ancak, iki durumda resmen idare görevlisinin kim olacağını kanun belirlemiştir: MK 592/II'ye göre, mirasbırakan bir vasiyeti yerine getirme görevlisi atamış ise, mirasın resmen yönetimi bu kişiye verilir. MK 592/III'e göre, mirasbırakan velayet veya vesayet altında iken ölmüşse, mirasın resmen yönetimi ile veli veya vasi görevli olacaktır. 1633

MK 592/II, vasiyeti yerine getirme görevlisinin tereke yönetimini üstlenmesinde önemli bir engel bulunuyorsa, hakimin bir başkasını görevlendirmesine imkân tanımaktadır. MK 592/III de veli veya vasinin terekeyi yönetmesinde bir sakınca bulunan durumlarda hakime aynı yetkiyi vermektedir. Böyle açık hüküm bulunmayan Eski MK zamanında da öğretide ve uygulamada,i hâkimin bu kişileri uygun bulmaması hâlinde başkasını görevlendirebileceği kabul edilmekteydi[1030]. 1634

c) Resmen yönetimin yürütümü ve sona ermesi

Resmen yönetim görevlisi, tereke mallarının korunması, zarar görmemesi, başkalarınca el konulmaması için gerekli her türlü işlemi yapmaya yetkilidir. Bununla beraber, MK 593 hükümlerinde bazı görevleri somut olarak zikredilmiştir. Sınırlayıcı olmayan bu görevler şunlardır: 1635

[1030] *Kocayusufpaşaoğlu*, 571; *İmre/Erman*, 279; BGE 98 II 279

1636 1- Henüz yapılmamışsa terekenin yazımı,

1637 2- Gereken koruma önlemlerinin alınması,

1638 3- Mirasçıların menfaatlerine veya iyi bir yönetimin gereklerine uygun düştüğü takdirde terekedeki malların satılması,

1639 4- Mirasbırakanın alacaklarının tahsili ve borçlarının ödenmesi,

1640 5- Mirasçıların yasal haklarını zedelemediği anlaşılan vasiyetlerin, sulh hakiminin izni ve asliye hakiminin onayı ile yerine getirilmesi,

1641 6- Terekeye ait paraların faiz getirmek üzere tüzükte belirtilen bir bankaya yatırılması veya bu paralarla Devlet tahvili alınması ve yeterli güvencesi bulunmayan yatırımların güvenceli yatırımlara dönüştürülmesi,

1642 7- Terekede ticarethane, imalathane veya başka bir işletme varsa, bunların olduğu gibi sürdürülmesi; sürdürmede yarar yoksa, tasfiyesi için gerekli önlemlerin alınması.

1643 MK 598/II uyarınca, tereke yöneticisi, görevine giren konularda miras ortaklığının temsilcisi olup, ortaklık aleyhine açılan davalarda ve yapılan icra takiplerinde ortaklığı temsil eder ve gereken hallerde ortaklık adına dava açmaya, icra takibinde bulunmaya, davadan feragate, kabule sulh olmaya ve tahkime yetkilidir. Ancak, davaları ve takipleri mirasçılara ihbar eder.

1644 Resmen idare görevlisi her ne kadar mirasçıların kanunî temsilcisi ise de, bu onlar tarafından verilmeyen bir temsil yetkisi olduğundan, tereke mallarını koruma amacıyla sınırlı olarak, mirasçıların talep ve talimatlarıyla bağlı değildir[1031].

1645 Görevli, MK 593/III (son) uyarınca, mirasçılara karşı, niteliklerine uygun olduğu ölçüde vesayete ilişkin hükümlere göre (vasi gibi: MK 489-494 hükümlerine göre) sorumlu olacaktır. Yasa, sulh hakiminin resmî yönetime ilişkin olarak yaptığı işlemlerden dolayı sorumluluğunu da aynı hükümlere tabi tutmuştur.

1646 Resmen yönetim bir koruma önlemi olduğundan, resmî yöneticinin tasfiye ve mirasın paylaştırılması işlemleri yapmaya yetkisi yoktur[1032]. Ancak, yukarıda belirtildiği gibi, terekenin korunması için zorunlu ise, bir tereke malının satışını yapması veya başka bir malla değiştirmesi hususunda yetkili sayılabilir. Örneğin, bozulacak olan ve korunması daha büyük masrafa yol açacak bulunan malların satılıp bedelinin bankaya yatırılması böyledir.

[1031] *Escher*, Art.554, N.14; *Kocayusufpaşaoğlu*, 573

[1032] *Escher*, Art.554, N.14; *Tuor/Picenoni*, Art.554, N.18; *Kocayusufpaşaoğlu*, 573; *İmre/Erman*, 280

594/IV(son) uyarınca, sulh hakimi, terekeyi yönetmekle görevlendirilen kimseye, istemi hâlinde terekeden karşılanmak üzere uygun bir ücret ödenmesine karar verir. 1647

Resmen yönetim ve resmi yöneticinin yetkisi, MK 593/I uyarınca, resmen yönetme sebeplerinin ortadan kalkmasına ya da paylaştırmanın tamamlanmasına kadar devam eder. kural olarak, bu yetkili sulh hakiminin kararı ile belirlenecektir (Tüzük m.34). Hâkim bu koruyucu önleme gerek kalmadığını görünce, böyle bir karar verecektir. Fakat böyle bir karar verilmemiş bile olsa, mirasın paylaşılmasının tamamlanması ile bu ihtiyati tedbir ve resmî görevlinin yetkisi kendiliğinden sona erer[1033]. 1648

II. MİRASÇILARIN SAPTANMASINA İLİŞKİN ÖNLEM

MK 594 hükmüne göre, Mirasbırakanın mirasçısı bulunup bulunmadığı veya mirasçılarının bilinenlerden ibaret olup olmadığı hususları kuşkulu ise, sulh hakimi yapacağı bir ilanla hak sahiplerini başvurmaya çağıracaktır. Başka mirasçı bulunması kuşkusunu hakim takdir edecektir. Tamamen gerçek dışı bir iddia olduğu kesin olmadıkça, hakim en küçük bir kuşkunun kendisine ulaşması hâlinde bile bu önleme başvurmalıdır. MK 594/I uyarınca, ilan iki kere yapılacaktır ve ilanların arası bir ay olacaktır. İlanın uygun araçlarla yapılması öngörülmüştür. Uygun aracı hakim belirleyecekse de, bunun en azından bir ulusal gazetede yapılması gerekecektir. İkinci ilanda, bu ilanın çıkmasından itibaren en geç bir yıl içinde hak sahiplerinin sıfatlarını mahkemeye bildirmeleri istenecektir. MK 594/II uyarınca, bu süre doluncaya kadar başvuran çıkmaz ise ve sulh hakimi de hiçbir mirasçı tespit edememişse, miras Devlete geçecektir. Şayet mevcut mirasçılar varsa, tereke onlara verilecektir. Ancak, her iki durumda da bundan sonra ortaya çıkacak mirasçıların, süreleri içinde miras sebebiyle istihkak davası açma haklarının saklı olduğu belirtilmiştir. 1649

III. VASİYETNAMELERE İLİŞKİN ÖNLEMLER

1. Vasiyetnamenin Teslim (Tevdi) Edilmesi

MK 595/I-II hükümleri, mirasbırakanın ölümü hâlinde kendisi tarafından düzenlenmiş bir vasiyetnameyi bulan veya esasen böyle bir vasiyetname elinde bulunan herkesi bunu derhal yetkili merci olan sulh hukuk mahkemesine teslim etmekle yükümlü tutmuştur. Burada vasiyetname şeklî anlamda bir ifade olup, konusu ister belirli mal vasiyeti isterse mirasçı atan- 1650

[1033] *İmre/Erman*, 281

ması olsun, teslim yükümlülüğü vardır. Fakat miras sözleşmelerinin de aynı yükümlülüğe konu olup olamayacağı tartışmalıdır[1034].

1651 Teslim yükümü mirasçı olsun olmasın vasiyetnameyi bulan veya elinde tutan herkes için sözkonusudur. Vasiyetnameyi görevinden dolayı saklayan noterler veya diğer resmî görevliler de bu hükme göre mahkemeye tevdi ile yükümlüdür (MK 595/II)[1035]. Bir mirasçı vasiyetnamenin sadece kendisine kazandırmada bulunduğunu ve başkaca bir hüküm de içermediğini ortaya koysa dahî bunu tevdiden kaçınamaz. Vasiyetnamenin yerini bilen, bunun geçersiz bir vasiyetname olduğunu ileri sürerek de teslim yükümünden kurtulamaz. Teslim yükümü vasiyetnamenin içeriğinden ve geçerliliğinden bağımsızdır.

1652 Teslim yükümünü yerine getirmeyen kişi, mahkeme kararı ile teslime zorlanabileceği (elinden vasiyetname zorla alınabileceği) gibi; bu yükümünü ihlali sebebiyle doğan (örneğin, vasiyet alacaklısının hakkına geç kavuşması yüzünden uğradığı zararlar gibi) her türlü zararı da –yasadan doğan bir borca aykırılık sebebiyle- tazminle yükümlü olur[1036].

1653 Kanımca vasiyetnameye zilyet olmamakla birlikte, vasiyetnamenin nerede olduğunu bilen ve başka kimsenin bu yeri bilmediğinden veya diğer bilenlerin vasiyetnameyi saklamak yahut yok etmek istediklerinden haberdar olan kişilerin de, MK 595 hükümlerine kıyasen, mahkemeye başvurarak ihbarda bulunma yükümleri kabul edilmelidir.

2. Vasiyetnamenin Açılması

1654 Vasiyetnamenin açılması, MK 596 hükümlerine göre, mahkemeye teslim edilen vasiyetnamenin çağrılan mirasçılar huzurunda hâkim tarafından okunmasıdır. Vasiyetnamenin okunduğu bir tutanakta tespit edilip hazır bulunan ilgililerce imzalanır.

1655 Vasiyetname mirasbırakanın son yerleşimyeri sulh mahkemesi tarafından açılır. MK 596/I uyarınca, hakim vasiyetnamenin tesliminden itibaren bir ay içinde vasiyetnameyi açmak zorundadır. Hakim vasiyetnameyi açmadan önce bilinen mirasçıları ve diğer ilgilileri[1037] açılma günü ve saatini

---

[1034] Bu tartışma için bkz.. *Kocayusufpaşaoğlu*, 576, *İmre/Erman*, 282; *Oğuzman*, 278; *Escher*, Art.556; n.2; *Tuor/Picenoni*, Art.556, N.2. Genellikle, miras mukavelesinin üçüncü kişiler yararına ölüme bağlı karşılıksız kazandırmalar içermesi hâlinde, vasiyet hükümlerine tabi olması gerektiği düşüncesiyle, tevdi yükümüne konu olması kabul edilmektedir.

[1035] Ancak, Tüzük m.35/f.2 uyarınca, noter vasiyetnamenin aslını değil bir örneğini mahkemeye gönderir.

[1036] Eski MK 535'de açıkça belirtilmeyen bu sonuç, Yeni MK 595'de İsviçre Medeni Kanunu ZGB Art.556 da olduğu gibi, açıkça belirtilmiştir.

[1037] Örneğin, vasiyet konusu mal üzerinde intifa hakkı veya ipotek hakkı bulunanları.

belirterek davet eder. Daveti Tüzük 36/II uyarınca, uygun gördüğü bir yolla yapacaktır. Buna göre, adresi belli mirasçılara ve diğer ilgililere yazılı tebligatta bulunulurken, adresi bulunmayan fakat varlığı belirli olanlar için ilanda da bulunulabilir. Hakimin mahkemeden başka bir yerde (örneğin mirasbırakanın öldüğü evde) vasiyetin açılmasına karar vermesine yasal bir engel yok görünmektedir[1038]. Davet zamanı bazı mirasçılar gelmemiş de olsa, hatta hiçbir mirasçı gelmemiş de olsa, vasiyetname açılır. Aksi takdirde, örneğin, mirasçılara hep birlikte karşı oldukları bir vasiyet alacaklısının hakkını elde etmesini zorlaştırma imkânı tanınmış olurdu. Bu sebeple, vasiyetname, usulüne göre yapılan çağrıda belirtilen gün okunduğunda, haberleri olsun olmasın, orada bulunmayan mirasçılar bakımından da açılmış olur.

Şayet birden fazla vasiyetname farklı zamanlarda teslim edilmişse, hakim bu süreye uymak kaydıyla, mümkün oldukça bunları aynı gün açar. Fakat içlerinden en erken teslim edilmiş olanın tesliminden itibaren bir ayı geçirmemelidir[1039]. Teslimler arasında uzun süre geçtiği için birlikte açılamayan vasiyetnameler için hâkim ayrı davetlerle ayrı açılma günleri tespit edecek ve bunlar ayrı tarihlerde açılmış olacaktır. 1656

Bununla birlikte, bir ay içinde açılma kuralı hâkime yönelik bir düzen hükmü olup, usulüne göre davet ve toplantı yapıldıktan sonra, bu süreyi aşan bir tarihte vasiyetname açılması farklı bir hukukî sonuç doğurmamalıdır. 1657

Vasiyetnamenin açılması anından itibaren, İptal ve tenkis davalarının 10 yıllık süreleri[1040] ve bu vasiyetname ile atanmış mirasçının 3 aylık mirası red süresi işlemeye başlar. 1658

Uygulamada "vasiyetnamenin tenfizi" ifadesi sıklıkla kullanılmakta ise de, gerçekte hukukumuzda böyle bir kurum mevcut ve düzenlenmiş değildir[1041]. Olsa olsa, vasiyetnamenin usulüne göre açıldığının ve bir itiraza uğramadığının tespiti davası[1042]; vasiyetnamenin içeriğine göre, vasiyet konusu alacağın ifası davası veya mirasçı atanması söz konusuysa mirasçılık sıfatına ve külli halef olmaya bağlı davalar açılabilir. 1659

[1038] Oysa, Eski MK 536/II deki "..son ikametgahı sulh mahkemesine verilir ve orada açılır" ifadesi buna engel görünmekteydi.

[1039] *İmre/Erman*, 238'de, birden fazla vasiyetin bulunması hâlinde bir aylık müddetin son tevdi gününden başlayacağı belirtilmişse de, kanunun ifadesine ters düşen bu görüşe katılmıyoruz.

[1040] Bkz. § 18 III B 3 b; § 22 II 3

[1041] *Oğuzman*, 278, not 65a; *İmre/Erman*, 284

[1042] Yargıtay, uygulamada "tenfiz davası" olarak adlandırılan davaları bu tespit davaları olarak nitelendirmektedir. Bak. HGK 13.2.1991, E.1990/2-648 K.1991/65 (YKD 1991, S.6, s.822). Bu hususta bkz. *Kocayusufpaşaoğlu*, Ek Kitap, 54

3. Vasiyetname Örneğinin Tebliği

1660 MK 597 uyarınca, mirasta hak sahibi olanların her birine, masrafı terekeye ait olmak üzere, açılan vasiyetnamenin kendilerini ilgilendiren kısımlarına ilişkin onaylı bir örnek, hakim tarafından tebliğ edilir. Şayet bunlar arasında yerleşimyeri bilinemeyenler varsa, bildirim resmî bir ilanla yapılacaktır (MK 597/II).

1661 Öğretide maddenin ifadesinin yetersiz olduğundan bahisle, tüm mirasçılara ve vasiyeti yerine getirme görevlisine, vasiyetnamelerin tümünün birer örneğinin gönderilmesi gerektiği belirtilmektedir[1043].

§ 30. Mirasçılık Belgesi (Veraset İlamı)

1662 MK 598 hükümlerinde, yasal mirasçılara, mirasçı atananlara ve vasiyet alacaklılarına, bu sıfatlarını gösteren resmî bir belgeyi talep etme hakkı düzenlenmiştir. İşte bu belge "mirasçılık belgesi" veya uygulamada daha sık kullanılan adıyla "veraset ilamı"dır[1044].

1663 Veraset belgesi sayesinde, bir taraftan yasal ve atanmış mirasçılarla vasiyet alacaklılarının bu sıfatları aleniyet kazanmış ve böylece tereke malları üzerinde hak iddia etmeleri kolaylaştırılmış olacağı gibi; onların bu sıfatlarına itiraz edecek kişilerin uyarılması ve açacakları davalarda geçerliliğine karşı çıkacakları somut bir belgenin bulunması da sağlanmış olacaktır.

1664 Yasal mirasçıların talebi üzerine mahkeme, mirasbırakanın nüfus kayıtlarının bulunduğu nüfus idaresine yazı göndererek kayıtlarda mirasçısı görünen yakınlarının adlarını ve yakınlık bilgilerini istemekte ve gelen bu bilgilere göre saptadığı mirasçıları miras payları ile birlikte gösteren bir ilamı müracaat edene vermektedir. İlamda, bu bilgiler aleyhine dava açma hakkının saklı olduğu da çoğu kez belirtilmektedir.

1665 Noterlik Kanununda 6217 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik ve buna göre çıkarılan yönetmelikle[1045], mirasçılık belgelerinin noterlerce de verilmesine imkân sağlanmıştır. Ancak, kayıtların yeterli olmaması, mirasçılık belgesi verilmesinin yargılamayı gerektirmesi ve talep edenin yabancı olması hâlinde, talep kabul edilmeyecektir.

1666 Esasen MK 598/III hükmü, mirasçılık belgesinin geçersizliğinin her zaman ileri sürülebileceğini hükme bağlamıştır.

[1043] *Kocayusufpaşaoğlu*, 579; *Oğuzman*, 279; *Serozan/Engin*, § 5, N. 78.

[1044] Eski MK 538 hükmünde bu vesikanın sadece mirasçı atananlara verileceği düzenlenmişse de, uygulaması en çok yasal mirasçılar bakımından olmuştur.

[1045] 4.10.2011 Tarih ve 28074 sayılı R.G.

MK 598/II uyarınca, mirası atanan veya vasiyette bulunulan kişinin belge talep etmesi üzerine, diğer mirasçılara ve vasiyet alacaklılarına bu talep bildirilecek ve bu bildirimden itibaren bir ay içinde bu kişiler tarafından talepte bulunanların sıfatına itiraz edilmemesi hâlinde, istenen belge verilecektir. 1667

MK 598/III uyarınca, bu belge talep sahibi atanmış mirasçı veya vasiyet alacaklısına verildikten sonra da ilgililerin ölüme bağlı tasarrufun iptaline ilişkin dava hakkı saklı kalacaktır. 1668

Mirasçılık belgesi talebi mirasın açıldığı sulh mahkemesine yöneltilecek veya noterden talep edilebilecektir. Buna karşılık, henüz yasada sağ kalan eşin intifa hakkı seçme imkânı kaldırılmamışken bu hakkı seçmiş bulunan eşin, mirastan yoksun bırakılan, mirastan çıkarılmış bulunan, mirastan feragat etmiş olan veya mirası reddetmiş olan kişilerin de mirasçılık belgesi talep etmeleri mümkün değildir. 1669

Mirasbırakanın alacaklılarının da mirasçıları daha rahat takip etme gerekçesiyle onlar adına mirasçılık belgesi talep etme yetkileri yoktur[1046]. Onlar doğrudan mirasçılara ifa davası açarak alacaklarını takip edebilecekleri davada mirasçının sıfatı belirlenebileceği gibi, resmî tasfiye[1047] de isteyebilirler. 1670

Talep, mirasın açıldığı sulh mahkemesine çekişmesiz (nizasız) bir dava ile yöneltilecektir. Noterden talep edildiğinde, noter gerekli araştırmayı elektronik ortamda yapabilecek, burada yeterli bilgiye ulaşılamazsa nüfus müdürlüğünden yazıyla isteyecektir. Mirasçılık belgesinde sadece bunu talep eden atanmış veya kanunî mirasçı değil, tüm mirasçılar miras paylarıyla gösterilir. Bu bakımdan, mirasçılardan sadece birinin mirasçılık belgesi alması, diğer mirasçıların da -aksi ispat edilmedikçe- haklarının belgeye bağlanması anlamına gelir. 1671

Tüzüğün 38. Maddesine göre, bir aylık süre içinde iptal veya tenkis davası açmak da itiraz hükmündedir. Bir Ay içinde itiraz eden mirasçı veya vasiyet alacaklısı, bir yıl içinde iptal veya tenkis davası açmazsa, itirazın etkisi kalkar ve atanmış mirasçıya mirasçılık belgesi verilir. 1672

Mirasçılık belgesi aksi ispat edilebilen bir delil niteliğinde olduğundan, bir aylık itiraz süresini geçirmiş olanlar da bu belgenin alınmasına veya alındıktan sonra geçerliliğine itiraz edebilirler. Fakat bu kez, belge sahibinin mirasçı olmadığını ispat yükü onların üzerindedir. Oysa, bir aylık süre 1673

[1046] *İmre/Erman*, 287.
[1047] Bkz. § 33.

içinde sadece itiraz etmekle mirasçılık belgesinin verilmesini engelleyebilirler.

1674 Mirasçılık belgesinin ibrazı, gerek yasal gerekse atanmış mirasçılardan pek çok işlem bakımından pek çok merci tarafından istenmektedir. Örneğin, terekedeki taşınmazların intikali için tapuya başvurulduğunda sicil memuru bu belge olmaksızın mirasçılar adına tescil yapmamakta; terekedeki bir alacağın tahsili için mahkeme veya icra dairesine mirasçılık belgesi ile başvurulmakta; mirasbırakanın parasının veya kıymetli evrak vb. değerlerinin yattığı banka mirasçılık belgesi olmaksızın bunları mirasçılara teslim etmemekte veya haklarında herhangi bir işlem yapmamakta; Mirasçılığa bağlı herhangi bir hakkın korunması için mahkemeye başvurulduğunda mirasçılık belgesi ibraz edenin ayrıca mirasçılık sıfatını ispatı aranmamakta; hatta, Sosyal Sigortalar, Emekli Sandığı gibi sosyal güvenlik kurumları mirasçılık belgesi ibraz etmedikçe ölenin mirasçılarına dul ve yetim maaşı bağlamamaktadır.

1675 Usulüne göre mahkemece veya noterce verilmiş bir mirasçılık belgesine rağmen belge sahibinin mirasçı olmadığı veya belgede görülen oranda hak sahibi olmadığı sonradan mahkeme kararı ile anlaşılırsa, bu belgeye güvenerek işlem yapan kişilerin iyi niyeti gerçek mirasçı ve hak sahiplerine karşı korunmaz. Belgenin böyle bir işlevi yoktur. Ancak, geçersiz mirasçılık belgesi sayesinde tapuda bir taşınmazı adına tescil ettiren kişiden bu taşınmazı devralanın iyi niyeti MK 1023 uyarınca ve gene geçersiz mirasçılık belgesi sayesinde bir taşınıra zilyet olan kişiden bu taşınmazı iyi niyetle devralan kişinin iktisabı da MK 988 uyarınca korunur.

BEŞİNCİ KISIM
MİRASIN KAZANILMASI (İKTİSABI)

§ 31. Mirasın kazanılmasındaki (iktisabındaki) temel kurallar

I. KÜLLİ HALEFİYET

Türk ve İsviçre Hukukunda, Cermen Hukukundan gelen bir özellik ola- 1676
rak[1048], mirasbırakanın ölümü ile mirasa konu tüm malvarlığı hiç bir işlem, talep ya da süre gerekmeksizin, bir bütün hâlinde mirasçılara geçer. Sadece yasal mirasçılar değil, atanmış mirasçılar da bu şekilde kendiliğinden tereke üzerinde doğrudan hak sahibi olurlar. Ayrıca mirasbırakanın malvarlığında yer alan tüm haklar ve borçlar , kanuni istisnalar hariç, bir bütün olarak mirasçılara geçer. Bu hakların her birinin devrine ilişkin kurallar (örneğin taşınmazlarda tapuya tescil, taşınırlarda zilyetlik nakline, alacaklarda alacağın temliki anlaşmasına gerek bulunmadığı gibi; borçlar için borcun nakli hükümlerine uyulması da aranmaz. MK 599/I *"Mirasçılar, mirasbırakanın ölümü ile mirası bir bütün olarak kanun gereği kazanırlar" ve MK 599/II, "Kanunda öngörülen ayrık durumlar saklı kalmak üzere mirasçılar, mirasbırakanın ayni haklarını,alacaklarını, diğer malvarlığı haklarını taşınır ve taşınmazlar üzerindeki zilyetliklerini doğrudan doğruya kazanırlar ve mirasbırakanın borçlarından kişisel olarak sorumlu olurlar"* olarak ifade edilen bu kurala, bütün olarak yerine geçme anlamında külli halefiyet ilkesi denilmektedir. Bu kural uyarınca, mirasçıların hiç bir zaman fiili egemenliğine geçememiş tereke mallarına dahi (zilyetliğin *corpus* unsuru aranmadan) zilyet sayılacakları ve zilyetlikten kaynaklanan dava ve hakları (örneğin menkul davası) kullanabilecekleri kabul edilmektedir[1049]. Belirtelim ki, MK 599/I ve III, külli halefiyetin atanmış mirasçıyı da kapsadığını açıkca düzenlemiştir. Buna karşılık vasiyet alacaklıları, doğrudan terek üzerinde hak sahibi ve külli halef olamazlar, cüzi haleftirler. Onların durumunu aşağıda ayrıca inceleyeceğiz.

[1048] Buna karşılık Roma hukukunun ve Ortak (Müşterek) Hukukun sırf ölümle mirasçıların tereke üzerinde hak sahibi olmamaları, terekenin doğrudan mirasçılar tarafından kazanılmayıp, özellikle mirası kabul üzerine kazanmanın gerçekleşmesi bugün Franasız Hukukunda kabul edilen sistemdir.

[1049] *İmre/Erman*, 296; *Oğuzman*, 284.

1677 Her ne kadar kural derhal geçis ve külli halefiyet ise de, mirasbırakan öldüğü zaman sahip bulunduğu malvarlığının oldugu gibi ve mirasçıların iradesine bakılmaksızın geçişi (intikali) ve kazanılması, bazı bakımlardan adaletsiz sonuçlar doğurduğu için, kanunumuz bu sistemi yumuşatan bazı istisnalar kabul etmiştir.

1678 İlk olarak mirasbırakanın malvarlığının iradelerine,hatta bilgilerine bile gerek olmadan mirasçılara geçmesi sistemi, süreyle sınırlı da olsa, mirasçılara *mirası ret hakkı* tanınarak yumuşatılmış; böylece mutlak şekilde zorunlu mirasçılık önlenmiştir. Hatta terekedeki borçların haklardan fazla olması hâlinde reddi asıl sayan MK 605/II hükmü sayesinde, böyle bir durumda istisnai olarak mirasçılık ve halefiyetin otomatik şekilde gerçekleşmesi önlenerek; mirasçıların, kendilerinin yol açmadıkları borçlar sebebiyle mirastan zarar görmeleri engellenmiştir[1050]. Gene ret imkânı sayesinde terekenin,kendi dışındaki mirasçılara payları oranında verilmesini isteyen mirasçının, miras payının devri veya her bir hakkın devri ile uğraşmaktan kurtulması da sağlanmış bulunmaktadır. Keza kanun, reddin yanında *resmi tasfiye ve mirasın tutulan deftere göre kabulü* gibi seçimlik imkânları da getirerek, mirasçıları tereke borçlarından tamamen kurtarmamakla beraber, sorumluluklarını sınırlamalarını mümkün kılmıştır. Bütün bu durumları aşağıda ayrıntılı şekilde açıklayacağız.

1679 Ayrıca mirasbırakanın sahip oluğu bazı hakların ve borçların ölüm ile sona ereceği, böylece külli halefiyet veya başka bir yolla mirasçıya geçmeyeceği öngörülmüştür. Taraflardan birinin ölümü ile sona eren hukuki ilişkilerden doğan hak ve borçlar böyledir. Örneğin vekâlet sözleşmesi vekil veya müvekkilin ölümü üzerine, hizmet sözleşmesi işçinin ölümü üzerine (yapılacak iş şahsına bağlıysa işverenin ölümü üzerine), eser sözleşmesi müteahhidin şahsı gözönünde bulundurularak yapılmışsa müteahhidin ölümü üzerine, kural olarak sona erdiğinden; mirasçıların bu sözleşmeye taraf olduklarından söz edilerek, hak kazanıp borç altına girdikleri söylenemez[1051].

1680 Temsil yetkisi de, aksi kararlaştırılmadıkça veya aksi işin niteliğinden anlaşılmadıkça BK 43 uyarınca sona erecektir[1052].

[1050] Bu durumda mirasın kazanılması için, mirasçıların kabul beyanına gerek vardır. Keza, MK 613-614 hükümlerindeki özel durumlarda da bazı mirasçıların mirası kazanmaları, onlara yapılan beyanı kabul etmelerine bağlanmıştır.

[1051] Ancak,bu durumlara ilişkin olarak taraflara bazı haklar tanıyan özel hükümlerin (örneğin BK 441/II, 486, 513/II) dikkate alınması gerektiği gibi, kendi edimini ifa eden tarafın sebepsiz zenginleşme talebi ileri sürebileceği de unutulmamalıdır.

[1052] Ölümden sonraya etkili temsil yetkisi verme (mandatum post mortem) niteliği ve sonuçları son derece tartışmalı bir durumdur. Bkz. § 23, IV, 2.

Kişiler ve Aile Hukukuna ilişkin haklar kişiye bağlı olduğundan, kural olarak ölümle sona erer, mirasçılara geçmezler. Kişilik hakları, derneğe üyelik ilişkisi, boşama davası açma hakkı ve açılmış davayı sürdürme imkânı, nafaka davası açma hakkı[1053] velayet ve vesayet hakları, nesebin reddi davası açma hakkı mirasçılara geçmez[1054]. 1681

Manevi tazminat isteme hakkının mirasçılara geçip geçmeyeceği uzun süre artışılmışsa da, 4.3.1988 tarihli 344 sayılı Kanun ile eski MK'ya eklenen 24a/III, manevi tazminat talebinin miras yoluyla geçeceğini açık olarak ükme bağlamıştı. Bu hüküm biraz değişiklikle MK 25/IV'e alınmıştır. Şöyle ki eski MK 24/III manevi tazminat davasının hiç bir sınırlama olmadan mirasçılara geçeceğini kabul etmişken; MK 25/IV, hakkın geçmesini, mirasbırakan tarafından manevi tazminat isteminin ileri sürülmüş olmasına bağlamıştır. Bunun yanında, nişanın bozulması hâlinde istenecek manevi tazminat hakkının mirasçılara geçmesini özel olarak düzenleyen MK 85/II hükmü yeni MK 121 ile kaldırılarak, bu halde de mirasçılara geçme MK 25/IV hükmüne tabi tutulmuş böylece eski MK 24a/III ile yine eski MK 85/II arasındaki çelişki de giderilmiştir[1055]. Böylece bu gün bütün manevi tazminat isteme hakları, mirasbırakanın sağlığında, bu iradesini herhangi bir şekilde açığa vurmuşsa, mirasçılara geçecektir. 1682

Ayni haklar ise kural olarak mirasçılara geçerse de, irtifak haklarından intifa hakkı (MK 797) ve sükna hakkı (MK 823), hak sahibinin ölümüyle son bulur[1056] ve mirasçılara geçmez. Şahısla kaim olarak tesis edilen irtifaklar bakımından da aynı şey söz konusudur. 1683

II. VASİYET ALACAKLISININ DURUMU

1. Vasiyet alacaklısının sahip olduğu hak

Vasiyet alacaklısı, bizim hukukumuzda kendisine vasiyet edilen mal üzerinde doğrudan hak kazanmaz. Bu imkân sadece yasal ve atanmış mirasçılar için söz konusudur. Çünkü vasiyet alacaklısı, mirasçıların aksine 1684

[1053] Ancak Yargıtay mirasbırkakanın açtığı nafaka davasını onun ölümü üzerine mirasçıların, ölüm tarihine kadar işleyen nafakayı talep etmeleri şartıyla sürdürüp sonuçlandırabilecekleri görüşündedir: 2HD 6.5.1974, 2936/ 2795 (YKD 1975, 5).

[1054] Buna karşılık çocuğun tanınmasına itirazın (MK 298), çocuğun altsoyu tarafından dava konusu yapılabileceğinin, mirasbırakanın babalığına ilişkin davanın, mirasbırakanı ölmesi halinde mirasçılarına karşı açılabilmsinin (MK 301/II), miras yoluyla geçmeyip, doğrudan mirasçının şahsında ölümle doğan haktan kaynaklandığından, yukarıda (§1, II, 4,b) söz vedilmişti. Aksi görüş *İmre/Erman*, 95.

[1055] Etraflı bilgi için *Dural/Öğüz*, 7.5.4.6.2.

[1056] Buna karşılık, üzerinde intifa veya sükna hakkı bulunan taşınmazın malikinin ölümüyle bu haklar sona ermez.

külli halef değildir[1057]. Bu bakımdan, mirasçı olmayan vasiyet alacaklısı, tereke üzerinde tam hak sahibi olmayıp, vasiyet borçlusuna karşı ileri sürebileceği bir şahsi (alacak) hakkı kazanır. MK 601 hükmü bu hususu açıkça düzenlemektedir. Bu sebeple vasiyet alacaklısı, kendisine vasiyet edilen şey üzerindeki hakka ancak bu malın vasiyet borçlusu (mirasçı ya da mirasçılar, vasiyeti yerine getirmekle görevlendirilmiş kişi ya da alt vasiyette, vasiyet alacaklısı) tarafından usulüne uygun olarak kendisine devri (taşınmazlarda tapuda tescil, taşınırlarda zilyetliğin devri, alacaklarda alacağın temliki, kıymetli evrakta senedin teslimi) ile kazanır. Keza, vasiyet alacaklısı, BK 118 vd. hükümlerinin şartlarının gerçekleşmesi hâlinde, vasiyet borçlusunun, kendisinden olan alacağıyla takas yoluyla vasiyet alacağını ortadan kaldırmasına itiraz edemez.

1685 Mirasbırakanın, ölümü üzerine toplu para ödenmesi hususunda yaptığı sigorta sözleşmesinden doğan hakkını vasiyet etmesi hâlinde, MK 601/II'nin bunun kendisine temlikine gerek olmadan, vasiyet alacaklısı tarafından doğrudan doğruya, sigorta şirketine karşı iler sürme imkânını tanımış olması, vasiyet alacaklısının sadece vasiyet borçlularına karşı bir alacak hakkı elde ettiğinin bir istisnası olarak gösterilmektedir[1058]. Şayet, doğrudan sigorta sözleşmesinde ödemenin üçüncü kişiye yapılması öngörülmüşse, bunun vasiyet ile ilgisi olmadığı unutulmamalıdır.

1686 Vasiyet alacaklısının alacak hakkının hukuki sebebi olan vasiyet her ne kadar mirasbırakanın sağlığında yapılıyorsa da, bu bir ölüme bağlı tasarruf olduğundan, vasiyet alacağı ancak mirasbırakanın ölümü ile doğar. Burada, vasiyet alacağının muaccel olması değil de, doğumu söz konusu olduğundan, mirasbırakanın ölümünden önce vasiyet alacaklısının, ileride doğacak hakkını korumak için, başvurabileceği hiç bir hukuki yol yoktur. Örneğin, henüz mirasbırakan yaşarken, lehine vasiyeti içeren vasiyetnameyi bir üçüncü kişinin, yok etmek istediğini öğrense, buna karşı bir tedbir isteyemez. Yapılacak tek şey bunu vasiyette bulunan mirasbırakana haber vermektir.

1687 Vasiyet alacaklısı her ne kadar mirasçı değilse de, vasiyet alacağını iktisap etmesi için, mirasbırakanın ölümü anında, mirasa ehil olma bahsinde açıkladığımız ehliyet unsurlarına sahip ollması gerekir (MK 581/I). Örne-

---

[1057] Vasiyet alacaklısı mirasbırakana mirasçı gibi *külli halef* olmadığı gibi, kanımca, kendisine vasiyet edilen şey bakımından *cüzi halef* olarak da nitelendirilemez. Şayet Fransız Hukukundaki gibi mirasbırakanın ölümü üzerine vasiyet konusu şey kendiliğinden vasiyet lehdarının malvarlığına girmiş (eşyalar bakımından onun mülkiyetine geçmiş) sayılsa idi, cüzi halefiyetten sözedilebilirdi. Bizim hukukumuzda cüzi halefiyete tek örnek MK 601/II'deki mirasbırakanın yaptığı sigorta sözleşmesinden doğan hakkın vasiyet sebebiyle iktisabı olabilir.

[1058] Oğuzman, 285, dn. 95.

ğin, sağ olması, gaip olmaması, mirastan yoksun olmaması gerekir. Vasiyet alacaklısı, vasiyet alacağının doğduğu tarihte bir an için ehliyet şartlarına sahipse ve alacağı iktisap ettikten hemen sonra kaybetse ya da ölse, sahip olduğu alacak hakkı kendi mirasçılarına geçer ve zamanaşımı süresi dolmadıkça onlar bu alacağın ifasını talep ve dava edebilirler.

Vasiyet alacaklısı, mirasçı olmamasına rağmen, MK 616 ona (tıpkı mi- 1688
rasçı gibi) vasiyet alacağını reddetme hakkı tanır. Bu hüküm, alacak haklarının ibra anlaşması yapılmaksızın, sadece alacaklının tek yanlı beyanı ile ortadan kaldırılamayacağı kuralına istisna teşkil etmektedir. Mirasın reddinden farklı olarak, vasiyetin reddi için kanunda öngörülmüş bir süre bulunmadığından, vasiyet reddinin bir süreye bağlı olmadığı kabul edilmektedir[1059]. Ancak, vasiyet alacağını talep hakkının (az sonra açıklanacağı gib) MK 602'ye göre on yılda zamanaşımına uğrayacağı düşünülecek olursa, azami red süresinin de bu olacağını kabul etmek gerekir[1059a]. Bunun gibi, mirasçıların, vasiyet konusu şeyi ifa ile, borcu sona erdirecek olurlarsa red yine mümkün olmaz.

Vasiyet alacaklarının zamanaşımı MK 602'ye göre on yıldır. Esasen bu 1689
hüküm olmasaydı bile, aksine bir hüküm olmadıkça her türlü alacak hakkını on yıllık zamanaşımına tabi tutan BK 146 hükmüne göre de aynı sonuca varılacaktı. Zamanaşımı, MK 602 uyarınca vasiyet alacaklısının kural olarak vasiyetten haberdar edildiği günden itibaren işlemeye başlar. *Ancak bu hükmü, zamanaşımının vasiyet borçlusunun mirası reddetme hakkının sona ermesi ile başlayacağı şeklinde anlamak gerekir.* Çünkü, vasiyet alacağı bu anda muaccel olur. Aksinin, yani vasiyet alacağının zamanaşımının ölümle başlayacağını kabul etmek, daha muaccel olmadan zamanaşımını işletmek anlamına gelir ki bu da,hiç bir alacakta muaccel olmadan zamanaşımının işlemeyeceği kuralına aykırı olur. Bu açıklamalar göre zamanaşımı en erken, vasiyet borçlusunun red hakkının düşmesi ile işlemeye başlayacaktır. Kural bu olmakla beraber, eğer vasiyetnamede muacceliyetin daha sonra başlayacağı öngörülmüşse (örneğin geciktirici şarta bağlı bir vasiyet varsa), süre bu tarihtin itibaren işlemeye başlar (MK 602). Eğer vasiyet borçlusu birden fazla mirasçıysa, her biri için zamanaşımı (daha ilerdeki bir muacceliyet tarihi yoksa), kendisinin red hakkının düştüğü tarihte başlar. Vasiyeti ifa borçlusu olan mirasçıların, müteselsil borçlu olmaları BK 134/I uyarınca, burada hakkında en son zamanaşımı işlemeye başlayanın süresine diğerlerinin de tabi olması şeklinde yorumlanamaz. Çünkü MK 134/I, zamanaşımının kesilmesinin diğer müteselsil borçlulara sirayetini düzenlemiştir. Oysa burada, zamanaşımının kesilmesi değil, henüz müteselsil vasiyet borçluları için işlemeye başlamamış olması söz konusudur.

[1059] *Tuor/Picenoni,* Art. 562 N 7; *Oğuzman*, 287; *Kocayusufpaşaoğlu*, 596; *Serozan/Engin*, § 6, N. 16.

[1059a] Aynı yolda: *Serozan/Engin*, § 6, N. 51.

1690 Vasiyet borçlusu ya da borçlularının, mirasçılık sıfatını kazanamamaları veya mirası reddetmeleri üzerine, yerlerine geçen mirasçı ya da mirasçılar vasiyet borçlusu olurlar, yoksa vasiyet sona ermez (MK 519/II). Örneğin M, A'ya bir milyon lira vasiyet eder ve bu borcu oğulları C ve D'den sadece D'ye yüklerse, D'nin mirasbırakandan önce ölmesi ya da mirastan yoksun olması hâlinde, eğer D'nin yerini alacak altsoyu yok ise, vasiyet borçlusu sıfatı C'ye geçer. Buna karşılık D'nin F adında bir çocuğu varsa, D'nin yerini F alacağı için vasiyet borçlusu da o olur. Aynı şekilde, bir vasiyet alacaklısının aynı zamanda vasiyet borçlusu olduğu altvasiyette, vasiyet borçlusu olan vasiyet alacaklısı (önvasiyet alacaklısı) MK 519'da belirtilen sebeplerden biriyle vasiyete nail olamazsa, vasiyet borçlusu sıfatı yasal mirasçılara geçer (MK621/I).

1691 Vasiyet borçlusu ya da borçlularının talep üzerine vasiyet yerine getirmemeleri hâlinde, borçların ifa edilmemesine ilişkin BK 112 vd. maddeleri uygulanacaktır[1060]. MK 600/III, açıkca, vasiyeti yerine getirmeyen mirasçılara karşı, vasiyet alacaklısının, vasiyet edilen şeyin verilmesi için aynen ifa ve (kusur hâlinde) tazminat davası açabileceğini belirtmiştir. Eğer vasiyetin konusu belli bir miktar para ise, kuşkusuz genel hükümler çerçevesinde gecikme sebebiyle temerrüt faizi de işleyecektir. Vasiyet konusu para borcu, kural olarak mirasçıların red hakkının düştüğü tarihten itibaren muaccel olacağından, bu muacceliyet anı BK 117/II çerçevesinde önceden belirlenmiş bir tarih olmadığından, temerrüt ihtarından önce faizin işlemeye başlamaması gerekir. Buna karşılık, mirasbırakan vasiyetinde muacceliyeti daha sonraki bir tarih olarak belirtmişse, bu durum BK 117/II'ye girdiği için,bu tarihten itibaren temerrüt faizi kendiliğinden işlemeye başlar. Vasiyet borçlusunun kimliği kendisinden gizlendiği için zamanında ihtarda bulunamayan vasiyet alacaklısının, bu yüzden uğradığı zararını BK 122'ye göre ayrıca talep etmesi mümkündür.

1692 Vasiyet alacağı yukarıda belirtildiği gibi kural olarak genel hükümlere tabi ise de, bazı konularda vasiyet alacağına ilişkin özel hükümler getirilmiştir. MK 518/I uyarınca, vasiyet borçlusu, vasiyet edilen şeyi mirasbırakanın ölümündeki hali ile vermekle yükümlüdürler. Bu hüküm, para dışındaki vasiyetler (taşınır, taşınmaz mal, alacağın temliki ve diğer haklar) bir anlam taşır. Buna göre, vasiyet konusu mal, mirasbırakanın vasiyetnameyi düzenlemesinden ölümüme kadar, ister değer yitirmiş, eskimiş, azalmış; ister değeri artmış, üzerine değer artışı eklemeler yapılmış olsun, vasiyet alacaklısına ölüm anındaki bu şekli ile verilecek;ne vasiyet alacaklısı bu aradaki değer azalmaları için bir şey talep edebilecek, ne de vasiyet borçlusu ya da borçluları değer artışının karşılığını isteyebileceklerdir. Gene aynı

[1060] *Kocayusufpaşaoğlu*, 595/596; *Oğuzman*, 286; *İmre/Erman*, 299.

hüküm uyarınca, mirasbırakanın ölümüne kadar malın getirdiği semereler, mirasçılara ait olacaktır. Mirasbırakanın ölümünden sonra, mirasçıların vasiyet konusu şeye yaptıkları eklemeler şayet sökülüp alınabiliyorsa, mirasçılar tarafından sökülüp alınabilecek ve MK 518/II uyarınca bu mala, mirasbırakanın ölümünden sonra mirasçılar tarafınan yapılan masraflar ve sonra malın uğradığı zararlar hakkında vekâletsiz iş görme hükümleri (BK 526 vd) uygulanacaktır. Buna göre, mirasçıların yapmış oldukları zorunlu ve yararlı masrafların ödenmesi vasiyet alacaklısından istenebilecek; vasiyet borçlusunun kusuruyla sebep olduğu zararların tazminini de vasiyet alacaklısı ondan talep edebilecektir. Mirasbırakanın ölümünden sonra şeyin getirdiği semereler hususunda, bir görüş, sadece vasiyet borcunun muaccel olduğu tarihten önceki semerelerin vasiyet alacaklısına verilmesini öngörürken; diğer bir görüş mirasbırakanın ölümünden itibaren oluşan semereleri vasiyet alacaklısının isteyebileceği yönündedir[1061].

2. Vasiyet alacaklısının diğer hak sahipleri karşısındaki durumu

a) Mirasbırakanın alacaklılarına karşı

MK 603/I uyarınca, mirasbırakanın alacaklılarının hakları vasiyet ala- 1693
caklılarından önce gelir. Böylece, önce mirasbırakanın alacaklılarının hakları karşılanacak; geriye kalan terekeden vasiyet alacaklısının hakkı yerine getirilecektir. Bunun sebebi, mirasbırakanın borçlarından sorumlu tutulmayacak olan vasiyet alacaklısının mirasbırkakanın alacaklılarının haklarını almalarını da etkilememesi gerektiği şeklindeki mantık kuralıdır. Şu halde, mirasbırakanın alacaklılarının tüm alacaklarını tahsil etmelerinden sonra geriye kalan malvarlığından vasiyet alacaklısı hakkını alabilecektir. Belirtelim ki, mirasbırakanın alacaklılarının tatmin edilmesinden sonra geriye kalan kısım üzerinden vasiyet alacaklılarının hakları karşılandığında mirasbırakanın tasarruf nisabı aşılıyorsa, daha önce tenkis bahsinde anlatıldığı üzere, bu vasiyet alacakları tenkisi edilecektir. Tenkisin saklı paylı mirasçılar tarafından defi olarak ileri sürülmesi de mümkündür.

Şayet mirasbırakanın bir alacaklısı sonradan ortaya çıktığı için hesap 1694
değişip, bir vasiyet alacaklısına yapılan ifanın kısmen ya da tamamen geri verilmesi gerektiğinde, mirasçılar, vasiyet alacaklısına verdiklerinin, tenkis edilebileceği oranda tenkisini isterler (MK 604/I). Ancak geri verme yükümlüsü vasiyet alacaklısı MK 604/II uyarınca, sadece geri isteme zamanında elinde kalanı geri vermekle yükümlü olur. Burada, geri verme yükümlüsünün iyiniyetli olmamasının, yani dava açılmadan önce de mirasbırakanın sonradan ortaya çıkan alacaklısının kendi iktisabının geri verilme-

[1061] Bu konudaki tartışmalar için bkz., *İmre/Erman*, 301.

sini gerektireceğini bilmesinin, davadan önce elden çıkarttığı kısımdan dolayı sorumlu olmasını gerektirip gerektirmeyeceği tartışmalıdır[1062]. Kanımızca, MK 604/II hükmünün sözüne sadık kalınarak, vasiyet konusu edimi alanın aleyhine dava açılmasından önceki kayıplardan ve zararlardan, geri vermekle yükümlü olduğunu bilse de sorumlu tutulamayacağı kabul edilse bile; şayet vasiyet konusu şeyi, geri verme yükümünden kurtulabilmek için kasten elden çıkardığı ispat edilirse, geri verme talebini elinde kalanla sınırlaması hakkın kötüye kullanılması sayılarak MK 2/II uyarınca engellenmelidir. Belirtelim ki, vasiyet alacağı bir miktar para ise, uygulamada, bunun alındıktan sonra elden çıkartıldığı gerekçesiyle geri verme yükümü azaltılamayacaktır. Öte yanda, elden çıkarttığı şeye karşılık vasiyet alacaklısının bir başka şeyi iktisap ettiği ispatlanırsa, bu kaim değer (surrogat) mirasçılar tarafından tenkis konusu yapılabilmelidir.

b) Mirasçıların alacaklılarına karşı

1695 MK 603/I hükmü mirasçının alacaklıları ile vasiyet alacaklılarının önceliğini de düzenlemiştir. Buna göre, vasiyet alacaklılarının alacağı, mirasçının şahsi alacaklılarının hakkından önce gelir. Başka bir deyiş ile, önce vasiyet alacağı ödenir ve mirasçının alacaklıları ancak bundan sonra geri kalan üzerinde bir hak iddia edebilirler. Yani, mirasbırakanın alacaklılarından farklı olarak, mirasçının şahsi alacaklılarının, vasiyet alacaklıları karşısında bir öncelikleri yoktur. Ancak saklı paylı mirasçıların alacaklılarının, tenkis davası ile korundukları da unutulmamalıdır.

§ 32. Mirasın Reddi

I. KAVRAM VE ÇEŞİTLERİ

1696 MK 605 vd. maddelerinide düzenlenmiş olan mirasın reddi, mirasçıya, mirasçılık sıfatını kabul etmeme imkânını veren bir yoldur. Red, ya mirasçının iradesinden kaynaklanır ya da kanunun getirdiği bir karineden. Birinci halde *gerçek redden*, ikinci halde *hükmi redden* söz edilir.

1. Gerçek ret

a) Genel bilgiler

1697 *Mirasçılık sıfatını kazanmış olan mirasçının kendi iradesi ile bu sıfata son vermesine gerçek ret denir* (MK 605/I). Bu sebeple ret, ancak mirasın geçmesi (intikali), yani mirasbırakanın ölümünden sonra gerçekleşebilir.

[1062] Bu hususlaki tartışmalar için bkz., *Oğuzman*, 288, dn. 108.

Mirasbırakanın sağlığında bu sıfatı kazanmak istemeyen mirasçı, bu sonucu, mirasbırakan ile yapacağı bir mirastan feragat sözleşmesi ile temin edebilir[1063].

Ret için mirasçının bir irade açıklamasına gerek vardır. Bu bir bozucu 1698
yenilik doğuran irade beyanı olup, herhangi bir şekle tabi değildir. Yazılı ya da sözlü olarak mirasbırakanın son yerleşim yeri sulh mahkemesine yapılır (MK 609/I, 576). Yazılı ya da sözlü olarak yapılan beyanın belirli kelimeleri içermesi gerekmez. Önemli olan beyandan reddin açık olarak anlaşılmasıdır. Yapılan beyan, sulh mahkemesi tarafından bir tutanakla tespit edilir (MK 609/III) ve mahkemedeki özel kütüğe kaydedilir . Reddeden mirasçı isterse ona reddi gösteren bir belge verilir (MK 609/IV). Fakat şekle ilişkin hükümlere uyulmamış olması reddi geçersiz hale getirmez. Ret beyanı, MK 609'e uygun olarak yapıldığı andan itibaren hüküm ifade eder. Tutanağın tutulmamış, özel kütüğe yazılmamış olma (belki ispat yönünden zorluklar doğurabilirse de) reddin geçerliğini etkilemez. Ret beyanında herhangi bir gerekçe gösterilmesi aranmaz[1064].

MK 609/V, tutanağın ve kütüğün nasıl tutulacağının bir tüzükle düzen- 1699
leneceğini öngörmüştür. Bu tüzük daha çıkartılmış değildir. Ancak halen yürürlükte olan eski Medeni Kanun zamanında çıkartılmış olan Türk Medeni Kanununun Velayet, Vesayet ve Miras Hükümlerinin Uygulanmasına Dair Tüzük'ün 40. maddesi, yeni düzenlemeye aykırı hükümler içermediği için bu konuda uygulanabilir. Bu hükme göre, *"Medeni Kanununun (eski) 459. maddesine göre mirasçının mirası reddetmesi hâlinde, reddeden mirasçının açık kimliği tespit edilir ve ayrıca bir tutanak düzenlenerek mirası reddedene veya talep bu konuda yetkili olan vekil tarafından yapılmış ise vekiline imza ettirilip hakim ve zabıt kâtibince imzalanır. Vekilin vekâletnamesi de bu tutanağa eklenir; durum mahkemenin esas defterine işlenir. Red için başvuran kimseye, mirasın reddi amacıyla başvurduğuna dair, mahkemenin esas defter kayıt numarasını ihtiva eden, mahkeme mührü ile mühürlenmiş ve zabıt kâtibi tarafından kayda uygunluğunun tasdiki edilmiş bir belge verilir".*

Ret beyanında bulunan mirasçının fiil ehliyetine sahip olması gerekir. 1700
Ret beyanında bulunma, kişiye sıkı sıkıya bağlı bir hak olmadığı için, istenirse temsilci kullanılabilinir. Ancak temsilcinin özel yetkiye sahip olması

[1063] *Şener* (Miras 190) ve ona katılan *Oğuzman* (288, dn.110), bu halde feragatin ivazsız olması gerektiğini ileri sürüyorlar.

[1064] 2. HD 10.10.1974, 5670/5788 (*Şener*, Miras, 1221); 2. HD 22.4.1972 tarih ve 27233/2667 sayılı kararında, ananın çocuğu adına mirası reddetmesi için kayyım tayinini gerekli görmesi, ancak red dolayısıyla çocuk ile ananın menfaatlerinin çatışması hali için doğrudur (RDK, 1972, II/2, 2803).

gerekir[1065]. Tam ehliyetsizlik hâlinde ret beyanını yasal temsilci yapar. Ancak tam ehliyetsiz vesayet altındaysa, vasinin beyanına sulh ve asliye mahkemelerinin izninin eklenmesi gerekir (MK 463 b.5). Sınırlı ehliyetsizlerde ret beyanını yasal temsilci ya da onun rızası ile sınırlı ehliyetsiz yapabilir. Vesayet altındaki sınırlı ehliyetsizlerde MK 463 b.5 kuralı uygulanır. Ancak ister tam ehliyetsiz ister sınırlı ehliyetsiz olsun, velayet altındaki küçük adına velisi mirası reddediyorsa, menfaat çatışması gerekçesi ile küçüğe kayyım atanmalıdır. Şayet veli de mirasçı olup kendi adına da mirası reddediyorsa, menfaat çatışması yok gibi görünüyorsa da, bir başka çocuğuna çıkar sağlamak için böyle davranmış olabilir. Bu bakımdan, redden küçüğün zarar görmeyeceği belli olmadıkça kayyım atanması isabetli olur. Son olarak belirtelim ki, karı koca arasında mal ortaklığı rejimi varsa, eşlerden hiç biri, ortaklığa girecek olan bir mirası, diğerinin rızası olmadan reddedemez (MK 265/I). Karşı tarafın haklı bir sebep olmaksızın rıza göstermemesi hâlinde ya da rızasının alınması mümkün değilse, rıza için sulh mahkemesinde dava açılabilir (MK 265/II).

1701 MK 609/II'ye göre ret beyanı kayıtsız şartsız olmalıdır. Bunun tek istisnası, aşağıda açıklanacak MK 614'de öngörülmüş olan, *sonra gelen mirasçı (madun derece) lehine reddir*. Kanunkoyucu, reddin açık olarak anlaşılması gerektiği için bu hükmü koymuştur. Ret, bir kayda ya da şarta bağlanmışsa geçersiz sayılır ve reddeden mirasçı mirası kazanır, meğer ki geri kalan süre içinde kayıtsız ve şartsız yeniden ret beyanında bulunsun[1066].

1702 Reddin kayıtsız şartsız olması kuralı *kısmi reddi* engeller mi? Eğer kısmi ret bir kayıtlı ret niteliğindeyse geçerli olmaz. Örneğin *taşınırları ret, taşınmazları kabul ediyorum* şeklindeki bir red, kayıtlı ret olduğu için geçersizdir. Buna karşılık miras payının kesirli bir bölümünün reddedilmesi (örneğin yarısını ret), bir kayda ya da şarta bağlanmış değil de içeriği sınırlandırılmış bir ret olduğu gerekçesiyle geçerli kabul edilmektedir[1067].

1703 Bir kimsenin hem yasal hem de atanmış mirasçı olması hâlinde, birini kabul edip diğerini reddetmesi kural olarak mümkündür, fakat anlamsızdır. Çünkü birinden birinin reddi hâlinde, reddeden diğer sıfatı ile mirasçı kalmaya devam edeceğinden, redle izlediği amacı elde edemez. Örneğin borçlardan kurtulmak amacıyla yasal ya da atanmış mirasçılığı reddeden kişi, diğer mirasçı sıfatı devam edeceği için yine borçlardan sorumlu kalmaya devam edecektir[1068].

[1065] Bkz., *Serozan/Engin*, § 6, N. 45; *Kocayusufpaşaoğlu*, 604, dn. 12'de anılan yazarlar ve *Helvacı*, 69.

[1066] *Escher*, Art. 570 N 16; *Tuor/Picenoni*, Art. 570 N 13; *Kocayusufpaşaoğlu*, 606; *Oğuzman*, 298, dn. 113; *İmre/Erman*, 313. *Helvacı*, 57.

[1067] Bkz., *Kocayusufpaşaoğlu*, 605 ve orada dn. 14'e anılan yazarlar; ayrıca, *İmre/Erman*, 313; *Helvacı*, 64.

[1068] Krş., *Helvacı*, 66.

Ret yenilik doğuran bir irade açıklaması olduğu için, sulh hakimine ulaştığı andan itibaren hüküm doğurur ve bu andan sonra geri alınamaz[1069]. Ancak bazı yazarlar, bütün mirasçıların rızasının bulunması şartıyla geri almanın mümkün olduğu görüşündedirler[1070]. *Kocayusufpaşaoğlu*[1071] ise, konunun hassasiyetinden hareketle, sadece mirasçıların değil, tüm ilgililerin rızasının aranması gerektiği görüşündedir. Yazara göre, ilgililer kavramına, mirasçıların yanında reddeden mirasçının alacakları da girer. 2.HD 1944 tarihli bir kararında[1072], bütün ilgililerin rızası ile redden dönmeyi geçerli kabul etmiştir. Ancak kararda, ilgililerin rızası yanında, reddin hata, hile ya da ikrah ile sakat olup olmadığının da araştırılması gerektiği belirtildiğinden, reddin geri mi alındığı yoksa yoksa irade sakatlığı sebebiyle iptal mi edildiği açık olarak anlaşılamamaktadır[1073]. 1704

Geçerli bir reddin geri alınması mümkün değilken, irade bozukluğuyla sakat olan bir red beyanının MK 23 vd. hükümlerine göre iptal edilmesi mümkündür[1074]. İptal etme, aynı zamanda mirası kabul etme şeklinde yorumlanabilirse, artık red hakkı da düşer. Bu yorumun yapılamadığı hallerde, mirasçı ret süresi içinde yeni bir beyanda bulunabilir. Bu arada ret süresi dolmuşsa, mirasçıya MK 616'ya göre yeni bir süre verilir[1075]. 1705

b) Ret hakkının düşmesi

Ret hakkı MK 606 ve 610/I'e göre şu hallerde düşer: 1706

aa) Sürenin dolması

MK 606/I'e göre, ret süresi üç aydır. Ret beyanı yenilik doğuran bir beyan olduğu için, üç aylık süre hak düşürücü süredir; durması ya da kesilmesi söz konusu olamaz. Beyanın süresi içinde kullanılmış sayılması için üç ay içinde mahkemeye ulaşmış olması gerekir. Süreye uyulup uyulmadığını mahkeme inceler.[1076] Süresi içinde reddetmeyen mirasçı, mirası kayıtsız şartsız kabul etmiş sayılır (MK 610/I). Susma burada,ana kuralın aksine, olumlu bir irade açıklaması anlamına gelmektedir. 1707

Ret süresinin başlangıcı, yasal mirasçılar için, ölüm ve kendi mirasçılı- 1708

[1069] 2. HD 10.6.1973, 3569/ 3616 (*Şener*, Miras, 1222); 2.HD 12.9.1978, 5695/5977 (*Şener*, Miras, 1222.

[1070] *Davran*, 331 vd; *Tuor/Picenoni*, Art. 570 N 6; *İmre/Erman*, 314.

[1071] *Kocayusufpaşaoğlu*, 606. *Helvacı*'nın da (110) bu görüşe katıldığı anlaşılmaktadır.

[1072] 2.HD 30.3.1944, 5381/5860 (*Olgaç*, MK I, No. 1684).

[1073] Krş., *Kocayusufpaşaoğlu*, 606, dn.18; Helvacı, 110

[1074] 2.HD 27.11.1959, 6381/5860 (*Şener*, Miras, 1223); 2.HD 12.9.19785695/5977 (*Şener*, Miras, 1222); 2.HD 12.12.1976, 8867/ 9200 (*Şener*, Miras, 1224)

[1075] *Kocayusufpaşaoğlu*, 607; *Oğuzman*, 290; *Helvacı*, 116.

[1076] 2. HD 22.4.1972, 2723/6667 (RKD 1972,II/2, 280.

ğını öğrendiği andır (MK 606/II). Daha açık bir deyişle, yasal mirasçılar için kural olarak süre mirasbırakanın ölümü ile işlemeye başayacaktır. Ancak, yasal mirasçı, kendisinin mirasçı olduğunu mirasbırakanın ölüm tarihinden daha sonraki bir zamanda öğrenmişse, süre ölümle değil, bu öğrenme ile işlemeye başlar. Bu bakımdan bu iki öğrenmenin birlikte bulunması gerekir.

1709 Vasiyetname ile atanan mirasçı için süre, MK597'ye göre lehine olan tasarrufun kendisine resmen bildirilmesiyle işlemeye başlar (MK 606/II). Ancak bildirim için de ölüme bağlı tasarrufun açılmış olması gerekir. Açılma ve tebliğ MK 596'ya göre sadece vasiyetnameler için söz konusu olduğuna göre, acaba, miras sözleşmesi ile atanan mirasçı için süre ne zaman işlemeye başlar. Bu konuda MK 606/II'de bir hüküm bulunmamaktadır. Kabul edilen baskın görüşe göre, miras sözleşmelerinde ret süresinin başlangıcına yasal mirasçılara ilişkin MK 606/II hükmü örneksemeyle uygulanır. Buna göre, miras sözlemesiyle mirasçı atanan kimse için ret süresi, mirasbırakanın ölümü ile başlayacaktır[1077]. Miras sözleşmesi ile mirasçı atanan kimsenin elinde miras sözeşmesinin bir sureti bulunacağı için, mirasçılık sıfatını daha sonra öğrenmesi sebebiyle, ret süresinin başlangıcının, bu sebeple daha ileriye atılması pek söz konusu olamaz. Miras sözleşmesiyle bir üçüncü kişi mirasçı olarak atanmışsa, onun için ret süresi, vasiyetname ile mirasçı atanması hükmüne tabi olur. Çünkü yukarıda da değinildiği gibi[1078], üçüncü kişi lehine olan miras sözleşmeleri, tıpkı vasiyetnameler gibi, açılır ve ilgiliye tebliğ olunur.

1710 Belirtmek gerekir ki, bir halde ret süresi hem yasal hem de atanmış mirasçılar için aynı anda işlemeye başlar ki, bu hal MK 607'de öngörülmüştür. Bu hükme göre, *"Koruma önlemi olarak terekenin yazımı hâlinde mirası ret süresi, yasal ve atanmış mirasçılar için yazım işleminin sona erdiğinin sulh mahkemesi tarafından kendilerine bildirimiyle başlar"*. Hemen belirtmek gerekir ki bu hüküm, açık ifadesinden anlaşılacağı üzere, sadece koruma önlemi olarak terekenin yazımının (ihtiyati tedbir niteliğinde defter tutulması) söz konusu olduğu hallerde uygulanır, yoksa MK 619'da öngörülmüş olan terekenin resmen defterinin tutulduğu hallerde değil...

1711 MK 615, sulh mahkemesine üç aylık ret süresini (henüz dolmamışsa) uzatma ya da (dolmuşsa) yeni bir süre tanıma imkânı vermektedir. Ancak,

---

[1077] *Escher*, Art. 570 N 17; *Tuor/Picenoni*, Art. 570 N 7; *Oğuzman*, 291; *Kocayusufpaşaoğlu*, 609; *Helvacı*, 82; *İmre/Erman* (311), miras sözleşmelerinin de açılıp tebliğ edileceğini kabul ettikleri için, süreyi tebliğ tarihinden itibaren işletmeye başlatırlar. Ancak miras sözleşmesinin yetkili mercie tevdi edilmemiş olması halinde, sürenin ölüm ve sıfatın öğrenilmesi ile başlayacağını kabul ederler.

[1078] Bkz., yukarıda IV,2, f.

bunların şartı, haklı bir sebebin bulunmasıdır. Kanunun öngördüğü üç aylık süre içinde karar vermenin fevkalâde zor olması ya da karar veme imkânının yokluğu haklı sebep sayılır. Bir başka deyişle üç ay içinde mirasçıdan karar vermesini beklemek hakkaniyete aykırı ise süre, haklı sebebin bulunması dolayısıyla uzatılır ya da yeni bir süre verilir. Böyle bir durumun olup olmadığını hakim her her olaya göre ayrı değerlendirir. Tereke mallarının dağınık olması, mirasçının sürekli hasta olması, ayırt atme gücünü kaybetmiş ve henüz yasal temsilci atanmamış olması, yabancı bir ülkede ikamet etmesi haklı sebebe örnek olarak gösterilebilir.

Önemle belirtmek gerekir ki, MK 615, sadece red süresinin susarak ge- 1712
çirilmesi hâlinde uygulanır. Ret hakkının, hemen aşağıda (bb)'de incelenecek olan sebeplerden biri ile süre geçmeden kaybında uzatma ya da yeni bir süre verilmesi söz konusu olamaz.

Bu konuya son vermeden önce red hakkının geçmesi üzerinde duralım. 1713
MK 608, ret hakkının geçmesi yönünden iki ihtimali düzenlemektedir.

a)Bunlardan ilki, ret hakkına sahip olan mirasçının, ret hakkının kul- 1714
lanmadan ve ret süresi dolmadan ölmesi hâlinde, onun yerine kaim olan mirasçının mirası hangi süre içinde reddedeceğidir. MK 608/I'e göre,ölen mirasçının ret hakkı, yerini alan mirasçıya geçer. O halde, ölenin yerini alan mirasçının iki ret hakkı bulunacaktır. Bunlardan biri, kendi mirasbırakanından kalan mirası ret hakkı; diğeri de, kendi mirasbırakanına onun mirasbırakanından kalan miras ret hakkıdır. Burada dikkat edilmesi gereken husus şudur: mirasçı her iki mirası da reddedebileceği gibi, sadece kendi mirasbırakanına kalan mirası da reddebilir. Buna karşılık kendi mirasbırakanından kalan mirası ret, fakat kendi mirasbırakanına kalan mirası kabul edemez. Çünkü ilk miras, ona, mirası reddetmeden ölen kendi mirasbırakanın terekesinin bir parçası olarak intikal etmektedir. Bu bakımdan, tamamı reddedip, tamamın bir parçasını kabul etmesi mümkün değildir[1079].

Şimdi cevaplandırılması gereken husus, ilk mirasbırakanın mirasını 1715
reddetme süresinin ne olacağıdır. MK 608/II, burada iki farklı süre öngörmüştür. Bunlardan birincisi, ortak süre olup[1080], mirasçının kendi mirasbırakanından kalan mirası reddetme süresidir. Yani mirasçı, hem kendi mirasbırakanından intikal eden mirası hem de dolaylı olarak kendisine geçen mirası, kendi mirasbırakan ölümü ve kendi mirasçılık sıfatını örendiği andan itibaren üç ay içinde reddebilir. Örneğin A, babası B'nin 20 Haziranda öldüğünü öğreniyor, fakat kendisi de 15 Temmuzda, daha ret süresi sona

---

[1079] *Tuor/Picenoni*, Art. 569 N 5; *Escher*, Art. 569 N; *Kocayusufpaşaoğlu*, 613; *Oğuzman*, 294.

[1080] Bu terim için bkz., *Tuor/Picenoni*, Art. 569 N 11.

ermeden ölüyor. B'nin ölümünü babası ile aynı anda öğrenen C, kendi babası A'nın ölümünü 10 Ağustosta öğreniyor. Bu durumda C'nin hem A'nın hem de B'nin mirasını reddebilme süresi, ortak süre olan 10 Kasımda sona erecektir. Bundan da anlaşılacağı üzere, ilk mirası reddetme süresi, mirasçının kendi mirasbırakanından kalan mirası reddetme süresinden hiç bir zaman daha kısa olamaz.

1716 Bu ortak süre yanında MK 608/II c.2, bir de ilk mirasın reddi yönünden bağımsız bir süre öngörmüştür. Bu sürenin başlangıcı, ret hakkına sahip olan mirasçının, birinci mirasın kendi mirasbırakanına intikal ettiğini öğrendiği andır. Kuşku yoktur ki, ret hakkı sahibi, aynı zamanda kendi mirasbırakanın da öldüğünü ve kendisinin de mirasçı olduğunu öğrenmiş olması gerekir. Yukarıdaki örnekte, C'nin, A'nın B'ye mirasçı olduğunu 10 Eylülde öğrendiğini varsayalım. Bu halde, A'nın mirasını ret hakkı yine 10 Kasımda sona ererken, B'nin mirasını ret hakkı 10 Aralıkta sona erecektir. Görüldüğü gibi, bağımsız sürenin, sadece ret hakkına sahip olan mirasçının, kendi mirasbırakanına miras intikal ettiğini, kendisine, kendi mirasbırakanından miras intikal etiğini öğrenmesinden daha geç öğrenmesi hâlinde bir pratik değeri vardır.

1717 b) MK 608'de düzenlenmiş olan ikinci durum,birinci mirasçının mirası reddetmesi hâlinde, onun yerini alan ikinci mirasçı için ret süresinin başlangıcının ne olacağıdır. Bunun cevabı MK 608/III'de verilmektedir. Buna göre, sürenin başlangıcı, ilk mirasçının mirası reddettiğini ve mirasın kendisine geçtiğini öğrenmedir ve süre yine üç aydır.

bb) Süre dolmadan ret hakkının düşmesi

aaa) Açık kabul beyanı ile ret hakkının düşmesi

1718 Mirasın kabulü için kural olarak bir beyana gerek yoksa da, mirasçı daha ret süresi dolmadan açık bir kabul beyanında bulunursa ret hakkı artık düşer.

bbb) Tereke işlerine gereğinden fazla karışma nedeniyle ret hakkının düşmesi (örtülü kabul)

1719 MK 610/II'ye göre, *"Ret süresi sona ermeden mirasçı olarak tereke işlerine karışan, terekenin olağan yönetimi niteliğinde olmayan veya mirasbırakanın işlerinin yürütülmesi için gerekli olanın dışında işler yapan..... mirasçı, mirası reddemez"*. Hükümden anlaşılacağı üzere, mirasçılardan birinin tereke işlerine gereğinden fazla[1081] karışmasını kanunkoyucu örtülü (zımni) kabul olarak görmüş ve tıpkı açık kabulde olduğu gibi, ret hakkının

[1081] Bu terim için bkz., ZGB Art. 571.

sona ereceğini belirtmiştir. Ne zaman mirasçının davranışının tereke işlerine gereğinden fazla karışma (kanunun deyişi ile, olağan yönetim niteliğinde olmayan ya da mirasbırakanın işlerinin yürütülmesi için gerekli olan işleri aşma) sayılacağına geçmeden önce açıklanması gereken husus, mirasçının bu yolla mirası kabul etme amacının bulunmasının gerekip gerekmediğidir.Bu konu son derece tartışmalıdır. İsviçre Federal Mahkemesine göre, tereke işlerine karışmanın ölçüsü objektiftir. Yani, fiilin objektif olarak tereke işlerine gereğinden fazla karışma niteliğinde olması ret hakkının düşmesi için yeterlidir;yoksa bu yolla mirasçının, mirasçılık sıfatını kesin olarak kazanma amacını gütmesi (yani sübjektif bir niyetinin olması) aranmaz[1082]. Ancak Yüksek Mahkemeye göre, objektif kriterin uygulanabilmesi için, mirasçının, üzerinde tasarruf ettiği şeyin terekeye dahil olduğunu bilmesi zorunludur[1083].

Objektif kritere karşı olanlara göre ise, tereke ile ilgili bir davranışta bulunan mirasçının maksadına bakmak gerekir, yani ölçü sübjektif olmalıdır. Yargıtay'da bu görüştedir. Hukuk Genel Kurulunun 8.2.1950 tarih ve 140/20 sayılı kararına göre[1084], *"Bir muamelenin alelade idari muamelattan olup olmadığını tayin için, bilhassa muameleyi yapan varisin maksadını nazara almak lâzımdır... Eğer bunun maksadı mirasçı sıfatıyla terekeden tasarruf olmayıp mücerret bilahare mirası kabul ettiği zaman ihmal yüzünden gelebilecek zararın önüne geçmek ise, yaptığı muamelenin alelade idari muamele olarak kabulü zaruridir. Ezcümle malların çalınmaması için tedbir ittihazı, malları deftere geçirmek, zamanaşımını kesmek için derhal dava açmak, bir otelin, gazinonun müşterilerinin dağılmaması için vergi vermek, davaya mani olmak için müstacel borçları ödemek alelade idarenin istilzam ettiği muamelattandır"*. 1720

Doktrinde baskın görüş ise, meselenin güven prensibine göre çözüme bağlanmasıdır. Çünkü mirasçının dışa yansımamış olan tasavvur ve düşüncesi (yani amacı) esas alınamaz. Bu sebeple, bir kimsenin dışa yansımış iradesi ya da davranışına (yoksa iç iradesine değil), bunun muhatabının dürüstlük kuralına göre (MK 2) kendisince bilinen ve bilinmesi gereken bütün hal ve şartları göz önünde bulundurarak vereceği anlama göre kabul sonucunu doğuracak tereke işlerine karışma olup olmadığı tespit edilmelidir[1085]. Bu tespitin sonucunda üçüncü kişi yönünden davranış, mirasın kesin olarak iktisap edildiği şeklinde değerlendirilebiliyorsa, tereke işlerine gereğinden 1721

[1082] BGE 54 II 416; 70 II 199.

[1083] Bu şartın eleştirisi için bkz., *Escher*, Art. 577 N 11.

[1084] *Yazıcı/Atasoy*, 1202; ayrıca TİK, c.1, No. 132.

[1085] Bu görüşte olan yazarlara örnek olarak bkz., *Guhl*, ZBJV, 1929 (65), 448; *Tuor/Piceno-ni*, Art. 571 N 9; *Escher*, Art. 571 N 11; *Oğuzman*, 293; *Kocayusufpaşaoğlu*, 616; *İm-re/Erman*, 308.

fazla karışma olarak kabul edilmeli ve mirasçının red hakkı düşmelidir. Öyle olunca da, bir davranışın tereke işlerine kabul sonucunu doğuracak bir karışma sayılıp sayılmayacağı her olayda hakim tarafından değerlendirilecektir. Bir kaç örnek vermek gerekirse, malların çalınmaması için önlem alınması, malların deftere geçirilmesi, zamanaşımını kesmek için dava açma ya da icra takibi[1086] bir işletmenin gerekli olan vergilerini vermek, acil onarım yapma, tereke işlerine karışma olarak kabul edilmemektedir[1087]. Buna karşılık, miras sebebiyle istihkak ya da paylaşama davası açma, paylaşmaya katılma, miras payının devri, alacakların tahsili,tereke mallarının satımı, bir taşınmazı kendi adına tescil ettirme, mirasçılık ya da bir vasiyeti ifa, ret hakkına son veren davranışlar olarak kabul edilmektedir[1088].

1722 Yeni Medeni Kanun bu son görüşü kabul etmiş gözükmektedir. Gerçekten MK 610/III'e göre, *"Zamanaşımı ve hak düşümü sürelerinin dolmasına engel olmak için dava açılması ve cebri icra takibi yapılması, ret hakkını ortadan kaldırmaz"*. Bu hükmün, tereke işlerine karışma sonucu mirası kabul etmiş sayılacağını düşünürek bu gibi yapılması gereken işleri yapmakta tereddüt edecek mirasçıların bu tereddütlerini engellemek amacıyla konulduğu maddenin gerekçesinde açık olarak belirtilmiştir[1089].

ccc) Ceza olarak ret hakkının düşmesi

1723 Terekeye dahil olan bir malı zimmetine geçirmeyi (kendisine mal etmeyi) ya da diğer mirasçılardan saklamayı (gizlemeyi) MK 610/II ret hakkının düşmesi biçiminde öngörmüştür. Ancak bunun için, mirasçının zimmetine geçirdiği ya da diğer mirasçılardan saklıdığı malın, terekeye dahil olduğunu bilmesi ve kasden böyle hareket etmesi gerekir. Bunun yanında bu tür bir şeyin değerli de olması lâzımdır. Kanun her ne kadar maldan söz ediyorsa da, bir hakkın, örneğin bir alacak hakkının zimmete geçirilmesi ya da saklanması da aynı sonucu doğurur[1090].

1724 MK 610/II'deki sebeplerden birinin varlığı hâlinde de mirasçı, tıpkı ret süresini reddetmeden geçirmede olduğu gibi (MK 610), mirası kayıtsız ve şartsız kabul etmiş sayılır.

2. Hükmi ret

1725 Hükmi ret, ret süresinin susarak geçirilmesi hâlinde mirasın kabul edilmiş sayılacağının tam tersine bir karine getirmiştir. MK 605/II'ye göre, *"Ölümü tarihinde mirasbırakanın ödemeden aczi açıkça belli veya resmen*

[1086] 2.HD 6.2.1975, 8495/ 1131 (*Şener*, Miras, 1232).
[1087] Bu ve buna benzer örnekler için bkz., *Kocayusufpaşaoğlu*, 616/617; *Oğuzman*, 292/ 293.
[1088] Bu ve buna benzer örnekler için bkz., *Kocayusufpaşaoğlu*, 617; *Oğuzman*, 293.
[1089] Bkz., Gerekçe, 507.
[1090] *Kocayusufpaşaoğlu*, 615; *Oğuzman*, 293.

tespit edilmiş ise, miras reddedilmiş sayılır". Hükümden anlaşılacağı üzere, belli şartların bulunduğu hallerde, mirasçıların mirası reddetmiş sayılacakları karinesi söz konusudur. Bu şart, mirasbırakanın ödemeden aczinin (borca batık) açıkca belli (şayi, yaygın) ya da resmen saptanmış (sabit) olmasıdır. Açıkça belli olma, mirasbırakanın ödemeden aczinin en az mirasbırakanın çevresi tarafından biliniyor olmasıdır. Resmen sabit olma ise, mirasbırakan hakkında aciz vesikasının alınmış olmasıdır.

Hükmi ret bir karine olduğundan, reddin gerçekleşmiş sayılması için, 1726
mirasçıların ret beyanında bulunmalarına gerek yoktur.; fakat, ileride doğacak ihtilafları önlemek için, sulh mahkemesine yine de bir beyanda bulunulmasında yarar vardır. Aksine, mirasçı, mirası kabul etmek istiyorsa, kabul beyanında ya da kabulü gösteren fiillerde bulunması gerekir. Hükmi reddin söz konusu olduğu hallerde, kabul için bir süre öngörülmüş değildir[1091]. Bunun gibi, hükmi redde dayanmak için de bir süre belirtilmiş değildir. Bunun tespiti mahkemeden her zaman istenebileceği gibi[1092]; tereke alacaklılarının açtığı davada da her zaman ileri sürülebilir. Bu, bir defi değil itirazdır[1093]. Böyle bir durumda mahkeme, hükmi reddin şartlarının bulunup bulunmadığını tespit eder. Yargıtay'a göre bu karar bütün mirasçılara karşı hüküm ifade eder[1094].

Bu konuya son vermeden belirtelim ki, mal ortaklığı rejiminde yaşayan 1727
eşlerden birinin borca batık olan bir miras için kabul beyanında bulunması, diğer eşin rızasına bağlıdır (MK 265/I). Diğer eşin rızasının alınmasına imkân yoksa ya da diğer eş haklı bir sebep olmadan rıza vermiyorsa, sulh mahkemesine izin için başvurulabilir (MK 265/II).

II. REDDİN SONUÇLARI

1. Yasal mirasçıların mirası reddetmesinin sonuçları

a) Genel olarak

MK 611'e göre ret, mirasçılık sıfatını geçmişe etkili olarak, mirasbıra- 1728
kanın ölümü anından itibaren sona erdirir. Miras, mirası reddetmiş olan mirasçı sanki mirasbırakandan önce ölmüş gibi paylaşılır. Buna göre, mirası

[1091] *Escher*, Art. 566 N 13/14; *Tuor/Picenoni*, Art. 566 N 11/12; *Kocayusufpaşaoğlu*, 621; *Oğuzman*, 295.

[1092] Ödemeden aczin tespitinde görevli mahkeme 23.12.1942 tarih ve 29/29 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararına göre (RG No. 5354) HUMK'un prensiplerine göre tespit edilir. Aynı şekilde yetki de HUMK'nunu genel prensiplerine tabidir (2.HD 6.7.1973, 4596/4438; RKD 1973, II/2, 490); ayrıca bkz., *Helvacı*, 195.

[1093] *Kocayusufpaşaoğlu*, 621.

[1094] İİD 30.5.1949, 4111/2585 (TİK, c.5, No.88); HGK 20.5.1953, 2201/60 (TİK, c.9, 65); 2.HD 1.4.1974, 2038/1187 (RKD 1974, II/2, 227).

reddeden bir yasal mirasçı ise ve altsoyu yoksa, zümrede onunla birlikte mirasçı olanların miras payı artar. Örneğin M'nin A, B ve C adlı üç çocuğundan A mirası reddedecek olursa, B ve C'nin miras payları 1/3'den _'ye yükselir.Buna karşılık reddedenin altsoyu varsa, altsoy ona halef olur. Yukarıdaki örnekte A'nın, D adında bir çocuğu olsa, D, A'ya halef olup ona düşen 1/3 miras payını alır, böylece B ve C'nin miras payları değişmez (MK 611/I). Reddedenin yerini alan altsoy mirasbırakana göre saklı paylı mirasçı değilse, reddedenin saklı payı, mirasbırakanın tasarruf nisabına eklenir[1095].

b) Özel durumlar

aa) En yakın yasal mirasçıların tümünün mirası reddi

1729 En yakın yasal mirasçıların tümü mirası reddedecek olursa, tereke MK 612/I'e göre sulh mahkemesi tarafından iflas hükümlerine göre tasfiye olunur. Yani miras, reddeki ana kuralın aksine reddedenlerin yerini alacak mirasçılara geçmez.

1730 Kanunun neden dolayı en yakın yasal mirasçıların tümünün mirası reddedemesi hâlinde ana prensipten farklı bir düzenleme getirdiğini Kocayusufpaşaoğlu şöyle açıklamaktadır[1096]: *"En yakın bütün kanuni mirasçılar tarafından reddedilen bir tereke genel olarak borç içinde olan bir tereke-dir. Arka planda gelen ve mirasbırakana olan nisbi uzaklıkları dolayısı ile manevi bağları daha zayıf bulunan diğer mirasçıların da bu terekeyi nasıl olsa reddedecekleri asıldır. Şu halde gereksiz yere zaman kaybetmemek ve intikali durdurarak terekeyi tasfiye yoluna gitmek daha isabetli olacaktır".*

1731 En yakın yasal mirasçılardan maksat, mirasbırakanın ölümünde, ona en yakın planda ve doğrudan mirasaçı olan kimselerdir. Eş de bu kavrama dahildir. Örneğin M'nin ölümünde eşi E yanında, A, B ve C adlı çocukları ile C'nin çocuğu D hayattaysa, en yakın yasal mirasçılar, E A B ve C'dir. D ise bu kavrama dahil olmaz, çünkü o ilk planda ve doğrudan M'nin mirasçısı değildir. M'nin hayatta olan hısımları babası B, kadeşleri C ve D ile C'nin çocuğu E ise, MK 612/I'in uygulanabilmesi için B,C ve D'nin mirası reddetmesi yeterlidir. E'nin bu konuda bir rolü yoktur.

1732 En yakın yasal mirasçıların tümünün mirası reddetmesi sonucu yapılan resmi tasfiyeden arda bir şey kalırsa bu, mirası reddetmemiş gibi (reddeden) mirasçılar arasında paylaştırılır (MK 612/II). Görüldüğü gibi, burada da, reddedenin miras payının onun yerini alacak mirasçılara geçmesi kura-

[1095] Reddin tasarruf nisabına etkisi için bkz., § 23.
[1096] *Kocayusufpaşaoğlu*, 624.

lının bir istisnası vardır[1097], çünkü, yukarıda da değinildiği gibi, bakiye yine reddedenlere ait olmaktadır.

Yasal mirasçıların yanında atanmış mirasçıların da bulunması hâlinde MK 612'nin uygulaması nasıl olacaktır? Burada üç ihtimal söz konusu olabilir: 1733

1. Sadece atanmış mirasçıların tümü mirası reddedecek olursa, MK 612 uygulanmaz. Bu halde onların payı terekeye geri döneceği için, redden yasal mirasçılar yararlanır[1098]. 1734

2. Hem yasal hem de atanmış mirasçıların tümü mirası reddedecek olursa MK 612 uygulanır ve resmi tasfiyeye gidilir. 1735

3.Sadece yasal mirasçılar mirası reddederler, atanmış mirasçılar mirası kabul edecek olurlarsa MK 612 uygulanmaz. Bu halde MK 611 yani ana kural uygulanıp, reddedenlerin payları yerlerini alan yasal mirasçılara geçer[1099]. 1736

bb) Mirasın altsoyun tamamı tarafından reddi.

Sadece altsoy yönünden uygulanacak olan bu hükme göre, altsoyun miras payının tamamı eşe geçer ve eşe tek başına mirasçı olur (MK 613). Görüldüğü gibi, burada da, bir zümrede hiç bir mirasçının bulunmaması hâlinde mirasın bir sonraki zümreye geçeceğinin bir istisnası bulunmaktadır. Yani altsoyun hepsinin mirası reddetmesi hâlinde, miras ikinci zümreye geçmemekte, bütünü ile eşe kalmaktadır. Neden böyle bir düzenleme yapıldığı MK 613'ün gerekçesinde şöyle açıklanmaktadır: *"Dar anlamda aile ve sağ kalan eşin mirasta daha fazla korunması yönündeki çağdaş eğilimlere uygun olarak, birinci zümrede yer alan ölenin altsoyunun tamamının mirası reddetmeleri hâlinde, bu redden sağ kalan eşin yararlanması gerektiği, böyle bir redden mirasbırakanın ikinci zümrede mirasçılarının yararlanmasının mantıklı olmayacağı düşünülmektedir"*[1100]. 1737

Altsoyun tamamından maksat, mirasbırakanın ölümü ile ilk sırada mirasçı olan altsoydur, yoksa altsoy zümresinin tamamı değil[1101]. O halde M'nin eşi E yanında oğulları A, B ve C ile A'nın çocuğu D ve C'nin çocuğu F hayattaysa, MK 613'ün uygulanabilmesi için sadece A,B ve C'nin birlikte mirası reddetmeleri yeterlidir. 1738

MK 613'ün açık ifadesinden anlaşılacağı üzere, bu hüküm mirasbıraka- 1739

[1097] Krş., *Kocayusufpaşaoğlu*, 626/627.
[1098] *Escher*, Art. 572 N 7; *Kocayusufpaşaoğlu*, 628; *Oğuzman*, 297.
[1099] Bunun gerekçesi için bkz., *Kocayusufpaşaoğlu*, 628; *Oğuzman*, 297.
[1100] Gerekçe, 509.
[1101] *Kocayusufpaşaoğlu*, 629; *Helvacı*, 164.

nın altsoyunun yanında eşinin de hayatta olması hâlinde uygulanabilecektir. Buna karşılık eş yoksa, bütün altsoyun mirası reddetmesi hâlinde ne yapılacağı düzenlenmiş değildir. *Fikrimce*, bu boşluk MK 612'nin örneksemeyle uygulanmasıyla doldurulabilir.

cc) Sonra gelen mirasçılar (madun derece) lehine ret

1740 MK 614'de öngörülmüş olan bu düzenleme, MK 609/II'deki, reddin kayıtsız ve şartsız olacağı kuralının bir istisnasıdır. Buna göre, mirasçıların tümü, bazıları ya da biri, kendisinden sonra gelen mirasçı ya da mirasçıların, kabul ya da ret için davet edilmeleri şartıyla mirası reddeder (MK 614/I). Alt dereceden kasıt, sonradan gelen derece (tabaka, hat) ya da bir sonraki zümredir. Örneğin M'nin oğulları A, B ve C ile A'nın çocukları D ve F hayattaysalar, A mirası sonra gelen mirasçılar lehine reddederse, kabul ya da ret D ve F'ye sorulacaktır. Çünkü, A'dan sonraki derecedeki mirasçılar onlardır. M öldüğü zaman oğlu A yanında babası B de hayattaysa ve A sonra gelen mirasçılar lehine mirası reddederse B mirası kabul ya da redde davet olunur. Bu daveti yapacak olan mirasbırakanın son yerleşim yeri sulh mahkemesidir. Sulh mahkemesi, alt derecedeki mirasçıları bir ay içinde karar vermeye davet eder. Süreyi susarak geçirme ret anlamına gelir (MK 614/II).Bu bir faraziye olduu için aksi ispat edilemez.

1741 Bir sonraki derecenin de mirası reddetmesi hâlinde, tereke resmen tasiye olunur. Tasfiye sonunda bakiye kalacak olursa, bu ilk planda mirası reddeden mirasçılara ait olur (MK 614/ III).

2. Atanmış mirasçıların mirası reddetmelerinin sonucu

1742 MK 611/II'ye göre, atanmış mirasçıların mirası reddetmelerinden yasal mirasçılar yararlanırlar, yani onlara tahsis edilmiş olan pay yasal mirasçılara geçer.Örneğin, mirasbırakanın mirasçıları oğulları A ve B'dir. M, tasarruf nisabı olan 1/2 için Ü'yü mirasçı atamış ve Ü mirası reddetmiştir. Ü'ye tahsis edilmiş olan bu oran eşit olarak (1/4) A ve B'ye geçer.

1743 Bu kural, mirasçı atamayı içeren ölüme bağlı tasarrufta aksine bir hüküm yoksa uygulanır (MK 611/II). Örneğin mirasbırakan yedek mirasçı atamışsa, ret hâlinde bundan yasal mirasçılar yararlanmaz, reddedenin yerini yedek mirasçı alır.

3. Vasiyet alacaklılarının vasiyeti reddinin sonucu

1744 MK 616'ya göre, "Vasiyet alacaklısının vasiyeti reddetmesi hâlinde, mirasbırakanın arzusunun başka türlü olduğu tasarruftan anlaşılmadıkça, bu redden vasiyet yükümlüsü yararlanır". Buna göre vasiyetin reddedilmesi

hâlinde, vasiyet borcu sona erer ve vasiyet edilen şey, vasiyet borçlusuna ait olur meğer ki, mirasbırakan yedek vasiyet alacaklısı atamış olsun.

III. REDDE KARŞI ALACAKLILARIN KORUNMASI

1. Mirasçıların kişisel alacaklılarının korunması

Malvarlığının aktifi, borçlarının karşılamaya yetmeyen bir mirasçı, sırf kendi alacaklılarına zarar vermek amacıyla mirası reddedecek olursa, alacaklıları ya da hakkında iflas açılmışsa iflas masası yeterli güvece verilmemesi hâlinde altı ay içinde reddi iptal ettirebiliriler (MK 617/ I). Bu altı aylık süre hak düşürücü süre olup, mirasçının mirası reddettiği andan itibaren işlemeye başlar[1102]. Mahkeme reddi iptaline karar verirse, miras resmen tasfiye edilir (MK 617/II). Tasfiye sonunda, reddeden mirasçının payına bir şey düşerse, bu önce itiraz eden alacaklılara tahsis olunur. Geriye bir şey kalırsa, redde itiraz etmeyen alacaklıların alacakları ödenir. Bundan sonra da bir şey kalacak olursa o da,reddeden mirasçının yerini alan mirasçılara verilir (MK 617/III). 1745

Reddi itiraz davasının kime karşı açılacağı tartışmalıdır. Bazı yazarlar, davanın reddedene, diğerleri ise, reddedenin yerini alana karşı açılacağını savunurlar[1103]. 1746

MK 617/I, reddin iptali için mirasçının alacaklılarına zarar verme kasdını aradığına göre, bu kasdın olmadığı hallerde, mirasçı kendi alacaklılarını tatmin edemese bile reddin iptali istenemeyecektir. 1747

2. Mirasbırakanın alacaklılarının korunması

Aktifi borçlarını karşılamaya yetmeyen bir mirası reddeden mirasçı, eğer ölümden önceki beş yıl içinde, denkleştirmeye tabi bir kazandırma almışsa bu miktardan, tereke alacaklılarına karşı paylaşmada geri vermekle yükümlü olduğu değerle sorumlu olur (MK 618/I). Ancak MK 618/II'ye göre, olağan eğitim ve öğretim giderleriyle adet üzere verilen çeyiz bundan istisnadır. Bunun yanında MK 618/III, reddeden mirasçının sorumlu olacağı miktar yönünden bir sınırlama getirmiştir. Buna göre, kötü niyetli mirasçı geri vermek zorunda olduğu kazandırmanın tam değeri ile sorumlu olurken; iyiniyetli mirasçı sadece sebepsiz zenginleşmeye göre (kazandırma ya da gelirinden elinde ne kalmışsa) sorumlu olur. Son olarak belirtelim ki, 1748

[1102] 2.HD 30.12.1974, 8465/8181 (YKD 1976, c. II, 304; 2.HD 7.11.1978, 7684/7879 (Yasa, 1978, 2030).

[1103] Bu yazarlar için bkz., *Kocayusufpaşaoğlu,* 631, dn. 17; *Oğuzman*, 299 dn. 153; *Helvacı,* 223.

MK 618'in şartları varsa, reddin iptal ettirilmesine gerek yoktur. Sonuç, yani sorumluluk kendiliğinden gerçekleşir, fakat mirasın reddi geçerli kalır.

1749 Tartışmalı olmakla beraber, reddeden mirasçının sorumluluğunun tali (ikinci derecede) olduğu genellikle kabul edilmektedir[1104]. Buna göre, eğer bütün mirasçılar mirası reddetmişse, tereke MK 612'ye göre resmen tasfiye edileceğinden MK 616'ya göre sorumlu olan mirasçılar, ancak tasfiye sonunda bütün alacaklar karşılanmamışsa (iade yükümlülükleriyle sınırlı olarak) sadece karşılanamayan kısım için sorumlu olurlar. Mirasçılardan sadece bir kısmı mirası reddetmişe, tereke alacaklıları önce reddetmeyenlere başvurmak zorundadırlar. Ancak, bu mirasçıların borçların tamamını ödeyemedikleri durumdadır ki, MK 616'ya göre reddeden mirasçıya karşı harekete geçebilirler.

§ 33. Resmi Defter Tutma

I. GENEL OLARAK

1750 Mirasın açılmasından sonra mirasçılar, mirası reddetme ya da kayıtsız şartsız kabul etme yerine, terekenin gerçek durumu hakkında güvenilir bilgiye sahip olduktan sonra ne yapacaklarına karar vermek isteyebilirler. İşte mirasçıların mirasın kazanılması hususunda ne yapacaklarına karar vermeleri için resmi yoldan terekenin durumunun saptanmasını isteyebileceklerini düzenleyen kanunkoyucu, buna ilişkin hükümleri Medeni Kanunun, Miras Hukuku kitabının 2. kısmının *Resmi Defter Tutma* başlıklı üçüncü ayırımında, MK 619-631 arasında düzenlemiştir[1105]. Bu yola başvurularak defter tutulması talep edilince, aşağıda açıklanan usule uygun olarak resmi defter tutulduktan sonra,resmi defter tutma talebinde bulunan mirasçıların zaten defter tutulmadan önce de var olan ret, kabul resmi tasifyeyi isteme hakları yanında, mirası tutulan deftere göre kabul etme şeklinde dördüncü bir seçimlik imkânları daha doğacaktır. Mirasın tutulan deftere göre kabulü ve resmi tasfiye şıkları daha aşağıda açıklanacaktır.

1751 Yukarıda söylenenleri açıklayacak olursak; mirasın geçmesi ile birlikte mirasçının elinde dört seçimlik imkân vardır. Bunlar: 1) mirası kayıtsız şartsız kabul, 2) Mirası ret, 3) resmi defter tutma isteminde bulunma ve 4) resmi tasfiyeyi isteme. Mirasın resmi defterinin tutulmasından sonra da mirasçının elinde şu seçimlik imkânlar vardır: 1) mirası kayıtsız şartsız kabul,

---

[1104] *Kocayusufpaşaoğlu*, 633 ve orada dn. 128'de anılan yazarlar; *Oğuzman*, 299, dn.155; *İmre/Erman*, 325; *İnan/Ertaş*, 420; *Helvacı*, 235.

[1105] Buradaki resmi defter tutmayı, daha önce açıkladığımız koruyucu önlem olarak tutulan defter ile karıştırmamak gerekir. Bkz., yukarıda § 29, I,1.

2) mirası tutulan deftere göre kabul, 3) mirası ret ve 4) resmi tasfiye isteminde bulunma. Ancak, mirasın, mirasçılardan biri tarafından kayıtsız şartsız ya da tutulan deftere göre kabul edilmesi hâlinde, artık mirasçılar resmi tasfiye isteminde bulunamazlar (MK 632/II). Bunun üzerinde, aşağıda resmi tasfiye bahsinde etraflı olarak durulacaktır[1106].

II. DEFTER TUTMA TALEBİ

Mirasbırakanın ölümünde, her mirasçılık sıfatına sahip olan kimse resmi defter tutma talebinde bulunabilir. Yasal mirasçılar kadar atanmış mirasçılar da bu hakka sahiptirler. Buna karşılık, vasiyet alacaklıları ve mirasçı ya da mirasbırakanın alacaklılarının resmi defter tutmayı isteme hakları yoktur. Defter tutmayı isteme hakkı bulunan mirasçı, bu hakkını, mirası reddetme hakkının işlemeye başladığı andan itibaren bir ay içinde kullanmalıdır (MK 612/II). Böylece MK 606 uyarınca resmi defter tutmayı isteme süresi, yasal mirasçılar ve miras sözleşmesi ile atanmış mirasçılar için, mirasbırakanın ölümünü öğrendikleri anda, vasiyetname ile atanmış mirasçılar için ise, mirasçı atandıkları kendilerine resmen bildirildiği anda işlemeyebaşlar. 1752

Mirasın resmi defterinin tutulmasını isteme süresinin, mirasın reddi için tanınan üç aylık süreden kısa tutulmasının sebebi, defter tutmanın diğer seçeneklere (bu arada mirası reddetmeye) başvurmaya engellemeyip, sadece ertelemesidir. 1753

Diğer mirasçılar resmi defter tutma talebinde bulunmasalar, hatta açıkça mirası kabul ya da ret etmiş olsalar bile, bir tek mirasçının talebi resmi defter tutma için yeterlidir. Ancak başka bir şıkkı seçenler, resmi defter tutmanın sonuçlarından yararlanamazlar[1107]. Başka bir deyişle, defter tutma tamamlandıktan sonra, aşağıda[1108] açıklanacak olan seçimlik hakları kullanamazlar. Mirası daha önce kabul etmiş olan , terekeyi bütün sonuçlarıyla devralacağı gibi, mirası reddeden de terekede hiç bir surette hak sahibi olamayacak ve tereke dolayısıyla borç altına girmeyecektir. Buna karşılık hiç bir seçeneği kullanmamış, fakat kendisi defter tutma için talepte bulunmamış mirasçı, talepte bulunan gibi, resmi defter tutmanın sonuçlarından yararlanacaktır (MK 619/III). Bunun gibi, seçim hakkını resmi tasfiye (MK 632 vd) yönünde kullanan bir mirasçının bu talebi resmi defter tutmanın sonuçlarına kadar ertelenir. Resmi defter tutmanın sonucunda, seçim hakkı bulunan mirasçılardan biri dahi mirası tutulan deftere göre kabul edecek olursa, daha önce resmi tasfiye isteminde bulunmuş olan mirasçıya, 1754

[1106] Bkz., § 34

[1107] *İmre/Erman*, 329.

[1108] Bkz., aşağıda IV.

resmi tasfiye dışındaki ihtimallerden birini seçmesi (mirası kayıtsız şartsız kabul, red ya da mirası tutulan deftere göre kabul) için süre verilir. Çünkü, az önce de açıklandığı gibi, MK 632/II'ye göre, mirasçılardan biri, mirası kayıtsız şartsız ya da tutulan deftere göre kabul ederse, resmi tasfiye istemi geçerli olmaz.

1755 Açıklamalardan anlaşılacağı üzere, resmi defter tutma talebi bir başına resmi tasfiyeyi önler. Fakat bu kesin değildir İleride defter tutulması sonucunda, diğer mirasçılardan hiç biri mirası kabul etmezse (ve daha önce de mirası kabul eden bir mirasçı yoksa) resmi tasfiye gerçekleşir.

1756 Resmi defter tutma için mirasçılardan birinin talepte bulunması şartının istisnası MK 631/II'de öngörülmüştür. Buna göre, mirasın Devlete kaldığı hallerde, talebe gerek olmadan terekenin resmen defterinin tutulması zorunludur.

1757 Resmi defter tutma talebi, mirasbırakanın son yerleşim yeri sulh mahkemesine, ret beyanındaki usule göre yapılacak bir başvuru ile gerçekleşir (MK 619/II).

III. RESMİ DEFTER TUTULMASI İŞLEMLERİ

1758 Resmi defter tutma işlemlerini yetkili olan mirasbırakanın son yerleşim yeri sulh mahkemesi yürütür (MK 620/I). Defter tutma masrafları kural olarak terekeden ödenir. Ancak bu mümkün olmazsa, masrafları defter tutulmasını isteyen mirasçı karşılar (MK 623/II). Velayet Vesayet ve Miras Tüzüğü'nün 49. maddesi, terekenin durumu masrafları karşılamaya yetse bile, o sırada para temini mümkün değilse, mirasçıdan, sonradan terekeden geri ödenmek kaydıyla avans niteliğinde para alınmasını öngörür.

1759 MK 620/IV'e göre, terekenin resmi defterinin tutulması şekli bir tüzük ile düzenlenecekse de bu tüzük daha çıkartılmış değildir. Bu bakımdan halen yürürlükte olan Velayet, Vesayet ve Miras Tüzüğü, aykırı olmadığı kadarıyla uygulanabilir.

1760 MK 620/I uyarınca, mahkeme tüm malları, hak ve borçları, değerlerini (gerekirsa bilirkişiye tespit ettirip), özellikleri, miktarları, üzerlerindeki kayıt ve yükümlülüklerle birlikte deftere kaydedecektir (Velayet, Vesayet Miras Tüzüğü 42). Şayet terekeye ait olarak görünen bir mal veya hak üzerinde üçüncü kişilerin istihkak iddiası varsa, bunların da defterde gösterilmesi gerekir.

1761 Hakim, deftere işlenecek hususlara ilişkin olarak her ilgiliden bilgi isteyebilir ve bu talebe rağmen bilgi vermeyenler, yanlış ya da eksik bilgi ve-

renler MK 620/II'ye göre bu yüzden, mirasçı, vasiyet alacaklısı ya da üçüncü kişilerin uğrayacakları zararı tazminle yükümlü olurlar.

Mirasçılar ise, hakim tarafından kendilerinden bilgi istenmese bile, mi- 1762
rasbırakanın kendilerince bilinen borçlarını mahkemeye bildirmekle yükümlüdürler (MK 620/III). Aksi takdirde onlar da MK 620/II'ye göre, bundan bir zarar doğarsa tazminat borcu altına girerler. Aslında her ne kadar MK 620/III " ... *mirasbırakanın kendilerince bilinen borçları* " demekteyse de, mirasçılar, terekenin gerçek durumunun saptanmasını sağlayacak, bilgileri dahilindeki her hususu bildirmekle yükümlü sayılmalıdırlar.

Mahkeme, mirasbırakanın, alacaklılarına ve borçlularına, alacak ve 1763
borçlarını belli bir süre içinde deftere kaydettirmelerini, bildirimde bulunamamaları hâlinde aleyhlerinde doğacak olan sonuçlarını da belirterek ilan yoluyula bildirir (MK 621/I ve II). Bu çağrı, kefalet sebebiyle alacaklı ve borçlu olanları da kapsar (MK621/I, c.2). İlan, ilki en az bir aylık bir süreyi içermesi şartıyla iki kere verilecektir (MK 621/I). Defter tutma işleminin ve özellikle mirası tutulan defter gereğince kabul etmenin esas fonksiyonu buradadır[1109].

Resmi kayıtlardan ve mahkemeye ulaşan diğer belgelerden anlaşılan 1764
alacak ve borçlar ile haklar, ilan ve başvuruya gerek olmadan resen deftere geçirilirler ve bu durum alacaklı ve borçlulara bildirilir (MK 623).

Resmi defter tutma işlemi sırasında, terekenin her bakımdan olabildi- 1765
ğince değişmeden kalması amacıyla, terekeyi ilgilendiren işlemler adeta buzdolabına kaldırılmıştır. Bu bakımdan MK 624/I'e göre, defter tutma sırasında, ancak gecikmesi terekeye zarar verecek olan işlemler yapılır. Bu işlemlerin yapılması hususunda hakim, mirasçılardan birini yetkili kılabilir. Bu halde mirasçılar, yönetim ile görevlendirilmiş mirasçıdan güvence (teminat) isteyebilirler (MK 624/II).

Velayet, Vesayet ve Miras Tüzüğü 41 ve 42'ye göre, defter tutma sıra- 1766
sında hakimin, saklanması imkânsız ya da değerine oranla çok masraflı olan malları sattırmak, terekede yer alan bir işletmenin faaliyete devamı gerekiyorsa, bunun için kayyım atama yetkisi vardır.

MK 625/I ve II'ye göre, defter tutma sırasında mirasbırakanın borçları 1767
hakkında icra takibi yapılamaz ve zamanaşımı da işlemez (ya da işleyen zamanaşımı durur). Bunun gibi, gecikmesinde zarar doğacak haller (acele haller) dışında açılmış olan davalar ertelenir ve yeni dava açılamaz (MK 625/III). Bazı yazarlar, maddenin sözü doğrultusunda, sadece terekeye karşı alacak hakkı ileri sürenlerin icra takibi yapamayacakları ve bunlar hak-

[1109] Bkz., aşağıda IV,2.

kında zamanaşımının işlemeyeceği ya da duracağını ileri sürmekte ve MK 625/III'deki, *"davalara devam edilemeyeceği gibi, yeni dava da açılamaz"* ibaresindeki davaların da, tereke alacaklıların davaları olduğunu ileri sürmektedirler[1110]. Bu görüşe göre, tereke alacakları için, icra takibi yapma ve dava açma ya da daha önce açılmış bir davayı sürdürme mümkün olduğu gibi (ve mümkün olduğu için), zamanaşımı da işleyecektir. Diğer bir grup yazar ise, MK 625'i, özellikle bir ve ikinci fakrasının lafzına aykırı bir şekilde geniş yorumlayarak gerek tereke aleyhine gerek tereke lehine olan alacaklarda zamanaşımının duracağını, mirasbırakanın davalı ya da davacı sıfatını taşıdığı bütün davalarla, terekenin mirasçılar tarafından yönetilmesi sebebiyle açılmış davaların da erteleneceğini ya da henüz açılmamışlarsa defter tutmanın sonuna kadar açılamayacağını ileri sürmektedirler[1111].

1768 İsviçre Hukukunda, ZGB Art. 586'da zamanaşımı ayrı bir fıkra olarak düzenlendiği için, yukarıdaki son görüş hakimdir[1112]. Medeni Kanunun yeni düzenlemesinde de zamanaşımı ayrı olarak (ikinci fıkra) düzenlendiği için Türk Hukuku yönünden de bu görüşün geçerli olup olmadığı üzerinde durulabilir.

1769 Deftere yapılan kayıtlar mahkemece belirlenen sürenin sonuda tamamlanır. Deftere yapılan kayıtların kapatılması üzerine ilgililere (mirasçılara) bildirimde bulunularak en az bir ay içinde defteri incelemeleri imkânın tanınır (MK 623/I). Bu sürenin dolması, mirasçıların seçim hakkını kullanma sürelerinin başlaması için önemli olup, deftere kaydedilen alacak ve borçlara ilgililerin itiraz etme imkânını ortadan kaldırmaz. Bu hususta çıkan bir uyuşmazlık sonradan açılan ayrı bir dava ile çözümlenebilir.

IV. RESMİ DEFTER TUTULMASININ SONUÇLARI

1. Mirasçının seçme imkânının doğması

1770 Resmi defter tutmanın tamamlanması ve MK 623/I'de belirtilen inceleme süresinin dolması üzerine, mirasçılara yapılacak bildirimle, daha önce mirası kabul ve ret etmemiş olmaları şartıyla, bu bildirimin ulaşmasından itibaren[1113] bir ay içinde kanunun tanıdığı imkânlardan birini seçmeleri istenir (MK 626/I). Hakim, terekedeki bir malın değerinin yeniden belirlenmesi ya da deftere kayıt edilen bir hususta çıkan uyuşmazlığın çözümlen-

---

[1110] *İmre/Erman*, 332. *Oğuzman*'ın (302/303) İcra takibi ve zamanaşımı yönünden bu görüşte olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü yazar davanın sürdürülmesi ve açılması yönünden bir beyanda bulunmamaktadır.

[1111] *Kocayusufpaşaoğlu*, 640; *İnan*, Miras Hukuku, Ankara 1969, 349.

[1112] *Escher*, Art. 586 N 5; *Tuor/Picenoni*, N 6.

[1113] *Escher*, Art. 587 N 2; *İmre/Erman*, 334; *Kocayusufpaşaoğlu*, 641.

mesi gerekçesiyle ya da benzeri durumlar için bu süreyi uzatabilir (MK 626/II).

Mirasçının yararlanabileceği seçenekler dört tanedir (MK 672/I). Bunlar: 1771

a) mirası kayıtsız şartsız kabul; 1772

b) mirası ret; 1773

c) Resmi tasfiye 1774

d) mirası tutulan deftere göre kabul. 1775

Görüldüğü üzere ilk üç imkânın varlığı defterin tutulmasına bağlı değilken, mirası tutulan deftere göre kabul seçeneği ancak resmi defterin tutulmasına bağlıdır. Resi defter tutmanın asıl getirdiği imkân bu sonuncusu olduğu için, seçim hakkına sahip olduğu halde seçimini bildirmeyen, yani süreyi susarak geçiren mirasçı MK 627/II uyarınca *mirası tutulan deftere göre kabul etmiş sayılır*. MK 627/II hükmü bir hukuki farziye (varsayım) olduğundan mirasçı bunun aksini ileri süremez. Örneğin elinde olmayan sebeplerle seçim hakkını zamanında kullanamadığını ve gerçek iradesinin bu olmadığı iddiasında bulunamaz. Mirasın tutulan defter gereğince kabul edildiği sonucu, geçmişe etkili olup, mirasçının seçim hakkını kullandığı andan ya da sürenin susarak geçirilmesi ile sona ermesi anından itibaren değil, mirasbırakanın ölümü anından itibaren hüküm ifade eder (MK 628/II). 1776

2. Mirasın tutulan deftere göre kabulünün sonuçları

Mirasın reddi ve kayıtsız şartsız kabulü konusunda daha önce açıklamalarda bulunulmuştur[1114]. Resmi tasfiye ise daha sonra açıklanacaktır[1115]. Burada ister açık kabul beyanı ile olsun ister süresinde seçim hakkı kullanılmadığı için kabul edilmiş sayılsın resmi defter tutmanın sonuçları üzerinde duracağız. 1777

Önce belirtelim ki, seçimde bulunma süresi içinde bazı mirasçıların mirası reddetmeleri ya da kayıtsız şartsız kabul etmeleri, mirası tutulan deftere göre kabul eden (ya da sustuğu için kabul etmiş sayılan) mirasçının yaptığı seçime bir etkisi olmaz. Herkes kendi seçiminin sonuçlarına tabi olur. Ancak resmi tasfiye istemi yönünden bazı özellikler üzerinde durulması gerekir. Şöyle ki, mirasçılar arasında daha önce mirası kayıtsız şartsız kabul etmiş bir kimse varsa, resmi defter tutmadan sonra seçim hakkı olan miras- 1778

[1114] Bkz., § 31 ve 32.
[1115] Bkz., § 34.

çı (bu, defter tutma isteminde bulunan mirasçı olabileceği gibi, daha önce seçim hakkının kullanmamış başka bir mirasçı da olabilir) resmi tasfiye isteminde bulunamaz. Çünkü sık sık değindiğimiz gibi, mirasın, bir tek mirasçı tarafından dahi kabulü resmi tasfiye işlemini geçersiz kılar (MK 632/II). Bu durumda, resmi defter tutmadan sonra seçim hakkı üçe (kayıtsız şartsız kabul, ret ve tutulan defter gereğince kabul) düşer. Aynı MK 632/II hükmü, daha önce yapılmış olan resmi tasfiye istemini de, daha sonra mirasın tutulan deftere göre kabul edilmesi hâlinde etkisiz hale getirir. Böylece resmi tasfiye istemi geçersiz sayılan, başka bir seçeneği bildirmeden karar süresi dolarsa, bazı yazarlara göre süreyi susarak geçirmiş gibi, MK 627/II uyarınca mirası tutulan deftere göre kabul etmiş sayılacaktırlar[1116]. Bazı yazarlar ise bu halde, ret süresinin uzatılmasına ilişkin MK 615'in kıyasen uygulanması sonucu, resmi tasfiye istiyen mirasçıya bir ek süre verilebileceği, ancak bu ek sürenin istenmemesi hâlinde, resmi tasfiyeyi seçmiş olan kişinin mirası tutulan deftere göre kabul etmiş sayılacağı görüşündedirler[1117].

1779 Seçim süresini susarak geçir, resmi tasfiye isteminde bulunan mirasçının, mirası tutulan deftere göre kabul etmiş sayılması yerinde ise de özel bir durum olarak hiç bir mirasçının açıkca mirası tutulan deftere göre kabul etmediği bir durumda, sadece bir ya da birden fazla mirasçı seçim hakkını su sarak geçirdi diye, resmi tasfiye talep eden mirasçılara rağmen resmi tasfiye yerine tutulan deftere göre kabulünü aşırı bulmak mümkündür[1118].

1780 Tutulan defteri göre mirası kabul eden mirasçı, mirası kural olarak *sadece deftere yazılı olan borçlarla* edinir. Ancak mirasçı bu borçlardan kendi malvarlığı ile de sorumludur (MK 628/I, III). Zira bunları defterde görerek kabul etmiş sayılır. Bu boçlar terekeye dahil olduğuna göre, yukarıda da değinildiği gibi borçlardan da mirasın geçtiği andan itibaren sorumlu olur (MK 628/I, III).

1781 Mirasçının deftere gecmiş olan borçlar için kendi malvarlığı ile de sorumlu olmasının bir istisnasını Devletin mirasçı olması hâlinde görmekteyiz. MK 631/II'ye göre, "*Devlet, deftere yazılan borçlardan sadece miras yoluyla* edindiği değerler ölçüsünde sorumludur".

1782 Herhangi bir sebeple deftere alacağı yazılmamış olan alacaklılara karşı ise, mirası tutulan defter gereğince kabul etmiş mirasçı kural olarak, ne şahsi malvarlığıyla ne de terekeden kendisine düşen kısım ile sorumludur (MK 629/I). Maddenin ifadesinden bunun bir defi olmayıp itiraz olduğu,

---

[1116] *Kocayusufpaşaoğlu*, 656.
[1117] *Oğuzman*, 306; *İmre/Erman*, 336.
[1118] Bkz., *Dural/Öz*, birinci basım 419.

mirasçının deftere kayıt edilmemiş olan bu borçlardan kurtuduğu ve alacaklının hakkını kaybettiği anlaşılmaktadır.

Kural yukarıda açıklandığı gibi olmakla beraber, alacaklı alacağını deftere yazdırmada kusuru olmadığını ya da bildirmiş olmasına rağmen deftere yazılmadığını ispat ederse, mirası tutulan deftere göre kabul etmiş olan mirasçıya karşı, ancak zenginleştiği oranda alacağını ileri sürebilir (MK 629/II). Görüldüğü bu halde mirası tutulan deftere göre kabul etmiş olan mirasçı ne şahsi malvaralığıyla ne de kendisine geçen miras payı oranında değil de, sadece miras sebebiyle zengileştiği oranda sorumlu olmaktadır. Belirtelim ki, bu sorumluluk sınırlaması, sadece mirası tutulan deftere göre kabul eden mirasçı yönünden vardır. Eğer onun yanında mirası kayıtsız şartsız kabul eden mirasçı ya da mirasçılar varsa, onların şahsi sorumlulukları devam ettiği için, borçtan şahsi malvarlıklarıyla sorumludurlar.Yani mirası tutulan deftere göre kabul eden mirasçının malvarlığına el atamayan alacaklı, diğer mirasçıların malvarlığına başvurabilir. 1783

Alacaklının, alacağını deftere yazdırmamada kusursuz olması bir çok sebebe dayanabilir. Alacaklının,ilanın çıktığı yayını okumasının ondan beklenemeyeceği, ilanın hatalı verildiği, ağır bir hastalık geçirdiği için vaktinde alacağını yazdıramadığı, alacağını yazdırmak için zamanında başvurmasına rağmen mahkemenin hatası sonucu kaydedilmediği vb. gibi gerekçeler kusursuzluğunu gösterebilir[1119]. MK 622/I'egöre resmi kayıtlardan ve mirasbırakanın mahkemeye ulaşan evrakından varlığı anlaşıldığı için başvuru yapılmadan mahkemece kaydedilmesi gereken bir alacak kaydedilmemişse, alacaklı başka bir hususu ispat etmeden kusursuz sayılmalıdır[1120]. 1784

Şayet bir mirasçı varalığını bildiği bir alacağı, yani tereke borcunu saklamış ve bu alacak deftere kayıt edilememişse MK 620/III'e göre mirasçıların bildikleri tereke borçlarını mahkemeye bildirme yükümleri olduğundan, aynı maddeye göre alacaklının bu sebeple zararından sorumlu olmalıdırlar. Buna göre, bilgisini gizleyen mirasçı, bu alacak deftere kaydedilseydi, hem tereke payı hem de şahsi malvarlığıyla sorumlu olarak alacaklıya vermek zorunda kalacağı miktarı tazmin edecektir. Ancak bu durumdaki alacaklının da hakkını yazdırmamakta kusuru varsa, BK 44/I'deki müterafik (birlikte) kusura ilişkin hükme kıyasen, mirasçının borcunda indirim yapılabilir. 1785

MK 629/III, alacakları *tereke malları ile güvence altına alınmış olan* alacaklının hakkı için özel bir düzenleme getirmiştir. Buna göre, alacağı bu şekilde güvence altına alınmış alacaklı, ister kusurlu ister kusursuz olarak 1786

[1119] Bu örnekler için bkz., *Kocayusufpaşaoğlu*, 642, dn. 15a.
[1120] *Oğuzman*, 304, dn. 180; *İmre/Erman*, 338.

alacağını deftere yazdırmamış olsun, bu güvencelere alacağının tümü için başvurabilir. Böylece alacaklı ihmal sonucu alacağını deftere yazdırmamış olsa bile, üzerinde rehin hakkına sahip olduğu tereke malını paraya çevirerek alacağını tahsil edebilir.

1787 Mirasbırakanın kefil sıfatıyla olan borçları hakkındaysa MK 630 resmi defter tutma hâlinde özel bir hüküm getirmektedir. Buna göre, mirasçılar, mirasbırakanın kefalet borcunun özel olarak deftere yazılması şartıyla ve sadece iflas hükümlerine göre terekenin tasfiye edilmesi hâlinde, alacaklıya düşecek miktarla sorumulu olacaklardır. MK 630 hükmündeki bu sınırlama, sadece mirası tutulan deftere göre kabul eden mirasçıları değil, defter tutma talebinden sonra mirası kayıtsız şartsız kabul eden mirasçıları da kapsar. Resmi defter tutmadan önce mirası kayıtsız şartsız kabul eden mirasçı, bu sınırlamadan yararlanamaz, bunlar küllif halef sıfatıyla aynen mirasbırakan gibi kefalet borcundan sorumlu olurlar, yani bu borcun tamamını ödemek zorundadırlar.

§ 34. Resmi Tasfiye

I. RESMİ TASFİYE KAVRAMI VE AMACI

1788 Resmi tasfiye, miasbırakanın ölümü üzerine mirasçıların, mirası kabul, ret ve resmi defter tutma seçenekleri yanında başvurabilecekleri dördüncü ve Miras Hukuku sistmemiz bakımından en orijinal seçenektir. Usulüne göre yapılan ve şartları gerçekleşen resmi tasfiye talebi üzerine, mirasın açılmasına rağmen, tereke resmi tasfiye sonuna kadar mirasçılar tarafından kazanılamaz, onların malvarlığından ayrı, bağımsız bir malvarlığı olarak kalır. Resmi tasfiyeyi düzenleyen MK 632-636 arasındaki hükümlerden bu açık olarak anlaşılmaktadır[1121]. Resmi tasfiyede mirasçılar borçlardan sorumlu olmazlar (MK 632/III). Mirasbırakanın alacaklıları, alacaklarını sadece terekeden elde edebilirler, mirasçıların şahsi sorumluluklarına gidemezler. Diğer yandan mirasçıların kişisel alacaklıları da tereke mallarına el uzatamazlar. Resmi tasfiye hâlinde mirasçıların malvarlığı ile terekenin hukukan birbirine karışması önlenmiş, tereke mirasçıların tasarrufunda değil, tasfiyeyi yönetecek olan sulh hakiminin tasarrufu altında ayrı bir malvarlığı haline getirilmiştir. Mirasçılar bu terekeyi ancak, aktifi ile pasifi karşılandıktan sonra geriye bir bakiye (olumlu artık) kalırsa onu iktisap ederler.

1789 Resmi tasfiye sırasındaki bu durum, miras Hukukumuzun, mirasın

[1121] *Tuor/Picenoni*, Art. 593 Vorbem. 1; *Kocayusufpaşaoğlu*, 644; *İmre/Erman*, 341; *Oğuzman*, 395; *Serozan/Engin*, § 6, N. 95.

otomatik ve ani geçiş sistemine aslında uymamakta, açıklanması güç bir hukuki durum oluşturmaktadır. Zira resmi tasfiye sırasında, tereke üzerinde henüz mirasçılar elbirliğiyle (iştirak hâlinde) hak sahibi olmamışlardır denemez. Çünkü, resmi tasfiyeyi yapan mahkeme, terekenin maliki olmayacağına göre, terekenin tasfiye sonucuna kadar sahipsiz olması gibi kabul edilemez bir sonuca varılırdı. Öte yandan, resmi tasfiye sırasında mirasçıların tereke üzerindeki hakları, tamamen tasfiye sonrası haklar için tasarruf imkânı verebilecektir. Tasfiye sırasında tereke tamamen mirasbırakanın alacaklılarının alacaklarının karşılanmasına tahsi edilmiş durumdadır.

II. RESMİ TASFİYE TALEBİ

Seçim hakkını kullanmamış her yasal ve atanmış mirasçı (MK 632) ve şartları gerçekleştiğinde mirasbırakanın alacaklıları (MK 633/I) resmi tasfiye talebinde bulunabiliriler. 1790

Birden fazla mirasçının bulunduğu durumlarda mirasçıların hiç biri mirası kabul etmemiş olmalıdır; yani ya mirası ret ya da resmi defter tutma isteminde bulunmuş olmalıdırlar. Şayet bir tek mirasçı, mirası kayıtsız şartsız ya da (resmi defter tutma işlemenden sonra) tutulan deftere göre kabul ederse, resmi tasfiye istemi sonuçu doğurmaz (MK 632/II). Ayrıca resmi tasfiye başladıktan sonra fakat tamamlanmadan önce, bir mirasçının mirası kabul etmesi üzerine, resmi tasfiyenin durdurulacağı Yargıtay'ca kabul edilmektedir[1122]. 1791

Resmi tasfiye talebi, sonradan diğer bir mirasçının mirası kayıtsız şartsız ya da tutulan deftere göre kabulü sebebiyle etkisiz kalan mirasçının, mirası reddedip reddetmeme hususunda, yukarıda da değinildiği gibi talebi üzerine MK 615'in örneksemeyle uygulanması sonucu kendisine tanınacak süre içinde karar vermesi mümkün olmalıdır[1123]. Keza, bizzat resmi tasfiye isteyen mirasçının, resmi tasfiye tamamlanıncaya kadar bu talebinden vaz geçerek mirası kabul edebileceğini ileri süren yazarlar da vardır[1124]. 1792

Resmi tasfiye istemi üç aylık süreye tabidir (MK 632/I). Bu sürenin başlangıcı yasal ve atanmış mirasçılar yönünden, ret süresi için MK 606/II'de belirtilmiş olanın aynısıdır[1125]. Bir başka deyişle, (resmi defter tutma talep edilmemişse), mirası ret süresi ile resmi tasfiyeyi isteme süresi aynı olup, aynı anda işlemeye başlar. Ancak resmi tasfiye talebinin, mirasın resmi defterinin tutulmasından sonra kallanılması, her iki tür mirasçı içi de karar vermeye davet edilmelerinden itibaren bir aydır (MK 626/I). 1793

[1122] 2.HD 16.4.1973, 2538/ 2504 (RKD 1973, II/2, 328).
[1123] Bkz., yukarıda, § 33,IV, 2; ayrıca *Oğuzman*, 306.
[1124] *İmre/Erman*, 343.
[1125] Bkz., yukarıda § 33, I,1,b.

1794 Mirasbırakanın alacaklıları için de resmi tasfiyeyi talep süresi ve süresinin başlangıcı aynıdır (MK 633/II). Yani alacaklılar da resmi tasfiye taleplerini, yasal ya da miras sözleşmesi ile atanmış mirasçılar varsa, mirasbırakanın ölümünden (terekenin açılmasından) itibaren; vasiyetname ile atanmış mirasçı varsa vasiyetnamenin açılmasından itibarın üç ay içinde ileri sürebileceklerdir: Şayet hem yasal hem de vasiyetname ile atanmış mirasçı varsa, süre vasiyetnamenin açılmasından itibaren işlemeye başlar[1126].

1795 Belirtmek gerekir ki, mirasbırakanın alacaklılarının resmi tasfiye talebinde bulunmalarının, mirasçılara göre bazı özellikleri vardır. Bunlardan birincisi, mirasbırakanın alacaklıları, mirası kabul eden bir mirasçı bulunsa bile resmi tasfiye isteyebilirler. Oysa MK 632/II hükmüne göre, bir mirasçının mirası kabul etmiş olmasının, diğer mirasçıların resmi tasfiye talebini engelleyeceğini bir defa daha hatırlatalım.

1796 Diğer bir şart da, mirasbırakanın alacaklılarının resmi tasiye isteyebilmeleri için, a) alacaklarını elde edemeyeceklerine ilişkin imandırıcı sebeplere dayanan kuşkularının (evleviyetle böyle bir tehlikenin) bulunması, b) alacaklarının talebe rağmen ödenmemiş ya da yetirli güvance verilmemiş olmasıdır MK 633/I). Kuşku (ya da tehlike), mirasçının borçlarını, kendi malvarlığı ile terekenin toplamının, resmi tasfiye isteyen mirasbırakanın alacaklısının alacağını karşılamasını önleyecek düzeyde olması hâlinde var demektir. Bu kuşkunun, miras açaldığı andaki mirasçının malvarlığına göre var olması yanında, mirasçının teşebbüsleri sebebiyle ileride gerçekleşecek olması (örneğin mirasçının çok riskli bir teşebbüse girmesi) da mirasbırakanın alacaklılarına resmi tesfiyeyi isteme hakkı verir[1127]. Ne var ki, mirasçı, mirasbırakanın borcunu öderse ya da ileride ödeyeceğine dair yeterli güvence (rehin, kefalet vs) verirse, mirasbırakanın alacaklısı resmi tasfiye talebinde bulunamaz. Mirasçı, mirasbırakanın ifa ya da güvence vermeye yönelik talebi ile bağlı değildir Örneğin, ifa isteyen mirasbırakanın alacaklısın alacağını karşılayan bir rehin vermeyi teklif eden ya da veren mirasçı, resmi tasfiye istemini etkisizleştirir. İfayı, mirasçı olmayan bir üçüncü kişi yapsa ya da yine mirasçı olmayan bir üçüncü kişi güvence verse, mirasbırakanın alacaklısı BK 67 uyarınca bunu kabul zorunda olduğu için, yine resmi tasfiye önlenir. Ayrıca ifa ya da güvence verme, resmi tasfiye tamamlanıncaya kadar gerçekleştirilerek, resmi tasfiyenin önleneceği de kabul edilmelidir.

1797 Resmi tasfiyeye gidebilmek için, mirasbırakanın alacaklılarından sadece birinin bunu talep etmesi yeterlidir. Mirasbırakakın diğer alacaklılarının

---

[1126] *İmre/Erman*, 346.
[1127] *İmre/Erman*, 345.

da bu talebe katılmaları gerekli değildir[1128]. Talepte bulunmayan alacaklılar da terekenin tasfiyesinden pay alırlar ve tereke malları üzerinde, mirasçının alacaklılarının önüne geçerler. Buna karşılık resmi tasfiye talep etmemiş alacaklıların, bir diğer alacaklı tarafından resmi tasfiye yaptırılması üzerine, şayet terekenin malları alacaklarını karşılamaya yetmemişse, mirasçılara başvurma imkânları devam etmelidir. Zira , bir alacaklının tek yanlı (resmi tasfiye) talebi ile buna katılmayan alacaklıların haklarını sınırlama yetkisi yoktur, yeter ki resmi tasfiyeyi bir mirasçı talep etmiş olmasın. Zira, bu son durumda, mirasbırakanın alacaklılarının resmi tasfiyeye tabi olmalarında iradeleri rol oynamaz.

Buna karşı, özellikle resmi tasfiyeden sonra ortaya çıkan alacaklılara 1798
karşı, mirasçıların sadece ifa talebi öne sürüldüğü anda terekeden zenginleştikleri oranda sorumlu olacakları kabul edilmektedir[1129].

Nihayet, bazı özel durumlarda ne mirasçıların ne de mirasbırakanın ala- 1799
caklılarının talebi bulunmasına rağmen, kanun esmi tasfiyeyi öngörmektedir. Bunlar, MK 612/I'e göre, en yakın yasal mirasçıların tümünün mirası reddetmesi hali ile borca batık bir mirasçının mirası reddini alacaklılarının MK 617/II'ye göre iptal ettirmeleri halidir. Bu durumda, kimse talep etmeden tereke hakimi resmi tasfiyeyi uygular.

Bu konuyu bitirmeden belirtelim ki, vasiyet alacaklılarına resmi tasfiye 1800
talep etme hakkı tanınmamıştır. Ancak MK 633/II'ye göre, resmi tasfiye söz konusuysa, mirasbırakanın alacaklılarının resmi tasfyeyi isteme şartlarının kendilerinde bulunması hâlinde, vasiyet alacaklıları haklarının korunması için gerekli önlemlerin alınmasını isteyebilirler.

III. RESMİ TASFİYENİN YAPILMASI

Resmi tasfiye, mirasın açıldığı yer (mirasbırakanın son yerleşim yeri) 1801
sulh hakimi ya da onun atayacağı bir ya da birden fazla tasfiye memuru tarafından yapılır (MK 634/I). Resmi tasfiyenin şartlarının gerçekleştiğini gören hakim, resmi tasfiyeye başlamak zorundadır. Tasfiye memuru olarak atanan kişiler, bu görevi başta kabul etmeyebilecekleri gibi, göreve başladıktan sonra da kural olarak her zaman çekilebilirler. Ancak, görevi uygun olmayan bir zamanda bırakmaları durumunda, bundan doğacak zarardan sorumlu olurlar[1130]. Çoğunluğun görüşüne göre, hakim, mirasçılara tasfiye memuru olarak atayamaz[1131].

[1128] *Oğuzman*, 306, dn. 188.
[1129] *Oğuzman*, 308; *İmre/Erman*, 351; *Kocayusufpaşaoğlu*, 652.
[1130] *İmre/Erman*, 347.
[1131] Hakim görüşe örnek olarak bkz., *Escher*, Art. 595 N 14; *Tuor/Picenoni*, Art. 595 N 3; aksi görüş, *Kocayusufpaşaoğlu*, 649.

1802 Tasfiye memurları sadece atanmada değil görevleri sırasında da sulh hakiminin denetimi altındadırlar. Bu hususu belirten MK 634/IV'e göre, mirasçılar da tasfiye memurları tarafından yürütülen ya da yürütülmesi planlanan işler hakkında sulh mahkemesine şikâyette bulunabilirler.Bunun süresi öğrenmeden itibaren yedi gündür. Doktrinde bu hakkın mirasbırakanın alacaklılarına da tanınması gerektiğini ileri sürenler vardır[1132]. Sulh hakimi,tasfiye memurlarına müdahele edebileceği gibi, gerekirse onları görevden alabilir.Velayet, Vesayet Miras Tüzüğü 59'a göre tasfiye memurlarının ücreti terekeden ödenir.

1803 Resmi tasfiyenin başlangıç işlemi mahkeme ve tasfiye memurlarınca yapılacak ilandır. Süreye bağlı olmayan bu ilanda, mirasbırakanın alacaklıları ve borçlularına ilanda belirtilen süre içinde alacak ve borçlarını kaydettirmeleri bildirilir. İlanın ardından terekenin aktif ve pasilerinin defteri tutulur. Daha önce resmi defter tutma talebi üzerine, terekenin defteri tutulmuşsa,resmi tasfiye bu defter üzerinden yapılacamdan, yeniden defter tutmaya gerek yoktur (MK 634/II).

1804 Süresinde başvurmamış olan mirasbırakanın alacaklılarının, bakiye mirasçılara devredildikten sonra da hakkını (resmi defter tutmadan farklı olarak, deftere yazdırmada kusuru bulunsa bile), doğrudan doğruya mirasçılara karşı ileri sürebileceği, ancak mirasçıların bu alacaklılara karşı sorumluluklarının terekeden ellerine geçen miktarla (zenginleştikleri oranla) sınırlı olacağı kabul edilmektedir[1133].

1805 Tasfiye sırasında mirasbırakanın alacaklıları tarafından ileri sürülen taleplere muhatap ve tereke alacakları için takipte bulunma yetkisi sahibi tasfiye memurlarıdır. Velayet, Vesayet ve Miras Tüzüğünün 52. maddesine göre, tasifye memurları TTK 211 vd. maddelerine göre iflas etmemiş bir kollektif şirketin tasfiye memurlarının yetkileri sahiptirler. Resmi tasfiye sırasında mirasçılar, tereke üzerinde herhangi bir tasarruf imkânına sahip olmadıkları için, tereke borçlarını kendileri takip edemeyecekleri gibi, tereke borçlularının doğrudan mirasçılara yapacakları ödemeler de, onları borçlarından kurtarmayıp, sadece sebepsiz zenginleşme oluşturur.

1806 Medeni Kanuna göre, resmi tasfiye, *alelade tasfiye ve iflas usulü ile tasfiye* olmak üzere iki şekilde yapılır.

1807 Resmi tasfiyede kural, MK 635'de düzenlenmiş olan *alelade* tasfiyedir. Bu maddede yapılacağı sayılan işlemler bir sıraya tabi tutulmamışsa da, tasfiye memurları önce terekedeki nakit para ile mirasbırakanın borçlarını ödemeye çalışmalıdırlar. Şayet bu yetmezse, önce tereke alacaklarını tahsil

---

[1132] *İmre/Erman*, 350.

[1133] *Kocayusufpaşaoğlu*, 652; *Oğuzman*, 308; *İmre/Erman*, 351; *Serozan/Engin*, § 6, N. 92.

ederek elde edecekleri para ile, bu da mümkün olmazsa ya da borçların ödenmesinin alacakların tahsili beklemeye tahammülü yoksa, tereke mallarını satıp paraya çevirerek bu borçları ödemelidirler. Mallar paraya çevrilirken tasfiye memuru ya da hakim, satışın açık arttırmayla mı yoksa pazarlık usulüyle mi yapılacağına karar verecektir. Ancak taşınmazlar, bütün mirasçılar anlaşırlarsa pazarlık usulüyle satılabilir (MK 635/III). Velayet Vesayet ve Miras Tüzüğünün 55. maddesi, şayet tereke borçlarının karşılanamayacağı kanısına varırsa, hakimin, bütün mirasçıların pazarlıkla satışta anlaşmasına rağmen, gene de taşınmazın açık arttırmaya satılmasına karar verebileceğini belirtmiştir.

Mirasbırakanın alacaklılarının alacaklarının tamamı tatmin edildikten 1808
ve bunlara ilişkin tereke borcu kalmadıktan sonra vasiyet alacaklılarına ifada bulunulabilir. Bu, mirasbırakanın alacaklılarının, vasiyet alacaklılarından önce geldikleri kuralının doğal bir sonucudur.

Mirasbırakanın alacaklılarının alacakları ödendikten ve vasiyet borçları 1809
yerine getirildikten sonra, kalan tereke malları mirasçılara verilir. İşte mirasçılar ancak bu suretle tereke üzerinde elbirliğiyle hak sahibi olmalarından doğan yetkilerini kullanabilirler, mirasın paylaşılmasını talep edebilirler.

MK 635/IV'e göre tasfiye işlemleri devam ederken (hatta başlarken bi- 1810
le), eğer mirasbırakanın borçlarını karşılamak için bazı tereke mallarının paraya çevrilimesine gerek kalmayacağı kesin olarak anlaşılıyorsa, mirasçılar tasfiye sonucunu beklemeden, bunların kendilerine verilmesini isteyebilirler ve hakim ya da tasfiye memuru, bu malları tasfiyeye tabi terekeden ayırarak miraçılara vermeye yetkili, hatta yükümlüdür.

Resmi tasfiyeye karar verildiği anda veya terekenin defterinin tutulma- 1811
sından sonra, terekenin aktifinin pasifini karşılamadığı (mirasbırakanın borçlarının tereke malları ve haklarından ödenmesinin mümkün olmayacağı) anlaşılırsa, tereke MK 636'ya göre, *iflas usulü ile* tasfiye edilir. Bu durumda hakim, kendiliğinden iflas usulüne göre tasfiyeye karar vereceği gibi, henüz böyle bir karar vermemişse, mirasbırakanın alacaklıları da, mahkemeye başvurarak, bu yolda bir karar vermesini isteyebilirler[1134]. İflas usulü ile tasfiye, adından da anlaşılacağı üzere İcra İflas Kanunu'nun ilgili hükümlerine göre (154, 156, 180. 208 vd.) sulh mahkemesince yapılacak bir tasfiyedir. İflas usulüne göre tasfiyede, doğal olarak mirasçılara bir şey kalmıyacaksa da; terekenin durumu başta iyi saptanmadığı için, tasfiye sonunda olağanüstü bir durum olarak bazı mallar kalırsa, bunlar, alelade tasfiyedeki gibi mirasçılara verilir.

[1134] *İmre/Erman*, 350; İİD 9.5.1969, 5155/5138 (ABD, 1971, sayı 4, 591).

1812 Herhangi bir tasfiye usulü sonucunda mirasçılara verilen tasfiye artığı (bakiye) onların malvarlıkları ile karışır ve artık onların alacaklıları tarafından takibe konu yapılabilir. Ancak, yukarıda da belirttiimiz üzere, mirasbırakanın sonradan ortaya çıkan alacaklılarının da tasfiye artığı ile sınırlı olarak mirasçıları takip edebileceği kabul edilmelidir. Mirasçılar, tenkis ve denkleştirme (iade) davaları ile miras sebebiyle istihkak davasını da bu andan (yani resmi tasfiyenin bitip, artığın mirasçıları verildiği andan) itibaren açabilirler.

§ 35. Mirasçıların Seçim Haklarını Farklı Şekilde Kullanmalarının Sonuçları

I. GENEL OLARAK

1813 Mirasçıların hepsinin, ister resmi defter tutmadan önce, ister sonra olsun, seçimlerini aynı yönde yapmaları hâlinde ortaya bir problem çıkmaz.Fakat, mirasçılar seçimlerini farklı yönde yapacak olurlarsa nasıl hareket edilecektir? İşte burada incelenecek olan konu budur.

II. MİRASÇILARIN RESMİ DEFTER TUTMA TALEBİNDEN ÖNCE SEÇİM HAKLARINI FARKLI YÖNDE KULLANMALARI

1814 1. M'nin mirasçılarından A resmi defter tutma talebinde bulunmuş, B mirası kayıtsız şartsız kabul etmiş, C mirası reddetmiştir. B ve C seçimleri ile kesin olarak bağlıdırlar. A'nın da resmi defter tutma talebi yerine getirilecek, ancak (B ve C seçimleri ile bağlı oldukları için), resmi defter tutmadan sonra sadece A'nın seçim hakkı olacaktır. Ne var ki, onun bu seçim hakkı, B'nin mirası kabulü dolayısıyla sınırlandırılmıştır. O artık, MK 632/II hükmü gereği, resmi tasfiye talebinde bulunamayıp, mirası kayıtsız şartsız ya da tutulan deftere göre kabul ya da ret şıklarından birini seçebilecektir.

1815 2. A, resmi tasfiye talep etmiş, B mirası reddetmiş ve C mirası kabul etmiştir. Bu durumda B, seçimi gereği mirasçılık sıftını kaybeder. C ise kabulü ile kesin olarak bağlıdır. A'nın resmi tasfiye talebi, mirası kabul eden birisi bulunduğu için (MK 632/II) geçerli olmaz. Bu durumda A, eğer ret süresi geçmemişse seçim hakkını yeniden kullanır Ret süresi geçmişse MK 615'in örneksemeyle uygulanmasıyla talebi üzerine hakim kendisine yeni bir süre verir. Ancak A, yeni bir süre için başvurmazsa, mirası kabul etmiş sayılır[1135].

[1135] *Tuor/Picenoni*, 593 N 3; *Escher*, Art. 593 N 9; *Kocayusufpaşaoğlu*, 654.

3. A mirası reddetmiş, B resmi resmi defter tutma talebinde bulunmuş C, resmi tasfiyeyi istemiştir. A, reddi ile bağlı olup aradan çıkar. B ve C'ye gelince; kanunun resmi tasfiyeyi mümkün olduğu kadar önleme amacı göz önünde bulundurularak ve mirasçılardan birinin resmi defter tutmayı istemesinden önce kesin olarak kabul ya da reddetmemiş bütün mirasçıların bundan yararlanacağı düşünülerek[1136], resmi defter tutmaya üstünlük tanınır. Bu halde, resmi defterin tutulmasından sonra B ve C'ye yeni bir seçim hakkı tanınır ve B'nin mirası kabul etmemesi şartıyla, C isterse yeniden resmi tasfiye talebinde bulunabilir.Her ikisi de bir aylık süreyi susarak geçirirlerse mirası tutulan deftere göre kabul etmiş sayılırlar (MK 627/II). 1816

4. A, mirası kabul, B reddetmiş, C resmi defter tutmayı talep etmiş, D ise resmi tasfiye istemiştir. A kabulü, B reddi ile bağlıdır. A kabul ve C resmi defter tutma talebinde bulunduğu için, D'nin resmi tasfiye talebi dinlenmez. O, resmi defter tumanın bitmesinden sonra C ile birlikte yeniden bir seçim hakkı elde eder. Ancak C ve D, A mirası kabul ettiği için resmi tasfiye isteminde bulunamazlar (MK 632/II). Süreyi susarak geçirirlerse, mirası tutulan deftere göre kabul etmiş sayılırlar (MK 627/II). 1817

Bütün bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, aslında resmi tasfiye, başka bir mirasçının mirası kayıtsız şartsız ya da tutulan deftere göre kabul etmemesi bozucu şartına bağlıdır. Bir mirasçı mirası kabul ederse, bozucu şart gerçekleştiği için, resmi tasfiye talebi geçersiz olur. 1818

III. MİRASÇILARIN RESMİ DEFTER TUTMA TALEBİNDEN SONRA SEÇİM HAKLARINI FARKLI YÖNDE KULLANMALARI

1. Mirasın resmen defterinin tutulmasından sonra A mirası kayıtsız şartsız kabul etmiş, B reddetmiş C tutulan deftere göre kabul etmiştir. Burada her bir mirasçi kendi seçimi ile bağlıdır. Yani B, mirasçılık sıfatını kaybeder, A, mirası kayıtsız şartsız kabul ettiği için, bütün borçlardan kişisel olarak da sorumlu olur. C ise, mirası tutulan deftere göre kabul ettiği için, *sadece deftere yazılı olan borçlardan kişisel olarak da sorumlu olur.* 1819

2. A, mirası reddetmiş, B tutulan deftere göre kabul etmiş, C ise resmi tasfiye istemiştir. A, reddi ile B de tutulan deftere göre kabulü ile bağlıdır. Kabul eden bir mirasçı bulunduğuna göre, C'nin resmi tasfiye talebi geçerli olmaz ve ona yeni bir seçim imkânın tanınır. Süreyi susarak geçirirse, mirası tutulan deftere göre kabul etmiş sayılır (MK 627/II)[1137]. 1820

[1136] *Kocayusufpaşaoğlu*, 654.

[1137] Örnekler, *Kocayusufpaşaoğlu*, 653 vd.den esinlenilerek hazırlanmıştır.

§ 36. Miras Sebebiyle İstihkak Davası

I. KAVRAM, NİTELİĞİ VE ÖZELLİKLERİ

1. Mirasçılık sıfatına bağlı özel bir dava olması

1821 Miras Hukuku sistememizde, mirasbırakanın ölümü üzerine mirasçılar, külli halefiyet yoluyla kendiliğinden terekede yer alan her mala ve hakka sahip olduklarından, onların tereke üzerindeki kendilerine intikal etmiş bu haklara dayanarak terekeye kısmen veya tamamen el koymak isteyen kişilerden bunları talep etmeleri mümkündür. Böylece mirasçılar, el konulan taşınırları, istihak ya da zilyetlik davaları ile; başkasının adına tescil edilen taşınmazları tapu kütüğünün düzeltilmesi davasıyla, tecavüz edilen taşınmazları müdahalenin meni davası ile; sahip oldukları alacak haklarını da bu hakları ileri sürerek ya da tespit davası ile korurlar. Bütün bunlar, mirasbırakanın bu haklara sahip olmasından kaynaklanan ve ondan mirasçılara külli halefiyet yoluyla geçmiş talep haklarıdır.

1822 Ne var ki Medeni Kanun, mirasçının sadece bunlarla korunmasıyla yetinmemiş, ayrıca mirasçılara, sadece bu sıfatlarından dolayı, sahip oldukları hakları koruyan özel bir dava hakkı tanımıştır. MK 637-639 arasında düzenlenen bu hakka, *miras sebebiyle istihkak davası* denir.

1823 Eskiden beri hukukçular arasında niteliği ve hükümleri çok tartışılan miras sebebiyle istihkak davası, mirasçıların tereke malları üzeinde münferit bazı aynî ve şahsî haklara sahip olmaları sebebiyle değil, miras hukuku hükümlerine göre mirasçı sıfatına sahip olmaları sebebiyle ve bu sıfatının sonucu olarak tereke üzerindeki çıkarlarını korumak için tanınmış, özel bir talep hakkını içeren eda davasıdır.

2. Mülkiyet hakkına dayanan istihkak davası ile farkları

1824 Miras sebebiyle istihkak davası her şeyden önce mirasçılık sıfatına bağlı ve bundan doğan bir dava olarak MK 683'deki mülkiyet hakkına dayanan (adi) istihkak davasından ayrılır. Bu bakımdan miras sebebiyle istihkak davası açacak olan kişi mirasçı sıfatına sahip olmalı ve bunu ön koşul olarak ispat edebilmelidir.

1825 Miras sebebiyle istihkak davasının da adi istihkak davası gibi aynî bir dava olduğundan söz edilirse de; burada kastedilen bunun mutlak hak niteliği taşıdığıdır. Yani terekede yer alan bir malı veya hakkı iade etmesi gereken herkese karşı yöneltilebilmesidir. Zira terekede yer alan aynî haklar dışındaki haklar (fikri haklar, alacak hakları vs.) da miras sebebiyle istihkak davasına konu olabilirler. Diğer bir deyişle adi istikak davasından fark-

lı olarak, miras sebebiyle istihkak davasına taşınır ve taşınmaz eşyalar dışındaki tereke unsurları da girebilir.

Miras sebebiyle istihakak davası aslında tüm terekeye ilişkin mirasçılık 1826
hakkının gaspedilmiş olması hâlinde açılan (külli dava), ancak baskın görüşe göre, bunun yanında sadece belirli tereke mallarına haksız zilyet olanlara karşı da açılabilen bir eda davasıdır (MK 637/I)[1138]. Buna karşılık adi istihkak davası, sadece belirli (münferit) mallar üzerinde haksız zilyet olanlara karşı açılır.

Belirtmek gerekir ki, eski hükümlerden farklı olarak (e. MK 577 vd), 1827
yeni Medeni Kanun'da *zilyet* yerine *elinde bulunduran* terimi kullanılmıştır. Gerekçe'de bu değişikliğin sebebi olarak elinde bulunduran teriminin zilyetlikten daha geniş bir kavram olduğu için tercih edildiği belirtilmiştir[1139]. Bu değişikliğin ne dereceye kadar doğru olduğu tartışmasına girmeden, elinde bulunduran bir çok halde (haksız) zilyet olacağı için biz, zilyet terimini kullanmaya devam edeceğiz.

Özellikle miras sebebiyle istihkak davasının bir tereke malına herhangi 1828
bir surette haksız zilyet olan herkese (örneğin esasın mirasçılık iddia etmeyen bir hırsız) karşı da açılabileceği kabul edilince;doğrusu bu davanın terekeye dahil münferit taşınır ve taşınmaz mallar hakkında açılması durumunda, adi istihkak davasından nitelik bakımından değil de sadece bazı sonuçları bakımından farkı kalmaktadır. Bunların en önemlileri: a) MK 638/II'de açıkca düzenlendiği üzere, miras sebebiyle istihkak davasında, davalının *kazandırıcı zamanaşımı* ile malı iktisap ettiğini ileri sürememesi; b) geri verilmesi talep edilen mal nerede ve kimin elinde bulunursa bulunsun, miras sebebiyle istihkak davasının, mirasbırakanın son yerleşim yeri mahkemesinde açılabilmesidir.

Özellikle adi istihkak davasını önleyen kazandırıcı zamanaşımı savun- 1829
masının miras sebebiyle istihkak davasında özel hükümle bertaraf edilmiş olması önemlidir. Böylece dava konusu malın mülkiyeti haksız zilyet tarafından mirasbırakanın ölümünden sonra MK 712,713 ve 777 hükümlerin

---

[1138] *Escher*, Art. 598 N 7-13; *Tuor/Picenoni*, Art. 598-601, Vorbem. 9-10; *Kocayusufpaşaoğlu*, 658; *İmre/Erman*, 353; *Oğuzman*, 309-310; *Serozan/Engin*, § 6, N. 105 vd., N. 113; *Tandoğan*, Miras Sebebiyle İstihkak Davası, AHFD, 1955, c.12, sayı 1-2, 270; *Güral*, Miras Sebebiyle İstihkak Davasına Kimler Taraf Olabilirler, ABD, 1953, sayı 5, 400. Artık terkedilmiş gibi görünen ve miras sebebiyle istihkak davasını, sadece bir mirasçının üstün mirasçılık hakkına dayanarak gaspedilmiş olan bu hakkın iadesi için açabileceği, fakat münferit mallar konu yapılarak ve bu malları esasen üstün hak iddia etmeyen kişinin elinde tutması durumunda açılamayacağı görüşünde, *Gönensay/Birsen*, Miras Hukuku, İstanbul 1956, 278 vd; *Akbıyık*, 123 vd.

[1139] Bkz., Gerekçe.

şartları gerçekleştirilip kazandırıcı zamanaşımı ile iktisap edilmiş olsa bile, miras sebebiyle istihkak davasının MK 639'da öngörülmüş zamanaşımı süreleri dolmadıkça, davalı zamanaşımı ile kazandığı mülkiyeti ileri sürerek malı geri vermekten kaçınamayacaktır.

1830 Şayet kazandırıcı zamanaşımının şartları, mirasbırakanın ölümünden önce gerçekleşmiş ve zilyet malik olmuşsa, bu durumda esasen bu mal terekede yer almaz ve esasen miras sebebiyle istihkak davasına konu olamaz (*Oğuzman*, 312).

1831 Burada dikkat edilmesi gereken husus, miras sebebiyle istihkak davasına karşı kazandırıcı zamanaşımının ileri sürülemeyeceğini belirten MK 638/II hükmünün, şartları gerçekleşen kazandırıcı zamanaşımı ile iktisabı önlemeyip, sadece bunun savunma olarak, miras sebebiyle istihkak davacısına karşı ileri sürülemeyeceğidir. Yoksa, örneğin, MK 683 gereğince açılan adi istihkak davasında, bu davayı bir mirasçı açmış olsa bile, kazandırıcı zamanaşımı ile iktisap ilare sürülebilecektir. Böylece kazandırıcı zamanaşımı ile, sadece miras sebebiyle istihkak davası açana karşı etkisiz bir mülkiyet hakkı kazanılmış olacaktır[1140].

1832 Kazandırıcı zamanaşımına karşı mirasçıyı koruduğu için, miras sebebiyle istihkak davası adi (mülkiyete dayalı) istihkak davasından daha avantajlı ise de; ileride açıklanacağı üzere, miras sebebiyle istihkak davasını kanun bazı zamanaşımı sürelerine bağlamışken, mülkiyete dayanan istihkak davası süre ile sınırlı değildir.

1833 Her iki davanın da şartlarının gerçekleştiği durumlarda, mirasçı talebini bunlardan dilediğine dayandırabilir, fakat, seçiminin sonuçlarını da olduğu gibi kabullenmek zorundadır.

3. Koruyucu önlemler (tedbirler)

1834 MK 637/III, miras sebebiyle istihkak davasını yalın bir eda davası olarak düzenlemekle yetinmemiş, ayrıca davacıya, hakkının korunması için bazı önlemlerin alınmasını hakimden isteme hakkını tanımıştır. Maddede bunlar, güvence gösterilmesi ve (taşınmazları için) tapuya şerh verilmesi belirtilmiştir. Ancak bunlar örnek kabilinden olup, sınırlayıcı değildir. Örneğin, hakim dava konusu malın, dava sonuna kadar korunmak üzere yeddi emine verilmesine de karar verebilir. MK 637/III'deki bu özel önlem hükümleri sayesinde, dava sonucuna kadar mirasçının hakkının tehlikede olduğu durumlarda HUMK hükümlerine gitmeye gerek kalmadan, önlem talep edilebilecektir.

[1140] *Escher*, Art. 599 N 25; *Kocayusufpaşaoğlu*, 66; *Akbıyık*, 277;

Ancak, miras sebebiyle istihkak davası nedeniyle MK 637/III'de tanınan önlem talepleri, asıl dava açılmadan istenemez. Maddenin ifadesi buna uygun değildir. Böyle bir ihtiyaç hâlinde Usul Hukuku kurallarına başvurulacaktır. 1835

II. DAVANIN KONUSU

Bu gün baskın görüşün kabul ettiği üzere[1141], miras sebebiyle istihkak davasının konusu tüm tereke ya da terekenin bir kısmı olabileceği gibi, terekeye giren münferit mal ya da haklar da olabilir. Bu baskın görüş ifadesini, "*... terekeyi veya bazı tereke mallarını...*" diyen MK 637/I'de ifadesini bulmuştur. Ancak, burada korunan, bu mal üzerindeki mülkiyet hakkı değil, mirasçının bu sıfat ile sahip olduğu tereke üzerindeki hakkı olduğundan,; miras sebebiyle istihkak davasının, ancak mirasçının mirasın açılmasından beri fiilen zilyetliğini (elinde bulundurmayı) elde edemediği tereke veya tereke malı (ya da terekede yer alan başka bir değer) için açılacağı kabul edilmektedir[1142]. Diğer bir deyişle, şayet terekenin tümü veya unsurlarından biri fiilen bir mirasçının zilyetliğine geçmiş, fakat sonradan izni olmaksızın onun elinden alınmışsa, artık miras sebebiyle istihak davası değil, adi istihkak davası (şayet miras paylaşılmamışsa bütün mirasçılar tarafından) ya da şartlara göre, eşya hukununun zilşyetliği kroruyan davaları açılabilir. Hemen belirtelim ki, burada MK 599/I uyarınca, mirasçıların mirasın açılması ile kazanış sayıldıkları ve fiili egemenliği gerektirmeyen zilyetlik[1143] kastedilmemektedir. Miras sebebiyle istihkak davasını engelleyen zilyetlik, tereke malını fiilen mirasçının hakimiyetine sokmuş, fakat sonradan haksız olarak başkasının zilyetliğine geçmiş olan zilyetliktir. Gene belirtelim ki, mirasçı henüz mirasbırakanın sağlığında, onun bir malına zilyet olmuş ve bu zilyetliği haksız olarak başkası tarafından gaspedildikten sonra mirasbırakan ölmüş ise, yine miras sebebiyle istihkak davası açılabilir. Zira, mirasçı, *mirasçı sıfatıyla* bu malın fiilen zilyetliğine hiç bir zaman sahip olmamıştır. 1836

Şayet miras sebebiyle istihkak davasının konusunu oluşturan mal, davalı tarafından elinden çıkartılmışsa, bunun yerine elde edilen karşılığın dava konusu yapılabileceği kabul edilmektedir[1144]. Böylece davalının tereke ma- 1837

[1141] Bkz. Dn. 431'de anılan yazarlar.

[1142] *Escher*, Art. 598 N 8; *Tuor/Picenoni*, Art 598 N 30; *Kocayusufpaşaoğlu*, 669; *Akbıyık*, 70.

[1143] MK 599/I hükmünün, mirasçıya gerçek zilyetliği temin etmeyip, sadece onun zilyetliği koruyan hükümlerden yararlanmasını temin ettiğine ilişkin bkz., *Kocayusufpaşaoğlu*, 669.

[1144] *Escher*, Art. 599 N 4; *Tuor/Picenoni*, Art. 599 N 14; *Kocayusufpaşaoğlu*, 661; *Oğuzman*, 312; *Serozan/Engin*, § 6, N. 109; *Akbıyık*, 244vd. HGK 20.1.1965, 15/32; bu sonuca tenkis ve iptal davalarındaki ayni ikame kavramından yararlanılarak varılmaktadır.

lını satması üzerine elde ettiği bedel alacağı, trampa etmesi üzerine aldığı mal miras sebebiyle istihkak davasına konu olabilecektir.

1838 Kuşkusuz üçüncü kişi iyiniyetli değilse,davalının tasarruf yetkisi eksikliği sebebiyle tereke malı üzerinde hak sahibi olamaz. Bu durumda davacı mirasçı, yapılan devri kabul edip, karşı edimi (ayni ikameyi) miras sebebiyle istihkak davasına konu yapabileceği gibi; bunun yerine yeni haksız zilyed üçüncü kişiye karşı miras sebebiyle istihkak davası da açabilir. Bu takdirde ilk davalıya karşı haksız fiil (bazan borca aykırılık) sebebiyle tazminat davası açabilecektir. Bu halde tazminat, malı üçüncü kişiden ne şekilde ve ne zaman alacağına göre belirlenecektir.

III. DAVANIN TARAFLARI

1. Davacı

1839 Miras sebebiyle istihkak davasının davacısı, mirasçı sıfatıyla terekeye dahil değerler üzerinde hak sahibi olan ve bu hakkı gaspedilmek istenen yasal ya da atanmış mirasçıdır. Yasal ya da atanmış mirasçı sıfatına sahip olmayanlar, örneğin vasiyet alacaklıları bu davayı açamaz. Belirtelim ki, vasiyet alacaklısının dava hakkı MK 662'de ayrıca düzenlenmiştir.

1840 Esasen vasiyet alacaklısı, sadece mirasaçıların bazısına ya da tümüne karşı ileri sürebileceği bir alacak hakkına sahip olduğundan, bu alacağın borçlusu olmayan kişilere karşı herhangi bir dava açma ya da talepte bulunma imkânına sahip değildir.

1841 Davacı, dava konusu tereke ya da tereke malında (değerinde) mirasçı sıfatıyla, davalıdan daha üstün bir hakka sahip olmalıdır. Mirasçının bunu ispatlaması gereken bazı durumlarda, esasen ölüme bağlı tasarrufun iptali ya da tenkis gibi başka bir davanın önce sonuçlandırılması gerekebilir. Zira dava konusu malın terekede yer alıp, mirasçının üstün hakkı çerçevesine girdiği ancak böyle ortaya çıkabilir.

1842 Miras ortaklığı devam ederken, mirasçılardan birinin tek başına tereke-yi ya da terekede bulunan bir değeri haksız olarak elinde bulunduran üçüncü kişiye karşı dava açabilip açamayacağına ilişkin eski Medeni Kanunda bir hüküm yoktu. Baskın görüş, miras ortaklığında, elbirliğiyle hak sahibi olmalarından hareketle, mirasçıların tek başlarına dava açamayacakları yönündeydi. Bu sebeple bütün mirasçıların bu davayı birlikte açmaları gerektiği söyleniyordu[1145].

[1145] *Escher*, Art. 598 N 3; *Tuor/Picenoni*, Art. 598 N 10; *Oğuzman*, 310; *Kocayusufpaşaoğlu*, 662.

Ne var ki, bu görüşe göre, hakim bir mirasçının açtığı davayı hemen 1843
reddetmeyip, bilinen diğer mirasçıların davaya katılması için süre vermelidir. Bu konuda doktrinde başka görüşler de ileri sürülmüştür. Örneğin bir kolaylık olmak üzere, mirasçı olmayan haksız zilyede karşı (varsa) vasiyeti yerine getirme görevlisinin de miras sebebiyle istihkak davası açabilmesi önerilmiştir[1146]. Gerekçe olarak, bunun tüm mirasçılar lehine olacağı, bu sebeple de vasiyeti yerine getirme görevlisinin, kanuni yetkisine dayanarak diğer mirasçıları temsilen ve hiç bir mirasçının da davaya karşı çıkmaması şartıyla, mirasçı olmayan kişiden tereke malını almak için bu davayı açabileceğini kabul etmenin makul olacağı ileri sürülmüştür[1147]. Aynı yetkinin miras ortaklığına atanan mirasçıya tanınmasını ileri süren yazarlar da vardır. Yine Eski Medeni Kanunun 584/a maddesi hükmüne göre de, mirasçılardan birinin talebi üzerine hakimin verdiği süre içinde diğer bir mirasçı itiraz etmediği ve paylaştırma davası da açılmadığı için, paylaştırmadan önce, elbirliği ile mülkiyet, paylı (müşterek) mülkiyete dönüşmüşse, eMK 625/I çerçevesinde bir koruyucu tedbir olarak, her mirasçı üçüncü kişiye karşı tek başına miras sebebiyle istihkak davası açabilir. Bu hükümler yeni MK 'da da (MK 644/I, 693/III) vardır. Ancak aşağıda açıklanacağı gibi, MK 640/IV karşısında mirasçının, haksız zilyet üçüncü işiye karşı tek başına miras sebebiyle istihkak davası açması için bu mekanizmaya başvurmasına artık gerek yoktur.

Mirasın paylaşılmasından sonra ise, her bir mirasçı, kendi payına düşen 1844
mallara ilişkin üçüncü kişiye karşı tek başına miras sebebiyle istihkak davası açacağı genel olarak kabul edilmekteydi[1148].

Oysa bu gün K 640/IV hükmü karşısında tam aksi yönde bir sonuca va- 1845
rıp, miras ortaklığının devamı sırasında da, ortaklığa dahil mirasçılardan her birinin tek başına terekeyi ya da terekeye dahil bir malı (değeri) haksız

---

[1146] *İmre*, (4. bası) 638.

[1147] *Dural/Öz*, birinci bası, 431.

[1148] Aksi görüş, *Oğuzman*, 310, dn. 209. Bu görüşü Piotet'ye atfen savunan yazar, eski MK 577'de, miras sebebiyle istihkak davasının, tereke malına haksız zilyet olan kişilere karşı açılacağından söz edilmesi sebebiyle, paylaştırmadan sonra belirli mirasçıya ayrılan malın artık tereke malı sayılmayacağından hareket etmiş olması gerekir. Kanımızca, şayet davacı mirasçı, paylaştırmadan sonra kendisine kalan malın fiili zilyetliğini hiç bir zaman elde edememişse, eMK 577'nin kapsamı amaca göre yorumlanarak bu malın haksız zilyedine karşı da miras sebebiyle istihkak davasının açılabilmesi gerekir. Zira mal, kavramsal olarak paylaşımdan sonra tereke malı sayılmayabilirse de tereke malı olduğu sırada haksız zilyetliği ele geçiren kişi hala bu durumunu sürdürmekte ve mirasçının da sonuçta miras menfaati gerçekleşmemiş olmaktadır. Kuşkusuz daha önce belirttiğimiz üzere, mirasçı mirasın açılmasından sonra malın fiili zilyetliğini ele geçirip de kaybetmişse, miras sebebiyle istihak davası değil, mülkiyet hakkına ya da zilyetliğin korunmasına dair dava açabilecektir.

olarak elinde bulundunan kimseye karşı miras sebebiyle istihkak davası açabileceğini kabul etmek gerekir[1149]. Gerçekten MK 640/IV'e göre, *"Mirasçılardan her biri,terekedeki hakların korunmasını isteyebilir. Sağlanan korumadan mirasçıların hepsi yararlanır"*. Görüldüğü gibi bu hüküm, miras ortaklığı devam ederken de mirasçılardan her birine terekedeki hakların korunması için harekete geçme, yani dava açma hakkını vermektedir. Terekenin geri alınması ya da terekeye dahil bir malın tekrar terekeye dönmesini temin hiç kuşkusuz *terekedeki hakkın korunması* amacını güder. Böyle olunca da, yukarıda da değinildiği gibi, miras ortaklığının devam ettiği süre içinde de, her bir mirasçının tek başına haksız zilyet üçüncü kişiye karşı miras sebebiyle istihkak davası açabileceğinden kuşku duymamak gerekir.

1846 Şayet mirasçılardan biri ya da bazıları, diğer mirasçılara karşı miras sebebiyle istihkak davası açmak isterlerse, bunların önce mirasın paylaştırılması davasını açıp sonucunu beklemeleri gerekir[1150]. Zira, hangi tereke kısmı ya da tereke malları üzerinde diğer mirasçıların üstün hakları olduğu daha önce bilinemez. MK 644/I hükmüne göre, tereke üzerindeki hakkın paylı mülkiyete dönüşmesi hâlinde de bir mirasçı diğerine karşı bu davayı açamaz. Zira her bir tereke malı üzerinde paylı mülkiyet hisseleri mevcut olup, buna paralel olarak, hiç bir mal üzerinde sadece bir mirasçının tek başınasahip olduğu mirasçılık hakkı yoktur. Ancak, davalı mirasçılık iddiası ile tereke malı üzerinde zilyet olsa bile, şayet davacı kendi mirasçılık sıfatını ispat etmenin yanında, davalının mirasçı sıfatına sahip olmadığını da tespit ettirirse, artık bu kişiye karşı, mirasın paylaşılmasını beklemeksizin miras sebebiyle istihkak davası açabilir.

1847 Mirasın paylaşılmasından sonra bir mirasçının kendisine düşen tereke kısmı hakkında diğer mirasçılara karşı miras sebebiyle istihkak davası açabilip açamayacağı da tartışmalıdır. Bizim katıldığımız görüşe göre, paylaştırmadan sonra kendisine ayrılan mallara zilyet olan diğer mirasçılara karşı, bu mallar payına düşen mirasçı, miras hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle miras sebebiyle istihkak davası açabilmelidir[1151]. Zira, miras sebebiyle istihkak davası bakımından, durumun, bu malı mirasçı olmayan kişinin gaspetmesinden farklı bir yönü yoktur. Bununla birlikte baskın görüş, paylaştırmaya katılan mirasçıların birbirlerine miras sebebiyle istihkak davası açamayıp, paylaştırmanın ifası davası açması gerektiği; ancak paylaştırmaya katılmamış olan mirasçının, paylaştırmadan sonra miras sebebiyle istih-

---

[1149] Aynı görüşte, *Akbıyık*, 160 vd.

[1150] *Escher*, Art. 598-601, Vorbem. 13-14; *Tuor/Picenoni*, Art. 598 N 12; *İmre/Erman*, 358; *Kocayusufpaşaoğlu*, 662; *Serozan/Engin*, § 6, N. 112.

[1151] Schucan, die Erbschaftsklage des schweizerischen Zivilgesetzbuches, Zürich 1943, 44; Beck, Schweizerische Juristische Karthotek, 873, 2.

kak davası açabileceği; paylaştırmaya katılan mirasçı, paylaştırmanın yanlış yapıldığını ileri sürüyorsa,bu paylaştırmanın iptali ile, yeni bir paylaştırma yapılmasını talep edebileceğidir[1152]. Diğer bir görüşe göre ise, paylaştırmaya katılsın katılmasın, paylaştırmadan sonra hiç bir mirasçı diğerine karşı miras sebebiyle istihkak davası açamayıp; paylaştırmada kendisine kalan malı istiyorsa,paylaştırmanın ifası,paylaştırma dışı kalmışsa paylaştırmanın iptali ve yeni bir paylaştırma yapılması davası açmalıdır[1153].

Son olarak belirtelim ki,bir davacının mirasçılık sıfatı tartışmalıysa, bu- 1848
nun tespiti için ayrı bir dava açılmasına gerek olmayıp, aynı dava içinde sıfat meselesi de çözülür (MK 637/II).

2. Davalı

Miras sebebiyle istihkak davasının, doğrudan tereke malları üzerindeki 1849
haklardan soyut olarak mirasçılık hakkını koruduğundan hareketle, sadece mirasçılık iddiası ile terekeye zilyet olanlara karşı açılabileceği şeklindeki sınırlayıcı görüş[1154] zayıflamış olup, bu gün artık tereke, mallarına mirasçılık iddiası ile ya da böyle bir iddiası olmadan haksız zilyet bununan (elinde bulunduran) herkese karşı açılabileceği görüşü baskındır[1155]. Neredeyse kırk senedir İsviçre Federal Mahkemesinin de, Yargıtay'ın da içtihatları bu doğrultudadır[1156]. Böylece bir hırsıza dahi miras sebebiyle istihkak davası açılabilmektedir, yeter ki, daha önce değinildiği üzere, mirasçı bu tereke malı üzerinde, mirasın açılmasından sonra fiili zilyetliği elde etmiş ve ardından mal elinden alınmış olmasın. Çünkü bu son halde adi istihkak davası açılacaktır[1157].

Davalı, aleyhine açılan davada, davacının mirasçı sıfatına sahip olma- 1850
dığını ya da kendisinin mirasçı sıfatıyla bu mal üzerinde hak sahibi olduğunu ya da kendisinin bir başta üstün hakka dayanarak bu mala zilyet olduğunu (örneğin, malın mirasbırakan tarafından kendisine kiralandığını ve kira sözleşmesinin devam ettiğini, bir başka deyişle, haksız zilyet olmadığını) savunma olarak ileri sürebilir. Davalı, mirasçı olduğunu iddia ediyorsa, bu iddiası (tıpkı davacının mirasçılık iddiasının tartışmalı olduğu hallerdeki gibi), miras sebebiyle istihkak davası içinde çözümlenir (MK 637/II).

[1152] *Escher*, Art. 498 Vorbem. 13; *Tuor/Picenoni*, Art. 498 N 12; *İmre/Erman*, 358; *Oğuzman*, 310 dn. 209.

[1153] *Baudat*, L'action en petition d' heredite en droit Suisse, Lausanne 1964, 23-24.

[1154] *Rossel/Mentha*, Manuel de Droit Civil Suisse, tome II, Lausanne et Geneve, 206; *Gönensay/Birsen*, Miras Hukuku, İstanbul 1956, 278/279.

[1155] Hakim fikre örnek olarak bkz, *Escher*, Art. 598 N 7 vd; *Tuor/Picenoni*, Art. 598 N 18; *Kocayusufpaşaoğlu*, 663 vd; *Oğuzman*, 311; *İmre/Erman*, 353 vd; *Akbıyık*, 201 vd.

[1156] HGK 12.10.1960, 32/66 (İKİD 1965, 3721 vd); BGE 91 II 336

[1157] Bkz., yukarıda, I, 4.

1851 Şayet davalının haksız zilyet olduğunun ve davacının miras hakkını ihlal ettiğinin saptanması bir başka işlemin geçersizliğinin tespitini ya da iptalini gerektiriyorsa bu ön mesele için başka bir dava açılmayıp, sorun MK 637/II'ye göre, açılmış olan miras sebebiyle istihkak davası çerçevesinde çözümlenir. Çünkü bu, mirasçılığın tespiti ile ilgili bir husustur Örneğin, davalı kendisinin de bu tereke ya da malda mirasçı olduğunu, zira mirasbırakan tarafından mirasçı atandığını ileri sürecek olursa, bu mirasçılık sıfatıyla ilgili bir uyuşmazlık olduğu için açılmış olan miras sebebiyle istihkak davası içinde çözümlenir, yoksa, onu atayan ölüme bağlı tasarrufun iptali için ayrı bir dava açılması gerekmez.

1852 Miras sebebiyle isitihkak davası bir eda (ifa) olup tazminat davası olmadığından, şayet davalı dava konusu malın zilyetliğini üçüncü kişiye devretmişse ya da üçüncü kişi davalının zilyetliğine son vererek mala zilyet olmuşsa, artık dava zilyetliği kaybeden kişiye değil, hali hazır haksız zilyet olan kişiye karşı açılıp yürütülmelidir. Kuşkusuz, miraçının kusurlu haksız zilyedin verdiği zararın tazminin dava etme imkânı saklıdır. Nihayet, daha önce açıklandığı üzere, malı eden çıkarması karşılığı davalı bir başka şey elde etmişse, miras bebebiyle istihkak davasının konusu bu şey olarak dava açılabilir ya da devam ettirilebilir.

1853 Haksız zilyet ölmüşse ve zilyetliği mirasçılarına geçmişse, bu durumda miras sebebiyle istihkak davası onun mirasçılarına karşı açılır.

1854 MK 638/I uyarınca, miras sebebiyle istihkak davasını kaybeden davalı, dava konusu malı zilyetlik hükümlerine göre davacıya geri verecektir. Bununla kastedilen, davalının iade yükümü belirlenirken, MK 993-995 hükümlerindeki haksız zilyedin iade sırasındaki sorumluluğuna ilişkin hükümlerin uygulanmasıdır. Böylece davalının kendisini mirasçıdan üstün hakka sahip gösterirken iyiniyetli sayılıp sayılmayacaına göre, sorumluluğu belirlenecektir.

1855 Miras sebebiyle istihkak davasında, davalının kazandırıcı zamanaşımı hükümlerine dayanmasının MK 638/II ile engellendiğini daha önce açıklamıştık[1158].

IV. SÜRE

1856 Miras sebebiyle istihakak davasının açılması, adi (mülkiyet hakkına dayanan) istihkak davasından farklı olarak, belirli sürelere bağlanmıştır. MK 639 bu süreleri açık olarak zamanaşımı süresi olarak düzenlediği için, BK 132 uyarınca durması ve BK 133 uyarınca da kesilmesi mümkündür.

[1158] Bkz., yukarıda I, 2.

Kanunda, davalı haksız zilyedin (elinde bulunduranın) iyiniyetli olup olmadığına göre farklı zamanaşımı süreleri getirilmiştir. 1857

Şayet davalı haksız zilyet iyiniyetli ise, yani davacının hakkını ve kendi haksızlığını bilmiyor ve bilmesi de gerekmiyorsa; zamanaşımı süresi, kendi mirasçılık hakkını ve davalının zilyetliğini öğrenmesinden itibaren *bir yıl* ve bunları öğrenmemiş olsa bile davacı, yasal mirasçı ya da miras sözleşmesi ile atanmış mirasçı ise, mirasın açıldığı (yani mirasbırakanın öldüğü) tarihten itibaren; vasiyetname ile atanmış mirasçıysa, vasiyetnamenin açılmasından itibaren *on yıldır* (MK 639/I). 1858

Eski Medeni Kanun zamanında, miras sebebiyle istihkak davasının akıbeti tereke malına zilyet olan kişinin haksızlığını ortaya koyacak bir başka davanın (örneğin vasiyetnamenin iptali davasının) sonucuna bağlanmışsa, bu dava sonuçlandırılmadıkça miras sebebiyle istihkak davasının bir yıllık süresinin işlemeyeceği kabul edilmekteydi[1159]. Yeni MK 637/II hükmü karşısında, artık bu görüşün uygulanabilirliği kalmamıştır. 1859

Buna karşılık, davalı iyiniyetli değilse zamanaşımı süresi *yirmi yıldır* (MK 639/II). Bu sürenin başlangıcına ilişkin kanunda bir hüküm yoksa da, iyiniyet hâlindeki on yıllık zamanaşımının başlangıç anı ile paralel olması gerektiği kabul edilmektedir[1160]. Böyle olunuca da yirmi yıllık süre, yasal mirasçılarla miras sözleşmesi ile atanan mirasçılar için mirasın intikali anından itibaren; vasiyetname ile atanmış mirasçılar için ise, vasiyetnamenin açılmasından itibaren işlemeye başlayacaktır. 1860

Tereke ya da tereke malına haksız zilyet olan kimse baştan beri kötüniyetliyse, bir ve on yıllık sürelerin yerini yirmi yıllık süre alır. Yani ona karşı yirmi yıl içinde dava açılabilir. Buna karşılık, haksız zilyet başlangıçta iyiniyetliyken, davacı mirasçının bir ve on yıllık süreleri dava açmadan geçirmesinden sonra gerçek durumu öğrenip kötü niyetli hale gelmesi, onu yirmi yıllık süreye tabi kılmaz ve artık bu gerekçe ile yirmi yıl dolmamış olsa bile aleyhine miras sebebiyle istihkak davası açılamaz. 1861

Önemle tekrar belirtmek gerekir ki, miras sebebiyle istihkak davasının bu açıkladığımız kurallara göre zamanaşımı süresi dolmamışsa, davalı, dava konusu mal üzerinde kazandırıcı zamanaşımı şartlarının gerçekleştiğini ileri sürerek savunma yapamaz. 1862

[1159] Örnek olarak bkz., *İmre/Erman*, 361-362.

[1160] *Kocayusufpaşaoğlu*, 671; *Oğuzman*, 313; *İmre/Erman*, 671; *Serozan/Engin*, § 6, N. 116; *Tuor/Picenoni*, Art. 600 N 6.

ALTINCI KISIM
MİRAS ORTAKLIĞI VE MİRASIN PAYLAŞILMASI

§ 37. Miras Ortaklığı

I. KAVRAM

1863 Mirasbırakanın tek mirasçısı varsa, terekenin yönetimi ve paylaştırılması konusunda herhangi bir sorun çıkmayacaktır. Burada sadece, tek bir mirasçının mirasbırakanın borçlarından sorumluluğu, vasiyet alacaklılarına karşı sorumluluğu, vergi hukukuna göre sorumluluğu ve tereke mallarını haksız zilyetlere karşı koruma gibi sorunlar gündeme gelebilir.

1864 Ne var ki, miras olaylarının büyük bir çoğunluğunda mirasbırakan geride birden fazla mirasaçı bırakır. Bu durumda gerek terekenin yönetimi gerekse mirasın paylaşılması sorunları çıkar. Söz konusu sorunlar çözümlenineeye kadar, mirasçıların oluşturdukları topluluk, hukuken kendi özgü bir ortaklık olarak düşünülmüş ve kanun buna *miras ortaklığı* demiştir. Kenar başlığında bu kavramı kullanan MK 640'a göre mirasın paylaştırılması tamamlanıncaya kadar tereke üzerinde *elbirliğiyle hak sahibi*[1161] *(iştirak hâlinde)* olan mirasçılar, bu süre boyunca kanun hükümlerine ve (varsa) aralarındaki sözleşmenin hükümlerine göre terekeyi yönetecek, borçlardan sorumlu olacak ve terekenin paylaştırılmasını talep edebileceklerdir.

1865 Aslında mirasın açılmasının doğal sonucu, esasen miras payları belirli (ya da belirlenebilir) olan mirasçıların terekedeki her bir mal ve hak üzerinde elbirliğiyle hak sahibi olmaları; yetki ve sorumlulukları ile bu malların yönetiminin paylı mülkiyete ilişkin genel hükümler olan MK 698-699 hükümlerine tabi olmasıydı. Gerçekten paylı (müşterek) mülkiyetin paya göre hak sahipliği sistemi ile miras hukukunun miras payları sistemi birbirine uymaktadır. Nitekim Roma Hukukunun kabul ettiği sistem genelde budur.

1866 Ancak, Alman Hukukunda olduğu gibi İsviçre ve Türk Hukuklarında

---

[1161] Terekededeki taşınır ve taşınmaz mallar bakımından elbirliğiyle mülkiyet söz konusu olacaksa da, diğer haklar üzerindeki mirasçılık durumunu da kapması bakımından elbirliğiyle hak sahipliği ifadesi daha doğrudur.

da, yasaca mirasın paylaşımına kadar, kural olarak terekenin mirasçıların malvarlığından ayrı bir malvarlığı oluşturması ve kendine özgü bu malvarlığı üzerinde, mirasçıların yine kendine özgü bir *elbirliğiyle hak sahipliği* bulunduğu kabul edilmiştir. İşte bu hakka sahip olan mirasçılar, *miras ortaklığını* oluştururlar.

Elbirliğiyle hak sahipliği sayesinde, örneğin mirasbırakandan alacaklı olan mirasçının aynı zamanda mirasçı sıfatıyla bu alacağın borçlusu olmasının, alacaklı ve borçlu sıfatlarının birleştiği gerekçesiyle sona erdirmeyeceği ileri sürülmektedir[1162]. 1867

Bu durum ortaklık olarak adlandırılmasına karşılık BK 520-541 hükümlerindeki ortaklık sözleşmesine uymayan özellikleri vardır. Bir kere, mirasçıların anlaşması gerekmeksizin, hatta bazılarının mirasın açıldığından haberleri olmadan ve gene bazıları karşı çıksa bile miras ortaklığı doğmakta; mirasın paylaşılması, mirasçıların iradelerine bakılmaksızın, kanun tarafından ortaklık amacı olarak varsayılmaktadır. *Önemle belirtelim ki, miras ortaklığının tüzel kişiliği yoktur.* 1868

Bu sistem sayesinde (ve bu sistem yüzünden) mirasın bir an önce paylaşılması büyük bir ihtiyaç olmakta, terekenin yönetimi için resmi bir temsilci atanması önem taşımakta, açılmış miras payının devrinin ayrı ve özel hükümlerle düzenlenmesi gerekmekte, miras bebebiyle istihkak davası gibi soyut ve çerçevesi tartışmalı bir hakkın varlığı mümkün olmaktadır. 1869

Ne var ki, kanunun bu sistemden de ayrılan bazı hükümleri varadır. Örneğin MK 641, tereke barçlarından dolayı mirasçıların (elbirliğiyle değil) müteselsil sorumluluğunu kabul etmiş; MK 644 ise, miras paylaştırılmadan bir mirasçının talebi üzerine bazı şartlarla tereke üzerindeki elbirliğiyle hak sahipliğinin paylı hat sahipliğine (mallar bakımından paylı mülkiyete) dönüşmesine imkân vermiştir. 1870

II. MİRAS ORTAKLIĞININ HÜKÜMLERİ

1. Tereke üzerinde mirasçıların hak ve yetkileri, davacı olmaları

Miras ortaklığı devam ederken mirasçılar tereke üzerinde elbirliğiyle hak sahibi olduklarından, terekedeki hakları paylı olarak değil bölünmez ve bütünsel bir hak olarak mirasçılara aittir. Böylece, örneğin, terekedeki taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde miras ortaklığı sırasında mirasçıların MK 701 uyarınca elbirliği hâlinde mülkiyet hakları vardır ve bu sebeple de mülkiyt hakları elbirliğiyle mülkiyet hükümlerine tabi olacaktır. Mülkiyet 1871

[1162] *Oğuzman*, 230.

dışındaki haklar bakımından ise, kanunumuz mülkiyet dışındaki haklarda elbirliğiyle hak sahipliğini düzenlemediği için, yine MK 701-703 hükümleri örneksemeyle uygulanacaktır. Ancak, Medeni Kanunun Miras Hukukuna ilişkin hükümleri, Eşya Hukuku hükümlerine göre özel hüküm nitelikte olduklarından, öncelikle uygulanırlar.

1872 Elbirliğiyle hak sahipliğinde, hak sahiplerinin payları yoktur. Yani elbirliğiyle mülkiyete tabi bir eşya üzerinde maliklerin mülkiyet payları bulunmaz. Buradaki mülkiyet hakkı kayden dahi bölünmez bir bütün oluşturur (MK 701/II). Elbirliği hâlindeki malikler, konumuz bakımından, miras ortaklığındaki mirasçılar, terekedeki her mal üzerinde bulunan *tek mülkiyet hakkının birden çok sahibidirler*.

1873 Bunun sonucu olarak elbirliği içindeki hak sahipleri, sahip oldukları bu hakka ilişkin her türlü işlemi, kural olarak, hep birlikte yapmak, her türlü kararı oybirliğiyle almak, şayet bir değerlendirme söz konusu olacaksa, hep birlikte değerlendirmek zorundadırlar (MK 702/II). Miras ortaklığına dahil mirasçılar da, terekede yer alan hiç bir unsur üzerinde, kural olarak tek başlarına ya da oyçokluğuyla[1163] hiç bir tasarrufta bulunamazlar (MK 640/II). Örneğin, bir ya da bir kaç mirasçı, tereke malını satamaz, kiralayamaz, ekip biçemez hatta olduğu yerden alıp başka yere götüremez.

1874 Kural, mirasçıların hep birlikte hareket etmeleri olmakla beraber, mirasçıların aralarındaki bir sözleşme sonucu temsilci atamışlarsa ya da kanunudan doğan bir temsil veya yönetim yetkilisi varsa, ortaklığı dahil mirasçıların hep birlikte hareket etmeleri aranmaz. Böyle bir halde, atanan temsilci ya da kanun gereği temsil ve yönetim yetkisine sahip olan kişi tek başına hareket eder (MK 640/II). Örneğin, vasiyeti yerine getirme görevlisinin bulunduğu hallerde durum böyledir. Mirasçıların anlaşarak temsilci atadıkarı halde de aynı şey söz konusudur. Ancak irade temsilci atanması hâlinde dikkat edilmesi gereken husus temsilci atamanın oybirliği ile olmasıdır. Ancak belirtmek gerekir ki, mirasçıların anlaşamamaları hâlinde, sulh hakimi bir mirasçının başvurusu üzerine ortaklığa bir temsilci atayabilir (MK 640/III). Mirasçıların atadıkları temsilci BK 32 vd. hükümlerine tabi olduğu için, mirasçılar BK 34'e göre temsil yetkisini her zaman kaldırabilirler ve kaldırmayacaklarına ilişkin önceden verecekleri taahhüt de geçersiz olacaktır.

1875 Mirasçıların MK 494-499 hükümlerine göre belirlenecek olan miras paylarına sahip olmaları, tereke üzerinde mülkiyet (ya da başka bir hak) payına sahip oldukları anlamına gelmez. Mirasçıların miras payları, miras

[1163] Oysa miras ortaklığında paylı mülkiyet olsaydı MK 690 uyarınca bazı kararların nitelikli (sayı ve pay bakımından) çoğunlukla, alınması mümkündü.

ortaklığı sırasında tereke üzerinde değil, bu terekenin paylaştırılması sırasında talep edecekleri kısım hakkındadır. Diğer bir deyişle, mirasçılar miras paylarına göre terekenin paylaştırılmasını isteyebilirler (ya da tenkis davası açabilirler), fakat miras ortaklığı devam ettiği sürece miras paylarına göre terekedeki mal ya da hakları kullanmayı, yönetmeyi, üçüncü kişiye devretmeyi isteyemezler.

Açılmış bir miras payının henüz miras ortaklığı devam ederken başka- 1876
sına devri mümkündür. Daha önce incelediğimiz bu durumdan[1164], elbirliğiyle hak sahipliğinin sonuçları etkilenmeyecektir. Zira MK 677 uyarınca, miras payı mirasçılar arasında devredilmişse, kalan mirasçılarla miras ortaklığı devam edecek ve burada, miras paylarının değişmesi esasen tereke üzerindeki hak ve yetkiler bakımından bir etki yapmayacaktır. Buna karşılık miras payı mirasçı olmayan bir kişiye devredilmişse, bu devir miras ortaklığına karşı hüküm ifade etmeyecektir.

Mirasçılardan bazılarının birbirlerine ya da üçüncü kişilere karşı tereke 1877
mallarını konu alan borçlandırıcı işlem yapmaları mümkün ve geçerlidir[1165]. Zira bu bir tasarruf işlemi olmadığı gibi, bu borcun ifası da imkânsız değildir. Ne var ki, borçlun ifa edilmesi, diğer bütün mirasçıların ifa (tasarruf işlemine) katılmaları ya da borçlu mirasçıyı yetkilendirmelerine bağlıdır. Aksi takdirde, örneğin, tek başına sattığı bir tereke malının mülkiyetini alıcıya geçiremeyecek olan mirasçı, ifa etmemeden sorumlu olacaktır.

Yukarıdaki açıklamalardan anlaşılacağı gibi, bir mirasçının tek başına 1878
tereke mallarını geçerli olarak satması ya da kiralaması mümkün olduğu için, aksi görüşü savunan *İmre/Erman*'a katılmak mümkün değildir[1166]. Borçlandırıcı işlem yapmak için tasarruf yetkisinin bulunmasına gerek görmeyen hukukumuzda, satıcının, başkasına ait bir malı satması bile geçerliyken, satıcının hiç olmazsa miras sebebiyle elbirliğiyle maliklerinden biri bulunduğu malın satışının geçersizliği asla ileri sürülemez. Böyle bir durumda, mirasçı sözleşmeyi, sadece kendi adına değil, diğer bütün mirasçıların da temsilcisi olarak yaptığını belirtmişse, belki temsil yetkisi eksikliğinden dolayı borçlandırıcı işlemin geçersiz olduğu savunulabilir. Acak bu husus dahi tartışma götürür. Zira, bu sonuca, satıcı mirasçının, diğer mirasçıların temsil yetkisi eksikliği üzerine kendisinin de bağlı olmayacağını baştan beyan etmiş sayılmasıyla varılmaktadır ki, böyle bir beyanın varlığı en azından her olayda kesin olmadığı gibi, bu tür bir savunmanın dürüstlük kuralına uygun olup olmadığı da tartışma götürür.

[1164] Bkz., yukarıda § 27, II.
[1165] *Kocayusufpaşaoğlu*, 692; *Oğuzman*, 315, dn. 31.
[1166] *İmre/Erman*, 380.

1879 Elbirliği ile mülkiyetin söz konusu olduğu hallerde, eski Medeni Kanun zamanında, elbirliğiyle mülkiyete tabi bir malın korunmasının gerektiği hallerde dahi ortakların oybirliği ile hareket etmeleri zorunluğu büyük bir sorun yaratıyordu. Kanundaki bu boşluk uygulamadaki kararlar ile çözülmeye çalışılmıştı[1167]. Yeni Medeni Kanun, bu sorunu gidermek amacıyla gerek elbirliği ile mülkiyeti genel olarak düzenleyen hükümlere (MK 702/IV) gerek miras ortaklığını düzenleyen hükümlere yeni bir düzenleme koyarak, elbirliğiyle malik olanların her birine, elbirliğine giren hakların korunuması amacıyla tek başına hareket etme imkânını vermiştir. Konumuzu ilgilendiren miras ortaklığında MK 640/IV'e göre, *"Mirasçılardan her biri, terekedeki hakların korunmasını isteyebilir. Sağlanan korumadan mirasçıların hepsi yararlanır"*.

1880 Bundan da anlaşılacağı gibi, terekeye dahil bir malın korunması için, zorunlu olan hallerde (örneğin, bir alacağın zamanaşımına uğramasını ya da bir taşınmaza yapılan tecavüzü engellemek amacıyla, ya da haksız zilyede karşı miras sebebiyle istihkak davası açmak), mirasçıların her biri tek başına, birlikte harekete gerek olmadan, temsil yetkisi verilmemiş olsa bile gerekli önlemleri aldırabilecek, örneğin dava açabilecek ya da icraya başvurabilecektir[1168]. Sonuç lehe olursa bundan bütün mirasçılar yararlanabilecek; aleyhte olması ise diğer mirasçıları etkilemeyecektir. Bu son halde, başka bir mirasçı ya da mirasçılar aynı konuda yeniden gerekli önlemlere başvurabileceklerdir[1169].

1881 Yukarıda da değinildiği gibi eski Medeni Kanunuda, MK 640'ı karşılayan MK 581'de böyle bir hüküm yoktu. Bu bakımdan mirasçılardan birinin tek başına terekeyi dahil olan bir hakkı korumak için dava açması hâlinde, mesele yukarıda belirtilen 11.10.1982 tarih ve 3/2 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı çerçevesinde çözümleniyordu. Buna göre, mirasçılardan birinin açtığı dava, davacı sıfatının yokluğu sebebiyle derhal reddedilmiyor, davaya diğer mirasçıların da katılabilmesini temin için bir süre veriliyordu. Bu katılmanın temin edilememesi hâlinde, hakim davayı yine reddetmeyip, mirasaçılardan birinin talebi üzerine miras ortaklığına bir temsilci atayıp, davayı sürdürebiliyordu. Buna karşılık terekeyi ilgilendiren bir dava, bir ya da birden fazla mirasçı tarafından, yine başka bazı mirasçılara karşı açılmışsa, esasen davalı mirasçının davaya onayını sormak mantıksız olacağından, sadece davalı olmayan mirasçıların onayının aranması yeterli görülmekteydi[1170].

[1167] Bkz., İBK 11.10.1982 3/2 (RG sayı 17884, 30.11.1982). Eski uygulama ile ilgili etraflı bilgi için bkz., *Dural/Öz*, birinci bası, 440).

[1168] 12.HD 5.10.1982, 6294/6893 (YKD 1982, c. VIII, 1559).

[1169] Gerekçe, 516.

[1170] *Escher*, Art. 602 N 61; *Kocayusufpaşaoğlu*, 694.

2. Mirasçıların davalı olması

a) Genel olarak

Terekeyi ilgilendiren bir hususta, üçüncü kişiler miras ortaklığı hâlinde 1882
kural olarak sadece bir mirasçıya değil, bütün mirasçılara arşı dava açmalıdırlar. Ancak, davanın konusu üçüncü kişinin alacak hakkıysa, tereke borçlarından mirasçılar elbirliği hâlinde değil de MK 641 uyarınca müteselsil sorumlu olduklarından, alacaklı dilediği bir ya da bir kaç mirasçıya dava açmakla yetinebilir Mirasçıladan tümüne bir davanın açılması gereken durumlarda, örneğin üçüncü kişinin terekede bulunan bir mal için istihkak davası açması hâlinde, bazı mirasçıların varlığı sonradan belirlenmişse, dava geçersiz sayılmayıp, bunların da davalılar arasına katılmak suretiyle, davanın görülmesi mümkün olmalıdır.

b) Vasiyet alacaklısı karşısında

Önemli bir sorun, terekedeki bir hakkın ya da malın devrine yönelik bir 1883
vasiyeti ifa borcunun mirasbırakanca sadece mirasçılardan birine ya da bir kısmına yüklenmiş olması hâlinde, vasiyet alacaklısının ne yapacağıdır. Zira vasiyette doğacak alacak hakkı nisbi olduğundan, alacaklı, vasiyet borçlusu olmayan mirasçıları dava edemeyip sadece vasiyet borçlusu mirasçıyı (ya da mirasçıları) dava edebilecektir. Oysa, miras ortaklığı devam ettiği sürece, bu mirasçının kendisine yüklenen vasiyet borcunu diğer mirasçıların da katılımı olmadan ifa etmesi mümkün değildir. Çünkü, elbirliğiyle hak sahipliğinin bir sonucu olarak, vasiyet konusu tereke malı ancak tüm mirasçıların rızasıyla vasiyet alacaklısına devredilebilir. Örneğin, mirasbırakan, terekesinde yer alan bir otomobilin mülkiyetini vasiyet ettiği kişiye devir yükümünü üç oğluindan sadece birine yüklemişse durum böyledir. Bu nakil yükümlüsü oğula karşı dava açan vasiyet alacaklısı, mahkemeden aynen ifa talep edemeyecektir. Zira davalının kardeşleri temsil yetkisi vermedikçe, bu borcvun ifası hususunda vasiyet borçlusunun temsil yetkisi yoktur. Mirasbırakanın bu vasiyetinin aynı zamanda vasiyet borçlusu davacıya vasiyet konusu otomobilin düşeceği konusunda bir paylaştırıma kuralı içerdiği kabul edilerek de sorun çözümlenemez. Çünkü, fiilen paylaşatırma yapılıp, otomobilin mülkiyeti tüm mirasçıların anlaşmasıyla ya da açılacak bir paylaştırma (taksim) davası sonucu mahkemenin paylaştırmasıyla vasiyet borçlusu mirasçıya geçinceye kadar, gene de, vasiyet borçlusu otomobilde, onu vasiyet alacaklısına devredecek tasarruf yetkisine sahip olmayacaktır.

Böylece vasiyet borçlusu kendisine yöneltilecek davada, esasen borcu 1884
ifa imkânına sahip olmadığını ve bunda kusursuz olduğunu kolayca ispat

edebileceğinden, kendisinden ifa yerine borca aykırılık sebebiyle tazminat da istenemeyecektir.

1885 Buna karşılık, vasiyet alacaklısının belli bir mirasçıdan terekedeki malın kendisine verilmesi hususundaki alacağının, esasen ancak terekenin paylaşılması tamamlanıp söz konusu mal vasiyet borçlusu mirasçıya devredilince muaccel olması düşünülebilir. Ne var ki, bu çözüm, vasiyet alacaklısının aleyhine bazı kötü kullanılmalara elverişlidir. Özellikle, vasiyet borcunu yerine getirmekten kurtulmak maksadıyla mirasçıların miras ortaklığını uzun zaman devam ettirmelerine karşı vasiyet alacaklısı çaresiz durumda kalacaktır.

1886 Buna karşılık, mirasçıların şahsi alacaklılarına hakimden paylaştırmaya müdahele etme hakkı veren MK 648 hükmünden kıyasen yararlanmak da sorunu çözmez. Çünkü bu hüküm, alacaklıya, mirasçılar yerine paylaştırmayı talep değil, zaten bir mirasçının başlattığı bir paylaştırmaya hakimin nezaretini sağlama imkânı vermektedir.

1887 Öte yandan, vasiyet alacaklılarına resmi tasfiyede ihtiyati tedbir talep etme imkânı tanıyan MK 633/II hükmüne kıyasen de incelediğimiz durumdaki vasiyet alacaklısının sorununa çözüm getirilemez. Çünkü bu hüküm, vasiyet alacaklısına resmi tasfiye isteme hakkı tanımadığı için, miras ortaklığı devam ettiği sürece ifaya ulşamamasına çare olamayacaktır.

1888 Bu durumlarda, acaba bir çare olarak, vasiyet borçlusunun borcu miras ortaklığı sırasında da muaccel olmakla birlikte, vasiyet alacaklısının sadece vasiyet borçlusuna değil, diğer mirasçılara karşı da ifa davası açması mümkün olabilir mi? *Kanımca* bu sonuç, adil ve pratik gözükmekle birlikte, vasiyet alacağının nisbi olduğu gerçeği karşısında, vasiyet borçlusu olmayan mirasçıların davalı sıfatına vasiyetname dışında bir hukuki gerekçe bulunması gerekecektir.

1889 Böyle bir durumda en doğrusu, önce sadece vasiyet borçlusu mirasçıya ifa davası açılması ve şayet bir davada vasiyet borçlusu, miras ortaklığı devam ettiği için diğer mirasçıların karşı çıkması yüzünden borcunu ifa edemeyeceğini ortaya koyarsa, vasiyeti ifa borçlusunun mirasçılık sıfatını kazanamaması üzerine bu borcu diğer mirasçılara yükleyen MK 519/II hükmüne kıyasen, davanın tüm mirasçılara yöneltilmesidir. Kuşkusuz, vasiyeti ifa borçlusunun kendi miras payının vasiyete konu tereke malını tamamen kapsayamayacağını ispat etmesi üzerine MK 519/I uyarınca sadece ona düşebilecek hissesinin vasiyet alacaklısına devri mümkün olmalıdır.

3. Tereke borçlarından sorumluluk

a. Müteselsil sorumluluk kuralı ve çerçevesi

MK 641/I, karşılığı olan eski MK 582'den farklı olarak, *müteveffanın* 1890
borçlarından değil de, *tereke borçlarından* söz eder (aslında yeni metinde hep tereke borçları terimi kullanılmaktadır). Bu kavram, müteveffanın borçları kavramından daha geniş olup, sadece mirasbırakandan intikal eden borçları değil, terekeye, yani mirasçılara karşı ileri sürülebilecek her türlü borcu (alacağı) kapsar. Böyle olunuca da, mirasçılar sadece, külli halefiyet gereği intikal eden borçlardan değil, terekeye karşı ileri sürülebilecek miras hukuku kaynaklı her türlü borçtan müteselsil sorumlu olacaklardır.

Mirasbırakanın borcu olmayan, fakat mirasçıların sorumlu oldukları di- 1891
ğer tereke borçlarının başında, MK 641/II'de belirtilmiş olanlar gelir. Bu hükme göre, *"Ana ve baba veya büyük ana ve büyük baba ile birlikte yaşayan ve emeklerini veya gelirlerini aileye özgüleyen ergin çocuklar ile torunlara verilecek uygun miktardaki tazminat, bu yüzden terekenin borç ödeme acze düşmemesi kaydıyla tereke borcu sayılır"*. Belirtmek gerekir ki, MK 641/II'ye göre, çocuk ya da torunlara ödenecek olan tazminat, mirasbırakanın borçları gibi, terekenin paylaşılmasından önce ödenecektir. Ancak kanun, bu ödemenin yapılmasına bir sınırlama getirmiştir ki, o da, bu ödeme sonucu terekenin aciz haline düşmemesedir. Eğer tereke bu sebeple aciz haline düşecekse bu tazminat ya hiç ya da tam olarak ödenmeyecektir. MK 641/II hükmü, sadece çocuklar ve torunlara tazminat ödemeyi öngördüğü için, başka hısımların, örneğin, amcası ile birlikte yaşayıp da, gelirini ya da emeğini amcasının ailesine özgüleyen bir yeğenin böyle biri talebi söz konusu olmayacaktır.

Aynı şekilde MK 507'de öngörülmüş olan cenaze masrafları, terekenini 1892
mühürlenmesi ve yazım giderleri, mirasbırakan ile birlikte yaşayan ve onun tarafından bakılan kimselerin üç aylık bakım giderleri de, tereke borcu olduklarından, mirasçılar bunlardan müteselsil sorumlu olurlar.

Bunun gibi, mirasbırakanın özel olarak vasiyet borçlusunu atamadığı 1893
hallerde mirasçıların vasiyet borcundan da müteselsil sorumlu olacakları MK 600/I'den açık olarak anlaşılmaktadır. Bunun üzerinde daha önce durulduğu için[1171], burada sadece hatırlatmakla yetinilecektir.

İşte bu tereke borçlarından mirasçılar MK 641/I'e göre, *müteselsil ola-* 1894
rak sorumludurlar. Bu hükme göre, miras ortaklığı devam ettiği süre içinde bile, mirasbırakanın sağlığında taraf olduğu borç ilişkisine külli halefiyet

[1171] Bkz., yukarıda § 17, 2,c,aa.

yoluyla taraf olan onun mirasçıları, bu ilişkiye bağlı borçlardan kişisel şekilde müteselsil sorumlu olacaklardır. Böylece mirasbırakanın alacaklıları, mirasçılar terekeden elbirliğiyle hak sahibi olmalarına rağmen, bu mirasçıların diledikleri birinden mirasbırakandan olan alacaklarını talep ya da dava edebileceklerdir.Kendisinden ifa talep edilen mirasçı, bu borçtan sadece miras payı oranında sorumlu olduğunu ileri süremeyecektir. Kısaca, alacaklı ve borçlular arasındaki teselsülü düzenleyen BK 162-168 hükümleri uygulama alanı bulacaktır. Belirtmek gerekir ki, mirasbırakanın alacaklısı isterse, yine müteselsil sorumluluk gereği, mirasçılardan biri yerine hepsinden de talepte bulunabilir.Bu söylenenlerin, mirasbırakandan intikal etmeyen diğer tereke borçları için de geçerli olduğunu bir defa daha hatırlatalım.

1895 Yukarıda söylenenler, mirasbırakanın sağlığında muaccel olmuş borçları için geçerli olduğu gibi, mirasın açılmasından sonra muaccel olacak (örneğin vadesi mirasbırakanın ölümünden sonra gelen) borçlar bakımından da söz konusudur. Hatta mirasbırakanın ölümüyle sona ermeyip, taraf sıfatı mirasçılara geçen sözleşmelerde, böyle bir sözleşmeden kaynaklanan dönemli bir borcun doğumu, mirasın açılmasından sonraya gelse bile, mirasçılar bundan da müteselsil sorumlu olacaklardır. Örneğin, kiracının ölümü üzerine mirasçıları olan eşi ve çocukları, sözleşme devam ettiği sürece, her ay kendi şahıslarında doğan kira borçlarından da müteselsil sorumlu olmalıdırlar. Burada, her ne kadar dar anlamda borçlar mirasbırakandan intikal etmeyip, mirasçıların şahsında doğuyorlarsa da, bunların aynaklandığı geniş anlamda borç ilişkisi (kira sözleşmesi) mirasbırakandan intikal etmiştir. Bunun sonucunda doğan borçlar da MK 651/I çerçevesine girmelidir.

1896 Bu konuyu bitirmeden önce, mirasbırakanın, mirasçılarına intikal eden borçlarıyla ilgili olarak bir kaç mesele üzerinde duralım. Mirasbırakan (vasiyet borçları yönünden müteselsil sorumluluğu kaldıran düzenlemeler getiribelirse de), kendisine ait olup da miras yoluyla geçen borçlarının ödenmesini sadece bazı mirasçılara yükleyerek, bu borçların alacaklılarına karşı tüm mirasçıların müteselsil sorumluluğunu ortadan kaldıramaz. Mirasbırakanın bir borcu sadece belli bir mirasçısına (ya da bazı mirasçılarına) yükleyen ölüme bağlı tasarrufu, sadece mirasın paylaşılmasına yönelik bir beyan sayılıp, mirasçılar arasındaki iç ilişkide sonuç doğuracak; alacaklının MK 641/I hükmüne göre, serbestçe seçip başvurduğu mirasçıların buna dayanarak savunma yapmalarına imkân vermeyecektir.

1897 Bir başka mesele de, tereke alacaklısının aynı zamanda bir mirasçı olduğu durumlarda müteselsil sorumluluğunun uygulanabilip uygulanamayacağıdır. Böyle bir durumda (örneğin kendi mirasbırakanına vaktiyle mal satmış olup henüz bedelini tahsil etmemiş bulunan mirasçının alacağı hakkında) MK 641/I hükmünün uygulanmayacağı ve diğer mirasçıların bu

borç için müteselsil sorumluluklarının bulunmayacağı kabul edilmektedir[1172]. Buna göre, tereke alacaklısı mirasçının bu alacağı, terekenin paylaşımı sırasında hesaba katılarak onun payı belirlenecek, bu aşamada gerekirse bazı tereke malları paraya çevrilerek ödenecektir. Bu çözüm, esasın mirasın paylaşımı yoluyla hesaplanacak olan mirasçılar arasında iki kez hesaplaşma ve iki ayrı ihtilaf çıkartılmasının hukuk ekonomisine aykırı ve mantıksız olduğuna dayanmaktadır ve isabetli olduğu söylenebilir. Bir mirasçının aynı zamanda vasiyet alacaklısı olması hâlinde (ön vasiyet) aynı sonuç kabuledilebilirse de; vasiyet alacağının ölüme bağlı bir tasarruftan kaynaklanan ve vasiyet alacaklısının mirasçı sıfatından ayrı olup, kanunda özel hükümlerle düzenlenen bir kurum olması sebebiyle, vasiyet alacaklısı mirasçının bu hakkını ileri sürerken herhangi bir vasiyet alacaklısından farklı olmaması gerektiği de ileri sürülebilir. Bu takdirde, vasiyet alacaklısı mirasçı- aksi mirasbırakan tarafından öngörülmedikçe-, kendi dışındaki diğer tüm mirasçılara karşı müteselsilen ve muaccel olur olmaz vasiyet alacağını ileri sürebilecektir.

Mirasbırakanın vergi borçlarından 5432 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun ikinci maddesine göre mirasçılar müteselsilen değil, miras payları kadar sorumlu olurlar. Mirasbırakanın ölümü üzerine mirasçıların şahsında doğan veraset ve intikal vergisi ödeme borcu da, aslında tereke borcu olmadığından, her birmirasçının payına göre doğar ve ödenir. 1898

b) Borcu ödeyen mirasçının rücu hakkı

Mirasçıların müteselsilen sorumlu oldukları bir borcu, sadece biri ya da bazısı öderse, diğerlerine başvurma hakkı doğar. Müteselsil borçluluğa ilişkin genel hükümlerde, yani BK 167'de düzenlenen rücu hakkı, müteselsil borçlu mirasçılar bakımından durumun özellikleri dikkate alınarak MK 482'de ayrıca düzenlenmemiştir. Bu hükme göre, iç ilişkide her mirasçı kural olarak, borcun kendi miras payı kadar olan kısmı yüklenecektir. Şu halde, kendi miras payından fazla ödeme yapan mirasçı diğer mirasçılardan her birine, ödediği fazla kısım için miras payları kadar başvurabilecektir. Kural bu olmakla beraber, iki halde rücu ilişkisi farklı olabilir. Bunlardan birincisi, mirasbırakanın, bir tereke borcunun tamamının ya da bir kısmının ödenmesini bir ölüme bağlı tasarrufla mirasçılardan sadece biri ya da bazılarına yüklemiş olmasıdır. Böyle bir halde rücu hakkı ölüme bağlı tasarrufta belirtildiği biçimde kullanılacaktır. Örneğin, mirasbırakan vasiyetnamesinde, vaktiyle satın aldığı malın bedelini ödemeyi malı kendisine bıraktığı oğluna yüklemişse; bedelin bir başka çocuk tarafından ödenmesi hâlinde, 1899

[1172] *İmre/Erman*, 398, 399.

ödeyen tüm bedelin tutarı için (yoksa miras payıyla orantılı kısmı için değil) asıl yükümlü olan kardeşine rücu edebilecektir.

1900 Şayet mirasbırakan, bu hususta ölüme bağlı tasarrufta bulunmayıp (örneğin bunu vasiyetnamesinde belirtmeyip), alacaklı ile yaptığı sözlaşmeye, ölümü hâlinde, sadece belirlediği mirasçısının borçlu olacağı hükmünü koydurmuşsa, bir tür ölüme bağlı tasarruf sayılacak bu beyan, vasiyetname şekillerinden biri ile yapılmadıkça geçerli olmayacaktır.

1901 İkinci hal ise, mirasçıların tümünün anlaşarak, tereke borcunu aralarından farklı yüklenmiş olmalarıdır. Bu takdirde de rücu MK 682'deki genel kurala göre değil, mirasçıların aralarındaki anlaşmaya göre gerçekleşecektir.

c) Mirasçıların güvence isteme hakkı

1902 MK 649/III, mirasçılardan her birine, tereke borçlarının paylaşmadan önce ifasını ya da güvenceye bağlanmasını isteme hakkı tanımıştır. Böylece mirasçıların müteselsilen sorumlu oldukları bir tereke borcunun ödenmesini isteyen mirasçının bu talebine diğer mirasçılar uymakla yükümlü sayılacaklar ve şayet karşı çıkarlarsa, talepte bulunan, mirasçı bu borcun terekedeki henüz paylaştırılmamış mal ve paralardan ödenmesini hakimden isteyebilecek, hakim de bu ödemeyi gerçekleştirecektir. Gene bu hüküm uyarınca, henüz tereke alacaklısı ifa talebinde bulunmadan, hatta bu borcun vadesi gelmeden, bir mirasçı tarafından ödenip, diğerlerine rücu edilmesi mümkün olduğu gibi, bu borcun ifası için diğer mirasçıların güvence vermesi de istenebilecektir.

1903 Talep olmadan ve borcun vadesi daha gelmeden bir mirasçı tarafından ödendikten sonra kendisine rücu edilen mirasçı, rücu edeni BK 143/son uyarınca bir ortak savunmayı yapmadığı gerekçesiyle sorumlu tutamamalıdır. Zira MK 649/III hükmü, özel bir müteselsil sorumluluk hükmü olarak, her bir müteselsil sorumlu mirasçıya paylaştırmadan önce ifada bulunma imkânı tanırken, borcun henüz vadesi gelmeden de ifada bulunmaya izin vermiş sayılmalıdır.

1904 Ayrıca MK 640/V uyarınca, mirasçılardan birinin aciz hâlinde bulunması üzerine, diğerleri haklarının korunması için gerekli tedbirlerin alınmasını hakimden isteyebilirler. Bu hüküm çerçevesinde de mirasçıların rücu hakkını korumak için tedbirler alınabilir.

1905 MK 682 hükmünde, kendi payından fazla ödeme bulunan mirasçının, alacaklıya halef olacağı belirtilmemişse de, BK 147 hükmünde rücu hakkı sahibine tanınanı burada da kabul etmeye bir engel yoktur. Böylece rücu

eden mirasçı, alacaklıya vaktiyle verilmiş rehin ve kefaletten de yararlanabilecektir.

d) Paylaşmanın tamamlanmasından sonraki durum

Mirasçıların tereke borçlarından (ve aksi mirasbırakan tarafından belir- 1906
tilmemişse vasiyet borçlarından) müteselsil sorumluluğu mirasın açılmasıyla başlar; fakat miras ortaklığının sona ermesiyle ortadan kalkmaz. MK 681/I hükmüne göre, alacaklı, alacak hakkının konusu olan borcun mirasçıler arasında bölünmesine ya da bazı mirasçılara nakline açık ya da örtülü olarak rıza göstermedikçe, mirasın paylaşılmasından itibaren ve şayet, bu tarihten daha sonra muaccel olan bir borç söz konusuysa, muacceliyet tarihinden itibaren beş yıl daha müteselsil sorumluluk devam eder (MK 681/II).

Terekenin paylaşılması sırasında mirasçılar tereke borcunu aralarında 1907
miras hisselerine göre veya farklı bir oranda paylaşabilecekleri gibi, bazı tereke borçlarını tamamen bir ya da bir kaç mirasçıya yükleyebilirler. Bu durum, kural olarak alacaklıya karşı olan müteselsil sorumluluğu etkilemez. Yani bu düzenlemeye rağmen, mirasçıların alacaklıya karşı müteselsil sorumlulukları devam eder. Ancak alacaklı, açık ya da örtülü bir beyanla, bu paylaşmaya kendisinin de uyacağını bildirirse artık müteselsil sorumluluk kalmaz (MK 681/I). Bu halde alacaklı, bu paylaşma uyarınca hangi mirasçı borcun ne kadarını üstlenmişse, sadece ona karşı bu kısmın ifasını talep ve dava edebilir. Alacaklının, bir mirasçıdan sadece, paylaşmada kendisine düşen kadar borcun ifasını istemesi veya mirasçılara borcun hangi kısmının kime yüklendiğini sorması, mirasçılar arasındaki paylaşmaya örtülü rıza gösterildiğine örnekler olabilir.

Şayet bir açık ya da örtülü beyan söz konusu değilse, müteselsil sorum- 1908
luluk paylaşmadan sonra da devam edecektir. Bu halde, eğer borç paylaşma anında zaten muaccel idiyse, paylaşmadan itibaren beş yıl, eğer borç, paylaşmadan sonraki bir tarihte muaccel olacaksa, bu tarihten itibaren beş yıl sonunda müteselsil sorumluluk son bulur.

MK 644 hükmüne göre, tereke üzerindeki elbirliğiyle mülkiyetin, pay- 1909
laştırma yapılmaksızın paylı mülkiyete dönüştürülmesi üzerine, bu tarihten itibaren beş yıl sonra müteselsil sorumluluğun sona ereceği kabul edilmelidir. Kuşkusuz ortak mültiyete dönüş tarihinden sonra muaccel olan borçlarda yine muacceliyet tarihi beş yıla başlangıç olacaktır.

MK 681/II uyarınca beş yıllık süre dolup, müteselsil borçluluk sona 1910
erince ne olacağı doktrinde tartışmalıdır. Bir görüş, mirasçıların bu durum-

da elbirliğiyle sorumlu olacakları[1173]; diğer bir görüş, aralarında yaptıkları anlaşmaya göre sorumlu olacakları, ancak böyle bir anlaşma yoksa miras payları oranında sorumlu olacakları şeklindeyse de[1174]; üçüncü ve bizim de katıldığımız görüşe göre, beş yılın dolmasından sonra, taraflar aralarında nasıl bir paylaşma yapmış olurlarsa olsunlar, alacaklıya karşı miras payları oranında sorumlu olmalıdırlar[1175]. Zira, tereke üzerinde bile elbirliğiyle hak sahipliği kalmamışken, beş yılın sonuda tereke borcunun elbirliğiyle sorumluluğa konu olması gerekçesiz ve mantıksız olup; yine beş yılın sonunda alacaklı, tarafı olmadığı gibi, rızasının da bulunmadığı bir paylaştırma anlaşmasından da etkilenmemelidir. Buna göre, katıldığımız görüş göre, örneğin, eşit miras payına sahip olan iki mirasçıdan biri, paylaştırmada, kendisine diğerinden fazla pay verilmesine karşılık, tereke borcunu da onun tek başına ödeyeceği kararlaştırılmış olsa bile; alacaklı beş yılın sonuda alacağını bu iki mirasçıdan yarı yarıya talep edebilecektir. Kuşkusuz iç ilişkiye göre bu borcu yüklenmemiş olan mirasçı, ödediği miktar için borcu tamamen üstlenen mirasçıya rücu edebilecektir.

1911 Nihayet belirtelim ki, MK 655, paylaştırmada rehinli tereke malı kendisine düşen mirasçının, bu rehinden doğan borcu ödemekle yükümlü olacağını belirtmektedir[1176]. Bu özel hüküm uyarınca rehinli alacaklı, borcun paylaştırılmasına razı olmasa bile, paylaştırmadan itibaren rehin konusu alacağını, sadece rehinli malın düştüğü mirasçıdan isteyebilecektir. Böylece MK 655 uyarınca, beş yılı beklemeye gerek kalmaksızın, mirasın paylaşıldığı anda, rehinli mal kendisine bırakılan mirasçı buna ilişkin tereke borcundan bizzat sorumlu olacak ve diğer mirasçılar alacaklıya karşı bu borçtan ne müteselsilen ne de kısmen sorumlu olacaklardır. Kuşkusuz rehinli alacaklının, şayet şartlar gerçekleşmişse, miras ortaklığı devam ederken tüm mirasçılara karşı rehnin paraya çevrilmesi için takipte bulunması mümkündür. Eğer miras ortaklığı MK 644 uyarınca paylı mülkiyete dönüşmüşse, rehinli mala ilişkin borçtan bu dönüşümden itibaren de beş yıl boyunca tüm mirasçılar müteselsilen sorumlu olacaklar; bu süre dolunca, miras paylarına, yani paylı mülkiyet paylarına göre sorumlu olacaklardır. Kuşkusuz her iki aşamada da rehnin paraya çevrilmesi için tüm mirasçılara

---

[1173] *Strebel*, die rechtliche Stellung der Gläubiger des Erblassers und der Erben, Bern, 1916, 29. Pek taraftar bulmayan bu görüşe doğrusu gerekçe bulmak zordur.

[1174] *von Tuhr/Escher*, Band II, § 99, IX, 402 vd; *Imre/Erman*, 518 vd.

[1175] *Escher*, Art.639 N 21; *Kocayusufpaşaoğlu*, 738; *Oğuzman*, 339.

[1176] Kuşkusuz bu, mirasbırakanın borcu için verilen rehinler bakımındandır. Mirasbırakan bir başka kişinin (isterse bu müstakbel mirasçılardan biri olsun) borcu için rehin vermişse; esasen bu borç terekede mevcut bulunmayacağından, hissesine rehinli mal düşen mirasçı müteselsilen ya da kısmen bu borçtan sorumlu olmayıp, sadece rehnin paraya çevrilmesine katlanacaktır.

karşı takipte bulunulacaktır, meğer ki, paylı mülkiyet dahi sona erdirilip, rehinli mal mirasçılardan birinin mülkiyetine geçmiş olsun.

4. Miras ortaklığına temsilci atanması

Miras ortaklığında tüm mirasçıların terekeyi elbirliğiyle yönetmek ve 1912
terekeyi ilgilendiren her işlemi birlikte yapmak zorunda oldukları yukarıda belirtilmişti. İşte bu sistem yüzünden çıkacak sorunlara çare, miras ortaklığına temsilci atanmasıdır.

MK 640/III'e göre, mirasçılardan birinin talebi üzerine, mirasın açıldığı 1913
yer sulh hakimi, miras ortaklığına temsilci atayabilir. Diğer mirasçıların bu talebe katılmaları aranmadığı gibi, hakim onların öneri ve itirazlarıyla da bağlı değildir. Ancak, hakim de, hiç bir mirasçı kendisine başvurmadan göreceği gerek üzerine miras ortaklığına kendiliğinden temsilci atayamaz. Öte yandan mirasçıların tümü anlaşırlarsa hakime gitmeye gerek kalmadan miras ortaklığına bir temsilci atayabilirler.

Hakime temsilci atanması için başvurmaya yetkili sadece yasal ve 1914
atanmış mirasçılar olup, vasiyet alacaklılarının böyle bir hakkı yoktur. Esasen onlar tereke üzerinde hak sahibi olmadıklarından,atanacak kişi onların temsilcisi olacak değildir.

Temsilci tayini istemi, miras ortaklığının doğmasından, sona ermesine 1915
kadar istenebilir. Hakim, genellikle tarafsız ve güvenilir bir kişiyi atayacaksa da , mirasçılar arasından birini de temsilci olarak atayabilir. Aralarında anlaşmazlık bulunan mirasçıların tümünün iyi geçindiği ve saygı uyduğu bir mirasçı varsa, hakim bu yolu tercih edecektir. Örneğin mirasbırakan annenin anlaşmazlık içinde olan çocuklarının tümünün saygı duyduğu ve aralarının iyi olduğu bir diğer mirasçı olan babalarınımiras ortaklığına temsilci atayabilir.

Eğer MK 550'ye göre mirasbırakan tarafından atanmış ve bu görevi 1916
kabul etmiş vasiyeti yerine getirme görevlisi varsa ya da mahkeme terekeyi resmen idare memuru atamışsa (MK 592), bunlar esasen yetkili oldukları hususlarda tüm mirasçıların temsilcisi sayıldıklarından , hakim ayrıca bir de miras ortaklığına temsilci atamaz.

Hakim, temsilci atamaya bir engel bulunmasa bile, bu atamayı yapmaya 1917
mecbur değildir. Eğer miras ortaklığı adına terekenin bir elden yönetilmesini somut olayda gerekli görürse, özellikle bazı mirasçılar arasında anlaşmazlıklar varsa bu talebi kabul edecektir. Ancak, doktrin ve uygulama , hakimin kendisine yapılan başvuru üzerine fazla eli sıkı davranmamasını, bir

temsilci atanmasında küçük bir fayda görmesi hâlinde bile atamayı yapmasını kabul etmektedir[1177].

1918 Miras ortaklığının tüzel kişiliği bulunmadığından, atanan temsilci, yetkileri çerçevesinde, her bir mirasçının temsilcisi gibidir. Temsilcinin, yetkileri bakımından, vasiyeti yerine getirme görevlisinin ve mirası resmen idareye memur olarak atananların yetkilerine ilişikin hükümler örneksemeyle uygulanacaktır[1178]. Temsilin sonuçları bakımından, temsil yetkisini düzenleyen BK 32 vd.deki genel hükümler de uygulanırsa da, bu hükümlerden farklı olarak, yetkinin sadece terekeyi ilgilendiren işlemlerle sınırlı olduğu ve hakim tarafından atanan bu temsilcinin, tüm mirasçılar birleşse bile görevinden alınamayacağı, temsil yetkisinin kaldırılamayacağı, ancak gene en az bir mirasçının onu atayan hakimi şikâyeti üzerine gerek görülürse hakim tarafından yetkisinin kaldırılarak görevine son verilecei unutulmamalıdır.

1919 Temsilci, terekenin iradesi ve korunması için gerekli her türlü işlemi yapmaya yetkilidir. Fakat yetkisi de bununla sınırlıdır. Örneğin, tereke malına el atanlara karşı dava açmaya, tereke alacaklarını tahsile, gerekirse bu konuda dava açmaya, tereke borçlarını ifaya yetkilidir. Buna karşılık, bir tereke malını, bir tereke borcunu ifa maksadı dışında, başkasına devretmeye (örneğin, daha değerli gördüğü bir malla değiştirimeye ya da iyi para ettiği gerekçesiyle satıp parasını almaya)[1179] ve terekeyi mirasçılar arasında paylaştırmaya yetkili değildir. Mirasçıların hepsinin atadığı temsilciden farklı olarak, hakimin bir mirasçının talebi üzerine atadığı temsilcinin bu yetkilerinin yine hakim tarafından kısıtlanması mümkün fakat genişletilmesi mümkün değildir[1180].

1920 Velayet Vesayet ve Miras Tüzüğünün 62. maddesine göre tereke mevcudu, temsilciye tutulan defterde gösterilerek teslim edilir ve 63. maddeye göre, temsilci kendisine teslim edilen malların idaresi hakkında her üç ayda bir mirasçılara ve kendisini atayan sulh mahkemesine belgeli bir rapor sunar. Bir mirasçı tarafandan yapılan şikâyet üzerine temsici hakkında vasinin denetimine ilişkin hükümlere göre işlem yapılır.

1921 Miras ortaklığına mahkemece atanan temsilci ile (en azından mahkemeye bu konuda başvurmamış mirasçlar bakımından) temsil ettiği kişiler arasında bir sözleşmenin kurulduğu söylenemez. Burada, hakimin kararı üzerine yasadan doğan bir ilişki kurulmuştur. Buna rağmen işin niteliği ba-

---

[1177] *Kocayusufpaşaoğlu*, 697; *Oğuzman*, 315; 2.HD, 21,4,1989 3984/ 3987 (YKD 1989, 1547).

[1178] *Escher*, Art. 602 N 78; *Tuor/Picenoni*, Art. 602 N 58; *Kocayusufpaşaoğlu*, 697 vd.

[1179] Ancak, bu işlevmleri yapmadığı takdirde mirasçıların ciddi zarara uğrayacağı ve gecikmesinde sakınca bulunan hallerde bu gibi işlemleri yapmaya yetkili sayılmalıdır.

[1180] *Escher*, Art. 60 N 79; *Tuor/Picenoni*, Art. 602 N 56.

kımından, miras ortaklığına atanan temsilci, örneksemeyle, vekilin sorumluluna ilişkin hükümlere tabi tutulmalıdır[1181].

Mahkeme tarafından atanan temsilci, görülen gerek üzerine mahkemece görevinden alınmazsa, miras ortaklığının devamı süresince sıfatı devam eder. Temsilcinin gereksiz ya da zamansız bir şekilde görevinden istifa etmesi hâlinde, BK 512 hükmüne kıyasen, mirasçılara karşı sorumlu olması mümkündür. Miras ortaklığının herhangi bir sebeple sona ermesi hâlindeyse, temsil yetkisi ve sıfatı, mahkeme kararına gerek olmadan kendiliğinden sona erer. 1922

III. MİRAS ORTAKLIĞININ SONA ERMESİ

1. Genel olarak

Miras ortaklığının sona ermesi, mirasın paylaşılması, tereke üzerindeki elbirliğiyle hak sahipliğinin paylı hak sahipliğine ya da miras ortaklığının başka bir ortaklığa dönüştürülmesi şeklinde olur. Bunlara, mirası red[1182] ya da miras payını devir[1183] yollarıyla mirasçı sayısının bire inmesi durumu da eklenebilir[1184]. Belirtelim ki, miras ortaklığının devamı sırasında bir mirasçının ya da bazı mirasçıların ölümü üzerine yerlerini külli halefiyet yoluyla ölenin mirasçıları alacağından, miras ortaklığı sona ermeyip, bunlarla devam eder (MK 580/II). 1923

2. Başlıca sona erme halleri

a) Mirasın tamamen paylaşılması

Mirasçıar arasında terekede mevcut tüm hakların ve borçların paylaşılmasıyla miras ortaklığı sona erer. Bu paylaşma, mirasçıların tümünün anlaşmasıyla gerçekleşebileceği gibi, mirasçılar arasında anlaşmazlık çıkarsa, içlerinden birinin açacağı bir paylaştırma (taksim) davası yoluyla da gerçekleşebilir. Mirasçıların anlaşarak paylaşmayı yapma biçimleri ile paylaştırma davasının açılma şartları ve hükümlerine aşağıda ayrı bir başlık altında ayrıntılı şekilde değineceğiz[1185]. Şimdiden şu kadarını belirtelim ki, sadece terekedeki bazı malların paylaşılması (objektif kısmi paylaşma) ya da sadece bazı mirasçılara miras payları karşılığı terekeden verilecek şeylerin belirlenmesi (sübjektif kısmi paylaşma), miras ortaklığını sona erdirmez. 1924

[1181] *İmre/Erman*, 392; *Oğuzman*, 316.

[1182] Bkz., yukarıda § 32.

[1183] Açılmış miras payının devri için bkz., § 28, II.

[1184] Diğer tüm yasal ve atanmış mirasçılar mirası reddetse bile, Devlet mirasçı olacağından, mirasçı sayısı yine bire düşmüş olacaktır.

[1185] Bkz., aşağıda, § 38.

Miras ortaklığı birinci durumda, henüz paylaşılmamış mallar için tüm mirasçılarla devam edecek; ikinci durumdaysa, henüz kendisine verilecek şeyler belirlenmemiş olan mirasçılar arasında devam edecektir.

b) Elbirliğiyle hak sahipliğinin paylı hak sahipliğine dönüşmesi

1925 MK 644'e göre mirasın açılmasından itibaren, miras ortaklığına dahil herhangi bir mirasçı mahkemeye başvurarak, hakimin gerek tüm tereke gerekse bazı tereke mallarının (MK 676) elbirliğiyle mülkiyetten paylı mülkiyete dönüştürülmesini talep edebilir. Eğer mirasçı sadece terekede var olan bir ya da bir kaç mal üzerindeki hakkın paylı mülkiyete dönüştürülmesini talep ederse, sonuçta sadece bu mallar üzerindeki elbirliğiyle mülkiyet yerini paylı mülkiyete bırakır ve miras ortaklığı kalan tereke malları ve diğer tereke unsurları üzerinde devam eder. Şu halde miras ortaklığını sona erdirecek olan, mirasçının mahkemeye başvurarak tüm tereke hakkında elbirliğiyle mülkiyetin paylı mülkiyete dönüştürülmesini istemesidir.

1926 Kuşkusuz terekedeki mallar dışındaki haklar üzerinde elbirliğiyle mülkiyet değil, kıyasen buna ilişkin hükümlerin uygulanacağı *elbirliğiyle hak sahipliği* söz konusudur ve paylı mülkiyete dönüştürülme hâlinde de yine kıyasen paylı müykiyet hükümlerinin uygulanacağı *paylı hak sahipliği söz* konusu olacaktır. Nitekim MK 644/III hükmü, terekeye dahil mülkiyet dışındaki hakların ve alacakların da talep üzerine aynı dönüşüme tabi tutulacağını belirterek bu hususu düzenlemiş bulunmaktadır.İçindeki mallar ve haklar dahil tüm tereke üzerindeki mirasçılık haklarının dönüşümü ifade edilirken, daha kapsayıcı bir terimi olan *iştirak hâlinde hak sahipliğinin paylı hak sahipliğine* dönüşümü ifadesi tercih edilmelidir.

1927 Bir mirasçının bu şekilde mahkemeye başvurması üzerine MK 644/I'e göre hakim, diğer mirasçılara tebligatta bulunarak, tayin ettiği süre sonuna kadar bir itirazları varsa bildirmeleri hususunda onları uyarır. Mahkemece bu süre verilmeden ve tüm diğer mirasçılara uyarıda bulunulmadan elbirliğiyile hak bahipliğini paylı hak sahipliğine dönüştürmek mümkün değildir.

1928 MK 644/II uyarınca verilen süre zarfında mirasçılardan herhangi biri, elbirliğiyle hak sahipliğinin devamını haklı kılan bir sebebin varlığını ileri sürerek ya da paylaştırma davası açarak elbirliğiyle hak sahipliğinin paylı hak sahipliğine dönüşmesini engelleyebilir.

1929 Hangi hallerde elbirliğiyle pay sahipliğinin devamını talep etmenin haklı sayılacağı maddede belirtilmemiştir. Mirasçılar arasında miras ortaklığının belirli bir süre devam etmesinin kararlaştırılmış olması, böyle bir haklı sebebi oluşturabilir. Bir mirasçının verilen süre içinde paylaştırma davası açması ise, paylı hak sahipliğine dönüştürülme talebini başlı başına etkisizleştirecektir.

Belirlenen sürede bu iki hususta bir gerçekleşmezse, hakim talebe gö- 1930
re bazı malların ya da terekenin tümünün elbirliğiyile hak sahipliğinden paylı hak sahipliğine dönüşümüne karar verecektir (MK 644/II). Hakimin kararı kurucu nitelikte olup derhal sonuç doğurur. Böylece kararın çerçevesine giren terekedeki taşınmaz ve taşınır mallar üzerinde tüm mirasçıların miras payları oranında paylı mükiyet hakları doğar. Örneğin mirasbırakanın geride bıraktığı mirasçıları eşit miras paylarına sahip üç oğlu ise, paylı mükiyete çevirme kapsamındaki eve bunlardan her biri 1/3 oranıda paylı malik olurlar.

Bu şekilde paylı mülkiyete dönüşen tereke mallarının artık mirasçılar 1931
arasında paylaşılması söz konusu olmaz. Bunların yönetimi, paylı malikle-rin hak, yetki ve yükümlülükleri ile bu mallar üzerinde üzerinde paylı mülkiyet ilişkisinin sona erdirilmesi, paylı mükiyeti düzenleyen 688 vd. hükümlerine tabi olacaktır. Örneğin bir mirasçı bu şekilde paylı mülkiyete dönüştürülmüş tereke mallarının paylaşılmasını MK 642 hükmüne göre talep ve dava edemeyecek, ancak MK 699 uyarınca paydaşlığın giderilmesi (izale-i şüyu) davası açarak paylı mülkiyete son verdirebilecektir. Bir de şartları gerçekleşmişse MK 696'ya göre paylı malikin paydaşlıktan çıkartılması davası açabileceektir.

Şayet sadece bazı mirasçılar değil, tüm tereke için elbirliğiyle hak sa- 1932
hipliğinin paylı hak sahipliğine dönüştürülmesine karar verilmişse, miras ortaklığı karar anında paşlaşmasız sona ermekle birlikte, tereke borçlarından dolayı mirasçıların müteselsil sorumluluğu karar anından itibaren (şayet borç daha sonra muaccel oluyorsa muacceliyet tarihinden itibaren) beş yıl geçince sona ermelidir. Bu sonucu öngören MK 681 her ne kadar paylaşatırmanın tamamlanmasından itibaren beş yıldan söz etmişse de, amaca göre yorum yapılarak, miras ortaklığının paylaştırma yerine paylı hak sapiliğine dönüştürülerek sona ermesinde de aynı sonuç benimsenmelidir.

c) Miras ortaklığının başka bir ortaklığa dönüşmesi

Terekenin paylaşılması ve tereke üzerindeki elbirliğiyle hak sahipliği- 1933
nin paylı hak sahipliğine dönüştürülmesi dışında miras ortaklığına son verebilecek bir durum, miras ortaklığının bir başka ortaklık tipine dönüştürülmesidir. Böylece, mirasçılar arasındaki hukuki bağ, kendi rızalarıyla benimsedikleri bir başka hukuki ilişkiye dönüşerek devam edecektir. Bu yeni ilişki, BK 620-645 hükümlerine tabi bir adi şirket ya da MK 373 vd. hükümlerine tabi bir aile malları ortaklığı şeklinde tüzel kişiliği bulunmayan çok taraflı bir sözleşme ilişkisi olabileceği gibi; Türk Ticaret Kanununa tabi bir ticaret ortaklığı kurulması da olabilir. Her tercih sonrası yaratılan ilişki artık miras hukuku hükümlerine değil, kendisini düzenleyen yasa hükümle-

rine tabi olacaktır. Şu kadarını belirtelim ki, adi şirket ya da aile malları ortaklığına dönüşme hâlinde, mirasçılar (şirket ortakları) hep birlikte sermaye olarak koydukları tereke malları üzerinde elbirliğiyle hak sahibi olmaya devam ederken, bir ticaret ortaklığı kurmaları üzerine, sermaye olarak koydukları tereke mallarına, mirasçılar değil, kurulan ortaklık tüzel kişiliği tek başına malik olacaktır. Miras ortaklığının, tüm mirasçılarca terekenin tahsis edilmesiyle kurulacak bir vakfın tüzel kişilik kazanmasıyla sona erdirilmesi de mümkündür. Bu takdirde de mirasçıların tereke malları üzerinde hiç bir hakları kalmayacaktır.

§ 38. Mirasın paylaşılması

I. GENEL OLARAK

1934 Miras Hukukunun kimlerin ne oranda mirasçı olacağına ve mirasçıların tereke üzerindeki hak ve yetkilerine ilişkin hükümlerini takiben son konusu, mirasa konu terekenin mirasçılar arasında nasıl paylaşılacağıdır. Buna kısaca mirasın paylaşılması denmektedir. Unutulmamalıdır ki, paylaşma, sadece birden fazla mirasçının bulunması, miras ortaklığının oluştuğu hallerde söz konusu olur.

1935 Eski Medeni Kanun zamanında yazılan kitaplarda çoğunlukla paylaşma yerine paylaştırma terimi kullanılmaktaydı. Yeni Medeni Kanun ise 640 vd. maddelerinde paylaşma terimini kullanmaktadır. Bu bakımdan biz de kanunun lafzına uygun olması yönünden *paylaşma terimini* kullanmayı tercih etmekteyiz.

1936 Mirasın paylaşılması başlığı, paylaşma biçimleri, paylaşma davası ve paylaşmanın yapılması gibi ana konuların yanında; mirasta denkleştirme, açılmış miras paylarının devri gibi bazı yan konuları da kapsar. Ne var ki, son iki konuyu sistematik bakımdan yaptığımız tercih sonucu daha önce başka bölümlerde incelemiş bulunuyoruz[1186]. Burada sadece doğrudan paylaşmaya ilişkin ana kurallar incelenecektir.

1937 Keza paylaşmayı, Mirasın Paylaşılması adı altında düzenleyen Miras Hukuku kitabının üçüncü bölümünde, miras ortaklığı da düzenlenmişse de, bu kurumu ve hükümlerini hemen bir önceki paragrafta ele almış bulunuyoruz.

1938 Aşağıdaki incelememizde sırasıyla, paylaşma, paylaşma davasının açılma şartları ve hükümlerini, payların oluşmasını ve nihayet payların mirasçı-

[1186] Mirasta denkleştirme için bkz. § 24, açılmış miras payının devri için bkz. § 27, II.

lara tahsisini (dağıtılmasını) açıklayacağız. Mirasçıların, paylaşmadan sonra tereke borçlarından sorumluluğuna ilişkin açıklamalar da yukarıda miras ortaklığı başlığı altında yapıldığından ayrıca ele alınmayacaktır.

II. PAYLAŞMA TÜRLERİ

1. Terekenin tümünün paylaşılması

Kanunumuzun mirasın paylaşılmasına ilişkin hükümleri, terekenin tü- 1939
münün paylaşılmasını esas almıştır. Gercekten de, miras ortaklığına son veren, mirasçıları bu sıfatlarıyla hukuki ilişkiler içine girmekten ve miras hukukune özgü hükümlere tabi olmaktan kurtarıp herhangi bir hak sahibi haline getiren, terekenin tümüyle paylaşılmasıdır.

Terekenin tümünün paylaşılması, yasal ve atanmış mirasçıların tümü- 1940
nün hep birlikte anlaşmaları yoluyla her zaman mümkündür. Hatta mirasbırakanın paylaşmanın nasıl yapılacağını geçerli bir ölüme bağlı tasarrufla belirtmiş olmasına rağmen[1187], mirasçıların tümü anlaşırsa, bundan farklı bir paylaşma yapılabilir ve bu geçerlidir. Mirasçıların bu paylaşma anlaşmasını ne şekilde yapabileceklerine aşağıda değineceğiz.

Şayet mirasçılardan biri bile paylaşma konusunda anlaşmaya yanaş- 1941
mazsa, diğerlerinin bir paylaşma davası açması ve bu dava yoluyla paylaşmayı gerçekleştirmeleri gerekir. Sayı ve/veya pay bakımından çoğunlukta olan mirasçıların en az paya sahip olan bir tek mirasaçıya bile kendi paylaşma anlaşmalarını dayatmaya hakları yoktur. Öte yandan, diğer mirasçıların paylaşma hususundaki görüşlerine katılmayan tek bir mirasçı da paylaşma davası açarak paylaşmayı sağlayabilir. Bu davanın şartları ve hükümlerine de aşağıda değineceğiz.

2. Terekenin bir kısmının paylaşılması

MK 676 incelendiği zaman prensip olarak kanunun terekenin tümünün 1942
paylaşılması noktasından hareket ettiği fakat ikinci fıkrasında paylaşmanın paylı mülkiyete çevrilme yoluyla yapılması hâlinde tereke mallarının kısmen paylaşılmasına cevaz verdiği görülmektedir. Gerçekten MK 676/II'ye göre, *"Paylaşma sözleşmesiyle mirasçılar, tereke mallarının tamamı veya bir kısmı üzerindeki elbirliği mülkiyetinin miras payları oranında paylı mülkiyete dönüştürülmesini de kabul edebilirler"* denilmektedir. Hüküm her ne kadar sadece terekedeki malların bir kısmının paylaşılması ve bu paylaşmanın da paylı mülkiyete çevrilme şeklinde olmasını öngörmekteyse

[1187] MK MK 647/III uyarınca, mirasçıya ne verileceğinin ölüme bağlı tasarrufla belirlenmesi, aksi ispat edilmedikiçe, payına ek bir kazandırma değil, bir paylaştırma kuralı sayılır.

de, irade serbestisi prensibine göre, kısmi paylaşmanın genişletilerek, fiilen kısmi paylaşma ile bazı mirasçılar arasında kısmı paylaşmayı kabul etmeye de bir engel yoktur. Nitekim doktrin de kısmi paylaşmanın objektif ve sübjektif kısmi paylaşma şeklinde ve sadece paylı mülkiyet çevrilme hâlinde değil de fiili paylaşma hâlinde de mümkün olacağını kabul etmektedir[1188].

a) Objektif kısmi paylaştırma:

1943 Terekedeki mal ve hakların bazılarının paylaşılıp, bazılarınınsa paylaşma dışı bırakılmasıdır. Paylaşma dışı bırakılan tereke malları üzerinde miras ortaklığı ve dolayısıyla da elbirliği mülkiyeti devam eder. Genellikle mirasçıların sadece bazı tereke mallarının kime kalacağı hususunda anlaşmaya varmalarına karşı bazı tereke mallarının nasıl paylaşılacağı konusunda anlaşamamaları hâlinde başvurulan bir yoldur. Böyle bir paylaşma, üzerinde anlaşma olmayan malların akıbeti belirleninceye kadar, esasen sorun yaratmayan malların paylaşılmasının geciktirilmemesi için yapılır. Örneğin babalarından kendilerine iki otomobil, iki ev kalan iki kardeş otomobillerin kime kalacağı hususunda anlaşmışlarsa, ev paylaşımı hususunda çekişmekte de olsalar, şimdilik sadece otomobilleri paylaşabilirler ve böylece evler üzerinde elbirliği mülkiyeti (ve miras ortaklığı) devam ederken, her biri bir otomobili kendi mülkiyetine geçirerek istediği gibi tasarruf etme imkânına sahip olur. MK 676/II'de öngörülmüş olan işte bu objektif kısmi paylaşmadır.

1944 *b) Sübjektif kısmi paylaşma:* Sadece bir ya da bir kaç mirasçının, payının saptanarak verilmesi ve geri kalan mirasçılar arasında miras ortaklığının devam etmesidir. Burada sadece bazı mallar elbirliğiyle mülkiyete konu olmaktan çıkartılmamakta, bazı mirasçılar da paylarının karşılığı kendilerine verilerek miras ortaklığından uzaklaşmaktadırlar. Bu paylaşma sonucu, geriye kalan mirasçıların geri kalan mallar ve haklar üzerinde elbirliği mülkiyetleri ve miras ortaklığı devam etmektedir. Bu kısmi paylaşma şekli, yukarıda da değinildiği gibi, Medeni Kanunda düzenlenmemiş olmakla beraber, irade serbestisi gereği geçerli olarak yapılabilir.

1945 İster objektif ister sübjektif olsun, kısmi paylaşmanın gerçekleşebilmesi için bütün mirasçıların bu konuda anlaşmaları şarttır[1189]. Sadece bir mirasçı diğerlerini kısmi paylaşmaya zorlayan bir paylaştırma davası açamaz. Bu objektif kısmi paylaşmayı düzenleyen MK 676/II'den de açık olarak anlaşılmaktadır. Fakat bütün mirasçılar kısmi paylaşma hususunda bağlayıcı

[1188] *Escher*, Art. 602 N 41,47; *Tuor/Picenoni*, Art. 602 N 8-11; *Kocayusufpaşaoğlu*, 686 vd.; *Oğuzman*, 321.

[1189] 6.HD 23.11.1983, 13358/13325 (YKD 1984, 1506); 6.HD 16.11.1992, 12621/1308 (YKD 1993, 1647).

yazılı şekilde anlaşmış olup da bazıları bunun ifasına yanaşmıyorlarsa, bir mirasçı kısmi paylaşmanın gerçekleştirilmesi için paylaştırma davası açabilir.

III. PAYLAŞMAYA İLİŞKİN GENEL KURALLAR

1. İrade özgürlüğü

Mirasın paylaşılmasında genel kural,mirasçıların irade özgürlüğüdür. 1946
Onlar, yasal miras payları ne olursa olsun, terekedeki her türlü mal, hak ve borcu serbestçe ve diledikleri gibi paylaşırlar. Mirasbırakanın alacaklılarının ve kural olarak mirasçının alacaklılarının paylaşmaya karışma ya da itiraz etme yetkileri yoktur. Bunun bir istisnası, bir mirasçıya düşen miras payını devralan ya da haczeden veya o mirasçı aleyhine borcu ödemeden aciz belgesi elde eden alacaklının talebi üzerine sulh mahkemesi tarafından atanacak bir kayyımın paylaşmaya katılmasına yetki veren MK 648 hükmüdür. Böylece, bu durumdaki bir mirasçının paylaşmada irade özgürlüğü ilkesinden yararlanarak, terekede yer alan ve miras payına göre kendisine düşmesi gereken tüm değerli malları diğer mirasçılara bırakarak alacaklısını mağdur etmesi engellenebilir.

Tereke alacaklıları bakımından böyle bir koruyucu hüküm gereksizdir. 1947
Zira onlar karşısında esasen tüm mirasçılar müteselsil olarak sorumludurlar. Vasiyetnameye göre, sadece bir mirasçının vasiyeti ifa ile borçlu olduğu durumlarda, bu mirasçının paylaştırmada vasiyet konusu malı kasden diğer mirasçılara bırakması sorunuyla karşılaşılabilir. Böyle bir durumda bir mirasçı MK 600/III'e göre vasiyet alacaklısının ifada olan çıkarını tazminle yükümlü tutulacağı gibi; MK 519/II'ye kıyasen vasiyet konusu malı devralan mirasçının ifa borcunu da üstlendiği kabul edilebilir.

Mirasın paylaşılması sırasında mirasçıların irade özgürlüğü ancak tü- 1948
münün anlaşmasıyla anlam taşır. Bir tek mirasçı dahi paylaşma anlaşmasına yanaşmazsa, paylaşma hakim tarafından gerçekleştirilir.

Mirasbırakanın, paylaşmanın nasıl yapılacağına dair bir ölüme bağlı ta- 1949
sarrufta bulunmuş olması mümkündür. Çünkü mirasbırakanın da irade özgürlüğü ilkesinden yararlanması söz konusudur ve böyle bir geçerli bir irade beyanının, ki bunun bir vasiyetname ile yapılması gerekir, bulunması hâlinde, kural olarak buna uyulacaktır. Örneğin, diğerleri karşı çıksa bile, bir mirasçı paylaşmanın buna göre yapılmasını isterse, paylaştırma mirasbırakanın belirlediği gibi yapılacaktır. Ancak, tüm mirasçıların anlaşarak mirasbırakanın belirlediğinden farklı bir paylaşmada bulunabilecekleri kabul edilmektedir[1190]. Böyle, mirasbırakanın belirlediğinden farklı bir paylaşma

[1190] *Kocayusufpaşaoğlu*, 740; *Oğuzman*, 326; *İmre/Erman*, 416.

anlaşması geçerli şekilde yapıldıktan sonra, anlaşmaya taraf olan hiç bir mirasçı, bunun mirasbırakanın vasiyetine aykırı olduğunu ileri sürerek geçersizliği iddia edemez. Ancak, mirasbırakan, belirlediği paylaşma tarzına uyulmazsa, bazı mirasçıların lehine yaptığı ölüme bağlı kazandırmaların geçersiz olacağını öngörmüş olabilir. Bu tür bir bozucu şart yoluyla, mirasbırakanın, koyduğu paylaşma kuralına uyulmamasını bir tür yaptırıma bağlaması mümkün ve geçerli sayılmaktadır[1191]. Keza, mirasbırakanın belirlediği paylaşma tarzına uyulmaz ise, bir mirasçı atamanın ya da vasiyetin hüküm ifade edeceği de öngörülebilir. Doktrinde, mirasbırakanın sadece paylaşma kuralı koymakla kalmayıp bunun ifası için bir vasiyeti yerine getirme görevlisi de ataması hâlinde, tüm mirasçılar anlaşsa dahi, atanan görevlinin paylaştırmayı mirasbırakanın istediği gibi yapmasına engel olamayacaklarını savunanlar varsa da[1192], katıldığımız görüş uyarınca, tüm mirasçıların üzerinde anlaştığı paylaşma tarzına vasiyeti yerine getirme görevlisi de uymak zorundadır[1193]. Nihayet belirtelim ki, mirasbırakanın öngördüğü paylaştırma mirasçıların bazısının saklı paylarını dahi alamamasına yol açıyorsa, esasen ortada sadece bir paylaşma tarzının belirlenmesi değil, bazı mirasçılara mirasbırakanın tasarruf nisabını aşan bir kazandırma yapılması söz konusudur ki, saklı payı tehlikeye düşen mirasçılar bu durumda tenkis davası açabileceklerdir.

2. Eşitlik

1950 MK 649/II hükmü, aksine bir hüküm bulunmadıkça, mirasçıların tereke malları üzerinde aynı haklara sahip olduklarını ifade ederek, eşitlik ilkesini yansıtmaktadır. Yasal ve atanmış mirasçılar arasında da eşitlik ilkesinin geçerli olduğu MK 646/I'de ifade edilmiştir. Gene bu doğrultuda olarak, mirasçıların yaşları, cinsiyetleri ve mirasbırakana yakınlık dereceleri de eşitlik ilkesini bozmaya gerekçe olamaz.

1951 Eşitlik ilkesi elbette, farklı miras paylarına sahip mirasçıların terekeden aynı değerde pay alması demek değildir.Yasanın, mirasçılık derecelerine ve sıfatlarına göre mirasçıların bazısının payının fazla bazısının payının eksik olacağını öngörmesi (örneğin, mirasbırakanın çocuğu eşinden fazla pay alacaktır), eşitlik ilkesiyle ilgili değildir. Eşitlik, mirasçıların sahip oldukları hakların niceliğinde değil, niteliğinde aranır.

1952 Eşitlik ilkesinin önemli bir sonucu, mirasçılık sıfatı ne olursa olsun ve miras payı ne kadar az olursa olsun, her mirasçının paylaşmaya aynı hak ve

---

[1191] *Tuor/Picenoni*, Art. 608 N 9; *Kocayusufpaşaoğlu*, 704.
[1192] *Escher*, Art. 518 N 17.
[1193] *Kocayusufpaşaoğlu*, 705 vd.

yetkilerle katılması, bir mirasçının rızası olmadan diğerlerinin çoğunlukla kararlaştırdıkları paylaştırmaya uymak zorunda olmamasıdır.

Eşitlik ilkesinin diğer bir sonucu, paylaşmanın olabildiğince mirasçıla- 1953
rın eline aynı türden tereke malları geçecek şekilde yapılmasıdır. Olabildiğince, mirasçılara verilecek tereke kısımlarının aynı nitelikte mallar olmasına çalışılacaktır. Örneğin, eşit paya sahip olan iki mirasçı, her biri 300 bin lira değerinde olan iki otomobili ve yine her biri 300 bin lira değerindeki iki evi paylaşacaksa,kendi aralarında anlaşamazlarsa, hakim, birine otomobilleri diğerine evleri bırakmayıp, her birine birer otomobil ve birer ev vermelidir.

Belirtelim ki, eşitlik ilkesi, mirasçıların tümünün anlaşmasıyla bir tarafa 1954
bırakılabilir ve buna aykırı bir paylaşma gerçekleştirilebilir. Ancak, mirasçılar arasında aksine bir anlaşma bulunmadıkça, özellikle paylaşma davası sırasında hakim (kendisine takdir hakkı veren ve ileride belirteceğimiz bazı özel durumlar dışında), bu ilkeye göre terekeyi paylaştıracaktır.

3. Aynen paylaşmanın asıl olması

Genellikle eşitlik ilkesi içinde açıklanan bu ilke[1194], aslında ayrı nitelik- 1955
tedir. Hatta çoğu kez eşitlik ilkesiyle çelişebilir. Aynen paylaşma ilkesi, miras hukukununun ölenin melvarlığını sahipsiz bırakmama amacından ve paylaşmaya ilişkin MK 650 hükmünün payların oluşturulmasına ilişkin ifadesinden çıkartılabilir. Aynen paylaşma ilkesine göre, paylaşma, olabildiğince terekedeki malların satılıp, bedelinin paylaşılması ya da başka bir şeyle değiştirilmesi yoluna başvurulmaksızın aynen mirasçılara verilmesi şeklinde gerçekleşmelidir. Örneğin eşit paya sahip iki mirasçı her biri 250 bin lira değerinde iki otomobil ve 500 bin lira değerinde bir evi paylaşacaksa, bir mirasçıya iki araba diğerine de ev verilmelidir. Burada eşitlik ilkesi mutlak şekilde kabul edilerek, mirasçılara birer otomobil verilmesi ve evin de satılıp bedelinin paylaştırılması yoluna gidilmemelidir. Bu, aynen paylaşma ilkesine ters düşer.

Aşağıda payların oluşturulması ve özellikle mirasçılara tahsis (özgüle- 1956
me) konuları ele alınırken, bu değer bakımından aynı fakat içeriği farklı payların dağıtılma yöntemi açıklanacaktır.

Aynen paylaşma ilkesi de mirasçıların tümünün anlaşmasıyla bertaraf 1957
edilebilir ve buna aykırı bir paylaşma gerçekleştirilebilir. Ancak, mirasçılar arasında aksine bir anlaşma bulunmadıkça, özellikle paylaşma davası sıra-

---

[1194] *Escher*, Art. 607 N 6 ve 610 N 1; *Tuor/Picenoni*, Art. 607 N 13 ve Art. 610 N 2; *Kocayusufpaşaoğlu*, 707/708.

sında hakim, aşağıda ele alınacak bazı özel durumlar hariç bu ilkeye göre paylaştırmayı yapacaktır.

4. Bilgi verme yükümü

1958 MK 649/II'ye göre, mirasçılar, mirasbırakanla aralarındaki ilişkilere ait olup paylaşmanın eşitlik ve adaletle gereçekleşmesine yarayan her türlü bilgiyi birbirlerine vermekle yükümlüdürler. Bu genel bilgi verme yükümü sebebiyle, örneğin mirasbırakandan sağlığında denkleştirmeye ya da tenkise tabi bir kazandırma almış olan mirasçı, bu durumu saklamayıp diğer mirasçılara bildirecektir. Özel bir bilgi verme yükümü MK 646/III'de düzenlenmiştir. Buna göre, bir tereke malına zilyet olan ya da mirasbırakana borçlu olan mirasçı, bu hususlarda diğer mirasçılara bilgi vermek zorundadır, Görüldüğü üzere gerçekte bu hükümde iki ayrı hususta bilgi verme yükümü düzenlenmiş olup; bunlardan birincisi bazı mirasçıların her nasılsa elinde bulunan tereke mallarını diğer mirasçılardan gizleyerek paylaşmadan kaçırmasına; ikincisi ise, mirasbırakana olan borcunu gizleyerek diğer mirasçılara payları oranında intikal eden bu alacak hakkının onlar tarafından kullanılmasını engellemesine yaptırım getirmektedir.

1959 Her mirasçı, bilgi verme yükümünü (niteliği sonucu), diğer mirasçılar talepte bulunmadan yerine getirmek zorundadır. Bu yükümlülük, kanundan doğan ve sözleşme benzeri bir hukuki ilişki olan miras ortaklığına dahil olmaya bağlanan bir borç olduğundan, ihlali hâlinde haksız fiil hükümleri değil, borca aykırılık hükümleri uygulanacaktır[1195]. Bu yükümü ihlal eden mirasçı BK 112 çerçevesinde kusursuz olduğunu ispat edemedikçe (işin niteliği gereği bu çok zordur), diğer mirasçıların bundan doğan tüm zararlarını tazmin borcu altına girecektir[1196].

5. Ayni ikame

1960 Mirasın açılmasından terekenin paylaşılmasının tamamlanmasına kadar, terekede yer alan bir mal ya da hakkın herhangi bir surette elden çıkması karşılığı yerine bir karşı edim verilmişse bu, o mal ya da hakkın yerine kendiliğinden terekeye girmiş sayılır. Buna *ayni ikame ilkesi* denir[1197]. Tereke malının satılması üzerine elde edilen bedel, trampa edilmesi hâlinde elde edilen mal, istimlak bedeli ve hasara uğraması karşılığı alınan sigorta bedeli, ayni ikame prensibi gereği terekeye dahil olacaklardır.

[1195] Bu bakımdan *İmre/Erman*, 418/418'da bilgi verme yükümüne aykırılığın haksız fiilden dolayı tazminat yükümü doğuracağı şeklindeki açıklamaları isabetsizdir.

[1196] *Escher*, Art. 607 N 8, 11; *Tuor/Picenoni*, Art. 607 N 9, 10; *Kocayusufpaşaoğlu*, 708/709; *İmre/Erman*, 418/419; *Oğuzman*, 327.

[1197] *Escher*, Art. 599 N 1-14; *Tuor/Picenoni*, Art. 599 N 15-18; *İmre/Erman*, 420.

IV. TÜM MİRASÇILARIN ANLAŞMASIYLA PAYLAŞMA

Esas olan mirasın mirasçıların anlaşmasıyla paylaşılmasıdır. Ancak bu anlaşmanın yapılış şekli MK 676'da özel olarak düzenlenmiştir. Bu hükümlere bakılırsa, mirasçıların anlaşarak terekeyi paylaşmaları iki şekilde olabilir: a) her mirasçının payına düşecek şeylerin belirlenmesi ve fiilen bu kişiye verilmesi (buna *elden paylaşma* denilmektedir); b) yazılı bir paylaşma (taksim) sözleşmesi yapılması. 1961

Belirtelim ki paylaşma davasından farklı olarak mirasçıların elden paylaşma ve paylaşma sözleşmesi ile tüm terekeyi paylaşmak yerine sadece belirli malları paylaşmaları (objektif kısmi paylaşma) ya da sadece bazı mirasçılara verilecek şeyleri saptamaları (sübjektif kısmi paylaşma) da mümkündür. Ancak, aşağıda belirtilecek sebeplerle, kısmi paylaşmaya burada ender rastlanacaktır. Mirasçıların anlaşmasıyla terekenin tümünün veya da bir kısmının paylaşılmasını sağlayan bu iki yolu yakından görelim. 1962

1. Elden paylaşma

MK 676/I'in yanıltıcı ifadesinde *payların oluşturulması ve fiilen alınması .....mirasçıları bağlar* denmişse de; doktrin ve uygulamada oybirliğiyle kabul edildiği üzere[1198], burada kastedilen şudur: şayet tüm mirasçılar tereke mallarının kime verileceği hususunda anlaşmakla kalmayıp, bu maksatla ilgili mirasçılara bu malların devri de yapılmışsa, artık söz konusu mallar geçerli şekilde paylaşılmış sayılacaktır. 1963

Bu tür paylaşma için tüm mirasçıların hangi tereke unsurunun kime verileceği hususunda kayıtsız şartsız anlaşmış olmaları ve gene tüm mirasçıların katılımı ve rızası ile[1199] her bir tereke unsurunun niteliğene göre gerekli tasarruf işleminin yapılarak verilecek kişiye devredilmiş olması gerekir. Böylece, terekedeki taşınırların mülkiyetini geçirme kasdıyla zilyetliklerinin devri, taşınmazların tescili, alacakların yazılı temlik sözleşmesiyle temliki gerçekleşmiş olmalıdır. Ancak bu devir işlemleri tamamlandıktan sonradır ki, elden paylaşma geçerli sayılır ve artık farklı bir paylaşma talep edilemez. 1964

Taşınmazların elden paylaşılmasında bir sorun vardır. Taşınmazların devir işlemi tapu sicilinde devralacak mirasçı adına tescil edilerek yapıla- 1965

[1198] *Escher*, Art. 634 N 1; *Tuor/Picenoni*, Art. 631 N 1 vd; *Jäggi*, Zwei Fragen aus dem Erbteilungsrecht, SJZ 63 (1967), 165; *Kocayusufpaşaoğlu*, 721; *İmre/Erman*, 500; *Oğuzman*, 336.

[1199] Ancak MK 648 uyarınca bir mirasçının yerine paylaşmaya sulh mahkemesinin atadığı kayyımın katılması kabul edilmişse, artık bu mirasçının katılımıyla elden paylaşma yapılması mümkün değildir.

caktır. Ancak, hukukumuzda tescilin yapılabilmesi için, kanunen belirlenmiş bazı istisnalar dışında MK 706 uyarınca resmi senet düzenlenmesi gerekmektedir. Bu ise, elden paylaşma kavramının dışına çıkan, aşağıda belirteceğimiz şekle tabi paylaşma sözleşmesinin kapsamına giren bir durum olur. Bu bakımdan baskın görüş, taşınmazların elden paylaşmasının tüm mirasçıların tapu siciline bu taşınmazın içlerinden belirli bir mirasçı adına tesci edilmesi taleplerini yöneltmeleri üzerine, sicilde tescilin yapılmasıyla gerçekleşeceğini, ayrıca tapuda resmi senet düzenlenmesine gerek olmadığı yolundadır[1200]. Ne var ki, bu görüş İsviçre Hukuku bakımından halen geçerli ise de, Türk Hukuku bakımından 18.5.1994 tarih ve 94/5623 sayılı Tapu Sicili Tüzüğü'nün[1201] yürürlüğe girmesine kadar anlam taşımaktaydı. Zira eski Tapu Sicil Nizamnamesi'nin 19 b.3 hükmünde tüm mirasçıların yazılı başvurularıyla terekedeki taşınmazın bir mirasçı adına tescili mümkün görülmüşken; bu günkü Tapu Sicil Tüzüğü 21/c ancak noterde düzenlenen bir paylaşma sözleşmesinden ya da yazılı olarak düzenlenmiş bir paylaşma sözleşmesinden sonra ve bu anlaşmaya dayanarak (bunu ibraz da ederek) mirasçıların yapacağı başvuru ile bir mirasçının adına tescili kabul etmektedir[1202]. Bu düzenleme karşısında artık yeni Tüzüğün yürürlüğe girmesinden itibaren ülkemizde taşınmazların elden paylaşılması mümkün değildir[1203].

1966 Tapuya kayıtlı olmayan taşınmazlar bakımındansa, tüm mirasçıların anlaşarak taşınmazın zilyetliğinin paylaşma maksadıyla bir mirasçıya ya da bazı mirasçılara devredilmesini Yargıtay geçerli bir paylaşma saymaktadır[1204].

1967 Elden paylaşmanın bazı mallarda birden çok mirasçı lehine paylı mülkiyet tesis edilmesi yoluyla da yapılması mümkündür.

1968 Elden paylaşma teorik olarak sadece bazı tereke malları (ya da hakları) için ya da sadece bazı mirasçılara verilecek şeyler için yapılabilirse de, burada dikkatli olunmalıdır. Böyle bir kısmi paylaşmanın geçerli olması için, paylaşma anında mirasçılar geriye kalan tereke mallarının nasıl paylaşılacağı hususunda anlaşmaya varamasalar bile, bu malların paylaşılmasının kesin olduğu hususunda anlaşmış oldukları söylenebilmelidir[1205]. Normal

---

[1200] *Escher*, Art. 634 N 5, 6; *Tuor/Picenoni*, Art. 634 N 5- 11; *Kocayusufpaşaoğlu*, 723 vd

[1201] RG 7.6.1994, No. 21953.

[1202] Yeni düzenlemeye göre, şayet anlaşma noterde düzenlenmişse bir mirasçının başvurusu, şayet adi yazılı şekilde yapılmışsa imzaları noterce tasdik edilmemiş olan mirasçıların başvurması gerekli ve yeterlidir.

[1203] Bkz., *Oğuzman*, 336.

[1204] HGK 10.3.1982 1450/258 (YKD 1983, 21 vd).

[1205] Bu konudaki farklı görüşlerin etraflı incelemesi ve eleştirisi için bkz., *Kocayusufpaşaoğlu*, 722.

olanı, mirasçıların tüm terekenin elden paylaşılmasına yönelik olarak anlaşmaları olduğundan, sadece bir kısım tereke malı bazı mirasçılara devredilmişse, bu kişiler esasen diğer mallardan bağımsız olarak sadece bu malların paylaşılmasının amaçlandığını ispat edemedikçe devredilen mallar için dahi geçerli bir elden paylaşma yapılmamış sayılmalıdır.

Nihayet belirtelim ki, bazı yazarlar, elden paylaşmanın paylaşma söz- 1969
leşmesi karşısındaki durumunu BK 289 hükmündeki elden bağışlamanın bağışlama taahhüdü karşısındaki durumuna benzetmektedirler ki[1206], bu takdirde MK 676'daki elden paylaşmanın aynı hükümdeki paylaşma sözleşmesinin yazılı şekil şartına aykırı yapılmasından doğan geçersizliğinin ifa ile düzelmesinden ibaret olduğu söylenebilir.

2. Paylaşma sözleşmesi

Elden paylaşma yapılmadıkça, mirasçıları bağlayacak bir paylaşma söz- 1970
leşmesi ancak *yazılı* şekilde yapılırsa geçerlidir. MK 676/III'de bu şart açık olarak belirtilmiştir. İşte, yine tüm mirasçıların katılması gereken ve *adi yazılı* şekilde yapılması şart olan bu sözleşmeye *paylaşma sözleşmesi* diyoruz.

Paylaşma sözleşmesinin geçerli olması için yazılı metnin tüm miras- 1971
çılar tarafından imzalanması şarttır. Şayet bazı mirasçılar (örneğin yaş küçüklüğü ya da akıl hastalığı gibi sebeplerle) ehliyetten yoksunsa, yasal temsilcileri onlar adına paylaşma sözleşmesini yapıp imzalayabilecek, eğer mirasçılar sanırlı ehliyetsizse sadece onay vermekle yetineceklerdir. Ancak MK 462 b.9 uyarınca, vasinin kısıtlı adına paylaşma sözleşmesi yapması ya da ona icazet vermesi için sulh mahkemesinin (vesayet makamı) izni de gereklidir. İstisnai bir durum olarak MK 648'e göre paylaşmaya bir mirasçı yerine bir sulh mahkemesince atanan kayyımın katılmasına karar verilmişse[1207], sözleşme bu kayyım tarafından imzalanacaktır.

Mirasın paylaşılması MK 449 kapsamındaki, önemli bağışlama, vakıf 1972
kurma ve kefil olma gibi tamamen ivazsız bir işlem sayılmayacağından, yasal temesilci tarafından yapılamayacağı söylenemez. Ancak, istisnaen bir kısmi paylaşma yapılıyor ve ehliyetsiz mirasçı bu sözmeşmede sadece devreden durumundaysa, bunun MK 449'a kıyasen yasal temsilci tarafından ya da onun izin veya icazetiyle yapılamayacağı savunulabilir.

Paylaşma sözleşmesi mirasın açılmasından itibaren ve başka bir yolla 1973
paylaşma tamamlanıncaya kadar yapılabilir. Mirasbırakanın ölümünden önce tüm müstakbel mirasçıların yapacağı paylaşma sözleşmesi MK 20 uyarınca ahlâka aykırılık sebebiyle geçersiz sayılmalıdır.

[1206] *Jäggi*, SJZ, 165.
[1207] Bkz., aşağıda VI.

1974 Ancak sonradan, bu sözleşme uyarınca mirasın elden paylaşılması, ahlâka aykırı bir sözleşmenin ifası olarak değil, MK 676/I'e göre geçerli bir paylaşma sayılmalıdır. Keza mirasçıların mirasbırakanın ölümünden (mirasın açılmasından) sonra, eskisiyle tamamen aynı hükümleri içeren, sadece tarihi yeni bir sözleşme yapmaları hâlinde de paylaşma sözleşmesi geçerli sayılacaktır.

1975 Paylaşma sözleşmesi yapılmadan önce bir mirasçı tarafından paylaşma davasının açılmış olması, davacı ve davalı tüm mirasçıların paylaşma sözleşmesi yapmalarına engel değildir. Davada, henüz paylar oluşturulmadan önce sözleşme yapılırsa, bu aynı zamanda sulh yoluyla davanın bitmesi demektir. Paylar oluşturulduktan sonra, fakat tahsis yapılmadan önce paylaşma sözleşmesinin yapılması, Velayet, Vesayet ve Miras Tüzüğü 65/I'e göre hakimin bu durumu bir tutanakla tespit ederek paylaşma sözleşmesine uymasını gerektirir. Mahkemece kura yoluyla payların tahsisi tamamlandıktan sonra, artık paylaşma sözleşmesi yapılamaz. Mirasın paylaşılmasının tamamlandığı bu aşamada böyle bir sözleme BK 27'ye göre hükümsüz olur. Bu aşamadan sonra artık mirasçıların her bir tereke malının mülkiyetini devir borcu doğması için gerekli şekillere uyularak karşılıklı trampa ya da satış sözleşmesi yapmaları gerekir.

1976 Paylaşma sözleşmesi bir borç doğuran işlemdir[1208]. Bu sözleşme yapıldı diye sözleşmede belirlenen tereke unsurları kararlaştırılan mirasçılara kendiliğinden geçmez (durum elden paylaşma gibi değildir). Her bir tereke unsurunun kendine özgü tasarruf işlemiyle gideceği mirasçıya geçirilmesi gerekir. Taşınırlar ayni anlaşma ve zilyetliğin devri, taşınmazlar tapuda tescil ve alacak hakları alacağın temliki işlemleriylegeçirilecektir. Ancak belirtelim ki, yazılı paylaşma sözleşmesi esasen hangi alacağın kime devredileceğini belirttiği ve altında tüm mirasçıların imzası bulunduğu için BK 183, 184 hükümlerindeki alacağın temlikinin şekil şartları gerçekleşmiş olacağından, ayrı bir temlik sözleşmesine gerek kalmayacaktır.

1977 Geçerli bir paylaşma sözleşmesine rağmen bazı mirasçılar gerekli tasarruf işlemlerini yapmaktan kaçınırsa, her mirasçı, kendisine verilmesi kararlaştırılan şeyler bakımından bunlara karşı ifa davası açabilir. Burada, esasen sözleşmeden doğan bir borcun ifasını talep söz konusudur ve bu dava MK 642'daki paylaşma davası ile karıştırılmamalıdır.

1978 Paylaşma sözleşmesi borçlandırıcı bir sözleşme olduğundan, bundan doğan borca aykırı davranışlar karşısında, borca aykırılığın tipine göre Borçlar Kanununun kusurlu ifa imkânsızlığı (BK 112), kusursuz ifa imkân-

---

[1208] *Escher*, Art. 634 N 8; *Tuor/Picenoni*, Art. 634 N 15; *Kocayusufpaşaoğlu*, 728; *Oğuzman*, 337; *Kılıçoğlu*, Miras Taksim Sözleşmesi, Ankara 1989, 76 vd.

sızlığı (BK 136), borçlu temerrüdü (BK 117 vd., paylaşılan paralar bakımından kanuni temerrüt faizi hatta kıyasen iki tarafa borç yükleyen sözleşmelere ilişkin BK 123 vd) hükümlerine başvurulabilir. Ayrıca MK 679 hükmünün düzenlemesi karşısında satım sözleşmesindeki zapta ve ayıba karşı tekeffül hükümleri (BK 214-231) de burada uygulanabilecektir. Bu son duruma ileride ayrıca değineceğiz.

MK 676 hükmünde paylaşma sözleşmesinin adi yazılı şekle tabi tutulması, terekede yer alan taşınmazların paylaşımı bakımından, taşınmaz mülkiyetini nakil borcu doğuran sözleşmelerin resmi şekilde yapılması kuralına bir istisnadır. Sadece bir düzen hükmü olarak kabul edilen Noterlik Kanununun 89. maddesi hükmünün de bu sonucu değiştirmeyeceği[1209] 26.11.1981 tarih ve 5/3 sayılı İBK ile kesinleşmiştir[1210]. Böylece adi yazılı şekilde yapılmış ve tüm mirasçılarca imzalanmış bir paylaşma sözleşmesine dayanarak, kendisine taşınmaz düşen mirasçı diğer mirasçılara karşı doğrudan tescili dava edebilecektir. 1979

Bazı mirasçıların temerrüdü sebebiyle terekedeki bir taşınmazın mülkiyeti paylaşma sözleşmesine göre devredilmesi gereken kişi adına tescil edilemiyorsa, sözleşmeye göre bunu alacak olan mirasçının açacağı ifa davasında, hakimin verdiği kararla MK 716 uyarınca mülkiyet kendiliğinden bu mirasçıya geçer. 1980

Tapu Sicil Tüzüğü 21/ b.c, paylaşma sözleşmesiyle bir taşınmaz payına düşmüş olan mirasçıya bir kolaylık sağlamıştır. Buna göre, eğer sözleşmedeki imzalar notere onaylatılmışsa, imzası noter onaylı bu mirasçılar aleyhine mahkemeye başvurmaya gerek olmadan, doğrudan sözleşmeyi tapuya ibraz ederek tescili sağlama imkânı tanımıştır. Madde metni amaca göre yorumlanarak aynı imkân noterde resen düzenleme şekliyle yapılan paylaşma sözleşmelerine de öncelikle (evleviyyetle) öncelikle uygulanabilmelidir[1211]. 1981

Paylaşma sözleşmesi, Borçlar Kanunun borca aykırılık hükümleri yanında, irade sakatlığı (BK 30 vd) ve gabin (BK 28) hükümlerine de tabidir ve bu hükümlere göre iptal edilebilir. *"Borçlar Kanununun geçersizliğe ilişkin genel hükümleri paylaşma sözleşmeleri hakkında da uygulanır"* diyen MK 680 hükmü ile bu husus açık olarak belirtilmiştir. 1982

[1209] *Oğuzman*, 338; *İmre/Erman*, 534; *Kocayusufpaşaoğlu*, 729.

[1210] RG 3.11.1981, No. 17209.

[1211] *Kılıçoğlu*, 93. Buna karşılık, madde metnini biçimsel yorumlayarak, paylaştırma sözleşmesinin noterde resen düzenlendiği durumlarda, sözleşme metninde bir mirasçıya tescili talep hakkı açıkca tanınmamışsa bu imkânın bulunmadığı görüşünde, *Oğuzman*, 337/338, dn. 366c.

1983 Son olarak belirtelim ki, elden kısmi paylaşmanın kanunda düzenlenmemiş (fakat doktrin tarafından kabul edilmektedir) olmasına karşın, paylaşma sözleşmesiyle terekenin (objektif) kısmi paylaşımı MK 676'da öngörülmüştür. Söz konusu hükme göre, *"Paylaşma sözleşmesiyle mirasçılar, tereke mallarının tamamı ya da bir kısmı üzerindeki elbirliği mülkiyetinin miras payları oranında paylı mülkiyete dönüştürülmesini de kabul edebilirler"* Hüküm her ne kadar kısmi paylaşmanın paylı mülkiyete çevrilmesi şeklinde olabileceğini öngörmekteyse de, paylı müykiyete çevirme değil de ferdi mülkiyeti tahsis şeklinde de bir paylaşma sözleşmesinin yapılmasına bir hukuki engel bulunmamaktadır.

V. PAYLAŞMA (TAKSİM) DAVASI

1984 Mirasın paylaşılması hususunda tüm mirasçıların yasanın aradığı şekil şartlarına uyarak anlaşmaları mümkün olmazsa[1212], her mirasçı paylaşmanın mahkeme eliyle yapılması için bir paylaşma davası açmaya yetkilidir. Bu davayı açma hakkının, mirasın açılmasıyla kurulan miras ortaklığından doğan, mirasçıların birbirine karşı terekeyi paylaşma borçlarını ifa etmekten kaçınmalarına (paylaşmaya yanaşmamaları) dayadığı, böylece bir tür ifa (eda) davası olduğu yolundaki görüş[1213] bu gün artık terkedilmiştir. Gerçekten de, kanunumuzda mirasçıların paylaşmaya yönelik bazı yükümlülükleri (örneğin bilgi verme borcu, tekeffül borcu) düzenlenmişse de, terekeyi paylaşma yükümü düzenlenmemiştir. Öte yandan,şayet mirasçıların birbirine karşı mirası paylaşmakla yükümlü oldukları kabul edilirse, herhangi bir mirasaçı paylaşma davası açmadan ya da açılmış dava sonuçlanmadan önce diğerlerine yaptığı makul paylaşma önerisini kabul edilmediği gerekçesiyle, gecikme tazminatı (ve terekedeki paralardan kendi payına düşecek kısım için temerrüt faizi) isteyebilecektir. Yasanın, paylaşmadan kaçınan mirasçıları böyle bir sorumluluk yüklediği kabul edilmez. Bu gün kabul edilen görüş, paylaşma davasının bir yenilik doğuran dava olduğudur[1214]. Gerçekten de, bu dava ile, mirasçıların tereke üzerindeki elbirliğiyle mülkiyet ilişkisi sona ererek, her bir mirasçının, her bir tereke unsuru üzerinde belirli hakları doğacaktır. Bu açıdan paylaşma davası açma, mirasçılar bakımından değiştirici yenilik doğuran bir hakkın kullanılması olup, mahkemece verilen karar da değiştirici yenilik doğuran bir karardır. Bununla birlikte paylaşma davası sırasında, daha önce açıkladığımız, iade davası gibi edaya yönelik talepler de olabilir[1215].

[1212] Geçerli şekilde yapılmış bir paylaşma sözleşmesine bazı mirasçıların uymaması paylaşma davası değil, bu sözleşmenin ifası davası açılmasına imkân verir.

[1213] Bu görüşün eleştirisi için bkz., *Kocayusufpaşaoğlu*, 687 vd; *Aral*, Türk Medeni Hukukunda Mirasın Taksimi Davası, Ankara, 51 vd.

[1214] *Escher*, Art. 604 N 5; *Kocayusufpaşaoğlu*, 688/689; *Oğuzman*, 320/321; *Aral*, 59.

[1215] *Kocayusufpaşaoğlu*, 689; *Oğuzman*, 321.

Paylaşma davası, tereke unsurlarının niteliklerine,bulundukları yerlere ve değerlerine bakılmaksızın, mirasın açıldığı yer, yani mirasbırakanın son yerleşim yerinin bulunduğu sulh mahkemesinde açılır. 1985

Paylaşma davası, mirasın paylaşılması hususunda yukarıda açıkladığımız biçimlerde (elden paylaşma ya da paylaşma sözleşmesi biçiminde) geçerli bir anlaşma yapılmamış olan (ya da böyle bir anlaşmanın sonradan iptal, ikale ya da sözleşmeden dönme yoluyla ortadan kaldırıldığı) durumlarda ve dava açan tarafından kural olarak tüm mirasçılar davalı gösterilerek açılır. Paylaşma davasının, genel kural olarak, tüm terekenin paylaşılması için açılması gerekir. Keyfi şekilde sadece bazı tereke mallarının gözönüne alınarak, paylaşmanın yapılması talebiyle paylaşma davası açılamaz. 1986

MK 676/II'deki paylı mülkiyete çevirme yoluyla objektif kısmi paylaşmaya imkân veren hüküm örnekseme yoluyla dahi paylaşma davasına uygulanamaz. Çünkü MK 676/II, bütün mirasçıların anlaşmasıyla uygulanabilecek bir hükümdür. Oysa paylaşma davası, mirasçıların paylaşmaya yönelik anlaşmaları temin edilemediği için açılmaktadır. 1987

Ancak, daha önce tüm mirasçılar terekedeki bir kısım malları geçerli şekilde paylaşmış (objektif ya da sübjektif kısmi paylaşma yapılmış) olup[1216], ayrıca bu paylaşmanın diğer tereke kısımlarının paylaşımı üzerinde anlaşmasalar da geçerli olacağı hususunu kararlaştırmışlarsa; istisinaen bu halde paylaşma davası sadece paylaşılmamış tereke kısımları için açılabilir[1217]. Keza, tüm mirasçılar bu kısmi paylaşma sırasında içlerinden birine ya da bazısına tüm miras payının verildiği hususunda geçerli şekilde anlaşmışlarsa (sübjektif kısmi paylaşma) ve kalan tereke kısmının kalan mirasçılar arasında paylaşılması hususunda anlaşmaya varamamalarının, paylarını alan mirasıçıları etkilemeyeceği de kararlaştırmışlarsa;paylaşma davası sadece henüz paylarını almamış bulunan diğer mirasçılara karşı açılabilecektir. 1988

Paylaşma davasında hakim, üzerinde elbirliğiyle hak sahipliği bulunan tereke unsurlarını, mirasçıların miras paylarına göre gruplara ayırarak, bunlar üzerinde tek başına hak sahibi olunacak şekilde her bir mirasçıya tahsis edecektir. Hakim, davacının, hatta çoğunlukta olan mirasçıların talebiyle dahi, paylaşmayı, bazı tereke malları üzerindeki elbirliği mülkiyetini paylı mülkiyete dönüştürerek yapamaz Bunun için tüm mirasçıların rızası olmalıdır (MK 676/II'nin örneksenmesiyle). Bu bakımdan, terekenin mevcudu her bir mirasçıya müstakil mallar vermeye uygun değilse, mirasçıların anla- 1989

[1216] Bkz., § 38, II, 2.

[1217] *Escher*, Art. 604 N 5; *Tuor/Picenoni*, Art. 604 N 4d; *Kocayusufpaşaoğlu*, 689/690; *Oğuzman*, 321.

şamaması hâlinde hakim bazı malları sattırarak bedelini paylaştırır (MK 651/II), fakat, yukarıda da değinildiği gibi, üzerinde paylı mülkiyet tesis edemez. Elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesi daha önce açıkladığımız MK 644 hükmünde düzenlenmiş olup paylaşma yapılmaksızın miras ortaklığını sona erdiren ayrı bir imkândır.

1990 Katıldığımız görüş uyarınca, dava sonunda oluşturulan payların hangi mirasçılara tahsis edildiğine ilişkin verilen kararla, bu mirasçılar kendilerine tahsis edilen şeylere derhal sahip olurlar. Yani paylaşım kararı, mirasçıların aralarında yaptıkları paylaşma sözleşmesi gibi, borç doğurucu değil, ayni etkiye sahiptir[1218]. Söz konusu şeyleri mirasçılara geçirmek için ayrıca tasarruf işlemi yapılmasına gerek yoktur. Böylece örneğin terekede yer alan bir taşınır, zilyetliğin devri gerekmeksizin ya da terekede yer alan bir taşınmaz tapu sicilinde tescil yapılmaksızın, hakimin tahsis kararı verdiği mirasçının mülkiyetine geçmiş sayılacaktır. Bu karardan sonra, kendisine tahsis edilen malı elde etmek isteyen mirasçı, bir ifa davası değil, taşınırlarda istihkak, taşınmazlarda yolsuz tescilin düzeltilmesi davası[1219] açacaktır.

1991 Paylaşma davası açma bir süreye bağlanmamıştır. Bu bakımdan, kural olarak, mirasın açılmasından başlayarak, başka bir yolla (paylaşma sözleşmesi, elden paylaşma, elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesi) miras ortaklığı sona ermedikçe, ne kadar uzun bir zaman geçerse geçsin paylaşma davası açılabilir. Fakat aşağıda açıklanacağı üzere, paylaşma davasının açılmasını önleyen ya da geciktiren bazı hukuki sebepler bulunmaktadır.

VI. PAYLAŞMAYI GECİKTİREN SEBEPLER

1. Paylaşmanın iradi olarak geciktirilmesi

a) Mirasçıların anlaşmasıyla

1992 Şayet mirasçılar bir süre miras ortaklığını ve tereke üzerindeki elbirliğiyle hak sahipliğini devam ettirme hususunda anlaşmışlarsa, sözleşme özgürlüğü ilkesi uyarınca geçerli ve bağlayıcı sayılacak bu anlaşmada belirtilen süre içinde bir mirasçı diğerlerine karşı paylaşma davası açamayacaktır. Eğer böyle bir dava açarsa, davalılardan birinin bu sözleşmeyi ileri sürmesiyle davacının talebi reddedilecektir.

1993 Paylaşmayı erteleme etkisine sahip olan miras ortaklığına devam sözleşmesi, tüm mirasçıların katılımıyla hüküm ifade eder. Söz gelimi, dört

---

[1218] *Aral*, 59; *Oğuzman*, 321.

[1219] Zira, tahsis kararı ile mülkiyeti kazandığından,o andan itibaren tapu sicilinde henüz diğer tüm mirasçılar (miras ortaklığı) adına mevcut tescil yolsuzlaşmış olacaktır.

mirasçıdan ikisi kendi aralarında miras ortaklığına devam sözleşmesi yapmış olsalar bile, bu, incelediğimiz anlamda paylaşmayı geciktiren bir sözleşme olmadığından, bizzat bu sözleşmenin taraflarından biri dahi paylaşma davası açabilir ve ortaklığa devam sözleşmesinin diğer tarafı bile bu davaya ve paylaşmaya itiraz edemez. Ancak sözleşmenin diğer tarafı olan mirasçı, paylaşmaya boyun eğmekle birlikte, kendi aralarında borç doğuran bu sözleşmeye akıtı davranan öbür mirasçıya, bu yüzden bir zarara uğradığını ispat ederse, tazminat davası açabilir.

Miras ortaklığına devam sözleşmesi,baskın görüşe göre, herhangi bir şekle bağlı değildir[1220]. Kuşkusuz, en azından adi yazılı şekilde yapılmaması hâlinde ispatı çok güç olacaktır. Ancak doktrin ve uygulamada benimsendiği üzere, mirasçıların içinde bulunduğu geçici bazı sorunlar ve şartlar, zarara uğramamaları için paylaşmanın bir süre geciktirilmesini makul göstermediği halde, mirasçılar uzun süre bu ortaklığa (yani elbirliğiyle hak sahipliğine) devam sözleşmesi yapmışlarsa, BK 19 uyarınca bu gerçekte aile malları ortaklığı (MK 373) sayılabilir ve buna ilişkin resmi şekilde (MK 374) yapılmadığı için geçersiz olur[1221]. Eğer bu anlaşma BK 620 vd. anlamında bir adi ortaklık sayılabilirse, artık tereke malları üzerindeki elbirliği hali miras hukukuna göre değil, adi ortaklığın sona ermesi ve tasfiyesi hakkındaki hükümlere göre (BK 639 vd, 642 vd.) sona erecektir. 1994

Eğer miras ortaklığına devam sözleşmesi aile malları ortaklığı ya da adi ortaklık sözleşmesi olarak yorumlanamıyorsa ve süresiz olarak ya da bazı mirasçılar bakımından kendilerinden katlanmaları beklenmeyecek kadar uzun süre için yapılmışsa, bunun, tarafların işlem ehliyetini kişilik hakkına aykırı düşecek kadar sınırladığı kabul edilerek, BK 27 uyarınca geçersiz sayılacaktır. 1995

Miras ortaklığına devam sözleşmesinin, hiç bir geçersizlik sebebi taşımadığı durumlarda bile, öngörülmemiş olan bir haklı sebebin ortaya çıktığını ispat eden mirasçı tarafından feshedilebileceği kabul edilmektedir[1222]. Buna tipik örnek, sözleşme yapıldıktan sonra bir mirasçının ölmesi ve ölenin yerini alan mirasçılar ile diğer mirasçıların ortaklığa devam etmek istememelerinin haklı sebep oluşturmasıdır. 1996

Miras ortaklığına devam sözleşmesinin, belirlenen sürenin dolması ya da feshi sebebiyle sona ermesi üzerine, her mirasçı artık paylaşma davası açabilecektir. 1997

[1220] *Escher*, Art. 604 N 7; *Tuor/Picenoni*, Art. 604 N 6-7; *Kocayusufpaşaoğlu*, 683/684; *Oğuzman*, 322; adi yazılı şekilde yapılması gerektiği görüşünde, *İmre/Erman*, 408.

[1221] *Escher*, Art. 604 N 2; *Kocayusufpaşaoğlu*, 683/684; *İmre/Erman*, 408/409.

[1222] *Oğuzman*, 322; *Aral*, 72 vd.

b) Mirasbırakanın tasarrufu ile

1998 Mirasbırakan bir ölüme bağlı tasarrufla, mirasçılar arasında miras ortaklığının tereke paylaşılmadan bir süre devam etmesini öngörmüş olabilir. Kural olarak bu tasarruf geçerlidir. Zira, mirasbırakanın ölüme bağlı tasarruf şekline uyarak bildirdiği iradesine olabildiğince uyma ilkesi (favor testamenti) bunu gerektirir.

1999 Ne var ki, mirasçıların tümünün anlaşmasıyla, mirasbırakanın bu iradesine aykırı olarak mirasın daha erken paylaşılabileceği de kabul edilmektedir[1223]. Zira, paylamada mirasçıların tümünün ortak iradesi mirasbırakanın iradesine üstün tutulur. Fakat, mirasçılardan birinin karşı çıkması hâlinde, mirasbırakanın miras ortaklığını uzatma iradesine aykırı bir paylaşma yapılamaz. Böyle bir durumda, bir mirasçının itirazı hâlinde açılan paylaşma davası reddedilecek; ancak mirasbırakanın belirlediği süre dolunca paylaşma davası açılabilecektir.

2000 Ne var ki, bunun da istisnaları vardır. Mirasbırakanın, paylaşmanın geciktirilmesine ilişkin tasarrufunun bazı mirasçıların saklı paylarına tecavüz oluşturması[1224] ya da mirasbırakanın miras ortaklığının süresiz devam etmesini öngörmesi[1225] veya mirasçılar tarafından katlanılması beklenemeyecek kadar uzun süre devamını öngörmesi geçersiz sayılacaktır. Böyle bir durumda bir mirasçı dahi paylaşma davası açabilecek ve diğer mirasçılar, mirasbırakanın tasarrufunu ileri sürerek paylaşmayı önleyemeyeceklerdir.

2. Paylaşmanın kanun gereği geciktirilmesi: mirasçılar arasında bir ceninin bulunması

2001 MK 643'e göre, mirasçılar arasında bir cenin (dölüt) varsa, paylaşma onun doğumuna kadar ertelenir. Bu erteleme, hiç bir mirasçının başvurusuna gerek olmadan ve hakimin takdir yetkisi söz konusu olmaksızın gerçekleşir. Çocuğu henüz ana karnındayken ölen müstakbel babanın; kendisinden önce ölen oğlunun eşi hamileyken ölen müstakbel büyük babanın, babası kendisinden önce ölmüş fakat annesi hamile olan müstakbel kardeşin mirasında durum böyledir Ayrıca aynı maddede, ceninin anası bu sırada bakıma muhtaç ise, kendisine bakım gideri de bağlanacağı öngörülmüştür.

2002 Aslında cenin, sağ ve tam olarak doğuncaya kadar kişi değildir. MK 28'de belirtilen bu kural, mirasçılık ehliyeti bakımından da MK 582'de tekrar edilmiştir. Şu halde mirasbırakan öldüğünde mevcut bir cenin aslında mirasçı değildir ve MK 643 olmasa, paylaşmanın o yokmuş gibi yapılması

[1223] *Kocayusufpaşaoğlu*, 685; *Oğuzman*, 322; *İmre/Erman*, 410; *Aral*, 275.
[1224] *Kocayusufpaşaoğlu*, 685; *Oğuzman*, 322.
[1225] *İmre/Erman*, 410.

gerekecektir. Ne var ki, böyle bir durumda, cenin, sonradan sağ ve tam olarak doğduğunda, geçmişe etkili olarak ana rahmine düştüğü andan itibaren kişi sayılacağından, mirasçılık sıfatını da geçmişe etkili olarak kazanacak ve yapılan paylaşma hukuka aykırı ve hükümsüz hale gelecektir. İşte paylaşma işlemlerini böyle yaz boz tahtası haline gelmekten korumak için, bu hükümle, ceninin sağ olarak doğup doğmacağı kesinleşinceye kadar paylaşma geciktirilmektedir. Bu sırada açılan paylaşma davasını hakim erteleyecektir[1226].

Cenin sağ doğarsa, o andan itibaren mirasçı olarak hesaba katılarak paylaşma yapılacak, aksine ölü olarak doğarsa, paylaşma o yokmuş gibi yapılacaktır. 2003

Belirtelim ki, ceninin doğumu beklenmeden o yokmuş gibi paylaşma yapılmışsa; cenin sağ olarak doğduğunda, yapılan paylaşma geçersiz sayılarak tekrar paylaşma talep edilebilecektir. Bu sonuç, ister paylaşma mirasçıların anlaşmasıyla yapılmış olsun, ister mahkeme kararıyla, değişmez. MK 643/II hükmünde, ceninin, bakıma muhtaç anasına terekeden bakım gideri bağlanmasına ilişkin yüküm, müstakbel ananın da mirasçı olmasına bağlı olmadığı gibi, ceninin sağ doğmasına da bağlı değildir[1227]. Cenini, ölür doğduğu için mirasçılık sıfatını kazanamamış ve böylece paylaşma boşuna geciktirilmiş olsa bile, anaya bu süre içinde verilen bakım giderleri sebepsiz zenginleşme oluşturmaz ve ondan geri istenemez. 2004

3. Hakim kararıyla paylaşmanın geciktirilmesi

Kanun, bazı özel durumlarda mirasçılardan birinin başvurması üzerine hakimin paylaşmayı erteleceyeceğini düzenlemiştir: Bu haller şunlardır: 2005

a)Terekenin derhal paylaşılması terekenin değeri ya da belli bir malın değeri önemli ölçüde düşecekse, MK 642/III'e göre, hakim, bir mirasçının talebi üzerine paylaşmanın ertelenmesinee karar verir. Hakimin saptayacağı gerek üzerine, tüm terekenin paylaşılması ertelenebileceği gibi, sadece bazı tereke mallarının paylaşılmasının ertelenip, diğerlerinin paylaşılması da mümkündür. Buna tipik örnek, paylaşma sırasında satılmaları gerekecek bazı tereke mallarının, o sırada mevcut piyasa şartlarında çok ucuza gidecek olmaları ve bu şartların makul bir zaman içinde değişerek malların değer kazanacağının kuvvetle muhtemel olmasıdır.Hakim, kararında paylaş- 2006

[1226] Henüz cenin doğmadan yasal temsilcinin muvafakatiyle paylaşmanın yapılabileceği şeklindeki görüşün (*Piotet*'den naklen, *Oğuzman*, 322,dn. 276) kabul edilmesi mümkün değildir. Henüz doğmamış bir çocuğun yasal temsilcinden söz edilemez. Çünkü bu aşamada temsil edilecek kişi henüz yoktur.

[1227] *Escher*, Art. 605 N 6,14; *Kocayusufpaşaoğlu*, 681.

mayı hangi zanmana kadar geciktirdiğini bildirmeksizin, sadece hangi sebeple ertelediğini bildirmelidir[1228]. Bu karardan sonra mirasaçılar her zaman erteleme gerekçesinin ortadan kalktığı iddiasıyla paylaşma talep edebilmelidirler. Fakat, erteleme gerekçesinin sona erip ermediğini resen inceleyecek olan hakim, bunun devam ettiğini görürse bu talebi reddedecektir. Kuşkusuz aradan geçen zaman, artık paylaşmayı ertelemeyi katlınılamaz kılıyorsa ya da, esasen ne kadar zaman geçerse geçsin erteleme kararının gerekçesindeki zarar tehlikesinin beraraf edilemeyeceği ortaya çıkmışsa, hakim, erteleme kararını kaldırarak paylaşmayı gerçekleştirmelidir.

2007 b) MK 649/III'e göre, bir mirasçının, hakimden, tereke borçlarının paylaşmadan önce ifasınıya da teminata bağlanmasını talep etmesi üzerine, bu borçlar ifa edilinceye ya da bunlar için yeterli teminat verilinceye kadar paylaşma geciktirilecektir. Paylaşmanın daha fazla gecikmeden gerçekleşmesini isteyen mirasçının yapacağı şey, bu borçları bizzat ödemek ya da rehin, kefalet gibi güvenceler vererek, ifayı teminat altına almaktır. Aksi takdirde söz konusu borçlar terekeden ödeninceye kadar ya da bir mirasçı veya bir üçüncü kişi ödeyinceye yahut da, ibra,takas vb. bir yolla ifa dışı sona erinceye kadar paylaşma ertelenecektir.

2008 c) MK 664/I uyarınca kendisine ekonomik bir bütün olarak işletilmekte olan bir tarımsal işletme özgülenen mirasçı, diğer mirasçıların paylarını karşılamak için işletme üzerinde önceden var olan güvenceler dahil olmak üzere dörtte üçünden fazlasını teminat olarak göstermek zorunda kalırsa, paylaşmanın ertelenmesini talep edebilecektir[1229]. Aynı maddenin ikinci fıkrasına göre göre, bu takdirde mirasçılar arasında kazançа paylı aile malları ortaklığı kurulmuş sayılır. Bu tür tarımsal işletmelerin paylaşılmasına ilişkin özel kurallara aşağıda değinilecektir.

2009 d) Tarımsal işletmeler yönünden bir başka hüküm de MK 663'de bulunmaktadır. Sadece altsoy yönünden uygulanabilecek bu hükme göre, mirasçılar arasında ayırt etme gücüne sahip ergin olmayan birisi varsa, paylaşma bu altsoy mirasçısı ya da mirasçılarının ergin olmasına kadar ertelenebilir. Bunu takdir edecek olan hakimdir. Hakim ertelemeye karar verecek olursa, özgülemenin gerçekleeceği ana kadar aile malları ortaklığı kurulur. Bunun üzerinde de aşağıda etraflı olarak durulacaktır.

[1228] Zira MK 642/III'nin amacı, elverişsiz şartlarda paylaşma yapılmasından kaçınılmasını talep imkânı vermek, yoksa bu şartların ne kadar süreceğine ilişkin hakimi kehanette bulunma yetsini vermek değildir.

[1229] İsviçre Medeni Kanunuda bunu karşılayan hüküm (ZGB 622) 1 Ocak 1994 tarihinde yürürlüğe giren 4 Ekim 1991 tarihli kanunla kaldırılmıştır.

VII. PAYLAŞMAYA HAKİMİN ATADIĞI BİR KAYYIMIN KATILMASI

Kural olarak paylaşma her aşamada mirasçılar ya da onların yasal temsilcileri tarafından gerçekleştirilecekse de, bazı istisnai durumlarda paylaşmaya hakimin atayacağı bir kayyım katılır. 2010

Hangi hallerde ve kimin paylaşmaya bir kayyımın katılmasını isteyebileceği MK 648'de belirtilmiştir. Buna göre, a) bir mirasçının açılmış olan miras payını devralmış kişiler (bu halde kayyım atanmasının amacı, payı devralanı korumak olduğuna göre, aynı hükmün örnekseme yoluyla açılmamış miras payını devralan kişiye de tanınması gerekir); b) bir mirasçının payını haczettirmiş olan alacaklılar ve c) bir mirasçıya karşı borcu ödemekten aciz belgesi almış alacaklılar, söz konusu mirasçının yerine paylaşmaya bir kayyımın atanmasını sulh mahkemesinden talep edebilirler. 2011

MK 648'i karşılayan eski MK 588, söz konusu hallerde talep üzerine sulh hakimin paylaşmaya katılmasını öngörüyordu[1230]. Yeni metinde, neden dolayı sulh hakiminin yerine, onun atayacağı bir kayyımın katılması gerektiği maddenin gerekçesinde şöyle açıklanmıştır: *"Yürürlükteki metinde, hakimin mirasçı yerine kaim olarak taksime iştirak edeceği belirtilmiştir. Ancak hakim, mirasçılar uyuşmadığı zaman, paylaştırmayı gerçekleştirimekle de görevlidir. Aynı hakimin hem paylaştırmayı gerçekleştirmesi hem de hem de mirasçılardan biri yerine onun (dolayısıyla alacaklının) yararlarını korumak için paylaştırmaya katılması uygun bir çözüm değildir..."*. 2012

MK 648'de belirtilen hallerin her biri ilgili yerlerde açıklanmıştır. Bu bakımdan burada, hepsine ilişkin ortak açıklamalar yapılacaktır. Önce, MK 648'deki şartlardan biri bulunsa bile, sulh hakimi talep olmadan kayyım atayamaz. Atama talebinin ilgili kişi tarafından , paylaşmanın başlamasından sona ermesine kadar, paylaşma davası açılmışsa, davanın sonuna kadar herhangi bir safhada ileri sürülmelidir. Sulh mahkemesinin ataması hâlinde kayyım, atandığı söz konusu mirasçının yerine (yoksa oun yanında değil) paylaşmaya, ya da paylaşma davasına katılır. Dava sırasında kayyımın atanması istenmişse, kayyım herhangi bir davalı ya da davacı gibidir. Kayyım, paylaşmada, kendisinin atanmasını iştemiş olan kişinin çıkarlarını korumakla yükümlüdür. Ayrıca kayyımın gerekli ise paylaştırma davası da açabileceği kabul edilmelidir[1231]. Aksi halde, kayyımın atanmasının pratik değeri son derece azalır. 2013

Paylaşmaya kayyımın katılması sulh hakimi tarafından kabul edildikten 2014

[1230] Eski metnin eleştirisi için bkz., *İmre/Erman*, 484.

[1231] *Escher*, Art. 609 N 19; *Kocayusufpaşaoğlu*, 719/720.

sonra, her paylaşma işlemini (elden paylaşma, paylaşma sözleşmesi, paylaşma davasında talepte ya da anlaşmada bulunma) yerine müdahele edilen mirasçı değil, onun yerine geçen kayyım yapar. Aksi halde bu işlemler, kayyım atanmasını istemiş olan, alacaklı ya da miras payını devralan kimseye karşı hüküm ifade etmez[1232].

VIII. PAYLAŞMANIN GERÇEKLEŞMESİ

2015 Mirasan paylaşılması MK 650 hükmünde belirtildiği üzere, tereke unsurlarının her bir mirasçının miras payına göre oluşturulacak gruplar hâlinde toplanması ve ardından da hangi mirasçıya verileceğinin saptanması olmak üzere iki aşamadan ibarettir. Bunların ilkine *payların oluşturulması*, ikincisine *payların tahsisi* denir. Belirtelim ki, bu iki aşama daha çok paylaşma davasında hakim tarafından yapılacak paylaştırma açısından önem taşıyacak olup, mirasçıların, dava dışı paylaşma sözleşmesiyle ya da elden paylaşma yoluyla mirası paylaşmalarında genellikle birleşerek tek aşama şeklinde gözükeceklerdir. Şimdi bu iki aşamayı ayrı ayrı ele alalım.

1. Miras paylarının oluşması

2016 Kural olarak paylar, mirasçıların anlaşmasıyla oluşturulacaktır (MK 560/I). Anlaşamamaları hâlinde, mirasçılardan birinin isteği üzerine paylar mahkeme arafından oluşturulur (MK 650/II). Prensipte bu iki durum arasında miras paylarının oluşturulmasında bir fark yoksa da, MK 650/II, hakimin paylaştırmayı yaparken nelere dikkat etmesi gerektiğini öngörmüştür. Bunun üzerinde aşağıda durulacaktır.

2017 Miras paylarının oluşturulması *mirasçı ya da ortak kökbaşı* sayısına göre yapılır (MK 650/I). Örneğin üç mirasçı varsa üç; iki kökbaşı varsa iki miras payı oluşturulacaktır. Bu işleme, yukarıda da değinildiği gibi, *payların oluşturulması (hisselerini teşkili)* denirse de, dikkat etmek gerekir ki, burada kastedilen, esasen her bir mirasçının, daha mirasın açıldığı anda belli olan miras payı (terekenin 1/2'si ya 1/3'ü gibi) değil (esasen bu oluşturulacak bir şey değildir), tereke mevcudundan oluşturulacak gruplardır. Bu anlamda paylar, terekedeki malların, hakların ve borçların mirasçı sayısında gruplar hâlinde toplanmasıyla oluşur.

2018 Bu sırada oluşturulacak payların maddi değerleri, mevcut mirasçıların miras payı oranlarına göre belirlenir. Böylece, bir mirasçının miras payı, diğer tüm mirasçılardan farklıysa, daha payların oluşturulması aşamasında aynı zamanda buna göre hesaplanan payın gideceği mirasçı da belirlenmiş

[1232] *Escher*, Art. 609 N 18; *Tuor/Picenoni*, Art. 609 N 14; *Kocayusufpaşaoğlu*, 720; *İmre/Erman*, 784.

olur. Örneğin, mirasbırakandan geriye eşi ve bir oğlu kalmış olup, tereke mevcudu 500 bin lira değerinde bir ev ve her biri 250 bin lira değerinde iki otomobilse; burada oluşturulacak iki paydan biri, terekenin değerinin 1/4'ü ve diğeri tereke değerinin 3/4'ü olacağından, bu da ancak bir paya ev ve bir otomobil (= 3/4) diğer paya ise sadece bir otomobil (=1/4) koymayı gerektirdiğinden; daha bu paylar oluşturulurken, ev ve otomobil konulan payın mirasbırakanın çocuğuna ve otomobilden ibaret olan payın eşine özgüleneceği (tahsisi edileceği) de belli olmuştur.

Ne var ki, bazı mirasçıların aynı oranda miras payına sahip olduğu du- 2019
rumlarda, payların oluşturulması ile bunların kime gideceği belli olmaz. Örneğin mirasbırakan geriye iki çocuğunu bırakmış olup, terekesi 250 bin lira değerinde bir ev ile 250 bin lira değerinde bir otomobilse; bir paya evin, bir paya otomobilin konulması suretiyle paylar oluşturulacaksa da, bunların hangi mirasçıya gideceği ancak özgüleme aşamasında belirlenecektir.

Mirasın açılmasından sonra, fakat payların oluşturulmasından önce mi- 2020
rasçılardan biri ölürse, bu durum payların oluşma aşamasını etkilemez. Ölen mirasçının yerine geçen birden fazla mirasçı bulunsa bile, o sanki sağmış gibi paylar oluşturulur. Fakat aşağıda açıklayacağımız özgüleme aşamasında, bu pay onun mirasçılarına özgülenirken, ayrıca kendi aralarında paylaşmaya tabi tutulacaktır. Bu sonuç, MK 580/II'nin, *"Miras açıldığı anda sağ olan mirasçı sonradan ölürse, onun miras hakkı kendi mirasçılarına kalır"* diyen ifadesinden açıkça çıkmaktadır.

Paylar oluşurken terekede yer alan malların ve hakların değerlerinin be- 2021
lirlenmesi gerekir. MK 657 taşınmazların paylaştırma sırasındaki gerçek değerlerinin esas alınacağını söyler. Bu değer, aynı maddenin ikinci fıkrasına göre, tarımsal taşınmazlarda gelir değeri, diğer taşınmazlarda sürüm değeridir. Paylaştırma sırasındaki değerin göz önünde bulundurulması, haklı olarak sadece taşınmazlar için değil, terekedeki tüm unsurlar için geçerli olacağı kabul edilmektedir[1233]. Mirasçıların değer üzerinde anlaşamamaları hâlinde, değeri başvuru üzerine sulh hakimi belirler (MK 658). Kuşkusuz sulh hakimi bu değerlendirmeyi çoğunlukla bilirkişilere yaptırılacaktır. Hakim ya da bilirkişiler değer takdirini yaparken, mevcut duruma göre (olabildiğince son andaki) değerleri gözönüne alacaklardır.

Payların oluşturulmasında, mirasçıların tümünün anlaşmasına mahkeme 2022
mutlak surette uyar. Böyle bir anlaşma yoksa mahkeme, mirasbırakanın geçerli bir ölüme bağlı tasarrufla öngördüğü paylaştırmaya uymak zorunda-

[1233] *Oğuzman*, 334.

dır. Böyle bir tasarruf da yoksa eşitlik[1234], olabildiğince aynen paşlaştırma[1235] ve ayni ikame[1236] ilkelerine uyularak paylar oluşturulacaktır. Bu ilkelerin uygulanması daha önce örneklerle açıklandığı için, burada tekrar edilmeyecektir.

2023 Bu ilkeler dışında MK 650/II, hakimin, payları oluştururken, olabildiğince a) yerel adetleri,b) mirasçıların kişisel durumlarını ve c) çoğunluğun arzularını da dikkate alacağını belirtmektedir. Böylece, örneğin eşit miras payına sahip olan iki mirasçıya paylaştırılacak olan terekede 200 bin lira değerinde iki otomobil, her biri 500 bin lira değerinde iki ev ve 1 milyon lira banka hesabı kalmışsa; hakim her bir mirasçıya bir otomobil, bir ev ve 50 bin lira ayırabileceği gibi[1237]; MK 650/II'deki unsurları dikkate alarak bir mirasçıya iki otomobil ve 800 bin lira, diğer mirasçıya iki ev 200 bin lira veya bir mirasçıya, iki araba, bir ev ve 300 bin lira, diğer mirasçıya bir ev ve 700 bin lira yahut bir mirasçıya bir otomobil ve 1 milyon lira, diğerine bir otomobil ve iki ev ayırması da mümkündür. Ancak belirtelim ki, eşitlik ilkesinden kısmen ayrılan bu paylaşmanın kanunuda öngörülen haklı sebebe dayanmaması hâlinde, karara itiraz edilebilecektir.

2024 Bütün mirasçılar anlaşmadıkça, hakimin bazı tereke malları üzerinde, bazı mirasçıların paylı mülkiyetine karar vererek pay oluşturması mümkün değildir. Bir diğer deyişle, oluşturulan paylarda bir tereke malının paylı mülkiyet hissesi yer alamaz. Üstelik bu kurala tam olarak uyulduğunda, üzerinde paylı mülkiyet tesis edilecek malın müstakbel paydaşlarının rızası ile dahi yapılamaz. Örneğin mirasbırakanın mirasçıları eşi ve iki oğlu olup, terekede dört ev varsa, hakim (1/4 miras payının karşılığı olarak) bir evi eşe verirken, kalan üç evi, her bir oğula birer ev üzerinde tek başına mülkiyet ve bir evin de 1/2'şer mülkiyet hisselerini vermek suretiyle paylar oluşturamaz. İki oğul, bu paylaşıma razı olduklarını belirtseler bile, eş rıza göstermedikçe öyle bir paylaşma yapılamayacaktır. Hakimin, her bir mirasçıya birer ev verdikten sonra, dördüncü evi sattırarak bedelini oğullara ayrılan iki paya ayrı ayrı eklemesi gerekecektir. Şu kadar ki, paylı mülkiyet kurulacak tereke malı, kendi payına düşmeyecek olan mirasçının bu tarz paylaşmaya itirazının hakkın kötüye kullanılması sayılarak bertaraf edilmesi düşünülebilir.

2025 Özel bir durum olarak Kat Mülkiyeti Kanununun 10.maddesine göre, bir taşınmazdaki ortaklığın giderilmesi davalarında, mirasçılardan biri talep ettiği takdirde, hakimin kat mülkiyeti kurması ve bağımsız bölümlerin mi-

---

[1234] Bkz., yukarıda § 37, III,2.
[1235] Bkz., § 38, III,3.
[1236] Bkz., § 38, III,5.
[1237] Eşitlik ilkesine göre asıl olanın bu paylaşma olduğu hakkında bkz., § 37, III,3.

ras paylarına eklenmesi suretiyle paylaştırıma yapması öngörülmüştür. Bu özel hüküm sayesinde, hakim kararıyla kat mülkiyetine geçen bir taşınmazda ortak yerler üzerinide mirasçılar paylı mülkiyet hükümlerine tabi olacaklardır. Ancak, belirtelim ki, hakimin böyle bir paylaştırma yapabilmesi için, ortada kat mülkiyetine dönüştürülmeye elverişli bir taşınmaz bulunması gerektiği gibi[1238], her bir mirasçıya en az bir bağımsız bölüm düşmesi ve hiç bir mirasçının, diğeriyle bağımsız bölüm üzerinde paydaş olmaması gerekir. Hakim payları oluştururken, her bir mirasçıya bir ya da bir kaç bağımsız bölüm üzerinde tek başına mülkiyet ayırmasından doğacak dengesizlikleri terekedeki diğer mal ve hakları ona göre dağıtarak dengeleyecektir.

Hakim payları tamamen tereke mevcuduna göre oluşturmakla yükümlü 2026
olup, tüm mirasçılar anlaşmadıkça, bir mirasçıya şahsi malvarlığından terekeye para ödemesi (ya da bir malını vermesi) karşılığında, payının izin verdiğinden daha değerli bir şey ayıramaz[1239]. Örneğin Mirasbırakanın geride mirasçısı olarak iki oğlu kalmış olup, terekesinde 300 bin liralık bir otomobil ile 500 bin liralık bir ev varsa; hakim, otomobili bir paya evi de diğer paya ayırıp, evin gideceği mirasçının diğer mirasçıya 100 bin lira denkleştirme bedeli ödemesini öngöremez. Ancak bir mirasçı, kendi tereke malının denkleştirme bedelini ödemek istediğinde, gene diğer mirasçılarının rızasının gerekip gerekmeyeceği tartışmalıdır[1240]. Örneğin, iki kardeşe miras kalan tereke 500 bin lira değerinde bir evden ibaretse; kardeşlerden birinin , evin olduğu gibi bir pay sayılarak kendisine verilmesi karşılığında 250 bin lira ödeyeceğini ve bu paranın diğer kardeşin payı olmasını hakime önererek, evin satışını önlemek istemesi hâlinde durum böyledir. Kanımızca, kural olarak tüm mirasçılar anlaşmadıkça, bir mirasaçı diğerlerini böyle bir paylaşmaya zorlayamamalıdır, meğer ki böyle bir denkleştirme önerisine itiraz somut olayda açıkca hakkın kötüye kullanılması sayılsın.

Terekedeki mallar ve haklar gibi, borçlar da paylar oluşturulurken he- 2027
saba katılabilir. Fakat bu şart değildir. Her halükârda, dış ilişkide alacaklılara karşı mirasaçılar MK 681'e göre, paylaşmadan sonra da bu maddede belirtilen süre boyunca borçlardan müteselsil sorumulu olacaklar, borçların paylaşımı ancak MK 682'deki rücu hakkı kullanılırken önem taşıyacaktır. Şayet borçlar paylaşılmamışsa, iç ilişkide sorumluluk her bir borç için miras payı oranında olacaktır.

[1238] Hakim, mirasçılara taşınmazda kat mülkiyetine tabi olmak üzere bir inşaat yapma ya da yarım kalmış bir inşaatı tamamlama yükümü yükleyemez. Kat mülkiyeti tahisi hakkında örnekler için bkz., aşağıda 3,d.

[1239] *İmre/Erman*, 426; *Kocayusufpaşaoğlu*, 711.

[1240] Bu tartışma için bkz., *Oğuzman*, 333, dn. 343; *Escher*, Art. 611 N 5; *Tuor/Picenoni*, Art. 611 N 11.

2. Miras paylarının özgülenmesi (tahsisi)

2028 Paylaşmada son aşama oluşturulan payların mirasçılara özgülenmesi, bir diğer deyişle, hangi mal ve hak grubunun hangi mirasçıya gideceğinin belirlenmesidir.

2029 Bazen, paylar oluşurken bunların hangi mirasçılara özgüleneceği de belli olur. Daha önce de değindiğimiz üzere, örneğin sadece bir mirasçının 1/4 paya sahip olduğu bir terekede, 1/4 karşılığı oluşturulan kısmın bu mirasçıya gideceği bellidir. Keza, MK 650/II uyarınca, mirasçıların özellikleri göz önüne alınarak oluşturulan bazı payların da kime özgüleneceği daha o aşamada belirlenmiş olabilir.

2030 Şayet özgüleme aşamasına gelinmiş olup da oluşturulan somut payların hangi mirasçılara gideceği belirsizse, MK 650/II, c.1, mirasçıların anlaşmasının asıl olduğunu belirtmektedir. Şu halde hakim, mirasçıların tümünün ittifak ettiği şekilde payları özgüleyecektir. Bu anlaşmanın, paylaşma sözleşmesi gibi yazılı şekiyde yapılması zorunlu olmayıp, paylaşma davasında hakimin yönelteceği soruya karşı tümünün aynı şekilde özgüleme yapılmasına dair beyanda bulunmaları ve bunun mahkemece saptanması yeterlidir.

2031 Kanunda, mirasçıların anlaşamaması hâlinde kura çekileceğinden söz edilmiş olmasına rağmen, şayet mirasbırakan ölüme bağlı tasarrufla özgülemenin nasıl yapılacağını düzenlemişse,önce buna uyulması gerektiği kabul edilmektedir[1241]. Örneğin, mirasbırakan, vasiyetnamesinde, kitaplarının iki çocuğundan küçük olana verilmesini istemişse, paylar oluşturulurken kitaplar hangi gruba düşmüşse, bu grup pay küçük çocuğa özgülenecektir.

2032 Mirasbırakanın payların özgülenmesini belirtmesini, payların oluşumunu belirtmesiyle karıştırmamaladır. Örneğin, verdiğimiz örnek mirasbırakanın özgülemeyi belirtmesiyken, kitaplarının otomobili ile birlikte bir pay ve evinin ayrı bir pay olarak kabul edilmesini öngörmesi, bunların kime gideceğini göstermediğinden, sadece payların oluşturulmasının düzenlenmesidir.

2033 Şayet mirasbırakaının da bir özgüleme belirlemesi yoksa, MK 650/III uyarınca özgüleme kura çekilmesi suretiyle yapılacaktır. Hakimin, kural olarak, payları kendisinin uygun gördüğü mirasçıya özgüleme yetkisi yoktur. Bunun istisnaları, yukarıda da değinildiği üzere, esasen bazı payların sadece belirli mirasçıya uygun olacak şekilde oluşturulması ile, aşağıda ele alacağımız üzere, amacı itibariyle bir bütün oluşturan eşyanın (MK 653/I) ve tarımsal işletmelerin (MK 659, 660) özgülenmesidir. Bu istisnalar dışında hakim Velayet Vesayet ve Miras Tüzüğü'nün 65. maddesine göre, anla-

---

[1241] *İmre/Erman*, 424.

şamayan mirasçıları kura çekmeye davet edecek ve kendi nezaretinde kura çekimini yaptırıp, sonucu bir tutanakla tespit edecektir. Kuranın koşulu, tüm mirasçıların davet edilmesi olup, belirtilen günde hepsi gelmese de kura çekilecektir. Aksi halde, davet üzerine mirasçıların tümünün gelmesi aransaydı, bazı mirasçılar gelmemek suretiyle özgülenmenin tamamlanmasını sürekli şekilde engelleyebilirlerdi.

Paylaşma davasının yenilik doğuran bir dava sayılmasının doğal sonucu, bu dava sonunda verilen kararın yenilik doğuran bir karar olması ve bu kararla özgüleme tamamlandığı anda, ayrıca tasarruf işlemine gerek kalmadan, her bir mirasçının kendisine özgülenen paydaki mallara ve haklara tek başına sahip olmasıdır[1242]. Yani, özgüleme kararıyla, mirasçılar, kendilerine verilen tereke unsurlarını, birbirlerinden isteme hususunda birer alacak hakkı değil; doğrudan bunlar üzerinde hak kazanırlar. Böylece, bir mirasçı kendisine tahsis edilen taşınırın mülkiyetini teslimsiz, taşınmazın mülkiyetini tesisiz ve alacak hakkını da alacağın temliki işlemi yapılmadan kazanır. Miras ortaklığı ve elbirliğiyle mülkiyet ilişkisi, karar anında sona ermiştir. Bu tarihten, sonra her hak sahibi kendisine özgülenen şeylere vermekten kaçınan kişelere karşı (bunlar diğer mirasçılar da olabilir) tek başına, taşınırlar için istihkak (MK 683), taşınmazlar için yolsuz tescilin düzeltilmesi (tapu kütüğünün tashihi) (MK 1025), davası açacak, alacaklara ise doğrudan sahip olarak, bunların borçlularından ifa isteyebilecektir. 2034

Ancak, davalar açılıncaya kadar, iyiniyetli kişilerin MK 988 ve MK 1023'e göre mülkiyet hakkını kazanma imkânlarının olduğu da unutulmamalıdır. 2035

Hatırlatalım ki, mahkeme (paylaşma davası) dışı bir paylaşma anlaşmasının yapılması, MK 678/III uyarınca yazılı şekle tabidir ve paylaşılan şeyler üzerinde mirasçılara doğrudan hak (örneğin taşınır ve taşınmazlarda mülkiyet hakkı) kazandırmayıp, her birinin niteliğine göre gerekli tasarruf işlemlerinin (teslim, tescil ya da temlik) yapılmasını isteme hususunda alacak hakları kazandırır. 2036

3. Paylaşmada bazı özel durumlar

a) Değerinde önemli azalma olmaksızın bölünemeyen mal

MK 651, *"Değerinde önemli azalma olmadan bölünemeyen tereke malı, bütün olarak mirasçılardan birine özgülenir.* 2037

Mirasçılar bir tereke malının bölünmesi ya da özgülenmesi konusunda anlaşamazlarsa, o mal satılır ve bedeli bölüştürülür. 2038

[1242] *Aral*, 59; *Kocayusufpaşaoğlu*, 688, 699; *Oğuzman*, 321; *İmre/Erman*, 402.

2039 *Mirasçılardan biri istemde bulunursa satış artırma yoluyla yapılır. Mirasçılar artırmanın şekli konusunda anlaşamazlarsa, sulh hakimi artırmanın mirasçılar arasında veya herkese açık yapılmasına karar verir"*, demektedir. Maddeyi yazıldığı şekliyle ele alırsak, yanlış sonuçlar doğabilir[1243].

2040 Bir kere ikinci fıkradaki, *"mirasçılar bir tereke malının bölünmesi veya özgülenmesi üzerinde anlaşama"* hâlinde satılacağına dair hükmün, sadece birinci fıkradaki değeri önemeli ölçüde *azalmaksızın* bölünemeyen malları ifade ettiği kabul edilmelidir. Aksi takdirde, bir payın içinde rahatça yer bulacak malların bile, bazı mirasçıların itirazıyla satılması gibi, garip ve kanuna aykırı bir sonuç çıkar.

2041 İkinci olarak, değerinde azalma olmaksızın bölünemeyen mal sadece bu niteliği sebebiyle değil, terekede paylar oluşturulurken hiç bir payın kapsamayacağı kadar değerli olması hâlinde de bu madde kapsamına girecek, yani tüm mirasçılar başka bir çözümde anlaşmadıkça satılacaktır. Örneğin mirasbırakanın iki çocuğu arasında eşit şekilde paylaştırılacak olan terekenin toplam değeri 1 milyon lira olup, tereke malları arasında yer alan evin değeri 600 bin Lira ise, durum böyledir.

2042 Değeri yüzünden tek başına dahi bir paya fazla geldiği için bu hükmün kapsamına giran mal, esasen hiç bölünemeyecek nitelikte olabileceği gibi; bölünmesi madden ve hukuken mümkün olmakla birlikte, bölünmesi hâlinde değerin önemli derecede azalacak bir mal da olabilir. Örneğin, ev, heykel, tek taşlı bir yüzük birinciye; parselasyonu mümkün, fakat değeri düşürülebilecek bir arsa, kesilerek iki parça haline getirilmesi mümkün değerli bir resim, üzerindeki mücevherlerin sökülebildiği bir kolye, ikinciye örneketir. Birinci tip malların, mirasçıların bazıları yasal paylarında fedakârlık etmedikçe veya denkleştirme bedeli ödemedikçe, bölünmeyip satılacağı esasen kesindir. Fakat ikinci tip malların madden bölünmeleri imkânı bulunduğundan, bu bölünmeden doğacak değer kaybının MK 651 çerçevesine girecek kadar büyük olup olmadığını hakim saptayacaktır. Değer kaybının büyük olması demek, bu malların paylara göre bölünmesi (örneğin taşınmazın ikiye bölünmesi) hâlinde, her iki kısmın taşıyacağı piyasa değerlerinin toplamının bütün olarak taşıdığı piyasa değerinden farkının, aynen paylaşma uğruna gözden çıkarılamayacak (feda edilemeyecek) bir miktar tutmasıdır. Örneğin, arsa imar durumu bakımından ancak bir bütün olarak üzerinde bir alış veriş merkezi yapmaya uygun olup, ikiye bölünmesi hâlinde her bir parselin bu imkânı olmadığından, her parçanın bağımsız pi-

[1243] Bu hususlara dikkat çeken, *Kocayusufpaşaoğlu*, 713, 714.

yasa değeri toplamı tek parça olmaları hâlindeki değerden çok düşük olabilir.

Değerinde önemli azalma olmaksızın bölünemeyen eşyanın bir paya yerleştirilmesi de mümkün değilse, hakim satışa karar verecektir. Hakim satışa karar verdikten sonra mirasçılardan biri açık artırmayı isterse, satış açık artırmayla yapılacaktır (MK 651/III, c. 1). Bu halde hakim, artık başka türlü bir satışa, örneğin pazarlık usulüne, karar veremez[1244]. Mirasçılar, açık artırmanın türü hususunda anlaşamazlarsa, o zaman hakim, bunun sırf mirasçılar arasında mı yoksa herkese açık olarak mı yapılacağına karar verir (MK 651/III. c 2). Buna karşılık, mirasçıların hiç birinden satışın açık artırma ile yapılmasına yönelik bir talep gelmezse, hakim, satışın pazarlık usulüyle mi yoksa açık artırmayla mı yapılacağına serbestçe karar verir. Açık artırmaya karar vermesi hâlinde de yine artırmanın türünü seçmekte hakim serbesttir. 2043

b) Bir bütün oluşturan eşya topluluğu ve aile belgeleri ile özel anı değeri olan eşya

MK 653/I, mirasçılardan birinin bile karşı çıkması hâlinde aslen ya da amacı bakımından bir bütün oluşturan eşya grubunun paylaştırılmayacağını; MK 653/II, aile belgeleri ve özel anı değeri olan eşyanın da mirasçılar dan birinin karşı çıkması hâlinde satılamayacağını belirtmiştir. 2. fıkranın ikinci cümlesi ise her iki halde de hakimin ne yapacağını birlikte düzenlemektedir. Oysa bunlar farklı nitelikte oldukları için ayrı ayrı ele alınması isabetli olur. 2044

aa) Bir bütün oluşturan eşya

MK 653/I hakmü ile kastedilen, fiziksel olarak ayrı ayrı mallar olmakla birlikte, nitelik ya da kullanım amacı bakımından bütünlük oluşturan eşyadır. Bir çok ciltten oluşmuş bir ansiklopedi, sofra takımı, koltuk takımı, pul kolleksiyonu buna örnektir. Üstelik, bunların paylaşmada birbirinden ayrılmaması için, MK 651/I'deki gibi birbirlerinden ayrılmalarının değerlerini azaltması da gerekmez, nitelikleri ve kullanım amaçları göz önünde bulundurulur. 2045

Gerçi işin niteliği gereği, çoğu kez, bu tür mal gruplarının dağıtılması hâlinde ayrı ayrı değerlerinin toplamı, birlikte değerlerinden çok daha düşük olacaktır. 2046

[1244] Bkz., Gerekçe, 520. Hakimin, mirasçılardan birinin açık artırma isteği ile bağlı olduğu MK 651'in karşılığı olan ZGB Art 612/III'de daha açık olarak ifade edilmiştir.

2047 MK 653/I uyarınca, hakim, tüm mirasçılar razı olmadıkça, bu tür mal topluluklarını bölerek paylaştıramaz. Örneğin, payları oluştururken, biri dahi itiraz etse, terekedeki 76 parçalı porselen yemek takımını, mirasbırakanın geride kalan dört çocuğuna her birine 19 parça vererek dağıtamayacaktır.

2048 MK 653/II c. 2, mirasçılar anlaşamazlarsa, hakimin bu eşya grubunu sattırmaya ya da yerel adetlere ve yerel adetler yoksa mirasçıların kişisel durum ve özelliklerine göre, paylarından mahsup edilmek üzere, birine özgülemeye yetkili olduğunu belirtmektedir. Belirtmek gerekir ki, MK 653/II, c. 2, *payına mahsup edilmek ve edilmemek* üzere mirasçılardan birine özgüleneceğini öngörmektedir. Ancak, hakimin, bir bütün oluşturan eşyayı, mirasçılardan birine payına mahsup edilmeden özgülemesi, maddi değeri değil de sırf manevi değeri olan tereke malı (yani aile belgesi ya da özel anı değeri olan ve maddi değeri çok yüksek olmayan tereke malı) için geçerlidir[1245]. Buna göre, hakim, bir oturma odası takımını, mirasçılardan birine miras payına mahsuben olmaksızın özgüleyemez. Aksi halde, özgülenen mirasçı hem koltuk takımını alacak hem de, sanki terekeden kendisine başka bir şey verilmemiş gibi, miras payının tamamını alacaktır. Bu ise, onun, terekeden diğer mirasçılar aleyhine payından fazlasını alması anlamına gelir ki, bu da kabul edilecek bir durum değildir.

2049 İsviçre doktrininde çok eleştirilen ve ancak yukarıda açıklandığı gibi uygulanması gerektiği belirtilen bu hükmün neden dolayı yeni Medeni kanuna alındığını anlamak mümkün değildir.

2050 Bu hükmün, bir bütün oluşturan eşyanın bir miras payına sığması hâlinde dahi, mirasçılar, bu payın kime verileceğinde anlaşamazlar ise, hakime bu eşyayı sattırma yetkisi verdiği kabul edilmektedir. Bu düzenleme, *mümkün oldukça aynen paylaştırma* ilkesine bir istisnadır. Şayet, MK 653/II c.2 hükmü, aynen paylaştırma ilkesine uyularak, bir bütün oluşturan eşyanın, ancak hiç bir paya tek başına sığmayacak kadar değerli olması hâlinde hakim tarafından sattırılabileceği şeklinde anlaşılırsa; cümlede, hakime satış yerine, bu eşyayı bir miras payına mahsuben bir mirasçıya özgülemesi yetkisi de tanınması açıklanamaz. Daha doğrusu, cümlede geçen *mahsup* sözüne uymamakla birlikte, olsa olsa, hakimin bir mirasçıya payından daha fazla değere sahip bir tereke malı verebileceği ve bu fazlalığın, o mirasçı tarafından ödeneceği şeklinde bir açıklama getirilebilir ki; bu kez de *tüm mirasçılar anlaşmadıkça hiç bir mirasçıya payından fazla mal tahsis edilememesi* kuralı çiğnenmiş olur. Şu halde, kanunun sistemine en uygun çözüm, MK 653 hükmü ile hakime, istisnaen özel nitelikte bazı malla-

[1245] *Tuor/Picenoni*, Art. 613, N 15.

rın bir pay içinde kendine rahatça yer bulmasına rağmen, satılıp bedelinin paylaşılmasına karar verme yetkisi tanındığıdır.

Gerçi bu haliyle hüküm, herhangi bir tekil tereke malının MK 650 uya- 2051
rınca bir paya konulup kura yoluyla özgülenmesine itiraz edemeyen mirasçıların, amaç itibariyle bir bütün oluşturan malların bir paya konulup kura yoluyla özgülenmesine itiraz etmelerine imkân vermesi bakımından eleştirilebilir.

Hakim yerel adete ve böyle bir adet yoksa mirasçıların durum ve kişisel 2052
özelliklerine göre bu mal grubunu bir mirasçıya özgüleyecektir. Örneğin porselen yemek takımını mirasçılar arasında yer alan tek kız çocuğuna ya da değerli ansiklopediyi mirasçılar arasında yer alan tek yüksek eğitim görmüş çocuğa özgüleyebilir. Mirasçılardan bazısının, hatta çoğunun buna itiraz etmesine rağmen, hakimin bu özgülemeye yetkisi vardır. Şayet hakim yerel adete veya mirasçıların kişisel özelliklerine göre mirasçılar arasında tercih edilebilecek hiç kimse göremiyorsa ve eşyaların bir paya konulmasına itiraz eden mirasçı varsa, sattırarak bedelini paylaştıracaktır. MK 653/II c.2 metni MK 650/III hükmünden farklı olarak, böyle bir durumda hakime eşya grubunu kura yoluyla özgüleme yetkisi vermemiş görünmektedir[1246].

bb) Aile belgeleri ve aile için özel anı değeri olan eşya

MK 653/II, c.1 uyarınca, mirasçılardan birinin karşı çıkması hâlinde ai- 2053
le belgeleri ve özel anı değeri olan eşya satılmaz. Aile begeleri ve anı eşyası, mirasçılar bakımından niteliği gereği taşıdığı manevi değerinin piyasadaki satış değerinden önce geldiği eşyadır. Ölene ya da ailenin daha önce ölmüş bireylarine ait aile fotorafları, mektuplar, diplomalar, madalyalar[1247], elbiseler, hatıra defterleri ve diğer kişisel eşya bu sınıfa girer. Bir eşyanın bu nitelikte sayılması için, tüm mirasçılar açısından aile belgesi ya da özel anı değeri olan eşya sayılması gerekmez. Örneğin, mirasbırakanın eski eşinden kalan ve sakladığı ölümünden sonra anlaşılan bazı resimler, mirasçıar arasında yer alan yeni eşi açısından aile belgesi ve anı değeri olan eşya sayılmasa bile, ilk eşinden olan çocukları gözönüne alınarak, bu hükme tabi olacaktır. Buna karşılık, objektif niteliği gereği aile belgesi ve anı eşyası sayılması mutad olmayan tereke mallarının, bazı mirasçıların özel duyarlığı bakımından böyle sayılması kabul edilemez. Örneğin, bir mirasçı, babası-

[1246] *Tuor/Picenoni* (Art. 613 N 10) mirasçıların bölünmeyi istemeleri ancak böründükten sonra paylaşmanın nasıl yapılacağı, yani hangi bölümün hangi mirasçıya verilmesi üzerinde anlaşamamaları halinde, hakimin kuraya gidebileceği görüşündedirler.

[1247] MK 653/III hükmü gereği madalyaların durumu kendi özel kanunlarına göre belirlenecektir. Bunun üzerinde aşağıda durulacaktır.

nın ölmeden önce kullandığı koltuk takımının ya da otomobilin anı eşyası hükümlerine tabi olması gerektiğini ileri süremez.

2054 İstisnaen aile belgeleri ve anı eşyasının yüksek piyasa değerine sahip olması da onu bu nitelikten çıkarmaz. Örneğin, çok köklü bir ailenin üyelerinden birinin ölümü üzerine terekesinde yer alan atalarından birinin ünlü bir ressam tarafından yapılmış portresi; ünlü bir sanatçı ya da politikacının ölümü ile ortaya çıkan hatıra defteri böyledir. Ancak, bu tür piyasa değeri yüksek olan anı eşyasının hiç bir miras payına sığmama ihtimali yüksektir ve böyle bir durumda tüm mirasçılar başka çözümde anlaşamazlarsa satılması gerekecektir.

2055 MK 653/II, c.1, aile belgeleri ve anı oluşturan eşya satılamaz dedikten sonra, yukarıda açıkladığımız bir bütün oluşturan eşyalar yanında, aile belgeleri ve anı eşyalarını da kapsıyor görünen MK 653/II, c. 2, mirasçılar arasında anlaşmazlık çıkarsa, sulh hakiminin bu gibi eşyanın satılmasına ya da yerel adetlere ve adet mevcut değilse mirasçıların kişisel durum ve özelliklerine bakarak bunlardan birine tahsisine karar verilebileceğini belirtmektedir. Bu aslında çelişik bir ifadedir. Fıkranın, aile belgeleri ve anı eşyalarının satılamayacağını belirten birinci cümlesini izleyen hemen ikinci cümlesinde, hakimin bu duruma göre bu eşyayı sattırmaya da yetkili olduğu belirtilmektedir. *Fikrimizce*, bu hüküm, hakimin paylaşma sırasında kesin bir zorunluluk olmadıkça, bu eşyayı satamayacağı şeklinde anlaşılmalıdır. Hakim, aile belgeleri ve anı eşya, değeri itibariyle bir paya sığdığı takdirde, mutlak surette mirasçılardan birine özgülemeli, yerel adet veya sahip oldukları özellik bakımından mirasçılar arasında bir seçim yapamadığını belirterek sattırma yetkisi olmamalıdır, meğer ki tüm mirasçılar kabul etmiş olsunlar. Buna karşılık aile belgeleri ve anı eşya, tek başına dahi pay sayılamayacak kadar değerliyse (ki yukarıda belirttiğimiz gibi nadiren gerçekleşecek bir durumdur), hakim tüm mirasçılar başka bir çözümde anlaşamadıkça satışa karar verecektir. Bu şıkta öğretide dahi belirtildiği üzere, hakimin sadece mirasçılar arasında şatışa karar vermesi mümkün, hatta gerekli sayılabilir, çünkü asıl olan bu tür şeylerin aile içinde kalmasıdır.

2056 Bazı yazarlar[1248], hakimin, ya mirasçılar arasında satışa ya da bir mirasçıya özgülemeye karar vermeye mecbur tutulabileceğinden söz etmektedirler. Oysa hakime açık arttırmayla karar verme hususunda hiç imkân bırakılmazsa, bu bazı kötü kullanmalara yol açabilir. Örneğin istisnaen piyasa değeri çok yüksek olan aile belgesini (basının çok yüksek bedeller önerdiği hatıra defterini) mirasçılar arasında yapılacak bir satışta ucuza kapatacak

[1248] *Tuor/Picenoni*, Art. 613 N 22; *Kocayusufpaşaoğlu*, 716.

olan varlıklı mirasçının, ardından bunu kendi malı olarak satışa çıkaracağının belli olması hâlinde, hakimin eli kolu bağlanmış olacaktır.

MK 653/III'e göre, *"Özel kanun hükümleri saklıdır"*. Buna göre, aile 2057
belgeleri özellikle de özel anı değeri olan eşyanın nasıl ve kime özgüleneceği bir özel kanunla düzenlenmişse, hakim özgülemeyi buna göre yapacaktır.

Örneğin T.C. Devleti tarafından verilen madalyaların intikalini düzen- 2058
leyen kanunlar vardır. Bunlardan 66 sayılı İstiklâl Madalyası Kanununun ek ikinci maddesi hükümlerine göre, İstiklâl Madalyası sahibi öldüğünde, madalya, bu ölüm anında sağ ve (kanunda belirtilmemişse de) mirasçı sıfatına sahip olmaları şartıyla, ölenin büyük oğluna, yoksa büyük kızına, yoksa babasına, yoksa eşine verilecektir. Bunların ölümünde de aynı sıraya uyulacaktır. Şayet bir madalya sahibinin ölümünde, bu sırada belirtilen mirasçılardan kimse yoksa, madalya diğer kanuni mirasçılara intikal edecektir. 2933 sayılı Madalya ve Nişanlar Kanununun 5. maddesi aynı intikal kurallarını ve sırasını daha düzgün bir ifadeyle ve önceliğin mirasbırakanın vasiyetine verileceğini de belirterek, T.C Devletinin, bu Kanunda tek tek sayılan tüm madalya ve nişanları için getirmiştir. Bu maddeye göre de, şayet sırasıyla belirtilen kişilerden bir mirasçı yoksa, Medeni Kanunun diğer mirasçılara ilişkin hükümlerine göre madalya ve nişan intikal edecektir. Bu düzenlemeler sonucu: madalya ve nişanlar bakımından hakimin MK 653/II c.2'ye göre özgüleyeceği mirasçıyı takdir yetkisi, sadece özel madalya ve nişanlar ve (2933 sayılı Kanunun 8.maddesine göre, Başbakanlık Personel Müdürlüğünce tescil edilenler hariç) yabanca devlet madalya ve nişanları ile;başta İstiklâl Madalyası olmak üzere, T.C. Devletinin madalya ve nişanlarının intikalinde ilgili kanunlarda sayılan yakın mirasçı olmaması ve sonrakii sırada gelen yakınların (kardeş, amca, hala, dayı, teyze, yeğen, kuzen) her zümrede aynı düzeyde birden fazla kişi olması hallerinde uygulama alanı bulacaktır. Belirtelim ki, böyle bir durumda hakim takdir yetkisini kullanırken 66 ve 2933 sayılı kanunlarda getirilen sıradan örneksemeyle yararlanacaktır (örneğin, ölenin erkek kardeşini, kız kardeşine tercih ederek, birden çok erkek kardeşten yaşı büyük olanı tercih ederek, yeğenler, kuzenler vb. bakımından da aynı ölçütleri uygulayarak özgülemede bulunmalıdır).

c) Aile konutu ve ev eşyasının sağ kalan eşe özgülenmesi

aa) Genel olarak

MK 652'ye göre, *"Eşlerden birinin ölümü hâlinde tereke malları ara-* 2059
sında bulunan ev eşyası veya eşlerin birlikte yaşadıkarı konut varsa; sağ

kalan eş bunlar üzerinde kendisine miras hakkına mahsuben mülkiyet hakkı tanınmasını isteyebilir.

2060 *Haklı sebeplerin varlığı hâlinde sağ kalan eş veya mirasbırakanın diğer yasal mirasçılarından birinin istemi üzerine, mülkiyet yerine intifa veya oturma hakkı tanınmasına da karar verilebilir.*

2061 *Mirasbırakanın bir meslek veya sanat icra ettiği ve altsoyundan birinin aynı meslek ve sanatı icra etmesi için gerekli olan bölümlerde, sağ kalan eş bu hakları kullanamaz. Tarımsal taşınmazlara ilişkin miras hukuku hükümleri saklıdır".*

2062 Miras hukuku yönünden eşlerin birlikte yaşadıkları konut ve ev eşyasının sağ kalan eşe özgülenmesini öngören bu hükme paralel olarak, aynı konuda mal varlığı rejimlerinde de eşlerin katılma ya da paylaşma alacağına ya da miras payına mahsup etmeye ilişkin hükümler bulunmaktadır. Gerçekten, edinilmiş mallara katılmada MK 240, *"Sağ kalan eş, eski yaşantısını devam ettirebilmesi için, ölen eşe ait olup da birlikte yaşadıkları konut üzerinde kedisine katılma alacağına mahsup edilmek, yetmez ise bedel eklenmek suretiyle intifa veya oturma hakkı tanınmasını isteyebilir; mal rejimi sözleşmesiyle kabul edilen başka düzenleme saklıdır.*

2063 *Sağ kalan eş, aynı koşullar altında, ev eşyası üzerinde kendisine mülkiyet hakkı tanınmasını isteyebilir.*

2064 *Haklı sebeplerin varlığı hâlinde, sağ kalan eşin veya ölen eşin yasal mirasçılarının istemiyle intifa veya oturma hakkı yerine konut üzerinde mülkiyet hakkı tanınabilir.*

2065 *Sağ kalan eş, mirasbırakanın bir meslek veya sanat icra ettiği ve altsoyundan birinin aynı meslek veya sanatı icra etmesi için gerekli olan bölümlerde bu hakları kulanamaz. Tarımsal taşınmazlara ilişkin miras hukuku hükümleri saklıdır"*, hükmünü içermektedir.

2066 Paylaşmalı mal ayırımında da, MK 255, *"Eşlerden birinin ölümü hâlinde, paylaşma konusu mallar arasında ev eşyası veya eşlerin birlikte yaşadıkları konut varsa; sağ kalan eş bunlar üzerinde kendisine miras ve paylaşmadan doğan hakkına mahsup edilmek ve yetmezse bir bedel eklemek suretiyle mülkiyet hakkı tanınmasını isteyebilir.*

2067 *Haklı sebeplerin varlığı hâlinde sağ kalan eşin veya ölenin yasal mirasçılarından birinin istemi üzerine mülkiyet yerine intifa veya oturma hakkın tanınmasına da karar verilebilir.*

2068 *Sağ kalan eş, mirasbırakanın bir meslek veya sanat icra ettiği ve altsoyundan birinin aynı meslek ve sanatı icra etmesi için gerekli olan bölüm-*

lerde bu hakları kullanamaz. Tarımsal taşınmazlara ilişkin miras hükümleri saklıdır", demektedir. MK 279/ I ve II'de mal ortaklığı için aynı konuda şu hüküm bulunmaktadır: "İşlerin birlikte yaşadıkları konut ve ev eşyası ortaklık mallarına dahil ise, sağ kalan eş, payına mahsuben bunların mülkiyetinin kendisine verilmesini isteyebilir.

Haklı sebeplerin varlığı hâlinde, sağ kalan eş veya ölenin yasal mirasçı- 2069
larının istemiyle bunlar üzerinde mülkiyet yerine intifa veya oturma hakkı tanınabilir.

Mal ayrılığında, katılma payı ya da paylaşma söz konusu olmadığı için, 2070
özel bir düzenleme yoktur. Her ne kadar MK 243, *"İspat, borçlardan sorumluluk ve paylı mülkün özgülenmesi konularında paylaşmalı mal ayrılığı rejimine ilişkin hükümler uygulanır"* denmekteyse de, atıf, maddenin lafzından açık olarak anlaşılacağı gibi, sadece borçlardan sorumluk ve paylı mülkiyetin özgülenmeye ilişkin olduğu için, konumuzu ilgilendirmemektedir.

Bu benzer hükümler karşısında, MK 652'nin uygulama alanının sap- 2071
tanması bakımından, hükümler arasında karşılaştırma yapmakta yarar vardır. Ancak bu saptamayı yapmadan önce önemle açıklanması gereken hususlar şunlardır: sağ kalan eşin, ortak konutun ya da ev eşyasının kendisine özgülenmemesini gerek mal rejimlerine göre gerek miras hukukuna göre isteme hakkının bulunduu hallerde her iki hakkı birden kullanması söz konusu değildir. O,özgülemeyi ya mal rejimlerindeki hükme dayanarak ya da miras hukukuna göre talep edecektir. Birine ilişkin hakkını kullandığı zaman diğeri de sona erecektir.

İkinci belirtilmesi gereken husus, yukarıda tekrarlanan kanun hükümle- 2072
rinin hepsinde *aile konutundan değil de, eşlerin birlikte yaşadıkları konuttan* söz edilmektedir. Buna göre, sağ kalan eşin, mülkiyet ya da intifa veya oturma hakkını isteyebileceği evin aile konunu haline dönüştürülmüş olması gerekli değildir. Önemli olan o konutta ölüm anında eşlerin birlikte oturuyor olmalarıdır.

Şimdi, esas konumuza dönecek olursak: 2073

1. MK 652, mal rejimleri yönünden aralarında bir ayırım yapmaz. Baş- 2074
ka bir deyişle, eşler, mal ayrılığı dahil, hangi mal rejimini seçmiş olurlarsa olsunlar, miras hukuku kuralı olan MK 652'ye dayanarak, ölen eş ile birlikte oturdukları ev ya da ev eşyasının miras paylarına mahsuben kendilerine özgülenmesini isteyebilirler[1249].

[1249] *Kılıçoğlu*, 293.

2075 2. Sağ kalan eşin mal rejimine göre özgülenmeyi isteyebilmesi için o mal rejimine göre paylaşılacak bir bir konutun ya da ev eşyasının bulunması ve sağ kalan eşin de paylaşma ya da katkı payı alabilecek olması gerekir. Örneğin edinilmiş mallara katılma rejiminde, mal rejimi sözleşmesi yapılırken, sağ kalan eşin ortak konut ve ev eşyaları üzerinde bir talep hakkının olmayacağı kararlaştırılmışsa (MK 240/I), o artık MK 240'a göre özgülemeyi isteyemez; fakat MK 652/I'e göre miras payı olarak isteyebilir. Bunun gibi, edinilmiş mallara katılım rejiminde, sağ kalan eş hiç bir mal edinmediği için katılım payı yoksa, MK 240/I'e göre bir talep hakkı olmadığı için ortak konut ve ev eşyasının özgülenmesini ancak MK 652/I'e göre isteyebilecektir[1250]. Bunun aksine, sağ kalan eşin MK 652/I'den yararlanabilmesi için, mirasçılık sıfatına sahip olması gerekir. Eş, örneğin mirası red ya da mirastan feragat gibi bir sebeple mirascı olamıyor, yani mirasın paylaşılmasına katılamıyorsa, ortak konut ve ev eşyasının özgülenmesini, sadece ilgili mal rejimi hükümlerine göre isteyebilecektir[1251].

2076 MK 240/I'de sağ kalan eşin ortak konut üzerinde mal rejimine göre sadece intifa ya da oturma hakkını isteyebileceği belirtilmiştir. *Fikrimizce* eş, isterse edinilmiş mallara katılım hükümlerine göre, konut üzerinde intifa ya da oturma hakkını; isterse MK 652'ye göre mülkiyeti isteyebilmesi gerekir.

2077 MK 652'deki talep kural olarak mülkiyete yöneliktir. Aynı durum, edinilmiş mallara katılımda, ortak konut için öngörülen hüküm hariç, MK 255 ve 279'a göre taleplerde de de söz konusudur. Bu sebeple, ancak mal rejimine göre yapılan tasfiyede, ortak konut ve ev eşyası üzerindeki mülkiyet hakkı kendisine geçmemiş olan sağ kalan eş MK 652'ye göre mülkiyeti isteyebilir. Aynı şekilde mal ayrılığında da, mülkiyetin ölen eşe ait olması gerekir. Örneğin, mal ortaklığı rejiminde, ortak konut ölen eşin şahsi malıysa, ancak o zaman sağ kalan eş, MK 652'ye göre mülkiyeti miras payına mahsuben isteyebilir.

bb) MK 652'nin uygulama alanı

2078 1. Kişisel açıdan hak sahibi *sadece sağ kalan eştir*. Niteliği açısından, eşin bu hakkı kişiye sıkı sıkıya bağlı, ona seçimlik bir rüçhan (öncelik) hakkı veren bir paylaşma kuralıdır[1252]. Kişiye sıkı sıkıya bağlı bir hak olması nedeniyle, sağ kalan eşin miras açıldıktan sonra ölmesi hâlinde onun mirasçılarına miras yoluyla geçmez. Ancak, hak seçimlik olduğu için, sağ kalan eş bu hakkını kullanmak zorunda değildir. Kanunda eşin ne süre içinde bu hakkını kullanacağına ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. *Fikrimiz-*

[1250] *Kılıçoğlu*, 237, 239.
[1251] *Honsell/Vogt/Geiser*, Art. 612a,N 4; *Kılıçoğlu*, 273 vd.
[1252] *Honsell/Vogt/Geiser*, Art. 612a N 9.

ce, eşin bu hakkını, ret süresi dolduktan sonra, fakat paylaşma başlamadan önce, en geç paylaşma sırasında kullanmasında isabet vardır.

İsviçre Hukukunda, eşin bu seçimlik hakkının mirasbırakanın yapacağı 2079
bir ölüme bağlı tasarrufla kaldırılıp kaldırılamayacağı tartışmalıdır. Federal Mahkeme, MK 652 (ZGB Art. 612a/I)'nin bir emredici kural olmadığı, bu sebeple mirasbırakanın yapacağı bir ölüme bağlı tasarrufla sağ kalan eşin elinden alınabileceği görüşündedir[1253].

Federal mahkemeye göre, MK 652'nin karşıtı olan ZGB Art. 612a'nın 2080
sistematik yerinden, yani mirasın paylaşılması içinde mirasın nasıl paylaşılacağını gösteren hükümler arasında olması, bunun bir paylaştırma kuralı olduunu göstermektedir. MK 647/I (ZGB Art. 608), mirasbırakanan ölüme bağlı tasarruf ile, paylaşmanın nasıl yapılacağını düzenleme yetkisi vermiştir. MK 652 (ZGB Art. 612a'nın metninde mirasbırakanın bu yetkisinin sınırlandığına ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. Eğer bir sınırlama getirilmek istenseydi, tarımsal işletmelerin özgülenmesine ilişkin hükümlerde olduğu gibi (MK 662) açık bir sınırlayıcı hüküm konulurdu.

2. Hakkın konusu, mirasbırakanın ölümünden önce birlikte oturulan ko- 2081
nut ve ev eşyasıdır. Bunların neler olduğu, hükmün konulmasının amacına göre saptanması gerekir. Amaç, *"Sağ kalan eşin eski hayatını devam ettirmesidir"* (MK 240/I). Böyle olunca da ortak oturulan konutun, *eşlerin son birlikte oturdukları konut* olarak anlaşılması gerekir. Bu, müstakil bir ev ya da birden fazla bağımsız bölümlü binanın bir dairesi ise, bir problem çıkmaz. Buna karşılık eşlerini ortak konutu, ölen eşin tümüne tek başına sahip olduğu çok daireli, kat mülkiyetine çevrilmemiş bir bina ise, sağ kalan eşin, buranın kat mülkiyetine çevrilip, oturdukarı yerin mülkiyetinin kendisine özgülenmesini isteyebileceğini söylemek, hükmün konuluş amacına aykırı düşer. Bu halde tek çare, MK 652/II'ye göre, haklı bir sebebin varlığını kabul ile, eşin intifa ya da oturuma hakkını istemesi ya da mülkiyeti istemesine rağmen, mirasçılardan birinin istemi üzerine, ona intifa ya da oturma hakkının tanınmasıdır[1254].

Ev eşyasında da aynı ölçüt kullanılacaktır. Böyle olunca da, talep, mül- 2082
kiyeti ölen eşde olup da, eşlerin birlikte kullandıkları, ev işlerinin yürütülebilmesi ya da evin kullanılması için zorunlu olan (örneğin mutfak araç ve gereçleri, möble, televizyon, çamaşır makinesi vb) eşya istemin kapsamına girecektir. Aynı şekilde, evin tefrişine hizmet eden ve çok değerli olmayan, resim, heykel, biblo gibi sanat eserleri de buraya girer. Buna karşılık, lüks

---

[1253] BGE 119 II 323.
[1254] *Honsell/Vogt/Geiser*, Art. 621a N 7.

sayılabilecek şeyler üzerinde sağ kalan eşin özgülemeyi isteme hakkı yoktur[1255].

2083 Amaç, sağ kalan eşin eski hayat seviyesini devam ettirimesi olduğuna göre, ortak konut ve ev eşyasının kendisine özgülenmesini isteyen eşin bunları bizzat kişisel ihtiyaçları için kullanması gerekir. Özellikle evden taşınmış eş yönünden artık şahsi ihtiyaçlar için kullanmadan söz edilemez[1256].

cc) MK 652/I'e göre ortak konut ve ev eşyasının sağ kalan eşe özgülenmesinin şartları

2084 1. Özgüleme için eşin talepte bulunması gerekir. Bu talebin geçerli olması, yukarıda da değinildiği gibi, eşin mirasçı sıfatını, yani terekenin paylaşılmasına katılma hakkını kazanmış olması gerekir. Eş, herhangi bir sebeple mirasçı sıfatını kazanamamışsa, MK 652/I'e göre özgüleme talebinde bulunamaz; ancak şartları varsa (mal ayrılığı hariç), mal rejimlerinin tasfiyesine ilişkin kurallara göre mahsubu isteyebilir.

2085 2. Eşin talebinin ilk safhada konusu ortak konut ve ev eşyasının *mülkiyetinin* kendisine verilmesidir. Bu bakımdan, bunların mülkiyetinin ölen eşe ait olması şarttır. Miras payına mahsup, eşyanın cari (piyasa, Pazar) fiatına göre yapılır[1257].

2086 3. Kural, sağ kalan eşin MK 652/I'e göre ortak konut ve ev eşyaları üzerinde mülkiyet hakkını istemesi ise de, MK 652/II, haklı bir sebebin bulunması hâlinde, eşe mülkiyet hakkı yerine intifa ya da oturma hakkının miras payına mahsuben isteme imkânını tanımıştır. Ancak MK 652/II intifa ya da oturma hakkının tanınmasını istemeyi sadece sağ kalan eşe değil, eşin mülkiyeti talep etmesi hâlinde, diğer mirasçılara da haklı bir sebebin bulunması hâlinde, eşe intifa ya da oturma hakkının miras payına mahsuben verilmesini istemeleri imkânını vermiştir. Gerek eş gerek mirasçılar yönünden haklı sebebe örnek olarak, eşin çok yaşlı olması, miras payının çok düşük olması, mirasbırakan ile diğer mirasçıların kişisel ilişkileri (örneğin o evin nesiller boyunca çocuklara tahsis ediliyor olması) gösterilebilir[1258].

2087 Eşin ya da diğer mirasçıların mülkiyet yerine intifa hakkını isteyebilmeleri, kuşkusuz özellikle ortak konut yönünden söz konusu olacaktır. Ev eşyaları üzerinde oturma hakkının söz konusu olamayacağı kendiliğinden anlaşılır. Bunlar üzerinde intifa hakkını istemek ise, doğrusu biraz anlamsız olur.

[1255] *Honsell/Vogt/Geiser*, Art. 612a N 8.
[1256] *Honsell/Vogt/Geiser*, Art 612a N 11.
[1257] *Honsell/Vogt/Geiser*, Art. 612a N 15.
[1258] *Honsell/Vogt/Geiser*, Art. 612a N 17.

4. MK 652/I ve II'nin eşe tanıdığı bu haklara MK 652/III bir sınırlama 2088
getirmektedir. Bu hükme göre, *"Mirasbırakanın bir meslek veya sanat icra ettiği ve altsoyundan birinin aynı meslek ve sanatı icra etmesi için gerekli olan bölümlerde sağ kalan eş bu haklarını kullanamaz"*. Hükümden anlaşılacağı üzere bu sınırlamadan sadece altsoy mirasçılar yararlanabilecektir. Mirasbırakanın örneğin kardeşi aynı mesleği ya da sanatı devam ettirecek olsa bile, eş yine mülkiyeti, intifayı ya da oturma hakkını isteyebilir.

Hükmün uygulanabilmesinin ilk şartı, altsoyun ya da bunlardan birinin 2089
mirasbırakanın icra ettiği meslek ya da sanatı devam ettirmeleridir. Kanun, altsoy terimini kullandığına göre, alt soy içinde bir sınırlama yoktur. Daha açık bir deyişle, meslek ya da sanatı devam ettirecek altsoyun, mirasbırakanın çocuğu olması şart değiildir. Örneğin, mirasbırakanın meslek ya da sanatını devam ettirecek olan onun torun çocuğu da olsa, mirasçılık sıfatını kazanmış olması şartıyla, sağ kalan eş MK 652/I ve II'nin kendisine tanıdığı imkândan yararlanamaz.

İkinci şart, söz konusu yerin ya da bir bölümünün mesleğin devam etti- 2090
rilebilmesi için gerekli olmasıdır. Gerekli olmanın anlamı, o yerin meslek ya da sanatın devam ettirilebilmesi için şart ya da bunlara başka bir iyerde devam etmenin çok masraflı (o meslek ya da sanatın icrası için gerekli olan makinelerin evin tamamı ya da bir bölümüne sabitlenmiş olmaları ve bunları söküp, başka yere götürüp takmanın, mesleği devam ettiren mirasçı ya da mirasçılar için katlanamayacak derecede masraflı) olmasıdır.

MK 652/III bölümden söz ettiğine göre, eğer meslek ya da sanatın de- 2091
vamı için konutun sadece bir bölümünün gerekli olduğu hallerde, sağ kalan eşin talep hakkı sadece o bölümler yönünden bulunmaz. Başka bir deyiş ile, ortak konutun tamamı meslek ve sanatın icrası için gerekli değilise, sağ kalan eş, diğer bölümler üzerinde mülkiyeti talep edemezse de, oturma hakkını isteyebilir. Bu görüşü, bir binanın bir bölümü üzerinde oturma hakkının kurulmasına imkân veren MK 823/I de destekler.

Nihayet, MK 653/III son cümle tarımsal işletmeleri ilişkin hükümleri 2092
saklı tuttuğuna göre, MK 569 vd.nin uygulanmasının söz konusu olduğu hallerde MK 652 uygulama alanı bulamayacaktır.

d) Mirasbırakanın mirasçılardan birinden olan alacağı

MK 654'e göre, *"Mirasbırakanın bir mirasaçıdaki alacağı, paylaşma* 2093
sırasında o mirasçının payına mahsup edilir". Bununla kastedilen şudur: mirasın açıldığı tarihte, mirasbırakana borçlu bulunan mirasçının bu borcun karşılığı olan alacağı, payların oluşturulması ve özgülenmesi sırasında onun

miras payına konulacaktır[1259]. Böylece diğer mirasçılar, bu alacak hakkı paylarına düşmeyeceği için borçlu mirasçıyı dava ve takip etmek zorunda kalmaksızın haklarını almış olacaklardır. Zira, payları ona göre oluşturulacaktır. Borçlu mirasçının payı ise, sanki mirasbırakanın alacak hakkı kadar olan bir değer ona verilmiş gibi oluşturulacak, fakat bu alacağın esas borçlusu kendisi olduğundan, BK 135 uyarınca alacaklı ve borçlu sıfatlarının aynı kişide birleşmesi sebebiyle, bu alacak ve borç sona erecektir.Örneğin, mirasbırakanın terekesinde 100 bin liralık hisse senedi, 100 bin liralık otomobil ve 100 bin lira alacak hakkı bulunup, bu alacağın borçlusu üç oğlundan birisi ise; çocuklarından birine hisse senetleri ve diğerine ev verilirken, borçlu çocuğa borcunun karşılığı olan alacak hakkı verilecektir. Bu paylaşma sonucunda, payı kendisine tahsis edilir edilmez, borçlu çocuk, 100 bin liralık alacağı kaybedecekse de, 100 bin liralık borcu da sona ermiş olacaktır.

2094 Ancak, mirasçıların tümünün anlaşmasıyla farklı bir paylaşma yapmaları, örneğin, alacak hakkının başka bir mirasçıya özgülenmesine karşılık, borçlu mirasçıya başka bir tereke malını vermeleri de mümkündür.

2095 Ayrıca, borçlu mirasçının, paylaşmanın yapılmasından önce mirasbırakana olan borcunu terekeye ödeyerek sona erdirmesi ve böyle bir borç/alacak silinmiş olarak terekenin paylaşılmasını temin etmesi de mümkündür[1260]. Yukarıdaki örnekteki borçlu çocuk henüz paylaşma yapılmadan terekeye 100 bin lira ödeyerek, hisse senetleri ve otomobilin paylaşılmasına eşit olarak katılabilecektir.

2096 Şayet diğer mirasçılar, onu hisse seneteri ve otomobilin paylaşılmasına sokmamak için ödeme teklifini kabul etmezlerse, borçlu çocuk, paylaşmanın tamamlanmasından önce alacaklı temerrüdü hükümlerine göre (BK 91, 92) borcunu tevdi ederek sona erdirip, yine paylaşmaya katılabilir.

e) Kat mülkiyetine çevirme yoluyla paylaşma

2097 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 10. maddesinin son fıkrası, mirasçılardan biri talep ettiği takdirde, bir taşınmazdaki ortaklığın giderilmesi davalarında hakimin kat mülkiyeti kurulması ve mirasçılara bağımsız bölümler tahsisi suretiyle paylaşma yapabileceğini düzenlemiştir. Bu hüküm, paylaşmanın mirasçıları paylı mülkiyet ilişkisi içine sokmaksızın yapılması kuralının istisnasıdır. Zira, kat mülkiyeti kurulup, mirasçılara bağımsız bölümler özgülenince, ortak yerlerde mirasçıların paylı mülkiyet ilişkisine girmelerine yol açılmış olacaktır.

[1259] *Tuor/Picenoni*, Art. 614 N 6; *Kocayusufpaşaoğlu*, 720; *Oğuzman*, 335.
[1260] *Escher*, Art. 614 N 15; *Tuor/Picenoni*, Art. 614 N 5; *Kocayusufpaşaoğlu*, 720.

Bununla birlikte, kat mülkiyeti kurularak bağımsız bölüm paylaşılması, 2098
tereke malının paylaşma sırasında tüm mirasçılar bakımından en kârlı şekilde değerlendirilmesini sağlayacaktır. Özellikle 634 sayılı KMK'nda 13.4.1983 tarih ve 2814 sayılı Kanunla yapılan değişiklikler sayesinde, aynı taşınmazdaki birbirinden ayrı birden çok bina da kat mülkiyetine tabi alacağından; mirasçıların aynı arsa üzerindeki birden çok evi de bu şekilde paylaşmaları imkânı doğmuştur.

Böyle bir paylaşma, ancak kat mülkiyetine dönüştürülmeye elverişli bir 2099
taşınmaz için söz konusu olabilir. Belirtelim ki, bu hükme dayanılarak, kat irtifakı tesis etilemeyeceği gibi; aynı anlama gelmek üzere, mirasçılara kat mülkiyetine tabi olacak binayı inşa ettirme veya yarım kalmış bir inşaatı tamamlama yükümü getiremez. Hakim sadece, esasen inşası tamamlanmış ve kat mülkiyetine çevrilmesi için gerekli belgelerin hazırlanarak müracaatların yapılması gibi biçimsel işlemler kalmış bir binanın bu şekilde paylaşılmasına karar verebilir.

KMK 10/IV uyarınca, hakimin kararı tapu memurunca düzenlemesi ge- 2100
reken resmi senedin yerine geçtiği gibi; aynı maddenin 5. fıkrasında belirtildiği üzere, kat mülkiyetine dönüşüm için 12. maddede belirtilen tüm belgelerin hazırlanmasını da sağlayacaktır.

Hakimin kat mülkiyetine dönüştürme yoluyla paylaştırmaya karar vere- 2101
bilmesi için, her mirasçıya en az bir bağımsız bölüm düşecek şekilde ve mirasçıların hiç bir bağımsız bölüm üzerinde paylı mülkiyet hükümlerine göre malik olamayacakları şekilde, payların oluşturulması ve özgülenmesi gereklidir. Bunu sağlamak için paylarda gerekli denkleştirme, diğer tereke mallarıyla yapılacaktır. Bu şartlar KMK 10/V'deki ifadelerden anlaşılmaktadır. Böylece, mirasçının payı bu taşınmazdaki tek bağımsız bölüm bile almasına yetmiyorsa, bu yolla paylaştırma yapılamaz. Örneğin, sekiz bağımsız bölüm kurulacak bir taşınmazda, bir mirasçının payı 1/10 ise; terekede mevcut para, otomobil vb. malları ile onun payını oluşturmak ve diğer mirasçılara bağımsız bölüm tahsis etmek, tüm mirasçılar anlaşmadıkça mümkün olmayacaktır. Öte yandan sekiz bağımsız bölüm kurulacak taşınmazda her bir 1/3 pay sahibi üç mirasçı varsa; paylar oluşturulurken iki paya üçer bağımsız bölüm ayrılırken bir paya iki bağımsız bölüm ve bir bağımsız bölüm değeri kadar terekedeki diğer mallar konulacak, özgülemede bütün mirasçıar anlaşamazlarsa, çekilecek kura ile bu paylar mirasçılara özgülenecektir. Şayet, terekedeki diğer mallar iki bağımsız bölüm alan payı, diğerleriyle aynı değere ulaştırmaya yetmiyorsa, bağımsız bölüm özgülenmesi suretiyle paylaşma yapılamayacaktır. Özellikle, her bir mirasçı, ikişer bağımsız bölüm ve artan iki bağımsız bölümün her birinde 1/3'er

mülkiyet payı verilmek suretiyle (bazı bölümlerde paylı mülkiyet kurulmak suretiyle), paylaştırma, tüm mirasçılar anlaşmadıkça yapılamayacaktır.

2102 Bununla birlikte öğretide, her mirasçıya en az bir bağımsız bölüm düşmeyen ve bazı bağımsız bölümlerde paylı mülkiyet kurulmadan paylaşmanın yapılamadığı durumlarda, hakimin gene de kat mülkiyetine dönüştürme kararı verebileceği, fakat, kurulacak bağımsız bölümleri mirasçılara özgülemek yerine sattırarak bedellerini paylaştırabileceği görüşü de savunulmaktadır[1261].

f) Tarımsal işletmelerin özgülenmesi

aa) Amacı ve özellikleri

2103 Tarımsal amaçla işletilen (ekilip, biçilen) taşınmazların mirasçılara paylaştırılmasına ilişkin olarak, 30.4.2014 Tarihli ve 6537 sayılı Kanun[1261a] ile değişik 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu hükümleriyle özel ve ayrıntılı bir düzenleme getirilmiştir. Daha önce aynı konuyu düzenleyen MK 659-668 hükümleri, 6537 SK m. 9 hükmü ile yürürlükten kaldırılmıştır.

2104 Tarımsal işletmenin paylaştırılmasındaki özel sistemlerin Ortaçağ Avrupa'sındaki feodaliteyle ve bunun ürünü olan soylu (aristokrat) sınıfının varlığını sürdürmesiyle de yakın ilgisi vardır. Bu sistem sayesinde, inceleyeceğimiz hükümlerdekilere benzer şekilde, ölen mülk sahibinin (kont, baron, lord, marki vb.) şatosu ve tarımsal arazisi, en büyük oğluna bırakılarak, diğer çocukları çok daha düşük ve değersiz miras paylarıyla bertaraf edilmekteydi. Bu sayede, yakın zamana kadar, hatta seyrekleşmiş de olsa bu güne değin, bazı arazilerin üzerindeki şato ve malikhaneyle birlikte yüzyıllardır ayni aileden gelen kişilerin elinde kaldığı görülebilmektedir. Tamamen eşit miras paylaşımının uygulandığı bir sistemde ise, en büyük servetlerin bile, bir kaç kuşak sonra paramparça olması, bölünemeyecek unsurların (şato, malikane vb) ise sık sık satılarak yeni zenginlerin eline geçmesi kaçınılmazdır.

2105 Bu düzenlemenin amacı tarımsal işletmelerin, nesilden nesile miras yoluyla geçerken sürekli parçalanarak küçülmesini ve bu suretle verimsizleşmesini önlemektir. Zira işin niteliği gereği, bütün hâlinde işletilen bir tarımsal işletmeden (bir tarladan) sağlanan gelir, örneğin bunun dört parçaya bölünmesi üzerine oluşturulacak dört küçük işletmenin sağlayacağı gelirlerin toplamından çok daha fazla olmaktadır.

[1261] *Oğuzman*, 335, 336.

[1261a] RG 15 Mayıs 2014, Sayı 29001.

Söz gelimi, bir arazi bir bütün iken, tek traktör, tek buğday öğütücü, tek bir silo yeterliyken; dörde bölündüğünde her birinin sahibinin, birer traktör, birer buğday öğütücü ve siloya ihtiyacı olacak, fakat alınacak ürün, en iyi ihtimalle aynı kalacaktır. Keza, çok büyük bir tarımsal işletmenin sahibi, elde ettiği yüksek gelirle üretimi artıracak, modern teknoloji satın alabilecekken; bunun parçalanması üzerine her bir parçanın sahibi elde edeceği sınırlı gelirle böyle bir teknolojiyi satın almaya para ayıramayabilecektir. Tarımsal işletmelerin parçalanmasındaki bu sakıncaya karşı, küçük işletme sahiplerinin kooperatif veya diğer tür ortaklıklar hâlinde örgütlenebilecekleri savunulabilirse de ,bundan elde edilecek yararın, işini bilen bir müteşebbisin (çiftçinin) tek başına yönettiği işletmeden elde edilecek yararın gene de altında kaldığı, yaşam deneyimleriyle ispatlanmıştır. 2106

Tarımsal taşınmazların bölünerek verimsizleşmesi, özellikle tarımsal üretimin önem taşıdığı ülke ekonomileri bakımından büyük önem taşır[1262]. Tarımın, hâla ekonomisinde önemli bir yer tuttuğu ülkemiz bakımından da tarımsal arazi ve işletmelerin, bunları en iyi değerlendirebilecek olan mirasçılara verilmesi özel bir önem taşımaktadır. Ne var ki, uygulamada, tarımsal işletmelerin paylaşılması sırasında, buna ilişkin özel hükümlerin yeterince ve gereğince göz önünde tutulmadığı görülmektedir. 2107

Gerek MK 659 vd. hükümlerinin, gerekse yerlerini alan 6537 SK hükümlerinin paylaşım kurallarına getirdiği en önemli istisna, mirasçılardan birinin yasal miras payının değerini aşan değerdeki bir tereke malının, yani tarımsal işletmenin,ona özgülenmesini mümkün kılmasıdır. Paylaşmaya ilişkin başka hiç bir özel hüküm, bir mirasçının bu şekilde paymdan fazla değerde bir mal almasına izin vermez. Bu kuralların ikinci getirdiği özellik, kendisine tarımsal işletme özgülenmiş bulunan mirasçının, bununla birlikte başka bazı taşınır hatta taşınmaz mallar da almasıdır. Nihayet, bu kuralların bir özelliği de, tarımsal işletmenin özgülenmesi sırasında bazı şartlarla, aile malları ortaklığının veya limited şirketin kurulmasına yol açmasıdır. 2108

bb) 6537 sayılı Kanun düzenlemesinin zaman bakımından uygulanması

Aslında 6537 sayılı Kanun, sadece Tarımsal işletmelerin miras yoluyla intikaline ilişkin sınırlayıcı özel bir düzenleme getirmemekte; ayrıca Medeni Kanun'un Eşya Hukuku kurallarına, özellikle taşınmazların bölünme ve birleşmeleriyle paylı mülkiyet hükümlerine de önemli istisnalar getirmektedir. Bu Kanun, adından da anlaşıldığı üzere, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nun değiştirilmesi ve bu kanuna bazı ekler ya- 2109

[1262] Tarımsal işletmelerin özgülenmesi hususunda İsviçre Medeni Kanununda bizdeki düzenlemeyi karşılayan ZGB Art. 620-626 hükümleri, 1 Ocak 1994 tarihinde yürürlüğe giren, 4 Ekim 1991 tarihli kanunla kaldırılmıştır.

pılmasına ilişkindir[1262a]. Biz ise burada bu değişikliklerden sadece mirasın paylaşılmasını ilgilendirenleri ele alacağız.

2110 6537 SK 9 hükmü ile, mirasın paylaşımında tarımsal arazilerin özgülenmesine ilişkin MK 659-668 hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. Bundan sonra tarımsal arazilerin özgülenmesinde Medeni Kanun'un hükümleri değil, 6537 SK 5 ile değişik 5403 SK 8/A-9 hükümleri uygulanacaktır. Ne var ki, 6537 SK Geçici 5. Maddesi, yeni düzenlemenin uygulama zamanına ilişkin özel bir sınır getirmiştir. Bu maddeye göre: *"Bu maddenin yayımı tarihinde mirasçılar arasında henüz paylaşımı yapılmamış tarımsal arazilerin devir işlemleri, bu maddeyi ihdas eden Kanundan önceki kanun hükümlerine göre tamamlanır (f. 1). Bu maddenin yayımı tarihinden önce tarımsal arazilerin paylaşımına ilişkin olarak açılmış ve halen devam etmekte olan davalarda, bu maddeyi ihdas eden Kanundan önceki kanun hükümleri uygulanır (f. 2). Bu maddenin yayımı tarihinden itibaren iki yıl içinde birinci fıkraya göre yapılacak devir işlemleri harçlardan müstesnadır. Bu süre Bakanlar Kurulu tarafından iki yıl uzatılabilir (f. 3)."*

2111 Bu düzenlemeye göre, Kanunun yayımı tarihi olan 15.5.2014 tarihinden önce açılmış miraslarda, henüz paylaşım yapılmamışsa; bu tarihten sonra da MK 659-669 hükümleri uygulamaya devam etmektedir. Yürürlüğe giren değişiklikler bunlara uygulanmayacaktır. Maddenin bu hükmü takip eden 2. fıkrasında, aynı tarihten önce açılmış ve devam etmekte olan davalarda gene MK m. 659-669 hükümlerinin uygulanacağı ayrıca belirtilmişse de, aslında 1. Fıkranın geniş anlamı zaten bu davaları da içermektedir.

2112 6537 sayılı Kanunun yayım tarihi olan 15.5.2014 gününden itibaren açılan miraslarda ise, mutlak şekilde yeni sistem uygulanacaktır. Biz bu düzenlemeye göre daha bir süre uygulanması söz konusu olacak mülga MK 659-668 hükümlerine ilişkin önceki basıdaki açıklamalarımızı, bu bahsin sonunda muhafaza ediyoruz.

[1262a] Bu kanunun 1. Maddesi, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nun 1. Maddesini şu şekilde değiştirmiştir:
"Bu Kanunun amacı; toprağın korunması, geliştirilmesi, tarım arazilerinin sınıflandırılması, asgari tarımsal arazi ve yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerinin belirlenmesi ve bölünmelerinin önlenmesi, tarımsal arazi ve yeter gelirli tarımsal arazilerin çevre öncelikli sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak planlı kullanımını sağlayacak usul ve esasları belirlemektir."
Aynı Kanunun 2. Maddesi ile değişik 5403 SK m. 2 uyarınca: "Bu Kanun; arazi ve toprak kaynaklarının bilimsel esaslara uygun olarak sınıflandırılması, tarımsal arazi ve yeter gelirli tarımsal arazilerin asgari büyüklüklerinin belirlenmesi ve bölünmelerinin önlenmesi, arazi kullanım planlarının hazırlanması, koruma geliştirme sürecinde toplumsal, ekonomik ve çevresel boyutlarının katılımcı yöntemlerle değerlendirilmesi, amaç dışı ve yanlış kullanımların önlenmesi, korumayı sağlayacak yöntemlerin oluşturulması ile görev, yetki ve sorumluluklara ilişkin usul ve esasları kapsar."

cc) Tarımsal arazinin bölünme sınırları

6537 sayılı Kanun, tarımsal arazilerin bölünmesini emredici hükümlerle 2113
sınırlarken, *"asgarî tarımsal arazi büyüklüğü"* ve *"yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğü"* olmak üzere iki ayrı limit tayin etmiş ve Ülke çapında olmak üzere, bunların –şayet varsa- *"yan sanayi işletmeleriyle"* birlikte, bölünmelerini önleyen emredici kurallar getirmiştir.

Asgari tarımsal arazi, *"üretim faaliyeti ve girdileri rasyonel ve ekono-* 2114
mik olarak kullanıldığı takdirde, bir tarımsal arazide elde edilen verimliliğin, söz konusu tarımsal arazinin daha fazla küçülmesi halinde elde edilemeyeceği Bakanlıkça belirlenen en küçük tarımsal parsel büyüklüğünü" ifade eder (6537 SK 3/h) Ancak bu büyüklük, *"mutlak tarım arazileri, marjinal tarım arazileri ve özel ürün arazilerinde 2 hektar, dikili tarım arazilerinde 0.5 hektar, örtü altı tarımı yapılan arazilerde 0,3 hektardan küçük belirlenemez"* (5403/8/2). Bu sınır esasen tapu sicilini ilgilendirecek şekilde her tarımsal parselin genel bir bölünme sınırıdır. *"...Belirlenen asgari büyüklüğe erişmiş tarımsal araziler, bölünemez eşya niteliği kazanmış olur."* (5403 SK m. 8/2). Gene, asgari tarımsal arazinin sadece daha küçük parseller olarak bölünmesi değil; *"hisselendirilemez.."* ifadesiyle, herhangi bir paydaşa bu limitin altına düşecek şekilde pay verilerek paylı mülkiyet kurulması da yasaklanmıştır (5403 SK 8/2). Buna rağmen, *"tarım dışı kullanım izni verilen alanlar ve çay, fındık, zeytin gibi özel iklim ve toprak ihtiyaçları olan bitkilerin yetiştiği alanlarda"*, gerekli görülürse, Bakanlığın uygun görüşü ile daha küçük parseller oluşturulabileceği belirtilmiştir (5403 SK 8/2). Mirasın paylaştırılmasında aşağıda açıklayacağımız kurallar uygulanarak, tarımsal arazinin bu sınırdan küçük parsele bölünerek paylaştırılması veya bu sınırdan küçük miktara isabet edecek pay yaratılarak paylı mülkiyete geçilmesi, önlenecektir.

Yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğü, *"farklılıkları göz önünde bulun-* 2115
durularak il ve ilçelerin ekli (1) sayılı listede belirlenen yeter gelirli tarımsal arazi büyüklükleri" ifade eder (5403 SK m. 3/ı). Belirtilen Kanuna ekli listede, her bir ilin her bir ilçesi hakkında, sulu, kuru, dikili ve örtülü altı arazi olmak üzere dört kategoride yeter gelirli tarımsal arazi büyüklükleri ayrı ayrı gösterilmiştir. Burada Bakanlığın belirlemesine yer bırakılmamıştır. Tarımsal araziler, asgari tarımsal arazi büyüklüğünün yanı sıra, ayrıca yeter gelirli tarımsal arazi adı altında bu yüz ölçümlerle de sınırlandırılmıştır. Tarımsal araziler, yeter gelirli tarımsal arazi yüzölçümleri listesinde ait olduğu ilçe için belirlenmiş yüzölçümünden küçük parsellere bölünemez (5403 SK 8/A). Daha küçük paylarla paylı mülkiyet kurulamayacağı açıkça belirtilmemişse de, Kanunun başka bazı maddelerinden (m. 8/C, a-b; 8/F/2; 8/Ğ) bu husus anlaşılmaktadır. Yeter gelirli tarımsal arazilerin tapu kayıtla-

rında, bu durum Bakanlık tarafından tapu müdürlüğüne yapılan bildirim üzerine, şerh verilecektir (5403/8/A). *"Yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerinin hesaplanmasında, aynı kişiye ait ve Bakanlıkça aralarında ekonomik bütünlük bulunduğu tespit edilen tarım arazileri birlikte değerlendirilir"* (5403 SK 8/A). Bu hüküm uyarınca, her bir parselin yüzölçümü listede belirtilenin altında olsa bile, birden fazla parsel aynı kişiye ait ve ekonomik bütünlük taşıyorsa (hemen daima komşu olacaklardır), bunların toplamının listedeki sınıra ulaşması halinde, hep birlikte yeter gelirli tarımsal arazi sayılacaklardır. Yeter gelirli tarımsal arazinin bölünememesine ve böylece bir kısmının tasarrufa veya intikale konu olamamasına, Kanun iki istisna getirmiştir: *"yeter gelirli tarımsal arazilerin ekonomik bütünlüğe sahip olmayan kısımları Bakanlığın izni ile satılabilir"* ve *"Bilimsel gelişmeler ve günün koşullarına göre bu Kanuna ekli (1) listede Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile değişiklik yapılabilir."* (5403 SK 8/A).

dd) Mirasçıların bölünemez tarımsal araziyi belli süre içinde belli yöntemlerle paylaşma yükümü

2116 Terekede yer alan taşınmazların asgari büyüklükte tarımsal arazi veya yeter gelirli tarımsal arazi vasfını koruyarak mirasçılar arasında paylaşılması mümkünse, bu aynen paylaşma asıldır (5403 SK m. 8/B/f.1). Fakat böyle bir anlaşma mümkün değilse veya mümkün olmasına rağmen mirasçılar paylaşma yapmıyorsa, Kanun, mirasçılara mirasın açılmasından itibaren bir yıl içinde aralarında anlaşarak şu yollardan birine başvurmalarını veya sulh hukuk mahkemesine başvurmalarını zorunlu kılmıştır (5403 SK 8/C):

– Bir mirasçıya veya her birinin payı yeter gelirli arazi büyüklüğünü karşılıyorsa birden fazla mirasçıya taşınmazın devri.

– MK 373 vd. maddelerine göre mirasçıların bir aile malları ortaklığı veya kazanç paylı aile malları ortaklığı kurmaları ve taşınmazın bu ortaklığa devri.

– Mirasçıların TTK. hükümlerine göre bir limited şirket kurmaları ve taşınmazın bu şirkete devri.

– Mirasçıların bu taşınmazı bütün olarak üçüncü kişilere devri.

2117 Mirasçılar mülkiyet devrini seçmeleri veya limited şirket kurmaları halinde tescil işlemine kadar harçlardan ve damga vergisinden muaf olacakları gibi, TTK hükümlerinde limited şirket için aranan sermaye ve diğer şartlar burada aranmayacaktır (5403 SK 8/I). Limited şirkete devir opsiyonunun anlamı, mirasçıların kuracakları limited şirkete bu taşınmazı sermaye olarak koymalarıdır. Zaten mevcut bir limited şirkete -kendileri kurmuş ol-

salar dahi- bu taşınmazı satmaları ve bedel karşılığı devretmeleri, zaten diğer bir seçenek olan "üçüncü kişiye devir" şıkkına girer.

Kanunun sadece ve özellikle limited şirket kurma ve asgari büyüklükteki tarımsal taşınmazı bu şirkete devretme imkânı tanımış olmasından, mirasçıların bir başka tür şirket kurarak örneğin bir anonim ortaklık kurarak taşınmazı bu şirkete sermaye olarak koymalarının yasaklandığı sonucu çıkacaktır. Mirasçılar –velev ki Kanuni süre içinde- hep birlikte hazırladıkları bir anonim şirket esas sözleşmesinde bu taşınmazı ayni sermaye olarak gösterirlerse, 5403 SK hükümlerine aykırılık sebebiyle bu esas sözleşme geçersiz sayılacak, bu anonim şirket kurulamayacaktır. Aksi halde, 5403 SK 8/C/f.1, c hükmünde özellikle ve sadece limited şirketten söz edilmesinin anlamı kalmaz. 2118

Mirasçıların aile ortaklığı veya kazanç paylı aile malları ortaklığı kurmaları şıkkında, ortaklardan birinin payını yabancıya satması halinde, diğerlerine önalım hakkı tanınmıştır (5403 SK 8/i). 2119

Limited şirketin veya aile malları ortaklığının yahut kazanç paylı aile malları ortaklığının sona ermesi halinde tasfiyede tarımsal araziler asgari büyüklüğün altında bölünemez. (5403 SK 8/J). Böylece, mirasçıların bu şıkları taşınmazı bölmek için aracı kılmaları önlenmiş olmaktadır. 2120

Mirasçıların taşınmazı üçüncü kişilere satmaları halinde, bununla sınırdaş tarımsal arazi maliklerine de önalım hakkı tanınmıştır. Ancak satış zaten sınırdaş taşınmaz malikine yapılmışsa, başka sınırdaş taşınmaz malikleri bu önalım hakkını kullanamaz. Sınırdaş olmayana yapılan satışta önalım hakkını birden fazla sınırdaş taşınmaz maliki kullanmak isterse, hakim tarımsal bütünlük arz eden sınırdaş arazi malikini tespit ederek mülkiyeti ona devredecektir (5403 SK 8/i/f.2). Birden fazla sınırdaş tarımsal bütünlük oluşturuyorsa ne olacağı düzenlenmemiştir. Böyle bir durumda da hakim gene en uygununu seçmeli ve ona devri yapmalıdır. 2121

ee) Mirasçılar veya Bakanlıkça açılacak dava ile paylaştırma.

Mirasçılar taşınmazı aralarında paylaşamadığı gibi Kanunun öngördüğü diğer üç yoldan birine başvurmak hususuna da anlaşamamışlarsa; gene aynı bir yıl içinde içlerinden birinin yetkili sulh hukuk mahkemesine dava açarak tarımsal arazinin akıbetine karar verilmesini istemesi gerekir (5403 SK 8/C/f.2). Kanımızca bu, MK 642 anlamında "paylaşma davası"ndan başka bir şey değildir. Bu bakımdan yetkili sulh mahkemesi de taşınmazların bulunduğu yere bakılmaksızın mirasın açıldığı yani miras bırakanın son yerleşim yeri sulh mahkemesidir. 5403 SK hükümlerindeki sulh mahkemesini ve mirasçıların taşınmaz hakkında açacakları davayı miras paylaşma davasın- 2122

dan ayrı ve özel bir dava saymak, mirasın dava yoluyla paylaştırılmasında büyük karışıklıklar ve sorunlar çıkarır. Şu halde, mirasçılar bu bir yıl içinde mirasın paylaşılması davası açmayıp sadece belli bir tarımsal taşınmazın paylaşımı için dava açamayacaklardır. Ancak, mirasçılar daha önce diğer tüm tereke mallarını ittifakla anlaşarak paylaşmışlarsa (objektif kısmi paylaşma), bu durumda paylaşma davası sadece tarımsal taşınmaz hakkında açılabilecektir.

2123 Mirasçılar kanunun gösterdiği yollarla tarımsal taşınmazı veya bedelini paylaşmamış ve paylaşma davası da açmamışlarsa; bu durumun kamu kurum ve kuruluşları ile finans kurumları tarafından öğrenilmesi halinde, bu kurum ve kuruluşlar durumu derhal Bakanlığa bildirecek ve Bakanlık Kanunun gösterdiği yollara başvurmaları için mirasçılara üç ay süre verecektir. Verilen süre sonunda devir olmaması halinde, Bakanlığın sulh hukuk mahkemesinde mirasçılar aleyhine dava açarak tarımsal taşınmazın devir veya satımını sağlaması düzenlenmiştir (5403 SK 8/Ç). Kanımızca, Bakanlığın verdiği üç aylık süre içinde mirasçılardan biri aynı maksatla paylaşma davası açarsa, Bakanlığın ayrıca dava açmasına gerek olmamalıdır.

2124 İster mirasçılardan biri veya bazısı paylaşma davası açsın ister bakanlık dava açsın, Kanun tarımsal arazinin paylaşımı hakkında mahkemenin uyacağı belirli kurallar getirmiştir. Buna göre:

2125 Yeter gelirli tarımsal araziler birden çok yeter gelir sağlayan tarımsal arazi büyüklüğüne bölünebiliyorsa, sulh hukuk hakimi bunlardan her birinin mülkiyetini mirasçılara ayrı ayrı devreder (5403 SK 8/C/f.3). Şayet bu şekilde herkese bir parsel düşmeyecekse, veya esasen taşınmaz Kanuni sınırlar sebebiyle bölünemiyorsa, hakim aşağıda belirteceğimiz kurallara göre hareket eder.

2126 Mahkeme tarımsal arazi veya yeter gelirli tarımsal arazi mülkiyetinin, *"kişisel yetenek ve durumları göz önünde tutulmak suretiyle tespit edilen ehil mirasçıya tarımsal gelir değeri üzerinden devrine, birden çok ehil mirasçının bulunması halinde, özellikle asgari geçimini bu yeter gelirli tarımsal araziden sağlayan mirasçıya, bunun bulunmaması halinde bu mirasçılar arasında en yüksek bedeli teklif eden mirasçıya devrine, ehil mirasçı olmaması halinde, mirasçılar arasından en yüksek bedeli teklif eden mirasçıya devrine karar verir"* (5403 SK 8/C/f.2,a).

2127 *"Birden fazla ehil mirasçı olması ve bu mirasçıların miras dışı tarımsal arazilere sahip olması durumunda, bu mirasçıların mevcut arazilerini yeter gelirli büyüklüğe ulaştırmak veya bu arazilerin ekonomik olarak işletilmesine katkı sağlamak amacıyla hâkim, tarım arazilerinin yeter gelir büyük-*

lüğünü aramaksızın bu mirasçılara devrine karar verebilir" (5403 SK 8/C/f.2, b).

"Mirasa konu yeter gelirli tarımsal arazinin kendisine devrini talep 2128
eden mirasçı bulunmadığı takdirde, hâkim satışına karar verir. Bu suretle yapılacak satış sonucu elde edilen gelir, mirasçılara payları oranında paylaştırılır" (5403 SK 8/C,f.2, c).

Kanun bu hükümler uygulanırken ehil mirasçı sıfatını saptamayı tama- 2129
men hâkimin takdirine bırakmamış, *"ehil mirasçıya ait nitelikler, Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir"* (5403 SK 8/C, f. 4) demek suretiyle, bu niteliklerin idare tarafından düzenlenecek normatif bir belgeye bağlanmasını öngörmüştür.

Kanun paylaşma davasının devamı süresince tarımsal arazinin yönetimi- 2130
ne ilişkin özel bir düzenlemeyi, sadece, bir mirasçının yaş küçüklüğü sebebiyle ayırt etme gücü olmadığı durumlar için yapmıştır. Böyle bir durumda hâkim, *"..yeter gelirli tarımsal arazilerin yönetimini dava sonuçlanana kadar ehil gördüğü mirasçılardan birine veya üçüncü bir kişiye tedbiran verebilir. Bu takdirde, elde edilen tarımsal gelir, işletme masrafları düşüldükten sonra mirasçılar arasında payları oranında dağıtılır"* (5403 SK 8/G). Ayırt etme gücüne yaş küçüklüğü değil de mesela akıl hastalığı sebebiyle sahip olmayan bir mirasçı varsa ne olacaktır? Böyle durumlarda, MK 589-592 hükümlerindeki koruma önlemlerine başvurulmasına bir engel yoktur.

ff) Denkleştirme hükümleri.

Şayet tarımsal arazinin tespit edilen ehil mirasçıya olduğu gibi devri 2131
üzerine terekedeki diğer mallar diğer mirasçıların miras paylarını karşılamıyorsa, tarımsal taşınmazı alanın diğerlerine miras paylarını karşılayacak miktarda denkleştirme ödemesi yapması gerekecektir. 5403 SK m. 8/D/f.1 uyarınca: *"Sulh hukuk hakimi, mülkiyetin devrini uygun bulduğu mirasçıya, diğer mirasçıların miras paylarının bedelini mahkeme veznesine depo etmek üzere altı aya kadar süre verir. Mirasçı tarafından talep edilmesi üzerine altı ay (daha) ek süre verilebilir. Belirlenen süreler içinde bedelin depo edilmemesi ve devir hususunda istekli başka mirasçı bulunmaması durumunda sulh hukuk hakimi, tarımsal arazinin veya yeter gelirli tarımsal arazinin açık arttırmayla satılmasına karar verir."*

Şayet mirasçılardan hiç biri ehil mirasçı niteliklerine sahip değilse, 5403 2132
SK m. 8/C/f.2/a, son cümle uyarınca, sulh hâkiminin taşınmaz için *"en yüksek bedeli teklif eden"* mirasçıya devri gerçekleştireceğini belirtmiştik. *"Alım bedeli"* diyebileceğimiz bu bedel, diğer mirasçılara miras payları oranında ödenecektir (elbette hakim taşınmazı devretmeden önce bu bedelin ödenme-

sini arayacaktır). İşte böyle bir durumda, şayet taşınmazı devralan mirasçının ödediği alım bedeli -taşınmazın değeri ve diğer mirasçılara kalan malvarlığı bakımından- denkleştirme bedeline eşit veya fazla ise, ayrıca denkleştirme bedeli ödenmeyecektir. Şayet denkleştirme bedelinden az ise, aradaki fark kadar gene denkleştirme bedeli ödemesi gerekecektir.

2133 Özel bir durum için özel bir denkleştirme hükmü getiren 5403 SK 8/Ğ uyarınca: *"Kendisine yeter gelirli tarımsal arazi mülkiyeti devredilen mirasçının, devir sebebiyle diğer mirasçılara payları karşılığı ödemesi gereken bedel ile miras bırakanın borcu dolayısıyla daha önce yeter gelirli tarımsal arazi üzerinde kurulmuş bulunan rehin konusu alacaklar birbiriyle denkleştirilir. Bakiye bir tutar kalırsa diğer mirasçılara payları oranında ödenir."* İyi bir ifadeye sahip olmayan bu düzenleme açıklanmaya muhtaçtır. Bu hükümle amaçlanan, tarımsal araziyi alan mirasçının diğer mirasçılara ödemesi gereken denkleştirme parasından bu ipotek konusu borç tutarını düşmesidir. Böylece, taşınmazı alarak ipotek konusu borcu da tek başına üstlenmiş sayılacak mirasçı, bunu payları oranında diğer mirasçılara yansıtmış olacaktır. Diğer mirasçılara ödenecek denkleştirme bedeli bu ipoteğe konu borçtan fazla ise, ipotekli taşınmazı alan mirasçı sadece aradaki farkı ödeyecektir. Şayet ipotek konusu borç denkleştirme bedellerinden fazla ise ne olacağına dair hüküm yoktur. Böyle bir durumda, taşınmazı alan mirasçı elbette hiçbir denkleştirme bedeli ödemeyeceği gibi, tersine, bu taşınmazı almakla miras payından daha az değerde şey almış duruma düşmemesi için, onun diğer mirasçılardan ipotekli borcun miras payını tamamlayacak kısmı kadar ödeme yapmalarını talep hakkı doğacaktır.

2134 Tarımsal arazi kendisine bırakılan mirasçının denkleştirme bedelini ödeyecek parası yoksa, hakimin verdiği süre içinde parayı kredi alarak sağlaması için Kanun özel bir imkân getirmiştir. 5403 SK m. 8/D/f.2 uyarınca: *"Kendisine yeter gelirli tarımsal arazi mülkiyeti devredilen mirasçılardan, diğer mirasçıların paylarının karşılığını öz kaynakları ile ödeyemeyecek durumda olanların bu ödemelerini gerçekleştirmek için bankalardan kullanacakları kredilere Bakanlığın ilgili yıl bütçesine bu amaçla konulacak ödenekten karşılanmak üzere faiz desteği verilebilir. Verilecek kredi miktarı diğer mirasçıların payları karşılığı tutarın toplamından fazla olamaz. Bu fıkra uyarınca verilecek kredilere ve yapılacak faiz desteğine ilişkin usul ve esaslar Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın ve Bakanlığın müşterek teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir."*

2135 Tarımsal arazilerin paylaşımından sonra ortaya çıkabilecek bir durum, bunların zaman içinde tarım dışı kullanım arazisi haline gelmesi ve böylece bu taşınmazı alan mirasçının, kanunun tarımsal verimin korunması amacına aykırı olarak, diğer mirasçılar aleyhine haksız bir menfaat elde etmesidir.

Bu duruma tipik örnek, tarımsal arazinin bulunduğu yerin sonradan konut alanı olması sayesinde, büyük bir inşaat rantı getirmesidir. Bu haksızlığı önlemek için, böyle durumlarda Kanun diğer mirasçılara bu değer artışına göre hesaplanacak bir alacak talebini ileri sürme hakkı tanımıştır. 5403 SK m. 8/C,f. son uyarınca: *"yeter gelirli tarımsal arazi mülkiyetinin mirasçılardan birine devredilmesinden itibaren yirmi yıl içinde bu arazilerden tamamının veya bir kısmının tarım dışı kullanım nedeniyle değerinde artış meydana gelmesi durumunda; devir tarihindeki, arazinin parasal değeri tarım dışı kullanıma izin verilen tarihe göre*[1262b] *yeniden hesaplanır. Bulunan değer ile arazinin yeni değeri arasındaki fark, diğer mirasçılara payları oranında arazinin mülkiyetini devralan mirasçı tarafından ödenir."* Yirmi yıl içinde bu vasıf değişiminin gerçekleşmesi üzerine, diğer mirasçıların doğacak olan alacak haklarının zamanaşımı süresi belirtilmemiştir. Burada TBK 146 uyarınca on yıllık zamanaşımı uygulanmalıdır. Şayet vasıf değişiminden itibaren on yıl geçmişse, devirden itibaren yirmi yıl geçmemiş olsa bile, diğer mirasçıların hakları zamanaşımına uğrar. Buna karşılık, yirmi yılın dolmasına on yıldan az bir süre kala taşınmaz vasıf değiştirmişse, diğer mirasçıların vasıf değişikliğinden kaynaklanan alacak hakları, yirmi yıllık süre dolduktan sonra da, on yıllık zamanaşımı süresi dolduncaya kadar engelsiz ileri sürülebilir.

gg) Bazı taşınırların ve yan sınaî işletmenin devri

aaa) Bazı taşınırların devri

Kanun yukarıdan beri açıkladığımız kurallara göre tarımsal arazinin bir 2136
mirasçıya özgülenme ve devrine karar verilmesi üzerine, ayrıca buna bağlı sayılan başka malvarlığı değerlerinin de aynı mirasçıya devredilmesini düzenlemektedir. Bunlar bazı taşınır mallar ve yan sınaî işletmedir.

5403 SK m. 8/E/f.1 uyarınca: *"Yeter gelirli tarımsal arazi mülkiyeti* 2137
kendisine devredilen kişi, bu araziler için zorunlu olan araç, gereç ve hayvanların mülkiyetini gerçek değerleri üzerinden kendisine devredilmesini isteyebilir." Burada kastedilen terekede yer alan taşınırlardır. Terekede yer almayıp bir mirasçının zaten kendisine ait olan bir malı, tarımsal arazide zorunlu olarak kullanılıyor olsa bile, mirasçı malını bu maddeye göre satmaya zorlanamamalıdır.

Bu hükmün uygulanmasında, şayet tarımsal arazinin değeri bunu alan 2138
mirasçının miras payını aşmıyorsa, kendisine devredilmesini isteyeceği bu

---

[1262b] Kanunun ifadesi, "tarım dışı kullanım tarihinde" değil, "tarım dışı kullanıma izin verilen tarihe göre" şeklinde olduğundan; tarımsal arazinin imara açıldığı tarihteki piyasa değeri esas alınacak olup, malikin bundan yararlanarak üzerine apartman diktirmesi üzerine taşıdığı yahut taşıyacağı değer esas alınmayacaktır.

taşınırların bedelini öderken kendi miras payı kadar indirim yapılmalıdır. Taşınmazın bu taşınmazı alanın miras payını aşan değer kısmı, bu taşınırların değerinden az ise; sadece aşan kısmın değeri ile taşınırların değeri arasındaki farkın kendi miras hissesine düşen kısmı kadar indirim yapılmalıdır.

2139 Mirasçının bu talebi ileri sürmesine kanunda süre tayin edilmemişse de, mirasın paylaşılmasının tamamlanmasından sonra bu talep ileri sürememelidir.

bbb) Yan sınai işletmenin devri.

2140 Yan sınai işletmeye ilişkin 5403 SK 8/H/f.1 hükmüne göre: *"Yeter gelirli tarımsal arazilere sıkı şekilde bağlı bir yan sınai işletme mevcut ise yan sınai işletme ile yeter gelirli tarımsal arazilerin mülkiyeti bir bütün olarak istemde bulunan ve ehil görülen mirasçıya gerçek değeri üzerinden devredilir."* Aynı Kanunun m. 3/u hükmü yan sınai işletmenin *"Yeter gelirli tarımsal arazilere ait ürün depolama, koruma, işleme ve pazarlama gibi faaliyetlere yönelik tesisleri"* ifade ettiğini belirtmiştir. Kanunda yan sınai işletmenin aynı taşınmaz üzerinde mi başka bir taşınmaz üzerinde mi olacağı belirtilmediğinden, işletmenin bulunduğu taşınmazın terekeye dahil olması şartıyla, her iki durumda da devir talep edilebilmelidir. Eğer işletme gene terekedeki başka taşınmaz üzerinde ise, değer tespitinde bu taşınmazla birlikte değeri esas alınacaktır.

2141 5403 SK 8/H uyarınca: *"Mirasçılardan birinin itiraz etmesi üzerine veya birden çok mirasçının kendilerine devir istemesi hâlinde sulh hukuk hâkimi yeter gelirli tarımsal arazi ve yan sınai işletmenin ekonomik gelir ve bütünlüğünü sürdürme imkânını ve mirasçıların kişisel durumlarını göz önünde bulundurarak yan sınai işletmenin birlikte veya ayrı olarak devrine ya da satışına karar verir."*

2142 Şayet mirasçılar süresi içinde 5403 SK m. 8/C/f.1,c hükmüne göre limited şirket kurarlarsa; yan sınai işletmenin de (5403 SK 8/H/f.3) arazi için zorunlu taşınır malların da (5403 SK 8/E/f.3), bu şirketin malvarlığına dâhil edileceği öngörülmüştür.

hh) Ölüme bağlı tasarrufla düzenlemeye getirilen sınırlar.

2143 Mirasbırakan bir ölüme bağlı tasarrufla, tarımsal arazinin özgülenmesine ve paylaştırılmasına ilişkin yukarıdan beri açıkladığımız kanun hükümlerinden ayrılan bir sonuç öngörmek isteyebilir. Ne var ki 5403 SK m. 8/F hükümleri bu imkânı sınırlandırmıştır. Bu maddenin 1. fıkrasına göre, *"Yeter gelirli tarımsal arazi mülkiyetinin kendisine devredilmesini isteyen ve buna ehil tek mirasçı olduğu anlaşılan mirasçının bu konudaki istem hakkı,*

ölüme bağlı tasarrufla ortadan kaldırılamaz. Mirastan çıkarma, mirastan yoksunluk ve mirastan feragat hâlleri saklıdır."

Aynı maddenin 2. Fıkrası ise, mirasbırakana sınırlı bir düzenleme 2144
imkânı tanımaktadır: *"Birden çok mirasçıda devir koşullarının bulunması hâlinde, kendisine devir yapılacak mirasçı ölüme bağlı tasarrufla belirlenebilir. Belirlenen bu mirasçıya itiraz edilmesi durumunda, ehil mirasçı sulh hukuk hakimi tarafından belirlenir."* Bu düzenleme pek mantıklı görünmemektedir. Birden çok mirasçıda devir koşullarının bulunması esasen 5403 SK 8/C/f.2, a ve b uyarınca birden çok ehil mirasçı olduğu durumları ifade edeceğine göre, bunlar arasında mirasbırakanın tercihine itiraz üzerine hakim başka bir mirasçıyı nasıl *"ehil"* sayacaktır. Hükmün ikinci cümlesi ilk cümlesinin getirdiği imkânı kaldırıyor görünmektedir. Bu hükmün en makul uygulaması, hakimin ancak, itiraz eden mirasçının mirasbırakanın öngördüğü mirasçıdan *"daha ehil"* olduğunu açıkça saptaması halinde, ölüme bağlı tasarruftan farklı bir özgüleme yapabilmesidir.

ıı) Mülga MK 659-668 düzenlemesi

aaa) Tarımsal işletme kavramı

MK 659 vd. hükümlerinin uygulanabilmesi için terekede bir tarımsal işletme yer 2145
almalıdır. Tarımsal işletme, tarımsal üretime tahsis edilmiş taşınmazlardır.Tarımsal üretim, kazanç maksadıyla bir taşınmazda bikti ve hayvan yetiştirme faaliyetlerinin tümünü kapsar. Ancak, bu anlamdaki tarımsal işletmenin MK 659 vd.'na tabi olabilimesi için, yeterli tarımsal varlığa sahip olması gerekir (MK 659/I). İşletmenin, yeterli tarımsal varlığa sahip olup olmadığı ise, "... tarım bölgeleriyle tarım ürünlerinin özellikileri göz önünde tutularak ilgili bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir " (MK 659/III). Bu niteliklere sahip olmayan bir işletme, MK 659 vd.'ndaki özel paylaşma hükümlerine tabi olmaz.

Özgüleme, gelir değeri üzerinden yapılacağı için (MK 659/I), tarımsal işletme- 2146
nin bir (asgari) gelir getirmesi gerekir. Bu (asgari) gelirin ölçüsü, tarımsal işletmenin bir yıllık gelirinin, karı, koca ve bunların ana ve babalarıyla, okul çağında iki çocuklarından oluşan bir çiftci ailesini geçindirmeye yetecek miktarda olmasıdır. Aksi halde, tarımsal işletme, özel paylaşma hükümlerine tabi olmaz.

Taşınmazın fiilen tarımsal işletmeye konu olmayıp, sadece bunun mümkün ol- 2147
ması ya da kendisine özgülenmesini talep eden mirasçının taşınmazı bu şekilde işleteceğini beyan etmesi, MK 659 vd. hükümlerinin kapsamına girmez. Fakat, önceden tarımsal işletme hâlindeki bir taşınmazın, mirasbırakan öldüğü sırada işletilmiyor olması, işletmenin devamı mümkün oldukça, gene de tarımsal işletme hükümlerine göre özgülenmesine bir engel oluşturmaz.

Tarımsal işletmenin birden fazla taşınmazdan oluşmasına bir engel yoktur. Hatta 2148
bunlar birbirlerine komşu olmasalar bile, hepsi bu hükümlere göre bir mirasçıya özgülenebilirler. Ancak, bu tarımsal taşınmazların, ekonomik bir birlik oluşturacak şe-

kilde işletilmesi gereklidir[1263]. Bunun anlamı, söz konusu taşınmazların, ekonomik işlevini yerine getirmelerinin birbirine bağlı olması, bir merkezden yönetilmelerinin gerekmesidir. Örneğin, ayrı parseller şeklindeki üç arazinin birinde kavak yetiştiriliyor olup, ikincisinde bunların kesildikten sonra depolandıkları tesisler ve üçüncüsünde de ayırma ve paketleme tesisleri ile yönetim binası varsa, bu üç arazi de MK 659 hükümlerine göre tek bir tarımsal işletme olarak bir mirasçıya özgülenebilecektir. Ne var ki, hakim, bu şekilde birbirine bağlı tarımsal işletmelerin, birden fazla talibi varsa, hepsini bir talibe özgülemek zorunda değildir. Hakim, MK 659/II'ye göre, değerinide azalma olmaması ve yeterli tarımsal varlığı sahip olmaları şartıyla bölüp, her bir bölümünü istemde bulunan bir mirasaçıya özgüleyebilir. Hatta hükümden anlaşılacağı üzere, aynı şartlarla tek bir tarımsal işletmeyi de bölüp, taliplerine ayrı ayrı özgüleyebilir. Bölünme hâlinde yeterli tarımsal varlığa sahip olup olmama, MK 659/II hükümlerine göre tespit edilir. Doğaldır ki,birden fazla arazi, birbirine bağımlı olmayan tarımsal işletme şeklinde çalıştırılıyorsa, bunların büyük bir ihtimalle aynı mirasçıya özglenmesi söz konusu olmayacaktır.

2149 MK 660 tarımsal işletmenin özgülenmesinin, burada yapılan tarımda kullanılan araç ve hayvanları da kapsayabileceğini belirtmiştir. Ancak, hükmün ifadesinden, bunun otomatik olarak gerçekleşmeyip, tarımsal işletmenin özgüleneceği mirasçının talebi üzerine yapılacağı anlaşılmaktadır.Bu takdiride özgüleme, araç, gereç ve hayvanların işletme için taşıdığı değer üzerinden yapılır.

2150 MK 667 daha da ileri giderek,tarımsal işletmede kullanılan, yukarıdaki taşınır mallar dışında kalan, tarımsal işletmeden ayrı olmakla beraber, ona şıkı şekilde bağlı, yan işletmenin de aynı mirasçıya özgülenebileceğini öngörmektedir. Böylece, örneğin, terekede yer alan büyük bir koyun çiftliğinin dışında ve uzağında (hatta başka bir şehirde) olmakla beraber, sadece bu koyunların yününü işletmek için kurulmuş bir atölye de çiftlikle birlikte özgülenecektir. Kanun bu tür işletmelere yan işletme demektedir. Sınai bir işletmenin bu hükme göre tahsisi için, tarımsal işletmenin hizmetine tahsis edilmiş ve ona göre ikincil(yan) faaliyet niteliği taşıması; ayrıca tarımsal işletmenin özgüleneceği mirasçının sınai işletmenin özgülenmesini de talep etmesi gerekmektedir (MK 660/I). Mirasçılardan birinin birlikte özgülenmeye itiraz etmesi ya da birden fazla talibin bulunması hâlinde, sulh hakimi, *"...her iki işletmenin ekonomik varlıklarını sürdürme olanaklarını ve mirasçıların kişisel durumlarını göz önünde bulundurarak yan işletmenin birlikte ya da ayrı satışına karar verir"*. Birlikte özgüleme hâlinde, yan işletme sürüm değeriyle, tarımsal işletme ise gelir değeriyle özgülenir (MK 667/II).

2151 Bu konuda son olarak belirtelim ki, mirasbırakan, ehil olan bir mirasçının, tarımsal işletmenin kendisine özgülenmesini isteme hakkını bir ölüme bağlı tasarrufla ortadan kaldıramaz (MK 662/I). Ancak MK 662/II, buna mirasçılıktan çıkarma ve mirastan feragat yönünden bir istisna getirmiştir. Buna göre, mirasçılıktan çıkarma sebebi varsa ve mirasbırakan bir vasiyetname ile özgülemeyi istemeye ehil mirasçıyı mirasından çıkarmışsa, bu kişi artık mirasçılık sıfatını kaybettiği için, tereke üzerinde hak sahibi olamaz ve doğal olarak tarımsal işletmenin de kendisine özgülenmesini isteyemez. Ancak MK 512ye göre, mirasçılıktan çıkarmaya karşı iptal ya da tenkis davası açılmış ve başarılı olmuş bir mirasçı özgülemeyi isteme hakkını yeniden kazanabilmelidir.

2152 Aynı durum mirastan feragat hali için de söz konusudur. Feragat sözleşmesinin

---

[1263] *Zevkliler*, Türk Miras Hukukunda Tarımsal İşletmelerin Tahsisi, Ankara 1970, 92 vd.; *Oğuzman*, 340; *İmre/Erman*, 438.

hükümsüz hale gelmesi üzerine de, feragat eden mirasçılık sıfatını yeniden kazanacağı için, özgülemeyi isteme hakkı da doğmalıdır.

Buna karşılık, birden fazla özgülemeyi istemeye ehil mirasçı varsa, mirasbırakan, özgülemenin hangisine yapılacağını bir ölüme bağlı tasarrufla belirleyebilir. 2153

bbb) Mirasçıya özgüleme ve aile ortaklığı

Tarımsal işletmenin ne şekilde paylaşılacağı veya hangi mirasçıya özgüleneceği hususunda tüm mirasçılar anlaşmaya varamazlarsa ve mirasbırakan da ölüme bağlı bir tasarufla kime özgüleneceğini belirtmemişse, hakim bu işletmeyi MK 661 hükümlerine belirleyeceği bir mirasaçıya özgüleyecektir. 2154

İlk olarak hakim, ancak bu işletmeyi, talep eden mirasçılardan birine özgüleyebilir (MK 668). Bu yönde, talepte bulunan mirasçının erkek ya da kadın olması arasında bir fark yoktur.Talepte bulunmayan bir mirasçıya, diğer ölçütlere uygun olduğu gerekçesiyle, isteği dışında özgülemede bulunamaz. 2155

Talepte bulunan mirasçı, tarımsal işletmeyi bizzat işletmeye ehil olmalıdır. İşletmeye ehil olmanın belirlenmesinde, özgülemeyi isteyen mirasçının varsa eşinin yetenekleri de göz önüne alınacaktır (MK 661/II). Bu bakımdan hakim, sadece mirasçının değil, eşinin de bilgi ve yeteneklerine bakacaktır. Hakim, özgülemeye karar verirken, bizzat işletmek isteyen mirasçıya öncelik tanır (MK 661/II). 2156

Kural olarak, tarımsal işletme bütünüyle talepte bulunana özgülenecektir. Ancak, yukarıda da değindiğimiz gibi, MK 659/II'ye göre, tarımsal işletme, değerinde azalma meydana gelmeksizin bölünebiliyorsa, hakim birden fazla talepte bulunan mirasçının olması hâlinde, bölerek de mirasçılara özgüleyebilir. 2157

Tarımsal işletmenin kendisine özgülenmesi hiç bir mirasçı tarafından talep edilmezse ya da talepte bulunan ehil olmadığı için talebi reddedilirse, MK 668'e göre mirasçılardan birinin isteği üzerine tarımsal işletme satılır. Bu halde, elde edilen bedel mirasçılar arasında paylaşılır. 2158

Ancak, yukarıda belirtilen durumlardan biri varsa ve mirasçılardan hiç biri satışı da istememişse, sulh hakiminin nasıl hareket edeceğine ilişkin kanunda bir hüküm yoktur[1264]. Bu durumda, böyle bir tarımsal işletme ortada sahipsiz bırakılamayacağına göre, sulh hükiminin, paylaşmayı genel olarak düzenleyen MK 646 vd. na göre hareket etmekten başka çaresi yoktur. 2159

Mirasçılardan birine tarımsal işletme özgülenince, diğer mirasçıların payları, terekede bulunan diğer unsurlar ile tamamlanacaktır. Fakat, tarımsal işletme büyük bir değer ifade ettiği için, diğer mirasçıların paylarını tamamlayacak kadar tereke malı kalmamış olabilir. İşte, miras hukukunun genel ilkeleri bu durumda özgülemeye izin vermezken, MK 664/I hükmü, bu durumda dahi tarımsal işletmenin bir mirasçıya özgüleneceğini kabul etmektedir. Böylece, tarımsal işletmeyi alan mirasçı, paymdan fazla tereke malı almış, diğerleri ise yasal miras paylarını alamamış olacaklardır. Bu durumun telafisi, tarımsal işletmeyi talep eden mirasının, diğer mirasçıların yasal miras paylarını tamamlayacak kadar kendi malvarlığından ödeme yapması suretiyle olacaktır. Kanun, bu özel durumda diğer mirasçıları, miras paylarını tazmin için yapılacak ödemeyi kabul yükümü altına sokmaktadır. 2160

MK 893 b.2, kendisine tarımsal işletme özgülenen mirasçının, diğer mirasçılara 2161

[1264] Oysa, MK 661'in karşıtı olan eski MK 598'de bu halde hakimin ya satışa ya da bölünmeye karar verebileceği hükmü vardı.

olan bu denkleştirme borcu için yasal ipotek hakkı tanımaktadır. Demek ki, diğer mirasçılar henüz bu denkleştirme alacakarını tahsil etmeden, tarımsal işletmenin, özgülendiği mirasçıya verilmesine razı olmak zorundadırlar. Yapabilecekleri şey, derhal bu ipotek hakkının tescilini sağlamalarıdır. Fakat, mirasçılar, özgülemeyi takiben, kural olarak, derhal (BK 90 uyarınca hemen muaccel olacak) bu borcun ifasını talep edebilirler ve ifa edilmezse, ipoteğin paraya çevrilmesini isteyebilirler.

2162 Ancak MK 664, bu tehlikeye karşı, tarımsal işletmeyi devralan mirasçıyı koruyucu bir hüküm getirmiştir.: şayet, diğer mirasçıların, bu alacakları için taşınmaz üzerine konulan ipoteklerin, daha önceden konulmuş olan teminatlarla birlikte toplamı, tarımsal işletmenin değerinin 3/4'ünden fazla ise, tarımsal işletme kendisine özgülenen mirasçı, paylaşmanın ertelenmesini isteyebilecektir.

2163 Tarımsal işletme kendisine özgülenen mirasçı böyle bir ertelemeyi talep ederse, MK 664/II uyarınca, bu süre boyunca miras ortaklığı, aile malları ortaklığına dönüşerek devam edecektir. İşletme kendisine özgülenen mirasçı, yönetimi tek başına üstlenecek, ancak diğer mirasçılar, aile malları ortaklığı hükümlerine göre, kazanç üzerinde hak sahibi olacaklardır[1265]. Ancak, diğer mirasçılar bu aile malları ortaklığına girmek zorunda değildirler. Aile malları ortaklığına girmek istemeyen mirasçı bunun yerine, kendi payının, işletmeye ait taşınmazlarla güvence altına alınmış bir alacak hakkına dönüştürülmesini isteyebilir (MK 666/I). Bu alacağa çevirmede, mirasçıya, alacağının karşılığı olarak,"... beş yıldan önce parala çevrilemeyen ve en fazla irat senetleri için geçerli oran üzerinden faizlendirilecek bir mirasçı irat senedi " (MK 666/II) verilmesi şeklinde olacaktır.Ancak, irat senetlerindeki yükün üst sınırına ve devletin sorumluluğuna ilişkin hükümler (MK 904, 905), mirasçı irat senetlerine uygulanmaz (MK 666/III).

2164 Aile malları ortaklığının kurulabileceği bir diğer hal de MK 663'de öngörülmüştür. Buna göre, *"Mirasçılar arasında ergin olmayan ayırt etme gücüne sahip altsoy varsa; paylaşma bunlar ergin oluncaya kadar ertelenebilir veya mirasçılar arasında özgülemeye karar verilebilecek tarihe kadar aile malları ortaklığı kurulur"*. Ancak hemen belirtmek gerekir ki, bu hüküm sadece alsoy mirasçıların bulunması hâlinde uygulanacaktır. Hükmün konulmasının amacı, her halde, ergin olmayan, fakat ayırt etme gücü olan altsoya da tarımsal işletmenin kendisine özgülenmesini isteyebilme imkânın tanınması olsa gerektir. Ancak, hükmün emredici olmadığı, sulh hakimine bir tadir yetkisi verdiği, maddede *ertelenir* yerine *ertelenebilir* kelimesinin kullanılmasından açık olarak anlaşılmaktadır. Bu hükme göre aile malları ortaklığının kurulduğu hallerde, MK 664-666 hükümleri uygulanacaktır.

2165 Kurulan aile malları ortaklığı devam ederken, tarımsal işletmeyi üstlenen mirasçı, işletmeyi büyük ölçüde borç altına sokmaksızın, işletmenin gelirinden diğer mirasçılara olan borçlarını ödeyecek duruma geldiği anda alacaklı mirasçılar ortaklıktan çıktıklarını bildirerek, paylarının karşılığını ödenmesini isteyebilirler (MK 665/I). Aksine bir anlaşma olmadıkça, kendisine tarımsal işletme özgülenen mirasçı da, aile malları ortaklığının sona erdirilmesini her zaman isteyebilir (MK 665/II).

IX. PAYLAŞMANIN SONUÇLARI

1. Mirasçıların birbirlerine karşı sorumlulukları

2166 MK 679/I hükmü, mirasçıların her birinin, yapılan paylaşma sonucu di-

[1265] *Zevkliler*, 161 vd.

ğerlerine düşen paylar bakımından satış hükümlerine göre sorumlu olacağının belirtmektedir. Burada, paylaşma sonucu her bir mirasçıya düşen malların ayıplı çıkmasından veya üçüncü kişiler tarafından zaptından dolayı, diğer mirasçıların, satım sözleşmesindeki ayıba karşı ve zapta karşı tekeffül hükümlerine göre sorumlu tutulacağının ifade edildiği kabul edilmektedir[1266].

Burada, satım sözleşmesindeki ayıba karşı tekeffül (BK 219-231) ve 2167
zapta karşı tekeffül (BK 214-218) hükümlerini açıklayacak değiliz. Sadece, konumuz bakımından önem taşıyan, buradaki uygulamaya ilişkin bazı özelliklere değineceğiz.

İlk olarak MK 679/I'in, satım sözleşmesindeki ayıba karşı tekeffül hü- 2168
kümlerine yaptığı yollama, sadece miras paylaşımının niteliğine uygun düşen hükümlerinin uygulanacağı şeklinde anlaşılmalıdır. Örneğin, mirasçıya özgüleme sırasında kendisince bilinen ayıptan, diğer mirasçıların sorumlu olmaması (BK 222), özgülemeden sonra malları muayene ve ihbar yükümlülüğü (BK 223), ağır kusurla bozuk mal özgülenmesinde, vaktinde bildirim mecburiyetinin olmaması (BK 225), ayıba karşı tekeffülden doğan taleplerin 2 yıllık zamanaşımı (BK 231), zapt hâlinde davayı diğer mirasçılara ihbar yükümü ve diğer mirasçılara üçüncü kişinin açtığı dava, zamanında bildirilseydi elde edilecek sonuç kadar sorumluluğun azalması kuralı (BK 215/III), özgülenen taşınmazın yüzölçümünün eksik çıkması üzerine yapılacaklara ilişkin hükümler (BK 244), mirasçıların sorumluluğuna uygulanabilecek hükümlerdir. Buna karşılık, mirasın paylaşımına uymayan hükümler uygulanamayacaktır. Örneğin, ayıp sebebiyle sözleşmeden dönme ve ayıplı maldaki değer düşüklüğü oranında bedel indirimi (BK 227), paylaşmaya uymayan hükümlerdir. Kendisine özgülenen mal zaptedilen ya da ayıplı çıkan mirasçı, diğer mirasçılardan, bu zapt ya da ayıp yüzünden uğradığı (kısmi ya da tam) değer kaybını talep etmekten ibaret bir hakka sahip olacaktır.

Ancak, *kanımızca*, misli bir eşyanın mirasçılar arasında paylaşılmasın- 2169
dan sonra, bir mirasçıya verilen kısım ayıplı çıkmışsa BK 227/4 hükümlerine kıyasen, bu mirasçı, diğer mirasçıların her birinden, aldıkları ayıpsız kısımlardan miras payları oranında bu ayıplı malı, ayıpsız misliyle değiştirmelerini isteyebilmeli veya yönelteceği tazminat talebine karşı, diğer mirasçılar bu değiştirmeyi önerebilmelidirler.

İkinci olarak, kendisine düşen maldaki ayıp oranında zapta ve ayıba 2170

[1266] *Escher*, Art. 637 N 17; *Tuor/Picenoni*, Art. 637 N 5; *Kocayusufpaşaoğlu*, 732; *İmre/Erman*, 509; *Oğuzman*, 338 (yazar, sadece ayıba karşı tekeffül sorumluluğuna değinmektedir).

karşı tekeffül hükümlerine göre, diğer mirasçılara başvuran mirasçı, talep edeceği tazminat tutarından, kendi miras payını çıkarmak zorundadır. Aksi takdirde, paylaşma adil şekle getirilmiş değil de, giderme bahanesiyle bu mirasçı zenginleşmiş olur. Örneğin, mirasbırakan, geride çocukları A, B ve C ile üç ev bırakmıştır. Evlerden her birine 100 bin lira değer biçilmiş ve böylece birer pay oluşturularak her bir mirasçıya verilmiştir. Ancak, C'ye düşen evin eksik malzeme ve kötü yalıtımla yapıldığı ortaya çıkmış ve bunun evin değerini 70 bin liraya düşürdüğü, diğer evlerle eşit değere gelebilmesi için 30 bin lira masraf yapılması gerektiği hesaplanmıştır. Burada C, diğer mirasçılar A ve B'den, 15'er bin lira olmak üzere 30 bin tazminat isteyemeyecek; zararda kendi miras payına (1/3) düşen 10 bin liraya katlanmak zorunda bırakılıp A ve B'den 10'ar bin olmak üzere toplam 20 bin lira talep edebilecektir.

2171 Mirasçının aldığı malın ayıplı olmasından ya da zaptından dolayı diğer mirasçılara yönelteceği talep hakkının zamanaşımı tartışmalıdır. Baskın görüşe göre, MK 679/III'de belirtilen (aşağıda değineceğimiz), tahsil edilemeyen alacak haklarından dolayı talepler için öngörülen bir yıllık zamanaşımı burada da uygulanacaktır[1267]. Bizim görüşümüz ise, burada satım sözleşmesinde ayıba ve zapta karşı tekeffül talepleri için öngörülen zamanaşımı sürelerinin (BK 146, 231) uygulanacağı şeklindedir[1268]. Bu yorum, MK 679/III'ün açık olarak garanti ve kefalete ilişkin taleplerin zamanaşımını düzenlediğine ilişkin lafzına daha uygun olduğu gibi, ayıpta ve zaptta, talep hakkı sahibi mirasçıya, çoğu kez daha uzun zamanaşımı süreleri sağlamaktadır.

2172 MK 680'in paylaşma sözleşmelerini, Borçlar Kanunun sözleşmenin geçersizliğine ilişkin genel hükümlerine tabi tutması karşısında, şartları varsa, ayıplı çıkan mal sebebiyle bunu alan mirasçı, yanılma (BK 31) ve aldatma (BK 36) hükümlerine dayanarak paylaşmayı BK 39 uyarınca iptal de edebilir. Fakat bu, bizim de katıldığımız, yanılma, aldatma hükümlerinin, ayıba karşı tekeffül hükümleriyle yarıştığı (ayıba karşı tekeffül hükümlerinin yanılma ve aldatma hükümleri karşısında özel hüküm olmadığı) görüşü[1269] benimsenirse mümkündür. Ayrıca, yanılma, aldatma hükümlerine ancak paylaşma sözleşmesi ve elden paylaşma yoluyla gerçekleşen paylaşmalarda (MK 676) başvurulabilecek olup; mahkeme kararıyla (MK 642) gerçekleşen paylaşmalarda, ortada iptal edilecek bir sözleşme olmadığından, sa-

---

[1267] *Escher*, 3. Aufl. Art. 637, N 17; *İmre/Erman*; 512; *Kocayusufpaşaoğlu*, 733.

[1268] *Escher*, 2. Aufl., Art. 637 N 18,19; *Tuor/Picenoni*, Art 634, N 10.

[1269] Bu konudaki açıklama ve tartışmalar için bkz., *Oğuzman/Öz*, Borçlar Hukuku, Genel Hükümler Cilt 1, 12. Bası, s. 103, 104.

dece ayıba karşı tekeffül hükümlerine ya da istisnaen, HMK 374, 375 uyarınca, yargılamanın iadesi yoluna başvurmak mümkün olabilir.

Ancak açılan paylaşma davasında, mahkeme payları oluşturduktan sonra, mirasçılara yaptığı çağrı sonucu MK 650/III özgülemenin yapılmasında mirasçılar anlaşmış, mahkeme bu anlaşmayla özgülemeyi tamamlamışsa, burada da irade sakatlığı sebebiyle paylaşma iptal edilebilecek midir? *Kanımızca*, mirasçıların kendi aralarında imzaladıkları bir yazılı sözleşme ile değil de, pay özgülenmesi aşamasında hakime kararlarını bildirme yoluyla yapılan özgüleme MK 676/I uyarınca paylaşma sözleşmesiyle değil, ortak arzularına göre özgülemeyi içeren mahkeme kararıyla gerçekleşmiş sayılmak gerektiğinden; bu paylaşmanın hata veya hile sebebiyle iptali mümkün olmamalıdır. 2173

MK 679/II paylaşılan tereke alacakları konusunda özel bir sorumluluk rejimi getirmiştir. Buna göre,mirasçılar, paylaştıkları tereke alacaklarının varlığı ve geçirliğini birbirlerine garanti ekmiş sayıldıkları gibi, borsaya kayıtlı kıymetli evrak hariç, borçuların ödeme güçlerini de temin etmiş ve bu hususta adi kefil gibi sorumlu sayılmışlardır. Böylece, alacak temlik edeni, ivazsız temliklerde alacağın varlığından bile sorumlu tutmayan, ivazlı temliklerde, alacağın varlığından ve borçlunun ödeme gücünden sorumlu tutan BK 191 hükümlerine göre, MK 679/II, alacak paylaşan mirasçıları çok daha sıkı bir sorumluluk altına sokmaktadır. Buna göre, kendi payına düşen bir alacak hakkı geçersiz veya sona ermiş çıkan mirasçı, diğer mirasçılardan payları oranında bu zararın karşılanmasını isteyebileceği gibi; borçlunun ödeme güçsüzlüğü karşısında, kendisine düşen takibi gereğince yaptığı halde, tahsil edemediği alacak için de diğer mirasçılara başvurabilecektir. Kuşkusuz, mirasçı kendisine intikal eden alacağın ortadan kalkmasına ya da elde edilememesine kendisi sebep olmuşsa (örneğin, borçluyu ibra etmişse ya da dava açmakta geciktiği için alacak zamanaşımına uğramışsa), zararı için diğer mirasçılara başvuramayacaktır. 2174

Tıpkı (yukarıda örneklediğimiz üzere) özgülenen mallar hakkında, ayıba karşı tekeffül hükümlerine göre tazminat istenirken yapıldığı gibi, tahsil edemediği alacak hakkından dolayı diğer mirasçılara başvuran mirasçı, bu alacak hakkından, kendi miras payı oranında indirim yaparak kalanı talep edebilecektir. 2175

MK 679/III, tahsil edilemeyen alacaklardan dolayı diğer mirasçılara başvurma hakkını özel bir zamanaşımına tabi tutmuştur. Buna göre, diğer mirasçılara başvurma hakkı, paylaşma sırasında muaccel bulunan alacaklardan dolayı, paylaşmanın tamamlanmasından itibaren bir yıl ve daha sonra muaccel olacak alacaklar için, muacceliyet tarihinden itibaren bir yıldır. 2176

2177 Gerek özgülenen malın ayıbından ya da zaptedilmesinden dolayı gerek özgülenen alacağın tahsil edilememesinden dolayı mirasçıların birbirlerine karşı sorumluğu, müteselsil olmayıp kısmidir. Mirasçıların birbirlrine karşı sorumluluğunu düzenleyen MK 679 hükümleri, mirasçıların tereke borcundan dolayı dışa (tereke alacaklılarına) karşı sorumluluğunu düzenleyen MK 681 hükmündeki gibi, müteselsil sorumluluk öngörmemiştir. BK 162 uyarınca müteselsil sorumluluk, ya tarafların anlaşmasından ya da açık bir kanun hükmünden doğabileceğine göre, burada, kıyas yoluyla da müteselsil sorumluluk kabul edilemez. Şu halde, diğer mirasçılara başvuran mirasçı, her birinden ancak payları kadar ödemede bulunmalarını isteyebilecektir. Örneğin, mirasçı A, kendisine özgülenen malda, 12 bin liralık ayıp çıktığında, kendi payını (1/3= 4 bin lira) düştükten sonra, kendisiyle eşit paya sahip olan diğer iki mirasçıdan biri olan B'den 4 bin lira ve diğeri olan C'den 4 bin lira isteyebilecek olup; B'ye yaptığı takip sonuçsuz kalsa bile, C'den 4 bin lirayı aşan bir ödeme isteyemeyecektir. Keza, babasının mirasından kendisine özgülenen malda 16 bin liralık ayıp çıkan A, diğer mirasçılar annesi B ve kardeşi kardeşi C ise; kendi payına düşen 3/8'in karşılığı olan 6 bin lirayı düştükten sonra, diğer mirasçılardan talep edebileceği 10 bin liranın (16 bin x 1/4) 4 bin lirasını annesi B'den, ve (16 bin x 3/8) 6 bin lirasını kardeşi C'den isteyebilecektir.

2. Dışa karşı sorumluluk

2178 MK 681 uyarınca, paylaşmadan sonra, mirasçıların tereke borçlarından dolayı sorumluluğu, paylaşmadan önce olduğu gibi, beş yıl süreyle şahsi ve müteselsil sorumluluk olarak devam edecektir. Gerek bu hükmü, gerek iç ilişkideki payından fazla ifada bulunan mirasçının, MK 682'de düzenlenen rücü hakkını, daha önce, miras ortaklığının hükümlerini açıklarken ele almıştık[1270]. Oradaki açıklamalarımıza yollama yapmakla yetiniyoruz.

2179 Özel bir durum olarak, mirasbırakanın alacaklısı aynı zamanda mirasçılarından biri ise, bu alacağı miras payı oranında "alacaklı ve borçlu sıfatlarının birleşmesi" sebebiyle sona erecektir (BK 135). Kendi miras payı dışında kalan kısmı, diğer mirasçılardan, paylaşmayı izleyen 5 yıl süreyle müteselsil olarak, sonra da, payları oranında talep edebilir.

[1270] Bkz., yukarıda § 37, II, 3, a,b.

BİBLİYOGRAFYA

Acar: 4721 Sayılı Yeni Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi Bağlamında Eşin Yasal Miras Payının Belirlenmesi, Ankara 2003.

Akbıyık: Karma Bağışlama Kavramı ve Miras Hukukunda Yeri, İstanbul 1997

Akbıyık: Miras Sebebiyle İstihkak Davası, İstanbul 2003

Akbıyık: Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi, İstanbul 2012

Akkanat: Ölümün Özel Hukuk İlişkilerine Etkisi, İstanbul 2004

Antalya: Mirastan Feragat Sözleşmesi, İstanbul 1999.

Aral: Türk Medeni Hukukunda Mirasın Taksimi Davası, Ankara 1979

Ataay/Kocayusufpaşaoğlu/Sungurbey/Kaneti: Notlu, Sistematik İsviçre Federal Mahkemesi Kararları ile Kanton Mahkemelerinin Medeni Hukuk Kararları, yıl 1955-1956, cilt 1-2 İstanbul 1956; yıl 1957; cilt 3, İstanbul 1959 (İBD eki)

Ayiter: Miras Hukuku, 4.bası Ankara 1978

Ayiter/Kılıçoğlu: Miras Hukuku, genişletilmiş 2. bası Ankara 1991

Barholomeyczik/Schlüter: Erbrech, 11. Auflage, München 1980

Baudat: L'Action en petition d'heredite en droit Suisse, Lausanne 1964

Beck: Schweizerische Juristen Kartothek

Becker: Kommentar zum schweizerischen Zivilgesetzbuch, Band VI Obligationenrecht, II. Abteilung, Bern 1934.

Benziger: Das Vermächtnis im schweizerischen Zivilgesetzbuch, Zürich 1917

Berki: Vasiyet ve Ölüme Bağlı tasarruflar, Ankara 1961

Burcuoğlu: 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 181. maddesinin 2. Fıkrası ile İlgili Bazı Gözlemler, Prof. Dr. Ergon A. Çetingil ve Prof. Dr. Rayegan Kender'e 50 Birlikte Çalışma Armağanı, İstanbul 2007, 381 vd.

Büttiker: Der Erbverzicht nach schweizerischen ZGB, Bern 1942

Çağa: Mahfuz Hisseli Mirasçıların Hukuki Vaziyeti, İstanbul 1950

Çilingiroğlu: Miras Paylarının Devri, İBD, 1993, s.7-8-9, 548 vd.

Çubukgil: Mirastan Adi Iskatın Hukuki Mahiyeti ve Sebepleri, AÜHFD, 1950, c.VII, s. 3-4, 441 vd.

Dalamanlı: Miras Hukuku Tatbikatı, Ankara 1975

Davran: Miras Red Hakkından Rücu Caiz midir? İleri Hukuk, s. 24, 231 vd.

Doğan: Boşanma Davasında Davacının Ölümü Halinde Sağkalan Eşin Mirasçılığı, Legal Hukuk Dergisi 2006, C. 4, Sayı 40, 1031 vd.

Druey: Grundriss des Erbrechts, 3.Auflage Bern 1992

Dural: Elyazısıyla Vasiyetname, İstanbul 1967 (Vasiyetname olarak kısaltılmıştır)

Dural: İsviçre/Türk Hukukunda (Müşterek) Ortak Vasiyetnameler, MHAD, yeni seri Yıl 3, No 4, İstanbul 1969'dan ayrı bası

Dural: Miras Hukuku, İstanbul 1983 (Miras olarak kısaltılmıştır)

Dural: Miras Sözleşmeleri, İstanbul 1980

Dural/Öğüz: Türk Özel Hukuku, c.II Kişiler Hukuku, 6. bası İstanbul 2002

Edis: Birlikte Yaşadığı Ailesine Emeğini ve Gelirini Tahsis Eden Reşit Çocuğun Tazminat Alacağı AÜHFD, 1964,c. 21, 375 vd.

Egger: Kommentar zum schweizerischen Zivilgesetzbuch Band II das Familienrecht, Zürich 1948

Eren: Türk Medeni Hukukunda Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali Davası,Ankara 1966 (İptal olarak kısaltılmıştır)

Erman: Evlilikdışı Çocuğun Tanınması, İBD 1988, c.62, 437 vd.

Erman: Sağ Kalan Eşin Mirasçılığı, İstanbul 1986

Escher: Kommentar zum schweizerischen Zivilgesetzbuch, Band III das Erbrecht, zweite neubearbeitete Auflage, Zürich 1937

Escher/Escher: Kommentar zum schweizerischen Zivilgesetzbuch Band III, das Erbrecht Dritte Auflage, Zürich 1960

Esener: Türk Hukukunda Muvazaalı İşlemler, Ankara 1956

Fahrländer: Die außenstehenda Tatsache in der bundesgerichtlichen Praxis zur Tastamentauslegung, Bern 1948

Ferid/Firsching: Internationales Privatrecht, Band 6, München 1999

Gautschi: Die öffentliche Beurkundung der öffentlichen Verfgügungen von Todes wegen Nach dem schweizerischen ZGB, Zürich 1932

Gönensay/Birsen: Miras Hukuku, İstanbul 1956

Gubler: Die ausfleichungspflichtigen Zuwendungen, Bern 1941

Guhl: Gesamthandschuldverhältnisse und deren grundbuchliche Behandlung, ZBJV, c. 53,5 vd.

Gutzwiller: Die Stiftungen, Schweizerisches Privatrecht II, Basel 1967

Güral: Miras Sebebiyle İstihkak Davasına Kimler Taraf Olabilir, ABD, 1953, sayı 5, 400 vd.

Gürsoy: Türk Medeni kanunu Hükümlerine Göre Mal Vasiyeti, Ankara 1955 (Vasiyet olarak kısaltılmıştır)

Gürsoy: Ölüme Bağlı Tasarruflarda Şart ve Mükellefiyet, AHFD c. X, 457 vd (Şart ve Mükellefiyet olarak kısaltılmıştır)

Hatemi: Önceki ve Bugünkü Türk Hukukunda Vakıf Kurma Muamelesi, İstanbul, 1969

Hatemi: Miras Hukuku, 4. bası, İstanbul 2004.

Hegnauer: Grundriß des Kindesrechts, des übrigen Verwandtshaftsrechts, 3.Auflage Bern 1989

Helvacı: Türk Medeni Kanununa Göre Mirasın Reddi, İstanbul 2002

Henrici: Erbvertrag und Ehevertrag, ZSR 1914 (33), 51 vd.

Herzer: Erbrechtliche Auflagen und Bedingungen nach Art. 482 ZGB,Zürich 1941

Honsel/Vogt/Geiser: Kommentar zum schweizerischen Zivilrecht, schweizerisches Zivilgesetzbuch, Band II, Basel und Frankfurt am Main, 1998

İmobersteg: Das Datum im eigenhändigen Tastament, Bern 1956

İmre: Miras Hukuku, 4. bası İstanbul 1978

İmre: Ölüme Bağlı Tasarrufların Ahlaka Aykırılık Sebebiyle İptali Konusunda İsviçre Mahkeme İçtihadlarında Görülen Gelişmeler ve Temayüller MHAD, yıl 1, 1967, sayı 1, 138 vd

İmre: Medeni Kanunun Vakıflara Ait Hükümlerini Değiştiren13 Temmuz1967 Tarihli ve 903 Sayılı Kanunun Miras Hukuku Kaidelerinde Yaptığı Önemli Değişiklikler Üzerine Düşünceler, AD 1968 yıl 58, sayı 3-4,123 vd.

İmre: Türk Miras Hukukuna ilişkin Bazı Düşünceler, Medeni Kanunu 50.Yıl Sempozyumu, İstanbul 1978, 189

İmre/Erman: Miras Hukuku, gözden geçirilmiş 3.bası, İstanbul 1995

İnan: Miras Hukuku, Ankara, 1960

İnan/Ertaş: Miras Hukuku, 3.bası Ankara 1995

İnan/Ertaş/Albaş: Türk Medeni Hukuku, Miras Hukuku, Güncelleşmiş 6. bası, Ankara 2006.

İşeri: Türk Medeni Hukukuna Göre Vakıf, Ankara 1968

Jaeggi: Zwei Fragen aus dem Erbteilungsrecht, SJZ 63 (1967), 165

Kaneti: Hukuki İşlemlerin Çevrilmesi (Tahvili) İstanbul 1972

Karayalçın: Mirasçının Muvazaa Sebebiyle İptal Davası Açma Hakkı Var mıdır? Yargıtay Dergisi, sayı 1-4, 323 vd.

Kılıçoğlu: El Yazısı ile Vasiyetnamede Düzenleme Yeri (2. HD'nin konulyal ilgili bir kararının eleştirisi), Akipek'e Armağan, Konya 1991, 327 vd.

Kılıçoğlu: Miras Taksim Sözleşmesi, Ankara 1989

Kılıçoğlu: Medeni Kanunu'muzun Aile- Miras- Eşya Hukukunda Getirdiği Yenilikiler Ankara 2003

Kipp/Coing: Lehrbuch des bürgerlichen Rechts, V. Band, Erbrecht, 10 Auflage, Tübingen 1955

Knapp: Les clauseses convantionelles et les clauses uniterales de pactes succesorous,Festschrift zum 70. Geburtstag Peter Tuor, Zürich 1946, 201 ff

Kocayusufpaşaoğlu: Miras Hukuku, üçüncü bası İstanbul 1987

Kocayusufpaşaoğlu: Miras Hukuku, ikinci ve üçüncü basılara ek kitap,İstanbul 1992

Kocayusufpaşaoğlu: En Yakın Kanuni mirasçıların Mirası Reddetmesi, Mehaza Göre Yorum, MHAD, 1957,s. 1, 37 vd.

Kocayusufpaşaoğlu: Tenkis (İndirim) Konusu Kazandırmalarda Mirasın Açılmasından Sonra Ekonomik İstikrarsızlık Sebebiyle Gerçekleşen Değer Değişiklikleri (MK 454 ve 506 Arsındaki İlişke) Yasa Hukuk Dergisi, 1986 s.8, 1053 vd.

Koçhisarlı oğlu: Salt Biyolojik Babalık ve Yasal Mirasçılık 1991-1992, 142 vd.

Koziol/Welser: Bürgerliches Recht Band II,Welser, Schuldrecht allgemeiner Teil, Schuldrecht besonderer Teil, Erbrecht, 11. Auflage Wien 200

Köprülü: Miras Hukuku Dersleri, genişletilmiş ve yenilenmiş ikinci bası, İstanbul 1985

Köprülü/Kaneti: Aile Hukuku, 2. bası İstanbul 1989

Krayenbühl: Etudes sur le legs, pracedee d'un apercu sur l'institution d'eheritier, la substitution fideicommiseire et la charges d'apres code civil suisse, Lausanne,1916

Merz: Die privatrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahre 1968, Familienrecht, ZBJV, 1970, 41 vd.

Müller: Das Verhältnis vonAusgleichung und Herabsetzung im schweizerischen Erbrecht, Bern 1949

Oğuzman: Miras Hukuku, gözden geçirilmiş 6. bası, İstanbul 1995

Oğuzman: Evlilik Dışı Çocukların Babalarına Mirasçılığı Sorunu, Prof. Dr. İlhan Öztark'a Armağan, 1994, 303 vd.

Oğuzman: Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları,5. bası İstanbul 1990

Oğuzman/Dural: Aile Hukuku, 3. bası İstanbul 2000

Oğuzman/Öz: Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, Cilt 1, 12. Bası, İstanbul 2014; Cilt 2, 11. Bası, İstanbul 2014.

Oser/Schönenberger: Kommentar zum schweizerischen Zivilgesetzbuch, Band VI, Obligationenrecht, II . Teil, 2. Auflage, Zürich 1936

Öğüz: Butlan Kararından Önce Ölen Diğer Eşin Mirasçılığı Sorununda Yargıtay'ınTutumu Üzerine Bir Karar İnclemesi, Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, yıl 1, sayı 1, Kocaeli 1997, 505 vd.

Öğüz: Ölüme Bağlı Bağışlama ve Bu Bağışlamaya Uygulanacak Hükümler Halit Kemal Elbire'e Armağan, İstanbul 1996, 386 vd.

Öz: Öğreti ve Uygulamada Sebepsiz Zenginleşme, İstanbul 1990

Özakman: Miras Payının Devrine İlişkin Sözleşmeler, İstanbul 1984

Öztrak: Tek Taraflı Ölüme Bağlı Tasarruflardan Rücu ve Vasiyetnamenin Ziyaı, Ankara 1964 (Rücu olarak kısaltılmıştır)

Öztrak: Miras Hukuku, Ankara 1968 (Miras olarak kısaltılmıştır)

Picenoni: Die Auslegung von Testament und Erbvertrag, Zürich 1955

Piotet: Schweizerisches Privatrecht, Band IV/1. Erbrecht erter Halbband (çev, Rene Couchepin) Basel und Stuttgart, 1978

Postacıoğlu: Medeni Usul Hukuku Dersleri, 5. bası, İstanbul 1970

Raschein: Die Ungültigkeit der Verfügungen von Todes wegen, Winterthur 1954

Rossier: La forme autantique du testament, Lausanne 1964

Rössli: Die Herabzetzung und Ausgleichung im schweizerischen Zivilgesetzbuch Andelfingen 1937

Saymen: Vasiyeti Tenfiz Memurunun Hukuki Mahiyeti, İBD 1938, c. XIII, 481 vd.

Saymen: Miras Hukuku Dersleri, İstanbul 1938

Schucan: Die Erbschaftsklage des schweizerischen Zivilgesetzbuchs, Zürich 1943

Schwarz: Aile Hukuku I (çev. Davran) İstanbul 1960

Schwendener: Die Ausgleichspflicht der Nachkommen unter sich und in Konkurrenz mit dem überlebenden Ehegatten, Zürich 1959

Serozan: Mirasçıya Geçen ve Geçmeyen Haklar, Mirasçının Aslından Kazandığı ve Mirasbırakanın Ölüm Sonrasına Uzanan Hakları, Prof. Dr. Nihal Uluocak'a Armağan, İstanbul 1993, 311 vd.

Serozan: Sağlararası İşlem Yoluyla Ölüme Bağlı Kazandırmalar, İstanbul 1997 (Kazandırma olarak kısaltılmıştır)

Serozan: Ölüme Bağlı Tasarrufların Yorumuna Değişik Bir yaklaşım, Halit Kemal Elbire'e Armağan, İstanbul 1996, 445 vd (Yorum olarak kısaltılmıştır)

Serozan: Yeni Medeni Kanunun Miras Hukuku Hakkındaki Yeniliklerinin Değerlendirilmesi, Prof. Dr. Ergun Özsunay'a Armağan, İst. 2004.

Serozan/Engin: Miras Hukuku, Genişletilmiş 2. bası, Ankara 2008; 3. Bası, Ankara 2012

Silbernagel/Weber: Kommentar zum schweizerischen Zivilgesetzbuch, Band II, Familienrecht, Zweite Abteilung, Art. Art. 5-359, Bern 1921

Speckert: Unterschied zwischen Testament und Erbvertrag, Zürich 1951

Spiro: Zur Form des Erbvertrags und des öffentlichen Testaments, Festschrift zum schweizerischen Juristentag, Basel 1963, 217 vd.

Stadtler: Die Enterbung im schweizerischen Zivilgesetzbuch, Ulster 1910

Strebel: Die rechtliche Stellung der Gläubiger des Erblassers und der Erben, Zürich 916

Sungurbey: Mirasbırakanın Muvazaası Durumuna İlişkin Yargıtay'ın 1.4.1974 gün, Sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı Değiştirilemez , Yasa, 1989, s. 6, 749 vd.

Sungurbey: El Birliğiyle (İştirak Halinde) Mülkiyetin Ne Olduğu ve Elbirliği İlişkisinin Yaşamsal Gücü, YD Özel Sayı,1989, 253 vd.

Şener: Eski ve Yeni Miras Hukuku, iki cilt bir arada, İstanbul 1981 (Miras olarak Kısaltılmıştır)

Şener: Vasiyet Hukuku, Ankara 1995 (Vasiyet olarak kısaltılmıştır)

Şener: Mirasçılık Sıfatının Yitirilmesi ve Benzeri Haller, AD 1976 c. 2, s., 81 vd.

Tandoğan: Borçlar Hukuku, Özel Borç İlişkileri, c.I/1 5.bası, İstanbul 1988

Tandoğan: Miras Sebebiyle İstihkak Davası, AÜHFD 1955, c.12, s.1-2, 270 vd.

Tekinay: Türk Aile Hukuku, yedinci bası, İstanbul 1990

Tekinay: El Yazısı ile Vasiyetnamede Tarih ve Yer Unsurlarının Doğruluğu, Reha Poroy'a Armağan, İstanbul 1995, 377 vd.

Tepeci: Notu ve İzahlı Türk Kanunu Medenisi c.1-2, 2.bası Ankara 1955

v. Tuhr/Peter: Allgemeiner Teil des schweizerischen Obligationenrechts,Band I/1 Zürich 1974, Band I/2, Zürich 1979

v.Tuhr/Escher: Allgemeiner Teil des schweizerischen Obligationenrechts, Band II, Zürich 1974

Tuor. Kommentar zum schweizerischen Zivilgesetzbuch, III. Band das Erbrecht erste Abteilung, 2.Aufl Bern 1952

Tuor/Picenoni: Kommentar zum schweizerischen Zivilgesetzbuch Band III Erbrecht,zweite Abteilung, Bern 1964

Tuor/Schnyer: Das schweizerische Zivilgesetzbuch, 10. Auflage, Zarich 1986

Vonfrufs: Die Ausgleichung der Erben nach dem schweizerischen Zivilgesetzbuch Zürich 1910

Yavuz: Miras Hukukunda Tenkisten Sonra Tenkis Konusunu Geri Verme (İade) Yükümlülüğü, İHFD, 1985, c.LI, sayı 1-4, 261 vd.

Yazıcı/Atasoy: Şahıs, Aile ve Miras Hukukuyla İlgili Yargıtay Tatbikatı, 1952-1970, Ankara 1970

Zevkliler: Medeni Hukuka Giriş, Başlangıç Hükümleri, Kişiler Hukuku, Aile Hukuku, 6.bası Ankara 1996

Zevkliler: Türk Miras Hukukunda Tarımsal İşletmelerin Tahsisi, Ankara 1970

Zevkliler/Acarbey/Gökyayla: Medeni Hukuk, gözden geçirilmiş 5. bası,Ankara 1997